LES ENJEUX DES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

À l'aube d'une nouvelle ère de mobilité transfrontalière

La *Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg*, dirigée par André Prüm, est dédiée au droit luxembourgeois, au droit européen et au droit comparé. Elle accueille des études pratiques, des manuels de cours, des monographies, des actes de colloque et des thèses. Fruit des travaux des professeurs, assistant-professeurs et autres enseignants-chercheurs de la jeune et dynamique Université du Luxembourg, elle constitue le reflet d'une équipe de juristes paneuropéenne.
Ancrés dans l'actualité et de haute qualité scientifique, les ouvrages de la Collection s'adressent aux praticiens et étudiants comme aux universitaires et chercheurs.

Dans la même collection :

A. Prüm (coord.), Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, 2008.
D. Hiez (coord.), Le droit luxembourgeois du divorce. Regards sur le projet de réforme, 2008.
S. Bot, Le mandat d'arrêt européen, 2009.
A. Prüm (coord.), La codification en droit luxembourgeois du droit de la consommation, 2009.
D. Hiez (dir.), Droit comparé des coopératives européennes, 2009.
J. Gerkrath (coord.), Droit d'asile au Grand-Duché de Luxembourg et en Europe, 2009
A. Canel, D Hiez, V. Hoffeld, W. Meynet, Guide pratique des associations et fondations luxembourgeoises, 2010.
C. Deschamp-Populin, La cause du paiement. Une analyse innovante du paiement et des modes de paiement, 2010.
J. Gerkrath (coord.), La refonte de la Constitution luxembourgeoise en débat, 2010.
P.-H. Conac (coord.), Fusions transfrontalières de sociétés, 2011.
I. Corbisier, La société : Contrat ou institution ?, 2011.
E. Poillot et I. Rueda, Les frontières du droit privé européen / The Boundaries of European Private Law, 2012.
A. Sotiropoulou, Les obligations d'information des sociétés cotées en droit de l'Union européenne, 2012.
C. Micheau, Droit des aides d'État et des subventions en fiscalité, 2013.
N. R. Tafotie Youmsi, Build, operate and transfer, 2013.
A. Quiquerez, La titrisation des actifs intellectuels, 2013.
M. Hofmann, International regulations of space communications, 2013.
T. Delille, L'analyse d'impact des règlementations dans le droit de l'Union européenne, 2013.
M. Gennart, Le contrôle parlementaire du principe de subsidiarité, 2013.
R. Ergec, Protection européenne et internationale des droits de l'homme, 3e édition, 2014.
S. Menetrey et B. Hess (dir.), Les dialogues des juges en Europe, 2014.
I. Pelin Raducu - Dialogue déférent des juges et protection des droits de l'homme, 2014.
E. Poillot (dir.), L'enseignement clinique du droit, 2014.
E. Neframi (dir.), Renvoi préjudiciel et marge d'appréciation du juge national, 2015.
W. Tadjudje, Le droit des coopératives et des mutuelles dans l'espace OHADA, 2015.
P. Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, 2015.
S. Menétrey, Procédure civile luxembourgeoise, 2016.
M. Marty, V. Malabat, La légalité de la preuve dans l'espace pénal européen, 2016.
M. Happold, M. Pichou, The Protection of Persons Fleeing armed Conflict and other Situations of armed Violence / La Protection de personnes fuyant un conflit armé et d'autres situations de violence, 2016.
A. Prüm (dir.), Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, 2016.
P. Ancel et L. Heuschling (dir.), La transnationalisation de l'enseignement du droit, 2016.
Fr. Hilger, Droit familial luxembourgeois. L'union du couple, 2017.
A. Prüm, La réforme du droit luxembourgeois des sociétés, 2017.
S. Gonzalez, Les accords judiciaires de coopération internationale, 2018.
H. Westendorf, Les sûretés et garanties du crédit en droit luxembourgeois, Tome 1, 2018.
C. Sauer, Contrôle juridictionnel des lois au Luxembourg, 2019.
F. Chaouche, Legitimate expectations in luxembourg tax law, 2019.
P. Ancel, A. Prüm, Réformer le droit des contrats ? Analyse comparée autour du droit luxembourgeois, 2020.
Fr. Hilger, Droit familial luxembourgeois. Union et désunion du couple après la loi du 27 juin 2018, 2020.
J. Gerkrath (dir.), La défense des droits et libertés au Grand-Duché de Luxembourg. Rôle, contribution respective et concertation des organes impliqués, 2020
C. Lacchi, Preliminary References to the Court of Justice of the European Union and Effective Judicial Protection, 2020.
H. Westendorf, Les sûretés et garanties du crédit en droit luxembourgeois. Tome 1. Les principales garanties mobilières conventionnelles, 2e édition 2020.
H. Westendorf, Les sûretés et garanties du crédit en droit luxembourgeois. Tome 3. Les sûretés personnelles, 2021.
P. Deumier, O. Gout, D. Hiez, Mélanges en l'honneur de Pascal Ancel, 2021.
I. Corbisier, A. Prüm, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pour le Luxembourg ? 2021.

LES ENJEUX DES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

À l'aube d'une nouvelle ère de mobilité transfrontalière

François Bernard

Texte arrêté au 21 novembre 2021

LARCIER

Collection de la Faculté de Droit, d'économie et de Finance de l'Université du Luxembourg

Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larcier.com.

© Lefebvre Sarrut Belgium SA, 2021
Éditions Larcier
Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

Imprimé en Belgique

Dépôt légal
Bibliothèque nationale, Paris : octobre 2021
Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles : 2022/0031/007 ISBN : 978-2-8079-3168-8

En hommage à feu Monsieur mon Père, Jean-François Bernard.



Remerciements

Bien que semblant de prime abord constituer le parangon des exercices solitaires, une thèse de doctorat ne peut être issue que de la conjonction des volontés de nombreuses personnes qu'il convient de remercier à juste titre.

Mes premiers remerciements vont à mon promoteur de thèse, Monsieur le Professeur Denis Philippe de l'UCLouvain, sans qui cette aventure n'aurait pu se réaliser et qui m'a permis de faire la plus belle rencontre de mon cursus doctoral, ma directrice de thèse à l'Université du Luxembourg, Madame la Professeure Isabelle Corbisier. Je ne peux que m'estimer extrêmement chanceux d'avoir eu le privilège de réaliser ce travail sous leur supervision et je leur exprime toute ma gratitude pour leurs précieux conseils, leur tutelle experte, leurs encouragements, ainsi que pour toutes les opportunités qu'ils m'ont offertes.

Je tiens également à remercier les membres de mon comité d'encadrement de thèse, Madame la Professeure Isabelle Riassetto de l'Université du Luxembourg et Monsieur le Professeur Yves De Cordt de l'UCLouvain pour leur soutien, leurs encouragements et leurs précieux conseils.

Je souhaite aussi adresser mes plus sincères remerciements à Madame la Professeure Jessica Schmidt de l'Université de Bayreuth et à Monsieur le Professeur Michel Menjucq de l'Université Panthéon-Sorbonne pour avoir accepté de faire partie de mon jury.

Ma plus profonde gratitude va également à Me Claire-Marie Darnand pour son indéfectible soutien, ainsi qu'aux autres associés du cabinet Stibbe Avocats, actuels et anciens, et notamment Bernard, Edouard, Gérald, Johan, Rony et Victorien, mais également Ayzo, Dirk et Diogo qui ont placé leur confiance en moi pendant toutes ces années et qui m'ont permis d'accomplir mon cursus doctoral tout en exerçant ma profession d'avocat. Que tous les autres avocats, et tout particulièrement Adrien, Anna, Frédéric, Giada, Guido, Inès, Jef, Estelle et Sabrina qui ont accepté de prendre le relais les jours consacrés à la recherche en soient également remerciés. Merci également à Valérie, Véronique et Alessandra pour l'aide dans la gestion et l'impression de tous mes documents de recherche !

Que Monsieur Pons, Madame Colette et Monsieur Offermann trouvent ici l'expression de ma reconnaissance pour avoir accepté de mettre mes recherches en pratique et m'avoir fait confiance tout au long de cet exercice.

J'adresse mes plus sincères remerciements à tous mes amis et notamment à Alexandre, Anaïs, Arnaud, Daniel, Franco, Isabelle, Johan, Jonathan, Marc, Polina, Réginald, Valérie-Anne et Xavier, ainsi qu'à tous les membres de ma famille qui m'ont soutenu tout au long de cette longue et passionnante aventure, et tout particulièrement mes parents, Jean-François et Isabelle, mais aussi Benoît, Boris, Damien, Elise, Gryté, Guy, Léon, Lise, Marie, Nathan et Ornella. Sans votre amitié et votre soutien, rien de ceci n'aurait pu être possible.

Je souhaite enfin remercier tout particulièrement mon épouse Emilie pour sa patience, ses relectures, ses judicieux conseils et son soutien sans lesquels cette thèse n'aurait pas abouti.

Préface

François Bernard a présenté son mémoire à l'UCLouvain en juin 2009 sous la direction du Professeur Denis Philippe. Le sujet qu'il avait choisi était les fusions transfrontalières ; c'était un excellent mémoire et sa future épouse Emilie était déjà présente pour l'écouter et le soutenir.

Ce sujet était précurseur de son sujet de thèse.

Par la suite, Denis Philippe et François Bernard se sont rencontrés au Luxembourg autour d'un bon repas et ont échangé différentes idées de rédaction de thèse proches des fusions transfrontalières. Et, après discussion avec la Professeure Isabelle Corbisier (Université du Luxembourg), François Bernard a choisi le thème de son ouvrage, à savoir les scissions transfrontalières. Il s'est agi de la première thèse en droit fondée sur un accord de cotutelle entre l'UCLouvain et l'Université du Luxembourg et l'expérience se transforma en succès éclatant qui laisse augurer d'autres aventures communes entre les deux universités.

La problématique des scissions transfrontalières est complexe. La scission nationale est déjà une opération compliquée puisque les patrimoines se séparent ; comment alors garantir le droit des créanciers, des actionnaires ou des travailleurs ? Des questions difficiles se posent mais que dire dans un contexte transfrontalier où se pose la problématique du droit applicable et surtout celle de la mise en œuvre de la liberté d'établissement, laquelle se doit de faciliter la circulation des sociétés dans l'espace européen.

M. Bernard a repéré au sein des normes européennes celles qui gagneraient à être éclaircies voire améliorées et formule d'intéressantes propositions permettant d'allier sécurité juridique et exercice effectif de la liberté d'établissement à l'occasion d'une opération de scission transfrontalière.

La défense privée de la thèse de M. Bernard eut lieu à Luxembourg et la soutenance publique à Louvain-la-Neuve. Les deux furent magistrales, M. Bernard répondant avec brio et aisance aux questions qui lui furent posées. Son épouse, Emilie, fut là aussi présente pour l'écouter et le soutenir. Le contexte d'une pandémie dont on n'a pas envie d'énoncer encore le nom avait marqué la fin des travaux de thèse de François Bernard de même que les deux soutenances, particulièrement sa soutenance publique dans la mesure où peu de personnes purent être présentes dans la salle. Néanmoins les ressources offertes par la technologie permirent au public notamment luxembourgeois d'assister à distance à sa brillante présentation et de participer ainsi à son succès.

Nous avons aujourd'hui le plaisir de présenter le livre, fruit de quatre années de travail acharné. M. Bernard n'y a rien laissé au hasard ; chaque sujet, combien ardu, est étudié avec minutie et lucidité. Son approche de droit comparé est très éclairante et les droits allemand et autrichien notamment, donnent un relief particulier à cette étude et permettent d'éclairer voire d'inspirer d'autres législateurs, comme les législateurs luxembourgeois et belge, à l'occasion de la transposition de la directive « mobilité ». Sans nul doute il attirera également l'attention du législateur européen lorsque celui-ci s'attellera à une révision de la directive en vue d'en peaufiner les règles.

Les membres du jury n'ont pas tari d'éloge sur l'ouvrage qui constituera désormais une référence incontournable tant pour les divers législateurs et la doctrine que pour les praticiens appelés à faire usage des règles gouvernant la scission transfrontalière.

M. Bernard enseigne déjà le droit au sein de l'Université du Luxembourg et est par ailleurs un avocat fort remarqué. Cette thèse sera une importante étape dans sa carrière qui ne pourra être que brillante. Au surplus, M. Bernard conjugue sa compétence professionnelle à de belles qualités humaines qu'il nous semble important de mettre en exergue en fin de préface.

Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'observer au cours des diverses réunions de comités d'accompagnement ou d'encadrement de sa thèse de même que lors de sa soutenance : des doctorants comme M. François Bernard, on en redemande. Aux lecteurs à présent d'apprécier la finesse et la pertinence de son travail.

Isabelle Corbisier & Denis Philippe

Liste des abréviations utilisées

ACE	Ace, magazine sur la comptabilité, fiscalité, audit et droit au Luxembourg
AG	Die Aktiengesellschaft
BB	Betriebs-Berater
B.I.J.,	Bulletin d'information sur la Jurisprudence
BJ	Bulletin Joly
BJS	Bulletin Joly Sociétés
BT-Drs.	Drucksache des Deutschen Bundestages
Bull. Barreau	Bulletin du Barreau
Bull. civ.	Bulletin civil de la Cour de cassation
Bull. usuel	Bull. usuel
Cah. dr. entr.	Cahiers de Droit de l'Entreprise
Cah. dr. eur.	Cahiers de Droit Européen
C.L.J.	The Cambridge Law Journal
C.M.L.R.	Common Market Law Review
Comp. Law.	Company Lawyer
Co. L.N.	Sweet and Maxwell's Company Law Newsletter
C.J.	Cahier du juriste
D.A. O.R.	Le droit des affaires – Het ondernemingsrecht
DB	Der Betrieb
DNotZ	Deutsche Notar-Zeitschrift
DStR	Deutsches Steuerrecht
EBOR	European Business Organization Law Review
ECFR	European Company and Financial Law Review
ECLJ	European Company Law Journal
EBLR	European Business Law Review
E.L. Rev.	European Law Review
EuR	Zeitschrift Europarecht
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWiR	Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
EWS	Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
F.T.	Financial Times
Gaz. Pal.	Gazette du Palais
GeS	Zeitschrift für Gesellschaftsrecht

GesRZ	Der Gesellschafter
GmbHR	GmbH-Rundschau
GmbH-StB	GmbH-Steuerberater
GPR	Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union
GWR	Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
HBM	Harvard Business manager
I.B.L.J.	International Business Law Journal
I.C.C.L.R.	International Company and Commercial Law Review
I.J.E.P.T.	International Journal of Economic Practices and Theories
IJMOS	International Jounral of Management & Organizational Studies
IPRax	Praxis des internationalen Privat- und Wirtschaftsrecht
IStR	Internationales Steuerrecht
J.B.L.	Journal of Business Law
J.C.F.	Jounral of Corporate Finance
J.C.P. E.	La Semaine juridique Entreprise et Affaires
JCl. Brevets	Jurisclasseur Brevets
J.D.E.	Journal de droit européen
J.L.M.B.	JLMB (revue de JP Liège, Mons et Bruxelles)
J.O.	Journal official de l'Union européenne
J.O.C.E.	Journal official des Communautés européennes
J.T.	Journal des Tribunaux
J.T.L.	Journal des Tribunaux Luxembourgeois
jurisPR-HaGesR	Juris PraxisReport Handels- und Gesellschaftsrecht
JZ	JuristenZeitung
M.B.	Moniteur belge
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NotBZ	Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis
NZA	Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZG	Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZI	Neue Zeitschrift für Insolvenz- und Sanierungsrecht
Pas.	Pasicrisie belge
Pasin.	Pasinomie belge
R.A.E.	Revue des Affaires Européennes
R.B.D.I.P.R.-T.I.P.R.	Revue de droit international privé – Tijdschrift voor Internationaal Privaatrecht
R.C.A.D.I.	Recueil des Cours de l'Académie de Droit International
R.C.D.I.P.	Revue critique de droit international privé
R.C.J.B.	Revue critique de jurisprudence belge
RdA	Recht der Arbeit
RDC	Revue de droit commercial belge
RDC-TBH	Revue de droit commercial belge – Tijdschrift voor belgisch Handelsrecht

RDIDC	Revue de Droit International et Droit Comparé
R.G.D.C.	Revue générale de droit civil belge
Rép. not.	Répertoire notarial
Rev. Dr. ULg.	Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège
Rev. soc.	Revue des Sociétés
R.G.F.	Revue Générale du Contentieux Fiscal
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft
RJDA	Revue de Jurisprudence de Droit des affaires
R.L.D.A.	Revue Lamy droit des affaires
RNotZ	Rheinische Notar-Zeitschrift
RPS	Revue Pratique des Sociétés civiles et commerciales
RPS-TRV	Revue pratique des sociétés – Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap
RTD com.	Revue trimestrielle de droit commercial
RTD civ.	Revue trimestrielle de droit civil
RTD eur.	Revue trimestrielle de droit européen
RW	Rechtskundig Weekblad
SMJ	Strategic Management Journal
T.F.R.	Tijdschrift voor Fiscaal Recht
WiVerw	Wirtschaft und Verwaltung
WM	Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
ZEuP	Zeitschrift für europäisches Privatrecht
ZFO	Zeitschrift Führung + Organisation
ZGR	Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR	Zeitschrift für das Gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

English summary

The challenges of cross-border divisions within the European Union

1. *Introduction*

Benefiting from renewed interest, of which the *Polbud* decision[1], the Mobility Directive[2] and the recent initiative of the European Law Institute aimed at achieving a Rome IV Regulation on the law applicable to companies[3] are only epiphenomena, the cross-border mobility of companies remains more than ever in the spotlight. However, it would be erroneous to analyse this trend as the manifestation of a unanimous desire to build an internal market where borders would gradually evaporate for companies. On the contrary, both the case law of the European Court of Justice on freedom of establishment and the slow and fragmentary construction of secondary European law on cross-border mobility illustrate perfectly to what extent any development in this area will necessarily be torn between the mistrust, or even protectionism, of certain Member States concerned by the impact of unbridled mobility on the various stakeholders and, on the contrary, the benevolence and liberalism of other Member States hoping for their national economies to benefit. It is at the heart of this dichotomy that this study on a virtually unexplored mechanism of cross-border mobility lies. More specifically, the aim is to provide an answer to the seemingly simple question of how to make cross-border divisions a reality within the European Union while properly addressing the various challenges posed by this type of operation for stakeholders.

1 C.J., gd. ch., case *Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.*, 25 october 2017, C-106/16, EU:C:2017:804, (the "***Polbud* decision**").

2 Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (Text with EEA relevance), OJ, L 321, 12.12.2019, pp. 1–44 (the "**Mobility Directive**").

3 For a detailed description of this initiative, see: https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibility-studies-and-other-activities/feasibility-studies/eu-laws-for-companies/ (09/10/2020).

2. *Immediate parties' perspective on cross-border divisions*

2.1. *Economic interest of divisions*

The attention given to this issue is fully warranted in light of the economic interest of cross-border divisions. Qualifying as a divestment operation, they represent a particularly flexible mechanism that can be used both as part of a defensive strategy aimed at preventing a devaluation of the company and as part of a more offensive strategy aimed at creating value. For example, a division will allow a company to refocus on its *core business* by correcting an error of judgement, eliminate negative synergies or carry out a genuine strategic reorientation dictated in particular by an economic recession or the disappointing financial results of a declining industry. They also make it possible to limit the effects of the diversification discount from which conglomerates tend to suffer, to correct a possible asymmetry of information existing between the company's managers and the external capital market, or to meet the capital needs of a promising branch of activity or of the conglomerate itself. A cross-border division may also serve as a defence against hostile takeover bids or fulfil certain purely legal objectives such as adapting to the requirements of competition law, benefitting from a more advantageous tax or regulatory regime or limiting the risks of civil liability arising from certain activities. The economic analysis of divisions also shows that while the increase in *shareholder value* is at the centre of the decision, the transaction will not necessarily be detrimental to other stakeholders and even be beneficial for them. Furthermore, a cross-border division will, in order to be sustainable in the long run, also have to take into account the interests of such stakeholders. Despite being potentially very advantageous, divisions are not infallible. For example, the company or companies resulting from the transaction may prove to be too small and therefore suffer from a liquidity discount or, on the contrary, be more exposed to the risks of a hostile takeover bid. A division may also make the resulting entities less attractive to investors as their activities will be less diversified. However, its main drawbacks remain the complexity of its implementation and the length of its preparation. An effective regime for cross-border divisions should therefore (i) on the one hand, take into consideration the interests of the stakeholders while favouring transactions that are beneficial to both majority shareholders and creditors, minority shareholders and employees and (ii) on the other hand, reduce the costs, duration and complexity of such a transaction to the absolute minimum.

2.2. *Legal nature and main characteristics*

The implementation of such a scheme firstly requires a precise definition of the operation itself. A demerger, of polymorphous legal nature, may be analysed as a restructuring operation which may take the form of either a *sui generis* contract or a unilateral legal act and is characterised in principle by (i) an atypical dissolution not entailing a subsequent liquidation, except in the case of partial divisions and divisions by separation, (ii) a universal transfer of fractions of the assets and liabilities of the company being divided to the recipient companies, (iii) the allotment, whether symmetrical or not, of shares

in the recipient companies to the shareholders of the divided company, or to the company being divided itself in the particular case of a division by separation, with or without an additional cash payment, except in the case of a silent division, and (iv) a specific international component.

2.3. *The impact of fundamental freedoms*

On the basis of this broad definition, it is possible to examine cross-border divisions from the particular perspective of freedom of establishment and free movement of capital. Such an exercise will result in identifying three different lessons from the ECJ case law in this area which will lay the foundations for a European regime for cross-border divisions. Firstly, the detailed study of the ECJ lessons with respect to cross-border mergers, transfers of seat and cross-border conversions makes it possible to establish in particular that cross-border divisions constitute "particular methods of exercise of the freedom of establishment"[4]. Consequently, the principles of equivalence and effectiveness imply that both the home and host Member States (provided they are familiar with national divisions) can neither treat cross-border divisions less favourably than domestic operations, nor make them impossible in practice or excessively difficult through their national legislation. Second, any barrier to freedom of establishment will only be permissible if it meets the conditions of the so-called "*Gebhard test*"[5]. In this respect, the fight against abuse of the freedom of establishment, the preservation of the effectiveness of tax controls or the fairness of commercial transactions and the protection of the interests of creditors, minority shareholders, employees or the tax authorities constitute overriding reasons in the general interest likely to justify such a barrier. Thirdly and from analysing the ECJ case law, the conflict of laws rule applicable to cross-border divisions by incorporation of new companies should lead to the application of the law of the Member State of the company being divided for the part of the procedure up to the issue of the pre-division certificate, whereas the rest of the procedure should in principle be governed by the law of the Member States of the new companies. In addition, the absence of secondary legislation specifically governing cross-border divisions cannot justify a refusal by Member States to recognise this type of operation if national divisions are allowed. Despite these valuable lessons, five limitations inherent to praetorian advances in the area of freedom of establishment, i.e. (i) legal uncertainty linked to the absence of a court decision specifically relating to a cross-border division (ii) inexistence of a clear regime providing a sufficient level of legal certainty, (iii) the fact that the ECJ has in essence only laid down a principle of non-discrimination whose application is conditional on the recognition of

4 C.J., gd. ch., case *SEVIC Systems AG v. Amtsgericht Neuwied*, December 13, 2005, C-411/03, EU:C:2005:762 (the "**Sevic decision**"), § 19.

5 According to the "*Gebhard test*" or "*rule of reason*", a restriction on freedom of establishment is permissible only if it is justified by overriding reasons in the public interest, it is appropriate for ensuring the attainment of the objective in question and it does not go beyond what is necessary to attain that objective. See *Polbud* decision, § 52 and *Sevic* decision, § 23.

division within the internal order, whereas the Company Law Directive[6] has not imposed the recognition of national divisions, (iv) uncertainty, first, as to the compatibility of certain obstacles essential for the protection of stakeholders with the freedom of establishment and, second, as to the need to introduce enhanced protection mechanisms because of the cross-border nature of the operation, and (v) reluctance of the Member States to acknowledge the advances made by the ECJ with regard to cross-border mobility, significantly limit their impact. The situation is not more encouraging with respect to free movement of capital. While capable of being applied to cross-border divisions, the study of the limits inherent to this other fundamental freedom both in a purely European context and in a situation also involving third countries has shown that it is of no practical interest. It follows that the negative harmonisation achieved by the ECJ through its case law on freedom of establishment is not, on its own, capable of making cross-border divisions a reality within the European Union, but must necessarily be accompanied by positive legal measures adopted either (i) by the various national legislators and articulated through specific rules of private international law or (ii) by the European legislator.

2.4. *Theories of private international law and national initiatives*

Regarding the first alternative, a study of the various theories of private international law developed in connection with cross-border divisions quickly reveal their limitations. However, it is clear that the close proximity between mergers and divisions means that the cross-border division procedure will necessarily be based to a very large extent on the regime applicable to cross-border mergers, whilst complying with the specific features of a division which, unlike a merger, is fundamentally characterised by a plurality of beneficiary companies and a single transferring company. However, in order to do so, and if cross-border divisions are indeed to be governed on the basis of the regime applicable to cross-border mergers, it will first be necessary to make their recognition by Member States mandatory in a purely domestic context in order to be able to structure the regime of cross-border divisions on the basis of the principle of the subsidiary application of the regime applicable to domestic divisions. Moreover, it is not conceivable to rely exclusively on national legislators in this area for two distinct reasons. Firstly, national approaches to cross-border divisions are likely to diverge significantly from one Member State to another and to generate frictions. This is easily demonstrated by the study of the Belgian and Luxembourg regimes. Second, some Member States which are less benevolent to cross-border mobility would undoubtedly refrain from introducing any regime altogether.

6 Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification) (Text with EEA relevance), *O.J.*, L 169, 30 June 2017, pp. 46–127 (the "**Company Law Directive**").

2.5. *The new regime of cross-border divisions by incorporation of companies*

In consideration of these shortcomings, it was only logical for the European legislator to adopt the Mobility Directive introducing for the first time a procedure for cross-border divisions by incorporation of new companies. While this Directive certainly represents a significant step towards the establishment of a European regime for cross-border divisions, it is not without drawbacks and suffers from four major shortcomings, i.e. (i) the absence of prior harmonisation of national divisions and the general inconsistencies resulting therefrom, (ii) a *ratione personae* scope limited to limited liability companies and depriving certain companies in a precarious situation of a potentially effective reorganisation mechanism and a *ratione materiae* scope excluding all cross-border divisions involving more than one pre-existing company, (iii) a vague anti-abuse provision which could easily lead to divergent and possibly abusive practices by more protectionist Member States and (iv) unjustified differences in treatment between cross-border mergers and divisions, to the disadvantage of the latter. These shortcomings, combined (i) with the lessons learned from the cross-border mergers experience showing that a high level of legal certainty resulting from a Directive making it possible to significantly reduce both the costs and the time required to carry them out acts as a catalyst for cross-border operations, (ii) the inadequacy of indirect methods to achieve a result identical to that of a division by acquisition, (iii) the deterrent effect of the continuous legal uncertainty affecting divisions falling outside the scope of the Mobility Directive and (iv) the need for adequate protection of stakeholders, render a further intervention by the European legislator in the field of cross-border divisions both desirable and unavoidable. The restrictive approach of the European Commission towards cross-border divisions in the context of the Mobility Directive is therefore difficult to understand. One possible explanation could be that the EU Commission deliberately chose to limit its first legislative initiative to the categories of divisions least likely to give rise to apprehension in mobility-averse Member States with a view to establishing that cross-border divisions represent an economically important restructuring method which is important for the internal market by relying on a significant increase in such operations following the national transposition of the Mobility Directive. Irrespective of the Commission's potentially hidden agenda, a European initiative in this area is unavoidable.

2.6. *The future of cross-border division regulation in the EU*

A new initiative in the field of cross-border divisions will necessarily take the form of a Directive insofar as (i) art. 50 TFEU imposes this form to gradually remove barriers to freedom of establishment and to ensure effective protection of stakeholders in this context, (ii) many restructuring procedures are already regulated in a Directive, (iii) the lightning legislative process of the Mobility Directive has sufficiently demonstrated the political acceptability of proceeding by this legislative method to regulate and strengthen cross-border mobility of companies within the EU. However, the intrinsic shortcomings of a Directive, such as the need to reach a political compromise leaving sufficient leeway to national legislators and the excessive complexity of such an operation due

at least in part to the need to preserve certain national particularities, mean that negative harmonisation by ECJ case law on freedom of establishment will continue to be necessary. Furthermore, a corresponding amendment of (i) the Regulation on the European Company[7], (ii) the Regulation on the European Cooperative Society[8] will also be necessary in the short run as they do not yet envisage cross-border divisions.

2.7. *The cornerstones of a European cross-border division regime*

The ambiguous and restrictive attitude of the European legislator towards cross-border divisions raises certain questions and one can only wonder whether, from the outset, the European Commission, sensing the reluctance of certain Member States, did not make the strategic choice to proceed in two successive stages to make cross-border divisions a reality within the European Union. In other words, it is quite possible that, from the Commission's perspective, the need to proceed with the harmonisation of cross-border divisions involving more than one pre-existing company has never been in doubt, but the best way it found to overcome any reluctance by Member States and to adapt to the skepticism of trade unions towards them was to proceed with a two-steps approach. The first step would consist in an asymmetrical harmonisation while at the same time accustoming Member States to divisions by incorporation of new companies, which are in essence less contentious, and the second step would consist in a more thorough harmonisation exercise of divisions. On this basis, it is worth examining the cross-border division regime of the Mobility Directive to determine to what extent it would also be compatible with both mixed cross-border divisions and divisions by acquisition. The exercise will consist both (i) in an identification of the indications supporting the fact that the Mobility Directive is only a preliminary step to a broader initiative and (ii) in an attempt to resolve possible incompatibilities by taking full advantage of the cross-border division regimes found in Belgian and Luxembourg law, as well as elements of comparison with German, Austrian, French and Italian law. This detailed analysis of the seven steps of the general European model for restructuring (namely (i) the common draft terms of division, (ii) the report(s) of the management or administrative body, (iii) the expert's report, (iv) the publicity measures, (v) the approval of the general meeting, (vi) the double legality control and (vii) the registration and entry into effect) on which the division by incorporation regime enshrined in the Mobility Directive is based, reveals that this regime is also generally compatible with the specific features of a cross-border division involving more than one existing company. However, it would be erroneous to conclude that a mere extension of the *ratione materiae* scope of the Mobility Directive would suffice to make cross-border divisions a reality within the European Union. This clearly comes out of the analysis as a significant

7 Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE), *O.J.*, L 294, 10 November 2001, pp. 1–21 (the "**Regulation on the European Company**").

8 Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE), *O.J.*, L 207, 18 August 2003, pp. 1–24 (the "**Regulation on the European Cooperative Society**").

number of amendments appeared necessary, including (i) the incorporation of a rule on the language of the common draft terms, (ii) the need to harmonise the question of the effective accounting date, (iii) the addition of the obligation to explain the allocation of the shares of the recipient companies to the shareholders of the company being divided in the report of the management or administrative body, (iv) the introduction of the possibility of drawing up a report of the management or administrative body common to all involved companies, (v) the need to provide for a procedure for the appointment of a common expert as well as the possibility of drawing up a single report for all involved companies, (vi) the allocation of the legality control to the competent national authority of the Member State of the company being divided and (vii) the introduction of a simplified regime providing for an exemption from the general meeting of the company being acquired in the case of the division of a common subsidiary.

2.8. *A latent reform*

Beyond the mere demonstration of the compatibility of the European model for cross-border operations and the identification of the procedural aspects still requiring adaptation to the specific features of a cross-border division involving more than one pre-existing company, the detailed analysis of the regime of cross-border divisions by incorporation of new companies enshrined in the Mobility Directive also revealed a significant number of indications of the Commission's political skill. This applies in particular to (i) the rule on the language of the draft terms of division which originally appeared in the Commission Proposal[9], (ii) the obligation to indicate in the draft terms of division the date from which the shares of the recipient companies allocated in the course of the operation give the right to participate in the profits and (iii) the possibility to provide for a retroactive accounting effective date. In addition, more fundamentally, the Commission could not ignore the fact that the decision of a competent national authority to refuse to issue the certificate of conformity in the context of a cross-border division by acquisition on the simple ground that this type of operation did not fall within the scope of the national provisions transposing the Mobility Directive would violate the principle of non-discrimination of cross-border operations vis-à-vis domestic ones laid down by the ECJ in the *Sevic* judgment[10]. This further strengthens the thesis that the Commission, through the Mobility Directive, did not only intended to harmonise cross-border divisions by incorporation of new companies, but already wished to prepare a more ambitious and thorough reform of divisions[11]. It follows that an extension of the current regime to cross-border divisions involving more

9 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions of April 25, 2018 (Text with EEA relevance), COM(2018) 241 final, available on http://eur-lex.europa.eu (27/11/2020).

10 *Sevic* decision, §§ 22 and 23.

11 For a detailed list of the different aspects of the regime for cross-border demergers which suggest that the Commission intended from the outset to proceed in two stages to make cross-border divisions a reality in the European Union, see Annex 6.

than one pre-existing company at the occasion of the revision of the Mobility Directive by 2027 at the latest would be perfectly justifiable.

3. *Stakeholders' perspective on cross-border divisions*

3.1. *A wider spectrum*

Cross-border divisions, far from only affecting companies and their majority shareholders, are also likely to have a significant impact on the situation of other stakeholders, mainly creditors, minority shareholders and employees. It is therefore essential to broaden the scope of the analysis so as to adequately take into account the main challenges of a cross-border division for these various stakeholders as the implementation of an efficient regime within the European Union is inconceivable without adequate safeguards for their interests. The second part of the analysis will therefore (i) identify to what extent the protection mechanisms enshrined in the Mobility Directive would be compatible with the specificities of a cross-border division involving more than one pre-existing company and (ii) remedy to any shortcomings of the latter in this respect. The method used, although systematically requiring certain adaptations due to the specificities of each category of stakeholders, is based on three-steps approach, namely (i) the identification of the challenges of a cross-border division for each category of stakeholder, (ii) the study of the way in which such challenges were addressed by the European legislator in the Mobility Directive and (iii) the determination of the necessary changes required in order to make any type of division a reality within the EU without unduly sacrificing the interests of the other stakeholders and without losing sight of the impact of freedom of establishment. The latter implies that any protection mechanism will necessarily have to respect both the principle of equivalence and the principle of effectiveness and any obstacle to the freedom of establishment generated by the establishment of specific protection mechanisms will necessarily have to comply with the conditions of the so-called "*Gebhard test*".

3.2. *Challenges of an effective creditor protection regime*

Fundamentally a heterogeneous category of stakeholder, a company's creditors may incur up to six distinct risks as a result of a cross-border division. Among these, the double risk linked to the universal transfer of assets and liabilities, the risk linked to the cross-border nature of the transaction and the risk linked to the free allocation of the fractions of the assets and liabilities of the divided entity affect either exclusively or mainly the creditors of the divided company. As harmonisation of protection mechanisms at EU level is much preferable both in order to enhance the legal certainty of cross-border divisions and to reduce the associated costs, the first challenge of an effective creditor protection regime will be to be sufficiently flexible to effectively adapt to the varying risks incurred by the various creditors impacted by the operation. The second challenge will be to develop a defensive strategy striking a delicate balance between the interests of creditors and those of the company and its majority shareholders. The third challenge will be to properly integrate the lessons of

the ECJ case law on freedom of establishment (i) by focusing on the vigilance of creditors, (ii) by examining to what extent the general legal framework for creditor protection, consisting *inter alia* of the Insolvency Regulation, puts into perspective the need to provide specific protection mechanisms for cross-border divisions, (iii) by considering that a general prohibition of cross-border divisions or an obligation to wind up the company being divided in order to protect the interests of creditors would not constitute proportionate measures and (iv) bearing in mind that the possibility to request adequate safeguards is the ECJ's preferred protection mechanism due to its proportionality. Moreover, the analysis of both the regime of cross-border mergers before the entry into force of the Mobility Directive in the light of the ECJ's lessons in the *KA Finanz* decision[12] and the new regime introduced by the Mobility Directive pleads against a reinforcement of the creditor protection mechanisms solely because of the cross-border nature of the transaction. While this conclusion is only partially supported by an examination of the position of both the Luxembourg and the Belgian legislators, and even if it is undeniable that the ECJ would be very reserved with regard to the conformity with freedom of establishment of such a violation of the principle of equivalence, it is impossible to conclude *ab initio that* such an impediment cannot be justified. On the other hand, the argument that increased protection of creditors impacted by a change in the *lex societatis* of their creditor was justified on account of the procedural difficulties which they would be facing in the event of a cross-border division could be refuted. It was further demonstrated that a cross-border division does not affect the law applicable to the contract into by and between a creditor and the divided company. Furthermore, the argument that greater protection is justified because the national law applicable to the receiving companies is less protective than that of the divided company could not be upheld due to the partial harmonisation of the different national company laws by the European legislator on the one hand and its overly simplistic nature. Consequently, an effective creditor protection regime will necessarily have to be largely based on the regime applicable to domestic transactions and the cross-border nature of the transaction alone does not justify tilting the balance in favour of the interests of creditors. However, a divided company's creditors will require particular attention in return for the great freedom enjoyed by the shareholders with regard to the distribution of the assets and liabilities of the divided entity combined with the substitution of the debtor which is imposed on them without their consent.

3.3. *The contours of an effective creditor protection regime*

A detailed study of the various individual and institutional protection mechanisms adopted both by the European legislator (such as the obligation to inform creditors, the declaration of the management or administrative body, the possibility of requesting an adequate guarantee, the passive joint and several liability of the beneficiary companies or the continued competence of the courts of the Member State of the divided company) and by various

12 C.J., case *KA Finanz AG v. Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group*, 7 April 2016, C-483/14, EU:C:2016:205 (the "**KA Finanz decision**").

national legislators (such as the *actio pauliana*, a veto right, a prior control by a national authority, the optional opposition right under French law, hardship, the separate management of assets or the joint and several liability of the members of the management body of the divided company) all show certain inadequacies and prove incapable, on a stand-alone basis, of adequately addressing the various challenges of creditor protection. The same goes for conventional protection mechanisms allowing creditors either to terminate the contractual relationship (such as non-transferability, *intuitu personae*, acceleration, change of control and prior approval clauses), or simply to adjust the pre-existing contractual relationship (such as jurisdiction clauses and hardship clauses). In conclusion, effective creditor protection will necessarily have to be based on an in-depth defence strategy consisting of four successive lines of defence which are gradually becoming more intrusive from the point of view of freedom of establishment:

- The first line of defence consists in contractual mechanisms. The study of these mechanisms has shown that they are both highly flexible and very effective for vigilant creditors. However, to ensure their effectiveness, it will also be necessary to establish a n institutional protection mechanism through extensive disclosure requirements. The latter will enable creditors to react in a timely manner and, where appropriate, to avail themselves of their contractual prerogatives before the division has taken effect. However, this first line of defence is far from being sufficient to guarantee adequate protection of creditors' interests as it will only benefits vigilant creditors who are aware of their claim, who are able to assess the impact of a cross-border transaction on the repayment capacity of their debtor and who have sufficient bargaining power vis-à-vis the debtor to enable them to adapt the terms of their claim accordingly.
- The second line of defence, which will also be the main line of resistance, will revolve around the individual protection mechanism of claiming adequate guarantees. This mechanism, advocated both by national and European legislators and by the ECJ, allows creditors to obtain additional guarantees if the company cannot credibly demonstrate that the transaction does not jeopardise the recovery of their debt and that the relevant creditors do not yet benefit from satisfactory guarantees. It appears to be an effective way of safeguarding the interests of creditors while respecting the balance of interests and the proportionality requirement of the Gebhard test, provided that it does not have suspensive effect. This specific mechanism, which will intervene *ex ante* for a period of three months from the publication of the joint draft, will necessarily have to demonstrate a certain flexibility through two simple presumptions that the transaction does not harm creditors, i.e. (i) in the presence of a conclusive expert report and (ii) if a payment right of equivalent quality was granted to the relevant creditor, in order to avoid the collateral damage that would be caused by a prohibition of a potentially mutually beneficial or harmless transaction. The flanks will be guarded by more general civil law mechanisms, among which the *actio pauliana* will rank first. This action has the undeniable advantage of benefiting from much longer prescription periods and of allowing a creditor to act in a significant number of

cases before the courts of the Member State of the divided company, thus avoiding the uncertainty linked to the obligation to act before foreign courts subject to different procedural or potentially less favourable rules for the plaintiff. In addition, the a*ctio pauliana*, while being widely represented in the Member States, (i) enjoys a certain flexibility in that the third party concerned may avail itself of the benefit of discussion or dismiss it by simply paying the creditor, (ii) prevents any competition with the creditors of the third party accomplice and (iii) may be brought against a third party sub-acquirer in the case of successive divisions. On the flank level, hardship combined with a right of unilateral termination could be of significant use where the allocation of an adequate guarantee is not sufficient to protect a creditor. This line of defence is, like the first one, insufficient in that it is primarily aimed at creditors who are vigilant, aware of their claim and have sufficient means to protect their rights. Moreover, the conditions of both the *actio pauliana* and hardship hard to meet, thus reserving such protective mechanisms to more exceptional situations.

- The third line of defence is articulated around the joint and several liability of the recipient companies for the debts of the divided company limited to the net assets transferred. This institutional mechanism par excellence will make it possible to overcome both the rational apathy obstacle and the information asymmetry existing between creditors and the relevant companies. Furthermore, it is capable both of effectively protecting involuntary creditors or those still unaware of the existence of their claim at the time of completion of the division and of compensating for the freedom enjoyed by the shareholders with regard to the distribution of the assets and liabilities of the divided company. However, it may only intervene in case of default of the company to which the claim was originally transferred and should also, in case of a partial division, benefit the creditors of the company being divided whose claim was not transferred in the operation.
- The final line of defence, which will only come into play if the first three lines have failed, will take full advantage of the functional interdependence between company law and insolvency law, and will consist of mechanisms under insolvency law. This last line of resistance will be characterised by a disruption of the balance in favour of creditors as well as by a particularly intrusive character from the point of view of freedom of establishment taking full advantage of both the ECJ case-law in the *Kornhaas* judgment[13] and the safeguards deployed by the Insolvency Regulation[14].

This defensive strategy should not, however, be uniformly implemented through exhaustive harmonisation, but will require a certain flexibility to adapt to the very different backgrounds of the general creditor protection regimes of the various Member States and to the fact that the mechanisms of which they are composed transcend company law alone and involve other branches of law

13 C.J., case *Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar*, 10 December 2015, C-594/14, EU:C:2015:806 (the "**Kornhaas decision**").

14 Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, *J.O.*, L 141, 5 June 2015, pp. 19–72 (the "**Insolvency Regulation**").

which are still inadequately harmonised. The study of the various harmonisation options showed that implementation of a highly harmonised creditor protection regime common to both internal and cross-border divisions, combined with the possibility for Member States to supplement it by specific measures, seems to be the ideal solution.

3.4. *The challenges of minority shareholders protection*

Although less salient than the issue of creditor protection, the question of the protection of minority shareholders in the context of a cross-border division nonetheless requires an adequate response. Minority shareholders are exposed to up to five distinct risks in a cross-border division, three of which (the risk of an inadequate exchange ratio, the risk of being forced to undertake a transaction by the majority shareholders and the risk of economic failure) are common to the shareholders of both the divided company and the beneficiary companies and two of which (the risk of asymmetrical divisions and the risk linked to the cross-border nature of the transaction) are specific to the shareholders of the divided company. The first challenge of an effective minority shareholders protection regime is therefore to adequately address these risks to avoid a negative impact on the company's access to capital. The second challenge is to achieve a double balance. Firstly, an effective regime must neither allow majority shareholders to spoliate minority shareholders nor constitute too great an obstacle to the completion of a transaction that is economically indispensable to the continuation of the underlying business. Secondly, it must neither lead to an excessive erosion of the assets or cash of the relevant company (which could be potentially be harmful to creditors), nor unduly sacrifice the interests of minority shareholders who may be forced to undertake a cross-border division against their will. The third challenge will ensure that any protective mechanism complies with the conditions of the so-called "*Gebhard test*". The fourth and final challenge will be to take into account the fact that, unlike creditors, minority shareholders incur an additional significant risk due to the cross-border nature of the transaction insofar as it entails a change in the *lex societatis*.

3.5. *The contours of an effective minority shareholders protection regime*

The analysis of the protective mechanisms introduced by the European legislator through the double prism of freedom of establishment and protection of creditors' interests while comparing them to the mechanisms of two jurisdictions that are less protective of minority shareholders' interests, namely Belgium and Luxembourg, and two jurisdictions with some of the most elaborate regimes in this area, namely Germany and Austria, has led to the conclusion that the regime advocated by the European legislator in the framework of the Mobility Directive remains relatively proportionate and even goes, to some extent, in the direction of enhanced cross-border mobility. As regards more specifically the mechanisms for protecting the interests of minority shareholders, the unanimous consent requirement at the level of the divided company's general meeting, although frequently introduced by national legislators in the case of asymmetrical divisions, must be rejected not only because of its

particularly intrusive character from a freedom of establishment perspective, but also because the granting of such a veto right risks sacrificing the creditors' interest in seeing an economically profitable operation being carried out. The granting of a withdrawal right appears to be more proportionate in light of the conditions of the "*Gebhard test*", but is still subject to five significant disadvantages, namely (i) an impact on the relevant companies' available cash reserves, (ii) an erosion of the relevant companies' assets, (iii) valuation problems of the adequate cash compensation, (iv) a risk of potential abuse and (v) uncertainty due to prolonged contestation procedures. However, the detailed study of this withdrawal right allowed to identify certain features ensuring that it will adequately meet the various challenges posed by cross-border divisions. This first protection mechanism will then have to be complemented by the right for minority shareholders of all involved companies to challenge the adequacy of the exchange ratio, while insisting on the fact that the withdrawal right and the right to challenge the exchange ratio should be mutually exclusive. If this analysis has shown that the approach of the EU legislator in the Mobility Directive is much less restrictive than it appears at first sight and that its protection regime would to a very large extent be perfectly compatible with cross-border divisions involving more than one pre-existing company, it would be erroneous to consider that the protection regime enshrined in the Mobility Directive is purely and simply transposable. Indeed, many aspects would need to be reviewed to take better account of the imperatives of freedom of establishment and the protection of creditors' interests. Moreover, the choice of the European legislator to opt for a resolutely minimal harmonisation regarding the protection of minority shareholders can only prove insufficient in the long term. However, it is possible to consider these legislative choices as a necessary precondition for making a more ambitious harmonisation politically acceptable.

3.6. *The challenges of protecting employee involvement*

Reluctant to any harmonisation and politically very sensitive, the question of preserving employee involvement[15] is a significant issue in a cross-border division as this type of operation could easily be used to avoid or undermine it.

3.7. *The contours of an effective employee participation protection regime*

The detailed study of the provisions of the Mobility Directive and the comparison with the regime for cross-border mergers both before and after the adoption of the Mobility Directive highlighted the fact that the current trend was towards a strengthening of the protection mechanisms and that the regime for cross-border divisions was stricter than the one applicable to cross-border mergers. This exercise also made it possible to outline the main features of a

[15] According to art. 2, h) of Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees, *OJ*, L 294, 10 November 2001, pp. 22–32 (the "**Employee Involvement Directive**"), "*employee involvement*" means "*any mechanism, including information, consultation and participation, through which employees' representatives may exercise an influence on decisions to be taken within the company*".

more general regime for cross-border divisions if it were to be based on the regime established by the Mobility Directive both for cross-border divisions by incorporation of new companies and for cross-border mergers and to isolate the elements requiring modification, such as in essence (i) harmonisation of the various employee involvement protection regimes across the different possible cross-border operations, (ii) the dereliction of the flexible threshold to the benefit of a 500-employee threshold, (iii) the further precision of the rule of permanence so that each subsequent cross-border operation would be governed by its own regime, (iv) the indication of the form and timing of the information to be provided to employees if the relevant company opts for the application of the standard rules[16], (v) the indication that if the special negotiating body[17] resolves at a qualified majority to either close current negotiations or to refrain from opening any, such majority will have to include the positive votes of employees working in at least two different Member States, (vi) the application of the standard rules to the divided company in case of partial division, (vii) the use in connection with a cross-border division of the definition of "*standard rules*" to be found in the cross-border merger regime in lieu of the one used for cross-border conversions, (viii) the application of the standard rules only if prior to the registration of the cross-border division, one or more forms of employee participation were applicable within one or more participating companies covering at least one third of the total number of employees of all participating companies, (ix) the clarification that in the absence of any employees affected by a change of lex societatis, the employee involvement protection regime should not be applied, (x) the removal of the transitory measure according to which the employee involvement rules applicable to the divided company will continue to apply until the application date of all rules agreed at a later stage between all involved parties or, in the absence of such rules, until the application of the standard rules, (xi) provide that in the composition of the special negotiating body, it shall be ensured that additional members are elected in such a way as to ensure that the special negotiating body includes at least one member representing the divided company and (xii) provide that the special negotiating body must have the possibility to agree to a reduction of involvement rights, while providing that if involvement concerns at least twenty-five percent of the total number of employees employed by the participating companies, such a decision shall require a two-thirds majority of the votes of the members of the special negotiating body representing at least two-thirds of the employees and including the votes of members representing employees employed in at least two Member States. Finally, when examining the Mobility Directive regime through the prism of freedom of establishment, its compatibility with the principle of proportionality raised certain questions and evidenced the need for a more comprehensive reform of this sensitive topic.

16 The "*standard rules*" are defined in Part 3 of the annex to the Employee Involvement Directive and are the dispositions imposing the highest level of participation.

17 The "*special negotiating body*" is the body established to negotiate with the competent of the participating companies regarding the establishment of arrangements for the involvement employees within the companies resulting from the operation. See article 2, g) of the Employee Involvement Directive.

3.8. *A delicate articulation with creditor protection mechanisms*

The detailed study of the protection regime for both minority shareholders and workers also highlighted the fact that there is a real interdependence between all protection regimes. Indeed, the effectiveness of the creditors' defensive system is intimately linked to the proportionality of the mechanisms for protecting minority shareholders and workers, which must neither lead to excessive financial erosion nor constitute a disproportionate obstacle to the completion of a transaction on which the ultimate satisfaction of creditors may depend. On the basis of this observation, it has thus been possible to identify certain aspects of the current regime of cross-border divisions by incorporation of new companies which would deserve to be improved in the framework of a new European initiative on cross-border mobility.

4. *General conclusion*

4.1. *The future of cross-border divisions*

Complex and delicate, cross-border divisions give the impression of a fragile clockwork, and the main challenge of a larger-scale initiative in this area will be to preserve the clever balance between the different potentially conflicting interests in presence under the impetus of the ECJ's progressive case law on freedom of establishment. At the end of this study, it appears that the best way to make cross-border divisions a reality within the European Union would be to proceed by means of a new directive on the subject, enshrining a seven-step procedure, the main elements of which would be derived from the regime for cross-border divisions by incorporation of new companies contained in the Mobility Directive, subject to a significant number of adaptations or corrections. The latter, identified in the course of the presentation, could be highlighted by means of a detailed analysis of the provisions of the Mobility Directive while taking full advantage of the lessons learned from (i) the ECJ case law on the freedom of establishment, (ii) the successful experience of cross-border mergers, (iii) the established regime of domestic divisions contained in the Company Law Directive and (iv) a broad comparative law exercise between the laws of Belgium, Luxembourg, Germany, Austria and France. However, cross-border divisions are not limited to majority shareholders controlling the process or members of the relevant management bodies but are also likely to affect a significant number of other stakeholders, mainly creditors, minority shareholders and employees. The methodical examination of the risks generated by this type of transaction for each of these categories of stakeholders combined with the evaluation of the various protection mechanisms developed by both the European and national legislators, while taking into account the ECJ's lessons in this area and the imperative need to strike a balance between the different interests involved lead to the conclusion that a revised regime for cross-border divisions will have to include a complex system of protection of *stakeholders*' interests articulated around (i) an elaborate regime for the protection of creditors' interests composed of four successive lines of defence progressively more intrusive from the point of view of freedom of establishment, (ii) a two-tier

regime for the protection of minority shareholders' interests consisting of a right of withdrawal and a right to challenge the adequacy of the exchange ratio and (iii) a regime for the protection of employee involvement largely inspired by the current regime applicable to cross-border divisions by incorporation of new companies but including a number of innovations designed to strengthen its proportionality in the light of freedom of establishment.

4.2. *A clever move by the Commission?*

Beyond this first conclusion, the in-depth examination of several provisions of the Mobility Directive made it possible to identify a significant number of provisions whose *ab initio* inadequacy reveals the need for a new European initiative in this area. To such extent that the future evaluation to be carried out by the European Commission by 1st February 2027[18] will in fact leave few surprises as to its conclusion. It can therefore be seen as a clever political maneuver on the part of the European Commission which, by voluntarily selecting the sticking points in the regime of cross-border divisions and by counting on a significant increase in the number of such operations through the at least partially harmonised legal framework of the Mobility Directive, hopes to make it easier for reluctant Member States to accept a new directive of a more extensive nature. Future developments in the law on the cross-border mobility of companies within the EU may make it possible to settle this question, but it will already be interesting to study the extent to which, when transposing the provisions of the Mobility Directive into national law, the Member States will naturally tend to remedy the imperfections of the current European regime for cross-border divisions.

18 Art. 4, § 1 of the Mobility Directive.

Sommaire

Remerciements 7

Préface 9

Liste des abréviations utilisées 11

English summary 15

Introduction générale 35

PARTIE I
Les scissions transfrontalières sous l'angle des parties immédiates

Introduction de la première partie 53

TITRE I
Les scissions transfrontalières, un procédé de déconcentration économique des entreprises

Introduction du titre I 59

Chapitre 1. Définition et comparaison avec d'autres types de restructuration 63

Chapitre 2. L'intérêt économique des scissions 71

Chapitre 3. La nature juridique des scissions 97

Chapitre 4. Les éléments caractéristiques des scissions transfrontalières 107

Conclusion sur le procédé de déconcentration économique que constituent les scissions transfrontalières 125

TITRE II
Les scissions transfrontalières sous l'angle des libertés fondamentales

Introduction du titre II 131

Chapitre 1. Les scissions transfrontalières sous l'angle de la liberté d'établissement 137

Chapitre 2. Les scissions transfrontalières sous l'angle de la libre circulation des capitaux 207

Conclusion sur les scissions transfrontalières sous l'angle des libertés fondamentales 225

TITRE III
Les scissions transfrontalières : entre droit international privé et initiatives nationales

Introduction du titre III 231

Chapitre 1. Les principes de droit international privé appliqués aux scissions transfrontalières 235

Chapitre 2. Initiatives nationales en matière de scissions transfrontalières 271

Conclusion sur les principes de droit international privé et les initiatives nationales en matière de scissions transfrontalières 281

TITRE IV
Company law package et nécessité d'une nouvelle initiative européenne

Introduction du titre IV 287

Chapitre 1. Le nouveau régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés 291

Chapitre 2. L'avenir de la réglementation des scissions transfrontalières en Europe 345

Conclusion sur le company law package et la nécessité d'une nouvelle intervention européenne 363

TITRE V
Les contours d'un régime européen des scissions transfrontalières

Introduction du titre V 369
Chapitre 1. La procédure générale de scission transfrontalière 373
Chapitre 2. Le régime des nullités des scissions transfrontalières 531
Chapitre 3. Les opérations simplifiées 537
Conclusion sur les contours d'un régime européen des scissions transfrontalières 547
Conclusion de la première partie 553

PARTIE II
Les scissions transfrontalières sous l'angle des principaux *stakeholders*

Introduction de la deuxième partie 559

TITRE I
La protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière

Introduction du titre I 565
Chapitre 1. Aspects généraux de la protection des créanciers 569
Chapitre 2. Les contours de la protection des créanciers dans les scissions transfrontalières 625
Conclusion sur la protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière 809

TITRE II
La protection des autres stakeholders dans le cadre d'une scission transfrontalière

Introduction du titre II 815
Chapitre 1. Les enjeux de la protection des associés minoritaires 819

Chapitre 2. Les enjeux d'une scission transfrontalière pour la participation des travailleurs 915

Conclusion sur la protection des autres stakeholders dans le cadre d'une scission transfrontalière 951

Conclusion de la deuxième partie 955

Conclusion générale 965

Annexes 983

Annexe 1. Illustration de l'utilité d'une scission transfrontalière dans le cadre de la vente d'un portefeuille d'actifs 985

Annexe 2. Illustration chiffrée de calcul du rapport d'échange 991

Annexe 3. Schéma de la défense en profondeur des créanciers 995

Annexe 4. Liste des indices de l'habileté politique de la Commission 999

Annexe 5. Liste des modifications nécessaires 1005

Glossaire 1021

Bibliographie 1029

Index alphabétique 1097

Table des matières 1105

Introduction générale

1. La scission partielle de Siemens AG. Certaines inventions ont eu l'effet d'un détonateur sur l'humanité et ont durablement contribué à façonner notre monde actuel. Dans ce panthéon des coups de génie trône indéniablement l'ampoule à incandescence dont l'origine remonte au XIXe siècle. De manière très intéressante, cet objet domestique par excellence n'a que peu évolué au gré du XXe siècle et, en dehors de l'utilisation d'un gaz noble puis d'un gaz halogène pour remplir l'ampoule et le remplacement du filament d'origine en coton carbonisé par un filament en tungstène pour tenter d'en prolonger la durée de vie, le procédé, et ses défauts, sont demeurés sensiblement identiques[19]. Il n'est dès lors guère surprenant de constater que son marché ait en définitive été fortement bouleversé, ce qu'a appris à ses dépens le groupe Siemens. En effet, ce gigantesque conglomérat actif dans un grand nombre de secteurs comme l'énergie, les soins de santé, la robotique industrielle ou encore les électroménagers comptait en 2012 une division dénommée Osram spécialisée dans l'éclairage. En 2011, cette division avait permis à l'entreprise de réaliser un bénéfice de 486 millions d'euros et en 2012, ce bénéfice est devenu une perte de 87 millions d'euros[20]. Ce revirement peut s'expliquer par le fait qu'entre 2011 et 2012, le marché des sources de lumière a subi une modification profonde due au bannissement définitif des ampoules à filament au sein de l'Union européenne par souci d'économies d'énergie[21] et à l'avènement des diodes électroluminescentes (LED)[22]. En effet, les LEDs ont une durée de vie de loin supérieure aux ampoules classiques. Par conséquent, le marché des ampoules et autre sources d'éclairage de remplacement qui était le plus important par le passé a subitement été éclipsé. À cela s'ajoute encore que l'avènement des LEDs a fait entrer de nouveaux concurrents asiatiques sur un marché qui était auparavant fortement consolidé et dominé essentiellement par Siemens, Philips et General Electrics. Face à cette évolution radicale de l'environnement concurrentiel, le directoire de Siemens AG a proposé de réaliser une scission partielle visant à rendre le pôle éclairage indépendant au sein d'une nouvelle société dénommée OSRAM Licht AG, suivie d'une entrée en bourse de cette entité. L'objectif de cette opération était double. Elle allait tout d'abord permettre à la nouvelle entité de prendre des décisions stratégiques beaucoup plus rapidement qu'au sein d'un conglomérat très intégré et donc lui donner la possibilité de s'adapter plus efficacement aux caprices d'un marché plus volatil. Ensuite, elle aurait également pour effet de faire bénéficier la nouvelle société d'un accès direct au marché des capitaux[23]. Le verdict du

19 Lampe à incandescence, https://fr.wikipedia.org/ (26/08/2021).

20 Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, und der OSRAM Licht AG, München, über die Abspaltung einer Mehrheitsbeteiligung an OSRAM gemäß § 127 Satz 1 Umwandlungsgesetz vom 28 November 2012, disponible sur https://www.siemens.com (08/03/2018), p. 24.

21 Voir à ce sujet : S. WAJSBROT, « La lampe à incandescence s'éteint en Europe », *Les Echos*, 28 décembre 2012, disponible sur www.lesechos.fr (06/07/2021).

22 J. HACK et M. SHEAHAN, « Osram va supprimer 4700 emplois après sa scission avec Siemens », *Reuters*, 30 novembre 2012, disponible sur www.reuters.com (06/08/2021).

23 Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, und der OSRAM Licht AG, München, über die Abspaltung einer Mehrheitsbeteiligung an OSRAM gemäß § 127 Satz 1 Umwandlungsgesetz vom 28 November 2012, disponible sur https://www.siemens.com (08/03/2018), pp. 29–31.

marché fut clair : d'un prix initial de 24 euros, l'action OSRAM Licht AG est passée à près de 35 euros en trois mois seulement et l'entreprise devenue indépendante a réalisé un profit de plus de 33 millions d'euros en 2013[24]. Cette scission a permis au groupe Osram de se réinventer et de se transformer en entreprise high-tech, tout en évitant le sort d'entreprises ayant raté le virage technologique comme Kodak[25].

2. Une opération à réhabiliter. Cet exemple de l'utilisation d'une scission, c'est-à-dire, de manière très générale, de l'opération par laquelle une société transfère, par suite ou non de sa dissolution sans liquidation, tout ou une partie seulement de son patrimoine actif et passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires soit nouvellement constituées, soit préexistantes, soit à une combinaison des deux, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée de titres ou d'actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, le cas échéant d'une soulte en espèces[26], n'en est qu'un parmi d'autres. En effet, si cette opération est fréquemment ceinte d'une aura négative en raison d'une assimilation à l'aveu d'un échec[27], elle n'en constitue pas moins un mécanisme de déconcentration économique particulièrement utile susceptible de remplir de multiples objectifs tels que la suppression de synergies négatives[28], l'adaptation aux évolutions des conditions de marché[29] ou encore la résolution amiable d'un conflit entre associés[30]. Il n'est dès lors guère surprenant de constater que cette opération s'inscrit fréquemment dans la stratégie agressive mise en place par des activistes issus de fonds spéculatifs (« *hedge funds* »)[31]. Cette polyvalence fait

24 Consolidated financial statements of the OSRAM Licht Group for the fiscal years ended September 30, 2013 and 2012, P&L, disponible sur www.osram-group.com (08/03/2018).

25 Fr. THÉRIN, « Comment Osram a su rester le roi de l'ampoule électrique », *Capital*, 6 mars 2018, www.capital.fr (06/08/2021).

26 Pour une définition plus précise de la notion de scission et une analyse des différentes formes qu'une telle opération peut revêtir, voir *infra* : Première partie, Titre I, Chapitre 1, Section 1.

27 D. BÖLLHOFF, Chr. BRAST, N. GRÜGER, « Demerger als Instrument strategischer Konzernorganisation – Eine fallstudienbasierte Analyse », *ZFO*, 2007/01, p. 23 ; A. CASCORBI, *Demerger-Management – Wertorientierte Desintegration von Unternehmen*, Wiesbaden, Deutsche Universitäts-Verlag, 2003, p. 58 ; P. GHEMAVAT et F. GHADAR, « Globale Megafusionen – ökonomisch nur selten zwingend geboten », *HBM*, 2001/1, p. 32 ; R. GRAML, *Unternehmenswertsteigerung durch Desinvestition: Eine Analyse unter besonderen Berücksichtigung des Management Buy-Out*, Frankfurt am Main, 1996, p. 253 et H. W. WALLENDER III, « A planned approach to divestment », *Management Review*, juillet 1973, p. 55.

28 À ce sujet, voir *infra* n°s 43 à 46.

29 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions, transfers of seat : Is there a need to legislate?*, June 2016, PE 556.960, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (28/02/2020), p. 26.

30 Impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions of April 25, 2018, SWD(2018) 141 final, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (28/02/2020) (ci-après l' « **Étude d'impact** »), p. 23.

31 Voir en ce sens : V. BESSIÈRE, M. KAESTNER et A.-L. LAFONT, « Hedge fund activism : insights from a French clinical study », *Applied Financial Economics*, 2011, 21, pp. 1226 et 1232 ; L. BOISSEAU, « La vague des scissions de sociétés touche l'Europe », *Les Echos*, 14 novembre 2017, disponible sur www.lesechos.fr (07/11/2021) ; Br. CHEFFINS et J. ARMOUR, « The past, present and future of shareholder activism by hedge funds », *Journal of Corporation Law*, 2011, vol. 37, n° 1, p. 60 ; A. CHRISTIE, « The new hedge fund activism : activist directors and the market for corporate quasi-control »,

que les scissions internes sont très fréquentes en pratique[32] et que les coûts qui y sont associés sont généralement bas[33]. *A contrario*, alors que dans un marché intérieur on aurait pu s'attendre à retrouver cette tendance à un niveau transfrontalier, c'est-à-dire lorsqu'au moins deux des sociétés impliquées sont soumises à un droit national différent, on estime qu'il n'y a qu'une centaine de scissions transfrontalières par an à travers toute l'Union européenne[34] et il s'avère que les coûts qui y sont associés sont potentiellement prohibitifs[35]. À titre de comparaison, 620 fusions transfrontalières ont pu être comptabilisées en 2018 dans seulement vingt-cinq États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen[36]. Ce déséquilibre se retrouve également dans la littérature scientifique. En effet, alors que les thèses portant spécifiquement sur les fusions transfrontalières sont relativement fréquentes[37], celles consacrées spécifiquement aux scissions transfrontalières sont beaucoup plus rares[38]. Le même désintérêt se retrouve chez le législateur européen qui n'a

Journal of corporate law studies, 2019, vol 19, n° 1, p. 9 et S. DAHIYA, I. HALLAK et Th. MATTHYS, « Targeted by an activist hedge fund, do the lenders care? », *Journal of Corporate Finance*, 2020, n° 62, p. 15.

32 Étude d'impact, p. 23, note 81 où il est précisé sur la base d'informations glanées lors de la consultation publique de 2015 et de données fournies par des autorités nationales, qu'il y a eu environ 700 scissions internes par an au Danemark au cours des cinq années précédentes, plus d'un millier en France, environ 500 en Pologne et en Estonie, environ 200 en Finlande, en Lettonie et en Suède et environ 150 en Belgique.

33 Voir en ce sens : Étude d'Impact, p. 26 où il est indiqué en outre que les coûts d'une scission interne varient de moins de EUR 10 000,- EUR à 60 000,- EUR.

34 Étude d'impact, p. 24, note 82.

35 Voir en ce sens : Étude d'Impact, p. 26 où il est indiqué que les coûts d'une scission transfrontalière varient de EUR 10 000,- EUR à plus de 100 000,- EUR.

36 Th. BIERMEYER et M. MEYER, *Cross-border corporate mobility in the EU – Empirical findings 2020–1st edition*, disponible sur https://papers.ssrn.com (30/09/2021), p. 24 qui ont collecté les données fournies par l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède.

37 Voir à titre d'illustration : D. BEUTEL, *Der neue rechtliche Rahmen grenzüberschreitender Verschmelzungen in der EU – Einflüsse des Gemeinschaftsrechts auf die Schaffung nationaler Rechtsgrundlagen grenzüberschreitender Verschmelzungen unter Beteiligung deutscher Kapitalgesellschaften*, München, Herbert Utz Verlag, 2008 ; C. DUPIN, *Les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux dans l'Union européenne – Aspects de droit social*, Neuilly S/ Seine, LexisNexis, 2013 ; T. FAHRION, *Das Schicksal der besonderen Rechte von Aktionären bei grenzüberschreitendn Verschmelzungen von deutschen und französischen Aktiengesellschaften*, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2011 ; R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2008 ; S. KULENKAMP, *Die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU*, Mannheim, Nomos, 2008 ; U. LENNERZ, *Die internationale Verschmelzung und Spaltung unter Beteiligung deutscher Gesellschaften*, Verlag Dr. Otto Schmidt, Cologne, 2001 ; J. MITTERECKER, *Grenzüberschreitende Verschmelzungen*, Wien, Verlag Österreich, 2014 ; N. NOHLEN, *Binnenmarktkonformer Minderheitenschutz bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung von Aktiengesellschaften*, Baden-Baden, Nomos, 2012 ; J. SCHMEIDLER, *La protection des créanciers dans les fusions internationales de sociétés : droit international et droit comparé*, thèse, Paris II, 2011 ; A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, Berlin, Duncker & Humblot, 2008 et Chr. WOLTER, *Der Gläubigerschutz bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften unter Beteiligung einer GmbH*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012.

38 Voir à titre d'illustration : Th. PRÜM, *Die grenzüberschreitende Spaltung*, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 2006 ; E. ROELOFS, *Grensoverschrijdende juridische Splitsing van Kapitaalvennootschappen*, Deventer, Kluwer, 2014 et U. LENNERZ, *ibidem*.

procédé à une harmonisation des scissions internes[39] que plus de quatre ans après les fusions internes[40] et à une harmonisation limitée des scissions transfrontalières[41] que quatorze ans après les fusions transfrontalières[42]. Cette tendance se confirme également auprès des législateurs nationaux puisque préalablement à l'adoption de la Directive Mobilité, moins de la moitié des États membres les autorisaient explicitement, que ce soit par le biais d'un régime *ad hoc*, par le biais d'une application par analogie d'un autre régime ou encore au moyen de l'intégration d'un acquis jurisprudentiel[43]. Une scission transfrontalière est pourtant loin d'être dénuée d'intérêt et peut, à l'instar d'une scission interne, remplir de multiples objectifs[44], avec l'avantage additionnel de pouvoir impliquer des sociétés issues de différents États membres. En outre, loin d'être l'apanage des seules grandes sociétés, les scissions transfrontalières peuvent se révéler être un outil tout à fait adapté aux petites et moyennes entreprises[45].

3. **Des enjeux non négligeables pour les *stakeholders*.** Si elles constituent certes un outil de restructuration potentiellement très utile pour les sociétés et les associés majoritaires, les scissions transfrontalières n'en constituent pas pour autant une opération inoffensive. En effet, ces dernières, en ce qu'elles peuvent en principe être imposées aux créanciers, aux associés minoritaires et aux travailleurs, pourraient aisément être détournées pour nuire aux intérêts de ces catégories de *stakeholders*. À titre d'illustration, en ce qui concerne les créanciers, une scission transfrontalière pourrait servir à isoler certaines dettes de la société au sein d'une autre entité à la solvabilité douteuse. Pour ce qui est des associés minoritaires, ces derniers pourraient se voir excessivement dilués au sein des entités bénéficiaires et quant aux travailleurs, l'opération pourrait servir à se réfugier dans une juridiction moins protectrice en matière sociale.

39 Sixième directive (CEE) 82/891 du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, *J.O.*, L 378, 31 décembre 1982, pp. 47 à 54 (ci-après la « **Sixième Directive** »).

40 Troisième directive (CEE) 78/855 du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, *J.O.*, L 295, 20 octobre 1978, pp. 36 à 43 (ci-après la « **Troisième Directive** »).

41 Art. 160*bis* à 160*duovicies* de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 321/1, 12 décembre 2019, pp. 1–44 (ci-après la « **Directive Mobilité** »).

42 Directive (CE) 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 310, 25 novembre 2005, pp. 1–9 (ci-après la « **Dixième Directive** »).

43 Selon l'Étude d'impact, il s'agit notamment de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, du Luxembourg, de la Roumanie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Voir Étude d'impact, p. 24 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 27.

44 Pour une étude détaillée des objectifs susceptibles d'être remplis par une scission transfrontalière, voir *infra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2.

45 À ce sujet voir le projet de scission du 13 septembre 2020 de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois TRANSLATE 4 U au profit de la société à responsabilité limitée de droit belge TRANSLATE 4U2, disponible sur https://www.lbr.lu (13/10/2020). Voir toutefois : Étude d'impact, p. 23 où, en se basant sur une étude réalisée par EY, il est indiqué que les scissions sont plus fréquemment utilisées par les grandes entreprises.

4. Objet de la thèse. Face à l'utilité pratique indéniable des scissions transfrontalières difficilement réconciliable avec leur faible nombre au sein de l'Union européenne et aux enjeux considérables posés par celles-ci pour les différents *stakeholders*, le présent travail a pour objectif de répondre à la question suivante : comment faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne tout en répondant de manière adéquate aux différents enjeux posés par une telle opération pour les *stakeholders* ?

5. Méthode. Pour parvenir à une réponse satisfaisante à cette question, il conviendra en premier lieu de scinder la question de base en deux sous-questions qui forment les deux parties de cette étude. La première sous-question consiste à déterminer comment faire des scissions transfrontalières une réalité du point de vue des parties immédiates, c'est-à-dire des parties contrôlant l'opération, donc fondamentalement des associés majoritaires et des membres de l'organe de gestion. La seconde sous-question implique d'élargir significativement l'angle de vision et d'analyser les différents enjeux posés par une scission transfrontalière pour les principaux *stakeholders*[46] que sont les créanciers, les associés minoritaires et les travailleurs et la manière dont il convient d'y répondre pour éviter qu'une scission transfrontalière ne soit utilisée pour nuire abusivement aux intérêts de ces parties prenantes. Les réponses à ces deux sous-questions seront obtenues au moyen d'une méthode originale s'articulant autour de cinq pôles distincts, à savoir (i) l'intégration d'éléments d'analyse économique seuls à même de justifier l'intérêt de la question et destinés également à rappeler qu'au-delà de l'aspect théorique, les scissions transfrontalières sont avant tout appelées à être un outil efficace au service tant des entreprises que des professionnels du droit, (ii) la prise en compte du rôle prépondérant joué par la liberté d'établissement des sociétés[47] telle qu'interprétée par la Cour de justice, (iii) l'utilisation des enseignements tirés du droit européen dérivé, et tout particulièrement du nouveau régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés introduit par la Directive Mobilité et de l'expérience des fusions transfrontalières qui, fort proches des scissions transfrontalières[48], bénéficient déjà d'un cadre harmonisé au sein de l'Union européenne depuis plus de quinze ans, (iv) l'étude des solutions développées en droit belge et en droit luxembourgeois qui présentent tous deux l'avantage d'une position plus libérale à l'égard de la mobilité transfrontalière des sociétés et de connaître d'ores et déjà un régime applicable aux scissions transfrontalières et (v) une approche comparatiste axée principalement sur les droits allemand et autrichien, qui présentent tous deux l'intérêt de connaître des mécanismes de protection des *stakeholders* particulièrement forts, mais élargie également au droit français, au droit suisse et, de manière ponctuelle, à d'autres droits tels que le droit italien, le droit anglais ou encore le droit polonais.

46 Par « *stakeholder* » on entend « tout individu ou groupe sur lequel les activités de la société ont un impact, en ce compris les travailleurs, les consommateurs et la communauté locale ». Voir : Chr. A. MALLIN, *Corporate governance*, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2007, p. xix.

47 Art. 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, *J.O.*, C 326, 26 octobre 2012, pp. 47–390 (ci-après le « **TFUE** »).

48 À ce sujet, voir *infra* n°s 26 et 27.

6. La notion de scission transfrontalière. Avant toute autre chose, il importe nécessairement d'identifier avec précision ce que l'on entend par le terme de scission transfrontalière par le biais d'une définition analytique se concentrant sur les composantes d'une telle opération[49]. Comme les scissions transfrontalières sont foncièrement polymorphes, cette définition de base s'accompagnera d'une typologie des principales formes que peuvent revêtir les scissions transfrontalières au gré des adaptations de leurs éléments constitutifs. On distinguera ainsi les scissions par constitution de nouvelles sociétés, les scissions par absorption, les scissions mixtes, les scissions partielles, les scissions silencieuses et les scissions par séparation. Fort de cette définition, il sera ensuite possible de replacer la scission au sein des différents modes de restructuration transfrontaliers en la distinguant des fusions transfrontalières avec lesquelles elles entretiennent un lien de parenté particulier[50], des apports d'actifs transfrontaliers avec lesquels la notion de scission fait preuve d'une certaine perméabilité[51], des transformations transfrontalières qui se caractérisent par une unicité de société impliquée[52] et des transferts de siège susceptibles d'être réalisés involontairement[53].

7. Pourquoi les scissions ? Le sujet d'étude une fois délimité, il sera ensuite nécessaire de justifier de manière détaillée l'intérêt de la question d'étude et, plus précisément, l'utilité économique des scissions transfrontalières pour les sociétés au sein du marché intérieur[54]. Multiplier les modes de restructuration transfrontaliers s'avérerait en effet être un exercice particulièrement vain s'il n'en résultait pas une certaine utilité pour les entreprises. L'analyse méthodique des huits principaux objectifs susceptibles d'être remplis par une scission, que ce soit dans le cadre d'une stratégie défensive visant à corriger une erreur d'appréciation ou, au contraire, dans le cadre d'une stratégie plus offensive destinée à créer de la valeur et l'étude systématique d'un exemple pratique pour chacun de ces objectifs, permettra de dissiper tout doute quant à l'utilité de cette question. En effet, comme une scission transfrontalière permet à une entreprise notamment (i) de se concentrer sur son *core business*, (ii) de limiter les effets d'une décote de diversification, (iii) de corriger une éventuelle asymétrie d'information entre une société et le marché des capitaux, (iii) de réagir face à des résultats financiers décevants, (iv) de répondre aux besoins en ressources et capitaux soit d'une branche d'activité prometteuse, soit des activités principales d'une entreprise ou encore (v) de s'adapter aux évolutions

49 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre I, Chapitre 1, Section 1.

50 Voir en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, « Les scissions transfrontalières », *Cah. dr. entr.*, n° 6, novembre 2011, dossier 36, p. 1 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *Rev. Soc.*, 2013, p. 414 ; H. LAMON, *Acquisitions, financement et cessions d'entreprises – Instruments financiers, structures d'acquisition et mécanismes de contrôle sous l'angle fiscal, comptable et financier*, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 125 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 16 ; A. REIK, *Grenzüberschreitende Restrukturierungen von Unternehmen – Eine bilaterale Untersuchung zwischen Deutschland und Frankreich*, thèse, Würzburg, 2001, disponible sur https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de (15/01/2019), p. 300 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 347 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 6, n° 9 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27 et Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package – Content and State of Play », *ECFR*, 1-2/2019, p. 13.

51 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 2.

52 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 3.

53 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 4.

54 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2.

de l'environnement concurrentiel, il y a un intérêt indéniable à ce que ce mode de restructuration figure dans l'arsenal de mobilité des sociétés au sein du marché intérieur. Ce constat sera confirmé par l'analyse économique de la valeur générée par une scission transfrontalière[55].

8. L'incidence de la nature juridique et des éléments constitutifs. Une fois démontré l'intérêt de la question fondamentale de recherche, la première étape vers une solution satisfaisante sera de préciser davantage la notion de scission transfrontalière en se prononçant sur la nature juridique d'une telle opération et en la disséquant pour mettre en évidence ses différents éléments constitutifs, à savoir (i) une dissolution sans liquidation, (ii) la transmission à titre universel des fractions du patrimoine de la société scindée, (iii) l'attribution de nouvelles actions aux associés de la société scindée et (iv) un élément d'extranéité bien déterminé. Ces précisions permettront au gré de l'analyse de se prononcer plus aisément sur les enjeux posés par une telle opération pour les différentes parties prenantes et d'affiner les conclusions au gré des variations des éléments constitutifs.

9. L'incidence des libertés fondamentales. Fort de ces précisions et convaincu de l'utilité de la question, il sera ensuite indispensable d'étudier la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement[56] et de libre circulation des capitaux[57] sur les scissions transfrontalières. Cette étape se justifie par le fait qu'en matière de mobilité transfrontalière des sociétés, la Cour de justice, qualifiée à juste titre d' « *aggressive engine of integration* »[58], a fréquemment joué un rôle d'éclaireur[59] ouvrant la voie à davantage d'intégration européenne et que la liberté d'établissement bénéficie d'un effet direct vertical depuis la fin de la période transitoire[60]. En d'autres termes, s'il devait s'avérer qu'il est déjà parfaitement possible de réaliser une scission transfrontalière sur la seule base des libertés du TFUE en protégeant adéquatement les différentes parties prenantes, il serait vain de pousser plus en avant l'analyse. Cependant, l'étude de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fusions transfrontalières, de transferts de siège et de transformations transfrontalières devrait permettre d'établir que ces libertés fondamentales souffrent d'un nombre important de limites intrinsèques cantonnant la Cour de justice à un rôle tantôt de guide incitant le législateur européen à harmoniser d'autres pans du droit des sociétés, tantôt de garde-fou sanctionnant les entraves injustifiées dressées par les États membres. Ce constat permettra d'aboutir à la conclusion que l'harmonisation négative opérée par la Cour de justice doit nécessairement être complétée par

55 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2, Section 4.

56 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.

57 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre II, Chapitre 2.

58 R. D. KELEMEN, « The political foundations of judicial independence in the European Union », *Journal of European Public Policy*, 2012, p. 51.

59 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften : Formwechsel durch isolierte Satzungssitzverlegung », *ZIP*, 2017, p. 2225 et M. COMBET, *L'établissement des sociétés en droit de l'Union européenne – Contribution à l'étude de la création jurisprudentielle d'un droit subjectif*, Paris, mare & martin, 2017, p. 51.

60 Cet effet direct de la liberté d'établissement qui constitue une disposition relative au marché commun suffisamment claire, précise et inconditionnelle a été consacré par la Cour de justice dès l'arrêt *Reyners*. Voir C.J.C.E., arrêt *Reyners c. État belge*, 21 juin 1974, C-2/74, EU:C:1974:68, pt. 30.

des mesures de droit positif qui pourront prendre deux formes différentes, à savoir soit des initiatives nationales qui s'articuleront par le biais de normes de droit international privé, soit des mesures de droit européen.

10. Insuffisances des normes de droit international privé et des initiatives nationales individuelles. Pour ce qui est de la première option, l'étude des différentes théories de droit international privé[61] et des régimes belges et luxembourgeois qui bénéficient d'ores et déjà tous deux d'un arsenal de normes applicables à tout type de scission transfrontalière[62] permettra d'établir que ces solutions montrent très vite leurs limites. En conséquence, c'est nécessairement vers l'autre option, donc l'initiative européenne, qu'il faudra se tourner.

11. La nécessité d'une nouvelle initiative européenne. Or à cet égard, la Directive Mobilité adoptée fin 2019 devrait permettre d'ici au 31 janvier 2023[63] de faire en sorte que tous les États membres connaissent une procédure de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés. Cependant, cette première intervention en la matière, si elle constitue certes un pas dans la bonne direction, ne permettra en aucun cas de clore d'ores et déjà le sujet. Ce constat sera fondé sur la mise en exergue de quatre insuffisances majeures de cette norme de droit dérivé, à savoir (i) l'absence d'harmonisation préalable du régime des scissions internes, (ii) un champ d'application trop restreint limité notamment aux seules scissions transfrontalières n'impliquant qu'une seule société préexistante[64], (iii) une disposition anti-abus critiquable à plus d'un titre et (iv) des différences de traitement injustifiées[65]. En se fondant sur (i) les enseignements des fusions transfrontalières qui bénéficient de longue date d'un régime européen à tout le moins partiellement harmonisé, (ii) les insuffisances des méthodes dérivées permettant d'aboutir indirectement à un résultat identique à celui d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, (iii) les effets néfastes d'une insécurité juridique persistante en la matière, (iv) la nécessité de protéger de manière adéquate les différents *stakeholders* et (v) certains indices d'une attitude ambiguë de la Commission européenne dans la Directive Mobilité, il sera ainsi possible de démontrer qu'une nouvelle initiative européenne en la matière est indispensable et qu'elle devra nécessairement prendre la forme d'une directive[66].

12. Les contours d'un régime européen sur les scissions transfrontalières. Cette conclusion permettra de passer à la dernière étape de la première partie qui concernera plus particulièrement la détermination des caractéristiques essentielles d'un régime paneuropéen des scissions transfrontalières du point de vue des parties immédiates. Pour ce faire, la méthode utilisée consistera à étudier le régime de la Directive Mobilité à l'aune des spécificités d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante et à résoudre les éventuelles incompatibilités en tirant pleinement parti de l'exemple des fusions transfrontalières, du régime des scissions transfrontalières qu'on retrouve en

61 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre III, Chapitre 1.
62 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre III, Chapitre 2.
63 Art. 3, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
64 8e considérant et art. 160*ter*, § 3 de la Directive Mobilité.
65 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1.
66 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 2.

droit belge et en droit luxembourgeois, ainsi que d'éléments de comparaison avec les droits allemand, autrichien, français et italien. Ce procédé permettra d'aboutir à un régime cohérent des scissions transfrontalières reposant sur le modèle général de restructuration habituellement prôné par le législateur européen et constitué de sept étapes distinctes, à savoir (i) le projet commun de scission, (ii) le ou les rapport(s) de l'organe de gestion ou d'administration, (iii) le rapport d'expert, (iv) les mesures de publicité, (v) l'approbation de l'assemblée générale, (vi) le double contrôle de légalité et (vii) l'immatriculation et la prise d'effet. On peut toutefois également s'attendre à ce qu'il en découle de manière limpide que le régime actuel nécessitera un certain nombre de modifications pour être parfaitement compatible avec les spécificités d'une scission impliquant plus d'une société préexistante[67]. Cette proposition de régime sera complétée par une prise de position sur la nécessité de mettre en place (i) un régime limité des nullités des scissions transfrontalières[68] et (ii) des règles spécifiques destinées à faciliter certaines opérations présentant en essence moins de risques pour les *stakeholders*[69]. Au gré de cet ambitieux exercice de détermination des caractéristiques essentielles d'un régime général des scissions transfrontalières, il sera en outre possible de rassembler un certain nombre de preuves que la Commission européenne n'entendait en aucun cas s'arrêter à la Directive Mobilité, mais, à l'instar d'un habile joueur d'échecs, s'était déjà arrangée pour avoir au moins un coup d'avance sur les États membres[70].

13. L'incidence d'une scission transfrontalière sur les différents *stakeholders*. Si l'intérêt des scissions transfrontalières a pu être démontré et si un régime général du point de vue des parties immédiates a pu être déterminé, il ne s'agit là que de la première étape vers la concrétisation d'un régime paneuropéen des scissions transfrontalières. En effet, arrêter là reviendrait à méconnaître fondamentalement le fait qu'une scission transfrontalière est susceptible d'avoir un impact non négligeable sur un nombre important de parties gravitant autour des sociétés impliquées. La deuxième partie dépassera par conséquent le cadre des seules personnes aux commandes du processus de scission pour prendre en compte les enjeux posés par une telle opération pour les principaux *stakeholders* et, plus particulièrement les créanciers, les associés minoritaires et les travailleurs. Plus précisément, il conviendra de déterminer comment faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne tout en préservant le délicat équilibre existant entre les intérêts des parties immédiates à réaliser une opération de restructuration et les intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des travailleurs à ne pas se voir indûment spoliés.

14. Méthode. Pour ce faire, pour chaque catégorie de *stakeholder*, il sera procédé en trois étapes successives, à savoir (i) l'identification des enjeux posés par une scission transfrontalière, (ii) l'examen de la manière dont il a été répondu à ces différents enjeux par le législateur européen dans la Directive Mobilité et (iii) la détermination des modifications de la législation européenne existante

67 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1.
68 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre V, Chapitre 2.
69 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre V, Chapitre 3.
70 Pour une liste des indices de l'habileté politique de la Commission européenne, voir Annexe 4.

qui s'avéreraient nécessaires en vue de faire de tout type de scission une réalité au sein de l'Union européenne tout en ne sacrifiant pas les intérêts des autres parties prenantes et en respectant l'incidence de la liberté d'établissement sur la matière.

15. Les aspects généraux de la protection des intérêts des créanciers. Dans la mesure où une scission transfrontalière implique par définition le fractionnement du patrimoine de la société scindée et sa répartition entre les différentes sociétés bénéficiaires, il est aisé de voir qu'une telle opération est susceptible d'être particulièrement dommageable pour les créanciers de la société scindée qui se verront confrontés à une substitution de débiteur sans leur consentement, à un éclatement du patrimoine de leur débiteur originel selon une clé de répartition décidée par les parties immédiates et à un changement de *lex societatis*. Cependant, les risques engendrés par une telle opération ne s'arrêtent pas là. Une fois la notion de créancier précisée[71], il conviendra en premier lieu d'identifier tous les différents risques posés par une scission transfrontalière, tant pour les créanciers de la société scindée que pour les éventuels créanciers des sociétés bénéficiaires[72] et à définir la situation d'équilibre entre les intérêts des différentes parties auquel un régime paneuropéen des scissions transfrontalières devrait parvenir tant d'un point de vue économique que du point de vue de la liberté d'établissement[73]. Il sera ensuite indispensable de se pencher sur les principes de droit international privé applicables aux mécanismes de protection des intérêts des créanciers afin de pouvoir cerner plus précisément l'impact qu'une scission transfrontalière est susceptible d'avoir sur ceux-ci[74]. Les résultats ainsi obtenus permettront d'aborder deux questions fondamentales auxquelles il convient de répondre avant même de pouvoir aborder les contours de la protection des créanciers dans la mesure où la réponse qui y sera apportée aura un impact considérable sur la direction que devra prendre un régime général de protection des intérêts créanciers. Ces deux questions ont trait (i) à la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection renforcés en raison de la seule nature transfrontalière de l'opération[75] et (ii) à la nécessité de protéger davantage les créanciers de la société scindée que ceux des sociétés bénéficiaires[76].

16. Les contours de la protection des intérêts des créanciers. Les conclusions tirées à l'égard des aspects plus généraux de la protection des intérêts des créanciers permettront d'aborder la question de la détermination d'un régime de protection des intérêts des créanciers efficace et proportionné. Pour ce faire, il conviendra en premier lieu d'examiner les différents mécanismes de protection prévus par les législateurs nationaux et européens[77], les mécanismes de protection conventionnels susceptibles de trouver à s'appliquer dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière[78] et les autres moyens de protection

71 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 1.
72 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 1.
73 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 2.
74 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 3.
75 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 4.
76 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 5.
77 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 2.
78 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 3.

envisageables[79] afin d'isoler ceux susceptibles de se retrouver au sein d'un régime paneuropéen applicable à tout type de scission transfrontalière. Les aspects temporels, et plus précisément le point de départ et la durée des différents mécanismes de protection sélectionnés, seront ensuite étudiés car ces derniers sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le caractère équilibré et proportionné d'un régime de protection[80]. Le régime auquel cette analyse aboutira ne devra toutefois pas être figé mais, au contraire, devra faire preuve d'une certaine flexibilité afin de pouvoir être allégé dans le cadre de certaines scissions transfrontalières emportant moins de risques pour les créanciers des sociétés impliquées[81]. Il serait en outre erroné de considérer ce régime de manière isolée car d'autres branches du droit sont susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur le degré de protection dont devront bénéficier les créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière. Ce sera ainsi tout particulièrement le cas du droit de l'insolvabilité dont les interactions avec un régime de protection relevant en premier lieu du droit des sociétés se devront d'être clarifiées[82]. Il importera ensuite de préciser comment ce régime devra s'articuler avec la protection des titulaires de titre autres que des actions auxquels sont attachés des droits spéciaux dans la mesure où ces derniers constituent une catégorie très particulière de créanciers[83]. À la suite de cet examen, il sera possible d'aborder la délicate question de la forme que devra revêtir l'harmonisation de la protection des créanciers dans le cadre des scissions transfrontalières au sein de l'Union européenne[84].

17. Les enjeux de la protection des associés minoritaires. Certes moins évidente *a priori* que la question de la protection des créanciers, la question de la protection des intérêts des associés minoritaires dans le cadre d'une scission transfrontalière n'en revêt pas moins une certaine importance. En effet, ces derniers encourent de nombreux risques du fait qu'ils sont susceptibles de se voir imposer une opération dont les conditions auront été dictées par les associés majoritaires. La première étape à l'égard de cette catégorie particulière de *stakeholder* en vue de la détermination d'un régime cohérent des scissions transfrontalières sera par conséquent d'identifier les différents risques auxquels ces derniers sont exposés et contre lesquels il conviendra, le cas échéant, de les protéger[85]. La deuxième étape consistera à déterminer les différentes positions d'équilibre auxquelles tout régime de protection des intérêts des associés minoritaires devra répondre. En effet, il est impossible d'étudier les spécificités de leur protection sans tenir compte de l'impact qu'un tel régime pourrait avoir sur l'accès des sociétés aux capitaux, l'intérêt des sociétés concernées à réaliser opération économiquement indispensable à la continuation de l'entreprise, les intérêts des créanciers à ce que les mécanismes de protection des associés minoritaires n'entraînent pas une érosion excessive

79 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 4.
80 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 2.
81 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 3.
82 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 4.
83 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 5.
84 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 6.
85 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 1.

du patrimoine ou des liquidités de la société concernée[86] et la nécessité qu'un tel régime ne constitue pas une entrave injustifiée à la liberté d'établissement des sociétés[87]. À l'instar de ce qui aura été fait pour les créanciers, il importera également de se prononcer sur la nécessité de protéger davantage les associés soumis à un changement de *lex societatis* que ceux qui n'y sont pas exposés[88]. Ces étapes préalables permettront d'aborder l'analyse des mécanismes de protection des associés minoritaires instaurés par le législateur européen et de les comparer aux mécanismes de deux juridictions moins protectrices des intérêts des associés minoritaires en matière de mobilité, à savoir la Belgique et le Luxembourg, et de deux juridictions disposant des régimes parmi les plus élaborés en la matière, à savoir l'Allemagne et l'Autriche[89]. Les conclusions tirées de cet exercice seront complétées par une prise de position sur la forme que devrait revêtir une éventuelle harmonisation européenne en la matière[90] ainsi que par une analyse des différents aspects temporels d'un régime de protection des associés minoritaires[91].

18. Les enjeux d'une scission transfrontalière pour la participation des travailleurs. Au-delà des créanciers et des associés minoritaires, une scission transfrontalière est également susceptible d'avoir de nombreux impacts sur la situation des travailleurs des sociétés concernées[92]. Cependant, la présente étude n'a pas vocation à analyser chacune des éventuelles conséquences sociales d'une scission transfrontalière, mais se concentrera sur un aspect de droit social qui est tout particulièrement susceptible d'être impacté par une scission transfrontalière et qui, contrairement à ce qui est généralement le cas[93], ne dépend pas d'un rattachement au droit du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail[94], mais d'un rattachement à la *lex societatis*. Cet aspect n'est autre que la très sensible question de la préservation de la participation des travailleurs[95]. Cette dernière ne manquera en effet pas de constituer un enjeu non négligeable d'une scission transfrontalière dans la mesure où ce type d'opération pourrait aisément être utilisé pour l'éluder. Comme pour les deux autres catégories de *stakeholders*, le point de départ consistera à identifier avec

86 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 2.
87 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 3.
88 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 4.
89 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 5.
90 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 6.
91 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 7.
92 Voir en ce sens : J. ROEST, « Corporate Mobility – The involvement of employees », *ECFR*, 1-2/2019, p. 84.
93 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 88 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Company Law Package », *NJW*, 2019, p. 1906 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts: Das "EU-Company Law Package 2018" », *NZG*, 2019, p. 246 et Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, pp. 10 et 11.
94 Art. 8, § 2 du Règlement Rome I et Étude d'impact, p. 39.
95 Par « participation », on entend on entend « l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société (i) en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ; ou (ii) en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer ». Voir art. 2, k) de la directive (CE) 2001/86 du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, *J.O.*, L 294, 10 novembre 2001, pp. 22–32 (ci-après la « **Directive Participation des Travailleurs** »).

précision les risques posés par une scission transfrontalière à cet égard[96], tout en rappelant la dimension politique significative de la matière[97] et la nécessité de parvenir à un équilibre tant sous l'angle des intérêts des différents *stakeholders*[98] que sous celui de l'incidence de la liberté d'établissement[99]. L'étude détaillée des dispositions de la Directive Mobilité en la matière et la comparaison avec le régime des fusions transfrontalières tant avant qu'après l'adoption de la Directive Mobilité permettront ensuite de dresser les contours qu'un régime plus général des scissions transfrontalières devrait revêtir s'il devait s'inspirer du régime mis en place par la Directive Mobilité tant à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés que des fusions transfrontalières[100]. Le régime auquel cet exercice aboutira méritera ensuite d'être examiné à l'aune de la liberté d'établissement et ce, afin de pouvoir tirer certains enseignements sur la nécessité d'une réforme plus globale de ce régime, même s'il ne s'agira pas là d'un préalable nécessaire à la consécration d'un régime plus général des scissions transfrontalières[101].

19. **Une délicate articulation entre les mécanismes de protection.** Au terme de cette étude détaillée du régime de protection tant des créanciers que des associés minoritaires et des travailleurs, il sera possible de porter un jugement éclairé sur l'éventuelle interdépendance entre les différents régimes. En effet, il serait logique que l'efficacité du système défensif des créanciers soit intimement liée à la proportionnalité des mécanismes de protection des associés minoritaires et des travailleurs qui ne peuvent ni entraîner une érosion financière excessive, ni constituer un obstacle démesuré à la réalisation d'une opération dont pourrait dépendre le désintéressement ultime des créanciers. Si cette interdépendance se vérifie, il sera ainsi possible d'identifier certains aspects du régime actuel des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés qui mériteraient d'être améliorés dans le cadre d'une nouvelle initiative européenne en matière de mobilité transfrontalière.

20. **L'avenir des scissions transfrontalières.** Procéder de la sorte permettra de tirer des conclusions non seulement sur le meilleur moyen pour faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne tout en protégeant efficacement et proportionnellement les intérêts des différents *stakeholders*, mais également sur l'état d'avancement précis de la mise en place d'un régime paneuropéen des scissions transfrontalières. En effet, il est fort possible qu'un certain nombre d'indices disséminés dans la Directive Mobilité laissent déjà la prochaine étape apparaître en transparence.

96 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 2.
97 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 3.
98 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 4.
99 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 5.
100 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 6.
101 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 7.

Partie I
Les scissions transfrontalières sous l'angle des parties immédiates

SOMMAIRE

Introduction de la première partie 53
Titre I. Les scissions transfrontalières, un procédé de déconcentration économique des entreprises 57
Titre II. Les scissions transfrontalières sous l'angle des libertés fondamentales 129
Titre III. Les scissions transfrontalières : entre droit international privé et initiatives nationales 229
Titre IV. Company law package et nécessité d'une nouvelle initiative européenne 285
Titre V. Les contours d'un régime européen des scissions transfrontalières ... 367
Conclusion de la première partie 553

Introduction de la première partie

21. Plan de la première partie. Cette première partie a pour principal objectif d'étudier les scissions transfrontalières sous l'angle des parties immédiates, à savoir les sociétés concernées et leurs associés majoritaires contrôlant l'opération. Ainsi, après avoir précisé la notion de scission transfrontalière, délimité plus précisément l'objet de recherche et justifié l'intérêt économique considérable des scissions transfrontalières (titre I), il sera examiné successivement si ce mode de restructuration pourrait devenir une réalité au sein de l'Union européenne par le biais de la jurisprudence de la Cour de justice tant en matière de liberté d'établissement que de libre circulation des capitaux (titre II), des principes de droit international privé applicables et des initiatives nationales existant à cet égard (titre III) et de la récente initiative du législateur européen sous la forme du *company law package* (titre IV). Face aux insuffisances de chacune de ces approches, les contours d'un régime paneuropéen applicable à tout type de scission seront esquissés (titre V), ce qui permettra de tirer de précieux enseignements sur l'avenir des scissions transfrontalières au sein de l'Union européenne.

TITRE I
Les scissions transfrontalières, un procédé de déconcentration économique des entreprises

SOMMAIRE

Introduction du titre I 59
Chapitre 1. Définition et comparaison avec d'autres types de restructuration 63
Chapitre 2. L'intérêt économique des scissions 71
Chapitre 3. La nature juridique des scissions 97
Chapitre 4. Les éléments caractéristiques des scissions transfrontalières 107
Conclusion sur le procédé de déconcentration économique que constituent les scissions transfrontalières 125

Introduction du titre I

22. Plan du titre I. Ce premier titre a tout d'abord pour objet de définir la notion de scission transfrontalière en la replaçant au sein des autres types de restructuration (chapitre 1) pour ensuite se pencher sur l'utilité économique des scissions transfrontalières (chapitre 2). Par après, en vue de préciser l'objet de la présente étude, la nature juridique (chapitre 3) et les éléments caractéristiques (chapitre 4) d'une telle opération seront examinés en détail.

Chapitre 1
Définition et comparaison avec d'autres types de restructuration

SECTION 1. DÉFINITION

23. Scission avec ou sans constitution de nouvelles sociétés. Le législateur européen définit une scission totale (*split-up* en anglais et *Aufspaltung* en allemand) comme l'opération par laquelle une société transfère à au moins deux sociétés bénéficiaires l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, par le biais d'une dissolution sans liquidation et moyennant l'attribution aux associés de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces. Si les sociétés bénéficiaires sont des entités existantes, l'opération est dite par absorption[102]. En revanche, si le transfert de patrimoine s'opère en faveur de nouvelles sociétés, la scission sera dite par constitution de nouvelles sociétés[103]. Un panachage entre ces deux formes, fréquent en pratique dans le cadre de la constitution de groupes de sociétés par voie de filialisation[104], est possible et est qualifié de scission mixte. Pour que la scission puisse être qualifiée de « transfrontalière », au moins deux des sociétés impliquées devront être régies par des droits nationaux différents[105].

24. Opérations assimilées. Au-delà de ces premières hypothèses, trois types d'opérations déviant légèrement de ces définitions sont susceptibles de bénéficier d'une assimilation aux scissions. Il s'agit tout d'abord du cas de la scission partielle (*spin-off* en anglais et *Abspaltung* en allemand), qui recouvre l'opération lors de laquelle la société scindée ne se trouve pas dissoute[106] et ensuite, du cas dans lequel la soulte en espèces dépasse la limite des dix pour cent[107], ce qui se rapproche dès lors davantage d'une opération de rachat[108]. Pour finir, les « scissions silencieuses », qui représentent un cas particulier de scission partielle[109], désignent l'opération par laquelle la société scindée transfère sans dissolution une partie de son patrimoine à une autre société qui est déjà titulaire de la totalité de ses actions et autres titres conférant un droit de vote[110],

102 Art. 136, § 1 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 169, 30 juin 2017, pp. 46–127 (ci-après la « **Directive Sociétés** »).

103 Art. 155, § 1 de la Directive Sociétés.

104 J.-M. MOULIN, « Fusion, scission et apport partiel d'actif », *Répertoire de droit des sociétés*, Paris, Dalloz, p. 69, www.dalloz.fr (26/08/2016).

105 Art. 160*bis*, § 1er de la Directive Mobilité.

106 Art. 159 de la Directive Sociétés.

107 Art. 158 de la Directive Sociétés.

108 S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 127 ; B. NAGEL, « Die Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung », *NZG*, 2006, p. 97 ; H.-W. NEYE, « Die neue Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *ZIP*, 2005, p. 1894 et Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches to cross-border mergers: exercising the right of establishment », *E.L. Rev.*, 2011, 36(1), p. 95.

109 Voir en ce sens : Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 300 et D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés : première analyse du Livre 12 du CSA » in K. GEENS et G. HORSEMANS, *Le projet de Code des sociétés et associations – Het ontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen*, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 325 et 326, n° 3.

110 Ce dernier type de scission assimilée est, à titre d'illustration, explicitement prévu par l'art. 12:8, 2° du CSA. Voir à ce sujet : Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 300 et D. WILLERMAIN, *ibidem*, pp. 331 et 332, n° 9.

de sorte que cette dernière opération, contrairement à une scission partielle classique, ne s'accompagne pas d'une émission d'actions[111].

SECTION 2. SCISSIONS ET AUTRES RESTRUCTURATIONS

25. Plan de la section 2. Afin de préciser la notion de scission transfrontalière, il est utile de la comparer successivement aux fusions transfrontalières (§ 1), aux apports d'actifs (§ 2), aux transformations transfrontalières (§ 3) et aux transferts de siège (§ 4).

§ 1. Scissions et fusions transfrontalières

26. Fusion avec ou sans constitution de nouvelle société. Par « fusion » (*merger* en anglais et *Verschmelzung* en allemand), on entend l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société bénéficiaire, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l'autre société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas dix pourcents de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts. Si la société bénéficiaire est préexistante, la fusion sera dite « par absorption »[112], alors que si elle est créée dans le cadre de l'opération, elle sera dite « par constitution de nouvelle société »[113]. À ces deux premières hypothèses s'ajoute encore celle des « fusions silencieuses » au cours desquelles une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social[114]. Une fusion sera dite « transfrontalière » si au moins deux des sociétés impliquées sont régies par des droits nationaux différents[115][116].

27. Un fort lien de parenté. Les opérations de scission entretiennent un lien de parenté très particulier avec les fusions[117] dans la mesure où, d'une part, elles

111 Selon l'art. 151, § 2 a) (scissions internes) de la Directive Sociétés et l'art. 160*novodecies*, § 6 de la Directive Mobilité, aucune action de la société bénéficiaire ne sera échangée contre les actions de la société scindée détenue par la société bénéficiaire elle-même. Il s'ensuit qu'en cas de scission partielle d'une société au profit d'une société qui détient l'intégralité des actions de cette société scindée, la scission ne s'accompagnera pas d'une émission d'actions. À ce sujet, voir *infra* n°s 113 à 117.

112 Art. 119, § 2, a) de la Directive Sociétés.

113 Art. 119, § 2, b) de la Directive Sociétés.

114 Art. 119, § 2, c) de la Directive Sociétés.

115 Art. 118 de la Directive Sociétés.

116 Pour une étude détaillée de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fusions transfrontalières, voir *infra* n°s 149 à 198.

117 L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 1 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, 2013, p. 414 ; H. LAMON, *op. cit.*, p. 125 et Th. PRÜM, *op. cit.* p. 16 ; A. REIK, *op. cit.*, p. 300 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 347 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 6, n° 9 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27 ; Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 13 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit belge après la transposition de la directive 2005/56/CE », *RPS*, 2009, p. 50, n° 71.

en constituent le reflet économique et d'autre part, toutes deux entraînent des effets parallèles[118]. Ainsi, tant les fusions que les scissions impliquent une dissolution sans liquidation de la société apporteuse, une transmission de patrimoine et l'attribution de nouvelles actions aux associés de la société apporteuse[119]. De plus, toute fusion est réversible par le biais d'une scission et vice versa[120].

§2. Scissions et apports d'actifs

28. Une notion vaste. Par « apport d'actifs » (*hive-down* en anglais et *Ausgliederung* en allemand), on entend l' « opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport »[121]. Par « branche d'activités », on entend l' « ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens », étant entendu que l'apport peut concerner la totalité des éléments d'actifs et passifs composant le patrimoine de la société apporteuse[122]. Cette notion n'est pas sans rappeler de prime abord une augmentation de capital par le biais de l'émission de nouvelles actions dont le prix de souscription serait payé en nature, les principales différences étant toutefois que l'apport d'actifs soumis à une procédure analogue à celle de scission entraîne (i) une transmission à titre universel des éléments d'actifs et de passifs transférés[123] et (ii) lorsque la société en question est soumise à un régime de

118 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 90 ; M. FRITZ, *Die Spaltung von Kapitalgesellschaften – Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Reformvorschläge*, Köln, Otto Schmidt, 1991, p. 21 ; H. HAHN, « Zum Gläubigerschutz bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften – Eine vergleichende Untersuchung des Entwurfs eines handelsrechtlichen Umwandlungsgesetzes vom 3. 8. 1988 und des französischen Gesetzes vom 24. 6. 1966 über die Handelsgesellschaften », *GmbHR*, 1991, p. 244 ; Th. PRÜM, *ibidem*, p. 16 et A. SCHWANNA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *Umwandlungsgesetz*, 5e éd., C. H. Beck, München, 2021, § 125, n° 1.

119 Art. 89, § 1er (fusion par absorption) ; 90, § 1er (fusion par constitution de nouvelle société) ; 136, § 1er (scission par absorption) ; 155, § 1er (scission par constitution de nouvelles sociétés) et 119, § 2 (fusions transfrontalières) de la Directive Sociétés et art. 160*ter*, 4), a) et b) de la Directive Mobilité (scissions transfrontalières).

120 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 16.

121 Art. 2, d) la directive (CE) 2009/133 du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre (version codifiée), *J.O.*, L 310/34, 25 novembre 2009, pp. 34–46 (ci-après la « **Directive Fiscale** »).

122 Il est intéressant de relever que certains droits nationaux opèrent en sus une distinction en fonction de l'étendue de la fraction du patrimoine de la société apporteuse ainsi transféré. Par ordre croissant, on retrouve ainsi (i) dans la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, les apports d'actifs (art. 1040-2), les apports de branche d'activité (art. 1040-3) et les apports d'universalité (art. 1040-4) et (ii) dans le CSA, les apports de branches d'activité (art. 12:10) et les apports d'universalité (art. 12:9).

123 Art. 1040-2 (apport partiel d'actif), 1040-3 (apport de branche d'activités) et 1040-4 (apport d'universalité) de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales ; 12:9 (apport d'universalité) et 12:10 (apport de branche d'activités) du CSA et § 123 (3) de l'Umwandlungsgesetz (UmwG), disponible sur https://www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021) (ci-après l' « **UmwG** ») et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *Umwandlungsgesetz*, 7e éd., Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 2020, § 123, n° 17.

participation des travailleurs[124], l'application de dispositions spécifiques destinées à protéger celle-ci[125].

29. Une notion proche de la scission partielle. Si les apports d'actifs sont très proches d'une scission partielle, la différence fondamentale entre les deux est que les actions ou titres de la société bénéficiaire de l'opération seront attribués à la société apporteuse et non aux associés de la société scindée[126]. En d'autres termes, alors qu'une scission partielle peut être qualifiée de scission horizontale, l'apport d'actifs constitue une forme de scission verticale[127].

30. La notion de « scission par séparation ». La Directive Mobilité, conformément aux recommandations faites en ce sens dans une des études préalables[128] et s'éloignant en cela de la terminologie qu'on retrouve dans la Directive Fiscale[129], mais également en droit belge[130] et en droit luxembourgeois[131], a intégré partiellement les apports d'universalité, de branche d'activités et d'actifs au sein de la famille des scissions en créant la notion de « *scission par séparation* », à savoir l'opération par laquelle « *une société scindée transfère une partie de ses éléments d'actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires* [nouvellement constituées au cours de l'opération] *moyennant l'attribution à la société scindée de titres ou d'actions dans les sociétés bénéficiaires* »[132]. S'il est indéniable que cette notion recouvre, à l'instar des scissions classiques, un procédé de déconcentration économique, on ne peut que relever que le fait que l'opération soit sans incidence sur les associés de la société scindée l'en distingue très nettement.

§ 3. Scissions et transformations transfrontalières

31. Une notion issue de la jurisprudence de la Cour de justice. Apparaissant pour la première fois dans un *obiter dictum* de la Cour de justice dans l'arrêt *Cartesio*[133], on entend par « transformation transfrontalière » (*cross-border*

124 Par « participation des travailleurs », on entend « l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société (i) en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ; ou (ii) en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer ». Voir art. 2, k) de la Directive Participation des Travailleurs.

125 § 325 UmwG.

126 J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 28 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 123, n° 11.

127 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 123, n° 12.

128 J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 29.

129 Voir art. 2, b), c), et d) de la Directive Fiscale.

130 Voir art. 12:4 à 12:8 du CSA pour les scissions et 12:9 à 12:11 du CSA pour les apports d'universalité ou de branche d'activités.

131 Voir art. 1030-1 à 1033-1 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales pour les scissions et art. 1040-1 à 1040-5 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales pour les transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité.

132 Art. 160*ter*, 4), b) de la Directive Mobilité.

133 C.J.C.E., gde ch., arrêt *CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt*, 16 décembre 2008, C-210/06, EU:C:2008:723, (ci-après l' « **arrêt *Cartesio*** »), pt. 111 où la Cour de justice a considéré qu' « un tel cas de transfert du siège d'une société constituée selon le droit d'un État membre dans un autre État membre sans changement du droit dont elle relève doit être distingué de celui relatif

conversion en anglais et *grenzüberschreitende Umwandlung* en allemand), l'opération par laquelle « une société, sans être dissoute, liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une forme juridique d'une société d'un État membre de destination et transfère au moins son siège social dans l'État membre de destination tout en conservant sa personnalité juridique »[134][135].

32. Un changement de droit applicable. Une transformation transfrontalière se distingue nettement d'une scission transfrontalière pour deux raisons. Tout d'abord, la première opération n'implique qu'une seule société isolée sans qu'il n'y ait de transmission de patrimoine ou d'échange de titres représentatifs du capital social. Ensuite, une transformation transfrontalière préserve la personnalité morale de la société scindée alors qu'une scission transfrontalière totale implique, par définition, la dissolution sans liquidation, et par conséquent la disparition, de la société scindée. Cependant, une scission transfrontalière s'apparente dans ses effets à une transformation transfrontalière dans la mesure où toutes deux s'accompagneront d'un changement du droit applicable aux associés[136], aux travailleurs[137] et, *a priori*, aux créanciers[138].

§4. Scissions transfrontalières et transferts de siège

33. Une opération volontaire ou involontaire. Par « transfert de siège » (*transfer of seat* en anglais et *Sitzverlegung* en allemand), on entend l'opération par laquelle une société transfère volontairement[139] ou involontairement[140] son siège social de son État membre d'origine vers un autre État membre[141]. Le transfert de siège est à distinguer clairement de l'hypothèse de la transformation transfrontalière car celui-ci ne s'accompagne pas d'une transformation volontaire de la forme juridique de la société concernée en une des formes juridiques de l'État membre de destination[142]. Par comparaison avec

au déplacement d'une société relevant d'un État membre vers un autre État membre avec changement du droit national applicable, la société se transformant en une forme de société relevant du droit national de l'État membre dans lequel elle se déplace ».

134 Art. 86*ter*, 2) de la Directive Mobilité.

135 Pour une étude détaillée de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transformations transfrontalières, voir *infra* n[os] 199 à 222.

136 Voir en ce sens : M. MENJUCQ, « Les opérations transfrontalières de rapprochement et de mobilité à l'épreuve de la diversité des droits nationaux », *Cah. dr. entr.*, n° 6, novembre 2011, dossier 34, disponible sur www.lexis360.fr (06/11/2020), p. 2. Sur l'impact d'une scission transfrontalière sur le droit applicable aux associés minoritaires, voir *infra* n° 982.

137 Sur l'impact d'une scission transfrontalière sur le droit applicable aux travailleurs, voir *infra* n° 1117.

138 Sur l'impact d'une scission transfrontalière sur le droit applicable aux créanciers, voir *infra* n° 699.

139 Pour un exemple pratique de transfert de siège volontaire, voir *infra* n[os] 172 les faits à l'origine de l'arrêt *Cartesio* où une société en commandite simple de droit hongrois dont le siège avait été établi en Hongrie, souhaitait transférer celui-ci en Italie, tout en continuant à relever du droit hongrois.

140 Pour un exemple pratique de transfert de siège involontaire, voir *infra* n[os] 186 et 187 les faits à l'origine de l'arrêt *Überseering* où une société de droit néerlandais a été considérée comme ayant transféré son siège de direction effective en Allemagne suite à l'acquisition de ses parts par deux ressortissants allemands tout en ne s'étant pas reconstituée selon le droit allemand.

141 Pour une étude détaillée de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transferts de siège, voir *infra* n[os] 167 à 197.

142 D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 55 et 56 et B. MEISTER, I. KLÖCKER et L. BERGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 190, n° 19.

la transformation transfrontalière, la société qui transfère son siège encourt le risque[143], à défaut de se reconstituer sous une forme sociale de l'État membre d'accueil, de se voir privée du bénéfice de la responsabilité limitée[144] ou encore de sa capacité juridique[145]. Cette distinction se trouve parfaitement illustrée par la question du sort à la suite du *Brexit* des sociétés britanniques (*limited liability partnerships*, *private companies limited by shares* et *public limited liability companies*) dont le siège réel était situé en Allemagne et qui, à défaut de se reconstituer sous une forme sociale de droit allemand, encouraient le risque de se voir requalifiées en sociétés à responsabilité illimitée (*Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR*) ou *offene Handelsgesellschaft (oHG)*), voire en cas de société unipersonnelle, en commerçant en nom personnel avec toutes les conséquences qui y sont associées[146].

34. Un point commun avec les scissions. Si tout comme les transformations transfrontalières, les transferts de siège se distinguent nettement des scissions transfrontalières par le fait qu'une seule société est impliquée, tous deux sont susceptibles d'avoir des effets similaires, dans le chef de la société scindée, dans la mesure où une scission transfrontalière est susceptible d'entraîner un déplacement du siège de direction effective de celle-ci dans l'État membre des sociétés bénéficiaires[147].

143 Sur l'incidence de la liberté d'établissement en la matière, voir *infra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1, Section 4.

144 Voir en ce sens : Al. AUTENNE et M. DE WOLF, « La mobilité transfrontalière des sociétés en droit européen : le cas particulier du transfert de siège social, regards croisés de droit des sociétés et de droit fiscal », *Cah. dr. eur.*, 2007, p. 658 ; B. GRZESZICK et D. VERSE, « Auswirkungen eines harten Brexit auf britische Gesellschaften in Deutschland – der Gesetzgeber ist gefordert ! », *NZG*, 2019, pp. 1130 et 1131 ; C. JUNG, « Die „deutsche" Limited als Gesellschaft sui generis? – Eine Diskussion bezüglich gesellschaftsrechtlicher Anerkennungsmöglichkeiten englischer Scheinauslandsgesellschaften », *GmbHR*, 2020, pp. 753 et 754 ; Chr. KUMPEN et Ph. PAUSCHINGER, « Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2016 », *EuZW*, 2016, pp. 331 et 332 ; S. ZWIRLEIN, H. GROSSERICHTER et A. GÄTSCH, « Handlungsoptionen für Gesellschaften englischen Rechts in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der LLP », *NZG*, 2017, p. 1042.

145 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1, Sections 4 et 5.

146 Voir en ce sens : B. GRZESZICK et D. VERSE, *op. cit.*, pp. 1130 et 1131 ; C. JUNG, *op. cit.*, pp. 753 et 754 et S. ZWIRLEIN, H. GROSSERICHTER et A. GÄTSCH, *op. cit.*, p. 1042.

147 Voir en ce sens : Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 16. Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 58 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, Bruxelles, Kluwer, 1993, p. 534, n° 750.

Chapitre 2
L'intérêt économique des scissions

35. Plan du chapitre 2. Afin d'appréhender de manière suffisamment précise les avantages économiques potentiellement générés par une opération de scission transfrontalière, et après avoir précisé qu'une telle opération ne s'inscrit pas nécessairement dans une stratégie défensive (section 1), il est important tout d'abord de replacer la scission au sein des autres modes de déconcentration des entreprises (section 2), pour ensuite analyser en détail les motifs poussant les entreprises à procéder à de telles opérations (section 3). Une fois que ce sera fait, il conviendra de se pencher sur la création de valeur engendrée par une scission (section 4).

SECTION 1. AVEU D'ÉCHEC OU TACTIQUE OFFENSIVE ?

36. Une aura négative. Contrairement aux opérations de concentration qui sont généralement parées d'une aura positive en raison de l'amalgame qui est fait entre celles-ci et la croissance d'une entreprise, les opérations de déconcentration ont longtemps été associées à l'aveu d'un échec[148]. Dans cette conception, qualifiée de défensive[149], une telle restructuration ne présente d'utilité que lorsque la branche d'activités n'a pas rencontré le succès escompté. Cependant, dans un contexte général prônant une désintégration progressive des entreprises qualifiées de monolithiques[150] à la suite de la reconnaissance du fait que la taille d'une entreprise ne représente pas une valeur en soi[151], les scissions vont progressivement, à l'instar de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, être davantage utilisées offensivement dans une perspective de création de valeur[152].

SECTION 2. TYPOLOGIE

37. Un vaste éventail d'opérations. Une opération de déconcentration, que l'on peut rapprocher de la notion anglo-saxonne de *demerger*, vise toute opération par laquelle une entreprise se retrouve éclatée en plusieurs éléments distincts. Cette terminologie peut être qualifiée de neutre dans la mesure où elle est indépendante tant du passé que de l'avenir de l'entreprise. En effet, elle ne requiert ni une intégration antérieure ni une intégration postérieure[153]. Au nombre des procédés de déconcentration économique, on compte notamment

148 D. BÖLLHOFF, Chr. BRAST, N. GRÜGER, *op. cit.*, p. 23 ; A. CASCORBI, *op. cit.*, 2003, p. 58 ; P. GHEMAVAT et F. GHADAR, *op. cit.*, p. 32 ; R. GRAML, *op. cit.*, 1996, p. 253 et H. W. WALLENDER III, *op. cit.*, p. 55.

149 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 1.

150 P. BRUPPACHER, « Unternehmensverkauf als strategischer Erfolgsfaktor », in *Meilensteine im Management: Mergers & Acquisitions*, Basel, Frankfurt am Main, Stuttgart, Helbing & Lichtenhahn / Schäffer Verlag für Wirtschaft und Steuern GmbH, 1990, p. 277. Au sujet de la vague des OPA aux États-Unis au cours des années 80 sur les sociétés multi-divisionnelles ayant fréquemment abouti au démantèlement des conglomérats, voir I. CORBISIER, *La société : contrat ou institution ?*, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 59–63.

151 A. CASCORBI, *op. cit.*, p. 1.

152 *Ibidem*.

153 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 9.

les *spin offs*[154] ainsi que les *split offs*[155] et les *split ups*[156], mais également d'autres types d'opérations tels que les apports d'actifs[157], l'*outsourcing*[158] ou encore les *equity carve-outs*[159], les *management buy-outs*[160], les *employee buy-outs*[161], mais également les *sell offs*[162][163]. Toutes ces opérations peuvent

154 Par *spin off*, d'un point de vue économique, on entend toute opération aboutissant à une déconcentration de l'entreprise d'origine par le biais de la création d'une ou de plusieurs nouvelles entités juridiquement indépendantes. Cette notion est utilisée de manière hétérogène et recouvre un vaste éventail de situations. À l'origine, elle désignait principalement l'opération qui consistait à confier des activités de recherche et développement à des entités juridiquement indépendantes de la société mère. À l'heure actuelle, une telle opération vise plus précisément la scission-distribution, soit la situation dans laquelle une société mère constitue, dans un premier temps, une nouvelle société et lui apporte une branche d'activités pour ensuite distribuer les actions de cette filiale à ses propres actionnaires sous forme de dividende payé en nature *au prorata* de leur participation dans la société mère. Cette opération, fréquente dans les pays anglo-saxons, est à rapprocher de la scission partielle, à ceci près qu'il n'y a pas d'échange de titres, mais une répartition proportionnelle des actions de la nouvelle société bénéficiaire de l'apport aux actionnaires de la société apporteuse. Elle se rapproche également de la notion de scission par séparation, à ceci près qu'en plus les actionnaires de la société apporteuse obtiendront des actions de la société bénéficiaire. Voir A. CASCORBI, *ibidem*, pp. 20 et 21 ; Th. KIRCHMAIER, *The Performance Effects of European Demergers*, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London, mai 2003, disponible sur http://papers.ssrn.com (20/05/2016), p. 1 ; Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, *Value creation through spin-offs: a review of the empirical evidence*, disponible sur http://papers.ssrn.com (20/05/2016), p. 1, et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 10 pour plus d'information.

155 Par *split off*, on entend l'opération de scission partielle, qu'elle soit par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou par combinaison des deux. Voir A. CASCORBI, *ibidem*, pp. 19 et 20 et Th. PRÜM, *ibidem*, p. 10 pour plus d'information.

156 Par *split up*, on entend l'opération de scission classique, qu'elle soit par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou par combinaison des deux. Voir A. CASCORBI, *ibidem*, p. 20 et Th. PRÜM, *ibidem*, p. 10 pour plus d'information.

157 Sur cette notion, voir *supra* n° 28.

158 Par *outsourcing*, on entend l'opération qui consiste, pour une entreprise, à externaliser certaines activités, telles que le marketing ou la gestion des ressources humaines, à des prestataires externes afin de réduire ses coûts. Cette stratégie repose sur le principe qu'il est parfois moins coûteux d'acquérir certains services auprès de prestataires externes que de les réaliser en interne. Voir www.investopedia.com et A. CASCORBI, *ibidem*, p. 21 pour plus d'information.

159 Par *equity carve-out*, également dénommé *subsidiary initial public offering* ou *partial public offering*, on entend l'opération par laquelle une société mère cède en bourse une participation minoritaire dans sa filiale directe à des investisseurs externes. Dans ce cas particulier, la déconcentration n'est pas totale dans la mesure où la société mère garde le contrôle de la filiale, que ce soit au niveau de l'actionnariat ou de la gestion. Ce type d'opération est généralement utilisé lorsqu'il n'existe pas d'acheteur susceptible de vouloir acquérir l'intégralité des actions de la filiale ou encore afin de permettre aux investisseurs d'accéder à la branche d'activités qui les intéresse le plus. Voir www.investopedia.com et A. CASCORBI, *ibidem*, p. 18 pour plus d'information.

160 Par *management buy-out*, on entend l'opération par laquelle les dirigeants d'une entreprise acquièrent une branche d'activités au sein de l'entreprise qu'ils gèrent. Une telle opération présente un intérêt pour les dirigeants dans la mesure où les bénéfices qu'ils pourront obtenir de la réussite potentielle de l'entreprise seront plus importants s'ils en sont également les propriétaires. Une telle stratégie de sortie est régulièrement utilisée par les conglomérats qui souhaitent se débarrasser de branches d'activité dépassant le cadre de leur *core business*. Voir www.investopedia.com ; D. BÖLLHOFF, *Demerger-Management – Eine empirische Analyse*, Wiesbaden, Gabler, 2009, p. 27 et A. CASCORBI, *ibidem*, p. 19 pour plus d'information.

161 Par *employee buy-out*, on entend l'opération par laquelle les travailleurs de la société acquièrent une participation majoritaire dans la société qui les emploie, généralement dans le cadre d'un *employee stock ownership plan*. Voir www.investopedia.com ; D. BÖLLHOFF, *ibidem*, p. 27 et A. CASCORBI, *ibidem*, p. 19 pour plus d'information.

162 Par *sell off*, on entend la cession de parties d'une entreprise négociée et conclue en dehors des marchés boursiers. Voir A. CASCORBI, *ibidem*, p. 17 pour plus d'information.

163 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 12.

être initiées pour des motifs divers qu'il convient d'analyser afin de pouvoir appréhender correctement l'enjeu économique des scissions transfrontalières.

SECTION 3. LES MOTIFS D'UNE SCISSION

38. Plan de la section 3. Après une brève présentation destinée à clarifier le fait qu'une scission se justifie généralement par une pluralité de motifs économiques (§ 1), huit objectifs susceptibles d'être réalisés au moyen d'une scission seront examinés successivement, à savoir la concentration sur le *core business* (§ 2), la limitation des effets de la décote de diversification (§ 3), la correction d'une asymétrie d'information (§ 4), la réorganisation face à des résultats financiers décevants (§ 5), la satisfaction de besoins excessifs en ressources et capitaux (§ 6), l'adaptation à l'environnement concurrentiel (§ 7), une défense face à une OPA hostile (§ 8) et la réalisation d'une concentration dans le respect des normes du droit de la concurrence ou d'autres objectifs purement juridiques (§ 9).

§1. Présentation

39. Une pluralité de motifs. Les objectifs poursuivis par les dirigeants d'une société dans le cadre d'une scission, et plus généralement dans le cadre d'une opération de déconcentration, sont très variés et sont susceptibles de s'insérer tant dans le cadre d'une stratégie défensive ayant pour objectif d'éviter une perte de valeur de l'entreprise, que dans le cadre d'une stratégie plus offensive visant à accroître la valeur de celle-ci[164]. De plus, quelle que soit la stratégie poursuivie dans le cadre de l'opération, celle-ci est susceptible d'être à court ou à long terme. Compte tenu de ces variables, il n'est pas surprenant de constater qu'en pratique, une scission se justifie généralement par une pluralité de motifs[165]. La typologie reprise ci-dessous a pour objectif de mettre en lumière les principales raisons poussant une entreprise à se séparer d'une de ses branches d'activités, mais n'a pas vocation à être exhaustive dans la mesure où des considérations propres à chaque entreprise entrent en ligne de compte dans ce type d'opérations.

§2. La concentration sur le core business

A. *Présentation*

40. L'éclatement des conglomérats. Au cours des années 1970, les entreprises ont démontré une forte tendance à former des conglomérats en s'aventurant dans des domaines d'activités différant considérablement de leur *core business*. Les raisons pour une telle diversification étaient multiples et résidaient, notamment, dans une volonté de répartir les risques, de réaliser des économies

164 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 1.
165 A. CAMPBELL, « When a spinoff makes strategic sense », *Harvard Business Review*, 2014/08, p. 1, disponible sur https://hbr.org (06/01/2017) et CASCORBI, *ibidem*, p. 54.

d'échelle, de bénéficier d'un accès aux capitaux plus aisé ou encore dans une volonté d'expansion effrénée de la part des dirigeants d'entreprise[166]. Cette tendance s'est par la suite inversée et, à partir des années 1980, on a pu observer une volonté de la part de certains grands conglomérats de se débarrasser soit de branches d'activités externes obtenues suite à une volonté de diversification dont les bienfaits pour l'entreprise avaient été surestimés[167] (B), soit de branches d'activité distinctes du *core business* et engendrant des synergies négatives au sein du groupe (C), soit encore de branches d'activité qui entraient auparavant dans le *core business*, mais étaient devenues obsolètes (D).

B. *L'hypothèse de la correction d'erreur*

41. La volonté de corriger une erreur de jugement. La nécessité d'une déconcentration peut ainsi découler d'une volonté de correction d'une erreur d'estimation de la part des dirigeants de l'entreprise qui ont fait preuve d'une forme d'*hybris*[168] et ont acquis une branche d'activités à un prix d'acquisition excédant sa valeur de marché en surestimant leur capacité à créer des synergies et à résoudre les problèmes d'intégration accompagnant l'acquisition en question[169]. Cette théorie, dénommée « *correction of mistake hypothesis* »[170], a été vérifiée empiriquement en analysant le cours des actions de l'entreprise acquéreuse. Ainsi, celui-ci va tout d'abord chuter à la suite de l'annonce de l'acquisition de la branche d'activités dont le marché ne perçoit pas l'intérêt direct pour l'entreprise, pour ensuite grimper à la suite de la correction de l'erreur par le biais de l'annonce du rejet de cette même branche d'activités, par exemple par le biais d'une scission suivie d'une vente[171].

42. Illustration : la scission de Procter & Gamble. Face à l'échec essuyé par le géant Procter & Gamble à la suite de son incapacité à parvenir à dépasser le groupe L'Oréal dans le secteur de la beauté, celui-ci a décidé en juillet 2015 de céder ses activités dans le parfum, le maquillage et les shampoings destinés aux salons de coiffure au groupe de cosmétiques Coty. Pour des raisons en toute vraisemblance d'optimisation fiscale, l'opération de cession a été structurée en deux temps par le biais de ce qui est qualifié de « *reverse Morris Trust transaction* »[172] aux États-Unis. Lors d'une première étape, une

166 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 38.

167 D. BÖLLHOFF, *op. cit.*, p. 17 ; A. CAMPBELL, *op. cit.*, p. 1 ; A. CASCORBI, *ibidem*, p. 38 et Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, *op. cit.*, p. 1.

168 A. CASCORBI, *ibidem*, pp. 35 et 36 et M. HAYWARD et D. HAMBRICK, « Explaining the premiums paid for large acquisitions: Evidence of CEO hubris », *Administrative Science Quarterly*, 1997/42, pp. 103 et s.

169 D. BÖLLHOFF, *op. cit.*, p. 16 et M. HAYWARD et D. HAMBRICK, *op. cit.*, pp. 103 et s.

170 J. ALLEN, S. LUMMER, J. Mc CONNELL et D. REED, « Can takeover losses explain spin-off gains? », *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1995/4, pp. 471 et 479 et s. ; A. CASCORBI, *op. cit.*, pp. 35 et 36 et M. HAYWARD et D. HAMBRICK, *op. cit.*, pp. 103 et s.

171 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 35.

172 Selon H. HICKS, D. LEVERE et R. STEVENSON, « [t]*he typical "Morris Trust" transaction involves a distributing corporation ("Public Distributing") that is a U.S. corporation and a controlled corporation ("Public Controlled") that is also a U.S. corporation. Public Distributing spins Public Controlled (new or existing) to its public shareholders (the "Public Spin") in preparation for the acquisition of Public Distributing in a nontaxable transaction by an unrelated (usually also domestic) corporation ("Acquiror"). An RMT transaction, in contrast, while also a divestiture transaction, involves Public Distributing spinning Public*

scission de The Procter & Gamble Company a été réalisée afin de parvenir à isoler les différents actifs et passifs au sein d'une entité séparée, dénommée Galleria Co., valorisée à plus de 12,5 milliards de dollars. Cette nouvelle entité a ensuite fusionné avec Green Acquisition Sub Inc., une entité du groupe Coty pour donner naissance au leader mondial des parfums et le troisième acteur mondial dans le secteur de la beauté[173].

C. *L'hypothèse des synergies négatives*

43. La notion de synergie négative. La nécessité de se recentrer sur le *core business* par le biais d'une opération de déconcentration peut également être la conséquence de l'apparition de synergies négatives, soit de situations dans lesquelles, à la suite de l'intégration d'une nouvelle branche d'activités, les coûts opérationnels sont supérieurs lorsque deux entreprises sont gérées conjointement par rapport à ceux encourus lorsque ces deux mêmes entreprises sont gérées séparément[174].

44. Les causes des synergies négatives. De telles synergies négatives font surface lorsque les coûts de coordination et de contrôle excèdent les avantages engendrés par la concentration. D'un point de vue empirique, de telles synergies négatives s'observent lorsque le succès d'une branche d'activités n'entrant pas dans le champ du *core business* d'une entreprise à la suite d'une opération de déconcentration s'avère supérieur à celui de branches d'activités déconcentrées et entrant dans le champ du *core business* d'une entreprise[175]. Les origines de ces synergies négatives sont tout d'abord à rechercher dans les défaillances du positionnement concurrentiel de l'entreprise qui sont dues à l'absence d'objectifs clairs ainsi qu'à l'incapacité de l'entreprise de se concentrer sur des activités clés, mais également dans des insuffisances organisationnelles dues à

Controlled in preparation for the nontaxable acquisition of Public Controlled by Acquiror. Hence, the "reverse" part of the name ». Sur cette notion, voir H. HICKS, D. LEVERE et R. STEVENSON, « Select cross-border tax issues in reverse morris trust transactions », *International Tax Journal*, November – December 2017, pp. 6 et s. Au sujet de l'opération impliquant The Procter & Gamble Company et Coty Inc., voir : A. SLOAN, « For tax techis, P&G's deal with Coty is a thing of beauty », *The Washington Post*, 16 juillet 2015, disponible sur https://www.washingtonpost.com (07/09/2020).

173 S. CAVALE et A. WENDLANDT, « Coty buying P&G beauty business for $12.5 billions », 9 juillet 2015, disponible sur https://www.reuters.com (07/09/2020) ; J.-B. JACQUIN, « Procter & Gamble – Coty : l'obsession fiscale pollue la stratégie », *Le Monde*, 10 juillet 2015, disponible sur https://www.lemonde.fr (07/09/2020) et I. LETESSIER, « Coty et Procter créent un géant de la beauté », *Le Figaro*, 10 juillet 2014, disponible sur https://www.lefigaro.fr/societes/2015/07/09/20005-20150709ARTFIG00265-coty-et-procter-creent-un-geant-de-la-beaute.php (17/02/2017). Voir également : Prospectus of The Procter & Gamble Company offer to exchange all the shares of common stock of Galleria Co. that are owned by The Procter & Gamble Company and will be converted into shares of class A common stock of Coty Inc. for shares of common stock of The Procter & Gamble Company, September 1st, 2016, disponible sur https://www.sec.gov (07/09/2020), pp. 156–198.

174 D. BÖLLHOFF, *op. cit.*, 16 ; A. CASCORBI, *op. cit.*, p. 36 ; S. LINN et M. ROZEFF, « The effect of voluntary spin-off on stock prices : the anergy hypothesis », *Advances in Financial Planning and Forecasting*, 1985, p. 273 et S. THISSEN, *Strategisches Desinvestitionsmanagement : Entwicklung eines Instrumentarium zur Bewährung ausgewählter Desinvestitionsformen*, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2000, p. 157.

175 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 36 et G. MÜLLER-STEWENS, M. SCHÄFER et G. SZELESS, « Wertschaffung durch strategische Desinvestitionen », *M&A Review*, 2001/1, p. 14.

la mauvaise allocation des ressources[176], des coûts de coordination élevés ou encore à l'absence d'incitants pour les dirigeants et employés[177].

45. L'impact d'une scission. La scission d'un conglomérat présentant des synergies négatives permettra tout d'abord de réduire les coûts de coordination en établissant une structure hiérarchique plus accessible et en fixant des objectifs clairs, propres à chaque entité issue de l'opération. La restructuration permettra ensuite aux entités issues de la scission d'être plus concurrentielles en raison d'une plus grande proximité avec le marché, d'une flexibilité et d'une capacité d'innovation accrues, d'un temps de réaction réduit et de la possibilité d'intervenir de manière plus active sur le marché[178]. Il s'ensuivra une augmentation de la valeur de l'entreprise à la suite de la suppression ou, le cas échéant, à la réduction des synergies négatives qui est qualifiée d' « effet de séparation »[179] et qui se traduira par une réaction positive des marchés[180].

46. Illustration : la scission d'Eridania-Béghin-Say (EBS). Le gigantesque conglomérat EBS, dont l'activité consistait principalement en la transformation de matières premières d'origine agricole, fut créé en 1992 à la suite de la fusion entre le groupe italien Eridania et le groupe français Béghin-Say[181]. Il était caractérisé par une très forte diversification tant au niveau géographique qu'au niveau de ses activités, ainsi que par le peu de synergies existant entre ses différentes activités. Malgré une progression continue de son chiffre d'affaires pendant les cinq premières années, le groupe a connu une baisse significative de son résultat d'exploitation et de sa marge nette, ce qui a entraîné une hausse considérable de sa dette, celle-ci ayant atteint le montant considérable de trois milliards d'euros. Cependant, cette situation globale difficile masquait de fortes disparités entre les différentes branches d'activités du groupe. En effet, si la branche Ceresure avait été fortement impactée par la faiblesse du cours du sucre et du peu de volumes exportés, la branche Provimi se chargeant du secteur de la nutrition animale avait vu son chiffre d'affaires croître d'année en année tout en n'étant que très peu endettée. Cependant, elle a souffert de la mauvaise allocation des ressources au sein du groupe et d'un accès plus difficile aux capitaux en raison de la mauvaise santé financière du conglomérat. Face à cette situation, le groupe a été scindé en juillet 2001 par le biais de la constitution de quatre nouvelles sociétés, à savoir Béghin-Say, qui a obtenu l'activité sucrière, Cereol, qui a obtenu l'activité oléagineuse, Cerestar, qui a obtenu l'activité de fourniture de produits à base d'amidon et Provimi, qui a obtenu l'activité de nutrition animale[182]. La réaction des marchés a été immédiate et

176 P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *Finance d'entreprise*, 2017, Paris, Dalloz, p. 1187.
177 A. ANDRUSHKO, « The Reverse Synergy : Another Way of Thinking », *I.J.E.P.T.*, avril 2012, vol. 2, n° 2, p. 60 et A. CASCORBI, *op. cit.*, pp. 36 et 37.
178 A. ANDRUSHKO, *op. cit.*, p. 60 ; A. CASCORBI, *ibidem*, p. 37 et P. DOMADENIK, L. LIZAL et M. PAHOR, « The effect of enterprise break-ups on performance. The case of the former Yugoslav Republic of Macedonia », *Revue économique*, 2012/5 (Vol. 63), p. 851.
179 D. BÖLLHOFF, *op. cit.*, p. 16 ; A. CASCORBI, *ibidem*, p. 36 ; R. GRAML, *op. cit.*, p. 94 et S. THISSEN, *op. cit.*, p. 157.
180 D. BÖLLHOFF, *ibidem*, p. 16.
181 P. BARNETO, « Scission et option d'abandon d'un conglomérat », *Finance*, 2002/15, p. 50.
182 « La scission d'Eridania Béghin-Say bénéfique aux actionnaires », *Les Echos*, 21 août 2001, disponible sur www.lesechos.fr (23/02/2017).

le premier jour, le titre Béghin-Say a progressé de 94 % par rapport au prix de référence calculé par la Bourse de Paris, alors que le titre Cerestar a perdu 27 %[183]. À la suite de l'opération, les quatre sociétés ont bénéficié d'un accès individuel au marché des capitaux, ont profité de davantage de latitude pour l'allocation de leurs ressources et ont joui d'une liberté stratégique accrue leur permettant de nouer des alliances rendues nécessaires par l'évolution de leur environnement concurrentiel[184]. En d'autres termes, la scission a permis de supprimer les synergies négatives qui affectaient l'ancien conglomérat.

D. *L'hypothèse de la réorientation stratégique*

47. Une stratégie tournée vers l'avenir. Contrairement aux deux premières hypothèses qui concernaient le cas d'un retour en arrière en vue de se concentrer sur un *core business* déjà existant, la réorientation stratégique vise le cas de la modification du *core business* d'une entreprise dont les activités clés ont perdu en attractivité[185]. L'objectif ici sera de désintégrer un conglomérat afin de permettre à l'entreprise de concentrer ses efforts sur de nouveaux secteurs d'activités prometteurs en se débarrassant de ses anciennes activités principales en perte de vitesse.

48. Illustration : la scission de Philips. En septembre 2014, le groupe néerlandais Philips a annoncé son intention de se scinder afin de séparer son pôle éclairage, activité historique du groupe, de ses activités de production d'appareils médicaux destinés aux professionnels et d'appareils électroniques destinés au grand public. En effet, le groupe, numéro un mondial de l'éclairage et actif dans ce secteur depuis 1891, avait dû faire face au retrait des ampoules à filament et devait encore affronter celui des ampoules éco-halogènes aux profits d'éclairages LED, dont la production était dominée par ses concurrents asiatiques[186]. Face à cette situation, l'externalisation du pôle éclairage en vue d'une reprise ultérieure par un industriel constituait une réorientation stratégique du groupe indispensable pour éviter sa disparition[187].

§ 3. La limitation des effets de la décote de diversification

49. Un effet propre aux conglomérats. Il ressort d'une étude de Philip Berger et d'Eli Ofek que la valeur d'un conglomérat diversifié est inférieure de 13 % à 15 % à la somme des valeurs des différentes branches d'activités le composant[188]. En d'autres termes, les actions d'un conglomérat font l'objet d'une

183 « La scission d'Eridania Béghin-Say bénéfique aux actionnaires », *Les Echos*, 21 août 2001, disponible sur www.lesechos.fr (23/02/2017).
184 P. BARNETO, *op. cit.*, p. 52.
185 A. CASCORBI, *op. cit.*, p. 39 et Étude d'impact, p. 23.
186 D. BURG et T. VILARS, « Philips engage une scission historique de ses activités », *Les Echos*, 23 septembre 2014, disponible sur www.lesechos.fr (21/02/2017).
187 L. DELANGEAIS, « Comment Frans van Houten a métamorphosé Philips », *Capital*, 10 février 2016, disponible sur www.capital.fr (21/02/2017).
188 P. BARNETO, *op. cit.*, p. 48 ; D. BÖLLHOFF, *op. cit.*, p. 18 et P. G. BERGER et E. OFEK, « Diversification's effect on firm value », *Journal of Financial Economics*, 1995/37, p. 40.

décote de diversification sur les marchés[189]. Cette décote est due notamment au fait que les conglomérats ont des coûts de fonctionnement propres qui viennent s'ajouter aux coûts des différentes unités opérationnelles sans pour autant créer de valeur[190]. Elle est également liée au fait que les conglomérats présentent des divisions moins rentables et que les ressources au sein de ceux-ci ne sont pas allouées de manière optimale[191]. La réalisation, par exemple, d'une scission partielle permettant d'extraire certaines branches d'activités du conglomérat va ainsi permettre de corriger cette décote et donc entraîner une hausse significative du cours des actions[192].

50. Illustration : la scission de Carphone Warehouse Group. Face à la constatation que les coûts opérationnels du groupe constituaient un frein à la compétitivité de ses branches d'activités et à leur capacité à générer des profits pour ses actionnaires, le groupe britannique Carphone Warehouse Group a séparé son activité d'opérateur télécoms de son activité de distribution de produits de téléphonie en juillet 2010 en allouant la première à une nouvelle entité dénommée TalkTalk. Cette opération fut un véritable succès dans la mesure où tant TalkTalk que Carphone Warehouse ont enregistré une forte hausse du cours de leurs titres[193], ceux de Carphone Warehouse ayant même présenté une hausse record de 184 % en 2010[194].

§4. La correction de l'asymétrie d'information

51. Un marché insuffisamment informé. Un autre objectif poursuivi lors de la réalisation d'une opération de scission est la correction de l'asymétrie d'information existant entre les dirigeants de l'entreprise et le marché des capitaux externes[195]. En effet, les conglomérats d'entreprises disparates présentent une certaine opacité vis-à-vis des marchés de sorte que les investisseurs externes, ayant naturellement une tendance dans un environnement de plus en plus complexe à privilégier la simplicité[196], ne parviennent que difficilement à en appréhender le potentiel de croissance. Ce problème est encore aggravé par le fait que, d'une part, les vastes conglomérats communiquent peu sur leurs branches d'activités de moindre importance, même si celles-ci sont prometteuses[197] et, d'autre part, les analystes financiers sont généralement spécialisés par secteur[198], de sorte qu'ils ne sont pas en mesure d'appréhender la valeur

189 Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, *op. cit.*, p. 7.
190 P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *op. cit.*, p. 1092 et A. RADDA, S. AKANNO, I. UZODINMA, S. ABBA et A. ABDULKADIR, « Demerger or Break-up of Companies: A Management Strategy or Tragedy », *IJMOS*, 2015/4(4), p. 183.
191 P. BARNETO, *op. cit.*, p. 48.
192 Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, *op. cit.*, p. 7.
193 A. RADDA, S. AKANNO, I. UZODINMA, S. ABBA et A. ABDULKADIR, *op. cit.*, p. 183.
194 L. HESSE, V. AGULHON, Cl. MARIEU, E. RIVEZ-DOMONT et Fr. LABROUSSE, « La mise en œuvre des opérations de spin off », *Conférence Jones Day donnée à Paris le 27 janvier 2011*, p. 5, disponible sur www.jonesday.com (20/02/2017).
195 P. BARNETO, *op. cit.*, p. 48.
196 P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *op. cit.*, p. 1187.
197 P. VERNIMMEN, P. QUIRY, M. DALLOCCHIO, Y. LE FUR, A. SALVI, *Corporate Finance – Theory and Practice*, Chichester, John Wiley & Sons, Ltd, 2005, p. 906.
198 P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *op. cit.*, p. 1187.

globale d'un conglomérat. Une opération de scission permettra de faciliter la communication avec les marchés et de simplifier l'information fournie. De plus, si la déconcentration est réalisée au moyen d'une scission partielle suivie de l'entrée en bourse des sociétés bénéficiaires, le nombre d'actions en circulation sur le marché augmentera considérablement, de sorte que le rôle d'information du prix s'en trouvera amélioré, entraînant ainsi une réduction de l'asymétrie d'information[199].

52. Illustration : la *spin off* d'Accor. Face à la constatation que le pôle services, comprenant notamment les Tickets Restaurant, du géant hôtelier Accor était mal valorisé par les marchés et ne présentait pas de synergies avec les autres activités du groupe, il a été décidé de le rendre autonome sous le nom d'Edenred par le biais d'une *spin off*. Celle-ci a été finalisée le 2 juillet 2010 par l'entrée en bourse d'Edenred et, trois ans après, la capitalisation boursière d'Edenred avait déjà pratiquement doublé. Cette réussite est également liée à un changement radical de la composition de l'actionnariat à la suite des efforts déployés pour corriger l'asymétrie d'information dont souffrait le pôle services. En effet, Edenred compte à présent des professionnels des paiements parmi ses actionnaires qui sont mieux à même de comprendre ses services particulièrement techniques et spécifiques, preuve s'il en est que le marché est à présent mieux informé[200].

§5. Les résultats financiers décevants

53. Une mesure défensive. Des résultats financiers médiocres d'une branche d'activités venant impacter la valeur du conglomérat constituent un motif fréquent de déconcentration[201]. Face à une telle situation, les dirigeants adoptent généralement une position défensive consistant en l'ablation de la branche d'activités déficitaire. Une telle déconcentration peut, notamment, se faire par le biais d'une scission destinée à isoler l'élément perturbateur pour pouvoir procéder à sa cession ultérieure à un tiers acquéreur.

54. Mais susceptible d'application offensive. Cependant, une telle opération est susceptible d'être également utilisée dans une approche plus offensive. En effet, face aux résultats médiocres d'une branche d'activités, un acquéreur potentiel pourrait s'estimer capable de la restructurer de manière efficace en vue d'en améliorer la rentabilité ou encore identifier des synergies potentielles avec ses propres activités. Il s'ensuit que ce dernier sera prêt à payer un prix d'acquisition excédant la valeur intrinsèque de la branche d'activités, de sorte que l'opération de déconcentration, en plus d'éviter une perte de revenus à la

199 Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, *op. cit.*, p. 8.

200 Fl. BAUCHARD, « Jacques Stern, la réussite d'une scission d'entreprises », *Les Echos*, 6 février 2014, www.lesechos.fr (22/02/2016).

201 D. BÖLLHOFF, *op. cit.*, p. 16 ; A. CAMPBELL, *op. cit.*, p. 1 ; A. CASCORBI, *op. cit.*, p. 32 ; I. DUHAIME et J. GRANT, « Factors influencing divestment decision-making : Evidence from a field study », *SMJ*, 1984/4, pp. 301 et s. ; I. DUHAIME et G. PATTON, « Selling off », *The Wharton Magazine*, 1980, pp. 43 et s. et R. GRAML, *op. cit.*, pp. 48 et s.

société mère due aux résultats médiocres de la branche d'activités, engendrera un gain lui permettant de bénéficier de nouveaux capitaux[202].

55. Illustration : la scission de Bayer MaterialScience. Ayant constaté que ses activités de polymères étaient à la traîne par rapport à ses autres activités, le géant Bayer AG a annoncé le 18 septembre 2014 son intention de procéder à une scission afin d'isoler Bayer MaterialScience, pour ensuite procéder à son introduction en bourse. L'objectif de l'opération était de permettre à Bayer AG de se recentrer sur ses activités particulièrement rentables dans les domaines de la pharmacie et de la chimie agraire. En effet, la marge brute d'exploitation de la division polymère n'atteignait que 11,2 % au premier semestre 2014 alors que la moyenne du groupe s'élevait alors à 23,6 %. L'effet de l'annonce sur le cours de l'action Bayer a été immédiat et a permis à ce dernier d'enregistrer une hausse de plus de 5 %[203]. Au-delà de cet effet immédiat, l'opération a également permis, selon Patrick Thomas, CEO de Bayer MaterialScience, renommée par après Covestro, à la branche polymère devenue indépendante d'être plus efficace dans un environnement très compétitif et de déployer ses atouts de manière plus flexible, plus rapide et plus efficiente[204]. Les faits lui ont donné raison dans la mesure où la première année de Covestro a été particulièrement profitable, lui permettant de remplir la totalité de ses objectifs financiers et de distribuer un premier dividende à ses actionnaires[205].

§6. Les besoins excessifs en ressources et capitaux

56. Les besoins en capitaux d'une branche d'activités. Des besoins en capitaux financiers ou en autres ressources d'une branche d'activités faisant partie du conglomérat et dépassant largement les capacités contributives de la société mère justifient également fréquemment le recours à une opération de déconcentration[206]. Cependant, contrairement aux déconcentrations réalisées à la suite des mauvais résultats financiers d'une branche d'activités, celles réalisées en raison de besoins trop importants d'une branche d'activités se caractérisent généralement par le fait que ladite branche d'activités présente des perspectives d'avenir intéressantes. Elles peuvent dès lors être réalisées par la combinaison d'une scission partielle pour isoler juridiquement la branche d'activités prometteuse de la société mère et d'une entrée en bourse pour lever les capitaux nécessaires à la poursuite de son activité[207].

57. Les besoins en capitaux du conglomérat. Cependant, les besoins en ressources peuvent aller au-delà des branches d'activité et concerner le

202 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 51.
203 G. PRODHAN et L. BURGER, « Bayer va scinder MaterialScience et se recentrer sur la santé », 18 septembre 2014, disponible sur http://fr.reuters.com/ (10/02/2017).
204 Communication de Bayer AG du 1er septembre 2015, *L'ancien Bayer MaterialScience est maintenant légalement et économiquement indépendant – Covestro opérationnel*, disponible sur www.bayer.be (10/02/2017).
205 Communication de Covestro du 23 février 2016, *Successful first year for Covestro*, disponible sur www.investor.covestro.com (10/02/2017).
206 D. BÖLLHOFF, *op. cit.*, p. 21 ; A. CASCORBI, *op. cit.*, p. 41 et I. DUHAIME et J. GRANT, *op. cit.*, pp. 301 et s.
207 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 42.

conglomérat lui-même qui pourrait nécessiter des capitaux soit pour soutenir une activité prometteuse, soit pour procéder à une nouvelle fusion-acquisition[208], soit encore pour soutenir une activité particulièrement gourmande en capitaux. Dans une telle hypothèse, la déconcentration pourra, par exemple, s'il s'avère qu'une des branches d'activités présente de belles perspectives de croissance bien connues des dirigeants de cette branche, être réalisée par le biais d'une scission suivie d'un *management buy-out*.

58. Illustration : la *spin off* de Wacker Chemie AG. En mars 2015, le géant allemand de la chimie, Wacker Chemie AG, a envisagé l'option de se séparer de sa division produisant des semi-conducteurs[209]. L'opération, réalisée par voie de *spin off* de sa filiale Filtronics AG, était destinée à permettre à la société mère de bénéficier de capitaux additionnels à investir dans son *core business*, à savoir la chimie et le polysilicium, tout en permettant à sa branche d'activités de bénéficier de bonnes perspectives de croissance. Cette opération est intéressante car elle a été examinée à un moment où l'entreprise florissait et venait d'enregistrer une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires, celui-ci ayant atteint la somme de 4,8 milliards d'euros en 2014[210].

§7. L'environnement concurrentiel

59. Une adaptation nécessaire. Les changements affectant l'environnement concurrentiel dans lequel évolue l'entreprise sont également susceptibles d'avoir un impact sur la propension des dirigeants à se séparer d'une branche d'activités[211]. Ainsi, des capacités de production excédant la demande du marché sont de nature à encourager une déconcentration[212]. De même, lorsque le secteur économique dans lequel la branche d'activités est active s'avère être en perte de vitesse ou en cas de récession économique, le nombre de déconcentrations va inéluctablement croître[213].

60. Illustration : la scission partielle de Siemens AG. Une excellente illustration de l'utilisation d'une scission pour répondre à un changement radical de l'environnement concurrentiel n'est autre que l'exemple de la scission partielle de Siemens AG au profit d'une société bénéficiaire, dénommée OSRAM Licht AG, décrit plus haut[214]. Face à une évolution radicale de l'environnement concurrentiel, la scission partielle de Siemens AG a permis à la société bénéficiaire, dénommée OSRAM Licht AG, d'une part de pouvoir prendre des décisions stratégiques beaucoup plus rapidement qu'au sein d'un conglomérat très intégré et donc de s'adapter rapidement à un marché changeant et, d'autre part, de

208 A. CASCORBI, *ibidem*, pp. 42 et 43.
209 *Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie denkt über eine Abspaltung seiner Halbleitersparte Siltronic nach*, disponible sur www.finanzen.net (21/02/2017).
210 « Wacker Chemie erwägt Abspaltung der Halbleiter Sparte », *Die Welt*, 10 mars 2015, disponible sur www.welt.de (21/02/2017).
211 J. H. MULHERIN et A. L. BOONE, « Comparing acquisitions and divestitures », *J.C.F.*, 2000/6, p. 135.
212 A. CASCORBI, *op. cit.*, pp. 44 et 45.
213 A. CASCORBI, *ibidem*, pp. 44 et 45 et R. HAMILTON et Y. KONG CHOW, « Why managers divest – Evidence from New Zealand's largest companies », *SMJ*, 1993/6, pp. 479 et s.
214 À ce sujet, voir *supra* n° 1.

bénéficier d'un accès direct au marché des capitaux[215]. Le verdict du marché fut clair : d'un prix initial de 24 euros, l'action OSRAM Licht AG est passée à près de 35 euros en trois mois seulement et l'entreprise devenue indépendante a réalisé un profit de plus de 33 millions d'euros en 2013[216].

§8. Une mesure anti-OPA

61. Une mesure de défense jouant sur le cours des actions. Lorsque les actions d'une société cotée en bourse ont un cours inférieur à la valeur réelle de la société, un tiers acquéreur pourrait tenter de lancer une offre publique d'acquisition. Une telle opération aura pour objectif d'acquérir la société à un prix avantageux en vue de la revendre une fois que le cours des actions correspondra à la valeur réelle de la société. De même, s'il s'avère que la valeur du conglomérat justifiant le cours des actions est jugée inférieure à la somme des valeurs des différentes branches d'activités le composant, une offre publique d'acquisition se justifierait en vue de désintégrer l'entreprise et de vendre chacune de ses branches d'activité séparément. Dans une de ces deux situations, et face à un risque d'offre publique d'acquisition hostile, les dirigeants de la cible envisageront éventuellement de procéder à une opération de déconcentration afin d'engendrer une hausse du cours des actions en supprimant les synergies négatives, en réorientant la stratégie de l'entreprise ou encore en informant davantage les marchés sur la valeur de certaines branches d'activités formant le conglomérat[217].

62. Illustration : la scission d'ICI. Au début des années 1990, le gigantesque conglomérat britannique Imperial Chemical Industries s'est retrouvé face au risque bien réel de faire l'objet d'une offre publique d'acquisition. En effet, celui-ci, en suivant la logique ayant prévalu dans le secteur de l'industrie chimique depuis les années 1930[218], avait poursuivi une politique d'intégration verticale[219] à outrance l'ayant conduit à investir dans des secteurs d'activités très divers. Sa stratégie de base consistait à investir continuellement en recherche et développement de manière à lancer régulièrement de nouveaux produits sur le marché, destinés à supplanter les activités en perte de vitesse[220]. Cette politique a cependant fini par l'empêcher de gérer efficacement ses différentes divisions pour répondre rapidement aux évolutions de son environnement concurrentiel. Cette incapacité à s'adapter, combinée à des révolutions

215 Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, und der OSRAM Licht AG, München, über die Abspaltung einer Mehrheitsbeteiligung an OSRAM gemäß § 127 Satz 1 Umwandlungsgesetz vom 28 November 2012, disponible sur https://www.siemens.com (08/03/2018), pp. 29–31.

216 Consolidated financial statements of the OSRAM Licht Group for the fiscal years ended September 30, 2013 and 2012, P&L, disponible sur www.osram-group.com (08/03/2018).

217 A. CASCORBI, *op. cit.*, p. 47.

218 G. OWEN et Tr. HARRISON, « Why ICI Chose to Demerge », *Harvard Business Review*, 1995/03, p. 2, disponible sur www.hbr.org (14/02/2017).

219 Par « intégration verticale », on entend « la gestion et le contrôle effectif d'au moins deux des étapes techniquement séparables du processus de production-distribution sous une autorité commune ». Voir Y. DUFEU, « Déterminants du choix d'intégration et de désintégration verticale des entreprises », *Finance Contrôle Stratégie*, mars 2008, vol. 11, n° 1, pp. 131–154 pour plus d'information.

220 G. OWEN et Tr. HARRISON, *op. cit.*, p. 2.

technologiques dans le domaine de la chimie, ont conduit à une situation où le cours de ses actions était inexorablement tiré vers le bas par les défaillances de certaines de ses branches d'activités et ne reflétait pas le succès économique de ses autres branches, telle que la pharmacie. Une restructuration pour éviter les affres d'une offre publique d'acquisition hostile en vue d'un démantèlement s'imposait. Pour parer à une telle éventualité et remédier à l'obsolescence de son modèle stratégique, Imperial Chemical Industries a opté pour une solution innovante[221], à savoir la scission en deux nouvelles sociétés mères, ICI et Zeneca. Cette scission a été réalisée sur la base du constat que la totalité des activités composant le conglomérat, ainsi que les synergies présentes, pouvaient être réparties efficacement entre deux pôles technologiques distincts nécessitant chacun un style de gestion particulier et répondant à des exigences techniques et organisationnelles différentes[222]. Ainsi, toutes les activités pharmaceutiques et agrochimiques ont été allouées à Zeneca, et les autres activités chimiques, regroupant par exemple la fabrication de peintures et d'explosifs, ont été confiées à la nouvelle ICI[223]. Le succès de l'opération a été retentissant. En plus de supprimer le risque d'une offre publique d'acquisition, la valeur combinée des deux nouvelles entités atteignait 13,2 milliards de livres sterling en décembre 1994 contre une valeur de 7,6 milliards de livres sterling pour l'ancienne entité Imperial Chemical Industries en juillet 1992, soit au moment de l'annonce de l'opération de scission[224].

§9. Le droit de la concurrence et les motifs purement juridiques

63. Des motifs légaux variés. Le dernier motif d'une déconcentration réside dans la modification du régime légal applicable à l'entreprise. L'opération peut ainsi avoir pour objectif d'adapter l'entreprise à l'évolution législative du secteur dans lequel elle opère ou encore de bénéficier d'un régime légal plus favorable soit en faisant en sorte de profiter d'un régime fiscal ou réglementaire plus avantageux, soit encore en limitant le risque de responsabilité civile engendré par certaines activités.

64. Les motifs fiscaux et réglementaires. En ce qui concerne tout d'abord les motifs fiscaux, une scission, dans la mesure où elle permet de modifier et de remodeler un groupe de sociétés, s'avère être un outil particulièrement utile pour la planification fiscale[225]. En outre, au niveau des motifs réglementaires, de par la réduction de la taille de la société qu'elle implique, une scission peut être utilisée afin d'éviter des contraintes imposées par une législation nationale défavorable en cas de dépassement de certains seuils, telle que l'obligation d'implication des travailleurs dans la gestion de la société en droit allemand[226].

221 G. OWEN et Tr. HARRISON, *ibidem*, pp. 1 et 2.
222 G. OWEN et Tr. HARRISON, *ibidem*, p. 3.
223 G. OWEN et Tr. HARRISON, *ibidem*, pp. 12 et 13.
224 G. OWEN et Tr. HARRISON, *ibidem*, pp. 18 et 19.
225 Study on the application of the cross-border mergers directive, Bech-Bruun, Lexidale, septembre 2013, disponible sur https://op.europa.eu (28/02/2020) (ci-après l' « **Étude Bech-Bruun et Lexidale** »), p. 9.
226 Au sujet de l'impact d'une scission transfrontalière sur le régime de participation des travailleurs, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre II.

De même, au niveau du droit de la concurrence, une scission peut présenter une double utilité. Elle peut ainsi tout d'abord être suivie d'une cession afin de réduire les parts de marché d'une entreprise pour ensuite lui permettre de réaliser de nouvelles concentrations jugées plus profitables, sans faire l'objet d'un contrôle par les autorités chargées de la protection de la concurrence[227]. Ensuite, elle peut se révéler être un outil efficace dans le cadre de la libéralisation de certains marchés dans la mesure où elle permet une séparation des activités régulées de celles faisant l'objet d'une ouverture à la concurrence.

65. Illustration : la scission de Gannett Corporation. En juin 2015, la société Gannett Corporation a finalisé sa scission afin de répartir son patrimoine entre deux sociétés, à savoir la nouvelle Gannett Corporation qui a conservé toutes les activités liées à la presse imprimée, incluant un portefeuille de 80 journaux locaux ainsi que USA Today, et la société TEGNA qui a recueilli notamment toutes les chaînes de télévision et les autres activités internet. Outre le fait que la scission présente l'avantage indéniable de séparer l'activité de presse écrite en perte de vitesse à la suite de la diminution des revenus publicitaires des autres activités hautement profitables du groupe, elle permet également de supprimer un obstacle réglementaire considérable à sa croissance, à savoir les limites imposées par le droit de la concurrence américain[228]. Selon Gracia Martore, la CEO de Gannett, en raison du fait que la société détenait de nombreux médias différents, chacune des deux divisions éprouvait des difficultés à réaliser des acquisitions jugées stratégiques. La séparation en deux entités juridiquement distinctes va ainsi permettre à chaque entité séparément de procéder à de nouvelles acquisitions sans être limitée par le droit de la concurrence américain[229] et de poursuivre leur croissance.

66. Illustration : la scission de Distrigaz. Dans un contexte général d'ouverture du marché gazier et en réponse à l'évolution réglementaire des marchés gaziers belge et européen et aux initiatives tant fédérales que régionales et européennes visant une séparation stricte entre les activités de transport et les autres activités[230], l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société belge Distrigaz S.A. a décidé, le 30 novembre 2001, d'approuver une opération de scission partielle par constitution de nouvelle société proposée par le conseil d'administration[231]. La nouvelle entité issue de la restructuration, dénommée Distrigaz S.A., s'est vue attribuer la totalité des activités de commerce de la société scindée, à savoir les activités d'achat et de fourniture de gaz naturel et la commercialisation des capacités de transit et de transport international[232] en vue de leur développement dans un marché gazier européen

227 D. BÖLLHOFF, *op. cit.*, p. 24 ; A. CAMPBELL, *op. cit.*, p. 4 et A. CASCORBI, *op. cit.*, p. 49.
228 A. CAMPBELL, *ibidem*, p. 4.
229 *Ibidem*.
230 *Demande d'inscription au premier marché de Euronext Brussels de toutes les parts sociales D de Distrigaz (nouvelle)*, disponible sur www.fluxys.com (17/07/2017), p. 7.
231 « Distrigaz S.A. : proposition de scission approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires », *Communiqué du 30 novembre 2011*, disponible sur www.fluxys.com (17/07/2017), p. 2.
232 *Demande d'inscription au premier marché de Euronext Brussels de toutes les parts sociales D de Distrigaz (nouvelle)*, disponible sur www.fluxys.com (17/07/2017), p. 7.

de plus en plus concurrentiel[233]. L'entité scindée, renommée Fluxys S.A., ne conserva, pour sa part, que les activités de transport afin d'en développer l'infrastructure et d'en commercialiser au mieux les capacités dans le contexte particulier d'un accès régulé au réseau[234].

67. Un outil de répartition des risques. Enfin, une scission permet de mieux répartir les risques liés à une éventuelle responsabilité civile en allouant à une nouvelle société toutes les activités du groupe présentant un risque élevé, de manière à préserver autant que possible les autres entités.

68. Illustration : La scission d'Altria Group Inc. Le meilleur exemple à cet égard peut être trouvé dans l'industrie du tabac qui, au vu du caractère nocif des produits distribués, est susceptible d'être à la source de nombreuses actions en responsabilité civile dont les conséquences, en raison de l'application de dommages et intérêts punitifs, sont non négligeables aux États-Unis. Pour limiter l'impact négatif de telles actions sur les activités du conglomérat Altria Group Inc. (anciennement Philip Morris Companies, Inc.), celui-ci a décidé en 2008 de procéder à une scission par voie de *spin-off* en séparant les activités sur le marché américain, en ce compris tous les risques liés aux actions en justice, de toutes les autres activités détenues par Philip Morris International Inc.[235].

SECTION 4. ANALYSE DE LA CRÉATION DE VALEUR ENGENDRÉE PAR UNE SCISSION

69. Plan de la section 4. En vue d'analyser précisément la valeur générée par une scission, il convient en premier lieu d'examiner si cet instrument de déconcentration n'est destiné qu'à accroître la *shareholder value* (§ 1), pour ensuite identifier les hypothèses dans lesquelles une scission doit être privilégiée parmi les autres modes de déconcentration disponibles (§ 2) et le type de valeur créée par une scission réussie (§ 3), pour finalement clarifier que ce type d'opération, bien que potentiellement très efficace, n'en constitue pas nécessairement un instrument sans risque (§ 4).

§1. Shareholder value vs. stakeholder value

70. Une opération axée sur la *shareholder value*. Suite à l'analyse des différents motifs sous-jacents à une opération de déconcentration, il est intéressant de relever que ceux-ci ont tous en commun d'avoir pour objectif d'augmenter la valeur de l'entreprise[236]. Ainsi, pour pouvoir analyser si une telle opération présente un quelconque intérêt, il convient d'en calculer la valeur actuelle nette (*net present value* ou *NPV*). En termes purement économiques, cela se

233 « Distrigaz S.A. : proposition de scission approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires », *Communiqué du 30 novembre 2011*, disponible sur www.fluxys.com (17/07/2017), p. 2.
234 *Ibidem*.
235 T. LACHAPELLE, « Altria Philip Morris Should Become One Company Again », *Bloomberg*, 28 juillet 2015, disponible sur www.bloomberg.com (21/02/2017).
236 A. CASCORBI, *op. cit.*, p. 53.

traduit par le principe fondamental qu'un projet, qu'il s'agisse d'une acquisition, d'un nouvel investissement ou d'une opération de déconcentration, ne devra être poursuivi que si la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs nets excède le montant de l'investissement initial requis pour réaliser le projet[237]. La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs nets désigne le montant en dollars américains qui rend les propriétaires de l'entreprise, donc les associés, indifférents au fait de recevoir cette somme aujourd'hui ou de recevoir le flux de trésorerie futur attendu[238]. Dans l'hypothèse plus particulière d'une scission, pour déterminer si une telle opération se justifie, il conviendra de soustraire le coût de l'investissement initial de la valeur présente des flux de bénéfices nets futurs pour ensuite analyser si le résultat, appelé valeur actuelle nette est positif ou négatif. S'il est positif, cela signifie que la valeur qui sera en principe créée par la scission dépasse le coût de celle-ci. Il résulte de ce principe de base que la création de valeur pour les associés, généralement dénommée en anglais *shareholder value*, est au centre de la décision de scission[239]. En outre, si on ajoute à cela le fait que la vague des OPA hostiles au cours des années 1980 a affirmé la prééminence de la *shareholder value* sous forme de valorisation boursière et que les restructurations se sont multipliées à compter de cette même période en vue de supprimer l'écart existant entre la valorisation boursière et la valeur de liquidation des conglomérats fortement diversifiés[240], on distingue très clairement qu'une scission, en ce qu'elle constitue un instrument de déconcentration[241] permettant de fragmenter une entreprise multidivisionnelle, va potentiellement à l'encontre de l'intérêt des dirigeants dont la rémunération dépendrait non pas de la valorisation boursière, mais du chiffre d'affaires global de l'entreprise[242] ou qui risqueraient de voir leur contrôle sur l'entreprise s'amenuiser[243].

71. Potentiellement au détriment des autres *stakeholders*. Cependant, une opération de scission est également susceptible d'impacter d'autres *stakeholders*[244], tels que les travailleurs dont la situation peut se détériorer suite, par

237 G. HAWAWINI et Cl. VIALLET, *Finance for Executives – Managing for Value Creation*, 4th ed., Mason, South-Western Cengage Learning, 2011, p. 5.

238 *Ibidem*.

239 D. BÖLLHOFF, *op. cit.*, p. 17.

240 Sur cette évolution, voir : M. ALBERT, Capitalisme contre capitalisme, Paris, Seuil, 1991, pp. 86 à 89 ; I. CORBISIER, « La société : contrat ou institution ? », *op. cit.*, p. 61 et D. SCIULLI, *Corporate power in civil society – An application of societal constitutionalism*, New York, New York University Press, 2001, pp. 31–57.

241 À ce sujet, voir *supra* n° 37.

242 Y. FENG, D. NANDY et Y. TIAN, « Executive compensation and the corporate spin-off decision », *Journal of Economics and Business*, n° 77, 2015, pp. 94–117 qui établissent que les dirigeants dont la rémunération dépend dans une large mesure de la valorisation des actions de la société sont plus enclins à prendre la décision de procéder à une scission, même si cela entraîne une érosion de leur contrôle sur l'entreprise.

243 À ce sujet, voir : Y. FENG, D. NANDY et Y. TIAN, *ibidem*, p. 115 qui relèvent que « [s]*ince spin-offs reduce the size of the firm under the management's control and increase the probability of takeover for the firm, CEOs may prefer not to spin off firm assets, even if doing so would be in the best interests of shareholders* ».

244 Par « *stakeholders* », on entend « l'ensemble des acteurs dont le sort est lié à la société par la mise qu'ils y ont placée, l'enjeu qu'elle représente pour eux et la confiance qu'elle leur a inspirée ». Ce terme recouvre donc par conséquent non seulement les actionnaires, mais d'autres acteurs économiques tels que les travailleurs, les créanciers, les fournisseurs, les consommateurs ou encore

exemple, à la disparition de l'obligation légale de les impliquer dans la gestion de l'entreprise, ou encore les créanciers sociaux, étant admis que la création de valeur engendrée par une scission, dans la mesure où elle est susceptible d'entraîner une expropriation de ceux-ci ou de considérablement compromettre le remboursement de leurs créances respectives, peut se faire à leur détriment[245]. Cependant, le fait de réaliser une opération de déconcentration avec pour objectif avéré la maximisation de la *shareholder value* de l'entreprise n'implique pas nécessairement que celle-ci aura un impact négatif pour les autres *stakeholders*, et notamment pour les créanciers sociaux. En effet, certains auteurs partent du principe que la création de valeur qui profite aux associés, profitera également aux autres *stakeholders*[246]. Ainsi, une scission entraînant la suppression de synergies négatives provoquera une augmentation de la valeur des sociétés issues de la scission. Combinée à une solidarité des sociétés issues de l'opération pour les dettes antérieures à l'opération[247], cette restructuration sera assurément avantageuse pour les créanciers sociaux dans la mesure où la valeur de l'entreprise, qui constitue leur gage commun, augmentera en principe par l'effet de la scission. *A contrario*, si la répartition du patrimoine de la société scindée est réalisée de telle manière que la totalité du passif est transférée à une seule des sociétés bénéficiaires et que les créanciers sociaux omettent de demander une sûreté de nature à garantir le paiement de leurs créances respectives, l'opération, en l'absence d'une solidarité des sociétés issues de la scission, leur sera défavorable car elle entraînera le déclin de leur gage commun[248].

72. Une convergence d'intérêts comme objectif premier. Il découle de ce qui précède qu'une scission ne sera envisagée et, *in fine* réalisée, que si elle est susceptible d'entraîner une augmentation de la *shareholder value*. Cette augmentation de valeur peut cependant également constituer le point de convergence des intérêts des autres *stakeholders* dans la mesure où ceux-ci sont également susceptibles d'en bénéficier, ou au contraire, être obtenue, en tout ou en partie, au détriment de leurs intérêts propres. Or, la « *stakeholder theory* »[249] postule que la capacité d'une entreprise à créer de la valeur pour

l'État. Voir J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *Précis de droit des sociétés*, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 245, n° 465 et Chr. MALLIN, *Corporate governance*, 2nd ed., New York, Oxford University Press, 2006, p. 16.

245 A. CASCORBI, *op. cit.*, pp. 60 et 61.

246 G. HAWAWINI et Cl. VIALLET, *op. cit.*, p. 5.

247 Sur ce mécanisme de protection des créanciers qu'on retrouve à l'art. 146, § 3 de la Directive Sociétés (scissions internes) et à l'art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité (scissions transfrontalières), voir *infra* nos 780 à 789.

248 P. VERNIMMEN, P. QUIRY, M. DALLOCCHIO, Y. LE FUR et A. SALVI, *op. cit.*, p. 906.

249 À ce sujet et sur les trois courants de cette théorie que sont la « *descriptive stakeholder theory* », la « *normative stakeholder theory* » et l' « *instrumental stakeholder theory* », voir : Fl. BRIDOUX et J. W. STOELHORST, « Microfoundations for stakeholder theory: managing stakeholders with heterogenous motives », *Strategic Management Journal*, n° 35, 2014, p. 107 ; Th. DONALDSON et L. E. PRESTON, « The stakeholder theory of the corporation : concepts, evidence and implications », *Academy of Management Review*, 1995, vol. 20, n° 1, pp. 65–91 et Th. JONES, J. HARRISON et W. FELPS, « How applying instrumental stakeholder theory can provide sustainable competitive advantage », *Academy of Management Review*, 2018, vol. 43, n° 3, pp. 371–391.

ses associés est liée à la manière dont elle traite les autres *stakeholders*[250]. En d'autres termes, une entreprise qui souhaite créer de la valeur pour ses associés se doit de construire une relation durablement profitable avec ses créanciers, ses travailleurs, ses fournisseurs et ses clients[251]. En outre, une telle relation de confiance est susceptible de lui fournir un avantage concurrentiel durable dans certaines circonstances[252]. S'il ne faut cependant pas perdre de vue que la création de valeur pour les associés doit rester l'objectif premier, une scission devra, pour que celle-ci soit durablement profitable, également tenir compte des intérêts des autres *stakeholders*.

73. Illustration : L'échec de la gamme de voitures Saturn. En janvier 1985, General Motors, le géant américain de l'automobile, a créé une nouvelle société pour construire et développer un nouveau type de voiture destiné à répondre à la concurrence de plus en plus agressive des constructeurs japonais. Le résultat a été la *Saturn*, une voiture présentant un excellent rapport qualité-prix, produite selon les dernières technologies et en impliquant et intéressant les travailleurs à la réussite du projet[253]. La philosophie de base était simple et révolutionnaire à la fois : traiter tous les *stakeholders* comme des partenaires afin que tous aient un intérêt à la réussite du projet[254]. Il s'ensuivit que les travailleurs furent particulièrement motivés, les concessionnaires arrivèrent à peine à suivre les commandes pendant les cinq premières années de production[255] et les consommateurs furent extrêmement satisfaits de la qualité du produit fini en raison de sa longévité et de son prix abordable[256]. Par conséquent, il est indéniable que ce projet économique fut un véritable succès du point de vue des *stakeholders* autres que les créanciers et les associés. Cependant, cette réussite n'empêcha pas General Motors d'y mettre un terme en 2010 après avoir perdu près de vingt milliards de dollars dans l'aventure. En effet, l'investissement initial de six milliards de dollars pour développer et mettre sur le marché les nouveaux véhicules était tellement élevé que General Motors aurait dû faire fonctionner continuellement ses usines à plein régime, faire des marges deux fois supérieures à la normale et conserver 40 % du prix de revente par les concessionnaires comme flux de trésorerie net pour pouvoir produire un

250 G. HAWAWINI et Cl. VIALLET, *op. cit.*, p. 3 et J. HARRISON, D. BOSSE et R. PHILLIPS, « Managing for stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive advantage », *Strategic Management Journal*, n° 31, 2010, pp. 65–69.

251 Voir en ce sens : D. BOSSE, R. PHILLIPS et J. HARRISON, « Stakeholders, reciprocity, and firm performance », *Strategic Management Journal*, 2009, n° 30, pp. 447 à 456 ; J. HARRISON, D. BOSSE et R. PHILLIPS, « Managing for stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive advantage », *Strategic Management Journal*, n° 31, 2010, pp. 65–69 ; A. HILLMAN et G. KEIM, « Shareholder value, stakeholder management, and social issues: what's the bottom line? », *Strategic Management Journal*, 2001, n° 22, pp. 125–139 et K. J. M., CREMERS, S. B. GUERNSEY et S. M. SEPE, *Stakeholder orientation and firm value*, avril 2019, disponible sur http://www.fmaconferences.org/ (15/10/2020), pp. 32 et 33.

252 Voir en ce sens : Th. JONES, J. HARRISON et W. FELPS, *op. cit.*, p. 388.

253 R. HERVEY, « Saturn – Le pari de General Motors », *Le Monde Diplomatique*, août 1986, p. 16, disponible sur https://www.monde-diplomatique.fr/1986/08/HERVEY/39411 (27/01/2017).

254 D. HANNA, « How GM destroyed its Saturn success », *Forbes*, 3 août 2010, p. 1, disponible sur http://www.forbes.com/2010/03/08/saturn-gm-innovation-leadership-managing-failure.html (27/01/2017).

255 *Ibidem*.

256 *Ibidem*.

revenu acceptable pour ses associés[257]. En d'autres termes, lorsqu'une entreprise néglige l'intérêt de ses associés au profit d'autres *stakeholders*, elle est vouée à l'échec à plus ou moins court terme. L'objectif primordial doit donc être d'augmenter la valeur pour les associés, ce qui ensuite pourra avoir un effet positif sur les autres *stakeholders*.

§2. Le choix de la scission comme mode de déconcentration

74. Quand privilégier une scission ? S'il s'avère que la valeur actuelle nette d'une opération de déconcentration est positive, c'est-à-dire qu'elle entraînerait une augmentation de la valeur de l'entreprise pour les associés, il convient encore de déterminer à quelle méthode de déconcentration il convient de recourir parmi la pléthore de types d'opérations disponibles[258]. Ainsi, une scission, une scission partielle ou encore une vente, qui ont toutes trois en commun d'entraîner l'indépendance de certaines parties d'une entreprise, se justifient lorsque certaines branches d'activités composant une entreprise ont davantage de valeur pour certaines personnes, tels que les dirigeants, ce qui peut justifier un *management buy out*, ou encore lorsque les branches d'activités composant une entreprise ont plus de valeur séparément qu'au sein du conglomérat[259]. Une scission va également s'imposer, lorsqu'en raison de l'asymétrie d'information affectant le conglomérat, le prix de cession susceptible d'être obtenu auprès d'un acquéreur externe s'avère être largement inférieur à la somme des valeurs réelles des différentes branches d'activités le composant[260]. De telles scissions pourront, le cas échéant, s'accompagner d'une intégration subséquente à une autre entreprise si celle-ci présente des synergies absentes de l'entreprise d'origine et qu'elle s'avère effectivement en mesure de les matérialiser[261].

§3. Une création de valeur immédiate ou différée

A. *Présentation*

75. Une création de valeur à deux instants différents. Si les motifs sous-jacents d'une opération de déconcentration sont clairs et présentent tous le dénominateur commun de la création, ou à tout le moins de la préservation, de la valeur de l'entreprise, il importe à présent d'analyser quels sont les effets concrets d'une scission sur la valeur d'une entreprise d'un point de vue purement empirique. À cet égard, il convient de se concentrer plus spécifiquement tout d'abord sur l'impact de l'opération de déconcentration sur le cours des

257 G. HAWAWINI et Cl. VIALLET, *op. cit.*, pp. 4 et 5 et J. Mc TAGGART, P. KONTES et M. MANKINS, *Value Imperative – Managing for superior shareholder returns*, University of Michigan, Free Press, 1994, p. 16.
258 À ce sujet, voir *supra* n° 37.
259 A. CASCORBI, *op. cit.*, p. 69.
260 A. CASCORBI, *ibidem*, pp. 47 et 48 et P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *op. cit.*, p. 1187.
261 A. CASCORBI, *ibidem*, p. 69 et S. SCHMIDT et M. SCHETTLER, « Ziele von Unternehmenszusammensch lüssen », *Zeitschrift Führung und Organisation*, 1999/6, p. 314.

actions de la société au jour de l'annonce de celle-ci pour ensuite aborder plus spécifiquement la question de la création de valeur sur le long terme.

B. *L'impact de l'annonce de l'opération*

76. Une réaction positive et immédiate des marchés. Il ressort d'un nombre considérable d'études portant sur les effets de l'annonce d'une opération de déconcentration sur le cours des actions qu'une telle annonce entraîne une augmentation anormale de celui-ci le même jour[262]. Cette augmentation se situe en moyenne autour de 3 %[263]. De manière assez intéressante, une opération de déconcentration aboutissant à l'exclusion d'une ou de plusieurs branches d'activités ne tombant pas dans le champ du *core business* de l'entreprise génère une hausse du cours des actions supérieure aux opérations impliquant une désintégration d'activités faisant partie du *core business*[264].

C. *L'impact sur le long terme*

77. Une tendance qui se confirme. La majorité des analyses empiriques concentrent leur attention sur l'effet immédiat de l'annonce d'une opération de déconcentration sur le cours des actions[265]. Il est cependant également utile de s'intéresser à la question de savoir si la création de valeur pour les associés s'avère être une réaction des marchés purement éphémère ou si, au contraire, elle se poursuit même après la réalisation de l'opération de scission. Or, à ce sujet, un certain nombre d'études empiriques ont mis en évidence le fait qu'une scission est susceptible d'améliorer la performance boursière à long terme et de créer davantage de valeur pour les associés[266] et ce, sur une période allant jusqu'à trois ans après la réalisation de l'opération[267]. Ainsi, la surperformance boursière des titres des sociétés issues de la scission est tout à fait susceptible de se confirmer sur le long terme[268].

262 J. H. MULHERIN et A. L. BOONE, *op. cit.*, p. 119 ; Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, *op. cit.*, p. 4 ; P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *op. cit.*, p. 1186 et P. VERNIMMEN, P. QUIRY, M. DALLOCCHIO, Y. LE FUR et A. SALVI, *op. cit.*, p. 905.

263 J. H. MULHERIN et A. L. BOONE, *ibidem*, p. 133 et Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, *ibidem*, p. 6.

264 Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, *ibidem*, p. 17.

265 Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, *ibidem*, p. 15.

266 Voir en ce sens : H. DESAI et Pr. JAIN, « Firm performance and focus: long-run stock market performance following spinoffs », *Journal of Financial Economics*, n° 54, 1999, p. 99 ; Y. FENG, D. NANDY et Y. TIAN, *op. cit.*, p. 95 ; S. KRISHNASWAMI et V. SUBRAMANIAM, « Information asymmetry, valuation, and the corporate spin-off decision », *Journal of Financial Economics*, n° 53, 1999, p. 74. Pour un point de vue plus mitigé, voir : A. KLEIN et J. ROSENFELD, « The long-run performance of sponsored and conventional spin-offs », *Financial Management*, 2010, p. 243. *Contra* en Europe: Chr. VELD et Y. VELD-MERKOULOVA, « Do spin-offs really create value? – The European case », *Journal of Banking & Finance*, n° 28, 2004, p. 1133 qui expliquent cette absence d'effet sur le long terme à une réaction plus efficiente des marchés européens à l'annonce de la scission.

267 H. DESAI et Pr. JAIN, *op. cit.*, p. 99.

268 P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *op. cit.*, p. 1186.

§4. Un outil de restructuration efficace mais pas sans risques

78. Un certain nombre de désavantages. S'il est vrai que les scissions sont susceptibles d'avoir de nombreux effets positifs et d'entraîner une hausse significative du cours des actions à la fois sur le long terme et sur le court terme[269], force est de constater que d'une part, elles ne constituent en aucun cas une panacée universelle aux problèmes engendrés par un conglomérat et que, d'autre part, elles ne sont pas exemptes d'inconvénients.

79. Décote de liquidité et risque de rachat. En effet, dans le cadre d'une scission partielle, la nouvelle société engendrée par la restructuration peut s'avérer être trop petite, de sorte qu'elle souffrira d'une décote de liquidité[270][271]. De plus, la taille réduite de la nouvelle société et la correction de l'asymétrie d'information l'ayant affectée précédemment vont paradoxalement renforcer le risque d'une offre publique d'acquisition hostile. En effet, si avant l'opération la taille du conglomérat ou la diversité de ses activités était de nature à dissuader les acquéreurs potentiels, les plus petites entités à fort potentiel de croissance engendrées par la scission sont, quant à elles, beaucoup plus attrayantes[272]. Ainsi, assez paradoxalement, les scissions peuvent, selon les circonstances, soit enrayer les risques d'une offre publique d'acquisition[273] soit, au contraire, les faciliter.

80. Des coûts de fonctionnement additionnels. À ces premiers désavantages s'ajoute évidemment le fait que les coûts de la gestion opérationnelle de deux sociétés sont évidemment supérieurs à ceux de la société unique avant la scission. À titre d'illustration, chacune des deux sociétés devra à présent disposer d'un organe de gestion et requerra des services juridiques, comptables et fiscaux distincts[274].

81. La perte de l'attrait de la diversification. De plus, dans la mesure où une scission entraîne, par définition, la répartition du portefeuille d'une entreprise entre au moins deux entreprises, il s'ensuivra que les portefeuilles de ces dernières seront immanquablement moins diversifiés. Si elles sont toutes deux cotées en bourse, elles pourraient s'avérer moins attrayantes pour des investisseurs[275], ce qui compliquera l'accès aux capitaux de celles-ci.

82. Deux inconvénients majeurs. Cependant, les principaux inconvénients d'une scission demeurent, tout comme à l'égard d'une fusion[276], la complexité

269 P. VERNIMMEN, P. QUIRY, M. DALLOCCHIO, Y. LE FUR, A. SALVI, *op. cit.*, p. 906 et P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *ibidem*, p. 1186.

270 Par « décote de liquidité » on entend la décote que subit une société en raison de la faible liquidité de ses actions. Cette faible liquidité est fréquente dans les petites et moyennes entreprises non cotées, ainsi que dans les sociétés cotées au flottant réduit et ne comprenant qu'un seul ou que quelques actionnaires. Voir P. VERNIMMEN, P. QUIRY, M. DALLOCCHIO, Y. LE FUR, A. SALVI, *ibidem*, p. 865 pour plus d'information.

271 P. VERNIMMEN, P. QUIRY, M. DALLOCCHIO, Y. LE FUR et A. SALVI, *ibidem*, p. 906.

272 P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *op. cit.*, p. 1187.

273 À ce sujet, voir *supra* n° 53.

274 A. RADDA, S. AKANNO, I. UZODINMA, S. ABBA et A. ABDULKADIR, *op. cit.*, pp. 183 et 184.

275 A. RADDA, S. AKANNO, I. UZODINMA, S. ABBA et A. ABDULKADIR, *ibidem*, p. 184.

276 Pour une étude détaillée des complexités de la procédure de fusion transfrontalière, voir M. KYRIAKIDES et Fr. FOURNARI, « Procedural harmonisation in cross-border mergers » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 209–222.

de leur mise en œuvre et la durée de leur préparation qui excède généralement six mois[277]. Ceux-ci expliquent à eux seuls pourquoi, malgré les nombreux avantages que les scissions sont susceptibles d'engendrer, celles-ci ne soient pas beaucoup plus fréquentes[278].

83. Illustration. La scission partielle de Cable and Wireless plc. Le 26 mars 2010, Cable and Wireless plc, le géant des services télécoms, a fait l'objet d'une scission partielle au cours de laquelle la société scindée, renommée par après Cable and Wireless Communications plc (CWC), a conservé le pôle services de télécommunications aux utilisateurs importants, tels les multinationales ou les gouvernements, et Cable and Wireless Worldwide plc (CWW), a obtenu le pôle services de télécommunications aux particuliers sur de nombreux marchés locaux. L'opération avait, selon Sir Richard Lapthone, alors président du groupe, pour objectif de séparer deux activités poursuivant chacune une stratégie claire et distincte afin de créer de la valeur pour les actionnaires en leur permettant d'investir directement dans l'une ou l'autre[279]. Cependant, l'opération fut loin de remporter le succès escompté. En effet, au moment de la scission, la capitalisation boursière était de 4 milliards de livres sterling. Or en juillet 2012, Vodafone Group a acquis CWW pour un prix d'acquisition d'un milliard de livres sterling[280]. Quant à CWC, sa valeur de marché en décembre 2012 était estimée à moins d'un milliard de livres sterling et elle s'est séparée de tout un portefeuille d'activités allant de Monaco aux Malouines afin de se concentrer essentiellement sur ses activités en Amérique du Nord et aux Caraïbes[281]. En définitive, CWC a fini par être cédée à Liberty Global en mai 2016 pour un prix d'acquisition de 3,5 milliards de livres sterling et une reprise de dette de 1,8 milliard de livres sterling[282]. Il en découle que l'opération de scission n'a pas permis de relancer les activités du groupe qui, peu avant les années 2000, était évalué à plus de 38 milliards de livres sterling[283]. Ainsi, une

277 P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *op. cit.*, p. 1187.

278 P. VERNIMMEN, P. QUIRY et Y. LE FUR, *ibidem*, p. 1187. Voir en ce sens également au sujet des fusions transfrontalières : I. CORBISIER, « The implementation of the cross-border mergers directive in Luxembourg » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 407 qui relève en outre qu'en droit luxembourgeois les fusions transfrontalières non simplifiées son peu fréquentes en raison de cette complexité et des incertitudes qui les affectent. Pour une étude détaillée des avantages d'une acquisition par rapport à une fusion transfrontalière notamment en raison de cette complexité et des délais qui y sont associés, voir : J. MUKWIRI, « Cross-border mergers directive and its impact in the UK » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 485 et 494 qui relève que les grandes sociétés britanniques occupant plus de 500 travailleurs préfèreront généralement se restructurer au moyen d'acquisitions d'actions que par le biais d'une fusion transfrontalière en raison de la complexité de négocier un accord sur la participation des travailleurs et qu'il est plus aisé pour une société étrangère d'acquérir une grande société britannique que de l'absorber au moyen d'une fusion.

279 « Cable Wireless plc. – Demerger update and interim management statement », 2 février 2010, disponible sur www.investegate.co.uk (22/02/2017).

280 A. HILL, « How C&W's radical restructure fell short », *F.T.*, 10 décembre 2012, disponible sur www.ft.com (22/02/2017).

281 *Ibidem*.

282 D. THOMAS, « End of the line for Cable & Wireless », *F.T.*, 17 novembre 2015, disponible sur www.ft.com (14/10/2020) et D. THOMAS, « Liberty Global completes Pounds 3.5 billion deal for CWC », *F.T.*, 16 mai 2016, disponible sur www.ft.com (14/10/2020).

283 A. HILL, *op. cit.*.

scission n'est pas infaillible et n'empêche pas nécessairement l'érosion de la valeur de l'entreprise.

SECTION 5. CONCLUSION SUR L'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DES SCISSIONS

84. Un instrument de désinvestissement au service des entreprises. Il découle de ce qui précède que les scissions constituent donc un outil indispensable pour les entreprises soumises à un environnement concurrentiel de plus en plus impitoyable qui requiert d'elles qu'elles s'adaptent et se restructurent continuellement, sous peine d'extinction[284]. Utilisées comme élément d'une stratégie globale visant à augmenter la compétitivité d'une entreprise et les revenus pour les associés, les scissions demeurent un instrument de restructuration essentiel pour les entreprises qui souhaitent se recentrer sur leur *core business* et renforcer leur position concurrentielle sur le marché en question. De plus, la création de valeur qu'elles sont susceptibles d'engendrer fait qu'elles présentent un indéniable attrait pour les investisseurs activistes[285]. Bien qu'elles ne soient pas exemptes d'inconvénients, elles sont généralement considérées comme un outil stratégique moins risqué que les fusions-acquisitions[286], ce qui s'explique, à tout le moins à l'égard des différentes scissions par constitution de nouvelles sociétés par le caractère interne du processus, par opposition aux fusions qui impliquent nécessairement toujours deux sociétés apporteuses. Ceci explique pourquoi les scissions internes sont si fréquentes au sein de l'Union européenne[287]. Si on combine cette réalité à la constatation que les entreprises sont poussées à être présentes sur des marchés géographiques très divers afin de pouvoir résister à un environnement concurrentiel en perpétuelle évolution, la nécessité de bénéficier d'un moyen de désinvestissement et de restructuration transfrontalier devient évidente.

284 A. RADDA, S. AKANNO, I. UZODINMA, S. ABBA et A. ABDULKADIR, *op. cit.*, p. 180.
285 Voir en ce sens : L. BOISSEAU, *op. cit.*.
286 A. RADDA, S. AKANNO, I. UZODINMA, S. ABBA et A. ABDULKADIR, *op. cit.*, p. 184.
287 Sur la base de la Consultation publique de 2015 et d'informations fournies par les différents registres nationaux, il y a eu environ 700 scissions internes par an au Danemark au cours des cinq années précédentes, plus d'un millier en France, environ 500 en Pologne et en Estonie, environ 200 en Finlande, Lituanie et Suède et environ 150 en Belgique. Voir Étude d'impact, p. 23, note 81.

Chapitre 3
La nature juridique des scissions

SECTION 1. PRÉSENTATION

85. Une nature juridique à préciser. L'intérêt économique des scissions transfrontalières ayant été démontré[288], il convient à présent de circonscrire davantage l'objet de recherche en se penchant sur la nature juridique des scissions. À cet égard, en partant de la définition foncièrement pragmatique du législateur européen dans la Directive Sociétés (section 2), tant la qualification d'apport en nature (section 3) que la thèse de la transformation seront rejetées (section 4) en vue de retenir la qualification de contrat *sui generis* (section 5) et de tirer une conclusion sur la nature foncièrement polymorphe de ce type d'opération (section 6).

SECTION 2. LA DÉFINITION DU LÉGISLATEUR EUROPÉEN

86. Une définition neutre. La définition d'une scission interne adoptée par le législateur européen dans la Directive Sociétés[289] est foncièrement axée sur les effets de cette dernière et n'apporte aucune précision quant à la nature juridique d'une telle opération. Il en va de même de la définition consacrée par la Directive Mobilité[290]. Le recours à une telle définition présente indéniablement l'intérêt d'être aisément transposable dans les différents droits nationaux[291]. Cependant, bénéficier d'une indication quant à l'essence d'une scission permettrait d'appréhender la marge de manœuvre laissée aux parties impliquées pour adapter l'opération à leurs besoins spécifiques. La tâche n'étant toutefois pas aisée, il n'est pas surprenant de constater que plusieurs thèses majeures se soient succédé au gré des évolutions jurisprudentielles et législatives en la matière.

SECTION 3. L'INADÉQUATION DE LA QUALIFICATION D'APPORT EN NATURE

87. La définition analytique. Une scission pourrait tout d'abord être définie de manière analytique comme la conjonction (i) d'une dissolution de la société bénéficiaire et (ii) d'apports en nature multiples effectués au profit d'au moins deux sociétés bénéficiaires. Une telle définition a l'avantage de permettre d'expliquer l'opération en recourant exclusivement à des concepts usuels du droit des sociétés et du droit des obligations[292]. Ceci explique qu'elle ait connu un certain succès au début du vingtième siècle alors que tant la jurisprudence que la doctrine peinaient à circonscrire ce type d'opérations pourtant déjà

288 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2.
289 Art. 136, § 1 et art. 155, § 1 de la Directive Sociétés.
290 Art. 160*ter*, 4) de la Directive Mobilité.
291 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 72, n° 88.
292 R. RAFFRAY, *La transmission universelle du patrimoine des personnes morales*, Nouvelle bibliothèque de thèses, Paris, Dalloz, 2011, vol. 108, p. 152.

pratiquées[293]. Une telle conception est à rapprocher de la vision primitive des fusions où on procédait d'abord à une dissolution suivie d'une liquidation de la société absorbée pour ensuite réaliser une augmentation de capital de la société bénéficiaire par le biais de l'émission de nouvelles actions libérées par l'apport en nature des *bonis* de liquidation[294].

88. L'inadéquation de la définition analytique. Cependant, dans la mesure où la notion d'apport en nature emporte en principe un transfert à titre particulier[295] d'un ou de plusieurs éléments d'actifs déterminés susceptibles d'évaluation économique, cette thèse s'avère incapable de justifier la transmission d'une universalité composée à la fois d'éléments actifs et d'éléments passifs qui est pourtant au cœur d'une scission. La combinaison de la consécration jurisprudentielle de la transmission universelle de patrimoine et de l'épineuse question de la substitution de débiteur entraînée par une telle opération[296], explique que la théorie de l'apport en nature, et avec elle, la définition analytique, soient tombées en désuétude[297].

SECTION 4. LA THÈSE DE LA TRANSFORMATION

89. L'analogie avec la reproduction monoparentale. La théorie de l'apport en nature ayant fini dans une impasse, certains auteurs ont argué qu'une scission est à analyser comme une opération de transformation de la société apporteuse[298] et est à rapprocher d'une forme de « scissiparité » ou de « parthénogenèse »[299]. Selon les tenants de cette thèse, une dissolution doit nécessairement s'accompagner d'une liquidation dans un souci de protection des créanciers[300]. *A contrario*, une scission entraîne une transformation de la société apporteuse qui survit dès lors à l'opération, la personnalité morale de cette dernière se retrouvant au sein des sociétés bénéficiaires, à l'instar du patrimoine génétique du géniteur en cas de reproduction monoparentale. Cette thèse est étayée par le fait qu'une dissolution qui n'a pas pour objectif de mettre fin aux activités de la société scindée ne constitue pas une véritable dissolution[301].

293 G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », in *Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés*, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 26 et 27.

294 C. HOUPIN, « De la situation des actionnaires et des créanciers, en cas de fusion de sociétés en ce qui concerne le règlement de la société absorbée », *Journ. soc.*, 1933, pp. 449 et s. et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 153.

295 R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 153.

296 F. LAGRANGE, *Nature juridique de la fusion des sociétés*, thèse, Paris II, 2001, p. 11, cité par R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 154, n° 184.

297 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 4 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 154.

298 Y. CHEMINADE, « Nature juridique de la fusion de sociétés anonymes », *Rev. trim. de droit com.*, 1970, p. 15 ; R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 154 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 71 et s.

299 Th. TILQUIN, *ibidem*, p. 71, n° 81.

300 D. BASTIAN, « La survie de la personnalité morale des sociétés pour les besoins de leur liquidation », *Journ. Soc.*, 1937, p. 1 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 154.

301 Y. CHEMINADE, *op. cit.*, p. 19 et R. ROUTIER, *Les fusions de sociétés commerciales – Prolégomènes pour un nouveau droit des rapprochements*, Paris, L.G.D.J., 1994, p. 27, n° 74.

90. Une thèse utile mais pas exempte de critiques. Cette thèse présente l'intérêt de justifier qu'une scission ait pour conséquence une substitution de débiteur sans novation et soit opposable aux tiers sans nécessiter leur consentement[302]. Elle a cependant été rejetée par la Cour de cassation française dès 1946[303] et certains auteurs ont rapidement considéré que cette théorie s'avérait incompatible avec les consécrations législatives successives du principe de la dissolution sans liquidation[304]. En effet, la dissolution sans liquidation entraîne en principe la disparition de la personnalité morale de l'apporteuse[305], l'absence de liquidation étant considérée comme une forme de clôture immédiate de cette liquidation par défaut d'objet et emportant par conséquent la disparition concomitante de la personnalité morale de la société scindée[306]. Cette faiblesse est par ailleurs reconnue par les défenseurs de cette théorie qui, pour sortir de cette impasse, se reposent sur le fait que la dissolution seule ne met pas fin à la personnalité morale de la société apporteuse qui continue à exister pour les besoins de sa liquidation. Il s'ensuivrait que le principe de la dissolution sans liquidation n'entame pas la personnalité morale de la société apporteuse[307]. Ce raisonnement a été critiqué sous deux angles. Tout d'abord, il semble malaisé de justifier la survie de la personnalité morale uniquement par l'absence de liquidation dans la mesure où c'est cette absence de liquidation qui justifie l'exclusion du principe de la survie passive de la société dissoute[308]. Ensuite, une telle analyse s'avère erronée *ab initio* si on considère au contraire que la Directive Sociétés a créé en réalité une deuxième variété de dissolution dérogeant au régime de droit commun et entraînant inéluctablement une disparition immédiate de la société apporteuse sans qu'une procédure de liquidation ne soit requise[309]. De plus, il convient de préciser que l'analogie avec la parthénogenèse ou la scissiparité n'est applicable qu'en cas de scission par constitution de nouvelles sociétés et méconnaît le fait qu'une scission peut également s'opérer au profit d'une ou de plusieurs sociétés existantes.

302 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 154 et N. SIMONART, *La personnalité morale en droit privé comparé*, Bruxelles, Bruylant, 1996, n° 437.

303 Cass. Civ. (France) 28 janvier 1946, *Recueil Dalloz*, 1946, p. 168.

304 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 162.

305 C. GAVOTY et P. ULLMANN, « L'absorption par une société par actions simplifiées exige-t-elle le consentement unanime des associés de la société absorbée ? », *BJS*, 2001, p. 831 ; P. LE CANNU, « De la SA à la SAS, pourquoi transformer à l'unanimité si l'on peut fusionner à la majorité ? », *BJS*, 2005, p. 557 et R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 162 et C.A. Versailles, 12e ch., sect. 2, 27 janvier 2005, *BJS*, 2005, p. 612.

306 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 73, n° 90.

307 *Ibidem* et P. VAN OMMESLAGHE, « La proposition de troisième directive sur l'harmonisation des fusions de sociétés anonymes », in *Quo vadis, ius societatum ? – Liber Amicorum Pieter Sanders 21 september 1912–1972*, s.l., Kluwer – Deventer Martinus Nijhoff – 'S-Gravenhage, 1972, p. 143.

308 K. GEENS, « Les effets de la fusion » in *Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal*, éd. du jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles, 1993, p. 134.

309 P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux relatifs à la fusion et à la scission selon les directives et les lois nouvelles », in *Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal*, éd. du jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles, 1993, p. 41.

SECTION 5. UN CONTRAT *SUI GENERIS*

91. L'adhésion volontaire à un contrat. Dans la mesure où une scission résulte des décisions unilatérales prises par les assemblées générales des sociétés impliquées et convergeant vers un objectif commun, une scission pourrait, à l'instar d'une fusion, s'analyser comme un contrat *sui generis* engendrant une nouvelle structure sociétaire[310]. Cette conception de la scission découle de son caractère éminemment volontaire[311] qui suppose la convergence des volontés des différents acteurs impliqués vers la réalisation d'un objectif commun. Cette nature contractuelle, qu'on retrouve à l'esprit du législateur belge lors de la transposition de la Troisième Directive et de la Sixième Directive[312], est confirmée, selon les défenseurs de cette théorie, par le fait qu'un vice de consentement affectant la résolution d'une des assemblées générales ayant été appelée à se prononcer sur l'opération est de nature à en entraîner la nullité s'il s'avère que sans ce vice, les conditions de quorum ou de majorité requis par la loi n'auraient pas été remplies[313]. À cette première justification s'ajoute encore le fait que tant la Directive Sociétés[314] que la Directive Mobilité[315] ne prévoient que le contenu minimum du projet de scission, laissant par là même une marge d'appréciation considérable permettant aux parties impliquées d'adapter conventionnellement l'opération à leur situation spécifique et que la qualification de contrat se retrouve dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne à propos des fusions transfrontalières[316].

92. Les caractéristiques du contrat de scission. Si on accepte la nature contractuelle de la scission, il convient toutefois de relever qu'il s'agit d'un contrat foncièrement *sui generis* en ce sens qu'il est soumis à un régime juridique atypique relevant en priorité du droit des sociétés[317], ce dernier dérogeant largement au régime de droit commun des obligations[318]. Ceci a conduit P. VAN OMMESLAGHE à y voir un contrat engendrant une nouvelle structure sociétaire, l'équivalent d'un « *Organvertrag* » de droit allemand, auquel le droit commun des obligations ne trouverait pas à s'appliquer[319]. Cependant, une telle

310 Voir en ce sens : F. T'KINT et I. CORBISIER, « La transmission des contrats et la protection des créanciers », in *Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés*, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 170 et P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux… », *op. cit.*, p. 38.

311 F. T'KINT et I. CORBISIER, *ibidem*, p. 171 et R. ROUTIER, *op. cit.*, pp. 229 et s.

312 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 13 où le législateur considère que la fusion prend effet « *au moment où se rencontrent les volontés concordantes des participants à l'opération* ».

313 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 159 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 395, n° 577.

314 Art. 137, § 2 de la Directive Sociétés.

315 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.

316 Voir C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:762.(ci-après l' « **arrêt *Sevic*** »), pts. 5 et 6 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 13 et 36 où il est explicitement fait référence à un « *contrat de fusion* », ainsi que pt. 26 où l'Avocat général qualifie les sociétés impliquées dans une procédure de fusion de « *personnes juridiques pleinement capables de négocier et de conclure l'acte de fusion* ».

317 P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux… », *op. cit.*, p. 38.

318 *Ibidem*.

319 *Ibidem*.

conception semble aller au-delà de la volonté du législateur européen qui a certes voulu créer un régime juridique dérogatoire au droit commun des obligations, mais n'a pas entendu l'exclure totalement. Cette intention ressort en effet clairement des dispositions de la Directive Sociétés qui prévoient des règles relatives à l'attribution d'un passif non réparti dans le projet commun de scission et qu'une interprétation de ce dernier ne permet pas d'attribuer[320], règles qui se retrouvent également dans le régime de la Directive Mobilité[321]. En effet, cette interprétation du projet commun à laquelle il est fait référence ne fait l'objet d'aucune autre disposition, de sorte qu'il faudra recourir aux principes généraux d'interprétation applicables aux conventions pour pouvoir l'appliquer efficacement. Ceci implique, par ricochet, une application supplétive des principes généraux du droit des obligations. A cela s'ajoute qu'il est tout à fait possible de replacer le contrat de scission au sein de la typologie classique des contrats. Ainsi, comme la société scindée s'engage à transférer la totalité de son patrimoine actif et passif répartie en fractions à au moins deux sociétés distinctes qui s'engagent en contrepartie à attribuer des actions dans leur capital social aux associés de la société scindée, le contrat de scission est indéniablement synallagmatique et à titre onéreux[322]. Il s'agit également d'un contrat commutatif[323] étant donné que le rapport d'échange fixé dans le projet commun implique que les diverses parties estiment que leurs prestations réciproques sont équivalentes. La nécessité d'accomplir un certain nombre de formalités spécifiques, au nombre desquelles on compte par exemple l'obligation de publier le projet de scission[324] ou encore le contrôle de ce dernier par un expert indépendant[325], en fait également un contrat solennel[326].

93. Intérêt de la conception contractuelle de la scission. L'analyse contractuelle de l'opération de scission présente indéniablement l'intérêt de définir la rencontre des volontés des parties impliquées comme l'hypocentre du phénomène et, par conséquent, de reconnaître une large place à l'autonomie de la volonté. Il paraît par conséquent logique qu'en pratique, les parties aménagent systématiquement différents aspects de la restructuration en y intégrant des clauses dépassant le cadre de base établi par la Directive Sociétés[327]. À titre d'illustration, on peut ainsi citer les clauses d'expertise[328] par lesquelles les intervenants à la scission entendent régler *a priori* les questions relatives à la nomination d'un expert qui sera chargé de vérifier le rapport d'échange ou encore l'ajout, dans le cadre du processus, de documents précontractuels tels que des accords de confidentialité[329].

320 Art. 137, § 3, al. 2 de la Directive Sociétés.
321 Art. 160*novodecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
322 R. ROUTIER, *op. cit.*, p. 230.
323 *Ibidem*.
324 Art. 138 de la Directive Sociétés.
325 Art. 142, § 1 de la de la Directive Sociétés.
326 R. ROUTIER, *op. cit.*, p. 231, n° 725.
327 Pour une analyse de la faculté des parties de compléter le projet commun de scission selon leurs besoins, voir *infra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Section 3, § 7, F.
328 R. ROUTIER, *ibidem*, pp. 262 et 263.
329 R. ROUTIER, *ibidem*, pp. 250 et 251.

94. Les limites de la conception purement contractuelle. Cependant, le fait d'envisager une scission comme un contrat pose un problème dans le cas spécifique d'une opération de scission se réalisant uniquement par constitution de nouvelles sociétés. En effet, dans pareille hypothèse, seuls les associés de la société scindée se prononcent sur le projet de scission[330] et les sociétés bénéficiaires n'acquerront de personnalité juridique qu'une fois la scission consommée. Pour sortir de cette impasse, il a été argué que le contrat de scission se muait en acte juridique unilatéral dans pareille hypothèse[331]. Il s'agira dès lors d'un acte juridique unilatéral réceptice[332] étant donné que celui-ci ne produira ses effets qu'une fois les nouvelles sociétés constituées[333], c'est-à-dire au moment où les bénéficiaires de l'opération auront effectivement pris connaissance de la décision unilatérale émanant de la société scindée. À cet égard, il est intéressant de relever que dès 1937, le droit allemand a connu un premier régime détaillé des fusions internes par le biais de l'AktG 1937[334], lequel se retrouve également en droit autrichien en 1938[335], alors que les droits plus réticents à la reconnaissance de la notion même d'acte juridique unilatéral ne l'ont reconnue que plus tardivement puisqu'en droit français, le premier régime des fusions et scissions date de 1966[336], en droit belge, il date de 1993[337] et en droit luxembourgeois, il date de 1987[338].

330 Art. 156, § 3 de la Directive Sociétés.

331 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 55 et 56, n° 68 et P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux… », *op. cit.*, p. 38.

332 Sur cette notion, voir : P. VAN OMMESLAGHE, *Droit des obligations*, Bruxelles, Brulant, 2010, t. II, n° 722, pp. 1051 et 1052.

333 Art. 151, § 1er, b) et 156 de la Directive Sociétés et art. 160*novodecies*, § 1er, b) de la Directive Mobilité.

334 §§ 233–251 du Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien (Aktiengesetz) du 30 janvier 1937, disponible sur http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1937&size=45&page=261 (16/10/2020) (ci-après l' « **AktG 1937** »). À ce sujet, voir : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *Umwandlungsgesetz*, 6e éd., Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 2019, p. 3, n° 5 qui relèvent également que si le premier régime détaillé des fusions internes se retrouve aux §§ 233–251 du AktG 1937, des fusions furent réalisées dès le milieu du XIXe siècle et que la première base légale date de 1861 avec les art. 215, § 2 et 247 de l'ADHGB de 1861.

335 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *Verschmelzung, Spaltung, Umwandlung*, 2e éd., Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2010, pp. 4 et 5, n° 4 à 6 qui relève également qu'en droit autrichien, la première base légale traitant de la fusion est l'art. 247 de l'AHGB 1862.

336 Art. 371 à 389 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (16/10/2020). À ce sujet, voir : C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *Fusion, scission et apport partiel d'actif*, Paris, Dalloz, 2019, pp. 24 et 25, nos 23 à 25 qui mentionnent également que des fusions étaient réalisées préalablement en pratique et relèvent également qu'un arrêt de la Cour de cassation française du 2 janvier 1946 avait reconnu ces opérations.

337 Loi du 29 juin 1993 modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, *M.B.*, 21 juillet 1993. À ce sujet, voir : Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 2 où il est précisé qu' « [e]n droit belge actuel, ni la fusion de sociétés, ni la scission de société ne sont réglementées. Ces opérations peuvent toutefois être réalisées et se voient d'ailleurs reconnues sur le plan fiscal (voir art. 123 et 124 CIR) ou dans certaines réglementations particulières(notamment dans le domaine bancaire ou dans celui des assurances). ». Voir également : G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *op. cit.*, p. 13 qui relèvent qu'en droit belge, la fusion était connue en pratique dès le XIXe siècle.

338 Loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, disponible sur http://legilux.public.lu/ (16/10/2020). À ce sujet, voir : Projet de loi modifiant la loi

SECTION 6. CONCLUSION SUR LA NATURE JURIDIQUE DES SCISSIONS

95. Une nature juridique polymorphe. À la suite de l'analyse des différentes conceptions juridiques de la scission, il ressort qu'elle doit être analysée comme une opération de restructuration pouvant revêtir tantôt la forme d'un contrat *sui generis* et tantôt la forme d'un acte juridique unilatéral. Il s'ensuit que la volonté des parties impliquées présentera un caractère nécessairement fondamental dans la mesure où tous les aspects n'ayant pas été spécifiquement réglementés seront librement déterminés par les parties.

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Rapport de la Commission des affaires juridiques en vue de la première lecture, *Doc.*, Ch. des députés, 1984–1985, n° 2897, disponible sur https://chd.lu (26/09/2019), p. 1 où il est relevé que « [n]otre législation nationale ne prévoit aucune disposition réglant de tels phénomènes, ce qui n'empêche pas qu'en pratique, des fusions et scissions puissent se réaliser au Luxembourg ».

Chapitre 4
Les éléments caractéristiques des scissions transfrontalières

96. Plan du chapitre 4. Afin de préciser encore davantage l'objet de recherche (section 5), il est utile d'examiner méthodiquement les quatre éléments caractéristiques d'une scission transfrontalière, à savoir (i) une dissolution sans liquidation (section 1), l'absorption du patrimoine de la société scindée (section 2), l'attribution de nouvelles actions aux associés de la société scindée (section 3) et un élément d'extranéité bien déterminé (section 4).

SECTION 1. UNE DISSOLUTION SANS LIQUIDATION

97. Une dissolution atypique. À la différence d'un apport partiel d'actifs, d'une scission par séparation et de la figure particulière de la scission partielle, une scission totale implique nécessairement la dissolution sans liquidation de la société scindée. Ceci signifie que cette dernière n'existera plus en tant que sujet de droit dès la prise d'effet de l'opération. Il convient toutefois de remarquer que cette dissolution présente des caractéristiques atypiques dans la mesure où elle n'a pas pour corollaire l'ouverture de la liquidation de la société scindée. Cette exception au droit commun n'a pas toujours fait l'unanimité[339] et a été expliquée à une certaine époque par le fait qu'une liquidation dans une hypothèse de scission devait être considérée comme immédiatement clôturée par défaut d'objet dans la mesure où celle-ci emportait transmission de la totalité du patrimoine actif et passif de la société scindée[340]. Cette question a cependant été résolue suite à la transposition de la Directive Sociétés qui pose comme principe que la dissolution de la société scindée n'emporte pas sa liquidation[341]. Il convient toutefois de remarquer que dans un contexte purement interne[342] cette dissolution n'a pas *ab initio* un caractère définitif dans la mesure où la société scindée survivra dans les limbes pendant tout au plus six mois après la date d'opposabilité de la prise d'effet de la scission[343] et ce, d'une part afin de permettre à celle-ci d'accomplir les formalités particulières relatives au transfert de certains éléments particuliers de son patrimoine[344] et d'autre part, afin de pouvoir la ressusciter en cas de nullité de l'opération[345].

339 P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux… », *op. cit.*, p. 10.

340 P. VAN OMMESLAGHE, *ibidem*, p. 10 et pp. 14 à 15 ; J. VAN RYN et P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence des sociétés commerciales », *R.C.J.B.*, 1967, n° 95, p. 390 et J. VAN RYN et P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence des sociétés commerciales », *R.C.J.B.*, 1973, n° 76, p. 546 et Cass., 8 mai 1930, *Pas.*, 1930, I, p. 202. Voir en ce sens également en droit allemand : T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 2, n° 33.

341 Art. 136, § 1er de la Directive Sociétés.

342 À l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, l'art. 160*duovicies*, al. 1er de la Directive Mobilité pose comme principe que la nullité ne peut en être prononcée.

343 Art. 153, c) de la Directive Sociétés.

344 Art. 151, § 3 de la Directive Sociétés.

345 Art. 153 de la Directive Sociétés. Sur la possibilité d'une nullité d'une scission transfrontalière, voir *infra* : Première partie, Titre V, Chapitre 2.

SECTION 2. L'ABSORPTION DU PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ SCINDÉE

§1. Les trois éléments constitutifs de l'absorption

A. *Présentation*

98. La déconcentration *ut singuli* ou *ut universi*. La déconcentration économique d'une entreprise peut être réalisée soit par le biais de l'absorption *ut singuli* des divers éléments d'actif et de passif composant le patrimoine de la société visée, soit par le biais de l'absorption *ut universi* du patrimoine de celle-ci par au moins une autre société. Les opérations de scission entrent dans cette deuxième catégorie de sorte que le patrimoine qui sera ainsi transmis s'entend comme une universalité de droit[346] comprenant à la fois tous les éléments actifs et tous les éléments passifs dont une personne morale est titulaire. Cette déconcentration *ut universi*, qui découle nécessairement de la dissolution sans liquidation[347], suppose la réunion de trois éléments distincts et successifs, à savoir (i) le fractionnement du patrimoine de la société scindée (B), (ii) la transmission à titre universel des fractions du patrimoine de la société scindée (C) et (iii) la confusion entre les fractions de patrimoine de la société scindée et celui des sociétés bénéficiaires (D).

B. *Le fractionnement du patrimoine de la société scindée*

99. L'éclatement du patrimoine de la société scindée. L'éclatement du patrimoine de la société scindée en diverses fractions qui seront réparties entre les sociétés bénéficiaires dans le projet commun de scission constitue une étape fondamentale du processus et est propre à ce type d'opération. Les parties jouiront à cet égard d'une liberté considérable, mais pas absolue[348], pour définir les diverses fractions du patrimoine de la société scindée, étant entendu qu'une telle fraction pourra être constituée d'un élément unique[349] et que la répartition ne doit pas nécessairement être rationnelle du point de vue de l'entreprise sous-jacente[350].

C. *La transmission à titre universel*

1. *Le principe*

100. Un principe essentiel. Une fois cette répartition réalisée, les divers éléments seront transmis à titre universel aux sociétés bénéficiaires sans, en principe, devoir obtenir l'accord préalable de chaque tiers intéressé, ni même de les faire intervenir. Il est intéressant de relever que seules les sociétés bénéficiaires de l'opération peuvent se voir transmettre les fractions du patrimoine de

346 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 278 et 279, n° 408.
347 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 155.
348 Sur la liberté dont les parties jouissent au niveau de la répartition des fractions du patrimoine actif et passif de la société scindée, voir *infra* n°s 484 à 498.
349 Voir en ce sens : M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 123, n° 1.
350 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 123, n° 1.

l'entité scindée. Il n'est donc pas possible d'attribuer certains éléments d'actif ou de passif déterminés à un tiers à l'opération tel qu'un associé de la société scindée[351]. Cette transmission à titre universel de patrimoine constitue la pierre angulaire des opérations de scission dans la mesure où elle permet d'éviter un fastidieux transfert *ut singuli* de tous les actifs et passifs de la société apporteuse. Elle constitue également la caractéristique essentielle qui distingue la scission de l'apport en nature d'actifs à deux ou plusieurs sociétés à la suite d'une liquidation de la société apporteuse[352]. Si l'application de ce principe aux fusions a été reconnue assez rapidement[353], la situation s'est avérée différente en matière de scissions, et ce en raison de la pluralité d'ayants cause dans ce type d'opération[354]. Ce point est à présent tranché, le législateur européen ayant choisi d'attribuer aux scissions des effets identiques à ceux d'une fusion[355].

2. *Une justification malaisée*

101. La justification par la continuation de la personnalité morale de la société scindée. Bien que fondamentale, cette transmission à titre universel n'en est cependant pas évidente. En effet, la théorie classique de la transmission universelle de patrimoine d'une personne physique reposait sur la fiction issue du droit romain[356] de la continuation de la personnalité du *de cujus* par son ayant cause[357]. Appliquée à l'hypothèse de la transmission universelle de patrimoine en cas de scission, cela a abouti à considérer que la personnalité de la société apporteuse se trouvait prolongée dans celle des sociétés bénéficiaires. Cette justification, qui a connu un certain succès en jurisprudence belge dans la première moitié du vingtième siècle[358], a permis une assimilation avec la situation de l'ayant cause suite au décès du *de cujus*[359] et a ainsi justifié le recours à la théorie de la cession des droits successifs fondée sur l'article 1122 du Code civil[360]. Cette théorie a, par après, fait l'objet d'une confirmation par la Cour de cassation belge qui a cependant rejeté la fiction de la continuation de la personnalité de la société apporteuse[361]. Ce rejet de la fiction de la continuation de la personnalité morale de la société apporteuse a, au demeurant, été considéré comme justifié par certains auteurs compte tenu du lien indissociable existant entre personnalité morale et patrimoine dans son acceptation subjective, ce dernier empêchant la survie du sujet suite à la transmission de son patrimoine[362].

351 Voir en ce sens : N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 20, n° 32.
352 G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *op. cit.*, p. 28.
353 Cass., 30 avril 1970, *Pas.*, 1970, I, p. 749.
354 K. GEENS, *op. cit.*, p. 147 et Bruxelles, 6 décembre 1991, *T.R.V.*, 1992, p. 253.
355 Art. 136, § 1er de la Directive Sociétés et art. 160*novodecies* de la Directive Mobilité.
356 R. LEDAIN SANTIAGO, *La circulation du cautionnement – Contribution à l'étude du transfert à titre particulier et de la transmission à titre universel du contrat de cautionnement*, Windhof, Promoculture, Larcier, 2014, pp. 73 et 74 ; R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 32 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 43, n° 48.
357 R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 4.
358 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 44 et 45, n° 49 et Liège, 31 mars 1939, *Rev. prat soc.*, 1939, p. 294 ; Comm. Bruxelles, 6 décembre 1935, *Rev. prat soc.*, 1936, p. 20 et Comm. Bruxelles, 30 mars 1932, *Rev. prat soc.*, 1932, p. 190.
359 Ch. RESTEAU, *Traité des sociétés anonymes*, 3e éd., Bruxelles, Swinnen, 1982, pp. 507 et 508.
360 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 45, n° 49.
361 Cass., 30 avril 1970, *Pas.*, 1970, I, p. 749.
362 F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, pp. 167 et s.

102. La justification par la continuation de la personnalité économique de la société scindée. Cependant, si la personnalité morale de la société apporteuse disparaît suite à la transmission de son patrimoine, sa personnalité économique, soit l'entreprise, se poursuit du fait même de l'absence de liquidation. Il est ainsi considéré tant en droit français[363] qu'en droit belge suite à l'adoption de la loi du 29 juin 1993 ayant transposé les Troisième et Sixième Directives[364] que la transmission universelle du patrimoine de la société apporteuse trouve sa justification dans la continuation de l'entreprise de la société apporteuse par les sociétés bénéficiaires. En d'autres termes, une scission peut s'analyser comme une opération de restructuration économique ayant pour objectif une rationalisation de l'entreprise en vue de poursuivre celle-ci de manière plus efficiente. Cette théorie offre l'avantage d'une part de la cohérence avec la transmission universelle de patrimoine des personnes physiques et, d'autre part, de correspondre à la réalité tangible du maintien suite à la réalisation de l'opération de scission de l'affectation des moyens matériels et humains à l'accomplissement d'une activité économique[365]. Elle prête néanmoins le flanc à la critique à certains égards. Ainsi la nature imprécise de la notion d'entreprise qui suppose l'existence d'une activité économique sous-jacente[366] s'avère incapable de justifier l'application du principe de la transmission universelle à des opérations de restructuration impliquant des personnes morales n'exerçant pas une activité économique[367]. Ensuite, cette théorie se révèle également incapable de justifier le recours à la transmission d'une universalité alors qu'une transmission *ut singuli* de tous les éléments d'actif et de passif en cas de cession de fonds de commerce permet également une telle continuation[368].

103. La justification par la continuation de l'activité. Face aux difficultés rencontrées par la thèse de la continuation d'entreprise à appréhender l'application des opérations emportant transmission universelle de patrimoine aux groupements, certains auteurs ont cherché une justification dans la continuité de l'activité de la société apporteuse[369]. Cependant, il a été reproché à cette justification de reposer sur une conception utilitariste de la personne morale dans la mesure où l'activité de celle-ci n'est que le moyen d'atteindre l'objectif fixé par les fondateurs et non l'objectif lui-même[370]. Par conséquent, même si la continuation de l'activité est à même de fonder la transmission des éléments d'actif et de passif inexorablement liés à l'activité de la société apporteuse, elle

363 Y. CHEMINADE, *op. cit.*, p. 15 ; M. DUBERTRET, « L'*intuitus personae* dans les fusions », *Rev. Soc.*, 2006, p. 721, disponible sur www.dalloz.fr (04/01/2020), p. 2 ; R. LEDAIN SANTIAGO, *op. cit.*, pp. 78 et 79 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 62.

364 G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *op. cit.*, pp. 26 et 27 et P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux… », *op. cit.*, p. 5.

365 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 63.

366 Al. JONES et Br. SUFRIN, *EC Competition Law*, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 128 et s. ; R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 63 et R. WHISH, *Competition Law*, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 82 et s. et C.J.C.E., arrêt *Klaus Höfner et Fritz Elser c. Macrotron GmbH*, 23 avril 1991, C-41/90, EU:C:1991:161, pt. 21.

367 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 65.

368 R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 64.

369 R. LEDAIN SANTIAGO, *op. cit.*, p. 81 ; R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 67 et F. WAREMBOURG-AUQUE, *La succession aux biens d'une personne morale de droit privé*, thèse, Lille, 1977, n° 232, cité par R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 67.

370 R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 69.

aboutit à confondre le but de la société, qui n'est autre que l'intérêt commun des associés, et le moyen de l'atteindre, qui est l'activité.

104. La justification par la modification de l'affectation. Si, en revanche, on place cette affectation sociale au centre de la réflexion et qu'on considère que la constitution d'une société n'est que l'acte par lequel les associés allouent un certain nombre de biens à la satisfaction d'un but commun et que cette affectation justifie à elle seule l'autonomie du patrimoine social, il peut être défendu qu'une opération de scission procède d'une modification de cette affectation[371] par le biais de l'allocation des biens composant le patrimoine de la société scindée à la satisfaction des intérêts des associés des sociétés bénéficiaires, celui-ci se confondant à la suite de l'opération avec celui des associés de la société apporteuse. Cependant, cette thèse, à l'instar de celle de la continuité de l'entreprise, peine à justifier le recours à la transmission universelle dans la mesure où une cession de fonds de commerce suivie d'une dissolution et d'une liquidation peuvent également procéder d'une modification de l'affectation. De plus, si on accepte la thèse voulant que les associés jouissent du pouvoir de créer un patrimoine d'affectation distinct du leur, il peut paraître surprenant qu'ils puissent modifier cette affectation autrement qu'à l'unanimité. Or, à titre d'illustration le droit belge prévoit, sauf dispositions statutaires plus contraignantes, que la scission n'impliquant que des sociétés anonymes doit être approuvée à la majorité des trois quarts des voix exprimées par une assemblée générale des associés lors de laquelle au moins la moitié du capital social est représentée[372].

105. Un principe foncièrement pragmatique. Il découle de ce qui précède que l'analogie avec la succession d'une personne physique s'avère foncièrement inadéquate, ne fût-ce que parce que la société apporteuse, contrairement au *de cujus*, peut, à tout le moins dans un contexte interne, revenir d'entre les morts[373] et qu'il lui est difficile d'expliquer pourquoi les sociétés bénéficiaires sont à qualifier d'ayants droit à titre universel en lieu et place des associés de la société scindée[374]. Indépendamment de toute justification doctrinale, la transmission universelle de patrimoine découle avant toute chose d'une nécessité économique, à savoir de permettre à une entreprise de réaliser une opération de déconcentration économique de manière simple et efficace sans devoir procéder à une fastidieuse transmission *ut singuli* de tous les éléments de son patrimoine, chose pratiquement impossible dans l'hypothèse d'une société cotée. Elle implique qu'une scission s'inscrive dans un processus de simplification du transfert des droits et obligations d'une personne morale[375] et doive nécessairement s'accompagner d'une transmission universelle de patrimoine *sui generis* non soumise aux limites traditionnelles applicables à la transmission du patrimoine d'une personne physique. Une telle possibilité laissée à la discrétion des assemblées générales statuant uniquement à une majorité renforcée présente néanmoins le désavantage, de par sa nature illimitée, d'entraîner

371 R. RAFFRAY, *ibidem*, pp. 69 et s.
372 Art. 12:67, § 1er et 12:83, § 1er du CSA.
373 Art. 153 de la Directive Sociétés.
374 R. ROUTIER, *op. cit.*, p. 28, n° 77.
375 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 98 et P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux… », *op. cit.*, p. 4.

le risque d'être particulièrement dommageable tant aux associés minoritaires s'étant opposés à une restructuration du patrimoine de la société apporteuse qu'aux tiers tels que les créanciers, aussi bien privilégiés que chirographaires.

D. *La confusion entre les fractions de patrimoine de la société scindée et celui des sociétés bénéficiaires*

106. Intégration des fractions de patrimoine. Suite à ce transfert, il y aura confusion entre les fractions de ce patrimoine et celui des sociétés bénéficiaires[376]. Cette confusion s'opérera, contrairement à ce qui était le cas lorsque les scissions s'analysaient comme un apport en nature, par simple addition comptable[377]. Il s'ensuit que des ensembles d'éléments composant le patrimoine de la société scindée se retrouveront intégrés dans le patrimoine des sociétés bénéficiaires sans autres formalités que celles requises pour l'opposabilité de l'opération elle-même et sans que les différents éléments les composant ne soient nécessairement évalués économiquement, à l'instar des créances qui seront transmises à la société bénéficiaire sans qu'il n'y ait novation et sans devoir respecter le formalisme de l'article 1690 du Code civil[378]. De même, le transfert de principe du volet passif, s'il a pour sa part longtemps posé problème dans la mesure où la novation par substitution de débiteur n'est possible qu'avec le consentement du créancier[379], est à présent acquis[380].

§ 2. Un principe aux contours incertains

107. Une transmission incertaine. Cependant, malgré ce principe, de nombreux cas particuliers demeurent obscurs et suscitent un important contentieux[381], notamment en raison du fait que le législateur européen a laissé une

376 R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 174.

377 P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux… », *op. cit.*, p. 53.

378 M. DUBERTRET, *op. cit.*, p. 2 et C.A. Luxembourg, 9 février 1994, n° 14595 et Cass. Com. (France) 1er juin 1993, *BJS*, 1993, p. 892.

379 Voir art. 1271 et s. du Code civil belge, disponible sur www.ejustice.just.fgov.be (07/11/2021) (ci-après le « **Code civil belge** ») et §§ 414 et s. Bürgerliches Gesetzbuch (ci-après le « **BGB** »), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021) et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 2, n° 9 et O. POELMANS, *Droit des obligations au Luxembourg – Principes généraux et examen de jurisprudence*, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 478 et 479. Au niveau du futur régime applicable à la cession de dette en droit belge dans le cadre de la réforme du Code civil, voir art. 5.187 à 5.192 de la proposition de loi portant le Livre 5 « Les Biens » du Code civil, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n° 55-1806/001.

380 D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, « Transmission *ut universi* en cas d'opérations de restructuration d'entreprises : principe et exceptions » in *Obligations. Traité théorique et pratique*, Bruxelles, Kluwer, 2014, p. 113.

381 Pour des études générales sur les limites à la transmission universelle de patrimoine dans le cadre d'une fusion ou d'une scission voir notamment : J. HAHN, *Grenzen der Gesamtrechtsnachfolge bei Verschmelzungen nach dem Umwandlungsgesetz*, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2012 ; J. HENNRICHS, *Formwechsel und Gesamtrechtsnachfolge bei Umwandlungen*, Berlin, Duncker & Humblot, 1995 ; R. LEDAIN SANTIAGO, *op. cit.*, N. LEONARD et St. SIMON in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 20, nos 8 à 72 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 20, nos 1–27 ; T.-V.-N. NGUYEN, *La protection des créanciers sociaux dans les opérations emportant transmission universelle de patrimoine*, thèse, Paris II, 2003 et R. RAFFRAY, *op. cit.*.

marge de manœuvre considérable aux États membres en leur permettant de prévoir des formalités particulières conditionnant l'opposabilité de la transmission de certains éléments particuliers du patrimoine[382]. Cette difficulté d'appréhension se retrouve également dans la Directive Mobilité où le législateur européen a, de manière a priori surprenante, pris la peine de préciser que les fractions de patrimoine transférées comprenaient « tous les contrats, crédits, droits et obligations »[383], ainsi « les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet »[384]. À titre d'exemples d'éléments du patrimoine de la société scindée dont la transmission est susceptible de présenter certaines difficultés, on peut citer les contrats *intuitu personae*[385] (comme les contrats de distribution commerciale[386], les contrats de mandat[387] ou encore une participation en tant qu'associé commandité dans une société en commandite[388]), les contrats de travail conclus avec la société absorbée ou scindée[389], les sûretés tant réelles que personnelles[390], les autorisations administratives concédées à la société absorbée[391], les instances civiles en cours

382 Art. 151, § 3 de la Directive Sociétés (scissions internes) et art. 160*novodecies*, § 5 (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

383 Art. 160*novodecies*, §§ 1, a) (scissions totales), 2, a) (scissions partielles) et 3, a) (scissions par séparation) de la Directive Mobilité. Voir à ce sujet : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *Der Konzern*, 2018/06, p. 243.

384 Art. 160*novodecies*, §§ 1, c) (scissions totales), 2, c) (scissions partielles) et 3, c) (scissions par séparation) de la Directive Mobilité.

385 Voir R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 6 qui prévoit que l'opération entraîne l'extinction des « *höchstpersönliche Rechte* ».

386 M. DUBERTRET, *op. cit.*, p. 2 et Cass. Com. (France) 7 juin 2006, *Recueil Dalloz*, 2006, p. 1685 ; Cass. Com. (France) 13 décembre 2005, *RTD com.*, 2006, p. 429 et Cass. Com. (France) 29 octobre 2002, *Recueil Dalloz*, 2006, p. 429.

387 M. DUBERTRET, *ibidem*, p. 2 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 24 qui part du principe que les procurations générales données par la société s'éteignent avec la scission. Voir en ce sens également : N. LEONARD et St. SIMON in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 17. *Contra* : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 25 qui considère qu'il est dans l'intérêt de la société absorbante de reprendre les procurations générales et qu'une exception à la transmission universelle n'est par conséquent pas justifiée.

388 Voir R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 20, n° 7 qui part du principe qu'une fusion s'assimile à l'hypothèse de la mort de l'associé commandité, impliquant qu'un transfert de cette participation ne sera possible que s'il est explicitement prévu par le contrat de société régissant la société en commandite. Voir également en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 20. *Contra* : N. LEONARD et St. SIMON in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 20, n°s 24 et 25 qui considèrent que la sécurité juridique impose de partir du principe que la part sociale de commandité est valablement transférée à l'entité absorbante, sauf si les statuts de la société en commandite prévoient le contraire, étant entendu que les autres actionnaires peuvent demander (i) à quitter la société ou (ii) l'exclusion de la société absorbante.

389 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 20, n° 11 ; Al. STEICHEN, *op. cit.*, 5e éd., p. 409, n° 554 et C.A. Luxembourg 20 janvier 2011, n° 35625, *Bull. Barreau 5/2011*, p. 71.

390 M. DUBERTRET, *op. cit.*, pp. 5–7 ; D. HOUTCHIEFF, « Contribution à l'étude de l'intuitus personae, Remarque sur la considération du créancier par la caution », *RTD civ.*, 2003, p. 3 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 20, n° 18 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 105 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 287 et 288, n°s 423 et 424 et Cass. com. 17 juillet 2001, *Recueil Dalloz*, 2001, p. 2414.

391 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 20, n°s 12 et 13 ; N. LEONARD et St. SIMON in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 20, n°s 70 à 71a ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 20, n° 26 qui considèrent que les autorisations administratives passent en principe à la société absorbante, à l'exception de celles qui sont *intuitu personae* ou liées à une

impliquant la société absorbée ou scindée[392], le transfert de la responsabilité pénale[393] ou civile[394] de la société scindée à une des sociétés bénéficiaires, le transfert de contrats dont l'exécution est inconciliable avec des contrats existants au niveau de la société absorbante[395], comme les contrats contenant une clause de non-concurrence ou encore les mécanismes conventionnels développés par la pratique pour empêcher le transfert d'un actif (comme les clauses d'incessibilité[396], d'agrément[397] ou de préemption[398]) ou d'un passif (comme les clauses d'exigibilité immédiate[399]). Un examen détaillé de ces différentes limites dépasserait de loin le cadre de la présente étude, mais il convient toutefois de retenir que (i) le principe fondamental reste celui de la transmission de la totalité (en cas de scission totale) ou d'une partie seulement (en cas de scission partielle) du patrimoine actif et passif de la société scindée et (ii) que des aménagements contractuels préalables à l'opération sont possibles[400].

108. Illustration : l'arrêt *Modelo Continente Hipermercados*. La difficile appréhension par les législateurs nationaux de la transmission universelle de patrimoine est parfaitement illustrée par les faits à la base de l'arrêt *Modelo Continente Hipermercados*[401]. Le litige en question opposait Modelo Continente

forme sociale particulière et Th. TILQUIN, *ibidem*, pp. 297 et 298, n° 439 qui part du principe que les autorisations administratives passent à la société bénéficiaire pour peu que celle-ci présente les caractéristiques nécessaires au maintien de l'autorisation.

392 K. GEENS, *op. cit.*, p. 149 ; B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 44 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 20, n° 11 et D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 124 qui partent tous du principe que la poursuite de la procédure se fait sans aucune interruption. *Contra* : J. HENNRICHS, *op. cit.*, p. 85 et M. STÖBER, « Die Auswirkungen einer Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz auf einen laufenden Zivilprozess », *NZG*, 2006, pp. 574 à 577 qui assimilent la dissolution sans liquidation au cas de la mort d'une partie au procès entraînant une interruption. Pour des cas d'application, voir notamment : BGH, 1er décembre 2003 (II ZR 161/02), *NZG*, 2004, pp. 186 à 189 qui prévoient une continuation sans interruption et Liège, 30 juin 1989, *RPS*, 1990, p. 173 pour une assimilation au décès d'une personne physique.

393 M. DUBERTRET, *op. cit.*, p. 4 et D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *ibidem*, pp. 116 et 117 et Cass. crim., 20 novembre 2001, *Bulletin Joly*, 2004, p. 65.

394 M. DUBERTRET, *ibidem*, p. 4 et D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *ibidem*, pp. 117 et 118.

395 P. VAN OMMESLAGHE, *op. cit.*, p. 49.

396 Al. STEICHEN, *op. cit.*, 5e éd., p. 408, n° 552.

397 G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, « La situation des actionnaires et leurs recours », in *Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal*, éd. du jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles, 1993, pp. 120 à 122, nos 4 à 6 et Al. STEICHEN, *ibidem*, 5e éd., p. 407, n° 551.

398 B. ESPESSON-VERGEAT, « Le jeu des clauses d'agrément et de préemption lors de la transmission universelle du patrimoine de la société », *Recueil Dalloz*, 2003, pp. 1216 et s. ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 109 ; F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, pp. 187 et 188 et Cass. com., 15 mai 2007, *BJS*, 1er octobre 2007, n° 10, p. 1075 ; Cass. com., 6 mai 2003, *BJS*, 2003, n° 10, pp. 812 et 813 et Cass. com., 3 juin 1986, *BJS*, 1986, p. 757.

399 D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *ibidem*, p. 114 et Th TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, pp. 310 et 311, n° 458.

400 Sur les mécanismes conventionnels permettant d'aménager les conséquences de la transmission à titre universel dont s'accompagne une scission en vue de protéger les créanciers de la société scindée, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 3, B.

401 C.J., arrêt *Modelo Continente Hipermercados SA c. Autoridade para as Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT)*, 5 mars 2015, C-343/13, EU:C:2015:146 (ci-après l' « **arrêt *Modelo Continente Hipermercados*** »). Sur cet arrêt, voir notamment : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits of the Company Law Package », *ECFR*, 1-2/2019, p. 269 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243 et D. VERSE et R. WIERSCH, « Die Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2014-2015 », *EuZW*, 2016, p. 332.

Hipermercados SA à l'autorité de surveillance des conditions de travail de Lisbonne. En effet, cette dernière avait infligé des amendes à Modelo Continente Hipermercados SA pour des infractions au droit du travail portugais commises par Good and Cheap – Comércio Retalhista SA avant son absorption par voie de fusion par Modelo Continente Hipermercados SA. La seule question préjudicielle retenue par la Cour de justice visait à déterminer si une fusion par absorption au sens de la Troisième Directive entraînait la transmission à la société absorbante de l'obligation de payer une amende infligée par décision définitive après la prise d'effet de la fusion pour des infractions commises par la société absorbée préalablement à la fusion[402], ce qui a été confirmé en définitive[403].

SECTION 3. L'ATTRIBUTION DE NOUVELLES ACTIONS AUX ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ SCINDÉE

109. Plan de la section 3. Étudier avec précision le troisième élément caractéristique d'une scission transfrontalière, à savoir l'attribution de nouvelles actions aux associés de la société scindée, implique de préciser en premier lieu la notion d'attribution (§ 1), pour ensuite se pencher sur les principes de répartition applicables (§ 2), le rôle joué par la soulte en espèces (§ 3), le sort des participations préalables (§ 4) et le cas des sociétés à l'actif net négatif (§ 5).

§1. La notion d'attribution

110. Entre émission et cession. Suite à la transmission à titre universel de patrimoine de la société scindée, les associés de celle-ci, ou la société scindée dans le cas particulier d'une scission par séparation, se verront attribuer des actions des sociétés bénéficiaires[404]. S'il s'avère que ces actions doivent être nouvellement émises, la scission devra nécessairement comprendre une augmentation de capital des sociétés bénéficiaires[405]. Les nouvelles actions feront ensuite l'objet d'une libération par apport en nature d'une fraction prédéterminée du patrimoine de la société scindée, étant entendu toutefois qu'en application de ce qui est qualifié de « principe de continuité de l'actionnariat » (*Grundsatz der Kontinuität der Mitgliedschaft*) en droit allemand, si des actions partiellement libérées de la société scindée font l'objet de l'échange, la scission n'aura pas pour effet de libérer les associés concernés de leur obligation de paiement du solde du prix de souscription[406]. Cependant, une scission ne

402 Arrêt *Modelo Continente Hipermercados*, pts. 21 et 22.

403 Arrêt *Modelo Continente Hipermercados*, pt. 35 où la Cour de justice a considéré qu'une fusion par absorption « entraîne la transmission, à la société absorbante, de l'obligation de payer une amende infligée par décision définitive après cette fusion pour des *infra*ctions au droit du travail commises par la société absorbée avant ladite fusion ».

404 Art. 136, § 1er de la Directive Sociétés.

405 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 3 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 11.

406 Voir en ce sens : T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 2, n° 32 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 20, n° 12 et A. STENGEL in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 2, n° 40.

doit pas nécessairement s'accompagner d'une émission de nouvelles actions. En effet, les associés de la société scindée, ou la société scindée elle-même en cas de scission par séparation, peuvent également se voir attribuer des actions détenues en propre par les sociétés bénéficiaires[407] pour autant que la répartition prévue par le projet de scission soit respectée.

§ 2. Les principes de répartition

111. Répartition symétrique ou asymétrique. La répartition des actions peut se faire de deux manières distinctes[408]. Il est ainsi possible soit d'attribuer symétriquement de nouvelles actions de toutes les sociétés bénéficiaires à l'intégralité des associés de la société scindée, soit de procéder à une répartition asymétrique des nouveaux titres[409]. Cette deuxième option dénommée « scission asymétrique » implique qu'il est ainsi possible d'aller jusqu'à une situation d'asymétrie totale où chaque associé de la société scindée ne sera associé que d'une seule société bénéficiaire[410]. Cette dernière configuration est fréquente dans les cas où l'actionnariat de la société scindée peut aisément être réparti entre deux groupes distincts ne souhaitant plus travailler ensemble[411]. Dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, elle est d'un intérêt non négligeable dans la mesure où elle permet de procéder à une répartition des nouvelles actions ou parts selon un critère géographique, ce qui sera par après de nature à faciliter le fonctionnement des sociétés bénéficiaires. Le concept de la scission asymétrique implique par ailleurs également que dans le cadre d'une scission partielle où, par définition, la société scindée ne cesse pas d'exister, il est possible qu'un des associés de celle-ci ne se voit attribuer aucune action de la société bénéficiaire[412]. En revanche, une répartition asymétrique compliquera la procédure en tant que telle dans la mesure où, comme elle porte atteinte à l'égalité des associés, de nombreux États membres ont prévu des conditions de majorité renforcée dans une telle hypothèse[413]. De plus, les États membres ont la possibilité de prévoir qu'en pareil cas, les associés minoritaires pourront exercer leur droit de faire acquérir leurs actions à un prix correspondant à la valeur de marché de celles-ci[414]. Il convient également de préciser qu'il découle de la définition même d'une scission interne contenue dans la Directive Sociétés[415] que seuls les associés de la société scindée pourront se

407 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 20, n° 3 ; J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 142 et J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 53, n° 134.

408 J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *op. cit.*, p. 1078, n° 1582 ; J.-M. MOULIN, *ibidem*, p. 75 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, pp. 219 et 220, n° 309.

409 Art. 139, § 2 de la Directive Sociétés.

410 J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *op. cit.*, p. 1078, n° 1582 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 75, n° 209 ; M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 123, n° 5 ; et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, pp. 219 et 220, n° 309.

411 J.-M. MOULIN, *ibidem*, p. 75, n° 209.

412 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 123, n° 5 et C. KUNKEL, « Zulässige nicht verhältniswahrende Spaltung in Form des „Spaltung zu Null" », *jurisPR-HaGesR*, 9/2013, p. 2.

413 Sur ce mécanisme de protection spécifique des intérêts des associés minoritaires, voir *infra* : Deuxième Partie, Titre II, Chapitre 1, Section 5, § 2.

414 Art. 139, § 2 de la Directive Sociétés et sur le droit de retrait des associés minoritaires, voir *infra* : Deuxième Partie, Titre II, Chapitre 1, Section 5, § 3.

415 Art. 136, § 1er et 155, § 1er de la Directive Sociétés.

voir attribuer de nouvelles actions. Une scission ne peut en effet être utilisée pour faire entrer un tiers dans le capital de la société[416].

§3. La soulte en espèces

112. La *ratio legis* de la soulte. Afin d'éviter la problématique des rompus[417], une soulte en espèces pouvant en principe aller jusqu'à dix pourcents de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable[418], pourra être attribuée aux associés de la société scindée, en plus des actions des sociétés bénéficiaires. Cette limite des dix pourcents n'est toutefois pas obligatoire et il est loisible aux États membres d'autoriser des opérations de scission au cours desquelles une soulte supérieure est attribuée[419].

§4. Les participations préalables

113. La problématique des participations préalables. L'échange des titres est susceptible d'engendrer des questions spécifiques dans quatre cas particuliers liés à l'existence de participations antérieures à l'opération de restructuration. La première hypothèse concerne le cas dans lequel une ou plusieurs sociétés bénéficiaires détiennent une participation dans la société scindée, la deuxième vise le cas inverse dans lequel la société scindée détient une participation dans le capital social d'au moins une des sociétés bénéficiaires de l'opération, la troisième vise le cas spécifique des participations croisées et la quatrième concerne les actions propres détenues par la société scindée.

114. La participation préalable par au moins une des sociétés bénéficiaires dans la société scindée. Dans la mesure où la définition d'une opération de scission implique nécessairement l'échange des actions détenues par les associés de la société scindée contre des actions des sociétés bénéficiaires conformément au ratio d'échange établi dans le projet commun de scission[420], les actions détenues par la société bénéficiaire ou par un tiers agissant pour le compte de celle-ci dans le capital social de la société scindée devraient en principe être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires. Ceci pourrait aboutir à une situation de détention d'actions propres et, par conséquent, de fictivité du capital social[421]. Afin d'éviter cette situation, aucune action ne sera échangée

416 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 123, n° 6.

417 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 2, n° 13 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 139 et 140 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 149 et J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 53, n° 135.

418 Art. 136, § 1er de la Directive Sociétés.

419 En droit luxembourgeois, une soulte en espèces supérieure à dix pour cent est possible en vertu de l'art. 1033-1, al. 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales. En revanche, en droit belge des scissions, il n'est pas possible de dépasser cette limite des dix pourcents et sa violation est susceptible d'entraîner la nullité de l'opération. Voir art. 12:19, al. 1er du CSA et sur la conformité de celui-ci au prescrit de la Sixième Directive, voir : G. HORSMANS, « Les nullités et les sanctions » in *Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés*, Centre Jean Renauld, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 231 à 233, nos 30 à 34.

420 Art. 151, § 1, b) de la Directive Sociétés.

421 J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 54.

contre les actions détenues par une société bénéficiaire dans le capital de la société scindée[422]. Cette solution, qui ne se retrouve pas dans la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières en raison du fait qu'elle ne couvre pas les scissions impliquant plus d'une société préexistante[423], si elle a certes l'avantage d'une certaine simplicité et d'être identique à celle applicable en cas de fusion[424], méconnaît cependant le fait qu'une scission implique nécessairement deux sociétés bénéficiaires. Par conséquent, et dans la mesure où une répartition asymétrique totale des actions des sociétés bénéficiaires à attribuer n'est pas exclue[425], il aurait également été possible de prévoir comme principe de base que les actions détenues par une société bénéficiaire dans le capital social de la société scindée doivent soit être échangées contre des actions de l'autre société bénéficiaire, soit, à défaut, ne donner lieu à aucun échange. Cette solution aurait eu pour avantages, d'une part de faciliter la répartition des actifs et passifs de la société scindée dans la mesure où il n'aurait plus été nécessaire de tenir compte de la perte des actions détenues par une des sociétés bénéficiaires et, d'autre part, de conférer davantage de flexibilité au niveau des effets de l'opération en permettant à une des sociétés bénéficiaires d'acquérir, par l'effet de la scission, une participation dans le capital social d'une ou de plusieurs autres sociétés bénéficiaires. En tout état de cause, il n'en demeure pas moins que dans le cadre d'une scission transfrontalière par absorption ou mixte, une participation par une des sociétés bénéficiaires dans la société scindée ne pourra donner lieu à l'attribution d'actions de cette même société bénéficiaire.

115. La participation préalable par la société scindée dans au moins une des sociétés bénéficiaires. L'hypothèse particulière de la détention par la société scindée d'une participation dans le capital social d'une des sociétés bénéficiaires n'a pas été explicitement visée par le législateur européen et n'est susceptible de poser problème que si les titres en question sont attribués à la société émettrice et non à une autre société bénéficiaire suite à la réalisation de l'opération de scission. Si tel est le cas, la situation aboutira à une détention d'actions propres qui, dans le cas des sociétés anonymes[426], doit être strictement encadrée[427]. Cependant, des règles dérogatoires spécifiques ont été prévues dans le cas particulier d'une opération emportant transmission universelle de patrimoine[428], dont une scission est un exemple, ce qui simplifiera la procédure d'acquisition.

116. Les participations croisées. En cas de participations détenues réciproquement par la société scindée et la société bénéficiaire, les deux mécanismes décrits ci-dessus trouveront à s'appliquer cumulativement[429].

422 Art. 151, § 2, a) de la Directive Sociétés.
423 Art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité.
424 Art. 105, § 2, a) et 131, § 5, a) de la Directive Sociétés.
425 J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *op. cit.*, p. 1078, n° 1582 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 75, n° 209 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 219 et 220, n° 309.
426 Art. 60 de la Directive Sociétés.
427 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 219.
428 Art. 61, § 1, b) de la Directive Sociétés.
429 J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 55, n° 141 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 251, n° 359.

117. Les actions propres. S'il s'avère finalement que la société scindée avait déjà acquis des actions dans son propre capital, par exemple pour protéger la société contre une offre publique d'acquisition[430], celles-ci feront l'objet d'une annulation par application du principe de renonciation[431]. Une telle règle se retrouve explicitement tant dans le régime des scissions internes de la Directive Sociétés[432] que dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité[433] qui couvrent tous deux également l'hypothèse dans laquelle les actions en question seraient détenues par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société scindée.

§5. Le cas des sociétés à l'actif net négatif

118. Un principe découlant des règles sur la souscription effective du capital social. Chaque fraction de patrimoine de la société scindée qui sera attribuée aux sociétés bénéficiaires ne pourra en principe avoir un actif net négatif ou nul, entendu comme la valeur nette des fractions apportées telle qu'utilisée dans le cadre d'un apport en nature[434], dans la mesure où l'apport de ces fractions de patrimoine est destiné à libérer le prix de souscription des actions nouvellement émises[435]. Il s'agit là d'une réminiscence de la théorie de l'apport en nature[436] tendant à éviter tout risque de capital social fictif des sociétés bénéficiaires.

119. L'exception de la scission de la filiale commune. À l'instar de ce qui a été fait en matière de fusions[437], on pourrait argumenter que dans le cas bien particulier de la scission d'une société détenue par toutes les sociétés bénéficiaires et lorsque le projet commun ne prévoit de ce fait pas d'émission d'actions, la scission d'une société ayant un actif net négatif dont le patrimoine sera réparti en deux fractions ayant chacune un actif net négatif pourrait être envisageable[438]. De même, la scission d'une société ayant un actif net positif ou négatif et dont le patrimoine serait réparti en deux fractions distinctes, l'une ayant une valeur positive, l'autre une valeur négative est possible dans l'hypothèse particulière où la société scindée est détenue partiellement par une des sociétés bénéficiaires de l'opération, que la répartition du patrimoine

430 J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *op. cit.*, p. 813, n° 1167.
431 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 248, n° 354.
432 Art. 151, § 2, b) de la Directive Sociétés.
433 Art. 160*novodecies*, § 6 de la Directive Mobilité.
434 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, pp. 24, 28 et 29 et G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *op. cit.*, p. 33 ; K. GEENS, *op. cit.*, p. 141 et P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux… », *op. cit.*, pp. 32 et 33.
435 J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 44, n° 101 ; J.-P. SPANG, « La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois : regard du praticien » in *Fusions transfrontalières de sociétés – Droit luxembourgeois et droit comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 94 et P. VAN OMMESLAGHE, *ibidem*, p. 32.
436 J.-P. SPANG, *op. cit.*, p. 95 ; Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 54, n° 64 et P. VAN OMMESLAGHE, *op. cit.*, p. 53.
437 J.-P. SPANG, *ibidem*, pp. 94 et 95 ; Th. TILQUIN, *ibidem*, p. 54, n° 64 et P. VAN OMMESLAGHE, « La proposition de troisième directive… », *op. cit.*, p. 124.
438 Voir en ce sens M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 123, n° 1 qui insiste sur l'intérêt d'une telle opération pour transférer les dettes relatives aux pensions d'une filiale à sa mère.

opérée dans le projet commun de scission est telle, qu'aucune nouvelle action ne doive être émise à la société détenant une participation préalable dans la société scindée et que la fraction de patrimoine ayant une valeur négative soit attribuée à cette société. Certains auteurs en matière de fusions ont redouté que l'exception de la filiale détenue à cent pourcents ne soit utilisée abusivement afin de réduire les effets d'une faillite de la société absorbée au détriment des créanciers, de sorte que la nécessité d'un actif net devait être considérée comme une condition essentielle d'une telle opération[439]. Cependant, force est de constater d'une part qu'une telle exigence ne figure ni dans la Directive Sociétés, ni dans la Directive Mobilité et ne devrait dès lors pas être imposée en l'absence de texte, et d'autre part, que l'argument de la protection des créanciers en cas de risque de faillite méconnaît les mécanismes de protection spécifiques prévus par le législateur européen à cet égard[440].

120. Un principe à l'efficacité restreinte. Par ailleurs, même si on part du principe que seules des sociétés dont l'actif net global est positif et dont le patrimoine peut être divisé en fractions ayant chacune également une valeur positive puissent faire l'objet d'une scission, force est de constater que ni la Directive Sociétés, ni la Directive Mobilité n'impose de méthode spécifique d'évaluation[441]. Par conséquent, en pratique, les parties veilleraient systématiquement à choisir la méthode d'évaluation aboutissant au résultat souhaité afin de contourner cette interdiction.

SECTION 4. UN ÉLÉMENT D'EXTRANÉITÉ BIEN DÉTERMINÉ

121. Scission nationale avec composantes multinationales. Il est peu fréquent qu'une opération de scission ne présente aucun élément d'extranéité. Ce dernier peut se manifester de multiples façons[442]. Ainsi, certains éléments composant le patrimoine, comme un immeuble ou une succursale, peuvent être situés dans un État membre distinct de celui de la société scindée. Il est également possible que certains associés ou certains créanciers de la société scindée soient issus d'un autre État membre. De telles situations sont indéniablement susceptibles de poser des problèmes de droit international privé, par exemple si l'État membre dans lequel est situé un bien immobilier détenu par une société scindée soumise au droit d'un autre État membre impose des formalités particulières en cas de transmission universelle d'un tel bien et que le droit applicable à ces formalités s'avère être la *lex rei sitae*. Cependant, si tant les sociétés bénéficiaires de la scission que la société scindée sont soumises au droit du même État membre, une telle scission sera qualifiée de nationale ou d'interne.

122. Scissions transnationales et scissions transfrontalières. Dès l'instant où la société scindée et une des sociétés bénéficiaires se trouvent soumises au droit

439 G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *op. cit.*, pp. 33 et 34.
440 Art. 137, § 3, al. 2 et 146 de la Directive Sociétés et art. 160*undecies* de la Directive Mobilité.
441 Sur cette insuffisance, voir *infra* n° 304 et n° 450.
442 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 7 et U. LENNERZ, « Die internationale Verschmelzung und Spaltung unter Beteiligung deutscher Gesellschaften », Verlag Dr. Otto Schmidt, Cologne, 2001, p. 14.

de deux États membres distincts, l'opération de scission est dite transfrontalière[443]. Il convient toutefois de remarquer que dans son acceptation la plus communément admise, le terme transfrontalier se réfère à « ce qui concerne le franchissement d'une frontière, ce qui se trouve de part et d'autre d'une même frontière »[444]. Dans la mesure où les hypothèses de scission envisagées ci-après ne recouvrent pas nécessairement des cas entre sociétés relevant du droit de pays limitrophes, il faudrait parler d'opérations « transfrontières » ou « transnationales »[445]. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne, soucieuse vraisemblablement de coller à la traduction du terme anglais « *cross-border* » semble avoir adopté cette terminologie pour désigner tout ce qui implique plusieurs États membres, peu important qu'ils soient limitrophes ou non.

123. Scission-émigration et scission-immigration. Dans toute hypothèse de scission transfrontalière, l'opération sera vue comme une émigration dans le chef de l'État membre de la société scindée et comme une immigration dans le chef de l'État membre de la ou des sociétés bénéficiaires. Il en découle que l'opération pourra se voir confrontée, d'une part, à des obstacles dressés à la sortie dans l'État membre d'origine et, d'autre part, à des obstacles dressés à l'entrée dans l'État membre d'accueil.

SECTION 5. CONCLUSION SUR LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES

124. Une définition complexe. Il résulte de ce qui précède qu'une scission transfrontalière totale *stricto sensu* peut être définie comme une opération de déconcentration, par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à au moins deux sociétés, chacune de celles-ci pouvant être soit préexistante soit nouvellement constituée et dont l'une est nécessairement soumise au droit d'un État membre distinct de celui de la société scindée, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces. Cette définition de base composée de quatre éléments est susceptible de subir trois aménagements spécifiques. Ainsi, si la scission ne s'accompagne pas de la dissolution sans liquidation de la société scindée, elle sera dite partielle. Si elle ne s'accompagne pas de l'émission d'actions de la société bénéficiaire dans la mesure où elle porte sur la scission partielle d'une filiale au profit de sa société-mère, elle sera dite silencieuse. En revanche, si les actions de la ou des sociétés bénéficiaires sont attribuées non pas aux associés de la société scindée, mais à la société scindée elle-même, la scission sera dite par séparation. On ne peut qu'en déduire que la notion de scission couvre en réalité un vaste éventail d'opérations distinctes.

443 Fl. GUILLAUME, « La fusion transfrontalière de sociétés de droit suisse » in *Fusions transfrontalières de sociétés – Droit luxembourgeois et droit comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 238. Voir également art. 160*bis*, § 1er de la Directive Mobilité selon lequel la scission sera transfrontalière si « au moins deux des sociétés de capitaux impliquées dans la scission sont régies par le droit d'États membres différents ».

444 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transfrontalier_transfrontali%C3%A8re/79124 (03/11/2021).

445 J. VERMEYLEN, « Arrêt « Vale Epítesí » : la mobilité transfrontalière du siège statutaire est-elle un droit ? », *J.D.E.*, 2012/9, p. 276.

Conclusion sur le procédé de déconcentration économique que constituent les scissions transfrontalières

125. Une opération particulière digne d'intérêt. Constituant le reflet économique des fusions, les scissions, qui peuvent être par séparation, par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou mixtes, constituent une opération de déconcentration dont l'efficacité n'est plus à démontrer et sont susceptibles d'être mises en œuvre tant dans le cadre d'une stratégie offensive que dans le cadre d'une stratégie défensive. Leur nature singulière se rapproche tantôt du contrat *sui generis* et tantôt de l'acte juridique unilatéral, mais malgré cette nature polymorphe, elles se caractérisent en principe par quatre éléments constitutifs fondamentaux, à savoir (i) une dissolution sans liquidation, (ii) l'absorption du patrimoine de la société scindée, (iii) l'attribution d'actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée en échange de leurs actions dans la société scindée et, le cas échéant d'une soulte en espèces et (iv) un élément d'extranéité bien déterminé, étant entendu que ces éléments sont susceptibles de subir certains aménagements dans les hypothèses d'une scission partielle, d'une scission par séparation ou encore d'une scission silencieuse.

TITRE II
Les scissions transfrontalières sous l'angle des libertés fondamentales

SOMMAIRE

Introduction du titre II 131
Chapitre 1. Les scissions transfrontalières sous l'angle de la liberté d'établissement 137
Chapitre 2. Les scissions transfrontalières sous l'angle de la libre circulation des capitaux 207
Conclusion sur les scissions transfrontalières sous l'angle des libertés fondamentales 225

Introduction du titre II

126. L'intérêt d'un regard favorable à l'intégration européenne. S'il a pu être démontré que les scissions transfrontalières présentaient un indéniable intérêt pour les entreprises, il reste encore à déterminer comment en faire une réalité au sein du marché intérieur. En vue de cette finalité, le présent titre consacré à l'incidence de deux libertés fondamentales sur les opérations de scission transfrontalière au sein de l'Union européenne a pour objet premier de mettre en lumière les enseignements que l'on peut tirer de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière. Il se justifie, malgré un caractère inévitablement fragmentaire dû à l'approche au cas par cas de la juridiction européenne suprême, pour deux raisons. Tout d'abord, suite aux nombreux échecs d'un grand nombre d'initiatives supranationales relatives à la mobilité transfrontalière des personnes morales au sein de l'Union européenne, comme la proposition de directive sur les fusions transfrontalières de 1985[446] ou le projet de quatorzième directive sur le transfert transfrontalier du siège statutaire d'une société[447], la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement a joué un rôle de précurseur dans les développements et la consécration des modes de mobilité transfrontalière des personnes morales[448]. Ensuite, contrairement aux autres institutions européennes, comme la Commission ou le Parlement, elle est moins sensible à la dimension politique de la matière[449][450] de sorte que les conclusions auxquelles elle aboutit sont

446 Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, COM (84) 727 final, présentée par la Commission au Conseil le 14 janvier 1985, *J.O.C.E.*, n° C 23/11, du 23 janvier 1985. Voir à ce sujet : D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 108 et 109 ; R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 6 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 100 et 101 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *J.T.*, 10 octobre 2009, n° 6365, p. 582.

447 Voir notamment à ce sujet : Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 16, n° 11 ; W. *VON BISMARCK, Grenzüberschreitende Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften in Europa – Gestaltungsvorschläge für eine 14. gesellschaftsrechtliche Richtlinie*, 2005, Frankfurt am Main, Peter Lang ; G.-J. VOSSESTEIN, « Transfer of the registered office – The European Commission's decision not to submit a proposal for a Directive », *Utrecht Law Review*, mars 2008, vol. 4, n° 1, pp. 53–65 et E. WYMEERSCH, « Is a directive on corporate mobility needed? », *E.B.O.R.*, mars 2007, vol. 8, n° 1, pp. 161–169. Voir également : Richtlinienvorentwurf zur Verlegung des Gesellschaftssitzes innerhalb der EU, Doc XV/6002/97, *ZIP*, 1997, pp. 1721–1724 pour le texte de la proposition de directive.

448 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 2225 et M. COMBET, *op. cit.*, p. 51.

449 Voir en ce sens : E. DUBOUT, « Le libéralisme politique de la Cour de justice – Le cas de la liberté d'entreprise », in L. CLÉMENT-WILTZ (dir.), *Le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 148 qui explique ce caractère dé-politisé par (i) les origines variées des juges, (ii) leurs profils foncièrement différents, leur nombre ainsi que par l'aléa de la composition de la Cour de justice ; A. GRIMMEL, « Politics in Robes ? The European Court of Justice and the Myth of "Judicial Activism" », *Discussion Paper N° 2/11*, disponible sur https://www.ssrn.com (05/05/2019), p. 21 et intervention de Mr. BARTLOMIEJ KURCZ lors de la conférence intitulée « Dialogue between experts and practitioners relating to the mobility aspects of the EU Commission's "Company Law Package" (from 25 April 2018) », p. 2. Voir également : J. FRANKENREITER, « Are Advocates General Political? – Policy preferences of EU Member State governments and the voting behavior of membres of the European Court of Justice », 20 février 2017, disponible sur https://www.ssrn.com (05/05/2019), pp. 1–38 qui, par le biais d'une approche quantitative, établit l'existence d'une relation entre les préférences politiques des gouvernements des États membres à l'égard de l'intégration européenne et le comportement décisionnel des avocats généraux nommés par ces gouvernements.

450 Il convient de préciser que certaines caractéristiques propres à la Cour de justice telles que l'utilisation d'arguments purement techniques et juridiques, l'absence de « *dissenting opinions* » à la

bien moins susceptibles d'être biaisées par des considérations extralégales[451] ou de refléter fidèlement les préférences politiques des États membres dont les différents juges sont issus[452]. En effet, dans l'abondante littérature relative au rôle politique joué par la Cour de justice[453], à la frontière entre le droit et les sciences politiques, il est fréquemment avancé que la Cour de justice est structurellement incitée à privilégier l'intégration européenne par le biais d'une interprétation téléologique du TFUE[454]. Si on combine cet aspect avec le fait qu'il a été démontré que la Cour jouit d'une indépendance unique par rapport aux « *court curbing mechanisms* »[455] classiques[456], une étude détaillée de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de mobilité transfrontalière des personnes morales pourrait permettre de cristalliser certains enseignements à l'égard des scissions transfrontalières qui seront, par définition, moins soumis à l'influence des agendas politiques disparates des États membres.

mode anglo-saxonne, le secret du délibéré et la brièveté des justifications des jugements rendent l'identification et l'appréhension d'un éventuel rôle politique de la Cour de justice particulièrement malaisée. Voir en ce sens : L. CLÉMENT-WILTZ, « Introduction : analyser juridiquement le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne », in L. CLÉMENT-WILTZ (dir.), *ibid.*, p. 15.

451 Selon les termes d'E. DUBOUT qui résume ainsi un des reproches formulés à l'encontre de la Cour de justice : « le conflit dans l'Union est figé dans une solution judiciaire structurellement tranchée selon une logique économique et technique, synonyme de la fin du politique ». Voir E. DUBOUT, *ibid.*, p. 153. Voir également Th. HORSLEY, « Reflections on the role of the Court of justice as the motor of European integration : legal limits to judicial lawmaking », *C.M.L.R.*, n° 50, 2013, p. 943 et Fr. SCHARPF, « Perpetual momentum: directed and unconstrained? », *Journal of European Policy*, 2012, p. 128.

452 Voir en ce sens : E. DUBOUT, *op. cit.*, p. 148 ; Th. HORSLEY, *op. cit.*, p. 943 et Fr. SCHARPF, *op. cit.*, p. 128.

453 Voir notamment : G. BECK, *The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU*, Oxford, Hart Publishing, 2012 ; L. CLÉMENT-WILTZ (dir.), *Le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles, Bruylant, 2018 ; G. CONWAY, *The Legal Limits of Legal Reasoning and the European Court of Justice*, Cambridge, CUP, 2012 ; M. DAWSON, Br. DE WITTE et E. MUIR (dir.), *Judicial Activism at the European Court of Justice*, Northampton, Edward Elgar, 2013 ; H. RASMUSSEN, *On Law and Policy in the European Court of Justice*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1986 et Al. STONE SWEET, *The Judicial Construction of Europe*, Oxford, OUP, 2004. Au sujet plus spécifiquement du rôle politique joué par la Cour de justice dans le cadre de la mobilité transfrontalière des personnes morales, voir : L. L. HANSEN, « Merger, moving and division across national borders – When case law breaks through and overtakes directives », *EBLR*, 2007, pp. 181–204.

454 Voir notamment en ce sens : G. CONWAY, *op. cit.*, p. 205 ; E. DUBOUT, *op. cit.*, p. 151 ; R. D. KELEMEN, *op. cit.*, p. 51 qui qualifie la Cour de justice d' « *aggressive engine of integration* » ; Th. HORSLEY, *op. cit.*, p. 954 qui plaide en faveur de l'analyse de la Cour de justice comme un « *leading institutional actor in the integration process* », à l'instar des organes politiques de l'Union européenne que sont la Commission, le Conseil et le Parlement européens et Y. POIRMEUR, « Comprendre la « justice politique » au niveau européen », in L. CLÉMENT-WILTZ (dir.), *op. cit.*, p. 60 qui avance que la Cour de justice a joué « un rôle politique majeur dans l'intégration européenne ».

455 Par « *court curbing mechanisms* », on entend les mécanismes par lesquels les acteurs politiques exercent une influence sur les juridictions pour les inciter à rendre des décisions ne divergeant pas excessivement des préférences des acteurs politiques. A titre d'exemples, on peut citer le « *resource punishment* » qui consiste à limiter les ressources des juridictions ou à réduire la rémunération des juges et le « *judicial selection and reappointment* » qui consiste à utiliser le pouvoir de nomination des juges par les acteurs politiques pour que les juridictions soient contrôlées par des juges partageant les mêmes préférences politiques que les acteurs politiques en question. Voir à ce sujet : R. D. KELEMEN, *op. cit.*, 2012, p. 44.

456 Voir en ce sens : R. D. KELEMEN, *op. cit.*, pp. 43–58 qui analyse méthodiquement l'incidence de toute une série de « *court curbing mechanisms* » sur la Cour de justice pour aboutir à la conclusion que celle-ci est bien protégée et jouit d'un degré d'indépendance considérable. Voir en ce sens également : Th. HORSLEY, *op. cit.*, p. 943 et Fr. SCHARPF, *op. cit.*, p. 128.

Il convient ainsi de se pencher en premier lieu sur la liberté d'établissement et d'examiner méthodiquement l'abondante jurisprudence en la matière qui, bien que ne visant jamais directement l'hypothèse d'une scission transfrontalière, est susceptible d'apporter de précieux enseignements en la matière (chapitre 1). Dans un second temps, il importera de se concentrer sur la libre circulation des capitaux qui, bien que jouissant généralement de moins de considération dans les études sur la mobilité des personnes morales au sein de l'Union européenne[457], mérite un examen approfondi en raison de son champ d'application particulier (chapitre 2).

457 Voir à titre d'illustration : U. LENNERZ, *op. cit.* ; Th. PRÜM, *op. cit.* et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, qui n'abordent absolument pas cette liberté fondamentale et D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 76–78 ; R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 79 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 82–94 qui n'y consacrent qu'un nombre limité de pages.

Chapitre 1
Les scissions transfrontalières sous l'angle de la liberté d'établissement

SECTION 1. PRÉSENTATION

127. Plan du chapitre 1. La première liberté fondamentale susceptible d'être impactée par une scission transfrontalière est indiscutablement la liberté d'établissement consacrée par les articles 49 et 54 du TFUE. Après un bref rappel des principes de base de cette liberté (section 1) ainsi que des conditions pour qu'une personne morale puisse en bénéficier à l'instar d'une personne physique (section 2), la jurisprudence de la Cour de justice relative aux différentes modalités d'exercice de cette liberté fera l'objet d'une analyse détaillée. En partant du constat que la Cour de justice n'a pas encore eu à connaître d'une scission transfrontalière, il conviendra de commencer par la jurisprudence en matière de fusions transfrontalières en raison de leur grande proximité avec les scissions transfrontalières (section 3), pour ensuite s'attarder sur les cas de transferts de siège (section 4) et de transformations transfrontalières (section 5) afin d'en cristalliser des enseignements aisément transposables aux scissions transfrontalières. Les conclusions auxquelles cette analyse aboutira seront ensuite relativisées par l'indentification des limites inhérentes à celle-ci (Section 6).

128. Liberté d'établissement primaire et secondaire. Consacrée actuellement à l'article 49 du TFUE (ancien article 43 du TCE)[458], la liberté d'établissement constitue une disposition fondamentale du Traité[459] qui permet à tout ressortissant d'un État membre de s'établir sur le territoire d'un autre État membre. En d'autres termes, elle permet à tout ressortissant de l'Union européenne de « participer, de façon stable et continue, à la vie économique d'un [autre] État membre »[460]. Elle consacre donc en tout premier lieu la liberté d'établissement primaire, c'est-à-dire le droit pour un ressortissant d'exercer une activité non salariée et de créer une entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y exercer une activité économique[461]. Elle recouvre toutefois également la liberté d'établissement secondaire, soit la possibilité pour un ressortissant établi à titre principal dans un État membre d'exercer une activité économique accessoire sur le territoire d'un autre État membre au moyen d'agences, de succursales ou de filiales, tout en précisant que la Cour de justice a rappelé à de nombreuses

458 Art. 49 du TFUE.

459 C.J.C.E., arrêt *Segers c. Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen*, 10 juillet 1986, EU:C:1986:308, C-79/85 (ci-après l' « **arrêt *Segers*** »), pt. 12.

460 C.J., arrêt *Trustees of the P Panayi Accumulation and Maintenance Settlements c. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*, 14 septembre 2017, C-646/15, EU:C:2017:682, pt. 27 ; C.J., gde ch., arrêt *Schmelz c. Finanzamt Waldviertel*, 26 octobre 2010, C-97/09, EU:C:2010:632, pt. 37 ; C.J.C.E., arrêt *Centro di Musicologia Walter Stauffer c. Finanzamt München für Körperschaften*, 14 septembre 2006, C-386/04, EU:C:2006:568, pt. 18 ; C.J.C.E., arrêt *Gebhard c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano*, 30 novembre 1995, C-55/94, EU:C:1995:411 (ci-après l' « **arrêt *Gebhard*** »), pt. 25 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *S EVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 29.

461 Chr. ALLMENDINGER, *Die Beschlussfassung zum grenzüberschreitenden Wegzug im Binnenmarkt*, Baden-Baden, Nomos, 2016, p. 25 ; St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *GmbHG*, 3e éd., München, Verlag C. H. Beck, 2017, p. 57, n° 20 et R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 31 et C.J.C.E., arrêt *Lasteyrie du Saillant c. Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie*, 11 mars 2004, C-9/02, EU:C:2004:138 (ci-après l' « **arrêt *Lasteyrie du Saillant*** »), pt. 40.

reprises que cette énumération n'était pas exhaustive[462]. En conséquence, le fait que les scissions transfrontalières n'apparaissent pas *expressis verbis* comme des modalités d'exercice de la liberté d'établissement secondaire dans l'article 49 du TFUE n'implique pas nécessairement que celles-ci soient exclues du champ d'application *ratione materiae* de celui-ci. La distinction entre liberté d'établissement primaire et secondaire n'est pas anodine car si tout ressortissant de l'Union européenne, qu'il se trouve dans un État membre ou un État tiers, peut se prévaloir de la liberté d'établissement primaire, le recours à la liberté d'établissement secondaire nécessite l'existence préalable d'un établissement principal au sein d'un État membre[463]. En revanche, cette distinction n'emporte aucune incidence au niveau de la justification d'une éventuelle entrave[464].

129. Une interprétation large. Compte tenu du fait que la liberté d'établissement est essentielle au développement du marché intérieur[465] car elle permet aux personnes morales d'avoir une activité économique à travers les différents États membres[466], celle-ci est généralement interprétée très largement par la Cour de justice[467]. Cette dernière a ainsi considéré que le champ d'application de cette liberté devait indéniablement recouvrir toutes les règles et pratiques touchant directement à l'exercice d'une activité économique, mais également les règles et pratiques « relatives aux diverses facultés générales, utiles à l'exercice de ces activités »[468], comme à titre d'illustration le « droit d'acquérir,

462 Voir en ce sens : M. LUBY, « Liberté d'établissement des sociétés et fusions transfrontalières », *Recueil Dalloz*, 2006, www.dalloz.fr (15/06/2016), p. 3 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 61 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 17, n° 12 et C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République fédérale d'Allemagne*, 4 décembre 1986, C-205/84, EU:C:1986:463, pt. 21 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 39.

463 R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 32 ; A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *Europarecht*, 11e éd., Tübingen, Mohr Siebeck, 2018, p. 477, n° 983 ; St. HOBE, *Europarecht*, 9e éd., München, Verlag Franz Vahlen, 2017, p. 235, n° 838 ; St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 57, n° 20 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 16, n° 10.

464 R. FRENZEL, *ibidem*, p. 32.

465 La notion de « marché intérieur » est définie à l'art. 26, § 2 du TFUE comme « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités ». Le terme « marché unique » lui est parfois substitué, mais celui-ci n'est pas le terme juridique consacré. Voir en ce sens : P. VAN CLEYNENBREUGEL, *Droit matériel de l'Union européenne – Libertés de circulation et marché intérieur*, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 33.

466 Voir en ce sens : Proposition de la Commission, p. 1 où la Commission considère que « [l]a liberté d'établissement joue un rôle capital dans le développement du marché unique car elle permet aux entreprises de mener des activités économiques dans d'autres États membres sur une base stable » et arrêt *Sevic*, pt. 19.

467 C.J., arrêt *Trustees of the P Panayi Accumulation and Maintenance Settlements c. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*, 14 septembre 2017, C-646/15, EU:C:2017:682, pt. 26 ; C.J., gde ch., arrêt *Schmelz c. Finanzamt Waldviertel*, EU:C:2010:632, 26 octobre 2010, C-97/09, pt. 37 ; C.J.C.E., arrêt *Centro di Musicologia Walter Stauffer c. Finanzamt München für Körperschaften*, 14 septembre 2006, C-386/04, EU:C:2006:568, pt. 18 et Av. Gén., J. KOKOTT, concl. préc. C.J., gde ch., arrêt *Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., en liquidation*, 4 mai 2017, C-106/16, EU:C:2017:351, pt. 33 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 44.

468 C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République hellénique*, 30 mai 1989, C-305/87, EU:C:1989:218, pt. 21 et C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République italienne*, 14 janvier 1988, C-63/86, EU:C:1988:9, pt. 14 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 29 à 32.

d'exploiter et d'aliéner des biens immobiliers sur le territoire d'un autre État membre »[469] ou encore la faculté « d'emprunter, et notamment d'accéder aux diverses formes de crédits »[470].

130. L'exigence d'un élément d'extranéité. Il est utile de préciser qu'il découle du texte même de l'article 49 du TFUE que la liberté d'établissement a exclusivement vocation à s'appliquer aux situations présentant un caractère transfrontalier. Par conséquent, les situations purement internes[471] demeurent de la compétence exclusive des États membres[472], même si la Cour de justice se contente d'un intérêt transfrontalier potentiel pour appliquer les dispositions du TFUE relatives à la liberté d'établissement[473].

131. L'interdiction des restrictions à la liberté d'établissement. Afin de garantir une protection efficace de la liberté d'établissement, l'article 49 du TFUE prohibe par conséquent non seulement les entraves à celle-ci qui génèrent une discrimination directe[474] ou indirecte[475] entre ressortissants, mais également toute mesure qui restreindrait l'exercice de celle-ci, même en dehors de toute hypothèse de discrimination[476]. Par conséquent, « toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de cette liberté »[477] sont

469 C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République hellénique*, 30 mai 1989, C-305/87, EU:C:1989:218, pt. 22.

470 Arrêt *Commission des Communautés européennes c. République italienne*, 14 janvier 1988, C-63/86, EU:C:1988:9, pt. 14.

471 Par « situation purement interne », on entend la situation « dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un État membre ». Voir en ce sens : P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 236 et, plus spécifiquement en matière de liberté d'établissement, C.J., gde ch., arrêt *Ullens de Schooten c. État belge*, 15 novembre 2016, C-268/15, EU:C:2016:874, pt. 47 ; C.J., arrêt *Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona c. Generalidad de Cataluña*, 20 mars 2014, C-139/12, EU:C:2014:174, pt. 42 et C.J.C.E., arrêt *Commission c. France*, 17 juillet 2008, C-389/05, EU:C:2008:411, pt. 49.

472 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, p. 475, n° 981 et C.J.C.E., arrêt *Unità Socio-Sanitaria Locale n° 47 di Biella (USSL) c. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, 16 janvier 1997, C-134/95, EU:C:1997:16, pts. 12 et s.

473 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *ibidem*, p. 475, n° 981 et C.J., arrêt *Promoimpresa Srl c. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro et Regione Lombardia et Mario Melis e.a. c. Comune di Loiri Porto San Paolo et Provincia di Olbia Tempio*, 14 juillet 2016, C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558, pts. 66 et s.

474 Par « discrimination directe », on entend toute discrimination fondée directement sur la nationalité des ressortissants. Pour un cas d'application, voir : C.J.C.E., arrêt *Royal Bank of Scotland plc c. Elliniko Dimosio (État hellénique)*, 29 avril 1999, C-311/97, EU:C:1999:216.

475 Par « discrimination indirecte », on entend toute discrimination qui, bien que n'étant pas directement basée sur la nationalité, aboutit au même résultat par le biais d'autres critères de distinction. Pour des cas d'application, voir : C.J., arrêt *Elodie Giersch e.a. c. État du Grand-Duché de Luxembourg*, 20 juin 2013, C-20/12, EU:C:2013:411 et C.J.C.E., arrêt *P. H. Asscher c. Staatssecretaris van Financiën*, 27 juin 1996, C-107/94, EU:C:1996:251, pts. 38 et 49.

476 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 63 et 64 ; A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, p. 490, n° 1006 ; St. HOBE, *op. cit.*, p. 237, n° 845 ; M. LUBY, « Liberté d'établissement des sociétés et fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 4 ; St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 57, n° 20 ; F. UNZICKER, *Niederlassungsfreiheit der Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union nach der Centros- und der Überseerings-Entscheidung des EuGH*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004, pp. 47–52 et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 253 et C.J., arrêt *Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE c. OCA Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña*, 15 octobre 2015, C-168/14, EU:C:2015:685, pt. 67 ; C.J.C.E., arrêt *Kraus c. Land Baden-Württemberg*, 31 mars 1993, C-19/92, EU:C:1993:125, (ci-après l' « **arrêt *Kraus*** »), pt. 32 et arrêt *Gebhard*, pt. 37.

477 C.J., arrêt *Euro Park Service c. Ministre des finances et des comptes publics*, 8 mars 2017, C-14/16, EU:C:2017:177, (ci-après l' « **arrêt *Euro Park Service*** »), pt. 59 ; C.J., gde ch., arrêt *National Grid*

donc prohibées. Il suffit à cet égard que la mesure nationale en question soit simplement de nature à « dissuader » un bénéficiaire de la liberté d'établissement pour que celle-ci soit en principe prohibée[478]. Il est utile de préciser que les interdictions posées par le TFUE en matière de liberté d'établissement bénéficient en outre d'un effet direct vertical depuis la fin de la période transitoire[479] et peuvent donc être invoquées par tout bénéficiaire à l'encontre d'une autorité nationale[480].

132. La justification des entraves à la liberté d'établissement. Si une discrimination directe ou indirecte sur la base de la nationalité n'est pas indispensable pour établir l'existence d'une entrave à la liberté d'établissement, la présence ou non de celle-ci aura une incidence sur la possible justification de cette entrave. En effet, les mesures directement discriminatoires ne peuvent, de jurisprudence constante[481], être tolérées que si elles sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique[482], à l'exclusion des objectifs purement économiques[483] et qu'elles respectent le principe de proportionnalité[484]. En revanche, il en va autrement pour les mesures indirectement discriminatoires et indistinctement applicables. En effet, ces deux dernières catégories sont susceptibles d'être également justifiées aux conditions du « *Gebhard test* », également dénommé « *rule of reason* »[485], c'est-à-dire qu'elles doivent (i) être justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général,

Indus BV c. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, 29 novembre 2011, C-371/10, EU:C:2011:785 (ci-après l' « **arrêt *National Grid Indus*** »), pt. 35 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Caixa Bank France c. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*, 5 octobre 2004, C-442/02, EU:C:2004:586, pt. 11 ; C.J.C.E., arrêt *Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA et ADP GSI SA*, 17 octobre 2002, C-79/01, EU:C:2002:592, pt. 26 ; C.J.C.E., arrêt *Mac Quen, Pouton, Godts, Antoun c. Grandvision Belgium SA*, 1er février 2001, C-108/96, EU:C:2001:67, pt. 26 et arrêt *Gebhard*, pt. 37.

478 Arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 45 et C.J.C.E., arrêt *The Queen c. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc*, 27 septembre 1988, C-81/87, EU:C:1988:456 (ci-après l' « **arrêt *Daily Mail*** »), pt. 16.

479 Cet effet direct de la liberté d'établissement qui constitue une disposition relative au marché commun suffisamment claire, précise et inconditionnelle a été consacrée par la Cour de justice dès l'arrêt *Reyners*. Voir C.J.C.E., arrêt *Reyners c. État belge*, 21 juin 1974, C-2/74, EU:C:1974:68, pt. 30.

480 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 40 ; A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, p. 487, n° 1000 ; et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 239.

481 C.J., arrêt *Commission c. Allemagne*, 21 janvier 2010, C-546/07, EU:C:2010:25, pt. 48 ; C.J.C.E., arrêt *Commission c. Allemagne*, 18 juillet 2007, C-490/04, EU:C:2007:430, pt. 86 ; C.J.C.E., arrêt *Ciola c. Land Vorarlberg*, 29 avril 1999, C-224/97, EU:C:1999:212, pt. 16 et C.J.C.E., arrêt *Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia (ERT AE) c. Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP) et Kouvelas*, 18 juin 1991, C-260/89, EU:C:1991:254, pt. 24.

482 Art. 52, § 1er du TFUE.

483 P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 266 et C.J.C.E., arrêt *Ciola c. Land Vorarlberg*, 29 avril 1999, C-224/97, EU:C:1999:212, pt. 16 et C.J.C.E., 4 mai 1993, arrêt *Federación de Distribuidores Cinematográficos*, 4 mai 1993, C-17/92, EU:C:1993:172, pt. 21.

484 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, p. 492, n° 1008 et C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République italienne*, 6 juin 1994, C-101/94, EU:C:1996:221, pt. 26.

485 La possibilité de justifier une entrave à une liberté fondamentale par le biais de la « *rule of reason* » trouve son origine dans l'arrêt *Cassis de Dijon* qui concernait plus spécifiquement le cas d'une entrave à la libre circulation des marchandises. Voir A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *ibidem*, pp. 493 et 494, n° 1011 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC – Zugleich eine Besprechung von EuGH RIW 2006, 240 – Sevic », *RIW*, 2006, p. 163 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 67 et Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, p. 79, note 48 et C.J.C.E., arrêt *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, 20 février 1979, C-120/78, EU:C:1979:42, pts. 8, 13 et 14.

(ii) être propres à réaliser cet objectif et (iii) ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre[486]. Malgré le caractère *a priori* manichéen de la distinction entre (i) mesure discriminatoire et (ii) mesure indirectement discriminatoire ou indistinctement applicable, il est cependant important de relever que la Cour de justice ne la suit pas nécessairement et se focalise davantage sur l'existence ou non d'une entrave à la liberté d'établissement[487]. À titre d'illustration de cette attitude de la Cour de justice, on peut citer l'arrêt *Sevic* dans lequel la Cour, contrairement à l'avocat général Tizzano[488], n'a pas pris position sur le caractère directement discriminatoire ou non de l'entrave dressée par l'État allemand avant de se pencher sur la question de la justification[489].

SECTION 2. LES CONDITIONS POUR QU'UNE SOCIÉTÉ PUISSE BÉNÉFICIER DE LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

§1. Présentation

133. L'extension aux sociétés. Les activités économiques au sein du marché intérieur n'étant pas exclusivement exercées par des personnes physiques, l'article 54 du TFUE étend la liberté d'établissement aux sociétés pour autant qu'elles remplissent deux conditions cumulatives, à savoir (i) qu'elles soient constituées en conformité avec le droit d'un État membre (§ 2) et (ii) qu'elles aient leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne (§ 3).

§2. La constitution en conformité avec la législation d'un État membre

134. Une question à la libre appréciation des États membres. Selon le texte de l'article 54 du TFUE, seules les sociétés « constituées en conformité de la législation d'un État membre » peuvent prétendre à la protection de la liberté d'établissement conférée par l'article 49 du TFUE. En d'autres termes, la société en question devra avoir été constituée conformément aux dispositions d'un droit national ayant vocation à s'appliquer à celle-ci en vertu du facteur de

486 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 71 ; J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 67 ; Th. PAPADOPOULOS, *ibidem*, p. 79 et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 267 et C.J., gde ch., arrêt *Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.*, 25 octobre 2017, C-106/16, EU:C:2017:804, (ci-après l' « **arrêt *Polbud*** »), pt. 52 ; arrêt *Sevic*, pt. 23 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Caixa Bank France c. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*, 5 octobre 2004, C-442/02, EU:C:2004:586, pt. 17 ; C.J.C.E., arrêt *Ciola c. Land Vorarlberg*, 29 avril 1999, C-224/97, EU:C:1999:212, pt. 16 ; arrêt *Gebhard*, pt. 37 et arrêt *Kraus*, pt. 32.

487 Voir en ce sens St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, p. 163 et Th. PAPADOPOULOS, *ibidem*, p. 80.

488 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 55–57.

489 *Pro* : T. DRYGALA « Zur grenzüberschreitenden Verschmelzung », *EWiR*, 2006, p. 26 et Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, p. 80. *Contra* : St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, p. 162 et G. J. VOSSESTEIN, « Companies freedom of establishment after Sevic », *E.C.L.*, 2006/3, p. 180, n° 37 qui pensent que dans l'arrêt *Sevic*, la Cour laisse entendre que la législation allemande n'est pas discriminatoire.

rattachement pour lequel l'État membre en question a opté[490]. Cette question de la constitution en conformité de la législation d'un État membre doit être appréciée exclusivement à l'aune du droit national impliqué, ce qui a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de justice[491].

§ 3. Le rattachement à la lex societatis d'un État membre

135. Plan du § 3. Étudier la condition du rattachement à la *lex societatis* d'un État membre implique tout d'abord de rappeler le principe du libre choix opéré en la matière par les États membres (A), pour ensuite étudier les différents critères de rattachement envisageables (B) et tirer certaines conclusions sur les conséquences de la coexistence d'une multiplicité de critères de rattachement au sein de l'Union européenne (C).

A. *Une liberté de choix des États membres*

136. L'équivalence des critères. Le principe selon lequel le choix du critère de rattachement à la *lex societatis* relève exclusivement du ressort des États membres a été rappelé à de nombreuses reprises par la Cour de justice de l'Union européenne[492]. Cette marge d'appréciation découle également de l'article 54 du TFUE qui met sur un pied d'égalité les trois facteurs principaux connus au sein des six États fondateurs[493] que sont le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement[494]. Ainsi, de manière très schématique, on peut distinguer entre les États membres appliquant la théorie du siège réel ou du principal établissement et ceux recourant à la théorie de l'incorporation ou du siège statutaire. Pour mémoire, il est intéressant de relever que ce ne sont pas les seuls critères auxquels on peut penser et qu'il existe une multitude de théories intermédiaires.

B. *Les différents critères de rattachement*

1. *La théorie du siège statutaire ou de l'incorporation*

137. Une théorie simple et libérale. La théorie du siège statutaire implique que le droit applicable à la société concernée sera déterminé en fonction du lieu de son siège social tel qu'indiqué dans ses statuts, alors que la théorie

490 M. FALLON et E.-J. NAVEZ, « La transformation transfrontalière d'une société par transfert du siège statutaire après l'arrêt *Polbud* », *RPS*, 2018, p. 356.

491 Voir : arrêt *National Grid Indus*, pt. 27 où la Cour a précisé « qu'un État membre dispose ainsi de la faculté de définir tant le lien de rattachement qui est exigé d'une société pour que celle-ci puisse être considérée comme constituée selon son droit national et susceptible, à ce titre, de bénéficier du droit d'établissement que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement ». Voir également : C.J., arrêt *VALE Építési kft*, 12 juillet 2012, C-378/10, EU:C:2012:440 (ci-après l' « **arrêt *Vale*** »), pt. 29 et arrêt *Cartesio*, pt. 110.

492 Arrêt *Polbud*, pt. 34 ; arrêt *Vale*, pt. 27 ; arrêt *Cartesio*, pts. 109 et 110 et arrêt *Daily Mail*, pt. 19.

493 M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 356 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 15, n° 9.

494 Arrêt *Cartesio*, pt. 106.

de l'incorporation implique que le droit applicable sera déterminé en fonction en fonction du lieu de constitution. L'origine de ces théories est à mettre en relation avec une approche résolument libérale du droit[495]. La théorie du siège d'incorporation est généralement appliquée dans les pays de *common law*[496] et trouve notamment son origine dans la volonté du législateur anglais de permettre aux sociétés de capitaux actives dans les colonies d'être soumises malgré tout au droit anglais[497]. Ces théories présentent l'avantage de la simplicité, de la prévisibilité et de la sécurité juridique[498], notamment en raison du fait que la détermination du siège d'incorporation ou du siège statutaire ne nécessite pas la prise en compte d'éléments purement factuels. Le critère sous-jacent du lieu de constitution ou du siège statutaire est avant tout caractérisé par son aspect subjectif et intentionnel[499] car seule la volonté des associés déterminera le droit applicable à la société[500]. Ces théories sont donc de nature à favoriser la mobilité des personnes morales[501]. En revanche, leurs détracteurs leur reprochent traditionnellement d'encourager les abus et d'entraîner un effet de « *race to the bottom* »[502] en matière de droit fiscal et de droit des

495 Chr. HJI PANAYI, « Corporate Mobility in Private International Law and European Community Law: Debunking Some Myths », *Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies Research Paper*, N° 26/2009, p. 6 et H. LAMON, « Les transferts de siège vers et en dehors de la Belgique » in *Les fusions transfrontalières d'entreprises*, Bruxelles, Séminaire Vanham & Vanham du 26 avril 2007, p. 4.

496 La théorie du siège d'incorporation est ainsi appliquée au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis, mais également en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Italie.

497 T. BIERMEYER, *Stakeholder Protection in Cross-Border Seat Transfers in the EU: between freedom and boundaries,* Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2015, p. 33 et St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *GmbHG*, 3e éd., München, Verlag C. H. Beck, 2017, p. 50, n° 7.

498 Al. AUTENNE et M. DE WOLF, *op. cit.*, pp. 655 et 656 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *ZIP*, 2017, p. 2234 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Sitzverlegungen und grenzüberschreitende Sitzverlegungen nach MoMiG, Cartesio und Trabrennbahn. Europäischer Rahmen, deutsche lex lata und rechtspolitische Desiderata », *ZHR*, 2009/173, p. 739 ; I. CORBISIER, « Arrêt « Polbud » : la consécration de la *possibilité* d'un principe inconditionnel de libre mobilité », *J.D.E.*, 2018/4, p. 135 ; Chr. HJI PANAYI, *op. cit.*, p. 7 ; St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, p. 52, n° 9 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 34.

499 M. AZENCOT, *Le transfert international de siège social*, Thèse de doctorat en Droit international soutenue le 8 décembre 2011, Université Panthéon-Assas, p. 17.

500 St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 50, n° 7 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 19 et 20 et N. THIRION (sous la coordination de), *Droit international et européen des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 16.

501 *Voir en ce sens :* W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 2234 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Sitzverlegungen… », *op. cit.*, p. 739 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 34. *Voir également :* M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 358 qui relativisent la portée de cet atout traditionnel de la théorie du siège d'incorporation en pointant du doigt le fait que la jurisprudence de la Cour de justice a mis en lumière que les États membres pratiquant traditionnellement celle-ci étaient parfaitement capables de dresser des barrières à l'entrée (cf. arrêts *Centros* et *Inspire Art*) et à la sortie (cf. arrêt *Daily Mail*).

502 L'expression « *race to the bottom* », qui peut se traduire par « course vers le nivellement par le bas » en matière réglementaire, désigne une des deux issues possibles de la concurrence entre les droits des sociétés étatiques aux États-Unis et a été utilisée par W. L. Cary pour désigner le phénomène par lequel l'État du Delaware impose son modèle de droit des sociétés favorisant les dirigeants au détriment des actionnaires aux autres États. Pour une étude détaillée des arguments « *race to the bottom* » et « *race to the top* », ainsi que des théories ayant tenté de dépasser cette dichotomie, voir : I. Corbisier, *La société : contrat ou institution*, *op. cit.*, pp. 289 à 292.

sociétés[503]. En effet, le lieu de constitution ou du siège statutaire pourrait être déterminé par les associés, non pas en considération de l'activité économique effective, mais bien en fonction des avantages réglementaires et fiscaux dont ils bénéficieront, et ce, éventuellement, au détriment des autres *stakeholder*s qui, par définition, se trouveront plus fréquemment dans l'État où la personne morale exerce l'essentiel de son activité économique[504]. Il convient toutefois de préciser que ce reproche ne vise que les cas où le choix de la théorie de l'incorporation ou du siège statutaire par un État membre ne s'accompagnerait pas de mesures connexes destinées à éviter les abus tant en matière fiscale qu'à l'égard des *stakeholders* impactés par l'opération[505].

2. *La théorie du siège réel ou du principal établissement*

138. Une théorie correspondant à la réalité économique. Développée au dix-neuvième siècle en France et en Allemagne[506], la théorie du siège réel[507] implique que la *lex societatis* applicable à une personne morale soit déterminée par le lieu où se trouve son siège réel ou son principal établissement, déterminé en tenant compte principalement du lieu où sont prises les décisions stratégiques relatives à l'entreprise, mais également de celui où sont localisées les activités de l'entreprise et, bien que de manière très limitée, le lieu du siège statutaire[508]. Elle repose sur le postulat que l'État du siège réel ou du principal établissement est celui qui a le plus de chances d'être impacté par les activités économiques d'une société. Il en découle logiquement que c'est le droit de cet État qui devra s'appliquer à la société[509]. Cette théorie permet ainsi un contrôle accru des activités économiques et une protection plus efficace des intérêts des associés, des créanciers, des travailleurs ainsi que des autres tiers intéressés[510]

Voir également : L. A. BEBCHUK et A. FERRELL, « Federalism and corporate law : the race to protect managers from takeovers », *Columbia Law Review*, vol. 99, n° 5, juin 1999, pp. 1168–1199 et W. L. CARY, « Federalism and corporate law : reflections upon Delaware », *The Yale Law Journal*, vol, 83, n° 4, mars 1974, pp. 663–705.

503 H. LAMON, *op. cit.*, p. 4 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 20 et 21 ; V. SIMONART, *op. cit.*, p. 156 et N. THIRION, *op. cit.*, pp. 17 et 18.

504 *Voir en ce sens :* Al. AUTENNE et M. DE WOLF, *op. cit.*, p. 656 et C.J.C.E., arrêt *Überseering BV c. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)*, 5 novembre 2002, C-208/00, EU:C:2002:632, (ci-après l' « **arrêt *Überseering*** »), pt. 15.

505 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 2234 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Sitzverlegungen… », *op. cit.*, p. 773 et St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 52, n° 10.

506 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 18.

507 La théorie du siège de réel est appliquée notamment au Luxembourg, en Allemagne, en France, en Autriche, en Grèce et au Portugal. Précisons à cet égard que la Belgique a abandonné, après près de 150 ans, le critère de l'établissement principal au profit de la théorie du siège statutaire. Voir art. 14 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, disponible sur https://www.ejustice.just.fgov.be (14/07/2020) qui a modifié l'art. 110 du Code de droit international privé belge et à ce sujet : M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 379 et J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE et H. CULOT, *op. cit.*, p. 262, n° 529.

508 St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 49, n° 4 ; J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *op. cit.*, p. 1183, n° 1742 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 18 et Fr. RIGAUX et M. FALLON, *op. cit.*, p. 980, n° 16.13.

509 Al. AUTENNE et M. DE WOLF, *op. cit.*, p. 656 ; Chr. HJI PANAYI, *op. cit.*, p. 10 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 39.

510 St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 49, n° 5 ; Chr. HJI PANAYI, *ibidem*, p. 10 et A. WENG, *ibidem*, p. 39.

en limitant les risques de *forum shopping*. De plus, ce critère renforce le contrôle étatique des sociétés et fait preuve d'une certaine logique car il se base sur la proximité avec les activités réelles d'une société[511]. Ce critère de rattachement présente comme caractéristiques d'être à la fois objectif, concret et factuel[512]. Les deux principales critiques qui peuvent lui être adressées sont, d'une part, qu'elle est susceptible de présenter un caractère protectionniste[513] et, d'autre part, qu'elle peut être source d'insécurité juridique dans la mesure où la détermination du siège réel dans un monde de plus en plus globalisé où les décisions sont fréquemment prises de manière décentralisée peut s'avérer être un exercice hasardeux[514]. Ce dernier désavantage est particulièrement évident en matière de scissions transfrontalières étant donné que suite à la réalisation de l'opération, le siège de direction effective de la société scindée se retrouvera inexorablement tiraillé entre sa juridiction d'origine où subsisteront éventuellement une activité économique et celles des sociétés bénéficiaires.

3. *Le critère du contrôle*

139. Un critère d'exception. Au-delà de ces deux premiers critères de rattachement, on mentionne occasionnellement le critère du contrôle en vertu duquel la *lex societatis* applicable à une personne morale sera déterminée en fonction de la nationalité des associés ou des membres de l'organe de direction de celle-ci, soit en d'autres termes, des personnes jouissant du contrôle de la société[515]. Ce critère, absent du triptyque cité par l'article 54 du TFUE, ne se retrouve que de manière exceptionnelle et essentiellement en temps de guerre où l'objectif est, pour un des belligérants, soit d'exclure certaines sociétés contrôlées par les ressortissants de l'ennemi du bénéfice de la législation nationale[516], soit de maintenir dans le giron du droit national des sociétés qui, suite à une déclaration d'indépendance, se retrouveraient soumises au droit du nouvel État en vertu des critères de rattachement classiques[517]. Il est également utilisé de manière marginale en temps de paix dans un but protectionniste, comme par exemple pour réserver le bénéfice de certains

511 St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, p. 49, n° 4 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 18.

512 M. AZENCOT, *op. cit.*, p. 17 ; St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, p. 49, n° 4 et J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *op. cit.*, p. 1183, n° 1742.

513 H. LAMON, « Emigration ou immigration de sociétés sous l'angle juridique belge et communautaire : tout est-il permis ? », *R.G.F.*, 2005/5, p. 2 et Th. TILQUIN, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *RPS*, 1998, p. 5.

514 E. R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 30 ; Chr. HJI PANAYI, *op. cit.*, p. 10 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 19 et N. THIRION, *op. cit.*, p. 19 et arrêt *Überseering*, pt. 51.

515 Chr. ALLMENDINGER, *op. cit.*, p. 46 ; J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *op. cit.*, p. 1185, n° 1744 ; V. SIMONART, *op. cit.*, p. 520 et s. et N. THIRION, *op. cit.*, pp. 20–22.

516 Voir p. ex. l'arrêté-loi belge du 10 novembre 1918 relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens et intérêts appartenant à des sujets des nations ennemies, *Pasin.*, 1918, n° 132 ou encore l'arrêté-loi belge du 23 août 1944 relatif au séquestre des biens, droits et intérêts ennemis, *Bull. usuel*, 1944, n° 107.

517 V. SIMONART, *op. cit.*, pp. 395 et s. et N. THIRION, *op. cit.*, p. 21 et Cass. française, 30 mai 1971, *Clunet*, 1972, p. 836 pour le cas des sociétés françaises ayant leur siège en Algérie et ayant été contrôlées dès l'origine par des ressortissants français.

marchés publics aux seuls nationaux[518] ou encore pour tenter de refuser le bénéfice des libertés fondamentales instaurées par le TFUE aux personnes morales dont les associés de contrôle sont des ressortissants d'un État tiers[519]. Étant foncièrement discriminatoire et dépassé à l'heure de la mondialisation[520], ce critère ne devrait plus être appliqué.

4. *Les théories intermédiaires*

140. La théorie de la différenciation. Face aux insuffisances intrinsèques tant de la théorie du siège réel que de la théorie du siège d'incorporation, un certain nombre de théories intermédiaires ont été développées. À titre d'illustration, on peut ainsi tout d'abord citer la théorie de la différenciation (« *Differenzierungstheorie* ») qui propose de soumettre les rapports internes d'une société, comme les règles régissant la constitution ou le fonctionnement de la société, à la *lex societatis* déterminée par le lieu du siège statutaire tout en précisant que les rapports externes, comme la capacité juridique d'une société ou le pouvoir de représentation de ses organes, seront déterminés soit par la loi du lieu du siège statutaire, soit par la *lex loci actus*[521], soit par la *lex causae*[522], le choix entre les différents droits ainsi déterminés étant opéré en privilégiant celui qui reconnaît la capacité juridique de la société, le pouvoir de représentation de ses organes ou encore la responsabilité de celle-ci, de ses organes ou de ses associés[523]. Compte tenu de la difficulté à distinguer clairement les rapports internes des rapports externes et du risque de voir une société régie par plusieurs droits nationaux distincts, il n'est pas étonnant que cette théorie n'ait pas rencontré le succès escompté[524].

141. La théorie de la superposition. Palliant partiellement les insuffisances de la théorie de la différenciation, la théorie de la superposition (« *Übertragungstheorie* ») prévoit qu'une personne morale sera en principe soumise au droit désigné par son siège de constitution, auquel viendront, en cas de dissociation du siège statutaire et du siège réel, se superposer les normes applicables en vertu de la théorie du siège réel pour garantir la protection des créanciers, des travailleurs et des associés minoritaires[525]. Malgré le fait qu'elle permette dans une certaine mesure de protéger les *stakeholders*

518 N. THIRION, *op. cit.*, p. 21.

519 Chr. ALLMENDINGER, *op. cit.*, p. 46 et Al. BLECKMANN, « Zur Dogmatik des Niederlassungsrecht im EWG-Vertrag », *WiVerw*, 1987, p. 120.

520 N. THIRION, *op. cit.*, p. 21.

521 Par « *lex loci actus* » on entend « la loi du lieu de passation de l'acte ». Voir M. VIVANT, « Fasc. 4900 – Régime international », *JCl. Brevets*, 6 juin 2018, n° 62.

522 Par « *lex causae* », on entend la loi applicable au fond du litige telle que désignée par le juge compétent. Voir O. CACHARD, *Droit international privé*, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 315, n° 575.

523 T. BIERMEYER, *op. cit.*, p. 34 ; G. GRASMANN, *System des internationalen Gesellschaftsrechts*, Herne, Neue Wirtschafts-Briefe, 1979 ; St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, pp. 52 et 53, n°s 12 et 13.

524 T. BIERMEYER, *ibidem*, p. 34 et St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, p. 53, n° 13.

525 T. BIERMEYER, *ibidem*, p. 35 ; St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, p. 53, n° 14 et O. SANDROCK, « Sitztheorie, Überlagerungstheorie und der EWG-Vertrag : Wasser, Öl und Feuer », *RIW*, 1989, pp. 512 et 513.

contre les abus des *pseudo-foreign companies*, cette théorie n'a pas été plébiscitée en raison de sa lourdeur et de l'insécurité juridique qu'elle génère[526].

142. La thèse de la combinaison. Face à cette impasse, la thèse de la combinaison (« *Kombinationslehre* ») s'inspire des principes du droit international des contrats et prévoit qu'en cas de dissociation du siège d'incorporation et du siège réel, c'est le droit du siège d'incorporation qui primera dès que la personne morale aura un certain nombre de relations internationales. En revanche, dès qu'il y a des liens substantiels avec un État membre, c'est le droit de ce dernier qui primera[527]. Par rapport aux deux précédentes, cette thèse présente l'indéniable avantage d'éviter de devoir combiner des droits nationaux potentiellement contradictoires, mais la détermination du moment où une personne morale dispose de suffisamment de relations internationales pour faire primer le droit du siège de constitution risque d'être source de difficultés pratiques[528].

C. *Les conséquences de la multiplicité des critères de rattachement*

143. Sociétés apatrides et sociétés binationales. En raison de l'absence d'harmonisation du critère de rattachement des sociétés et en cas de dissociation du siège de constitution et du siège réel, il est possible d'aboutir à la situation spécifique d'une société binationale ou encore d'une société apatride. Le premier cas concerne l'hypothèse d'une société constituée dans un État reconnaissant la théorie du siège de constitution alors que son siège de direction effective est situé dans un autre État membre appliquant la théorie du siège réel. Le deuxième cas vise l'exacte situation inverse. Ainsi, dans le cas d'une société susceptible de relever de deux ordres juridiques distincts, on pourrait aboutir à la situation où une opération de scission de celle-ci au profit de deux sociétés relevant du droit de l'État membre du siège de direction effective de la société scindée serait considérée comme une opération interne du point de vue de l'État des sociétés bénéficiaires qui applique la théorie du siège de direction effective et transfrontalière du point de vue de l'État membre de la société scindée qui applique la théorie du siège d'incorporation[529].

144. Un certain flou juridique dans le choix du critère de rattachement. Au-delà de cette première difficulté liée à la seule coexistence de différents critères de rattachement s'ajoute celle liée au fait que chacune des théories décrites ci-dessus n'est que très rarement appliquée sans aménagements spécifiques. Ceci explique pourquoi dans l'Étude d'impact, la Commission a choisi de répartir les différents États membres en quatre catégories distinctes, à savoir

526 T. BIERMEYER, *ibidem,* p. 35 ; B. EBENROTH, « Neuere Entwicklungen im deutschen internationalen Gesellschaftsrecht », *JZ*, 1988, p. 21 et St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, pp. 53 et 54, n° 14.

527 St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, p. 54, n° 15 et D. ZIMMER, *Internationales Gesellschaftsrecht – Das Kollisionsrecht der Gesellschaften und sein Verhältnis zum Internationalen Unternehmensrecht*, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaftsrecht, 1996, pp. 219–240.

528 St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, p. 54, n° 15.

529 Pour un raisonnement similaire en matière de fusions transfrontalières, voir U. LENNERZ, *op. cit.*, pp. 11 et 12 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, Berlin, Duncker & Humblot, 2008, p. 32.

(i) les États adhérant à la théorie de l'incorporation sans aménagements spécifiques[530], (ii) les États membres appliquant soit la théorie de l'incorporation sans que cela soit clair pour des profanes, soit la théorie de l'incorporation de manière claire, mais avec certaines exceptions[531], (iii) les États membres où la théorie de l'incorporation est sujette à certaines exceptions mais où le régime légal n'est pas clair pour des profanes[532] et (iv) les États membres où mêmes les spécialistes ne parviennent pas à identifier si l'État adhère ou non à la théorie de l'incorporation[533]. L'existence de telles divergences n'est aucunement de nature à simplifier les opérations transfrontalières au sein de l'Union européenne et explique pourquoi 28 % des autorités publiques interrogées lors de la consultation publique de 2017 ont considéré que l'absence de règles de conflit de lois harmonisées constituait un obstacle majeur au fonctionnement du marché intérieur[534].

§4. Au-delà des sociétés de capitaux

145. La société au sens du TFUE. Contrairement à bon nombre de normes de droit dérivé[535], l'article 54 du TFUE ne limite pas le bénéficie de la liberté d'établissement à certaines formes de sociétés commerciales et recourt à une définition autonome de la notion de « société »[536]. Ainsi, sont donc visées (i) toutes les sociétés de droit civil et commercial, y compris les sociétés coopératives et (ii) toutes les autres personnes morales de droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. En d'autres termes, le critère pour pouvoir relever du champ d'application de la liberté d'établissement est celui de « l'offre de prestations économiques contre rémunération »[537]. Ce vaste champ d'application *ratione personae* justifie à lui seul une étude détaillée des scissions transfrontalières à l'aune de la liberté d'établissement en dépit de l'existence de la Directive Mobilité. En effet, lors de la détermination du champ d'application de cette dernière la Commission, en se

530 Selon les données collectées par la Commission, il s'agit de la Bulgarie, de Chypre, de la République tchèque, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Irlande, de la Lituanie, de Malte, des Pays-Bas, de la Slovaquie, de la Suède et du Royaume-Uni. Voir Étude d'impact, p. 36.

531 Selon les données collectées par la Commission, il s'agit de l'Autriche, de la Belgique, de la Croatie, de l'Estonie, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Roumanie, de la Slovénie et de l'Espagne. Voir Étude d'impact, p. 36.

532 Selon les données collectées par la Commission, il s'agit du Danemark, de la Grèce, de la Lettonie et du Luxembourg. Voir Étude d'impact, p. 36.

533 Selon les données collectées par la Commission, il s'agit de la Pologne et du Portugal. Voir Étude d'impact, p. 36.

534 Feedback statement to the 2017 public consultation on "EU Company Law upgraded: digital solutions and providing efficicient rules for cross-border operations of companies", 25 avril 2018, http://ec.europa.eu (29/03/2019) (ci-après la « **Consultation publique de 2017** »), p. 12.

535 Voir à titre d'illustration : (i) art. 2, §§1 et 2 ; art. 44, §§1 et 2 ; art. 45, §2 ; art. 87, §§1 et 2 et art. 135 de la Directive Sociétés qui restreignent le champ d'application de certains régimes aux sociétés anonymes figurant à l'annexe I de la Directive Sociétés et (ii) art. 7, §1 ; art. 13 ; art. 29, §1 ; art. 36, §1 ; art. 67, §1 et art. 119, §1, point a) de la Directive Sociétés qui restreignent le champ d'application de certains régimes aux seules sociétés de capitaux figurant à l'annexe II de la Directive Sociétés.

536 R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 273 et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 228.

537 P. VAN CLEYNENBREUGEL, *ibidem*, p. 228.

basant sur les résultats de l'étude d'impact[538] et face aux risques engendrés par le faible degré d'harmonisation des sociétés de personnes au sein de l'Union européenne[539], a préféré purement et simplement exclure ces dernières du nouveau régime des scissions transfrontalières[540]. Par conséquent, ces formes sociales ne pourront se reposer que sur les libertés fondamentales pour réaliser une telle opération.

§5. L'incidence de l'assimilation aux personnes physiques sur les scissions transfrontalières

146. Champ d'application *ratione personae* ou *ratione materiae* ? Si la méthode d'assimilation des personnes morales aux personnes physiques semble logique de prime abord, il est toutefois important de préciser que celle-ci n'est destinée à avoir une incidence que sur le champ d'application *ratione personae* de la liberté d'établissement. En d'autres termes, il serait erroné de concevoir cette assimilation comme impliquant qu'une activité spécifique ne pourra bénéficier de la protection de la liberté d'établissement que si elle est susceptible d'être également exercée par une personne physique[541]. Cette assertion revêt une importance toute particulière à l'égard des scissions transfrontalières dans la mesure où il s'agit là d'une opération qui ne peut par définition être exercée que par une personne morale.

§6. Un champ d'application *ratione loci* dépassant l'Union européenne

147. Les États membres de l'EEE. La liberté d'établissement s'appliquera également aux personnes physiques et morales de l'Espace économique européen, à savoir la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein en vertu des articles 31 et 34 de l'Accord sur l'Espace économique européen.

SECTION 3. LES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES, UN MODE PARTICULIER D'EXERCICE DE LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

148. Plan de la section 3. Dans le cadre de l'étude des scissions transfrontalières sous l'angle particulier de la liberté d'établissement, il est utile de partir des enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Sevic* en matière de fusions transfrontalières (§ 1), pour ensuite étudier leur incidence sur le mode

538 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, pp. 20 et 21 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, Main Findings, pp. 80 et 81 d'où il ressort que dans une période de référence allant de 2008 à 2012, 66 % des sociétés acquéreuses et 70 % des sociétés qui fusionnent dans le cadre d'opérations de fusions transfrontalières étaient des sociétés de capitaux privées, tandis que 32 % des sociétés acquéreuses et 28 % des sociétés qui fusionnent dans le cadre d'opérations de fusions transfrontalières étaient des sociétés anonymes.

539 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, pp. 20 et 21.

540 Art. 160*bis*, § 1er ; 160*ter*, (1) et 160*quater*, § 2 de la Proposition de la Commission.

541 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 46 ; U. LENNERZ, *op. cit.*, pp. 71 et 72 et R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 49 et 50.

de restructuration particulier que constituent les scissions transfrontalières (§ 2) et leurs limites (§ 3) et finir avec les précisions apportées par la Cour de justice dans l'arrêt *Euro Park Service* (§ 4).

§ 1. Les enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Sevic*

A. *Les faits en cause*

149. Le refus de l'*Amtsgericht* de *Neuwied*. Les faits à l'origine de l'arrêt *Sevic* concernaient le refus de l'*Amtsgericht* de *Neuwied* d'inscrire la fusion par absorption de Security Vision Concept SA, une société anonyme de droit luxembourgeois par Sevic System AG, une société anonyme de droit allemand au registre allemand du commerce au motif qu'en vertu de l'article premier, paragraphe premier, point 1 de l'*Umwandlungsgesetz*, seules les sociétés ayant leur siège sur le territoire national pouvaient réaliser une fusion. Confronté à ces différents éléments, le *Landgericht* de Koblenz a préféré surseoir à statuer et interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de la législation allemande avec la liberté d'établissement garantie par les articles 49 et 54 du TFUE[542].

B. *Les enseignements de la Cour de justice*

150. Le champ d'application de la liberté d'établissement. Procédant tout d'abord à une reformulation de la question préjudicielle de sorte qu'elle porte sur la compatibilité avec la liberté d'établissement d'une différence de traitement entre les fusions internes, autorisées et réglementées par l'*Umwandlungsgesetz* et les fusions transfrontalières qui seraient refusées de manière générale en raison de leur caractère international[543], la Cour a tout d'abord consacré l'application de la liberté d'établissement aux fusions transfrontalières, considérant que celles-ci répondaient « aux nécessités de coopération et de regroupement entre sociétés établies dans des États membres différent »[544] et constituaient par conséquent des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »[545]. Par conséquent, la Cour relègue aux oubliettes la théorie du *corporate suicide* avancée notamment par les gouvernements allemands et néerlandais en vertu de laquelle la liberté d'établissement ne devait pas s'appliquer aux fusions, puisque (i) elles impliquaient la dissolution, et non un établissement, de la société absorbée et (ii) depuis l'arrêt *Daily Mail* ces aspects sont de la seule compétence des États membres[546]. En effet, comme l'a très

542 Arrêt *Sevic*, pts. 6–10 et LG Koblenz, 16 septembre 2003, 4 HK T 1/03, *ZIP*, 2003, p. 2210.
543 Arrêt *Sevic*, pt. 15.
544 Arrêt *Sevic*, pt. 19.
545 Arrêt *Sevic*, pt. 19.
546 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 22 et R. DORR et G. STUKENBORG, « "Going to the Chapel": Grenzüberschreitende Ehen im Gesellschaftsrecht – Die ersten transnationalen Verschmelzungen nach dem UmwG (1994) », *DB*, 2003, p. 649 ; H. HECKSCHEN, « Ist das deutsche Umwandlungsrecht gemeinschaftsrechtswidrig? », *NotBZ*, 2005, p. 317 ; Th. KUNTZ, « Zur Möglichkeit

justement fait remarquer l'avocat général Tizzano[547], un tel argument procède d'une logique à contresens, l'extinction de la société absorbée n'étant qu'un effet de la fusion survenant après la réalisation de celle-ci.

151. Une entrave à la liberté d'établissement. En ce qui concerne ensuite plus spécifiquement la différence de traitement entre les opérations internes et transfrontalières existant en droit allemand, la Cour précise qu'une telle entrave dans le pays d'accueil est en principe interdite étant donné qu'elle est de nature à dissuader les sociétés d'exercer leur liberté d'établissement[548]. Elle pose en cela un principe fondamental de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes[549].

152. La justification de l'entrave à la liberté d'établissement. Une telle différence de traitement n'est, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice en la matière[550], justifiable que si (i) la restriction poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité, (ii) elle est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et (iii) son application est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, tout en n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Si, sans grande surprise, la Cour de justice a estimé que le refus général d'inscription des fusions transfrontalières était une mesure disproportionnée[551], il est toutefois intéressant de remarquer que la Cour, se référant à sa jurisprudence antérieure[552], cite un certain nombre d'exemples de raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une entrave à la liberté d'établissement, à savoir « la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des salariés » ou encore « la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux et la loyauté des transactions commerciales ».

§2. L'incidence sur les scissions transfrontalières

153. Les « *modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement* ». Bien que concernant principalement une entrave à une fusion transfrontalière dans l'État de la société absorbante, l'arrêt *Sevic* contient un certain nombre d'enseignements précieux pour les scissions transfrontalières. Ainsi, tout d'abord, en confirmant l'applicabilité de la liberté d'établissement aux fusions transfrontalières, la Cour a pris garde de ne pas restreindre le champ d'application des articles 49 et 54 du TFUE à ce seul type d'opération. Au contraire,

grenzübeschreitender Fusionen – Die Schlussanträge in Sachen SEVIC Systems Aktiengesellschaft », *EuZW*, 2005, p. 526 et W. PAEFGEN, « Umwandlung, europäische Grundfreiheiten und Kollisionsrecht », *GmbHR*, 2004, p. 469.

547 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 25–27.

548 Arrêt *Sevic*, pts. 22 et 23.

549 D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 69 et s. et S. WEISS et H.-T. WÖHLERT, *op. cit.*, p. 583.

550 Arrêt *Sevic*, pt. 23 ; arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 49 ; C.J.C.E., arrêt *Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen*, 9 mars 1999, C-212/97, EU:C:1999:126, (ci-après l' « **arrêt *Centros*** »), pt. 34 ; arrêt *Gebhard*, pt. 37 et arrêt *Kraus*, pt. 32.

551 Arrêt *Sevic*, pt. 30.

552 Arrêt *Sevic*, pt. 28 ; C.J.C.E., arrêt *Inspire Art Ltd c. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam*, 30 septembre 2003, C-167/01, EU:C:2003:512, (ci-après l' « **arrêt *Inspire Art*** »), pt. 132 et arrêt *Überseering*, pt. 92.

elle a stipulé explicitement que « les opérations de fusions transfrontalières, à l'instar des autres opérations de transformation de sociétés […] constituent des modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »[553], ce qui est généralement interprété par les auteurs comme signifiant que les scissions intracommunautaires doivent être également protégées par la liberté d'établissement[554]. À l'appui de cet argument s'ajoute encore le fait que l'arrêt *Sevic* concernait principalement la question de la conformité à la liberté d'établissement de l'article premier, paragraphe premier, point 1 de l'*Umwandlungsgesetz* qui vise non seulement les fusions, mais également tous types de transformations telles que les scissions, les transmissions du patrimoine et le changement de forme juridique[555]. Cette protection des scissions transfrontalières par la liberté d'établissement a par ailleurs été confirmée ultérieurement par la Commission européenne dans la Proposition de la Commission[556]. Il s'ensuit également que le principe de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes posé par la Cour de justice[557] s'appliquera également aux scissions transfrontalières.

154. Une base légale pour une intervention du législateur européen. L'incidence de cette précision du champ d'application *ratione materiae* de la liberté d'établissement n'est pas anodine non plus du point de vue d'une éventuelle initiative législative visant explicitement les scissions transfrontalières

553 Arrêt *Sevic*, pt. 19.

554 Voir en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, « Les scissions transfrontalières », *Cah. dr. entr.*, n° 6, novembre 2011, dossier 36, p. 3 ; H. BUNGERT, « Grenzüberschreitende Verschmelzungsmobilität – Anmerkung zur *SEVIC*-Entscheidung des EuGH », *BB*, 2006, p. 55 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1161 ; T. DRYGALA, *op. cit.*, p. 26 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, « Cross-Border Conversions in the EU : The EU Commission Proposal », *ECFR*, 1-2/2019, p. 19 ; V. GEYRHALTER et Th. WEBER, « Transnationale Verschmelzungen – im Spannungsfeld zwischen SEVIC Systems und der Verschmelzungsrichtlinie », *DStR*, 2006, p. 150 ; L. HANSEN, *op. cit.*, p. 195 ; S. HERRLER, « Ermöglichung grenzüberschreitender Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften durch Umänderung des Umwandlungsgesetzes – Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie unter Vernachlässigung der primärrechtlichen Rahmenbedingungen », *EuZW*, 2007, pp. 298 et 299 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen nach Sevic Systems und der EU-Verschmelzungsrichtlinie », *AG*, 2006, pp. 226 et 234 ; N. KRAUSE et N. KULPA, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen – Vor dem Hintergrund der SEVIC-Entscheidung und der Reform des deutschen Umwandlungsrecht », *ZHR 171*, 2007, p. 45 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *Rev. Soc.*, 2013, p. 416 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, pp. 165 et 166 ; W. MEILICKE et D. E. RABBACK, « Die EuGH-Entscheidung in der Rechtsache Sevic und die Folgen für das deutsche Umwandlungsrecht nach Handels- und Steuerrecht », *GmbHR*, 2006, pp. 126 et 127 ; Fl. PARREIN, « De wet van 8 Juni 2008 en de grensoverschrijdende fusie », *RW*, n° 8, 23 octobre 2010, p. 320 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 236 ; J. SEDEMUND, « EU-weite Verschmelzungen : Gesellschaftsrechtliche Vorgaben und steuerliche Implikationen des SEVIC-Urteils des EuGH vom 13.12.2005 », *BB*, 2006, p. 521 ; M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *EBOR*, n° 8, 2007, disponible sur http://papers.ssrn.com (20/05/2016), p. 314 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften nach „Sevic" », *ZIP*, 2006, p. 358 ; Chr. TEICHMANN et R. KNAIER, « Grenzüberschreitender Formwechsel nach "Polbud" – Die neue Umwandlungsfreiheit im Binnenmarkt », *GmbHR*, 2017, p. 1319 et S. WEISS et H.-T. WÖHLERT, « Die „Sevic-Entscheidung"des EUGH - „sudden death"für Societas Europaea und Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung und Wegbereiter für grenzüberschreitende Spaltungen ? », *WM*, 2007, pp. 584 et 585.

555 Arrêt *Sevic*, pt. 3 et en ce sens : R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 308 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 219, n° 65.

556 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 10.

557 Arrêt *Sevic*, pts. 22 et 23.

puisque le TFUE prévoit que le Conseil et le Parlement européen peuvent intervenir par voie de directives en vue de réaliser la liberté d'établissement[558] et, plus particulièrement, en vue de supprimer progressivement les entraves à celle-ci[559]. En d'autres termes, la Cour de justice a fourni une base légale claire pour une intervention du législateur européen[560].

155. L'incidence sur le droit dérivé. Ainsi, tout d'abord, la primauté revenant aux articles 49 et 54 du TFUE implique que toute initiative législative en la matière, qu'elle soit de droit européen dérivé ou de droit national, devra nécessairement être mesurée à l'aune de ceux-ci[561]. En d'autres termes, la hiérarchie des normes implique que (i) d'une part, aucune disposition d'une éventuelle directive sur les scissions transfrontalières ne pourra créer d'entrave injustifiée à la liberté d'établissement, sous peine de risquer de se voir annulée par la Cour de justice sur la base des articles 263, alinéa 2 et 264 du TFUE et, (ii) d'autre part, les États membres devront veiller à respecter scrupuleusement le prescrit des articles 49 et 54 du TFUE lors de la transposition de toute norme de droit européen. Ensuite, cette primauté pose également une règle d'interprétation stricte. En effet, lorsqu'une disposition d'une norme de droit européen est sujette à plusieurs interprétations, c'est indiscutablement celle qui est compatible avec la liberté d'établissement qui primera. Si on est en présence de plusieurs interprétations conformes au droit primaire, il faudra privilégier celle qui limite au minimum la restriction de la liberté d'établissement[562]. Pour finir, il convient de préciser que dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière tombant à la fois dans le champ d'application d'une norme de droit dérivé et de la liberté d'établissement, comme la scission transfrontalière intra-européenne d'une société à responsabilité limitée par constitution de deux nouvelles sociétés à responsabilité limitée qui est explicitement visée par la Directive Mobilité[563], le droit primaire ne pourra servir à éluder l'application du régime propre à ce type d'opérations et relevant du droit dérivé, si tant est que celui-ci a fait l'objet d'une transposition en droit national[564] et qu'en application du principe *lex specialis legi generali derogat*, il conviendra d'appliquer

558 Art. 50, § 1er du TFUE.

559 Art. 50, § 2, f) du TFUE.

560 La Commission européenne a par ailleurs explicitement fait référence à l'art. 50, § 2, point f) du TFUE qui prévoit la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement en tant que base juridique sur laquelle repose l'initiative de la Proposition de la Commission. Voir Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 13.

561 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 112 ; M. MÖSTL, « Grenzen der Rechtsangleichung im europäischen Binnenmarkt – Kompetenzielle, grundfreiheitliche und grundrechtliche Schranken des Gemeinschaftsgesetzgebers », *EuR*, 2002, p. 322 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms: application of the freedom of establishment to the Cross-Border Mergers Directive », *EBLR*, 2012, p. 527 et C. P. SCHINDLER, « Cross-border mergers in Europe – Company Law is Catching-Up – Commentary on the ECJ's Decision on *Sevic Systems AG* », *ECFR*, 3/2006, p. 118.

562 Voir à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 115 et Th. DELVAUX, « Fusion internationale et liberté de circulation », note sous C.J.C.E., 13 décembre 2005, n° C-411/03, *J.T.*, 2006, p. 147 et C.J.C.E., arrêt *Nicolas Decker c. Caisse de maladie des employés privés*, 28 avril 1998, C-120/95, EU:C:1998:167, pt. 27 et Av. gén., G. TESAURO, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Nicolas Decker c. Caisse de maladie des employés privés*, 28 avril 1998, C-411/03, EU:C:1997:399, pt. 32.

563 Art. 160*ter* de la Directive Mobilité.

564 P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 44 et R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 273.

en priorité la norme de droit dérivé[565]. En d'autres termes, alors que tous les types de scissions sont couverts par la liberté d'établissement[566] et doivent être possibles pour peu que les États membres concernés reconnaissent les scissions dans leur ordre interne[567], à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés tombant dans le champ d'application de la Directive Mobilité[568], il conviendra impérativement de s'en référer au régime de droit dérivé, et non à une délicate application par analogie du régime des scissions internes sur la base de la liberté d'établissement, comme pour les scissions tombant en dehors du champ d'application de la Directive Mobilité lorsqu'aucun régime national spécifique n'existe à leur égard.

156. Un large champ d'application. De plus, malgré le champ d'application actuellement relativement limité du régime des scissions internes[569], il découle de la protection des scissions transfrontalières par la liberté d'établissement que tous ceux qui entrent dans le champ d'application de la liberté d'établissement, c'est-à-dire aussi bien les sociétés de capitaux que les sociétés de personnes[570] et qui disposent de la possibilité de se scinder en vertu du droit interne, pourront en principe procéder à une telle opération[571]. Dans un même ordre d'idées, bien que la Directive Mobilité se soit limitée explicitement aux seules scissions n'impliquant qu'une seule société préexistante[572], la liberté d'établissement couvre tous les types de scission, en ce compris les scissions par absorption.

157. Liberté d'établissement primaire et secondaire. À l'instar de ce qui a été avancé par l'Avocat général Tizzano[573] ainsi que par un grand nombre d'auteurs[574] à l'égard des fusions transfrontalières, une scission transfrontalière

565 P. VAN CLEYNENBREUGEL, *ibidem*, p. 44.
566 À ce sujet, voir *supra* n° 153.
567 À ce sujet, voir *infra* n° 156.
568 Sur le champ d'application excessivement limité de la Directive Mobilité, voir *infra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1, Section 2, § 3.
569 Art. 135, § 1er de la Directive Sociétés.
570 À ce sujet, voir *supra* n° 145.
571 Voir à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *NJW*, 7/2006, p. 401 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Schutz der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch die Niederlassungsfreiheit », *ZIP*, 5/2006, p. 212 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 94 ; E. EVRARD et M. VAN DER VAEREN, « Les fusions transfrontalières : un pas de plus vers une Europe harmonisée », *D.A. O.R.*, 2007, p. 109 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 48 et Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, p. 87.
572 Art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité.
573 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 35 à 37.
574 *Voir en ce sens :* P. BEHRENS, « Die neue Lektion aus Luxemburg zur internationalen Mobilität von Gesellschaften: Grenzüberschreitende Verschmelzungen sind möglich ! », *EuZW*, 2006, p. 65 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 58 et 59 ; E. GOTTSCHALK, « Zur Frage grenzüberschreitender Verschmelzungen und der Eintragungsfähigkeit in das nationale Handelsregister », *EuZW*, 2006, p. 84 ; L. KLOSTER, « EU-grenzüberschreitende Verschmelzungen sind (steuerneutral) durchführbar », *GmbHR*, 2003, p. 1414 ; Th. KUNTZ, *op. cit.*, p. 526 ; St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 64, n° 34 ; W. PAEFGEN, « Umwandlung, europäische Grundfreiheiten und Kollisionsrecht », *op. cit.*, p. 469 ; W. PAEFGEN, « Umwandlung über die Grenze - ein leichtes Spiel? », *IPRax*, 2004, p. 133 ; Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 542, n° 758 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 19, n° 14 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen, op. cit.*, p. 82.

peut non seulement s'analyser sous l'angle de la liberté d'établissement primaire, mais également sous l'angle de la liberté d'établissement secondaire. En effet, suite à la transmission à titre universel de patrimoine dont s'accompagne l'opération de scission, les sociétés bénéficiaires pourront se retrouver titulaires de moyens de production, de biens meubles ou immeubles ou encore de travailleurs situés dans l'État membre de la société scindée. Si on combine cette situation avec le fait que la notion d'établissement secondaire peut revêtir des formes très diverses, l'énumération de l'article 49 du TFUE n'étant qu'exemplative à cet égard[575], il s'ensuit que les sociétés bénéficiaires seront susceptibles de se retrouver, par l'effet de l'opération, à titre secondaire, avec un établissement stable dans l'État membre de la société scindée. Par conséquent, une scission transfrontalière bénéficie de la protection de la liberté d'établissement primaire dans le chef de la société scindée et de la liberté d'établissement secondaire dans le chef des sociétés absorbantes[576]. Si on ne peut qu'adhérer à ce raisonnement dans l'hypothèse d'une société scindée disposant de moyens de production spécifiques tels qu'une usine ou un centre de distribution, la situation est plus complexe dans le cas d'une société ayant pour seul objet la détention de participations dans d'autres entités dispersées à travers plusieurs États membres sans détenir d'autres biens ou moyens susceptibles d'être qualifiés d'établissements secondaires[577]. Il en découlerait que la protection des scissions transfrontalières dans le chef des sociétés absorbantes par le biais de la liberté d'établissement secondaire ne serait en aucun cas automatique et constituerait une question qui devrait être analysée au cas par cas et tranchée en fonction des éléments factuels propres au cas d'espèce.

158. Le cas particulier des scissions partielles. Au sujet des scissions partielles, il a été avancé que celles-ci constituaient nécessairement des « autres opérations de transformation de sociétés » au sens de l'arrêt *Sevic*[578] et que celles-ci étaient nécessairement protégées par la liberté d'établissement, ne fût-ce que parce que la survie de la société apporteuse exclut toute émigration susceptible de justifier l'application des enseignements de *Daily Mail*[579]. Si le cas de la scission partielle transfrontalière par constitution de nouvelle société ne pose pas de difficultés dans la mesure où elle peut s'analyser aisément comme l'exercice par la société scindée de sa liberté d'établissement secondaire dans l'État membre de la nouvelle société, on est en droit de s'interroger sur le sort à réserver à la scission partielle par absorption au

575 Voir en ce sens : M. LUBY, *op. cit.*, p. 3 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 61 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 17, n° 12 et C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République fédérale d'Allemagne*, 4 décembre 1986, C-205/84, EU:C:1986:463, pt. 21 **et** Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 39.

576 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 35 à 37.

577 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 60 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 65 et 66. Voir également en ce sens à propos des scissions transfrontalières : L. HANSEN, *op. cit.*, p. 193.

578 Arrêt *Sevic*, pt. 19.

579 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 91 et H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 234.

profit d'une société existante. En effet, ce type d'opérations implique avant tout un fractionnement du patrimoine d'une société existante au profit d'une autre société existante sans que ni l'une ni l'autre n'ait l'intention d'exercer une activité économique à titre accessoire sur le territoire d'un autre État membre. La logique voudrait que ce type d'opérations soit également protégé par la liberté d'établissement, ne fût-ce que parce que la scission partielle par constitution de nouvelle société qui bénéficie pour sa part de la protection par la liberté d'établissement secondaire permet d'aboutir à un résultat identique si elle est subséquemment combinée à une fusion interne, mais force est de constater qu'il subsiste certains doutes à l'égard de ce type d'opération qui ne peuvent être levés simplement en considérant que la survie de l'entité scindée implique nécessairement la protection de l'opération par la liberté d'établissement secondaire.

159. Le cas particulier des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés. Préalablement à l'arrêt *Sevic*, l'idée qu'une fusion transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés ne pouvait en tout état de cause bénéficier de la protection de la liberté d'établissement avait été défendue. En effet, tout d'abord, la société bénéficiaire ne vient à être constituée qu'après la prise d'effet de l'opération[580]. N'existant pas en tant que sujet de droit au moment de la fusion transfrontalière, il serait logique de considérer qu'elle ne peut bénéficier de la protection de l'article 54 du TFUE puisque seules les sociétés constituées en conformité avec le droit d'un État membre peuvent s'en prévaloir[581]. En outre, la société apporteuse étant dissoute dans le cadre de l'opération, elle ne devrait pas non plus pouvoir bénéficier de la protection de la liberté d'établissement[582]. Un tel raisonnement, transposé aux scissions transfrontalières, signifierait que les scissions par constitution de nouvelles sociétés ne devraient pas être couvertes par la liberté d'établissement. Or, l'arrêt *Sevic*, en rejetant la théorie du *corporate suicide*, est venu fortement relativiser cette conception puisque du point de vue de la société scindée, la question de savoir si l'opération se fera uniquement au bénéfice de sociétés préexistantes ou, si au contraire, elle impliquera la constitution d'au moins une nouvelle société, est sans incidence[583]. En effet, dans ce dernier cas l'opération peut s'analyser comme un cas particulier d'exercice de la liberté d'établissement primaire[584], notamment parce que par l'effet de l'opération, les associés majoritaires de la société scindée acquièrent le contrôle de nouvelles sociétés établies dans un autre État membre et, partant, font usage de

580 Voir en ce sens : U. LENNERZ, *op. cit.*, pp. 76 et 77 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 71.

581 Voir en ce sens : L. KLOSTER, *op. cit.*, p. 1414 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 78 et 79 ; U. LENNERZ, *ibidem*, p. 77 ; J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 71 et R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 93.

582 Voir en ce sens : U. LENNERZ, *ibidem*, p. 77.

583 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 89 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 70 et M. SIEMS, « Sevic : Der letzte Mosaikstein im internationalen Gesellschaftsrecht der EU », *EuZW*, 2006, p. 136.

584 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 79 ; J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 70 ; Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, p. 82 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 82.

leur liberté d'établissement[585][586]. Face à cette évolution, il a été proposé de nuancer cette première analyse en considérant qu'une fusion transfrontalière par constitution de nouvelle société bénéficie de la protection de la liberté d'établissement primaire dans le chef des sociétés fusionnantes, mais pas de la liberté d'établissement secondaire dans le chef de la nouvelle société[587]. Une telle analyse peut être transposée aux scissions transfrontalières se réalisant au profit d'une ou de plusieurs nouvelles sociétés, de sorte qu'il convient de considérer que la société scindée, en procédant à sa scission manifeste sa volonté de « participer, de façon stable et continue, à la vie économique »[588] de l'État membre ou des États membres des sociétés scindées et par conséquent, jouit de la protection de la liberté d'établissement primaire. En revanche, la constitution des nouvelles sociétés n'étant, à l'instar de la disparition de la société scindée, qu'une conséquence de l'opération de scission, celles-ci ne peuvent se prévaloir de la liberté d'établissement, ne fût-ce qu'en raison du fait qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application *ratione personae* de la liberté d'établissement au moment où celle-ci est effectivement exercée, c'est-à-dire au moment où l'assemblée générale de la société scindée approuve l'opération.

160. Une incitation pour les législateurs nationaux. Pour finir, la protection des scissions transfrontalières par la liberté d'établissement signifie également que celles-ci ne sont pas conditionnées par l'adoption de directives destinées à en harmoniser la procédure[589]. Ce fait, combiné aux enseignements de l'arrêt *Sevic*, a directement incité certains États membres, comme la Norvège et la République tchèque, à mettre en place une législation applicable aux scissions transfrontalières[590].

---

585 Th. PAPADOPOULOS, *ibidem*, p. 82 et A. WENG, *ibidem*, p. 131 et arrêt *Überseering*, pt. 77 où la Cour a considéré qu' « en principe l'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques résidant dans un État membre de parts dans une société constituée et établie dans un autre État membre relève, dès lors qu'une telle participation ne confère pas à ces personnes physiques une influence certaine sur les décisions de la société et ne leur permet pas d'en déterminer les activités, des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux. En revanche, dès lors que l'acquisition porte sur la totalité des parts d'une société ayant son siège statutaire dans un autre État membre et qu'une telle participation confère une influence certaine sur les décisions de la société et leur permet d'en déterminer les activités, ce sont les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement qui trouvent à s'appliquer ».

586 Il convient toutefois de ne pas accorder trop d'importance à l'argument de la prise de contrôle car il signifie que la liberté d'établissement est impuissante face à l'hypothèse d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés dans laquelle (i) l'actionnaire unique serait une société soumise au droit de l'État membre des sociétés bénéficiaires et (ii) aucun établissement secondaire ne subsisterait dans l'État membre de la société scindée.

587 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 93 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 78 et 79 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 71 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 100. *Contra* : P. BEHRENS, « Die neue Lektion aus Luxemburg zur internationalen Mobilität von Gesellschaften: Grenzüberschreitende Verschmelzungen sind möglich ! », *op. cit.*, p. 65 qui n'opère pas une telle distinction.

588 C.J., arrêt *Trustees of the P Panayi Accumulation and Maintenance Settlements c. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*, 14 septembre 2017, C-646/15, EU:C:2017:682, pt. 27 ; arrêt *Gebhard*, pt. 25 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 29.

589 Arrêt *Sevic*, pt. 26 ; arrêt *Überseering*, pt. 55 et arrêt *Kraus*, pt. 30.

590 Étude Bech-Bruun et Lexidale, Main Findings, p. 83.

§ 3. Les limites de la jurisprudence Sevic

161. Les limites de l'arrêt *Sevic*. Bien que la Cour de justice ait défendu une conception étendue du champ d'application de la liberté d'établissement dans l'arrêt *Sevic* en affirmant sa volonté de permettre aux sociétés de capitaux établies au sein de l'Union européenne de bénéficier de nouveaux instruments de mobilité transfrontalière[591], force est de constater que les faits sous-jacents concernaient uniquement l'hypothèse d'une entrave dans l'État d'accueil à une fusion par absorption[592]. La Cour de justice, contrairement à l'avocat général Tizzano[593], ne s'est en revanche pas explicitement prononcée sur le sort à réserver aux barrières dressées par l'État d'origine[594]. C'est d'autant plus regrettable que les risques pour les *stakeholders* engendrés par une telle opération dans l'État d'origine sont beaucoup plus significatifs que dans l'État de destination[595].

162. Les arguments en faveur de l'exclusion des scissions émigration. Face à cela, certains auteurs n'ont pas hésité à défendre l'idée que les barrières dressées à une fusion transfrontalière par l'État d'origine ne tombaient pas dans le champ d'application de la liberté d'établissement[596]. Cette justification repose sur le principe que les sociétés commerciales, à l'inverse des personnes physiques, n' « ont d'existence qu'à travers les différentes législations nationales qui en déterminent la constitution et le fonctionnement »[597] et partant, également la disparition par le biais d'une fusion par absorption[598]. En outre, les tenants de cette théorie avancent également que la société absorbée ne doit pas bénéficier de la protection de la liberté d'établissement primaire dans la mesure où elle disparaît dans le cadre de l'opération projetée et n'a donc aucunement l'intention de participer à la vie économique de l'État membre de la société bénéficiaire[599]. Compte tenu de la proximité entre fusions et scissions transfrontalières, de tels arguments pourraient aisément être avancés à l'encontre de ces dernières.

591 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 78.
592 Arrêt *Sevic*, pts. 6–10.
593 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 34 à 41 où l'avocat général considère qu'une fusion transfrontalière peut s'analyser du point de vue de la liberté d'établissement secondaire à l'égard de l'État d'origine.
594 À certains moments de son raisonnement, la Cour de justice fait explicitement référence aux seules fusions du point de vue de l'État d'accueil. Voir arrêt *Sevic*, pts. 18, 20 et 22.
595 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 72.
596 Voir en ce sens : U. GROHMANN et N. GRUSCHINSKE, « Die identitätswahrende grenzüberschreitende Satzungssitzverlegung in Europa – Schein oder Realität? », *GmbHR*, 2008, p. 30 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC – Zugleich eine Besprechung von EuGH », *RIW*, 2006, p. 165 et M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 309.
597 Arrêt *Daily Mail*, pt. 19.
598 St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, pp. 64 et 65, n° 34 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, p. 166 et M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 309.
599 Voir en ce sens : U. GROHMANN et N. GRUSCHINSKE, « Die identitätswahrende grenzüberschreitende Satzungssitzverlegung in Europa – Schein oder Realität? », *op. cit.*, p. 30 ; Th. KUNTZ, *op. cit.*, p. 526 et St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT, *ibidem*, pp. 64 et 65, n° 34.

163. Les arguments en faveur de la protection des scissions émigration par la liberté d'établissement. Cette conception restrictive de la liberté d'établissement est toutefois loin de faire l'unanimité et de nombreux auteurs considèrent que la formulation générale de la Cour de justice à l'endroit des fusions transfrontalières qui semble détachée des faits à l'origine du litige implique qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment les fusions-immigrations des fusions-émigrations[600][601]. En effet, cette interprétation restrictive, qui n'est pas sans rappeler celle des Gouvernements néerlandais et allemand dans l'arrêt *Sevic*[602], peut être réfutée tout d'abord par le fait qu'elle méconnaît les caractéristiques d'une fusion transfrontalière puisque celle-ci implique toujours nécessairement plusieurs sociétés situées dans des États membres distincts, de sorte que dresser des barrières dans l'État de la société apporteuse constitue une entrave en principe interdite à la liberté d'établissement secondaire des sociétés bénéficiaires[603]. Ce premier argument, transposable de prime abord aux scissions transfrontalières, doit être relativisé (i) dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés puisqu'il a été démontré que la liberté d'établissement secondaire ne s'appliquait pas aux sociétés bénéficiaires dans une telle hypothèse[604], de même que dans le cas particulier où aucun établissement secondaire ne subsiste dans l'État membre de la société scindée, par exemple en cas de scission d'une société dont la seule activité économique est la détention de participations dans des sociétés étrangères. Il est certes possible de sortir de cette impasse en adhérant au raisonnement des auteurs qui considèrent que dans l'arrêt *Sevic*, la Cour ne s'est pas penchée sur les fusions transfrontalières sous l'angle de la société apporteuse ou

600 *Pro* : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Schutz der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch die Niederlassungsfreiheit », *op. cit.*, p. 211 ; P. BEHRENS, « Die neue Lektion aus Luxemburg zur internationalen Mobilität von Gesellschaften: Grenzüberschreitende Verschmelzungen sind möglich ! », *op. cit.*, p. 65 ; H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 56 ; R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 56–58 ; L. L. HANSEN, *op. cit.*, p. 188 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 226 qui déplorent malgré tout que la Cour de justice n'ait pas explicitement relégué sa jurisprudence *Daily Mail* aux oubliettes ; ; E.-M. KIENINGER, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen in der EU – das SEVIC-Urteil des EuGH », *EWS*, 2006, pp. 51 et 52 ; P.-Chr. MÜLLER – GRAFF, « Gesellschaftsrecht im Kontext des Europäischen Wirtschaftsordnungsrechts », *EWS*, 2009, p. 495 J. PIEPER, *op. cit.*, p. 172 et Th. WACHTER, « Ausländische GmbH: Rechts- und Parteifähigkeit einer liechtensteinischen Kapitalgesellschaft mit tatsächlichem Verwaltungssitz im Inland », *GmbHR*, 2005, p. 1485. *Contra* : J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 74 et 75 qui considère que la formulation générale de la Cour est uniquement due au fait qu'elle a précédemment limité le champ des questions préjudicielles ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, p. 166 qui considèrent que la position de la Cour de justice n'est pas claire et Cl. SCHMIDT et S. MAUL, *op. cit.*, p. 14 qui refusent de tirer des conclusions au-delà des circonstances factuelles à la base de l'arrêt *Sevic*.

601 Au sujet de l'obstacle à la sortie dressé malgré tout par la Directive Mobilité en la forme de la disposition anti-abus, voir *infra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1, Section 2, § 4.

602 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 20–23.

603 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 56 ; L. L. HANSEN, *op. cit.*, p. 188 ; N. KRAUSE et N. KULPA, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen – Vor dem Hintergrund der SEVIC-Entscheidung und der Reform des deutschen Umwandlungsrecht », *ZHR 171*, 2007, p. 41 ; W. MEILICKE et D. RABBACK, « Die EuGH-Entscheidung in der Rechtssache SEVIC und die Folgen für das deutsche Umwandlungsrecht nach Handelsrecht und Steuerrecht », *GmbHR*, 2006, p. 126 ; Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, p. 80 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 219.

604 À ce sujet, voir *supra* n° 159.

de la société bénéficiaire, mais bien comme un procédé unique[605], de sorte que la question du maintien de moyens économiques dans l'État membre de la société scindée devrait être considérée comme sans incidence. En d'autres termes, le fait pour l'État d'origine de dresser des barrières alors qu'il admet le principe des scissions internes équivaut à violer le principe de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes[606]. En outre, considérer que les scissions transfrontalières peuvent être interdites dans l'État d'origine alors qu'elles ne peuvent en principe l'être dans l'État d'accueil reviendrait à instaurer une distinction absente des articles 49 et 54 du TFUE qui viderait de sa substance l'intérêt de la protection des opérations transfrontalières dans l'État d'accueil[607]. Malgré ces considérations, force est de constater que la question des barrières dans l'État d'origine demeure entourée d'un certain flou.

§4. Les enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Euro Park Service*

A. *Les faits en cause*

164. Le refus du report de l'imposition des plus-values. Suite à sa fusion par absorption par son associé unique Euro Park, une société de droit luxembourgeois, la société de droit français Cairnbulg s'est vu refuser par l'administration fiscale française le bénéfice du régime fiscal des fusions évitant que les plus-values nettes et les profits dégagés sur les actifs apportés à l'associé unique ne soient soumis à l'impôt des sociétés français. Ce refus était motivé d'une part par le fait que Cairnbulg n'avait pas sollicité l'agrément ministériel prévu par le code général des impôts français alors en vigueur et dont l'obtention conditionne l'application du régime fiscal de faveur et (ii) d'autre part par le fait que cet agrément n'aurait en tout état de cause pas été accordé car l'opération, loin d'être justifiée par une raison économique aurait en réalité poursuivi un objectif de fraude ou d'évasion fiscale. Saisi du litige suite au rejet des prétentions de Cairnbulg par le tribunal administratif et la Cour administrative d'appel de Paris, le Conseil d'État a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de justice notamment sur la compatibilité de la législation anti-abus française à l'aune de la liberté d'établissement[608].

605 Voir en ce sens : Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *ZIP*, 2006, pp. 356 et 358 ; P. KINDLER, « Der Wegzug von Gesellschaften in Europa », *Der Konzern*, 2006, pp. 818 et 819 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, pp. 91 et 94.

606 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 69 et s.

607 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : V. GEYRHALTER et Th. WEBER, *op. cit.*, p. 147 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 78 et J. PIEPER, *op. cit.*, p. 172.

608 Arrêt *Euro Park Service*, pts. 12 à 17. Voir notamment au sujet de cet arrêt : L. BERNARDEAU, Ol. PEIFFERT, Fr. SCHMIED, « Jurisprudence de la C.J.U.E. : fiscalité directe (janvier/mars 2017), *Rev. Dr. Fisc.*, n° 17, 27 avril 2017, p. 3 ; M. MENJUCQ, « Une nouvelle étape dans la libéralisation des fusions transfrontalières », note sous Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2017, n° C-14/16, Euro Park Service c/ Ministre des finances et des comptes publics, *Rev. Soc.*, juillet-août 2017, pp. 435–438 ; K. MORBÉE, « Hof van Justitie 8 maart 2017, C-14/16, Euro Park Service », *T.F.R.*, 2017,

B. *Les enseignements de la Cour de justice*

165. Le rejet d'une présomption générale de fraude ou d'évasion fiscales. Après avoir confirmé qu'une mesure nationale adoptée en application de la faculté offerte par l'article 11, § 1er, a) de la directive (CE) 90/434[609] autorisant les États membres à prévoir des dispositions anti-abus peut être appréciée au regard du droit primaire comme elle n'opère pas une harmonisation exhaustive[610], la Cour de justice a commencé par rappeler qu'une fusion transfrontalière constitue « une modalité particulière d'exercice de la liberté d'établissement, importante pour le bon fonctionnement du marché intérieur, et relève donc des activités économiques pour lesquelles les États membres sont tenus au respect de cette liberté »[611]. Elle s'est ensuite efforcée de démontrer que la législation nationale française en cause, en ce qu'elle instaure une présomption générale de fraude ou d'évasion fiscales, est contraire à l'article 11, § 1er, a) de la directive (CE) 90/434[612] pour se pencher finalement sur la compatibilité avec la liberté d'établissement. À cet égard, elle a jugé que la mesure nationale en cause constitue une entrave à la liberté d'établissement en ce qu'elle instaure une différence de traitement entre opération interne et opération transfrontalière et que, bien que « la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales que la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres » constituent des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une telle entrave[613], l'instauration d'une présomption générale de fraude ou d'évasion fiscales va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi[614].

C. *L'incidence sur les scissions transfrontalières*

166. Le sort d'une entrave dans l'État d'origine. L'arrêt *Euro Park Service* a indéniablement le mérite de concerner une entrave dans l'État d'origine à une fusion transfrontalière et de considérer que la liberté d'établissement est applicable à une telle situation sans recourir à la distinction entre établissement primaire et secondaire. Il semble par conséquent que par analogie, l'État membre de la société scindée ne pourra pas davantage dresser de barrière à une scission transfrontalière que ne le peut l'État membre d'accueil en vertu de l'arrêt *Sevic*. Cependant, il convient de garder à l'esprit que cet arrêt relève de la matière fiscale et concerne en premier lieu une question d'interprétation de

n° 523, p. 501 et K. LENAERTS, « Le concept d'abus de droit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de fiscalité directe » in *L'Europe au présent !*, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 846–849.

609 Directive (CEE) 90/434 du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, *J.O.*, L 225, 20 août 1990, pp. 1–5. Cette directive n'est plus en vigueur depuis le 14 décembre 2009 et a été abrogée par la Directive Fiscale.

610 C.J., arrêt *Euro Park Service c. Ministre des finances et des comptes publics*, 8 mars 2017, C-14/16, EU:C:2017:177, pt. 26.

611 Arrêt *Euro Park Service*, pt. 28.

612 Arrêt *Euro Park Service*, pts. 56 et 57.

613 Arrêt *Euro Park Service*, pt. 65.

614 Arrêt *Euro Park Service*, pt. 69.

l'article 11, § 1er, a) de la directive (CE) 90/434. Il serait dès lors à tout le moins hasardeux d'en déduire de manière générale que les scissions transfrontalières sont protégées par la liberté d'établissement tant dans l'État membre d'origine que dans l'État membre de destination. Il s'agit néanmoins d'un indice important de la direction qui pourrait être empruntée par la Cour de justice en la matière.

SECTION 4. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

§1. L'incidence de la nature particulière des scissions

167. Un transfert du siège réel implicite. Si une scission transfrontalière et un transfert de siège transfrontalier constituent certes des opérations juridiquement distinctes[615], il n'en demeure pas moins que tous deux sont susceptibles d'avoir des effets similaires, dans le chef de la société apporteuse, dans la mesure où la scission transfrontalière va, par définition, entraîner un déplacement du siège de direction effective de celle-ci dans l'État membre des sociétés bénéficiaires[616]. Il est donc utile d'examiner les enseignements de la Cour de justice en matière de transfert de siège tant du point de vue de l'État d'origine (§ 2) que de l'État d'accueil (§ 3) à travers le prisme de la scission transfrontalière qui se caractérise notamment par (i) la dissolution sans liquidation de la société apporteuse et (ii) une pluralité de sociétés bénéficiaires soumises au droit de l'État d'accueil et ce, afin d'en tirer des conclusions susceptibles soit de dépasser les enseignements de la Cour de justice en matière de fusions transfrontalières, soit d'en préciser la portée (§ 4).

§2. Les scissions émigration

A. *Présentation*

168. La limite de l'assimilation des personnes morales aux personnes physiques. À l'égard des personnes physiques, la liberté d'établissement est invocable tant à l'encontre des barrières dressées par l'État d'accueil[617] que de celles dressées par l'État d'origine[618]. De prime abord, de telles considérations devraient également s'appliquer à la liberté d'établissement des personnes morales en raison de leur assimilation aux personnes physiques. Cependant, les personnes morales, du fait même qu'elles ne sont que des « entités créées

615 Sur cette différence, voir *supra* n° 33.

616 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 16. Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 58 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 534, n° 750.

617 C.J.C.E., arrêt *Christopher Stanton et SA belge d'assurances « L'Étoile 1905 » c. Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)*, 7 juillet 1988, C-143/87, EU:C:1988:378, pt. 12.

618 Arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 42.

en vertu d'un ordre juridique […] national »[619] ne disposent pas de la même protection face à leur État d'origine car elles n'ont d'existence qu'à travers celui-ci[620]. Il s'ensuit que les États membres d'origine disposent d'une grande marge de manœuvre pour déterminer à partir de quand une société est un sujet de droit bénéficiant de la liberté d'établissement. Il est dès lors utile d'étudier la jurisprudence de la Cour de justice en matière d'émigration pour déterminer l'incidence de cette particularité des personnes morales sur les scissions transfrontalières.

B. *Les enseignements de la Cour de justice en matière d'émigration*

1. *L'arrêt* Daily Mail

1.1. Les faits en cause

169. Le transfert du siège fiscal. L'arrêt *Daily Mail* du 27 septembre 1988 est le premier qui ait traité, en matière de liberté d'établissement, des entraves à la mobilité transfrontalière dressée par l'État membre d'origine. Les faits à l'origine de celui-ci concernaient la compatibilité de l'article 482, paragraphe premier, A de la loi britannique sur l'impôt et le revenu des sociétés, qui subordonnait le transfert du siège fiscal d'un État membre à un autre à l'obtention préalable d'une autorisation de la part du Trésor britannique avec les articles 49 et 54 du TFUE (anciens articles 43 et 48 du Traité CE). En effet, la société Daily Mail and General Trust plc, estimant que la nécessité de cette autorisation constituait une atteinte injustifiée à sa liberté d'établissement, avait transféré son siège de direction aux Pays-Bas Bas, et par conséquent son siège fiscal, tout en demeurant une société de droit anglais, en vue d'y bénéficier de la législation fiscale plus favorable en matière de plus-values sur titres, sans attendre d'avoir obtenu ladite autorisation. Afin de résoudre le différend avec le Trésor britannique qui s'est ensuivi, elle a alors saisi la High Court of Justice qui a directement posé la question de la compatibilité de la législation britannique avec la liberté d'établissement à la Cour de justice[621].

1.2. Les enseignements de la Cour

170. La légitimation des entraves dans l'État d'origine. Allant à l'encontre de l'avis de l'avocat général Marco Darmon[622], la Cour de justice a considéré que les articles 49 et 54 du TFUE (anciens articles 43 et 48 du Traité CE) ne

619 Arrêt *Daily Mail*, pt. 19.
620 Voir en ce sens : A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, p. 476, n° 981.
621 Arrêt *Daily Mail*, pts. 1–10.
622 L'Avocat général Marco Darmon avait conseillé à la Cour de justice de considérer que « [l]e transfert, dans un autre État membre, de l'administration centrale d'une société peut constituer une modalité d'exercice du droit d'établissement, sous réserve de l'appréciation, par le juge national, d'éléments de fait permettant de vérifier qu'un tel transfert traduit l'intégration réelle de ladite société dans l'activité économique de l'État d'accueil ». Voir Av. gén., M. DARMON, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *The Queen c. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc*, 27 septembre 1988, C-81/87, EU:C:1988:286, pt. 15.

conféraient « aucun droit, en l'état actuel du droit communautaire, à une société constituée en conformité de la législation d'un État membre et y ayant son siège statutaire, de transférer son siège de direction dans un autre État membre »[623].

171. Appréciation critique. Il s'agit là indéniablement d'un arrêt très restrictif en matière de mobilité des entreprises[624] dans lequel la Cour de justice a pour la première fois fait application du principe selon lequel une personne morale n'est que la créature de la législation nationale qui régit sa constitution et son fonctionnement[625]. De nombreux auteurs y ont par ailleurs également vu la confirmation de la compatibilité d'une application stricte de la théorie du siège réel avec la liberté d'établissement[626] et le caractère protectionniste de cet arrêt a mis en lumière la nécessité de favoriser la mobilité des entreprises par d'autres moyens que la jurisprudence de la Cour de justice[627]. Il ne faut toutefois pas exagérer la portée de cet arrêt dans la mesure où celui-ci relève exclusivement de la liberté d'établissement en matière fiscale pour laquelle les États membres disposent par définition d'une plus grande marge de manœuvre pour poser certaines limites puisque ces règles relèvent de l'ordre public et poursuivent une raison impérieuse d'intérêt général[628].

2. *L'arrêt* Cartesio

2.1. Les faits en cause

172. Un transfert de siège sans changement de droit applicable. Dans cette affaire, dont les faits ne sont pas sans rappeler ceux à l'origine de l'arrêt *Daily Mail*, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, une société en commandite simple de droit hongrois dont le siège avait été établi à Baja, en Hongrie, souhaitait transférer son siège de direction effective à Gallarate, en Italie, tout en continuant à relever du droit hongrois. Elle a dès lors demandé la modification de la

623 Arrêt *Daily Mail*, pt. 25.

624 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 83 et R. KOVAR, « La mobilité des sociétés dans l'espace européen », note sous C.J.C.E., 16 décembre 2008 (CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt), C-210/06, *Recueil Dalloz*, février 2009, p. 467.

625 Arrêt *Daily Mail*, pt. 19.

626 *Pro :* E. BEHRENS, « Die Umstrukturierung von Unternehmen durch Sitzverlegung oder Fusion über die Grenze im Licht der Niederlassungsfreiheit im Europäischen Binnenmarkt (Art 52 und 58 EWGV) », *ZGR*, 1994, pp. 20 et 21 ; C. T. EBENROTH et U. EYLES, « Die innereuropäische Verlegung des Gesellschaftssitzes als Ausfluß der Niederlassungsfreiheit? (Teil 1) - Die Mobilität von Unternehmen im Spannungsfeld von Harmonisierungsbestrebungen und der Anerkennung divergierender Rechtsstandards », *DB*, 1989, p. 372 ; B. GROSSFELD et Th. KÖNIG, « Das Internationale Gesellschaftsrecht in der Europäischen Gemeinschaft », *RIW*, 1992, p. 435 ; P. KINDLER, « Niederlassungsfreiheit für Scheinauslandsgesellschaften? – Die „Centros"-Entscheidung des EuGH und das internationale Privatrecht », *NJW*, 1999, p. 1997 ; P. KINDLER, « Neue Offenlegungspflichten für Zweigniederlassungen ausländischer Kapitalgesellschaften - Zur Umsetzung der Elften gesellschaftsrechtlichen Richtlinie der EG in deutsches Recht », *NJW*, 1993, pp. 3304 et 3305 et U. KOCH, « Die Entwicklung des Gesellschaftsrechts in den Jahren 1989/90 - Rechtspolitische Entwicklungen, Steuerrecht, deutsches internationales Gesellschaftsrecht, Recht der Personengesellschaften », *NJW*, 1992, p. 412. *Contra :* B. KNOBBE-KEUK, « Umzug von Gesellschaften in Europa », *ZHR*, 1990, p. 333.

627 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, pp. 2225 et 2226.

628 Al. AUTENNE et M. DE WOLF, *op. cit.*, pp. 677 et 678 et St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 58, n° 23.

mention concernant celui-ci dans le registre hongrois des sociétés. Néanmoins, cette demande a été rejetée au motif que le droit hongrois, dans la mesure où il applique la théorie du siège réel, ne permet pas à une société constituée selon son droit de transférer son siège à l'étranger tout en continuant à être soumise à la loi hongroise[629]. En seconde instance, face à cette situation, la cour d'appel régionale de Szeged a en substance demandé à la Cour de justice si la liberté d'établissement telle que consacrée par les articles 49 et 54 TFUE s'oppose à une réglementation d'un État membre qui empêche une société constituée en vertu du droit de cet État membre de transférer son siège dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l'État membre selon la législation duquel elle a été constituée[630].

2.2. Les enseignements de la Cour de justice

173. La confirmation de la jurisprudence *Daily Mail*. Contrairement aux espoirs d'une partie de la doctrine[631] qui souhaitaient voir la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire *Daily Mail* définitivement reléguée aux oubliettes, la Cour de justice a choisi de ne pas suivre l'avis de l'avocat général Poiares Maduro[632] et a énoncé qu' « en l'état actuel du droit communautaire, les articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui empêche une société constituée en vertu du droit national de cet État membre de transférer son siège dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l'État membre selon la législation duquel elle a été constituée »[633].

174. La confirmation de la distinction entre immigration et émigration. Au-delà de ce premier point, la Cour a en outre explicitement réaffirmé la distinction entre les hypothèses d'émigration et d'immigration tout en considérant que sa jurisprudence *Sevic* ne concernait que le cas d'une entrave dans l'État d'accueil et qu'elle ne saurait dès lors avoir d'incidence sur la portée de sa jurisprudence en matière d'émigration[634].

629 Arrêt *Cartesio*, pts. 20–40.

630 Voir arrêt *Cartesio*, pt. 40, 4) pour les quatre sous-questions relatives à la liberté d'établissement posées par la Cour de justice et pt. 99 pour la reformulation de la Cour.

631 C. BEHME et N. NOHLEN, « Zur Wegzugsfreiheit von Gesellschaften – Der Schlussantrag von Generalanwalt Maduro in der Rechtssache Cartesio (C-210/06) », *NZG*, 2008, p. 497 ; J. CAMPOS-NAVE, « Die Liberalisierung der Wegzugsfreiheit in Europa », *BB*, 2008, p. 1413 ; R. FRENZEL, « Immer noch keine Wegzugsfreiheit für Gesellschaften im Europäischen Binnenmarkt – die Cartesio-Entscheidung des EuGH », *EWS*, 2009, p. 158 ; U. GROHMANN et N. GRUSCHINSKE, « Beschränkungen des Wegzugs von Gesellschaften innerhalb der EU – die Rechtssache Cartesio », *EuZW*, 2008, p. 464 et A. WENG, « Die Rechtssache Cartesio – Das Ende Daily Mails? », *EWS*, 2008, p. 265.

632 Selon l'Avocat général Poiares Maduro, la Cour aurait dû considérer que les articles 49 et 54 du TFUE « s'opposent à l'application de règles nationales rendant impossible pour une société constituée en vertu de la loi nationale de transférer son administration centrale vers un autre État membre ». Voir Av. gén., M. M. POIARES MADURO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt*, 16 décembre 2008, C-210/06, EU:C:2008:294, pts. 35 et 36.

633 Arrêt *Cartesio*, pt. 124.

634 Arrêt *Cartesio*, pts. 121 et 122.

175. Un *obiter dictum* sur les transformations transfrontalières. S'il est certes vrai que les auteurs qui se basaient sur les enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Hughes de Lasteyrie du Saillant*[635] combinés à l'assimilation des personnes morales aux personnes physiques prévue par l'article 54 du TFUE pour considérer que l'arrêt *Daily Mail* était définitivement dépassé[636] ne se sont pas vus donner raison par la Cour de justice, il ne faut toutefois pas s'arrêter là. Il y a en effet, dans l'arrêt *Cartesio,* une innovation majeure qui le distingue de l'arrêt *Daily Mail*[637]. En effet, la Cour a pris la peine de préciser dans un *obiter dictum* que les faits à l'origine du litige devaient être clairement distingués de l'hypothèse dans laquelle une société relevant du droit d'un État membre se déplace vers un autre État membre en se transformant en une forme de société relevant du droit national de celui-ci[638]. Par conséquent, même si les sociétés ne sont que les créatures du droit de l'État membre de leur constitution, ce dernier ne peut les empêcher de se transformer en une société de droit national d'un autre État membre, pour peu que le droit de ce dernier le permette, en leur imposant une dissolution et une liquidation, sans commettre une atteinte aux articles 49 et 54 du TFUE qui ne pourra être justifiée que par une raison impérieuse d'intérêt général[639]. En d'autres termes, la Cour établit que les transformations de sociétés, c'est-à-dire les opérations dans lesquelles une société souhaite changer le droit qui lui est applicable en altérant son facteur de rattachement à l'État d'origine, tombent dans le champ d'application de la liberté d'établissement[640]. Elle contribue

635 Dans l'arrêt *Lasteyrie du Saillant*, la Cour de justice a considéré que la liberté d'établissement consacrée par le TFUE « s'oppose à ce qu'un État membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values latentes, tel que celui prévu à l'article 167*bis* du CGI, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet État ». Voir arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 58.

636 Voir en ce sens : J. CAMPOS-NAVE, « Die Wegzugsbesteurung als Einschränkung der europäischen Niederlassungsfreiheit », *NZG*, 2004, p. 898 ; T. FROBENIUS, « „Cartesio": Partielle Wegzugsfreiheit für Gesellschaften in Europa », *DStR*, 2009, p. 487 ; J. KLEINERT et P. PROBST, « Endgültiges Aus für Sonderanknüpfungen bei (Schein-) Auslandsgesellschaften », *DB*, 2003, p. 2218 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Cartesio – fortgeltende Sitztheorie, grenzüberschreitender Formwechsel und Verbot materiellrechtlicher Wegzugsbeschränkungen », *BB*, 2009, p. 60 ; P. MANKOWSKI, « Entwicklungen im Internationalen Privat- und Prozessrecht 2003/2004 », *RIW*, 2004, p. 484 et M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 309. *Contra :* D. BARTHEL, *op. cit.*, p. 323 ; Chr. TEICHMANN, « Cartesio : Die Freiheit zum formwechselnden Wegzug », *ZIP*, 2009, p. 394 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, pp. 46–48. Pour un avis plus nuancé, voir M.-Ph. WELLER, « Zum identitätswahrenden Wegzug deutscher Gesellschaften », *DStR*, 2004, 1219 et 1220 qui considère que les arrêts *Daily Mail* et *Lasteyrie du Saillant* ne sont pas contradictoires, la Cour de justice ayant uniquement précisé dans l'arrêt *Daily Mail* que l'État d'origine peut s'opposer à l'émigration de ces sociétés, ce qui ne signifie pas que l'État d'origine puisse dresser librement tous types d'entraves fiscales à ce type d'opérations.

637 R. KOVAR, *op. cit.*, p. 469 ; St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 65, n° 36 et Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, pp. 85 et 86.

638 Arrêt *Cartesio*, pt. 111.

639 Arrêt *Cartesio*, pts. 112 et 113.

640 D. BARTHEL, *op. cit.*, p. 325 ; Ph. BOLLACHER, « Keine Verletzung der Niederlassungsfreiheit durch nationale Beschränkungen des Wegzugs von Gesellschaften – Besprechung zu EuGH, RIW 2009, 70 – Cartesio », *RIW*, 2009, pp. 152 et 153 ; A. FRANCK, *Formwechsel im Binnenmarkt*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2016, p. 32 et Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, p. 85 et 86.

ainsi, bien que de manière insidieuse[641], à renforcer la mobilité des sociétés au sein de l'espace européen en sapant l'emprise des droits nationaux sur les opérations de transformation transfrontalière. Par conséquent, l'arrêt *Cartesio* s'inscrit certes dans la continuité de l'arrêt *Daily Mail*[642], mais il en précise considérablement la portée[643].

C. *Les enseignements de la Cour appliqués aux scissions transfrontalières*

176. La pertinence de la distinction entre immigration et émigration. La partie de l'arrêt *Cartesio* réaffirmant la pertinence de la distinction entre immigration et émigration[644] laisse de prime abord à penser que l'État membre de la société scindée pourrait purement et simplement interdire les scissions transfrontalières. Une telle interprétation est toutefois excessive car en limitant l'incidence de ses enseignements dans l'arrêt *Sevic*, la Cour de justice a simplement voulu distinguer les faits à la base de l'arrêt *Cartesio* qui concernaient le champ d'application *ratione personae* de la liberté d'établissement puisqu'il n'était pas certain que la société en question tombait dans le champ d'application de la liberté d'établissement[645], de ceux à la base de l'arrêt *Sevic* qui concernaient le champ d'application *ratione materiae* de la liberté d'établissement, c'est-à-dire l'application de celle-ci à l'hypothèse d'une fusion transfrontalière[646]. Or, si dans l'hypothèse d'un transfert de siège sans adoption d'une forme sociale de l'État membre de destination, on peut effectivement argumenter que la société en question ne tombe plus dans le champ d'application *ratione personae* de la liberté d'établissement car elle ne remplit plus la condition de la constitution en conformité avec le droit d'un État membre posée par l'article 54 du TFUE, un tel raisonnement ne tient pas dans le cas d'une scission transfrontalière, que celle-ci soit par absorption, mixte ou par constitution de nouvelles sociétés. En effet, une scission transfrontalière par absorption ou mixte peut s'analyser à la fois sous l'angle de la liberté d'établissement primaire de la société scindée et sous l'angle de la liberté d'établissement secondaire des sociétés bénéficiaires

641 G. PARLEANI, « L'arrêt *Cartesio* ou l'ingénieuse incitation à la migration intra communautaire des sociétés », note sous C.J.C.E., 16 décembre 2008 (CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt), C-210/06, *Rev. Soc.*, 2009, p. 151.

642 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, Einleitung C, n° 12 ; H. KUSSMAUL, L. RICHTER et Chr. RUINER, « Grenzenlose Mobilität?! - Zum Zuzug und Wegzug von Gesellschaften in Europa », *EWS*, 2009, p. 7 ; V. KOROM, « La liberté d'établissement des personnes morales et l'affaire *Cartesio* : un pas en arrière ? », *R.L.D.A.*, mars 2009, p. 13 ; St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 65, n°s 35 et 36 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Cartesio – fortgeltende Sitztheorie, grenzüberschreitender Formwechsel und Verbot materiellrechtlicher Wegzugsbeschränkungen », *op. cit.*, p. 58 et F. MELIN, « Déplacement de siège social dans la Communauté européenne », note sous C.J.C.E., 16 décembre 2008 (CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt), C-210/06, *J.C.P. E.*, 2009, p. 44.

643 A.-S. CORNETTE DE SAINT-CYR, « Le transfert de siège social transfrontalier », *J.C.P. E.*, 2009, p. 25 ; A. KHAN, « Corporate mobility, market access and the internal market », *E.L. Rev.*, 2015, p. 374 ; R. KOVAR, *op. cit.*, p. 469 et St. LEIBLE et J. HOFFMANN, *ibidem*, p. 60.

644 Arrêt *Cartesio*, pts. 121–124.

645 D. BARTHEL, « Die Niederlassungsfreiheit der Gesellschaften nach EuGH "Cartesio" - die Suche nach dem Gleichgewicht zwischen Wettbewerb im Binnenmarkt und nationalstaatlicher Regelungsautonomie », *EWS*, 2010, pp. 319 et 320 ; Ph. BOLLACHER, *op. cit.*, p. 154 et arrêt *Cartesio*, pts. 109 et 110.

646 Arrêt *Sevic*, pts. 16–19.

préexistantes de sorte qu'une entrave dans l'État d'origine d'une des entités constitue nécessairement une entrave dans l'État d'accueil pour au moins une des autres entités impliquées, rendant par conséquent la distinction entre immigration et émigration inopérante. Ensuite, dans le cas d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, on constate que le transfert de siège impliqué par une telle opération s'accompagne nécessairement de l'adoption d'une forme juridique de l'État de destination[647], ce qui est précisément l'hypothèse visée par l'*obiter dictum* de l'arrêt *Cartesio*[648].

177. L'ombre de *Daily Mail*. Malgré la relativisation des enseignements de l'arrêt *Daily Mail* et la lueur d'espoir générée par l'*obiter dictum* de l'arrêt *Cartesio*, force est néanmoins de constater que la jurisprudence de la Cour de justice en matière d'entraves dans le pays d'origine aux transferts de siège laisse planer un doute quant au sort qui serait réservé à une réglementation nationale qui s'opposerait à la scission d'une de ses sociétés au profit de sociétés bénéficiaires étrangères[649]. En effet, même si l'argument avancé précédemment selon lequel une scission transfrontalière constituerait une modalité particulière d'exercice de la liberté d'établissement secondaire des sociétés bénéficiaires est convaincant, il est impossible de garantir que ce raisonnement sera suivi par la Cour de justice. Il en découle une certaine insécurité juridique de nature à dissuader les acteurs économiques de recourir à ce type de restructuration.

§ 3. Les scissions immigration

A. *Présentation*

178. La précision de *Sevic*. S'il est certes vrai que les faits à la base de l'arrêt *Sevic* concernaient explicitement l'hypothèse d'une entrave dressée par l'État d'accueil, celui-ci n'en est pas pour autant exempt de zones d'ombre, notamment en ce qui concerne les possibles justifications d'une entrave à la liberté d'établissement. Il est dès lors utile de se pencher sur les enseignements de la Cour de justice en matière d'immigration (B) afin d'en tirer des conséquences applicables aux scissions transfrontalières et de préciser ses enseignements en matière de fusions transfrontalières (C).

B. *Les enseignements de la Cour de justice en matière d'immigration*

179. Plan du point B. Étudier les enseignements de la Cour de justice en matière d'immigration implique d'examiner méthodiquement et par ordre chronologique, les arrêts *Segers* (1), *Centros* (2), *Überseering* (3) et *Inspire Art* (4).

647 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : R. FRENZEL, « Immer noch keine Wegzugsfreiheit… », *op. cit.*, p. 163.
648 Arrêt *Cartesio*, pt. 111.
649 Voir en ce sens également : R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 280.

1. *L'arrêt* Segers

1.1. Les faits en cause

180. La *limited* des époux Segers. Le premier arrêt de la Cour de justice en matière de liberté d'immigration des sociétés n'est autre que l'arrêt *Segers* rendu le 10 juillet 1986. Dans cette affaire, M. Segers avait créé, à parts égales avec son épouse, une *limited company* anglaise ayant son siège social à Londres pour ensuite lui apporter intégralement sa société unipersonnelle dont le siège social était situé aux Pays-Bas. Celle-ci est donc devenue *de facto* la filiale de la *limited company* et c'est au travers de cette dernière que M. Segers, nommé directeur de la filiale, exerçait l'intégralité de ses activités, d'ailleurs uniquement localisées aux Pays-Bas. Souhaitant par la suite bénéficier de prestations d'assurance maladie aux Pays-Bas, M. Segers a fait une déclaration auprès de l'association professionnelle du secteur bancaire, des assurances, du commerce de gros et des professions libérales, administration qui lui en a refusé le bénéfice au motif qu'il n'avait pas travaillé au sein de la *limited company* en vertu d'un contrat de travail. M. Segers n'a pas manqué de s'opposer à cette décision en invoquant la jurisprudence du *Centrale Raad van Beroep* selon laquelle le directeur d'une société qui détient lui-même la moitié ou plus des parts de la même société doit être considéré comme fournissant une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination dans la même société. L'administration néerlandaise a alors justifié son refus en affirmant que cette jurisprudence ne devait s'appliquer qu'aux directeurs de sociétés qui ont leur siège social aux Pays-Bas et, en aucun cas, dans l'hypothèse d'une société de droit étranger. Face à cette situation, la juridiction néerlandaise a préféré demander à la Cour de justice si les articles 49 et 54 du TFUE s'opposaient à une différence de traitement entre le directeur d'une société de droit néerlandais et celui d'une société de droit étranger, et ce, même si la société de droit étranger exerçait manifestement l'entièreté de ses activités commerciales aux Pays-Bas.

1.2. La décision de la Cour

181. La protection des *pseudo foreign companies*. La Cour de justice a répondu par l'affirmative à cette question en estimant que le refus des autorités néerlandaises « pour le seul fait que la société a été constituée en conformité de la législation d'un autre État membre où elle a également son siège social, même si elle n'y exerce pas d'activités commerciales » était contraire à la liberté d'établissement[650]. Cette décision est, selon elle, justifiée par le fait que permettre à l'État membre dans lequel une société régulièrement constituée dans un autre État membre souhaite faire usage de sa liberté d'établissement secondaire par le biais d'une agence, succursale ou filiale d'instaurer une différence de traitement sur la seule base du lieu où est situé le siège social de la société priverait l'article 49 du TFUE de tout intérêt[651]. Le fait que la société constituée par M. Segers s'apparente en réalité à une *pseudo foreign*

650 Arrêt *Segers*, pt. 19.
651 Arrêt *Segers*, pt. 14.

company, c'est-à-dire une société qui exerce *de facto* la totalité de ses activités économiques dans un État distinct de son État d'incorporation a été jugé sans incidence sur la question de l'applicabilité de la liberté d'établissement dans la mesure où seules (i) une constitution valable en vertu du droit national applicable et (ii) la présence du siège statutaire, de l'administration centrale ou du principal établissement à l'intérieur du territoire de l'Union européenne sont requises par l'article 54 du TFUE pour qu'une société puisse effectivement bénéficier de la liberté d'établissement[652].

2. *L'arrêt* Centros

2.1. Les faits en cause

182. La *pseudo foreign company* des époux Bryde. Les faits à l'origine de l'arrêt *Centros* du 9 mars 1999 présentent de fortes similitudes avec ceux de l'arrêt *Segers*[653]. Il n'est dès lors pas étonnant que cet arrêt n'ait apporté que peu de nouveautés[654], mais il a eu un effet beaucoup plus retentissant. Dans cette affaire, les époux Bryde, deux ressortissants danois résidant au Danemark, se partageaient les parts sociales de la société Centros Ltd., une *limited liability company* de droit anglais dont le siège social était établi au domicile d'un ami de M. Bryde. Les époux ont ensuite tenté d'établir une succursale de leur société britannique au Danemark, mais ils se sont vu opposer un refus de la direction générale du commerce et des sociétés du Danemark d'immatriculer celle-ci au motif notamment que la société n'exerçait aucune activité commerciale au Royaume-Uni et cherchait en réalité à constituer au Danemark, non pas une succursale, mais un établissement principal, en éludant les règles nationales relatives notamment au montant minimum et à la libération du capital social[655].

2.2. Les enseignements de la Cour

183. La confirmation de la protection des *pseudo foreign companies*. La Cour a vu dans ce refus d'immatriculation une violation des articles 49 et 54 du TFUE et a confirmé l'application de la liberté d'établissement aux *pseudo foreign companies*[656]. Elle a ainsi clairement précisé que le fait pour un ressortissant de choisir de constituer une société dans un État membre pour la seule raison que le droit des sociétés de ce dernier est plus avantageux et d'exercer ses activités économiques dans un autre État membre au moyen d'une succursale ne constitue pas en soi un usage abusif de la liberté d'établissement[657].

652 Arrêt *Segers*, pt. 16.
653 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 114.
654 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 51 ; W.-H. ROTH, « "Centros" – Viel Lärm um nichts? - Besprechung der Entscheidung EuGH », *ZGR*, 2000, p. 317 et D. ZIMMER, « Mysterium "Centros" – Von der schwierigen Suche nach der Bedeutung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes », *ZHR*, 2000, p. 39.
655 Arrêt *Centros*, pts. 1–12.
656 Arrêt *Centros*, pt. 30.
657 Arrêt *Centros*, pt. 27.

184. L'incidence sur la théorie du siège réel. Certains auteurs n'ont pas hésité à déduire de cet arrêt que la Cour de justice avait sonné le glas de la théorie du siège réel et s'était indirectement prononcée en faveur de la théorie de l'incorporation[658]. D'autres, en revanche, ont considéré que l'arrêt n'avait aucune incidence sur les États membres appliquant la théorie du siège réel puisque, d'une part, les États impliqués recourent tous les deux à la théorie du siège d'incorporation et, d'autre part, la Cour de justice a basé son raisonnement sur le fait que la société Centros Ltd. avait été valablement constituée en vertu du droit de son État d'origine[659].

185. La possibilité d'une justification. Il faut néanmoins encore mentionner que la Cour a pris soin de préciser qu'une restriction à une liberté fondamentale, en ce compris la liberté d'établissement dont il est question en l'occurrence, est susceptible d'être justifiée à condition de remplir quatre conditions cumulatives. Une restriction nationale doit ainsi s'appliquer de manière non-discriminatoire, être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre[660]. Dans le cas présent, l'entrave ne pouvait être considérée comme justifiée d'une part parce qu'elle n'était pas à même de garantir l'objectif poursuivi, à savoir la protection des créanciers[661] et d'autre part, parce qu'en tout état de cause, le principe de proportionnalité n'était pas respecté[662].

3. *L'arrêt* Überseering

3.1. Les faits en cause

186. L'incidence du transfert du siège de direction effective. Dans l'affaire *Überseering* du 5 novembre 2002, Überseering BV, une société de droit néerlandais, avait confié en 1990 la rénovation d'un motel et d'un garage situés à Düsseldorf, en Allemagne, à la Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, une société de construction de droit allemand. En 1994, deux ressortissants allemands avaient acquis la totalité des titres de la société Überseering BV, provoquant *de facto* un transfert du siège de direction effective des Pays-Bas vers l'Allemagne. En 1996, Überseering BV a décidé d'assigner la Nordic Construction Company en raison de vices dans l'exécution des travaux de

658 Pour un exposé de la problématique, voir : St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, pp. 59 et 60, n° 25. *Pro* : V. GEYRHALTER, « Niederlassungsfreiheit contra Sitztheorie – Good Bye Daily Mail », *EWS*, 1999, p. 203 ; W. MEILICKE, « Auswirkungen der „Centros-Entscheidung" auf die 14. EU-Sitzverlegungs-Richtlinie », *GmbHR*, 1999, p. 896 et J. SEDEMUND et L. HAUSMANN, « Niederlassungsfreiheit contra Siztheorie – Abschied von Daily Mail », *BB*, 1999, p. 810.

659 W. EBKE, « Das Centros-Urteil des EuGH und seine Relevanz für das deutsche Internationale Gesellschaftsrecht – Das Schicksal der Sitztheorie nach dem Centros-Urteil des EuGH », *JZ*, 1999, p. 658 ; P. KINDLER, « Niederlassungsfreiheit für Scheinauslandsgesellschaften? – Die „Centros"-Entscheidung des EuGH und das internationale Privatrecht », *op. cit.*, p. 1997 et K. LANGE, « Zur Niederlassungsfreiheit im Zusammenhang mit der Eintragung einer inländischen Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft », *DNotZ*, 1999, p. 606.

660 Arrêt *Centros*, pt. 34 ; arrêt *Gebhard*, pt. 37 et arrêt *Kraus*, pt. 34.

661 Arrêt *Centros*, pt. 35.

662 Arrêt *Centros*, pts. 37 et 38.

rénovation. Néanmoins tant le *Landgericht* que l'*Oberlandesgericht* ont déclaré l'action irrecevable au motif qu'Überseering BV ne jouissait pas de la capacité juridique en droit allemand. En effet, étant donné que le droit allemand applique la théorie du siège réel et que la société Überseering BV avait transféré ce dernier en Allemagne en 1994, sa capacité juridique devait s'apprécier au regard du droit allemand. Or, pour pouvoir en jouir, elle aurait dû se reconstituer selon le droit allemand. Il faut cependant remarquer que cela n'a pas empêché la société Überseering BV de se faire condamner entretemps par le *Landgericht* de Düsseldorf à régler les honoraires dus à l'architecte pour la rénovation de son motel dans le cadre d'une procédure où elle était défenderesse[663].

187. Les deux questions préjudicielles du BGH. Face à cette situation, le *Bundesgerichtshof* devant lequel Überseering BV s'était pourvue en cassation s'est demandé premièrement si les articles 49 et 54 du TFUE ne s'opposaient pas à ce que la capacité d'une personne morale valablement constituée en vertu du droit d'un État membre soit appréciée à l'aune du droit d'un autre État membre sur le territoire duquel la personne morale en question a transféré son siège de direction effective lorsqu'il en résulte qu'elle se retrouve privée de la possibilité de faire valoir en justice les droits qu'elle tire d'un contrat et, deuxièmement, si en cas de réponse positive à la première question, la liberté d'établissement imposait d'apprécier la capacité juridique et partant, la capacité d'ester en justice d'une société au regard du droit de l'État où elle avait été constituée[664].

3.2. Les enseignements de la Cour de justice

188. Une reconnaissance automatique. Sans grande surprise, la Cour, suivant en cela l'avis de l'avocat général Dámaso Colomer[665], a répondu par l'affirmative à la première question[666]. Pour ce qui est de la réponse à la deuxième question, en revanche, la Cour a choisi de s'écarter de l'avis de l'avocat général[667] et a considéré que « lorsqu'une société constituée conformément à la législation d'un État membre sur le territoire duquel elle a son siège statutaire exerce sa liberté d'établissement dans un autre État membre, les articles 43 CE et 48 CE imposent à ce dernier de respecter la capacité juridique et, partant, la capacité d'ester en justice que cette société possède en vertu du droit de son État de constitution »[668]. Par conséquent, à partir du moment où une société possède la capacité juridique en vertu du droit de son État d'origine, l'État d'accueil

663 Arrêt *Überseering*, pts. 6–12.
664 Arrêt *Überseering*, pt. 22.
665 Av. gén., M. D. R.-J. COLOMER, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Überseering BV c. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)*, 5 novembre 2002, C-208/00, EU:C:2001:655, pt. 62.
666 Arrêt *Überseering*, pt. 94.
667 L'avocat général avait conseillé à la Cour de s'abstenir de répondre à la deuxième question en raison de son caractère abstrait qui aurait contraint la Cour à s'immiscer dans le droit national et subsidiairement, d'y répondre par la négative. Voir av. gén., M. D. R.-J. COLOMER, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Überseering BV c. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)*, 5 novembre 2002, C-208/00, EU:C:2001:655, pt. 70.
668 Arrêt *Überseering*, pt. 95.

est tenu de reconnaître inconditionnellement la capacité de celle-ci lorsque cette dernière fait usage de sa liberté d'établissement[669]. La Cour relativise donc sensiblement l'importance de son arrêt *Daily Mail* en distinguant entre les barrières à la sortie, pour lesquelles les États membres disposent a priori d'une certaine latitude, et les barrières à l'entrée, où la marge de manœuvre des États membres est beaucoup plus réduite[670].

189. La possibilité d'une justification. La Cour de justice semble par ailleurs même avoir durci sa position en excluant la possibilité de justifier une telle entrave à la liberté d'établissement en invoquant des raisons impérieuses d'intérêt général dans la mesure où elle a considéré que le fait de refuser de reconnaître toute capacité juridique à une société régulièrement constituée dans un autre État membre équivaut à une négation pure et simple de la liberté d'établissement[671].

4. *L'arrêt* Inspire Art

4.1. Les faits en cause

190. La « *Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen* ». Les faits à la base de l'arrêt *Inspire Art* concernaient une *private limited company by shares* de droit anglais, Inspire Art Ltd, spécialisée dans la vente d'objets d'art qui exerçait l'ensemble de son activité à Amsterdam par l'intermédiaire de sa succursale. Ce montage lui permettait de bénéficier de la législation anglaise particulièrement favorable en matière de capital minimal et de responsabilité des administrateurs tout en exerçant l'essentiel de ses activités dans un autre État membre. Néanmoins, afin de lutter contre ce type manœuvres, le législateur néerlandais avait adopté une loi destinée à encadrer les sociétés étrangères de pure forme qui imposait à ces *pseudo foreign companies* d'être immatriculées au registre du commerce avec la mention « société étrangère de pure forme ». L'adjonction de cette mention avait pour conséquence l'application de conditions plus sévères en matière de capital minimal et de responsabilité des administrateurs. La chambre de commerce d'Amsterdam, estimant qu'Inspire Art Ltd était en situation irrégulière a alors saisi le *Kantongerecht* afin de faire ordonner que l'immatriculation d'Inspire Art Ltd soit complétée par la mention « société étrangère de pure forme ». Le *Kantongerecht*, bien qu'estimant que

669 Voir en ce sens : P. BEHRENS, « Das Internationale Gesellschaftsrecht nach dem Überseering Urteil des EuGH und den Schlussanträgen zu Inspire Art », *IPRax*, 2003, p. 204 ; M. BINZ et G. MAYER, « Die ausländische Kapitalgesellschaft & Co. KG im Aufwind? – Konsequenzen aus dem „Überseering"-Urteil des EuGH v. 5.11.2002 », *GmbHR*, 2003, pp. 254 et 255 ; W. EBKE, « Überseering: Die wahre Liberalität ist Anerkennung », *JZ*, 2003, p. 929 ; H. EIDENMÜLLER, « Wettbewerb der Gesellschaftsrechte in Europa », *ZIP*, 2002, pp. 2238 et 2239 ; U. FORSTHOFF, « EuGH fördert Vielfalt im Gesellschaftsrecht – Traditionelle deutsche Sitztheorie verstößt gegen Niederlassungsfreiheit », *DB*, 2002, p. 2474 ; M. LUTTER, « "Überseering" und die Folge », *BB*, 2003, p. 9 ; M. REHBERG, « Internationales Gesellschaftsrecht im Wandel: Das Überseering-Urteil des EuGH und seine Folgen », *IPRax*, 2003, p. 180 et D. ZIMMER, « Wie es Euch gefällt? Offene Fragen nach dem Überseering-Urteil des EuGH », *BB*, 2003, p. 5.

670 Arrêt *Überseering*, pts. 69–73 et St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 62, n° 29.

671 Arrêt *Überseering*, pt. 93.

la nature de la société Inspire Art Ltd aurait dû compléter son immatriculation, posa néanmoins tout d'abord la question de savoir si la loi néerlandaise en ce qu'elle subordonne l'établissement aux Pays-Bas des sociétés étrangères de pure forme à des conditions supplémentaires est contraire aux articles 49 et 54 du TFUE et, deuxièmement, si la Cour devait donner une réponse positive à la première question, si cette entrave à la liberté d'établissement est susceptible d'être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général[672].

4.2. Les enseignements de la Cour de justice

191. L'exclusion des régimes d'exception. Les faits sont donc très similaires à ceux de l'arrêt *Centros*[673], à ceci près qu'ici la législation néerlandaise ne s'opposait pas à l'immatriculation d'une succursale, mais exigeait seulement que celle-ci s'accompagne d'une mention supplémentaire qui entraînerait l'application de règles nationales plus strictes que celles de l'État de constitution. Cette distinction n'a pas empêché la Cour de justice de considérer que le fait de soumettre l'exercice de la liberté d'établissement secondaire d'une société constituée en conformité avec le droit d'un autre État membre au respect de certaines conditions relatives au capital social minimal et à la responsabilité des administrateurs prévues par le droit interne de l'État d'accueil était contraire aux articles 49 et 54 du TFUE[674]. Par conséquent, il ressort clairement de l'arrêt que, sauf en cas d'abus, le fait de constituer une société en optant pour le droit national le moins contraignant tout en ayant l'intention d'exercer l'intégralité des activités économiques au moyen d'une succursale établie dans un autre État membre est sans incidence sur la question de l'applicabilité de la liberté d'établissement[675] et est inhérent à la mobilité engendrée par le marché intérieur[676].

192. Les trois tentatives de justification. Au niveau de l'éventuelle justification de l'entrave, la Cour est restée fidèle aux conditions établies par sa jurisprudence antérieure[677] et a estimé qu'aucune des raisons impérieuses d'intérêt général invoquées par le gouvernement néerlandais n'était à même de justifier l'entrave à l'exercice de la liberté d'établissement créée par la loi sur les sociétés étrangères de pure forme[678]. Tout d'abord, au sujet de l'éventuelle justification de l'entrave par la nécessité de garantir une certaine protection des créanciers, la Cour a jugé que ceux-ci étaient suffisamment informés du fait que la société était soumise au droit anglais et que partant, l'application d'un régime d'exception n'était pas nécessaire pour les protéger davantage[679]. Ce premier raisonnement a été fortement critiqué par certains auteurs dans la mesure où (i) en cas de responsabilité délictuelle de la société étrangère, les

672 Arrêt *Inspire Art*, pt. 39.
673 À ce sujet, voir *supra* n° 182.
674 Arrêt *Inspire Art*, pt. 105.
675 Arrêt *Inspire Art*, pt. 105.
676 Arrêt *Inspire Art*, pt. 138.
677 Arrêt *Inspire Art*, pt. 133 ; arrêt *Centros*, pt. 34 ; arrêt *Gebhard*, pt. 37 ; arrêt *Kraus*, pt. 34 et arrêt *Gebhard*, pt. 37.
678 Arrêt *Inspire Art*, pt. 142.
679 Arrêt *Inspire Art*, pt. 135.

créanciers nationaux n'auront pas choisi la société débitrice en pleine connaissance de cause[680] et (ii) les travailleurs nationaux de la société risquent fort de se retrouver dans une position moins favorable[681]. Ensuite, s'il est indéniable qu'un État membre est en droit de prendre des mesures spécifiques destinées à éviter que certains de leurs ressortissants ne recourent abusivement ou frauduleusement aux libertés fondamentales instaurées par le TFUE pour se soustraire abusivement à leur législation nationale[682], le fait pour un ressortissant de choisir de s'établir à titre principal dans l'État membre dont les règles lui paraissent les moins contraignantes et de créer ensuite des succursales dans d'autres États membres pour exercer l'essentiel ou la totalité de ses activités économiques ne suffit pas à démontrer un usage abusif ou frauduleux de la liberté d'établissement[683]. Dans un même ordre d'idées, si la préservation de la loyauté dans les transactions commerciales et l'efficacité des contrôles fiscaux sont bel et bien susceptibles de justifier une entrave à la liberté d'établissement, la Cour a considéré que ni la chambre de commerce, ni le gouvernement néerlandais n'étaient parvenus à démontrer que la loi sur les sociétés étrangères de pure forme remplissait les différents critères d'efficacité, de proportionnalité et de non-discrimination[684].

C. *Les enseignements de la Cour de justice appliqués aux scissions transfrontalières*

1. *Les scissions transfrontalières du point de vue de l'État d'accueil*

193. Une liberté de choix de la structure. Si la Cour de justice de l'Union européenne n'a certes pas encore eu à traiter du cas particulier d'une entrave à une opération de scission transfrontalière, sa jurisprudence en matière d'immigration fournit de précieuses indications quant au sort à réserver aux entraves dressées dans l'État d'accueil des sociétés bénéficiaires de l'opération. Ainsi, l'État membre des sociétés bénéficiaires ne pourra s'opposer à la réalisation de l'opération au seul motif que celle-ci permettrait d'éluder des règles nationales plus contraignantes[685]. En outre, on peut déduire de la jurisprudence de la Cour de justice[686] que les bénéficiaires de la liberté d'établissement disposent de la possibilité de choisir la structure qui est la plus adaptée à l'exercice de leur activité économique, ce qui emporte également le droit de modifier celle-ci en cours d'existence pour s'adapter aux conditions changeantes du marché[687].

680 *Voir en ce sens :* St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 63, n° 32 ; G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, « Der Gläubigerschutz im Gesellschaftsrecht nach Inspire Art », *RIW*, 2004, p. 14 et D. ZIMMER, « Wie es Euch gefällt? Offene Fragen nach dem Überseering-Urteil des EuGH », *op. cit.*, p. 63, n° 32.

681 St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, p. 63, n° 32 et G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, *op. cit.*, p. 14.

682 Arrêt *Inspire Art*, pt. 136 et arrêt *Centros*, pt. 24 et jurisprudence citée.

683 Arrêt *Inspire Art*, pts. 138 et 139 ; arrêt *Centros*, pts. 27 et 29 et arrêt *Segers*, pt. 16.

684 Arrêt *Inspire Art*, pt. 140.

685 Arrêt *Centros*, pt. 30.

686 Voir en ce sens : Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, pp. 74 et 78 qui considère en outre que la notion de « gestion d'entreprises » figurant à l'art. 49, § 2 du TFUE emporte le droit de modifier et de réorganiser une entreprise au gré de ses besoins.

687 Arrêt *Inspire Art*, pt. 138 ; arrêt *Centros*, pt. 27 ; arrêt *Gebhard*, pt. 37 et arrêt *Kraus*, pt. 32.

194. L'incidence du principe de non-discrimination. En outre, le principe de reconnaissance automatique de la capacité juridique des personnes morales existant valablement en vertu du droit de leur État d'origine[688] et le rejet concomitant de l'exigence de reconstitution en vertu du droit de l'État membre d'accueil[689] posés par la Cour de justice dans l'arrêt *Überseering* impliquent que lorsqu'un État d'accueil de siège réel reconnaît les scissions dans un contexte purement interne, le fait pour celui-ci d'imposer à la société scindée de procéder d'abord à sa reconstitution en vertu du droit national de l'État d'accueil au motif qu'une telle opération entraîne *de facto* un transfert du siège réel de la société scindée devrait être considéré comme une entrave à la liberté d'établissement[690].

2. *La justification d'une entrave à une scission transfrontalière dans l'État d'accueil*

195. La possibilité d'une entrave aux scissions transfrontalières dans l'État membre d'accueil. Une restriction à l'exercice de la liberté d'établissement par une société régulièrement constituée dans un autre État membre est susceptible d'être justifiée aux conditions développées par la Cour de justice dans l'arrêt *Centros*[691], c'est-à-dire que la mesure en question (i) soit non-discriminatoire, (ii) soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, (iii) soit propre à garantir l'objectif qu'elle poursuit et (iv) n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Cependant, une restriction imposée par un État membre d'accueil à une opération de scission transfrontalière ne pourra être tellement contraignante qu'elle équivaudrait à une négation pure et simple de la liberté d'établissement de la société scindée auquel cas elle ne pourrait être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général[692].

196. Une grande variété de raisons impérieuses d'intérêt général. Parmi les raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une telle entrave, on peut citer « la lutte contre le recours abusif à la liberté d'établissement [et] la préservation tant de l'efficacité des contrôles fiscaux que de la loyauté des transactions commerciales »[693], mais également « la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires, des salariés ou encore du fisc »[694].

197. L'incidence du principe de proportionnalité sur les régimes de protection des créanciers. En ce qui concerne la justification d'une éventuelle entrave à la liberté de se scinder par-delà les frontières en vue de garantir un certain niveau de protection aux créanciers, on peut déduire de la jurisprudence de la Cour de justice[695] que le principe de proportionnalité a pour conséquence que

688 Arrêt *Überseering*, pt. 95.
689 Arrêt *Überseering*, pt. 81.
690 Pour un raisonnement similaire en matière de fusions transfrontalières, voir : R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 33–35.
691 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 120.
692 Arrêt *Überseering*, pts. 92 et 93.
693 Arrêt *Inspire Art*, pt. 132.
694 Arrêt *Überseering*, pt. 92.
695 Arrêt *Inspire Art*, pts. 135 et 142.

l'accent devra être mis sur leur information et que les régimes plus intrusifs en termes de liberté d'établissement devront rester exceptionnels.

§4. La nécessité d'une analyse additionnelle de la jurisprudence en matière de liberté d'établissement

198. Une incertitude demeure. Si la balance semble certes pencher en faveur de la protection des scissions transfrontalières à la fois dans l'État membre de la société scindée que dans celui des sociétés bénéficiaires, force est de constater qu'une certaine incertitude demeure. Celle-ci, combinée aux formulations quelquefois sibyllines de la Cour[696], empêche de tirer des conséquences générales de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fusions transfrontalières pour d'autres formes de restructuration analysées sous l'angle de l'État d'origine sans courir le risque d'une extrapolation excessive. Il est donc indispensable de poursuivre l'analyse de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement.

SECTION 5. L'APPLICATION DES ENSEIGNEMENTS DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE TRANSFORMATION TRANSFRONTALIÈRE

§1. Introduction

199. Une autre « modalité particulière d'exercice de la liberté d'établissement ». Il découle de ce qui précède qu'un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fusions transfrontalières et de transfert de siège ne permet pas de résoudre l'intégralité des questions susceptibles de se poser à propos de la protection des scissions transfrontalières sous leurs diverses formes par la liberté d'établissement, notamment en matière d'entraves dressées dans l'État d'origine et d'opérations emportant la constitution de nouvelles sociétés. Pour tirer certaines conclusions additionnelles sur l'interaction entre la liberté d'établissement et les scissions transfrontalières (§ 4), il est par conséquent nécessaire d'examiner les enseignements de la Cour de justice à propos d'une autre « modalité particulière d'exercice de la liberté d'établissement », à savoir les transformations transfrontalières, et plus précisément, les arrêts *Vale* (§ 2) et *Polbud* (§ 3). Par transformation transfrontalière, on entend l' « opération par laquelle une société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une des formes juridiques de l'État membre de destination […] et transfère au moins son siège statutaire dans l'État membre de destination, tout en tout en conservant sa personnalité juridique »[697].

696 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 78.
697 Art. 86*ter*, 2) de la Directive Mobilité.

§2. L'arrêt *Vale*

A. *Les faits en cause*

200. La transformation transfrontalière de *Vale*. Dans cette affaire, la société à responsabilité limitée de droit italien VALE Construzioni Srl avait obtenu sa radiation du registre des sociétés de Rome suite à la notification de sa décision de transférer à la fois son siège statutaire et son activité commerciale en Hongrie. Conformément à ce qui avait été annoncé, elle a ensuite procédé à sa transformation en VALE Epítési kft, une société à responsabilité limitée de droit hongrois, tout en respectant les exigences nationales relatives à la constitution d'une telle société, notamment en matière de capital social, en vue de pouvoir demander son enregistrement auprès du tribunal de commerce de Budapest. Cette affaire impliquait ainsi *de facto* à la fois un transfert du siège statutaire et du siège réel de la société concernée de l'Italie vers la Hongrie. Le tribunal de commerce a cependant rejeté la demande d'enregistrement au motif qu'en vertu du droit des sociétés hongrois, les transformations ne sont possibles que dans des hypothèses internes et que par conséquent, une société constituée et enregistrée en Italie ne peut transférer son siège social en Hongrie, ni s'y faire enregistrer sous forme de société à responsabilité limitée. Cette décision a par après été confirmée par la cour d'appel régionale de Budapest et Vale s'est ensuite pourvue en cassation devant la Cour suprême de Hongrie qui s'est interrogée sur la compatibilité de la législation hongroise avec les articles 49 et 54 du TFUE[698]. Les faits en cause présentent par conséquent une certaine originalité dans la mesure où il s'agit de la première fois où la Cour de justice de l'Union européenne a eu à examiner l'hypothèse d'une transformation transfrontalière sous l'angle de l'État d'accueil[699].

B. *Les enseignements de la Cour*

1. *Les transformations transfrontalières constituent des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »*

201. Le champ d'application de la liberté d'établissement. Rejetant l'argumentation des gouvernements hongrois, allemand, britannique et irlandais, la Cour a commencé par préciser que le fait que l'opération en cause implique la constitution d'une nouvelle société selon le droit national de l'État membre d'accueil n'excluait pas l'opération en cause du champ d'application de la liberté d'établissement[700]. En effet, si en l'état actuel du droit communautaire, il ne fait aucun doute que la détermination du critère de rattachement en vertu duquel une société pourra être considérée à la fois comme valablement constituée et existante en vertu d'un droit national relève de la seule compétence

698 Arrêt *Vale*, pts. 9–16.
699 Arrêt *Vale*, pt. 15 et Av. gén. M. NIILO JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *VALE Építési kft*, 12 juillet 2012, C-378/10, EU:C:2011:841, pt. 3.
700 Arrêt *Vale*, pts. 24–26.

des États membres[701], la reconnaissance du fait que les transformations transfrontalières tombent dans le champ d'application de la liberté d'établissement n'est pas de nature à porter atteinte à cette faculté[702]. En d'autres termes, la Cour dissocie d'emblée la question de la détermination du facteur de rattachement permettant à une société d'être valablement constituée en vertu d'un ordre juridique national et, par conséquent, de bénéficier de la protection des articles 49 et 54 du TFUE de celle de la détermination de la modalité dont cette liberté d'établissement est exercée en pratique. Il s'ensuit qu'il convient de considérer qu'une opération de transformation transfrontalière constitue une des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement » à laquelle la Cour a fait référence dans l'arrêt *Sevic*[703].

202. La clarification de l'arrêt *Cartesio*. Cet enseignement, combiné au raisonnement de la Cour dans l'arrêt *Cartesio*[704], implique que les opérations de transformation transfrontalière intracommunautaires relèvent du champ d'application de la liberté d'établissement tant à l'égard de l'État d'origine que de celui de l'État membre d'accueil[705]. Cette interprétation foncièrement libérale est étayée par la volonté de la Cour de clarifier sa jurisprudence de l'arrêt *Cartesio* dans laquelle elle avait laissé planer un doute sur la faculté de l'État membre d'accueil de s'opposer d'office à une transformation transfrontalière, par opposition à l'État membre d'origine[706]. En effet, loin de conforter cette interprétation qui aurait pu constituer un frein significatif à la mobilité intracommunautaire, la Cour précise que son raisonnement selon lequel l'État membre de constitution ne saurait s'opposer à la transformation d'une société relevant de son droit national en une société soumise au droit d'un autre État membre « pour autant que ce droit le permette »[707] avait uniquement pour vocation de rappeler qu'une société n'a d'existence qu'à travers l'ordre juridique national dont elle relève, pour autant qu'elle en respecte les règles applicables à sa constitution et à son fonctionnement[708].

701 Arrêt *Daily Mail*, pt. 19 ; arrêt *Cartesio*, pt. 104 et arrêt *Vale*, pt. 27.
702 Arrêt *Vale*, pts. 27–30.
703 Arrêt *Sevic*, pt. 19.
704 Arrêt *Cartesio*, pt. 111.
705 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Das Vale-Urteil des EuGH: Die endgültige Bestätigung der Niederlassungsfreiheit als „Formwechselfreiheit" », *ZIP*, 2012, p. 1481 et HO-DAC, M., "Un pas supplémentaire en faveur de la mobilité européenne des sociétés : le droit au transfert de siège social avec changement de droit applicable", *Rev. Eur.*, 2012/3, p. 655.
706 Voir en faveur d'une telle interprétation : R. FRENZEL, « Immer noch keine Wegzugsfreiheit… », *op. cit.*, pp. 160 et 164 ; A. JOHNSTON et Ph. SYRPIS, « Regulatory competition in European company law after Cartesio », *E.L. Rev.*, 2009, 34(3), p. 387 et W. PAEFGEN, « "Cartesio": Niederlassungsfreiheit minderer Güte », *WM*, 2009, p. 532. *Contra* : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Sitzverlegungen… », *op. cit.*, pp. 759 et s. et Chr. TEICHMANN, « Cartesio: die Freiheit zum formwechselnden Wegzug », *ZIP*, 2009, p. 402.
707 Arrêt *Cartesio*, pt. 112.
708 Arrêt *Vale*, pt. 32.

2. *La reconnaissance de l'existence d'une entrave à la liberté d'établissement et son éventuelle justification*

203. L'application du principe de non-discrimination. Fidèle à sa jurisprudence antérieure[709], la Cour de justice a ensuite considéré qu'une différence de traitement entre des sociétés en fonction de la nature interne ou transfrontalière de l'opération qui s'avère être de nature à dissuader les sociétés d'exercer leur liberté d'établissement constitue une restriction en principe interdite[710]. Étant donné que la réglementation hongroise traite les sociétés différemment en fonction de la nature interne ou transfrontalière de la transformation, elle est en principe contraire aux articles 49 et 54 du TFUE[711].

204. La justification possible des entraves. Si tout comme dans l'arrêt *Sevic*[712], la Cour de justice a considéré que les transformations transfrontalières engendraient des « *problèmes spécifiques* » liés à l'application consécutive de deux droits nationaux distincts, elle a également insisté sur le fait que l'absence de règles de droit dérivé de l'Union européenne ne saurait justifier une discrimination sur la base de la nature interne ou transfrontalière de l'opération[713]. En revanche, la Cour a confirmé sa jurisprudence antérieure[714] en précisant qu'une entrave à la liberté d'établissement est susceptible d'être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général au nombre desquelles on compte, à titre d'illustration, « la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des salariés ainsi que la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux et de la loyauté des transactions commerciales »[715] pour autant que la mesure restrictive en cause soit propre à garantir l'objectif poursuivi et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.[716] Dans le cas présent, il était clair qu'une interdiction générale des transformations transfrontalières violait en tout état de cause le principe de proportionnalité[717] et ne pouvait par conséquent être justifiée.

3. *Une règle de conflit de lois*

205. L'application des principes d'équivalence et d'effectivité. Une des grandes originalités de cet arrêt est que la Cour s'est prononcée sur le droit applicable à une transformation transfrontalière[718], alors qu'elle évitait dans tous les autres arrêts, y compris l'arrêt *Sevic*, de se prononcer sur ces points dans la mesure où cela dépassait systématiquement le cadre des questions préjudicielles qui lui étaient posées. Partant du constat qu' (i) en l'absence de normes de droit

709 Arrêt *Sevic*, pts. 22 et 23.
710 Arrêt *Vale*, pt. 36.
711 Arrêt *Vale*, pt. 36.
712 Arrêt *Sevic*, pt. 27.
713 Arrêt *Vale*, pt. 37.
714 Arrêt *Sevic*, pts. 27 et 28.
715 Arrêt *Vale*, pt. 39.
716 Arrêt *Vale*, pt. 39.
717 Arrêt *Vale*, pt. 40.
718 Voir en ce sens : S. ZWIRLEIN, « Grenzüberschreitender Formwechsel – europarechtlich veranlasste Substitution im UmwG – Zugleich Besprechung von KG, Beschluss v. 21.3.2016, 22 W 64/15 », *ZGR*, 2017, p. 119.

dérivé de l'Union, il convient de s'en remettre aux droits nationaux impliqués[719] et (ii) les articles 49 et 54 du TFUE ne permettent pas de déterminer une procédure précise à suivre en cas de transformation transfrontalière, la Cour précise que, conformément à sa jurisprudence dans d'autres domaines tels que la répétition de l'indu[720], le droit administratif[721], la responsabilité non contractuelle d'un État membre[722] ou encore l'exigence d'une attestation aux fins d'un avantage fiscal[723], le droit interne ainsi appliqué devra respecter à la fois le principe d'équivalence et le principe d'effectivité[724]. Le principe d'équivalence implique que les dispositions nationales régissant les transformations transfrontalières ne peuvent être moins favorables aux justiciables que celles régissant une transformation interne[725]. En d'autres termes, les opérations transfrontalières ne doivent pas nécessairement être traitées plus favorablement que les opérations internes, mais elles ne peuvent en tout cas être défavorisées par rapport à celles-ci[726]. Le principe d'effectivité impose aux États membres de ne pas rendre les transformations transfrontalières impossibles en pratique ou excessivement difficiles par le biais de leur législation nationale[727].

206. La marge de manœuvre de l'État d'accueil. Forte de cette analyse, la Cour de justice apporte également un certain nombre de précisions sur les parties de la procédure de transformation transfrontalière relevant de l'État d'accueil. En effet, comme les sociétés ne sont que les créatures des États membres qui en déterminent librement tant la constitution que le fonctionnement[728], les dispositions nationales régissant notamment (i) l'exigence d'un bilan et d'un inventaire d'actifs[729], (ii) l'exigence d'une stricte continuité juridique et économique entre la société pré-transformation et la société post-transformation[730] et (iii) la procédure d'enregistrement et, notamment, les preuves à apporter par la société en question que les conditions posées par l'État membre d'origine et compatibles avec les dispositions du TFUE ont bien été remplies[731] relèvent de l'État membre d'accueil. Bien que la Cour n'ait pas repris les conditions relatives au capital social, aux associés et au contenu des statuts mentionnés par l'Avocat

719 Arrêt *Vale*, pt. 43.
720 C.J.C.E., arrêt *Ministero delle Finanze c. IN. CO. GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl, Camed Srl, Pomezia Progetti Appalti Srl (PPA), Edilcam Srl, A. Cecchini & C. Srl, EMO Srl, Emoda Srl, Sappesi Srl, Ing. Luigi Martini Srl, Giacomo Srl et Mafar Srl*, 22 octobre 1998, C-10/97 à C-22/97, EU:C:1998:498, pt. 54.
721 C.J.C.E., arrêt *J. van der Weerd et autres (C-222/05), H. de Rooy sr. et H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van't Oever et autres (C-224/05) et B. J. van Middendorp (C-225/05) c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit*, 7 juin 2007, C-222/05 à C-225/05, EU:C:2007:318, pt. 28.
722 C.J.C.E., gde ch., arrêt *Danske Slagterier c. Bundesrepublik Deutschland*, 24 mars 2009, C-445/06, EU:C:2009:178, pt. 31.
723 C.J., arrêt *Wienand Meilicke et autres contre Finanzamt Bonn-Innenstadt*, 30 juin 2011, C-262/09, EU:C:2011:438, pt. 55.
724 Arrêt *Vale*, pt. 48.
725 Arrêt *Vale*, pt. 48.
726 Arrêt *Vale*, pt. 54.
727 Arrêt *Vale*, pt. 48.
728 Arrêt *Vale*, pt. 51 ; arrêt *Cartesio*, pt. 104 et arrêt *Daily Mail*, pt. 10.
729 Arrêt *Vale*, pt. 52.
730 Arrêt *Vale*, pt. 55.
731 Arrêt *Vale*, pt. 59.

général[732], il n'y a aucune raison de penser que celles-ci ne devraient pas également trouver à s'appliquer puisqu'elles relèvent également des normes de l'État d'accueil régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés.

207. La reconnaissance des documents émanant d'une autorité étrangère. De manière très concrète, la Cour de justice a également eu à se prononcer sur la pertinence que l'État d'accueil doit accorder aux documents émis par une autorité nationale de l'État membre d'origine et établissant en substance que les formalités requises en vertu du droit de l'État membre d'origine ont bien été accomplies sans interruption de la personnalité juridique de la société en question[733]. À cet égard, tout en reconnaissant que l'examen réalisé par l'autorité nationale compétente de l'État membre d'origine constitue « *le lien indispensable* » entre les deux procédures d'enregistrement, la Cour a précisé qu'en l'absence de norme de droit dérivé en la matière, c'est le droit de l'État membre d'accueil qui déterminera les éléments de preuve requis en la matière[734] qui pourront, à titre d'illustration, inclure des traductions ou des documents apostillés[735].

208. L'ombre d'une règle générale de droit international privé. Avec le bénéfice d'un regard *a posteriori*, on voit déjà se dessiner avec une certaine netteté la règle de droit international privé consacrée par la Directive Mobilité en matière de transformations transfrontalières et qui veut que (i) les procédures et formalités à respecter dans le cadre d'une transformation transfrontalière en vue de l'obtention du certificat préalable à l'opération soient régies par le droit de l'État membre de départ alors que (ii) les procédures et formalités à remplir après la réception du certificat préalable relèveront du droit de l'État membre d'accueil[736]. Cette interprétation est confortée par la confirmation par la Cour de justice que le principe d'effectivité impose à l'État membre d'accueil de « tenir dûment compte » des documents émanant des autorités de l'État d'origine et établissant que les conditions applicables à la transformation transfrontalière en vertu du droit de cet État membre ont bien été remplies[737]. En effet, au-delà d'un simple principe de reconnaissance mutuelle, la Cour de justice sous-entend que la partie de la procédure jusqu'à l'émission des documents probants par l'autorité de l'État membre d'origine sera soumise au droit interne de celui-ci, tandis que la suite de la procédure sera pour sa part soumise au droit de l'État membre de destination. C'est donc l'approche prônée par la *Vereinigungstheorie*[738] qui s'en trouve dès lors consacrée[739]. À titre de comparaison, cette approche fut également retenue dès le début à l'égard des fusions transfrontalières dans la Directive Sociétés[740] et la meilleure illustra-

732 Av. gén. M. NIILO JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *VALE Építési kft*, 12 juillet 2012, C-378/10, EU:C:2011:841, pt. 75. Voir également à ce sujet : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Das Vale-Urteil des EuGH… », *op. cit.*, p. 1488.
733 Arrêt *Vale*, pt. 58.
734 Arrêt *Vale*, pt. 59.
735 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Das Vale-Urteil des EuGH… », *op. cit.*, p. 1490.
736 Art. 86*quater* de la Directive Mobilité.
737 Arrêt *Vale*, pt. 61.
738 Voir *infra* n°s 271 à 281 pour une définition ainsi qu'une analyse des limites de cette théorie.
739 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Das Vale-Urteil des EuGH… », *op. cit.*, p. 1490.
740 À ce sujet voir *infra* n° 296.

tion se trouve au niveau de la répartition des tâches dans le cadre du double contrôle de légalité[741]. En effet, dans le cadre de ce dernier, la conformité de la partie de la procédure à la législation nationale pour chacune des sociétés impliquées sera vérifiée distributivement par un notaire, un tribunal ou toute autre autorité compétente désignée par chaque État membre concerné[742] et il ne sera en principe pas loisible à l'autorité nationale de l'État membre de la société issue de la fusion et en charge du contrôle de légalité[743] de remettre en cause ce qui a été établi dans le certificat de conformité par l'autorité nationale compétente pour l'État membre de la société absorbée[744].

4. *Un* obiter dictum *à la portée incertaine*

209. L'exigence d'une implantation réelle. De manière assez inattendue, la Cour de justice, se référant à sa jurisprudence antérieure en matière fiscale[745], a indiqué dans un *obiter dictum* à la portée incertaine que « la notion d'établissement, au sens des dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement, implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable dans l'État membre d'accueil pour une durée indéterminée »[746], celle-ci supposant par conséquent « une implantation réelle de la société concernée dans cet État et l'exercice d'une activité économique effective dans celui-ci »[747]. Cette précision pourrait être considérée comme une rupture par la Cour avec sa jurisprudence antérieure notamment dans les arrêts *Centros, Überseering* et *Inspire Art* où elle avait justement fait fi de l'exigence d'un siège réel[748]. Il n'est dès lors pas étonnant de constater que cela ait incité un grand nombre d'auteurs à considérer que le transfert isolé du seul siège statutaire ne devait pas être couvert par la liberté d'établissement[749].

741 Art. 127 (certificat préalable à la fusion) et 128 (contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière) de la Directive Sociétés. Pour une étude détaillée du contrôle du processus de scission transfrontalière, voir *infra* n°s 642 à 661.

742 Art. 127, § 1er de la Directive Sociétés.

743 Pour une étude détaillée de cette étape du processus de scission transfrontalière, voir *infra* n°s 657 à 660.

744 À ce sujet, voir *infra* n° 657.

745 Arrêt *Vale*, pt. 34 et C.J.C.E., gde ch., arrêt *Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd c. Commissioners of Inland Revenue*, 12 septembre 2006, C-196/04, EU:C:2006:544, (ci-après l' « **arrêt *Cadbury Schweppes*** »), pt. 54.

746 Arrêt *Vale*, pt. 34, *in initio*.

747 Arrêt *Vale*, pt. 34, *in fine*.

748 Voir en ce sens : L. BÖTTCHER et J. KRAFT, « Grenzüberschreitender Formwechsel und tatsächliche Sitzverlegung – Die Entscheidung VALE des EuGH », *NJW*, 2012, p. 2701 ; E.-M. KIENINGER, « Niederlassungsfreiheit als Freiheit der nachträglichen Rechtswahl – Die Polbud Entscheidung des EuGH », *NJW*, 2017, p. 3626 ; D. KÖNIG et J. BORMANN, « „Genuine Link"und freie Rechtsformwahl im Binnenmarkt – Trendwende bei der Anerkennung von „Scheinauslandsgesellschaften"du rch die VALE-Entscheidung des EuGH? », *NZG*, 2012, p. 1241 et G. H. ROTH, « Das Ende der Briefkastengründung? – Vale contra Centros », *ZIP*, 2012, p. 1744.

749 Voir en ce sens : P. KINDLER, « Der reale Niederlassungsbegriff nach dem VALE-Urteil des EuGH », *EuZW*, 2012, pp. 891 et 892 ; D. KÖNIG et J. BORMANN, *ibidem*, p. 1243 ; St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 68, n° 41 ; O. MÖRSDORF et Chr. JOPEN, « Grenzüberschreitender Formwechsel einer Gesellschaft („Vale") », *ZIP*, 2012, p. 1399 et B. SEIBOLD, « Der grenzüberschreitende Herein-Formwechsel in eine deutsche GmbH – Geht doch ! », *ZIP*, 2017, p. 457.

210. Une source d'incertitudes pour les scissions transfrontalières. Du point de vue des scissions transfrontalières, cet *obiter dictum* soulève des interrogations quant à la possible protection par la liberté d'établissement de certaines scissions ne s'accompagnant pas d'un transfert du siège réel ou de l'activité économique sous-jacente hors des frontières de l'État membre de la société scindée. Ainsi, dans l'hypothèse d'une opération de scission partielle par constitution de nouvelle société située dans un État membre appliquant la théorie de l'incorporation, tout en maintenant l'activité économique effective dans l'État membre de la société scindée et en ne transférant que des dettes et de l'argent liquide, il n'y a pas nécessairement de transfert concomitant du siège réel et peu ou prou d'exercice d'activité économique dans l'État membre d'accueil. En se basant sur une interprétation large de l'*obiter dictum* de la Cour de justice dans l'arrêt *Vale*, un État membre pourrait arguer qu'une telle opération ne relève pas du champ d'application *ratione materiae* de la liberté d'établissement et qu'il lui est par conséquent loisible de s'y opposer sans devoir se plier aux exigences du « *Gebhard test* »[750]. En outre, une telle conception impliquerait pour chaque scission transfrontalière de vérifier si celle-ci s'accompagne ou non d'une « implantation réelle » ainsi que de l' « exercice effectif d'une activité économique » dans l'État membre des sociétés bénéficiaires en se basant sur des éléments purement factuels. Or, un tel exercice ne manquerait pas de nuire sensiblement à la sécurité juridique d'une telle opération, avec pour conséquence que les acteurs économiques auront tendance à recourir à d'autres techniques de restructurations potentiellement plus longues et plus coûteuses, mais mieux encadrées juridiquement[751].

§ 3. L'arrêt *Polbud*

A. *Les faits en cause*

211. La transformation transfrontalière de *Polbud*. Le 30 septembre 2011, l'assemblée générale des associés de Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., une société à responsabilité limitée de droit polonais, a décidé de transférer le siège social de la société de la Pologne vers le Grand-Duché de Luxembourg, sans toutefois prévoir explicitement de transfert concomitant ni du lieu de la direction des affaires de la société, ni du lieu d'exercice effectif de son activité économique. Suite à cette résolution, la société a fait inscrire le 26 octobre 2011 l'ouverture d'une procédure de liquidation et la nomination d'un liquidateur au registre de commerce compétent conformément au droit polonais applicable. Le 27 mai 2013 en Pologne et le 28 mai 2013 au Luxembourg, l'assemblée générale a mis en œuvre le transfert en adoptant une résolution en vue notamment de (i) transférer le siège statutaire de la Pologne au Luxembourg, (ii) adopter la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois renommée Consoil Geotechnik S. à r.l. et (iii) mettre les statuts de celle-ci

750 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.

751 Pour un examen détaillé des autres méthodes permettant d'aboutir à un résultat similaire à celui d'une scission transfrontalière, voir *infra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 2, Section 2, § 2.

en conformité avec les exigences du droit luxembourgeois[752]. Moins d'un mois après, la société a déposé une demande de radiation auprès du tribunal en charge de la tenue du registre de commerce polonais. Ce dernier a ensuite invité la société à lui remettre un certain nombre de documents en lien avec sa liquidation, tels que les comptes de liquidation et les résolutions de l'assemblée générale se prononçant sur la clôture de la liquidation. La société n'ayant aucunement eu l'intention de mettre fin à ses activités ou d'être dissoute, mais souhaitant au contraire uniquement poursuivre son existence en tant que société de droit luxembourgeois, elle a indiqué au tribunal qu'elle n'estimait pas devoir fournir de tels documents. Sur ce, le tribunal a rejeté la demande de radiation, et cette décision a été confirmée en deuxième instance par les juridictions polonaises. La société s'est ensuite pourvue en cassation et la Cour suprême de Pologne a posé trois questions préjudicielles. Si les deux premières avaient davantage trait à la question de la conformité du droit polonais aux principes de la liberté d'établissement, la troisième avait une portée beaucoup plus fondamentale[753] dans la mesure où elle visait directement la question de savoir si une société qui déplace son siège statutaire dans un autre État membre en vue de sa transformation en une société relevant du droit de cet autre État membre, sans toutefois déplacer son siège réel qui restera dans l'État d'origine, devait bénéficier de la protection des articles 49 et 54 du TFUE[754].

B. *La décision de la Cour*

212. La clarification de l'arrêt *Vale*. Après avoir rappelé que conformément à sa jurisprudence antérieure[755], en l'absence de réglementation européenne à cet égard, chaque État membre demeurait libre de choisir entre le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement comme lien de rattachement qui est exigé d'une société pour que celle-ci puisse être considérée comme constituée selon sa législation nationale[756], la Cour de justice s'est basée sur sa décision dans l'arrêt *Centros*[757] pour considérer que l'opération par laquelle une société constituée selon le droit d'un État membre se transforme en une société relevant du droit d'un autre État membre en respectant le critère de rattachement imposé par ce dernier tombait dans le champ d'application de la liberté d'établissement, peu important à cet égard que l'essentiel ou la totalité des activités économiques de cette société demeure dans l'État

752 Minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of CONSOIL GEOTECHNIK S. à r.l. of May 28, 2013, disponible sur https://www.lbr.lu (19/04/2018), pp. 2 et 3.

753 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 2227.

754 Arrêt *Polbud*, pts. 8–18.

755 Arrêt *Vale*, pt. 29 ; arrêt *National Grid Indus*, pt. 27 et arrêt *Cartesio*, pt. 110.

756 Arrêt *Polbud*, pt. 43.

757 Dans son arrêt *Centros*, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la liberté d'établissement s'opposait à ce qu' « un État membre refuse l'immatriculation d'une succursale d'une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre dans lequel elle a son siège sans y exercer d'activités commerciales lorsque la succursale est destinée à permettre à la société en cause d'exercer l'ensemble de son activité dans l'État où cette succursale sera constituée, en évitant d'y constituer une société et en éludant ainsi l'application des règles de constitution des sociétés qui y sont plus contraignantes en matière de libération d'un capital social minimal ». Voir arrêt *Centros*, pt. 39.

membre d'origine[758]. Réaffirmant ensuite le principe de non-discrimination des opérations de transformation transfrontalière par rapport aux opérations de transformation interne déjà présent dans l'arrêt *Vale*[759] en vertu duquel il n'est pas loisible aux États membres d'imposer à une société souhaitant procéder à une transformation transfrontalière des conditions plus restrictives que celles qui régissent ce type d'opération en interne[760], elle a finalement balayé les arguments des gouvernements polonais et autrichiens[761] ainsi que ceux de l'Avocate générale[762], en répondant à la troisième question préjudicielle que la liberté d'établissement prévue par les articles 49 et 54 du TFUE s'appliquait au transfert isolé du siège statutaire d'une société constituée en vertu du droit d'un État membre vers un autre État membre, en vue de sa transformation conformément au droit de l'État d'accueil en une société relevant de ce droit, sans que cette opération ne doive nécessairement s'accompagner d'un transfert concomitant du siège réel[763]. En d'autres termes, la question de la possibilité d'un transfert isolé du siège statutaire dans le cadre d'une transformation transfrontalière en une forme de société relevant du droit de l'État d'accueil dépendra du facteur de rattachement adopté par ce dernier.

§4. Les enseignements de la Cour de justice appliqués aux scissions transfrontalières

213. Plan du § 4. À la suite de cette analyse de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transformations transfrontalières, pas moins de sept enseignements distincts peuvent être tirés à l'égard des scissions transfrontalières. Les cinq premiers ont trait à l'incidence générale de la jurisprudence de la Cour de justice sur la mobilité des sociétés au sein de l'Union européenne (A), à l'incidence des principes d'effectivité et d'équivalence (B), à l'impact de cette jurisprudence sur les règles de droit international privé applicables à une opération transfrontalière (C), à l'incidence de l'absence d'une norme de droit dérivé (D) et aux limites applicables à la liberté de procéder à une scission transfrontalière (E). Les deux derniers enseignements concerneront le cas particulier des scissions de sociétés de participation financière (F), ainsi que celui des scissions par constitution de nouvelles sociétés (G).

758 Arrêt *Polbud*, pt. 38.
759 Arrêt *Vale*, pt. 36.
760 Arrêt *Polbud*, pt. 43.
761 Arrêt *Polbud*, pts. 30 et 31.
762 L'Avocate générale, Mme Juliane Kokott, avait considéré qu'une opération de transformation transfrontalière ne pouvait être protégée par la liberté d'établissement qu'à condition « qu'il existe ou que soit envisagée une implantation réelle de cette société dans l'autre État membre aux fins de l'exercice d'une activité économique effective ». En d'autres termes, elle s'opposait à une transformation transfrontalière par le biais d'un transfert isolé de siège statutaire dans le seul but de bénéficier d'une législation plus favorable. *Voir* Av. Gén., J. KOKOTT, concl. préc. C.J., gde ch., arrêt *Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., en liquidation*, 4 mai 2017, C-106/16, EU:C:2017:351, pt. 43.
763 Arrêt *Polbud*, pt. 44.

A. *Une incidence générale sur la mobilité des sociétés au sein de l'Union européenne*

214. Le renforcement de la concurrence réglementaire. Par l'arrêt *Polbud* qui constitue la suite logique des enseignements de la Cour dans l'arrêt *Vale*[764] et de *l'obiter dictum* dans l'arrêt *Cartesio*[765], la Cour de justice, avec tout le caractère solennel qui découle d'une décision de la grande chambre, a mis fin à une controverse doctrinale sur la question de la protection du transfert isolé du siège statutaire par la liberté d'établissement. Ainsi, les auteurs ayant avancé que l'exigence posée par la Cour de justice d'un « exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable dans l'État membre d'accueil pour une durée indéterminée »[766] dans l'arrêt *Vale* s'opposait par définition à la protection par la liberté d'établissement du transfert isolé du siège statutaire[767] se sont vus déboutés, et ceux qui considéraient que les premiers auteurs donnaient une portée trop grande à l'exigence posée par la Cour dans l'arrêt *Vale* dans la mesure où celle-ci avait simplement voulu se référer de manière limitée à sa jurisprudence antérieure dans l'arrêt *Cadbury Schweppes*[768] qui concernait plus précisément la justification d'une restriction à la liberté d'établissement en vue d'éviter certaines pratiques abusives en matière fiscale[769], ont obtenu raison. Au-delà de la résolution de cette controverse, cet

764 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 2225.

765 Dans son *obiter dictum*, la Cour de justice, après avoir considéré que le principe de la libre détermination du facteur de rattachement par les États membres impliquait qu'un État membre pouvait librement s'opposer à ce qu'une société relevant de son droit national conserve cette qualité en cas de transfert de siège sur le territoire d'un autre État membre, avait insisté sur le fait que ce cas devait être clairement distingué du cas du « déplacement d'une société relevant d'un État membre vers un autre État membre avec changement du droit national applicable, la société se transformant en une forme de société relevant du droit national de l'État membre dans lequel elle se déplace ». Voir arrêt *Cartesio*, pts. 110 et 111.

766 Arrêt *Vale*, pt. 34.

767 Voir en ce sens : C. GERNER – BEUERLE, M. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, « Cross-border reincorporations in the European Union, the case for comprehensive harmonisation », *Journal of Corporate Law Studies*, 2018, vol. 18, p. 11 ; A. KHAN, *op. cit.*, p. 375 ; E.-M. KIENINGER, « Niederlassungsfreiheit als Freiheit der nachträglichen Rechtswahl », *op. cit.*, p. 3624 ; P. KINDLER, « Unternehmen im Binnenmarkt – Transparenz und Nachhaltigkeit », *DNotZ - Sonderheft*, 2016, pp. 93 et s. ; P. KINDLER, « Der reale Niederlassungsbegriff… », *op. cit.*, pp. 891 et 892 ; D. KÖNIG et J. BORMANN, *op. cit.*, p. 1243 ; M. MENJUCQ, « La Cour de justice libéralise la transformation transfrontalière de sociétés », *Sem. Jur.*, n° 3, 18 janvier 2018, disponible sur http://www.lexisnexis.com (31/05/2018), p. 8, n° 22 ; O. MÖRSDORF, « Nun also doch! – Die überraschende Umdeutung der Niederlassungsfreiheit zur Rechtswahlsfreiheit durch den EuGH im Urteil Polbud », *ZIP*, 2017, p. 2382 ; O. MÖRSDORF et Chr. JOPEN, *op. cit.*, p. 1399 ; Kr. OPLUSTIL et P. SIKORA, « Grenzüberschreitende Verlegung des statutarischen Gesellschaftssitzes aus der Perspektive des Gründungstaates: Vorlagefragen des polnischen Obersten Gerichts an den EuGH », *EWS*, 2017, p. 141 ; G. H. ROTH, « Das Ende der Briefkastengründung? – Vale contra Centros », *ZIP*, 2012, pp. 1744 et 1745 ; A. SCHALL, « EuGH bestätigt grenzüberschreitenden Rechtsformwechsel in der EU! », *DB*, 2017, p. M4 ; E. SCHOLLMEYER, « Von der Niederlassungsfreiheit zur Rechtswahlfreiheit? – Das „Polbud"-Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 25. Oktober 2017 », *ZGR*, 2018, p. 190 et J. VERMEYLEN, *op. cit.*, p. 278.

768 Arrêt *Vale*, pt. 34 et arrêt *Cadbury Schweppes*, pt. 54.

769 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, pp. 2227 et 2228 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Das Vale-Urteil des EuGH… », *op. cit.*, pp. 1486 et 1487 ; C. BEHME, « Der grenzüberschreitende Formwechsel von Gesellschaften nach Cartesio und Vale », *NZG*, 2012, p. 939 et T. FRANZ, « Grenzüberschreitende Sitzverlegung und Niederlassungsfreiheit – eine systematische Betrachtung offener und geklärter Fragen », *EuZW*, 2016, p. 931.

arrêt est de nature à faciliter la mobilité des personnes morales au sein du marché intérieur. En outre, il va très certainement renforcer le phénomène de concurrence réglementaire entre les différents États membres[770], la Cour ayant souligné à deux reprises dans son arrêt que le recours à la liberté d'établissement dans le seul but de bénéficier d'une législation nationale plus favorable n'était pas en soi constitutif d'un abus[771]. Cet arrêt, accueilli de manière critique par certains[772] et favorablement par d'autres[773], n'est en soi que le résultat logique de l'addition (i) du principe d'équivalence des différents critères de rattachement permettant à un État membre de déterminer librement à partir de quand une société relève de son droit national et, par conséquent, peut bénéficier de la liberté d'établissement[774], (ii) de la conception de la liberté

770 I. CORBISIER, « Arrêt « Polbud » : la consécration de la *possibilité* d'un principe inconditionnel de libre mobilité », *J.D.E.*, 2018/4, p. 136 ; I. CORBISIER, « L'arrêt Polbud de la C.J.U.E. ou le Luxembourg à la croisée des chemins – Maintien d'un critère de rattachement appliqué de manière ambiguë ou choix franc d'un libéralisme rendu possible par la Cour de justice ? », *J.T.L.*, 5 avril 2018, n° 56, p. 35, n° 12 ; E.-M. KIENINGER, « Niederlassungsfreiheit als Freiheit der nachträglichen Rechtswahl », *op. cit.*, p. 3624 ; J. MEEUSEN, « Het Polbud-arrest van het Hof van Justitie : Europese vennootschapsmobiliteit op nieuwe wegen », *RW*, 16 décembre 2017, p. 602 ; Th. WACHTER, « Verstoß einer die Sitzverlegung von vorheriger Auflösung der Gesellschaft machender innerstaatlicher Regelung gegen die Niederlassungsfreiheit – Polbud », *NZG*, 2017, p. 1312 et H. WICKE, « EuGH : Grenzüberschreitender Formwechsel kann ohne Verlegung des Verwaltungssitzes in Zuzugstaat zulässig sein », *DStR*, 2017, p. 2691.

771 Arrêt *Polbud*, pts. 40 et 62.

772 Voir à titre d'illustration : P. KINDLER, « Unternehmensmobilität nach „Polbud": Der grenzüberschreitende Formwechsel in Gestaltungspraxis und Rechtspolitik », *NZG*, 2018, pp. 3, 4 et 7 qui considère que la protection du transfert isolé du siège statutaire est (i) contraire à l'esprit et à l'objectif de la liberté d'établissement qui est destinée à permettre aux acteurs économiques de choisir le lieu d'établissement de leurs activités économiques, pas de choisir librement le droit qui leur sera applicable et (ii) incohérente avec la solution prévue par l'article 7 du Règlement sur la Société européenne qui impose aux sociétés européennes d'avoir leur siège statutaire et leur principal établissement au sein du même État membre ; M. MENJUCQ, « La Cour de justice libéralise la transformation transfrontalière de sociétés », *op. cit.*, p. 9 qui parle d'une « libéralisation à tous crin de la transformation transfrontalière » ; O. MÖRSDORF, « Nun also doch!… », *op. cit.*, pp. 2387 et 2386 qui considère que l'arrêt *Polbud* est un véritable *overruling* de la jurisprudence antérieure de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement et qui laisse sous-entendre que la Cour de justice, en interprétant la liberté d'établissement comme une liberté de choix du droit applicable, a outrepassé ses compétences ; P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitender Formwechsel durch isolierte Verlegung des Satzungssitzes – EuGH präzisiert den Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit », *EuZW*, 2017, p. 893 qui voit également une contradiction avec l'esprit de la liberté d'établissement ; Chr. TEICHMANN, « Der Fall „Polbud" : Formwechsel in die Briefkastengesellschaft », *GmbHR*, 2017, p. R357 qui dénonce le fait que la Cour de justice autorise explicitement une forme de *cherry-picking* (« *Rosinenpicken* ») en matière de droit des sociétés ; Chr. TEICHMANN et R. KNAIER qui qualifient le classement dogmatique de la décision de la Cour de justice de « *casse-tête* » et Th. WACHTER, « Verstoß einer die Sitzverlegung von vorheriger Auflösung der Gesellschaft machender innerstaatlicher Regelung gegen die Niederlassungsfreiheit – Polbud », *op. cit.*, p. 1312 qui dénonce la possibilité donnée aux sociétés de contourner purement et simplement une législation nationale par le biais d'une « boîte aux lettres » étrangère.

773 I. BARSAN, « Que reste-t-il du critère du siège réel après l'arrêt Polbud ? », *Droit des sociétés*, n° 3, mars 2018, disponible sur http://www.lexisnexis.com (31/05/2018), p. 8 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 2228 ; I. CORBISIER, « Arrêt « Polbud »… », *op. cit.*, p. 137 ; I. CORBISIER, « L'arrêt Polbud de la C.J.U.E. ou le Luxembourg à la croisée des chemins… », *op. cit.*, p. 36, n° 14 ; M. HO-DAC, « L'affirmation d'un droit au transfert intra-européen du siège statutaire avec changement de loi applicable : une nouvelle donne pour la reconnaissance mutuelle des sociétés dans l'Union », *R.A.E.*, 2017/4, pp. 730–737 et Chr. KUMPAN et Ph. PAUSCHLINGER, « Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2016 », *EuZW – Sonderausgabe*, 2017, p. 4 et A. SCHALL, *op. cit.*, p. M5.

774 Arrêt *Polbud*, pt. 40 ; arrêt *Vale*, pt. 32 ; arrêt *Cartesio*, pt. 110 et arrêt *Daily Mail*, pts. 19 à 21.

d'établissement prônée par la Cour de justice selon laquelle l'exercice d'une activité économique effective n'est pas une condition pour tomber dans le champ d'application des articles 49 et 54 du TFUE[775] et (iii) du rejet de toute présomption d'abus en cas d'utilisation de la liberté d'établissement dans le seul but de bénéficier d'une législation nationale plus favorable posée dès l'arrêt *Centros*[776]. Au-delà de ce premier argument, plusieurs auteurs[777] ont d'ores et déjà relevé qu'imposer que tout transfert de siège statutaire s'accompagne nécessairement d'un transfert concomitant du siège réel serait dénué d'intérêt puisque la jurisprudence antérieure de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement[778] permet de transférer par après le siège réel isolément dans l'État d'origine et d'exercer ainsi l'intégralité de l'activité économique de l'entreprise au moyen d'une succursale. Il n'en demeure pas moins que cet arrêt marque le début d'une nouvelle ère de mobilité des sociétés au sein du marché intérieur axée autour d'une reconnaissance mutuelle des personnes morales où les États membres attachés à la théorie du siège réel risquent d'être fortement désavantagés[779]. Ceci n'a pas échappé au législateur belge qui a fait référence directement à l'arrêt *Polbud* dans l'exposé des motifs du projet de loi (i) introduisant le Code des sociétés et associations[780] dans lequel figure une procédure spécifique pour les scissions[781] et les transformations transfrontalières[782] et (ii) modifiant le Code de droit international privé par l'abandon de la théorie du siège réel à laquelle le législateur belge était attaché depuis plus de 150 ans[783].

B. *L'incidence des principes d'effectivité et d'équivalence*

215. Une extension implicite aux scissions transfrontalières. Contrairement à l'arrêt *Sevic*, les enseignements de la Cour de justice en matière de transformations transfrontalières présentent l'avantage de concerner à la fois des entraves dans l'État de destination et des entraves dans l'État d'origine. Si on part du principe que les scissions transfrontalières constituent bel et bien

775 I. BARSAN, *op. cit.*, p. 5 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Das Vale-Urteil des EuGH… », *op. cit.*, pp. 1486 et 1487 ; C. BEHME, *op. cit.*, p. 939 et J. HUSHAHN, « Der isolierte grenzüberschreitende Formwechsel – Zugleich Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 25.10.2017 in der Rechtssache Polbud », *RNotZ*, 2018, p. 24.

776 Arrêt *Centros*, pt. 27.

777 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, pp. 2230 et 2231 et I. CORBISIER, « Arrêt « Polbud » … », *op. cit.*, p. 137.

778 Arrêt *Inspire Art*, pt. 110 ; arrêt *Überseering*, pts. 94 et 95 et arrêt *Centros*, pt. 39.

779 I. BARSAN, *op. cit.*, pp. 2 et s. ; M. COMBET, « Le renforcement du droit à transformation des sociétés dans le marché intérieur », *Sem. Jur.*, n° 51, 18 décembre 2017, disponible sur http://www.lexisnexis.com (31/05/2018), p. 8 ; I. CORBISIER, « Arrêt Polbud de la C.J.U.E. : de la créature de droit national au sujet de droit de l'Union européenne », *RPS-TRV*, 2018, p. 154 et J. MEEUSEN, *op. cit.*, p. 602.

780 Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, pp. 323 et 324.

781 Art. 12:73 et 12:90 du CSA.

782 Partie 4, Livre 14, Titre 1, Chapitre 3 du CSA.

783 Art. 110 du Code de droit international privé belge et à ce sujet, voir : M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 379 et J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE et H. CULOT, *op. cit.*, p. 262, n° 529.

des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »[784], il s'ensuit que les principes d'effectivité et d'équivalence devront également s'appliquer en la matière. Par conséquent, sous peine d'entraver la liberté d'établissement des sociétés concernées, les États membres ne pourront, pour peu qu'ils connaissent la figure de la scission en droit interne, ni traiter les scissions transfrontalières moins favorablement que les opérations internes, ni rendre les scissions transfrontalières impossibles en pratique ou excessivement difficiles par le biais de leur législation nationale.

C. *Les enseignements en droit international privé*

216. Une règle transposable aux scissions par constitution de nouvelles sociétés. En se penchant sur la compatibilité de la législation hongroise avec la liberté d'établissement dans l'arrêt *Vale*, la Cour de justice a eu l'occasion de se prononcer directement sur le droit applicable à une transformation transfrontalière[785]. Bien que les faits à l'origine du litige n'aient pas directement concerné l'hypothèse d'une scission transfrontalière, il est possible de tirer certaines conclusions à leur égard de cet enseignement qui consacre l'application consécutive des deux droits nationaux impliqués autour du moment charnière de l'émission du certificat de conformité. S'il a certes déjà été avancé que la même règle de conflit de lois devrait s'appliquer à tous types de scissions transfrontalières[786], il semble préférable de restreindre cette règle aux seules scissions par constitution de nouvelles sociétés. En effet, le raisonnement de la Cour à l'égard des transformations transfrontalières est que celles-ci sont régies, pour la partie de la procédure jusqu'à l'émission du certificat de conformité par le droit de l'État membre d'origine, alors que le reste de la procédure doit en principe être régi par le droit de l'État membre d'accueil. Un tel principe de droit international privé est aisément transposable au cas d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés et est par ailleurs identique à celui adopté dans la Directive Mobilité[787]. En revanche, les scissions transfrontalières impliquant au moins une société préexistante ne permettent pas d'appliquer une telle règle sans adaptation préalable puisqu'au moins deux droits nationaux distincts entrent en concurrence avant même l'émission du certificat de conformité. On peut certes modifier les enseignements de la Cour et considérer que ceux-ci impliquent que (i) la partie de la procédure précédant

784 Voir en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 3 ; H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 55 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1161 ; T. DRYGALA, *op. cit.*, p. 26 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 19 ; V. GEYRHALTER et Th. WEBER, *op. cit.*, p. 150 ; L. HANSEN, *op. cit.*, p. 195 ; S. HERRLER, *op. cit.*, pp. 298 et 299 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, pp. 226 et 234 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 45 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 416 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, pp. 165 et 166 ; W. MEILICKE et D. E. RABBACK, *op. cit.*, pp. 126 et 127 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 320 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 236 ; J. SEDEMUND, *op. cit.*, p. 521 ; M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 314 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 358 ; Chr. TEICHMANN et R. K KNAIER, *op. cit.*, p. 1319 et S. WEISS et H.-T. WÖHLERT, *op. cit.*, pp. 584 et 585.

785 À ce sujet, voir *supra* n[os] 205 à 208.

786 Voir en ce sens : R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 340.

787 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.

l'émission du certificat de conformité doit, pour chaque société préexistante impliquée, être régie par son propre droit national, alors que (ii) la partie de la procédure suivant l'émission dudit certificat doit être régie par les droits nationaux des sociétés bénéficiaires. Cependant, une telle interprétation, bien que logique et cohérente avec la règle de droit international privé applicable aux fusions transfrontalières tombant dans le champ d'application de la Directive Sociétés[788], s'éloigne dangereusement des faits à la base de l'arrêt *Vale*[789] et souffre dès lors d'une forte insécurité juridique.

D. *L'incidence de l'absence de normes de droit dérivé*

217. Le droit dérivé de l'Union : utile, mais pas indispensable. Si la Cour de justice a certes reconnu que les transformations transfrontalières, à l'instar des fusions transfrontalières[790] sont sources de problèmes spécifiques en ce qu'elles impliquent l'application consécutive de deux droits nationaux distincts[791], elle a également souligné, tout comme en matière de fusions transfrontalières dans l'arrêt *Sevic*[792], que l'absence de normes de droit dérivé règlementant les opérations de transformation transfrontalière n'est en aucun cas de nature à justifier une différence de traitement en fonction de la nature transfrontalière ou interne de l'opération[793]. Transposé aux scissions transfrontalières, cet enseignement signifie qu'un État membre ne pourrait refuser de manière générale de reconnaître une scission transfrontalière au simple motif que les problèmes de droit international privé engendrés par ce type d'opération nécessiteraient l'adoption de normes de droit dérivé de l'Union. Ce point est particulièrement précieux à la lumière du fait que le champ d'application de la Directive Mobilité est limité aux seules scissions partielles, totales ou par séparation par constitution de nouvelles sociétés[794] au motif que les scissions par absorption au profit d'une ou de plusieurs sociétés préexistantes sont d'une complexité accrue liée à la pluralité d'autorités nationales impliquées et aux risques supplémentaires de fraude[795]. En effet, un État membre ne pourra se prévaloir des mêmes arguments que ceux avancés par le législateur européen pour s'opposer de manière générale aux scissions transfrontalières au profit d'une ou de plusieurs sociétés préexistantes. En outre, plus spécifiquement en ce qui concerne les opérations de scission couvertes par la Directive Mobilité, il est important de préciser qu'il découle de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transformations transfrontalières qu'un État membre ne pourra se reposer sur le fait que la norme de droit dérivé de l'Union n'a pas encore

788 Art. 121, § 1er, b) de la Directive Sociétés.
789 Voir *supra* n° 200.
790 Arrêt *Vale*, pt. 37 et arrêt *Sevic*, pt. 27.
791 Arrêt *Vale*, pt. 37.
792 Arrêt *Sevic*, pt. 26 où la Cour de justice a considéré que « si des règles communautaires d'harmonisation sont certes utiles pour faciliter les fusions transfrontalières, l'existence de telles règles d'harmonisation ne saurait être érigée en condition préalable pour la mise en œuvre de la liberté d'établissement ». Sur l'incitation à adopter un régime des scissions transfrontalières que cet enseignement de la Cour de justice a pu avoir sur les États membres, voir *supra* n° 160.
793 Arrêt *Vale*, pt. 38.
794 Art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité.
795 8e considérant de la Directive Mobilité.

été adoptée pour soit refuser toute scission transfrontalière soit suspendre la date de prise d'effet de celles-ci jusqu'à l'adoption de la directive finale et sa transposition en droit interne.

E. *Une liberté de scission encadrée*

218. La possibilité d'une restriction justifiée à la liberté d'établissement. Dans la mesure où une application stricte du principe d'équivalence méconnaîtrait fondamentalement le fait que les opérations transfrontalières sont susceptibles d'être plus dommageables à des intérêts légitimes que des opérations purement internes, la jurisprudence en matière de transformations transfrontalières confirme que les États membres disposent de la possibilité d'adopter des normes spécifiques destinées à protéger ces intérêts[796] et de lutter contre les éventuelles pratiques abusives[797]. Pour qu'une telle restriction soit admise, elle doit (i) être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, (ii) être propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et (iii) ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif[798].

219. Deux exemples de mécanismes de protection disproportionnés. Au-delà de ce principe général, il découle de la jurisprudence en matière de transformations transfrontalières qu'une interdiction générale des scissions transfrontalières dans l'État d'origine alors que les scissions internes sont reconnues ne remplit pas la condition de proportionnalité du « *Gebhard test* » dans la mesure où elle irait au-delà de ce qui est nécessaire pour remplir l'objectif de protection des intérêts légitimes en jeu[799]. On peut également en déduire que, bien que la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des travailleurs constitue une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la liberté d'établissement[800], une mesure de droit interne qui imposerait la liquidation de la société scindée en vue de protéger lesdits intérêts ne remplirait pas la condition de proportionnalité. En effet, il serait difficilement justifiable qu'une telle mesure soit prohibée en cas de transformation transfrontalière et permise à l'égard des scissions transfrontalières alors que ces deux types d'opérations ont des conséquences similaires pour ces différentes catégories de *stakeholders*.

F. *Le cas particulier des scissions de sociétés de participation financière*

220. L'incidence sur les sociétés de participation financière. La jurisprudence de la Cour de justice en matière de transformations transfrontalières est également susceptible d'avoir une utilité particulière à l'égard de la protection par la liberté d'établissement d'une scission transfrontalière d'une société ayant

796 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; arrêt *Vale*, pt. 39 et arrêt *Sevic*, pt. 28.
797 Arrêt *Polbud*, pt. 39 ; arrêt *Centros*, pts. 18 et 24 et arrêt *Inspire Art*, pt. 96.
798 Arrêt *Polbud*, pt. 52 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; arrêt *National Grid Indus*, pt. 42 ; arrêt *Cadbury Schweppes*, pt. 47 et arrêt *Sevic*, pts. 28 et 29.
799 Arrêt *Vale*, pt. 40 et arrêt *Sevic*, pt. 30.
800 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; arrêt *Vale*, pt. 39 et arrêt *Sevic*, pt. 28.

pour seul objet la détention de participations dans d'autres sociétés dispersées à travers plusieurs États membres. En effet, dans un tel cas d'espèce, il est difficile d'arguer que les entraves à la scission transfrontalière dans l'État d'origine doivent être interdites dans la mesure où une telle opération relève de la liberté d'établissement secondaire des sociétés bénéficiaires puisque celles-ci se retrouveront, par l'effet même de l'opération, titulaires d'un ensemble de biens et de moyens de production localisés dans l'État d'origine[801]. En revanche, en matière de transformations transfrontalières, la Cour de justice s'est basée sur les enseignements de l'arrêt *Sevic* pour considérer que « les opérations de transformation de sociétés relèvent, en principe, des activités économiques pour lesquelles les États membres sont tenus au respect de la liberté d'établissement »[802], sans opérer de distinction entre entrave dans l'État d'origine et dans l'État d'accueil. En d'autres termes, la Cour semble adhérer au raisonnement des auteurs qui interprétaient l'arrêt *Sevic* dans le sens d'un rejet de toute distinction entre barrières dans l'État d'origine et barrières dans l'État d'accueil[803]. En outre, il ressort de l'arrêt *Polbud* qu'une personne morale peut bénéficier de la protection de la liberté d'établissement lorsqu'elle se transforme en une société relevant du droit d'un autre État membre quand bien même elle exercerait l'essentiel ou l'intégralité de ses activités dans un autre État membre[804]. Si on ajoute à cela que, dans l'arrêt *Polbud*, la Cour de justice a clarifié sa référence à l'arrêt *Cadbury Schweppes* dans son arrêt *Vale*[805], il ne peut dès lors être avancé qu'une scission transfrontalière d'une société de participation financière ne tombe pas dans le champ d'application de la liberté d'établissement parce qu'elle ne s'accompagne pas de l' « exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable dans l'État membre d'accueil pour une durée indéterminée »[806]. Il en découle que la scission transfrontalière d'une société de participation financière relèvera de la liberté d'établissement, quand bien même il ne resterait plus d'établissement secondaire dans l'État membre de la société scindée à la suite de l'opération.

221. La limite des dispositions anti-abus. Il convient toutefois de remarquer que la question de l'applicabilité de la liberté d'établissement à ce type d'opérations est à distinguer de la possibilité dont jouissent les États membres d'adopter des mesures défensives visant à lutter contre les pratiques abusives[807], étant entendu qu'une opération de scission transfrontalière dans le

801 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 66 et 67 qui considère que s'il n'y a pas d'activité économique dans l'État membre d'origine, on se situe hors du champ d'application matériel de la liberté d'établissement. Par conséquent, la protection de l'opération dans le chef de la société bénéficiaire par le biais de la liberté d'établissement secondaire requerra une analyse au cas par cas. Voir également S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 109 qui considère également qu'une telle opération ne relève pas de la liberté d'établissement, mais de la libre circulation des capitaux.

802 Arrêt *Vale*, pt. 24 où la Cour de justice se réfère au point 19 de l'arrêt *Sevic*.

803 Voir en faveur d'une telle interprétation de l'arrêt *Sevic* : Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, pp. 356 et 358 ; P. KINDLER, « Der Wegzug von Gesellschaften in Europa », *op. cit.*, pp. 818 et 819 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, pp. 91 et 94.

804 Arrêt *Polbud*, pt. 38.

805 Arrêt *Vale*, pt. 34 et *supra* n° 212.

806 Arrêt *Vale*, pt. 34.

807 Arrêt *Polbud*, pt. 39 ; arrêt *Centros*, pts 18 et 24 et arrêt *Inspire Art*, pt. 98.

but de bénéficier d'une législation plus avantageuse ne pourra en elle-même être constitutive d'abus[808].

G. *Le cas particulier des scissions par constitution de nouvelles sociétés*

222. Absence d'exclusion des scissions par constitution de nouvelles sociétés. La jurisprudence de la Cour de justice en matière d'émigration, en affirmant que « toute société créée en vertu d'un ordre juridique national n'a d'existence qu'à travers la législation nationale qui en détermine la constitution et le fonctionnement »[809], avait laissé planer un doute sur l'applicabilité de la liberté d'établissement aux scissions par constitution de nouvelles sociétés. En appliquant les enseignements de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de transformations transfrontalières aux scissions transfrontalières, on peut considérer que la question de savoir si ces opérations tombent dans le champ d'application de la liberté d'établissement est à dissocier de la question de la détermination des règles de constitution et de fonctionnement des nouvelles sociétés issues de la scission transfrontalière[810]. En effet, l'obligation de reconnaître les scissions transfrontalières si de telles opérations sont admises dans l'ordre juridique interne ne porte pas atteinte à la faculté de l'État membre des sociétés bénéficiaires de déterminer les règles de constitution et de fonctionnement de celle-ci. Il s'ensuit que l'argumentation selon laquelle une réglementation nationale discriminatoire s'opposant à la réalisation d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés ne relève pas du champ d'application des articles 49 et 54 du TFUE dans la mesure où une telle opération aboutit à la constitution d'une ou de plusieurs sociétés dans l'État membre d'accueil et qu'il est de jurisprudence constante les États membres sont seuls compétents pour déterminer les règles régissant tant la constitution que le fonctionnement des sociétés relevant de leur ordre juridique national[811] ne pourrait être retenue par la Cour de justice et que les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés tombent bel et bien dans le champ d'application de la liberté d'établissement.

SECTION 6. LES LIMITES DES ENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

223. Plan de la section 6. Malgré une indéniable utilité, les enseignements de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement n'en souffrent pas moins de cinq limites qu'il importe d'étudier successivement, à savoir l'absence d'une décision portant explicitement sur les scissions transfrontalières (§ 1), l'absence de description des modalités concrètes de réalisation d'une scission transfrontalière (§ 2), l'exigence d'une discrimination (§ 3), la justification des entraves à la liberté d'établissement (§ 4) et la réticence des États membres (§ 5).

808 Arrêt *Polbud*, pt. 40 ; arrêt *Centros*, pt. 27 et arrêt *Inspire Art*, pt. 96.
809 Arrêt *Cartesio*, pt. 104 et arrêt *Daily Mail*, pt. 19.
810 Arrêt *Vale*, pt. 30.
811 Arrêt *Vale*, pt. 27 ; arrêt *Daily Mail*, pt. 19 et arrêt *Cartesio*, pt. 104.

§1. L'absence d'une décision portant explicitement sur les scissions transfrontalières

224. Un raisonnement par analogie. Si l'analyse de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fusions transfrontalières, de transferts de siège et de transformations transfrontalières a clairement démontré qu'il n'était pas plus loisible à l'État membre d'origine qu'à l'État membre d'accueil de dresser des barrières à une scission transfrontalière si une telle opération est admise dans l'ordre interne, force est d'admettre qu'un tel raisonnement repose sur une application par analogie qui pourrait impliquer qu'en l'absence d'une décision de la Cour de justice portant explicitement sur un cas de scission transfrontalière, une telle opération demeurerait inévitablement moins attrayante du point de vue de la sécurité juridique qu'une fusion transfrontalière combinée à une scission interne. En d'autres termes, en prônant l'application de la liberté d'établissement aux scissions transfrontalières par le biais d'un argument *a pari*[812] en raison du traitement relativement univoque réservé aux opérations voisines que constituent les fusions transfrontalières et les scissions transfrontalières par la Cour de justice, on ne peut aboutir qu'à une forme de « vérité probable »[813] ou, pour reprendre les termes de Charles Chaumont, « [d]'une analogie, on ne peut jamais tirer une identité »[814]. Cependant, cette première limite, si elle ne peut être ignorée, se doit d'être fortement nuancée. En effet, tout d'abord il convient de relever que la Cour de justice ne dédaigne pas de procéder par le biais d'un raisonnement par analogie[815] et qu'en outre, plus

812 Selon François Ost, l'argument *a pari* repose sur un raisonnement par analogie qui peut être résumé comme suit : « [l]e législateur, ayant réglé expressément telle hypothèse, a — suppose-t-on — voulu réserver le même traitement à telle autre hypothèse essentiellement semblable ». Voir F. OST, « L'interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur » in M. VAN DE KERCHOVE (dir.), *L'interprétation en droit – approche pluridisciplinaire*, Bruxelles, Presses de l'Université Saint-Louis, 1978, p. 80, n° 157.

813 F. OST, *ibidem*, p. 80, n° 158.

814 C. CHAUMONT, « Cours général de droit international public », *R.C.A.D.I.*, 1970/1, t. 129, p. 506.

815 Voir à titre d'illustration : C.J., gde ch., arrêt *Conseil de l'Union européenne et Commission européenne c. Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe*, 13 janvier 2015, C-404/12, EU:C:2015:5, pt. 31 (au sujet du rejet d'un pourvoi incident qui ne tend en réalité qu'à obtenir une substitution de motifs par analogie avec une décision de rejet d'un pourvoi principal ayant le même objectif) ; C.J., gde ch., arrêt *Lesoochranárske zoskupenie VLK c. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky*, 8 mars 2011, C-240/09, EU:C:2011:125, pt. 31 (en matière de compétence de la Cour de justice pour traiter des questions relatives à une convention internationale conclue par la Communauté européenne et les États membres en vertu d'une compétence partagée) ; C.J.C.E., arrêt *Hans Eckelkamp et autres c. Belgische Staat*, 11 septembre 2008, C-11/07, EU:C:2008:489, pt. 63 (en matière de libre circulation des capitaux par analogie avec la jurisprudence en matière de droit d'établissement) et C.J.C.E., gde ch., arrêt *Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato c. Lucchini SpA, anciennement Lucchini Siderurgica SpA*, 18 juillet 2007, C-119/05, EU:C:2007:434, pt. 50 (sur les compétences des juridictions nationales en matière d'aides d'État). Voir également : M. WALBROECK, *Droit international, intégration européenne et libre marché – Etudes de droit communautaire européen 1965–2008*, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 191. Sur les méthodes d'interprétation de la Cour de justice, voir notamment : St. GRUNDMANN, *Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts durch den europäischen Gerichtshof*, Konstanz, Hartung-Gorre, 1997, pp. 238 et s. ; M. MAHIEU, « L'interprétation du droit communautaire » in M. VAN DE KERCHOVE (dir.), *L'interprétation en droit – approche pluridisciplinaire*, Bruxelles, Presses de l'Université Saint-Louis, 1978, pp. 247–250, n°s 55 à 74 et B. WEGENER in Chr. CALLIESS et M. RUFFERT (dir.), *EUV/AEUV – Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta*, 5e éd., München, C.H.Beck, 2016 EU-Vertrag (Lissabon) art. 19, n° 16.

fondamentalement, si on accepte le postulat de la rationalité du législateur[816], on ne voit pas comment il serait possible de justifier de traiter différemment les scissions et les fusions transfrontalières alors que ces deux espèces d'opérations sont très similaires et entretiennent un fort lien de parenté[817] tout en privilégiant une interprétation téléologique des dispositions du TFUE chère à la Cour de justice[818].

§ 2. L'absence de description des modalités concrètes de réalisation de la scission

225. L'incidence du principe d'équivalence. Bien que la protection des scissions transfrontalières par la liberté d'établissement ne pose pas de question[819], on reste néanmoins en droit de s'interroger sur la manière dont il convient de réaliser concrètement une telle opération. En effet, la liberté d'établissement est certes utile en ce qu'elle permet de supprimer des mesures discriminatoires qui ne manqueraient pas de limiter la mobilité des sociétés au sein de l'Union européenne, mais elle ne permet pas à la Cour de justice de remplacer ou de compléter les mesures législatives nationales jugées contraires aux articles 49 et 54 du TFUE[820]. En outre, il convient de ne pas perdre de vue que la Cour de justice n'intervient jamais que sur des points particuliers et est limitée par l'étendue des questions préjudicielles qui lui sont soumises[821]. Elle n'a par conséquent pas vocation à déterminer d'autorité un régime spécifique de scission transfrontalière. À l'instar de ce qui avait été avancé (i) à l'égard des fusions transfrontalières avant l'adoption de la Dixième Directive[822] et (ii) des transformations transfrontalières[823], on pourrait argumenter que le principe d'équivalence interdisant la discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes implique que les règles régissant les scissions internes devront en principe trouver à s'appliquer *mutatis mutandis*. Cette solution, appliquée à plusieurs reprises par des juridictions allemandes en matière de transformations transfrontalières suite aux enseignements de l'arrêt *Vale*

816 Sur ce postulat, voir F. OST, *op. cit.*, pp., nos 79 à 92.

817 Sur le lien de parenté entre les fusions et les scissions, voir *supra* n° 27.

818 Voir en ce sens : M. MAHIEU, *op. cit.*, p. 247, nos 53 et 54 qui relève que la méthode d'interprétation de la Cour se trouve résumée dans un arrêt de la Cour de justice du 21 février 1973 où la Cour a considéré qu' « *il convient, pour résoudre ce problème, d'envisager à la fois l'esprit, l'économie et les termes de l'article 86, compte tenu du système du Traité et des finalités qui lui sont propres* ». Voir C.J.C.E., arrêt *Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. c. Commission des Communautés européennes*, 21 février 1973, C-6/72, EU:C:1973:22, pt. 22. Voir également : C. TOADER, « Méthodes d'interprétation en droit de l'Union européenne en matière de protection du consommateur : une approche pratique » in V. KRONENBERGER, M. T, D'ALESSIO et V. PLACCO (coord.), *De Rome à Lisbonne : les juridictions de l'Union européenne à la croisée des chemins*, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 450.

819 À ce sujet, voir *supra* n° 153.

820 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 41 et Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 359.

821 Art. 267 du TFUE et Étude d'impact, p. 33.

822 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Schutz der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch die Niederlassungsfreiheit », *op. cit.*, p. 212 ; H. BUNGERT, *op. cit.*, pp. 54 et 55 et Cl. SCHMIDT et S. MAUL, *op. cit.*, p. 13.

823 Voir en ce sens : Th. HORSLEY, *op. cit.*, p. 943 ; B. SEIBOLD, *op. cit.*, p. 456 et S. ZWIRLEIN, *op. cit.*, p. 122.

tant dans des cas d'émigration[824] que dans des cas d'immigration[825], impose néanmoins de se livrer à un délicat exercice de droit international privé nuisant inéluctablement à la sécurité juridique d'une telle opération.

226. La nécessité d'un régime spécifique. En d'autres termes, en l'absence d'un cadre juridique certain applicable aux scissions transfrontalières, la seule liberté d'établissement n'est pas en mesure de permettre la réalisation de scissions transfrontalières[826], pas plus que d'assurer une mobilité générale des sociétés par-delà les frontières[827] avec un degré de sécurité juridique suffisant. Cette limite, mise très clairement en lumière lors de la consultation publique de 2015 réalisée par la Commission[828], ressort également de la Directive Mobilité dans la mesure où elle a pour objectif de renforcer la sécurité juridique tout en réduisant les coûts associés à l'absence d'un cadre légal harmonisé[829]. Par conséquent, même si on considère comme la majorité des auteurs que les scissions transfrontalières constituent des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »[830], force est de constater qu'à l'instar de ce qu'a remarqué la Cour de justice au sujet plus particulièrement des cas de transfert

824 KG, 21 mars 2016, 22 W 64/15, disponible sur https://openjur.de/u/888885.html où le *Kammergericht* a appliqué par analogie le régime prévu aux §§ 190 et s. de l'*Umwandlungsgesetz* (transformations nationales) à l'hypothèse de la transformation d'une société à responsabilité française en son équivalent allemand et OLG Nürnberg, 19 juin 2013, 12 W 520/13, *ZIP*, 2014, pp. 128–130 où l'Oberlandesgericht a appliqué le même raisonnement à l'hypothèse de la transformation d'une société à responsabilité luxembourgeoise en son équivalent allemand. Voir à ce sujet : B. SEIBOLD, *op. cit.*, p. 456 et S. ZWIRLEIN, *op. cit.*, pp. 114–128.

825 OLG Frankfurt, 3 janvier 2017, 20 W 88/15, *ZIP*, 2017, pp. 611–617 et *DNotZ*, 2017, pp. 381–390 où l'Oberlandesgericht a appliqué par analogie le régime prévu aux §§ 190 et s. de l'*Umwandlungsgesetz* (transformations nationales) à la transformation d'une société à responsabilité limitée allemande en son équivalent italien. Voir à ce sujet : R. KNAIER, note sous OLG Frankfurt, 3 janvier 2017, *DNotZ*, 2017, pp. 390–394.

826 Proposition de la Commission, pp. 1 et 2 et T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, « Gegenwart und Zukunft grenzüberschreitender Verschmelzungen und Spaltungen », *NZG*, 2016, p. 1161 ; S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 795 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 11 et 12. Voir également en ce sens à propos des transformations transfrontalières : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 42.

827 Proposition de la Commission, pp. 1 et 2 et W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 2225 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 200 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 19 ; Th. WACHTER, « Verstoß einer die Sitzverlegung von vorheriger Auflösung der Gesellschaft machender innerstaatlicher Regelung gegen die Niederlassungsfreiheit – Polbud », *op. cit.*, p. 1313 et S. ZWIERLEIN, *op. cit.*, pp. 126 et 128.

828 Lors de la consultation de 2015, l'insécurité juridique liée à l'absence de règles européennes a été épinglée comme le principal obstacle à une scission transfrontalière par 68 % des répondants. Voir Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 17.

829 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 11 et 10e, 17e, 22e et 50e considérants de la Directive Mobilité.

830 Voir en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 3 ; H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 55 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1161 ; T. DRYGALA, *op. cit.*, p. 26 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 19 ; V. GEYRHALTER et Th. WEBER, *op. cit.*, p. 150 ; L. HANSEN, *op. cit.*, p. 195 ; S. HERRLER, *op. cit.*, pp. 298 et 299 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, pp. 226 et 234 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 45 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 416 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, pp. 165 et 166 ; W. MEILICKE et D. E. RABBACK, *op. cit.*, pp. 126 et 127 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 320 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 236 ; J. SEDEMUND, *op. cit.*, p. 521 ; M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 314 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 358 ; Chr. TEICHMANN et R. K KNAIER, *op. cit.*, p. 1319 et S. WEISS et H.-T. WÖHLERT, *op. cit.*, pp. 584 et 585.

de siège social[831], les modalités concrètes de nature à permettre de réaliser une scission transfrontalière constituent des difficultés spécifiques qui n'ont pas vocation à être résolues par les dispositions du TFUE relatives à la liberté d'établissement. Cette position se retrouve dans la Proposition de la Commission[832] et explique pourquoi certains auteurs ont considéré que l'avancée première de la Dixième Directive n'est pas d'avoir permis la reconnaissance des fusions transfrontalières, mais de leur avoir fourni un cadre légal permettant d'atténuer l'incertitude qui caractérisait ce type de procédures[833].

§ 3. L'exigence d'une discrimination

227. Les limites de l'assimilation des sociétés aux personnes physiques. Malgré le caractère *a priori* général de l'assimilation des sociétés aux personnes physiques prônée par l'article 54 du TFUE, celle-ci connaît malgré tout certaines limites. Ces dernières tiennent tout d'abord au fait qu'une société, contrairement à une personne physique, n'a d'existence qu'à travers un ordre juridique particulier qui en détermine les caractéristiques[834]. Or, comme les scissions concernent l'existence ou à tout le moins les caractéristiques essentielles des personnes morales[835], il en découle que l'ouverture de ce type d'opérations relève, en l'absence de norme de droit dérivé, de la seule compétence des États membres[836]. Ce raisonnement est confirmé par le texte de la Directive Sociétés relatif aux fusions transfrontalières qui n'ouvre ce type de restructuration qu'aux seules sociétés pouvant fusionner en vertu de leur ordre juridique national. A cela s'ajoute que la transmission à titre universel dont s'accompagne par définition une scission doit nécessairement être prévue par une norme de droit positif[837]. Il s'ensuit que ni l'arrêt *Sevic*, ni les arrêts *Vale* et *Polbud* n'imposent aux différents États membres de procéder à une reconnaissance automatique des opérations de restructuration transfrontalière[838]. En effet, il ne pose en réalité qu'un principe de non-discrimination des opérations internes par rapport aux opérations transfrontalières[839] qui n'est autre que la conséquence logique du principe d'équivalence[840]. En d'autres termes, comme la liberté d'établissement n'est pas en elle-même créatrice de droits subjectifs[841], le refus de l'État de la société scindée de reconnaître une opération de scission

831 Arrêt *Daily Mail*, pts. 21 à 23 ; arrêt *Überseering*, pt. 69 et arrêt *Cartesio*, pt. 108.
832 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 14.
833 Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, p. 94 et J. PIEPER, « European Cross-Border Mergers after SEVIC », *Comp. Law.*, 2009, 30(6), p. 173.
834 Arrêt *Daily Mail*, pt. 47.
835 A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 53.
836 Art. 121, § 1er, point a de la Directive Sociétés.
837 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 65 et U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 16.
838 St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 67, n° 40 ; A. WENG, *op. cit.*, pp. 103 et 104 et S. ZWIRLEIN, *op. cit.*, p. 119.
839 St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, p. 163 ; J. PIEPER, *op. cit.*, pp. 172 et 173 ; H. DE WULF, « Grensoverschrijdende fusies na *Sevic* en de Tiende Richtlijn », *IPR. be/DIPr.be*, 2006, p. 87 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 308 et Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 358.
840 Arrêt *Vale*, pt. 54.
841 H. DE WULF, *op. cit.*, p. 87, n° 10 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 14, n° 8.

transfrontalière d'une société d'un type auquel la législation nationale n'ouvre pas cette forme de restructuration ne sera pas contraire aux principes de la liberté d'établissement, quand bien même l'État membre des sociétés bénéficiaires ne s'opposerait pas à ce type d'opérations[842].

228. L'incidence de la reconnaissance facultative des scissions internes. Cette problématique, déjà largement identifiée dans le cadre des fusions transfrontalières[843] et des transformations transfrontalières[844], est accentuée à l'égard des scissions transfrontalières. En effet, si la Directive Sociétés a imposé aux États membres de reconnaître la figure de la fusion interne[845], tel ne fut pas le cas des scissions internes pour lesquelles la seule exigence était que si les États décidaient de reconnaître cette forme de restructuration pour les sociétés anonymes, ils la soumettent à la procédure instaurée par la Directive Sociétés[846]. Il s'ensuit que si un État membre décide de ne plus reconnaître les opérations de scission interne, les personnes morales soumises à son droit national se verront *de facto* privées de la faculté de réaliser une opération transfrontalière. En effet, il serait erroné d'interpréter la liberté d'établissement comme imposant aux États membres de reconnaître les scissions transfrontalières alors qu'une telle opération ne serait pas prévue dans l'ordre juridique purement interne[847].

§4. La justification des entraves à la liberté d'établissement

229. Une insécurité juridique renforcée. Si la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement a certes été à l'origine d'une avancée considérable en vue de la reconnaissance des scissions transfrontalières, il convient de ne pas en exagérer la portée, principalement à l'égard d'une possible justification d'une entrave à la liberté d'établissement. En effet, outre la confirmation qu'une entrave à l'exercice de la liberté d'établissement peut être tolérée aux conditions du « *Gebhard test* »[848] et quelques exemples de mesures ne remplissant pas la condition de proportionnalité[849], celle-ci ne contient pas d'autre indication exploitable par les législateurs nationaux. Il est dès lors impossible, sur cette seule base, de déterminer avec un degré de certitude suffisant quelles mesures de protection des *stakeholders* ou procédures peuvent être adoptées par les États membres en conformité avec les

842 St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, p. 163 ; Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approach… », *op. cit.*, p. 87 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 53.

843 Th. PAPADOPOULOS, *ibidem*, p. 87.

844 St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 67, n° 40 et S. ZWIRLEIN, *op. cit.*, p. 119.

845 Art. 88 de la Directive Sociétés.

846 Art. 135, §§ 1–3 de la Directive Sociétés.

847 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : St. LEIBLE *in* S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 67, n° 40.

848 Arrêt *Polbud*, pt. 52 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; arrêt *National Grid Indus*, pt. 42 ; arrêt *Sevic*, pt. 23 ; arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 49 ; arrêt *Inspire Art*, pt. 133 ; arrêt *Überseering*, pt. 92 ; arrêt *Centros*, pt. 34 ; arrêt *Gebhard*, pt. 37 et arrêt *Kraus*, pt. 32.

849 Arrêt *Polbud*, pts. 58 et 59 ; arrêt *Vale*, pt. 40 ; arrêt *Sevic*, pt. 30 ; arrêt *Inspire Art*, pts. 135 et 142 ; arrêt *Überseering*, pt. 93 et arrêt *Centros*, pt. 35.

exigences de la liberté d'établissement[850]. On peut certes déduire du principe de non-discrimination des opérations internes par rapport aux opérations transfrontalières que les mécanismes de protection existant à l'égard des opérations nationales devraient être transposables aux opérations transfrontalières[851], mais ce principe souffre de deux limites. Tout d'abord, s'il est d'une certaine utilité à l'égard des fusions transfrontalières qui ont fait l'objet d'une reconnaissance obligatoire[852], la reconnaissance facultative des scissions internes[853] limite son intérêt pratique à l'égard des scissions transfrontalières. Ensuite, plus fondamentalement, les opérations transfrontalières emportent des risques plus importants pour les *stakeholders* que les opérations internes de sorte que la simple adaptation des mécanismes internes s'avère insuffisante pour garantir une protection efficace de leurs intérêts[854].

230. La nécessité d'une protection asymétrique ? Au-delà de ces premières considérations, il convient encore de relever que si une restriction à l'exercice de la liberté d'établissement dans le cadre d'une opération de scission devra en tout état de cause satisfaire les quatre conditions du « *Gebhard test* », on peut s'interroger si la condition de proportionnalité ne devrait pas être appréciée de manière moins stricte si l'entrave se trouve dans l'État d'origine plutôt que dans l'État d'accueil[855]. En effet, les risques engendrés par l'opération pour les différents *stakeholders* de la société scindée sont potentiellement plus accrus. Pour ce qui est des créanciers, ceux-ci voient le patrimoine de leur débiteur éclaté et se verront éventuellement contraints de réclamer le paiement de leur créance devant une juridiction étrangère[856]. Les associés minoritaires risquent, pour leur part, de se retrouver, par l'effet de l'opération, soumis à une législation moins protectrice de leurs intérêts[857] et les travailleurs risquent de voir leurs droits de participation soit amoindris, soit disparaître totalement[858]. Ces besoins asymétriques en matière de mesures de protection rendent l'exercice d'appréciation imposé par le « *Gebhard test* » au mieux hasardeux pour les États membres puisque la même mesure est susceptible d'être appréciée différemment en fonction de ce qu'elle s'applique à la société absorbée ou aux sociétés bénéficiaires. Il en résultera nécessairement une certaine insécurité

850 St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, p. 164.

851 St. LEIBLE et J. HOFFMANN, *ibidem*, p. 164.

852 Art. 87, § 1er de la Directive Sociétés.

853 Art. 135, §§ 1–3 de la Directive Sociétés.

854 Voir *infra* la Deuxième Partie qui analyse en détail l'impact d'une scission sur les différents *stakeholders* et la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection spécifiques justifiés par la nature transfrontalière de l'opération.

855 Voir en faveur d'une protection accrue des *stakeholders* dans l'État de la société absorbée : H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 56 ; T. DRYGALA, *op. cit.*, p. 26 ; L. KLOSTER, *op. cit.*, p. 1415 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 81 ; M. SIEMS, « Sevic : Der letzte Mosaikstein im internationalen Gesellschaftsrecht der EU », *op. cit.*, pp. 138 et 139. *Contra* : U. LENNERZ, *op. cit.*, pp. 100 et 101.

856 Pour une analyse détaillée des conséquences d'une scission transfrontalière pour les créanciers, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 1.

857 Pour une analyse détaillée des conséquences d'une scission transfrontalière pour les associés minoritaires, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 1.

858 Pour une analyse détaillée des conséquences d'une scission transfrontalière sur le régime de participation des travailleurs, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 2.

juridique de nature à nuire à l'attractivité des scissions transfrontalières pour les acteurs économiques.

§5. Réticence des États membres et « rules jungle »

231. Les insuffisances d'une harmonisation négative. Si l'harmonisation négative opérée par la Cour de justice de l'Union européenne par le biais de sa jurisprudence en matière de liberté d'établissement a indéniablement été à l'origine de progrès significatifs en termes de mobilité intracommunautaire des sociétés, la compétence limitée de celle-ci[859] l'empêche de pallier les déficiences de l'harmonisation positive[860]. En effet, tout d'abord, il convient de ne pas perdre de vue que les différents arrêts de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement ne concernent à chaque fois qu'une situation factuelle bien définie de sorte que, même en présence d'*obiter dicta*, ses enseignements donnent naissance à des controverses doctrinales sur leur interprétation, ce qui est inhérent à tout raisonnement par extrapolation partant d'un cas d'espèce. À titre d'illustration, il suffit de se reporter à la vaste controverse doctrinale générée par l'*obiter dictum* de la Cour de justice dans l'arrêt *Vale*[861]. Ce point est tel que certains auteurs n'ont pas hésité à qualifier les règles établies par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement de « *rules jungle* »[862]. Ensuite, quand bien même certains points s'avéreraient clairs, comme le principe de non-discrimination des opérations internes par rapport aux opérations transfrontalières, il convient de ne pas sous-estimer la réticence des États membres à adapter leur législation nationale aux avancées prétoriennes en matière de liberté d'établissement. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à l'exemple des transformations transfrontalières qui malgré les enseignements précieux de la Cour de justice en la matière[863] et en attendant la transposition des dispositions de la Directive Mobilité en la matière[864], s'avèrent encore impossibles en pratique, voire interdites, dans de nombreux États membres[865], ce qui a été mis en lumière par les faits à l'origine de l'arrêt *Polbud* qui ont eu lieu malgré les enseignements de la Cour dans les arrêts *Sevic*, *Cartesio* et *Vale*.

859 Dans l'arrêt *Vale*, la Cour de justice a précisé très clairement d'une part que « le droit dérivé de l'Union européenne ne prévoyant pas, en l'état actuel, de règles spécifiques régissant des transformations transfrontalières, les dispositions qui permettent la mise en œuvre d'une telle opération ne peuvent se trouver que dans le droit national, à savoir celui de l'État membre d'origine duquel relève la société cherchant à se transformer et celui de l'État membre d'accueil dont relèvera la société à l'issue de cette transformation » et d'autre part qu' « il ne saurait être inféré des articles 49 TFUE et 54 TFUE des règles précises susceptibles de se substituer aux dispositions nationales ». Voir arrêt *Vale*, pts. 43 et 45.

860 Voir en ce sens : Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 14 et G. PARLEANI, « Le transfert du siège », *Rev. Soc.*, 2013, p. 408, disponible sur www.dalloz.fr (03/08/2018), p. 3.

861 À ce sujet, voir *supra* n°s 209 et 210.

862 T. BIERMEYER, « Shaping the space of cross-border conversions in the EU: between right and autonomy », *C.M.L.R.*, 2013, p. 571 et A. KAHN, *op. cit.*, p. 381.

863 À ce sujet, voir *supra* n°s 199 à 212.

864 Art. 86*bis* à 86*unvicies* de la Directive Mobilité.

865 Voir en ce sens : C. GERNER – BEUERLE, M. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, pp. 17–25 et M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 367.

SECTION 7. CONCLUSION SUR LES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES SOUS L'ANGLE DE LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

232. L'apport de la jurisprudence en matière de fusions transfrontalières. De l'analyse détaillée de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement, on peut tirer un certain nombre d'enseignements précieux pour l'étude des scissions transfrontalières. Ainsi, tout d'abord, la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fusions transfrontalières et le principe d'équivalence qu'elle y a consacré interdisent de prime abord aux États membres d'accueil de dresser des barrières à l'entrée de la société scindée. En revanche, cette jurisprudence est limitée et laisse planer un doute quant au sort à réserver aux entraves à une scission transfrontalière dressées par une réglementation de l'État membre de la société scindée, ainsi qu'à l'égard des scissions des sociétés de participation financière et des scissions par constitution de nouvelles sociétés.

233. L'apport de la jurisprudence en matière de transferts de siège. L'étude des arrêts *Daily Mail* et *Cartesio* qui concernaient spécifiquement des cas de barrières à la sortie ne permettent malheureusement pas d'affirmer que l'État d'origine doit s'abstenir d'entraver la scission de ses sociétés au bénéfice d'entités étrangères. En revanche, la jurisprudence en matière de barrières à l'entrée permet d'avancer que (i) un État membre d'accueil ne pourra en principe s'opposer à la réalisation d'une scission transfrontalière s'il reconnaît ce type de restructuration dans son ordre interne, (ii) une entrave peut être admise si elle remplit les conditions du « *Gebhard test* », (iii) la lutte contre le recours abusif à la liberté d'établissement, la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux ou de la loyauté des transactions commerciales et la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires, des salariés ou encore du fisc constituent des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une entrave et (iv) dans le cadre d'une entrave justifiée par la protection des créanciers, le principe de proportionnalité a pour conséquence que l'accent devra être mis sur leur information et que les régimes plus intrusifs en termes de liberté d'établissement devront rester exceptionnels.

234. L'apport de la jurisprudence en matière de transformations transfrontalières. Les arrêts *Vale* et *Polbud*, outre le renforcement de la concurrence réglementaire qu'ils ont induit et qui est susceptible d'inciter les États membres à adapter leur législation en matière de mobilité transfrontalière, permettent de pallier les insuffisances de la jurisprudence en matière de fusions transfrontalières et de conclure que les principes d'équivalence et d'effectivité imposent tant à l'État membre d'origine qu'aux États membres d'accueil, pour peu qu'ils connaissent la figure de la scission en droit interne, de ne pas traiter les scissions transfrontalières moins favorablement que les opérations internes, ni de rendre les scissions transfrontalières impossibles en pratique ou excessivement difficiles par le biais de leur législation nationale. De plus, la règle de droit international privé posée par la Cour à l'égard des transformations transfrontalières est aisément transposable aux scissions par constitution de nouvelles sociétés. Il s'ensuit que celles-ci seront régies, pour la partie de la procédure jusqu'à l'émission du certificat de conformité, par le droit de l'État membre

d'origine, alors que le reste de la procédure devra en principe être régi par le droit des États membres d'accueil, cette solution étant celle consacrée par la Directive Mobilité[866]. En outre, on peut également déduire de la jurisprudence que l'adoption d'une norme de droit dérivé régissant spécifiquement les scissions transfrontalières, bien qu'utile pour résoudre les problèmes spécifiques posés par celles-ci, ne peut justifier un refus de la part des États membres de reconnaître ce type d'opérations dans un contexte transfrontalier s'ils le font dans l'ordre interne. Au niveau de la justification des éventuelles entraves, il s'avère de plus que ni une interdiction générale des scissions transfrontalières, ni la liquidation préalable de la société scindée, ne constituent des entraves proportionnées à la liberté d'établissement des sociétés impliquées, pour peu que les scissions soient reconnues dans l'ordre interne. Pour finir, la jurisprudence en matière de transformations transfrontalières confirme que tant une scission d'une société de participation financière qu'une scission par constitution de nouvelles sociétés tombent dans le champ d'application de la liberté d'établissement.

235. Des limites significatives. Ces différents enseignements, bien que fondamentaux pour la reconnaissance de principe des scissions transfrontalières, souffrent malgré tout de cinq insuffisances, à savoir (i) un certain degré d'insécurité juridique dû au fait que la Cour de justice n'a encore jamais eu à traiter d'une scission transfrontalière, (ii) une absence de régime clair permettant de réaliser ce type d'opération avec un niveau de sécurité juridique suffisant, (iii) le fait que la Cour ne pose en essence qu'un principe de non-discrimination dont l'application est conditionnée par la reconnaissance des scissions dans l'ordre interne alors que la Directive Sociétés n'a pas imposé la reconnaissance des scissions nationales, (iv) l'incertitude tout d'abord quant à la compatibilité de certaines entraves indispensables à la protection des *stakeholders* avec la liberté d'établissement et ensuite quant à la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection asymétrique dans le cadre des scissions transfrontalières et (v) la réticence des États membres à intégrer les progrès prétoriens en termes de mobilité transfrontalière.

236. L'ombre de la Cour de justice. On peut déduire de cette étude de la jurisprudence en matière de liberté d'établissement que le droit des scissions transfrontalières intra-européennes ne peut résulter d'une construction purement prétorienne. En revanche, il est indéniable que la Cour de justice continuera à jouer un rôle considérable dans le cadre de la mobilité transfrontalière des sociétés. Ainsi, tout d'abord, la protection des scissions transfrontalières par la liberté d'établissement combinée avec (i) l'effet direct vertical dont elle bénéficie et (ii) le fait qu'il ressorte clairement de la jurisprudence de la Cour de justice que l'adoption d'une norme de droit dérivé n'est pas une condition préalable à la reconnaissance des scissions transfrontalières, implique que toutes les personnes morales, même celles n'ayant pas encore fait l'objet d'une harmonisation étendue au sein de l'Union européenne telles que les sociétés en nom collectif ou les sociétés coopératives, pourront en bénéficier pour peu que les scissions leur soient ouvertes dans l'ordre interne. Ensuite, son vaste champ

866 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.

d'application signifie qu'elle conservera un intérêt considérable même après la transposition de la Directive Mobilité pour toutes les personnes morales ne tombant pas dans son champ d'application *ratione personae* limité[867], ainsi que pour tous types de scission ou de déconcentration ne tombant dans son champ d'application *ratione materiae*[868]. En outre, l'application de la liberté d'établissement aux scissions transfrontalières implique que (i) toute disposition de la Directive Mobilité ou de toute mesure nationale relative aux scissions transfrontalières ne pourra créer d'entrave injustifiée à la liberté d'établissement[869] et (ii) les dispositions de la Directive Mobilité ou de toute autre mesure nationale ou supranationale devront être interprétées en conformité avec la liberté d'établissement[870].

867 Au sujet du champ d'application *ratione personae* limité de la Directive Mobilité, voir *infra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1er, Section 2, § 3, A.

868 Au sujet du champ d'application *ratione materiae* limité de la Directive Mobilité, voir *infra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1er, Section 2, § 3, B.

869 À ce sujet, voir *supra* nos 153 ; 166 ; 176 ; 193 à 197 ; 215 et 218 à 222.

870 À ce sujet, voir *supra* n° 155.

Chapitre 2
Les scissions transfrontalières sous l'angle de la libre circulation des capitaux

SECTION 1. PRÉSENTATION

237. Plan du chapitre 2. Au-delà de la liberté d'établissement, les scissions transfrontalières peuvent également être appréhendées sous l'angle de la libre circulation des capitaux. Après un bref rappel des spécificités de cette autre liberté fondamentale (section 1) et un examen des enseignements qui peuvent être tirés de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fusions transfrontalières (section 2), il sera défendu que les scissions transfrontalières constituent également des modalités particulières d'exercice de la libre circulation des capitaux (section 3). Ceci impliquera de déterminer exactement comment cette autre liberté fondamentale devra s'articuler avec la liberté d'établissement (section 4) pour finir par une brève description de l'incidence de cette analyse sur les scissions transfrontalières impliquant un État tiers (section 5).

238. L'effet *erga omnes* de la libre circulation des capitaux. Au-delà de la liberté d'établissement, les scissions transfrontalières sont également susceptibles d'être analysées sous l'angle de la libre circulation des capitaux[871]. Le cinquante-sixième considérant de la Directive Sociétés[872], identique au troisième considérant de la Dixième Directive, laisse clairement sous-entendre que cette liberté s'applique aux fusions transfrontalières et on distingue difficilement en quoi il devrait en être autrement pour les scissions transfrontalières. L'intérêt de la question est loin d'être négligeable car cette autre liberté fondamentale consacrée par les articles 63 et suivants du TFUE est la seule à jouir d'un effet *erga omnes* en ce sens qu'elle est applicable aux mouvements de capitaux à la fois entre États membres et entre un État membre et un État tiers[873]. Par conséquent, contrairement à la liberté d'établissement, elle serait applicable à l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant une société soumise au droit d'un État tiers[874]. Cette caractéristique essentielle qui découle du texte même de l'article 63 du TFUE qui vise les mouvements de capitaux « entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers » justifie que,

871 Voir notamment en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 76 ; H.-G. KOPPENSTEINER, « Zur grenzüberschreitenden Verschmelzung », *Der Konzern*, 2006, p. 42 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 94 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 84 ; W. PAEFGEN, « Umwandlung, europäische Grundfreiheiten und Kollisionsrecht », *op. cit.*, p. 472 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 132 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 71–78.

872 Selon le 56e considérant de la Directive Sociétés, « […] [i]l convient qu'aucune des dispositions et formalités de la législation nationale auxquelles il est fait référence dans la présente directive n'introduise de restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des capitaux, à moins que ces restrictions puissent être justifiées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par des exigences d'intérêt général, et qu'elles soient à la fois nécessaires pour satisfaire à de telles exigences impératives et proportionnelles à celles-ci ».

873 Pour un cas d'illustration voir : C.J., arrêt *Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company c. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy*, 10 avril 2014, C-190/12, EU:C:2014:249 qui concernait un litige au principal entre un fonds d'investissement situé aux États-Unis et l'administration fiscale polonaise.

874 Voir au sujet des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 76 ; Th. DELVAUX, « La politique jurisprudentielle de la Cour de justice des Communautés européennes » in Droit international et européen des sociétés, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 292, n° 523 ; M. GÜNES, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen unter Beteiligung von Kapitalgesellschaften aus Drittstaaten », *IStR*, 2013, p. 214 ; ST. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC »,

malgré la protection des scissions transfrontalières par le biais de la liberté d'établissement[875], il soit utile d'analyser ce type d'opérations sous l'angle de cette autre liberté fondamentale, *a fortiori* en prenant en considération le fait que cette liberté bénéficie d'un effet direct vertical[876].

239. L'importance pour les sociétés de participation financière. En outre, comme vu précédemment, la protection par la liberté d'établissement d'une scission-émigration d'une société ayant pour seul objet la détention d'un portefeuille de titres dans l'État d'origine est susceptible d'engendrer certaines interrogations dans la mesure où une telle opération n'implique pas le maintien d'un établissement secondaire dans l'État d'origine. S'il est possible de défendre qu'une entrave dans l'État d'origine devrait en principe être interdite malgré tout en se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transformation transfrontalière[877], il est également intéressant d'examiner si, à titre subsidiaire, une telle opération pourrait être protégée par la libre circulation des capitaux.

240. La situation incertaine des scissions partielles transfrontalières. Pour finir, la libre circulation des capitaux pourrait présenter un certain intérêt pour l'étude des scissions partielles transfrontalières dont l'insertion dans le champ d'application de la liberté d'établissement est plus délicate. En effet, comme la société scindée ne disparaît pas dans l'opération, il est impossible d'arguer que celle-ci a fait usage de sa liberté d'établissement primaire. De même, le recours à la liberté secondaire n'est pas forcément évident dans la mesure où la société bénéficiaire ne se retrouvera pas dans un lien de dépendance du point de vue du droit des sociétés par rapport à la société scindée. S'il est possible de s'en sortir en considérant que la scission transfrontalière constitue une modalité particulière d'exercice de la liberté d'établissement secondaire de la société scindée[878], cette interprétation est affectée d'un certain aléa en l'absence d'une décision de la Cour de justice portant spécifiquement sur le sujet. Il est dès lors également intéressant de savoir si la libre circulation des capitaux serait susceptible de s'appliquer à une telle hypothèse, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire.

SECTION 2. LES ENSEIGNEMENTS DE L'ARRÊT *SEVIC*

241. Le raisonnement de l'Avocat général Tizzano. Dépassant le cadre des questions préjudicielles posées à la Cour de justice et se basant sur une observation faite par la Commission, l'Avocat général Tizzano, après avoir examiné la conformité du § 1er, al. 1er, pt. 1 de l'*Umwandlungsgesetz* à l'aune de la liberté d'établissement, s'est également intéressé à l'incidence éventuelle de

op. cit., pp. 166 et 167 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 88 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 20, n° 15 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 33.

875 À ce sujet, voir *supra* n° 153.

876 C.J.C.E., arrêt *Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional c. Sanz de Lera, Jiménez et Kapanoglu*, 14 décembre 1995, C-163/94, C-165/94 et C-250/94, EU:C:1995:451, pt. 41.

877 À ce sujet, voir *supra* n° 220.

878 À ce sujet, voir *supra* n° 158.

la libre circulation des capitaux[879]. Bien qu'il ait précisé à titre liminaire qu'une telle analyse pouvait paraître superflue étant donné qu'il avait déjà conclu à une violation de la liberté d'établissement, il a malgré tout jugé utile de se pencher sur cette question afin de parer à l'éventualité où la Cour de justice aurait décidé de ne pas suivre son raisonnement principal[880]. Il a ensuite établi que les fusions constituaient nécessairement des « mouvements de capitaux », que la mesure nationale en cause avait un effet restrictif sur l'exercice de la libre circulation des capitaux en ce qu'elle interdisait « l'utilisation d'un instrument privilégié pour procéder à des opérations d'acquisition ou de création de sociétés se trouvant à l'étranger » et que cette dernière n'était pas justifiable[881].

242. Le silence de la Cour de justice. Malgré le fait que tant l'Avocat général que la Commission avaient vu dans la législation allemande en cause une restriction à la libre circulation des capitaux prévue par l'article 63 du TFUE[882], la Cour de justice ne s'est pas prononcée sur ce point, notamment parce que cela dépassait le cadre des questions préjudicielles qui lui avaient été soumises[883] et qu'en matière de libertés fondamentales, il est fréquent que la Cour limite son analyse à la liberté de circulation la plus pertinente[884].

SECTION 3. LES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES, UNE MODALITÉ PARTICULIÈRE D'EXERCICE DE LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX ?

§1. Présentation

243. Le champ d'application. Pour qu'une mesure nationale applicable aux scissions transfrontalières tombe dans le champ d'application de la libre circulation des capitaux, il est nécessaire qu'elle vise un mouvement de capitaux entre plusieurs États. Si une scission transfrontalière tombe indiscutablement dans le champ d'application *ratione loci* en ce que, par définition, les sociétés impliquées seront situées dans des États membres distincts, il convient d'examiner s'il en va de même pour le champ d'application *ratione materiae*.

§2. Le champ d'application *ratione materiae*

244. Une notion vaste. La notion de « mouvements de capitaux » reprise à l'article 63, § 1er du TFUE ne fait pas l'objet d'une définition dans le TFUE, ce qui est vraisemblablement dû à sa nature polymorphe d'un point de vue

879 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 71–78.

880 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 74.

881 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 76–78.

882 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 75.

883 Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 21, n° 16.

884 Voir en ce sens : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 94 et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 276.

économique[885]. Il ressort néanmoins de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière que cette notion recouvre « des opérations financières qui visent essentiellement le placement ou l'investissement du montant en cause et non la rémunération d'une prestation »[886] et que la nomenclature annexée à la directive (CEE) 88/361[887] revêt une valeur indicative, mais en aucun cas exhaustive[888] de ce qui constitue un mouvement de capitaux, bien qu'elle ne soit plus en vigueur. Or, la première des treize catégories distinctes de cette nomenclature vise les « investissements directs » qui recouvrent notamment « l'acquisition intégrale d'entreprises existantes »[889] ainsi que « la participation à des entreprises nouvelles ou existantes en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables »[890]. Comme les scissions transfrontalières sont, à l'instar des fusions transfrontalières[891], par définition, « indissolublement liées à un mouvement de capitaux »[892] en ce qu'elles impliquent, sauf cas particulier, à la fois (i) la transmission de tout ou d'une partie seulement du patrimoine actif et passif de la société scindée et (ii) l'attribution aux associés de la société scindée d'actions dans le capital d'une ou de plusieurs société(s) bénéficiaire(s)[893], elles sont, en toute vraisemblance, visées également par cette première catégorie qui doit être entendue dans son sens le plus large[894].

245. L'exclusion des prises de contrôle. Cependant, la situation n'est pas si claire car en matière d' « investissements directs », la Cour de justice a tendance à distinguer entre les prises de participation « permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions d'une société et de déterminer les activités de celle-ci » qui relèveront exclusivement de la liberté d'établissement[895] et

885 S. KULENKAMP, *ibidem*, p. 95.

886 C.J.C.E., arrêt *Graziana Luisi et Giuseppe Carbone c. Ministero del Tesoro*, 31 janvier 1984, C-286/82 et C-26/83, EU:C:1984:35, pt. 2.

887 Directive (CEE) 88/361 du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, *J.O.*, 8 juillet 1988, pp. 5–18.

888 Voir not. : C.J., arrêt *Staatssecretaris van Financiën c. L. A. C. van Putten, P. Mook et G. Frank*, 26 avril 2012, C-578/10 à C-580/10, EU:C:2012:246, pt. 28 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Hein Persche c. Finanzamt Lüdenscheid*, 27 janvier 2009, C-318/07, EU:C:2009:33, pt. 24 ; C.J.C.E., arrêt *Héritiers de M. E. A. van Hilten-van der Heijden c. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen*, 23 février 2006, C-513/03, EU:C:2006:131, pt. 39 et C.J.C.E., arrêt *Manfred Trummer et Peter Mayer*, 16 mars 1999, C-222/97, EU:C:1999:143, pt. 21.

889 Point I, A. de la nomenclature figurant à l'annexe I de la directive (CEE) 88/361 du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, *J.O.*, 8 juillet 1988, pp. 5–18.

890 Point I, B., troisième tiret de la nomenclature figurant à l'annexe I de la directive (CEE) 88/361 du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, *J.O.*, 8 juillet 1988, pp. 5–18.

891 D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 76 et 77 ; Th. DELVAUX, « Fusion internationale et liberté de circulation », *op. cit.*, p. 148 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 94 et 95 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, p. 166 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 90 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 85 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 76.

892 C.J.C.E., arrêt *Manfred Trummer et Peter Mayer*, 16 mars 1999, C-222/97, EU:C:1999:143, pt. 24 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 76.

893 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. GÜNES, *op. cit.*, p. 214.

894 Notes explicatives de l'annexe I de la Directive (CEE) 88/361 du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, *J.O.*, 8 juillet 1988, pp. 5–18.

895 C.J., arrêt *Marianne Scheunemann contre Finanzamt Bremerhaven*, 19 juillet 2012, EU:C:2012:481, C-31/11, pt. 23 ; C.J., arrêt *Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH et Österreichische Salinen AG c. Finanzamt Linz*, 10 février 2011, C-437/08 et C-436/08, EU:C:2011:61, pt. 35 ; C.J., gde. ch.,

« les participations effectuées dans la seule intention de réaliser un placement financier sans intention d'influer sur la gestion et le contrôle de l'entreprise » qui relèveront exclusivement de la libre circulation des capitaux[896]. Face à ce constat, un auteur a avancé que la Cour de justice ayant, de jurisprudence constante, systématiquement considéré que les acquisitions d'actions ou de parts représentatives du capital destinées à acquérir le contrôle d'une société relevaient exclusivement de la liberté d'établissement, la libre circulation des capitaux ne s'appliquant qu'aux acquisitions ne tombant pas dans cette première catégorie, « il pourrait s'en déduire que, pour la Cour de justice, la fusion par absorption relève exclusivement de la liberté d'établissement »[897].

246. Les associés de la société scindée. Une telle exclusion générale des fusions par absorption et, par analogie, des scissions par absorption sur cette seule base apparaît trop hâtive et doit, à tout le moins, être nuancée. Tout d'abord, la Cour de justice a déjà considéré qu'il y avait prise de participation permettant d'exercer une influence sur les décisions de la société dès que le pourcentage de participation excédait vingt à vingt-cinq pourcents[898]. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, si aucun associé de la société scindée ne se voit attribuer d'actions représentant au moins vingt pourcents d'une des sociétés bénéficiaires, l'opération pourrait s'analyser sous l'angle de la libre circulation des capitaux puisque l'opération ne permettra pas aux associés de la société scindée d'exercer d'influence sur les décisions au sein des sociétés bénéficiaires. Les opérations de scission par absorption constituent donc une opération mixte susceptible d'entraîner une prise d'influence. Or, dans une telle hypothèse, la Cour de justice tient compte « des éléments factuels du cas d'espèce » pour déterminer s'il convient de se baser sur la liberté d'établissement ou sur la libre circulation des capitaux[899]. Il en découle qu'une scission par absorption pourrait dans certains cas constituer un « investissement direct » des associés

arrêt *Test Claimants in the FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue et The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*, 13 novembre 2012, C-35/11, EU:C:2012:707, pt. 37 ; C.J., arrêt *Idryma Typou AE contre Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis*, 21 octobre 2010, C-81/09, EU:C:2010:622, pt. 47 ; C.J.C.E., Commission des Communautés européennes c. République italienne, 26 mars 2009, C-326/07, EU:C:2009:193, pt. 34 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt Commission des Communautés européennes c. République fédérale d'Allemagne, 23 octobre 2007, C-112/05, EU:C:2007:623, pt. 13 et C.J.C.E., arrêt *C. Baars c. Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem*, 13 avril 2000, C-251/98, EU:C:2000:205, pt. 22.

896 C.J., arrêt *Marianne Scheunemann contre Finanzamt Bremerhaven*, 19 juillet 2012, EU:C:2012:481, C-31/11, pt. 23 ; C.J., arrêt *Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH et Österreichische Salinen AG c. Finanzamt Linz*, 10 février 2011, C-437/08 et C-436/08, EU:C:2011:61, pt. 35 ; C.J., gde. ch., arrêt *Test Claimants in the FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue et The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*, 13 novembre 2012, C-35/11, EU:C:2012:707, pt. 38 et C.J.C.E., arrêt *Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG c. Finanzamt München II*, 17 septembre 2009, C-182/08, EU:C:2009:559, pts. 40 et 45 à 52.

897 Th. DELVAUX, « La politique jurisprudentielle de la Cour de justice des Communautés européennes », *op. cit.*, p. 291, n° 522.

898 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, p. 538, n° 1077 et G. RESS et J. ÜKROW in E. GRABITZ, M. HILF et M. NETTESHEIM (dir.), *Das Recht der Europäischen Union*, 65. EL, C.H. Beck, Munich, août 2018, n° 313 et C.J., arrêt *Commission européenne c. République hellénique*, 8 novembre 2012, C-244/11, EU:C:2012:694, pts. 19 et s. (pour un seuil de 20 %) et C.J., arrêt *Marianne Scheunemann c. Finanzamt Bremerhaven*, 19 juillet 2012, EU:C:2012:481, C-31/11, pts. 25 et s. (pour un seuil de 25 %).

899 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *ibidem*, p. 538, n° 1078 et C.J., gde. ch., arrêt *Test Claimants in the FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue et The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*, 13 novembre 2012, C-35/11, EU:C:2012:707, pt. 94 ;

de la société scindée dans les sociétés bénéficiaires au sens de la nomenclature annexée à la directive (CEE) 88/361[900]. Cependant, il serait erroné d'arrêter l'analyse à ce stade. En effet, comme il est de jurisprudence constante que les catégories de la nomenclature annexée à la directive (CEE) 88/361 n'ont qu'une valeur indicative, mais en aucun cas exhaustive[901] et que les scissions transfrontalières constituent des opérations complexes dont les effets multiples ne se résument pas à un simple investissement[902], ces dernières pourraient très bien constituer une catégorie de mouvements de capitaux à part non reprise dans la nomenclature ou encore être visée par la catégorie « autres mouvements de capitaux », sous-catégorie « divers » de la nomenclature annexée à la directive (CEE) 88/361[903]. Ceci aurait pour conséquence que les scissions transfrontalières pourraient constituer des modalités particulières d'exercice de la libre circulation des capitaux indépendamment du taux de participation des associés de la société scindée dans les sociétés bénéficiaires. En l'absence de décision de la Cour de justice à ce sujet, il est impossible de déterminer quelle sera la ligne de conduite adoptée par celle-ci, même si la deuxième alternative présente le double avantage (i) d'être plus conforme à la nature complexe d'une scission et (ii) d'éviter de devoir baser l'analyse sur un élément factuel dépendant du rapport d'échange alors que celui-ci est susceptible d'évoluer en cours de procédure[904]. Dans un cas comme dans l'autre, il est indéniable qu'une scission transfrontalière est susceptible de relever de la libre circulation des capitaux des associés de la société scindée, ceux-ci faisant usage de leur liberté fondamentale en votant en faveur de l'opération lors de l'assemblée générale[905].

247. Société scindée et sociétés bénéficiaires. Du point de vue des sociétés bénéficiaires, la transmission à titre universel du patrimoine de la société scindée va constituer, dans le chef de celles-ci, une participation à une entreprise existante au sens de la nomenclature annexée à la directive (CEE) 88/361[906]. Cette interprétation doit être préférée à celle qui assimilerait une scission transfrontalière à la création d'une succursale visée également par la nomenclature

C.J., arrêt *Société de Gestion Industrielle (SGI) c. État belge*, 21 janvier 2010, C-311/08, EU:C:2010:26, pts. 33–37 et C.J.C.E., arrêt *Finanzamt Hamburg-Am Tierpark c. Burda GmbH*, 6 juin 2008, C-284/06, EU:C:2008:365, pts. 71 et 72.

900 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, pp. 144 et 145.

901 *Voir not. :* C.J., arrêt *Staatssecretaris van Financiën c. L. A. C. van Putten e.a.*, 26 avril 2012, C-578/10 à C-580/10, EU:C:2012:246, pt. 28 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Hein Persche c. Finanzamt Lüdenscheid*, 27 janvier 2009, C-318/07, EU:C:2009:33, pt. 24 ; C.J.C.E., arrêt *Héritiers de M. E. A. van Hilten-van der Heijden c. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen*, 23 février 2006, C-513/03, EU:C:2006:131, pt. 39 et C.J.C.E., arrêt *Manfred Trummer et Peter Mayer*, 16 mars 1999, C-222/97, EU:C:1999:143, pt. 21.

902 Voir *supra* Première partie, Titre I, Chapitre 4.

903 Point XIII, F de la nomenclature figurant à l'annexe I de la directive (CEE) 88/361 du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, *J.O.*, 8 juillet 1988, pp. 5–18.

904 Voir *infra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1er, Section 7, § 5 sur la possibilité de modification du rapport d'échange entre le dépôt du projet commun de scission et la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération et *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1er, Section 5, § 5 sur la possibilité de contestation du rapport d'échange par des actionnaires minoritaires.

905 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : A. WENG, *Durchführung und Zulässigkeit grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 145.

906 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. GÜNES, *op. cit.*, p. 216 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 94 et 95 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 92.

annexée à la directive (CEE) 88/361[907] dans la mesure où les sociétés bénéficiaires ne conserveront pas nécessairement une succursale en bonne et due forme dans l'État membre de la société scindée. La question est plus épineuse au sujet de la société absorbée dans la mesure où celle-ci est susceptible de disparaître par l'effet de l'opération. À l'égard des fusions transfrontalières, il a dès lors été défendu que comme la société absorbée disparaît dans l'opération et n'est par conséquent plus en mesure de gérer son investissement à l'avenir en vue d'en retirer des bénéfices personnels, une telle opération ne peut constituer dans son chef l'acquisition intégrale d'une entreprise ou la participation à une entreprise nouvelle ou existante[908]. Il s'agit là d'une conséquence de la définition de la notion d' « investissement direct » figurant dans les notes explicatives de l'annexe I de la directive (CEE) 88/361 et selon laquelle cette notion implique la création ou le maintien de relations durables et directes entre le bailleur de fonds et le bénéficiaire de l'apport[909]. Cet argument doit cependant être fortement nuancé. En effet, tout d'abord il convient de ne pas oublier que les catégories de la nomenclature n'ont qu'une valeur indicative et en aucun cas exhaustive[910], de sorte qu'une scission transfrontalière, tout comme une fusion transfrontalière, pourrait constituer une catégorie à part de « mouvements de capitaux » écartant *de facto* une exclusion sur la base de l'interprétation de la notion d' « investissement direct » dans le chef de la société absorbée. En effet, en tout état de cause, on ne comprend pas en quoi l'intention de la société scindée de procéder à une scission transfrontalière en plaçant tout ou partie de son patrimoine au sein de plusieurs entités bénéficiaires ne rentrerait pas dans la définition de « mouvements de capitaux » prônée par la Cour de justice dans sa jurisprudence en la matière[911]. Ensuite, plus fondamentalement, un tel raisonnement est incompatible avec l'hypothèse d'une scission partielle qui, par définition, n'implique pas la disparition de la société absorbée de sorte que la transmission par la société scindée d'une partie de son patrimoine à la société bénéficiaire crée des liens économiques durables entre les deux entités. Pour finir, outre le fait que l'Avocat général *Tizzano* n'a pas opéré une telle distinction dans ses conclusions[912], on est également en droit de s'interroger sur la compatibilité d'un tel raisonnement avec le rejet de la théorie du *corporate*

907 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : A. WENG, *Durchführung und Zulässigkeit grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p 143.

908 Voir en ce sens : M. GÜNES, *op. cit.*, p. 216 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 92 et A. WENG, *ibidem*, p. 142.

909 Selon les notes explicatives de l'annexe I de la directive (CEE) 88/361 du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, *J.O.*, 8 juillet 1988, pp. 5–18, la notion d' « investissements directs » recouvre des « investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques, les entreprises commerciales, industrielles ou financières et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et le chef d'entreprise ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique ».

910 *Voir not. :* C.J., arrêt *Staatssecretaris van Financiën c. L. A. C. van Putten e.a.*, 26 avril 2012, C-578/10 à C-580/10, EU:C:2012:246, pt. 28 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Hein Persche c. Finanzamt Lüdenscheid*, 27 janvier 2009, C-318/07, EU:C:2009:33, pt. 24 ; C.J.C.E., arrêt *Héritiers de M. E. A. van Hilten-van der Heijden c. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen*, 23 février 2006, C-513/03, EU:C:2006:131, pt. 39 et C.J.C.E., arrêt *Manfred Trummer et Peter Mayer*, 16 mars 1999, C-222/97, EU:C:1999:143, pt. 21.

911 C.J.C.E., arrêt *Graziana Luisi et Giuseppe Carbone c. Ministero del Tesoro*, 31 janvier 1984, C-286/82 et C-26/83, EU:C:1984:35, pt. 2.

912 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pts. 71 à 78.

suicide en matière de liberté d'établissement par la Cour de justice dans l'arrêt *Sevic*[913]. Ce point n'a pas échappé aux tenants de la théorie de l'exclusion de la société absorbée du bénéfice de la libre circulation des capitaux qui justifient tant bien que mal une telle différentiation par l'argument selon lequel un « investissement direct » ne produirait ses effets qu'à l'avenir, soit à un moment où la société apporteuse n'existerait déjà plus et ne serait donc plus en mesure de percevoir les fruits de son investissement alors que dans le cadre de la liberté d'établissement, l'exercice de la liberté d'établissement produit ses effets de manière concomitante à la disparition de la société absorbée[914]. Cette différence temporelle ne justifie toutefois pas une exclusion générale de la société absorbée du bénéfice de la libre circulation des capitaux ne fût-ce que parce qu' (i) elle n'envisage pas la possibilité qu'une scission constitue une modalité particulière d'exercice de la libre circulation des capitaux visée au point XIII, F de la nomenclature figurant à l'annexe I de la directive (CEE) 88/361 en raison du fait qu'à l'instar d'une fusion transfrontalière, elle est « indissolublement liée à un mouvement de capitaux »[915] et (ii) au moment où l'assemblée générale décide de procéder à l'opération, ce qui correspond au moment où la société exerce effectivement sa liberté fondamentale, elle existe toujours.

248. Quid en cas de scission par constitution de nouvelles sociétés ? Les développements ci-dessus doivent toutefois être nuancés dans l'hypothèse où la scission implique la constitution d'une nouvelle société, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'une scission partielle ou totale, d'une scission par constitution de nouvelle société ou encore d'une scission mixte. En effet, dans un tel cas, la création d'une nouvelle entité n'est que la conséquence de la réalisation de l'opération, impliquant par conséquent que celle-ci ne pourra se prévaloir de la libre circulation des capitaux puisqu'elle n'existera pas encore au moment de la prise de décision de procéder à l'opération[916]. En revanche, dans le chef de la société scindée, une telle opération pourrait constituer une forme d'exercice de la libre circulation des capitaux, soit en tant qu' « investissement direct », et plus précisément de participation à une nouvelle entreprise au sens de la nomenclature de la directive (CEE) 88/361[917], soit en tant que nouvelle catégorie de « mouvement de capitaux ».

249. Une modalité particulière d'exercice de la libre circulation des capitaux. Il découle de ce qui précède qu'une scission transfrontalière est susceptible de bénéficier de la protection de la libre circulation des capitaux consacrée par l'article 63 du TFUE[918]. Cependant, compte tenu du fait qu'une telle opération

913 À ce sujet, voir *supra* n° 150.

914 M. GÜNES, *op. cit.*, p. 216 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 92 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen, op. cit.*, 2008, pp. 142 et 143.

915 C.J.C.E., arrêt *Manfred Trummer et Peter Mayer*, 16 mars 1999, C-222/97, EU:C:1999:143, pt. 24 et Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 76.

916 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 93 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen, op. cit.*, p. 144.

917 Point I, B., troisième tiret de la nomenclature figurant à l'annexe I de la directive (CEE) 88/361 du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, *J.O.*, 8 juillet 1988, pp. 5–18.

918 Th. DELVAUX, obs. sous C.J.C.E., 13 décembre 2005, n° C-411/03 : « Fusion internationale et liberté de circulation », *J.T.*, 2006, p. 147 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 88 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 20, n° 16.

relève nécessairement également du champ d'application de la liberté d'établissement, il convient à présent d'analyser l'interaction entre la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement.

SECTION 4. L'ARTICULATION ENTRE LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

250. Une relation ambiguë au sein du TFUE. Il découle de ce qui précède que les scissions transfrontalières constituent à la fois une hypothèse particulière d'exercice de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux. Il reste toutefois encore à clarifier le rapport entre ces deux libertés fondamentales. À titre liminaire, on peut d'ores et déjà préciser que les dispositions du TFUE en la matière ne sont pas claires étant donné que l'art. 49, § 2 du TFUE semble établir la primauté de la libre circulation des capitaux[919], alors que l'art. 65, § 2 du TFUE paraît en revanche privilégier la liberté d'établissement[920]. Il est dès lors impossible à la seule lecture des dispositions du TFUE de déterminer si ces deux libertés fondamentales ont vocation à s'exclure mutuellement ou si une application cumulative est envisageable[921].

251. Les enseignements de la Cour de justice. De même, une analyse de la jurisprudence européenne en la matière ne s'avère pas être d'un grand secours dans la mesure où la Cour de justice, bien qu'elle ait eu à traiter un nombre considérable d'affaires où les deux libertés fondamentales avaient été invoquées cumulativement[922], ne se penche, comme établi de longue date[923], que

919 Selon l'art. 49, § 2 du TFUE, « [l]a liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ».

920 Selon l'art. 65, § 2 du TFUE, « [l]e présent chapitre [relatif aux paiements et aux capitaux] ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec les traités ». Voir en faveur d'une prééminence de la liberté d'établissement sur la libre circulation des capitaux sur cette base : St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, p. 166.

921 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, pp. 536 et 537, n° 1076 ; G. RESS et J. ÜKROW in E. GRABITZ, M. HILF et M. NETTESHEIM (dir.), *op. cit.*, n° 303 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, pp. 132 et 133.

922 Voir notamment : arrêt *Cadbury Schweppes* ; C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. Royaume d'Espagne*, 13 mai 2003, C-463/00, EU:C:2003:272 ; C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord*, 13 mai 2003, C-98/01, EU:C:2003:273 ; C.J.C.E., arrêt *Baars c. Inspecteur der Belastingen Particulieren/ Ondernemingen Gorinchem*, 13 avril 2000, C-251/98, EU:C:2000:205 et C.J.C.E., arrêt *Klaus Konle c. Republik Österreich*, 1er juin 1999, C-302/97, EU:C:1999:271.

923 *Voir notamment :* C.J., arrêt *Strojírny Prostějov, a.s., ACO Industries Tábor s.r.o. c. Odvolací finanční ředitelství*, 19 juin 2014, C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, pt. 24 ; C.J., gde. ch., arrêt *Test Claimants in the FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue et The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*, 13 novembre 2012, C-35/11, EU:C:2012:707, pt. 90 ; C.J., arrêt *Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH et Österreichische Salinen AG c. Finanzamt Linz*, 10 février 2011, C-437/08 et C-436/08, EU:C:2011:61, pt. 34 ; arrêt *Cadbury Schweppes*, pt. 33 et C.J.C.E., arrêt *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, 14 octobre 2004, C-36/02, EU:C:2004:614, pt. 27.

sur la liberté de circulation qu'elle juge la plus appropriée au cas d'espèce[924]. À cet égard, il découle d'une application par analogie des enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Sevic* aux scissions transfrontalières que ces dernières constituent en priorité des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement » dont la protection relève par conséquent en priorité de cette liberté. Il s'ensuit que toute atteinte connexe à la libre circulation des capitaux ne pourrait être que « la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement »[925], excluant *de facto* la nécessité d'examiner l'entrave sous ce second angle[926]. On peut donc partir du principe que dans l'hypothèse d'une entrave à une scission transfrontalière au sein de l'Union européenne, la Cour de justice ne l'abordera pas sous l'angle de la libre circulation des capitaux. Cette position serait cohérente non seulement avec les enseignements (i) de l'arrêt *Sevic* où la Cour n'a pas jugé nécessaire d'examiner la législation allemande sous l'angle de la libre circulation des capitaux et (ii) de l'arrêt *Überseering* où la Cour semble tracer une ligne de démarcation claire entre les situations de mobilité transfrontalière tombant dans le champ d'application de la liberté d'établissement et celles relevant de la libre circulation des capitaux[927].

SECTION 5. L'IMPACT SUR LES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES AVEC LES ÉTATS TIERS

252. Plan de la section 5. Afin de porter un jugement un jugement éclairé sur l'utilité de la libre circulation des capitaux afin de réaliser des scissions transfrontalières impliquant une ou plusieurs sociétés relevant du droit d'États tiers, il convient de se prononcer sur la nécessaire application alternative de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux (§ 1), d'exposer tant les deux limites propres à l'exercice de la libre circulation des capitaux

924 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 87 ; P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 276 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen, op. cit.*, p. 136. Voir également : P.-Chr. MÜLLER – GRAFF, *op. cit.*, p. 493 pour la prééminence de la liberté d'établissement en matière de mobilité des sociétés.

925 C.J.C.E., arrêt *Finanzamt Hamburg-Am Tierpark c. Burda GmbH*, 6 juin 2008, C-284/06, EU:C:2008:365, pt. 74 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Oy AA*, 18 juillet 2007, C-231/05, EU:C:2007:439, pt. 24 ; C.J.C.E., ord. *Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH c. Finanzamt Emmendingen*, 10 mai 2007, C-492/04, EU:C:2007:273, pt. 25 et arrêt *Cadbury Schweppes*, pt. 33.

926 C.J.C.E., arrêt *Finanzamt Hamburg-Am Tierpark c. Burda GmbH*, 6 juin 2008, C-284/06, EU:C:2008:365, pt. 74 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Oy AA*, 18 juillet 2007, C-231/05, EU:C:2007:439, pt. 24 ; C.J.C.E., ord. *Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH c. Finanzamt Emmendingen*, 10 mai 2007, C-492/04, EU:C:2007:273, pt. 25 et arrêt *Cadbury Schweppes*, pt. 33 et en ce sens : G. RESS et J. ÜKROW in E. GRABITZ, M. HILF et M. NETTESHEIM (dir.), *op. cit.*, n° 307.

927 Arrêt *Überseering*, pt. 77 où la Cour a précisé qu' « [i]l convient, par ailleurs, de rappeler qu'en principe l'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques résidant dans un État membre de parts dans une société constituée et établie dans un autre État membre de parts dans une société constituée et établie dans un autre État membre relève, dès lors qu'une telle participation ne confère pas à ces personnes physiques une influence certaine sur les décisions de la société et ne leur permet pas d'en déterminer les activités, des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux. En revanche, dès lors que l'acquisition porte sur la totalité des parts d'une société ayant son siège statutaire dans un autre État membre et qu'une telle participation confère une influence certaine sur les décisions de la société et leur permet d'en déterminer les activités, ce sont les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement qui trouvent à s'appliquer ».

impliquant des États tiers (§ 2) que les dérogations générales affectant la libre circulation des capitaux (§ 3) et de mettre en lumière la politique jurisprudentielle restrictive de la Cour de justice en la matière (§ 4).

§1. Une application alternative de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux ?

253. Au-delà de la liberté d'établissement. Si la primauté de la liberté d'établissement dans l'hypothèse d'une situation purement intracommunautaire est certes établie, il n'en demeure pas moins que la libre circulation, de par son effet *erga omnes*, dispose d'un champ d'application *ratione loci* plus vaste. On pourrait dès lors penser qu'une mesure nationale entravant une scission transfrontalière entre des sociétés situées en partie dans un État membre et en partie dans un État tiers devrait être interdite sur la base de la libre circulation des capitaux, alors que dans l'hypothèse d'une scission purement intracommunautaire, il conviendrait de recourir à la liberté d'établissement en raison de sa primauté en la matière. Cependant, cette assertion se doit d'être fortement limitée, premièrement parce que le TFUE contient deux restrictions spécifiques à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un pays tiers, deuxièmement en raison de l'existence de dérogations générales propres à l'exercice de la libre circulation des capitaux et, troisièmement, en raison de la politique jurisprudentielle de la Cour de justice.

§2. Deux limites propres à l'exercice de la libre circulation des capitaux impliquant un État tiers

254. La « *clause de stand still* » de l'article 64, § 1er du TFUE. L'effet *erga omnes* de la libre circulation des capitaux doit être relativisé par l'application de la « *clause de stand still* » ou « clause de gel » contenue à l'article 64, § 1er du TFUE[928] et qui vise tous les « investissements directs »[929]. En vertu de cet article, toutes les restrictions à la libre circulation entre un État membre et un État tiers existant au 31 décembre 1999 pour la Bulgarie, l'Estonie et la Hongrie et au 31 décembre 1993 pour les autres États membres ne peuvent être remises en question sur la base de la libre circulation des capitaux. L'impact de cette clause ne doit pas être sous-estimé non seulement parce qu'elle est interprétée par la Cour de justice comme visant à la fois les mesures législatives faisant partie intégrante de « l'ordre juridique de l'État membre concerné d'une manière ininterrompue depuis cette date »[930] et « les dispositions qui, dans

928 Selon l'article 63, § 1er du TFUE, « [l]'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999 ».

929 C.J., arrêt *Yvon Welte c. Finanzamt Velbert*, 17 octobre 2013, C-181/12, EU:C:2013:662, pt. 29.

930 C.J., arrêt *SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA c. Fazenda Pública*, 24 novembre 2016, C-464/14, EU:C:2016:896, pt. 81.

leur substance, sont identiques à une législation antérieure ou qui se bornent à réduire ou à supprimer un obstacle à l'exercice des droits et des libertés communautaires figurant dans la législation antérieure »[931], mais également parce qu'elle a bénéficié d'une interprétation assez extensive de la Cour de justice qui a considéré, notamment, que pour l'application de cette clause, les Iles Vierges britanniques devaient être considérées comme un État tiers[932]. Du point de vue des scissions transfrontalières, on peut en tirer comme conclusion que si (i) celles-ci devaient tomber dans la catégorie des « investissements directs » et si (ii) un État membre s'est toujours opposé à la réalisation de telles opérations avec une société relevant du droit d'un État tiers, que ce soit au moyen d'une disposition légale expresse ou par une simple pratique judiciaire continue, on ne pourra se baser sur la libre circulation des capitaux pour ouvrir ce type de restructuration. Cette conclusion s'impose quand bien même tant les scissions internes que les scissions transfrontalières purement intracommunautaires seraient reconnues dans l'État membre en question.

255. Les mesures de sauvegarde exceptionnelles. Au-delà de cette première limite s'ajoute le fait que l'article 66 du TFUE autorise le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard des pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires et uniquement lorsqu'en cas de circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire. Il convient toutefois de préciser que cette exception n'a encore jamais été utilisée[933].

§ 3. Les dérogations générales

256. L'importance de la condition de proportionnalité. Une des spécificités du régime de la libre circulation des capitaux par rapport à celui de la liberté d'établissement est que l'article 65, § 1er du TFUE prévoit un certain nombre de dérogations générales au principe de l'interdiction des entraves à la libre circulation des capitaux. Les États membres jouissent ainsi de la possibilité (i) « d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis » et (ii) « de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins

931 C.J., arrêt *SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA c. Fazenda Pública*, 24 novembre 2016, C-464/14, EU:C:2016:896, pt. 88 ; C.J.C.E., arrêt *Winfried L. Holböck c. Finanzamt Salzburg-Land*, 24 mai 2007, C-157/05, EU:C:2007:297, pt. 41 et C.J.C.E., gde ch., arrêt *Test Claimants in the FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue*, 12 décembre 2006, C-446/04, EU:C:2006:774, pt. 192.

932 C.J., arrêt *Prunus SARL, Polonium SA c. Directeur des services fiscaux*, 5 mai 2011, C-384/09, EU:C:2011:276, pt. 31.

933 P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 145.

d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique ». Il est certes vrai que ces dérogations concernent aussi bien les mouvements de capitaux intra-européens que ceux impliquant un État tiers. Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que pour être admises, de telles restrictions doivent être notamment proportionnées[934]. Or, il s'avère que cette condition de proportionnalité est appréciée de façon divergente en fonction de l'implication ou non d'un État tiers en cas de restriction de nature fiscale[935]. Cette sévérité accrue en matière fiscale, qui se justifie par l'absence de mesures de coopération fiscale[936], a pour effet de relativiser encore davantage l'intérêt de la protection des scissions transfrontalières par la libre circulation des capitaux, *a fortiori* si on prend en compte le fait que de telles opérations sont principalement réalisées pour des motifs fiscaux[937].

§4. Une politique jurisprudentielle restrictive

257. La jurisprudence de la Cour de justice en la matière. Il ressort très clairement d'une analyse de la jurisprudence de la Cour de justice dans les affaires impliquant un État tiers et susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la libre circulation des capitaux que cette dernière fait l'objet d'une interprétation très restrictive et n'est généralement pas appliquée si, dans les faits en cause, la liberté de circulation des capitaux est secondaire par rapport à une autre liberté qui aurait trouvé à s'appliquer si l'affaire avait été purement intra-européenne[938]. Plus précisément, en cas de concurrence entre liberté d'établissement et libre circulation des capitaux, la Cour de justice a considéré que « dès lors que le traité n'étend pas la liberté d'établissement aux pays tiers,

934 C.J., arrêt *Établissements Rimbaud SA c. Directeur général des impôts et Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence*, 28 octobre 2010, C-72/09, EU:C:2010:645, pt. 33 ; C.J.C.E., arrêt *Skatteverket contre A.*, 18 décembre 2007, C-101/05, EU:C:2007:804, pt. 56 et C.J.C.E., arrêt *Marks & Spencer plc c. David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes)*, 13 décembre 2005, C-446/03, EU:C:2005:763, pt. 35.

935 Voir en ce sens : A. MAITROT DE LA MOTTE, « Les spécificités de la libre circulation des capitaux : l'exemple de la contestation des entraves fiscales » in *L'unité des libertés de circulation*, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 322 et C.J.C.E., arrêt *Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (ELISA) c. Directeur général des impôts et Ministère public*, 11 octobre 2007, C-451/05, EU:C:2007:594, pts. 98 à 100 où la Cour de justice a jugé qu'une réglementation française visant à lutter contre l'évasion fiscale était une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux entre la France et le Luxembourg et C.J., arrêt *Établissements Rimbaud SA c. Directeur général des impôts et Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence*, 28 octobre 2010, C-72/09, EU:C:2010:645, pts. 50 à 52 où la Cour a jugé que cette même réglementation fiscale constituait une entrave justifiée à la libre circulation des capitaux entre la France et le Liechtenstein en raison du fait que ce dernier, contrairement au Luxembourg, n'était pas soumis aux dispositions de la directive (CE) 77/799 du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects.

936 Voir en ce sens : A. MAITROT DE LA MOTTE, *op. cit.*, pp. 322 et 323, n°s 31 et 32.

937 European Commission – Feedback Statement – Summary of responses to the public consultation on cross border mergers and divisions, October 2015, http://ec.europa.eu/internal_market/ (11/03/2016) (ci-après la « **Consultation publique de 2015** »), p. 19 et *supra* n° 64.

938 *Voir en ce sens :* C.J.C.E., ord. *Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH c. Finanzamt Emmendingen*, 10 mai 2007, C-492/04, EU:C:2007:273, pt. 25 ; C.J.C.E., ord. *Skatteverket c. À et B*, 10 mai 2007, C-102/05, EU:C:2007:275, pts. 21 et 22 et C.J.C.E., arrêt *Fidium Finanz AG c. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, 3 octobre 2006, C-452/04, EU:C:2006:631, pt. 34.

il importe d'éviter que l'interprétation de l'article 63, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne les relations avec les pays tiers, permette à des opérateurs économiques qui ne rentrent pas dans les limites du champ d'application territorial de la liberté d'établissement de tirer profit de celle-ci »[939]. Or, dans le cas d'une mesure nationale restreignant les scissions transfrontalières, il découle de l'arrêt *Sevic* que la liberté d'établissement serait plus que vraisemblablement considérée comme principale[940] et qu'un examen sous l'angle de la libre circulation des capitaux aurait pour conséquence de permettre à des opérateurs économiques se trouvant hors du champ d'application *ratione loci* de la liberté d'établissement de bénéficier de celle-ci. Il s'ensuit qu'un examen autonome de la mesure en cause au regard de la libre circulation des capitaux ne se justifierait pas, même dans un cas d'espèce impliquant un État tiers.

SECTION 6. CONCLUSION SUR LES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES SOUS L'ANGLE DE LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

258. L'écartement de la libre circulation des capitaux. Si une scission transfrontalière est susceptible de relever du champ d'application *ratione materiae* de la libre circulation des capitaux soit en tant qu' « investissement direct », soit en tant qu' « autre mouvement de capitaux » et si tant la société scindée que la société bénéficiaire, à l'exception des nouvelles sociétés, entrent dans son champ d'application *ratione personae*, force est de constater que son intérêt concret pour les scissions transfrontalières est fortement limité. Tout d'abord, dans une situation purement intra-européenne, la Cour de justice aura tendance à considérer que la libre circulation des capitaux est accessoire par rapport à la liberté d'établissement, excluant *de facto* un examen sous l'angle de cette première liberté fondamentale. Un examen sous l'angle de la libre circulation des capitaux aurait malgré tout pu avoir un intérêt pour les scissions transfrontalières impliquant une société établie dans un pays tiers en raison de son champ d'application *ratione loci* beaucoup plus vaste que celui de la liberté d'établissement, mais (i) la « *clause de standstill* » de l'art. 64, § 1er du TFUE, (ii) la possibilité pour le Conseil d'adopter des mesures de sauvegarde exceptionnelles, (iii) l'existence de dérogations générales au principe de l'interdiction des entraves à la libre circulation des capitaux dont la proportionnalité en matière fiscale est appréciée de manière moins stricte lorsqu'un État tiers est impliqué et (iv) le fait que la Cour de justice aurait tendance à considérer que le recours à la libre circulation des capitaux permettrait d'étendre artificiellement le champ d'application *ratione loci* de la liberté d'établissement viennent démentir cette idée. Il s'ensuit que la libre circulation des capitaux ne présente pas d'intérêt pratique pour les scissions transfrontalières.

939 C.J., arrêt *Kronos International Inc. c. Finanzamt Leverkusen*, 11 septembre 2014, C-47/12, EU:C:2014:2200, pt. 53 et C.J., gde. ch., arrêt *Test Claimants in the FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue et The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*, 13 novembre 2012, C-35/11, EU:C:2012:707, pt. 100.

940 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 78 ; M. GÜNES, *op. cit.*, p. 216 et St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, pp. 166 et 167.

259. Appréciation critique. Compte tenu de l'intérêt économique indéniable des scissions transfrontalières pour les entreprises dans un monde de plus en plus globalisé qui a été démontré précédemment[941], l'inapplicabilité de la libre circulation des capitaux aux scissions transfrontalières impliquant une personne morale située dans un pays tiers peut paraître regrettable de prime abord. Cependant, ce tableau doit être relativisé à la lumière du fait que les scissions sont susceptibles d'impacter des *stakeholders* très variés[942]. Il en découle que les normes nationales destinées à régir les scissions transfrontalières n'auront par définition pas pour seul objectif de protéger les investisseurs, mais également d'autres intéressés, tels que les créanciers sociaux ou les travailleurs. Or, une appréciation de ces normes nationales à l'aune de la libre circulation des capitaux aurait pour conséquence que dès qu'une norme nationale privilégierait les intérêts de certains tiers intéressés par rapport aux intérêts des investisseurs, elle constituerait une violation de la libre circulation des capitaux. À cet égard, il est important de relever qu'une entrave à la libre circulation des capitaux ne présuppose pas l'existence d'une discrimination sur la base de la nationalité[943] mais sera reconnue dès qu'une mesure nationale « entrave actuellement ou potentiellement, directement ou indirectement, la libre circulation des capitaux »[944]. Cette conséquence négative est encore aggravée par le fait que les causes de justification, et plus précisément les raisons impérieuses d'intérêt général, reconnues par la Cour de justice en matière de libre circulation des capitaux sont trop restreintes et ne parviennent pas à recouvrir la convergence d'intérêts parfois opposés qu'implique une scission transfrontalière[945]. En effet, même si, à titre d'illustration, la protection des créanciers[946] ou des associés minoritaires[947] a déjà été reconnue par la Cour de justice comme une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre circulation des capitaux, de telles restrictions ne peuvent être admises que si elles s'appliquent de manière non-discriminatoire[948]. Or, une telle condition méconnaît que les opérations transfrontalières sont susceptibles d'être

941 Voir *infra* Première partie, Titre I, Chapitre 2.

942 À ce sujet, voir Deuxième Partie.

943 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *ibidem*, p. 541, n° 1083 et C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République française*, 4 juin 2002, C-483/99, EU:C:2002:327, pt. 40 où la Cour a considéré que l'interdiction des entraves à la libre circulation des capitaux « va au-delà de l'élimination d'un traitement inégal des opérateurs sur les marchés financiers en raison de leur nationalité ».

944 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *ibidem*, pp. 541 et 542, n° 1083 et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 141.

945 Voir en ce sens : P. BÖCKLI, P. DAVIES, E. FERRAN, G. FERRARINI, J. GARRIDO, K. HOPT, Al. PIETRANCOSTA, K. PISTOR, R. SKOG, St. SOLTYNSINSKI, J. WINTER et Ed. WYMEERSCH, *op. cit.*, p. 5. Pour une liste exemplative des raisons impérieuses d'intérêt général reconnues par la Cour de justice voir : A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *ibidem*, pp. 545 et 546, n° 1095–1097 et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, pp. 147 et 148.

946 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, pp. 547 et 548, n° 1095 et C.J.C.E., arrêt *Manfred Trummer et Peter Mayer*, 16 mars 1999, C-222/97, EU:C:1999:143, pt. 30.

947 F. PICOT, « Investissements et libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne », *RAE*, 2014/4, p. 682 et C.J.C.E., C.J.C.E., gde ch., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République fédérale d'Allemagne*, 23 octobre 2007, C-112/05, EU:C:2007:623, pts. 77–79.

948 A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, p. 547, n° 1095 et C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. Royaume de Belgique*, 4 juin 2002, C-503/99, EU:C:2002:328, pt. 45 et C.J.C.E., arrêt *Klaus Konle c. Republik Österreich*, 1er juin 1999, C-302/97, EU:C:1999:271.

fortement plus dommageables pour certains *stakeholders* que les opérations internes en raison notamment de l'adoption d'une *lex societatis* potentiellement moins protectrice à leur égard. Même si la Cour de justice semble avoir abandonné cette condition[949] et considère que des mesures directement ou indirectement discriminatoires peuvent être justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général, force est de constater qu'il en résulte malgré tout une certaine insécurité juridique. Par conséquent, même si la protection des scissions transfrontalières par la libre circulation des capitaux aurait pu être intéressante dans un souci de mobilité globale des entreprises, une telle évolution n'est pas souhaitable, ne fût-ce que dans l'intérêt des *stakeholders* et de la sécurité juridique.

949 *Pro* : P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 148 et C.J., arrêt *Staatssecretaris van Financiën c. L. A. C. van Putten e.a.*, 26 avril 2012, C-578/10 à C-580/10, EU:C:2012:246, pt. 44. *Contra* : A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, p. 547, n° 1095 et L. VOGEL, « Titre 3 – Libre circulation des capitaux » in *Traité de droit économique – Tome 4 : Droit européen des affaires*, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 310 et 311 et C.J.C.E, gde ch., arrêt Commission des Communautés européennes c. République italienne, 19 mai 2009, C-531/06, EU:C:2009:315, pt. 49 ; C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. Royaume de Belgique*, 4 juin 2002, C-503/99, EU:C:2002:328, pt. 45 et C.J.C.E., arrêt *Klaus Konle c. Republik Österreich*, 1er juin 1999, C-302/97, EU:C:1999:271. Voir également : F. PICOT, *op. cit.*, p. 680 qui fait état de l'incohérence de la Cour de justice à cet égard et qui appelle à une clarification jurisprudentielle.

Conclusion sur les scissions transfrontalières sous l'angle des libertés fondamentales

260. *Pathfinder*, mais sans plus. Si l'harmonisation négative (*bottom-up*) opérée par la Cour de justice par le biais de sa jurisprudence en matière de liberté d'établissement permet de pallier partiellement aux déficiences de l'harmonisation positive livrée aux aléas de la politique européenne et a l'avantage d'être perçue comme moins intrusive par les États membres qu'une mesure législative[950], les principes fondamentaux posés par la Cour de justice en matière de libertés fondamentales devront nécessairement être complétés par un régime juridique spécifique instauré soit par les législateurs nationaux et cristallisé par le jeu de la concurrence réglementaire, soit par le législateur communautaire au moyen de l'adoption d'une norme de droit dérivé[951]. En effet, si l'applicabilité de la liberté d'établissement aux modes de restructurations transfrontalières – qu'il s'agisse de scissions, de fusions ou encore de transformations – n'est pas conditionnée par l'adoption de normes de droit dérivé[952], il n'appartient pas à la Cour de justice de se substituer au législateur national ou européen en adoptant des règles de droit positif. En d'autres termes, la construction de la mobilité européenne des personnes morales requiert le concours tant du droit primaire sous la forme de la liberté d'établissement pour écarter les obstacles dressés par les différents droits nationaux que du droit secondaire pour instaurer un régime spécifique tenant compte des difficultés concrètes posées par ce type d'opérations et offrant un niveau de sécurité juridique adéquat[953]. Cette nécessité d'une approche bicéphale est étayée par des données chiffrées recueillies par la Commission européenne qui révèlent que si les scissions internes ont été particulièrement fréquentes en pratique au courant des cinq années ayant précédé la consultation publique de 2015[954], on estime qu'il n'y a eu qu'entre 50 et 200 opérations de scission transfrontalière au sein de l'Union européenne en 2016[955]. Une telle différence s'explique nécessairement en partie par l'insécurité juridique affectant ce type d'opérations et ce, malgré les précieux enseignements de la Cour de justice en la matière[956]. Ceci étant, la dynamique de mobilité transfrontalière initiée par la jurisprudence de la Cour de justice représente une avancée majeure dans la consécration des scissions transfrontalières au sein de l'Union européenne.

950 Voir en ce sens : M. BLAUBERGER et S. SCHMIDT, « The European Court of Justice and its political impact », *West European Politics*, 2017, p. 913 et Chr. KNILL et D. LEHMKUHL, « The National Impact of European Union Regulatory Policy: Three Europeanization Mechanisms », *European Journal of Political Research*, 2002, p. 258.

951 Voir en faveur d'une intervention législative complémentaire à la jurisprudence de la Cour de justice : V. GEYRHALTER et Th. WEBER, *op. cit.*, p. 147 ; St. KAPPES, « Zulässigkeit grenzüberschreitender Verschmelzungen », *NZG*, 2006, p. 103 et Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 360. *Contra* : Th. KUNTZ, *op. cit.*, p. 528.

952 Arrêt *Sevic*, pt. 26 ; arrêt *Überseering*, pt. 55 et arrêt *Centros*, pt. 28.

953 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 45 et Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, pp. 359 et 360.

954 Sur la base de la consultation publique réalisée en 2015 et d'informations fournies par les différents registres nationaux, il y a eu environ 700 scissions internes par an au Danemark au cours des cinq années précédentes, plus d'un millier en France, environ 500 en Pologne et en Estonie, environ 200 en Finlande, Lituanie et Suède et environ 150 en Belgique. Voir Étude d'impact, p. 23, note 81.

955 Étude d'impact, p. 23.

956 Étude d'impact, p. 23.

TITRE III
Les scissions transfrontalières : entre droit international privé et initiatives nationales

SOMMAIRE

Introduction du titre III 231
Chapitre 1. Les principes de droit international privé appliqués aux scissions transfrontalières 235
Chapitre 2. Initiatives nationales en matière de scissions transfrontalières 271
Conclusion sur les principes de droit international privé et les initiatives nationales en matière de scissions transfrontalières 281

Introduction du titre III

261. Plan du titre III. Face à l'incapacité des libertés fondamentales à faire des scissions transfrontalières une réalité au sein du marché intérieur, il est temps de se tourner vers les principes de droit international privé applicables aux scissions transfrontalières et les solutions développées par la doctrine pour résoudre les différents conflits de lois susceptibles d'apparaître dans le cadre d'une scission transfrontalière (chapitre 1), pour ensuite se tourner vers les initiatives nationales en la matière (chapitre 2).

Chapitre 1
Les principes de droit international privé appliqués aux scissions transfrontalières

SECTION 1. PRÉSENTATION

262. Une dimension supranationale. Par définition, une scission transfrontalière impliquera nécessairement que la société scindée et au moins une des sociétés bénéficiaires se trouvent soumises au droit de deux États distincts[957]. Il s'ensuit qu'au moins deux ordres juridiques séparés auront vocation à régir les différentes facettes d'une opération de scission qui devra, malgré tout, rester caractérisée par une certaine unicité[958]. Ainsi, une fois clarifiées les questions de la capacité générale et de la capacité concrète de scission des sociétés impliquées (sections 2 et 3), il conviendra d'examiner en détail les différentes théories développées en droit international privé pour résoudre les nombreux conflits de lois susceptibles de se présenter au cours de l'opération (section 4), pour ensuite poursuivre par une brève analyse des aspects d'une scission transfrontalière ne relevant pas de la seule *lex societatis* (section 5).

SECTION 2. LA CAPACITÉ GÉNÉRALE OU ACTIVE DE SCISSION

263. Une transposition à géométrie variable de la Directive Sociétés. La première question à analyser est celle de savoir si les différents droits nationaux reconnaissent ce mode spécifique de restructuration à tout le moins dans un contexte purement national. Ceci équivaut à vérifier si les sociétés disposent de la capacité générale de se scinder[959], également appelée capacité active[960]. En effet, à la grande différence des fusions internes et transfrontalières de sociétés[961], la Directive Sociétés n'a pas imposé aux États membres de nécessairement reconnaître la figure de la scission interne[962]. Il s'ensuit qu'en dehors du champ d'application *ratione materiae* limité de la Directive Mobilité[963], une telle opération sera impossible *ab initio* si au moins un des États membres impliqués a fait le choix de ne pas reconnaître ce type d'opérations[964].

957 À ce sujet, voir *supra* n°s 121 à 123.
958 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 60.
959 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 90 et Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD, *op. cit.*, Einleitung C, n° 16.
960 U. LENNERZ, *Die internationale Verschmelzung und Spaltung unter Beteiligung deutscher Gesellschaften* ; Köln, 2001, p. 153.
961 Art. 87 et 118 de la Directive Sociétés.
962 Art. 135 de la Directive Sociétés et Projet de rapport du 15 décembre 2016 de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières, (2016/2065(INI)), www.europarl.europa.eu (08/03/2017), p. 10 et P. VAN OMMESLAGHE, « Les principes généraux… », *op. cit.*, p. 17.
963 À ce sujet, voir *infra* n°s 341 à 346.
964 Voir en ce sens : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, Einleitung C, n° 16 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, pp. 53 et 54.

SECTION 3. LA CAPACITÉ CONCRÈTE DE SCISSION

264. L'incidence de la forme sociale. Une fois vérifiée la capacité générale ou active de scission, il convient d'examiner si les différentes sociétés impliquées jouissent de la capacité concrète ou passive de scission. Ceci signifie que pour qu'une opération de scission transfrontalière puisse être envisagée, il faut que les différentes *lex societatis* autorisent la scission entre les différentes formes de sociétés impliquées[965]. Cette question est loin d'être anodine étant donné que les dispositions de la Directive Sociétés relatives aux scissions internes[966], à l'instar de celles applicables aux fusions internes[967], ne traitent que des sociétés anonymes. Par conséquent, rien n'empêche un État membre d'interdire les scissions hétérogènes ou même de réserver ce type d'opérations aux seules sociétés anonymes. À ce premier risque de transposition asymétrique s'ajoute encore le fait que la Directive Sociétés permet aux États membres d'exclure du bénéfice des scissions internes les sociétés coopératives[968] ainsi que celles qui font l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat ou d'une procédure analogue[969]. Cette question de la capacité concrète ou passive de scission relèvera, en tout état de cause et à l'instar de la capacité générale ou active de scission, exclusivement des différentes *lex societatis* en présence appliquées distributivement[970] et ce, en raison du fait que la possibilité de réaliser une scission touche à l'existence d'une société, ce qui, de jurisprudence constante[971], relève de la seule compétence des États membres[972].

SECTION 4. LES RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS APPLICABLES

§1. Un conflit de lois omniprésent

265. Une situation de conflit de lois par définition. Une opération de scission transfrontalière mettra, par définition, toujours en concurrence au moins deux *lex societatis* distinctes[973]. De plus, par rapport à la fusion transfrontalière, une scission transfrontalière présente, pour peu qu'elle ne soit pas partielle, la difficulté additionnelle de mettre plus régulièrement en conflit le droit de trois États membres distincts, dans la mesure où le patrimoine de la société scindée doit être réparti entre au moins deux sociétés bénéficiaires, chacune étant susceptible de relever d'un droit national distinct.

965 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 26 et U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 158 et, pour les fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 135 ; J. RICKFORD, « The proposed tenth Company Law Directive on cross border mergers and its impact in the UK », *EBLR*, 2005, n° 16, p. 1402 et A. WENG, *ibidem*, p. 53.
966 Art. 135, § 1 de la Directive Sociétés.
967 Art. 87, § 1 de la Directive Sociétés.
968 Art. 87, § 2 et 135, § 4 de la Directive Sociétés.
969 Art. 87, § 3 et 135, § 4 de la Directive Sociétés.
970 A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 53.
971 Arrêt *Vale*, pt. 27 ; arrêt *Cartesio*, pt. 104 et arrêt *Daily Mail*, pt. 19.
972 Voir en ce sens essentiellement à propos des fusions transfrontalières : A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 53.
973 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 530, n° 745.

§2. Les différentes théories

266. Plan du § 2. Dans le cadre de l'étude des règles de conflit de lois applicables aux scissions transfrontalières, sept théories méritent d'être exposées successivement, à savoir le principe de la primauté du droit de la société scindée (A), le principe de la primauté du droit des sociétés bénéficiaires (B), l'application tantôt cumulative, tantôt distributive des droits des sociétés impliquées (C), la théorie de Lennerz (D), la théorie de la concordance (E), la solution reconnue en droit international privé suisse (F) et l'application par analogie du régime des fusions transfrontalières (G).

A. *La primauté du droit de la société scindée (*Übertragungstheorie*)*

267. Une théorie simple mais irréaliste. La théorie qui consacre la primauté de la *lex societatis* de la société scindée, connue sous le terme d'*Übertragungstheorie* en droit allemand et en droit autrichien, présente l'avantage de l'unicité, même lorsque les différentes sociétés bénéficiaires relèvent de *lex societatis* distinctes et s'avère indéniablement facilement acceptable tant pour les juridictions que pour l'administration de la société scindée. De plus, elle a été défendue et appliquée par l'*Oberste Gerichtshof* autrichien dans une décision concernant une fusion par absorption d'une société de droit autrichien par sa société mère soumise au droit allemand[974]. Le recours à cette théorie a été justifié par le fait que les règles qui entourent l'acquisition et la perte de la personnalité juridique sont en principe déterminées par la *lex societatis* de la société scindée[975]. Cependant, consacrer cette théorie qui consiste à écarter purement et simplement le droit des diverses sociétés issues de l'opération revient à renier l'existence de spécificités propres aux scissions transfrontalières dont l'essence est de mettre en concurrence plusieurs ordres juridiques distincts. Cette insuffisance est également mise en lumière par l'*Oberste Gerichtshof* autrichien qui, afin d'éviter de devoir se prononcer sur l'admissibilité d'une fusion transfrontalière simplifiée du point de vue du droit autrichien, à l'instar des deux premières juridictions, a préféré au contraire considérer qu'il s'agissait en réalité d'une transformation de la société autrichienne par transmission de l'entreprise à l'associé unique, opération certes inconnue du droit allemand mais dont la soumission exclusive au droit autrichien ne faisait aucun doute[976]. Si cette solution a certes l'avantage de présenter une apparente simplicité, il lui a été reproché d'aboutir à un résultat déséquilibré[977]. Au-delà de cela, on est en droit de s'interroger sur sa logique intrinsèque et sur son acceptabilité pour les différents États membres. En effet, s'il est vrai que d'une part, il est concevable que tant le principe de la transmission universelle de patrimoine

974 Oberster Gerichtshof Österreichs, 20 mars 2003, 6OB283/02i, disponible sur www.ris.bka.gv.at (04/05/2017), pp. 1–17.

975 Oberster Gerichtshof Österreichs, 20 mars 2003, 6OB283/02i, disponible sur www.ris.bka.gv.at (04/05/2017), p. 10.

976 Oberster Gerichtshof Österreichs, 20 mars 2003, 6OB283/02i, disponible sur www.ris.bka.gv.at (04/05/2017), p. 9.

977 U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 138 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 25 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 55.

que les différents mécanismes de protection qui en découlent relèvent de la *lex societatis* de la société scindée[978] et que d'autre part, les conditions d'existence et de transformation de la société scindée relèvent de la loi de celle-ci, il n'en va pas de même pour bon nombre d'autres aspects d'une scission comme le contrôle de conformité[979], les conditions relatives à l'approbation de l'opération par les assemblées générales des sociétés bénéficiaires[980] ou encore les conditions relatives à la constitution des sociétés bénéficiaires en cas de scission par constitution de nouvelles sociétés. De plus, le fait d'écarter les mécanismes de protection prévus par le droit national des sociétés issues de la scission heurte les principes de droit international privé en ce que la souveraineté nationale d'un État s'en trouve violée[981] et, de surcroît, va avoir pour conséquence que ce dernier va s'opposer à la réalisation de l'opération[982].

268. Illustration : une opération de scission par constitution de nouvelles sociétés. Pour se convaincre de l'inadéquation de cette théorie, il suffit d'envisager l'hypothèse d'une scission d'une société située dans un premier État membre par constitution de nouvelles sociétés dans un autre État membre imposant des règles relatives au capital social minimum beaucoup plus strictes que le premier. Ainsi, si le premier État autorise la constitution d'une société à responsabilité limitée avec un capital social de douze mille euros alors que le deuxième impose un capital social minimum de dix-huit mille euros, il est évident que ce dernier refusera d'enregistrer la constitution de deux nouvelles sociétés à responsabilité limitée issues d'une scission transfrontalière si celles-ci ont un capital social de quatorze mille euros et ce, alors même qu'elles respecteraient les conditions imposées par la *lex societatis* de la société scindée.

B. *La primauté du droit des sociétés bénéficiaires* (Aufnahmetheorie)

269. Des insuffisances marquées en plus d'une méconnaissance des spécificités d'une opération de scission. Cette théorie, qui postule la primauté du droit des sociétés bénéficiaires, est sujette aux mêmes critiques que celle qui, au contraire, prônait de privilégier la *lex societatis* de la société scindée. Tout comme celle-ci, elle méconnaît le caractère complexe d'une scission transfrontalière dont les différentes étapes et conséquences ne peuvent être régies intégralement par une seule *lex societatis*[983]. De plus, et c'est là une des objections majeures que l'on peut formuler à l'encontre de cette théorie, elle aurait pour conséquence que la dissolution de la société scindée serait, contrairement aux principes de droit international privé, déterminée par une loi

978 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 533, n° 748.
979 À ce sujet, voir *infra* n°s 642 à 655.
980 À ce sujet, voir *infra* n°s 617 à 638.
981 E. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 344 et 345.
982 Ci. KRAUSE, *Die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften im deutschen und französischen Recht*, Berlin, W. de Gruyter, 1966, p. 12 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 26 ; Th PRÜM, *op. cit.*, p. 58 ; A. REIK, *op. cit.*, p. 240 et Th. ZIEGLER, *Gesellschafts- und Steuerrechtliche Probleme der Fusion zwischen deutschen und französischen Aktiengesellschaften*, thèse, Tübingen, 1997, p. 5.
983 Th PRÜM, *ibidem*, p. 58 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 43.

autre que sa *lex societatis*[984]. À cela s'ajoute encore le fait que cette théorie, développée pour les fusions transfrontalières[985], n'est en aucun cas toujours transposable aux scissions transfrontalières qui ont la particularité de compter au moins deux sociétés bénéficiaires susceptibles de relever chacune d'une *lex societatis* distincte.

270. Illustration : les mécanismes de protection des créanciers. La Directive Sociétés a imposé aux États membres de mettre en place un système de protection des créanciers adéquat pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de scission[986]. Au-delà de cette exigence, elle n'impose pas de mécanisme particulier, mais se borne à fixer un régime de protection minimum consistant notamment en la possibilité pour les créanciers d'obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière de la société scindée l'exige et que ceux-ci ne bénéficient pas encore de telles garanties[987]. La Directive Sociétés n'entre pas davantage dans les détails et ne précise par exemple pas le délai d'action dont pourront bénéficier les créanciers pour introduire leur demande en obtention d'une garantie. Il s'ensuit que ce délai d'action diffère sensiblement d'un État membre à un autre. Il est ainsi de deux mois à partir de la publication de l'acte constatant la scission au Luxembourg[988], alors qu'il est de six mois à partir de la publication de l'inscription de la scission en droit autrichien[989]. En présence de la scission transfrontalière d'une société autrichienne au profit d'une société luxembourgeoise et d'une autre société autrichienne, on aboutirait dès lors, par application de la théorie de la primauté du droit des sociétés issues de la scission, à une situation de flou juridique où les créanciers de la société autrichienne pourraient potentiellement se retrouver dans une situation moins favorable que dans le cas d'une scission interne.

C. *L'application tantôt cumulative, tantôt distributive des droits des sociétés impliquées (*Vereinigungstheorie*)*

1. *Présentation*

271. Présentation. Face à l'impossibilité de parvenir à une solution satisfaisante en soumettant la totalité de l'opération soit à la loi de la société scindée, soit à la loi des sociétés bénéficiaires, il est généralement avancé qu'il convient de s'inspirer des réflexions sur les fusions transfrontalières[990] et d'appliquer tantôt distributivement, tantôt cumulativement les différentes règles en présence[991].

984 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 16.
985 D. BEUTEL, *ibidem*, pp. 16 et 17.
986 Art. 146, § 1er de la Directive Sociétés.
987 Art. 146, § 2 de la Directive Sociétés.
988 Art. 1031-10, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
989 § 15 (2) Spaltungsgesetz (SpaltG), disp. sur www.jusline.at (07/11/2021) (ci-après « **SpaltG** »).
990 Th. KUNTZ, « Internationales Umwandlungsrecht – zugleich eine Besprechung des Urteils „Sevic-Systems" », *IStR*, 2006, pp. 225 et s. ; P. LIMMER, « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Sevic-Urteil des EuGH und den Neuregelungen des UmwG (Teil 1) », *op. cit.*, p. 247 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 59 ; A. REIK, *op. cit.*, pp. 300 et s. et Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 361.
991 Voir en ce sens : P. LIMMER, *ibidem*, p. 247 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *Rev. Soc.*, 2008, p. 2 ; H. LAMON, *op. cit.*, p. 723 ; Th. TILQUIN,

Cette théorie, dénommée *Vereinigungstheorie* en droit allemand et en droit autrichien, permet de contrer une des principales critiques formulées à l'encontre des théories visant à soumettre l'intégralité d'une opération de scission transfrontalière à un droit unique dans la mesure où elle prend en considération les différents mécanismes de protection des *stakeholders* prévus par la *lex societatis* de chaque société impliquée[992].

272. Les trois étapes d'une fusion transfrontalière. La *Vereinigungstheorie* repose sur le postulat qu'une opération de fusion transfrontalière se divise en trois composantes distinctes, à savoir (i) les conditions de la fusion, (ii) la procédure de fusion en tant que telle et (iii) les effets de la fusion[993]. L'examen des conditions d'une fusion, ce qui correspond en réalité à l'examen de la capacité générale et de la capacité concrète de fusionner requiert une application distributive des différents droits nationaux[994]. La raison en est qu'à cette étape précise du processus, les sociétés n'ont pas encore d'interaction l'une avec l'autre[995]. Les règles relatives à la procédure de fusion en tant que telles feront soit l'objet d'une application cumulative en cas d'imbrication des diverses règles impliquant la nécessité d'un traitement unitaire, soit l'objet d'une application distributive si, au contraire, l'étape du processus en question impacte les sociétés isolément[996]. Quant aux effets de la fusion, dans la mesure où ceux-ci doivent être identiques dans toutes les juridictions impliquées, ils requerront une application cumulative[997]. Il ne paraît pas forcément opportun aux tenants de cette théorie d'aller au-delà de cette division tripartite dans la mesure où un éclatement du processus en plus petits éléments complexifierait celui-ci de manière inutile et, en outre, nuirait à la sécurité juridique de l'opération car générerait davantage d'incertitudes quant à la loi à appliquer[998].

J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, « Les fusions transfrontalières », *C.J.*, 2010/2, p. 30 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 44 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 544–546, n° 759.

992 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 17.

993 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 17 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, Einleitung C, n° 16 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 28 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 60 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 232 et 233 et Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 361.

994 G. BEITZKE, « Les conflits de lois en matière de fusions de sociétés (droit communautaire et droit international privé) », *R.C.D.I.P.*, 1967, I, pp. 6 et s. ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, Einleitung C, n° 16 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 2 ; J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 28 ; Th. PRÜM, *ibidem*, p. 60 et E. ROELOFS, *ibidem*, p. 333.

995 J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 28 et Th. PRÜM, *ibidem*, p. 60.

996 H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 2 ; Th. PRÜM, *ibidem*, p. 61 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 332 et 334 et A. STEIGER, *Grenzüberschreitende Fusion und Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften innerhalb der EU nach spanischem und portugiesischem Recht*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1997, p. 35.

997 *Pro* : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 18 ; C. T. EBENROTH et T. OFFENLOCH, « Kollisionsrechtliche Untersuchung grenzüberschreitender Ausgliederungen », *RIW*, 1997, p. 4 ; M. LUTTER et T. DRYGALA, « Internationale Verschmelzungen in Europa », *JZ*, 2006, p. 775 et TH. PRÜM, *ibidem*, p. 61. *Contra* : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, Einleitung C, n° 17 qui considère que la transmission de patrimoine et la dissolution sans liquidation doivent être régies par le droit de la société apporteuse.

998 Th. PRÜM, *ibidem*, p. 60.

273. L'application aux scissions transfrontalières. Comme les opérations de scission entretiennent un lien de parenté très particulier avec les fusions[999] dans la mesure où (i) l'une est réversible par l'autre[1000] et (ii) toutes deux entraînent des effets parallèles[1001], il semble logique d'assumer que la *Vereinigungstheorie* pourrait également être applicable aux opérations de scission[1002], à ceci près que sa mise en œuvre sera plus complexe dans la mesure où une scission transfrontalière mettra plus fréquemment en concurrence plus de deux droits nationaux distincts.

2. *Analyse de deux règles de conflit de lois fondamentales appliquées aux scissions transfrontalières*

274. Une application distributive combinée à un principe de reconnaissance mutuelle. L'application distributive des règles en présence implique que chaque société sera soumise aux dispositions de sa propre *lex societatis* applicables à une scission interne. Cette solution emporte toutefois d'une part la nécessité de reconnaître les diverses formalités accomplies dans l'autre État membre lorsque celles-ci diffèrent, mais également la limitation des formalités propres à un ordre juridique national aux seules sociétés qui lui sont soumises[1003].

275. Illustration : l'autorité nationale en charge du contrôle de conformité. Ainsi, à titre d'illustration, si la réglementation nationale de la société scindée prévoit un contrôle de conformité[1004] opéré par un notaire, alors que celle des sociétés bénéficiaires de l'opération impose que ce contrôle soit réalisé par une autorité judiciaire, ceux-ci devront être considérés comme équivalents par les différents ordres juridiques en présence.

276. Application cumulative en cas de nécessité de traitement unitaire des sociétés impliquées. Une application distributive des diverses règles nationales présente indéniablement l'avantage de la simplicité étant donné que pour les sociétés, l'opération s'apparentera à une scission interne. Cependant, certains aspects d'une scission transfrontalière requièrent un traitement unitaire dans la mesure où ils ont vocation à s'appliquer concomitamment à toutes les sociétés en présence. Il conviendra dès lors d'appliquer

999 L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 1 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. LAMON, *op. cit.*, p. 125 et Th. PRÜM, *ibidem*, p. 16 ; A. REIK, *op. cit.*, p. 300 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 347 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 6, n° 9 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27 et Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 13.

1000 Th. PRÜM, *ibidem*, p. 16 et Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *ibidem*, p. 13.

1001 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 90 ; M. FRITZ, *op. cit.*, p. 21 ; Th. PRÜM, *ibidem*, p. 16 et A. SCHWANNA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 125, n° 1.

1002 Voir en ce sens : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, Einleitung C, n° 16 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen nach Sevic Systems und der EU-Verschmelzungsrichtlinie », *AG*, 2006, p. 230 ; Th. PRÜM, *ibidem*, p. 62 ; A. REIK, *op. cit.*, p. 300 et H.-T. WÖHLERT, *Gestaltungsfreiheit und Gläubigerschutz bei Spaltungen*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, p. 48.

1003 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 545, n° 759.

1004 Sur cette étape du processus de scission, voir *infra* n°s 642 à 655.

cumulativement les différentes règles en présence[1005], tout en privilégiant la règle la plus sévère[1006].

277. Illustration : la forme du projet commun de scission. Cette règle de conflit de lois peut ainsi par exemple être parfaitement illustrée par la problématique de la forme du projet de scission[1007]. En effet, à l'exception du cas très particulier dans lequel les États membres n'ont pas prévu de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité portant sur tous les aspects de l'opération et que l'opération ne doit pas être approuvée par toutes les assemblées générales des sociétés impliquées[1008], les dispositions de la Directive Sociétés relatives aux scissions internes[1009], de même celles relatives aux fusions internes[1010], prévoient uniquement que le projet doit être établi par écrit, sans autres formes de précisions[1011]. Lorsque les législations nationales prévoient la même exigence de forme, la question ne présente pas de difficultés. En revanche, elle s'avère être plus épineuse en présence de législations nationales contradictoires. En effet, bien que, contrairement aux dispositions de la Directive Sociétés applicables aux fusions transfrontalières[1012], celles relatives au projet de scission[1013] ne prévoient pas explicitement que celui-ci doive nécessairement être commun[1014]. On ne peut toutefois concevoir que celui-ci ne doive l'être en raison de la nature éminemment contractuelle de la scission[1015]. Cette conception est par ailleurs également une conséquence logique de la possibilité donnée aux sociétés impliquées dans une opération de scission interne[1016], de fusion interne[1017] ou de fusion transfrontalière[1018] de procéder à la publication du projet sur leur site internet afin d'être dispensées de l'obligation de dépôt et de publication du projet commun au registre de commerce ou au registre des sociétés en conformité avec les exigences de la Directive Sociétés[1019]. Par conséquent, au vu de ce caractère unique, la solution sera, tout comme en

1005 H. LAMON, *op. cit.*, p. 724 ; P. LIMMER, « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Sevic-Urteil des EuGH und den Neuregelungen des UmwG (Teil 1) », *op. cit.*, p. 247 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 30 ; E. POTTIER et M. WYCKAERT, « Fusions et scissions transfrontalières : perspectives, contraintes et alternatives », in *Les restructurations d'entreprises sous l'angle fiscal*, Séminaire Vanham & Vanham, 18 novembre 1999, p. 8, n° 10 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 30 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, pp. 45 et 46.

1006 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 128 ; U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 165 et P. LIMMER, « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Sevic-Urteil des EuGH und den Neuregelungen des UmwG (Teil 1) », *op. cit.*, p. 247.

1007 À ce sujet, voir *infra* n°s 423 à 432.

1008 Art. 102, § 1er et 148 de la Directive Sociétés.

1009 Art. 137, § 1er de la Directive Sociétés.

1010 Art. 91, § 1er de la Directive Sociétés.

1011 *A contrario*, l'article 7, paragraphe 2 de la Convention de 1973 et l'article 5, paragraphe 2 de la proposition de dixième directive de 1985 prévoyaient que le projet de fusion devait être passé par acte authentique lorsque la législation nationale d'une des sociétés impliquées l'exigeait.

1012 Art. 122 de la Directive Sociétés.

1013 Art. 137 de la Directive Sociétés.

1014 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 et D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 161.

1015 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 3.

1016 Art. 138, § 2 de la Directive Sociétés.

1017 Art. 92, § 2 de la Directive Sociétés.

1018 Art. 123, § 2 de la Directive Sociétés.

1019 Art. 16 de la Directive Sociétés.

matière de fusions transfrontalières[1020], celle d'une application cumulative tout en privilégiant la règle la plus sévère. Il est toutefois intéressant de relever que cette solution ne fait pas l'unanimité en doctrine. En effet, certains auteurs ont argué qu'une telle application cumulative ne se justifiait pas et, au contraire, n'était pas souhaitable en raison des coûts et des difficultés qu'elle engendrait inutilement. Ainsi, Thomas Prüm part du principe qu'il convient au contraire de procéder en deux étapes, à savoir le recours à une application distributive des différentes formalités nationales pour ensuite vérifier par la technique de la substitution si l'exigence de forme imposée par un droit national est suffisamment remplie par l'application des règles d'un autre droit national[1021]. Cette solution n'est toutefois pas convaincante. En effet, d'une part elle implique en tout état de cause de procéder à un délicat exercice de comparaison des exigences de différents systèmes juridiques et, d'autre part, à supposer que les exigences posées soient remplies et pussent être considérées comme équivalentes, on comprend difficilement pourquoi les exigences de forme en cas de scission transfrontalière devraient être allégées par rapport aux règles applicables aux fusions transfrontalières, et ce alors même que l'application de la *Vereinigungstheorie* développée en matière de fusions repose sur le postulat de la forte parenté entre les scissions et les fusions[1022].

3. *La nécessité de recourir à la méthode de l'adaptation*

278. Une nécessité dictée par la complexité d'une opération de scission transfrontalière. Si le recours à une application tantôt distributive, tantôt cumulative des différentes *lex societatis* en présence a certes l'avantage de la simplicité, il y a cependant un certain nombre de situations où la solution dégagée par l'articulation de ces deux règles de conflit de lois ne s'avère pas satisfaisante. Ce sera ainsi par exemple le cas dans l'hypothèse de législations nationales incompatibles rendant une application cumulative impossible[1023]. Dans pareille situation, on prône le recours à la méthode de l'adaptation[1024] qui consiste (i) à adapter la loi étrangère à la loi du for en la rapprochant d'une institution

1020 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n°s 7 et 8 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 161 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 334 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 30 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 546 et Ch. VERDURE, « La réglementation des fusions transfrontalières : une nouvelle étape dans la modernisation du droit européen des sociétés », *RDIDC*, 1/2008, p. 116.

1021 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 83.

1022 L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 1 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. LAMON, *op. cit.*, p. 125 ; Th. PRÜM, *ibidem*, p. 16 ; A. REIK, *op. cit.*, p. 300 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 347 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27.

1023 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, Einleitung C, n° 16 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach "Sevic" – Zugleich eine Besprechung von EuGH », *RIW*, 2006, p. 161 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 30 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 46.

1024 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, Einleitung C, n° 16 ; P. LIMMER, « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Sevic-Urteil des EuGH und den Neuregelungen des UmwG (Teil 1) », *op. cit.*, p. 247 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 27 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, pp. 60 et 61 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *ibidem*, p. 30 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge » in P.-H. CONAC (dir.), *Fusions transfrontalières de sociétés – Droit luxembourgeois et droit comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 179 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 46.

de la loi du for ayant la même *ratio legis* ou offrant les mêmes garanties, (ii) à transposer la loi étrangère dans la loi du for en la modifiant afin de la rendre compatible avec cette dernière ou encore (iii) en combinant ces deux méthodes afin de parvenir à une certaine harmonisation entre les différents ordres juridiques en présence.

279. Illustration : les mesures de publicité entourant la réalisation de l'opération de scission. L'exemple classique d'application de la méthode de l'adaptation concerne l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la réalisation de l'opération[1025]. En effet, ces dernières sont susceptibles de différer considérablement d'un État membre à un autre dans la mesure où les dispositions de la Directive Sociétés relatives aux scissions internes renvoient explicitement aux modes de publicité déterminés par chaque État membre en conformité avec le prescrit de cette même directive[1026]. Ainsi, le droit belge prévoit le dépôt dans les trente jours de l'acte définitif au greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale et la publication dans les dix jours du dépôt de l'acte constatant la décision de participation à la scission prise lors de la réunion de l'organe compétent qui s'est tenue en dernier lieu aux annexes du Moniteur belge[1027]. Le droit luxembourgeois prévoit le dépôt dans le mois des actes définitifs et la publication intégrale dans les quinze jours du dépôt des procès-verbaux des assemblées générales qui décident de la scission établis par actes notariés au recueil électronique des sociétés et associations[1028]. Le droit autrichien, quant à lui, prévoit le dépôt des décisions approuvant l'opération ainsi que d'un nombre important d'annexes telles que la preuve de la publication du projet de scission ou encore une attestation de l'organe de gestion établissant que dans le mois de la décision d'approbation de l'opération, aucun associé n'a remis en cause la validité de la décision, à moins que ceux-ci n'aient renoncé à l'unanimité et au moyen d'un acte authentique à leur droit de contester ladite décision[1029]. Une fois que le processus de vérification de la conformité de l'opération à la loi autrichienne aura été clôturé avec succès, il sera procédé à l'enregistrement de l'opération auprès du registre des sociétés[1030] et à la publication de l'enregistrement de celle-ci dans l'*Amtsblatt* de la *Wiener Zeitung* dans les deux mois de l'autorisation d'impression ainsi que dans l'*Ediktdatei*[1031]. Le droit allemand prévoit pour sa part que l'opération de scission ne pourra faire l'objet d'un enregistrement auprès du registre de commerce de l'*Amtsgericht* compétent pour la société scindée que si celle-ci a d'abord été enregistrée auprès des registres des *Amtsgerichte* compétents pour les différentes sociétés bénéficiaires[1032]. Suite à l'analyse de ces différentes législations, il apparaît clairement que les prescrits légaux entourant

1025 G. BEITZKE, *op. cit.*, p. 9, n° 5 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 46.
1026 Art. 16 et 150 de la Directive Sociétés.
1027 Art. 2:7 ; 2:8 ; 2:14 ; 12:70 et 12:87 du CSA.
1028 Art. 1031-15 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et art. 19-1 et 19-2 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, disponible sur www.legilux.lu (07/11/2021).
1029 § 12, § 13 et § 17 (6) SpaltG.
1030 § 14 (1) et § 17 (1) SpaltG.
1031 § 10 Unternehmensgesetzbuch (UGB), disponible sur www.jusline.at (28/04/2017).
1032 § 131 UmwG.

les mécanismes de publicité de la décision de scission divergent fortement d'un État membre à un autre. Ceci s'explique notamment par le fait que certains États membres ont choisi de subordonner la prise d'effet de l'opération à la réalisation de ces formalités[1033] alors que d'autres non[1034]. En appliquant la méthode de l'adaptation, il est possible de réconcilier ces différents procédés en combinant la preuve que toutes les formalités de publicité imposées par la loi étrangère et poursuivant les mêmes objectifs que celles de la loi du for ont bien été accomplies[1035] avec le principe de reconnaissance des garanties offertes par la loi étrangère comme équivalentes à celles de la loi du for.

280. Une méthode délicate à mettre en pratique. Si elle paraît certes séduisante de prime abord, force est de constater que cette théorie s'avère pour le moins délicate à mettre en pratique dans la mesure où la complexité intrinsèque d'une scission transfrontalière est susceptible de multiplier les situations d'incompatibilités entre les législations nationales. Cette méthode donnerait dès lors lieu à un fastidieux exercice complexifiant considérablement l'opération tout en n'en garantissant pas la réussite dans la mesure où, comme cela a été identifié dans le cadre des fusions transfrontalières[1036], cette méthode ne permet pas toujours d'aboutir à une solution satisfaisante, tout particulièrement lorsque la Directive Sociétés a été transposée de manières fortement divergentes.

281. Illustration : la date de prise d'effet de l'opération. Les insuffisances de cette méthode apparaissent clairement lorsque l'on se penche sur l'épineuse question de la date de prise d'effet d'une scission transfrontalière par absorption. En effet, la Directive Sociétés s'est contentée de préciser à cet égard que les États membres étaient libres de déterminer la date à laquelle la scission prend effet[1037]. Par conséquent, cette date est susceptible de diverger fortement d'un État membre à un autre. Ainsi, en droit belge[1038], tout comme en droit luxembourgeois[1039] ou en droit français[1040], une scission interne par absorption prendra effet lorsque toutes les décisions concordantes seront intervenues au sein des sociétés concernées. En revanche, en droit allemand[1041], tout comme en droit autrichien[1042], la scission par absorption ne prendra effet qu'au moment de son inscription dans le registre des sociétés compétent. Or, il est difficilement concevable qu'une scission puisse prendre effet à des dates distinctes en fonction des législations nationales dont relèvent les différentes

1033 § 14 (2) et § 17 (1) SpaltG en droit autrichien et § 131 (1) UmwG en droit allemand.
1034 Art. 12:69, al. 2 et art. 12:86 du CSA et art. 1031-14 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
1035 G. BEITZKE, *op. cit.*, p. 9, n° 5 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 46.
1036 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Schutz der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch die Niederlassungsfreiheit », *op. cit.*, p. 213 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 46 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 179.
1037 Art. 149 de la Directive Sociétés.
1038 Art. 12:69, al. 2 du CSA.
1039 Art. 1031-14 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
1040 Art. L. 236-4, 2° du Code de commerce, www.legifrance.gouv.fr (07/11/2021) (ci-après le « **Code de commerce français** »).
1041 § 131 (1) UmwG.
1042 § 14 (1) SpaltG.

sociétés impliquées[1043]. Cette double exigence d'unicité de traitement et de conformité aux différentes législations nationales fait que ni le mécanisme de l'application distributive, ni celui de l'application cumulative combinée à la méthode de l'adaptation[1044], ni encore l'application cumulative tout en privilégiant la norme la plus sévère n'aboutissent à une solution satisfaisante. Il est certes possible de sortir de cette impasse en privilégiant l'application du droit de la société bénéficiaire[1045] ou encore de considérer qu'une application cumulative tout en privilégiant la norme la plus sévère aboutit à recourir à la date la plus éloignée dans le temps[1046], mais aucune de ces solutions n'est réellement satisfaisante du point de vue de la sécurité juridique. En effet, la première est difficilement compatible avec l'hypothèse d'une scission totale qui se caractérise par une multiplicité de sociétés bénéficiaires et la seconde n'aboutit pas toujours à un résultat clair car il n'est pas nécessairement aisé de déterminer quelle est la norme la plus sévère car d'autres considérations peuvent entrer en ligne de compte, tels que les délais de publication de l'acte de scission applicables dans les différents États membres impliqués si la date de prise d'effet de la scission la plus éloignée est celle de la publication de l'acte constatant la scission.

D. *La théorie de Lennerz*

1. *L'échec de la* Vereinigungstheorie

282. Les bases incertaines de la *Vereinigungstheorie*. La réflexion à la base de la *Vereinigungstheorie* implique un éclatement d'une opération de scission en trois parties distinctes, à savoir les conditions, le processus et les effets[1047]. Alors qu'il convient dans la plupart des cas d'appliquer distributivement les différents droits nationaux tant pour ce qui est des conditions que du processus, le conflit de lois engendré au niveau des effets ne peut être résolu que par une application cumulative des différents droits en présence[1048]. Cette théorie, d'apparence aisée à mettre en œuvre, présente cependant l'inconvénient de faire dépendre la règle de conflit de lois d'une qualification imprécise. En effet, les limites de la division tripartite d'une scission transfrontalière s'avèrent floues en ce qui concerne certains mécanismes de protection qui, en fonction du choix opéré par les États membres au moment de la transposition de la Directive Sociétés, sont susceptibles d'intervenir tantôt au moment du processus de restructuration, tantôt au moment des effets de la scission[1049].

1043 Sur la délicate question de la date de prise d'effet d'une scission transfrontalière, voir *infra* n°s 666 et 667.

1044 Ba. BESSENICH, *Die grenzüberschreitende Fusion nach den Bestimmungen des IPRG und des OR*, Basel und Frankfurt am Main, Helbing & Lichtenhahn, 1991, p. 123.

1045 Voir en ce sens : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, Einleitung C, n° 17.

1046 Voir en ce sens : U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 263.

1047 U. LENNERZ, *ibidem*, pp. 142 et 143 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 74 et Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 361.

1048 U. LENNERZ, *ibidem*, p. 143.

1049 U. LENNERZ, *ibidem*, pp. 142 et s.

283. Une règle de conflit de lois délicate à mettre en œuvre. Au-delà de cette insuffisance, Ursula Lennerz insiste sur le caractère imprécis du principe de l'application cumulative tout en privilégiant la règle la plus sévère[1050]. En effet, outre le fastidieux exercice comparatiste engendré par cette règle, force est de constater qu'il n'est toujours pas aisé de déterminer avec certitude quelle norme présente une plus grande sévérité[1051]. Il s'ensuit que la *Vereinigungstheorie*, d'une part, entraîne des coûts importants pour les sociétés impliquées dans la mesure où elles se trouvent dans l'obligation de recourir à des conseils spécialisés à même de comparer les différentes normes en présence, et, d'autre part, est source d'une certaine insécurité juridique étant donné que les solutions auxquelles elle aboutit ne sont pas infaillibles. En effet, si l'on accepte le principe de la primauté de la norme la plus sévère, il reste encore à déterminer les critères à prendre en compte pour pouvoir apprécier la sévérité d'une norme. Faut-il tenir compte des conditions, des effets ou encore des délais d'action ? Ainsi, à titre d'illustration, faut-il privilégier la norme qui prévoit un droit d'opposition à la scission limité dans le temps pour les créanciers des sociétés impliquées ou celle qui prévoit le droit de demander des sûretés ou encore celle qui impose une solidarité de principe des débiteurs pour les créances nées antérieurement à l'opération[1052] ? De plus, il n'est pas certain qu'il ne faille tenir compte que de critères quantitatifs pour régler cette question. En effet, des critères qualitatifs sont également susceptibles d'entrer en jeu[1053]. Ainsi, on peut s'interroger sur la question de savoir si une norme nationale qui permet, sous certaines conditions strictes, aux créanciers d'obtenir non seulement des sûretés, mais également de s'opposer à la scission est plus ou moins stricte qu'une norme nationale qui garantit l'obtention de garanties adéquates à tous les créanciers qui en feraient la requête.

284. Une règle contraire aux objectifs du droit international privé. Par ailleurs, on peut également reprocher à la règle de la primauté de la norme la plus sévère d'être contraire au principe de base du droit international privé qui vise à déterminer le droit qui a le plus vocation à s'appliquer à une situation donnée en fonction d'une règle de rattachement, indépendamment du contenu des droits matériels en présence[1054]. En effet, par définition, cette théorie implique une intrusion dans le droit matériel pour justifier une règle de conflit de lois et, d'autre part, de porter un jugement de valeur sur les différentes normes nationales en présence.

2. *Un régime plus conforme à la complexité de l'opération*

285. Une norme de droit international privé plus aboutie. Pour pallier les insuffisances de la *Vereinigungstheorie* tout en écartant l'application cumulative pure et simple des différents droits nationaux jugée inadaptée à la complexité des restructurations[1055], Ursula Lennerz propose ainsi de fragmenter

[1050] Ba. BESSENICH, *op. cit.*, p. 14 ; U. LENNERZ, *ibidem*, p. 214 et Th. PRÜM, *op. cit.*, pp. 62 et 63.
[1051] U. LENNERZ, *ibidem*, p. 214 et Th. PRÜM, *ibidem*, pp. 62 et 63.
[1052] U. LENNERZ, *ibidem*, p. 214 et Th. PRÜM, *ibidem*, pp. 62 et 63.
[1053] U. LENNERZ, *ibidem*, p. 217.
[1054] U. LENNERZ, *ibidem*, p. 215 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 63.
[1055] U. LENNERZ, *ibidem*, p. 217.

une opération de scission transfrontalière en huit parties distinctes[1056]. Elle prône ensuite une application distributive des différents droits en présence pour résoudre les questions relatives (i) aux conditions de l'opération sous l'angle des sociétés impliquées, (ii) aux actes de préparation internes des sociétés impliquées, (iii) aux rapports des sociétés aux associés, dirigeants et autre porteurs de droits spéciaux et (iv) aux formalités d'enregistrement et de publicité[1057]. La transmission universelle de patrimoine ainsi que ses conséquences relèveront du droit de la société scindée, alors que l'émission des nouvelles actions et la remise des actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée relèveront du droit des sociétés bénéficiaires. La protection des créanciers sociaux relèvera pour sa part du droit de la société débitrice et, en cas de lacune ou d'incompatibilité entre les normes nationales en présence, il faudra recourir à la théorie de l'adaptation[1058]. L'épineuse question de la date de prise d'effet de l'opération de scission, s'il s'avère impossible de fixer contractuellement celle-ci dans le projet commun, sera déterminée par une règle matérielle prévoyant qu'en cas de dates de prise d'effet distinctes, il conviendra de privilégier la date la plus éloignée dans le temps[1059].

286. Illustration : les mécanismes de protection des créanciers. En matière de protection des créanciers, une opération de scission transfrontalière est susceptible de mettre en concurrence des mécanismes dont tant l'efficacité que l'étendue peuvent diverger fortement. En effet, la Directive Sociétés s'est contentée de fixer un régime minimum en termes de protection à mettre en place, à savoir essentiellement la possibilité pour les créanciers de demander des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés impliquées dans l'opération rend une telle protection nécessaire et que ceux-ci ne disposent pas déjà d'une telle garantie[1060]. Ainsi, en droit belge[1061] et en droit luxembourgeois[1062], la possibilité de demander de telles garanties est ouverte aux créanciers de toutes les sociétés impliquées dans l'opération dont la créance est antérieure à la publication des actes constatant la réalisation de la scission. En droit autrichien, en revanche, ce droit n'est ouvert qu'aux seuls créanciers de la société scindée[1063]. En cas de scission transfrontalière d'une société belge au profit à la fois d'une société luxembourgeoise et d'une société autrichienne, on peut dès lors s'interroger sur la question de savoir si le créancier de la société autrichienne doit, ou non, pouvoir demander une garantie. Pour résoudre cette question, il convient de recourir à une application distributive des différents droits en présence en partant du principe que les règles régissant la protection des créanciers doivent être déterminées par le seul droit de la société débitrice[1064]. Il s'ensuit que contrairement au créancier de la société luxembourgeoise, le créancier de la société autrichienne ne pourra demander de garantie.

1056 U. LENNERZ, *ibidem*, pp. 153–264.
1057 U. LENNERZ, *ibidem*, p. 264.
1058 U. LENNERZ, *ibidem*, p. 221 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 63.
1059 U. LENNERZ, *ibidem*, p. 265.
1060 Art. 146, §§ 1 et 2 de la Directive Sociétés.
1061 Art. 12:15, § 1er du CSA.
1062 Art. 1031-10, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
1063 § 15 (2) SpaltG.
1064 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 20 ; U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 212 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 63.

3. *Appréciation critique*

287. Une théorie aux mérites indéniables. Cette théorie, qui vise avant tout à promouvoir l'application pour chaque société impliquée de son propre droit national présente l'avantage d'une certaine simplicité tout en étant facilement acceptable par les différents États membres dont la souveraineté est, dans la mesure du possible, strictement respectée.

288. Une théorie pas exempte de critiques. La théorie de Lennerz n'est toutefois pas infaillible. Ainsi, la critique du fait que la règle de conflits de lois prônant une application cumulative des différentes règles nationales en présence tout en privilégiant la plus sévère est contraire aux objectifs du droit international privé procède en réalité d'une simplification erronée de celui-ci. En effet, l'objectif premier d'une règle de rattachement est avant tout de résoudre un conflit de lois en appliquant un ordre juridique national à un rapport juridique déterminé au moyen d'une catégorie de rattachement, ce qui ne peut se faire qu'en prenant en considération un facteur de rattachement géographique[1065]. Or, s'il est certes vrai que les règles de rattachement ont pour objectif de déterminer l'ordre juridique le plus approprié[1066], il est admis de longue date que le droit international privé se compose également de règles de rattachement de caractère substantiel qui, par définition, « retiennent simultanément plusieurs facteurs de rattachement, désignant des droits étatiques différents entre lesquels le choix est opéré selon le contenu des effets juridiques qu'ils attachent respectivement à la situation particulière »[1067]. Une telle règle se justifie notamment en cas de poursuite d'un objectif de protection des intérêts d'une partie à une relation juridique jugée faible[1068]. À cette première critique, s'ajoute le fait que cette théorie part du postulat, au niveau de la protection des créanciers, que ceux-ci ne doivent avoir droit qu'à la protection qui leur est conférée dans le cadre d'une opération interne[1069]. En faisant cela, elle méconnaît le fait que dans le cadre d'une opération transfrontalière, l'interaction des différents mécanismes de protection est susceptible de compromettre l'efficacité de mécanismes élaborés isolément.

289. Illustration : les mécanismes de protection des créanciers impactant toutes les sociétés en présence. Ainsi, en droit belge[1070], il est prévu que si un créancier a obtenu de la juridiction compétente qu'il soit ordonné à une des sociétés participant à l'opération de lui fournir une sûreté adéquate et que celle-ci ne s'exécute pas dans le délai imparti, la créance deviendra immédiatement exigible et toutes les sociétés participant à l'opération de scission en seront solidairement tenues. En revanche, en droit autrichien[1071], la sanction en cas de refus d'exécution est la solidarité de la totalité des sociétés impliquées et en droit allemand[1072], une solidarité de toutes les sociétés impliquées dans

1065 Fr. RIGAUX et M. FALLON, *Droit international privé*, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2005, p. 106, n° 3.37.
1066 Fr. RIGAUX et M. FALLON, *ibidem*, p. 116, n° 3.49.
1067 Fr. RIGAUX et M. FALLON, *ibidem*, p. 121, n° 3.58.
1068 Fr. RIGAUX et M. FALLON, *ibidem*, p. 121, n° 3.58.
1069 U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 230.
1070 Art. 12:15, § 1er, al. 5 du CSA.
1071 § 15(3) SpaltG.
1072 § 133(1) UmwG.

l'opération a été prévue pour les dettes de la société scindée antérieures à la prise d'effet de la scission. Si on envisage à présent l'hypothèse d'une scission d'une société allemande au profit à la fois d'une société belge et d'une société autrichienne au cours de laquelle la société belge refuse, malgré l'ordre du président du tribunal de commerce, de fournir une garantie, la créance deviendra immédiatement exigible, ce qui impactera l'efficacité du système de protection allemand qui, lui, n'envisage pas d'exigibilité immédiate. Il s'ensuivra que les créanciers de la société allemande se retrouveront dans une situation moins favorable que dans le cadre d'une scission interne.

E. *La théorie de la concordance (*Konkordanzlehre*)*

290. La mise en concordance des différents droits nationaux. Partant du constat que la *Vereinigungstheorie*, en ce qu'elle repose sur une division tripartite d'une opération de scission en conditions, procédure et effets[1073], finit dans une impasse lorsque les différents droits nationaux ne procèdent pas à une répartition identique des composantes du régime des scissions entre ces trois subdivisions[1074], Thomas Prüm plaide en faveur d'une révision de la *Vereinigungstheorie*[1075]. Cette révision sera axée sur une volonté de mettre en concordance les différents droits nationaux en rejetant, à l'instar d'Ursula Lennerz[1076], la règle de conflit de lois visant à promouvoir l'application de la règle la plus stricte à un aspect du processus de scission requérant un traitement unitaire au motif qu'une règle de conflit de lois doit, par définition, s'abstenir de tout jugement de valeur sur les droits matériels en présence. Ainsi, les différents droits nationaux seront, par défaut, appliqués de manière distributive. S'il s'avère qu'une norme d'un État a vocation à s'appliquer aux sujets de droit d'un autre État, il conviendra de recourir à la théorie de l'adaptation. Cette application distributive ne connaîtra d'exception que pour ce qui concerne l'acceptabilité de la scission et les conditions du contrat de scission[1077]. En substance, cette théorie peut être résumée comme suit : la capacité de plusieurs sociétés à participer à une scission transfrontalière est à analyser du point de vue de tous les droits en présence. Si cette première condition est remplie, la procédure de scission sera régie, pour chacune des sociétés impliquées, par son propre droit national, à l'exception du contenu du projet de scission qui devra être déterminé en appliquant cumulativement les différents droits en présence. La date de prise d'effet de la scission sera déterminée par le droit des sociétés bénéficiaires, étant entendu que cette date ne pourra en tout état de cause être antérieure à la date d'accomplissement de toutes les exigences formelles applicables à toutes les sociétés impliquées dans l'opération[1078].

291. Illustration : la forme du projet de scission. À l'exception du cas très particulier dans lequel les États membres n'ont pas prévu de contrôle préventif

1073 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 74.
1074 U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 144 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 74.
1075 Th. PRÜM, *ibidem*, pp. 74 et s.
1076 U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 215.
1077 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 75.
1078 Th. PRÜM, *ibidem*, p. 88.

judiciaire ou administratif de légalité portant sur tous les aspects de l'opération et que l'opération ne doit pas être approuvée par toutes les assemblées générales de sociétés impliquées[1079], la seule exigence posée par la Directive Sociétés à l'égard de la forme du projet de scission interne est que celui-ci soit établi par écrit par les sociétés impliquées dans l'opération[1080]. Il s'ensuit que les États membres sont en principe libres d'imposer la forme de leur choix, et, plus particulièrement, d'imposer la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé. Il s'ensuit que les règles à ce sujet sont susceptibles de différer fortement d'un État membre à un autre. Ainsi, le droit belge laisse le choix entre un acte authentique ou un acte sous seing privé[1081], le droit luxembourgeois n'impose que la formalité d'un écrit[1082] et le droit allemand impose un acte notarié[1083]. Dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, il faudra par conséquent parvenir à réconcilier des législations potentiellement contradictoires. Par application de la théorie de la concordance, il faudrait dès lors appliquer distributivement les différentes normes en présence pour ensuite vérifier par application de la méthode de la substitution dans quelle mesure les conditions de forme imposées par une législation nationale sont respectées par la norme étrangère[1084]. Ceci signifie qu'à partir du moment où une opération de scission transfrontalière implique une société soumise au droit allemand, la forme notariée sera en principe requise[1085] et il restera à vérifier si cette exigence formelle pourra être jugée suffisante du point de vue des différents autres droits nationaux impliqués. Si tel est le cas, les formalités imposées par ces différents droits nationaux seront considérées comme remplies sans autre condition.

292. Appréciation critique. Cette théorie de la concordance, caractérisée par la même volonté de privilégier autant que possible une application distributive des différents droits nationaux en présence que l'on retrouve aussi bien dans le Règlement sur la Société européenne[1086] que dans le régime des fusions transfrontalières[1087] et des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[1088], présente de prime abord un certain intérêt dans la mesure où elle assimile autant que possible les opérations transfrontalières aux opérations internes. Si une telle assimilation est indéniablement de nature à faciliter celles-ci[1089], on peut lui reprocher de sous-estimer l'impact d'une application distributive des différents droits nationaux sur la sécurité juridique. En effet, la volonté de promouvoir une application distributive ne dispense pas les acteurs économiques de recourir, pour certains aspects de l'opération, à la méthode

1079 Art. 102, § 1er et 148 de la Directive Sociétés.
1080 Art. 137, § 1er de la Directive Sociétés.
1081 Art. 12:59, al. 1er et 12:75, al. 1er du CSA.
1082 Art. 1031-1, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
1083 § 6 et § 125 UmwG.
1084 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 83.
1085 Th. PRÜM, *ibidem*, p. 83.
1086 Art. 5 du Règlement (CE) 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, *J.O.*, L 294, 10 octobre 2001, pp. 1–21 (ci-après le « **Règlement sur la Société européenne** »).
1087 Art. 121, § 1, b) de la Directive Sociétés.
1088 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.
1089 Cinquante-sixième considérant de la Directive Sociétés.

de la substitution[1090] qui implique un délicat exercice de droit comparé susceptible d'être impacté par des spécificités nationales. Ainsi, à titre d'illustration, en droit allemand, le *Bundesgerichtshof* a jugé que les conditions pour la reconnaissance d'un acte notarié étranger enregistrant des décisions d'une assemblée générale ayant un impact organisationnel sur la société devaient être appréciées plus sévèrement et, en l'occurrence, impliquait également la nécessité de comparer les différents systèmes de responsabilité professionnelle en présence[1091]. Ainsi, s'il s'avère que le notaire étranger a, d'une manière ou d'une autre, limité sa responsabilité professionnelle, il est généralement considéré que l'acte étranger ne peut être considéré comme équivalent à un acte allemand[1092]. Cet exemple illustre bien l'insécurité juridique susceptible d'affecter cette méthode. Si on ajoute à cela que l'insécurité juridique est considérée comme un des obstacles actuels majeurs aux scissions transfrontalières[1093], on aboutit à la conclusion que ce pan de la théorie de la concordance prête le flanc à la critique.

F. *La situation en droit suisse*

293. Une reconnaissance explicite des scissions transfrontalières. Le droit international privé suisse mérite un bref examen à ce stade dans la mesure où il présente la particularité de comprendre des dispositions visant expressément les scissions transfrontalières[1094]. En effet, celui-ci prévoit que, par analogie avec les dispositions applicables aux fusions transfrontalières[1095], il convient tout d'abord de vérifier si l'opération est autorisée du point de vue des différentes *lex societatis* impliquées. À cet égard, on peut préciser qu'en droit suisse, seules les sociétés de capitaux sont autorisées à participer à une opération de scission[1096]. Si cette première condition qui rappelle les enseignements de la *Vereinigungstheorie* est bien remplie, l'opération sera régie par la *lex societatis* de la société scindée[1097], à l'exception du contrat de scission qui pourra être soumis au droit choisi par les parties[1098]. À défaut de choix par les parties, le contrat de scission sera, lui aussi, soumis au droit de la société scindée[1099]. Il est intéressant de relever que cette solution est à l'opposé de celle applicable aux fusions transfrontalières pour lesquelles le droit international privé suisse

1090 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 83.
1091 S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 206 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 226 et T. SCHOTT, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2009, p. 113 et BGH, Beschluss vom 24.10.1988 (II ZB 7/88), *BGHZ 105*, 1989, pp. 341 et s.
1092 St. KLEIN, « Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *RNotZ*, 2007, pp. 565 et s. et J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 226.
1093 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Sitzverlegungen… », *op. cit.*, p. 768 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 12.
1094 Art. 163d de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, disponible sur https://www.admin.ch (07/11/2021) (ci-après la « **Loi suisse sur le droit international privé** »).
1095 Art. 163a de la Loi suisse sur le droit international privé.
1096 Art. 30 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, disponible sur https://www.admin.ch (07/11/2021) (ci-après la « **Loi suisse sur les fusions et scission**s »).
1097 Art. 163d, § 2 de la Loi suisse sur le droit international privé.
1098 Art. 163c, § 2 et art. 163d, al. 3 de la Loi suisse sur le droit international privé.
1099 Art. 163d, al. 3 de la Loi suisse sur le droit international privé.

prévoit une primauté du droit de la société absorbante[1100]. La raison de cette différenciation est liée au fait que, dans le cadre d'une scission transfrontalière, on considère que c'est le droit de la société scindée qui présente les liens les plus étroits avec l'opération[1101].

294. Illustration : la date de la prise d'effet de la scission transfrontalière d'une société suisse. La délicate question de la date de prise d'effet d'une scission transfrontalière d'une société suisse est résolue en prévoyant qu'en tout état de cause, l'opération ne prendra pas effet avant la date prévue pour cela par le droit des sociétés suisse[1102]. Ainsi, il ne pourra être procédé à la radiation d'une société suisse, date de la prise d'effet de la scission en droit interne[1103], que sur présentation (i) d'un rapport par un expert indépendant établissant que les droits des créanciers et des associés minoritaires ont été respectés[1104], le rapport sur les droits des créanciers pouvant être remplacé par la preuve que les créanciers ont approuvé la radiation[1105] et (ii) de la preuve que la scission est devenue juridiquement valable en vertu du droit étranger[1106]. Il en découle qu'une scission transfrontalière d'une société de droit suisse pourrait présenter des difficultés avec une législation nationale qui, par analogie avec les dispositions de la Directive Sociétés sur les fusions transfrontalières[1107], prévoirait que la date de la prise d'effet d'une scission par absorption serait déterminée par le droit des sociétés bénéficiaires[1108]. Le droit international privé suisse a cependant le mérite indéniable de tenir compte des spécificités d'une scission qui se caractérise par une unicité de société scindée, contrairement à une fusion qui se caractérise par une unicité de société bénéficiaire.

G. *L'application par analogie du régime des fusions transfrontalières*

1. *Présentation*

295. Un cadre législatif efficace. Malgré un intérêt évident pour l'intégration européenne reconnu près d'un demi-siècle avant son adoption[1109], la Dixième Directive, à présent codifiée au sein de la Directive Sociétés, n'a été adoptée que le 26 octobre 2005 et a finalement permis de faire des fusions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne. Forte de l'expérience glanée au cours de la création du régime de la société européenne[1110] et suite à l'échec

1100 Art. 163a, § 2 et art 163b, § 4 de la Loi suisse sur le droit international privé.
1101 Fl. GUILLAUME, *op. cit.*, p. 251.
1102 Art. 164, §§ 1 et 2 de la Loi suisse sur le droit international privé.
1103 Art. 52 de la Loi suisse sur les fusions et scissions.
1104 Art. 164, §§ 1 et 2 de la Loi suisse sur le droit international privé.
1105 Art. 164, § 1 de la Loi suisse sur le droit international privé.
1106 Art. 164, § 2 de la Loi suisse sur le droit international privé.
1107 Art. 129 de la Directive Sociétés.
1108 L'art. 160*decies* de la Directive Mobilité prévoit à cet égard en matière de scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés que la date de prise d'effet de l'opération sera déterminée par le droit de l'État membre de la société scindée. À ce sujet, voir *infra* n°s 666 et 667.
1109 L'art. 220 du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 reconnaissait déjà la nécessité de mettre en place un régime règlementant les fusions transfrontalières, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (22/05/2017).
1110 Règlement sur la Société européenne et Directive Participation des Travailleurs.

du projet de directive de 1985[1111], la Directive Sociétés se présente comme un entrelacs de normes de conflits de lois et de règles de droit matériel destinées à régir les aspects transfrontaliers de l'opération[1112]. Conforme à la fois aux principes de proportionnalité et de subsidiarité[1113] et au mode particulier de rapprochement des législations nationales qu'est une directive[1114], la Directive Sociétés n'a en effet pas pour objectif de créer un cadre législatif supranational applicable aux fusions transfrontalières qui soit exhaustif[1115]. Elle a toutefois permis de mettre en place un cadre légal harmonisé d'une part renforçant la sécurité juridique de ce type particulier de restructuration et permettant de réaliser des opérations complexes au sein du marché intérieur[1116], d'autre part, réduisant de manière significative les coûts liés à une telle opération[1117]. Il s'est ensuivi une forte augmentation du nombre des fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne[1118], le nombre de celles-ci ayant augmenté de 173 % entre 2008 et 2012[1119] et les chiffres entre 2013 et 2017 confirment cette augmentation puisque dans seulement huit pays européens[1120] il y a eu presque autant de fusions transfrontalières que dans toute l'Union européenne au cours des cinq années précédentes[1121]. Ce succès retentissant a été confirmé notamment par l'Étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale[1122], mais également par une étude comparée dans douze États membres publiée en 2019[1123].

1111 Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, COM (84) 727 final du 14 décembre 1984, présentée par la Commission au Conseil le 14 janvier 1985, *J.O.*, n° C 23/11.

1112 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 121 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.,* p. 6 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 30 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit belge après la transposition de la directive (CE) 2005/56 », *op. cit.*, p. 43.

1113 Art. 5 du TUE et quinzième considérant de la Dixième Directive.

1114 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 221.

1115 Troisième considérant de la Dixième Directive.

1116 Th. PAPADOPOULOS, « Reviewing the implementation for the cross-border mergers Directive » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 31.

1117 J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 16.

1118 J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 16. Voir également M. KYRIAKIDES et Fr. FOURNARI, « Procedural harmonisation in cross-border mergers » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 209 et 210 selon lesquels « *there is undoubtedly a general consensus that the Directive has successfully filled an important gap in the corporate legal framework in the European Union* ».

1119 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 5 et Th. PAPADOPOULOS, « Reviewing the implementation… », *op. cit.*, p. 6.

1120 L'étude réalisée a pris en compte les données fournies par l'Autriche (2013), la Finlande (2014–2016), la France (2013–2017), l'Allemagne (2013–2017), l'Italie (2015–2017), les Pays-Bas (2013–2017) et le Royaume-Uni (2013–2017) et a identifié pas moins de 1163 fusions transfrontalières contre 1227 identifiées dans toute l'Union européenne identifiées par l'Étude Bech-Bruun et Lexidale dans toute l'Union européenne pour la période de 2008 à 2012. À ce sujet, voir Th. BIERMEYER et M. MEYER, « An empirical research on cross-border mergers at EU level » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 39.

1121 Th. BIERMEYER et M. MEYER, *ibidem*, pp. 39 et 40.

1122 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 6 à 8.

1123 H. S. BIRKMOSE, « Cross-border mergers: the Danish experience » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 275 pour le Danemark qui parle néanmoins de « *limited success* » ; I. CORBISIER, « The implementation of… », *op. cit.*, pp. 403 et 407 pour le Luxembourg et qui relève toutefois que les fusions non-simplifiées sont rares en raison de l'insécurité juridique et du haut degré de complexité qui y sont

296. Une consécration de la *Vereinigungstheorie*, mais pas seulement. S'il est certes vrai que la Directive Sociétés reconnaît effectivement la solution traditionnelle qui consiste à appliquer les dispositions des différents droits nationaux tantôt cumulativement, tantôt distributivement, elle va toutefois au-delà en combinant des règles de conflit de lois avec des règles de droit matériel[1124]. Ainsi, la règle de conflits de lois à sa base est identique à celle prévue par le Règlement sur la Société européenne[1125] et prévoit qu'en principe chaque société impliquée dans une fusion transfrontalière reste soumise aux dispositions de la loi nationale dont elle relève et qui seraient applicables à une fusion interne[1126]. En revanche, tous les aspects véritablement transfrontaliers de l'opération[1127], au nombre desquels on compte notamment le contrôle de légalité de l'opération[1128] ou encore la date de prise d'effet[1129], font l'objet de règles matérielles[1130]. Cette méthode de réglementation repose également sur le postulat que la Troisième Directive, actuellement codifiée au sein de la Directive Sociétés, a procédé à une harmonisation suffisante des fusions

généralement associés ; B. FRANÇOIS, « Cross-border mergers in France » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 321 pour la France ; Al. MARTINEZ-ECHEVARRIA, « The mutual influence between cross-border merger and common merger regimes in Spanish law » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 473 pour l'Espagne ; Th. PAPADOPOULOS, « Experiences from the implementation of the cross-border mergers Directive in Cyprus » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 226 pour Chypre ; Th. PAPADOPOULOS, « Experiences from the implementation of the cross-border mergers Directive in Greece » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 373 pour la Grèce ; M. A. VERBRUGH, « Implementation of the cross-border merger Directive in the Netherlands » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 412 pour les Pays-Bas. Voir également : S. GILOTTA, « The implementation of the cross-border mergers Directive in Italy: an overview with a critical assessment of dissenting shareholders' appraisal » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 379–399 pour un point de vue généralement positif en Italie. Pour un bilan plus mitigé (i) en Pologne, voir A. MUCHA et Ar. RADWAN, « Cross-border mergers: the experiences from Poland » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 439 et 440 et (ii) au Royaume-Uni, voir J. MUKWIRI, *op. cit.*, pp. 501 et 502. Pour un point de vue plus négatif en Allemagne, voir : S. MOCK, « The implementation of the cross-border mergers Directive (2005/56/EC) in Germany: a story of insufficiencies and (better) alternatives » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 325.

1124 M. MENJUCQ, « La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux » in *Fusions transfrontalières de sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 22 ; S. MAQUET, « Les fusions transfrontalières en droit belge des sociétés » in *Actualités en droit des sociétés*, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 35 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 106 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 30 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 43.

1125 Art. 15, § 1 et art. 18 du Règlement sur la Société européenne.

1126 Cinquante-sixième considérant et art. 121 de la Directive Sociétés.

1127 H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 4 ; S. MAUL, Chr. TEICHMANN et M. WENZ, « Der Richlinienvorschlag zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *BB*, 2003, p. 2633 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 106 et 107.

1128 J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 106.

1129 Art. 129 de la Directive Sociétés.

1130 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 121 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 4 ; S. MAUL, Chr. TEICHMANN et M. WENZ, *op. cit.*, p. 2633 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 106 et 107 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 66.

internes et qu'il est donc possible de renvoyer directement aux régimes nationaux[1131]. Même si ce n'est pas forcément le cas dans la mesure où le champ d'application des dispositions relatives aux fusions internes de la Troisième Directive n'englobait que les sociétés anonymes[1132], il est indéniable que cette méthode limite les mesures à transposer au strict minimum tout en permettant aux acteurs économiques de recourir, autant que possible, aux mécanismes familiers des fusions internes[1133].

297. L'intérêt d'une application par analogie. Une transposition des solutions développées par la Directive Sociétés en matière de fusions transfrontalières aux scissions transfrontalières[1134] en la justifiant sur le fort lien de parenté existant avec les fusions[1135] présente l'intérêt principal de pouvoir appliquer les règles de conflits de loi ainsi que, dans une certaine mesure, les normes de droit matériel introduites par celle-ci, aux scissions transfrontalières. Ceci explique pourquoi certains États membres ont d'ores et déjà fait le choix (i) d'introduire un régime applicable aux scissions transfrontalières basé sur les dispositions nationales ayant transposé la Dixième Directive[1136] ou encore (ii) d'appliquer les dispositions relatives aux fusions transfrontalières aux scissions transfrontalières[1137]. Dans un même ordre d'idées, certains auteurs avaient également plaidé en faveur d'une telle solution dans le cadre des transformations transfrontalières[1138] avant l'avènement de la Directive Mobilité. Par conséquent, par le biais de cette solution, qui n'est pas sans rappeler celle recommandée par la Commission en matière de transfert de siège dans l'arrêt *Cartesio*[1139], il sera possible de résoudre un certain nombre de difficultés liées au caractère transfrontalier de l'opération sans devoir recourir aux règles traditionnelles du droit international privé qui montrent rapidement leurs limites.

1131 J. MITTERECKER, *ibidem*, pp. 106 et 107.

1132 Art. 87, § 1 de la Directive Sociétés.

1133 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 121 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 115 ; G. LEUTNER et Th. WAGNER, « Verabschiedung der EG-Verschmelzungsrichtlinie », *GPR*, 2006, p. 32 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 107 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 66.

1134 *Pro* : H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, pp. 231 et s. et R. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 346 et s. Voir également Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, Einleitung C, n° 40 qui se montre davantage sceptique à l'égard d'une application par analogie sans base légale.

1135 L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 1 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. LAMON, *op. cit.*, p. 125 ; Th. PRÜM, *ibidem*, p. 16 ; A. REIK, *op. cit.*, p. 300 ; E. ROELOFS, *ibidem*, p. 347 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 6, n° 9 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27 et Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 13.

1136 Il s'agit notamment de la République tchèque, du Danemark et de la Finlande. Voir Étude d'impact, p. 24.

1137 C'est le cas notamment de la Suède et de l'Italie. Voir Étude d'impact, p. 145.

1138 *Pro* : H. ALTMEPPEN et G. ROTH, *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG – Kommentar*, München, C.H. Beck, 2019, § 4a, n° 25 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Das Vale-Urteil des EuGH… », *op. cit.*, p. 1488 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Sitzverlegungen… », *op. cit.*, p. 763 et P. KINDLER, « Der reale Niederlassungsbegriff… », *op. cit.*, p. 890. *Contra* : B. SEIBOLD, *op. cit.*, p. 458.

1139 Dans cet arrêt, la Commission avait estimé que les règles relatives au transfert de siège prévues dans les règlements relatifs au groupement européen d'intérêt économique, à la société européenne et à la société coopérative européenne « pourraient, voire devraient, être appliquées mutatis mutandis, au transfert transfrontalier du siège réel d'une société constituée selon le droit national d'un État membre ». Voir arrêt *Cartesio*, pts. 115 et 116.

298. Illustration : les conséquences d'une transposition à géométrie variable de la limite de la soulte. Les dispositions relatives aux scissions internes de la Directive Sociétés excluent en principe de leur champ d'application les opérations s'accompagnant d'une soulte excédant dix pourcents de la valeur nominale des nouvelles actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable[1140]. Cette possibilité d'attribuer une soulte a été introduite afin de faciliter la détermination du rapport d'échange tout en évitant la problématique des rompus[1141], mais elle est susceptible de servir à d'autres usages tels que l'établissement d'un rapport d'échange plus facile, le rachat des minoritaires détenant une participation négligeable ou encore comme dédommagement pour des droits préférentiels[1142]. La limite des dix pourcents sert d'une part à garantir l'institution de la scission dont l'attribution d'actions est, en dehors du cas particulier de la scission silencieuse[1143], une composante essentielle[1144] et, d'autre part, à protéger les associés de la société scindée contre ce qui s'apparenterait à un rachat pur et simple[1145]. Cependant, les États membres ont joui d'une certaine marge d'appréciation à cet égard dans la mesure où il leur était loisible d'étendre le régime des scissions aux opérations où cette soulte dépasse cette limite des dix pourcents[1146]. Cette option a, par exemple, été choisie par le Luxembourg[1147]. Cependant, d'autres États membres, comme la Belgique[1148], l'Autriche[1149] ou encore l'Allemagne[1150], ont préféré ne pas faire usage de cette faculté. Il en résulte que dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière d'une société luxembourgeoise au profit d'une société belge et d'une société allemande s'accompagnant d'une soulte dépassant le plafond des dix pourcents, on se retrouve dans une situation où la même opération serait valable du point de vue du droit luxembourgeois et prohibée du point de vue des droits des sociétés bénéficiaires. Si on part du principe que la détermination du rapport d'échange ainsi que du montant de la soulte en espèces requièrent un traitement unitaire, une application classique des principes de droit international privé aboutirait à une application cumulative des différents droits en présence[1151]. Toutefois, il est également possible de considérer que le plafond de la soulte sert à protéger les créanciers et les associés de la société scindée, ce qui, au contraire, plaiderait en faveur de l'application du droit de la société scindée[1152]. Il est finalement également possible de considérer que cette limite protège également les associés des sociétés

1140 Art. 136, § 1er de la Directive Sociétés.
1141 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 2, n° 13 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 149 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 139 et 140 et J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 30.
1142 J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 139.
1143 Sur cette notion, voir *supra* n° 24.
1144 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 149 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 127 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 140 et H.-W. NEYE, *op. cit.*, p. 1894.
1145 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 149 ; S. KULENKAMP, *ibidem*, p. 127 ; J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 140 et H.-W. NEYE, *ibidem*, p. 1893.
1146 Art. 158 de la Directive Sociétés.
1147 Art. 1033-1 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
1148 Art. 12:4 ; 12:5 et 12:6 du CSA.
1149 § 2 (1) 3. SpaltG.
1150 §§ 54 (4), 68 (3) et 125 UmwG.
1151 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 150 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 142.
1152 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 150 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 130 et s. et J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 142.

bénéficiaires dans la mesure où elle vise à protéger l'intégrité du capital social de celles-ci, ce qui justifierait une application cumulative[1153]. Il est possible de sortir de cette impasse en appliquant par analogie la solution prévue par les dispositions relatives aux fusions transfrontalières de la Directive Sociétés en se basant sur les similitudes que présentent les opérations de fusion et de scission[1154] et le fait que la Sixième Directive a, à l'origine, été adoptée en vue d'éviter que les garanties données en matière de fusions ne soient éludées en raison d'une absence de législation secondaire spécifique applicable aux scissions[1155]. Or, à l'égard des fusions transfrontalières, la Directive Sociétés prévoit explicitement qu'il suffit que la législation d'au moins un des États membres concernés permette le versement d'une soulte supérieure à dix pourcents de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres ou parts émis pour que l'opération tombe dans son champ d'application[1156]. Par conséquent, une application par analogie de cette règle de conflit de lois aux scissions transfrontalières aboutira à la conclusion qu'il suffira qu'un seul État membre impliqué dans l'opération autorise une soulte supérieure à dix pourcents pour qu'une telle soulte soit possible au niveau transfrontalier[1157].

2. *Les insuffisances d'un tel régime*

2.1. Présentation

299. Deux types d'insuffisances. Si une application par analogie du régime des fusions transfrontalières présente indéniablement certains avantages, au nombre desquels on compte essentiellement la possibilité de bénéficier de normes de droit matériel adaptées au cadre supranational, cette méthode est

1153 J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 142.
1154 4e considérant de la Sixième Directive.
1155 4e considérant de la Sixième Directive.
1156 Selon le texte de l'art. 120, § 1er de la Directive Sociétés, « [n]onobstant l'article 119, point 2), le présent chapitre s'applique également aux fusions transfrontalières lorsque la législation d'au moins un des États membres concernés permet que le versement de la soulte en espèces visée à l'article 119, point 2), a) et b), dépasse 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière ».
1157 Il convient de préciser qu'une telle interprétation de l'article 120, § 1er de la Directive Sociétés ne fait pas l'unanimité en doctrine. En effet, en droit autrichien, certains auteurs considèrent qu'une fusion transfrontalière s'accompagnant d'une soulte en espèces excédant la limite des dix pour cent n'est possible que dans l'hypothèse d'une fusion émigration s'accompagnant d'une renonciation expresse de la part des actionnaires de l'absorbée au bénéfice de cette limite. Cette interprétation est justifiée sur la base de l'article 121, § 1er, b) et § 2 qui permet aux États membres de mettre en place des mesures de protection destinées notamment à protéger les intérêts des créanciers et des associés minoritaires (v. J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 139–143). Une telle position n'est toutefois pas justifiée dans la mesure où elle intervertit la norme générale et l'exception. En effet, la règle générale est celle qui permet aux États membres d'adopter des mesures de protection et l'exception n'est autre que la règle prévoyant qu'il suffit que la législation d'un seul État membre autorise les fusions avec une soulte supérieure à dix pour cent pour que celles-ci doivent nécessairement être acceptées au niveau transfrontalier. Une telle interprétation est par ailleurs souhaitable dans la mesure où elle va vers un renforcement de la sécurité juridique (v. dans ce sens D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 150). Voir également J. RICKFORD, *op. cit.*, p. 1402 qui part du principe que les États membres peuvent aller jusqu'à une soulte en espèces représentant 99,9 % de la valeur nominale des actions ainsi émises ou, à défaut, de leur pair comptable.

toutefois affectée de certaines insuffisances qui peuvent être réparties en deux catégories distinctes, à savoir les insuffisances propres au régime des fusions transfrontalières (2.2) et les insuffisances intrinsèques à une application par analogie (2.3).

2.2. Les insuffisances propres au régime des fusions transfrontalières

300. Présentation. Malgré un indéniable succès[1158], le régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés souffre d'un certain nombre d'insuffisances[1159] qui ont été particulièrement mises en lumière par l'étude sur l'application de la Dixième Directive publiée par Bech-Bruun et Lexidale en septembre 2013[1160], par deux consultations publiques lancées par la Commission européenne en 2015[1161] et 2017[1162], par deux études préalables[1163], ainsi que par une étude comparée dans douze États membres européens publiée en 2019[1164]. Si un nombre relativement important d'insuffisances ont pu être rectifiées par la Directive Mobilité, il n'en demeure pas moins que le régime n'en est pas parfait pour autant.

301. Un champ d'application restreint. Au nombre de ces obstacles, on compte ainsi tout d'abord les limites qui affectent le champ d'application des dispositions relatives aux fusions transfrontalières de la Directive Sociétés, celles-ci ne prétendant s'appliquer qu'aux seules sociétés de capitaux[1165], ce qui n'a pas été

1158 Selon l'Étude d'impact, le nombre de fusions transfrontalières a connu une augmentation de 173 % entre 2008 et 2012. Voir Étude d'impact, p. 19 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 223.

1159 Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 15 et 16 ; Étude d'impact, p. 20 et Fusions et scissions transfrontalières – Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), http://www.europarl.europa.eu (27/09/2017), p. 3.

1160 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 52–88.

1161 Consultation de la Commission européenne sur les fusions et scissions transfrontalières lancée le 8 septembre 2014 et clôturée de 31 janvier 2015, http://ec.europa.eu (11/05/2018) et Consultation publique de 2015.

1162 Consultation de la Commission européenne sur la modernisation du droit européen des sociétés : règles relatives aux solutions numériques et à l'efficacité des opérations transfrontalières lancée le 10 mai 2017 et clôturée le 6 août 2017, http://ec.europa.eu (11/05/2018).

1163 J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 16 - 25 et St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, « Ex-post assessment of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions », December 2016, PE 593.796, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (15/06/2017), *op. cit.*, pp. 34–50.

1164 Pour une analyse générale des insuffisances du régime des fusions transfrontalières, voir : Th. PAPADOPOULOS, « Reviewing the implementation of the cross-border mergers directive », *op. cit.*, pp. 7–23. Pour les insuffisances existant au sein des États membres, voir : H. S. BIRKMOSE, *op. cit.*, pp. 275–294 pour le Danemark ; I. CORBISIER, « The implementation of… », *op. cit.*, pp. 405–407 pour le Luxembourg ; B. FRANÇOIS, *op. cit.*, pp. 321 et 322 pour la France ; S. GILOTTA, *op. cit.*, pp. 379–398 pour l'Italie ; Al. MARTINEZ-ECHEVARRIA, *op. cit.*, pp. 467–471 pour l'Espagne ; S. MOCK, *op. cit.*, pp. 326–334 pour l'Allemagne ; A. MUCHA et Ar. RADWAN, *op. cit.*, pp. 439 et 440 pour la Pologne ; J. MUKWIRI, *op. cit.*, pp. 477–502 pour le Royaume-Uni ; Th. PAPADOPOULOS, « Experiences from the implementation of the cross-border mergers Directive in Cyprus », *op. cit.*, pp. 245–273 pour Chypre ; Th. PAPADOPOULOS, « Experiences from the implementation of the cross-border mergers Directive in Greece », *op. cit.*, pp. 343–374 pour la Grèce et M. A. VERBRUGH, *op. cit.*, pp. 411–423 pour les Pays-Bas.

1165 Art. 119, § 1er de la Directive Sociétés.

altéré par la Directive Mobilité[1166]. Il en découle que les sociétés de personnes, ainsi que celles dénuées de personnalité juridique, sont en pratique exclues du bénéfice des fusions transfrontalières car privées d'un cadre juridique certain[1167]. Si certains États membres, comme la Belgique[1168] et le Luxembourg[1169] ont choisi d'étendre le champ d'application des fusions transfrontalières, tel n'est pas le cas de tous[1170]. À cette première restriction s'ajoute le fait que la Directive Mobilité n'a vocation qu'à s'appliquer aux seules sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté[1171]. Il s'ensuit que non seulement les fusions transfrontalières impliquant une société relevant de la *lex societatis* d'un État tiers ne sont en principe pas couvertes, mais également que les sociétés constituées hors de l'Union européenne, respectivement de l'Espace économique européen et qui procèdent ensuite à un transfert de siège au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont en principe exclues du régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés[1172].

302. Des difficultés liées à la date de prise d'effet comptable. En application des dispositions relatives aux fusions transfrontalières de la Directive Sociétés, le projet commun de fusion est tenu de comprendre, entre autres, la date de prise d'effet comptable de la fusion, soit la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire[1173]. Or, à cet égard, trois régimes distincts existent au sein des États membres. Ainsi, la date de prise d'effet comptable peut être antérieure à la date de prise d'effet juridique, concomitante à celle-ci ou encore librement déterminée par les sociétés participantes dans le projet commun de fusion[1174]. Il n'est dès lors pas surprenant qu'en cas de législations difficilement conciliables, cette question de la prise d'effet comptable soit susceptible de compromettre l'opération. Ce sera, par exemple, le cas dans l'hypothèse d'une fusion par absorption d'une société luxembourgeoise par une société roumaine. En effet, le droit luxembourgeois reconnaît la rétroactivité comptable d'une fusion[1175], alors qu'en droit roumain, la date de prise d'effet comptable doit coïncider avec la date de prise d'effet juridique[1176]. Ainsi, pendant le laps de

1166 Pour un point de vue critique de cet aspect de la Directive Mobilité, voir *infra* n°s 333 à 336.
1167 W. BAYER et J. SCHMIDT, *op. cit.*, p. 766 ; B. FRANÇOIS, *op. cit.*, p. 321 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 5 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 17.
1168 Art. 12:1 et 12:106 du CSA qui prévoient que le régime des fusions transfrontalières s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique, à l'exception des sociétés d'investissement publiques à capital variable et des sociétés qui sont en liquidation.
1169 Art. 1020-1 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales qui prévoit que le régime des fusions transfrontalières s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique.
1170 J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 17.
1171 Art. 118 de la Directive Sociétés.
1172 *Pro* : St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 36 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 85. *Contra* : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 130.
1173 Art. 122, f) de la Directive Sociétés.
1174 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 64.
1175 Art. 1021-1, § 2, e) de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
1176 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 65.

temps s'écoulant entre la date de prise d'effet comptable en vertu du droit luxembourgeois et la date de prise d'effet juridique en vertu du droit roumain, les transactions ne devraient être incluses ni dans la comptabilité de la société apporteuse, ni dans celle de la société bénéficiaire. Cette problématique est loin d'être résolue dans la mesure où il n'a pas été possible d'aboutir à une solution satisfaisante à cet égard dans la Directive Mobilité[1177].

303. La communication entre les registres nationaux. D'un point de vue plus pratique, une autre difficulté réside dans les problèmes de communication entre les différents registres nationaux. En effet, une fois que la fusion a pris effet, il incombe au registre compétent pour l'immatriculation de la société issue de l'opération de notifier cette prise d'effet à tous les autres registres concernés. Jusqu'il y a peu, il s'ensuivait en toute logique des difficultés de communication entre les registres, ne fût-ce qu'au niveau de la langue utilisée pour la notification et du risque engendré par l'utilisation de courriers postaux pour effectuer cette notification[1178]. Ces difficultés, qui entraînaient des retards et des coûts importants pour les sociétés impliquées[1179], ont entretemps été résolues par la mise en place du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (BRIS)[1180] qui est devenu une réalité en juin 2017[1181] et qui permet au registre compétent de notifier la prise d'effet de la fusion par voie électronique aux autres registres concernés[1182].

304. Des difficultés liées aux règles d'évaluation. Au nombre des difficultés d'ordre plus pratique on retrouve les divergences existant entre les diverses règles d'évaluation au sein des États membres[1183]. Ces divergences auront un double impact sur une fusion transfrontalière, à savoir d'une part au niveau de l'établissement du rapport d'échange et d'autre part, au niveau de l'évaluation du patrimoine transféré[1184]. Il importe d'autant plus de distinguer ces deux composantes qu'il est possible dans le cadre de l'établissement du rapport d'échange de se baser sur les principes comptables, mais également d'intégrer d'autres données de nature plus financière, alors que la détermination de la valeur d'apport n'est régie que par les seuls principes comptables[1185]. Ainsi, en ce qui concerne tout d'abord le rapport d'échange, en droit autrichien[1186], tout comme en droit allemand[1187], on tend à privilégier l'utilisation de la méthode de la valeur de rendement (*Ertragswertmethode*) pour évaluer la valeur d'une entreprise. Celle-ci consiste à évaluer une entreprise en se

1177 Sur cette problématique dans le cadre des scissions transfrontalières, voir *infra* n°s 468 à 474.
1178 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 61 et 62.
1179 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 62.
1180 Art. 22 de la Directive Sociétés et en ce sens : B. FRANÇOIS, *op. cit.*, p. 319.
1181 Voir : https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_at_european_level-105-en.do (27/10/2020).
1182 Art. 130, § 2 de la Directive Sociétés. Voir en ce sens : M. KYRIAKIDES et Fr. FOURNARI, *op. cit.*, p. 218.
1183 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, pp. 49 et 50 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 23.
1184 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *ibidem*, pp. 49 et 50 et J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 23.
1185 J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 28, n° 49.
1186 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 236 et M. WINNER, *Wert und Preis im Zivilrecht*, Wien, Springer, 2008, p. 404.
1187 R. KIEM, « Die Ermittlung der Verschmelzungsrelation bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *ZGR*, 2007, pp. 543 et 551 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 49 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 23.

basant sur les bénéfices ajustés futurs escomptés avec un taux de capitalisation adapté à la date déterminante pour l'évaluation[1188]. Cependant, d'autres méthodes sont envisageables, telles que la méthode de l'actif net réévalué qui consiste à évaluer une entreprise en additionnant l'ensemble de ses actifs réévalués à leur valeur de marché et en en soustrayant ses dettes[1189], l'actif net corrigé majoré du *goodwill*[1190] ou encore la méthode des flux de trésorerie actualisés (*discounted cash flow method*) qui permet d'évaluer une entreprise en se basant sur la valeur actuelle de ses flux de trésorerie attendus et en y appliquant une décote reflétant le risque lié à celle-ci[1191]. À cet égard, d'autres États, comme la Belgique[1192] et le Luxembourg[1193], n'expriment pas de préférence pour une méthode particulière, alors que d'autres, comme la France, tendent à privilégier une approche multicritère prenant en considération la valeur établie selon la méthode des flux de trésorerie futurs, les comparables boursiers, la valeur établie selon le cours de bourse, les transactions comparables ou encore la valeur établie selon un critère patrimonial, comme l'actif net corrigé[1194]. À cette trame de fond déjà complexe, s'ajoute encore le fait que certains États membres connaissent des restrictions particulières quant au recours à certaines méthodes d'évaluation. Ainsi, en droit autrichien, il est établi que le cours de bourse des titres cotés ne peut, à lui seul, servir à l'évaluation d'une entreprise, mais, *a contrario*, doit être pris en considération dans la mesure où il constitue le plancher en dessous duquel une entreprise cotée ne peut être évaluée[1195]. Cet entrelacs de règles et de méthodes compliquera bien souvent l'établissement du rapport d'échange[1196] dans la mesure où celui-ci repose sur une comparaison des valeurs des différentes entreprises impliquées dans l'opération[1197]. À cette difficulté liée au rapport d'échange vient ensuite s'ajouter le problème de l'absence d'harmonisation des règles d'évaluation du patrimoine transféré par la société apporteuse. En effet, le projet commun de fusion doit nécessairement contenir des informations sur l'évaluation de ce patrimoine[1198]. Or, de manière assez schématique, les États membres prônent généralement soit un recours à la valeur de marché ou réelle, soit un recours à

1188 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 236 et Définition de la valeur de rendement, Portail suisse des petites et moyennes entreprises, https://www.kmu.admin.ch (16/06/2017).
1189 Al. STEICHEN, *Précis de droit des sociétés*, 6e éd., Luxembourg, éd. Saint Paul, 2018, p. 246, n° 317.
1190 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, pp. 166 et 167, n° 216.
1191 G. HAWAWINI et Cl. VIALLET, *op. cit.*, p. 619.
1192 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 284.
1193 Recommandation professionnelle de l'IRE sur la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre des opérations de fusions et de scissions du 28 juin 2005, http://www.ire.lu (22/06/2017), pp. 4 et 5 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 679.
1194 Position – recommandation AMF n° 2011/11. Opérations d'apport ou de fusion, http://www.amf-france.org (19/06/2017), p. 2 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 49 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 23.
1195 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 257 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 14a ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 236 et 237 et M. WINNER, *Wert und Preis im Zivilrecht*, *op. cit.*, p. 481 et Oberster Gerichtshof Österreichs, 20 janvier 2009, 4OB188/08p, www.ris.bka.gv.at (04/05/2017).
1196 J. MITTERECKER, *ibidem*, pp. 237 et 238 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 49 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 24.
1197 J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 238.
1198 Art. 122, k) de la Directive Sociétés.

la valeur comptable ou historique pour évaluer un actif ou un passif[1199]. Dans la mesure où ces deux méthodes sont susceptibles d'aboutir à des résultats forts différents pour le même élément d'actif ou de passif et où une fusion transfrontalière est susceptible d'impliquer deux États membres appliquant chacun une méthode distincte, l'absence d'harmonisation de ces normes d'évaluation est susceptible de sérieusement compliquer l'opération[1200].

2.3. Les insuffisances intrinsèques à une application par analogie

305. Présentation. A ces premières insuffisances qui peuvent être qualifiées d'inhérentes au régime des fusions transfrontalières viennent s'ajouter quatre autres limites découlant de la nature même de la méthode utilisée.

306. Une insécurité juridique liée à des bases fragiles. L'application par analogie des solutions développées en matière de fusions transfrontalières par la Directive Sociétés aux scissions transfrontalières repose d'une part sur la parenté existant entre les opérations de fusion et de scission[1201] et, d'autre part, sur la nécessité de bénéficier d'un régime similaire pour les scissions transfrontalières afin de ne pas compromettre les garanties prévues dans le cadre des fusions transfrontalières, à l'instar de ce qui jadis a poussé à l'adoption de la Sixième Directive[1202]. Or, force est de constater que ces bases sont fragiles, pour ne pas dire insuffisantes, pour justifier l'application de règles matérielles spécifiques aux scissions transfrontalières. Si Erwin Roelofs part du principe que les règles de droit matériel développées en matière de fusions transfrontalières sont susceptibles de s'appliquer aux scissions transfrontalières pour peu que celles-ci ne soient pas contraires à des normes impératives applicables aux sociétés impliquées et que ces règles soient appliquées sur une base volontaire par les sociétés participant à la scission[1203], il convient de ne pas oublier qu'une procédure de scission transfrontalière impliquera nécessairement également certaines autorités nationales qui pourraient s'opposer à l'opération et, plus particulièrement, aux règles adoptées de commun accord par les sociétés. Si on ajoute à cela qu'il ressort de la consultation publique sur les fusions et scissions transfrontalières réalisée par la Commission européenne en 2015 que l'insécurité juridique demeure le principal obstacle de ce type d'opérations[1204], on conçoit difficilement comment une application par analogie du régime applicable à un autre type de restructuration pourrait constituer une solution satisfaisante à tous points de vue.

1199 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 65.

1200 B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *Rev. Soc.*, janvier 2019, p. 31 ; ST. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, pp. 49 et 50 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 244 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 23 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 66 et 67.

1201 L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 1 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. LAMON, *op. cit.*, p. 125 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 16 ; A. REIK, *op. cit.*, p. 300 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 347 et J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 27.

1202 4e considérant de la Sixième Directive.

1203 E. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 347 et 348.

1204 Lors de la consultation de 2015, l'insécurité juridique liée à l'absence de règles européennes a été épinglée comme le principal obstacle à une scission transfrontalière par 68 % des répondants. Voir Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 17.

307. Une application subsidiaire. Compte tenu des bases fragiles sur lesquelles reposerait une éventuelle application par analogie, celle-ci ne pourrait par définition se justifier qu'à titre subsidiaire. En d'autres termes, il ne convient de recourir à l'application par analogie du régime des fusions transfrontalières que lorsque l'application distributive ou, le cas échéant, cumulative des différents régimes des scissions internes ne permet pas de parvenir à une solution satisfaisante[1205]. Ceci signifie, d'une part, qu'un délicat exercice de droit international privé demeurera en tout état de cause requis et qu'il ne sera pas possible de simplement transposer la totalité du régime des fusions transfrontalières aux scissions transfrontalières pour en renforcer la sécurité juridique et, d'autre part, qu'en fonction des États membres impliqués, la procédure à suivre pourra varier sensiblement, ce qui n'encouragera pas les acteurs économiques à opter pour ce type de restructuration.

308. Une réglementation européenne relative aux scissions internes à transposition facultative. Au-delà de ces deux premières limites, on peut également remarquer que la méthode adoptée par la Directive Sociétés relatives aux fusions transfrontalières reposait fortement sur le constat que les procédures de fusion interne avaient été très largement harmonisées[1206]. Or, contrairement aux dispositions de la Directive Sociétés relatives aux fusions internes, le régime adopté pour les scissions internes n'impose pas aux États membres de reconnaître les opérations de scission[1207]. La situation de départ est donc différente étant donné qu'il n'existe pas nécessairement de législation nationale applicable à une scission interne dans tous les États membres.

309. Une méconnaissance des spécificités d'une opération de scission. La troisième limite concerne finalement le fait qu'une application par analogie se fonde toujours sur les ressemblances existant entre deux opérations. Or, fusions et scissions, bien que présentant de nombreux points communs et n'étant en soi que le reflet l'une de l'autre[1208], ne sont toutefois pas identiques. Il s'ensuit qu'une application pure et simple du régime des fusions transfrontalières aux scissions transfrontalières n'est pas à même de tenir compte de leurs spécificités et est susceptible de générer de nouvelles incertitudes.

310. Illustration : la date de prise d'effet de la scission transfrontalière. Une fusion transfrontalière requiert en principe une date de réalisation unique[1209]. Cette exigence que ne parviennent à satisfaire ni une application cumulative, ni une application distributive des différentes lois en présence, est remplie par la Directive Sociétés au moyen de la combinaison d'une règle de conflit

[1205] Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : B. SEIBOLD, *op. cit.*, p. 459 et KG, 21 mars 2016, 22 W 64/15, *ZIP*, 2016, pp. 1224.
[1206] J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 106 et 107.
[1207] Art. 135 de la Directive Sociétés.
[1208] D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 90 ; M. FRITZ, *op. cit.*, p. 21 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 16 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 6, n° 9 et A. SCHWANNA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 125, n° 1.
[1209] H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 14.

de lois et d'une règle matérielle[1210]. Ainsi, la règle de conflit de lois prévoit que la date de prise d'effet de l'opération sera en principe déterminée par le droit de la société bénéficiaire[1211], alors que la règle matérielle prévoit que cette date ne pourra, en tout état de cause, être antérieure au contrôle de légalité[1212]. Si cette règle ne pose aucun problème en matière de fusions transfrontalières en raison du fait que la société bénéficiaire est toujours par définition unique, la situation est inversée en matière de scissions. En effet, dans ce dernier type d'opérations, seule la société scindée est nécessairement unique et c'est donc la législation applicable à celle-ci qui devrait, en toute logique, déterminer la date de prise d'effet de l'opération, toujours toutefois sous la condition que cette date de prise d'effet ne puisse être antérieure au contrôle de légalité.

SECTION 5. ASPECTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DÉPASSANT LE CADRE DE LA *LEX SOCIETATIS*

311. Au-delà de la *lex societatis* des sociétés impliquées. S'il est clair que la grande majorité des aspects d'une scission transfrontalière seront, par analogie avec une fusion transfrontalière[1213], en principe régis par la *lex societatis* des entités impliquées, il n'en demeure pas moins que certaines de ses facettes peuvent être régies par d'autres règles de rattachement[1214]. Il pourra en être ainsi, à titre d'illustration, au niveau des aspects entourant le principe et la publicité de la transmission à titre universel du patrimoine de la société scindée lorsque la société scindée détient des biens immobiliers situés dans d'autres États membres[1215] auquel cas certaines dispositions déterminées par la *lex rei sitae* trouveront à s'appliquer. Il est également possible que certaines limites ou formalités puissent être imposées par la *lex contractus* si le patrimoine de la société scindée inclut certains contrats soumis à un droit étranger[1216], par la *lex societatis* d'une société tierce dont les actions ou les parts sociales se verraient transférées dans le cadre de la procédure[1217] ou encore par la *lex fori* si le patrimoine en question inclut des procédures judiciaires en cours[1218]. Ces interactions dépassant, d'une certaine manière, le cadre strict de l'opération de restructuration, ont été expressément envisagées sous l'angle des formalités particulières d'opposabilité par le législateur européen, que ce

1210 H. LE NABASQUE, *ibidem*, p. 14.
1211 Art. 129, première phrase de la Directive Sociétés.
1212 Art. 129, deuxième phrase de la Directive Sociétés.
1213 Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 43 ; Fr. RIGAUX et M. FALLON, *op. cit.*, p. 987, n° 16.19 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 527–529, n°s 742 et 743.
1214 Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 177.
1215 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 37, Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 177 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 530, n° 745.
1216 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 38.
1217 *Ibidem*.
1218 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 350 et 351, n° 519.

soit au niveau de la société européenne[1219], des fusions transfrontalières[1220], des scissions internes[1221] ou encore des fusions internes[1222].

SECTION 6. CONCLUSION SUR LES PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ APPLIQUÉS AUX SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES

312. Les insuffisances des méthodes traditionnelles du droit international privé. Suite à l'analyse des différentes règles de conflits de lois et méthodes susceptibles d'aboutir à une réglementation cohérente des scissions transfrontalières, il s'avère qu'aucune prise isolément n'offre de solution pleinement satisfaisante. Compte tenu des difficultés inhérentes à un processus de restructuration transfrontalier et de la nécessité de garder une certaine cohérence entre les procédures de fusions et de scissions transfrontalières en raison de leur proximité[1223], il est clair que le régime des scissions transfrontalières devrait s'inspirer de celui mis en place par la Directive Sociétés pour les fusions transfrontalières[1224].

313. Le respect des spécificités d'une scission. Cependant, il serait erroné de purement et simplement transposer celui-ci étant donné qu'une fusion et une scission sont loin d'être des opérations identiques. En effet, chacune a ses propres enjeux et est susceptible d'impacter les différents *stakeholders* de manières fortement distinctes. Ceci se voit très clairement au fait que la procédure de scission interne instaurée par la Directive Sociétés, tout en étant assez similaire à celle prévue pour les fusions internes, n'en contient pas moins certaines dispositions particulières n'ayant de raison d'être que dans le cadre d'une scission. À titre d'illustration, on peut ainsi citer le mécanisme particulier qui prévoit qu'en cas de non-attribution d'un élément d'actif dans le projet commun de scission, cet élément ou sa contre-valeur sera réparti entre les sociétés bénéficiaires proportionnellement à l'actif attribué à chacune d'elles dans le projet commun de scission[1225]. Une telle disposition ne fait de sens qu'en cas de pluralité de sociétés bénéficiaires, ce qui demeure une distinction essentielle avec les fusions où la société bénéficiaire est nécessairement unique. Un régime des scissions transfrontalières devra dès lors nécessairement intégrer des dispositions spécifiques adaptées à la nature particulière des scissions.

314. Un préalable nécessaire. Cependant, avant de pouvoir mettre en place un cadre légal spécifiquement applicable aux scissions transfrontalières, il convient de ne pas perdre de vue qu'un des principes essentiels sous-tendant le régime des fusions transfrontalières instauré par la Directive Sociétés

[1219] Art. 29, § 3 du Règlement sur la Société européenne.
[1220] Art. 131, § 3 de la Directive Sociétés.
[1221] Art. 151, § 3 de la Directive Sociétés.
[1222] Art. 105, § 3 de la Directive Sociétés.
[1223] L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 1 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. LAMON, *op. cit.*, p. 125 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 16 ; A. REIK, *op. cit.*, p. 300 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 27.
[1224] E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 599 et J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 27.
[1225] Art. 137, § 3, a) de la Directive Sociétés.

est celui de l'application subsidiaire du régime des fusions internes[1226]. Or, contrairement aux fusions internes que les États membres ont été contraints à reconnaître, à tout le moins pour les sociétés anonymes[1227], la Directive Sociétés s'est contentée de laisser aux États membres la faculté de reconnaître les scissions[1228]. Il en découle que tous les États membres ne doivent pas nécessairement disposer d'un régime applicable aux scissions internes. Le préalable nécessaire à la mise en place de règles propres aux scissions transfrontalières tout en s'inspirant de celles développées pour les fusions transfrontalières sera dès lors de s'assurer de la reconnaissance des scissions dans tous les États membres afin de garantir l'existence d'un régime des scissions internes auquel celui applicable aux scissions transfrontalières puisse, le cas échéant, se référer.

[1226] Art. 121, § 1, b) de la Directive Sociétés.
[1227] Art. 88 de la Directive Sociétés.
[1228] Art. 135 de la Directive Sociétés.

Chapitre 2
Initiatives nationales en matière de scissions transfrontalières

315. Plan du chapitre 2. Afin de pouvoir se prononcer sur l'efficacité des initiatives nationales en matière de scissions transfrontalières (section 3), il est intéressant de se pencher successivement sur la situation en droit international privé belge (section 1) et la situation en droit international privé luxembourgeois (section 2).

SECTION 1. LA SITUATION EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ BELGE

316. Plan de la section 1. Apprécier à sa juste valeur la situation en droit international privé belge implique de procéder en deux étapes, à savoir étudier en premier la situation préalablement à l'entrée en vigueur du Code des sociétés et associations (§ 1) et analyser ensuite le nouveau régime des scissions transfrontalières introduit par le Code des sociétés et associations (§ 2).

§1. La situation avant l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations

A. *La difficile reconnaissance des opérations transfrontalières*

317. L'incidence de la théorie des éléments essentiels. Une scission transfrontalière, à l'instar d'une fusion transfrontalière[1229], va nécessairement entraîner un changement de *lex societatis* qui aura des répercussions sur les associés de la société scindée dans la mesure où ceux-ci vont devenir associés d'une personne morale soumise à une autre *lex societatis* par l'effet de l'échange d'actions. La doctrine belge traditionnelle, par application de la « théorie des éléments essentiels intangibles »[1230] considérait dès lors que ce type d'opérations devait nécessairement entraîner la dissolution et la liquidation de la personne morale[1231], à tout le moins lorsque la société belge était la société scindée[1232]. Suite à l'abrogation de ses fondements légaux et à l'adoption du

1229 Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 34.

1230 P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 » in *Les fusions transfrontalières d'entreprises*, Bruxelles, Séminaire Vanham & Vanham du 26 avril 2007, p. 3.

1231 J. RENAULD et G. KEUTGEN, « Obstacles à une concentration internationale des entreprises dans le cadre de la C.E.E. », *Revue*, 1970, n° 5606, p. 278, n° 23 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 34 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 175 ; R. VAN DER ELST et M. WESER, *Droit international privé belge et droit conventionnel international*, t. I, *Conflit de lois*, Bruxelles, Bruylant, 1983, n° 55.5, p. 253 ; P. VAN OMMESLAGHE et X. DIEUX, « Examen de jurisprudence (1979 à 1990) – les sociétés commerciales », *R.C.J.B.*, 1992, p. 677, n° 45 ; J. VAN RYN, « Conséquences juridiques du transfert en Belgique du siège social d'une société étrangère et du transfert à l'étranger d'une société belge », note sous Cass., 12 novembre 1965, *R.C.J.B.*, 1966, p. 409, n° 20 ; J. VAN RYN, *Principes de droit commercial*, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1954, pp. 264 et 265 ; D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 582 et M. WYCKAERT, « Grensoverschrijdende fusies », *trv*, 2006, p. 97, note 36.

1232 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 3.

Code des sociétés belge le 7 mai 1999, cette théorie, déjà battue en brèche par le Conseil d'État qui dans son arrêt *Vanneste* du 19 juin 1987 avait reconnu que le droit belge n'imposait pas la perte de la personnalité juridique à une société qui procédait au transfert de son siège social à l'étranger[1233], a finalement été abandonnée[1234]. Par conséquent, le changement de *lex societatis* n'est plus en lui-même un obstacle. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de dispositions législatives spécifiques, la question de savoir si une telle opération, puisqu'elle entraîne en principe un changement de nationalité de la société scindée, devrait en principe être approuvée à l'unanimité par les associés de celle-ci[1235], n'en est pas encore définitivement tranchée.

B. *La reconnaissance implicite des scissions transfrontalières, mais un régime absent*

318. Une reconnaissance implicite confirmée par le droit fiscal. Contrairement aux fusions transfrontalières qui faisaient l'objet d'une reconnaissance explicite de l'article 113 du Code de droit international privé belge ainsi que du Titre V*bis* du Code des sociétés belge, les scissions transfrontalières n'étaient pas prévues expressément par le Code des sociétés ou le Code de droit international privé. Il était toutefois généralement considéré que celles-ci étaient possibles[1236]. Ceci était confirmé notamment par (i) le fait qu'elles sont visées par le régime fiscal favorable prévu par l'article 211 du Code des impôts sur le revenu et (ii) le texte des travaux préparatoires[1237] de la loi du 11 décembre 2008[1238]. Il est en effet difficilement concevable que ces opérations puissent être prohibées en droit des sociétés alors qu'elles font l'objet d'une reconnaissance explicite par le droit

1233 C.E., 29 juin 1987, n° 28.267, *Pas.*, IV, 1990, p. 114.

1234 Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 222 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 38 et P. VAN OMMESLAGHE, *op. cit.*, p. 3.

1235 P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 3 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 582.

1236 A. BROHEZ, K. DE SCHUTTER, M. DHAENE, A. GUBBELS, L. KETELS, G. PALMAERS et F. SAELENS, *Les réorganisations transfrontalières, Évolutions législatives récentes en droit des sociétés, droit social et droit fiscal*, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 107 ; Commission des Normes Comptables, « 3.9 – Réorganisations » in *Annuaire 2017 CNC*, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 12031 ; J. HAMON, *op. cit.*, p. 725 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 30 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 222 ; D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, p. 335, n° 12 et D. WILLERMAIN, *ibidem*, p. 584.

1237 Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre, modifiée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2007–2008, n° 52–1398/001, p. 6.

1238 Loi du 11 décembre 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre, modifiée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, disponible sur www.juridat.be (18/10/2017).

fiscal[1239], ce dernier conditionnant l'application du régime de report des plus-values latentes notamment au respect des dispositions du Code des sociétés.

319. Un régime indéterminé. S'il était certes admis de longue date qu'une scission transfrontalière n'était pas prohibée en droit belge[1240], le régime qui lui était applicable demeurait, en revanche, particulièrement vague. En effet, en l'absence de dispositions lui étant spécifiquement consacrées, la procédure de scission transfrontalière était soumise aux principes de droit international privé qui étaient applicables aux fusions transfrontalières avant la transposition de la Directive Sociétés[1241]. Il convenait dès lors de procéder en deux étapes. La première consistait à vérifier si les sociétés impliquées disposaient à la fois de la capacité générale et de la capacité concrète de participer à une opération de scission. La seconde étape consistait ensuite à appliquer les différentes *leges societatum* tantôt distributivement, tantôt cumulativement. Le principe de base demeurant que chaque société se verra, en règle générale, appliquer distributivement les dispositions de sa *lex societatis* réglementant une scission interne. Une application cumulative n'était utilisée que dans les hypothèses où le processus de scission nécessitait un traitement unitaire, au besoin en recourant à la méthode de l'adaptation. Il n'est dès lors pas étonnant que les scissions transfrontalières se soient avérées, à l'instar des fusions transfrontalières avant l'avènement de la Directive Sociétés[1242], particulièrement ardues, voire impossibles en pratique en présence de droits matériels trop distincts.

§2. Le régime du CSA

320. Une réforme en profondeur. Adopté par la loi du 23 mars 2019[1243] et entré en vigueur le 1er mai 2019[1244], le Code des sociétés et des associations belge[1245] a pour ambition de réformer en profondeur le droit des sociétés belge en vue de renforcer son attractivité en le rendant plus compétitif par rapport aux droits des autres États membres de l'Union européenne[1246]. En effet, au-delà

1239 A. BROHEZ, K. DE SCHUTTER, M. DHAENE, A. GUBBELS, L. KETELS, G. PALMAERS et F. SAELENS, *Les réorganisations transfrontalières, Évolutions législatives récentes en droit des sociétés, droit social et droit fiscal*, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 107 ; Commission des Normes Comptables, « 3.9 – Réorganisations » in *Annuaire 2017 CNC*, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 12031 ; J. HAMON, *op. cit.*, p. 725 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 30 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 222 et D. WILLERMAIN, *op. cit.*, p. 584.

1240 A. BROHEZ, K. DE SCHUTTER, M. DHAENE, A. GUBBELS, L. KETELS, G. PALMAERS et F. SAELENS, *ibidem*, p. 107 ; Commission des Normes Comptables, *ibidem*, p. 12031 ; J. HAMON, *op. cit.*, p. 725 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 30 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 222 et D. WILLERMAIN, *ibidem*, p. 584.

1241 Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 222.

1242 Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *ibidem*, p. 179.

1243 Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, disponible sur https://www.ejustice.just.fgov.be (14/07/2020).

1244 Art. 38 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, disponible sur https://www.ejustice.just.fgov.be (14/07/2020). Voir toutefois également les art. 39 à 44 de cette loi qui prévoient un certain nombre de dispositions transitoires.

1245 Code des sociétés et des associations, version consolidée disponible sur https://www.ejustice.just.fgov.be (07/11/2021) (ci-après le « **CSA** »).

1246 Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 5.

des incohérences que présentait l'ancien Code des sociétés belge[1247], le législateur belge avait pris l'habitude d'étendre le champ d'application des directives européennes en matière de sociétés, avec pour conséquence directe de rigidifier plus que de besoin le régime de formes sociales en principe plus flexibles[1248]. Face aux évolutions de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement qui est devenue particulièrement favorable aux opérations transfrontalières[1249] combinées à l'attitude résolument plus libérale de certains États membres voisins[1250], le droit belge avait perdu en attractivité et il était devenu de plus en plus fréquent que l'essentiel des activités économiques d'une entreprise soit exercé en Belgique au moyen d'une succursale d'une société constituée sous l'empire d'un droit des sociétés jugé plus flexible[1251]. Pour contrer cette évolution, le CSA a procédé à une révision en profondeur du droit des sociétés belge en articulant celle-ci autour de trois lignes directrices, à savoir une simplification de grande envergure, une flexibilisation poussée tout en étant attentif aux droits des *stakeholders* et une adaptation aux évolutions européennes[1252].

321. Un régime des scissions transfrontalières. Dans le cadre de cet exercice, la possibilité de réaliser une scission transfrontalière s'est vue explicitement confirmée au sein du Livre 12 consacré aux restructurations de sociétés[1253], pour peu que le droit applicable à la société étrangère connaisse la figure de la scission et reconnaisse la validité et les effets juridiques d'une scission transfrontalière impliquant une société belge[1254]. Le régime consacré par le législateur belge repose ainsi sur une application distributive de principe des différentes procédures[1255], combinée le cas échéant à une application cumulative, en particulier à l'égard de la protection des *stakeholders*[1256].

1247 Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 5.

1248 Les travaux parlementaires citent à titre d'illustration l'extension des dispositions européennes protectrices du capital social des sociétés par actions à la SPRL. Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 6.

1249 Sur ces évolutions, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1er.

1250 Les travaux parlementaires citent les exemples de la France, des Pays-Bas, des pays scandinaves, de l'Italie et des pays anglo-saxons qui ont veillé à moderniser leur droit des sociétés pour le rendre plus attractif. Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 6.

1251 Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 6.

1252 Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, pp. 7–16.

1253 Pour une analyse de ces dispositions, voir : MALHERBE, J., DE CORDT, Y., LAMBRECHT, Ph., MALHERBE, Ph. et CULOT, H., *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020., pp. 99–124 ; S. MAQUET et D. WILLERMAIN, « Les restructurations des sociétés : de la théorie à la pratique », *Le nouveau droit des sociétés et associations*, E.-J. Navez (dir.), Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 453–527 et D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, pp. 323–343.

1254 Art. 12:73, § 1er (scissions par absorption) et 12:90, § 1er (scissions par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.

1255 Art. 12:73, § 1er, 1° et 12:90, § 1er, 2° du CSA. Voir également : Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 310.

1256 Projet de loi du 4 juin 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations, et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 310.

SECTION 2. LA SITUATION EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ LUXEMBOURGEOIS

322. Un droit des restructurations transfrontalières. Fidèle à son caractère foncièrement libéral[1257], le législateur luxembourgeois a choisi, lors de la première mesure législative visant à transposer les dispositions de la Dixième Directive relatives aux fusions transfrontalières en droit interne[1258], de reconnaître explicitement la validité non seulement des fusions transfrontalières[1259], mais également des apports partiels d'actifs[1260], de branches d'activités[1261] ou d'universalités[1262], des transferts de patrimoine professionnels[1263] et, surtout, des opérations de scissions transfrontalières[1264]. Cependant, cette reconnaissance, justifiée parce qu'il semblait « opportun » au législateur luxembourgeois de signaler que le droit luxembourgeois était ouvert à ce type de restructurations[1265], souffre d'une double limite. Ainsi, une scission transfrontalière ne sera possible que si le droit national de l'autre État membre impliqué ne s'y oppose pas. Ensuite, cette consécration ne s'est pas accompagnée de la mise en place d'un régime propre aux scissions transfrontalières s'inspirant éventuellement de celui applicable aux fusions transfrontalières. Il en découle la nécessité de recourir aux principes de droit international privé pour déterminer leur régime, à l'instar de ce qui était le cas pour les fusions transfrontalières avant la transposition de la Directive Sociétés[1266], avec, pour inévitable corollaire, un certain degré d'insécurité juridique.

SECTION 3. UNE SITUATION FONCIÈREMENT INSATISFAISANTE

323. Inexistence, divergences et incompatibilités. Avant une initiative paneuropéenne en la matière, moins de la moitié des États membres permettaient déjà de réaliser des scissions transfrontalières[1267]. Compte tenu des enseignements de la

1257 Voir en ce sens : I. CORBISIER et F. BERNARD, « Cross-border mobility within the EU and specifically in Luxembourg and Belgium : same destination, different roads », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, p. 19 et I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *RPS-TRV*, 2017, p. 418.

1258 Loi du 23 mars 2007 modifiant 1. La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 2. La loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, et 3. La loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle, disponible sur www.legilux.lu (27/06/2017).

1259 Art. 1020-1, § 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

1260 Art. 1040-2 et art. 1030-1, § 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

1261 Art. 1040-3, § 2 et art. 1030-1, § 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

1262 Art. 1040-4, § 2 et art. 1030-1, § 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

1263 Art. 1040-6, § 2 et art. 1030-1, § 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

1264 Art. 1030-1, § 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

1265 Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, commentaire des articles, Ch. des députés, 2001–2002, n° 4992, p. 18.

1266 J.-P. SPANG, *op. cit.*, p. 97.

1267 Selon l'Étude d'impact, il s'agit de l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Roumanie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède l'Espagne et le Royaume-Uni. Voir Avis CESE (défini ci-après), pt. 3.6.9. ; Proposition de la Commission (défini ci-après), exposé des motifs, p. 8 et Étude d'impact, p. 24. Voir également : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 103.

Cour de justice dans l'arrêt *Sevic*[1268], on ne peut que s'étonner de la passivité des États membres en la matière[1269]. De plus, même au sein de ces États, l'approche à l'égard de ces dernières différait fortement[1270]. En effet certains États membres avaient fait le choix d'instaurer un régime spécifique pour les scissions transfrontalières en s'inspirant du régime existant pour les fusions transfrontalières[1271], alors que d'autres se bornaient à les autoriser dans leur principe et à les réglementer par le biais d'une application par analogie du régime des scissions internes en tirant pleinement parti de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt *Sevic*[1272]. À titre d'illustration, le régime belge des scissions transfrontalières instauré par le CSA s'inspire ouvertement du régime des fusions transfrontalières, ce qui se voit clairement dans l'application du double contrôle de légalité de l'opération[1273] ou encore de la même règle de droit international privé consacrant une application distributive par défaut des différentes règles nationales[1274], alors que le régime luxembourgeois des scissions transfrontalières repose sur une application par analogie du régime des scissions internes[1275]. Il n'est dès lors pas surprenant de constater que de nombreuses divergences existent entre les droits des États membres autorisant ce type d'opération[1276].

324. Illustration : CSA et Loi de 1915. À titre d'illustration de cette incapacité des États membres à parvenir à une solution satisfaisante indépendamment d'une initiative supranationale, il est intéressant de se pencher sur la question de la date de prise d'effet d'une scission transfrontalière[1277] tant en vertu du droit belge que du droit luxembourgeois. En effet, en droit belge, la date de prise d'effet d'une scission interne est celle de la dernière décision concordante prise au sein des sociétés intéressées en cas de scission par absorption[1278] et celle de la constitution des nouvelles sociétés en cas de scission par constitution de nouvelles sociétés[1279]. Par dérogation à ce régime interne, certaines règles spécifiques ont été prévues en matière de scissions transfrontalières[1280] pour tenir compte du caractère atypique de ce type d'opération en vue de

1268 Sur l'importance de l'arrêt *Sevic* pour les scissions transfrontalières, voir *supra* n°s 149 à 163.
1269 Sur la passivité des États membres à l'égard des opérations transfrontalières, voir Avis CAJ (défini ci-après), p. 215.
1270 5e considérant de la Directive Mobilité et Avis CESE (défini ci-après), pt. 3.6.9.
1271 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 104 et Étude d'impact, p. 24.
1272 Étude Bech-Bruun et Lexidale et Étude d'impact, p. 24.
1273 Comparer art. 12:73, §§ 3–5 et art. 12:90, §§ 3–5 du CSA pour les scissions transfrontalières et art. 12:117 et art. 12:118 du CSA pour les fusions transfrontalières.
1274 Art. 12:73, § 1er, 2° et art. 12:90, § 1er, 2° du CSA pour les scissions transfrontalières. Au sujet des fusions transfrontalières, voir : art. 113 du Code de droit international privé belge et S. MAQUET et D. WILLERMAIN, « Les restructurations des sociétés : de la théorie à la pratique », in E.-J. NAVEZ (dir.), *Le nouveau droit des sociétés et associations*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 469 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit belge », *op. cit.*, p. 44, n°s 56 et 57 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 581, n° 6.
1275 La procédure de scission interne consacrée aux art. 1031-1 à 1031-19 (scission par absorption), à l'art. 1032-1 (scission par constitution de nouvelles sociétés) et à l'art. 1033-1 (autres opérations assimilées à la scission) est également applicable aux scissions transfrontalières. Voir à ce sujet : I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, pp. 18 à 20 et J.-P. SPANG, *op. cit.*, pp. 96 et 97.
1276 Étude d'impact, p. 25.
1277 Pour une étude détaillée de la question de la date de prise d'effet d'une scission transfrontalière, voir *infra* n°s 666 et 667.
1278 Art. 12:69, al. 2 du CSA.
1279 Art. 12:86 du CSA.
1280 Art. 12:73, §§ 3 et 4 et art. 12:90, §§ 4 et 5 du CSA.

protéger les créanciers[1281]. Il est ainsi prévu, en cas de scission transfrontalière par absorption et par constitution de nouvelles sociétés, que (i) si une ou plusieurs sociétés bénéficiaires sont régies par le droit belge, l'opération ne prendra effet qu'au plus tôt à la date à laquelle un notaire belge aura constaté la réalisation de la scission à la requête des sociétés participantes sur présentation des certificats préalables et autres documents probants[1282] et (ii) si seule la société scindée est régie par le droit belge, la date de prise d'effet de l'opération sera déterminée par le droit applicable aux sociétés bénéficiaires à la condition expresse toutefois que le notaire belge ait délivré le certificat préalable[1283] et, pour les scissions transfrontalières par absorption uniquement[1284], que les sociétés concernées aient approuvé l'opération par le biais de décisions concordantes. En droit luxembourgeois, en revanche, il est uniquement prévu que la scission sera réalisée quand les décisions concordantes au sein des sociétés concernées auront été prises[1285], sans autre forme de précision quant à la nature interne ou transfrontalière de l'opération, ni quant au type de scission concerné. Il en résulte qu'en cas de scission partielle transfrontalière d'une société luxembourgeoise par constitution d'une nouvelle société belge, la scission prendra effet, du point de vue du droit luxembourgeois, à la date de l'acte notarié enregistrant la décision de l'assemblée générale d'approuver l'opération, alors que du point de vue du droit belge, l'opération ne pourra prendre effet que lorsque la réalisation de l'opération aura été constatée par le notaire belge. Il est certes vrai qu'en pratique une telle apparente incompatibilité peut aisément être surmontée en veillant à passer l'acte notarié belge et l'acte notarié luxembourgeois le même jour ou encore en clarifiant la question de la date de prise d'effet dans le projet de scission, mais il n'en demeure pas moins que la situation est loin d'être idéale du point de vue de la sécurité juridique.

1281 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, pp. 311 et 314.
1282 Art. 12:73, § 4, 1re phrase et art. 12:90, § 4, 1re phrase du CSA.
1283 Art. 12:73, § 5 du CSA et 12:90, § 5 du CSA.
1284 Art. 12:73, § 5, 2e phrase du CSA.
1285 Art. 1031-14 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Conclusion sur les principes de droit international privé et les initiatives nationales en matière de scissions transfrontalières

325. La nécessité d'une intervention du législateur européen. Malgré les précieux enseignements de la Cour de justice en matière de mobilité transfrontalière, ni les différents mécanismes de droit international privé qui ont pu être défendus, ni une application par analogie du régime des fusions transfrontalières ne permettent d'aboutir à une procédure de scission transfrontalière offrant un degré de sécurité juridique suffisant. Si des initiatives nationales en la matière vont certes dans la bonne direction, l'analyse des exemples belge et luxembourgeois montre que, même face à des législateurs nationaux favorables à la mobilité transfrontalière, il n'est pas aisé de faire des scissions transfrontalières une réalité.

TITRE IV
Company law package et nécessité d'une nouvelle initiative européenne

SOMMAIRE

Introduction du titre IV 287

Chapitre 1. Le nouveau régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés 291

Chapitre 2. L'avenir de la réglementation des scissions transfrontalières en Europe 345

Conclusion sur le company law package et la nécessité d'une nouvelle intervention européenne 363

Introduction du titre IV

326. Plan du titre IV. Les règles de droit international privé et les initiatives nationales isolées ayant montré leurs limites, une initiative européenne en matière de scissions transfrontalières s'avérait inéluctable, ce qui explique le chemin emprunté par le législateur européen dans le cadre de l'adoption de la Directive Mobilité. Cependant, loin de clore le débat, les insuffisances de cette norme de droit dérivé ne font qu'attiser les braises du brûlot lancé par la Cour de justice (chapitre 1), rendant une nouvelle initiative européenne en la matière inévitable (chapitre 2).

Chapitre 1
Le nouveau régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés

SECTION 1. PRÉSENTATION

327. Un processus législatif expéditif. Le 12 décembre 2019, la Directive Mobilité a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne à la suite de son adoption à une écrasante majorité au niveau du Conseil[1286]. Aboutissement d'un processus législatif pour le moins expéditif[1287] initié par la Commission européenne en 2018[1288] conformément à l'objectif annoncé dans sa communication au Parlement européen portant sur l'amélioration du marché unique[1289] et suite notamment aux résultats (i) de l'Étude Bech-Bruun et Lexidale, (ii) de deux consultations publiques sur les fusions et les scissions transfrontalières[1290] et (iii) de deux études sur la question[1291], cette nouvelle directive en matière de droit des sociétés modernise le régime actuel des fusions transfrontalières et introduit une nouvelle procédure de transformation et de scission transfrontalières. La rapidité du processus législatif ne peut que surprendre puisque le 17 octobre 2018, le Comité économique et social a remis son avis[1292], de même que la Commission des affaires économiques et monétaires le 14 novembre 2018[1293] et la Commission de l'emploi et des affaires sociales le 21 novembre 2018[1294]. Dès le 18 décembre 2018, la Présidence du Conseil de l'Union européenne a proposé un premier

1286 Selon la note du Conseil de l'Union européenne du 2 décembre 2019, sur le résultat du vote du Conseil de l'Union européenne sur la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (première lecture) lors de la 3728e session du Conseil de l'Union européenne tenue le 18 novembre 2019, 14768/19, disponible sur https://data.consilium.europa.eu (07/11/2021), 26 États membres ont voté en faveur et deux États-Membres, dont le Royaume-Uni, se sont abstenus.

1287 J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0 : Die MobilR eröffnet ab 2023 neue Wege », *BB*, 3.2020, p. 1.

1288 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2018 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), COM(2018) 241 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (07/11/2021) (ci-après la « **Proposition de la Commission** »).

1289 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 octobre 2015, Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, COM(2015) 550 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (07/11/2021), p. 6.

1290 Étude d'impact, pp. 106–118 ; Consultation publique de 2017 et Consultation publique de 2015.

1291 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *Ex-post assessment of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions*, PE 593.796, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (28/02/2020) et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*.

1292 Avis du Comité économique et social européen sur a) une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés [COM(2018) 239 final — 2018/0113 (COD)] et sur b) une proposition de directive modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières [COM(2018) 241 final — 2018/0114 (COD)] (Rapporteur Dimitris Dimitriadis), EESC 2018/01917, 17 octobre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020) (ci-après, l' « **Avis CESE** »).

1293 Avis de la Commission des affaires économiques et monétaires à l'intention de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)) (Rapporteur Olle Ludvigsson), PE625.524v03-00, 14 novembre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020) (ci-après, l' « **Avis CAEM** »).

1294 Avis de la Commission de l'emploi et des affaires sociales à l'intention de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)) (Rapporteure Anthea McIntyre), PE625.524v03-00, 21 novembre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020) (ci-après, l' « **Avis CEAS** »).

compromis[1295] qui a été suivi peu de temps après par le rapport de la Commission des affaires juridiques le 9 janvier 2019[1296] et par un deuxième compromis le 15 janvier 2019[1297]. Le 25 janvier 2019, le secrétariat général du Conseil a invité le Comité des Représentants Permanents à mandater la Présidence pour entamer le processus de négociations avec le Parlement européen sur la base d'un compromis modifié[1298]. La Présidence a ainsi été mandatée le 30 janvier 2019[1299] et le premier trilogue a eu lieu le 31 janvier 2019[1300]. À l'issue du cinquième trilogue ayant eu lieu du 11 au 13 mars 2019, un accord *ad referendum* a été atteint sur un compromis amendé[1301]. Le 18 avril 2019, le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture[1302], position qui a été modifiée par un rectificatif adopté par le Parlement européen le 22 octobre 2019[1303] suite à la mise au point d'un texte adopté par les juristes-linguistes[1304], ce qui a ensuite permis au Conseil d'approuver la position du Parlement en première lecture[1305] et d'aboutir à la

1295 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions – Presidency compromise proposal, ST 15678 2018 INIT, 18 décembre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020) (ci-après, le « **Premier Compromis de la Présidence** »).

1296 Rapport de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)) (Rapporteure Evelyn Regner), A8-0002/2019, 9 janvier 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020) (ci-après, l' « **Avis CAJ** »).

1297 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions – Presidency compromise proposal, ST 5380 2019 INIT, 15 janvier 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020) (ci-après, le « **Deuxième Compromis de la Présidence** »).

1298 Note from the General Secretariat of the Council to the Permanent Representatives Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions, ST 5401 2019 INIT, 25 janvier 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020) (ci-après, le « **Compromis des Représentants Permanents** »).

1299 Analysis of the final compromise text with a view to agreement on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions, ST 7426 2019 INIT, 22 mars 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020) (ci-après, le « **Compromis Final** »), p. 3.

1300 Compromis Final, p. 3.

1301 Compromis Final, annexe.

1302 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)), P8_TA-PROV(2019)0429, 18 avril 2019 (ci-après, la « **Proposition du Parlement** »).

1303 Note du Secrétariat général du Conseil au Comité des représentants permanents et au Conseil, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations., fusions et scissions transfrontalières – Résultat de la première lecture du Parlement européen et procédure de rectificatif (Strasbourg, les 18 avril 2019 et 22 octobre 2019), ST 8499 2019 INIT, 29 octobre 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020), p. 2.

1304 Note du Secrétariat général du Conseil au Comité des représentants permanents et au Conseil, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations., fusions et scissions transfrontalières – Résultat de la première lecture du Parlement européen et procédure de rectificatif (Strasbourg, les 18 avril 2019 et 22 octobre 2019), ST 8499 2019 INIT, 29 octobre 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020), p. 2.

1305 Note du Conseil de l'Union européenne du 2 décembre 2019, sur le résultat du vote du Conseil de l'Union européenne sur la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (première lecture) lors de la 3728e session du Conseil de l'Union européenne tenue le 18 novembre 2019, 14768/19, disponible sur https://data.consilium.europa.eu (07/11/2021).

signature de la Directive Mobilité par le Président du Parlement et le Président du Conseil de l'Union européenne le 27 novembre 2019. Cette dernière est entrée en vigueur le premier janvier 2020, correspondant au vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne[1306] et les États membres auront ainsi jusqu'au 31 janvier 2023 pour procéder à sa transposition[1307].

328. Une initiative insuffisante ? Cette initiative introduit de nombreuses innovations déjà abondamment commentées[1308] et destinées avant tout à encadrer

[1306] Art. 5 de la Directive Mobilité.

[1307] Art. 3, § 1er de la Directive Mobilité.

[1308] À ce sujet, voir notamment : St. BARTMANN, « The adopted proposal for an EU Directive on cross-border operations : a realistic compromise », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 140–142 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *BB*, 44/2018, pp. 2566–2572 ; N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, « Gesellschafterschutz in der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *ZIP*, 2018, pp. 2254–2261 ; F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *D.A. O.R.*, 2018/3, n° 127, pp. 5–48 ; Th. BIERMEYER et M. MEYER, "European Commission proposal on corporate mobility and digitalization : between enabling (cross-border corporate) freedom and fighting the "bad guy" », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 110 et 111 ; S. BINARD et L. SCHUMMER, « The case for further flexibility in matters of cross-border mobility », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 31–37 ; D. BOMPOINT, « Le droit de retrait des actionnaires minoritaires de sociétés cotées après la directive n° 2019/2121 sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières », *BJS*, juillet 2020, n° 07-08, disponible sur www.lextenso.fr (13/08/2020), pp. 1–3 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen nach dem EU-Company Law Package », *ZIP, 2018*, pp. 300–312 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen und Formwechsel nach dem EU-Company Law Package », *ZIP*, 2019, pp. 353–365 ; T. O. BRANDI, « Grenzüberschreitender (Heraus-)Formwechsel – praktische Erfahrungen und Vergleich mit Reformvorschlägen im EU Company Law Package », *BB*, 2018, pp. 2626–2635 ; N. BRIDGLAND et M. KULIŃSKA, « Brexit and EU corporate mobility », *C.J.*, 2018/2-3, pp. 59–66 ; Al. BUTTERSTEIN, « Modernisierung des EU-Gesellschaftsrechts zur Stärkung der grenzüberschreitenden Mobilität von Gesellschaften », *EuZW*, 2018, pp. 838–845 ; C. CATHIARD, « Les nouvelles modalités du contrôle des opérations de transformations, fusions et scissions transfrontalières : s'assurer de l'absence de fins abusives, frauduleuses ou criminelles », *BJS*, juillet 2020, n° 07-08, disponible sur www.lextenso.fr (13/08/2020), pp. 1–3 ; P.-H. CONAC, « Le retour du courage politique à Bruxelles : l'Odyssée du "Paquet droit des sociétés" de 2018 », *Rev. Soc.*, janvier 2019, pp. 7–9 ; I. CORBISIER, « Les nouvelles dispositions européennes en matière de mobilité transfrontalière : légitimation du retour à une certaine forme de protectionnisme ? », *RPS-TRV*, 2019, pp. 809 et 810 ; I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, pp. 18–30 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU) in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM (2018) 241 », *NZG*, 2018, pp. 857–867 ; European Company Law Experts (ECLE), « The Commission's 2018 proposal on corporate mobility – An assessment », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 196–221 ; D. FABRIS, « European companies' "mutilated freedom". From the freedom of establishment to the right of cross-border conversion », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 106–113 ; M. FUENTES NAHARRO, M., « Cross-border conversions and the company law package » in Er. KOVÁCS et M. WINNER (dir.), *Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues*, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp. 13–48 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, « Cross-Border Conversions in the EU : The EU Commission Proposal », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 15–43 ; G. VAN GELDER, « The Polbud-case and new EU company law proposal : expanding the possibilities for cross-border conversions in Europe », *EC Tax Review*, pp. 260–266 ; M. GÖTTE et P. MÜCKL, « Unternehmensmitbestimmung und grenzüberschreitende Unternehmensmobilität », *BB*, 2018, pp. 2036–2043 ; M. HABERSACK, « Sekundärrechtlicher grenzüberschreitender Formwechsel ante portas », *ZHR*, 2018, pp. 495–503 ; H. HECKSCHEN, « Das Company Law Package und die Auswirkungen für das Notariat – Digitalisierungs- und Umwandlungsrichtlinie », *NotBZ*, 2020, pp. 241–248 ; M. HIPPELI, « Das Company Law Package der EU-Kommission vom 25.04.2018 », *jurisPR-HaGesR*, 7/2018, Anm, 1, pp. 1–5 ; J. HOFFMANN, « Mitbestimmungsfreie Gesellschaften deutschen Rechts durch grenzüberschreitenden Formwechsel », *EuZW*, 2018, pp. 785–786 ; H. JOCHUM et Al. HEMMELRATH, « Der grenzüberschreitende Hinausformwechsel in Europa – Ein Beitrag zur richterlichen Weitsicht und zum RL-Vorschlag der EU-Kommission v. 25.4.2018 für die Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 », *IStR,* 2019, pp. 517–524 ; R. KNAIER, « Crossing borders, digitally ? Das "Company Law Package" auf dem Prüfstand », *GmbHR*, 2018,

la promesse d'une mobilité accrue des sociétés au sein du marché intérieur faite par la Cour de justice au gré de ses décisions jurisprudentielles en matière

R148 – R150 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht – Die Zukunft der Unternehmensmobilität im Binnenmarkt », *GmbHR*, 2018, pp. 607–624 ; B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés – Evènement historique en droit européen des sociétés : adoption de la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », *Rev. Soc.*, mai 2019, pp. 360–364 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 24–31 ; Th. LUY, « Die Austrittserklärung des Minderheitsgesellschafters nach dem Company Law Package », *GmbHR*, 2019, pp. 1105–1109 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, pp. 1905–1910 ; Th. MASTRULLO, « La protection des créanciers dans la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », *BJS*, juillet 2020, n° 07-08, p. 63, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–3 ; Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *BJS*, juillet 2018, n° 07-08, p. 456, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–8 ; M. MENJUCQ, *Droit international et européen des sociétés*, 6e éd., Paris, L.G.D.J., 2021, pp. 403 à 471 ; M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *Rev. Soc.*, janvier 2019, pp. 17–24 ; M. MENJUCQ, « Les transformations transfrontalières », *BJS*, juillet 2018, n° 07-08, p. 450, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–8 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie für grenzüberschreitende Umwandlungen – Meilenstein oder Scheinriese », *EuZW*, 2019, pp. 141–148 ; C. MÜLLER, « Richtlinie zu grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen in Kraft getreten », *AG*, 2020, R5 – R6 ; M. NOACK, « Das Company Law Package – Vorschläge der Europäischen Kommission zur Harmonisierung des materiellen Schutzes der Minderheitsgesellschafter bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *AG*, 2018, pp. 780–788 ; J. KRAFT et Ul. NOACK, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität – der Richtlinienvorschlag im Company Law Package », *DB*, 2018, pp. 1577–1582 ; G. PARLEANI, « Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux ou « transformations transfrontalières » », *Rev. Soc.*, janvier 2019, pp. 9–17 ; L. PÜTZ, « Die Unternehmensmitbestimmung nach dem „Company Law Package" der EU – Erste Überlegungen zur Umsetzung der neugefassten Mobilitäts-Richtlinie (EU) 2017/1132 in das deutsche Recht », *AG*, 2020, pp. 117–123 ; J. ROEST, *op. cit.*, pp. 74–105 ; E. SCHLUMBERGER, « Le sort des associés dans les opérations de mobilité transfrontalière », *BJS*, juillet 2020, n° 07-08, p. 52, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–4 ; E. SCHLUMBERGER, « Les fusions transfrontalières », *BJS*, juillet 2018, n° 07-08, p. 463, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–9 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU – Eckpunkte des Rechtsrahmens und Herausforderungen bei der Umsetzung », *ZEuP*, 2020, pp. 565–590 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0… », *op. cit.*, 3.2020, p. 1 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects of the EU Commission's Company Law Package : or – "The Good, the Bad and the Ugly" », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 13–17 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 222–271 ; J. SCHMIDT, « Coming soon : „Company Law Package Part 2 - Implementation" », *EuZW*, 2019, pp. 801 et 802 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, pp. 229–244 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *Der Konzern*, 2018/07-08, pp. 273–285 ; Fr. SCHURR, « Schutzbestimmungen und Verfahrensregeln in der neuen Richtlinie zu grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen », *EuZW*, 2019, pp. 539–544 ; E. SCHOLLMEYER, « Der Verschmelzungs-, Spaltungs- und Formwechselbericht nach der neuen Umwandlungsrichtlinie », *AG*, 2019, pp. 541–550 ; E. SCHOLLMEYER, « Die „künstliche Gestaltung" - der Herr Tur Tur unter den Rechtsfiguren », *NZG*, 2018, pp. 977–978 ; Chr. SCHULTE, « Grenzüberschreitende Umwandlungen und Spaltungen – Das Company Law Package in der möglichen registergerichtlichen Umsetzung bis zu einer Transformation in nationales Recht », *GmbHR*, 2020, pp. 139–146 ; M. SELENT, « Die Mitbestimmung nach dem Company Law Package aus Perspektive des deutschen Kompromissvorschlags zur europäischen Mitbestimmung », *NZG*, 2018, pp. 1171–1178 ; A. SOTIROPOULOU, « Réflexions sur l'abus et la fraude en matière de transformations transfrontalières des sociétés », *BJS*, juin 2020, n° 120/5, p. 54, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–9 ; P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie – harmonisierte Verfahren für grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *GmbHR*, 2020, pp. 61–76 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz nach der neuen Umwandlungsrichtlinie », *ZIP*, 2019, pp. 2437–2447 ; Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, pp. 3–14 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, pp. 241–248 ; Chr. TEICHMANN, « Grenzüberschreitende Umwandlungen : EU erweitert die Palette – Neuregelung im Spannungsfeld von Gestaltungsfreiheit und Missbrauchsgefahren », *DB*, 2019, pp. M4 et M5 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *GmbH-StB*, 2018, pp. 283–296 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen

de liberté d'établissement[1309] et principalement dans l'arrêt *Polbud*[1310], tout en intégrant des mécanismes destinés à sauvegarder les intérêts des différents *stakeholders* impactés par une opération transfrontalière[1311]. Si une partie des incohérences du projet d'origine[1312] a certes été rectifiée au cours du processus législatif[1313] et si l'adoption d'une première réglementation relative aux scissions et aux transformations transfrontalières est indéniablement à considérer comme une réussite en soi[1314], il n'en demeure pas moins que la Directive Mobilité souffre d'un certain nombre d'insuffisances.

SECTION 2. LES INSUFFISANCES DU NOUVEAU RÉGIME

§1. Présentation

329. Méthode. À l'égard de l'étude des scissions transfrontalières, il importe d'établir dans quelle mesure les dispositions de la Directive Mobilité ne permettent pas de clore définitivement le débat et justifient, au contraire, que l'on continue à s'intéresser à la question. Pour ce faire, cinq insuffisances majeures seront étudiées, à savoir l'absence d'harmonisation préalable du régime des scissions internes (§ 2), le champ d'application excessivement limité de la Directive Mobilité (§ 3), la disposition anti-abus (§ 4) et les différences de traitement injustifiées (§ 5). Afin de mieux pouvoir les appréhender, il sera, sauf pour la première insuffisance, procédé en quatre étapes distinctes à savoir (i) l'exposé des dispositions de la Proposition de la Commission, (ii) l'examen des critiques formulées à l'encontre de celles-ci, (iii) l'étude de l'évolution de ces dispositions au gré du processus législatif et (iv) la mise en exergue des insuffisances restantes. D'autres insuffisances plus spécifiques seront mises en lumière lors de l'examen de la procédure de scission transfrontalière[1315] et de l'étude des enjeux des différents mécanismes de protection des *stakeholders*[1316], mais, à ce stade de l'analyse, il est indispensable d'établir à quel point la question des scissions transfrontalière n'a pas été close par la Directive Mobilité.

Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *GmbH-StB*, 2018, pp. 317–332 ; H. WICKE, « Optionen und Komplikationen bei der Umsetzung des Richtlinienvorschlags zum grenzüberschreitenden Formwechsel (Teil II) », *DStR*, 2018, pp. 2703–2710 ; H. WICKE, « Optionen und Komplikationen bei der Umsetzung des Richtlinienvorschlags zum grenzüberschreitenden Formwechsel (Teil I) », *DStR*, 2018, pp. 2642–2647 et M. WINNER, « Protection of creditors and minority shareholders », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 44–73.

1309 À ce sujet, voir *supra* Première partie, Titre II, Chapitre 1.

1310 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 45.

1311 4e considérant de la Directive Mobilité.

1312 Pour une étude détaillée des défaillances de la Proposition de la Commission, voir : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 222–271 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, pp. 13–17.

1313 Voir en ce sens : P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 62.

1314 P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2437.

1315 À ce sujet, voir *infra* Première partie, Titre V.

1316 À ce sujet, voir *infra* Deuxième Partie.

§ 2. L'absence d'harmonisation préalable du régime des scissions internes

330. Une question ignorée. Bien que l'Étude d'Impact ait explicitement fait référence au fait que la Sixième Directive avait un champ d'application très restreint[1317], à aucun moment du processus législatif ayant conduit à l'adoption de la Directive Mobilité, il n'a été envisagé de procéder à une harmonisation plus étendue du régime des scissions internes. Pourtant, une telle harmonisation présente un intérêt en ce qu'elle prépare le terrain à une éventuelle mesure d'harmonisation des scissions transfrontalières[1318], sans restriction quant au type de scission couvert[1319], ce qui a pu être démontré par l'exemple des fusions transfrontalières[1320]. En outre, compte tenu du principe fondamental de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes posé par la Cour de justice, une révision préalable du régime des scissions internes aurait indéniablement permis de renforcer la cohérence du régime général des scissions tant internes que transfrontalières consacré par le législateur européen. Au lieu de cela, on aboutit à une situation surprenante nuisant à la cohérence générale du système, illustrée par les deux exemples suivants.

331. Première illustration : une reconnaissance tantôt facultative, tantôt obligatoire. Contrairement aux fusions internes dont la reconnaissance par les États membres a été rendue obligatoire[1321], tel ne fut pas le cas des scissions internes pour lesquelles la seule exigence était que si les États membres décidaient de reconnaître cette forme de restructuration pour les sociétés anonymes, ils la soumettent à la procédure instaurée par la Directive Sociétés[1322]. Compte tenu du fait que la Directive Mobilité ne laisse pas aux États membres le loisir de ne pas reconnaître les scissions transfrontalières[1323], on aboutit à la situation un peu surprenante où les scissions transfrontalières sont traitées plus favorablement que les scissions internes. S'il est certes vrai que cette différence de traitement n'entraînera que peu de conséquences pratiques dans la mesure où on ne voit que difficilement comment un législateur national pourrait mettre en place un régime applicable aux scissions transfrontalières sans, au préalable, autoriser les scissions internes, il n'en demeure pas moins que la cohérence du régime général des scissions en souffre. Il aurait dès lors été préférable de procéder au préalable à une reconnaissance obligatoire de la figure de la scission interne, comme cela avait déjà été recommandé par le passé[1324].

332. Deuxième illustration : le contenu du projet commun de scission. Dans la mesure où les dispositions de la Directive Mobilité en matière de

1317 Étude d'impact, p. 24.
1318 Voir en ce sens : Th. PAPADOPOULOS, « The Magnitude of EU Fundamental Freedoms… », *op. cit.*, p. 524.
1319 Sur le champ d'application *ratione materiae* excessivement limité de la Directive Mobilité, voir *infra* n°s 341 à 346.
1320 Voir en ce sens : K. GEENS et M. WYCKAERT, « Cross-border mergers and minority protection – An open-ended harmonization », *Utrecht Law Review*, mars 2008, vol. 4, n° 1, p. 41.
1321 Art. 88 de la Directive Sociétés.
1322 Art. 135, §§ 1–3 de la Directive Sociétés.
1323 Art. 160*bis* de la Directive Mobilité.
1324 E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 375, n° 3.

transformations et de scissions transfrontalières s'inspirent du régime existant des fusions transfrontalières[1325], il n'est pas surprenant de constater que le projet commun de scission transfrontalière intègre des mentions supplémentaires par rapport au projet de scission interne[1326]. Si, comme pour les fusions transfrontalières[1327], certaines de ces mentions additionnelles se justifient par le caractère transfrontalier de l'opération, on peut néanmoins se demander si les risques encourus par les différents *stakeholders* dans le cadre d'une scission[1328] n'auraient pas justifié une extension de ce régime aux scissions internes. Ce point est clairement illustré dans le cadre de la protection des créanciers. Afin de garantir une information adéquate de ces derniers, il est ainsi prévu dans le cadre des scissions transfrontalières que le projet de scission devra notamment inclure « des dispositions relatives au traitement d'éléments d'actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du projet de scission transfrontalière, tels que des éléments d'actif ou de passif inconnus à la date d'établissement du projet de scission transfrontalière »[1329], de même que « les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages »[1330]. Or, les faits à la base du récent arrêt *I.G.I.*[1331] ont montré à suffisance qu'une scission interne pouvait être très facilement utilisée par un débiteur pour agir en fraude des droits de ses créanciers[1332]. En effet, à l'origine du litige, on trouve la scission partielle par constitution de nouvelle société par le biais de laquelle la société de droit italien Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl avait transféré la majeure partie de son patrimoine actif à la nouvelle société dénommée I.G.I. Srl de manière à ne plus conserver dans son propre patrimoine que quelques parcelles de terrain de faible valeur et ce, au grand dam de ses créanciers[1333]. On ne peut dès lors que s'interroger sur la question de savoir pourquoi de telles mentions, pourtant utiles à la bonne information des créanciers, ne devraient pas également se retrouver dans le projet de scission interne. *A fortiori* si on prend également en ligne de compte le fait que la société souhaitant réaliser une scission transfrontalière pour mettre une partie de son patrimoine à l'abri des créanciers tout en limitant l'information fournie aux créanciers à cet égard n'aura qu'à procéder en deux étapes en réalisant

1325 J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 300 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2438 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 62.

1326 Pour une étude détaillée des mentions figurant dans le projet de scission transfrontalière, voir *infra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1er, Section 3, § 7.

1327 Proposition de directive du Parlement et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux du 18 novembre 2003, COM2003 (703) final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (08/12/2017), p. 3 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 113 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 312 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 394 et D. WILLERMAIN, *op. cit.*, p. 586.

1328 Sur ces risques, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 1er pour les risques encourus par les créanciers ; Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 1er pour les risques encourus par les associés minoritaires et Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 1 pour les risques encourus par les travailleurs.

1329 Art. 160*quinquies*, l) *in fine* de la Directive Mobilité.

1330 Art. 160*quinquies*, q) de la Directive Mobilité.

1331 Arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele, en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 30 janvier 2020, C-394/18, EU:C:2020:56 (ci-après l' « **Arrêt *I.G.I.*** »).

1332 Pour une étude détaillée de cet arrêt, voir *infra* n° 799.

1333 Arrêt *I.G.I.*, pts. 25 et 26.

tout d'abord une scission partielle par le biais de laquelle la majeure partie de son patrimoine actif serait transférée à une nouvelle société nationale, suivie de près d'une transformation transfrontalière pour éluder d'éventuels mécanismes de protection. Certes, la procédure de transformation transfrontalière prévoit également que le projet de transformation devra inclure un certain nombre de mentions essentiellement destinées à garantir une bonne information des créanciers comme l'obligation de mentionner « les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages »[1334], mais celles-ci ne seront d'aucune utilité aux créanciers spoliés de la société scindée.

§ 3. Un champ d'application volontairement limité

A. *Un champ d'application* ratione personae *limité*

1. *La limite des sociétés de capitaux*

333. Le choix du législateur européen. Alors que les dispositions de la Directive Sociétés applicables en matière de scissions internes étaient strictement limitées aux seules sociétés anonymes[1335], les dispositions de la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières s'appliquent à toutes les sociétés de capitaux[1336]. Si cette limitation aux seules sociétés de capitaux a pu être justifiée (i) d'une part par le fait que les données statistiques relatives aux fusions transfrontalières ont établi que seuls deux pourcents des sociétés impliquées dans une fusion transfrontalière n'étaient pas soit une société à responsabilité limitée, soit une société anonyme[1337] et (ii) d'autre part par le fait que les règles de droit des sociétés et de droit comptable n'ont été harmonisées au niveau européen qu'à l'égard des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes[1338], elle ne manque pas de surprendre, notamment au vu des critiques ayant été adressées au champ d'application trop restreint de la Directive Sociétés à l'égard des fusions transfrontalières[1339].

334. Une incohérence avec la liberté d'établissement. La première remarque concerne le fait que, nonobstant les limitations du champ *ratione personae* adoptées par le législateur européen dans la Directive Mobilité, la liberté d'établissement, qui s'applique également aux scissions transfrontalières[1340], profite, selon les termes du TFUE à toutes « les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but

1334 Art. 86*quinquies*, f) de la Directive Mobilité.
1335 Art. 135, § 1er et annexe I de la Directive Sociétés.
1336 Art. 160*ter*, § 1er et annexe II de la Directive Mobilité.
1337 Étude d'impact p. 57 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 101 et 102 qui ont démontré qu'entre 2008 et 2012, 66 % des sociétés absorbantes et 70 % des sociétés fusionnantes impliquées dans une fusion transfrontalière étaient des sociétés à responsabilité limitée et 32 % des sociétés absorbantes et 28 % des sociétés fusionnantes étaient des sociétés anonymes.
1338 Étude d'impact, p. 57.
1339 À ce sujet, voir *supra* n° 301.
1340 À ce sujet, voir *supra* n° 153.

lucratif »[1341], ce qui va bien au-delà des seules sociétés de capitaux. Si l'objectif du législateur européen est effectivement de supprimer certains obstacles à la liberté d'établissement tout en garantissant une protection optimale des travailleurs, des créanciers et des associés minoritaires[1342], il est essentiel, à terme, d'assurer un certain parallélisme entre le champ d'application *ratione personae* de la liberté d'établissement et celui des mesures de droit dérivé destinées à encadrer et à concrétiser certaines modalités d'exercice de la liberté d'établissement[1343]. Ce point n'avait déjà pas échappé au législateur belge lors de la transposition de la Dixième Directive qui, au vu des enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Sevic* et du fait que les activités transfrontalières ne sont pas l'apanage des seules sociétés anonymes, avait fait le choix d'autoriser les fusions transfrontalières pour toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique[1344]. Cette tendance, encouragée par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement se retrouve en outre dans de nombreux États membres à l'égard des fusions transfrontalières[1345] et même le Parlement européen semble partir du principe qu'il s'agit là de l'objectif ultime des initiatives législatives en matière de mobilité des entreprises[1346].

335. Des données chiffrées sujettes à interprétations divergentes. Le faible nombre de fusions transfrontalières impliquant des sociétés autres que des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée ne s'explique pas nécessairement que par le fait que les autres formes sociales ne souhaitent pas procéder à des restructurations transfrontalières. Bien au contraire, il est tout à fait possible que l'absence de cadre harmonisé applicable à celles-ci les dissuade tout simplement d'y recourir en raison des coûts prohibitifs et de l'insécurité juridique qui y sont associés[1347].

1341 Art. 54, al. 2 du TFUE.

1342 5e considérant de la Directive Mobilité.

1343 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2572 ; J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 354 ; T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2630 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 841 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 857 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 143 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 230 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 13 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 285 ; P. STELMASZCYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 62, n° 8 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 318 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 286 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil I) », *op. cit.*, p. 2643.

1344 Projet de loi portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2007–2008, n° 1012/001, p. 54.

1345 Étude Bech-Bruun & Lexidale, p. 100.

1346 Selon le Parlement européen, « il importe de prévoir une harmonisation la plus complète possible pour les futures propositions législatives relatives à la mobilité des entreprises, notamment en ce qui concerne les normes procédurales, les droits des acteurs de la gouvernance d'entreprise – en particulier les acteurs minoritaires – et l'*extension du champ d'application à tous les agents définis comme « entreprise » selon l'article 54 du traité FUE* ». Voir Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pt. 3.

1347 Voir en ce sens également : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 230 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 285.

336. Une certaine forme de « discrimination à rebours » difficilement justifiable. Assez étonnamment, alors que le régime des scissions internes consacré par la Directive Sociétés ne s'applique qu'aux seules sociétés anonymes[1348], les dispositions de la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières ont vocation à s'appliquer également aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux sociétés en commandite par actions[1349]. Selon l'exposé des motifs de la Proposition de la Commission[1350], l'extension du régime des scissions transfrontalières aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux sociétés en commandite par actions par rapport aux dispositions de la Directive Sociétés applicables aux scissions internes s'explique par la volonté de « garantir la cohérence avec l'acquis de l'UE dans le domaine du droit des sociétés ». Il est certes vrai qu'il eût été absurde d'ouvrir les transformations et les fusions transfrontalières à toutes les sociétés de capitaux tout en limitant les dispositions applicables aux scissions transfrontalières aux seules sociétés anonymes, ne fût-ce qu'en raison de l'exigence de cohérence entre les différentes formes de restructuration car elles sont aisément interchangeables[1351]. En outre, l'arrêt *Polbud* a montré à suffisance la nécessité d'un cadre harmonisé dépassant la seule limite des sociétés anonymes puisque les faits à l'origine du litige concernaient une société à responsabilité limitée[1352]. Malgré cette évolution bienvenue[1353], on ne peut que s'étonner du fait que ce souci de cohérence n'ait pas poussé le législateur européen à aligner le champ d'application *ratione personae* des scissions internes sur celui des autres opérations et ce, d'autant plus que de nombreux États membres, tels que la Belgique[1354], le Luxembourg[1355], la France[1356], l'Allemagne[1357] ou encore l'Autriche[1358], ont fait le choix d'ouvrir les scissions internes à des sociétés autres que les sociétés anonymes. Il en résulte une situation pour le moins surprenante où une société à responsabilité limitée pourrait bénéficier d'un régime des scissions transfrontalières harmonisé, mais pas d'un régime des scissions internes.

2. *La question de l'exclusion des sociétés en situation précaire*

337. L'exclusion catégorique de la Proposition de la Commission. Allant au-delà des exclusions prévues par la Directive Sociétés[1359], les dispositions de la Proposition de la Commission prévoyaient que les sociétés qui faisaient

1348 Art. 135, § 1er et annexe I de la Directive Sociétés.
1349 Art. 160*bis*, § 1er et 160 *ter*, point 1) de la Directive Mobilité.
1350 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 31.
1351 Voir en ce sens : P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 62.
1352 Arrêt *Polbud*, pt. 8.
1353 Voir à ce sujet : R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 576, n° 12 qui plaidait déjà en faveur d'une extension du champ d'application de la Sixième Directive aux sociétés à responsabilité limitée en vue de faire des scissions transfrontalières une réalité.
1354 Art. 12:1, § 1er, al. 1er du CSA.
1355 Art. 1030-1, al. 1er de la Loi sur les sociétés commerciales.
1356 Art. L-236-1, al. 2 du Code de commerce français.
1357 § 1(1) UmwG.
1358 § 1(1) SpaltG.
1359 Selon l'art. 120, § 4 de la Directive Sociétés, les États membres ont l'obligation d'exclure les « sociétés qui font l'objet de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ».

l'objet d'une procédure de dissolution, de liquidation ou d'insolvabilité[1360], d'une mesure préventive de restructuration en cas de risque de faillite[1361], ainsi que celles qui se trouvaient en état de cessation de paiements[1362], les sociétés faisant l'objet d'une mesure nationale préventive afin d'éviter une des trois situations d'exclusion précédentes ainsi que celles qui faisaient l'objet de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59[1363][1364] devaient être exclues de son champ d'application. Cependant, une exclusion obligatoire de ces catégories de sociétés, bien qu'elle ait pour objectif d'éviter que les scissions transfrontalières ne soient utilisées abusivement dans un contexte particulièrement délicat pour les différents *stakeholders*[1365] et qu'elle ait pu être qualifiée de « protection générale des « parties prenantes » »[1366], pourrait potentiellement être contraire à la liberté d'établissement[1367] et aller au-delà de ce qui est nécessaire[1368]. En outre, elle ne se justifie pas dans la mesure où une opération de scission transfrontalière peut s'avérer être une méthode d'assainissement particulièrement efficace[1369] permettant notamment à une société de se débarrasser de certaines branches d'activités en perte de vitesse ou trop gourmandes en capitaux[1370].

1360 Art. 160*quinquies*, § 2, (a) de la Proposition de la Commission.

1361 Art. 160*quinquies*, § 2, (b) de la Proposition de la Commission.

1362 Art. 160*quinquies*, § 2, (c) de la Proposition de la Commission.

1363 Directive (UE) 2014/59 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive (CEE) 82/891 du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil (CE) 2001/24, (CE) 2002/47, (CE) 2004/25, (CE) 2005/56, (CE) 2007/36, (UE) 2011/35, (UE) 2012/30 et (UE) 2013/36et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 1093/2010 et (UE) 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 173, 12 juin 2014, pp. 190–348.

1364 Art. 160*quinquies*, § 2, (d) de la Proposition de la Commission.

1365 J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 301 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, pp. 612 et 613 ; Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 3 et 4 ; M. MENJUCQ, « Les transformations transfrontalières », *op. cit.*, p. 5, n° 34 ; G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 11, n° 14 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 236 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 ; P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 63 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 324 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 287.

1366 M. MENJUCQ, *ibidem*, p. 5, n° 34.

1367 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 23.

1368 *Pro :* Avis CAEM, pp. 30, 32, 80 et 81 ; J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, pp. 301 et 302 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 236 ; P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie – harmonisierte Verfahren für grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 63 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil I) », *op. cit.*, p. 2643. *Contra :* G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 11, n° 14 qui considère qu'une telle exclusion est logique dans la mesure où dans de telles situations, la territorialité est nécessaire à la protection des créanciers. Voir également en faveur de l'exclusion générale de la Proposition de la Commission : Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 287.

1369 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 22. Voir en ce sens à propos des scissions internes : Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 5.

1370 Pour une explication détaillée de l'intérêt économique des scissions transfrontalières, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2. Voir en ce sens déjà à propos des scissions internes : Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 5.

Ce point n'a pas manqué d'être relevé par la Commission des affaires économiques et monétaires dans son avis où elle a suggéré de supprimer l'exclusion obligatoire des sociétés faisant l'objet d'une mesure préventive de restructuration en cas de risque d'insolvabilité, tout en la remplaçant par l'exigence que les sociétés en proie à des mesures de restructuration préventive en raison d'une faillite probable fassent l'objet d'un examen par les autorités compétentes des États membres visant à déterminer si la scission pourrait présenter une quelconque utilité dans le cadre de la procédure destinée à éviter la faillite[1371]. La Commission des affaires juridiques a, pour sa part, prôné la suppression de l'exclusion obligatoire des sociétés faisant l'objet d'une mesure préventive de restructuration en cas de risque d'insolvabilité[1372]. En remplacement, elle a proposé d'introduire l'obligation de procéder à une appréciation approfondie dans le cadre du contrôle de légalité[1373] si la société fait l'objet d'une procédure de restructuration préventive en raison de la probabilité d'insolvabilité ou fait l'objet de vérifications, inspections ou enquêtes prévues au chapitre VI de la directive 2006/123/CE, ou dans la directive 2014/67/UE[1374].

338. La position plus nuancée du Conseil. Passant d'un extrême à l'autre, le Premier Compromis de la Présidence a réduit l'exclusion trop générale de la Proposition de la Commission à (i) une exclusion obligatoire des sociétés sujettes à des procédures de dissolution applicables à des sociétés en situation d'insolvabilité, ainsi que de celles qui faisaient l'objet de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59[1375] et (ii) une exclusion facultative des sociétés en proie à des procédures d'insolvabilité préventive autres que celles visées par l'exclusion obligatoire ou encore des cadres de restructuration préventifs. Cette position a été complétée dans le Deuxième Compromis de la Présidence par l'ajout d'une exclusion facultative des sociétés sujettes à des procédures de dissolution et de liquidation autres que celles visées par l'exclusion obligatoire, ainsi que de celles faisant l'objet de mesures de prévention de crise au sens de l'art. 2, § 1er, point 101 de la directive (UE) 2014/59.

339. Le compromis de la Directive Mobilité. Lors des négociations ayant conduit à l'adoption du Compromis des Représentants Permanents, un certain nombre de délégations ont fait pression pour bénéficier d'un *opt-out* plus large couvrant directement les sociétés en liquidation volontaire ainsi que celles qui sont sujettes à des mesures de prévention de crise couvertes par la directive (UE) 2014/59, alors que d'autres auraient, au contraire, préféré un régime s'inspirant de celui applicable alors aux fusions transfrontalières[1376] mais plus flexible de manière à couvrir également d'autres procédures[1377]. Le compromis auquel ces négociations ont abouti prévoit une exclusion obligatoire

1371 Avis CAEM, pp. 80 et 81.
1372 Avis CAJ, p. 169.
1373 Sur l'appréciation approfondie dans le cadre du contrôle anti-abus, voir *infra* n° 348.
1374 Avis CAJ, p. 206.
1375 Art. 160c, §§ 4 et 5 du Premier Compromis de la Présidence.
1376 Selon l'art. 120, § 4 de la Directive Sociétés, les États membres ont l'obligation d'exclure les « sociétés qui font l'objet de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ».
1377 Compromis des Représentants Permanents, p. 3.

du régime des scissions transfrontalières (i) des sociétés en liquidation et ayant commencé à distribuer leurs actifs à leurs associés et (ii) des sociétés sujettes à des outils de résolution, des pouvoirs ou encore des mécanismes visés par le titre IV de la directive (UE) 2014/59[1378] ou au titre V du Règlement (UE) 2021/23[1379][1380], ainsi qu'une exclusion facultative des sociétés sujettes à (i) des procédures d'insolvabilité ou des cadres de restructuration préventifs, (ii) des procédures de liquidation autres que celles faisant l'objet d'une exclusion obligatoire et (iii) des mesures de prévention de crise au sens de l'art. 2, § 1er, point 101 de la directive (UE) 2014/59[1381] ou de l'article 2, point 48) du Règlement (UE) 2021/23[1382]. Cette position est celle qui s'est retrouvée à l'issue du trilogue dans le Compromis Final[1383], la Proposition du Parlement[1384] et la Directive Mobilité[1385].

340. Des insuffisances persistantes. Si le fait de reléguer un certain nombre des exclusions obligatoires de la Proposition de la Commission au rang de simples exclusions facultatives a certes permis d'aboutir à un compromis politique acceptable, il n'en demeure pas moins que les insuffisances d'origine n'en ont pas pour autant été écartées. En effet, l'exclusion facultative des sociétés soumises à des cadres de restructuration préventive méconnaît toujours le fait qu'une scission transfrontalière peut s'avérer être un instrument d'assainissement particulièrement efficace[1386]. De même, la possible interdiction générale faite aux sociétés soumises à des cadres de restructuration préventive soulève des interrogations à l'aune de la liberté d'établissement[1387] dont il a été établi qu'elle devait trouver à s'appliquer également aux scissions transfrontalières[1388].

1378 Art. 160c, § 4 du Compromis des Représentants Permanents.

1379 Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) nos 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 22, 22 janvier 2021, pp. 1–102.

1380 Cette modification du texte de la Directive Mobilité découle de l'article 92, point 5), point a) du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) nos 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 22, 22 janvier 2021, pp. 1–102.

1381 Art. 160c, § 5 du Compromis des Représentants Permanents.

1382 Cette modification du texte de la Directive Mobilité découle de l'article 92, point 5), point b) du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) nos 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 22, 22 janvier 2021, pp. 1–102.

1383 Art. 160c, §§ 4 et 5 du Compromis Final.

1384 Art. 160*quater*, §§ 4 et 5 de la Proposition du Parlement.

1385 Art. 160*bis*, §§ 4 et 5 de la Directive Mobilité.

1386 Voir en ce sens : Avis CAEM, pp. 30, 32, 80 et 81 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, pp. 22 et 23 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 568 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 236. Voir également en ce sens à propos des scissions internes : Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 5.

1387 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *ibidem*, p. 23.

1388 À ce sujet, voir *supra* n° 153.

En effet, au vu notamment (i) de la solution moins intrusive de l'examen au cas par cas proposé par la Commission des affaires économiques et monétaires au cours du processus législatif[1389] et (ii) de la protection efficace des intérêts des créanciers que pourrait prodiguer une transposition nationale de l'exigence d'une déclaration de solvabilité tirant pleinement parti des enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Kornhaas*[1390], il est peu probable que la condition de proportionnalité du « *Gebhard test* »[1391] soit remplie en l'occurrence.

B. *Un champ d'application* ratione materiae *limité*

341. Le choix réservé de la Proposition de la Commission. Alors que dans sa résolution du 13 juin 2017, le Parlement européen avait clairement indiqué qu'une initiative en matière de scissions transfrontalières devrait couvrir toutes les formes de scissions pratiquées actuellement[1392], et malgré les recommandations des études préalables[1393] et la large définition de la notion de scission transfrontalière prônée par l'Étude d'impact[1394], la Proposition de la Commission ne traite que des opérations de scission entraînant la constitution d'une ou de plusieurs nouvelle(s) société(s)[1395]. La Commission explique ce choix dans l'exposé des motifs par la « complexité de la gestion des risques d'abus » dans le cas d'une scission transfrontalière impliquant une société bénéficiaire préexistante[1396], ainsi qu'au 38e considérant par le fait que les scissions de ce type ont été considérées comme étant « très complexes, nécessitant la participation d'autorités compétentes de plusieurs États membres et entraînant des risques supplémentaires en termes de fraude et de contournement de ces règles »[1397]. En revanche, elle ne cite aucune étude empirique étayant cette méfiance à l'égard des scissions par acquisition et des scissions mixtes[1398].

342. Un choix critiquable à plus d'un titre. Cependant, malgré ces tentatives de justification, le choix de la Commission est critiquable à plus d'un titre[1399].

1389 Avis CAEM, pp. 80 et 81.

1390 Sur l'intérêt de la déclaration de solvabilité en cas d'insolvabilité suivant de près la réalisation d'une scission transfrontalière, voir *infra* nos 914 à 916.

1391 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.

1392 Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pt. 18.

1393 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 53 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 29.

1394 Étude d'impact, p. 8.

1395 Art. 160*ter*, § 3 de la Proposition de la Commission.

1396 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 9.

1397 38e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité.

1398 Voir en ce sens : P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 62, n° 5.

1399 Pour un point de vue critique, voir : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », p. 2570 ; F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 12 ; J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 355 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 845 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 866 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 201 et 202 ; I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 21 ; M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 18, n° 8 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 142 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 234 et 235 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, pp. 14 et 15 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) »,

Tout d'abord, comme cela a été très justement soulevé tôt dans le processus législatif[1400], les scissions transfrontalières sont, de manière générale, des opérations très complexes impliquant des autorités compétentes de plusieurs États membres et ce, peu importe que les sociétés bénéficiaires soient préexistantes ou nouvellement constituées. Ensuite, la Commission se montre très vague en alléguant des risques additionnels en termes de fraude et de contournement des règles mais elle s'abstient d'en donner un exemple ou d'expliquer pourquoi il est préférable de maintenir ce type d'opération dans un vide juridique[1401]. Certes, il est vrai qu'en matière de protection des créanciers, les scissions transfrontalières par acquisition présentent un risque additionnel non négligeable pour les créanciers de la société scindée s'il s'avère qu'une des sociétés bénéficiaires est en situation financière précaire[1402], mais il existe des mécanismes de protection efficaces permettant de contrer d'éventuels abus[1403] et de préserver l'objectif de neutralité de ce type d'opération sur la situation des créanciers[1404]. En outre, on peut relever qu'il a été établi que la liberté d'établissement couvrait tous types de scissions transfrontalières, indépendamment du fait qu'elles soient par acquisition ou par constitution de nouvelles sociétés[1405]. Ainsi, par application du principe de non-discrimination des opérations internes par rapport aux opérations transfrontalières[1406], il s'ensuit que si une société dispose de la possibilité de réaliser une scission par acquisition dans l'ordre interne, elle aura nécessairement la possibilité de réaliser une telle opération dans un cadre transfrontalier. Or, si de telles opérations présentent des risques additionnels pour les *stakeholders* comme l'avance la Commission, mais que d'un autre côté elle justifie son intervention à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés à l'aune du principe de subsidiarité en arguant de la nécessité d'une intervention du législateur européen pour garantir l'efficacité de la protection des *stakeholders*, quand bien même cette dernière ne serait essentiellement fixée qu'à l'échelon national[1407], on ne peut s'empêcher d'y

op. cit., p. 273 ; P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 64 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 243 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 329. *Pro* : Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 3 qui avance qu' « [i]l est cependant difficile de reprocher à la Commission de faire preuve de prudence pour éviter que le droit de l'Union soit invoqué aux fins d'abus ».

1400 J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 355 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, pp. 234 et 235 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 275.

1401 F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 11 et 12 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 845 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, pp. 234 et 235 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 275 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 64.

1402 Sur ce risque, voir *infra* n° 700.

1403 Sur les différents mécanismes de protection envisageables à l'égard des créanciers, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1.

1404 Sur cet objectif de neutralité, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 2.

1405 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1, Section 7.

1406 Sur ce principe, voir *supra* n° 153.

1407 Selon la Commission, « [a]lors que les niveaux substantiels de protection des travailleurs, des actionnaires minoritaires et des créanciers resteraient fixés à l'échelon national, un cadre de procédures pour leur application en cas d'opérations transfrontalières devrait être fixé à l'échelon de l'UE aux fins de garantir la sécurité juridique et l'efficacité d'une telle protection ». Voir Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 14.

voir une certaine contradiction. En effet, la Commission justifie son intervention notamment par la nécessité de protéger les *stakeholders*, mais *a contrario*, elle s'abstient de réglementer les opérations les plus hasardeuses pour ces derniers. D'autant plus qu'en introduisant une procédure de transformation transfrontalière[1408], elle simplifie la réalisation d'une scission par acquisition transfrontalière en deux étapes en passant par une scission interne suivie à brève échéance d'une transformation transfrontalière[1409]. Au-delà de cela, on peut encore relever que la Commission justifie également son intervention législative par la nécessité de réduire les coûts excessifs pour les entreprises dus notamment à l'absence de procédure harmonisée[1410]. Cet argument est étayé par des données chiffrées qui figuraient déjà dans l'Étude d'impact[1411], mais en se penchant sur ces dernières, on ne peut que s'étonner du fait que la Commission escomptait créer davantage d'économies pour les entreprises par le biais de sa réglementation sur les scissions transfrontalières que par le biais de celle applicable aux transformations transfrontalières[1412]. Or, si les scissions par acquisition transfrontalières sont effectivement des opérations plus complexes[1413], elles en sont nécessairement également plus coûteuses. Par conséquent, à ce titre également, le choix de la Commission de délaisser ces dernières surprend. À titre subsidiaire, on peut également relever que, dans un contexte purement interne, les risques spécifiques posés par une scission impliquant plus d'une société préexistante pour les différents *stakeholders*, abstraction faite des risques additionnels engendrés par la nature transfrontalière de l'opération[1414], n'ont pas empêché l'adoption d'un régime harmonisé pour les scissions par acquisition[1415].

343. Des avis très divergents. Dès le 17 octobre 2018, le Comité économique et social européen, tout en reconnaissant la nécessité d'introduire une réglementation spécifiquement applicable aux scissions transfrontalières, a tenu à souligner la nécessité de réglementer également les scissions transfrontalières par acquisition[1416]. Adoptant une attitude radicalement opposée, la Commission des affaires économiques et monétaires a exprimé son scepticisme quant à la nécessité de réglementer les scissions transfrontalières en général[1417]. Cependant, on peut toutefois relever que l'opinion de cette dernière

1408 Voir chapitre Ier de la Proposition de la Commission.
1409 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, pp. 201 et 202.
1410 Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 14, 15 et 23.
1411 Étude d'impact, p. 58.
1412 Selon la Commission, l'introduction de nouvelles règles communes sur les scissions transfrontalières devait permettre aux entreprises de réaliser des économies de l'ordre de 12 000,- à 37 000,- EUR, alors que les règles applicables aux conversions transfrontalières ne devaient permettre que de faire des économies de l'ordre de 12 000,- à 19 000,- EUR. Voir : Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 23.
1413 Étude d'impact, pp. 25 et 26.
1414 Sur la nécessité d'une protection renforcée des créanciers en raison de la nature transfrontalière de l'opération, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1er, Section 4. Sur la nécessité d'une protection renforcée des associés minoritaires en raison de la nature transfrontalière de l'opération, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1er, Section 4.
1415 Art. 136, § 1er de la Directive Sociétés.
1416 Avis CESE, recommandation 3.6.9.
1417 Selon l'Avis CAEM, « [t]*he rapporteur is not convinced of including cross-border divisions in the proposal. The division proposal only covers a limited range of divisions, that is splitting up the firm*

est quelque peu contradictoire. En effet, d'un côté elle semble se baser sur le fait que la Proposition de la Commission ne couvre que les scissions par constitution de nouvelles sociétés pour justifier sa position, mais d'un autre côté, il ne voit pas la nécessité de réglementer ce type d'opérations et y voit même un danger, sans toutefois préciser davantage ce dernier ou expliquer en quoi un vide juridique serait préférable à une réglementation. En outre, loin de supprimer les dispositions de la Proposition de la Commission dans ses commentaires, elle prend malgré tout la peine de faire des suggestions destinées à en améliorer le régime, comme par exemple rendre la déclaration de solvabilité de l'organe de gestion ou d'administration obligatoire[1418] ou encore la suggestion de condenser les deux rapports de l'organe de gestion ou d'administration en un seul[1419]. La Commission de l'emploi et des affaires sociales ne semble pas s'être préoccupée de cette question. En revanche, la Commission des affaires juridiques, tout en prodiguant des remarques d'ordre légistique à cet égard en proposant de condenser les diverses définitions au sein d'un nouvel article 1*bis* sans toutefois étendre la définition de scission transfrontalière[1420], a également suggéré de supprimer le chapitre sur les scissions transfrontalières en arguant que les sociétés désireuses de réaliser une telle opération pouvaient se contenter de réaliser une scission interne suivie d'une transformation transfrontalière[1421].

344. Les évolutions au gré des différents compromis. Le Premier Compromis de la Présidence n'a, pour sa part, pas changé la position initiale de la Proposition de la Commission à l'égard des scissions par acquisition et s'est contenté d'adhérer au champ d'application *ratione materiae* limité[1422] tout en intégrant les scissions par séparation[1423]. Ces dernières, dont l'ajout avait été souhaité par une partie de la doctrine[1424], visent l'opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs société(s) nouvellement constituée(s) en échange de l'émission d'instruments où d'actions de la société bénéficiaire, non pas aux associés de la société scindée comme dans le cadre d'une scission classique[1425], mais à la société scindée elle-même. Cette opération correspond à un apport partiel d'actifs par constitution de nouvelle société tel qu'il existe déjà dans le droit de nombreux

into two or more newly created companies. There are doubts about the need for divisions to be included, as well as concerns about the risks and dangers of doing it, and it is therefore suggested to delete this part from the proposal. ». Voir Avis CAEM, p. 3.

1418 Avis CAEM, amendement 188.

1419 Avis CAEM, amendement 159.

1420 Avis CAJ, pp. 75 et 76, art. 1*bis*, 11).

1421 Avis CAJ, exposé des motifs, p. 217.

1422 9e considérant du Premier Compromis de la Présidence.

1423 Art. 160b, 3), (c) du Premier Compromis de la Présidence.

1424 W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », p. 2570 ; J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 355 ; S. BINARD et L. SCHUMMER, *op. cit.*, p. 36 ; M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 18, n° 4 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 234 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, pp. 14 et 15 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 275.

1425 Sur la notion de « scission », voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 1.

États membres[1426] et se rapproche en outre de la notion d' « apport d'actifs » (*division by separation*, *hive-down*, *Ausgliederung*) telle qu'elle figure dans la Directive Fiscale[1427]. Si l'intégration de ce type d'opérations correspond certes aux recommandations faites par les deux études préliminaires[1428] ainsi que par l'Étude d'impact[1429] et permettra indéniablement de simplifier la situation applicable dans certains États membres comme l'Autriche où une telle opération ne s'accompagne pas des bénéfices de la transmission à titre universel[1430], on ne peut que déplorer que le champ d'application de ce type d'opération soit à nouveau strictement limité aux opérations n'impliquant pas une société bénéficiaire préexistante. Cet état de fait n'a changé ni dans le Deuxième Compromis de la Présidence[1431], ni dans le Compromis des Représentants Permanents[1432], ni dans le Compromis final[1433], ni encore dans la Proposition du Parlement[1434].

345. La position insatisfaisante de la Directive Mobilité. À la suite de ces évolutions législatives et malgré les appels répétés de la doctrine[1435], il est regrettable que la Directive Mobilité exclue de son champ d'application les scissions impliquant plus d'une société préexistante[1436]. Au sujet de la motivation de ce choix, la seule différence avec la Proposition de la Commission est que la Directive Mobilité n'avance plus le risque accru de fraude lié aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[1437]. Par contre, elle retient toujours que ce type de scission est particulièrement complexe en ce qu'il (i) nécessite la participation des autorités compétentes de plusieurs États membres et (ii) entraîne des risques de contournement des règles européennes et nationales[1438]. Il s'ensuit qu'elle présente les mêmes insuffisances que la Proposition de la Commission[1439], notamment au regard du caractère laconique

1426 § 123(3), 2. UmwG ; art. 1040-2 à 1040-4 de la Loi sur les sociétés commerciales ; art. 12:9 et 12:10 du CSA et L236-6-1 du Code de commerce français.

1427 Selon l'art. 2, b) de la directive (CE) 2009/133 du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre (version codifiée), *J.O.U.E.*, L 310/34, 25 novembre 2009, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (14/01/2019) (ci-après la « **Directive Fiscale** »), on entend par « apport d'actifs », l' « opération par laquelle une société apporte sans être dissoute l'ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ».

1428 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 53 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 29.

1429 Étude d'impact, pp. 8, 9 et 57 à 60.

1430 Sur la situation complexe de l' « *Ausgliederung* » en droit autrichien, voir S. KALSS in S. KALSS (dir)., *op. cit.*, p. 777 et 778, n° 25.

1431 9e considérant et art. 160b, § 3 du Deuxième Compromis de la Présidence.

1432 9e considérant et art. 160b, § 3 du Compromis des Représentants Permanents.

1433 47e considérant et art. 160b, § 3 du Compromis final.

1434 47e considérant et art. 160*ter*, § 3 de la Proposition du Parlement.

1435 W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2570 ; J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 355 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 201 et 202 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, pp. 14 et 15 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 275.

1436 8e considérant et art. 160*ter*, § 3 de la Directive Mobilité.

1437 38e considérant de la Proposition de la Commission et 8e considérant de la Directive Mobilité.

1438 38e considérant de la Proposition de la Commission et 8e considérant de la Directive Mobilité.

1439 Sur ces insuffisances, voir *supra* n° 341.

de sa justification, ainsi qu'à l'aune de la liberté d'établissement. En outre, elle aura pour conséquence de créer un régime des scissions transfrontalières à deux vitesses[1440], à savoir (i) un régime bien encadré fondé sur le modèle européen des opérations transfrontalières[1441] et applicable aux seules scissions n'impliquant pas une société bénéficiaire préexistante et (ii) un régime flou applicable aux scissions par acquisition et aux scissions mixtes qui souffrira d'une insécurité juridique manifeste et ce, potentiellement au détriment des *stakeholders* puisqu'à titre d'illustration, ces opérations n'intégreront pas de droit de retrait pour les associés minoritaires s'étant opposés à l'opération[1442], alors même que les risques sont plus importants[1443].

346. Une lueur d'espoir. Il est toutefois intéressant de relever que la Commission a malgré tout déjà entrouvert la porte en précisant que la possibilité d'inclure les scissions par acquisition[1444] pourrait faire l'objet d'une réévaluation une fois que les premiers enseignements du nouveau régime applicable aux scissions par constitution de nouvelles sociétés auront pu être tirés[1445]. Cette volonté est confirmée par le fait que la Commission prévoyait d'ores et déjà que le rapport d'évaluation de la Directive Mobilité qu'elle devrait soumettre au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen au plus tard cinq ans après la date de fin de la période de transposition comprendrait nécessairement une évaluation de la faisabilité de l'introduction de règles destinées à régir les opérations de scission non couvertes par la Proposition de la Commission[1446] et s'accompagnerait, le cas échéant, d'une proposition législative[1447]. La même brèche se retrouve dans la Directive Mobilité, à ceci près que cette dernière mentionne explicitement que cette évaluation de la faisabilité de la définition de règles additionnelles pour les types de scissions encore exclues du champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité couvrira « en particulier, les scissions transfrontalières par acquisition »[1448]. S'il a pu être avancé que cette exclusion volontaire par le législateur européen des scissions transfrontalières impliquant au moins une société bénéficiaire préexistante s'opposait à une application par analogie du régime de la Directive Mobilité

1440 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 355 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 64.

1441 W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569. Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 842 ; G. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 264 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 622 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 143 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0… », *op. cit.*, p. 1 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 232 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 273 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2643.

1442 Sur ce mécanisme de protection des associés minoritaires, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1er, Section 5, § 3.

1443 Sur les risques encourus par les associés minoritaires dans le cadre d'une scission transfrontalière, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1er, Section 2, § 1er.

1444 La Proposition de la Commission utilise le terme de « scission par acquisition » pour désigner les scissions impliquant des sociétés bénéficiaires préexistantes, délaissant par là même la terminologie de « scission par absorption » consacrée en matière de scissions internes par l'art. 136, § 1er de la Directive Sociétés.

1445 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 9.

1446 Art. 3, § 3 de la Proposition de la Commission.

1447 Art. 3, § 1er de la Proposition de la Commission.

1448 Art. 3, § 4 de la Directive Mobilité.

à ce type d'opérations[1449] et qu'il serait judicieux pour les États membres de recourir au *gold-plating*[1450] en étendant le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés aux scissions par acquisition ainsi qu'aux scissions mixtes[1451], le tableau n'est peut-être pas aussi noir qu'il y paraît. En effet, si on prend en compte toutes les portes laissées entrouvertes par la Commission, on peut malgré tout se demander s'il ne s'agit pas d'une habile manœuvre destinée à contourner les éventuelles méfiances des États membres à l'égard des scissions transfrontalières. Ce sera indubitablement le cas si le rapport d'évaluation est soumis bien avant l'écoulement du délai de quatre ans et s'il comprend effectivement une résolution législative réglementant les scissions par acquisition. Il faudra cependant encore faire preuve de patience pour voir cette insuffisance significative de la Directive Mobilité rectifiée.

§4. La disposition anti-abus

A. *La Proposition de la Commission*

347. La prohibition des « montages artificiels » de la Proposition de la Commission. L'Étude d'impact a rappelé la nécessité pour un régime européen des scissions transfrontalières d'intégrer des mécanismes permettant aux États membres d'agir contre les éventuelles pratiques abusives des opérateurs économiques[1452] et l'introduction de telles mesures avait été explicitement souhaitée par le Parlement européen dans sa résolution du 13 juin 2017[1453]. C'est ainsi que la Proposition de la Commission prévoyait que l'État membre de la société scindée devait veiller à ce que l'autorité nationale en charge du contrôle de conformité[1454], n'autorise pas la scission transfrontalière lorsque celle-ci constitue « un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment atteinte aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés »[1455]. Cette prohibition des opérations abusives est, tout comme dans le cas des transformations transfrontalières[1456], considérée comme un élément crucial de la procédure[1457]. Il s'ensuit que l'autorité nationale en charge du contrôle de conformité devra, sur la base (i) du projet de scission, des rapports de l'organe de gestion ou d'administration et de l'expert

1449 Chr. SCHULTE, *op. cit.*, pp. 143 et 144, n°s 9 et 10.

1450 Par « *gold-plating* », on entend le fait pour un État membre de créer, par le biais d'une mesure de transposition nationale, des obligations additionnelles allant au-delà du minimum requis par une directive. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 19 et à ce sujet : Kr. MARESCAU et A. FINK, « Mobilité transfrontalière des sociétés et concurrence réglementaires au niveau du droit des sociétés », *RPS*, 2014/2, p. 196 et S. WEATHERHILL, « Harmonisation : how much, how little ? », *EBLR*, 2005, pp. 538–541.

1451 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 355 ; J. SCHMIDT, « Coming soon : „Company Law Package Part 2 - Implementation" », *op. cit.*, p. 802 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 64.

1452 Étude d'impact, pp. 5, 6, 44, 45.

1453 Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, www.europarl.europa.eu (04/05/2018), p. 4.

1454 Sur ce contrôle dans le cadre de la procédure de scission transfrontalière, voir *infra* n°s 642 à 655.

1455 Art. 160*quinquies*, § 3 de la Proposition de la Commission.

1456 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 4.

1457 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 9.

indépendant et des informations relatives à la décision de l'assemblée générale approuvant l'opération[1458], ainsi que (ii) des observations formulées en temps utile par les associés, les créanciers et les travailleurs de la société scindée[1459], (iii) d'une indication que la procédure destinée à protéger le régime de participation des travailleurs[1460] au sein de la société scindée a bien débuté[1461] et, le cas échéant, des informations reçues par d'autres autorités « ayant des prérogatives dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière »[1462] au nombre desquels il est raisonnable de compter l'administration fiscale, adopter une des trois décisions laissées à sa discrétion par la Proposition de la Commission. Elle pourra ainsi dans un délai d'un mois à compter à partir de la réception des informations relatives à l'approbation de l'opération par l'assemblée générale (i) soit décider de délivrer un certificat de conformité si toutes les conditions, procédures et formalités imposées par le droit national applicable à la société scindée ont bien été remplies[1463], (ii) soit refuser de délivrer le certificat avec ou sans délai de grâce si toutes les conditions, procédures et formalités imposées par le droit national applicable à la société scindée n'ont pas été remplies[1464], (iii) soit encore, et il s'agit là d'une innovation majeure par rapport au contrôle de conformité consacré par la Directive Sociétés[1465] ou le Règlement sur la Société européenne[1466] en matière de fusions transfrontalières, initier une appréciation approfondie dans le cadre de la disposition anti-abus[1467].

348. La possibilité d'une « appréciation approfondie ». En effet, en cas de préoccupations sérieuses que la scission transfrontalière, bien que respectant le prescrit du droit national de la société scindée, constitue un « montage artificiel »[1468], l'autorité nationale pourra décider, en principe au cas par cas et en aucun cas de manière systématique[1469], de procéder à une appréciation approfondie de l'opération[1470]. Si elle décide de recourir à un tel procédé, elle devra en avertir la société concernée et lui faire part des résultats obtenus[1471]. Pour pouvoir déterminer si la scission envisagée constitue ou non un montage artificiel prohibé, l'autorité compétente devra prendre en compte tous les faits et circonstances pertinents, la Proposition de la Commission énumérant ensuite un certain nombre de données factuelles ayant trait à l'activité économique et au traitement fiscal de la société scindée et des sociétés bénéficiaires[1472] qui

1458 Art. 160*sexdecies*, § 2 de la Proposition de la Commission.
1459 Art. 160*undecies*, § 1er, (c) et 160*sexdecies*, § 5, (b) de la Proposition de la Commission.
1460 Sur cette problématique, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2.
1461 Art. 160*sexdecies*, § 5, (c) et 160*quindecies*, § 5 (c) de la Proposition de la Commission.
1462 Art. 160*sexdecies*, § 6 de la Proposition de la Commission.
1463 Art. 160*sexdecies*, § 7, (a) de la Proposition de la Commission.
1464 Art. 160*sexdecies*, § 7, (b) de la Proposition de la Commission.
1465 Art. 127 de la Directive Sociétés.
1466 Art. 25 du Règlement sur la Société européenne.
1467 Art. 160*sexdecies*, § 7, (c) de la Proposition de la Commission.
1468 Art. 160*quinquies*, § 3 de la Proposition de la Commission.
1469 52e considérant de la Proposition de la Commission.
1470 Art. 160*sexdecies*, § 7, c) de la Proposition de la Commission.
1471 Art. 160*sexdecies*, § 7, c) de la Proposition de la Commission.
1472 Selon l'art. 160*septdecies*, § 1er, al. 1er de la Proposition de la Commission, l'autorité nationale devra à tout le moins prendre en compte « les caractéristiques de l'établissement dans les États membres concernés, y compris l'intention, le secteur, l'investissement, le chiffre d'affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur

devront faire l'objet d'une appréciation globale[1473]. En outre, l'autorité nationale disposera également de la possibilité de convoquer et d'entendre les observations (i) de la société, (ii) des associés, des créanciers et des travailleurs qui ont présenté des observations suite à la publication du projet de scission et (iii) de tout tiers intéressé[1474]. Sur la base de ces différents éléments, l'autorité nationale devra prendre une décision au plus tard deux mois après le début de l'appréciation approfondie[1475], et ce afin de ne pas trop retarder la date de prise d'effet de l'opération[1476].

349. L'expert indépendant, auxiliaire de la lutte anti-abus. Afin de simplifier le travail de l'autorité nationale compétente chargée d'évaluer si l'opération envisagée constitue ou non un montage artificiel, la Proposition de la Commission prévoit explicitement que le rapport d'expert indépendant devra inclure les informations pertinentes permettant à l'autorité nationale de prendre une décision sur le caractère abusif ou non de l'opération envisagée[1477]. Tous les éléments factuels que l'autorité nationale compétente devra au minimum prendre en compte[1478] se retrouveront ainsi dans le rapport d'expert indépendant[1479].

B. *Un mécanisme anti-abus critiquable à plus d'un titre*

350. Un régime compréhensible dans son principe. Cette disposition est en ligne avec (i) les objectifs de la Commission européenne de créer un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne[1480], (ii) la volonté du Parlement européen d'éviter que la mobilité transfrontalière des personnes morales au sein de l'Union européenne ne soit utilisée à des fins de *dumping* fiscal[1481] et (iii) les récentes initiatives législatives du Conseil en la matière[1482]. Elle tient également compte des intérêts des *stakeholders* en permet-

localisation, le lieu de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d'exigibilité des cotisations sociales et les risques commerciaux assumés par la société faisant l'objet de la scission dans l'État membre de ladite société et dans les États membres des sociétés bénéficiaires ».

1473 Art. 160*septdecies*, § 1er, al. 2 de la Proposition de la Commission.

1474 Art. 160*septdecies*, § 2, *in initio* de la Proposition de la Commission.

1475 Art. 160*septdecies*, § 2, *in initio* de la Proposition de la Commission.

1476 52e considérant de la Proposition de la Commission.

1477 Proposition de la Commission, commentaire des articles, p. 32 et 45e considérant et art. 160*decies*, § 3, (f) de la Proposition de la Commission.

1478 Art. 160*septdecies*, § 1er de la Proposition de la Commission.

1479 Art. 160*decies*, § 3, (f) de la Proposition de la Commission.

1480 Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 12 et 13 et Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 17 juin 2015, Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne : cinq domaines d'action prioritaires, COM(2015) 302 final, http://eur-lex.europa.eu (04/05/2018).

1481 Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, www.europarl.europa.eu (04/05/2018), p. 4.

1482 Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, *J.O.*, L 139, 5 juin 2018, pp. 1–13 (ci-après la « **Directive DAC 6** ») ; directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, *J.O.*, L 144, 7 juin 2017, pp. 1- 11 ; directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une

tant à une autorité nationale de s'opposer à une scission transfrontalière réalisée en fraude de leurs droits et elle n'est par ailleurs pas sans rappeler les conseils de l'Avocat général Tizzano qui, dans l'affaire *Sevic*, avait cité, à titre d'exemple de restriction à la liberté d'établissement proportionnée, le refus au cas par cas d'enregistrement de l'opération pour garantir la « protection des intérêts des travailleurs, créanciers ou actionnaires minoritaires des sociétés intéressées »[1483]. Malgré le fait que ce mécanisme s'inscrive dans une certaine logique[1484], et sans encore aborder la question de la cohérence d'ensemble du régime de mobilité transfrontalière de la Proposition de la Commission qui exempte mystérieusement les fusions transfrontalières d'un tel contrôle anti-abus[1485], il convient de relever qu'il prête le flanc à la critique sous neuf angles distincts.

351. Premièrement : une mission peu adaptée aux notaires, voire aux registres de commerce. La Proposition de la Commission, à l'instar du régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés[1486], laisse le choix de l'autorité nationale compétente pour effectuer le contrôle de conformité aux États membres[1487]. Au niveau des fusions transfrontalières, il en est résulté une forte disparité, même si les États membres ont en majorité opté pour le choix des registres de commerce[1488], alors même que les notaires, malgré leurs moyens plus limités par rapport à une autorité judiciaire[1489], semblaient avoir les faveurs des praticiens et des acteurs économiques en raison de leur disponibilité, de leur coût réduit et de leur flexibilité[1490]. Or, l'instauration d'un tel contrôle anti-abus n'est absolument pas adaptée à l'hypothèse où le contrôle doit être effectué par un notaire[1491]. En effet, outre le fait qu'une telle mission dépasse

incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, *J.O.*, L 193, 19 juillet 2016, pp. 1–14 (ci-après la « **Directive ATAD** ») ; directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, *J.O.*, L 146, 3 juin 2016, pp. 8–21 et directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, *J.O.*, L 332, 18 décembre 2015, pp. 1–10.

1483 Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437, pt. 65.

1484 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 257 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 360 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, pp. 276 et 282. *Contra :* F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 23.

1485 À ce sujet, voir *infra* n° 377.

1486 60e considérant et art. 127, § 1er de la Directive Sociétés.

1487 Art. 160*sexdecies*, § 1er de la Proposition de la Commission.

1488 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale, 11 États membres (la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, Malte, la Norvège, le Portugal, la Roumanie et la Suède) ont opté pour le registre de commerce, 9 (l'Allemagne, l'Autriche, Chypre, la France, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne, le Royaume-Uni et la Slovénie) pour un tribunal, 7 (la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la République tchèque et la Slovaquie) pour un notaire et 3 (le Danemark, la Grèce et le Liechtenstein) pour un autre type d'autorité. Voir l'Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, p. 62.

1489 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, pp. 70 et 71 et S. MAQUET, *op. cit.*, p. 48.

1490 Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, p. 61.

1491 Voir en ce sens : St. BARTMANN, *op. cit.*, p. 141 ; F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 35 ; I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 26 ; ECLE, *op. cit.*, p. 205 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 23 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 238 et 239.

très largement le cadre des fonctions traditionnelles d'un notaire[1492], la mise en place d'une telle procédure, en ce qu'elle augmente considérablement la charge de travail pesant sur l'autorité compétente[1493], constituerait une tâche bien trop lourde, *a fortiori* si la Proposition de la Commission fait exploser le nombre de scissions transfrontalières. A cela s'ajoute encore que la crainte de multiples contentieux pour refus abusif de la part du notaire ne manquera pas de nuire à l'efficacité d'un tel contrôle. En vue de simplifier la procédure, il avait été proposé de confier le contrôle exclusivement aux registres de commerce[1494]. Suite à la mise en place du système d'interconnexion des registres de commerce (BRIS) et à la volonté avérée de la Commission européenne de promouvoir l'utilisation de moyens digitaux pour simplifier les procédures relevant du droit des sociétés dans le cadre de la mise en place du marché unique numérique[1495], une telle évolution, qui n'a pas été intégrée dans la Proposition de la Commission[1496], n'aurait toutefois pas permis de résoudre ces problèmes puisque même dans les pays où le contrôle de conformité est effectué par un registre de commerce, des doutes ont été émis quant à leur adéquation en raison de l'importance des moyens nécessaires[1497].

352. Deuxièmement : le refus d'intégration de l'acquis jurisprudentiel en matière de liberté d'établissement. Lorsque l'on examine les différents critères proposés par la Commission pour déterminer s'il s'agit ou non d'un montage artificiel prohibé, on se rend compte que l'accent est mis sur l'exercice effectif d'une activité économique dans l'État membre de destination. Ceci fait immédiatement penser aux arguments tant des gouvernements polonais et autrichiens que de l'Avocate générale dans l'arrêt *Polbud* selon lesquels une société ne pourrait se prévaloir de la liberté d'établissement lorsque le transfert de siège qu'elle envisage n'est pas « motivé par l'exercice d'une activité économique effective au moyen d'une installation stable dans l'État membre d'accueil »[1498]. Or, la résurrection par la Commission de cette approche de la liberté d'établissement ne peut qu'étonner au vu (i) de la jurisprudence *Centros* où la Cour a justement précisé que la liberté d'établissement implique pour une société valablement constituée en vertu du droit d'un État membre le droit d'exercer l'intégralité de ses activités économiques au moyen d'une succursale établie dans un autre État membre[1499] et (ii) de la jurisprudence *Polbud* où la Cour de justice a considéré que le transfert isolé du seul siège statutaire constituait une opération susceptible d'être protégée par la liberté

1492 Selon l'art. 1er de la loi belge du 25 Ventôse An XI contenant organisation du notariat, https://www.notaire.be (17/07/2018) et l'art. 1er de la loi luxembourgeoise du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, www.legilux.lu (17/07/2018), les notaires ont pour mission première de « recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ».

1493 Voir en ce sens : F. BERNARD, *ibidem*, p. 35 ; T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2633 ; I. CORBISIER et F. BERNARD, *ibidem*, p. 26 ; ECLE, *ibidem*, p. 205 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.* p. 15.

1494 Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, p. 63.

1495 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 11.

1496 Art. 160*sexdecies*, § 1er de la Proposition de la Commission.

1497 T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2633 ; ECLE, *op. cit.*, p. 205 ; H. JOCHUM et Al. HEMMELRATH, *op. cit.*, p. 521 et Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 248.

1498 Arrêt *Polbud*, pt. 30.

1499 Arrêt *Centros*, pt. 17.

d'établissement[1500]. Cette incohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement s'explique en partie par le fait qu'à l'origine, il était prévu d'imposer que le transfert du siège statutaire s'accompagne nécessairement du transfert concomitant du siège réel ou des activités économiques de la société[1501]. Cependant, elle ne manquera pas de créer certaines difficultés pratiques dans la mesure où il n'y a qu'un pas à franchir avant d'arguer que la Proposition de la Commission viole les dispositions du TFUE à cet égard[1502], alors même que le droit primaire devrait l'emporter[1503].

353. Troisièmement : une durée excessive. Troisièmement, il ressort de la consultation publique de 2015 que la durée et la complexité actuelles de la procédure non harmonisée de scission transfrontalière constituent un obstacle majeur à la réalisation de telles opérations[1504]. Or, la mise en place d'une appréciation approfondie susceptible de durer deux mois[1505] risque de significativement allonger la procédure[1506]. En outre, même si la Commission a pris la peine de préciser que cette appréciation approfondie ne devait pas être appliquée de manière systématique[1507], la formulation conditionnelle[1508] ne semble pas prohiber un tel contrôle approfondi automatique, ce qui ne manquera pas d'avoir un impact considérable sur la durée totale de l'opération.

354. Quatrièmement : un risque d'abus. Quatrièmement, l'absence de définition de la notion de « montage artificiel »[1509] et la terminologie vague utilisée par la Commission tel que le critère de l' « avantage fiscal indu »[1510] ou encore de l'atteinte indue aux « droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés »[1511] sont sources d'insécurité juridique[1512]. Même si c'est

1500 Arrêt *Polbud*, pt. 34.

1501 Étude d'impact, p. 76 et I. CORBISIER, « Les nouvelles dispositions… », *op. cit.*, p. 810 et O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 147.

1502 F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 35 et I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 29. Voir également au sujet de la mesure dans laquelle un transfert isolé du siège statutaire pourrait constituer un « montage artificiel » au sens de la Proposition de la Commission : J. LIEDER et M. BIALLUCH, *op. cit.*, p. 287.

1503 O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 148.

1504 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 17. Lors de la consultation publique de 2015, 62 % des personnes s'étant prononcées sur le sujet ont estimé que la durée et la complexité de la procédure à suivre pour réaliser une scission transfrontalière constituaient un obstacle majeur à la réalisation de ce type d'opérations. Voir : Consultation publique de 2015, p. 20.

1505 Art. 160*septdecies*, § 2, *in fine* de la Proposition de la Commission.

1506 St. BARTMANN, *op. cit.*, p. 141 ; F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 35 ; Th. BIERMEYER et M. MEYER, *op. cit.*, p. 111 ; S. BINARD et L. SCHUMMER, *op. cit.*, p. 36 ; T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2633 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 238et 239 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.* p. 15.

1507 52e considérant, 4e phrase de la Proposition de la Commission.

1508 Dans la version anglaise du 52e considérant de la Proposition de la Commission, il est précisé que « *this in-depth assessment should not be carried out systematically but it should be conducted on a case-by-case basis where there are serious concerns as to the existence of an artificial arrangement* ».

1509 Art. 160*quinquies*, § 3 de la Proposition de la Commission.

1510 Art. 160*quinquies*, § 3 de la Proposition de la Commission.

1511 Art. 160*quinquies*, § 3 de la Proposition de la Commission.

1512 Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 5 et Th. BIERMEYER et M. MEYER, *op. cit.*, p. 111 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK,

à dessein que cette lacune se retrouve dans la Proposition de la Commission dans la mesure où elle est de nature à faciliter l'acceptabilité politique de l'initiative en question[1513], on peut nourrir de sérieux doutes quant à une possible application discrétionnaire de cette disposition anti-abus[1514] et force est de constater que ce point n'a pas échappé à la Commission européenne qui a pris le soin de mentionner que les différents éléments factuels à prendre en compte ne peuvent être utilisés que comme des « facteurs indicatifs » et ne sont pas à considérer de manière isolée, bien qu'il ait été avancé qu'une telle liste indicative ne contribuait pas à la clarté de la disposition en question[1515]. Il s'ensuit qu'une autorité nationale compétente ne pourrait, en principe, s'arrêter à la seule localisation de la résidence fiscale pour arguer un abus. En outre, la Commission précise que toute mesure anti-abus applicable à une scission transfrontalière constitue une dérogation à la liberté d'établissement et, par conséquent, doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. Forte de cette vérité, elle tente ensuite de mettre en place un régime spécifique encadrant l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire par les différentes autorités nationales compétentes[1516] afin de garantir que la décision prise par l'autorité compétente soit « équitable, objective et non discriminatoire »[1517]. Cependant, la marge de manœuvre considérable dont jouissent les États membres risque d'engendrer de nombreux refus abusifs et discrétionnaires de la part des autorités nationales[1518], par exemple dès que celles-ci considéreront qu'une scission s'inscrit dans une stratégie fiscale trop agressive ou ne correspondra pas à un agenda politique occulte[1519], ou, à tout le moins, des pratiques nationales fortement divergentes contribuant à accentuer l'insécurité juridique[1520]. Certes, il sera

« Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 360 ; T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2633 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 621 ; B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés… », *op. cit.*, pp. 362 et 363 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1907 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 147 ; J. ROEST, *op. cit.*, p. 97 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0… », *op. cit.*, p. 1 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 238 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 15 ; E. SCHOLLMEYER, « Die „künstliche Gestaltung" - der Herr Tur Tur unter den Rechtsfiguren », *op. cit.*, pp. 977 et 978 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 288 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2704.

1513 P.-H. CONAC, *op. cit.*, p. 8 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 202 et 203 et B. LECOURT, *ibidem*, p. 363.

1514 I. CORBISIER, « Les nouvelles dispositions… », *op. cit.*, p. 810 ; R. KNAIER et J. PFLEGER, *op. cit.*, p. 191 ; B. LECOURT, *ibidem*, pp. 362 et 363 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 147 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 238 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2704.

1515 DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 863 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, p. 238.

1516 40e considérant de la Proposition de la Commission.

1517 41e considérant, 2e phrase de la Proposition de la Commission.

1518 St. BARTMANN, *op. cit.*, p. 141 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2571 ; F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 35 et 36 ; T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2633 ; U. NOACK et J. KRAFT, *op. cit.*, p. 1580 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 238 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.* p. 15.

1519 Voir en ce sens : St. BARTMANN, *ibidem*, p. 141 et S. BINARD et L. SCHUMMER, *op. cit.*, p. 36.

1520 F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 35 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 276 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 238 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *ibidem*, p. 15 et E. SCHOLLMEYER, *op. cit.*, p. 978.

toujours loisible aux personnes morales impliquées de se prévaloir au cas par cas d'une violation de la liberté d'établissement, mais la procédure est longue et coûteuse. Par ailleurs, quand bien même l'autorité nationale compétente souhaiterait éviter autant que possible une quelconque application abusive, force est de constater qu'il est particulièrement malaisé de déterminer *ex ante* ce qui constitue un « montage artificiel »[1521].

355. Cinquièmement : une possible contrariété à la liberté d'établissement. Cinquièmement, on peut nourrir certains doutes quant à la conformité générale de cette procédure à la liberté d'établissement[1522]. En effet, s'il est vrai que la Commission se base sur deux enseignements de la Cour de justice en instaurant une telle disposition[1523], à savoir (i) le fait qu'un État membre dispose, de jurisprudence constante[1524], de la possibilité d'adopter des mesures destinées à empêcher que ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à leur législation nationale par le biais des possibilités offertes par le TFUE[1525] et (ii) le fait qu' « une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement peut être justifiée lorsqu'elle vise spécifiquement les montages purement artificiels dont le but est d'échapper à l'emprise de la législation de l'État membre concerné »[1526], il convient de ne pas perdre de vue que le refus par une autorité nationale de délivrer le certificat représente une forme de restriction de la liberté d'établissement de la société scindée[1527]. En effet, l'instauration de la clause anti-abus dans le droit national constitue une mesure qui interdit, gêne ou rend moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement[1528]. Elle devra par conséquent nécessairement être (i) justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, (ii) être propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et (iii) ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif[1529].

1521 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 37, note 66 qui relève à cet égard que l'approche *ex post* consacrée par la Directive ATAD est préférable.

1522 I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 26.

1523 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2570 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 359 ; P.-H. CONAC, *op. cit.*, p. 8 ; R. KNAIER et J. PFLEGER, *op. cit.*, p. 191 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 618 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 237 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 276. Voir également : Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 31 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 71, n° 69.

1524 Arrêt *Polbud*, pt. 39 ; arrêt *Inspire Art*, pt. 98 et arrêt *Centros*, pts 18 et 24.

1525 À ce sujet, voir W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2570.

1526 Arrêt *Cadbury Schweppes*, pt. 51 et en ce sens également : C.J.C.E., arrêt *Marks & Spencer plc c. David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes)*, 13 décembre 2005, C-446/03, EU:C:2005:763, pt. 57 ; arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 50 ; C.J.C.E., arrêt *Lankhorst-Hohorst GmbH c. Finanzamt Steinfurt*, 12 décembre 2002, C-324/00, EU:C:2002:749, pt. 37 et C.J.C.E., arrêt *Imperial Chemical Industries plc (ICI) c. Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes)*, 16 juillet 1998, C-264/96, EU:C:1998:37, pt. 26.

1527 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : H. JOCHUM et Al. HEMMELRATH, *op. cit.*, p. 520.

1528 Arrêt *Polbud*, pt. 46 ; arrêt *National Grid Indus*, pt. 36 ; C.J.C.E., arrêt *Columbus Container Services BVBA & Co. c. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt*, 6 décembre 2007, C-298/05, EU:C:2007:754, pt. 30 et C.J.C.E., gde ch., arrêt *Caixa Bank France c. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*, 5 octobre 2004, C-442/02, EU:C:2004:586, pt. 11.

1529 Arrêt *Polbud*, pt. 52 et arrêt *National Grid Indus*, pt. 42.

Dans la mesure où la protection des associés minoritaires, des créanciers et des travailleurs constitue bel et bien une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la liberté d'établissement[1530], de même que « la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux et de la loyauté des transactions commerciales »[1531] et que cette clause vise à garantir celles-ci, on peut partir du principe que la première condition du « *Gebhard test* » est bien remplie, même si, à l'égard de l'objectif fiscal, la Cour de justice a déjà eu l'occasion de préciser que « la nécessité de prévenir la réduction des recettes fiscales » ne constitue pas une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la liberté d'établissement[1532]. Il en va de même du caractère adéquat étant donné que la non-délivrance du certificat de conformité équivaut à un refus pur et simple de la scission transfrontalière. En revanche, comme la Directive Mobilité met déjà en place des mesures moins restrictives destinées à sauvegarder les intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des travailleurs[1533] et que les aspects fiscaux des scissions transfrontalières font l'objet de directives spécifiques[1534 1535], on peut émettre de sérieux doutes quant à son caractère proportionné[1536]. En effet, il convient de rappeler à cet égard que la Cour de justice a considéré que le simple fait de réaliser une opération transfrontalière en vue de bénéficier d'une législation plus favorable ne constituait pas en soi un usage abusif de la liberté d'établissement[1537]. Ce caractère disproportionné apparaît de manière encore plus flagrante lorsque l'on se penche davantage sur son application en matière fiscale. En effet, d'une part, la Cour de justice permet aux États membres de combattre « des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dans le but d'éluder l'impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national »[1538] et, d'autre part, les

1530 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 et arrêt *Überseering*, pt. 92.

1531 Arrêt *Sevic*, pt. 28 et arrêt *Inspire Art*, pt. 132.

1532 Arrêt *Cadbury Schweppes*, pt. 49 ; C.J.C.E., arrêt *Försäkringsaktiebolaget Skandia (pub) et Ola Ramstedt c. Riksskatteverket*, 26 juin 2003, C-422/01, EU:C:2003:380, pt. 53 et C.J.C.E., arrêt *Rolf Dieter Banner*, 3 octobre 2002, C-136/00, EU:C:2002:558, pt. 56.

1533 Art. 160*decies* (protection des associés) ; 160*undecies* (protection des créanciers) ; 160*duodecies* (information et consultation des travailleurs) et 160*terdecies* (participation des travailleurs) de la Directive Mobilité.

1534 Directive Fiscale, mais également Directive DAC 6, Directive ATAD ; directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, *J.O.*, L 146, 3 juin 2016, pp. 8–21 et directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, *J.O.*, L-332, 18 décembre 2015, pp. 1–10.

1535 Voir en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 36 T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2633 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 240 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.* p. 15.

1536 F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 23 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 288. Pour un avis plus nuancé, voir ECLE, *op. cit.*, pp. 204 et 205 où il est avancé que la disposition anti-abus pourrait néanmoins servir d' « *emergency brake* » face à des opérations excessivement dommageables pour les *stakeholders*, sans toutefois donner d'exemple.

1537 Étude d'impact, p. 29 et arrêt *Polbud*, pt. 40 ; arrêt *Inspire Art*, pt. 96 et arrêt *Centros*, pt. 27.

1538 Arrêt *Cadbury Schweppes*, pt. 55.

dispositions anti-abus de la Directive ATAD[1539] et de la Directive Fiscale[1540] permettent d'ignorer un montage artificiel pour les besoins du calcul de la charge fiscale des sociétés. Si, d'un point de vue légistique, ce mécanisme est supérieur à celui de la Proposition de la Commission[1541], il génère également une entrave plus proportionnée à la liberté d'établissement de la société concernée en ne remettant pas en cause la validité juridique de l'opération concernée. Par conséquent, il y a fort à parier qu'à partir du moment où les dispositions protectrices auront été respectées par la société scindée, un refus pur et simple de délivrance du certificat par une autorité nationale constitue une entrave injustifiée à la liberté d'établissement, même en respectant la procédure instaurée par la Commission.

356. Sixièmement : une instrumentalisation inadéquate du droit des sociétés. Recourir à une mesure relevant du droit des sociétés pour remplir des objectifs de nature éminemment fiscale, sociale ou encore financière est foncièrement inadéquat[1542] et surprend tout particulièrement dans la mesure où l'Étude d'impact mentionne clairement le fait que l'initiative de la Commission ne se préoccupera pas de la matière fiscale[1543]. À titre d'illustration, il a été avancé que la prohibition des « montages artificiels visant à obtenir des avantages fiscaux indus »[1544] était destinée à compléter la Directive DAC 6[1545]qui recourt à un système de marqueurs[1546] pour identifier les « dispositifs transfrontières »[1547] comprenant une caractéristique ou une particularité indiquant un risque potentiel d'évasion fiscale[1548] et qui comprend au nombre de ces marqueurs le fait qu'un des participants au dispositif transfrontière prenne « artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction »[1549], ce qui couvrirait aisément l'hypothèse de la scission transfrontalière d'une société réalisant des profits au bénéfice de deux sociétés ayant des pertes non utilisées fiscalement. Il serait beaucoup plus opportun d'intégrer de telles mesures destinées à prévenir les abus en matière fiscale ou à empêcher

1539 Art. 6 de la Directive ATAD.
1540 Art. 15, § 1er, a) de la Directive Fiscale.
1541 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 204.
1542 F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 43 ; R. KNAIER et J. PFLEGER, *op. cit.*, p. 191 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU – Eckpunkte des Rechtsrahmens und Herausforderungen bei des Umsetzung », *op. cit.*, p. 576 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 240 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, pp. 288 et 289. *Contra* : S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *op. cit.*, p. 27 qui considèrent que « [t]*he introduction in the new company rules of the notion of "artificial arrangements" as a safeguard clause permitting to deny the cross-border conversion is fundamental for tackling unfair tax competition* ».
1543 Étude d'impact, p. 44.
1544 Art. 160*quinquies*, § 3 de la Proposition de la Commission.
1545 Voir en ce sens : Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 842.
1546 Annexe IV de la Directive DAC 6.
1547 Voir art. § 1er, § 1er, b), n° 18 de la Directive DAC 6 pour une définition de la notion de « dispositif transfrontière » en matière fiscale.
1548 Voir art. § 1er, § 1er, b), n° 20 de la Directive DAC 6.
1549 Annexe IV, partie II, B., 1. de la directive DAC 6.

le recours à de telles procédures dans la législation sectorielle spécifique[1550]. Pour ce qui est des aspects de la protection des créanciers, des travailleurs et des associés minoritaires qui relèvent plus particulièrement du droit des sociétés, la Proposition de la Commission intègre déjà des mécanismes destinés à sauvegarder leurs intérêts de manière plus appropriée qu'une prohibition générale des « montages artificiels », de sorte que cette dernière ne se justifie pas davantage à cet égard[1551].

357. Septièmement : l'extension excessive du rôle de l'expert indépendant. Si le rapport d'expert indépendant est certes destiné à faciliter l'appréciation de l'opération par l'autorité nationale compétente en lui fournissant tous les éléments factuels nécessaires et que son intervention pourrait s'avérer fort utile lorsque l'autorité compétente est un notaire[1552] ou pour accélérer le processus de contrôle[1553] et que compte tenu de son rôle étendu dans le cadre de la procédure[1554], il se penche déjà sur nombre d'éléments importants pour un contrôle anti-abus[1555], de nombreux auteurs ont émis des doutes quant à la pertinence d'une telle instrumentalisation de l'expert indépendant[1556] dont le corollaire direct est l'impossibilité pour les associés de renoncer à l'unanimité au rapport d'expert[1557] contrairement au régime des fusions transfrontalières[1558] et qui nécessite de mettre en place des mécanismes efficaces en vue de garantir l'indépendance de l'expert en question[1559]. En effet, on peut s'interroger sur l'opportunité d'imposer à toute société, en dehors des petites et

1550 Voir en ce sens : St. BARTMANN, *op. cit.*, p. 141 ; F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 36 ; S. BINARD et L. SCHUMMER, *op. cit.*, p. 37 ; T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2633 ; I. CORBISIER, « Les nouvelles dispositions… », *op. cit.*, p. 810 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 240 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.* p. 15 et Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 248.

1551 T. O. BRANDI, *ibidem*, p. 2633 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 858 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 23 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, p. 240 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *ibidem*, p. 15.

1552 Voir en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 26 et 27 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, p. 239.

1553 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 357 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, p. 239.

1554 À ce sujet, voir n°s 572 à 582.

1555 J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 239 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 278.

1556 T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2631 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 859 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU – Eckpunkte des Rechtsrahmens und Herausforderungen bei des Umsetzung », *op. cit.*, p. 576 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, p. 239 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.* p. 15 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *ibidem*, p. 278 et E. SCHOLLMEYER, « Die „künstliche Gestaltung" - der Herr Tur Tur unter den Rechtsfiguren », *op. cit.*, p. 978. Voir en faveur d'une telle extension du rôle de l'expert indépendant : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 5 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 68, n° 51.

1557 Art. 160*decies* de la Proposition de la Commission.

1558 Art. 125, § 4 de la Directive Sociétés.

1559 ECLE, *op. cit.*, p. 205.

micro-entreprises[1560][1561], la charge de recourir à un expert indépendant pour prouver que l'opération envisagée ne constitue pas un montage artificiel alors qu'elle recourt à un mécanisme de restructuration légal[1562]. En outre, on peut émettre certaines réserves sur la capacité de l'expert indépendant à parvenir à identifier les intentions sous-jacentes des parties impliquées dans l'opération[1563].

358. Huitièmement : une augmentation significative des coûts. Un des objectifs de la Proposition de la Commission est de réduire les coûts associés aux scissions transfrontalières[1564]. Or, la liste impressionnante des éléments à prendre en compte par l'autorité nationale compétente qui se retrouveront dans le rapport d'expert indépendant ne manquera pas d'entraîner un surcoût significatif, *a fortiori* si on prend en compte le fait qu'il ne s'agit là que d'une liste minimale que les États membres pourraient, le cas échéant, compléter[1565]. De plus, compte tenu de la responsabilité de l'expert indépendant[1566] et des assurances que ce dernier ne manquera pas de contracter en vue de s'en prémunir, il est fort probable que l'assistance fournie par l'expert indépendant dans le cadre de la lutte anti-abus entraînera un coût significatif pour les entreprises, sans parler des coûts engendrés par la nécessité de faire le cas échéant appel contre un refus abusif de la part d'une autorité compétente. S'il ressort de l'Étude d'impact que cet aspect n'a pas échappé au législateur européen et qu'il a été jugé que ce coût était largement compensé par l'introduction de règles procédurales harmonisées[1567], il n'empêche que la procédure de scission transfrontalière entraîne un certain nombre de surcoûts[1568] risquant, à eux seuls, d'encourager bien des entreprises à recourir à des moyens détournés pour réaliser leur opération de déconcentration économique[1569].

[1560] 46e considérant et art. 160*decies*, § 6 de la Proposition de la Commission.

[1561] Cette exclusion a également fait l'objet de certaines critiques dans la mesure où c'est justement à l'égard de ces entreprises qu'il y a un risque accru d'opération réalisée en fraude des droits des créanciers. Voir en ce sens : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 5 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 239 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, pp. 279 et 280 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil I) », *op. cit.*, p. 2646.

[1562] T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2631 et DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 859. *Contra* : ECLE, *op. cit.*, p. 205 qui considère même que les micros et petites entreprises ne devraient pas être exemptées du rapport d'expert.

[1563] B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés… », *op. cit.*, p. 364. Voir également G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 14, n° 35 selon lequel la mission de l'expert à cet égard pourrait s'avérer « singulièrement délicate, voire presque divinatoire ».

[1564] Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 11, 14, 21 et 23.

[1565] Tant l'art. 160*decies*, § 3, (f) que l'art. 160*septdecies*, § 1er de la Proposition de la Commission utilisent les termes « au minimum ».

[1566] Art. 160*tervicies* de la Proposition de la Commission.

[1567] Étude d'impact, p. 78.

[1568] Voir en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 26 et 27 ; Th. BIERMEYER et M. MEYER, *op. cit.*, p. 111 et E. SCHOLLMEYER, « Die „künstliche Gestaltung" - der Herr Tur Tur unter den Rechtsfiguren », *op. cit.*, p. 978.

[1569] St. BARTMANN, *op. cit.*, p. 141.

359. Neuvièmement : un possible contournement des règles spécifiques applicables à l'adoption de directives fiscales. Il est difficilement contestable que la prohibition des « *montages artificiels* » est une mesure éminemment fiscale[1570]. Or, l'adoption d'une telle mesure requiert une approbation à l'unanimité au Conseil en raison de l'application d'une procédure législative spéciale[1571], contrairement à la procédure législative ordinaire qui est applicable aux mesures relevant de la liberté d'établissement[1572] et sur laquelle l'initiative de la Commission se base[1573]. Il s'ensuit qu'il n'y a qu'un pas à franchir pour arguer que la base légale invoquée par la Commission est insuffisante[1574].

C. *Les évolutions au cours du processus législatif*

1. *Le durcissement du CESE, de la CAEM, de la CEAS et de la CAJ*

360. L'avis approbateur du CESE. Si le Comité économique et social européen a soutenu la disposition anti-abus introduite par la Proposition de la Commission, il a malgré tout souligné le caractère vague de la notion de « montage artificiel » destiné à obtenir des avantages fiscaux indus[1575] et semble avoir perçu tant la dimension arbitraire de ce critère que sa délicate réconciliation avec la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement puisqu'il souligne la nécessité d'établir des critères ou des indicateurs précis afin d'éviter d'entraver de véritables activités économiques fondées sur des décisions économiques saines[1576].

361. Le durcissement prôné par la CAEM. Cet avis semble partagé par la Commission des affaires économiques et monétaires qui plaide en faveur de l'introduction d'une définition de la notion de « montage artificiel »[1577] et ce, afin d'éviter des applications divergentes par les États membres[1578]. En outre, afin de renforcer l'efficacité du contrôle, il a été suggéré d'imposer à la société scindée de prouver, sur la base de facteurs tangibles et objectifs qu'elle est

---

1570 Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 12 et 13 et 7e et 40e considérants. Voir également en ce sens : S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *The Polbud judgment and the freedom of establishment for companies in the European Union : problems and perspectives*, Study for the JURI committee, PE 608.833, October 2018, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (04/05/2018), p. 27 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 38, note 67 ; G. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 264 et H. JOCHUM et Al. HEMMELRATH, *op. cit.*, p. 521. Voir toutefois : 57e et 58e considérants de la Proposition de la Commission.

1571 Art. 114, § 2 et 115 du TFUE.

1572 Art. 50 et 114, § 1er du TFUE.

1573 Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 13 et 15.

1574 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 38, note 67. Voir également : E. SCHOLLEYER, « Die „künstliche Gestaltung" - der Herr Tur Tur unter den Rechtsfiguren », *op. cit.*, p. 978 qui relève cette problématique.

1575 Avis CESE, pts. 1.14. et 3.6.6.

1576 Avis CESE, pts. 1.14. et 3.6.6.

1577 Selon l'Avis CAEM, il y a lieu d'entendre par « montage artificiel », « un dispositif mis en place dans le but essentiel de contourner les obligations des entreprises découlant des droits légaux et contractuels des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires minoritaires, d'éviter des cotisations de sécurité sociale ou de transférer les bénéfices en vue de réduire les obligations en matière d'impôt sur les sociétés, et qui n'exerce pas une activité économique substantielle ou réelle dans l'État membre de destination ». Voir Avis CAEM, justification succincte, p. 307 et amendement 39.

1578 Avis CAEM, justification succincte, p. 307.

effectivement établie dans l'État membre de destination et qu'elle y exerce une activité économique réelle et substantielle tout en lui permettant de bénéficier d'une présomption en cas de transfert de l'administration centrale ou du principal établissement dans l'État membre de destination[1579]. Il est intéressant de relever que cette présomption n'est pourtant pas du tout adaptée au régime des scissions transfrontalières caractérisées par une pluralité de sociétés bénéficiaires. Cette incohérence est due à la transposition d'une partie du régime des transformations transfrontalières[1580] aux scissions transfrontalières et n'est pas surprenante dans la mesure où la Commission des affaires économiques et monétaires avait plaidé en faveur de la suppression pure et simple du régime des scissions transfrontalières[1581]. Par ailleurs, compte tenu de l'importance de l'examen par l'expert indépendant dans la lutte contre les abus dans la Proposition de la Commission, elle propose de le confier à l'autorité compétente pour le contrôle de conformité[1582]. Elle va même plus loin en prévoyant la mise en place de procédures *ex post* destinées à combattre les abus qui ne seraient découverts qu'après que l'opération ait pris effet[1583]. Pour finir, ces changements qui traduisent indéniablement une volonté de durcissement de la lutte contre les pratiques abusives en matière de mobilité transfrontalière sont complétés par (i) une extension des délais pour le contrôle de conformité[1584] et l'appréciation approfondie[1585] et (ii) des mesures de nature ouvertement fiscale, comme le droit pour l'État membre de départ d'imposer les plus-values latentes au moment de la scission transfrontalière, combiné au choix pour cette société d'opter soit pour un paiement immédiat soit pour un paiement différé moyennant intérêts légaux et possibilité pour l'administration fiscale concernée de demander une garantie bancaire[1586] ou encore l'intégration d'informations fiscales dans le projet commun[1587] et le rapport de l'organe d'administration ou de gestion[1588]. Cette position méfiante, voire hostile à la mobilité transfrontalière s'explique, à tout le moins en partie, par une attitude désapprobatrice de la CAEM à l'égard de la position bienveillante de la Cour de justice en la matière[1589].

1579 Avis CAEM, amendement 154.

1580 Avis CAEM, amendement 46 qui impose en outre que les activités de la société en question produisent une valeur au sein de l'État membre de destination et soient matériellement dotées de personnel, d'équipements, d'actifs et de locaux.

1581 Avis CAEM, justification succincte, p. 308.

1582 Avis CAEM, justification succincte, p. 308 et amendements 173 et 210.

1583 Avis CAEM, amendement 10.

1584 Avis CAEM, amendement 200.

1585 Avis CAEM, amendement 203.

1586 Avis CAEM, amendement 155.

1587 Avis CAEM, amendement 156.

1588 Avis CAEM, amendement 165.

1589 Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher sur la troisième phrase du nouveau considérant 2*bis* que la CAEM proposait d'introduire et selon laquelle « [l]a jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative au droit très large aux transformations transfrontalières est regrettable étant donné que la possibilité dont disposent les entreprises de déplacer leur siège sans déplacer leurs activités principales a contribué à l'incompréhension et au sentiment anti-européen des travailleurs et d'autres acteurs à l'égard de cette forme problématique de concurrence. ». Voir Avis CAEM, amendement 3.

362. La position de la CEAS. Bien que la Commission de l'emploi et des affaires sociales soutienne l'introduction d'une disposition anti-abus articulée autour de la possibilité pour l'autorité compétente de réaliser une évaluation approfondie, elle insiste également sur la nécessité de modifier la Proposition de la Commission afin d'éviter que les entreprises n'aient à rapporter la délicate preuve qu'elles ne tentent pas de contourner ou d'enfreindre la législation applicable[1590]. C'est ainsi que la CEAS suggère à la Commission d'élaborer des « lignes directrices communes » censées aider les autorités nationales compétentes à identifier plus aisément les situations nécessitant une appréciation approfondie[1591]. Elle propose en outre l'intégration d'une définition de la notion de « montage artificiel »[1592] qui rejoint celle de la CAEM[1593] combinée à une exclusion pure et simple, et pour le moins excessive à l'aune de l'entrave à la liberté d'établissement qu'elle génère, du bénéfice des scissions transfrontalières (i) des sociétés faisant l'objet d'une enquête, poursuivies ou condamnées au cours des trois dernières années pour violation des lois sur le travail ou des droits des travailleurs, fraude sociale ou fiscale, évasion fiscale optimisation fiscale, blanchiment de capitaux ou toute autre forme de criminalité financière[1594], (ii) des sociétés ayant fait l'objet de mesures disciplinaires ou administratives ou contre lesquelles des décisions pénales ont été prises concernant des pratiques frauduleuses qui ont un rapport direct avec les compétences ou la fiabilité de la société[1595], ainsi que (iii) des sociétés faisant l'objet d'une enquête, poursuivies ou ayant été condamnées au cours des trois dernières années pour violation des droits fondamentaux ou des droits de l'homme[1596]. De plus, afin de contrer à tout le moins partiellement le caractère potentiellement arbitraire d'un refus de l'autorité compétente de valider une scission transfrontalière qui constituerait un montage artificiel, la CEAS précise qu'un tel refus devra reposer sur des « raisons motivées et objectives »[1597]. En outre, elle vient également étendre le contenu du rapport d'expert indépendant[1598] censé simplifier le contrôle anti-abus de l'autorité compétente en lui imposant d'inclure (i) des informations étendues sur les travailleurs impactés par l'opération et (ii) le bilan de la société scindée[1599].

1590 Avis CEAS, justification succincte, p. 220.
1591 Avis CEAS, justification succincte, p. 220.
1592 Selon la CEAS, il faut entendre par « montage artificiel », « un dispositif mis en place dans le but essentiel de contourner les obligations des entreprises découlant des droits légaux et contractuels des travailleurs, des créanciers ou des actionnaires minoritaires, d'éviter les cotisations de sécurité sociale ou de transférer des bénéfices en vue de réduire les obligations en matière d'impôt sur les sociétés, et qui n'exerce pas une activité économique substantielle ou réelle dans l'État membre de destination ». Voir Avis CEAS, amendement 35.
1593 Avis CAEM, amendement 39.
1594 Avis CEAS, amendement 97.
1595 Avis CEAS, amendement 98.
1596 Avis CEAS, amendement 99.
1597 Avis CEAS, amendement 100.
1598 La formulation de l'amendement 109 du CEAS laisse à désirer en ce qu'elle fait systématiquement référence à un État membre de destination unique, ignorant par là le fait qu'une scission transfrontalière est susceptible d'impliquer plus d'un État membre de destination dans la mesure où elle se caractérise par une pluralité de sociétés bénéficiaires.
1599 Avis CEAS, amendement 109.

363. La position de la CAJ. Partageant la position critique de la Commission des affaires économiques et monétaires[1600] à l'encontre de la jurisprudence progressiste de la Cour de justice[1601], la Commission des affaires juridiques réaffirme la nécessité de lutter contre les scissions transfrontalières qui constituent des montages artificiels[1602] et considère que les États membres devraient lutter contre les sociétés boîte aux lettres en veillant, en s'inspirant de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt *Cadbury Schweppes*[1603] en la matière[1604], à ce que seules les scissions transfrontalières impliquant l'exercice réel d'une activité économique réelle fondée sur un établissement fixe dans les États membres des sociétés bénéficiaires pour une durée indéterminée soient autorisées[1605]. De plus, elle interdit purement et simplement à une société de réaliser une scission transfrontalière (i) si elle fait l'objet de procédures judiciaires pour infractions à la législation sociale, fiscale, environnementale ou du travail, ou encore pour violation des droits fondamentaux et des droits de l'homme, et (ii) s'il existe un risque que les dommages finaux ne soient pas couverts dans le cadre des mesures de l'Union relevant de la coopération judiciaire en matière civile et si la société n'a pas fourni de garantie financière couvrant ce risque[1606]. Elle propose ainsi une définition de la notion de « montage artificiel » plus large[1607] que la CAEM[1608] et la CEAS[1609] puisque l'existence d'un établissement fictif est reléguée au rang de simple illustration d'un tel montage, alors qu'il s'agissait d'une condition expresse dans les deux définitions précédentes. Afin de simplifier la tâche de l'autorité nationale compétente, le projet de scission devra intégrer un nombre considérable d'informations additionnelles[1610], comme le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires imposable total de la société scindée pour la dernière période de déclaration[1611] ou encore le montant de l'impôt sur les bénéfices acquittés par la société scindée ainsi que par ses filiales et succursales[1612]. En outre, la désignation d'un expert indépendant est laissée à l'entière discrétion de l'autorité compétente[1613] et dépendra de l'aide dont

1600 Avis CAEM, amendement 3.
1601 Avis CAJ, exposé des motifs, pp. 214 et 215.
1602 Avis CAJ, amendement 60.
1603 Dans l'arrêt *Cadbury Schweppes*, la Cour de justice a considéré que « la notion d'établissement, au sens Les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement, implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable dans cet état pour une durée indéterminée […]. elle suppose par conséquent une implantation réelle de la société concernée dans l'état membre d'accueil et l'exercice d'une activité économique effective dans celui-ci. ». Voir arrêt *Cadbury Schweppes*, pt. 54.
1604 Avis CAJ, exposé des motifs, p. 217.
1605 Avis CAJ, amendement 60.
1606 Avis CAJ, amendement 289.
1607 Selon la CAJ, il y a lieu d'entendre par « montage artificiel », « un montage par lequel une société vise à se soustraire, à éviter ou à contourner les obligations qui lui incombent au regard du droit de l'Union ou du droit national, ou par lequel une société se soustrait, évite ou contourne ces obligations, y compris les droits légaux et contractuels des travailleurs, des créanciers et des associés, ou des obligations financières, par exemple au moyen d'un établissement fictif ou provisoire qui n'exerce aucune activité économique réelle dans l'État membre de destination ».
1608 Avis CAEM, justification succincte, p. 307 et amendement 39.
1609 Avis CEAS, amendement 35.
1610 Avis CAJ, amendements 248 à 258.
1611 Avis CAJ, amendements 62 et 257.
1612 Avis CAJ, amendements 62 et 258.
1613 Avis CAJ, amendement 283.

l'autorité nationale compétente aura éventuellement besoin dans le cadre de la rédaction de son rapport[1614]. Alors que la Proposition de la Commission prévoyait un délai d'un mois à compter de la date de réception des informations concernant l'approbation de l'opération transfrontalière[1615], la CAJ fait passer ce délai à trois mois[1616]. En outre, l'appréciation approfondie aura lieu non seulement en cas de suspicion d'existence d'un montage artificiel, comme dans la Proposition de la Commission[1617], mais également lorsque (i) la société fait l'objet d'une procédure engagée en raison de la probabilité de l'insolvabilité ou de certaines mesures d'investigation et (ii) elle a été condamnée par un tribunal au cours des trois dernières années ou fait l'objet de procédures judiciaires en cours pour infractions à la législation sociale, fiscale, environnementale ou du travail, ou encore pour violation des droits fondamentaux et des droits de l'homme[1618]. Cette lutte anti-abus ne se cantonne toutefois pas à un contrôle *ex ante*, mais intègre également un contrôle *ex post*[1619]. Ainsi, si au cours des deux années suivant la prise d'effet de la scission de nouvelles informations suggérant une infraction sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières auront la possibilité de réviser leur évaluation et, le cas échéant, d'adopter des sanctions en présence d'un montage artificiel[1620].

364. Un durcissement généralisé. Il se dégage indéniablement un sentiment de suspicion généralisé à l'encontre de la mobilité transfrontalière des différents amendements proposés par le Comité économique et social européen et les différentes commissions et ce n'est pas surprenant si on prend en compte les différents scandales fiscaux[1621] et les abus en matière de détachement des travailleurs[1622] à l'esprit de la CAJ au moment de rendre son avis. En outre, dans le cas de cette dernière, il est intéressant de relever que la rapporteuse part du principe que la Cour de justice considère qu' « une société ne saurait invoquer la liberté d'établissement dans un autre État membre à la seule fin d'y bénéficier d'une législation plus avantageuse sauf si l'établissement dans l'autre État membre vise à y exercer une activité économique effective »[1623] et refuse *de facto* de reconnaître les enseignements progressistes de l'arrêt *Polbud*[1624].

2. *Le revirement au gré des compromis*

365. Le revirement du Premier Compromis de la Présidence. À contre-pied de la position de la Commission, ainsi que de celles du CESE, de la CAEM, de la CEAS et de la CAJ[1625], le Premier Compromis de la Présidence prévoit la

1614 Avis CAJ, amendement 284.
1615 Art. 160*sexdecies*, § 7 de la Proposition de la Commission.
1616 Amendement 327 de l'Avis CAJ.
1617 52e considérant et art. 160*sexdecies*, § 7, c) de la Proposition de la Commission.
1618 Avis CAJ, amendement 328.
1619 Avis CAJ, amendements 61 et 338.
1620 Avis CAJ, amendements 73 et art. 338.
1621 Voir Avis CAJ, exposé des motifs, p. 215 qui mentionne successivement les *Swiss Leaks*, *Luxembourg Leaks*, *Panama Papers*, *Bahamas Leaks* et *Paradise Papers*.
1622 Avis CAJ, exposé des motifs, p. 215.
1623 Avis CAJ, exposé des motifs, p. 217.
1624 Sur cet arrêt, voir *supra* nos 211 et 212.
1625 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, pp. 360 et 361.

suppression pure et simple de la prohibition des montages artificiels et laisse délibérément l'opportunité de l'instauration d'un contrôle anti-abus dans le cadre du contrôle de conformité à la libre appréciation des États membres[1626] au motif que l'appréciation du caractère frauduleux ou abusif d'une telle opération peut s'avérer délicate[1627]. Il en va de même de la possibilité de procéder à une évaluation approfondie[1628] pour laquelle le Premier Compromis de la Présidence prévoit uniquement que si les États membres souhaitent autoriser leur autorité nationale compétente à la réaliser, cette dernière pourra prendre plus de trois mois pour rendre sa décision[1629] et devra tenir compte de toute une série d'indices tels que les caractéristiques de l'établissement dans les États membres de destination, l'objectif de l'opération, le secteur, l'investissement, le chiffre d'affaires net, le profit ou la perte, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur situation géographique, le lieu de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu où sont dues les cotisations de sécurité sociale ainsi que les risques commerciaux encourus par les sociétés avant et après l'opération transfrontalière[1630]. Il est également précisé que ces différents indices ne sont pas considérés isolément mais à prendre en compte dans le cadre d'une appréciation globale[1631]. Le Premier Compromis de la Présidence prévoit également que l'autorité compétente pourra considérer que le fait pour les sociétés à l'issue de l'opération d'avoir le siège de direction effective et/ou l'activité économique de la société dans le ou les État(s) membre(s) de destination après la réalisation de l'opération transfrontalière est un indice de l'absence d'abus ou de fraude[1632].

366. La confirmation des compromis successifs. Cette position beaucoup plus modérée s'est ensuite retrouvée inchangée dans le Deuxième Compromis de la Présidence[1633] et le Compromis des Représentants Permanents[1634]. La question de l'introduction de mécanismes de protection contre les abus et les « montages artificiels » a, à nouveau, fait l'objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil, ce dernier ayant fini par l'emporter en avançant que de telles mesures de sauvegarde risquaient d'entraver la liberté d'établissement de manière non proportionnée si elles avaient pour conséquence de gêner ou de décourager non seulement des opérations frauduleuses, mais également des opérations légitimes[1635]. Tant le Compromis Final que la Proposition du Parlement prévoient ainsi, dans le cadre d'une disposition anti-abus générale, que l'autorité compétente pour le contrôle de conformité devra s'abstenir de délivrer le certificat de conformité lorsqu'il s'avère que la scission transfrontalière a été mise en place (i) pour des raisons frauduleuses ou abusives, (ii) pour

1626 Art. 160o, § 8 du Premier Compromis de la Présidence.
1627 34e considérant du Premier Compromis de la Présidence.
1628 35e considérant, 1re phrase et art. 160o, § 7 du Premier Compromis de la Présidence.
1629 35e considérant, 1re phrase du Premier Compromis de la Présidence.
1630 35e considérant, 2e phrase du Premier Compromis de la Présidence.
1631 35e considérant, 3e phrase du Premier Compromis de la Présidence.
1632 35e considérant, 4e phrase du Premier Compromis de la Présidence.
1633 34e et 35e considérants et art. 160o, §§ 7 et 8 du Deuxième Compromis de la Présidence.
1634 34e et 35e considérants et art. 160o, §§ 7 et 8 du Compromis des Représentants Permanents.
1635 Compromis final, main issues/latest elements of the compromise proposal, pt. 11.

éluder ou contourner le droit national ou le droit européen ou encore (iii) pour des raisons criminelles[1636]. Par rapport au Premier Compromis de la Présidence, au Deuxième Compromis de la Présidence et au Compromis des Représentants Permanents, on notera toutefois que l'instauration d'un contrôle anti-abus n'est plus optionnelle[1637], mais obligatoire[1638][1639]. De plus, lorsqu'au cours de son évaluation, l'autorité compétente nourrit de sérieux doutes quant au fait que l'opération envisagée est de nature frauduleuse ou abusive, elle devra s'abstenir de délivrer le certificat de conformité et pourra poursuivre son évaluation pendant un délai additionnel de trois mois[1640], voire plus si l'opération s'avère particulièrement complexe[1641], le cas échéant en recourant aux services d'un expert indépendant[1642]. Cette forme d'évaluation approfondie sera régie par le droit national[1643], mais il est toutefois précisé que dans le cadre de cette dernière, l'autorité compétente devra tenir compte notamment de tous les indices factuels déjà mentionnés dans le Premier Compromis de la Présidence, mais également de l'équipement, des bénéficiaires effectifs de la société scindée, du nombre de travailleurs en poste l'année précédant l'opération au sens du Règlement (CE) 883/2004[1644] et la directive (CE) 96/71[1645] et du nombre de travailleurs travaillant simultanément dans plus d'un État membre au sens du Règlement (CE) 883/2004[1646] et des circonstances entourant les discussions sur la participation des travailleurs, en particulier lorsque les discussions sur ce sujet sont dues au dépassement des 4/5es du seuil national[1647][1648]. Dans un même ordre d'idées, l'autorité compétente devra veiller à ce que l'opération ne porte pas préjudice aux créanciers, en vérifiant tout particulièrement que les obligations envers les créanciers publics ont été remplies ou sont suffisamment

1636 Art. 160o, § 7 du Compromis Final et art. 160*sexdecies*, § 8 de la Proposition du Parlement.

1637 Art. 160o, § 8 du Premier Compromis de la Présidence : art. 160o, § 8 du Deuxième Compromis de la Présidence et art. 160o, § 8 du Compromis des Représentants Permanents selon lesquels « *Member States* may provide *that the competent authority shall refuse to issue a pre-division certificate, if the cross-border division is set up for abusive or fraudulent purposes, leading or aimed to lead to the evasion or circumvention of national or EU law or for criminal purposes* ».

1638 Art. 160o, § 7 du Compromis Final selon lequel « *Member States* shall ensure *that the competent authority shall not issue the pre-division certificate, if it is determined in compliance with national law that a cross-border division is set-up for abusive or fraudulent purposes leading or aimed to lead to evasion or circumvention of national or EU law, or for criminal purposes* » et qui correspond à l'art. 160*sexdecies*, § 7 de la Proposition du Parlement.

1639 Voir I. CORBISIER, « Les nouvelles dispositions… », *op. cit.*, p. 810 qui insiste sur l'importance de ce revirement.

1640 31e et 32e considérants et art. 160o, § 9 du Compromis Final et 31e et 32e considérants et art. 160*sexdecies*, § 10 de la Proposition du Parlement.

1641 Art. 160o, § 10 du Compromis Final et art. 160*sexdecies*, § 11 de la Proposition du Parlement.

1642 35e considérant et art. 160o, § 11 du Compromis Final et 35e considérant et art. 160*sexdecies*, § 12 de la Proposition du Parlement.

1643 Art. 160o, § 8 du Compromis Final et art. 160*sexdecies*, § 9 de la Proposition du Parlement.

1644 Règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, *J.O.*, L 166, 30 avril 2004, pp. 1–123.

1645 Directive (CE) 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, *J.O.*, L 18, 21 janvier 1997, pp. 1–6.

1646 33e considérant, 1re phrase du Compromis Final et 33e considérant, 1re phrase de la Proposition du Parlement.

1647 À ce sujet, voir *infra* n° 1128.

1648 33e considérant, 2e phrase du Compromis Final et 33e considérant, 2e phrase de la Proposition du Parlement.

garanties[1649] et que la société n'est pas en proie à des procédures en cours susceptibles de générer des obligations additionnelles[1650]. Tout comme dans le Premier Compromis de la Présidence[1651], ces différents indices seront à apprécier de manière globale[1652] et l'autorité compétente pourra considérer que le fait pour les sociétés issues de l'opération d'avoir le siège de direction effective et/ou une activité économique dans le ou les États membres de destination après la réalisation de l'opération transfrontalière est un indice de l'absence d'abus ou de fraude[1653].

D. *Directive mobilité et insuffisances restantes*

367. Une marge de manœuvre excessive pour les États membres. La position consacrée en définitive par la Directive Mobilité correspond à celles du Compromis Final et de la Proposition du Parlement et remplace définitivement la prohibition des « montages artificiels », par une simple disposition anti-abus obligatoire[1654] tout en laissant une large marge de manœuvre aux États membres[1655] quant à l'organisation du premier contrôle de légalité puisque ces derniers disposent de la possibilité (i) de désigner l'autorité compétente pour effectuer ce contrôle[1656], (ii) de déterminer les procédures applicables à la lutte anti-abus, en ce compris une éventuelle évaluation[1657], (iii) de déterminer les délais applicables, étant entendu que la durée du premier contrôle ne pourra excéder trois mois[1658] et que la durée de l'évaluation additionnelle en cas de suspicion de fraude ou d'abus ne pourra, sauf circonstances exceptionnelles[1659], prolonger la procédure d'une durée additionnelle supérieure à trois mois[1660], (iv) de déterminer les « faits et circonstances pertinents » dont l'autorité nationale compétente devra tenir compte dans le cadre de l'évaluation puisque la Directive Mobilité ne fait que reprendre la liste minimale d'indices[1661] du Compromis final[1662], (v) d'introduire ou non la présomption d'absence d'abus ou de fraude lorsque la scission transfrontalière a pour conséquence que la direction effective ou l'activité économique, sera implantée dans l'État membre

[1649] 36e considérant, 1re phrase du Compromis Final et 36e considérant, 1re phrase de la Proposition du Parlement.
[1650] 36e considérant, 2e phrase du Compromis Final et 36e considérant, 2e phrase de la Proposition du Parlement.
[1651] 35e considérant, 3e et 4e phrases du Premier Compromis de la Présidence et 35e considérant, 3e et 4e phrases de la Proposition du Parlement.
[1652] 33e considérant, 3e phrase et art. 160o, § 8, 1re phrase du Compromis Final et 33e considérant, 3e phrase et art. 160*sexdecies*, § 9, 1re phrase de la Proposition du Parlement.
[1653] 33e considérant, 4e phrase du Compromis Final et 33e considérant, 4e phrase de la Proposition du Parlement.
[1654] Art. 160*quaterdecies*, § 8 de la Directive Mobilité. Voir en ce sens : Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 13.
[1655] Voir en ce sens : P. STEMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 73, n° 81.
[1656] 34e considérant et art 160*quaterdecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
[1657] 35e considérant, 4e phrase et art. 160*quaterdecies*, § 9, al. 2 de la Directive Mobilité.
[1658] Art. 160*quaterdecies*, § 3 de la Directive Mobilité.
[1659] Art. 160*quaterdecies*, § 11 de la Directive Mobilité.
[1660] 35e considérant, 5e phrase et art. 160*quaterdecies*, § 10 de la Directive Mobilité.
[1661] 36e considérant, al. 1er de la Directive Mobilité.
[1662] 33e considérant, 1re phrase du Compromis Final.

de destination[1663], même si cette présomption semble davantage adaptée aux transformations transfrontalières qui ne se caractérisent pas par une pluralité de sociétés bénéficiaires, (vi) de décider si l'autorité compétente doit ou non contrôler si la société a rempli ses obligations vis-à-vis des créanciers publics, si ces obligations éventuelles sont suffisamment garanties et si elle fait l'objet de procédures judiciaires en cours dont pourraient résulter de nouvelles obligations[1664] et (vii) d'imposer aux sociétés scindées de fournir également des informations sur le nombre de ses travailleurs au moment de la rédaction du projet de scission, l'existence et, le cas échéant, la situation géographique des filiales et des informations sur le respect des engagements envers les organismes publics[1665]. Elle risque d'inciter certains États membres à adopter des mesures anti-abus particulièrement strictes en imposant notamment l'exercice d'une implantation réelle au moyen de l'exercice d'une activité économique réelle dans les États membres de destination pour autoriser l'opération transfrontalière avec tous les refus abusifs qui pourraient en découler et ce, malgré les enseignements de la Cour de justice[1666]. *A contrario*, d'autres États membres plus favorables à la mobilité transfrontalière, comme la Belgique ou le Luxembourg, en profiteront pour instaurer des régimes anti-abus plus minimalistes. Il s'ensuit qu'à l'issue du processus législatif, on en est arrivé à l'exacte situation que la Commission souhaitait éviter en instaurant un contrôle anti-abus à tout le moins partiellement harmonisé dans la Proposition de la Commission[1667], puisque la porte est désormais ouverte à la multiplication des régimes anti-abus divergents[1668], et potentiellement excessivement intrusifs[1669], dont la conformité à la liberté d'établissement ne sera vérifiée que laborieusement par la Cour de justice au gré des questions préjudicielles. À cet égard, on ne peut que relever que, malgré les enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Polbud*, le *Bundesrat* allemand avait suggéré de remplacer la disposition anti-abus de la Proposition de la Commission par une obligation pour l'État membre de destination d'exiger un lien économique réel de la part de la société migrante et de s'opposer au transfert isolé du siège statutaire[1670].

1663 36e considérant, al. 2 de la Directive Mobilité.

1664 39e considérant et art. 160*quaterdecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.

1665 Art. 160*quaterdecies*, § 3 de la Directive Mobilité.

1666 Voir en ce sens déjà à propos de la marge de manœuvre laissée aux États membres par la Proposition de la Commission : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 238 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 276. Voir également au sujet des transformations transfrontalières : J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU – Eckpunkte des Rechtsrahmens und Herausforderungen bei des Umsetzung », *op. cit.*, p. 577.

1667 Voir 40e considérant de la Proposition de la Commission.

1668 Voir à ce sujet : P. STEMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 74, n° 84 qui invite la Commission à fournir des lignes directrices pour la transposition nationale du contrôle anti-abus.

1669 Voir en ce sens : P.-H. CONAC, *op. cit.*, p. 8 ; I. CORBISIER, « Les nouvelles dispositions… », *op. cit.*, p. 810 et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0… », *op. cit.*, p. 1.

1670 Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 5. Pour un point de vue critique de cette position, voir : H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, pp. 2704 et 2705.

368. Une possible contrariété à la liberté d'établissement. S'il ressort clairement de l'étude détaillée du processus législatif que la question de la lutte contre les abus semble également avoir été omniprésente[1671] et si on ne peut que se réjouir de l'abandon de la notion de « montage artificiel »[1672], on peut malgré tout se demander si la solution finale n'est pas suboptimale et ne soulève pas également de nombreuses interrogations à l'aune de la liberté d'établissement. En effet, la Directive Mobilité contient un certain nombre d'exemples de pratiques abusives ou frauduleuses[1673] au nombre desquelles on compte le contournement des obligations fiscales. Or, la Directive ATAD contient déjà un mécanisme anti-abus en matière fiscale permettant à un État membre d'ignorer un montage artificiel pour les besoins du calcul de la charge fiscale des sociétés[1674] et la Directive Fiscale permet aux États membres de refuser d'appliquer le régime fiscal favorable normalement applicable aux scissions « a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale »[1675], sans pour autant interdire la réalisation de l'opération du point de vue du droit des sociétés. La disposition anti-abus de la Directive Mobilité est donc moins proportionnée puisqu'elle permet d'empêcher purement et simplement une société de faire usage de sa liberté d'établissement[1676]. Si on ajoute à cela le fait qu'une initiative de droit dérivé en matière de mobilité transfrontalière ne peut être contraire aux dispositions du TFUE en matière de liberté d'établissement[1677] et que cette dernière a fait

1671 Selon N. BĂDĂLĂU, ministre roumain de l'économie en 2019, « [Les nouvelles règles en matière de transformations, fusions et scissions transfrontalières] instaurent un équilibre délicat. Elles permettent aux entreprises de l'UE de renforcer leur compétitivité en tirant pleinement parti du marché unique. Dans le même temps, elles offrent des garanties renforcées aux travailleurs, aux actionnaires et aux créanciers et elles sont adaptées pour tenir compte des risques d'abus potentiels. ». Voir : Communiqué de presse du Conseil de l'Union européenne, « L'UE va faciliter la mobilité transfrontalière des entreprises », 27 mars 2019, disponible sur https://www.consilium.europa.eu (19/03/2020).

1672 Voir en ce sens : St. BARTMANN, *op. cit.*, p. 142 qui qualifie la solution prônée par la Proposition du Parlement de « *sensible and realistic compromise* ».

1673 35e considérant de la Directive Mobilité.

1674 Art. 6 de la Directive ATAD.

1675 Art. 15, § 1er, a) de la Directive Fiscale.

1676 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, pp. 36 et 37, note 66.

1677 Selon P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 43, « les instruments d'harmonisation allant à l'encontre des principes clés de la libre circulation tels que prévus en droit primaire ne peuvent être considérés comme valables ». Sur l'obligation du droit secondaire de ne pas être contraire au droit primaire, voir également : A. HARATSCH, Chr. KOENIG et M. PECHSTEIN, *op. cit.*, p. 487, n° 1000 ; P. MANKOWSKI, « Insolvenzrecht gegen Gesellschaftsrecht 2:0 im europäischen Spiel um § 64 GmbHG », *NZG*, 2016, p. 284 ; K. MORTELMANS, « The relationship between the Treaty Rules and Community Measures for the establishment and functioning of the Internal Market : towards a concordance rule? », *C.M.L.R.*, 2002, pp. 1303–1346 et W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *E.L. Rev.*, 2017, 42(2), pp. 274 et 275. Voir également dans des matières autres que la liberté d'établissement : C.J.C.E., arrêt *Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.*, 13 septembre 2001, C-169/99, EU:C:2001:439, pt. 37 ; C.J.C.E., arrêt *Safety Hi-Tech Srl c. S. & T. Srl.*, 14 juillet 1998, C-284/95, EU:C:1998:352, pt. 63 C.J.C.E., arrêt *procédure pénale c. René Kieffer et Romain Thill*, 25 juin 1997, C-114/96, EU:C:1997:316, pts. 27 et 33 ; C.J.C.E., arrêt *Meyhui NV c. Schott Zwiesel Glaswerke AG*, 9 août 1994, C-51/93, EU:C:1994:312, pt. 11 ; C.J.C.E., arrêt *Parti écologiste "Les Verts" c. Parlement européen*, 23 avril 1986, C-294/83, EU:C:1986:166, pt. 23 ; C.J.C.E., arrêt *Denkavit Nederland BV c. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten*, 17 mai 1984, C-15/83, EU:C:1984:183, pt. 15 ; C.J.C.E., arrêt *Société Les Commissionnaires Réunis SARL c. Receveur des douanes ; SARL Les fils de Henri Ramel c. Receveur des douanes*, 20 avril 1978, C-80 et 81/77 EU:C:1978:87, pt. 38.

l'objet d'une interprétation extensive par la Cour de justice, à tout le moins dans sa jurisprudence récente[1678], on ne peut que constater que la disposition anti-abus frôle la limite de l'admissible. En outre, compte tenu de l'attitude plus tolérante de la Cour de justice à l'égard d'entraves relevant d'autres branches du droit, comme le droit de l'insolvabilité[1679], on ne peut que se demander si le choix du législateur européen est réellement opportun, à moins que l'objectif n'ait été de tirer pleinement parti de l'attitude favorable à la mobilité transfrontalière de la Cour de justice pour limiter la disposition anti-abus autant que possible en s'assurant d'un contrôle particulièrement strict à l'aune de la liberté d'établissement[1680].

369. Une inadéquation aux notaires. Tout comme la Proposition de la Commission[1681], la Directive Mobilité laisse le choix de l'autorité compétente aux États membres[1682]. Or, force est de noter que la même remarque[1683] s'impose : cette mission de contrôle anti-abus est fort éloignée des missions traditionnellement dévolues aux notaires et demeure peu adaptée aux moyens limités de ces derniers.

370. Une durée excessive. La Directive Mobilité prévoit dorénavant que le contrôle de conformité devra être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et informations concernant l'approbation de l'opération par l'assemblée générale[1684]. En outre, en cas de soupçons sérieux de la part de l'autorité compétente que la scission envisagée est abusive ou frauduleuse, elle pourra procéder à une évaluation plus approfondie[1685] et disposera d'un délai additionnel de trois mois pour ce faire[1686], étant entendu que le législateur européen laisse largement sous-entendre que ces délais pourront être dépassés par l'autorité compétente si l'opération transfrontalière s'avère particulièrement complexe[1687]. Il s'ensuit que la procédure anti-abus de la Directive Mobilité soulève également un certain nombre d'interrogations en termes de délais[1688]. De manière plus insidieuse, on peut également relever que l'autorité nationale compétente hostile à la mobilité

1678 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.
1679 À ce sujet, voir *infra* n°s 913 et 914.
1680 Pour une étude détaillée de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.
1681 Art. 160*sexdecies*, § 1er de la Proposition de la Commission.
1682 Art. 160*quaterdecies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
1683 À ce sujet, voir *supra* n° 351.
1684 Art. 160*quaterdecies*, § 7, 1re phrase de la Directive Mobilité.
1685 Art. 160*quaterdecies*, § 9 de la Directive Mobilité.
1686 Art. 160*quaterdecies*, § 10 de la Directive Mobilité.
1687 Art. 160*quaterdecies*, § 10 de la Directive Mobilité et en ce sens : P. STEMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 72, n° 74.
1688 Th. LUY, « Die Austrittserklärung des Minderheitsgesellschafters nach dem Company Law Package », *op. cit.*, p. 1108, note 26 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1907 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0… », *op. cit.*, p. 1 et P. STEMASZCZYK, *ibidem*, p. 72, n° 74. Voir également : Déclaration de l'Estonie sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières du 8 novembre 2019, 13691/19 ADD1, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020), p. 2 qui avance que « les règles énoncées dans la directive ne tiennent compte ni de l'environnement des entreprises qui évolue rapidement, ni de l'économie numérique ».

transfrontalière mais consciente du caractère abusif et des éventuelles responsabilités qu'un refus pur et simple engendrerait, pourrait fort bien être tentée de prolonger excessivement les délais de manière à décourager les acteurs économiques de recourir aux scissions transfrontalières.

371. Une présomption discutable. La faculté laissée aux États membres d'introduire une présomption d'absence d'abus en cas de transfert concomitant de la direction effective ou de l'activité économique[1689] prête également le flanc à la critique car, *a contrario*, elle pourrait être interprétée comme signifiant que les opérations n'entraînant pas de transfert concomitant du siège réel seront ceintes d'une aura négative, voire seront, dans les faits, présumées frauduleuses par les autorités compétentes hostiles à la mobilité transfrontalière. Si l'on ajoute à cela le fait que nombre d'États membres s'avèrent réticents à intégrer l'acquis jurisprudentiel en matière de liberté d'établissement[1690] et que la théorie du siège réel n'est que difficilement compatible avec les évolutions technologiques[1691], on peut craindre, comme l'a fait remarquer l'Estonie, que l'on ne crée « essentiellement une présomption selon laquelle les entreprises numériques mondiales actuelles sont, en fait, des sociétés frauduleuses ou des "sociétés-écrans" »[1692]. Or la Cour de justice a déjà eu l'occasion de préciser qu'une présomption générale de fraude ou d'évasion fiscale ne respectait pas le principe de proportionnalité que toute entrave à la liberté d'établissement se doit de remplir[1693]. On se retrouve donc une fois de plus dans une situation difficilement compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice.

372. Une disposition potentiellement superflue. La Directive Mobilité intègre de nombreux mécanismes de protection destinés à sauvegarder les intérêts des *stakeholders* potentiellement impactés par l'opération en question, à savoir les travailleurs[1694], les associés minoritaires[1695] et les créanciers[1696]. En outre, à titre d'illustration, à l'égard de ces derniers, la Directive Mobilité prévoit expressément que l'autorité compétente pourra vérifier que la société a bien rempli ses obligations vis-à-vis de ses créanciers publics[1697]. De plus, il est explicitement mentionné que la Directive Mobilité est sans préjudice de nombre de législations sectorielles protectrices[1698], notamment en matière fiscale[1699], sociale[1700] ou pénale[1701]. Si l'on ajoute à cela le fait que ni l'Étude *Bech-Bruun*

1689 36e considérant, al. 2, 3e phrase de la Directive Mobilité.
1690 À ce sujet, voir *supra* n° 231.
1691 Sur ces insuffisances de la théorie du siège réel, voir *supra* n° 138.
1692 Déclaration de l'Estonie sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières du 8 novembre 2019, 13691/19 ADD1, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020), p. 2.
1693 Arrêt *Euro Park Service*, pt. 69 où la Cour a considéré qu' « une législation fiscale, telle que celle en cause au principal, qui instaure une présomption générale de fraude ou d'évasion fiscales va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif et ne saurait dès lors justifier une entrave à cette liberté ».
1694 Art. 160*duodecies* et 160*terdecies* de la Directive Mobilité.
1695 Art. 160*decies* de la Directive Mobilité.
1696 Art. 160*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
1697 39e considérant, 1re phrase de la Directive Mobilité.
1698 50e à 57e considérants de la Directive Mobilité.
1699 50e, 51e, 52e, 53e et 54e considérants de la Directive Mobilité.
1700 50e et 52e considérants de la Directive Mobilité.
1701 50e et 55e considérants de la Directive Mobilité.

et Lexidale, ni les deux consultations publiques, ni encore les deux études préalables ne font mention de la nécessité d'une telle disposition anti-abus, on peut se demander si, au-delà de son intérêt politique[1702], une telle mesure est vraiment nécessaire.

373. La faculté de nommer un expert indépendant. Même si l'expert indépendant a perdu son rôle d'auxiliaire direct de l'autorité compétente tel que prévu dans la Proposition de la Commission[1703] et qu'il est dorénavant prévu que les associés peuvent renoncer à l'unanimité à la nomination d'un expert[1704], la Directive Mobilité prévoit néanmoins que l'autorité compétente devrait avoir la possibilité de recourir aux services d'un expert indépendant dans le cadre de l'évaluation[1705]. Par conséquent, les remarques en termes de coûts, de durée et d'indépendance formulées à l'encontre de la Proposition de la Commission[1706] peuvent être réitérées. En outre, dans la mesure où la Cour de justice a rappelé que la preuve d'une pratique abusive nécessitait « d'une part, un ensemble de circonstances objectives dont il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l'Union, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint et, d'autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un avantage résultant de la réglementation de l'Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention »[1707], on peut se demander si un expert indépendant est bien indiqué pour démontrer un tel élément subjectif[1708].

374. Un risque d'abus persistant. Malgré l'abandon de la notion de « montage artificiel », on ne peut que remarquer que la notion de « fins abusives ou frauduleuses » demeure vague[1709], *a fortiori* si on prend en compte le fait qu'une telle appréciation devra être faite « conformément au droit national » appliqué par l'autorité compétente[1710]. Il s'ensuit que la remarque faite à l'origine à l'encontre de la disposition anti-abus de la Proposition de la Commission[1711] quant à une possible application protectionniste et discrétionnaire demeure

1702 P.-H. CONAC, *op. cit.*, p. 8 ; B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés… », *op. cit.*, p. 363 et Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 248.

1703 Art. 160*decies*, § 3, f) de la Directive Mobilité.

1704 Art. 160*septies*, § 3, al. 1er de la Directive Mobilité. Pour un point de vue critique de cette faculté de renonciation, voir : Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1907.

1705 38e considérant de la Directive Mobilité.

1706 À ce sujet, voir *supra* n° 357.

1707 C.J., gde ch., arrêt *N Luxembourg 1 e.a. c. Skatteministeriet*, 26 février 2019, C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, EU:C:2019:134, pt. 124 ; C.J., gd ch., arrêt *O c. Minister voor Immigratie, Intgratie en Asiel et Minister voor Immigratie, Intgratie en Asiel c. B.*, 12 mars 2014, C-456/12, EU:C:2014:135, pt. 58 et C.J.C.E., arrêt *Emsland-Stärke GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, 14 décembre 2000, C-110/99, EU:C:2000:695, pts 52 et 53.

1708 B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés… », *op. cit.*, p. 364 et G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 14, n° 35.

1709 I. CORBISIER, « Les nouvelles dispositions… », *op. cit.*, p. 810 ; P.-H. CONAC, *op. cit.*, p. 8 ; B. LECOURT, *ibidem*, p. 363 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1907 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0… », *op. cit.*, p. 1 ; P. STEMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 72, n° 74 et Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 248.

1710 Art. 160*quaterdecies*, § 8 de la Directive Mobilité.

1711 À ce sujet, voir *supra* n° 354.

d'actualité[1712] et que le texte final ne va pas dans le sens d'un renforcement de la sécurité juridique liée aux opérations transfrontalières[1713].

375. Une question loin d'être clôturée. En guise de conclusion, si on comprend aisément qu'une initiative européenne en matière de scissions transfrontalières intégrant une disposition anti-abus présente certains avantages d'ordre politique dans la mesure où elle permet de rassurer les États membres plus sceptiques à l'encontre de la mobilité transfrontalière des personnes morales[1714], il n'en demeure pas moins qu'elle continuera à susciter de nombreuses interrogations et que la Cour de justice n'a certainement pas fini d'être saisie de questions préjudicielles à cet égard[1715]. L'avenir nous révélera s'il fallait voir en cette disposition anti-abus un véritable « cheval de Troie »[1716], mais on peut d'ores et déjà remarquer son caractère potentiellement dévastateur pour la mobilité transfrontalière au sein de l'Union européenne. En outre, dans le cadre spécifique de l'étude des scissions transfrontalières et face à la méfiance de certains États membres à l'égard des scissions par acquisition jugées plus risquées[1717], on ne peut que craindre que la prohibition des « montages artificiels » de la Proposition de la Commission dont on distingue toujours le spectre au gré du processus législatif, fasse son retour sous une forme renforcée dans le rapport que la Commission devra fournir sur ces dernières au plus tard en 2027[1718].

§5. Des différences de traitement injustifiées

376. La position inconfortable du législateur européen. Bien que le régime des scissions transfrontalières consacré par la Directive Mobilité se base sur le modèle éprouvé des fusions transfrontalières[1719], la Commission, en choisissant de ne pas suivre les recommandations faites à cet égard dans une des études préalables[1720], a décidé de manière critiquable[1721] de réglementer séparément les transformations, les fusions et les scissions transfrontalières. Cette approche

[1712] Voir en ce sens : I. CORBISIER, « Les nouvelles dispositions… », *op. cit.*, p. 810 ; P.-H. CONAC, *op. cit.*, p. 8 et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0… », *op. cit.*, p. 1. Pour une position plus optimiste, voir B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés… », *op. cit.*, p. 363 pour qui ce risque ne doit pas être exagéré.

[1713] Voir en ce sens : P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 72, n° 74.

[1714] Voir en ce sens : B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés… », *op. cit.*, p. 363.

[1715] Voir en ce sens : P. STEMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 74, n° 84.

[1716] O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 148.

[1717] 8e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité.

[1718] Art. 4, §§ 1er et 3 de la Directive Mobilité.

[1719] Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 354 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 306 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 841 ; S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *op. cit.*, p. 7 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 14 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 232 ; P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 62, n° 4, P. STEMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2437 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil I) », *op. cit.*, p. 2643.

[1720] J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 37.

[1721] Pour un point de vue critique, voir : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *ibidem*, p. 2570 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 14.

législative a, en toute logique, engendré de multiples répétitions et incohérences entre les différentes procédures[1722] qui, à terme, ne manqueront pas de nuire à l'attrait du régime des scissions transfrontalières[1723].

377. Prohibition des « montages artificiels » et fusions transfrontalières. Parmi ces incohérences, la plus marquante de la Proposition de la Commission n'est autre que l'absence d'extension du mécanisme anti-abus aux fusions transfrontalières[1724]. Toutefois, loin d'être un simple oubli[1725], cette incohérence n'est que la manifestation de la position inconfortable dans laquelle la Commission s'est retrouvée à la suite de l'arrêt *Polbud* puisque d'une part, elle a été confrontée à la nécessité de rassurer les États membres face aux potentiels abus susceptibles de découler de l'interprétation de la liberté d'établissement prônée par la Cour de justice[1726] et, d'autre part, elle ne pouvait ignorer l'indéniable succès du régime des fusions transfrontalières[1727] mis en lumière notamment par l'Étude Bech-Bruun et Lexidale[1728] et les deux études préliminaires[1729]. En effet, un tel contrôle anti-abus aurait risqué d'aboutir à l'égard de ces dernières, à une réduction de la mobilité transfrontalière par rapport à la situation antérieure[1730]. L'extension de cette disposition aux scissions transfrontalières a été simplement justifiée par le fait que les risques inhérents aux scissions transfrontalières étaient similaires à ceux engendrés par une transformation

1722 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *ibidem*, p. 2570 ; I. CORBISIER, et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 19 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 232 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 14.

1723 Avis CESE, pts. 1.12 et 3.6.13 qui insiste sur les risques que de telles différences de traitements pourraient engendrer pour l'attractivité des scissions et des transformations transfrontalières par rapport aux fusions transfrontalières.

1724 Pour un point de vue critique, voir : St. BARTMANN, *op. cit.*, p. 141 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, pp. 354 et 360 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 842 ; I. CORBISIER, et F. BERNARD, *ibidem*, pp. 25 et 26 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, pp. 857 et 858 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 205 et 221 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, pp. 24 et 43 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 618 ; B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés… », *op. cit.*, p. 362 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 147 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 15 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 240 et 241 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 276 ; P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, pp. 62, n° 5 et 71, n° 72 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 288 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen … (Teil II) », *op. cit.*, p. 2704.

1725 *Contra* : M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 23, n° 42. Voir également : Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 288 qui rejette cette thèse de l'oubli.

1726 Selon l'Étude d'impact, ce mécanisme anti-abus lié a vu le jour suite à l'impossibilité d'imposer un transfert concomitant du siège statutaire et du siège réel en raison des enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Polbud*. Voir Étude d'impact, p. 76. Voir également : S. BINARD et L. SCHUMMER, *op. cit.*, p. 32 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 202 et 203 et O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 147.

1727 Sur ce dilemme, voir : P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2438 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 62, n° 5 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 288.

1728 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 5 à 9.

1729 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, pp. 24 et 25 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 16.

1730 Voir en ce sens : O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 147.

transfrontalière[1731], tout en négligeant purement et simplement le fait que les scissions ne sont que le reflet économique des fusions. Cette incohérence flagrante, qui a fort heureusement été rectifiée au cours du processus législatif par une extension du contrôle anti-abus révisé aux fusions transfrontalières[1732], aurait eu pour conséquence que les parties souhaitant procéder à une scission transfrontalière pour des raisons essentiellement fiscales n'auraient eu qu'à réaliser une fusion transfrontalière suivie d'une scission interne pour éluder le risque de cette clause anti-abus[1733].

378. Des insuffisances restantes. Alors que l'incohérence au niveau de la disposition anti-abus a pu être rectifiée au cours du processus législatif en prévoyant l'application d'une version révisée de celle-ci également aux fusions transfrontalières dès le Premier Compromis de la Présidence[1734], de même que d'autres incohérences[1735], il n'en demeure pas moins que les régimes de fusion, de scission et de transformation transfrontalières consacrés en définitive par la Directive Mobilité continuent de présenter certaines incohérences. Celles-ci seront illustrées par les deux exemples suivants :

379. Premier exemple : une différence de traitement notable au niveau de la participation des travailleurs. De manière assez surprenante, seul le régime de participation des travailleurs[1736] applicable aux fusions transfrontalières[1737] ouvre aux organes compétents des sociétés qui fusionnent le droit de ne pas ouvrir de négociations préalables et d'être directement soumis aux « dispositions de référence »[1738] telles que déterminées par le droit de l'État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière et de respecter ces dispositions à compter de la date d'immatriculation[1739]. Une telle faculté permettant de simplifier le régime applicable à la participation des travailleurs est absente tant du régime des scissions

1731 Étude d'impact, p. 78.

1732 Art. 127, § 8 du Premier Compromis de la Présidence.

1733 Voir en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 36 ; ECLE., *op. cit.*, p. 205 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 24 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 618 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 15.

1734 Selon l'art. 127, § 8 du Premier Compromis de la Présidence selon lequel « *Member States may provide that the competent authority shall refuse to issue a pre-merger certificate, if the cross-border merger is set up for abusive or fraudulent purposes, leading or aimed to lead to the evasion or circumvention of national or EU law or for criminal purposes.* ».

1735 Voir en ce sens J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 271. À titre d'illustration, on peut citer le seuil de 4/5es pour le déclenchement du mécanisme de protection de la participation des travailleurs qui a été étendu aux fusions transfrontalières au cours du processus législatif. À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 6, § 3, A.

1736 Par « participation », on entend « l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société :
– en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ; ou
– en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer ». Voir art. 2, k) de la Directive Participation des Travailleurs.

1737 Sur le régime applicable à la protection de la participation des travailleurs dans le cadre d'une scission transfrontalière, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2.

1738 Les « dispositions de référence » sont définies à la Partie 3 de l'annexe de la Directive Participation des Travailleurs et sont celles qui prévoient le plus haut niveau de participation.

1739 Art. 133, § 4, a) de la Directive Mobilité.

transfrontalières[1740] que de celui des transformations transfrontalières[1741]. Or, cette règle par défaut, fréquemment utilisée dans la pratique allemande[1742], permet d'éluder tant la constitution d'un groupe spécial de négociation[1743], que les discussions avec ce dernier et par conséquent, d'accélérer le processus et d'en réduire le coût[1744]. Cette incohérence figurait déjà dans la Proposition de la Commission[1745] et il a été suggéré[1746], au cours du processus législatif, de la rectifier en supprimant purement et simplement cette faculté de ne pas ouvrir de négociations[1747]. Si fort heureusement cette possibilité de ne pas ouvrir de négociations n'a pas été supprimée au cours du processus législatif pour les fusions transfrontalières, on ne peut que regretter qu'elle n'ait pas également été étendue aux transformations et aux scissions transfrontalières[1748]. Il s'ensuit qu'en présence d'un régime de participation des travailleurs, les parties pourraient malgré tout être incitées recourir à une construction en plusieurs étapes en privilégiant une fusion transfrontalière[1749].

380. Deuxième exemple : la nécessité d'obtenir l'accord de certains associés. Contrairement au régime des fusions transfrontalières[1750], tant le régime des transformations transfrontalières[1751] que celui des scissions transfrontalières[1752] prévoient que, lorsqu'une clause du projet ou une modification de l'acte constitutif de la société scindée ou transformée entraîne « une augmentation des engagements économiques d'un associé à l'égard de la société ou de tiers », les États membres pourront prévoir qu'une telle clause ou modification soit

1740 Art. 160*terdecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
1741 Art. 86*terdecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
1742 P. MÜCKL et M. GÖTTE, *op. cit.*, p. 2040 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 267 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281.
1743 Sur le « groupe spécial de négociation », voir *infra* n° 1147.
1744 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364 ; T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2632 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 29, n° 26 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2446.
1745 Art. 86*terdecies*, § 4 (transformations), 133 (fusions) et 160*quindecies*, § 4 (scissions) de la Directive Mobilité et art. 133, § 4, a) de la Directive Sociétés.
1746 Avis CEAS, justification succincte, p. 220 où il est précisé que « la rapporteure a également eu à cœur de mettre la proposition en conformité avec la législation en vigueur sur les fusions (directive 2017/1132), garantissant ainsi que les mêmes règles s'appliquent pour les transformations et les scissions. Ceci afin d'éviter la création de nouvelles règles compliquées pour les entreprises. ». Voir également Avis CAJ, exposé des motifs, p. 216 où il est avancé que « [c]ontrairement aux transformations et aux scissions transfrontalières, les droits de participation des travailleurs n'ont pas été modifiés, en conséquence de quoi ils se retrouvent inférieurs à ceux prévus pour les transformations et les scissions ».
1747 Avis CEAS, amendements 56, 83 et 112 et Avis CAJ, amendements 156, 235 et 314. Voir en ce sens également : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 365. *Contra* : T. O. BRANDI, *op. cit.*, p. 2632 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 268 qui plaidaient, au contraire, en faveur d'une extension de cette flexibilité au régime des scissions et transformations transfrontalières.
1748 Voir en ce sens également : P. MÜCKL et M. GÖTTE, *op. cit.*, p. 2040 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 267 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, pp. 294 et 295.
1749 Voir en ce sens : P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *ibidem*, p. 2446.
1750 Art. 126 de la Directive Sociétés tel que modifié par l'art. 126 de la Directive Mobilité.
1751 Art. 86*nonies*, § 4 de la Directive Mobilité.
1752 Art. 160*nonies*, § 4 de la Directive Mobilité.

approuvée par l'associé en question, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d'exercer son droit de retrait. Cette disposition, qui a fait son apparition dès le Compromis des Représentants Permanents[1753], a généré une certaine incompréhension notamment en raison du fait qu'elle ne s'applique pas à la perte de droits politiques comme un droit de veto[1754].

381. Incohérences et risques d'abus. Un certain nombre d'autres incohérences entre les différentes procédures peuvent encore être relevées, comme par exemple (i) l'obligation de faire figurer le calendrier indicatif envisagé pour l'opération qui n'existe que pour les scissions[1755] et les transformations[1756] transfrontalières, (ii) l'obligation de mentionner dans le projet de transformation transfrontalière si une mesure d'incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l'État membre d'origine au cours des cinq dernières années[1757] qui ne se retrouve ni dans le régime des fusions transfrontalières[1758], ni dans celui des scissions transfrontalières[1759], (iii) les conditions de présence et de majorité spécifiques instaurées exclusivement pour les transformations[1760] et les scissions transfrontalières[1761] ou encore (iv) la *perpetuatio fori* instaurée exclusivement dans l'intérêt des créanciers d'une société procédant à une transformation transfrontalière[1762]. Ces différents points de friction peuvent s'expliquer à tout le moins en partie par la position délicate du législateur européen puisque, d'une part, il devait veiller à ne pas excessivement alourdir le régime des fusions transfrontalières dont les différentes études réalisées durant la phase préparatoire ont révélé qu'il était globalement efficace et, d'autre part, rassurer les États membres face à la position libérale de la Cour de justice dans l'arrêt *Polbud* en introduisant des mesures de sauvegarde des intérêts des s*takeholders* et des dispositions anti-abus[1763]. À cet égard, la déclaration de N. BĂDĂLĂU, ministre roumain de l'économie en 2019, est particulièrement éloquente puisque selon lui, les nouvelles règles en matière de transformations, fusions et scissions transfrontalières « instaurent un équilibre délicat. Elles permettent aux entreprises de l'UE de renforcer leur compétitivité en tirant pleinement parti du marché unique. Dans le même temps, elles offrent des garanties renforcées aux travailleurs, aux actionnaires et aux créanciers et

1753 Art. 86i, § 3a et 160k, § 3a du Compromis des Représentants Permanents. Il convient toutefois de relever que cette modification a dû apparaître pour la première fois dans le document ST 5380/1/19 REV 1 puis que le Compromis des Représentants Permanents intègre une modification de la disposition en question. Ce document n'est toutefois pas disponible sur https://eur-lex.europa.eu (07/05/2020).

1754 P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 70, n° 59.

1755 Art. 160*quinquies*, d) de la Directive Mobilité.

1756 Art. 86*quinquies*, d) de la Directive Mobilité.

1757 Art. 86*quinquies*, h) de la Directive Mobilité. Pour un point de vue critique de cette mention additionnelle dans le cadre des transformations transfrontalières, voir : J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 569.

1758 Art. 122 de la Directive Mobilité.

1759 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.

1760 Art. 86*nonies*, § 3 de la Directive Mobilité.

1761 Art. 160*nonies*, § 3 de la Directive Mobilité.

1762 Art. 86*undecies*, § 4 de la Directive Mobilité.

1763 P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2438.

elles sont adaptées pour tenir compte des risques d'abus potentiels. »[1764]. Pour partiellement excusables qu'elles puissent être, il n'en demeure pas moins que ces inconsistances nuisent à la cohérence générale du régime consacré par le législateur européen. Il est en effet important de ne pas perdre de vue que les opérations de restructuration transfrontalière sont relativement aisément substituables[1765], de sorte que les praticiens imaginatifs pourront tirer parti de ces incohérences pour contourner des régimes jugés trop protecteurs. Si l'objectif est effectivement de veiller à ce que les acteurs économiques puissent choisir entre les différents types de restructuration en fonction de l'effet économique recherché, il est indispensable de veiller à la cohérence d'ensemble des régimes, tout en évitant autant que faire se peut les divergences injustifiées[1766]. Il a été avancé par certains auteurs qu'il aurait été de loin préférable de prévoir un régime s'articulant autour d'un tronc commun pour toutes les opérations transfrontalières, voire à terme pour toutes les opérations tant internes que transfrontalières, et des parties spécifiques tenant compte des particularités de chaque type d'opération[1767]. Si le recours à une telle technique légistique aurait indéniablement permis de renforcer la lisibilité et la cohérence d'ensemble du régime, il n'en demeure pas moins qu'un tel objectif eût été foncièrement irréalisable à ce stade en raison de la délicate position politique dans laquelle la Commission s'est retrouvée. Il est toutefois également possible d'y voir une habileté politique de la Commission[1768] qui aurait pu volontairement alourdir les régimes et générer certaines incohérences en vue de justifier plus facilement une modification plus en profondeur des régimes de mobilité interne et transfrontalière lors de l'évaluation qui interviendra au plus tard le 1er février 2027. Il est même possible d'en déceler une éventuelle trace dans le fait que la Commission a pris soin de ne pas limiter le champ de son rapport aux seules transformations et scissions transfrontalières[1769].

1764 Voir : Communiqué de presse du Conseil de l'Union européenne, « L'UE va faciliter la mobilité transfrontalière des entreprises », 27 mars 2019, disponible sur https://www.consilium.europa.eu (19/03/2020).

1765 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, pp. 354 et 360 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 199 et 200 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 43 ; P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 62, n° 4 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2438. Voir également : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 2.

1766 P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 62, n° 4.

1767 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2570 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 232 et 233 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 14 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil I) », *op. cit.*, p. 2643.

1768 Voir sur l'habileté politique de la Commission européenne dans le cadre de l'adoption de la Directive Mobilité : P.-H. CONAC, *op. cit.*, pp. 7–9 et I. CORBISIER, « Les nouvelles dispositions… », *op. cit.*, p. 810.

1769 Selon l'art. 4, § 3 de la Directive Mobilité, le rapport de la Commission « évalue *notamment* les procédures visées aux chapitre -I [transformations transfrontalières] et IV [scissions transfrontalières de sociétés de capitaux] de la directive (UE) 2017/1132, notamment en termes de durée et de coûts ».

SECTION 3. CONCLUSION SUR LE NOUVEAU RÉGIME DES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES PAR CONSTITUTION DE NOUVELLES SOCIÉTÉS

382. Deux pas en avant, un pas en arrière. Considérée comme « un des projets les plus ambitieux jamais vu dans l'histoire du droit européen des sociétés »[1770], la Directive Mobilité constitue indéniablement une réussite en soi[1771] et son adoption en un temps record relève du tour de force[1772]. L'initiative de la Commission se devait d'être saluée, ne fût-ce qu'en raison du fait qu'il s'agit de la première tentative de réglementer les scissions transfrontalières[1773]. Cependant, malgré cela, force est de constater qu'elle souffre d'un nombre conséquent d'insuffisances de sorte que le sujet de la mobilité transfrontalière au sein de l'Union européenne s'en retrouve très loin d'être clos. En outre, le caractère vague de nombre de dispositions, à commencer par la disposition anti-abus, laisse présager de beaux jours pour le rôle de la Cour de justice dans le cadre de la concrétisation prétorienne de la liberté d'établissement.

1770 Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *ECFR*, 1-2/2019, p. 3.
1771 J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0… », *op. cit.*, p. 1 ; P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 61, n° 1 et P. STEMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2437.
1772 P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *ibidem*, p. 61, n° 1 et P. STEMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *ibidem*, p. 2437.
1773 St. BARTMANN, *op. cit.*, p. 140.

Chapitre 2
L'avenir de la réglementation des scissions transfrontalières en Europe

SECTION 1. PRÉSENTATION

383. Deux questions complémentaires. S'il est établi que la Directive Mobilité souffre d'un certain nombre d'insuffisances ne permettant pas de clôturer les discussions sur le régime des scissions transfrontalières au sein de l'Union européenne et afin de pouvoir tirer certaines conclusions sur l'avenir de la réglementation des scissions transfrontalières au sein de l'Union européenne, il convient à présent d'établir qu'une nouvelle intervention du législateur européen est nécessaire (section 2) et qu'elle devrait prendre la forme d'une directive (section 3). Pour ce faire, les raisons ayant poussé à l'adoption du régime des scissions transfrontalières consacré par la Directive Mobilité seront étudiées à l'aune plus particulièrement des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante qui ont été volontairement exclues du champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité.

SECTION 2. LA NÉCESSITÉ D'UNE INTERVENTION DU LÉGISLATEUR EUROPÉEN

384. Plan de la section 2. Pour aboutir à la conclusion qu'une nouvelle initiative européenne est indispensable pour faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne (§ 5), il convient tout d'abord de tirer pleinement profit de l'enseignement des fusions transfrontalières (§ 1) pour ensuite établir (i) les insuffisances des méthodes dérivées permettant d'aboutir indirectement au résultat d'une scission transfrontalière (§ 2), (ii) l'insécurité juridique persistante en la matière (§ 3) et (iii) la nécessité de protéger les *stakeholders* de manière adéquate (§ 4).

§1. L'enseignement des fusions transfrontalières

385. L'impact positif d'une réglementation harmonisée. La sécurité juridique et la réduction des coûts offertes par le cadre harmonisé introduit à l'origine par la Dixième Directive ont entraîné une hausse significative du nombre de fusions transfrontalières. En effet, il a pu être établi qu'entre 2008 et 2012, 1.227 fusions transfrontalières ont pu être réalisées, ce qui représente une augmentation de 173 %[1774]. En outre, entre 2013 et 2017, il y a eu 1 163 fusions transfrontalières dans seulement 9 États membres[1775]. Cette hausse significative s'explique aisément par le fait que la Dixième Directive a (i) généré un régime cohérent offrant un niveau de sécurité juridique satisfaisant pour les fusions transfrontalières, (ii) permis de significativement réduire les coûts prohibitifs généralement associés à ce type d'opérations et (iii) diminué les délais excessifs nécessaires auparavant pour réaliser ce type d'opérations[1776]. À titre de comparaison, lors de la consultation de 2015, sur les neuf autorités publiques ayant

1774 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 6 et Étude d'impact, p. 19.
1775 Étude d'impact, p. 19 et Th. BIERMEYER et M. MEYER, *op. cit.*, p. 5.
1776 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 6 à 9 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 223.

fourni une réponse quant au nombre de scissions transfrontalières réalisées au cours des 5 dernières années, huit ont indiqué qu'il y en avait eu entre 0 et 10 et une autorité nationale a indiqué qu'il y en avait eu entre 11 et 20[1777]. Il n'est dès lors pas surprenant de constater que cette initiative européenne est généralement considérée comme une réussite[1778] et a été saluée en ce sens par le Parlement européen[1779].

386. La nécessité d'une harmonisation plus poussée. Malgré ces indéniables progrès, tant les deux études préalables[1780] que l'Étude Bech-Bruun et Lexidale[1781] et les consultations publiques[1782] ont mis en lumière un nombre conséquent d'insuffisances nuisant à la pleine effectivité du régime des fusions transfrontalières liées, à tout le moins en partie, au fait que les dispositions de la Directive Sociétés relatives aux fusions transfrontalières sont issues d'un fragile compromis politique[1783]. La Directive Mobilité tente d'y remédier par un plus haut degré d'harmonisation comme, à titre d'illustration, à l'égard de la protection des créanciers[1784] et des associés minoritaires[1785]. Si la solution reste suboptimale en ce que les États membres continueront à l'avenir de disposer d'une marge de manœuvre, comme en témoigne par exemple le régime anti-abus[1786], il n'en demeure pas moins que le degré d'harmonisation prôné par la Directive Mobilité est supérieur à celui de la Directive Sociétés. Cela se voit clairement au fait que la Directive Mobilité intègre des dispositions applicables à la protection des créanciers[1787] et des associés minoritaires[1788], alors que la Directive Sociétés s'en remettait essentiellement aux États membres à cet égard[1789]. Il y a donc un

1777 Consultation publique de 2015, p. 25.

1778 Voir en ce sens : Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 6. Voir également en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 300 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 841 ; R. KNAIER, « Crossing borders, digitally ? Das "Company Law Package" auf dem Prüfstand », *op. cit.*, p. R149 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 24 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, pp. 24 et 25 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 235 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 16. Voir également : Déclaration de l'Estonie sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières du 8 novembre 2019, 13691/19 ADD1, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020), p. 2.

1779 Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pt. 5.

1780 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, pp. 34 à 50 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 16 à 25.

1781 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 9 à 15.

1782 Consultation publique de 2017, pp. 6 et 7 et Consultation publique de 2015, pp. 5 à 18.

1783 Voir en ce sens : N. BENZ, L : HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2254.

1784 Art. 126*ter* de la Directive Mobilité.

1785 Art. 126*bis* de la Directive Mobilité et en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2261.

1786 À ce sujet, voir *supra* n° 366.

1787 Art. 126*ter* de la Directive Mobilité.

1788 17e considérant et art. 126*bis* de la Directive Mobilité et voir à ce sujet : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 236 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 19 et 20.

1789 Art. 121, § 2 de la Directive Sociétés et à ce sujet : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2254.

enseignement fondamental à tirer de cette évolution : l'intégration européenne en matière de mobilité transfrontalière est un processus par étapes et le meilleur moyen de contourner les éventuelles réticences des États membres à l'encontre d'un plus haut degré d'harmonisation consiste à leur faire accepter un premier régime peu intrusif pour ensuite mettre en exergue de façon incontestable, par le biais d'études scientifiques et de consultations publiques, la nécessité de remédier aux insuffisances de ce régime par un plus haut degré d'harmonisation et ainsi de suite. Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher sur l'article 4 de la Directive Mobilité qui traite de l'évaluation et du réexamen de la mise en œuvre des dispositions de la Directive Mobilité et qui couvre notamment la participation des travailleurs[1790], l'évaluation des procédures existantes de transformation, fusion et scission transfrontalières[1791] et l'opportunité d'introduire un régime harmonisé pour les scissions par acquisition[1792]. On entrevoit ainsi déjà clairement qu'une nouvelle proposition de directive destinée à rectifier le régime existant verra le jour à la suite du rapport de la Commission sur la Directive Mobilité, et il ne reste qu'à espérer que cette disposition ne restera pas lettre morte, comme dans le cas de la société européenne et de la société coopérative européenne dont les régimes ne permettent toujours pas à ces formes sociales d'avoir leur administration centrale et leur siège statutaire dans des États membres différents[1793], malgré une possibilité de révision explicitement prévue et les enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Polbud*[1794].

387. Conséquences sur les scissions transfrontalières. Compte tenu du fort lien de parenté entre fusions et scissions[1795] et de l'indéniable utilité économique de ces dernières[1796], il est fort probable que l'introduction d'un cadre harmonisé pour les scissions transfrontalières en augmenterait considérablement le nombre en réduisant tant leur coût que l'insécurité juridique qui y est liée. Cela permettrait en outre d'ouvrir plus facilement ce type d'opérations aux petites et moyennes entreprises qui semblent davantage frileuses à leur

1790 Art. 4, § 1er de la Directive Mobilité.
1791 Art. 4, § 2 de la Directive Mobilité.
1792 Art. 4, § 3 de la Directive Mobilité.
1793 Selon l'art. 69, a) du Règlement sur la Société européenne, « [a]u plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport sur l'application du règlement et, le cas échéant, des propositions de modifications. Le rapport examine en particulier s'il convient : (a) de permettre à une SE d'avoir son administration centrale et son siège statutaire dans des États membres différents ». Dans un même ordre d'idées, l'art. 79, a) du Règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, *J.O.*, L 207, 18 août 2003, pp. 1–24 (ci-après le « **Règlement sur la Société Coopérative européenne** »), « [a]u plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et, le cas échéant, des propositions de modifications. Le rapport examine en particulier s'il convient : (a) de permettre à une SEC d'avoir son administration centrale et son siège statutaire dans des États membres différents ».
1794 Au sujet de cet arrêt, voir *supra* nos 211 et 212.
1795 Voir en ce sens : L. Athlan et St. Torck, *op. cit.*, p. 1 ; H. Le Nabasque, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. Lamon, *op. cit.*, p. 125 et Th. Prüm, *ibidem*, p. 16 ; A. Reik, *op. cit.*, p. 300 ; E. Roelofs, *op. cit.*, p. 347 ; J. Schmeidler, *op. cit.*, p. 6, n° 9 ; J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27 et Chr. Teichmann, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 13.
1796 Sur l'intérêt économique des scissions transfrontalières, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2.

égard[1797]. Cette analyse est confortée par le fait qu'à l'heure actuelle, les scissions internes qui bénéficient d'un cadre harmonisé depuis la Sixième Directive sont très fréquentes[1798], alors que les scissions transfrontalières demeurent pour le moins exceptionnelles[1799].

§ 2. Les insuffisances des méthodes dérivées

388. L'argument des mécanismes dérivés de scission. Préalablement à l'adoption de la Directive Mobilité, il était fréquent que lorsque des acteurs économiques souhaitaient réaliser une opération transfrontalière pour laquelle il n'existait pas de procédure directe offrant un degré de sécurité juridique suffisant, ils recourent à une fastidieuse superposition d'opérations distinctes et suffisamment harmonisées pour atteindre le même résultat tout en bénéficiant d'un aléa moindre[1800]. Cette solution a été unanimement considérée comme suboptimale dans la mesure où elle complexifie la procédure tout en en augmentant et le coût et la durée[1801] et, par ricochet, met ce type de restructuration hors de portée de nombreuses petites et moyennes entreprises[1802]. Cette situation foncièrement insatisfaisante a été utilisée pour justifier l'adoption de la Directive Mobilité[1803], mais une étude détaillée de la manière de réaliser une scission par acquisition par le biais des nouvelles méthodes dérivées introduites par la Directive Mobilité en se basant sur la substituabilité du point de vue du droit des sociétés des différents mécanismes de restructuration[1804], va démontrer que cet argument pourrait toujours servir à justifier une nouvelle initiative européenne en la matière. À cet égard, du point de vue méthodologique, il semble plus opportun de se concentrer sur les nouvelles opportunités offertes par la Directive Mobilité puisque les autres mécanismes utilisés avant la Directive Mobilité, tels que la « *scission indirecte* » consistant en la constitution d'une nouvelle société dans l'État membre de destination et le fastidieux transfert contractuel des éléments d'actif et de passif[1805], ont largement montré leurs limites en raison des délais et des coûts excessifs qu'ils engendrent. Trois constructions permettant

1797 Étude d'impact, p. 23.

1798 Selon les données chiffrées citées par l'Étude d'impact, il y aurait près de 700 scissions internes par an au Danemark, plus d'un millier en France, environ 500 en Pologne et en Estonie, environ 200 en Finlande, en Lettonie et en Suède et environ 150 en Belgique. Ces données sont certes à prendre avec une certaine circonspection dans la mesure où elles se basent exclusivement sur les résultats de la consultation publique de 2015 et des informations recueillies auprès des différents registres de commerce et se rapportent aux cinq années précédentes, mais il n'en demeure pas moins que les scissions transfrontalières demeurent des opérations fréquentes. Voir Étude d'impact, p. 23.

1799 Selon des estimations très approximatives, on estime qu'en 2018, il n'y eu qu'une centaine de scissions transfrontalières au sein de l'Union européenne. Voir Étude d'impact, p. 24.

1800 Étude d'impact, p. 26.

1801 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 8 et Étude d'impact, p. 26.

1802 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 1 et 27e considérant de la Proposition de la Commission.

1803 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 8 et Étude d'impact, p. 26.

1804 Voir en ce sens J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 354 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2438.

1805 Sur les insuffisances de cette solution qui implique d'obtenir l'accord de chaque créancier de la société concernée, voir Étude d'impact, p. 57 ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 104 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 26.

d'aboutir au même résultat qu'une scission transfrontalière par absorption seront ainsi étudiées, à savoir (i) la scission transfrontalière par absorption articulée autour de multiples fusions transfrontalières, (ii) la scission transfrontalière par absorption articulée autour de multiples transformations transfrontalières et (iii) la scission transfrontalière par absorption articulée autour d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés.

389. La structuration autour de multiples fusions transfrontalières. Une première solution intéressante du point de vue de la sécurité juridique, et qui rappelle celle occasionnellement recommandée à l'égard des transformations transfrontalières[1806], consiste à procéder à un éclatement de la procédure de scission transfrontalière en deux étapes distinctes, à savoir une scission interne par constitution de nouvelles sociétés combinée ensuite à plusieurs fusions transfrontalières avec les sociétés bénéficiaires préexistantes destinées à permettre l'absorption transfrontalière des diverses branches d'activités issues de l'opération. Cette solution est loin d'être inédite[1807] et rappelle la conclusion du rapport de 2002 du *High Level Group of Company Law Experts* qui mettait en doute la nécessité de procéder à une harmonisation des scissions transfrontalières dans le cadre des travaux relatifs à l'adoption de la Dixième Directive au motif qu' « une société qui souhaite réaliser une scission transfrontalière peut tout d'abord séparer des pans d'activités pour les constituer en filiales distinctes en vue de leur cession ultérieure dans une opération de fusion »[1808]. Cependant, même si la Directive Mobilité a permis de rectifier un certain nombre d'insuffisances de la procédure de fusion transfrontalière, force est de constater que cette solution demeure longue et complexe[1809]. De plus, si la pratique a permis de développer certains mécanismes destinés à simplifier les opérations de restructuration en cascade, comme par exemple le fait de publier les différents projets communs le même jour en précisant que chaque opération est envisagée sous la condition expresse de la réalisation de l'opération précédente[1810] afin de faire courir les différents délais devant s'écouler

1806 C. GERNER-BEURLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, « Cross-border reincorporations in the European Union, the case for comprehensive harmonisation », *Journal of Corporate Law Studies*, 2018, vol. 18, p. 6 et A.-L. SIBONY, *op. cit.*, p. 2.

1807 Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pt. 15 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 104 et K. BYTTEBIER, *Fusies en overnames*, Brugge, die Keure, 2007, p. 321, n° 568 ; L. HANSEN, *op. cit.*, p. 192 ; Th. MASTRULLO, *op. cit.*, p. 1 ; Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, p. 84 ; R. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 69 et 70 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 320 ; M. WYCKAERT et F. JENNE, « Corporate mobility in a European context » in K. GEENS et K. J. HOPT (éd.), *The European Company Law Action Plan Revisited – Reassessment of the 2003 priorities of the European Commission*, Leuven, Leuven University Press, 2010, p. 313, n° 21. Voir également : R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 622 qui propose de recourir à une scission par séparation combinée à une fusion transfrontalière.

1808 Rapport final du Groupe de haut niveau d'experts en Droit des Sociétés (2002), http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_fr.pdf (26/05/2016), p. 126.

1809 Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, n° 15 et R. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 69 et 70.

1810 À titre d'illustration, on peut citer l'exemple de (i) la fusion transfrontalière entre la *naamloze vennootschap* de droit néerlandais Wright Medical Group N.V., en tant que société absorbée et sa filiale détenue à 100 %, la société anonyme de droit luxembourgeois Wright Luxembourg S.A. en tant que société absorbante combinée à (ii) la fusion transfrontalière entre la société anonyme de droit luxembourgeois Wright Luxembourg S.A. en tant que société absorbée et sa filiale détenue à

entre la publication du projet et la tenue de l'assemblée générale de manière concomitante, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une opération présentant néanmoins l'inconvénient majeur d'être particulièrement coûteuse[1811]. À titre d'illustration, au Royaume-Uni où, en raison de l'absence de dispositions procédurales propres aux scissions transfrontalières, il est nécessaire de recourir à une telle construction, les coûts engendrés peuvent excéder 100 000,- euros, alors qu'une scission interne ne coûte qu'entre 30 000,- et 60 000,- euros[1812]. Ce surcoût s'explique aisément par la nécessité de passer par deux procédures distinctes requérant toutes deux la préparation de documents spécifiques[1813]. Par conséquent, les nombreuses critiques formulées de longue date[1814] à l'encontre de cette solution et qui ressortaient clairement de la consultation publique de 2015[1815] demeurent indéniablement d'actualité et ce, nonobstant la modernisation du régime des fusions transfrontalières par la Directive Mobilité.

390. La structuration autour de multiples transformations transfrontalières. Selon la rapporteuse Evelyn Regner, les entreprises recouraient aux scissions nationales combinées aux fusions transfrontalières pour réaliser une scission transfrontalière uniquement en raison de l'absence de règles sur les transformations transfrontalières. Dans la mesure où la Proposition de la Commission intègre des dispositions destinées spécifiquement à réglementer les transformations transfrontalières et que seul un petit nombre de scissions transfrontalières entre dans son champ d'application *ratione materiae*, elle a tout simplement proposé de supprimer le chapitre applicable aux scissions transfrontalières[1816]. Une telle argumentation, si elle est déjà douteuse à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés et n'a, fort heureusement, pas été suivie dans le cadre de la Directive Mobilité, l'est d'autant plus à l'égard des scissions transfrontalières par absorption puisqu'afin d'aboutir au même résultat juridique et économique par le biais d'une transformation transfrontalière, il conviendrait de superposer pas moins de trois opérations distinctes. En effet, il faudrait tout d'abord procéder à une scission interne par constitution de nouvelles sociétés pour isoler les différentes fractions du patrimoine de la société initiale. Ensuite, chacune des nouvelles entités ainsi constituées devrait réaliser une transformation transfrontalière vers le ou les États membres où se

100 % Wright Medical Ltd., une *exempted limited liability company* soumise au droit des Bermudes. Les deux projets communs ont été publiés le 20 mars 2020 au Recueil électronique des sociétés et associations luxembourgeois et il est expressément prévu à la clause 2.2.1 du deuxième projet de fusion que la deuxième fusion transfrontalière ne pourra être réalisée qu'à la condition expresse que la première fusion transfrontalière ait pris effet. Voir : Common draft terms of the cross-border merger between Wright Medical Group N.V. as absorbed company and Wright Luxembourg S.A. as absorbing company du 13 mars 2020, disponible sur https://www.lbr.lu (28/05/2020) et Common draft terms of merger (second-step statutory merger agreement) between Wright Luxembourg S.A. and Wright Medical Ltd. du 13 mars 2020, disponible sur https://www.lbr.lu (28/05/2020).

1811 Voir en ce sens également : R. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 69 et 70 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 26.

1812 Étude d'impact, p. 25.

1813 Étude d'impact, p. 26.

1814 Sur les insuffisances de cette solution, voir Étude d'impact, p. 57 et R. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 69 et 70 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 26. Voir également le cas pratique exposé en annexe de l'Étude d'impact, pp. 144 et 145.

1815 À ce sujet, voir Consultation publique de 2015, p. 20.

1816 Avis CAJ, p. 217.

trouvent les sociétés bénéficiaires préexistantes. Une fois cette étape finalisée, il conviendrait de réaliser plusieurs fusions internes par absorption des sociétés transformées par les sociétés bénéficiaires préexistantes. Cette solution, si elle offre certes un degré de sécurité juridique appréciable en ce qu'elle ne recourt qu'à des techniques de restructuration harmonisées, présente néanmoins le considérable inconvénient d'être fastidieuse, longue et très coûteuse[1817] en raison du nombre important d'étapes (pas moins de cinq pour une scission transfrontalière par absorption n'impliquant pourtant que deux sociétés bénéficiaires préexistantes).

391. La structuration autour d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés. Dans la mesure où, fort heureusement, la Directive Mobilité a procédé à l'harmonisation des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, il est tout à fait possible de réaliser une scission transfrontalière par absorption par ce biais. En effet, pour ce faire, il suffit de procéder en deux étapes, la première consistant à réaliser une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés et la deuxième en deux fusions internes entre les sociétés nouvellement constituées et les sociétés bénéficiaires préexistantes[1818]. Cependant, à nouveau, un tel changement de structure ne requerrait pas moins de trois opérations distinctes, ce qui implique des coûts conséquents et des délais potentiellement allongés.

392. L'incidence de la participation des travailleurs. En outre, les deux derniers mécanismes, à savoir celui faisant intervenir une transformation transfrontalière et celui faisant intervenir une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés souffrent d'une insuffisance majeure pour peu que le mécanisme destiné à préserver la participation des travailleurs trouve à s'appliquer[1819]. En effet, le régime instauré par la Directive Mobilité à l'égard de ces deux types d'opérations consacre explicitement un principe de permanence destiné à protéger le régime de participation des travailleurs en cas d'opérations successives. Il est ainsi prévu que la société issue de la scission transfrontalière[1820] ou de la transformation transfrontalière[1821] sera tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits des travailleurs en matière de participation soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieures et ce, pendant un délai excessivement long[1822] de quatre ans suivant la date de prise d'effet de l'opération en répétant *mutatis mutandis* la procédure de protection des droits de participation des travailleurs applicable à celle-ci. Il est intéressant de relever qu'une telle règle existe également à l'égard des fusions transfrontalières[1823], mais son incidence est moindre dans le cas présent puisque dans la construction étudiée ci-dessus[1824], les fusions transfrontalières constituent la dernière étape. En tout état de cause, cette règle aura pour conséquence de devoir réitérer le long et coûteux

1817 Voir également à ce sujet : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 104.
1818 ECLE, *op. cit.*, p. 201, note 25.
1819 Pour une étude détaillée de ce mécanisme, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2.
1820 Art. 160*terdecies*, § 7 de la Directive Mobilité.
1821 Art. 86*terdecies*, § 7 de la Directive Mobilité.
1822 À ce sujet, voir *infra* n° 1146.
1823 Art. 133, § 7 de la Directive Mobilité.
1824 À ce sujet, voir *supra* n° 388.

processus de négociation avec le groupe spécial de négociations et ce, d'autant plus que, contrairement au régime des fusions transfrontalières[1825], ni le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, ni le régime des transformations transfrontalières ne prévoient la possibilité pour les organes compétents des sociétés concernées de choisir sans négociation préalable d'être directement soumis aux dispositions de référence relatives à la participation[1826].

393. Des solutions foncièrement insuffisantes. De telles constructions sophistiquées entraînent nécessairement un coût significatif de sorte que ces alternatives demeurent largement hors de portée des petites et moyennes entreprises qui se retrouvent dès lors privées de la possibilité de se scinder par-delà les frontières[1827]. Lorsqu'on ajoute à cela le fait qu'en 2016, on estimait à plus de 19 millions le nombre de sociétés à responsabilité limitée au sein de l'Union européenne[1828] et que parmi celles-ci, au moins 98 % sont de petites et moyennes entreprises[1829], on constate aisément que les méthodes alternatives ne sont en aucun cas une solution satisfaisante en raison des coûts prohibitifs qu'elles engendrent. Il s'ensuit que les critiques formulées à l'encontre de l'inexistence d'un régime européen des scissions transfrontalières avant l'adoption de la Directive Mobilité[1830] demeurent d'actualité à l'égard des opérations exclues du champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité[1831]. De plus, l'objectif sous-tendant la Directive Mobilité et qui est de réduire les coûts et charges que de tels mécanismes engendrent pour les entreprises[1832] pourrait tout aussi bien se retrouver tel quel dans une nouvelle initiative européenne portant sur les scissions par acquisition.

§ 3. Une insécurité juridique persistante

394. Une difficulté délicate à surmonter pour les législateurs nationaux. Les divergences existant entre les droits nationaux sont un obstacle majeur à la réalisation d'une opération transfrontalière[1833] et ce point a été très clairement confirmé par la consultation publique de 2015 au cours de laquelle 82 % des personnes s'étant prononcées sur la question du principal obstacle à la

1825 Art. 133, § 4, a) de la Directive Mobilité.
1826 Sur cette insuffisance, voir *supra* n° 379.
1827 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 1.
1828 Étude d'impact, p. 5. Ce nombre correspond à 80 % de 24,4 millions. Voir également : Assessment and quantification of drivers, problems and impacts related to cross-border transfers of registered offices and cross-border divisions of companies, EY, 5 février 2018, disponible sur https://ec.europa.eu (13/03/2020) (ci-après l' « **Étude EY** »), pp. 13–17.
1829 Étude d'impact, p. 5 et Étude EY, pp. 15–17.
1830 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 8 ; Consultation publique de 2015, p. 2 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 104. Voir également en ce sens : J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 13.
1831 Sur le caractère excessivement limité du champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières, voir *supra* n°s 341 à 346.
1832 Étude d'impact, p. 42 et Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 14, 15 et 23.
1833 Étude d'impact, p. 25 et F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 42 ; Th. MASTRULLO, *op. cit.*, p. 1 ; M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 17 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, pp. 141 et 142 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2437.

réalisation d'une scission transfrontalière ont indiqué qu'il s'agissait de l'insécurité juridique due à l'absence de règles européennes en la matière[1834]. Compte tenu des insuffisances de la Directive Mobilité, à commencer par son champ d'application *ratione materiae* particulièrement limité[1835] et malgré les appels à une forme de *goldplating* par laquelle les États membres iraient volontairement au-delà du champ d'application très limité de la Directive Mobilité par souci de cohérence de leur régime de droit national[1836], ces divergences et insuffisances ne disparaîtront certainement pas. En outre, compte tenu de l'expérience réussie des fusions transfrontalières[1837] et des réticences de nombreux États membres à l'égard de la construction prétorienne du marché intérieur par la Cour de justice au moyen de sa jurisprudence en matière de liberté d'établissement[1838], il ne subsiste aucun doute quant à l'incapacité des États membres à parvenir à une solution satisfaisante en l'absence d'une initiative européenne[1839]. Il s'ensuit que, tout comme dans le cadre de la Directive Mobilité[1840], une initiative européenne en la matière serait nécessairement conforme tant au principe de subsidiarité[1841] qu'au principe de proportionnalité[1842].

§4. La nécessité de protéger les stakeholders de manière adéquate

395. Une situation de départ insatisfaisante. Si l'intérêt économique des scissions transfrontalières est indéniable[1843], il n'en demeure pas moins que ce type d'opérations est susceptible d'avoir un impact considérable sur les différents *stakeholders*[1844]. Or, l'absence de régime paneuropéen des scissions transfrontalières a pour conséquence que les intérêts des *stakeholders* potentiellement impactés par l'opération sont traités de manières fort divergentes[1845]. En effet, soit ceux-ci sont insuffisamment protégés[1846], soit, au contraire, ils se voient attribuer des prérogatives exorbitantes allant jusqu'à leur permettre de bloquer

1834 Consultation publique de 2015, p. 20.
1835 À ce sujet, voir *supra* n°s 341 à 346.
1836 Voir en ce sens : J. Bormann et P. Stelmaszcyk, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 355 ; J. Schmidt, « Coming soon : „Company Law Package Part 2 - Implementation" », *op. cit.*, p. 802 et P. Stelmaszczyk, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 64.
1837 À ce sujet, voir *supra* n° 385.
1838 À ce sujet, voir *supra* n° 231.
1839 Voir en ce sens : 58e considérant de la Directive Mobilité ; Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 14 et Étude d'impact, pp. 98 et 99.
1840 58e considérant de la Directive Mobilité.
1841 Art. 5, § 3 du Traité dur l'Union européenne (version consolidée), *J.O.*, C 326, 26 octobre 2012, pp. 1–390 (ci-après le « **TUE** ») et à ce sujet, voir notamment : Cl. Blumann et L. Dubois, Droit institutionnel de l'Union européenne, 5e éd., LexisNexis, Paris, 2013, pp. 459 à 473.
1842 Art. 5, § 4 du TUE et Cl. Blumann et L. Dubois, *ibidem*, pp. 474 à 477.
1843 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2.
1844 Pour une étude détaillée des différents risques encourus par les *stakeholders* dans le cadre d'une scission transfrontalière, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 1 (créanciers), Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 1 (actionnaires minoritaires) et Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section 1 (travailleurs). Voir également en ce sens : Étude d'impact, p. 5 et Th. Mastrullo, *op. cit.*, p. 1.
1845 Voir en ce sens : M. Menjucq, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 17 et P. Stelmaszczyk, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2437.
1846 Étude d'impact, p. 6 et P. Stelmaszczyk, *ibidem*, p. 2437 et Chr. Teichmann, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 242.

l'opération[1847] malgré la potentielle nécessité économique de celle-ci pour l'entreprise sous-jacente. Cette situation insatisfaisante, avancée pour justifier l'intervention du législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité en vue d'introduire un régime de protection à la fois effectif et proportionné[1848], ne manquera pas de se répéter à l'égard des scissions par acquisition au sujet desquelles le législateur européen reconnaît spontanément qu'elles entraînent « des risques supplémentaires en termes de contournement des règles de l'Union et des règles nationales »[1849].

396. Illustration : le droit de retrait des associés minoritaires. Afin d'assurer la protection des associés minoritaires dans le cadre d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, la Directive Mobilité instaure un droit de retrait pour les associés minoritaires de la société scindée ayant voté contre l'opération[1850]. Or, en droit belge et luxembourgeois, un tel droit de retrait est inconnu en matière de scissions tant internes que transfrontalières de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée. Il s'ensuit que si ces deux législateurs nationaux s'en tiennent à une transposition stricte de la Directive Mobilité, un droit de retrait pour les associés minoritaires n'existera que pour les scissions transfrontalières n'impliquant qu'une société préexistante, c'est-à-dire pour le type de scission présentant par définition le moins de risques pour les associés minoritaires puisqu'ils ne risquent pas d'être excessivement dilués par rapport aux associés des sociétés bénéficiaires[1851].

397. Un objectif toujours d'actualité. On peut donc aisément avancer que l'objectif consistant à offrir une protection efficace et proportionnée aux différents *stakeholders*[1852] demeure d'actualité et pourrait sans difficulté aucune figurer à nouveau dans une initiative européenne portant sur les scissions par acquisition et les scissions mixtes. Par ailleurs, il est pratiquement inconcevable que la Commission ait tout simplement commis la grossière erreur d'ignorer les risques considérables qu'une scission transfrontalière par acquisition fait courir pour les différents *stakeholders*. La seule explication possible tient à nouveau au fait que cette négligence volontaire s'inscrit dans une stratégie plus large.

§ 5. Une attitude ambiguë du législateur européen

398. Une étape intermédiaire. En conséquence de ce qui précède, il n'est pas étonnant de constater que le législateur européen, malgré l'apparente limitation du régime de la Directive Mobilité aux seules scissions par constitution de nouvelles sociétés ne semblait aucunement douter de la nécessité d'introduire un régime cohérent de règles applicables aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. En effet, à la lecture de l'art. 4, § 3 de la Directive Mobilité, qui vient uniquement préciser que le rapport de la

1847 P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2437 et Chr. TEICHMANN, *ibidem*, p. 242.
1848 5e considérant de la Directive Mobilité ; Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 1 et 2 et Étude d'impact, pp. 26 à 28.
1849 8e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité.
1850 Art. 160*decies*, § 1er de la Directive Mobilité.
1851 Sur ce risque, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 1.
1852 Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 1, 2 et 9 et Étude d'impact, p. 42.

Commission devra comprendre « une évaluation de la faisabilité de la définition de règles pour les types de scission transfrontalière qui ne sont pas couverts par la présente directive, y compris, en particulier, les scissions transfrontalières par acquisition » sans se prononcer toutefois sur la nécessité de telles règles comme si celle-ci semblait d'ores et déjà acquise. Cette thèse est en outre étayée par le fait que le cas pratique exposé en annexe de l'Étude d'impact et mettant en lumière la nécessité d'harmoniser les scissions transfrontalières concerne la scission partielle transfrontalière d'une société italienne au profit de sa sœur britannique[1853], ce qui constitue une scission transfrontalière par acquisition partielle, pourtant explicitement exclue du champ d'application de la Directive Mobilité[1854]. Le seul moyen de réconcilier ces deux attitudes a priori contradictoires est de considérer que la Commission s'attendait indéniablement à une certaine réticence de la part des États membres à l'égard des scissions. Cette réticence transparaît notamment de l'avis de la CAEM sur la Proposition de la Commission dans lequel le rapporteur Olle Ludvigsson a suggéré de supprimer la partie sur les scissions transfrontalières en raison de « préoccupations concernant les risques et les dangers qui découlent de cette inclusion »[1855]. En habile politicienne, elle a par conséquent préféré limiter sa première initiative législative aux catégories de scission les moins susceptibles de susciter d'appréhension des États membres plus frileux à l'égard de la mobilité transfrontalière des sociétés, à savoir les scissions par constitution de nouvelles sociétés[1856]. Ce faisant, elle vise tout d'abord à démontrer aux États membres qu'une scission transfrontalière est une opération de restructuration économiquement importante qui doit nécessairement figurer au sein de l'arsenal des acteurs économiques du marché intérieur en misant sur une hausse conséquente de ces opérations, à l'instar de ce qui s'est produit pour les fusions transfrontalières. Ensuite, en comparant cette hausse aux scissions par acquisition dont le nombre sera nécessairement inférieur en raison de l'inexistence d'un cadre harmonisé offrant un degré de sécurité juridique suffisant, il sera plus aisé de faire accepter une initiative européenne à l'égard de ces dernières. En conclusion, comme l'a très justement fait remarquer le Comité économique et social européen à propos de la Proposition de la Commission, il ne s'agit que d' « une première étape »[1857]. Cependant, l'habileté politique de la Commission ne s'arrête pas là puisqu'un des effets accessoires de son attitude volontairement restrictive à l'égard des scissions transfrontalières pourrait avoir comme avantage non négligeable que les États membres pourraient être incités à étendre volontairement le champ d'application du régime européen au moment de la transposition et ce, afin de préserver la cohérence de leur droit des sociétés national[1858], ce qui ne manquera pas de renforcer l'acceptabilité politique d'une nouvelle initiative en la matière.

1853 Étude d'impact, pp. 144 et 145.
1854 Art. 160*ter*, § 4 de la Directive Mobilité.
1855 Avis CAEM, p. 308.
1856 Art. 160*ter*, § 4 de la Directive Mobilité.
1857 Avis CESE, pt. 3.6.9.
1858 Voir : J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 355 qui plaide en faveur d'une telle extension du champ d'application *ratione materiae* lors de la transposition en droit allemand.

SECTION 3. LA FORME D'UNE INTERVENTION DU LÉGISLATEUR EUROPÉEN

399. Présentation. S'il est à présent établi (i) que la Directive Mobilité présente un nombre considérable d'insuffisances ne permettant aucunement de clore les discussions sur les scissions transfrontalières et (ii) qu'une nouvelle intervention du législateur européen reste indispensable pour faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne, il reste à déterminer la forme qu'une telle initiative européenne devra revêtir.

400. La nécessité d'une nouvelle directive. Dans le cadre de la Directive Mobilité[1859], le législateur européen a agi, entre autres, sur la base de l'article 4, § 2, point a du TFUE selon lequel les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent notamment au marché intérieur. Cette base légale est complétée par l'article 50 du TFUE, autorisant le Parlement et le Conseil à statuer par voie de directives en vue de réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée[1860] et imposant à ces organes d'exercer leurs prérogatives (i) en supprimant progressivement les restrictions à la liberté d'établissement qui figureraient dans les conditions applicables à la création d'agences, de succursales et de filiales sur le territoire d'un État membre[1861] et (ii) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées des sociétés pour assurer la protection des intérêts tant des associés que des tiers[1862]. Compte tenu du fait que l'article 50 du TFUE ne laisse aucun choix au législateur européen quant à la forme de l'instrument[1863], le choix d'une directive s'impose naturellement et correspond aux recommandations faites en ce sens par les deux études préliminaires[1864]. En outre, ce choix est étayé par deux autres arguments. Tout d'abord, nombre de procédures de restructuration, parmi lesquelles on compte les fusions internes[1865] et transfrontalières[1866], les scissions internes[1867], les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[1868] et les transformations transfrontalières[1869], figurent déjà au sein d'une directive. Par conséquent, par souci de cohésion et de cohérence du droit des sociétés européen, il serait logique qu'une initiative en matière de scission transfrontalière par acquisition figure également dans une directive. Cette conclusion est renforcée par les résultats de la consultation de 2015 lors de laquelle 79 % des personnes ayant fourni une réponse quant à la question de savoir si des règles harmonisées en matière de scissions transfrontalières devaient être introduites au sein du cadre existant pour les fusions transfrontalières ont répondu par l'affirmative[1870].

1859 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 15 et Étude d'impact, p. 41.
1860 Art. 50, § 1er du TFUE.
1861 Art. 50, § 2, point f) du TFUE.
1862 Art. 50, § 2, point g) du TFUE.
1863 Étude d'impact, p. 99.
1864 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, pp. 61 et 62 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, pp. 37 et 38.
1865 Art. 87 à 117 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
1866 Art. 118 à 134 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
1867 Art. 135 à 160 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
1868 Art. 160*bis* à 160 *duovicies* de la Directive Mobilité.
1869 Art. 86*bis* à 86*unvicies* de la Directive Mobilité.
1870 Consultation publique de 2015, p. 24.

Ensuite, le processus législatif éclair par lequel la Directive Mobilité est passée démontre à suffisance l'acceptabilité politique du fait de procéder par le biais de cette mesure législative en vue d'encadrer et de renforcer la mobilité transfrontalière des sociétés au sein de l'Union européenne.

401. L'insuffisance d'une nouvelle directive. Si une nouvelle directive en matière de mobilité transfrontalière semble effectivement indispensable, ne fût-ce que pour gommer à tout le moins partiellement les nombreux obstacles aux scissions transfrontalières qui ne manqueront pas d'être engendrés par les insuffisances de la Directive Mobilité et si la Commission européenne a effectivement déjà préparé le terrain pour celle-ci[1871], il est fort peu probable qu'il s'agisse là de la fin du voyage. En effet, les aléas politiques dont cette initiative législative ne manquera pas d'être affectée, laisseront systématiquement de la place pour des améliorations. En effet, il est d'ores et déjà possible de relever qu'une nouvelle directive, bien qu'avantageuse dans le cadre de la construction d'un régime paneuropéen de mobilité transfrontalière, ne manquera pas d'être affectée d'un certain nombre d'insuffisances endémiques à ce mécanisme d'harmonisation. Au nombre de celles-ci, on compte fréquemment le caractère foncièrement limité du champ d'application qui a tendance à se concentrer sur les sociétés de capitaux, l'absence d'harmonisation effective en raison de la nécessité d'aboutir à un compromis politique laissant malgré tout une certaine marge de manœuvre aux législateurs nationaux et une complexité excessive de la matière due à tout le moins en partie à la nécessité de préserver certains particularismes nationaux[1872]. Ces différents manquements se vérifient à l'égard du régime limité des scissions transfrontalières consacré par la Directive Mobilité dont (i) le champ d'application n'inclut pas toutes les sociétés jouissant de la liberté d'établissement[1873], (ii) l'harmonisation *a minima* prônée dans le cadre de la protection des associés minoritaires[1874] laisse une large marge de manœuvre aux différents législateurs nationaux et (iii) le mécanisme de la déclaration de solvabilité dans le cadre de la protection des créanciers requiert une délicate articulation avec les régimes de responsabilité spécifiques relevant des droits nationaux de l'insolvabilité pour être efficace[1875]. Il y a dès lors fort à parier qu'une nouvelle initiative européenne sous la forme d'une directive intégrant un régime spécifiquement applicable aux scissions impliquant plus d'une société préexistante se retrouve également affectée de tels défauts. Par conséquent, l'objectif du Parlement européen selon lequel « il importe de prévoir une harmonisation la plus complète possible pour les futures propositions législatives relatives à la mobilité des entreprises »[1876] ne sera certainement pas exclusivement rempli au moyen d'une nouvelle directive,

1871 Voir *supra* n° 398.

1872 Sur les insuffisances des directives dans le cadre de la construction du droit européen des sociétés, voir Kr. Marescau et A. Fink, *op. cit.*, pp. 195 et 196 ; N. Thirion (sous la coordination de), *op. cit.*, pp. 261 à 263, n°s 477 à 479 et J. Wouters, « European company law *: quo vadis* ? », *C.M.L.R.*, 2000, vol. 37, issue 2, pp. 275 et 276.

1873 À ce sujet, voir *supra* n°s 333 à 336.

1874 17e considérant et art. 160*decies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

1875 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 2, B., 2.

1876 Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pt. 3.

mais continuera de nécessiter l'harmonisation négative de la Cour de justice par le biais de sa jurisprudence en matière de liberté d'établissement[1877].

402. Quid de la société européenne ? Alors que le Règlement sur la Société européenne contient une procédure spécifique de constitution par voie de fusion transfrontalière[1878], la possibilité de créer une nouvelle société européenne par voie de scission n'est pas prévue. Cela n'implique toutefois pas qu'une société européenne soit privée de la possibilité de participer à une scission et il est généralement admis qu'une société européenne puisse procéder à la constitution d'une société européenne filiale[1879] au moyen d'une scission par séparation par constitution de nouvelle société[1880]. En outre, suite à la transposition de la Directive Mobilité dans les régimes nationaux des sociétés anonymes, une société européenne devrait pouvoir procéder à une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés autres que des sociétés européennes, pour peu que les droits nationaux applicables l'autorisent[1881]. En revanche, la possibilité de procéder à une scission par constitution d'une nouvelle société européenne est majoritairement exclue en raison du caractère limitatif de l'énumération des modes de constitution d'une société européenne[1882]. Même si cette interprétation ne fait pas l'unanimité dans la mesure où certains ont argué que l'application subsidiaire du régime national applicable aux sociétés anonymes consacré par le Règlement sur la Société européenne[1883] impliquait la possibilité de constituer une société européenne par voie de scission[1884], il s'ensuit que pour réaliser une telle opération avec un niveau de sécurité juridique appréciable, il faudra réaliser soit (i) une scission nationale suivie d'une fusion transfrontalière par constitution de société européenne ou d'une fusion transfrontalière classique suivie d'une transformation

1877 Sur l'importance de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement pour la concrétisation des scissions transfrontalières au sein du marché intérieur, voir *supra* n°s 232 à 236. Sur la complémentarité entre harmonisation positive et harmonisation négative, voir : P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, pp. 43 et 44.

1878 Art. 17 à 31 du Règlement sur la Société européenne.

1879 Art. 3, § 2 du Règlement sur la Société européenne.

1880 Voir en ce sens : M. CASPER in G. SPINDLER et E. STILZ (dir.), *Kommentar zum Aktiengesetz*, 4e éd., C.H. Beck, München, 2019 SE-VO Art. 3, n° 40 ; M. CASPER, « Numerus Clausus und Mehrstaatlichkeit bei der SE-Gründung », *AG*, 2007, p. 104 ; J. LIEDER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 124, n° 8 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, Anhang I, n° 137 ; A. KOSSMANN et E. HEINRICH, « Möglichkeiten der Umwandlung einer bestehenden SE », *ZIP*, 2007, p. 168 ; R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 366 et A. SCHWANNA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 125, n° 9.

1881 Voir en ce sens à propos des scissions internes : M. CASPER in SPINDLER et STILZ (dir.), *ibidem*, SE-VO Art. 3, n° 40 ; M. CASPER, *ibidem*, p. 104 ; J. LIEDER in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 124, n° 6 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, Anhang I, n° 135 et A. SCHWANNA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 125, n° 9.

1882 Voir en ce sens : M. CASPER in G. SPINDLER et E. STILZ (dir.), *ibidem*, SE-VO Art. 3, n° 40 ; M. CASPER, *ibidem*, p. 104 ; A. KOSSMANN et E. HEINRICH, *op. cit.*, p. 168 ; J. LIEDER in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 124, n° 8 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, Anhang I, n° 5 ; A. SCHWANNA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 125, n° 9 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 124, n° 1. *Contra* : Kr. OPLUSTIL et M. SCHNEIDER, « Zur Stellung der Europäischen Aktiengesellschaft im Umwandlungsrecht », *NZG*, 2003, p. 17. Voir également : O. VOSSIUS, « Gründung und Umwandlung der deutschen Europäischen Gesellschaft (SE) », *ZIP*, 2005, pp. 748 et 749 qui n'opère aucune distinction en la matière.

1883 Art. 9, § 1er, *c*), i) du Règlement sur la Société européenne.

1884 En faveur de cette possibilité dans le cadre d'une scission interne : Kr. OPLUSTIL et M. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 17.

en société européenne, soit (ii) une scission nationale suivie d'une transformation en société européenne et d'un transfert transfrontalier du siège statutaire de la société européenne[1885]. Cette insuffisance, malgré sa mise en évidence dans le rapport de la Commission au Parlement européen en 2010[1886], ainsi que les remarques de certains auteurs pour lesquels une telle possibilité aurait eu un intérêt pratique[1887], n'a pas fait l'objet d'une rectification à ce jour. Cette lacune est encore plus flagrante depuis l'entrée en vigueur de la Directive Mobilité puisque toutes les sociétés anonymes nationales pourront dorénavant être constituées par voie de scission transfrontalière. Par conséquent, alors que dans le cadre des fusions transfrontalières, c'est l'adoption du Règlement sur la Société européenne qui a servi de catalyseur à l'avènement de la Dixième Directive[1888], il s'avère à présent que c'est la consécration d'un régime européen des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés qui devrait inciter le législateur européen à réactualiser le régime de la société européenne par souci de cohérence juridique. Par souci d'exhaustivité, il convient de mentionner (i) que le même raisonnement devrait s'appliquer à la société coopérative européenne dont le régime actuel n'envisage pas la constitution par voie de scission transfrontalière[1889] et (ii) qu'il conviendrait également de régler le cas de la scission des groupements européen d'intérêt économique dont la réglementation n'envisage pas ce type d'opération et qui présentent en outre la difficulté additionnelle de ne pas être nécessairement doté de la personnalité juridique[1890].

SECTION 4. CONCLUSION SUR L'AVENIR DE LA RÉGLEMENTATION DES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES EN EUROPE

403. Une double intervention nécessaire. La nécessité d'une nouvelle intervention du législateur européen portant sur les scissions transfrontalières ressort indéniablement de l'expérience glanée en matière de fusions transfrontalières combinée aux insuffisances intrinsèques des mécanismes dérivés permettant

1885 Voir Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), (COM(2010) 676 final – SEC(2010) 1391), 17 novembre 2010, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (25/10/2019), p. 7, note 11.

1886 Voir Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), (COM(2010) 676 final – SEC(2010) 1391), 17 novembre 2010, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (25/10/2019), pp. 7 et 8 qui relève que cette insuffisance a été soulignée par les participants à la conférence et à la consultation externe, mais également qu'aucune des SE interrogées n'a mentionné cet aspect comme facteur négatif.

1887 Voir en ce sens : M. CASPER in G. SPINDLER et E. STILZ (dir.), *op. cit.*, SE-VO Art. 3, n° 40 ; M. CASPER, *op. cit.*, pp. 104 et 105 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, Anhang I, n° 5.

1888 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 110.

1889 Voir art. 2 du Règlement sur la Société Coopérative européenne et, sur le caractère limité des modes de constitution d'une société coopérative européenne, voir : A. SCHWANNA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 125, n° 9.

1890 Selon l'art. 1er, § 3 du Règlement (CEE) 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), *J.O.*, L 199, 31 juillet 1985, pp. 1–9 (ci-après le « **Règlement GEIE** »), « [l]es États membres déterminent si les groupements immatriculés à leurs registres en vertu de l'article 6 ont ou non la personnalité juridique ».

d'aboutir au même résultat qu'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. L'incapacité des États membres à parvenir seuls à une situation offrant un niveau de sécurité juridique suffisant et la nécessité d'offrir une protection efficace et proportionnée aux différents *stakeholders* viennent confirmer ce besoin. Face à ces évidences, l'attitude ambiguë du législateur européen soulève certaines interrogations et on ne peut que se demander si dès l'origine, la Commission européenne, pressentant les réticences de certains États membres, n'a pas fait le choix stratégique de procéder en deux étapes successives pour faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que pour que l'introduction d'un régime européen des scissions transfrontalières constitue bel et bien une pierre additionnelle pour la construction d'un droit européen des sociétés cohérent, il convient que celui-ci s'articule autour (i) de l'adoption d'une nouvelle directive venant modifier le régime existant des scissions internes[1891] et transfrontalières et (ii) de la modification du Règlement sur la Société européenne, du Règlement sur la Société Coopérative européenne et du Règlement sur le GEIE pour couvrir également la possibilité de réaliser des scissions transfrontalières, même si compte tenu du nombre limité de sociétés européennes[1892], de sociétés coopératives européennes[1893] et du groupement européen d'intérêt économique[1894], ce deuxième pan revêt une importance moindre.

1891 Sur la nécessité d'harmoniser également le régime des scissions internes, voir *supra* n°s 330 à 332.

1892 Au 7 novembre 2021, il y avait 3420 sociétés européennes au sein de l'Union européenne. Voir http://ecdb.worker-participation.eu (07/11/2021).

1893 En 2011, seules 24 sociétés coopératives européennes existaient au sein des États membres. Voir à ce sujet : Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique e social européen et au Comité des régions sur l'application du Règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE), COM/2012/072 final, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (15/11/2020), p. 6.

1894 Au 17 novembre 2020, il y avait 2678 GEIE dans toute l'Union européenne, dont 270 au Royaume-Uni. Pour des données statistiques précises à ce sujet, voir : EWIV-Statistik des Europäischen EWIV-Informationszentrums (bei LIBERTAS – Europäisches Institut GmbH), disponible sur https://www.libertas-institut.com (07/11/2021).

Conclusion sur le *company law package* et la nécessité d'une nouvelle intervention européenne

404. Une étape intermédiaire habilement prévue. Comment la Commission a-t-elle pu être aveugle au point de passer à côté de la nécessité de réglementer en priorité les scissions par acquisition ? Comment expliquer une Directive Mobilité qui semble presque aller à contresens de la jurisprudence particulièrement libérale de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement en laissant une marge de manœuvre excessive aux États membres pour bloquer une opération ? Le caractère lacunaire de la Directive Mobilité surprend d'autant plus à la lumière de l'indéniable nécessité d'une intervention du législateur européen en la matière, corroborée par l'enseignement des fusions transfrontalières, les insuffisances des méthodes dérivées articulées autour des nouvelles possibilités offertes par la Directive Mobilité et la nécessité de protéger les différents *stakeholders*. La réponse est simple : dans l'esprit de la Commission, la nécessité de procéder à l'harmonisation des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante n'a jamais fait l'ombre d'un doute, mais le meilleur moyen qui lui soit apparu pour surmonter les éventuelles réticences des États membres et tenir compte du scepticisme des syndicats à leur égard mis en lumière lors des consultations publiques de 2015[1895] et de 2017[1896] a été de générer davantage de difficultés par le biais d'une harmonisation asymétrique tout en habituant en même temps les États membres aux scissions par constitution de nouvelles sociétés, en essence moins litigieuses, par le biais d'une adaptation de la procédure des fusions transfrontalières à laquelle ils sont coutumiers. Ce faisant, il est fort probable que l'évaluation que la Commission réalisera sur l'application de la Directive Mobilité au plus tard le 1er février 2027[1897] établira les éléments suivants. Tout d'abord, il s'avérera que la Directive Mobilité aura eu pour effet d'accroître considérablement le nombre de scissions transfrontalières n'impliquant qu'une seule société préexistante, alors qu'*a contrario*, le nombre de scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante sera pour sa part resté négligeable. En outre, comme les États membres seront également tenus de fournir des informations sur les scissions transfrontalières pour lesquelles l'octroi du certificat préalable aura été refusé[1898], il sera possible de déterminer l'impact concret de la disposition anti-abus sur la mobilité transfrontalière et, le cas échéant, de l'émousser. En conséquence, la Directive Mobilité est très loin de clore le sujet des scissions transfrontalières et ne constitue en réalité qu'une étape de plus dans l'Odyssée de la mobilité transfrontalière des personnes morales au sein de l'Union européenne. Il s'ensuit qu'une nouvelle directive en matière de restructurations qui couvre à la fois les scissions internes et tous les types de scissions transfrontalières est inéluctable pour atteindre l'objectif ultime d'un régime cohérent de la mobilité transfrontalière des sociétés présentant le niveau d'harmonisation souhaité par le Parlement européen dans sa résolution

1895 Consultation publique de 2015, p. 19.

1896 Étude d'impact, p. 56 et Consultation publique de 2017, p. 9 établissant que 70 % des syndicats ayant répondu étaient hostiles à l'introduction d'une réglementation sur les scissions transfrontalières en raison d'une part de la dilution des seuils de protection des travailleurs et du risque de concentrer les travailleurs au sein d'une entité financièrement plus faible.

1897 Art. 4, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

1898 Art. 4, § 1er, al. 1er, 1re phrase de la Directive Mobilité.

de 2017[1899]. Cependant, bien que nécessaire, l'harmonisation positive du législateur européen n'en est pas pour autant suffisante et l'harmonisation négative de la Cour de justice[1900] permettant à cette dernière d'encadrer la marge de manœuvre laissée aux États membres par le législateur européen demeure plus que jamais nécessaire.

[1899] Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pt. 3.
[1900] À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.

TITRE V
Les contours d'un régime européen des scissions transfrontalières

SOMMAIRE

Introduction du titre V 369
Chapitre 1. La procédure générale de scission transfrontalière 373
Chapitre 2. Le régime des nullités des scissions transfrontalières 531
Chapitre 3. Les opérations simplifiées 537
Conclusion sur les contours d'un régime européen des scissions transfrontalières 547

Introduction du titre V

405. Plan du titre V. Il découle du chapitre précédent que malgré une approche *a priori* restrictive à l'égard des scissions transfrontalières, le législateur européen semble déjà avoir semé les germes d'une réforme plus ambitieuse des scissions au sein de l'Union européenne. À ce stade de l'analyse et toujours dans l'objectif de répondre à la question de comment faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne, il est donc opportun de procéder à une analyse détaillée du régime général des scissions transfrontalières prôné par le législateur européen dans le cadre des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés pour déterminer dans quelle mesure celui-ci serait également compatible avec les scissions transfrontalières mixtes et par acquisition. Ce faisant, il sera possible d'identifier les indices étayant le fait que la Directive Mobilité n'est qu'une étape préliminaire à une initiative de plus grande envergure. En outre, en mettant le régime des scissions de la Directive Mobilité en perspective avec le régime des fusions transfrontalières et ceux des scissions transfrontalières qu'on retrouve en droit belge et en droit luxembourgeois, il sera possible d'identifier et de résoudre les éventuelles insuffisances de la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières mixtes et par acquisition. Les trois aspects de la procédure générale de scission transfrontalière qui feront l'objet d'une analyse dans ce titre sont la procédure générale de scission transfrontalière (chapitre 1), le régime spécifique des nullités d'une telle opération (chapitre 2) et l'opportunité d'un régime dérogatoire applicable aux opérations simplifiées (chapitre 3).

Chapitre 1
La procédure générale de scission transfrontalière

SECTION 1. PRÉSENTATION

406. Plan du chapitre 1. À l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, le législateur européen s'est inspiré très largement du schéma général de restructuration qu'il utilise habituellement[1901] et qui se retrouve notamment dans le régime de la société européenne et dans la Directive Sociétés[1902]. De manière très schématique, en excluant les négociations préliminaires qui ne sont jamais couvertes (section 2) celui-ci peut être décomposé en sept étapes distinctes, à savoir l'établissement du projet de scission (section 3), l'établissement des rapports des organes la gestion ou d'administration (section 4), l'établissement du rapport d'expert indépendant (section 5), les mesures de publicité (section 6), l'approbation de l'assemblée générale (section 7), le double contrôle de légalité (section 8) et l'immatriculation et la prise d'effet de l'opération (section 9). Chacune de ces étapes sera passée en revue et mise en perspective avec le régime des fusions transfrontalières, ainsi qu'avec les régimes des scissions par acquisition transfrontalières applicables en droit belge et en droit luxembourgeois. Des éléments de comparaison avec les droits allemand, autrichien, français et italien seront également intégrés lorsqu'ils apparaîtront pertinents pour l'analyse.

SECTION 2. LES NÉGOCIATIONS PRÉLIMINAIRES

407. Une phase généralement absente des réglementations spécifiques. Le choix de procéder à une opération de scission, peu important qu'elle soit interne ou transfrontalière, est généralement l'aboutissement d'une phase préliminaire plus ou moins longue au cours de laquelle les différentes parties impliquées et leurs conseils évaluent les mérites des différentes possibilités de restructuration qui s'offrent à elles à l'aune des objectifs poursuivis. Différents critères entrent en ligne de compte quant au choix d'une ou de plusieurs opérations, au nombre desquels on compte principalement la durée de l'opération, les coûts engendrés par celle-ci et les différents degrés de sécurité juridique et fiscale accompagnant les diverses options. Ces négociations préliminaires ont généralement lieu entre les associés de contrôle des sociétés impliquées et leurs conseils ou encore entre les différents organes de gestion des sociétés impliquées[1903]. Elles sont susceptibles de durer de quelques jours à plusieurs mois, notamment dans l'hypothèse où une confirmation des autorités fiscales quant au traitement de l'opération est requise. Elles aboutiront tantôt à un plan général de restructuration dont une scission ne constituera qu'une étape parmi d'autres, par exemple en vue d'isoler un actif spécifique avant de procéder à

[1901] À ce sujet, voir : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 3 ; W. Bayer et J. Schmidt, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569 ; N. Benz, L. Hübner et A. Zimmermann, *op. cit.*, p. 2255 et J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 354.

[1902] Étude d'impact, p. 56.

[1903] J.-M. Nelissen Grade, « La réalisation de la fusion – Les opérations conduisant à la fusion » in *Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal*, Bruxelles, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 1993, p. 72.

sa cession, tantôt à la rédaction d'un protocole plus spécifiquement axé sur la scission[1904]. Ce plan général de restructuration ou ce protocole de scission pourra, le cas échéant, s'accompagner d'autres documents tels qu'un calendrier des opérations, des accords de confidentialité ou encore des engagements d'exclusivité[1905]. La valeur juridique de ce document dépendra fortement de son contenu, susceptible de se limiter à une déclaration de principe ou, au contraire, reprenant déjà certaines obligations claires qui engageront les parties à cet avant-projet[1906]. Il est ainsi parfaitement concevable que le protocole de scission contienne d'ores et déjà des dispositions spécifiques sur le fonctionnement interne des sociétés issues de l'opération ou encore des indications sur les méthodes d'évaluation des entreprises choisies[1907]. Il est également fréquent que ce type de document inclue une analyse fiscale détaillée du traitement et des conséquences de l'opération, et ce, dans toutes les juridictions impliquées.

408. Illustration : la vente d'un portefeuille de biens immobiliers. Une des méthodes régulièrement appliquées afin de structurer un investissement important dans un portefeuille composé d'actifs situés dans différents États membres est de procéder à une ségrégation des actifs, qu'il s'agisse soit directement des biens immobiliers, soit de sociétés *holding* locales, en fonction des États membres entre lesquels ils sont répartis. On se retrouvera généralement ainsi avec le fonds d'investissement tout en haut de la chaîne qui détiendra une société maîtresse, elle-même détenant les diverses sociétés *holding* intermédiaires détenant l'investissement dans les sociétés *holding* finales ou directement les biens immobiliers. Les sociétés *holding* intermédiaires sont généralement localisées dans des États membres jouissant d'un régime fiscal avantageux ou d'une réglementation libérale en matière de droit des sociétés facilitant les cessions d'actions. Outre le côté rationnel d'une telle organisation, celle-ci permet de céder un nombre important d'investissements situés dans un État membre en cédant simplement les actions de la société *holding* intermédiaire. Cependant, il peut arriver qu'un acquéreur potentiel ne souhaite acquérir qu'un investissement précis. Dans une telle hypothèse, il pourra être procédé à une scission partielle par constitution de nouvelle société de la société *holding* intermédiaire afin de transférer l'investissement cédé à une nouvelle entité intermédiaire en vue de sa cession ultérieure. Dans une telle hypothèse, la scission transfrontalière ne constituera qu'une étape parmi d'autres du processus repris dans un contrat de cession signé en amont de la restructuration[1908].

409. Le droit applicable à la phase préliminaire. Cette phase préliminaire, pourtant particulièrement fréquente en pratique, n'est visée ni par la Directive Sociétés, ni par la Directive Mobilité, ni par le régime des scissions du CSA, ni par le régime des scissions de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, peu important à cet égard qu'elle aboutisse à un quelconque protocole

1904 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 159, n°s 209 et 210.
1905 Th. TILQUIN, *ibidem*, p. 159, n° 209.
1906 J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 32, n° 62 et T. com. Nantes, 31 janvier 1974, *Gaz. Pal.*, 1974, 1, p. 433.
1907 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 159 et 160, n° 210.
1908 Pour un schéma illustrant l'utilité d'une scission transfrontalière dans le cadre de la vente d'un portefeuille de biens immobiliers, voir Annexe 1.

d'accord ou soit jalonnée d'autres documents contractuels. Il en résulte que cette période sera, dans le cadre d'une scission transfrontalière, régie par le droit commun[1909]. Les parties impliquées auront à tout le moins l'obligation de négocier de bonne foi[1910] et pourraient voir leur responsabilité engagée en cas de rupture abusive des pourparlers[1911]. Une telle responsabilité sera de nature délictuelle en droit belge[1912] et en droit luxembourgeois[1913], mais il n'en va pas nécessairement de même dans tous les États membres[1914] comme, à titre d'illustration, en Allemagne et en Autriche[1915]. En conséquence, le Règlement Rome II intègre une disposition spécifiquement destinée à résoudre les situations de conflit de lois engendrées par une *culpa in contrahendo* commise dans le cadre des négociations préliminaires[1916] et qui pourra dès lors s'appliquer également à l'hypothèse d'une opération de scission transfrontalière. Par conséquent, le droit applicable sera en principe celui qui aurait dû s'appliquer au contrat de scission[1917]. Cependant, comme ce dernier peut s'avérer particulièrement délicat à déterminer du fait des imbrications des différents droits nationaux impliqués, on peut considérer que le droit applicable sera (i) celui de l'État de la survenance du dommage[1918] ou (ii) celui de l'État dans lequel les parties ont leur résidence habituelle au moment de la survenance du fait générateur pour peu que les parties aient leur résidence habituelle dans le même État[1919] ou (iii) le droit de l'État avec lequel l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits[1920]. Si ce n'est pas nécessairement le cas, cette phase précontractuelle est parfois jalonnée de certains avant-contrats, comme par exemple des éventuelles garanties de passif consenties par les associés

1909 P. Van Ommeslaghe, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14.

1910 P. Ancel, *Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois – Approche comparative*, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 219, n° 173 ; O. Poelmans, *op. cit.*, p. 36, n° 21 ; G. Ravarani, *La responsabilité civile des personnes privées et publiques*, 3e éd., Luxembourg, Pasicrisie Luxembourgeoise, 2014, p. 506, n° 486 ; Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 160, n° 211 et P. Van Ommeslaghe, *Traité de droit civil belge*, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 536 et 537, n° 336.

1911 Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 160, n° 211.

1912 P. Van Ommeslaghe, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, pp. 536–538, n° 336.

1913 P. Ancel, *op. cit.*, pp. 219 et 220, n° 174 ; O. Poelmans, *op. cit.*, pp. 35 et 36, nos 20 et 21 et G. Ravarani, *op. cit.*, p. 506, n° 486 et C.A. Luxembourg, 13 février 2014, n° 38087 ; C.A. Luxembourg, 28 janvier 2004, n° 27591 et T.A. Luxembourg, 14 janvier 2002, *B.I.J.*, 2004/7, p. 119.

1914 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 sur la loi applicable aux obligatoires non contractuelles (« Rome II »), COM(2003) 427 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (07/11/2021), Exposé des motifs, p. 8, « [l]a ligne de partage entre obligations contractuelles et délictuelles n'est cependant pas identique dans tous les États membres et des doutes peuvent apparaître quant à l'application de tel ou tel instrument - la Convention de Rome ou le règlement proposé - à un litige donné, par exemple en matière de responsabilité précontractuelle, de culpa in contrahendo ou d'action paulienne ».

1915 À ce sujet, voir : P. Mankowski, « Die Qualifikation der culpa in contrahendo – Nagelprobe für den Vertragsbegriff des europäischen IZPR und IPR », *IPRax*, 2003, pp. 132 et 133 et C. Tubeuf, « Enrichissement sans cause, gestion d'affaires et "*culpa in contrahendo*" », *RDC-TBH*, 2006/8, p. 540, n° 24.

1916 Art. 1 et 2, § 1er du Règlement (CE) 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), *J.O.*, L 199, 31 juillet 2007, pp. 73–82 (ci-après le « **Règlement Rome II** »).

1917 Art. 12, § 1er du Règlement Rome II.

1918 Art. 12, § 2, a) du Règlement Rome II.

1919 Art. 12, § 2, b) du Règlement Rome II.

1920 Art. 12, § 2, c) du Règlement Rome II.

en présence[1921], un accord de confidentialité formel, une lettre d'intention ou encore une obligation de négociation de bonne foi en vue de parvenir à la réalisation de l'opération[1922]. Dans l'hypothèse particulière d'une scission transfrontalière, la question du droit applicable à ces contrats préliminaires sera en principe réglée par les dispositions du Règlement Rome I[1923]. Il s'ensuit que les parties auront en principe le choix du droit applicable à leur convention[1924], et, en pratique, de telles clauses seront fréquentes. À défaut de choix, le droit applicable devra être déterminé au cas par cas en appliquant les règles par défaut. Le contrat sera par conséquent régi par le droit de l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle[1925], sauf si (i) le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre État[1926] ou si (ii) ce facteur de rattachement ne permet pas de déterminer le droit applicable, auquel cas on appliquera le droit de l'État avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits[1927].

410. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. Compte tenu du caractère foncièrement hétérogène des différents documents susceptibles de jalonner cette période préliminaire, il n'est pas utile de la couvrir dans un régime général des scissions transfrontalières.

SECTION 3. LE PROJET COMMUN DE SCISSION

411. Plan de la section 3. Pour pleinement saisir les enjeux gravitant autour de l'étape fondamentale du processus de scission transfrontalière que constitue l'établissement du projet commun, il convient de procéder en sept étapes, à savoir (i) déterminer l'organe compétent (§ 1), (ii) identifier les objectifs que le projet commun entend remplir (§ 2), (iii) préciser une caractéristique essentielle du projet de scission (§ 3), (iv) clarifier sa nature juridique (§ 4), (v) analyser les exigences de forme s'y appliquant (§ 5), (vi) déterminer son régime linguistique (§ 6) et, en définitive, (vii) détailler méthodiquement son contenu (§ 7).

§ 1. L'organe compétent

412. La compétence de principe de l'organe d'administration ou de direction. Le projet commun de scission doit en principe être établi par les organes d'administration ou de direction des sociétés participant à l'opération[1928].

1921 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 161 et 162, n° 212.
1922 P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge, op. cit.*, p. 538, n° 336.
1923 Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), *J.O.*, L 177, 4 juillet 2008, pp. 6–16 (ci-après le « **Règlement Rome I** »).
1924 Art. 3 du Règlement Rome I.
1925 Art. 4, § 2 du Règlement Rome I.
1926 Art. 4, § 3 du Règlement Rome I.
1927 Art. 4, § 4 du Règlement Rome I.
1928 Art. 137, § 1er de la Directive Sociétés (scissions internes) et art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité. Voir également art. 12:59 et 12:75 du CSA et art. 1031-1, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Si une des sociétés impliquées s'avère faire l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou de toute autre procédure analogue, l'établissement du projet commun de scission incombera alors au curateur ou au liquidateur[1929], pour peu que tous les États membres impliqués aient fait le choix d'ouvrir la scission aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une procédure analogue[1930].

413. Une application distributive des différentes *lex societatis* en présence. En tout état de cause, l'organe compétent pour établir le projet commun de scission sera déterminé, comme dans le cas d'une fusion transfrontalière[1931], par le droit national de chaque société en présence. Cette application distributive se justifie par le fait que le processus de décision au sein des diverses sociétés n'intéresse que l'ordre interne de celles-ci et ne nécessite pas de traitement unitaire. Ce principe est cependant source de complexités additionnelles en pratique dans la mesure où certaines autorités administratives, comme le registre des sociétés autrichien en matière de fusions transfrontalières[1932], ont pris l'habitude de demander une preuve, sous forme d'extrait ou de certificat, du pouvoir de représentation des membres de l'organe de direction ou de surveillance de l'entité étrangère impliquée.

414. Le cas particulier de la scission par constitution de nouvelle société. Si la détermination de l'organe compétent pour l'établissement du projet commun de scission ne pose pas de problématique particulière dans le cadre d'une scission par absorption, certaines interrogations sont susceptibles de se poser dans le cadre d'une scission impliquant la constitution d'au moins une nouvelle société. Ainsi, dans une telle hypothèse, il aurait pu être défendu que l'établissement du projet commun de scission devait être considéré comme un acte de la société en formation. Cependant, cette interprétation se heurte à l'argument de texte de la Directive Sociétés[1933] selon lequel seules les sociétés participant à l'opération doivent établir le projet de scission. Or, la nouvelle société ne participe pas à l'opération de sorte qu'elle ne contribue pas à l'élaboration du projet commun de scission[1934]. Ce point a été confirmé par le législateur européen dans la Directive Mobilité puisqu'il y est explicitement prévu que le projet de scission sera établi par l'organe d'administration ou de direction de la société scindée[1935].

1929 Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 177, n° 233.
1930 Art. 87, § 3 et 135, § 4 de la Directive Sociétés et art. 160*bis*, §§ 4 et 5 de la Directive Mobilité. Sur le champ d'application limité de la Directive Mobilité à cet égard, voir *supra* : Première partie, Titre IV, Section 2, § 3, A., 2.
1931 N. Adensamer et G. Eckert, « Das Kollisionsrecht der grenzüberschreitenden Verschmelzung (Teil I) », *GeS*, 2007, p. 95 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 202.
1932 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 202.
1933 Art. 137, § 1er de la Directive Sociétés.
1934 E. Roelofs, *op. cit.*, p. 393 et Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 176 et 177, n° 232.
1935 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.

§ 2. Les objectifs du projet de scission

415. Un triple objectif. Le projet de scission, tout comme un projet de fusion interne ou transfrontalière, poursuit trois objectifs distincts[1936]. Il a ainsi avant toute autre chose, pour but de mettre fin à la période de négociations préliminaires et d'entamer le processus de scission. Il matérialise au sein d'un document qui servira de pierre angulaire à l'ensemble de la procédure de scission l'issue des tractations préliminaires entre parties et fixe les grands principes de l'opération[1937]. Au-delà de ce premier objectif, le projet de scission va également servir à l'information des différents *stakeholders* potentiellement impactés par la restructuration que sont, notamment, les créanciers[1938], les associés minoritaires[1939] et les travailleurs[1940]. Finalement, le projet de scission va servir de base à quatre autres étapes composant le processus de scission, à savoir le ou les rapports de l'organe d'administration ou de direction[1941], le rapport d'expert indépendant[1942], la délibération de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission[1943] et le double contrôle de légalité[1944].

§ 3. Une caractéristique essentielle

416. Un caractère nécessairement commun. En matière fusions transfrontalières[1945], la formulation même de la Directive Sociétés incite à attribuer un caractère d'unicité à ce projet et il devra en être de même en cas de scission transfrontalière. En effet, bien que le terme « commun » présent dans législation sur les fusions transfrontalières[1946] n'apparaisse pas dans la législation relative aux scissions internes[1947], l'emploi exclusif du singulier à l'égard du projet de scission ne peut qu'être révélateur de son caractère unique et commun. De plus, il serait difficilement concevable qu'un document aussi fondamental à un processus de restructuration soit commun dans l'hypothèse d'une fusion transfrontalière et individuel dans le cas d'une scission transfrontalière, même si en

1936 Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 311 ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n°s 4 et 5 ; Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 174, n° 227 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.

1937 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 1 et Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 4.

1938 Sur les enjeux des scissions transfrontalières pour les créanciers, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I.

1939 Sur les enjeux des scissions transfrontalières pour les associés minoritaires, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1.

1940 Sur les enjeux des scissions transfrontalières pour les travailleurs, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2.

1941 À ce sujet, voir *infra* n°s 529 à 560.

1942 À ce sujet, voir *infra* n°s 561 à 589.

1943 À ce sujet, voir *infra* n°s 617 à 638.

1944 À ce sujet, voir *infra* n°s 639 à 661.

1945 H. KALLMEYER, « Der gemeinsame Verschmelzungsplan für grenzüberschreitende Verschmelzungen », *AG*, 2007, p. 473.

1946 Art. 122 de la Directive Sociétés.

1947 Art. 137 de la Directive Sociétés.

raison de son champ d'application limité[1948], cette précision est actuellement absente du régime des scissions transfrontalières de la Directive Mobilité[1949].

417. Une nécessaire identité des termes. Cependant, au-delà de cet aspect commun, il convient de considérer que le projet de scission transfrontalière doit nécessairement être rédigé dans des termes identiques pour toutes les sociétés impliquées. Tout d'abord, une opération de scission, malgré la présence d'une pluralité de sociétés bénéficiaires, constitue un ensemble d'éléments indissociables et interconnectés de sorte que les assemblées générales des sociétés impliquées devront se prononcer sur l'intégralité de ces aspects[1950]. Il est donc exclu de recourir à un projet de scission ne reprenant qu'une partie des informations, comme un projet soumis à l'assemblée générale d'une des sociétés bénéficiaires ne contenant que les seules informations pertinentes pour celle-ci[1951]. Ensuite, au niveau des fusions transfrontalières, il ressort clairement de la Directive Sociétés[1952], et il serait difficilement concevable qu'il puisse en être autrement dans le cadre d'une scission transfrontalière, que le contenu du projet de scission doit aller au-delà d'une simple correspondance des termes et être identique pour toutes les sociétés en présence. Cette exigence s'explique fondamentalement par la nature contractuelle d'une opération de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante[1953] étant donné que celle-ci requiert un accord de toutes les sociétés impliquées sur des termes identiques.

§4. La nature juridique du projet commun de scission

418. Une nature juridique incertaine. En l'absence d'indication précise à ce sujet dans la Directive Sociétés[1954] et dans la Directive Mobilité, la nature juridique du projet de scission est, à l'instar de celle du projet commun de fusion, incertaine et susceptible de varier en fonction des différents ordres juridiques au sein de l'Union européenne[1955]. Le terme de projet, apparaissant pour la première fois dans la Troisième Directive[1956], avait par ailleurs été choisi pour sa neutralité en raison de fortes divergences existant au sein des États membres quant à la nature de l'accord auquel parviennent les différents

1948 À ce sujet, voir *supra* n°s 341 à 346.
1949 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.
1950 Voir en ce sens à propos des scissions internes : M. Heidenhain, « Spaltungsvertrag und Spaltungsplan », *NJW*, 1995, p. 2873 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 9. Voir également en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 5.
1951 Voir en ce sens à propos des scissions internes : H.-J. Priester in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 8 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard, *ibidem*, § 126, n° 9.
1952 57e considérant de la Directive Sociétés.
1953 À ce sujet, voir *supra* n°s 85 à 95.
1954 À ce sujet, voir : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 3.
1955 P. Van Ommeslaghe, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14 et D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.
1956 Art. 5, § 1er de la Troisième Directive.

organes de direction ou d'administration des sociétés impliquées[1957]. En effet, la Commission européenne a eu tôt fait de constater que le document préparé par les différents organes d'administration ou de gestion pouvait, en fonction des législations nationales, être considéré comme un contrat conclu avant l'approbation de l'opération par les assemblées générales, un simple projet de contrat à établir avant les assemblées générales, un contrat ne pouvant être conclu qu'après approbation en bonne et due forme de l'opération par les assemblées générales ou encore un document dénué de tout effet juridique[1958]. Si des divergences de conceptions à cet égard ne posent pas de difficultés dans l'hypothèse d'une opération purement interne, il en va autrement dans le cas d'une scission transfrontalière où la nature, contractuelle ou non, du projet est susceptible d'avoir des conséquences sur les règles de droit international privé qui lui seraient éventuellement applicables.

419. Un contrat issu du processus de négociations. Il pourrait ainsi être avancé, à l'instar de ce qui a été fait pour les fusions transfrontalières[1959], que le projet de scission, en ce qu'il est l'aboutissement des négociations conduites entre les organes d'administration ou de direction des sociétés impliquées et représente un accord de volontés entre les différentes entités parties à l'opération ne peut être autre chose qu'un contrat liant les sociétés impliquées. Cette conception, identique à celle du droit suisse qui fait par ailleurs expressément l'économie du terme de projet au profit de la notion de contrat[1960], justifie notamment la solution originale en droit international privé suisse qui veut que, dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, le contrat de scission, bien que devant nécessairement respecter les dispositions impératives de la *lex societatis* de chaque entité participant à l'opération, soit régi par le droit choisi par les parties[1961]. À défaut de choix, le contrat de scission sera régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits, celui-ci étant présumé être celui de la société qui se scinde[1962].

420. Un acte juridique organisationnel sans valeur contractuelle. Cependant, il est généralement considéré que le projet commun de fusion transfrontalière ne constitue pas un contrat[1963] et qu'il ne saurait en tout état de cause servir

[1957] Proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, § 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes du 12 juin 1970, Com (1970) 633, http://publications.europa.eu, p. 23.

[1958] Proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, § 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes du 12 juin 1970, Com (1970) 633, http://publications.europa.eu, p. 23.

[1959] Fr. BEHRENS, *op. cit.*, pp. 65 et 66 ; H.-G. KOPPENSTEINER, « Zur grenzüberschreitenden Verschmelzung », *op. cit.*, p. 40 ; N. KRAUSE et N. KULPA, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen – Vor dem Hintergrund der SEVIC-Entscheidung und der Reform des deutschen Umwandlungsrecht », *ZHR 171*, 2007, p. 38 et H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Richtlinienentwurf der EU-Kommission », *ZIP*, 2004, p. 1790.

[1960] Art. 12 de la Loi suisse sur les fusions et scissions.

[1961] Art. 163c, § 2 et 163d, § 3 de la Loi suisse sur le droit international privé.

[1962] Art. 163c, § 2 et 163d, § 3 de la Loi suisse sur le droit international privé.

[1963] W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 3 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 158 et 159 ; H. KALLMEYER, *op. cit.*, pp. 473 et 474 ; S. MAQUET, *op. cit.*, p. 35 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.),

de base à une action en justice[1964]. Compte tenu du fort lien de parenté entre fusions et scissions[1965], il devrait en être de même du projet de scission transfrontalière. En effet, le projet de scission en tant que tel est l'aboutissement d'un processus de négociations entre des organes n'ayant pas la capacité d'engager les sociétés, que ce soit quant au principe de la scission ou quant à ses modalités[1966]. De plus, le fait de considérer que le projet pourrait avoir une nature contractuelle semble en contradiction avec les termes de la Directive Sociétés dans la mesure où, bien qu'uniquement au sujet des fusions internes, cette dernière opère une distinction claire entre le projet de fusion qui est établi par les organes de direction ou d'administration des entités impliquées qui est antérieur aux assemblées générales[1967] et le contrat de fusion qui, pour sa part, est nécessairement postérieur aux assemblées générales[1968]. L'exclusion de la nature contractuelle est par ailleurs également confortée par une comparaison entre le texte de la Directive Sociétés relatif au projet commun de fusion transfrontalière où il n'est pas fait mention d'un contrat de fusion[1969] et celui du projet de convention sur la fusion internationale de sociétés anonymes du 20 décembre 1972 où il est expressément prévu que si la législation d'un des États membres impliqués impose la rédaction d'un contrat de fusion, celui-ci tiendra lieu de projet de fusion[1970]. Si le projet de convention a finalement été abandonné en 1980 suite à son incapacité à être adopté par les États membres[1971], il en découle toutefois que dans l'esprit du législateur européen, le choix du terme projet au lieu de contrat n'est pas anodin et que les deux ne sont en aucun cas à mettre sur un pied d'égalité[1972]. En revanche, il est indéniable que le projet commun a, à tout le moins, une fonction organisationnelle[1973] dans la mesure où il a vocation à servir de base à l'opération de scission et à en établir les aspects jugés les plus fondamentaux.

op. cit., § 122c, n° 4 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, pp. 203 et s. ; P. Van Ommeslaghe, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14 et M. Wyckaert, « Grensoverschrijdende fusies », *op. cit.*, p. 97.

1964 P. Van Ommeslaghe, *ibidem*, p. 14.

1965 Voir en ce sens : L. Athlan et St. Torck, *op. cit.*, p. 1 ; H. Le Nabasque, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. Lamon, *op. cit.*, p. 125 et Th. Prüm, *ibidem*, p. 16 ; A. Reik, *op. cit.*, p. 300 ; E. Roelofs, *op. cit.*, p. 347 ; J. Schmeidler, *op. cit.*, p. 6, n° 9 ; J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27 et Chr. Teichmann, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 13.

1966 Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, pp. 174 et 175, n° 228.

1967 Art. 91, § 1er de la Directive Sociétés.

1968 Art. 102, § 1er de la Directive Sociétés.

1969 Art. 122, § 1er de la Directive Sociétés.

1970 Projet de convention sur la fusion internationale de sociétés anonymes, *Bulletin des Communautés européennes*, suppl. 13/73.

1971 D. Beutel, *op. cit.*, p. 107 ; M. Frischhut, « Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften – ein Überblick über die Zehnte gesellschaftsrechtliche Richtlinie », *EWS*, 2006, p. 56 ; H.-G. Koppensteiner, « Grundlagenkritische Bemerkungen zum EWG-Entwurf eines Übereinkommens über die internationale Verschmelzung von Aktiengesellschaften », *RabelsZ*, 1975, p. 408 ; U. Lennerz, *op. cit.*, p. 21 et H.-W. Neye, *op. cit.*, p. 1893.

1972 Voir en ce sens : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 3 ; R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 4 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 211 et S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 162.

1973 D. Beutel, *op. cit.*, p. 158 ; U. Lennerz, *op. cit.*, p. 193 ; S. Maquet, *op. cit.*, p. 35 ; J. Mitterecker, *ibidem*, pp. 212 et 213 et Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 174, n° 227.

421. Des effets juridiques limités. Cependant, le projet commun de scission en lui-même n'en est pas pour autant dénué d'effets juridiques dans la mesure où, d'une part, il emporte néanmoins une obligation de poursuivre de bonne foi le processus de scission afin d'aboutir à la réalisation de celle-ci[1974] et, d'autre part, il contraint les organes compétents pour l'établir à le soumettre à l'assemblée générale[1975]. Il a été avancé que le projet commun de fusion transfrontalière équivalait à un ensemble de résolutions des différents organes de direction ou d'administration par lesquelles ceux-ci approuvaient de manière contraignante le projet de fusion[1976]. Cette conception est confortée par le fait que les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société scindée pourront, en tout état de cause, voir leur responsabilité engagée par les associés de la société scindée pour les fautes commises par ceux-ci dans le cadre de la préparation et de la réalisation de la scission[1977], ce qui inclut nécessairement les fautes commises dans le cadre de l'établissement du projet commun[1978].

422. Des engagements contractuels accessoires. Au-delà de cette nature intrinsèque, il est, malgré tout, loisible aux différents organes de direction ou d'administration des sociétés impliquées de faire figurer certaines obligations contractuelles dans le projet commun de scission[1979]. En effet, il ressort clairement du texte tant de la Directive Sociétés à l'égard des scissions internes[1980], des fusions internes[1981] et des fusions transfrontalières[1982] que de la Directive Mobilité à l'égard des transformations[1983] et des scissions[1984] transfrontalières, que les différents organes de gestion chargés d'établir le projet commun peuvent le compléter comme bon leur semble[1985]. Il serait dès lors

1974 S. MAQUET, *ibidem*, p. 35 et P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14.

1975 P. NICAISE, « La procédure et le rôle des conseils d'administration » in *Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés*, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 96 ; Fl. PARREIN, « De wet van 8 juni 2008 en de grensoverschrijdende fusie », *RW*, 23 octobre 2010, n° 8, p. 312 et M. WYCKAERT, « Grensoverschrijdende fusies – De procedurele kant », in *Grensoverschrijdende fusies zjn een feit*, Bruxelles, Knops Publishing, 2009, p. 57, n° 7.

1976 H. KALLMEYER, *op. cit.*, p. 474.

1977 Art. 152 de la Directive Sociétés.

1978 P. NICAISE, *op. cit.*, p. 97.

1979 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 159 ; H. KALLMEYER, *op. cit.*, p. 159 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 4 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 213.

1980 Art. 137, § 2 de la Directive Sociétés.

1981 Art. 91, § 2 de la Directive Sociétés.

1982 Art. 122 de la Directive Sociétés.

1983 Art. 86*quinquies* de la Directive Mobilité.

1984 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.

1985 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 402 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 162 et 163 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 11 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung inländischer Gesellschaften nach Erlass der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in Europa », *RIW*, 2006, p. 83 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n°s 853 et 856 ; S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 796 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 231 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 256 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 33, n° 67 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 313 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 394 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 188 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 31 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 15 et Ch. VERDURE, *op. cit.*, p. 114.

envisageable qu'un projet de scission transfrontalière contienne également une clause d'indemnisation à charge d'une partie à l'égard des autres en cas d'échec de l'opération dû à une faute de celle-ci ou encore un engagement de confidentialité assorti d'une clause pénale. De tels engagements auront indéniablement une valeur contractuelle pour les sociétés impliquées, mais il convient malgré tout de préciser qu'ils ne seront en pratique que très rarement intégrés dans le projet commun étant donné que celui-ci doit faire l'objet d'une publication[1986] et que les organes de gestion concernés préféreront généralement préserver une certaine confidentialité.

§5. La forme du projet commun de scission

423. Plan du § 5. Afin de clarifier la forme que devra revêtir le projet commun de scission transfrontalière, il convient de partir des exigences minimales posées par la Directive Sociétés (A) et de la diversité des normes au sein des États membres qui en est résulté (B), pour ensuite étudier la règle de conflit de lois applicable en la matière (C) et établir en quoi celle-ci ne fait pas l'unanimité (D). Pour finir, il sera intéressant de s'arrêter sur le cas particulier de la scission par constitution de nouvelles sociétés (E).

A. *Les exigences minimales de la Directive Sociétés*

424. Un projet écrit. De manière surprenante, la Directive Sociétés ne contient que très peu d'indications quant à la forme du projet de scission interne. Ainsi, la seule exigence générale est, à l'instar de ce qui est prévu pour une fusion interne[1987], celle d'un écrit[1988]. Celui-ci ne devra obligatoirement revêtir la forme d'un acte authentique que dans le cas particulier où (i) les États membres n'auront pas prévu de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité portant sur tous les aspects de l'opération et (ii) l'opération ne doit pas faire l'objet d'une approbation de la part des assemblées générales de toutes les sociétés impliquées[1989]. Les dispositions relatives aux fusions transfrontalières de la Directive Sociétés[1990] et les dispositions relatives aux scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[1991] ne contiennent, quant à elles, aucune exigence explicite de ce type. Cependant, il est généralement déduit de l'exigence subséquente de publication du projet que celui-ci doit nécessairement également être à tout le moins écrit[1992]. Cette interprétation est par ailleurs confortée tant (i) par la règle de conflit de lois posée par la Directive Sociétés à l'égard des fusions transfrontalières et qui veut qu'en l'absence

1986 Art. 92 ; 123 et 138 de la Directive Sociétés.
1987 Art. 137, § 1er de la Directive Sociétés.
1988 Art. 91, § 1er de la Directive Sociétés.
1989 Art. 102, § 1er et 148 de la Directive Sociétés.
1990 Art. 122 de la Directive Sociétés.
1991 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.
1992 Voir en ce sens : D. Beutel, *op. cit.*, p. 159. Voir également en ce sens à propos du régime des scissions transfrontalières instauré par la Directive Mobilité : F. Bernard, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 14.

de dispositions spécifiques aux fusions transfrontalières, l'opération soit régie pour chaque société impliquée par les dispositions applicables à une fusion interne[1993] que (ii) par la règle de conflit de lois posée par la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés et qui veut que le droit de l'État membre de la société scindée régisse les parties des procédures et formalités à respecter en vue de l'obtention du certificat préalable à la scission[1994]. Il y a lieu de considérer que, par analogie, cette exigence minimale doit également s'appliquer aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

425. Le silence des directives. Au-delà de cette première exigence, la Directive Sociétés est muette. Ce silence aurait pu être interprété comme une interdiction faite aux États membres d'imposer une forme plus contraignante que celle d'un simple écrit et ce point a fait l'objet de quelques discussions en doctrine au sujet des fusions transfrontalières[1995]. Cependant, il ressort clairement de l'analyse des dispositions de la Directive Sociétés relatives aux scissions internes que le législateur européen avait pour objectif non pas de fixer un cadre légal exhaustif, mais de prévoir une harmonisation minimale des opérations de scission à partir du moment où un État membre avait fait le choix de reconnaître ce type de restructuration. Cette interprétation, conforme à la méthode de réglementation particulière que représente une directive[1996], se voit aisément au niveau des nombreuses options législatives laissées aux États membres où le législateur européen s'est contenté de fixer des exigences minimales, comme au niveau de la protection des créanciers[1997] ou encore au sujet du contenu du projet commun de scission[1998]. Comme la Directive Mobilité n'apporte pas de précisions additionnelles à ce sujet, que ce soit à l'égard des fusions transfrontalières[1999] ou des scissions transfrontalières[2000], il conviendra de s'en remettre aux différents droits nationaux concernés dans le cas d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante.

B. *Une certaine diversité au sein des États membres*

426. Acte notarié ou acte sous seing privé. Compte tenu du caractère limité des dispositions de la Directive Sociétés à l'égard des scissions internes, il n'est pas surprenant de constater que les États membres aient imposé des exigences divergentes à ce sujet. Ainsi, dans le cadre d'une scission interne, le droit belge[2001] et le droit luxembourgeois[2002] laissent le choix entre un acte notarié ou

1993 56e considérant et art. 121, § 1er de la Directive Sociétés et en ce J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 220.
1994 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.
1995 D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 159 et 160 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, pp. 227 et 228 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 218–220.
1996 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 160.
1997 Art. 146, § 2 de la Directive Sociétés.
1998 Art. 137, § 2 de la Directive Sociétés.
1999 Art. 122 de la Directive Sociétés.
2000 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.
2001 Art. 12:59 et 12:75 du CSA.
2002 Art. 1031-1 et 1032-1 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

un acte sous seing privé, le droit français n'impose la forme d'un acte authentique que lorsque des immeubles ou des droits immobiliers seront transmis par l'effet de l'opération[2003], le droit allemand[2004] impose un acte notarié et le droit autrichien laisse le choix entre un acte sous seing privé et un acte notarié, ce dernier n'étant requis que lorsque des parts d'une société sont transmises dans le cadre de l'opération[2005]. Si ces divergences de forme ne posent pas de problème dans le cadre d'une scission interne, il reste toutefois à déterminer la règle qu'il conviendra d'appliquer dans le cas d'une opération transfrontalière mettant en concurrence des législations contradictoires.

C. *La règle de conflit de lois applicable*

427. L'incidence du caractère commun. Le projet de scission transfrontalière étant par essence commun, la détermination de sa forme requerra, à l'instar d'un projet commun de fusion transfrontalière[2006], en principe un traitement unitaire[2007]. Ce point ne ressort pas de la Directive Mobilité[2008], mais cela s'explique aisément par le fait qu'elle ne couvre que les opérations par constitution de nouvelles sociétés[2009]. Face à ce constat, il conviendra dès lors de recourir à une application cumulative des différentes *lex societatis* en présence, tout en privilégiant la règle la plus sévère, comme dans le cas d'un projet commun de fusion transfrontalière[2010]. Par conséquent, il suffit que la législation d'un seul des États membres impliqués dans l'opération impose la forme notariée pour que celle-ci s'impose face aux actes sous seing privé. Cette solution a par ailleurs l'avantage d'une certaine cohérence historique dans la mesure où elle correspond au prescrit du projet de convention de 1973[2011] et de la proposition de dixième directive de 1985[2012] qui prévoyaient toutes deux que le projet de fusion transfrontalière devait être passé par acte authentique lorsque la législation nationale d'une des sociétés impliquées l'exigeait.

2003 Art. L. 236-6 du Code de commerce français et à ce sujet : J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 33, n° 65.
2004 §§ 6 et 125 UmwG.
2005 § 2 SpaltG qui ne mentionne aucune exigence de forme et à ce sujet : S. Kalss in S. Kalss (dir.), *op. cit.*, p. 804, n° 11.
2006 D. Beutel, *op. cit.*, p. 18 ; H. Kallmeyer, *op. cit.*, p. 474 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 224 et Th. Tilquin et J.-A. Delcorde, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 46.
2007 E. Roelofs, *op. cit.*, pp. 397 et 398.
2008 Conformément à la règle de droit international privé posée par la Directive Mobilité, la forme du projet de scission transfrontalière sera déterminée par la législation applicable à la société scindée. Voir art. 160*quater* de la Directive Mobilité.
2009 Art. 160*ter* de la Directive Mobilité.
2010 W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 7 ; D. Beutel, *op. cit.*, p. 161 ; M. Evrard et E. van der Vaeren, *op. cit.*, p. 114 ; St. Klein, *op. cit.*, p. 584 ; R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n°s 43 et 44 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 224. ; Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 546, n° 759 et Ch. Verdure, *op. cit.*, pp. 115 et 116.
2011 Art. 7, § 2 du projet de convention sur la fusion internationale de sociétés anonymes, *Bulletin des Communautés européennes*, suppl. 13/73.
2012 Art. 5, § 2 de la proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, COM (84) 727 final du 14 décembre 1984, présentée par la Commission au Conseil le 14 janvier 1985, *J.O.*, n°C 23/11.

428. Une économie d'actes notariés dans certaines circonstances. Une application stricte de cette règle de conflit de lois est cependant susceptible d'entraîner la nécessité d'établir autant d'actes notariés qu'il y a de *lex societatis* impliquées dans l'opération qui imposent la formalité d'un acte notarié. Une telle rigueur n'irait toutefois pas sans entraîner un certain coût, ni potentiellement retarder la réalisation de l'opération. Ceci explique pourquoi, dans le cadre des fusions transfrontalières[2013], il est généralement considéré qu'à partir du moment où le projet commun doit être établi sous forme authentique, les parties pourront choisir l'État membre dans lequel elles souhaitent l'établir. Ce point doit toutefois être nuancé par la condition que l'acte notarié établi dans un des États membres soit considéré, dans le chef des autres États membres, comme équivalant à un acte notarié interne[2014]. Ce point est loin d'être anodin dans la mesure où en Allemagne, les actes notariés étrangers établis dans le cadre d'un processus de restructuration ne sont pas considérés comme équivalents aux actes notariés internes[2015]. Cette différence de traitement est justifiée par le fait que l'établissement d'un acte notarié intéresse l'ordre public dans la mesure où en l'établissant, le notaire vérifie la conformité du procédé au droit en vigueur[2016]. En application de cette logique, un acte notarié étranger ne pourrait être acceptable que si le notaire étranger a reçu une formation en droit allemand équivalente à celle d'un notaire allemand et si le procédé relatif à l'établissement de l'acte notarié offre les mêmes garanties. Cet exercice de comparaison va même jusqu'à impliquer la nécessité de vérifier l'équivalence des régimes de responsabilité professionnelle[2017]. Il est dès lors pratiquement impossible qu'un acte étranger puisse remplacer un acte notarié allemand[2018]. De plus, ce régime strict d'équivalence des actes notariés n'est pas limité au droit allemand et a également cours en droit autrichien[2019]. Il s'ensuit que les parties à une opération de scission transfrontalière pourraient, si elles n'ont pas pris soin d'examiner cette question à l'avance, se retrouver dans la situation où elles devraient établir le projet commun de scission sous forme de plusieurs actes notariés, ce qui ne manquera pas de retarder le processus et d'engendrer des coûts additionnels[2020]. Ainsi, dans le cadre de la préparation de l'opération, les parties impliquées seraient bien avisées de vérifier les exigences relatives à l'équivalence des actes notariés dans les différents États membres impliqués,

2013 J.-A. DELCORDE et Th. TILQUIN, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 66 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 114 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 311 ; S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 796 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.

2014 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 8 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 170–175 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 224.

2015 S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 796 ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 6, n° 16 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 6, n° 11 et BGH, Beschluss vom 24.10.1988 (II ZB 7/88), *BGHZ 105*, 1989, pp. 341 et s.

2016 N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 6, n° 11 et BGH, Beschluss vom 24.10.1988 (II ZB 7/88), *BGHZ 105*, 1989, pp. 341 et s.

2017 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 226 ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 6, n° 17 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 6, n° 11.

2018 St. KLEIN, *op. cit.*, p. 565 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 227.

2019 J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 227.

2020 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 8.

tout en privilégiant la législation nationale la plus stricte et, au besoin, en multipliant les actes notariés.

429. Une solution suboptimale. Cette solution qui consiste à devoir, le cas échéant, établir plusieurs actes notariés en fonction des États membres impliqués dans l'opération est clairement suboptimale au niveau des coûts et des retards engendrés, *a fortiori* dans le cadre d'une cession transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante puisque le nombre d'états membres impliqués et, par ricochet, le nombre d'actes notariés nécessaires risque d'être élevé. Cependant, autoriser les parties à l'opération à choisir l'État membre dans lequel ils établiraient le projet de scission sous forme d'acte notarié ne serait certainement pas politiquement acceptable à l'heure actuelle et explique notamment pourquoi la Directive Mobilité ne contient aucune règle spécifique à ce sujet à l'égard du projet commun de fusion transfrontalière.

D. *Une règle de conflit de lois qui ne fait pas l'unanimité*

430. La question de la contrariété à la liberté d'établissement. Il a été avancé par certains auteurs que le fait d'imposer des exigences de formes plus strictes pour le projet commun dans le cadre d'une opération transfrontalière constituait une entrave à la liberté d'établissement de la société dont la *lex societatis* impose des conditions de forme moins strictes dans la mesure où les opérations transfrontalières s'en trouveraient discriminées par rapport aux opérations internes[2021]. Une telle argumentation a été rejetée dans le cadre des fusions transfrontalières[2022] en raison du fait que cette entrave découle de l'application de la *lex societatis* d'une des sociétés impliquées et que l'application de celle-ci découle du texte même de la Directive Sociétés[2023]. Étant donné que la règle en vertu de laquelle chaque opération de restructuration reste en principe soumise aux exigences de sa propre *lex societatis* sauf pour ce qui est de ses aspects plus proprement transfrontaliers devrait également s'appliquer aux scissions transfrontalières[2024], ne fût-ce que par cohérence avec le régime des fusions transfrontalières dont elles sont très proches[2025], la solution doit être identique dans le cadre d'une scission transfrontalière.

431. La primauté de la norme la plus sévère. Sur la base du constat qu'une application stricte de la règle de conflit de lois prônant la primauté de la norme la plus sévère est susceptible de complexifier considérablement l'opération, il a été avancé que les exigences de forme des différentes *lex societatis* relatives au projet de scission devaient faire l'objet d'une application purement distributive[2026]. Une telle application se justifierait notamment en raison du fait que les exigences de forme applicables aux autres étapes du processus de scission

2021 H. Kallmeyer, *op. cit.*, p. 474 et H. Kallmeyer et St. Kappes, *op. cit.*, p. 230.
2022 D. Beutel, *op. cit.*, p. 129.
2023 Art. 121, § 1er, lit. b de la Directive Sociétés.
2024 À ce sujet, voir *supra* n° 314. Voir également : art. 160*quater* de la Directive Mobilité.
2025 L. Athlan et St. Torck, *op. cit.*, p. 1 ; H. Le Nabasque, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. Lamon, *op. cit.*, p. 125 ; Th. Prüm, *op. cit.*, p. 16 ; A. Reik, *op. cit.*, p. 300 ; E. Roelofs, *op. cit.*, p. 347 et J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27.
2026 Th. Prüm, *op. cit.*, p. 83.

transfrontalière, comme par exemple les décisions des assemblées générales, sont appliquées de manière distributive[2027]. Afin d'éviter une multiplication des actes notariés lorsque la *lex societatis* de chacune des sociétés impliquées requiert cette forme, il est recommandé de recourir à la méthode de la substitution qui consiste à vérifier si les actes notariés sont interchangeables[2028]. En d'autres termes, si une application distributive des normes en conflit requérait en principe l'établissement de plusieurs actes notariés, mais qu'un acte notarié établi dans un des États membres impliqués est reconnu comme équivalent par les autres, il suffira d'établir ce seul acte pour remplir toutes les exigences de forme. Cette théorie n'est toutefois pas satisfaisante. En effet, elle méconnaît le caractère commun du projet de scission qui s'oppose à une application par analogie de la règle de droit international privé relative à la forme du procès-verbal des assemblées générales se prononçant sur l'opération. En effet, dans ce dernier cas, chaque société doit en principe tenir sa propre assemblée générale de sorte qu'une application distributive est pleinement justifiée, alors que l'établissement du projet de scission requiert une collaboration internationale entre les différentes entités impliquées[2029], justifiant par conséquent un traitement unitaire[2030] qui ne peut être atteint qu'en privilégiant la norme la plus sévère[2031].

E. *Le cas particulier de la scission par constitution de nouvelles sociétés*

432. Les exigences de forme de la *lex societatis* de la nouvelle société. Il reste toutefois encore à clarifier la solution qu'il convient d'adopter dans l'hypothèse particulière d'une scission transfrontalière par constitution d'une ou de plusieurs nouvelles sociétés et où seule la *lex societatis* de la ou des nouvelles sociétés impose la forme notariée. Ce sera par exemple le cas de la scission d'une société luxembourgeoise au profit de deux nouvelles sociétés allemandes. Toute la difficulté dans ce type d'opération viendra du fait qu'une nouvelle société issue d'une scission n'est pas partie à l'opération[2032] et n'est dès lors pas visée par l'obligation d'établissement du projet commun de scission[2033]. Cette interprétation ressort clairement du texte de la Directive Sociétés qui, dans l'hypothèse de la scission interne par constitution de nouvelles sociétés exclut explicitement les sociétés nouvellement créées des sociétés participant à la scission[2034]. Il en découle que les formalités particulières relatives à

2027 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 83.
2028 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 83.
2029 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 161 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 224 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 46.
2030 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 161 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 114 ; St. KLEIN, *op. cit.*, p. 584 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER, *op. cit.*, § 122c, n°s 43 et 44 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 224 et Ch. VERDURE, *op. cit.*, p. 116.
2031 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 7 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *ibidem*, p. 114 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER, *ibidem*, § 122c, n°s 43 et 44.
2032 E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 393 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, pp. 176 et 177, n° 232.
2033 Art. 137 de la Directive Sociétés.
2034 Art. 156, § 1er de la Directive Sociétés.

la forme du projet ne devraient être déterminées que par la *lex societatis* des sociétés existantes au moment de l'établissement de celui-ci puisqu'il s'agit des seuls droits nationaux ayant vocation à s'appliquer au projet de scission. Par conséquent, au niveau de la détermination de la forme du projet commun de scission transfrontalière, il convient de ne pas tenir compte du prescrit de la *lex societatis* de la société nouvellement créée. Cette solution logique s'est par conséquent retrouvée dans la règle de droit international privé consacrée par la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2035].

§6. La langue du projet commun de scission

433. Absence d'indication dans la Directive Sociétés. Contrairement à ce qui existe en matière d'offre publique d'acquisition où le législateur européen a expressément prévu que le prospectus devait être rédigé dans une langue usuelle de la sphère financière internationale dans un contexte transfrontalier[2036], la Directive Sociétés ne prévoit pas de règle spécifique concernant la langue dans laquelle le projet commun de fusion transfrontalière devra être rédigé. Face à ce silence, il faudra appliquer cumulativement les législations nationales des différents États membres dont les sociétés fusionnantes ressortent. On peut y voir une conséquence du fait que le projet commun est, notamment, destiné à informer les différents *stakeholders* dont tous ne sont pas nécessairement capables d'apprécier les subtilités d'un document rédigé en anglais.

434. Un multilinguisme de principe. On peut par conséquent partir du principe que le projet de fusion sera généralement rédigé en plusieurs langues[2037] puisqu'un des objectifs principaux du contrôle de légalité de l'opération est justement de s'assurer que les différentes traductions du projet commun de fusion concordent[2038]. La même solution devra être appliquée dans le cas des scissions transfrontalières et il s'ensuit qu'en fonction des spécificités propres des législations de chaque État membre impliqué, le processus peut s'en voir complexifié. Ainsi, à titre d'illustration, en droit belge, le projet de scission devra nécessairement être rédigé en français, en néerlandais ou en allemand en fonction du lieu du siège d'exploitation[2039] et en droit autrichien, le projet de scission transfrontalière pourra être rédigé dans une autre langue européenne, pour autant qu'il soit accompagné d'une traduction certifiée en allemand[2040].

2035 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.

2036 Art. 27, § 2 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), J.O., L 168, 30 juin 2017, pp. 12–82.

2037 D. Beutel, *op. cit.*, p. 161 ; M. Evrard et E. van der Vaeren, « Les fusions transfrontalières : un pas de plus vers une Europe harmonisée », *D.A. O.R.*, 2007, p. 114 ; N. Krause et N. Kulpa, *op. cit.*, p. 59 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 216.

2038 Art. 127, § 1er de la Directive Sociétés.

2039 D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 590.

2040 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 217.

435. Un obstacle pour les parties à l'opération. Cette disparité en matière d'emploi des langues est source de coûts et d'incertitudes[2041], de sorte qu'il a été suggéré d'envisager de permettre de ne rédiger le projet commun qu'en anglais, pour peu que cela soit politiquement possible[2042]. Compte tenu du nombre nécessairement plus élevé de sociétés impliquées dans une opération de scission transfrontalière susceptible d'entraîner *de facto* un nombre de problèmes linguistiques supérieur à une fusion transfrontalière, une telle mesure serait indéniablement de nature à faciliter l'opération. Cependant, compte tenu de l'objectif d'information qui incombe également au projet commun, il faudra mettre cette simplification en équilibre avec la nécessaire accessibilité du document pour des personnes n'étant pas nécessairement des professionnels du secteur financier.

436. La solution innovante de la Proposition de la Commission. Suivant en cela la recommandation faite par une des études préliminaires[2043], la Proposition de la Commission entendait simplifier l'élaboration du projet de de scission[2044] en permettant aux parties de rédiger celui-ci dans « une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales » en plus de la langue officielle des États membres concernés, étant entendu qu'il aurait été loisible à l'État membre de la société scindée de déterminer quelle version linguistique ferait foi en cas de divergences entre les différentes versions[2045]. Cette innovation, qui s'inspire éventuellement du régime des offres publiques d'acquisition[2046] a été saluée par certains auteurs[2047], même si son intérêt à l'aune du champ d'application *ratione materiae* limité[2048] du régime des scissions transfrontalières de la Proposition de la Commission peut laisser perplexe. En effet, dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière mixte ou par absorption, le projet de scission serait à considérer comme un document commun aux entités absorbantes et à l'entité scindée, entraînant par conséquent une application cumulative des différentes législations nationales applicables en matière d'emploi des langues, comme dans le cas d'une fusion transfrontalière[2049]. En revanche, dans l'hypothèse d'une scission au profit d'une ou de plusieurs nouvelles sociétés, la règle de conflit de lois posée par la Proposition

2041 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 78 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 243 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 24 et F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 15.

2042 J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 24.

2043 J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 24.

2044 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 31.

2045 Art. 160*sexies*, § 4 de la Proposition de la Commission.

2046 Art. 27, § 2 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 168, 30 juin 2017, pp. 12–82.

2047 W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569 ; Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 4 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 240. *Contra* : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 302.

2048 Art. 160*ter*, § 3 de la Proposition de la Commission.

2049 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 5 ; R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 217 et 218 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 9 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 216–218.

de la Commission[2050] impliquait nécessairement que le projet commun serait rédigé en tenant compte exclusivement des exigences de la loi nationale de la société scindée, excluant par conséquent tout conflit de lois. Deux raisons justifient malgré tout la présence de cette règle dans le régime des scissions transfrontalières tel que proposé par la Commission. Tout d'abord, le projet commun est notamment destiné à informer les différents *stakeholders*, ce qui, compte tenu du contexte économique globalisé au sein duquel les entreprises évoluent à l'heure actuelle, sera plus efficacement réalisé par le biais d'une version anglaise. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que la Directive Mobilité est destinée à préparer le terrain pour l'introduction d'un régime applicable à toutes les formes de scission[2051] dans lequel une telle règle en matière d'emploi des langues se justifierait pleinement. D'un point de vue plus critique, on peut tout d'abord relever que la Proposition de la Commission ne précise pas que le projet puisse être rédigé exclusivement en anglais[2052] et ce, malgré l'utilité pratique évidente d'une telle précision[2053]. En outre, on aurait pu se demander si laisser la possibilité aux États membres de prévoir qu'en cas de divergences entre les différentes versions, ce serait la langue nationale qui prévaudrait, n'aurait pas amputé cette disposition d'une bonne partie de son effet utile[2054]. En effet, si chaque État membre opte pour cette solution, on se retrouvera nécessairement dans une situation très similaire à la situation actuelle en matière de fusions transfrontalières[2055]. En tout état de cause, il est regrettable que cette disposition sur l'emploi des langues ait disparu dès le Premier Compromis de la Présidence[2056] et ne soit réapparue ni dans le Deuxième Compromis de la Présidence[2057], ni dans le Compromis des Représentants Permanents[2058], ni dans le Compromis Final[2059], ni encore dans la Proposition du Parlement[2060]. Cette disparition s'explique par le caractère éminemment politique de cette

2050 Art. 160*quinquies*, § 4 de la Proposition de la Commission.
2051 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 9.
2052 Art. 160*sexies*, § 4, 1re phrase de la Proposition de la Commission.
2053 J. Schmidt, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 243 ; J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 240 et Th. Wachter, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 290.
2054 Voir en ce sens : J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 302 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 858, n° 13 ; R. Knaier, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 614 ; J. Schmidt, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 243 ; J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 147 et H. Wicke, « Optionen und Komplikationen… (Teil I) », *op. cit.*, p. 2645.
2055 Voir en ce sens : W. Bayer et J. Schmidt, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *ibidem*, p. 2569 ; F. Bernard, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 15 et J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 240.
2056 Art. 160e du Premier Compromis de la Présidence et en ce sens : J. Schmidt, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 570 et J. Schmidt, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, p. 244.
2057 Art. 160e du Deuxième Compromis de la Présidence.
2058 Art. 160e du Compromis des Représentants Permanents.
2059 Art. 160e du Compromis Final.
2060 Art. 160*sexies* de la Proposition du Parlement.

question[2061]. Il est toutefois intéressant de relever que l'Avis de la CAJ, bien qu'il ait transformé la possibilité d'utiliser « une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales » en simple faculté pour les États membres[2062], poussait en revanche encore davantage le raisonnement de la Commission visant à simplifier l'élaboration du projet puisqu'il souhaitait que ce fût la société scindée, et non l'État membre concerné, qui déterminât la langue qui ferait foi en cas de divergences entre les différentes versions[2063].

437. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. Compte tenu du fait qu'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante mettra nécessairement en concurrence différents droits nationaux reprenant chacun des règles en matière d'emploi des langues potentiellement divergentes, un régime européen général des scissions devra idéalement inclure des dispositions sur la langue du projet commun sous peine de réitérer les insuffisances du régime des fusions transfrontalières mises en lumière ci-dessus. Une solution éventuelle à cet égard serait d'imposer aux États membres de permettre aux sociétés concernées (i) d'établir le projet commun de scission transfrontalière en anglais et (ii) de prévoir, lorsque l'État membre en question préfère ne pas laisser aux sociétés concernées le choix d'établir le projet de scission exclusivement en anglais, que cette version prévaudrait sur toutes les éventuelles traductions dans les langues officielles des États membres concernés qui pourraient être requises en vertu des législations nationales applicables. Pour assurer malgré tout une parfaite information des différents *stakeholders* potentiellement impactés par l'opération dans l'hypothèse où les États membres feraient le choix d'autoriser les sociétés concernées à ne rédiger le projet de scission qu'en anglais, cette flexibilité devrait en tout état de cause être combinée avec la possibilité pour les *stakeholders* autres que les associés d'en obtenir, sur simple demande et sans frais de leur part, une version dans une des langues nationales de l'État membre de la société concernée, étant entendu qu'en cas de divergences, la version anglaise prévaudrait nécessairement. Imposer aux parties de rédiger nécessairement le projet commun en anglais ne semble toutefois pas souhaitable[2064] en vue de promouvoir le recours aux scissions transfrontalières par les petites et moyennes entreprises. À titre d'illustration, dans l'hypothèse d'une scission partielle transfrontalière d'une société luxembourgeoise au profit d'une société française, exiger nécessairement une version anglaise serait superflu. Cette solution équilibrée et compatible avec un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante risque toutefois d'être difficilement acceptable sur le plan politique.

2061 Sur le caractère éminemment politique de la question linguistique, voir : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 244 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 240 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 24. Pour s'en convaincre, il suffit de voir l'hostilité du Bundesrat allemand à l'égard de la disposition en question. Voir : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 4.

2062 Amendement 260 de l'Avis CAJ.

2063 Amendement 260 de l'Avis CAJ.

2064 *Contra* : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 240 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 24 qui considère que la solution la plus simple consisterait à imposer aux parties de rédiger non seulement le projet commun mais également tous les documents connexes à tout le moins en anglais.

§7. Le contenu du projet commun de scission

A. *Présentation*

438. Un contenu minimum. Contrairement au projet de dixième directive de 1985[2065] qui prévoyait une liste exhaustive des diverses mentions devant figurer dans le projet commun de fusion transfrontalière afin d'éviter tout risque de discordances entre les législations nationales[2066], les dispositions de la Directive Sociétés relatives aux scissions internes[2067], à l'instar de celles relatives aux fusions internes[2068], aux fusions transfrontalières[2069] et aux sociétés européennes[2070], ne prévoient qu'un contenu minimum qu'il est loisible aux parties de compléter[2071]. Cette spécificité apparaît par ailleurs explicitement dans le projet de la Commission de 2003[2072] ainsi qu'en matière de fusions transfrontalières d'OPCVM[2073].

439. Un projet plus complet. Cependant, lorsqu'on procède à une comparaison entre le régime des fusions internes[2074] et des scissions internes[2075] avec celui des fusions transfrontalières[2076], on constate que le législateur européen a imposé des mentions additionnelles dans le cadre d'une opération transfrontalière. Ce contenu étendu est justifié par la nature internationale de l'opération qui implique d'assurer une meilleure information des associés, des travailleurs et des créanciers[2077]. Un constat similaire s'impose lorsqu'on compare les

2065 Art. 5 de la proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, COM (84) 727 final du 14 décembre 1984, présentée par la Commission au Conseil le 14 janvier 1985, *J.O.*, C 23/11.

2066 Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, COM (84) 727 final du 14 décembre 1984, présentée par la Commission au Conseil le 14 janvier 1985, *J.O.*, C 23/11, *Exposé des motifs*, p. 8.

2067 Art. 137, § 2 de la Directive Sociétés.

2068 Art. 91, § 2 de la Directive Sociétés.

2069 Art. 122 de la Directive Sociétés.

2070 Art. 20, § 1er du Règlement sur la Société européenne.

2071 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 402 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 162 et 163 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 11 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung… », *op. cit.*, p. 83 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, nos 853 et 856 ; S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 796 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 231 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 256 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 33, n° 67 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 313 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 394 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *op. cit.*, p. 188 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 31 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 15 et Ch. VERDURE, *op. cit.*, p. 114.

2072 Art. 3, § 2 de la proposition de directive du Parlement et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux du 18 novembre 2003, COM2003 (703) final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (08/12/2017), p. 12.

2073 Art. 40, § 2 de la directive (CE) 2009/65 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), version consolidée disponible sur https://eur-lex.europa.eu (07/11/2021) (ci-après la « **Directive OPCVM** »).

2074 Art. 91, § 2 de la Directive Sociétés.

2075 Art. 137, § 2 de la Directive Sociétés.

2076 Art. 122 de la Directive Sociétés.

2077 D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.

mentions imposées par la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières[2078] par rapport à celles de la Directive Sociétés en matière de scissions internes[2079].

440. Une différence fondamentale avec le régime des opérations internes. Les différences entre le régime des fusions internes et celui des fusions transfrontalières ne s'arrêtent toutefois pas là. En effet, s'il est généralement considéré que les dispositions de la Directive Sociétés relatives au contenu du projet commun de fusion interne peuvent être librement complétées par les États membres[2080], tel n'est pas le cas de celles relatives aux fusions transfrontalières. En effet, le cinquante-septième considérant de la Directive Sociétés précise explicitement qu'il est loisible aux parties de compléter le projet de fusion transfrontalière[2081]. *A contrario*, il a été avancé que cela signifiait que les États membres ne devraient pas disposer de la possibilité de compléter le catalogue en imposant d'autres mentions obligatoires[2082]. Une telle interprétation est, selon ses défenseurs, de plus confortée (i) d'une part par l'objectif de ces dispositions qui est de mettre en place une réglementation composée d'éléments communs applicables de manière transnationale[2083][2084] et, (ii) d'autre part, par le principe de subsidiarité des régimes nationaux[2085]. En effet, il a été avancé que le fait que la Directive Sociétés prévoie une disposition spécifique propre au contenu du projet de fusion transfrontalière excluait *de facto* l'application des régimes nationaux des fusions internes potentiellement complétés par les États membres[2086]. On ne peut d'ores et déjà que relever la faiblesse de ces arguments dans la mesure où (i) le premier argument consiste à recourir à un

2078 Voir art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité qui cite pas moins de dix-sept éléments obligatoires.
2079 Voir article 137, § 2 de la Directive Sociétés qui cite neuf éléments obligatoires.
2080 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 162 et E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 394.
2081 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 402 ; D. BEUTEL, *ibidem*, pp. 162 et 163 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 11 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung… », *op. cit.*, p. 83 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n°s 853 et 856 ; S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 796 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 231 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 256 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 33, n° 67 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 313 ; E. ROELOFS, *ibidem*, p. 394 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 188 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 31 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 15 et Ch. VERDURE, *op. cit.*, p. 114.
2082 *Pro* : D. BEUTEL, *ibidem*, pp. 162 et 163 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes – Erleichterung grenzüberschreitender Verschmelzungen für deutsche Kapitalgesellshaften ? », *BB*, 2006, p. 727 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 11 ; M. FRISCHHUT, *op. cit.*, p. 58, note 52 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *ibidem*, p. 227 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 57 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 172 et Chr. LOUVEN, *op. cit.*, p. 2025. *Contra* : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 402 et P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 15.
2083 Quinzième considérant de la dixième directive (CE) 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'E.E.E), http://eur-lex.europa.eu (11/03/2016), non repris dans la Directive Sociétés.
2084 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 163 et H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 227.
2085 Art. 121, § 1er, lit. b, *in initio* de la Directive Sociétés selon lequel « [s]auf disposition contraire de la présente directive, […] b) une société participant à une fusion transfrontalière se conforme aux dispositions et aux formalités de la législation nationale dont elle relève. ». Voir en ce sens : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 171.
2086 S. KULENKAMP, *ibidem*, p. 171 et H.-W. NEYE, *op. cit.*, p. 1895.

délicat raisonnement *a contrario* à partir d'un simple considérant alors que le texte même de la directive est muet à ce sujet et (ii) le deuxième argument méconnaît le fait que la norme en question n'est qu'une directive n'ayant que vocation à compléter une application cumulative des différents droits nationaux en présence[2087].

441. Une interprétation difficile à accepter par les États membres. Ce raisonnement est certes convaincant de prime abord d'un point de vue théorique, mais il aboutit à une conséquence difficilement acceptable pour les États membres, à savoir que dans le cas où un État membre a choisi de compléter ce qui est requis dans le cadre de l'établissement du projet commun de fusion interne, une fusion transfrontalière devrait s'en trouver exclue et s'avérerait par conséquent facilitée par rapport à une opération interne. Cet état de fait explique à lui seul pourquoi de nombreux États membres ont, malgré tout, choisi de compléter le catalogue des mentions obligatoires dans le cadre d'une fusion transfrontalière. Ainsi, à titre d'illustration, en droit belge, le projet de fusion transfrontalière doit également inclure l'objet social des sociétés appelées à être dissoutes et ainsi que celui envisagé pour la société issue de l'opération[2088].

442. Une interprétation qui méconnaît un des objectifs fondamentaux du projet commun de scission. Au-delà de la simplification potentielle d'une opération transfrontalière par rapport à une opération interne, la théorie exposée ci-dessus prête toutefois également le flanc à la critique en ce qu'elle méconnaît un des objectifs fondamentaux du projet commun qui est celui de l'information des *stakeholders*[2089]. En d'autres termes, le projet de scission n'est pas destiné qu'aux parties mais s'inscrit également dans une dynamique de protection des tiers intéressés par l'opération. Or, les dispositions sur les fusions transfrontalières de la Directive Sociétés permettent explicitement aux États membres d'adopter des mesures destinées à assurer la protection de ces différents *stakeholders*[2090] au sein desquelles peut dès lors se retrouver une norme nationale imposant une mention additionnelle dans le projet commun. À titre d'illustration, on peut citer le droit autrichien qui prévoit que le projet commun doit contenir les conditions auxquelles il pourra être procédé au rachat des actions des associés minoritaires s'étant opposé à la fusion dans le cadre d'une fusion-émigration[2091]. Le même raisonnement s'applique également à l'égard de la Directive Mobilité d'où il ressort clairement qu'en matière de protection des intérêts tant des créanciers que les associés minoritaires, le législateur européen a opté pour une harmonisation *a minima*[2092].

2087 Art. 121 de la Directive Sociétés et 3e considérant de la Dixième Directive. Voir en ce sens : W. Bayer et J. Schmidt, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 402.

2088 Art. 12:24, al. 2, 1° et 12:37, al. 2, 1° du CSA.

2089 Fl. Parrein, *op. cit.*, p. 311 ; Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 174, n° 227 ; P. Van Ommeslaghe, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14 et D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.

2090 Art. 121, § 2 de la Directive Sociétés.

2091 § 5 (4) EU-VerschG.

2092 Voir à ce sujet dans le cadre de la protection des créanciers : n° 954 et dans le cadre de la protection des associés minoritaires : n° 1089.

443. L'impact sur les scissions transfrontalières. Il s'ensuit dès lors que ni les dispositions de la Directive Sociétés relatives au contenu du projet commun de fusion transfrontalière, ni celles relatives au projet de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité ne doivent être considérées comme une norme de droit matériel[2093] qu'il conviendrait d'appliquer *mutatis mutandis* aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. Si on ajoute à cela que la détermination du contenu du projet commun de scission requiert en principe un traitement unitaire[2094], il en découle que la règle de droit international privé applicable à la question de la détermination du contenu du projet commun de scission sera celle d'une application cumulative des différents droits en présence tout en privilégiant la norme la plus sévère[2095]. Appliquée aux scissions transfrontalières, cette règle signifie que la totalité des mentions imposées par les différents droits nationaux en présence devront nécessairement se retrouver dans le projet commun de scission, quand bien même elles seraient inconnues de la *lex societatis* d'une des sociétés impliquées dans l'opération. Ainsi, à titre d'illustration, le droit autrichien prévoit que dans l'hypothèse d'une scission partielle, le projet commun de scission devra également inclure des informations sur les spécificités de la réduction de capital de la société scindée lorsqu'il est prévu que celle-ci réduise son capital social dans le cadre d'une scission partielle[2096] alors qu'une telle exigence n'existe pas en droit luxembourgeois[2097] ou en droit belge[2098]. Une telle mention devra par conséquent se retrouver dans le projet commun de scission partielle d'une société autrichienne au profit d'une société luxembourgeoise préexistante. Cependant, il serait erroné de penser que pour pouvoir déterminer avec précision le contenu minimal du projet commun de scission transfrontalière, il suffit d'appliquer cumulativement les diverses règles nationales applicables aux scissions internes en privilégiant la règle la plus sévère. Procéder ainsi reviendrait à méconnaître la dimension transfrontalière de l'opération et ne permettrait pas au projet de scission de remplir son objectif d'information adéquate des différents *stakeholders*. En effet, le caractère transfrontalier de l'opération justifie à lui seul la nécessité d'inclure davantage d'informations. Afin de pouvoir déterminer avec précision le contenu minimum du projet de scission transfrontalière impliquant plus d'une société existante, il sera dès lors nécessaire de tout d'abord inclure toutes les mentions requises dans le cadre d'une scission interne par chacun des États membres concernés (B). Ensuite, il conviendra d'examiner les mentions nécessaires dans le cadre d'une fusion transfrontalière par absorption et d'analyser dans quelle mesure celles-ci sont transposables aux scissions transfrontalières (C). Une fois ces deux premières étapes réalisées, il sera intéressant de comparer le résultat

2093 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : S. MAQUET, *op. cit.*, p. 35. *Contra :* S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 171 et H.-W. NEYE, *op. cit.*, p. 1895.

2094 57e considérant de la Directive Sociétés et Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 313 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 393 ; et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 46.

2095 Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 313 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 182 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 392 et 393 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, pp. 188 et 189 et Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 31.

2096 § 2 (1) 4. SpaltG.

2097 Art. 1031-1, § 2 et 1032-1, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

2098 Art. 12:59, al. 2 et 12:75, al. 2 du CSA.

ainsi obtenu avec le contenu minimum imposé par le législateur européen dans la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières afin de déterminer d'une part dans quelle mesure celui-ci pourrait d'ores et déjà s'avérer compatible avec les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante (D) et, d'autre part, identifier d'éventuelles autres mentions obligatoires (E) ou facultatives (F) qui n'auraient pas encore été mises en lumière lors des deux étapes précédentes.

B. *Le contenu inspiré des scissions internes*

444. Plan du point B. Pas moins de neuf éléments inspirés du régime des scissions internes devront se retrouver au sein du projet commun de scission transfrontalière, à savoir : les informations relatives aux sociétés (1), le rapport d'échange et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces (2), les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires (3), la date à partir de laquelle les actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toutes modalités particulières relatives à ce droit (4), le ou les date(s) de prise d'effet comptable (5), les droit assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard (6), les avantages particuliers attribués aux experts et aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle (7), la description et la répartition précise des éléments du patrimoine actif et passif de la société scindée (8) et les informations relatives à la répartition des actions ou des titres des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée (9). Chacune de ces mentions fera l'objet d'une brève description afin d'en clarifier l'utilité dans le cadre du processus particulièrement complexe que représente une scission transfrontalière.

1. *Les informations relatives aux sociétés concernées*

445. Identification et vérification de la capacité de scission. Les premières informations qu'il convient de faire figurer dans le projet de scission concernent les sociétés participant à l'opération[2099], soit la société scindée et les sociétés bénéficiaires, mais également, le cas échéant, les sociétés nouvellement créées dans le cadre de la scission[2100]. À défaut de dispositions nationales plus contraignantes[2101], il faudra ainsi à tout le moins mentionner la forme, la dénomination et le siège social de chacune de ces entités[2102]. L'indication de la forme permettra ainsi aux autorités judiciaires et administratives impliquées de vérifier aisément que les sociétés ont bien tant la capacité concrète que la capacité générale de scission[2103]. À l'égard de la dénomination, il conviendra

[2099] Voir en matière de scissions internes : art. 127, § 2 de la Directive Sociétés.
[2100] Voir en matière de scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés : art. 160*quinquies*, a) de la Directive Mobilité.
[2101] En droit belge, les art. 12:59, al. 2, 1° et 12:75, al. 2, 1° du CSA imposent également de faire figurer l'objet social dans le projet de scission.
[2102] Art. 137, § 2 et 156, § 2 de la Directive Sociétés.
[2103] R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 9 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 230.

non seulement d'indiquer la dénomination actuelle mais également la dénomination future s'il est prévu de modifier celle-ci en conséquence de la scission[2104]. Cette mention devra se retrouver telle quelle dans un régime européen plus général des scissions transfrontalières et figure déjà dans la Directive Mobilité à l'égard des scissions par constitution de nouvelles sociétés.

2. *Le rapport d'échange et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces*

446. Plan du point 2. Afin de clarifier le rôle prépondérant que joue la mention relative au rapport d'échange dans le cadre d'une scission transfrontalière, il importe en premier lieu d'en rappeler le principe et les limites (2.1), pour ensuite s'arrêter sur l'importance de la soulte en espèces (2.2) et sur la date d'établissement du rapport d'échange (2.3). En dernier lieu, il conviendra de préciser en quoi cette mention revêt un caractère facultatif dans certaines hypothèses (2.4).

2.1. Le principe et ses limites

447. Un enjeu considérable. Fixé généralement dans son principe dès les négociations préliminaires, le rapport d'échange désigne le nombre d'actions des sociétés bénéficiaires (qu'elles soient existantes ou nouvellement constituées dans le cadre de l'opération) qui seront attribuées en échange d'une ou de plusieurs action(s) de la société scindée suite à la transmission à titre universel du patrimoine de cette dernière[2105]. Il revêt par conséquent une importance centrale dans la mesure où c'est de l'application de celui-ci que découlera la composition du nouvel actionnariat des sociétés bénéficiaires et son caractère juste et approprié est essentiel pour garantir la protection des associés tant de la société scindée que des sociétés bénéficiaires[2106]. En effet, les premiers auront tout intérêt à ce que leurs actions soient surévaluées afin de s'assurer que leur investissement prenne de la valeur dans le cadre de l'opération, ou à tout le moins n'en perde pas. Les associés des sociétés bénéficiaires chercheront, au contraire, à éviter une sous-évaluation de leurs actions qui aurait pour conséquence une réduction de la valeur de leur participation dans la société bénéficiaire et une dilution excessive de leurs droits. L'exercice de l'établissement du rapport d'échange consiste donc à trouver un délicat équilibre entre les prétentions des différents associés impliqués. À ce stade, il convient de préciser que le projet commun de scission ne doit contenir que la mention du rapport d'échange et, le cas échéant du montant de la soulte en espèces[2107]. Il n'est par conséquent pas requis d'inclure une justification des méthodes

2104 R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 9 et J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 230.
2105 G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 126, n° 8 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 233 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 35.
2106 Sur le risque de dilution en raison d'un rapport d'échange inadéquat, voir *infra* n° 979.
2107 Art. 137, § 2, b) de la Directive Sociétés.

utilisées[2108], celles-ci devant être expliquées et vérifiées à deux stades ultérieurs de la procédure[2109].

448. Une formule mathématique d'apparence simple. Le rapport d'échange peut s'obtenir assez aisément par un procédé qui consiste tout d'abord à effectuer une évaluation séparée de chacune des sociétés participant à la scission. L'évaluation des sociétés sera ensuite divisée par le nombre d'actions émises par la société en question afin d'aboutir à une valeur unitaire. Ensuite, il suffira de rapporter ces deux variables au sein d'une fraction dont le numérateur sera la valeur unitaire des actions de la société scindée et le dénominateur sera la valeur unitaire des actions de la société bénéficiaire pour obtenir le rapport d'échange entre les actions de la société scindée et celles d'une des sociétés bénéficiaires. Une fois cette fraction obtenue, il faudra réaliser une évaluation de chacune des quoteparts du patrimoine de la société scindée pour ensuite diviser celle-ci par la valeur unitaire des actions de la société scindée afin d'obtenir le nombre d'actions dans le capital de la société scindée qui représentent chaque quotepart. Pour finir, il suffira de multiplier le nombre d'actions de la société scindée représentant la quotepart du patrimoine attribué à la première société bénéficiaire par la fraction pour connaître le nombre d'actions de la société bénéficiaire à attribuer dans le cadre de la scission. Cette opération devra être répétée pour chaque société bénéficiaire, ce qui implique qu'une scission par acquisition entraînera normalement l'établissement d'au moins deux rapports d'échange distincts.

449. Illustration chiffrée. Si la société scindée est évaluée à 100 000,- euros et que son capital social est représenté par 100 actions, la valeur unitaire de chacune de ces actions sera de 1 000 euros. Si (i) la première société bénéficiaire est évaluée à 200 000,- euros et que son capital social est représenté par 100 actions, la valeur unitaire de chacune de ces actions sera de 2 000,- euros. Ces données nous donnent une fraction avec 1 000 au numérateur et 2 000 au dénominateur, soit 1 sur 2. Par conséquent, chaque action de la société scindée donnera droit à une demi-action de la première société bénéficiaire. En d'autres termes, il faudra échanger deux actions de la société scindée pour obtenir une action de la première société bénéficiaire. Si la seconde société bénéficiaire est évaluée à 500 000 euros et que son capital social est représenté par 100 actions, la valeur unitaire de chacune de ces actions sera de 5 000 euros, ce qui nous donnera un rapport d'échange d'une action de la société scindée pour un cinquième d'action de la société bénéficiaire, soit 5 actions de la société scindée pour une action de la société bénéficiaire. Si à présent dans le cadre de la scission, la première société bénéficiaire récolte une quotepart du patrimoine de la société scindée évaluée à 20 000 euros, cette quotepart sera représentée par 20 actions. Par application du rapport d'échange calculé plus haut, il faudra donc émettre 10 nouvelles actions de la première société bénéficiaire. Comme la seconde société bénéficiaire récoltera une quotepart

[2108] C. Engelmeyer, « Das Spaltungsverfahren bei der Spaltung von Aktiengesellschaften », *AG*, 1996, p. 195 ; H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 25 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 233.

[2109] Art. 141 (rapport des organes de direction ou d'administration) et 142 (rapport d'expert) de la Directive Sociétés.

de 80 000 euros représentée par 80 actions de la société scindée, par application du second rapport d'échange, il faudra émettre 16 nouvelles actions de la seconde société bénéficiaire[2110].

450. Les limites liées à l'évaluation des sociétés. S'il est indéniable que le rapport d'échange se doit d'être approprié afin d'éviter que l'opération ne se réalise au détriment d'un groupe d'associés en particulier, ce résultat n'en est pas pour autant aisé à obtenir en pratique. En effet, en examinant la formule mathématique, on se rend immédiatement compte que les éléments déterminants seront les évaluations des diverses sociétés qui seront réalisées. Or à cet égard, comme remarqué dans le cadre de l'examen des limites intrinsèques au régime des fusions transfrontalières[2111], il existe une grande diversité de méthodes d'évaluation au sein des États membres au nombre desquelles on compte, par exemple, la valeur de rendement[2112], l'actif net réévalué[2113], la valeur établie selon le cours de bourse ou encore la méthode des flux de trésorerie actualisés (*discounted cash flow method*)[2114]. Malgré ces divergences et les souhaits exprimés à cet égard[2115], la Directive Mobilité n'est pas venue harmoniser les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement du rapport d'échange. Autour de cette diversité de règles d'évaluation de base, gravitent ensuite d'autres règles modalisant le recours à ces méthodes ou en adaptant certaines composantes. Ainsi, à titre d'illustration, en droit autrichien, il est établi que le *goodwill* ne doit pas entrer en ligne de compte, pas plus que les synergies potentiellement engendrées par l'opération[2116]. Par conséquent, la première tâche des organes d'administration ou de direction des entités participant à l'opération sera de déterminer les diverses méthodes d'évaluation qui seront utilisées dans le cadre de l'établissement du rapport d'échange[2117]. Une fois celles-ci déterminées, il conviendra en plus de tenir compte de potentielles applications divergentes existant entre les différents États membres impliqués. En effet, à titre d'illustration, à supposer que la méthode des flux de trésorerie actualisés (*discounted cash flow method*), qui permet d'évaluer une entreprise en se basant sur la valeur actuelle de ses flux de trésorerie attendus en y appliquant une décote reflétant le risque lié à celle-ci[2118], ait été parmi les méthodes retenues, il conviendra encore d'examiner si la décote de risque est déterminée de manière uniforme entre les différents États membres impliqués[2119]. L'objectif sera donc de garantir que les diverses sociétés participant à l'opération soient

2110 Pour une illustration chiffrée du calcul du rapport d'échange, voir Annexe 2.
2111 À ce sujet, voir *supra* n° 304.
2112 R. KIEM, « Die Ermittlung der Verschmelzungsrelation bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *op. cit.*, pp. 542, 543 et 551 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 13 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 236 et St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 49.
2113 Al. STEICHEN, *op. cit.*, pp. 236 et 237.
2114 G. HAWAWINI et Cl. VIALLET, *op. cit.*, p. 619 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 14 et St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 49.
2115 Voir en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, « Gesellschafterschutz in der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *op. cit.*, p. 2258.
2116 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 237.
2117 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 49 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 23.
2118 G. HAWAWINI et Cl. VIALLET, *op. cit.*, p. 619.
2119 S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 177 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 238.

évaluées selon des méthodes et des critères identiques ou, à tout le moins, comparables[2120]. À défaut d'harmonisation de cet aspect pourtant fondamental de l'établissement du rapport d'échange dans un cadre transfrontalier, il peut s'avérer judicieux de compléter le projet commun de scission transfrontalière par un bref descriptif de la méthode d'évaluation utilisée par les parties[2121]. Si cet ajout est indéniablement utile dans le cadre d'une fusion transfrontalière[2122], il l'est d'autant plus dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière où davantage d'ordres juridiques et de méthodes d'évaluation distincts sont susceptibles d'entrer en concurrence.

451. Une formule d'application facultative. Si la formule mathématique décrite ci-dessus est certes de nature à aboutir à un rapport d'échange approprié dans la plupart des situations, son utilisation n'en est pour autant pas nécessairement obligatoire. En effet, rien n'empêche les associés souhaitant éluder la fastidieuse et coûteuse phase d'évaluation des entités participant à l'opération de se mettre d'accord sur un rapport d'échange qu'eux-mêmes jugent satisfaisant[2123], soit encore de modifier la formule comme bon leur semble ou encore d'établir eux-mêmes leur propre formule de calcul, la seule exigence étant que le rapport d'échange demeure pertinent et raisonnable[2124]. Ainsi, dans l'hypothèse d'une scission intragroupe d'une société, rien n'empêche les parties d'utiliser simplement le montant du capital social de chaque société ou encore de fixer arbitrairement un rapport qu'elles jugent opportun[2125]. Dans un même ordre d'idées, l'évaluation individuelle des sociétés peut également n'être utilisée que comme point de départ pour ensuite tenir compte d'autres facteurs comme par exemple les synergies futures créées au sein d'une des sociétés bénéficiaires, les besoins d'investissement des sociétés impliquées[2126] ou encore des informations de nature plus confidentielle[2127] comme le développement d'un nouveau produit ou l'obtention d'un brevet. Il convient également de préciser qu'il n'est pas requis que le rapport d'échange soit parfaitement équitable[2128]. En effet, les négociations préliminaires peuvent en tout état de cause aboutir à un rapport d'échange qui, sans être tout à fait équitable,

2120 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 11 ; J. Mitterecker, *ibidem*, p. 235 ; J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 23 et T. Schott, *op. cit.*, p. 121.

2121 W. Bayer et J. Schmidt, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569 ; N. Benz, L. Hübner et A. Zimmermann, *op. cit.*, p. 2258 et J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 241.

2122 N. Benz, L. Hübner et A. Zimmermann, *ibidem*, p. 2258 et G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 11.

2123 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 235 et H. Schröer et G. Greitemann in A. Semler et J. Stengel (dir.), *op. cit.*, p. 1023, n° 37.

2124 Art. 96, § 2 (fusions internes) et 142, § 2 (scissions internes) de la Directive Sociétés. Voir également : art. 125, § 3 (fusions transfrontalières) et art. 160*septies*, § 2 de la Directive Mobilité qui implique que le rapport d'échange doit être « *adéquat* ».

2125 Voir le projet commun de scission de la société luxembourgeoise Immo Finland S.à r.l. du 29 janvier 2018, disponible sur https://www.rcsl.lu (05/04/2018), p. 3 pour un cas d'application.

2126 J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 28, n° 49 et C.A. Paris, 28 décembre 1992, *Bull. Joly*, 1993, p. 434.

2127 Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 172, n° 224.

2128 G. Keutgen et J.-F. Tossens, *op. cit.*, p. 125 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 238 et H. Schröer et G. Greiteman in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard, *op. cit.*, § 5, n° 25.

demeure néanmoins pertinent et raisonnable tel que requis par la Directive Sociétés dans l'hypothèse d'une opération interne[2129].

452. Un caractère nécessairement unique. Quelle que soit la méthode utilisée pour parvenir à l'établissement du rapport d'échange, celui-ci devra en tout état de cause revêtir un caractère unique[2130]. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible en pratique de prévoir plusieurs rapports d'échange dans le but, par exemple, de favoriser les associés de contrôle[2131] ou encore de pénaliser les associés n'ayant pas encore intégralement libéré les actions qu'ils détiennent dans la société scindée[2132]. Il est cependant évident qu'un rapport d'échange distinct devra être établi pour chaque société bénéficiaire.

2.2. L'importance de la soulte

453. Un double objectif. La possibilité de prévoir une soulte en espèces n'est pas destinée à être utilisée pour remplacer l'attribution de nouvelles actions[2133] mais est destinée à faciliter celle-ci en éludant la problématique des rompus[2134]. Au-delà de ce premier objectif, elle va également permettre dans certaines circonstances de faciliter l'opération de scission en fournissant une possibilité de rachat des minoritaires détenant une participation négligeable ou encore, en servant de dédommagement pour des droits préférentiels détenus par certains associés de la société scindée alors que seules des actions ordinaires seront attribuées par les sociétés bénéficiaires[2135].

454. Une limite facultative de la soulte. Le régime des scissions internes tel qu'instauré par la Directive Sociétés prévoit en principe, à l'instar de ce qui a été prévu pour les fusions internes[2136], les fusions transfrontalières[2137] et les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2138], que le montant de la soulte en espèces ne peut dépasser la limite de dix pourcents de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces actions[2139]. Cette limite a pu être expliquée tantôt par une volonté de protéger les associés minoritaires contre un rachat pur et simple[2140], tantôt

2129 Art. 96, § 2 et 142, § 2 de la Directive Sociétés.
2130 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 170, n° 220.
2131 Th. TILQUIN, *ibidem*, p. 170, n° 220.
2132 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 7 et Th. TILQUIN, *ibidem*, p. 170, n° 221.
2133 H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 41 ; G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, pp. 122 et 123 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 9 et Cass., 16 novembre 1966, *Pas.*, 1967, I, p. 354.
2134 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 149 ; G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *ibidem*, p. 122 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 53, n° 135 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 31 et § 126, n° 41.
2135 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 139 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD, *op. cit.*, § 126, n° 42.
2136 Art. 89, § 1er et 90, § 1er de la Directive Sociétés.
2137 Art. 119, § 2 de la Directive Sociétés.
2138 Art. 160*ter*, § 4 de la Directive Mobilité.
2139 Art. 136, § 1er et 155, § 1er de la Directive Sociétés.
2140 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 149 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 140 et J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten », *NZG*, 2006, pp. 162 et 163.

comme une disposition destinée à protéger les liquidités et la base capitalistique des sociétés bénéficiaires[2141], tantôt encore par une nécessité de protéger les caractéristiques essentielles d'une fusion[2142]. Cependant, cette limite n'était pas contraignante et les États membres ayant choisi de reconnaître les scissions ont eu la possibilité d'étendre le régime des scissions aux opérations où cette soulte dépasse cette limite[2143]. Cette extension était motivée à l'origine par la volonté du législateur européen d'étendre les garanties prévues tant pour les associés que pour les tiers à « certaines opérations juridiques ayant sur des points essentiels des caractéristiques analogues à celles de la fusion » afin d'éviter que ces mécanismes de protection ne puissent être aisément éludés[2144]. À titre d'illustration, le Luxembourg[2145] a fait usage de cette option, mais d'autres États membres comme la Belgique[2146], l'Autriche[2147] ou encore l'Allemagne[2148] ont préféré ne pas y recourir. Comme indiqué ci-dessus[2149], dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière mettant en concurrence des législations nationales contradictoires à cet égard, il conviendra d'appliquer par analogie la solution prévue par la Directive Sociétés en matière de fusions transfrontalières[2150], qui correspond à la solution prévue par la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières[2151], en vertu de laquelle il suffira qu'un seul État membre impliqué dans l'opération autorise une soulte supérieure à dix pour cent pour qu'une telle soulte soit possible au niveau transfrontalier. Compte tenu des similitudes entre les deux types d'opérations[2152] et la volonté

2141 Voir en ce sens : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 16.

2142 Selon le texte de la proposition de troisième directive sur les fusions internes, « [l]e volume de ces soultes en espèces restant faible, les caractéristiques de la fusion n'en sont pas modifiées. En pratique, l'utilité du paiement de ces soultes est de permettre de déterminer de façon aussi simple que possible le rapport d'échange des actions ». Voir : Proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, paragraphe 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes du 5 juin 1970, COM (70)633, p. 21.

2143 Art. 158 de la Directive Sociétés.

2144 Voir 8e considérant de la proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, paragraphe 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes du 5 juin 1970, COM (70)633, p. 21. Il est intéressant de relever que la proposition de directive en question ne contient pas de référence directe à la possibilité d'une soulte en espèces supérieure à 10 %, mais l'avis du Parlement sur cette proposition « fait observer que les opérations pour lesquelles les soultes en espèces sont supérieures à 10 %, mais ne dépassent pas 100 %, relèvent de l'article 21 [qui traite des autres opérations également soumises au régime de la fusion] ». Voir : Avis du Parlement européen du 16 novembre 1972 sur la proposition d'une troisième directive tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés, au sens de l'article 58 paragraphe 2 du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes, *J.O.*, C 129, 11 décembre 1972, pp. 50–57, pt. 32. Voir également : 8e considérant de la Troisième Directive ; 10e considérant de la Sixième Directive et 54e et 72e considérants de la Directive Sociétés.

2145 Art. 1033-1 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

2146 Art. 12:4 ; 12:5 et 12:6 du CSA.

2147 § 2 (1) 3. SpaltG.

2148 §§ 54 (4), 68 (3) et 125 UmwG.

2149 À ce sujet, voir *supra* n° 298.

2150 Art. 120, § 1er de la Directive Sociétés.

2151 Art. 160*bis*, § 2 de la Directive Mobilité.

2152 L. Athlan et St. Torck, *op. cit.*, p. 1 ; H. Le Nabasque, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. Lamon, *op. cit.*, p. 125 ; Th. Prüm, *op. cit.*, p. 16 ; A. Reik, *op. cit.*, p. 300 ; E. Roelofs, *op. cit.*, p. 347 et J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27.

du législateur européen de mettre en place un régime des scissions internes en vue d'éviter que la législation sur les fusions internes ne soit trop aisément éludée par le biais d'une scission[2153], on comprendrait difficilement comment il pourrait en être autrement. Il conviendra toutefois de clarifier cette règle de conflit de lois dans la mesure où certains États membres, au nombre desquels on compte l'Allemagne[2154] et l'Autriche[2155] font preuve d'une certaine réticence à autoriser les fusions transfrontalières avec une soulte supérieure à dix pourcents. En effet, en droit autrichien, il a été avancé que dans la mesure où le plafonnement de la soulte avait été instauré en vue de protéger (i) les associés de la société apporteuse en cas de fusion-émigration et (ii) les associés de la société bénéficiaire en cas de fusion-immigration dans la mesure où les limites maximales de la soulte sont destinées à protéger la base capitalistique de la société bénéficiaire, de sorte que ni les fusions transfrontalières immigration avec une soulte supérieure à 10 %, ni les fusions transfrontalières émigration avec une soulte supérieure à 10 % ne devraient être admises[2156]. Une telle interprétation protectionniste n'est toutefois pas réconciliable avec le texte de la Directive Sociétés et repose sur un refus particulièrement douteux de voir en la règle de conflit de lois posée dans le régime des fusions transfrontalières autre chose qu'une simple autorisation aux États membres d'accepter les fusions transfrontalières impliquant une soulte supérieure à 10 %[2157] et ce malgré le sens clair de la disposition de la Directive Sociétés[2158]. Dans la mesure où les problèmes posés à cet égard risquent d'être encore plus accrus dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière par absorption en raison de la probabilité qu'un nombre plus important de juridictions distinctes soient impliquées compte tenu de la présence d'au moins trois sociétés distinctes, il serait toutefois utile qu'une nouvelle initiative européenne en la matière clarifie définitivement ce point en précisant que la règle de conflit de lois spécifique s'applique nonobstant l'existence d'une limite plus stricte du montant de la soulte en espèces dans l'hypothèse d'une opération interne au sein d'un ou de plusieurs États membres concernés et ce, peu important que le droit autorisant la soulte supérieure soit celui de la société scindée ou celui d'une des sociétés bénéficiaires.

2153 4e considérant de la Sixième Directive.

2154 Voir en faveur d'une prohibition des fusions transfrontalières avec une soulte supérieure à 10 % lorsque le droit applicable à la société absorbée l'interdit : J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, pp. 162 et 163. Voir en faveur de la possibilité de réaliser une fusion transfrontalière avec une soulte supérieure à 10 % uniquement lorsque le droit applicable à la société absorbante le permet : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 133 ; G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 12 et W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 16. Voir en faveur de l'autorisation de toutes les fusions transfrontalières impliquant une soulte en espèces supérieure à 10 % dès que le droit d'un État membre impliqué l'autorise : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 150.

2155 G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 621 et 622, n° 14 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 139 à 143.

2156 G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *ibidem*, pp. 621 et 622, n° 14 et J. MITTERECKER, *ibidem*, pp. 139 à 143.

2157 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 140.

2158 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 150 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 58, n° 86 et A. UGLIANO, « The new cross-border merger directive : Harmonisation of European company law and free movement », *EBLR*, 2007, n° 18, p. 601.

455. La nature de la soulte. La terminologie de soulte en espèces présente à la fois dans le régime des scissions internes[2159], des fusions internes[2160] et des fusions transfrontalières[2161], semble exclure *ab initio* tout paiement en nature et on verrait difficilement pourquoi il pourrait en être autrement dans le cadre d'une scission transfrontalière. Cependant, une telle interprétation est beaucoup trop restrictive et il faut partir du principe que l'exigence d'une soulte en espèces doit uniquement être comprise comme impliquant l'indication dans le projet commun d'une soulte exprimée en espèces, rien ne s'opposant par après à ce que les sociétés, de commun accord avec les associés concernés, s'en acquittent par le biais d'un paiement en nature[2162].

456. Les bénéficiaires de la soulte. Seuls les associés de la société scindée peuvent prétendre à l'obtention d'une soulte dans le cadre d'une scission interne[2163] et il n'y a aucune raison d'adopter un traitement différent dans le cas d'une scission transfrontalière. Cependant, compte tenu du fait que le rapport d'échange et le montant de toute soulte éventuelle sont *in fine* l'aboutissement d'un processus de négociations, il peut s'avérer nécessaire afin de garantir la réalisation de l'opération de combiner celle-ci à une distribution au profit des associés des sociétés bénéficiaires. Ainsi, ceux-ci n'auront pas l'impression que leurs droits financiers aux bénéfices reportés sont mis en danger. Une telle distribution ne pourra cependant intervenir qu'en amont de l'opération[2164] ou encore par un aménagement des droits attachés aux nouvelles actions[2165].

457. L'hypothèse d'une soulte négative. Il découle de la terminologie utilisée par le législateur européen et, plus précisément, de l'emploi du terme « *attribution* » que seule l'hypothèse d'une soulte devant être payée aux associés de la société scindée a été envisagée pour régler la problématique des rompus, que ce soit dans l'hypothèse des fusions internes[2166] ou transfrontalières[2167] ou encore dans celle des scissions internes[2168] ou transfrontalières. Cependant, il aurait également pu être envisagé de remédier à cette problématique en imposant aux associés de la société scindée de procéder à un apport additionnel au profit d'une ou des société(s) bénéficiaire(s). Rien ne s'oppose à cette solution qui peut présenter une certaine utilité en présence de rompus et si les sociétés bénéficiaires se retrouvent dans l'incapacité de procéder au paiement d'une soulte en raison d'un manque de liquidités. Cependant, il est généralement considéré qu'un tel mécanisme requerra à tout le moins l'approbation de tous les associés concernés[2169], ce qui s'explique aisément par le fait que cela équivaut à augmenter leurs engagements. Il n'en demeure pas moins que, du point de vue des créanciers des sociétés concernées, une

2159 Art. 136, § 1er de la Directive Sociétés.
2160 Art. 89, § 1er et 90, § 1er de la Directive Sociétés.
2161 Art. 119, § 2 de la Directive Sociétés.
2162 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 22.
2163 Art. 136, § 1er de la Directive Sociétés.
2164 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 22.
2165 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1er, Section 3, § 7, B., 4.
2166 Art. 89, § 1er et 90, § 1er de la Directive Sociétés.
2167 Art. 119, § 2 de la Directive Sociétés.
2168 Art. 136, § 1er de la Directive Sociétés.
2169 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 22.

telle flexibilité s'avérerait potentiellement intéressante dans la mesure où elle limiterait l'impact négatif du paiement d'une soulte en espèces sur les liquidités de la société concernée[2170].

2.3. La date du rapport d'échange

458. Une nécessité découlant du caractère pertinent et raisonnable. Il est également intéressant de relever que la Directive Sociétés ne contient pas de mention spécifique relative à la date à laquelle il convient de se placer pour procéder à l'établissement du rapport d'échange[2171]. Il a dès lors été argumenté dans le cadre des fusions internes que celle-ci devait correspondre à la date de prise d'effet comptable de l'opération[2172]. Cependant, s'il est vrai que l'on comprendrait difficilement pourquoi il conviendrait de se placer en amont de la date de prise d'effet comptable de l'opération pour procéder aux évaluations respectives des sociétés impliquées, une telle contrainte d'une part ne se retrouve dans aucune des opérations visées par la Directive Sociétés et, d'autre part, méconnaît, d'une certaine manière, la distinction entre valeur d'apport et rapport d'échange. En effet, si la valeur d'apport, qui désigne simplement la valeur à laquelle les actifs et passifs de la société scindée seront comptabilisés dans le chef de chacune des sociétés bénéficiaires[2173], est soumise aux principes comptables[2174], le rapport d'échange est avant tout issu d'un processus de négociation et se doit uniquement d'être pertinent et raisonnable[2175]. Il s'ensuit que les parties à l'opération jouissent d'une certaine liberté quant à l'établissement de celui-ci, y compris à l'égard du choix de la date des évaluations respectives des sociétés impliquées. Afin de garantir toutefois un rapport d'échange pertinent et raisonnable susceptible d'être accepté par les assemblées générales des associés, il est plus judicieux de se baser sur des comptes intérimaires établis à une date aussi proche que possible de celle du projet de scission pour procéder aux évaluations respectives. Ceci est d'autant plus vrai que dans le cadre de la vérification du caractère pertinent et raisonnable du rapport d'échange effectuée par un expert à un stade ultérieur de la procédure[2176], celui-ci se basera non seulement sur les comptes annuels et les comptes consolidés, s'il y en a, des sociétés impliquées, mais également sur les derniers états financiers disponibles[2177] ou toute autre information financière à laquelle l'expert aura accès[2178].

2170 Sur ce risque pour les créanciers, voir *infra* n° 701.

2171 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 166 et R. KIEM, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *op. cit.*, p. 1095.

2172 G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *op. cit.*, p. 43 et P. VAN OMMESLAGHE, « La réforme des fusions et des scissions de sociétés en droit belge », in *Le droit des affaires en évolution*, Actes de la 1re Journée du Juriste d'Entreprises, tenue à Bruxelles le 15 novembre 1990, Bruylant, Bruxelles, 1992, p. 125.

2173 J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 28, n° 49 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 162, n° 213.

2174 J.-M. MOULIN, *ibidem*, p. 28, n° 49.

2175 Art. 96, § 2 et 142, § 2 de la Directive Sociétés.

2176 À ce sujet, voir *infra* nos 577 à 579.

2177 Recommandation professionnelle de l'IRE sur la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre des opérations de fusions et de scissions du 28 juin 2005, http://www.ire.lu (22/06/2017), pp. 4 et 5.

2178 Norme de l'IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021), pp. 5 et 6.

2.4. Une mention facultative dans certaines hypothèses

459. Le sort des actions détenues par une société bénéficiaire dans la société scindée. Si le rapport d'échange apparaît dans la plupart des cas comme un élément fondamental du projet de scission, il n'est toutefois pas toujours nécessaire d'en établir un. Cette conclusion découle du fait que dans le cadre des scissions internes, (i) une société bénéficiaire ne se verra attribuer aucune action en échange de celles qu'elle détient elle-même ou par un intermédiaire agissant pour le compte de celle-ci dans la société scindée[2179] et (ii) les actions détenues par la société scindée dans son propre capital, soit directement, soit par un intermédiaire agissant pour le compte de celle-ci, ne feront l'objet d'aucun échange[2180]. Par conséquent, en cas de scission par absorption d'une filiale commune au profit des seuls associés de celle-ci, aucune nouvelle action ne devra être émise. Il en découle dès lors que l'établissement d'un rapport d'échange sera superflu dans une telle hypothèse[2181]. Il en sera de même dans l'hypothèse d'une scission partielle d'une filiale au profit de sa société mère. Motivée par le souci de limiter les risques de fictivité du capital social dans le cadre de la détention d'actions propres, cette solution doit être identique en matière de scissions transfrontalières.

3. *Les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires*

460. Un certain nombre d'informations pratiques à fournir. Le projet commun de scission transfrontalière par acquisition ou mixte, à l'instar d'un projet de scission interne[2182], de fusion interne[2183] ou encore de fusion transfrontalière[2184] et de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés[2185] devra également comporter certaines indications relatives aux modalités entourant la remise des actions aux associés de la société scindée. Il conviendra dès lors d'indiquer non seulement la répartition des frais liés à l'émission des nouvelles actions, mais également s'il s'agira d'actions propres détenues par les sociétés bénéficiaires ou s'il sera, au contraire, nécessaire de procéder à une nouvelle émission d'actions[2186]. Le montant exact des frais liés à l'attribution des nouvelles actions n'est, pour sa part, pas requis[2187], ce qui s'explique notamment par le fait que ce dernier est, à ce stade de la procédure, encore susceptible de fluctuer fortement. Les modalités peuvent également concerner une éventuelle modification de la valeur nominale des actions des sociétés bénéficiaires si les parties souhaitent s'assurer dans le cadre de l'opération que chaque minoritaire

2179 Art. 151, § 2, a) de la Directive Sociétés.
2180 Art. 151, § 2, b) de la Directive Sociétés.
2181 Sur les opérations simplifiées, voir *infra* n°s 671 à 682.
2182 Art. 137, § 2, c) de la Directive Sociétés.
2183 Art. 91, § 2, c) de la Directive Sociétés.
2184 Art. 122, c) de la Directive Sociétés.
2185 Art. 160*quinquies*, c) de la Directive Mobilité.
2186 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 13 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 243 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 5, n°s 35 et 36 et § 126, n° 44.
2187 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 13 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 5, n° 35 et § 126, n° 44.

ait la possibilité d'obtenir à tout le moins une action dans le capital d'une des sociétés bénéficiaires[2188].

461. Quid en cas d'échange partiel ou d'absence d'échange ? S'il devait s'avérer que l'attribution des nouvelles actions n'était pas nécessaire, soit totalement, soit partiellement[2189], il conviendrait, afin de garantir une information adéquate des associés[2190], de préciser les circonstances factuelles justifiant l'absence d'attribution d'actions des sociétés bénéficiaires. Ainsi, à titre d'illustration, dans l'hypothèse de la scission d'une société détenant huit pourcents de son propre capital social, il conviendra d'indiquer d'une part les modalités spécifiques liées à l'attribution d'actions des sociétés bénéficiaires en échange d'actions représentant nonante-deux pour cent du capital social de la société scindée et, d'autre part, d'indiquer que les huit pourcents restant ne donneront droit à aucune action des sociétés bénéficiaires au motif qu'il s'agit d'actions propres.

462. La règle de conflit de lois applicable en la matière. Il reste toutefois encore à clarifier ce qu'il convient de faire en présence d'une législation nationale imposant certaines mentions additionnelles relatives à l'attribution des actions des sociétés bénéficiaires. Il en sera ainsi par exemple en droit allemand dans l'hypothèse de la scission où les sociétés bénéficiaires sont des sociétés anonymes[2191] ou encore des sociétés en commandite par actions[2192]. En effet, dans une telle hypothèse, il sera requis de procéder à la nomination d'un mandataire qui sera chargé de recueillir les actions attribuées et, le cas échéant, la soulte en espèces et les informations relatives à ce mandataire devront figurer dans le projet commun de scission[2193]. Ce mécanisme, également utilisé pour les sociétés anonymes en droit autrichien[2194], est inconnu en droit belge ou en droit luxembourgeois et sert essentiellement à protéger les associés de la société scindée[2195] dans la mesure où l'opération, dans l'hypothèse d'une scission interne, ne pourra être inscrite auprès du registre des sociétés et, par conséquent, prendre effet en vertu du droit allemand[2196] ou du droit autrichien[2197], qu'une fois que le mandataire aura confirmé à la juridiction compétente qu'il a reçu tant les nouvelles actions que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces. Dans le cas d'une scission transfrontalière, il conviendra dès lors de déterminer si ce mécanisme devra, ou non, trouver application, ce qui ne sera pas sans conséquences sur le contenu du projet de scission. À cet égard, il aurait été possible de recourir au principe de l'application cumulative des différents droits nationaux tout en privilégiant la norme la plus sévère[2198] étant donné que la détermination du contenu du projet

2188 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 5, n° 8.
2189 Art. 151, § 2 de la Directive Sociétés.
2190 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 246.
2191 §§ 71(1) et 125 UmwG.
2192 §§ 71(1) ; 78 et 125 UmwG.
2193 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 24.
2194 § 17(5) SpaltG et § 225a(2) öAktG.
2195 J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 243 et 244.
2196 §§ 71(1) ; 78 ; 125 et 131(1) UmwG.
2197 § 17(5) SpaltG et § 225a(2) öAktG.
2198 Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 313 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 182 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 392 et 393 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, pp. 188 et 189 et Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 31.

commun de scission requiert en principe un traitement unitaire[2199]. Cependant, adopter ce point de vue revient à méconnaître que l'obligation d'ajouter les informations relatives au mandataire n'est en réalité qu'une conséquence des règles relatives à l'émission des actions dans le chef de la société absorbante. Il faudrait donc en réalité recourir à une application distributive des droits en présence[2200], la nomination d'un mandataire n'étant par conséquent requise que lorsque la *lex societatis* des sociétés bénéficiaires le requiert[2201]. Il reste encore à préciser que dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière où seule la *lex societatis* applicable à une des sociétés bénéficiaires impose le mécanisme de nomination d'un mandataire, il ne sera nécessaire de prévoir celui-ci que pour l'attribution des actions de cette seule société. À titre d'illustration, ce sera le cas dans l'hypothèse de la scission transfrontalière d'une société anonyme de droit luxembourgeois au profit d'une société anonyme de droit belge et d'une société anonyme de droit allemand, pour peu que le législateur allemand étende la solution applicable aux scissions internes[2202] aux scissions transfrontalières. En effet, dans une telle hypothèse, il ne sera pas nécessaire de nommer de mandataire pour l'attribution des nouvelles actions de la société bénéficiaire de droit belge.

4. *La date à partir de laquelle les actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toutes modalités particulières relatives à ce droit*

463. Un risque pour les associés des sociétés bénéficiaires. En l'absence de disposition contraire, le droit de participer aux bénéfices des sociétés absorbantes suite à la prise d'effet de la scission transfrontalière devrait être acquis dès l'attribution des nouveaux titres. Cependant, cette date ne coïncidera en général pas avec le début de l'exercice social des sociétés absorbantes de sorte que les droits économiques attachés aux nouvelles actions devraient en principe également porter sur les bénéfices réalisés antérieurement à la réalisation de l'opération et non encore distribués définitivement[2203]. Cet état de fait est susceptible de porter préjudice aux associés des sociétés absorbantes qui verront leur part des bénéfices distribuables réduite à due concurrence. À cela s'ajoute encore le fait qu'une scission est une opération complexe dont la date de prise d'effet n'est que très difficile à déterminer avec exactitude a priori.

464. Une date flexible. Pour remédier à ces incertitudes[2204], la Directive Sociétés prévoit, tant en matière de fusions internes[2205] ou transfrontalières[2206] que de

2199 57e considérant de la Directive Sociétés et Fl. Parrein, *ibidem*, p. 313 ; E. Roelofs, *ibidem*, p. 393 et Th. Tilquin et J.-A. Delcorde, « La fusion transfrontalière… », *ibidem*, p. 46.

2200 H. Le Nabasque, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, pp. 2 et 3 ; U. Lennerz, *op. cit.*, pp. 264 et 265 ; Th. Prüm, *op. cit.*, pp. 85 et 86 ; E. Roelofs, *ibidem*, p. 394 ; Th. Tilquin, J.-A. Delcorde, Ph. Malherbe, D. Garabedian et P. Geerebaert, *op. cit.*, p. 30 ; Th. Tilquin et J.-A. Delcorde, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 189 et Th. Tilquin et J.-A. Delcorde, « La fusion transfrontalière… », *ibidem*, p. 45 *Contra :* S. Herrler et S. Schneider, *op. cit.*, p. 796.

2201 R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 14.

2202 §§ 71(1) ; 78 et 125 UmwG.

2203 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 251 et Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 255, n° 365.

2204 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 251.

2205 Art. 91, § 2, d) de la Directive Sociétés.

2206 Art. 122, e) de la Directive Sociétés.

scissions internes[2207], qu'il est possible de fixer une date dans le projet commun de scission à partir de laquelle le droit de participer aux bénéfices sera acquis aux associés de la société scindée. De manière assez surprenante, alors qu'il s'agit là d'un problème ne présentant un véritable intérêt que dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, la Directive Mobilité propose également que cette mention figure dans le projet commun de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés[2208]. Il faut à nouveau y voir une manifestation de la volonté du législateur européen de préparer le terrain pour une harmonisation de tous les types de scissions transfrontalières. Cette date peut être fixe, comme par exemple la date de la fin de l'exercice social précédent de la société scindée ou encore une autre date rétroactive au choix des parties[2209], mais elle peut également être variable[2210], par exemple si les parties souhaitent faire coïncider celle-ci avec la date de prise d'effet juridique de la scission transfrontalière. Par souci de simplification et de cohérence comptable, il est généralement conseillé d'aligner la date de participation aux bénéfices sur celle de la prise d'effet comptable[2211], même si ce n'est pas obligatoire[2212].

465. Les modalités relatives aux droits économiques attachés aux nouvelles actions. En plus de la date à partir de laquelle le droit de participer aux bénéfices de la société absorbante est acquis, il conviendra également de préciser les différentes modalités susceptibles d'affecter celui-ci. Il faudra donc indiquer dans le projet commun toutes les spécificités dérogeant au principe selon lequel chaque action donne droit à une part proportionnelle des bénéfices de la société[2213]. Il est ainsi possible de préciser que tous les dividendes intérimaires intervenus préalablement à la réalisation de l'opération devront être imputés sur le montant total des bénéfices de l'année en cours[2214] et que les actions nouvelles ne donneront droit qu'à une quote-part de la différence entre le bénéfice annuel réalisé et les dividendes intérimaires distribués préalablement à la réalisation de l'opération. Dans un même ordre d'idées, toutes les dispositions spécifiques relatives à la distribution des bénéfices contenues dans les statuts des sociétés absorbantes ou découlant d'autres arrangements entre associés, comme non seulement les *waterfall clauses*[2215] ou encore celles

2207 Art. 137, § 2, d) de la Directive Sociétés.
2208 Art. 160*quinquies*, f) de la Directive Mobilité.
2209 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 28 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 45.
2210 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 5, n° 29 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 126, n° 45.
2211 G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 126, n° 14.
2212 M. HEIDENHAIN, *op. cit.*, p. 2876 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 126, n° 14.
2213 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 252 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 46.
2214 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 255, n° 365.
2215 Par *waterfall clause*, on entend toute clause contractuelle établissant un ordre de priorité précis pour (i) la distribution des bénéfices et/ou la répartition des *bonis* de liquidation d'une société entre actionnaires ou porteurs d'autres titres ou (ii) le paiement des dettes de la société à ses créanciers. De telles clauses sont fréquentes dans les pactes d'actionnaires, les *joint venture agreements* ou encore les *intercreditor agreements*. Voir https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com et P. HOSS, « Les nouveaux droits des actionnaires » in *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 209 pour plus d'information.

établissant les conditions d'actions traçantes[2216], mais également celles imposant une thésaurisation d'une partie des bénéfices, celles instituant des règles de quorum et de majorité renforcées pour toute distribution ou encore celles déviant des pratiques habituelles de la société scindée, devront figurer dans le projet commun de scission[2217].

466. Une interaction avec le rapport d'échange. Quelles que soient les conditions dont les parties à l'opération voudront assortir le droit aux bénéfices attaché aux actions nouvelles, il ne faudra pas perdre de vue qu'une opération de scission transfrontalière est avant tout l'aboutissement d'un processus de négociation d'ensemble. Il s'ensuit que les spécificités relatives au partage des bénéfices sont susceptibles d'avoir un impact sur d'autres aspects de l'opération et principalement sur celles relatives à l'établissement du rapport d'échange[2218]. En effet, l'établissement du rapport d'échange peut se faire en considération de données de nature davantage financière[2219] au nombre desquelles peuvent figurer la date et les modalités relatives à la distribution des bénéfices. Cet enchevêtrement a cependant un effet positif indéniable dans certaines circonstances, dans la mesure où il est susceptible de simplifier les négociations du rapport d'échange. En effet, par exemple en présence d'actions partiellement libérées de la société scindée, il sera possible d'imputer le solde du prix de souscription ainsi qu'un intérêt sur celui-ci sur la quote-part des bénéfices futurs des sociétés bénéficiaires auxquels les actions nouvellement émises donneront droit[2220].

467. La limite des clauses léonines. Cependant, si les parties jouissent d'une certaine liberté en la matière, celle-ci n'est toutefois pas absolue. En effet, elles ne pourront en tout état de cause pas contrevenir à la prohibition des clauses léonines[2221] en dépouillant une catégorie d'associés de leurs droits aux bénéfices ou en la dispensant de toute contribution aux pertes des sociétés bénéficiaires de l'opération.

2216 Par *actions traçantes* ou *tracking stock*, on entend une classe distincte d'actions émises par une société qui trace les résultats économiques d'un actif ou d'une filiale spécifiques. En d'autres termes, les droits financiers attachés à ces actions seront intimement liés aux performances de l'actif ou de la filiale tracés. Ce type d'actions est fréquemment utilisé (i) pour structurer des *private equity investments* afin d'opérer une ségrégation des différents investissements détenus par une société holding ou encore (ii) par des sociétés cotées pour mettre en valeur une filiale hautement valorisée. Voir B. Caradet et J. Herbert, « Capital and financial markets », *I.B.L.J.*, 2001, 2, pp. 220 et 221 ; P. Hoss, *ibidem*, pp. 208–210 et V. Marrison, « Tracking stock », *I.C.C.L.R.*, 2000, 11(7), pp. 235–239 pour plus d'informations.

2217 R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer, *op. cit.*, § 5, n° 27 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 252.

2218 C. H. Barz, « Rechtliche Fragen zur Verschmelzung von Unternehmen », *AG*, 1972, p. 3 ; M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 14 ; R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 28 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, pp. 251 et 252 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 45.

2219 J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 28, n° 49.

2220 G.-A. Dal et M. Van Den Abbeele, *op. cit.*, pp. 55 et 56 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 126, n° 45.

2221 Art. 5:14 ; 6:15 et 7:16 du CSA et art. 1855 du Code civil luxembourgeois, disponible sur www.legilux.lu (07/11/2021). Voir à ce sujet en droit belge : J. Malherbe, Y. de Cordt, Ph. Lambrecht, Ph. Malherbe et H. Culot, *Précis de la Faculté de Droit et de Criminologie de l'Université catholique de Louvain – Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 228 et 229, nos 456 à 458.

5. *La ou les date(s) de prise d'effet comptable*

468. Le principe de la rétroactivité comptable. Le projet commun devra ensuite contenir la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée seront, d'un point de vue comptable, accomplies pour le compte des sociétés bénéficiaires. Cette règle, que l'on retrouve à l'identique dans les opérations de scission interne[2222] ou encore de fusion interne[2223] ou transfrontalière[2224] se retrouve également dans le régime des scissions par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité[2225]. Elle permet de pallier l'aléa qui affecte la date de prise d'effet juridique de l'opération en fixant une date de prise d'effet économique[2226]. Ces deux dates pourraient évidemment coïncider, mais il ne s'agit pas là d'une obligation dans la mesure où la date de prise d'effet comptable pourra être, dans certaines limites, déterminée librement par les parties. Ainsi, il sera possible aux parties de faire en sorte que la date de prise d'effet comptable soit identique à la date de début d'un exercice social[2227] ou encore de la fixer à une date variable en fonction, par exemple, de la date des assemblées générales approuvant l'opération[2228]. Au-delà de cette simplification comptable, la suppression de l'incertitude affectant la date de prise d'effet juridique permettra également de faciliter l'établissement du rapport d'échange en fixant la date de prise d'effet comptable à la date des comptes utilisés pour procéder à l'évaluation des sociétés impliquées[2229]. Cette liberté n'est toutefois pas absolue dans la mesure où, par application du principe de l'annualité des comptes[2230], elle ne pourra pas être antérieure à la date de clôture de l'année sociale précédente[2231], ce qui figure *expressis verbis* dans les dispositions du Code des sociétés et associations belge applicable en la matière[2232].

469. *Quid* du report à une date postérieure à la prise d'effet juridique ? La possibilité de prévoir que la scission ne produira ses effets comptables qu'à une date postérieure à celle de la prise d'effet juridique ne semble pas reconnue[2233]. Cette solution n'est pas surprenante dans la mesure où un report

2222 Art. 137, § 2, e) de la Directive Sociétés.
2223 Art. 91, § 2, e) de la Directive Sociétés.
2224 Art. 122, f) de la Directive Sociétés.
2225 Art. 160*quinquies*, g) de la Directive Mobilité.
2226 G. LANFERMANN in H. KALLMEYER, *op. cit.*, § 5, n°s 31 et 32 et F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 16.
2227 D. BOONE et Ch. PIETTE, « Fusion et rétroactivité », *JurisNews*, 7-8/2014, p. 277 ; P. HAINAUT-HAMENDE, « La société anonyme. Deuxième partie : Opérations sur le capital. Emissions publiques. Transformation. Fusion – Scission », *Rep. not.*, Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 3, 2 février, Bruxelles, Larcier, 2009, n°s 853 et 856 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 53 et § 126, n° 48.
2228 G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 36 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 253 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 5, n° 53 et § 126, n° 48.
2229 D. BOONE et Ch. PIETTE, *op. cit.*, p. 277 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n° 853 ; S. MAQUET, *op. cit.*, p. 36 et J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 52, n° 127.
2230 Al. STEICHEN, *op. cit.*, p. 412, n° 557.
2231 D. BOONE et Ch. PIETTE, *op. cit.*, p. 278 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n° 853 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 267, n° 385.
2232 Art. 12:59, al. 2, 5° *in fine* du CSA qui prévoit que la date de prise d'effet comptable ne peut « remonter avant le premier jour de l'exercice social en cours ».
2233 G. LANFERMANN in H. KALLMEYER, *op. cit.*, § 122c, n° 22 ; Ph. ERNST et J. VERSTRAELEN, *Réorganisations juridiques de sociétés*, coll. Etudes pratiques de droit fiscal, n° 16, Bruxelles, Kluwer, 2002, p. 54 et P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n° 853 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 267, n° 388.

comptable aurait eu pour conséquence qu'il aurait fallu maintenir la société scindée comptablement en vie alors même que juridiquement elle aurait cessé, par définition[2234], d'exister au jour de la prise d'effet juridique de l'opération.

470. La règle de conflit de lois. Si les principes sous-tendant la rétroactivité comptable ne posent de prime abord aucun souci, il convient encore de déterminer l'attitude face à des législations nationales contradictoires en la matière. En effet, la Directive Sociétés n'ayant fixé aucune limite spécifique en la matière[2235], il était loisible aux États membres de restreindre cette rétroactivité au-delà des limites décrites ci-dessus. Certains États membres, comme la Roumanie[2236], ont dès lors été jusqu'à imposer une identité entre la date de prise d'effet juridique et la date de prise d'effet comptable, alors que d'autres autorisent une dissociation entre les deux selon des limites variables[2237]. Ainsi, en droit autrichien, par exemple, en matière de fusions transfrontalières, la date de prise d'effet comptable ne peut être antérieure de plus de neuf mois à la date de dépôt de l'opération[2238], celle-ci se trouvant encore en amont de sa date de prise d'effet juridique[2239]. De même en droit allemand, si la société apporteuse est soumise à celui-ci, la date de prise d'effet comptable ne pourra être antérieure de plus de huit mois à la date de dépôt de l'opération[2240]. De telles limites ne se retrouvent en revanche ni en droit belge, ni en droit luxembourgeois. Comme il s'agit d'un aspect proprement transfrontalier de l'opération, un conflit de lois devra être résolu par le biais d'une application cumulative des différentes *lex societatis* en présence, tout en privilégiant la norme la plus sévère. La norme limitant le plus la rétroactivité comptable devra dès lors être appliquée. Malgré cette règle, l'exemple des fusions transfrontalières a montré que l'absence d'harmonisation de la prise d'effet comptable pouvait aboutir à la situation déplaisante où les transactions de la société absorbée n'étaient pas déclarées pendant une certaine période ou, au contraire, faisaient l'objet d'une double déclaration[2241].

471. Une innovation de la Proposition de la Commission. Face aux difficultés pratiques causées par des législations contradictoires en la matière[2242], et en vue de renforcer la sécurité juridique des opérations transfrontalières[2243], la Proposition de la Commission intégrait une règle spécifique destinée à harmoniser les dates de prise d'effet comptable dans l'hypothèse d'une scission

2234 Art. 136, § 1er et 155, § 1er de la Directive Sociétés.
2235 Art. 91, § 2, e), 122, f) et 137, § 2, e) de la Directive Sociétés.
2236 St. Reynolds, A. Scherrer et E. Truli, *op. cit.*, p. 49 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 65.
2237 St. Reynolds, A. Scherrer et E. Truli, *op. cit.*, p. 48 ; J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 22 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 64 et s..
2238 § 220 (3) öAktG et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 254.
2239 § 225a (3) öAktG.
2240 Il s'agit d'une conséquence de la règle prévue par le § 17 (2) UmwG qui impose de joindre un bilan final de la société scindée à la demande d'enregistrement de l'opération, celui-ci ne pouvant être antérieur de plus de huit mois à partir de la date de dépôt. Voir Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 24.
2241 30e considérant de la Proposition de la Commission.
2242 Voir en ce sens : W. Bayer et J. Schmidt, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569 ; J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 356 ; J. Schmidt, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 242 et J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 240.
2243 Voir en ce sens : F. Bernard, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 17.

transfrontalière[2244]. Il était ainsi prévu que les dates de prise d'effet comptable pouvaient être fixées par l'organe de direction ou d'administration dans le projet de scission[2245], mais que celles-ci correspondraient nécessairement à la date de prise d'effet juridique en l'absence de disposition contraire dans le projet[2246]. Il était en outre précisé que si une date de prise d'effet comptable distincte de la date de prise d'effet juridique était fixée, celle-ci (i) ne pouvait être antérieure à la date du bilan des derniers états financiers établis et publiés par la société scindée, (ii) ne pouvait, pour chaque société bénéficiaire, être antérieure à la date de constitution de la société bénéficiaire en question et (iii) devait permettre à chaque société issue de l'opération d'établir les états financiers annuels, conformément au droit applicable à la date du bilan immédiatement après la date à laquelle la scission transfrontalière a pris effet[2247]. La Proposition de la Commission prenait également le soin de préciser que (i) les États membres devaient veiller à ce que les dates de prise d'effet comptable soient considérées comme les dates à compter desquelles les transactions transférées par la société scindée seront considérées comme étant celles de chaque société bénéficiaire par le droit national applicable à toutes les sociétés bénéficiaires[2248] et (ii) les États membres devaient veiller à ce que pour la comptabilisation et l'évaluation des actifs et passifs, les régimes comptables des sociétés bénéficiaires soient utilisés à compter des dates respectives de prise d'effet comptable[2249]. Une telle réglementation aurait tout à fait pu se retrouver dans un régime plus général des scissions transfrontalières impliquant au moins une société bénéficiaire préexistante en ajoutant toutefois la précision inspirée du régime des fusions transfrontalières de la Proposition de la Commission[2250] selon laquelle chaque date de prise d'effet comptable ne pourrait être antérieure à la date du bilan des derniers états financiers annuels établis et publiés par la société scindée et la société bénéficiaire concernée. Bien que l'harmonisation de la date de prise d'effet comptable fût saluée par de nombreux auteurs[2251], elle disparut dès le Premier Compromis de la Présidence[2252] et ne réapparut ni dans le Deuxième Compromis de la Présidence[2253], ni dans le Compromis des Représentants Permanents[2254], ni dans le Compromis Final, ni dans la Proposition du Parlement.

472. L'incidence sur les autres aspects du projet commun. Malgré cette liberté, il est fréquent que cette date corresponde à la date à partir de laquelle les nouvelles actions donneront le droit de participer aux bénéfices des sociétés

2244 Art. 160*septies* de la Proposition de la Commission.
2245 Art. 160*septies*, § 1er, al. 1er de la Proposition de la Commission.
2246 Art. 160*septies*, § 1er, al. 2 de la Proposition de la Commission.
2247 Art. 160*septies*, § 1er, al. 3 de la Proposition de la Commission.
2248 Art. 160*septies*, § 2 de la Proposition de la Commission.
2249 Art. 160*septies*, § 2 de la Proposition de la Commission.
2250 Art. 122*bis*, § 1er, a) de la Proposition de la Commission.
2251 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 303 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 240.
2252 Art. 160f du Premier Compromis de la Présidence.
2253 Art. 160f du Deuxième Compromis de la Présidence.
2254 Art. 160f du Compromis des Représentants Permanents.

bénéficiaires[2255]. Cette solution a l'indéniable avantage de la cohérence dans la mesure où il est logique que les actions nouvellement attribuées n'emportent un droit financier qu'à partir du moment où les sociétés bénéficiaires sont en mesure de dégager effectivement un bénéfice d'un point de vue comptable des actifs et passifs qui lui auront été transférés. En revanche, si les parties optent pour une dissociation de ces deux dates, il faudra en tenir compte au moment de l'établissement du rapport d'échange[2256].

473. Une date nécessairement unique ? Une question intéressante à aborder est celle de savoir s'il est possible de prévoir une date de prise d'effet comptable distincte pour chacune des sociétés impliquées dans l'opération, par exemple dans l'hypothèse où les parties souhaiteraient faire coïncider la date de prise d'effet comptable avec celle du début de l'exercice social et que les sociétés bénéficiaires n'ont pas les mêmes dates de début et de fin d'exercice social. Dans une telle hypothèse, il doit être possible de prévoir une date de prise d'effet comptable par société bénéficiaire[2257]. Une telle conception est de plus confortée (i) par la possibilité de prévoir un rapport d'échange distinct par société impliquée dans la scission et (ii) par un argument de texte découlant de la formulation de la Directive Sociétés qui impose l'indication dans le projet commun de la date de prise d'effet comptable pour l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires[2258]. Elle ressort en outre clairement du texte de la Directive Sociétés à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés puisqu'il y est explicitement précisé que le projet devait contenir « *la ou les dates* à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires »[2259]. Cette précision est d'une moindre importance dans le cadre de des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés puisque l'exercice social de chacune des sociétés bénéficiaires commencera nécessairement à la date de constitution de celle-ci et que celles-ci coïncideront avec la date de prise d'effet juridique de l'opération. Cependant, de telles précisions font du sens si le législateur européen souhaitait effectivement préparer le terrain à une initiative destinée à harmoniser les scissions par acquisition et les scissions mixtes. En effet, prévoir des dates de prise d'effet comptable distinctes s'impose d'autant plus dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière par acquisition puisque les sociétés bénéficiaires préexistantes n'auront pas nécessairement le même exercice social.

474. Le cas particulier de la scission partielle. Dans le cas d'une scission partielle, la société scindée subsiste à l'opération. Ceci signifie qu'afin de faciliter la mise en œuvre de la rétroactivité comptable, il conviendra que la société tienne à partir de la date de prise d'effet comptable une comptabilité spécifique relative exclusivement aux éléments actifs et passifs du patrimoine qui

2255 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 35 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, pp. 253 et 254 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 58.
2256 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 5, n° 35 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 5, n° 58.
2257 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 37.
2258 Art. 137, § 2, e) de la Directive Sociétés.
2259 Art. 160*quinquies*, g) de la Directive Mobilité.

seront attribués à la société bénéficiaire[2260]. Une fois que l'opération aura pris effet d'un point de vue juridique, cette comptabilité sera intégrée dans celle de la société bénéficiaire.

6. *Les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard*

475. Un objectif d'information. L'exigence de faire figurer au sein du projet commun la description des droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des associés ou les mesures proposées à leur égard se retrouve à la fois tant dans le régime des fusions internes[2261] et transfrontalières[2262], que dans celui des scissions internes[2263] et transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2264]. Il devrait dès lors en être de même dans le cas des scissions transfrontalières mixtes ou par acquisition. L'objectif premier de cette disposition est d'assurer une information adéquate des associés ordinaires sur tous les régimes particuliers consentis à certains associés ou autres porteurs de titres de la société scindée, et ce afin de garantir une décision éclairée au sein de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération[2265]. Bien que les porteurs de titres de la société scindée soient ceux dont la position privilégiée est la plus susceptible d'être compromise par l'opération, aucune distinction n'est faite entre ceux-ci et les porteurs de titres des sociétés bénéficiaires de sorte qu'il faudra en principe faire figurer le descriptif du traitement réservé à ces deux catégories[2266]. Ainsi, s'il s'avère nécessaire de rompre l'égalité entre associés d'une des sociétés bénéficiaires en octroyant par exemple un droit à un dividende préférentiel à un associé réticent afin de le convaincre de voter en faveur de l'opération envisagée[2267], ce traitement devra être révélé dans le projet commun de scission.

476. Les associés jouissant de droits spéciaux. Le premier groupe visé par cette disposition est celui des associés ayant des droits spéciaux. Par droits spéciaux, on entend non seulement les privilèges de nature financière, mais également tous droits politiques extraordinaires, tels qu'un droit de veto, des actions à vote plural ou encore des droits spécifiques relatifs à la nomination des membres de l'organe de gestion ou d'administration[2268]. *A contrario*, cette disposition ne recouvre pas les avantages consentis individuellement par les

2260 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 17.
2261 Art. 91, § 2, f) de la Directive Sociétés.
2262 Art. 122, g) de la Directive Sociétés.
2263 Art. 137, § 2, f) de la Directive Sociétés.
2264 Art. 160*quinquies*, i) de la Directive Mobilité.
2265 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER, *op. cit.*, § 5, n° 40 ; Fr. BEHRENS, *op. cit.*, p. 88 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 188 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 255 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 55.
2266 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER, *ibidem*, § 5, n° 40 et J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 255.
2267 S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 188 et J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 255.
2268 H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 49.

associés entre eux[2269] et dès lors non assurés par les sociétés bénéficiaires, à l'instar d'un droit de préemption ou d'un droit de sortie conjointe figurant dans un pacte d'associés. À la lumière de l'objectif de cette disposition qui est de garantir une prise de décision éclairée par les associés des sociétés impliquées ne bénéficiant pas d'un traitement privilégié face à une rupture de l'égalité entre associés, il a été avancé que si tous les associés bénéficiaient des mêmes droits privilégiés, il ne serait pas nécessaire de l'indiquer dans le projet commun[2270]. Cependant, il convient de ne pas perdre de vue qu'au-delà de l'information des seuls associés, le projet commun de scission est également destiné à informer les autres *stakeholders*[2271]. Par conséquent, même en cas de traitement égalitaire des associés, tout mécanisme déviant du régime de base que ce soit au niveau des droits financiers ou des droits politiques, devrait faire l'objet d'une mention. En l'absence de droits ou régimes spécifiques, le projet de scission devra, dans certains États membres comme l'Autriche[2272], contenir une mention attestant de l'absence de ceux-ci, alors que dans d'autres, comme l'Allemagne[2273], aucune indication à ce sujet ne sera nécessaire. En cas de scission transfrontalière impliquant des entités situées dans des États membres ayant des pratiques divergentes à cet égard, il conviendra de procéder à une application cumulative des normes en présence tout en privilégiant la règle la plus sévère, c'est-à-dire celle qui impose à tout le moins une mention de l'absence de droits spéciaux.

477. Les porteurs d'autres titres. Au-delà des associés privilégiés politiquement ou financièrement, la disposition vise également les porteurs de titres autres que des actions ou de parts sociales. On entend par là, à titre d'illustration, les titulaires de parts bénéficiaires, d'actions sans droit de vote, de *warrants*, d'obligations ou d'autres instruments, qu'ils soient convertibles ou non. Les mêmes réflexions que celles développées à l'égard des associés détenteurs de droits spéciaux s'appliquent *mutatis mutandis* à la matière.

478. La mention des autres mesures. L'obligation de faire état dans le projet de scission des autres mesures proposées à l'égard des associés ayant des droits spéciaux ou aux porteurs d'autres titres vise l'hypothèse dans laquelle il n'est pas possible d'offrir des droits équivalents dans les sociétés bénéficiaires issues de l'opération[2274]. Dans un tel cas, susceptible de survenir par exemple lorsque la *lex societatis* des sociétés bénéficiaires ne connaît pas certains types de titres prévus par la *lex societatis* de la société scindée, il conviendra de proposer des mesures alternatives tel qu'un paiement en espèces à ce groupe

2269 T. Drygala in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 77 ; R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 41 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 256.

2270 R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 5, n° 41 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, pp. 188 et s. et J. Mitterecker, *ibidem*, p. 256.

2271 Fl. Parrein, *op. cit.*, p. 311 ; Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 174, n° 227 ; P. Van Ommeslaghe, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14 et D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.

2272 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 256.

2273 R. Marsch-Barner in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 40 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 58.

2274 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 257.

de *stakeholders* ou encore le rachat de leurs titres. Ces différents avantages devront être révélés dans le projet de scission afin de permettre non seulement à toutes les personnes intéressées de comprendre le sort qui leur sera réservé à la suite de l'opération, mais également aux créanciers d'apprécier l'éventuelle érosion de leur gage commun qui pourrait en résulter[2275].

479. L'incidence sur les scissions transfrontalières. L'existence de tels droits spéciaux est un élément à prendre en compte au moment d'envisager une opération de scission transfrontalière. En effet, les disparités existant au sein des États membres au sujet des droits spéciaux dont peuvent jouir certaines catégories de *stakeholders* pourront sensiblement complexifier le processus. À titre d'illustration et par analogie, la possibilité en droit français pour certains actionnaires de jouir d'un droit de vote double a été jugée par de nombreux praticiens comme constituant une particularité nationale susceptible d'être un obstacle à la réalisation d'une fusion transfrontalière[2276]. La question sera d'autant plus délicate dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante puisqu'il conviendra également de tenir compte de l'impact des mesures consenties aux titulaires de droit spéciaux de la société scindée sur les associés et titulaires de droits spéciaux de sociétés bénéficiaires. Dans le cadre de la mise en place d'un régime européen des scissions transfrontalières, les dispositions de la Directive Mobilité devraient être modifiées en s'inspirant du régime des scissions internes[2277] de manière à ne pas limiter cet élément du projet de scission aux seuls titulaires de droits spéciaux de la société scindée[2278].

7. *Les avantages particuliers attribués aux experts et aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle*

480. Une transparence dans l'intérêt des associés. Dans le cadre d'une scission interne, il conviendra également de faire figurer dans le projet commun tous les avantages particuliers dont pourraient bénéficier soit les experts destinés à intervenir dans le cadre de l'opération, soit les différents membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des entités impliquées. Cette disposition que l'on retrouve à l'identique dans les scissions internes[2279] et les fusions internes[2280] est sensée permettre aux associés des entités impliquées d'apprécier l'objectivité des différents acteurs étant intervenus dans le cadre du processus préparatoire[2281]. En effet, compte tenu

2275 Sur ce risque pour les créanciers, voir *infra* n° 701.

2276 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 195.

2277 L'art. 137, § 2, f) de la Directive Sociétés précise que la scission devra inclure « les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard ».

2278 L'article 160*quinquies*, i) de la Directive Mobilité précise que le projet de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés devrait uniquement mentionner « les droits accordés par les sociétés bénéficiaires *aux associés de la société scindée* ayant des droits spéciaux *ou aux porteurs de titres autres que des actions représentatives du capital social de la société scindée*, ou les mesures proposées à leur égard ».

2279 Art. 137, § 2, g) de la Directive Sociétés.

2280 Art. 91, § 2, g) de la Directive Sociétés.

2281 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 44 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 257 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 54.

du fait qu'une scission entraîne par définition la disparition de la société scindée et, partant, de ses organes, il n'est pas rare que les membres de ceux-ci se voient attribuer certains avantages destinés à compenser les pertes subies du fait de l'opération. À titre d'illustration, on pourrait citer la promesse d'un poste au sein des entités bénéficiaires, un paiement en espèces ou encore l'octroi de *warrants* par les sociétés bénéficiaires[2282].

481. La portée de l'obligation à l'égard des membres des organes. Cette obligation de transparence ne doit cependant pas s'interpréter trop largement en ce sens que seuls devront être révélés les avantages perçus par les membres des organes d'administration, de direction, de contrôle ou de surveillance à l'occasion de la scission[2283]. En d'autres termes, tout traitement privilégié qui n'aurait pas été octroyé en l'absence de restructuration devra faire l'objet d'une mention spécifique. Il s'ensuit, par exemple, que la rémunération à laquelle un membre du conseil d'administration ou de direction a droit en contrepartie de l'exécution de son mandat ne devra pas être signalée. En revanche, tout traitement de faveur excédant ce qui est dû strictement par la société au titre de cette rémunération ne pourra être gardé sous silence[2284]. De même, la promesse de l'octroi d'une décharge suite à la réalisation de la scission devrait figurer dans le projet commun[2285].

482. Un régime spécifique pour les experts. Pour ce qui est des experts intervenant dans le processus de scission, il n'est pas requis de dévoiler le montant de leurs honoraires perçus pour l'accomplissement de leur mission. En revanche, tout avantage excédant ces émoluments devra faire l'objet d'une mention[2286], les mêmes réflexions que celles relatives aux membres des organes s'appliquant également à leur égard.

483. Une obligation d'autant plus justifiée en matière de scissions transfrontalières. Cette obligation de transparence, si elle est certes déjà justifiée dans l'hypothèse d'une scission interne, l'est d'autant plus dans le cadre d'une scission transfrontalière où les associés des entités impliquées auront, de par la mise en concurrence de plusieurs droits nationaux, plus de difficultés à apprécier les différents avantages attribués aux membres des organes de direction ou de surveillance ou encore aux experts. Ceci explique notamment pourquoi la Proposition de la Commission prévoyait que le projet de scission transfrontalière devrait inclure la description (i) des avantages particuliers accordés aux membres de l'organe d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée[2287] et (ii) de tous les avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet[2288]. Si les mentions relatives aux avantages perçus par les membres de l'organe de gestion se sont effectivement

2282 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 257 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 54.
2283 R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 25 et J. Mitterecker, *ibidem*, p. 258.
2284 R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 5, n° 44 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 54.
2285 R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 5, n° 44.
2286 R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 5, n° 46.
2287 Art. 160*sexies*, § 1er, h) de la Proposition de la Commission.
2288 Art. 160*sexies*, § 1er, j) de la Proposition de la Commission.

retrouvées dans le régime final de la Directive Mobilité[2289], il n'en va pas de même des dispositions relatives aux avantages perçus par les experts indépendants. En effet, elle a été supprimée dès le Premier Compromis de la Présidence[2290] et n'est pas réapparue par la suite[2291]. Cette suppression s'explique partiellement par l'introduction de règles spécifiques destinées à garantir l'indépendance de l'expert intervenant au cours du processus de scission[2292], même si compte tenu des risques accrus engendrés par une scission transfrontalière impliquant au moins une société bénéficiaire préexistante tant pour les créanciers[2293] que pour les associés minoritaires[2294], une telle mention mériterait d'être réintégrée dans un régime européen plus général des scissions transfrontalières[2295] et ce, d'autant plus qu'on ne s'explique que difficilement pourquoi de tels avantages devraient être mentionnés en cas de scission interne[2296], mais pas en cas de scission transfrontalière[2297]. Il est toutefois également possible d'y voir un indice de la volonté du législateur européen de procéder à une harmonisation plus ambitieuse en matière de scission et qui couvrirait également les scissions internes.

8. *La description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif de la société scindée*

484. Plan du point 8. Pour saisir clairement les différents enjeux se cachant derrière cette mention, il convient, après quelques précisions liminaires (8.1), de clarifier quels sont les éléments visés (8.2) ainsi que l'étendue de cette obligation (8.3) et le principe de la répartition libre (8.4), pour ensuite s'intéresser au sort des éléments oubliés (8.5).

8.1. Présentation

485. Une exigence liée aux caractéristiques d'une scission. Cet élément est propre au régime des scissions[2298] et ne se retrouve pas dans le projet commun d'une fusion interne[2299] ou transfrontalière[2300]. En effet, une telle description ne se justifie que dans l'hypothèse d'une pluralité de sociétés bénéficiaires, ce qui, à l'exception du cas particulier de la scission partielle, est une caractéristique fondamentale d'une opération de scission.

2289 Art. 160*quinquies*, h) de la Directive Mobilité.
2290 Art. 160e, § 1er du Premier Compromis de la Présidence.
2291 Art. 160e, § 1er du Deuxième Compromis de la Présidence ; art. 160e, § 1er du Compromis des Représentants Permanents ; art. 160e du Compromis Final et art. 160*sexies* de la Proposition du Parlement.
2292 Art. 160*unvicies* de la Directive Mobilité et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 65, n° 26.
2293 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 1.
2294 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 1.
2295 Voir en ce sens de manière plus générale en faveur d'une réintégration de cette mention obligatoire : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 356.
2296 Art. 137, g) de la Directive Sociétés.
2297 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.
2298 Art. 137, § 2, h) de la Directive Sociétés et art. 160*quinquies*, l) de la Directive Mobilité.
2299 Art. 91, § 2 de la Directive Sociétés.
2300 Art. 122 de la Directive Sociétés.

8.2. Les éléments visés

486. Les éléments du patrimoine actif et passif. Les termes éléments du patrimoine actif et passif doivent s'entendre très largement en ce sens qu'ils recouvrent tant des éléments matériels tels qu'un immeuble ou un meuble, que des éléments immatériels tels qu'un brevet, une créance ou encore une dette[2301]. De plus, ce sont non seulement les éléments certains qui devront être alloués, mais également les éléments incertains ou encore inconnus. Ainsi, par exemple, les éléments de passif connus de la société scindée mais dont le montant n'est pas encore certain et qui ne sont que provisionnés dans les comptes de celle-ci sont visés, mais également les éléments de passif encore inconnus au moment de la scission, tels que la responsabilité pour des dégâts environnementaux antérieurs à l'opération[2302]. Il en sera de même des transactions commerciales en cours de négociations[2303].

487. Quid des éléments intransmissibles ? Une question intéressante à se poser est celle de la nécessité de mentionner ou non les éléments du patrimoine qui ne pourront être transférés par le biais de la transmission universelle dont s'accompagnera l'opération. Est-il par exemple nécessaire d'énumérer les autorisations administratives personnelles[2304] ou des contrats affectés d'une clause d'incessibilité couvrant explicitement le transfert à titre universel dont s'accompagne une scission[2305] ? Si la question se pose moins à l'égard des scissions partielles puisqu'à l'égard de ces dernières, le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés prévoit explicitement que le projet de scission devra intégrer une description des éléments conservés par la société scindée[2306], ce qui inclura nécessairement les éléments intransmissibles, elle revêt une autre dimension en cas de scission complète. Si on s'en tient à une interprétation littérale du texte de la Directive Mobilité, on constate que seuls sont à énumérer les éléments du patrimoine à répartir entre les sociétés bénéficiaires[2307]. *A contrario*, on pourrait en conclure que les éléments impossibles à répartir ne sont pas visés par cette disposition. Ceci étant dit, compte tenu du fait que le projet commun de scission poursuit également un objectif d'information des *stakeholders*[2308] et que les parties ont la possibilité

2301 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 56 et M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 19.

2302 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 27 et Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 335, n° 501.

2303 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 56.

2304 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 126, n° 59 et M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 20.

2305 Sur ce mécanisme spécifique de protection des intérêts des créanciers, voir *infra* n°s 851 à 853.

2306 Art. 160*quinquies*, l) de la Directive Mobilité.

2307 *Ibidem*.

2308 Fl. Parrein, *op. cit.*, p. 311 ; H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126 n°s 4 et 5 ; Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 174, n° 227 ; P. van Ommeslaghe, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14 et D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.

de le compléter[2309], il serait toutefois opportun d'y faire figurer également les principaux éléments intransmissibles, ne fût-ce qu'en raison du fait que les associés des sociétés bénéficiaires ignorent vraisemblablement les restrictions à la transmission à titre universel en vigueur dans l'État membre de la société scindée. Dans la mesure où le nombre de *stakeholders* potentiellement impactés par l'opération est d'autant plus élevé dans le cadre d'une scission transfrontalière acquisition, cette précision mériterait d'être ajoutée au texte de la Directive Mobilité, *a fortiori* dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante.

8.3. L'étendue de l'obligation

488. Un niveau de détail susceptible d'être limité. Malgré la formulation générale de cette exigence, il n'est toutefois pas requis de procéder à une contraignante et particulièrement fastidieuse énumération de la totalité des éléments du patrimoine actif et passif de la société scindée[2310]. La solution se doit d'être identique en cas de scission transfrontalière[2311]. En effet, il suffit, sauf cas particulier, que les différents éléments, ainsi que leur répartition, soient déterminables[2312]. Ainsi il est tout à fait possible de procéder à une répartition par masses afin de faciliter le processus, tout en se bornant à énumérer les éléments principaux de chacune des masses. De même, dans l'hypothèse où une majorité du patrimoine de la société scindée passerait à une des sociétés bénéficiaires, il est également possible de procéder par délimitation négative[2313] en indiquant, par exemple, que la totalité du patrimoine de la société scindée passera à la première société bénéficiaire alors que la seconde ne récoltera que certains éléments bien déterminés. Une répartition par branches d'activité est également envisageable[2314], ce qui a l'avantage de permettre de prévoir que tous les éléments, matériels ou immatériels, connus ou inconnus au moment de l'établissement du projet de scission et liés, soit intégralement,

2309 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 402 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 162 et 163 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 11 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung… », *op. cit.*, p. 83 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n°s 853 et 856 ; S. HERRLER et S. SCHNEIDER, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung zwischen Deutschland und Österreich », *GmbH Rundschau*, 2011, p. 796 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 231 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 256 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 33, n° 67 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 313 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 394 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 188 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 31 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *ibidem*, p. 15 et Ch. VERDURE, *op. cit.*, p. 114.

2310 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 19.

2311 F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 18.

2312 H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 61 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 19.

2313 H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 126, n° 61 ; M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 126, n° 19 et R. THIELE et M. KÖNIG, « Die Anforderungen an die Bezeichnung der zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens gem. § 126 I Nr. 9 UmwG », *NZG*, 2015, p. 178.

2314 H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 126, n° 56 ; M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 126, n° 20 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 176.

soit principalement, à une branche d'activités de l'entreprise seront attribués à une entité bénéficiaire bien déterminée.

489. Une nécessité de respecter l'intégrité des branches d'activités ? Malgré ses avantages, une telle répartition par branches d'activité n'est toutefois pas obligatoire. Il a été avancé qu'une telle division découlait nécessairement de la cause d'une scission en ce qu'elle est conforme à sa finalité économique qui est d'isoler une activité particulière soit en vue de sa meilleure valorisation sur les marchés soit de sa cession ultérieure[2315]. Cependant, une telle exigence contraignante ne figure ni dans le régime des scissions internes de la Directive Sociétés, ni dans le régime des scissions transfrontalières de la Directive Mobilité, et s'avère même difficilement compatible avec le texte de celles-ci qui requiert explicitement une description précise non pas des branches d'activité transférées, mais des éléments du patrimoine actif et passif[2316]. A cela s'ajoute qu'une telle exigence sera difficile à réconcilier avec la scission d'une entité dont la seule activité est la détention de participations, d'un bien immobilier ou d'un droit intellectuel[2317]. Il doit ainsi, à titre d'illustration, demeurer possible aux parties à une opération de scission d'allouer toutes les créances détenues à l'égard de plusieurs filiales à une des sociétés bénéficiaires et, toutes les actions détenues par la société scindée dans ces filiales à l'autre société bénéficiaire.

490. Les limites à la liberté des parties. Si la liberté des parties à l'égard des modalités de description des éléments transférés du patrimoine de la société scindée est certes grande, elle n'en est pas pour autant absolue. En effet, certaines règles nationales propres au transfert de certains biens imposant des normes de description plus strictes devront être respectées. À titre d'illustration, on peut ainsi citer la norme de droit allemand qui impose qu'un bien immobilier qui sera transféré dans le cadre d'une scission interne soit décrit très précisément, soit en reprenant les informations figurant dans le registre cadastral, soit en y faisant une référence explicite[2318].

491. Quid en cas de conflit de lois ? En cas de normes plus strictes, par exemple si l'État membre de la société scindée venait à ériger le respect de l'intégrité des branches d'activité comme condition de l'opération alors que les États membres des sociétés bénéficiaires préféraient préserver la liberté des parties quant à la répartition du patrimoine de la société scindée, il conviendrait de recourir à une application cumulative des différentes règles en présence tout en privilégiant la norme la plus sévère. Dans l'exemple ci-dessus, cela reviendrait dès lors à imposer une répartition par branches d'activité.

2315 R. Raffray, *ibidem*, p. 175, n° 210.
2316 Art. 137, § 2, h) de la Directive Sociétés et art. 160*quinquies*, l) de la Directive Mobilité.
2317 *Contra :* R. Raffray, *op. cit.*, p. 175, n° 210.
2318 § 28 GBO et § 126(2) UmwG.

8.4. Une répartition libre

492. Le principe. La liberté à l'égard de la répartition des différents éléments du patrimoine de la société scindée est considérable[2319] et ni le régime des scissions internes instauré par la Directive Sociétés, ni le régime des scissions transfrontalières instauré par la Directive Mobilité n'y prévoient de limites spécifiques[2320]. Il est donc tout à fait possible de procéder, dans le cadre de la scission, à un démembrement d'un droit de propriété ou encore de partager certains droits[2321]. Ainsi, à titre d'illustration, une créance en argent pourrait être partagée entre les deux sociétés bénéficiaires[2322] et une dette, pour peu qu'elle soit divisible, pourrait être répartie entre plusieurs sociétés bénéficiaires[2323].

493. Les limites relatives à la répartition des différents éléments. Si elle est certes grande, la liberté des parties n'en est pas pour autant absolue. En effet, les parties sont susceptibles d'être confrontées à quatre limites distinctes. Tout d'abord, il est possible que certains éléments soient indivisibles et ne puissent dès lors pas être répartis entre les différentes sociétés bénéficiaires. Il en sera par exemple ainsi en droit belge des permis d'urbanisme attribués en considération d'un projet immobilier global, et non en fonction des différentes composantes des projets sous-jacents[2324]. Il s'ensuit qu'en cas de scission d'une société de droit belge possédant un important patrimoine immobilier et un seul permis d'urbanisme pour l'ensemble de ses projets, il faudra soit que tout le patrimoine immobilier visé par le permis et le permis ne soient attribués qu'à une seule des sociétés bénéficiaires, soit répartir les actifs immobiliers entre les différentes sociétés et prévoir qu'il leur faudra obtenir de nouveaux permis d'urbanisme. La deuxième limite concerne, pour sa part, le cas d'éléments du patrimoine qui, bien que séparés, s'avèrent être indissociables. Ainsi, en droit allemand, il est généralement considéré que des droits principaux et des droits accessoires, comme une créance et l'hypothèque qui en garantit le paiement, ne peuvent être séparés[2325]. Dans un même ordre d'idées, il conviendra de respecter les limites imposées par le droit du travail imposant qu'en cas de transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise, les contrats de travail des travailleurs de cette entreprise ou partie d'entreprise soient automatiquement

2319 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 823 et 824, n° 59 ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 55 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 19.

2320 Art. 137, § 2, h) de la Directive Sociétés.

2321 H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 63 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 22.

2322 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 126, n° 24 et V. RIEBLE, « Verschmelzung und Spaltung von Unternehmen und ihre Folgen für Schuldverhältnisse mit Dritten », *ZIP*, 1997, p. 310.

2323 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 126, n° 25 ; M. HEIDENHAIN, *op. cit.*, p. 2877 et V. RIEBLE, *ibidem*, p. 310.

2324 P. NIHOUL et D. LAGASSE, « Les permis d'urbanisme et de bâtir », in *L'urbanisme dans les actes*, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 387 et M. VON KUEGELGEN, « La cession des permis d'urbanisme, de lotir et d'urbanisation », *Jurim Pratique*, 2012/2, p. 345.

2325 M. HEIDENHAIN, *op. cit.*, p. 2877 ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 67 ; R. SCHWEDHELM, M. STRECK et A. MACK, « Die Spaltung der GmbH nach neuem Umwandlungsrecht », *GmbHR*, 1995, p. 10 ; M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 24 et V. RIEBLE, *op. cit.*, p. 310.

transférés au cessionnaire de cette entreprise[2326]. À ces deux premières limites s'ajoute encore la restriction que, sauf le cas très spécifique de la scission d'une filiale commune détenue à cent pour cent[2327], les quoteparts attribuées à chacune des sociétés bénéficiaires ne pourront avoir un actif net négatif[2328]. La dernière limite concerne la valeur de chacune des quotes-parts attribuées. En effet, celle-ci ne pourra être inférieure soit au montant du capital social minimum des sociétés bénéficiaires en cas de scission par constitution de nouvelles sociétés, soit au montant de l'augmentation de capital nécessaire à l'émission des nouvelles actions par chaque société bénéficiaire en cas de scission par acquisition[2329].

494. Une répartition équitable du passif et de l'actif ? De manière assez intéressante, il n'y a aucune exigence de proportionnalité entre le passif et l'actif transféré. En d'autres termes, il est tout à fait possible dans le cadre d'une scission de prévoir qu'une des sociétés bénéficiaires recueillera davantage d'actifs que l'autre, et ce même si la seconde société bénéficiaire recueille une part plus importante du passif. Un des intérêts d'une telle répartition non-proportionnelle est de pouvoir influer sur l'évaluation des quoteparts du patrimoine de la société scindée effectuée au moment de l'établissement du rapport d'échange et, partant, d'aboutir à un résultat spécifique[2330]. Cependant, une telle liberté est susceptible d'avoir une incidence considérable sur les *stakeholders* et en particulier sur les créanciers[2331] et les associés minoritaires[2332].

495. Quid en cas de conflit de lois ? Dans l'hypothèse de règles nationales divergentes imposant des contraintes plus ou moins importantes aux parties quant à la répartition des quoteparts du patrimoine de la société scindée, il conviendra de recourir à une application cumulative des différentes règles en présence tout en privilégiant la norme la plus sévère.

2326 Art. 3, § 1er de la directive (CE) 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, http://eur-lex.europa.eu (20/10/2017), transposé (i) en droit belge par l'art. 7 de la convention collective de travail n° 32*bis* du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32 ter du 2 décembre 1986, 32*quater* du 19 décembre 1989, 32*quinquies* du 13 mars 2002 et 32*sexies* du 27 septembre 2016, disponible sur http://www.cnt-nar.be (20/10/2017) et (ii) en droit luxembourgeois par l'art. L. 127-3., § 1er du Code du travail, disponible sur http://data.legilux.public.lu (20/10/2017).

2327 À ce sujet, voir *supra* n° 119.

2328 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 4, Section 3, § 5.

2329 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 71 et M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 29.

2330 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 126, n° 70 et M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 28.

2331 Sur les risques engendrés par cette répartition libre sur la situation des créanciers, voir *infra* n° 702.

2332 Sur les risques engendrés par cette répartition libre sur la situation des actionnaires minoritaires, voir *infra* n° 981.

8.5. Le sort des éléments oubliés

496. Une clé de répartition en deux temps. Il reste encore à déterminer le sort réservé aux éléments du patrimoine qui auraient pu être omis de la répartition figurant au projet commun de scission. En effet, malgré une répartition précise et *a priori* exhaustive de ce qui est transféré[2333], il est toujours possible qu'un élément ait été oublié. Dans pareille hypothèse, le régime des scissions internes prévoit qu'il conviendra dans un premier temps de voir si une interprétation du projet commun ne permettrait pas de résoudre la question de l'allocation de l'élément en question, et ce, peu importe qu'il s'agisse d'un élément d'actif ou de passif[2334]. Comme il s'agit là d'une solution de bon sens, elle devrait être identique dans le cas d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. À cet égard, une ventilation du patrimoine de la société scindée en respectant l'intégrité des branches d'activités ou faisant preuve d'une certaine cohérence est indéniablement de nature à fournir une clé d'interprétation du projet commun facilitant l'allocation d'un élément oublié[2335]. En outre, la Directive Mobilité devrait simplifier une allocation sur la base du projet de scission puisqu'elle impose dorénavant aux parties d'intégrer une clé de répartition des éléments qui n'auraient pas été explicitement alloués dans le projet de scission[2336]. Cependant, il est des cas où l'interprétation seule du projet commun de scission ne permet pas de résoudre la question de l'allocation d'un élément oublié. Dans ce second temps, il faudra distinguer en fonction de ce que l'élément relève du volet actif ou du volet passif du patrimoine de la société scindée. S'il s'agit d'un élément du patrimoine actif, la règle, à défaut de disposition contraire dans le projet commun de scission[2337], sera que celui-ci ou, le cas échéant, sa contre-valeur, fera l'objet d'une répartition entre les sociétés bénéficiaires, proportionnellement à l'actif attribué à chacune d'elles[2338]. À cet égard il convient de relever que l'effet de ce mécanisme ne sera pas de créer une indivision entre les sociétés bénéficiaires[2339], mais, au contraire, soit de diviser l'actif en question entre celles-ci, pour peu que cela soit possible, soit d'allouer l'élément à l'une d'elles et une compensation correspondant à la quotepart de l'élément transféré à l'autre. S'il s'agit en revanche d'un élément du passif de la société scindée, comme par exemple un cas de responsabilité du fait d'un produit défectueux mis sur le marché par la société scindée[2340], chacune des sociétés bénéficiaires en sera solidairement responsable. Cette solidarité s'étendra (i) en matière de scissions internes, en fonction de l'option choisie par les États membres au moment de

2333 Art. 137, § 2, h) de la Directive Sociétés.
2334 Art. 137, § 3, al. 1 et 2 de la Directive Sociétés.
2335 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 175, n° 210 ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 79 ; M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 66 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 335, n° 502.
2336 Art. 160*quater*, l) de la Directive Mobilité.
2337 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 336, n° 503.
2338 Art. 137, § 3, al. 1er de la Directive Sociétés.
2339 *Contra :* R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 177, n° 212.
2340 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 25 et G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, p. 128.

la transposition de la Directive Sociétés, soit sur la totalité du patrimoine des sociétés bénéficiaires, soit uniquement sur l'actif net attribué à chacune d'elles dans le cadre de l'opération[2341] ou (ii) en cas de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, obligatoirement à l'actif net transféré[2342]. Cette règle de répartition par défaut est logique et avait à l'origine été reprise dans la Proposition de la Commission à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés tout en rendant la limite de l'actif net obligatoire[2343], mais elle a malheureusement disparu dès le Premier Compromis de la Présidence[2344].

497. La règle de conflit de lois applicable. Il reste à déterminer la règle de conflit de lois applicable dans l'hypothèse où les règles de répartition par défaut des éléments du patrimoine actif et passif de la société scindée ont été transposées de manières divergentes. Si la question ne revêt pas d'importance dans le cas d'un actif oublié, elle est en revanche beaucoup plus fondamentale dans le cas d'un passif. En effet, le mécanisme de solidarité passive instauré en matière de scissions internes[2345] vise avant tout à protéger les créanciers de la société scindée par le biais d'une reconstitution artificielle du patrimoine de leur débiteur[2346]. Or, cette règle a été aménagée de diverses manières par les États membres. Ainsi, en droit français, cette solidarité passive revêt un caractère supplétif, de sorte qu'il est loisible aux parties à l'opération d'en écarter l'application par une simple stipulation[2347], la perte du bénéfice de la solidarité étant compensée dans le chef des créanciers par l'octroi d'un droit d'opposition[2348]. Le droit belge[2349], tout comme le droit autrichien[2350], prévoit une solidarité qui n'est pas limitée à l'actif net, contrairement au droit luxembourgeois[2351] qui connaît cette limite. De plus, le droit belge décrète une inopposabilité aux tiers d'une clause relative à l'attribution d'un élément de passif oublié dérogeant au régime légal, même si une telle clause reste valable au stade de la contribution à la dette[2352]. Le droit allemand, pour sa part, n'a réglé explicitement que le sort des éléments du patrimoine actif oubliés[2353], de sorte qu'en cas de passif non-attribué, il faudra (i) soit recourir à une application par analogie de la solution prévue pour les actifs oubliés, ce qui équivaut à une répartition entre les sociétés en fonction de l'actif net

2341 Art. 137, § 3, al. 2 de la Directive Sociétés.
2342 Art. 160*sexies*, § 2 de la Directive Mobilité et sur l'intérêt d'une limitation obligatoire de la solidarité passive à l'actif net transféré, voir *infra* n° 784.
2343 Art. 160*sexies*, §§ 2 et 3 de la Proposition de la Commission.
2344 Art. 160e du Premier Compromis de la Présidence.
2345 Art. 137, § 3, al. 2 de la Directive Sociétés.
2346 R. Raffray, *op. cit.*, p. 177 et 178, n° 214.
2347 Art. L. 236-21, al. 1er et L. 236-23, al. 1er du Code de commerce français et J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 73, n° 199 et R. Raffray, *op. cit.*, pp. 179 et 180, nos 216–219.
2348 Art. L. 236-21, al. 2 et L. 236-23, al. 1er du Code de commerce français et J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 73, n° 199 et R. Raffray, *op. cit.*, pp. 179 et 180, n° 216–219.
2349 Art. 12:60, al. 2 (scissions par absorption) et 12:76, al. 2 (scissions par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.
2350 § 14 (5) SpaltG.
2351 Art. 1031-1, § 3, b) de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
2352 Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 33 et 337, n° 504.
2353 § 131 (1) UmwG et M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 131, n° 29.

attribué à chacune d'entre elles[2354], (ii) soit appliquer le mécanisme général de protection des créanciers de la société scindée, à savoir une solidarité des sociétés bénéficiaires pour toutes les dettes nées antérieurement à l'opération et devenues exigibles moins de cinq ans après la prise d'effet de la scission[2355], (iii) soit considérer que comme la dette a été oubliée, elle n'a pas été attribuée à une des sociétés bénéficiaires de sorte que le délai de prescription ne peut commencer à courir et que la solidarité est illimitée[2356]. Ces mécanismes sont certes différents, mais ils ont tous comme point commun la volonté de préserver les intérêts des créanciers de la société scindée. Dans la mesure où la règle de base en matière de droit international privé à l'égard des mécanismes de protection des créanciers est celle d'une application distributive des différents droits nationaux en présence[2357], il s'ensuit que le droit applicable au sort des éléments oubliés sera celui de la société scindée[2358].

498. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. Compte tenu de ces divergences nationales, ainsi que du fait que dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, l'allocation d'éléments oubliés ou inconnus du patrimoine de la société scindée est susceptible d'impacter non seulement les créanciers de la société scindée mais également les créanciers des sociétés bénéficiaires, il serait préférable, dans un souci de prévisibilité et de sécurité juridique, de procéder à une harmonisation des règles d'attribution par défaut, à l'instar de ce que le législateur européen avait fait dans la Proposition de la Commission[2359].

9. *Les informations relatives à la répartition des actions ou des titres des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée*

499. Une proportionnalité facultative. À l'instar de l'élément précédent, ces informations sont uniquement requises dans l'hypothèse d'une scission[2360] et n'apparaissent en toute logique pas dans un projet de fusion interne[2361] ou transfrontalière[2362]. La répartition des nouvelles actions ou de titres des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée sera en principe proportionnelle à la participation de ceux-ci dans la société scindée[2363]. Toutefois, une telle répartition n'est en rien une obligation. Il est en effet tout à fait possible

2354 § 131 (1) UmwG et M. HEIDENHAIN, *op. cit.*, p. 2878 ; G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 37 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 131, n° 29.

2355 § 133 UmwG et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 133, n° 38 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 131, n° 29.

2356 § 133 UmwG et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 126, n° 80 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 131, n° 29.

2357 À ce sujet, voir *infra* n° 712.

2358 D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 19 et 20 ; U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 212 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 178, n° 7 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 45, n° 57 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, pp. 86 et 87 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 583.

2359 Art. 160*sexies*, §§ 2 et 3 de la Proposition de la Commission.

2360 Art. 137, § 2, i) de la Directive Sociétés.

2361 Art. 91, § 2 de la Directive Sociétés.

2362 Art. 122 de la Directive Sociétés.

2363 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 41 et Commission des Normes Comptables, *op. cit.*, p. 1206.

de prévoir une répartition non-proportionnelle des actions des sociétés bénéficiaires[2364]. Celle-ci pourra revêtir deux formes distinctes[2365], à savoir soit une répartition telle qu'une participation inférieure dans une des sociétés bénéficiaires sera compensée par une participation plus importante dans l'autre société bénéficiaire ou par un paiement en espèces, soit une asymétrie totale où les associés ne pourront obtenir que des actions d'une seule des sociétés bénéficiaires[2366]. Il est également possible de combiner une répartition proportionnelle pour certains associés et une répartition non-proportionnelle pour d'autres[2367]. La grande latitude laissée aux parties présente un intérêt non négligeable pour profiter de l'opération afin de résoudre des conflits entre associés[2368].

500. L'impossibilité d'émettre des actions à des tiers. La liberté des parties au niveau de l'attribution des actions des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée par le fait qu'il n'est pas possible de profiter de l'opération pour ouvrir le capital à des tiers dans la foulée. Cette solution découle du texte même de la Directive Sociétés pour les scissions internes[2369] et de la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2370]. Elle devrait en tout état de cause être identique dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière mixte ou par absorption. En effet, par définition, les actions des sociétés bénéficiaires sont attribuées aux associés de la société scindée en échange de leurs actions dans celle-ci. Il ne s'agit donc pas d'une classique augmentation de capital des sociétés bénéficiaires à laquelle des tiers pourraient le cas échéant participer.

C. *Le contenu inspiré du régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés*

1. *Présentation*

501. Un contenu étendu en cas de fusion transfrontalière. Par rapport à une fusion interne[2371], le projet commun dans le cas d'une fusion transfrontalière devra nécessairement comprendre sept mentions additionnelles, à savoir : (i) les effets probables de la fusion sur l'emploi[2372], (ii) l'acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière, le cas échéant, et les statuts de celle-ci s'ils font l'objet d'un acte distinct[2373], (iii) le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles seront fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits dans la société issue de

2364 Sur les risques encourus par les associés minoritaires du fait de cette répartition non proportionnelle, voir *infra* n° 981.
2365 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 41 et C. Kunkel, « Zulässige nicht verhältniswahrende Spaltung in Form der "Spaltung zu Null" », *jurisPR-HaGesR.*, 9/2013, Anm.3, p. 2.
2366 C. Kunkel, *ibidem*, p. 2.
2367 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 84.
2368 G. Keutgen et J.-F. Tossens, *op. cit.*, p. 128 et J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 75, n° 209.
2369 Art. 137, § 2, i) de la Directive Sociétés.
2370 Art. 160*quinquies*, o) de la Directive Mobilité.
2371 Art. 91, § 2 de la Directive Sociétés.
2372 Art. 122, d) de la Directive Sociétés.
2373 Art. 122, i) de la Directive Sociétés telle que modifié par la Directive Mobilité.

l'opération[2374], (iv) des informations relatives à l'évaluation du patrimoine actif et passif de la société absorbée[2375], (v) les dates des comptes utilisés pour définir les conditions de l'opération[2376], (vi) les modalités d'attribution d'une soulte en espèces aux associés faisant usage de leur droit de retrait[2377] et (vii) les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages[2378]. Ces mentions additionnelles sont justifiées par le caractère transfrontalier de l'opération[2379] qui implique la nécessité de veiller à ce que les différents *stakeholders* soient davantage informés que dans le cadre d'une opération interne[2380].

502. Quid en cas de scission transfrontalière ? Face à cette situation et au vu du caractère transfrontalier d'une scission transfrontalière, il a été avancé que, comme les parties sont libres de compléter volontairement un projet commun de scission[2381], il leur était loisible d'y intégrer également des éléments issus des fusions transfrontalières[2382]. Il s'agit également de l'attitude suivie par le législateur européen, puisque ces sept éléments se retrouvent également dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité[2383]. Cependant, compte tenu du fait que certains aspects d'une scission transfrontalière ne peuvent, en l'état actuel du droit européen, n'être résolus que par le biais d'une application par analogie des solutions développées par la Directive Sociétés[2384], il convient également de se plier aux exigences imposées par celle-ci et justifiées par le caractère transfrontalier de l'opération. En d'autres termes, le projet commun d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante devra nécessairement inclure les mentions additionnelles imposées en cas de fusion transfrontalière. Cette solution apparaît comme évidente lorsqu'on procède à l'examen des différentes mentions en question.

2374 Art. 122, j) de la Directive Sociétés.
2375 Art. 122, k) de la Directive Sociétés.
2376 Art. 122, l) de la Directive Sociétés.
2377 Art. 122, m) de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
2378 Art. 122, n) de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
2379 Proposition de directive du Parlement et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux du 18 novembre 2003, COM2003 (703) final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (08/12/2017), p. 3 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 113 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 312 et E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 394.
2380 D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.
2381 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 402 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 162 et 163 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 11 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung… », *op. cit.*, p. 83 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n°s 853 et 856 ; S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 796 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 231 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 256 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 33, n° 67 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 313 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 394 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 188 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 31 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 15 et Ch. VERDURE, *op. cit.*, p. 114.
2382 E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 394.
2383 Art. 160*quinquies*, e), m), n), p) et q) de la Directive Mobilité.
2384 À ce sujet, voir *supra* n° 298. Ce sera notamment le cas dans l'hypothèse où une seule des *lex societatis* impliquées autorise une soulte supérieure à 10 % ou encore lorsque les dates de prise d'effet de l'opération divergent d'un État membre à un autre.

2. *Analyse des mentions additionnelles*

2.1. Les effets probables sur l'emploi

503. Une mention à géométrie variable. En principe absente du régime des scissions internes[2385], mais reprise par le législateur européen dans le cadre du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2386], l'obligation de faire figurer les effets probables de l'opération sur l'emploi dans le cas d'une fusion transfrontalière n'est pas claire[2387]. Le législateur européen s'est en effet abstenu d'expliciter cette obligation de sorte qu'on est en droit de s'interroger sur l'étendue exacte de celle-ci. Il n'est dès lors pas surprenant de constater que l'interprétation de cette norme varie d'un État membre à un autre. Ainsi, en droit allemand, la question est fortement débattue[2388], et ce notamment parce que dans l'hypothèse d'une fusion ou d'une scission interne, le législateur allemand a pris la liberté d'imposer aux parties de faire figurer les conséquences de l'opération sur les travailleurs et leurs représentants, ainsi que les mesures prévues à cet égard dans le contrat de fusion[2389] ou de scission[2390]. L'objectif de cet ajout était de permettre au conseil d'entreprise d'exercer ses prérogatives en parfaite connaissance de cause et le plus tôt possible[2391]. Les projets communs d'opérations de restructuration internes soumis au droit allemand sont dès lors généralement assez détaillés à ce sujet et comprennent la répartition des différents contrats de travail[2392], l'impact de l'opération sur les conseils d'entreprise[2393], toutes les modifications envisagées du personnel[2394], la préservation éventuelle du système de participation des travailleurs[2395] et le sort des éventuelles conventions collectives présentes au niveau de la société

2385 Art. 137, § 2 de la Directive Sociétés.
2386 Art. 160*sexies*, § 1er, *e*) de la Proposition de la Commission.
2387 St. Simon in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 78 et J. Vetter, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im UmwG », *AG*, 2006, p. 619. Voir également en ce sens à propos de l'art. 160*sexies*, § 1er, e) de la Directive Mobilité : W. Bayer et J. Schmidt, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569.
2388 En faveur d'une conception restreinte : D. Beutel, *op. cit.*, p. 165 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 249 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 248 ; H. W. Neye, *op. cit.*, p. 1895 et J. Vetter, *op. cit.*, p. 620. En faveur d'une conception étendue : Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, p. 950, n° 21 ; R. Kiem, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *op. cit.*, p. 1095 et H. J. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 16.
2389 § 5 (1), n° 9. UmwG.
2390 § 126 (1), n° 11 UmwG.
2391 St. Simon in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 5, n° 76 ; H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 5, n° 81 et J. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 5, n° 49.
2392 St. Simon in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 86 et H. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 43.
2393 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 5, n° 87 et St. Simon in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, p. 1035, n° 90 et H. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 43.
2394 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, p. 120, n° 83.
2395 H. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 43 et H. J. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 53.

scindée ou absorbée[2396]. Certains auteurs vont même jusqu'à considérer qu'en cas d'opérations en chaîne, il faut indiquer les conséquences sur l'emploi des opérations prises dans leur ensemble[2397]. En d'autres termes, en cas de scissions subséquentes, le projet commun relatif à la première scission devrait déjà contenir des informations sur les conséquences des scissions suivantes sur l'emploi au sein de la première société scindée. En revanche, en droit autrichien, c'est une conception plus restrictive qui prévaut et on considère qu'il n'est pas nécessaire d'intégrer des informations au sujet de la représentation des travailleurs ou du sort des conventions collectives de travail[2398]. En droit belge, la question n'a pas fait l'objet de débats, pas plus qu'en droit luxembourgeois. Pour ce qui est de ce dernier, la raison tient certainement au fait que la plupart des opérations de fusion et de scission rencontrées en pratique concernent des sociétés *holding* n'ayant pas de travailleurs[2399].

504. Appréciation critique. De prime abord, il est tentant de considérer que cette disposition vise à informer en temps utile tant les travailleurs que leurs représentants sur les conséquences sociales de l'opération envisagée et qu'elle constitue en quelque sorte, la preuve du souci croissant porté aux intérêts des travailleurs par le législateur européen[2400]. Cependant, cette conception a pu être rejetée pour deux raisons distinctes. Premièrement, il convient de ne pas perdre de vue que le projet de fusion est destiné en priorité aux associés et non aux travailleurs[2401], le rapport de l'organe de gestion ou de direction qui est établi à un stade ultérieur de la procédure de fusion transfrontalière constituant une mesure spécifique d'information à l'égard des travailleurs ou de leurs représentants[2402]. Par conséquent, il a pu être avancé que le véritable objectif de cette disposition était d'informer les associés[2403], ce qui était conforté également par le fait que dans le régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés[2404], seul le rapport devait être mis à la disposition des représentants des travailleurs ou, à défaut, des salariés eux-mêmes au moins un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion[2405]. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la Directive Mobilité, tant le rapport de l'organe de gestion que le projet commun doivent à présent être mis à disposition[2406], de sorte que cet argument s'en trouve

2396 H. WILLEMSEN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 126, n° 43 et H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 90 et St. SIMON in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 90.

2397 H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 5, n° 83 et H. J. WILLEMSEN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 5, n° 60a.

2398 J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 247 et 249.

2399 Art. 160*sexies*, § 1er, e) de la Directive Mobilité.

2400 M. WYCKAERT, « Grensoverschrijdende fusies », *op. cit.*, p. 97, note 36.

2401 D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 164 et 165 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 248.

2402 Art. 124, §§ 5 et 6 (fusions transfrontalières) de la Directive Mobilité et art 160*sexies*, §§ 5 et 6 de la Directive Mobilité.

2403 W. BAYER in M. LUTTER, *op. cit.*, § 122c, n° 19 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 165 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 248 ; H. W. NEYE, *op. cit.*, p. 1895 et H. J. WILLEMSEN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 30.

2404 Art. 124, al. 2 de la Directive Sociétés.

2405 Art. 124, al. 2 de la Directive Sociétés et W. BAYER in M. LUTTER, *op. cit.*, § 122c, n° 19 et H. J. WILLEMSEN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 16.

2406 Art. 124, § 6, al. 1er (fusions transfrontalières) et 160*sexies*, § 6 (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

fortement relativisé. Deuxièmement, et plus fondamentalement, pour assurer une information effective des associés, il importe de limiter les informations qui leur sont fournies à ce qui est réellement pertinent. Or, noyer les associés sous une masse d'informations relatives aux relations sociales au sein des entreprises concernées risquerait assez paradoxalement de brouiller leur conception de l'opération et de nuire à une prise de décision éclairée au sein de l'assemblée générale, alors qu'il est parfaitement possible d'assurer une parfaite information des travailleurs au moyen du seul rapport de l'organe de gestion. Il faut donc retenir que seuls les aspects sociaux susceptibles d'intéresser les associés, comme par exemple le nombre de travailleurs, les éventuels plans sociaux et tout ce qui pourrait influencer la rentabilité de leur investissement ou entraîner des coûts additionnels[2407], devraient figurer dans le projet commun[2408]. Ceci sera d'autant plus vrai dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière où, par définition, la quantité d'informations fournies sera plus importante car au moins trois sociétés distinctes seront impliquées. Afin de dissiper tout potentiel malentendu à cet égard, il serait toutefois utile qu'une nouvelle initiative européenne en la matière clarifie l'étendue de cette mention.

2.2. Les statuts des sociétés issues de l'opération

505. Une information destinée à tous les *stakeholders*. Dans un souci d'assurer une information adéquate des associés de la société absorbée ainsi que de tous les autres *stakeholders* qui vont par l'effet même de l'opération être exposés à des règles issues d'une *lex societatis* distincte[2409], il est prévu, à l'instar de l'hypothèse d'une fusion transfrontalière donnant naissance à une société européenne[2410], que le projet commun de fusion contienne l'acte constitutif de la société issue de l'opération, le cas échéant, et les statuts, s'ils font l'objet d'un acte distinct[2411]. Les statuts ainsi visés sont ceux qui seront immédiatement en vigueur après l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération, c'est-à-dire incluant les diverses modifications requises dans le cadre de la fusion comme l'augmentation de capital nécessaire à l'émission des nouvelles actions. Ceux-ci pourront être présents sous forme définitive ou de projet susceptible d'être modifié ultérieurement par l'assemblée générale[2412]. Compte tenu de l'objectif poursuivi et des risques accrus encourus par, à tout le moins, les

2407 D. Beutel, *op. cit.*, p. 165 et J. Vetter, *op. cit.*, p. 620.

2408 Voir en ce sens : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 19 ; D. Beutel, *ibidem*, p. 165 ; B. Dzida, « Die Unterrichtung des „zuständigen" Betriebsrats bei innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *GmbHR*, 2009, p. 465 ; B. Dzida et N. Schramm, « Arbeitsrechtliche Pflichtangaben bei innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *NZG*, 2008, p. 526 ; S. Herrler et S. Schneider, *op. cit.*, p. 796 ; H. Kallmeyer et St. Kappes, *op. cit.*, p. 231 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 249 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 248 ; H. W. Neye, *op. cit.*, p. 1895 et J. Vetter, *op. cit.*, p. 620. *Contra* : Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 21 et G. Eckert in S. Kalss (dir.), *op. cit.*, p. 625, n° 19.

2409 Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 30 ; S. Maquet, *op. cit.*, p. 35 ; R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 26 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 259.

2410 Art. 20, § 1er, h) du Règlement sur la société européenne.

2411 Art. 122, (i) de la Directive Sociétés.

2412 E. Roelofs, *op. cit.*, p. 394 et D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.

stakeholders de la société apporteuse dans le cadre d'une scission transfrontalière, il est indéniable que faire figurer les statuts de toutes les sociétés bénéficiaires de l'opération se justifierait également. Ceci permettrait en outre d'assurer une information adéquate des associés de la société scindée qui, par définition, ne seront pas encore associés des sociétés bénéficiaires au moment de la modification des statuts de celles-ci[2413]. Il n'est donc pas surprenant de constater que cette mention figure au sein du catalogue mis en place par le législateur européen à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2414]. Il convient toutefois encore de préciser que dans l'hypothèse particulière d'une scission partielle, toute modification de l'acte constitutif de la société scindée devra également figurer au sein du projet de scission[2415].

506. Une difficulté linguistique. Le seul véritable inconvénient lié à l'intégration de cette mention dans un projet de scission transfrontalière sera la nécessité, dans certains cas particuliers de devoir procéder à une traduction de l'intégralité des statuts des sociétés issues de la scission. En effet, comme ces statuts sont à considérer comme parties intégrantes du projet commun[2416], peu important à cet égard qu'ils figurent en annexe ou dans le corps du texte[2417], il conviendra de leur appliquer le même régime linguistique[2418]. Ceci renforce d'autant plus l'intérêt d'une norme harmonisée relative à la langue du projet commun[2419].

2.3. Les informations relatives à la participation des travailleurs

507. L'incidence sur le contenu du projet commun. Dès l'instant où le régime de participation des travailleurs[2420] qui sera mis en place dans l'entité issue de la fusion pourra être distinct de celui prévu par défaut par le droit national[2421], le projet commun de fusion devra nécessairement inclure un certain nombre d'informations sur les modalités selon lesquelles seront fixés les droits de participation des travailleurs dans la société issue de l'opération[2422]. Par conséquent, il faudra, le cas échéant, inclure une description des grandes lignes du processus de négociation, ainsi que des issues possibles, sans toutefois devoir entrer dans les détails[2423]. Il a même été avancé que seule une description de la procédure à

2413 P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n° 853.
2414 Art. 160*quinquies*, j) de la Directive Mobilité.
2415 *Ibidem*.
2416 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 260 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 26.
2417 Il est généralement considéré que les parties peuvent se contenter d'annexer les statuts de la société issue de l'opération au projet commun de fusion. Voir Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 30 ; St. KLEIN, *op. cit.*, p. 581 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 26 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 618.
2418 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 260.
2419 Sur ce point, voir *supra* n°s 433 à 437.
2420 Sur cette notion et la délicate question de la participation des travailleurs dans le cadre des scissions transfrontalières, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2.
2421 S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 796 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 262.
2422 Art. 122, j) de la Directive Sociétés.
2423 Voir en ce sens : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 31 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 262 et H. J. WILLEMSEN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 28. *Contra* : H.-F. MÜLLER, « Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrechts : Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *ZIP*, 2007, p. 1084.

suivre devait suffire[2424]. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que (i) l'objectif est ici encore de fournir une information adéquate et adaptée aux associés[2425] et (ii) une telle interprétation serait difficilement compatible avec les travaux préparatoires de la Dixième Directive dans lesquels la Commission européenne a insisté sur la nécessité d'inclure les modalités relatives à la participation des travailleurs dans le processus décisionnel au sein de la société bénéficiaire[2426]. Il est donc important que toutes les informations pertinentes pour ceux-ci figurent dans le projet commun, en ce compris celles relatives au régime concret qui sera mis en place suite à la réalisation de l'opération. À cet égard, dans la mesure où le processus de négociations avec les travailleurs n'aura pas nécessairement encore abouti au moment de l'adoption du projet commun de fusion transfrontalière, on pourra simplement veiller à inclure un descriptif de l'état d'avancement des négociations[2427]. Si, au contraire, le processus devait déjà avoir abouti, il conviendrait évidemment d'indiquer le résultat final[2428], voire d'annexer une convention conclue à ce sujet au projet commun[2429]. Ces développements peuvent surprendre, notamment au regard du fait que le régime des fusions transfrontalières ne prévoit le début de la procédure de négociation du sort de la participation des travailleurs qu'à partir de la publication du projet commun de fusion[2430]. Cependant, compte tenu de la longueur du processus de négociation, la possibilité d'initier celui-ci avant même la publication du projet commun de fusion est généralement reconnue[2431].

508. Quid s'il n'y a pas de négociations ? La question s'est posée de ce qui devait figurer dans le projet commun dans l'hypothèse où aucune négociation en tant que telle n'avait lieu, comme par exemple (i) dans le cas où les organes d'administration des sociétés participant à l'opération décident d'appliquer les dispositions de référence[2432], ou encore (ii) lorsque l'organe spécial de négociation décide de son plein gré de ne pas entamer le processus de discussion et d'appliquer les règles de l'État du siège statutaire de la société bénéficiaire[2433]. Si on s'en tient à une interprétation purement littérale du texte, on remarque que les mentions relatives aux modalités de détermination du régime de participation des travailleurs ne sont requises que « le cas échéant »[2434]. Par le biais d'un raisonnement *a contrario*, il a ainsi été avancé que dans les cas où

2424 D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.
2425 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 262 et H. J. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 30.
2426 Proposition de directive du Parlement et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux du 18 novembre 2003, COM2003 (703) final, http://eur-lex.europa.eu (08/12/2017), p. 6.
2427 S. Herrler et S. Schneider, *op. cit.*, p. 796 ; P. Limmer, « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Sevic-Urteil des EuGH und den Neuregelungen des UmwG », *ZNotP*, 2007, p. 254 et H. J. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 29.
2428 Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 31 et H. J. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 29.
2429 H. J. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 29.
2430 Art. 133, § 3, a) de la Directive Sociétés et art. 3, § 1er de la directive (CE) 2001/86 du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, http://eur-lex.europa.eu (22/05/2017).
2431 Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 31, note 73 et H. J. Willemsen in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 29.
2432 Art. 133, § 4, a) de la Directive Sociétés.
2433 Art. 133, § 4, b) de la Directive Sociétés.
2434 Art. 122, j) de la Directive Sociétés.

aucune négociation n'avait lieu, le projet commun de fusion ne devait contenir aucune information à ce sujet[2435]. Un tel raisonnement est toutefois difficilement compatible d'une part avec les travaux préparatoires qui font clairement référence aux modalités de participation[2436], par opposition au seul processus de négociation, et d'autre part, avec l'objectif d'information poursuivi par le projet commun[2437]. Par conséquent, les termes « le cas échéant » doivent être interprétés comme impliquant uniquement les cas où une des sociétés impliquées connaît un régime de participation des travailleurs. Il s'ensuit en toute logique que lorsqu'aucune des sociétés fusionnantes ne connaît de régime de participation, le projet de fusion ne devra contenir aucune indication sur ce point[2438].

509. L'impact sur les scissions transfrontalières ? Considérée comme une des questions les plus délicates en droit des sociétés européen[2439], il n'est pas étonnant de constater que dans le cadre du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, le législateur européen ait également imposé de mentionner des informations sur les procédures selon lesquelles seront fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leur droit de participation dans les sociétés issues de l'opération[2440]. Compte tenu du fait qu'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante présente des risques au moins aussi significatifs pour les régimes de participation des travailleurs qu'une fusion transfrontalière, un régime spécifique de protection devra nécessairement être mis en place également à l'égard des scissions transfrontalières[2441]. Il en découle que le projet commun de scission transfrontalière devra contenir, à tout le moins, un certain nombre d'indications à ce sujet.

2.4. Les informations relatives à l'évaluation du patrimoine de la société absorbée

510. Une portée plus réduite qu'il n'y paraît. Introduite à l'initiative de la délégation française[2442] en vue de renforcer la transparence du projet commun[2443], l'obligation de faire figurer des informations relatives à l'évaluation du

2435 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 262.

2436 Proposition de directive du Parlement et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux du 18 novembre 2003, COM2003 (703) final, http://eur-lex.europa.eu (08/12/2017), p. 6.

2437 D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 164 et 165 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 248 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 311 ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n°s 4 et 5 ; Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 174, n° 227 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14 ; H. J. WILLEMSEN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 28 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.

2438 H. J. WILLEMSEN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 27.

2439 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 26 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 21 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 70.

2440 Art. 160*quinquies*, k) de la Directive Mobilité.

2441 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre 2, Chapitre 2, Section 2.

2442 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 32 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 263 et H. W. NEYE et B. TIMM, « Die geplante Umsetzung der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften im Umwandlungsgesetz », *DB*, 2006, p. 489.

2443 J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 263 et S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 196.

patrimoine actif et passif transféré à la société bénéficiaire[2444], qui se retrouve également dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés consacré par le législateur européen[2445], ne doit pas être interprétée comme imposant aux parties à l'opération d'expliciter en détail le processus d'établissement du rapport d'échange[2446]. En effet, si cela avait été l'objectif du législateur européen, celui-ci n'aurait pas manqué de requérir que tant des informations sur le patrimoine de la société absorbée que sur celui de la société absorbante figurent dans le projet commun[2447]. De plus, si cela avait dû être la portée de cette disposition, il y aurait un double emploi difficilement justifiable avec les rapports de l'organe de direction ou d'administration[2448] et de l'expert indépendant[2449] qui doivent comprendre des informations précises à ce sujet[2450]. Plus modestement, on aurait pu considérer que cette disposition était uniquement destinée à clarifier la première étape de la détermination du rapport d'échange, à savoir la ou les méthodes d'évaluation utilisées ayant servi de base à la détermination de la valeur de l'entreprise absorbée[2451]. À la lumière des difficultés pratiques engendrées par l'existence d'une multitude de méthodes d'évaluation des entreprises au sein des États membres[2452], une telle interprétation n'aurait certes pas été dénuée d'intérêt. Cependant, comme l'évaluation du patrimoine actif et passif n'est qu'un élément parmi d'autres qui est pris en compte pour établir la valeur d'une entreprise[2453], cela reviendrait à donner à la disposition une portée qu'elle n'a pas[2454].

511. Une simple information comptable. La seule interprétation possible est celle qui consiste à considérer que cette disposition impose aux parties d'indiquer comment le patrimoine de la société absorbée sera comptabilisé[2455]. En d'autres termes, et de manière un peu schématique, les parties devront indiquer si elles vont comptabiliser les différents éléments (i) à la valeur de marché ou réelle ou (ii) à la valeur comptable ou historique[2456]. Une telle interprétation

2444 Art. 122, k) de la Directive Sociétés.
2445 Art. 160*quinquies*, m) de la Directive Mobilité.
2446 Voir en ce sens : D. Beutel, *op. cit.*, p. 166 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 33 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 264 et J. Vetter, *op. cit.*, p. 618.
2447 D. Beutel, *op. cit.*, p. 166 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 33 et G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 31.
2448 Art. 124, § 3, b) de la Directive Mobilité.
2449 Art. 96, § 2 de la Directive Sociétés et art. 125, § 3 de la Directive Mobilité.
2450 D. Beutel, *op. cit.*, p. 166 et R. Kiem, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *op. cit.*, p. 1095.
2451 D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586, note 52 et Th. Tilquin et J.-A. Delcorde, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 68, n° 99.
2452 St. Reynolds, A. Scherrer et E. Truli, *op. cit.*, pp. 49 et 50 et J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 23.
2453 Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 34 et J. Vetter, *op. cit.*, p. 618.
2454 D. Beutel, *op. cit.*, p. 166 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 34 et J. Vetter, *ibidem*, p. 618.
2455 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 31 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 263.
2456 Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 35 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 233 ; St. Reynolds, A. Scherrer et E. Truli, *op. cit.*, pp. 49 et 50 ; J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 23 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 65.

correspond au texte du décret français ayant servi de base[2457][2458] et est compatible avec le fait que seule la société absorbée soit visée. Il convient de préciser que ce choix devra nécessairement intervenir au moment de l'établissement du projet commun de fusion puisque l'objectif est d'informer les associés avant que ceux-ci ne se prononcent sur l'opération[2459]. Par conséquent, les parties ne pourront se limiter à différer l'évaluation des actifs et passifs transférés à un stade ultérieur, comme par exemple au moment de l'établissement des comptes annuels de la société bénéficiaire[2460].

512. La règle de droit international privé. Compte tenu du fait que deux régimes comptables distincts coexistent au sein des États membres, il est encore nécessaire de clarifier comment traiter l'hypothèse dans laquelle les États membres impliqués n'ont pas recours aux mêmes normes comptables. Dans une telle situation, il a été avancé qu'il fallait considérer que le droit de la société bénéficiaire devait l'emporter[2461]. Une telle solution repose sur un argument de texte[2462] puisque tant la Directive Sociétés[2463] que la Directive Mobilité[2464] font explicitement référence à la société bénéficiaire. Au-delà de cette première justification, force est de constater que cette solution s'impose en outre par pure logique. En effet, il serait surprenant qu'une société comptabilisant son patrimoine à la valeur historique puisse comptabiliser les éléments absorbés du patrimoine d'une société étrangère à la valeur réelle.

513. L'étendue de l'obligation. Il reste à présent encore à préciser la quantité d'information que les parties devront faire figurer dans le projet commun au titre de cette mention. À cet égard, il est unanimement admis qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une fastidieuse énumération de tous les éléments composant le patrimoine de la société absorbée et de leur valeur correspondante[2465]. Une telle énumération serait non seulement incompatible avec la définition d'une fusion transfrontalière dont la transmission universelle de patrimoine est une composante essentielle[2466], mais nuirait également à l'objectif d'information des associés en ce qu'elle noierait ceux-ci sous des informations qui leur seront en tout état de cause fournies au moment de l'établissement des comptes annuels. Cependant, si les parties souhaitent, pour peu que cela

2457 Art. 254, 3° du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, www.legifrance.gouv.fr (7/12/2017), lequel a été abrogé par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce, disponible sur www.legifrance.gouv.fr (7/12/2017). La disposition en question figure à présent à l'art. R. 236-1, 3° du Code de commerce français.

2458 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 35 et H. W. NEYE, *op. cit.*, p. 1895.

2459 G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 31.

2460 *Pro :* Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 36 ; G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 31 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 265. *Contra :* P. LIMMER, « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Sevic-Urteil des EuGH und den Neuregelungen des UmwG (Teil 1) », *op. cit.*, p. 254 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 619.

2461 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 263.

2462 *Ibidem*.

2463 Art. 122, k) de la Directive Sociétés.

2464 Art. 160*quinquies*, m) de la Directive Mobilité.

2465 S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 196 et 197 ; G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 31 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 263 et 264.

2466 S. KULENKAMP, *ibidem*, pp. 196 et 197 ; Chr. LOUVEN, « Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie », *ZIP*, 2006, p. 2021 ; J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 264 et J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 33, n° 67.

soit permis en vertu du droit de la société bénéficiaire, opérer un panachage entre les méthodes de comptabilisation, les éléments dérogeant à la règle générale devront en principe être identifiés et, le cas échéant, être énumérés dans le projet commun[2467].

514. Quid en cas de scission transfrontalière ? Dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, il est indéniable que l'ajout de ces informations présenterait un intérêt limité, mais certain dans le cadre de l'information des associés. Il n'est donc pas surprenant de constater que le législateur européen ait fait le choix de l'intégrer dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2468] et il devrait en être de même dans le cadre d'un régime applicable également aux scissions impliquant plus d'une société préexistante.

2.5. Les dates des comptes utilisés pour définir les conditions de l'opération

515. Une information floue. À l'instar de l'élément précédent, l'obligation de mentionner la date des comptes utilisés pour déterminer les conditions de la fusion[2469] a été intégrée à l'initiative de la délégation française[2470] et ne se retrouve ni dans le régime des fusions internes[2471], ni dans celui de la société européenne[2472]. De prime abord, cette mention peut paraître énigmatique[2473] étant donné que l'objectif de celle-ci n'est pas évident. À cela s'ajoute encore l'utilisation d'une terminologie peu claire. Que faut-il en effet comprendre par la définition des conditions de la fusion ? Instinctivement, le premier réflexe serait de considérer qu'on entend par cette mention la date des comptes intérimaires ou annuels ayant servi de base au calcul du rapport d'échange[2474]. Cependant, une telle interprétation prête le flanc à la critique sous trois aspects distincts. Tout d'abord, comme indiqué précédemment, la valeur purement comptable des entreprises n'est qu'un élément parmi d'autres qui puisse être pris en compte dans le cadre de la détermination du rapport d'échange[2475]. Ensuite, elle se heurte également au problème du double emploi difficilement justifiable avec les rapports de l'organe de direction ou d'administration[2476] et de l'expert indépendant[2477]. Pour finir, si l'objectif était réellement de fournir des informations aux associés sur le calcul du rapport d'échange, on s'explique difficilement pourquoi celles-ci seraient limitées aux seules dates des comptes utilisés.

2467 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 32.
2468 Art. 160*quinquies*, m) de la Directive Mobilité.
2469 Art. 122, l) de la Directive Sociétés.
2470 R. Kiem, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *WM*, 2006, p. 1091 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 265 ; H.-W. Neye, *op. cit.*, p. 1893. ; H. W. Neye et B. Timm, *op. cit.*, p. 189.
2471 Art. 91, § 2 de la Directive Sociétés.
2472 Art. 20, § 1er du Règlement sur la Société européenne.
2473 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 36 et J. Vetter, *op. cit.*, p. 619.
2474 D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.
2475 D. Beutel, *op. cit.*, pp. 167 et 168 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 34 et J. Vetter, *op. cit.*, p. 618.
2476 Art. 124, § 3 de la Directive Mobilité.
2477 Art. 125, § 3 de la Directive Mobilité.

516. La possibilité d'une lecture combinée. Face à cette incompréhension, il a été avancé que cette disposition devait être lue en conjonction avec la disposition précédente. Par conséquent, elle aurait pour objectif de venir compléter les informations relatives à l'évaluation des éléments d'actif et de passif transférés[2478] en imposant d'indiquer la date des comptes de clôture[2479]. Ce raisonnement a même été poussé jusqu'à impliquer que cette disposition ne devait, à l'instar de la précédente, couvrir que la date des comptes de la société apporteuse[2480]. Cependant, une telle interprétation n'est que difficilement réconciliable avec le texte de la directive qui vise explicitement toutes les sociétés impliquées dans l'opération[2481]. De même, si le seul objectif avait été d'informer les destinataires du projet commun de la date des comptes de clôture, on comprendrait difficilement pourquoi le législateur européen aurait opté pour une formulation aussi vague.

517. Une disposition à interpréter à la lumière des objectifs du projet commun. En revanche, si on examine cette disposition à l'aune de l'objectif d'information poursuivi par le projet de fusion, on peut en déduire qu'elle a pour seul objectif de permettre aux différents *stakeholders* de pouvoir vérifier le caractère approprié et actuel des informations ayant servi de base aux organes de direction ou d'administration dans le cadre de l'établissement des modalités de l'opération. Par conséquent, devront non seulement figurer dans le projet commun les dates de clôture des comptes des sociétés participantes, mais également les dates de tous les comptes ayant pu être utilisés pour déterminer toute condition de l'opération comme, par exemple, ceux ayant servi de base à la détermination des mesures proposées à l'égard des associés ayant des droits spéciaux[2482] ou encore les avantages particuliers attribués aux membres de l'organe d'administration[2483][2484].

518. L'étendue de l'obligation. En termes d'information à fournir, il est important de préciser que seules les dates des comptes utilisés devront figurer dans le projet commun. Il n'est par conséquent pas requis d'annexer les comptes *in extenso*[2485].

519. L'impact sur les scissions transfrontalières. Au vu de l'importance d'assurer une information adéquate des différents *stakeholders*, et plus particulièrement des associés, dans le cadre d'une opération transfrontalière par rapport à une opération interne, il serait judicieux qu'un projet commun de scission transfrontalière intègre également des informations relatives aux documents

2478 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 167 ; D. HARITZ et B. VON WOLFF, « Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrecht. Zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *GmbHR*, 2006, p. 341 et R. KIEM, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *op. cit.*, p. 1095.

2479 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 167 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 37 ; D. HARITZ et B. VON WOLFF, *ibidem*, p. 341 et R. KIEM, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *op. cit.*, p. 1095.

2480 D. BEUTEL, *ibidem*, pp. 167 et 168.

2481 Art. 122, l) de la Directive Sociétés.

2482 Art. 122, g) de la Directive Sociétés.

2483 Art. 122, h) de la Directive Sociétés.

2484 G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 38.

2485 *Pro :* G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122c, n° 36 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 619. *Contra :* D. HARITZ et B. VON WOLFF, *op. cit.*, p. 341.

comptables ayant servi de base à l'établissement des conditions de l'opération. Il n'est donc pas surprenant de constater que le législateur européen l'ait également intégrée dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2486]. Cependant, les nombreuses incertitudes concernant les obligations des parties à l'égard de la quantité d'informations à fournir à cet égard plaident en faveur d'une précision de celles-ci, par exemple par le biais d'une énumération, si ce n'est exhaustive, à tout le moins exemplative des différents documents à prendre en compte.

2.6. Les modalités d'attribution d'une soulte en espèces

520. Une nécessaire information des associés minoritaires. Étant donné que le législateur européen a fait le choix d'harmoniser également la protection des associés minoritaires[2487], la Directive Mobilité impose désormais d'intégrer dans le projet de fusion transfrontalière les modalités d'attribution d'une soulte en espèces aux associés souhaitant faire usage de leur droit de retrait, ce qui doit être interprété comme l'obligation de mentionner l'offre *qualitate qua*[2488]. Compte tenu de l'impact potentiellement dommageable d'une scission transfrontalière sur la situation des associés minoritaires de la société scindée[2489], il n'est pas surprenant de constater que le législateur européen ait également imposé cette mention dans le cadre des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés au sein du projet de scission[2490]. À partir du moment où la protection des intérêts des associés minoritaires est garantie par le biais d'un droit de retrait, une telle mention devrait nécessairement se retrouver dans le projet requis pour ce type d'opération de manière à informer les différents associés concernés dès que possible de leur possibilité d'en faire usage[2491].

2.7. Les garanties offertes aux créanciers

521. Une meilleure information des créanciers. Cette disposition s'intègre dans le système général de protection des intérêts des créanciers mis en place par le législateur européen[2492] en assurant une meilleure information des créanciers impactés par l'opération[2493]. Son objectif est avant tout de permettre aux créanciers concernés de décider s'ils souhaitent ou non faire usage de leur droit de demander des garanties adéquates[2494], mais également, le cas échéant, de permettre à la société concernée d'éviter toute discussion avec

2486 Art. 160*quinquies*, n) de la Directive Mobilité.
2487 Sur l'harmonisation de la protection des actionnaires minoritaires, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 6.
2488 À ce sujet, voir *infra* n° 1035.
2489 Sur les risques encourus par les actionnaires minoritaires de la société scindée en cas de scission transfrontalière, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 1.
2490 Art. 160*quinquies*, p) de la Directive Mobilité.
2491 Sur la nécessité de mentionner l'offre *qualitate qua* dans le projet de scission, voir *infra* n° 1035.
2492 Sur les mécanismes de protection des créanciers en cas de scission transfrontalière, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1.
2493 W. Bayer et J. Schmidt, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568.
2494 Sur ce mécanisme de protection, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 2, B., 3.

ses créanciers en leur offrant suffisamment de garanties[2495]. Si dans le cadre du champ d'application foncièrement limité de la Directive Mobilité[2496], cette disposition ne couvrira nécessairement que les garanties offertes au créancier de la société scindée, il en ira différemment dans l'hypothèse d'une scission par acquisition où tant les garanties offertes aux créanciers de la société scindée que celles offertes aux créanciers des sociétés bénéficiaires préexistantes devront être mentionnées, comme c'est le cas *mutatis mutandis* à l'égard des fusions transfrontalières[2497]. Il est toutefois intéressant de relever que le législateur européen a préféré adopter une formulation plus générale en se référant aux « garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages »[2498], de sorte que la formulation est d'ores et déjà compatible avec un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

D. *Le contenu inspiré des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés*

522. Plan du point D. Au-delà des mentions obligatoires issues du régime des scissions internes et des fusions transfrontalières, deux mentions additionnelles issues du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité devront se retrouver dans le projet commun, à savoir le calendrier indicatif de l'opération (1) et une clé de répartition des éléments inconnus ou oubliés (2).

1. *Le calendrier indicatif de l'opération*

523. Une mention purement informationnelle. La Directive Mobilité prévoit que le projet de scission transfrontalière devra nécessairement inclure un calendrier indicatif envisagé pour la scission[2499]. Cette mention, qu'on retrouve également dans le régime des transformations transfrontalières[2500], est absente du nouveau régime des fusions transfrontalières[2501] et avait été supprimée dès le Premier Compromis de la Présidence[2502] pour être ensuite réintégrée dans le Compromis Final[2503]. Dans la mesure où il ne s'agira jamais que d'un calendrier non contraignant, son intérêt est limité[2504] et il a été suggéré de supprimer cette mention purement et simplement[2505]. Elle pourrait tout au plus présenter

2495 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16.
2496 Art. 160*ter* de la Directive Mobilité.
2497 Art. 122, n) de la Directive Mobilité.
2498 Art. 160*quinquies*, q) de la Directive Mobilité.
2499 Art. 160*quinquies*, d) de la Directive Mobilité.
2500 Art. 86*quinquies*, d) de la Directive Mobilité.
2501 Art. 122 de la Directive Mobilité.
2502 Art. 160e du Premier Compromis de la Présidence.
2503 Art. 160e d) du Compromis Final.
2504 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 356 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 845 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil I) », *op. cit.*, p. 2644.
2505 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 356 ; Al. BUTTERSTEIN, *ibidem*, p. 845 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 858, n° 10 et H. WICKE, *ibidem*, p. 2644.

un intérêt limité à l'égard des créanciers en les informant sur la date présumée de la prise d'effet de l'opération[2506].

2. *L'indication d'une clé de répartition pour les éléments inconnus ou oubliés*

524. Une mention utile. Alors qu'à l'égard des scissions internes, il était généralement recommandé aux parties de régler *ab initio* le sort des éléments oubliés dans le projet commun en intégrant une clé de répartition par défaut[2507], la Directive Mobilité impose dorénavant que le projet de scission intègre des dispositions relatives au traitement des éléments d'actif ou de passif qui n'auraient pas été explicitement alloués dans le projet de scission transfrontalière[2508], comme à titre d'illustration, des éléments inconnus du patrimoine de la société scindée[2509]. L'intégration d'une telle disposition se justifie pleinement en raison des spécificités d'une scission qui se caractérise par définition par le fractionnement et le partage entre plusieurs sociétés bénéficiaires du patrimoine de la société scindée. Elle est donc tout à fait à sa place dans un régime applicable exclusivement aux scissions transfrontalières par constitution d'une nouvelle société, mais elle se justifierait encore davantage dans un régime applicable aux scissions transfrontalières impliquant au moins une société bénéficiaire préexistante. En effet, cette disposition sert avant tout à informer les créanciers de l'impact de la scission sur leurs créances respectives. Or, dans l'hypothèse d'une scission par acquisition, toutes les informations relatives à la répartition du patrimoine actif et passif de la société scindée intéresseront non seulement les créanciers de la société scindée comme dans le cadre d'une scission par constitution de nouvelles sociétés, mais également tous les créanciers des sociétés bénéficiaires.

E. *Autres mentions obligatoires*

525. Un catalogue national plus complet. Au-delà de ces mentions minimales, il ne faut pas perdre de vue que certains États membres ont choisi de compléter le catalogue des mentions obligatoires dans le cadre des scissions internes[2510]. À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions nationales relatives au contenu du projet commun de scission s'appliquent de manière cumulative[2511]. Par conséquent, dès lors que la *lex societatis* d'une entité impliquée dans une scission transfrontalière impose une mention additionnelle, celle-ci devra nécessairement se retrouver dans le projet commun. À titre d'exemples de

2506 *Contra* : J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 356 qui plaident faveur de la suppression pure et simple de cette mention.
2507 Voir en ce sens : F. T'Kint et I. Corbisier, *op. cit.*, p. 206, n° 39.
2508 Art. 160*quinquies*, l) de la Directive Mobilité.
2509 Sur le traitement des éléments de passif inconnus ou oubliés et la protection des créanciers dans ce cadre, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 5, § 4.
2510 À ce sujet, voir *supra* n° 438.
2511 Fl. Parrein, *op. cit.*, p. 313 ; Th. Prüm, *op. cit.*, p. 182 ; E. Roelofs, *op. cit.*, pp. 392 et 393 ; Th. Tilquin et J.-A. Delcorde, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, pp. 188 et 189 et Th. Tilquin, J.-A. Delcorde, Ph. Malherbe, D. Garabedian et P. Geerebaert, *op. cit.*, p. 31.

telles mentions obligatoires, on peut citer le droit français qui impose d'expliciter les motifs, buts et conditions de la scission dans le projet commun[2512]. D'un point de vue pratique, ces divergences vont nécessiter de réaliser un délicat exercice de droit comparé entre les régimes, ce qui ne manquera pas d'entraîner des coûts additionnels pour les entités impliquées. Il serait dès lors préférable de ne pas permettre aux législateurs nationaux de compléter le catalogue des mentions obligatoires en intégrant une disposition similaire à celle qu'on retrouve dans la Directive OPCVM[2513], mais ce point risque de s'avérer particulièrement délicat d'un point de vue politique.

F. *Le contenu facultatif*

526. Une disposition dérivée de la liberté contractuelle. Les organes d'administration ou de direction des sociétés impliquées restent toutefois libres de compléter le contenu du projet commun comme bon leur semble[2514]. Cette disposition relative aux scissions internes[2515], qui se retrouve également dans les fusions internes[2516] et transfrontalières[2517], mais également dans le régime de la société européenne[2518], dans celui des transformations transfrontalières[2519] et dans celui des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2520], devrait en toute logique être aussi applicable dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante.

527. La scission analysée comme une opération de rachat. Cette disposition qui paraît, de prime abord, relativement anodine revêt cependant une importance considérable dans l'hypothèse d'une opération qui n'est pas réalisée au sein du même groupe de sociétés. En effet, dans ce cas, l'opération pourra s'analyser, à tout le moins d'un point de vue économique, comme l'acquisition de la société scindée contre paiement d'un prix consistant dans les nouvelles actions à attribuer[2521]. Si on combine cette analyse avec le fait que dans certains États membres, le projet de scission interne est analysé comme un véritable

2512 Art. R. 236-1 du Code de commerce français.

2513 Art. 40, § 1er, al. 3 de la Directive OPCVM qui précise que « [l]es autorités compétentes ne peuvent pas exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans les projets communs de fusions ».

2514 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 402 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 162 et 163 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122c, n° 11 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung… », *op. cit.*, p. 83 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, nos 853 et 856 ; S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 796 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 231 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 256 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 33, n° 67 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 313 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 394 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 188 ; Th. TILQUIN, J.-A. DELCORDE, Ph. MALHERBE, D. GARABEDIAN et P. GEEREBAERT, *op. cit.*, p. 31 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 15 et Ch. VERDURE, *op. cit.*, p. 114.

2515 Art. 137, § 2 de la Directive Sociétés.

2516 Art. 91, § 2 de la Directive Sociétés.

2517 Considérant 57 et art. 122 de la Directive Sociétés.

2518 Art. 20, § 2 du Règlement sur la Société européenne.

2519 Art. 86*quinquies* de la Directive Mobilité.

2520 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.

2521 H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 95 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 44.

contrat générateur d'obligations[2522], il n'est pas étonnant de constater que celui-ci finisse par inclure un catalogue de clauses digne d'un véritable contrat de vente[2523]. On pourra ainsi, par exemple, y retrouver des garanties relatives à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations comptables ayant servi de base à la détermination du rapport d'échange[2524] ou encore la garantie que la poursuite de l'activité de l'entité scindée ne nécessite pas d'investissements significatifs dans les prochaines années[2525].

528. Une grande diversité de mentions additionnelles. Au-delà de ces premières mentions justifiées par le caractère commercial de l'opération et qui ont comme caractéristique commune de garantir en quelque sorte le prix tel que déterminé par les parties, un grand nombre d'autres mentions sont susceptibles de se retrouver dans un projet commun de scission. Ainsi, on peut tout d'abord rencontrer des clauses ayant pour objet d'encadrer les conséquences de l'opération, comme une clause de « *best efforts* » par laquelle les parties s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir le transfert d'un élément d'actif requérant l'autorisation d'un tiers ou d'une administration[2526] ou encore une clause attribuant explicitement tous les éléments oubliés du patrimoine de la société scindée à une des sociétés bénéficiaires[2527]. D'autres clauses auront ensuite pour objectif de régler certains aspects plus pratiques de l'opération, comme une clause de répartition des coûts[2528], une clause d'arbitrage[2529] ou encore une clause prévoyant la nomination de nouveaux membres au sein des organes de direction ou d'administration des sociétés bénéficiaires[2530]. Pour finir, d'autres mentions auront pour objectif de subordonner la réalisation de l'opération à la réalisation de certaines conditions, comme l'approbation de l'opération par les autorités de la concurrence[2531] ou encore l'obtention d'un avis fiscal favorable. La liberté des parties est considérable en la matière et se justifie par le fait que chaque opération de restructuration présente certaines caractéristiques uniques que les parties sont les mieux à même d'apprécier. Cette explication justifie en outre l'application de cette liberté aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante qui constituent des opérations dont la complexité nécessitera fréquemment le recours à des clauses déterminées au cas par cas.

2522 Voir en ce sens en droit allemand : M. Heidenehain, *op. cit.*, p. 2873 et M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 44.
2523 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 44–63b.
2524 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 45.
2525 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 49.
2526 J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 33, n° 67 ; H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 102 ; M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 55 et Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, pp. 297 et 298, n° 439.
2527 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 104.
2528 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 126, n° 105 et M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 63b.
2529 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 63a.
2530 H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 99 et M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 126, n° 63.
2531 J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 33, n° 67 et H. Schröer et G. Greitemann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 103.

SECTION 4. LE RAPPORT DES ORGANES D'ADMINISTRATION OU DE DIRECTION

529. Plan de la section 4. Afin de mettre en lumière le rôle important joué par le rapport des organes d'administration ou de direction dans le cadre de la procédure de scission transfrontalière, il convient, après quelques précisions introductives (§ 1), d'étudier l'organe compétent pour l'établir (§ 2), les objectifs destinés à être remplis par ce rapport (§ 3), le contenu du rapport (§ 4), l'incidence du droit au secret (§ 5), le niveau de détail variable de ce rapport (§ 6), la possibilité d'un rapport commun (§ 7), le régime linguistique du rapport (§ 8), la possibilité de renoncer au rapport (§ 9), la mise à disposition du rapport (§ 10) et l'annexion de l'avis des représentants des travailleurs (§ 11).

§1. Le principe

530. Un rapport plus détaillé que dans le cadre d'une scission interne. Suite à la finalisation d'un projet commun de scission interne, les organes d'administration ou de direction des sociétés impliquées ont l'obligation d'établir un rapport écrit et détaillé contenant une explication et une justification tant juridique qu'économique de l'opération envisagée et, tout particulièrement, du rapport d'échange ainsi que des critères utilisés pour la répartition des nouvelles actions[2532]. Les difficultés particulières d'évaluation survenues dans le cadre du processus de détermination du rapport d'échange devront tout particulièrement être mentionnées[2533]. À l'exception de la justification de la répartition des nouvelles actions, ce contenu est très similaire à celui du rapport dans le cadre d'une fusion interne[2534], mais présente certaines différences avec celui d'une fusion transfrontalière[2535] et d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés[2536]. Dans la mesure où une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante présente au moins le même niveau de risque, on peut logiquement argumenter que le rapport de l'organe de direction ou d'administration dans le cas d'une telle opération devra s'inspirer de celui qu'on retrouve dans la Directive Mobilité.

531. Le droit applicable. Sous réserve du cas particulier du rapport commun[2537], les différents droits nationaux s'appliqueront distributivement en la matière, comme dans le cas d'une fusion transfrontalière[2538]. Tant la société scindée que chaque société bénéficiaire préexistante seront ainsi dans l'obligation de respecter le prescrit de sa propre *lex societatis*.

2532 Art. 141, § 1er de la Directive Sociétés.
2533 Art. 141, § 2 de la Directive Sociétés.
2534 Art. 95, § 1er de la Directive Sociétés.
2535 Art. 124, §§ 1 à 5 de la Directive Mobilité.
2536 Art. 160*sexies* §§ 1 à 5 de la Directive Mobilité.
2537 À ce sujet, voir *infra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Section 4, § 7.
2538 Art. 121, § 1er, lit. b de la Directive Sociétés et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 275.

§2. L'organe compétent

532. Une certaine flexibilité au niveau de l'établissement du rapport. Selon le texte même tant de la Directive Sociétés que de la Directive Mobilité, le rapport devra, qu'il soit relatif à une fusion interne[2539] ou transfrontalière[2540] ou à une scission interne[2541] ou transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés[2542], être établi par l'organe de direction ou d'administration de chacune des sociétés impliquées. L'identification de cet organe dépendra logiquement de la *lex societatis* de chaque société impliquée, mais on est en droit de s'interroger si ce rapport doit nécessairement être le fruit d'un travail commun entre tous les membres de cet organe ou s'il suffit que le rapport final soit adopté par l'organe compétent. En l'absence d'indication contraire à ce sujet, on peut partir du principe qu'il n'est pas requis que ce rapport résulte d'un travail commun entre tous les membres de l'organe compétent[2543], mais il suffit qu'il soit en définitive adopté par celui-ci aux conditions simples de quorum et de majorité[2544]. En ce qui concerne l'établissement de ce rapport, rien ne s'oppose à ce que le projet de rapport soit établi par les conseillers juridiques et comptables des sociétés sous la direction d'un ou de plusieurs membres de l'organe compétent, voire même par certains salariés de l'entreprise[2545], avant d'être soumis formellement à l'approbation de l'organe compétent. La solution doit être identique dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante car aucune différence de traitement ne se justifierait en l'occurrence.

§3. Les objectifs du rapport des organes de direction ou d'administration

533. Un objectif d'information dépassant les seuls associés. Que la scission ou la fusion soit interne ou transfrontalière, il est indéniable que le rapport est avant tout destiné à informer les associés afin de garantir une prise de décision éclairée au moment de la tenue de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur l'opération[2546]. Cependant, par application par analogie de la solution développée en matière de fusions transfrontalières et de scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, le rapport de l'organe de direction ou d'administration jouera également un rôle dans le cadre de l'information des travailleurs. Ce double objectif tire parti des enseignements du régime des fusions transfrontalières. En effet, dans ce dernier type d'opérations, comme le rapport devait inclure une explication des conséquences de l'opération pour les créanciers et les travailleurs[2547], on pouvait se demander

2539 Art. 95, § 1er de la Directive Sociétés.
2540 Art. 124, § 1er de la Directive Mobilité.
2541 Art. 141, § 1er de la Directive Sociétés.
2542 Art. Art. 160*sexies*, § 1er de la Directive Mobilité.
2543 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 280.
2544 *Pro* : J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 281. *Contra* : Chr. Gehling in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 5 et M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 4.
2545 Chr. Gehling in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 5.
2546 R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 1 et J. Mitterecker, *op. cit.*, pp. 275 et 276.
2547 Art. 124, al. 1er de la Directive Sociétés.

si ce rapport n'était pas également destiné à informer ces deux catégories de *stakeholders*. L'enjeu de cette question était loin d'être négligeable puisque si on considérait que le rapport servait uniquement à informer les associés, les seules informations relatives aux travailleurs et aux créanciers qui devaient y figurer étaient celles susceptibles d'intéresser les associés[2548]. Si à l'égard des travailleurs, il découlait des travaux préparatoires[2549] et de l'exigence de mise à disposition du rapport[2550] que ceux-ci constituaient, à l'instar des associés, des destinataires directs du rapport[2551], la situation était moins claire pour les créanciers dans la mesure où le rapport ne devait pas leur être transmis. On considérait toutefois généralement que ceux-ci ne constituaient pas des destinataires du rapport[2552]. La situation est à présent définitivement clarifiée dans la mesure où la Directive Mobilité n'exige plus explicitement que le rapport contienne des informations relatives aux créanciers et laisse le choix entre l'établissement (i) de deux rapports séparés, l'un à destination des associés et l'autre à destination des travailleurs et (ii) d'un un seul rapport contenant deux sections distinctes, l'une à destination des associés et l'autre à destination des travailleurs.

534. Appréciation critique. L'intérêt du rapport de l'organe de direction ou d'administration semble varier d'un État membre à un autre. Ainsi, si en droit allemand[2553] et en droit autrichien[2554] des fusions transfrontalières, les auteurs

2548 D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 178 et 179.

2549 Rapport de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (COM(2003)0703 – C5-0561/2003–2003/0277(COD)) (Rapporteur : Klaus-Heiner Lehne), *P.E. Doc.*, A6-0089/2005 du 25 avril 2005, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (12/01/2018), p. 19.

2550 Art. 124, al. 2 de la Directive Sociétés.

2551 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 179 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 2 et D. WILLERMAIN, *op. cit.*, p. 587, n° 24.

2552 *Pro :* Fr. BEHRENS, *Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach der Richtlinie 2005/56/EG (Verschmelzungsrichtlinie)*, Göttingen, Cuvillier Verlag, 2007, p. 101 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 179 et 180 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 122e, n° 2 ; B. GRUNEWALD, « Der Gläubigerschutz bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach dem Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des UmwG », *Der Konzern*, 2007, p. 108 ; R. KIEM, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *WM*, 2006, p. 1096 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 220 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 1 (qui y voit toutefois un moyen de protection indirect des créanciers) et J. VETTER, *op. cit.*, p. 620. *Contra :* J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 276 et pp. 278 et 279 en raison d'une particularité du droit autrichien. En effet, le § 6 EU-VerschG relatif au contenu du rapport prévoit en son second paragraphe que lorsque la société absorbée est autrichienne, le rapport de l'organe de direction ou d'administration doit également contenir des informations relatives au montant nominal du capital social des sociétés impliquées et des réserves qui y sont associées. Cette information relève d'une certaine importance en matière de protection des créanciers puisque par application du § 13 (1) EU-VerschG les créanciers n'ont pas besoin d'apporter la preuve que le paiement de leur créance est mis en danger par l'opération afin d'obtenir une sûreté si la somme du capital social et des réserves qui y sont liées de la société issue de l'opération est inférieure à la somme du capital et des réserves qui y sont liées de la société débitrice avant la réalisation de l'opération. En d'autres termes, le rapport de l'organe de direction ou d'administration s'inscrit dans la dynamique du mécanisme de protection des créanciers mis en place par le législateur autrichien, ce qui explique pourquoi il est défendu en droit autrichien que le rapport est également destiné à la protection des créanciers.

2553 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 6 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 122e, n° 2 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122e, n°s 7 à 9.

2554 G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 633 et 634, n° 3 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 276.

en font généralement un rouage important de la procédure de restructuration, son intérêt peut être discuté en pratique dans la mesure où il est fréquent que les organes de gestion ou d'administration reprennent les informations figurant déjà dans le projet commun[2555]. Il est d'ailleurs intéressant de relever que tant dans le régime belge des scissions transfrontalières[2556], que dans le régime luxembourgeois des scissions transfrontalières[2557], le contenu du rapport de l'organe d'administration ou de direction est identique à celui qu'on retrouverait dans une opération purement interne, et il n'a pas été jugé opportun de s'inspirer du régime des fusions transfrontalières. En étendant le contenu du ou des rapports[2558], le législateur européen octroie davantage d'importance au rapport de l'organe de direction ou d'administration et en fait un instrument étendu d'information des associés et des travailleurs, ce qui ressort clairement de l'étude de son contenu.

§4. Le contenu du rapport

A. *Le principe*

535. Au-delà du contenu requis en cas de scission interne. Afin de déterminer le contenu du rapport en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, il convient de partir de la réglementation instaurée par le législateur européen à l'égard des scissions par constitution de nouvelles sociétés et d'analyser, à l'aune de la réglementation applicable aux fusions transfrontalières et aux scissions internes, si certaines modifications pourraient s'avérer nécessaires. À cet égard, afin notamment de régler certaines questions débattues sur la possibilité de renonciation au rapport de l'organe de direction ou d'administration dans l'hypothèse d'une fusion transfrontalière selon la Directive Sociétés[2559], le législateur européen a prévu de scinder le rapport soit en deux rapports distincts, soit en deux sections distinctes en fonction du destinataire[2560]. Il conviendra ainsi d'étudier en premier lieu le rapport ou la section destiné(e)) aux associés (B) et en deuxième lieu le rapport ou la section destiné(e) aux travailleurs (C), mais également le contenu additionnel imposé par certains législateurs nationaux (D).

2555 A. Tilleux et E. Weemaels, *op. cit.*, p. 148, n° 18.
2556 Art. 12:61, al. 1er (scissions par absorption) et art. 12:77, al. 1er (scissions par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.
2557 Art. 1031-5, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
2558 Voir en ce sens : Al. Butterstein, *op. cit.*, p. 843 et ECLE, *op. cit.*, p. 209. Voir toutefois également : J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 241 qui relève que ce contenu additionnel à l'égard des actionnaires correspond majoritairement à la pratique existante.
2559 Voir en ce sens : J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 304 ; T. Brandi, *op. cit.*, p. 2630 ; I. Corbisier et F. Bernard, *op. cit.*, p. 24 et J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 241.
2560 Art. 160*sexies* de la Directive Mobilité.

B. *Le rapport ou la section destiné(e) aux associés*

1. *Un contenu plus complet que dans le cadre d'une opération interne*

536. La justification des aspects juridiques et économiques de l'opération. L'organe d'administration ou de direction de chaque société préexistante impliquée aura ainsi tout d'abord l'obligation d'établir un rapport écrit et détaillé contenant une explication et une justification tant juridique qu'économique de l'opération envisagée[2561]. Afin de préciser ce qui est attendu en matière de justification, la Directive Mobilité requiert que les parties détaillent notamment les conséquences de l'opération sur les activités futures des sociétés bénéficiaires[2562]. Il s'ensuit que l'organe de direction ou d'administration devra défendre le choix des partenaires à l'aune des objectifs économiques poursuivis[2563], ainsi que le choix de la scission comme mode de restructuration, sans toutefois nécessairement devoir proposer d'autres alternatives à la scission[2564]. Ce tableau devra, le cas échéant, être complété par une description des risques économiques encourus et une indication sur les chances de réussite de l'opération[2565]. Il devra également informer les associés sur les caractéristiques essentielles de la scission telles que la transmission à titre universel de patrimoine dont elle s'accompagnera et les éventuelles spécificités existant à cet égard[2566]. Compte tenu du fait que les informations relatives aux autres sociétés impliquées dans l'opération ne seront parfois que difficilement accessibles, le projet de scission contiendra utilement également un certain nombre d'informations à leur sujet[2567] et excédant ce qui figure dans le projet commun. Dans un même ordre d'idées, d'éventuelles informations relatives aux travailleurs et susceptibles d'intéresser les associés devront également figurer au sein du rapport[2568].

537. L'explication de la soulte en espèces. À l'instar du rapport en droit allemand[2569] et en droit autrichien[2570], le rapport devra expliquer la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer[2571]. À supposer que le droit allemand ait servi de modèle au législateur européen[2572] qui a introduit

2561 Art. 160*sexies*, § 1er de la Directive Mobilité.
2562 Art. 160*sexies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
2563 Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 15 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 285 ; P. NICAISE, *op. cit.*, p. 98 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 5.
2564 *Pro :* M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 5. *Contra :* T. SCHÖNE, *Die Spaltung unter Beteiligung von GmbH gem. §§ 123 ff. UmwG – Grundlagen, Anteilsgewährung, Beschlußfassung, Informationspflichten*, Köln, Otto Schmidt, 1998, p. 319.
2565 Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 16.
2566 Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 17 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 285 et 286.
2567 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 122e, n° 8 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER, *op. cit.*, § 122e, n° 7 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 286.
2568 J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 241.
2569 § 8(1), 1re phrase UmwG et voir à ce sujet : T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 8, nos 28 et 29 ; Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 49 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 8, nos 22 et 23.
2570 § 220a öAktG et à ce sujet, voir : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 62, n° 16.
2571 Art. 160*sexies*, § 3, a) de la Directive Mobilité.
2572 Au sujet de l'influence du droit allemand sur la Directive Mobilité, voir : P.-H. CONAC, « Le retour du courage politique à Bruxelles : l'Odyssée du "Paquet droit des sociétés" de 2018 », *op. cit.*, p. 8.

cette mention supplémentaire dès le Premier Compromis de la Présidence[2573], il s'ensuit que le rapport devra rendre plausible le montant de la soulte en espèces[2574]. Cette explication est particulièrement importante dans la mesure où elle devra permettre aux associés sortants, le cas échéant, de décider s'il souhaite ou non faire usage de la procédure de contestation de la soulte en espèces instaurée par le législateur européen en vue de sauvegarder leurs intérêts[2575].

538. L'explication insuffisante du rapport d'échange. L'organe de gestion ou de direction se devra également d'éclairer les associés sur le rapport d'échange des actions et la méthode ou les méthodes utilisées pour le déterminer[2576]. Le rapport devra dès lors inclure au moins un exposé sommaire de la ou des méthodes d'évaluation utilisées[2577], sauf si les parties n'ont pas procédé à une évaluation, comme par exemple en cas de scission symétrique par constitution de nouvelles sociétés[2578]. En tout état de cause, le rapport devra contenir une explication de la formule à la base du calcul du rapport d'échange et une justification, le cas échéant du montant de la soulte, ceci afin de permettre aux associés de vérifier ou, le cas échéant, de faire vérifier les calculs de l'organe de direction ou d'administration[2579]. Cependant, contrairement au régime des scissions internes[2580], le législateur européen a choisi de ne pas requérir une explication du critère utilisé pour la répartition des actions des sociétés bénéficiaires à attribuer[2581]. Compte tenu toutefois de l'importance fondamentale de cet aspect d'une scission pour les associés tant de la société scindée que des sociétés bénéficiaires préexistantes, il conviendrait de le compléter dans le cadre d'un régime européen plus général des scissions transfrontalières[2582].

539. Les implications de la scission transfrontalière. Tout comme dans le cadre des fusions transfrontalières[2583] et contrairement à ce qui est prévu en matière de fusions[2584] et de scissions[2585] internes, le législateur européen a précisé que le rapport devait expliquer les conséquences de l'opération pour les associés[2586]. On peut en déduire que le caractère transfrontalier de l'opération

2573 Art. 160g, § 2, aa) du Premier Compromis de la Présidence.
2574 Voir en ce sens : T. Drygala in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 8, n°s 28 et 29 ; Chr. Gehling in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 49 et R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 8, n°s 22 et 23.
2575 Art. 160*decies*, § 4 de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 5, § 3, E.
2576 Art. 160*sexies*, § 2, b) de la Directive Mobilité.
2577 W. Bayer, « Informationsrechte bei der Verschmelzung von Aktiengesellschaften », *AG*, 1988, p. 327 ; R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 11 et P. Nicaise, *op. cit.*, p. 98.
2578 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 127, n° 7.
2579 Chr. Gehling in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 26 et R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 11.
2580 Art. 141, § 1er, *in fine* de la Directive Sociétés.
2581 Art. 160*sexies*, § 3, b) de la Directive Mobilité.
2582 Sur cette insuffisance de la Proposition de la Commission, voir : F. Bernard, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 20.
2583 Art. 124, § 3, c) de la Directive Mobilité.
2584 Art. 95, § 1er de la Directive Sociétés.
2585 Art. 141, § 1er de la Directive Sociétés.
2586 Art. 160*sexies*, § 3, b) de la Directive Mobilité.

justifie une information davantage détaillée à l'attention des associés. Comme ce caractère transfrontalier est d'autant plus présent en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, on peut partir du principe que cette exigence renforcée s'appliquera également dans leur hypothèse. Il s'ensuit que, tout comme c'était le cas à l'égard des fusions transfrontalières en vertu de la Directive Sociétés[2587], le rapport devra expliquer aux associés dans quelle mesure leur situation sera altérée par l'opération envisagée. La quantité d'information à fournir à cet égard est susceptible de varier sensiblement au gré des spécificités de la scission et en fonction de ce que la société est bénéficiaire de l'opération ou non[2588]. Ainsi, dans l'hypothèse d'une société scindée dans laquelle l'actionnariat n'est pas anonyme, il peut être utile de préciser pour chaque associé ce qu'il adviendra de sa participation une fois la restructuration consommée[2589]. Il est également utile de décrire la structure de participation au sein des sociétés bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la composition de leur actionnariat[2590].

540. Quid des difficultés particulières d'évaluation ? Dans l'hypothèse d'une scission interne[2591], le rapport de l'organe de direction ou d'administration devra également nécessairement inclure une mention relative aux éventuelles difficultés d'évaluation. Cette mention se retrouvait également à l'origine dans la Proposition de la Commission[2592], mais a été supprimée dès le Premier Compromis de la Présidence[2593] et n'est pas réapparue par la suite[2594]. À l'égard des scissions internes, cette exigence ne recouvre évidemment pas les difficultés inhérentes à toute évaluation d'entreprise, mais vise plutôt l'ensemble des circonstances factuelles propres à la scission et susceptibles de contrarier ou de compliquer les méthodes habituelles d'évaluation[2595]. Ce sera par exemple le cas si une des sociétés impliquées vient d'être créée[2596] ou encore si l'intégrité des différentes branches d'activité de la société scindée au moment de la répartition des différents éléments d'actif et de passif n'est pas respectée et qu'il est prévu d'attribuer un ou plusieurs éléments du patrimoine de la société scindée pris isolément à une des sociétés bénéficiaires[2597]. Si on combine à cela le fait que la liberté de répartition dont bénéficient les organes d'administration ou de gestion pourrait être utilisée pour spolier les associés

2587 Art. 124, al. 1er de la Directive Sociétés.
2588 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 42.
2589 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 127, n° 41 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 25.
2590 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 127, n° 41.
2591 Art. 141, § 2, al. 1er de la Directive Sociétés.
2592 Art. 160*octies*, § 2, c) de la Proposition de la Commission.
2593 Art. 160g, § 2, c) du Premier Compromis de la Présidence.
2594 Voir art. 160g, § 2, c) du Deuxième Compromis de la Présidence et art. 160g, § 2, c) du Compromis des Représentants Permanents qui confirment la suppression de cette mention.
2595 Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 40.
2596 Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 127, n° 40.
2597 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 11.

minoritaires[2598], on comprend aisément l'intérêt de faire figurer toute difficulté particulière d'évaluation ainsi qu'une justification de la solution choisie dans le projet commun de scission[2599]. Cependant, sa suppression du régime de la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières[2600] correspond à l'intégration de l'obligation d'expliquer la méthode utilisée pour parvenir tant au rapport d'échange[2601] qu'au montant de la soulte en espèces[2602]. Il est donc raisonnable de considérer que les éventuelles difficultés d'évaluation qui auraient pu apparaître devraient être reprises dans le descriptif de la méthode utilisée pour fixer tant le rapport d'échange que la soulte en espèces.

2. *L'absence d'informations relatives aux créanciers*

541. Une mention superflue. Le rejet par le législateur européen de l'exigence qui figurait dans le régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés d'inclure une description des conséquences de l'opération pour les créanciers[2603] est tout à fait logique dans la mesure où cette précision n'avait que peu d'intérêt en pratique. En effet, comme le rapport en cas de fusion n'était de toute façon pas directement destiné aux créanciers[2604], l'information qu'il contenait à leur égard était nécessairement gardée plus succincte que celle à l'égard des associés ou des travailleurs et se limitait généralement à une brève description des conséquences de l'opération sur le gage commun et des mécanismes destinés à assurer la protection des créanciers en vertu de la législation nationale applicable[2605]. En d'autres termes, l'accent était mis sur les informations relatives aux créanciers susceptibles d'avoir un impact sur les associés[2606] et celles-ci seront reprises dans la description des aspects juridiques et économiques de l'opération.

C. *Le rapport ou la section destiné(e) aux travailleurs*

542. Une meilleure information des travailleurs. En plus du premier rapport ou de la première section du rapport à destination des associés, les organes de direction ou d'administration des sociétés impliquées devront également établir un deuxième rapport directement destiné aux représentants des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs eux-mêmes[2607]. Ce rapport ou cette section de rapport se concentrera sur tous les aspects de l'opération considérés

2598 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 127, n° 11 et W. ZÖLLNER, « Aktienrechtsreform in Permanenz – Was wird aus den Rechten des Aktionärs ? », *AG*, 1994, p. 340.
2599 Voir en ce sens : M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 127, n° 11.
2600 Art. 160g, § 2, c) du Premier Compromis de la Présidence.
2601 Art. 160g, § 2, b) du Premier Compromis de la Présidence.
2602 Art. 160g, § 2, aa) du Premier Compromis de la Présidence.
2603 Art. 124, al. 1er de la Directive Sociétés.
2604 À ce sujet, voir *supra* n° 533.
2605 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 181 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 10 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 8 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 291 et 292.
2606 Fr. BEHRENS, *op. cit.*, p. 101 ; D. BEUTEL, *ibidem*, p. 179 ; R. KIEM, *op. cit.*, p. 1096 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 220 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 620.
2607 Art. 160*sexies*, § 5 de la Directive Mobilité.

comme essentiels pour les travailleurs[2608]. Au nombre de ceux-ci, on comptera (i) les conséquences de l'opération sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations[2609] et (ii) tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société[2610]. Par conséquent, le rapport devra couvrir non seulement les conséquences directes de l'opération, telles que le transfert des contrats de travail ou le sort du système de participation en place au niveau de la société scindée, mais également les conséquences indirectes de l'opération, au nombre desquelles on peut par exemple citer les éventuelles mesures de rationalisation envisagées ou encore la modification éventuelle des conventions collectives de travail dont bénéficiaient les salariés de la société scindée. Loin de s'arrêter là, la Directive Mobilité impose de manière surprenante que les explications à fournir par l'organe de direction ou d'administration devront également couvrir les filiales de la société scindée[2611]. Cette exigence additionnelle, qui omet de préciser si elle se limite aux filiales directes de la société scindée ou s'il convient également d'inclure les filiales indirectes, va certes dans le sens d'une information exhaustive des travailleurs, mais elle impose une charge excessive pour les sociétés à la tête de grands groupes, et ce, *a fortiori* dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante puisque chaque société impliquée devra nécessairement couvrir ses filiales. On peut ajouter que son intérêt est de toute façon limité puisque le rapport ne sera pas mis à la disposition des représentants des travailleurs des filiales. Cependant, compte tenu du caractère éminemment politique de la question de la protection des travailleurs, il serait illusoire d'espérer une simplification du rapport à cet égard.

D. *Le contenu additionnel imposé par les législateurs nationaux*

543. Des catalogues nationaux potentiellement plus complets. En plus des mentions obligatoires imposées par la Directive Sociétés en matière de scissions internes, il ne faut pas perdre de vue que certains législateurs nationaux ont choisi d'imposer un contenu additionnel. Ainsi, (i) en droit belge, tant à l'égard d'une scission interne que d'une scission transfrontalière, le rapport devra contenir un exposé de la situation patrimoniale des entités participant à l'opération[2612], (ii) en droit allemand, à l'égard des scissions internes, il faudra compléter le rapport avec des informations sur les entreprises liées[2613] et (iii) en droit autrichien, à l'égard des scissions internes, il faudra inclure une justification juridique et économique des mesures prévues à l'égard des obligataires et des détenteurs de parts bénéficiaires[2614]. Cette situation n'est en aucun cas problématique si chaque entité participant à la scission transfrontalière établit un

2608 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 31.
2609 Art. 160*sexies*, § 5, a) de la Directive Mobilité.
2610 Art. 160*sexies*, § 5, b) de la Directive Mobilité.
2611 Art. 160*sexies*, § 5, b) de la Directive Mobilité.
2612 Art. 12:61, al. 1er (scissions par absorption) et 12:77, al. 1er (scissions par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.
2613 §§ 8(1) et 125 UmwG.
2614 §§ 4(1) et 15(5) SpaltG.

rapport distinct dans la mesure où, à l'instar de la solution adoptée en matière de fusions transfrontalières[2615], les dispositions nationales régissant spécifiquement le contenu du rapport s'appliqueront distributivement. En revanche, en cas de rapport commun, le contenu devra être conforme aux exigences de toutes les *lex societatis* en présence[2616].

§5. Le droit au secret

544. Une limite à l'obligation d'information. Il est intéressant de relever qu'en matière de scissions internes, certains États membres, comme l'Allemagne[2617] et l'Autriche[2618], ont fait le choix de permettre explicitement à l'organe de direction ou d'administration de garder secrètes des informations sensibles qui auraient dû être révélées dans son rapport suite à une interprétation stricte des termes de la Directive Sociétés. Au cours du processus d'adoption de la Directive Mobilité, il a été suggéré d'introduire un tel droit au secret[2619], mais cette mention ne s'est en définitive pas retrouvée dans le texte final. Si ce droit est reconnu dans le cas d'une opération interne, il serait malaisé de l'exclure en cas de mise en place d'un régime spécifique pour les scissions transfrontalières. On pourrait dès lors s'interroger sur le sort de ce droit au secret en cas de rapport commun alors que ce droit ne serait explicitement reconnu que par un seul État membre.

545. Une conséquence du devoir de loyauté. La première manière de résoudre ce conflit serait évidemment de renoncer au bénéfice du rapport commun et de recourir à un rapport distinct pour la société dont le droit national prévoit un tel droit au secret. Cette solution a l'indéniable avantage de la sécurité juridique, mais elle n'en est pas pour autant inéluctable. En effet, cette exception n'est pas incompatible avec l'obligation d'information tant de la Directive Sociétés que de la Directive Mobilité dans la mesure où il est difficilement défendable que celle-ci pût imposer une obligation de se nuire à soi-même[2620]. D'autre part, ce droit au secret n'est que la conséquence du devoir de loyauté de l'administrateur envers sa société. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, les obligations de divulgation de l'organe de direction ou d'administration en cas de fusion ou de scission ne peuvent aboutir à ce qu'ils violent leurs devoirs envers la société.

2615 Art. 121, § 1er, b) de la Directive Sociétés et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 275.

2616 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 3.

2617 § 8 (2) *in initio* et § 125 UmwG.

2618 § 4 (1) *in fine* SpaltG et § 118(3) öAktG.

2619 Voir l'art. 160*octies*, § 4*ter* de l'Avis CEAS selon lequel « [l]es États membres prévoient que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, l'entreprise n'est pas obligée de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement ou lui porteraient préjudice ».

2620 W. Bayer et J. Schmidt, *op. cit.*, p. 403 ; D. Beutel, *op. cit.*, p. 181 ; Fl. Drinhausen et H. Gesell, « Gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten grenzüberschreitender Mobilität von Unternehmen in Europa », *BB-Special*, 8/2006, p. 16 ; R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 30 et H.-F. Müller, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 288.

546. L'intérêt d'une obligation de justification complémentaire. Une telle exception est naturellement propice aux abus de sorte qu'on ne peut qu'adhérer à la solution développée par le droit allemand[2621] et qui impose à l'organe qui en fait usage de mentionner les raisons d'une omission dans le rapport. Dans un souci de sécurité juridique, compte tenu du fait qu'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante va nécessairement mettre en concurrence différents droits nationaux à cet égard, il serait préférable de réintégrer ce droit au secret moyennant motivation dans une initiative européenne destinée à réglementer tous les types de scissions transfrontalières, pour autant que cela soit possible sans divulguer l'information confidentielle.

§ 6. Un niveau de détail variable

547. Un niveau de détail variable. Contrairement au régime actuel des scissions internes[2622], la Directive Mobilité ne précise pas que le rapport doive être « détaillé ». Compte tenu du fait que le rapport est destiné à assurer une prise de décision éclairée des associés, que ce soit au niveau de l'assemblée devant se prononcer sur le projet, ou au moment de décider d'exercer leur droit de retrait[2623], on peut néanmoins considérer que le caractère détaillé sera immanquablement fonction des circonstances propres à chaque opération[2624]. En d'autres termes, une scission intragroupe d'une société ayant un associé unique requerra inévitablement un niveau de détail moindre que la scission d'une société cotée à l'actionnariat fortement dispersé. Dans un même ordre d'idées, on considère généralement que les scissions asymétriques ou les scissions dans lesquelles la société scindée et les sociétés bénéficiaires ne présentent pas un actionnariat identique nécessitent davantage d'explications[2625]. En tout état de cause, le niveau de détail, devra être suffisant afin de permettre à un associé normalement prudent et diligent de prendre une décision éclairée au moment de l'assemblée générale[2626] et, le cas échéant, d'effectuer un contrôle sur les conditions essentielles de l'opération[2627]. Compte tenu du fait que le rapport en cas de fusion transfrontalière poursuit également un objectif d'information des travailleurs[2628], il faudra, par analogie, et par opposition au rapport en cas de scission interne, que le rapport sur le projet de scission transfrontalière soit suffisamment exhaustif pour remplir également cet objectif de manière adéquate.

2621 § 8(2) *in fine* et § 125 UmwG. À ce sujet, voir : T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 52 et Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 65 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 8, n° 32.

2622 Art. 141, § 1er de la Directive Sociétés.

2623 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 1 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 277 et 278.

2624 Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 11 et J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 284.

2625 Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 127, n° 27.

2626 Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 127, n° 11 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 8, nos 1 et 6 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 284.

2627 Chr. GEHLING in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 1 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 127, n° 8.

2628 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Section 4, § 4, C.

§7. La possibilité d'un rapport commun

548. Position et enjeu de la question. La possibilité pour les entités impliquées de rédiger un rapport commun n'est pas explicitement prévue par la Directive Sociétés à l'égard des scissions internes[2629] et les dispositions de la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières ne sont d'aucune aide à cet égard dans la mesure où la question ne peut, par définition, se poser que dans l'hypothèse d'une scission impliquant plusieurs sociétés préexistantes. En revanche, le législateur allemand a explicitement envisagé cette possibilité[2630], et elle devrait être généralement reconnue, notamment au vu du fait que l'objectif d'information poursuivi par le rapport sera au moins aussi bien rempli par l'établissement d'un rapport commun que par plusieurs rapports individuels[2631]. Dans un même ordre d'idées, il est généralement admis qu'il est également possible d'établir un rapport au niveau de la société scindée et un rapport commun au niveau des sociétés bénéficiaires[2632]. Il reste donc à déterminer si la solution doit être identique en matière de scissions transfrontalières, tout en précisant d'ores et déjà que la question ne se posera que dans l'hypothèse d'une scission par absorption étant donné que seuls les organes de direction ou d'administration d'une société existante ont l'obligation d'établir un tel rapport[2633].

549. Méthodologie. Pour pouvoir aboutir à une réponse satisfaisante à cette question, il convient tout d'abord d'analyser la solution adoptée en matière de fusions transfrontalières, pour ensuite examiner si les spécificités d'une scission requéraient un traitement distinct.

550. Comparaison avec le régime des fusions transfrontalières. Pour les fusions transfrontalières, on pourrait être tout d'abord tenté de penser qu'une telle possibilité n'a pas lieu d'être. En effet, contrairement au cas du rapport d'expert d'indépendant pour lequel la Directive Sociétés a explicitement prévu une possibilité de rapport unique[2634], rien de tel n'a été établi pour le rapport de l'organe d'administration ou de direction[2635] et la Directive Mobilité n'est pas venue altérer ce point[2636]. De plus, le texte même tant de la Directive Sociétés[2637] que de la Directive Mobilité[2638] semble s'opposer à une telle possibilité en ce qu'il fait explicitement référence à un rapport établi par l'organe compétent de « *chacune des sociétés qui fusionnent* »[2639]. Cependant, le raisonnement *a contrario* à partir du régime du rapport d'expert indépendant peut être rejeté en ce que ce dernier peut être interprété comme une règle matérielle imposant

2629 Art. 141 de la Directive Sociétés.
2630 § 127 UmwG.
2631 S. Herrler et S. Schneider, *op. cit.*, p. 798 ; R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 4 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 281.
2632 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 127, n° 10 et Chr. Gehling in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 127, n° 6.
2633 M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 127, n° 2.
2634 Art. 125, § 2 de la Directive Sociétés.
2635 Art. 124 de la Directive Sociétés.
2636 Art. 124 de la Directive Mobilité.
2637 Art. 124, al. 1er de la Directive Sociétés.
2638 Art. 124, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
2639 Art. 124, al. 1er de la Directive Sociétés.

aux États membres de reconnaître obligatoirement la possibilité d'une telle renonciation, indépendamment de la solution adoptée à l'égard du rapport de l'organe de direction ou d'administration[2640]. L'argument de texte peut, pour sa part, être attaqué sous deux angles distincts. Tout d'abord, d'un point de vue purement téléologique, force est de constater qu'un rapport commun permet une information des associés et des travailleurs tout aussi adéquate que des rapports séparés[2641]. On peut même argumenter qu'un rapport commun offrirait des garanties additionnelles en ce qu'en incluant les informations relatives à toutes les *leges societatum* impliquées, il permet d'éviter d'oublier des mentions relatives aux sociétés étrangères utiles aux associés susceptibles d'être laissées de côté dans le cas d'un rapport purement national. Ensuite, compte tenu du principe fondamental de la réglementation des fusions transfrontalières selon lequel, sauf dispositions contraires, chaque société reste régie par les dispositions de la législation nationale dont elle relève[2642], on peut considérer que le législateur européen a souhaité laisser cette question à la discrétion des différents législateurs nationaux[2643]. Il en découle qu'un rapport commun doit en tout état de cause être admis si les différents droits nationaux en présence l'autorisent[2644]. Dans une telle hypothèse, il ne faudra toutefois pas perdre de vue que le rapport deviendra un acte de procédure commun aux entités impliquées requérant une application cumulative des différents droits en présence[2645].

551. Examen à l'aune des spécificités d'une scission. Il reste à présent à vérifier si les caractéristiques intrinsèques d'une scission seraient de nature à s'opposer à une application par analogie de la conclusion tirée dans le cadre des fusions transfrontalières. Or, à cet égard, on constate qu'une scission présente des risques potentiellement supérieurs à une fusion pour les associés dans la mesure où (i) le patrimoine de leur société commune va se retrouver éclaté et réparti entre plusieurs sociétés distinctes et (ii) contrairement au cas d'une fusion où ils encourent les désavantages liés au fait d'être associés d'une société étrangère, ils sont susceptibles, au gré de la répartition des nouvelles

2640 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 4 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 180 et 181, note 949 ; Chr. LOUVEN, *op. cit.*, p. 2026 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 282 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 621.

2641 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 282.

2642 Art. 121, § 1er, lit. b de la Directive Sociétés.

2643 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 4 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 180 et 181, note 949 ; Chr. LOUVEN, *op. cit.*, p. 2026 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 282 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 621.

2644 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 4 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes… », *op. cit.*, p. 728 ; R. FRENZEL, « Grenzüberschreitende Verschmelzung nach Ablauf der Umsetzungsfrist », *op. cit.*, p. 17 ; R. KIEM, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *op. cit.*, p. 1096 ; St. KLEIN, *op. cit.*, p. 592 ; Chr. LOUVEN, « Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie », *op. cit.*, p. 2026 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 3 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 282 ; H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 288 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 621.

2645 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 181 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 5 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 3.

actions, de se retrouver associés de plusieurs sociétés étrangères distinctes[2646]. Il s'ensuit qu'une information détaillée des associés s'impose d'autant plus dans le cas d'une scission que d'une fusion. En outre, si on garde à l'esprit le fait qu'un rapport commun est garant d'une information plus exhaustive, on aboutit à la conclusion que la solution appliquée aux fusions transfrontalières s'impose d'autant plus en cas de scission transfrontalière et que les caractéristiques de cette dernière, loin d'exclure une application par analogie, justifient d'autant plus la solution développée en matière de fusions. Par souci de sécurité juridique, il serait toutefois préférable que cette possibilité d'établir un rapport unique apparaisse clairement dans une initiative européenne à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

§8. La langue du rapport

552. La langue du rapport. Étant donné qu'en principe l'organe de gestion de chaque entité impliquée dans l'opération va devoir établir un rapport, les règles nationales en la matière s'appliqueront distributivement. Cependant, dans l'hypothèse d'un rapport commun, il faudra nécessairement recourir à une application cumulative des différentes lois en présence, ce qui, selon les circonstances, peut aboutir à un projet de scission rédigé en plusieurs langues[2647]. Il serait dès lors préférable, à l'instar de ce qui avait été suggéré à l'égard du projet commun[2648], de prévoir la possibilité d'établir le rapport dans une « langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales »[2649], tout en concédant aux destinataires du rapport le droit d'obtenir sans frais une version dans une des langues nationales des sociétés concernées.

§9. La renonciation au rapport de l'organe de direction ou d'administration

553. Une réponse incertaine à l'égard des fusions transfrontalières. Alors qu'en cas de fusions et de scissions internes, les États membres disposaient explicitement de la possibilité d'autoriser une renonciation unanime au rapport de l'organe de direction ou d'administration[2650], sous réserve des différents mécanismes de protection des intérêts des créanciers et de ceux visant à garantir une bonne information des travailleurs et des autorités publiques[2651], une telle possibilité est restée lettre morte en cas de fusions transfrontalières dans la Directive Sociétés[2652]. L'explication pourrait tenir au fait que dans le cadre d'une fusion transfrontalière, le rapport de l'organe de direction ou d'administration

2646 Sur les risques encourus par les actionnaires minoritaires dans le cadre d'une scission transfrontalière, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 1.
2647 Voir en ce sens au sujet des scissions transfrontalières : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 4 et R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 3.
2648 À ce sujet, voir *supra* n°s 433 à 437.
2649 Voir en ce sens : J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 24.
2650 Considérant 75, art. 95, § 3 et art. 144, § 2 de la Directive Sociétés.
2651 Considérant 76 de la Directive Sociétés.
2652 Art. 124 de la Directive Sociétés.

est également destiné à informer les salariés[2653]. Certains auteurs avaient dès lors avancé que ceci ne devrait pas constituer un obstacle à une éventuelle renonciation pour autant que tant les associés que les salariés renoncent au bénéfice du rapport[2654] ou si la société en question ne dispose pas de travailleurs[2655]. Il serait en effet difficilement compréhensible que le législateur européen ait souhaité protéger ces deux catégories de *stakeholders* même contre leur volonté[2656], même si par souci de sécurité juridique, il eût été préférable de disposer d'une possibilité explicite de renonciation unanime écartant tout risque que cette règle ne puisse être considérée comme faisant partie de l'ordre public sociétaire[2657] par certains États membres.

554. Le régime de la Directive Mobilité. La division du rapport de l'organe de direction ou d'administration en deux rapports distincts ou, le cas échéant, en deux sections distinctes en fonction de ses destinataires opérée par la Directive Mobilité a le mérite de clarifier la situation. En application du principe de proportionnalité[2658], il sera ainsi dorénavant possible de renoncer au rapport ou à la section du rapport destiné(e) aux associés moyennant l'accord unanime de tous les associés de la société scindée[2659], malgré le fait qu'au cours du processus législatif il ait été suggéré de supprimer purement et simplement cette faculté[2660]. Cette flexibilité a été complétée dès le Premier Compromis de la Présidence par la possibilité pour les États membres d'exclure les sociétés unipersonnelles de l'obligation d'établir un rapport de l'organe d'administration

2653 Rapport de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (COM(2003)0703 – C5-0561/2003–2003/0277(COD)) (Rapporteur : Klaus-Heiner Lehne), *P.E. Doc.*, A6-0089/2005 du 25 avril 2005, http://www.europarl.europa.eu (12/01/2018), p. 19 et D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 179 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 12 ; H. HECKSCHEN, *op. cit.*, p. 459 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 232 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 62 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 289 ; H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 288 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 22.

2654 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes – Eine kritische Stellungnahme », *NZG*, 2006, p. 842 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 184 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 13 ; H. GESELL et M. KRÖMKER, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen nach SEVIC : Praxisbericht über die Verschmelzung einer niederländischen auf eine deutsche Kapitalgesellschaft », *DB*, 2006, p. 2562 ; Chr. LOUVEN, *op. cit.*, p. 2026 ; S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 798 ; H.-F. MÜLLER, « Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, pp. 1084 et 1085 ; S. SANDHAUS, « Richtlinienvorschlag der Kommission zur Vereinfachung der Berichts- und Dokumentationspflichten bei Verschmelzungen und Spaltungen », *NZG*, 2009, p. 43 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 620.

2655 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 183 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 13 ; Chr. LOUVEN, *op. cit.*, p. 2026 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 299 et 300 ; H.-F. MÜLLER, *ibidem*, p. 1084 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 22 et J. VETTER, *op. cit.*, pp. 620 et 621.

2656 H.-F. MÜLLER, *ibidem*, p. 1084 et J. VETTER, *ibidem*, pp. 620 et 621.

2657 L'ordre public sociétaire « règlemente le fonctionnement de la société, intéresse la collectivité mouvante des associés, actionnaires et participants et met en cause l'intérêt collectif conçu comme un intérêt de la société ». À ce sujet, voir : M. COIPEL et M. DAVAGLE, « Associations sans but lucratif », *Rép. not.*, Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 8, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 796, n° 1047 et V. SIMONART, « L'ordre public et le droit des sociétés », *RDC-TBH*, 1994, p. 122, n° 39.

2658 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 31.

2659 Art. 160*sexies*, § 4, 1re phrase de la Directive Mobilité.

2660 Amendement 168 de l'Avis CAEM.

ou de direction en dehors de toute renonciation formelle de la part de l'associé unique[2661] et cette disposition, absente de la Proposition de la Commission[2662], s'est retrouvée dans le Deuxième Compromis de la Présidence[2663], le Compromis des Représentants Permanents[2664], le Compromis Final[2665], la Proposition du Parlement[2666] et la Directive Mobilité[2667]. On ne peut toutefois que s'interroger sur sa pertinence à l'égard de la partie du rapport ou du rapport à destination des travailleurs dans la mesure où rien ne justifie de les priver du bénéfice d'une information additionnelle au seul motif que l'intégralité des actions sont détenues par un seul associé[2668]. De manière nettement moins critiquable, le caractère superflu du rapport destiné aux travailleurs lorsque la société et ses éventuelles filiales n'en comptent pas ou ne comptent que des travailleurs membres de l'organe de direction ou d'administration est à présent explicitement reconnu[2669]. En revanche, on ne peut que déplorer qu'il ne soit pas prévu que les travailleurs puissent y renoncer à l'unanimité[2670], ce qui aurait pu être utile dans les petites structures où (i) d'une part la proximité entre les travailleurs et l'organe de direction rendent une telle information moins importante que dans une grande structure où les décisions stratégiques sont prises au niveau d'une société mère située à l'étranger et (ii) d'autre part une telle possibilité de renonciation aurait été conforme à l'objectif de la Commission de limiter les coûts et les charges pesant sur les petites et très petites entreprises[2671] désireuses de réaliser une scission transfrontalière[2672].

555. Appréciation critique. Compte tenu d'une part des coûts importants engendrés par la nécessité de rédiger un ou, le cas échéant, deux rapports, tout particulièrement en raison du contenu particulièrement étendu imposé par le législateur européen dans la Directive Mobilité[2673], cette possibilité de renonciation est bienvenue[2674] et mériterait indéniablement de se retrouver

2661 Art. 160*g*, § 4, 2e phrase du Premier Compromis de la Présidence.
2662 Art. 160*octies*, § 4 de la Proposition de la Commission.
2663 Art. 160*g*, § 4, 2e phrase du Deuxième Compromis de la Présidence.
2664 Art. 160*g*, § 4, 2e phrase du Compromis des Représentants Permanents.
2665 Art. 160*g*, § 3a, 2e phrase du Compromis Final.
2666 Art. 160*octies*, § 4, 2e phrase de la Proposition du Parlement.
2667 Art. 160*sexies*, § 4, 2e phrase de la Directive Mobilité.
2668 Voir en ce sens : J. Schmidt, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 571 qui y voit une erreur de rédaction.
2669 Art. 160*sexies*, § 8 de la Directive Mobilité.
2670 Voir en ce sens : J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 304 ; J. Schmidt, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, pp. 570 et 571 et J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 241.
2671 Pour ce qui est de la définition de « microentreprise » et de « petite entreprise », la Proposition de la Commission opère un renvoi à l'article 2 de la Recommandation de la Commission (CE) 2003/361 du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), disponible sur http://eur-lex.europa.eu (17/06/2018), qui définit les microentreprises comme celles qui occupent « moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros » et les petites entreprises comme celles qui occupent « moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ».
2672 46e considérant de la Proposition de la Commission et 7e considérant de la Directive Mobilité.
2673 À ce sujet, voir *supra* n° 537.
2674 Voir en ce sens : Al. Butterstein, *op. cit.*, p. 843 et J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 242.

dans un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. Cependant, compte tenu du fait que dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, le nombre de travailleurs potentiellement impactés sera d'autant plus important, il serait, toujours en vue de réduire les coûts liés à une scission transfrontalière, particulièrement utile de prévoir que les travailleurs pourront, à l'unanimité, renoncer au rapport qui leur est dû.

§ 10. La mise à disposition du ou des rapport(s) de l'organe de direction ou d'administration

556. Une mise à disposition des travailleurs et des associés. Une des différences entre la procédure de scission interne[2675] et celle de scission transfrontalière[2676] réside dans le fait que dans ce dernier cas, le ou, le cas échéant, les rapports de l'organe de gestion devront être mis à la disposition non seulement des associés, mais également des représentants des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs eux-mêmes. Cette particularité tient au fait que le rapport poursuit également un objectif d'information des travailleurs dans le cadre d'une opération transfrontalière[2677]. De prime abord, on pourrait s'étonner de la nécessité de devoir mettre le rapport *a priori* destiné aux associés à la disposition des travailleurs dans la mesure où ceux-ci auront droit à leur propre rapport. Cependant, une telle mise à disposition se justifie tant sous l'angle de la protection des travailleurs que sous celui de la protection des associés. En ce qui concerne les premiers, l'accès au rapport destiné aux associés va leur permettre de vérifier les informations qui figurent dans le rapport qui leur est destiné et va, par conséquent, les protéger contre les omissions volontaires de la part de l'organe de direction ou d'administration. Du point de vue des seconds, connaître l'avis des représentants des travailleurs sur l'opération projetée et sur les conséquences sociales de celle-ci est indiscutablement de nature à leur permettre de prendre une décision éclairée au moment de l'assemblée générale. Cette solution, qu'on retrouve à l'identique dans le régime des fusions transfrontalières[2678], ne devrait pas être différente à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

557. Le délai de mise à disposition. Alors que la Proposition de la Commission prévoyait que les rapports de l'organe de direction ou d'administration devaient être mis à la disposition des travailleurs et des associés au moins deux mois

2675 Art. 143, § 1er, d) de la Directive Sociétés.
2676 Art. 160*sexies*, § 6 de la Directive Mobilité.
2677 Rapport de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (COM(2003)0703 – C5-0561/2003–2003/0277(COD)) (Rapporteur : Klaus-Heiner Lehne), *P.E. Doc.*, A6-0089/2005 du 25 avril 2005, http://www.europarl.europa.eu (12/01/2018), p. 19 et D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 179 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 12 ; H. HECKSCHEN, *op. cit.*, p. 459 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 232 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 62 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 289 ; H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 288 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 22.
2678 Art. 124, § 6, al. 1er de la Directive Mobilité.

avant la date de l'assemblée générale[2679], ce délai minimum est passé à un mois dès le Premier Compromis de la Présidence[2680] et resté à un mois dans le deuxième Compromis de la Présidence[2681] et le Compromis des Représentants Permanents[2682], mais a été étendu à six semaines dans le Compromis Final[2683], la Proposition du Parlement[2684] et la Directive Mobilité[2685]. Compte tenu du fait que ce délai est, d'une part, destiné à permettre aux associés de se préparer à l'assemblée générale et, d'autre part, à s'assurer de ce que les représentants des travailleurs disposent d'un délai suffisant pour émettre un avis, on peut considérer que les bénéficiaires peuvent y renoncer à l'unanimité[2686], étant entendu que les seuls associés ne peuvent disposer d'une telle faculté[2687]. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il serait toutefois bon de préciser ce point dans le cadre d'un régime européen des scissions transfrontalières.

558. La forme de la mise à disposition des travailleurs. En matière de fusions transfrontalières, la Directive Sociétés ne contenait aucune disposition spécifique relative à forme de la mise à disposition des travailleurs du rapport de l'organe de direction ou d'administration. Il s'ensuit que chaque État membre demeurait libre d'en déterminer les modalités. Elle pouvait par conséquent être réalisée par le biais (i) d'un téléchargement sur le site internet ou sur l'intranet de la société[2688], (ii) de la mise à disposition d'une version papier dans les locaux de la société[2689] ou encore, en allant toutefois au-delà des exigences de la directive, (iii) d'une communication électronique ou papier adressée aux travailleurs ou à leurs représentants[2690]. Ce point a été clarifié dans la Directive Mobilité où il est dorénavant prévu que le ou les rapports devront être mis à disposition à tout le moins par voie électronique[2691]. Cette solution, qui va dans le sens d'une certaine flexibilité pour les sociétés concernées, serait également tout à fait justifiée dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, même s'il conviendrait de préciser que la mise à disposition devrait en outre être notifiée aux intéressés[2692].

2679 Art. 160*octies*, § 3 et 160*nonies*, § 3 de la Proposition de la Commission.
2680 Art. 160g, § 3 et 160h, § 3 du Premier Compromis de la Présidence.
2681 Art. 160g, § 3 et 160h, § 3 du Deuxième Compromis de la Présidence.
2682 Art. 160g, § 3 et 160h, § 3 du Compromis des Représentants Permanents.
2683 Art. 160g, § 6 du Compromis Final.
2684 Art. 160*octies*, § 9 de la Proposition du Parlement.
2685 Art. 160*sexies*, § 6 de la Directive Mobilité.
2686 R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 4.
2687 S. Maquet, *op. cit.*, p. 40 ; Fl. Parrein, *op. cit.*, p. 314 et D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 587, n° 24.
2688 D. Beutel, *op. cit.*, pp. 185 et 186 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 296.
2689 D. Beutel, *ibidem*, p. 185 ; Fl. Drinhausen et A. Keinath, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes… », *op. cit.*, p. 725 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122e, n° 17 et J. Mitterecker, *ibidem*, p. 296.
2690 D. Beutel, *op. cit.*, p. 186 et R. Kiem, « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *op. cit.*, p. 1096.
2691 Art. 160*sexies*, § 6 de la Directive Mobilité.
2692 Pour un point de vue critique des dispositions de la Proposition de la Commission à cet égard, voir : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, pp. 858 et 859, n° 15.

§ 11. L'annexion de l'avis des représentants des travailleurs

559. Une mesure dans l'intérêt des associés. La Directive Mobilité prévoit en outre que lorsque l'organe d'administration ou de direction reçoit en temps utile un avis de la part des représentants des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs eux-mêmes, les associés doivent en être informés et l'avis en question devrait être annexé au rapport[2693]. Cette disposition, qu'on retrouve également dans le régime des fusions transfrontalières[2694], constitue avant tout une mesure destinée à informer les associés de la réaction des représentants des travailleurs à l'opération envisagée afin de garantir une prise de décision éclairée au moment de l'assemblée générale. Compte tenu de cette utilité, il convient de plaider en faveur de l'application de cette disposition aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

560. La nécessité d'une réponse. Au cours du processus législatif ayant conduit à l'adoption de la Directive Mobilité, il a été suggéré d'imposer à l'organe de direction ou d'administration de la société scindée de présenter une réponse motivée à l'avis émis par les représentants des travailleurs avant la date de l'assemblée générale[2695]. Une telle disposition n'aurait eu qu'une valeur limitée dans la mesure où la décision de procéder ou non à l'opération incombe *in fine* à l'assemblée générale et n'aurait en outre pas manqué de retarder potentiellement excessivement la réalisation de l'opération, *a fortiori* dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante où un nombre plus important de rapports aurait dû être établi. Il est donc heureux que cette disposition ne se soit pas retrouvée en définitive dans le texte de la Directive Mobilité.

SECTION 5. LE RAPPORT D'EXPERT INDÉPENDANT

561. Plan de la section 5. Rouage essentiel à plus d'un titre, le rapport d'expert indépendant mérite quelques développements non seulement dans le cadre de l'étude de la procédure de scission transfrontalière, mais également en raison du rôle qu'il joue à l'égard de la protection des *stakeholders*[2696]. Après avoir exposé de principe de l'intervention d'un expert indépendant (§ 1), il conviendra dès lors d'étudier neuf aspects distincts de cette étape, à savoir le processus de nomination de l'expert (§ 2), l'étendue des pouvoirs de l'expert indépendant (§ 3), les objectifs poursuivis au moyen de ce rapport d'expert (§ 4), la possibilité d'établir un rapport unique (§ 5), l'étendue de la mission de contrôle de l'expert indépendant (§ 6), le contenu du rapport d'expert (§ 7), la langue du rapport (§ 8), la possibilité d'une renonciation au rapport d'expert (§ 9) et les cas d'exemption de celui-ci (§ 10).

2693 Art. 124, § 6, al. 1er de la Directive Mobilité.
2694 Art. 160*sexies*, § 7 de la Directive Mobilité.
2695 Art. 160*octies*, § 4*octies* de l'Avis CAJ.
2696 Sur le rôle de l'expert indépendant dans le cadre de la protection des créanciers, voir *infra* nos 929 et 931. Sur le rôle de l'expert indépendant dans le cadre de la protection des associés minoritaires, voir *infra* nos 1055 à 1058 et 1083.

§1. Le principe

562. Un deuxième rapport établi par un expert indépendant. Afin de compléter l'information des associés avant la tenue de l'assemblée générale qui sera amenée à se prononcer sur l'opération de restructuration envisagée[2697], il est uniformément prévu en matière de scissions internes[2698], de scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2699], de fusions internes[2700] et de fusions transfrontalières[2701], qu'un rapport sur l'opération devra être établi par un expert. En principe, chaque société participante devra faire établir un tel rapport. La logique derrière cette approche est d'introduire une forme de « *gatekeeper control* »[2702] dans la procédure de restructuration transfrontalière en faisant intervenir un tiers expert en vue de prévenir l'apparition d'un éventuel conflit d'agence et devrait en toute logique se retrouver également dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante.

563. Droit applicable. À l'instar de la solution adoptée à l'égard du rapport de l'organe de direction ou d'administration[2703] et, comme en matière de fusions transfrontalières[2704], chaque rapport d'expert requis dans le cadre d'une scission transfrontalière sera en principe soumis à son propre droit national, sauf dans l'hypothèse d'un rapport commun[2705].

§2. La nomination de l'expert indépendant

A. *Les caractéristiques de l'expert*

564. Indépendance et nature juridique. La seule exigence relative à l'expert qui figurait dans la Directive Sociétés était que celui-ci soit indépendant[2706], ce qui est une évidence au vu des objectifs de ce rapport[2707]. Il était également précisé que l'expert pourrait être une personne physique ou morale en fonction du choix opéré par les législateurs nationaux[2708]. Ce point a fait l'objet de certaines précisions lors de l'adoption de la Directive Mobilité[2709] compte tenu du rôle

2697 Art. 1.2. de la norme de l'IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, disponible sur https://www.ibr-ire.be (01/09/2021) et G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 9, n°s 2 et 3.
2698 Art. 142, § 1er de la Directive Sociétés.
2699 Art. 160*septies*, § 1er de la Directive Mobilité.
2700 Art. 96, § 1er de la Directive Sociétés.
2701 Art. 125, § 1er de la Directive Sociétés.
2702 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 207. Sur cette notion, voir J. Armour, H. Hansmann et R. Kraakman, « Agency problems and legal strategies », *op. cit.*, pp. 42 et 43, selon lesquels « [gatekeeper control] *works by harnessing the control that gatekeepers have over corporate transactions, and giving them a strong incentive to use that control to prevent unwanted conduct* ».
2703 À ce sujet, voir *supra* n° 531.
2704 J. Mitterecker, *op. cit.*, pp. 304 et 305.
2705 À ce sujet, voir *infra* n° 571.
2706 Art. 96, § 1er, 25, § 1er et 142, § 1er de la Directive Sociétés.
2707 À ce sujet, voir *infra* n°s 569 et 570.
2708 Art. 96, § 1er, 25, § 1er et 142, § 1er de la Directive Sociétés.
2709 Art. 160*unvicies* de la Directive Mobilité.

fondamental joué par l'expert indépendant, notamment à l'égard de la protection des créanciers[2710] et des associés minoritaires[2711]. Ces précisions s'articulent autour de deux axes. Dans un premier temps, il est ainsi tout d'abord précisé que les États membres sont dans l'obligation d'établir des règles régissant à tout le moins la responsabilité civile de l'expert indépendant intervenant dans le processus de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, ce qui laisse clairement sous-entendre qu'une responsabilité pénale ne serait pas exclue. Cette stratégie vise avant tout à éviter l'émergence d'un conflit d'agence au niveau du « *gatekeeper* »[2712] et présente une utilité indéniable[2713]. Le deuxième axe impose aux États membres d'instaurer une réglementation spécifique veillant à ce que l'expert soit indépendant et n'ait aucun conflit d'intérêts avec la société demandant le certificat préalable[2714] et à ce que son avis soit impartial, objectif et rendu dans le but d'aider l'autorité compétente[2715]. Cette disposition logique qui se retrouve également dans le régime des fusions transfrontalières[2716] et des transformations transfrontalières[2717] devrait, malgré la nervosité qu'un tel régime de responsabilité ne manquera pas de générer à l'égard des experts indépendants[2718], se retrouver dans un régime européen plus général des scissions.

B. *La solution excessive de la Proposition de la Commission*

565. Une nomination échappant à la société scindée. Afin de garantir l'indépendance de l'expert indépendant[2719], la Proposition de la Commission prévoyait à l'origine que sa nomination échapperait à la société scindée[2720], contrairement à ce qui était prévu dans le cas d'une opération interne[2721]. La société scindée aurait ainsi dû introduire une demande auprès de l'autorité en charge du contrôle de conformité au moins deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale. À l'appui de cette demande, la société scindée aurait dû remettre le projet de scission ainsi que les deux rapports de l'organe de direction ou d'administration à l'autorité compétente[2722]. Cette autorité nationale aurait ensuite eu la tâche de procéder à la nomination de l'expert indépendant dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction de la demande, tout en appréciant l'indépendance de celui-ci à l'aune des critères

2710 Sur le rôle de l'expert indépendant dans le cadre de la protection des créanciers, voir *infra* n°s 929 et 931.
2711 Sur le rôle de l'expert indépendant dans le cadre de la protection des associés minoritaires, voir *infra* n°s 1055 à 1058 et 1083.
2712 Sur la nécessité d'un tel garde-fou dans le cadre de la mise en place d'un « *gatekeeper control* », voir : J. ARMOUR, H. HANSMANN et R. KRAAKMAN, « Agency problems and legal strategies », *op. cit.*, p. 43.
2713 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 242.
2714 Art. 160*unvicies*, § 2, a) de la Directive Mobilité.
2715 Art. 160*unvicies*, § 2, b) de la Directive Mobilité.
2716 Art. 133*bis* de la Directive Mobilité.
2717 Art. 86*vicies* de la Directive Mobilité.
2718 À ce sujet, voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 235.
2719 45e considérant de la Proposition de la Commission.
2720 Art. 160*decies*, §§ 1 et 2 de la Proposition de la Commission.
2721 Art. 142 de la Directive Sociétés.
2722 Art. 160*decies*, § 1er, al. 2 de la Proposition de la Commission.

établis pour garantir l'indépendance et l'objectivité du contrôleur ou du cabinet d'audit dans le cadre du contrôle légal des comptes[2723].

566. Appréciation critique du mode de nomination prôné par la Proposition de la Commission. Ce mode de nomination de l'expert qui découlait des nouvelles missions qui lui étaient confiées dans le cadre d'une scission transfrontalière par rapport à une scission interne[2724], n'était pas sans rappeler la procédure de nomination d'un expert unique dans le régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés[2725] ou de la constitution d'une société européenne par voie de fusion. À ceci près que ni la Directive Sociétés, ni le Règlement sur la Société européenne ne contiennent de disposition au sujet de l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour désigner l'expert, ceci impliquant que les parties peuvent s'adresser au for de leur choix[2726] parmi ceux éligibles en vertu du droit national applicable aux sociétés fusionnantes et que la *lex fori* s'appliquera à la procédure[2727]. A cela s'ajoute qu'en toute logique, l'autorité ainsi désignée nommera vraisemblablement un expert indépendant issu du même État membre, même si elle n'en a pas l'obligation et qu'elle pourrait tout aussi bien nommer un expert issu d'un autre État membre[2728]. Par conséquent, le choix de la juridiction compétente par les parties opère *de facto* un choix du droit applicable à l'expert[2729], que ce soit au niveau de ses qualifications ou de son régime de responsabilité professionnelle. Face à cette situation, et dans un souci évident de protection des associés minoritaires, on aurait pu être tenté de considérer que la désignation de l'autorité en charge du contrôle de conformité comme autorité compétente pour désigner l'expert indépendant constituait un progrès, mais ce point doit être fortement relativisé. En effet, tout d'abord il convient de garder à l'esprit que les États membres disposent d'une grande latitude quant au choix de l'autorité nationale compétente pour effectuer le contrôle de conformité[2730]. En matière de fusions transfrontalières, il en résulte une importante disparité, même si les États membres ont en

2723 Art. 160*decies*, § 2, in fine de la Proposition de la Commission et art. 22 et 22*bis* de la directive (CE) 2006/43 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 157, 9 juin 2006, pp. 87–107.

2724 Sur le rôle de l'expert indépendant dans le cadre de la disposition anti-abus, voir *supra* n°s 357 et 373.

2725 Art. 125, § 2 de la Directive Sociétés.

2726 W. Bayer et J. Schmidt, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 ; W. Bayer et J. Schmidt, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *op. cit.*, p. 842 ; D. Beutel, *op. cit.*, p. 189 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 5 ; M. Evrard et E. van der Vaeren, *op. cit.*, p. 115 ; G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 10 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 309 ; H.-F. Müller, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 288 ; R. Roelofs, *op. cit.*, p. 405 et Th. Tilquin et J.-A. Delcorde, « La fusion transfrontalière… », *RPS*, 2009, p. 74, n° 110.

2727 W. Bayer et J. Schmidt, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *ibidem*, p. 842 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 122f, n° 5 ; G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 10 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 310 ; Fl. Parrein, *op. cit.*, p. 314 et R. Roelofs, *op. cit.*, p. 405.

2728 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 122f, n° 12 et J. Mitterecker, *ibidem*, p. 310.

2729 W. Bayer et J. Schmidt, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *op. cit.*, p. 842 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 5 ; G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 122f, n° 9 et J. Mitterecker, *ibidem*, p. 310.

2730 Art. 160*sexdecies*, § 1er et 160*octodecies*, § 1er de la Proposition de la Commission.

majorité opté pour le choix des registres de commerce[2731], alors même que les notaires, malgré leurs moyens plus limités par rapport à une autorité judiciaire[2732], semblent avoir les faveurs des praticiens et des acteurs économiques en raison de leur disponibilité, de leur coût réduit et de leur flexibilité[2733]. Or, si imposer à une autorité judiciaire ou administrative de statuer sur la désignation d'un expert dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande tout en se prononçant sur l'indépendance de celui-ci ne devrait pas poser de problème particulier, il en va autrement dans le cas d'un notaire. En effet, outre le fait que cette tâche dépasse le cadre des missions qui lui sont ordinairement confiées[2734], le respect du délai de cinq jours pour rendre une décision est illusoire. A cela s'ajoute que les problèmes de partialité éventuelle d'un expert indépendant doivent être relativisés dans la mesure où (i) la Proposition de la Commission impose, tout comme en matière de scissions internes[2735], aux États membres d'instaurer un régime minimal de responsabilité civile des experts[2736] et (ii) les qualifications des contrôleurs légaux des comptes, qui sont généralement nommés en qualité d'experts indépendants à l'heure actuelle, ont fait l'objet d'une harmonisation par le biais de la directive (CE) 2006/43[2737]. C'est donc à juste titre que ce mode de nomination de l'expert a été rejeté dès le Premier Compromis de la Présidence[2738] et n'est réapparu ni dans le Deuxième Compromis de la Présidence[2739], ni dans le Compromis des Représentants Permanents[2740], ni dans le Compromis Final[2741], ni dans la Proposition du Parlement[2742]. Le régime des scissions transfrontalières de la Directive Mobilité s'en remet donc explicitement au droit national de l'État membre de la société scindée pour ce qui est de la nomination de l'expert

2731 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale, 11 États membres (la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, Malte, la Norvège, le Portugal, la Roumanie et la Suède) ont opté pour le registre de commerce, 9 (l'Allemagne, l'Autriche, Chypre, la France, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne, le Royaume-Uni et la Slovénie) pour un tribunal, 7 (la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la République tchèque et la Slovaquie) pour un notaire et 3 (le Danemark, la Grèce et le Liechtenstein) pour un autre type d'autorité. Voir l'Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, p. 62.

2732 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, pp. 70 et 71 et S. MAQUET, *op. cit.*, p. 48.

2733 Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, p. 61.

2734 Selon l'art. 1er de la loi belge du 25 Ventôse An XI contenant organisation du notariat, https://www.notaire.be (17/07/2018) et l'art. 1er de la loi luxembourgeoise du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, www.legilux.lu (17/07/2018), les notaires ont pour mission première de « recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ».

2735 Art. 152 de la Directive Sociétés.

2736 Art. 160*tervicies* de la Proposition de la Commission.

2737 Art. 3 à 25 de la directive (CE) 2006/43 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 157, 9 juin 2006, pp. 87–107.

2738 Art. 160i du Premier Compromis de la Présidence.

2739 Art. 160i du Deuxième Compromis de la Présidence.

2740 Art. 160i du Compromis des Représentants Permanents.

2741 Art. 160i du Compromis Final.

2742 Art. 160*decies* de la Proposition du Parlement.

indépendant[2743]. Dans le cadre de la mise en place d'un régime européen s'appliquant aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, il convient de se tourner vers la solution prônée en matière de fusions transfrontalières et qui veut qu'en dehors du cas particulier de la nomination d'un expert unique[2744], les différents droits nationaux s'appliquent distributivement en la matière[2745].

§ 3. Les pouvoirs de l'expert indépendant

A. *Au-delà d'un simple droit d'investigation*

567. Les pouvoirs de l'expert indépendant. En matière de scissions internes[2746] et de fusions internes[2747], l'expert indépendant jouira non seulement d'un droit d'investigation lui permettant d'obtenir tous les documents et renseignements nécessaires, mais également d'un droit de vérification des informations qui lui auront ainsi été fournies. La Proposition de la Commission prévoyait qu'en plus des pouvoirs dont il dispose également en cas de scission interne[2748], l'expert indépendant pourrait recueillir des avis et des commentaires émis sur l'opération tant par les représentants des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes que par les créanciers et les associés de la société scindée[2749]. Ces pouvoirs étendus étaient à mettre en relation avec le fait que le rapport d'expert constituait un rouage important de la procédure anti-abus[2750]. Suite à la restriction considérable de celle-ci au gré du processus législatif[2751], les droits de l'expert indépendant ont été restreints au simple droit d'obtenir toutes les informations qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission[2752], sans les compléter du droit d'obtenir des documents ou du droit de vérification pourtant explicitement prévus en cas d'opérations internes[2753]. On pourrait dès lors se demander si le législateur européen n'a pas expressément souhaité prévoir des pouvoirs plus restreints en cas d'opération transfrontalière. Cependant, comme rien ne justifie un pouvoir d'investigation limité dans le cadre d'une opération transfrontalière et qu'une telle restriction aurait de surcroît pour effet de compliquer sensiblement la mission des experts[2754], il faut partir du principe qu'en ne mentionnant que le droit d'investigation, le législateur européen n'a pas voulu instaurer de règle matérielle restreignant les pouvoirs de l'expert, mais qu'au contraire, les règles régissant la question

2743 Art. 160*quater* et 160*septies* de la Directive Mobilité.
2744 À ce sujet, voir *infra* n° 571.
2745 Voir en matière de fusions transfrontalières : art. 121, § 1er de la Directive Société telle que modifiée par la Directive Mobilité.
2746 Art. 92, § 2 et 96, § 3 de la Directive Sociétés.
2747 Art. 96, § 3 de la Directive Sociétés.
2748 Art. 96, § 3 et 142, § 2 de la Directive Sociétés.
2749 Art. 160*decies*, § 4 de la Proposition de la Commission.
2750 Sur l'instrumentalisation de l'expert indépendant dans le cadre de la procédure anti-abus, voir *supra* nos 357 et 373.
2751 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1, Section 2, § 4.
2752 Art. 160*septies*, § 2, al. 2 de la Directive Mobilité.
2753 Art. 96, § 3 et art. 142, § 2 de la Directive Sociétés.
2754 D. Beutel, *op. cit.*, p. 190.

en cas de scission interne doivent également s'appliquer en l'occurrence[2755]. Il s'ensuit que dans le cas d'une scission transfrontalière, l'expert indépendant chargé de la vérification de l'opération jouira non seulement d'un droit d'investigation, mais que celui-ci devra également être complété par un droit d'obtenir des documents et d'un droit de vérification. Une telle solution est parfaitement compatible avec un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

B. *Quid des informations confidentielles ?*

568. Une mesure dans l'intérêt des associés minoritaires. Alors que la Directive Sociétés ne contenait aucune indication explicite sur le sort des informations confidentielles que l'expert indépendant serait amené à traiter dans le cadre de sa mission, la Proposition de la Commission visait explicitement cette hypothèse. Il était même prévu que l'expert indépendant aurait la possibilité de rédiger un rapport séparé qui serait destiné exclusivement à l'autorité en charge du contrôle de légalité et à la société scindée, à l'exclusion des tiers[2756]. Cette innovation utile[2757] visait principalement à éviter que les membres de l'organe de direction ou d'administration ne se retranchent derrière leur devoir de loyauté envers la société scindée pour refuser de partager des informations confidentielles avec l'expert indépendant, ce qui par ricochet aurait potentiellement nui à l'efficacité du contrôle anti-abus. Malgré la limitation de ce contrôle au cours du processus législatif[2758], le traitement des informations confidentielles n'en a pas pour autant disparu de la Directive Mobilité et celle-ci prévoit que lorsque les États membres font le choix d'exiger que le rapport de l'expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre de compétent[2759], la société ait la possibilité d'en exclure les éventuelles informations confidentielles[2760]. Cette disposition présente un intérêt certain dans le cadre d'une scission transfrontalière puisqu'elle implique *a contrario* que le rapport de l'expert indépendant auquel seuls les associés auront accès devra inclure d'éventuelles informations confidentielles assurant par conséquent une meilleure information de ceux-ci et leur permettant, le cas échéant, de faire usage de leur droit de retrait en pleine connaissance de cause. Une telle conception est prioritairement dans l'intérêt des associés minoritaires n'ayant pas nécessairement toujours accès à toutes les

2755 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Art. 3.1., al. 3 de la norme professionnelle NP2018-07 du 19 juin 2018 de l'IRE luxembourgeois sur les diligences professionnelles du réviseur d'entreprises dans le cadre des opérations de fusions et scissions, www.ire.lu (01/09/2021) et D. BEUTEL, *ibidem*, p. 190 et H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem neuen Richtlinienentwurf der EU-Kommission », *ZIP*, 2004, p. 1790 qui aboutissent toutefois au même résultat au moyen d'une interprétation large du terme « *information* » du régime des fusions transfrontalières qui, selon eux, doit également comprendre le droit d'obtenir des documents et le droit de vérification.

2756 Art. 160*decies*, § 5 de la Proposition de la Commission. Il convient toutefois de remarquer que la version française est erronée et qu'il convient de se reporter à la version anglaise du texte de la Proposition de la Commission.

2757 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 278.

2758 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1, Section 2, § 4.

2759 Art. 160*octies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.

2760 Art. 160*octies*, § 1er, al. 3 de la Directive Mobilité.

informations confidentielles et aurait indéniablement sa place dans un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante et présentant, par définition, davantage de risques pour des associés minoritaires[2761].

§4. Les objectifs du rapport d'expert

569. Un rapport à l'intention des associés. Contrairement au rapport de l'organe de direction ou d'administration qui, en cas de scission transfrontalière, sera destiné non seulement aux associés, mais également aux travailleurs[2762], le rapport d'expert sera prioritairement destiné aux associés. Cette primauté se retrouve tant en matière de scissions internes[2763] et transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2764], qu'en matière de fusions internes[2765] ou transfrontalières[2766] et de transformations transfrontalières[2767]. Le but est de s'assurer que les associés disposent d'une vision claire de la manière dont les sociétés impliquées ont été évaluées et le rapport d'échange fixé[2768]. Une telle information servira en outre à garantir une prise de décision éclairée de la part des associés lors de la tenue de l'assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur le projet de restructuration[2769].

570. Une garantie additionnelle d'objectivité. Au-delà de ce premier objectif que l'on retrouve également dans le cadre du rapport établi par l'organe de direction ou d'administration[2770], le rapport d'expert indépendant vise également à fournir une information objective aux associés[2771]. En d'autres termes, comme il se peut que l'organe de direction ou d'administration ayant établi le projet commun de scission et le rapport sur celui-ci ait un intérêt personnel dans l'opération ou soit à la solde d'un associé majoritaire favorable à la scission, il est nécessaire de prévoir une mesure destinée à assurer une information aussi objective que possible des associés minoritaires[2772].

§5. La possibilité d'un rapport unique

571. Une faculté laissée à la discrétion des États membres. Un rapport d'expert indépendant est indéniablement de nature à protéger les intérêts des associés de manière efficace dans certaines circonstances. En revanche, comme

2761 Sur les risques accrus encourus par les associés minoritaires dans le cadre d'une scission transfrontalière, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 2, § 1.
2762 À ce sujet, voir *supra* n°s 533 et 534.
2763 Art. 142, § 1er de la Directive Sociétés.
2764 Art. 160*septies*, § 1er, 1re phrase de la Directive Mobilité.
2765 Art. 96, § 1er de la Directive Sociétés.
2766 Art. 125, § 1er de la Directive Sociétés.
2767 Art. 86*septies*, § 1er, 1re phrase de la Directive Mobilité.
2768 D. Beutel, *op. cit.*, p. 188 ; G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 1 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 305 et J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 38, n° 78.
2769 Norme de l'IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021), p. 3.
2770 À ce sujet, voir *supra* n° 533.
2771 50e et 69e considérants de la Directive Sociétés.
2772 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 305 ; J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 36, n° 74 et Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 189, n° 253.

l'établissement d'un tel rapport entraîne généralement des coûts importants[2773], il est expressément prévu dans le cadre des scissions internes[2774], ainsi que des fusions internes[2775] et transfrontalières[2776], qu'il est loisible aux États membres de prévoir que les entités impliquées dans l'opération puissent conjointement demander la désignation d'un expert commun à une autorité administrative ou judiciaire. Dans un contexte transfrontalier, il convient de préciser qu'une telle possibilité ne sera ouverte que si elle est reconnue par tous les États membres concernés[2777]. Cette possibilité est toutefois absente du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés mis en place par le législateur européen dans la Directive Mobilité et ce, pour la simple raison que seul un rapport dans l'État membre de la société scindée devra être établi[2778]. Cependant, dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, un rapport séparé devra en principe être établi pour chaque société impliquée comme dans le cas d'une scission interne[2779]. Ceci signifie que dans l'hypothèse d'une scission par absorption classique, pas moins de trois rapports distincts devront être établis. Dans un souci de réduire les coûts associés à un rapport d'experts, un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante devrait par conséquent nécessairement prévoir une procédure de désignation d'un expert commun, combinée à l'établissement d'un rapport unique pour toutes les sociétés impliquées dans l'opération.

§ 6. L'étendue de la mission de contrôle de l'expert

572. Plan du § 6. Afin de se faire une idée détaillée de l'étendue exacte de la mission de contrôle de l'expert, il importe en premier lieu de préciser l'objet du contrôle de l'expert (A), pour ensuite s'intéresser à la vérification du projet commun (B), au contrôle du rapport d'échange (C) et au contrôle du montant de la soulte en espèces (D). En dernier lieu, il conviendra d'apprécier les éventuelles incidences du caractère transfrontalier de l'opération (E) et des spécificités d'une scission (F).

A. *L'objet du contrôle de l'expert*

573. Une mission centrée sur le projet commun de scission. Suite à sa nomination, l'expert devra à tout le moins procéder, tant en cas de scission interne[2780] ou transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés[2781] qu'en cas de fusion

2773 59e considérant de la Directive Sociétés et D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 189 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 115 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 13 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 17 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 587, n° 26.
2774 Art. 142, § 2 de la Directive Sociétés.
2775 Art. 96, § 2, de la Directive Sociétés.
2776 Art. 125, § 3 de la Directive Sociétés.
2777 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 309 et R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 403.
2778 Art. 160*septies* de la Directive Mobilité qui ne fait référence qu'à la société scindée.
2779 Art. 142, § 1er, 1re phrase de la Directive Société.
2780 Art. 142, § 2 de la Directive Sociétés.
2781 Art. 160*septies*, § 1er, 1re phrase de la Directive Mobilité.

interne[2782] ou transfrontalière[2783], à un examen méticuleux du projet commun de scission. Il en découle nécessairement que le ou les rapport(s) de l'organe de direction ou d'administration ne seront pas directement l'objet du contrôle de l'expert[2784], contrairement à ce qu'envisageait à l'origine la Proposition de la Commission[2785]. Cependant, en exécutant sa mission, l'expert devra nécessairement tenir compte de toutes les spécificités et circonstances entourant l'opération, en allant jusqu'au contexte économique global[2786]. Ceci implique que si un rapport de l'organe de direction ou d'administration a été établi, l'expert indépendant ne pourra faire l'impasse sur celui-ci, fut-il encore à l'état de projet[2787], et pourra s'en servir pour interpréter le projet de scission[2788]. On comprendrait en effet difficilement comment il pourrait lui être possible de donner un avis éclairé sur l'opération envisagée sans tenir compte des informations plus détaillées figurant dans le rapport de l'organe de direction ou d'administration.

B. *La vérification du projet commun*

574. Un contrôle assez large. L'expert indépendant aura tout d'abord pour mission de vérifier le projet commun de scission. Il s'ensuit qu'il devra indiquer dans son rapport si celui-ci est complet et exact[2789].

575. Un projet complet. La vérification du caractère exhaustif du projet commun de scission signifie simplement que l'expert indépendant devra vérifier que le contenu de celui-ci est bien conforme au prescrit de la loi[2790]. Cette exigence appelle deux remarques dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière. Tout d'abord, comme il a été démontré que le projet commun de scission transfrontalière devait nécessairement inclure des éléments inspirés du régime des fusions transfrontalières pour remplir correctement son objectif d'information[2791] et que celui-ci sera nécessairement plus complet que dans l'hypothèse d'une opération purement interne, il s'ensuit que l'étendue du contrôle de

2782 Art. 96, § 2 de la Directive Sociétés.
2783 Art. 125, § 3 de la Directive Sociétés.
2784 D. Beutel, *op. cit.*, p. 188 ; G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 9, n° 11 ; J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 278 ; Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 190, n° 255 et G. Zeidler in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 9, n° 17.
2785 Art. 160*decies*, § 1er et § 3, e) de la Proposition de la Commission et à ce sujet, voir : F. Bernard, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 26.
2786 Art. 1.2.1. de la norme de l'IRE belge relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021).
2787 Art. 2.1.2., al. 2 de la norme de l'IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021).
2788 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 9, n° 11 et G. Zeidler in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 9, n° 19.
2789 Art. 2.6. de la norme de l'IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021) et D. Beutel, *op. cit.*, pp. 188 et 199 ; G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 9, n° 17 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 313 et G. Zeidler in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 9, n 25.
2790 G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 9, n° 12 et G. Zeidler in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 9, n° 26.
2791 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Section 3, C.

l'expert indépendant sera plus vaste dans ce cas de figure. Ensuite, dans le cas particulier d'un projet commun à toutes les entités impliquées dans l'opération[2792], l'expert indépendant devra nécessairement vérifier que le contenu est conforme au prescrit de l'ensemble des *lex societatis* en présence appliquées cumulativement tout en privilégiant la norme la plus sévère.

576. Un projet exact. Une fois le caractère complet du projet commun de scission vérifié, l'expert indépendant devra procéder à un examen de l'exactitude des mentions figurant dans celui-ci[2793]. Cette mission ne doit pas être exagérée et il convient d'en fixer les limites à l'aune de l'objectif d'information du rapport d'expert[2794]. Il s'ensuit que l'expert devra avant tout vérifier si les mentions figurant dans le projet commun de scission ne sont pas en contradiction de quelque manière que ce soit avec les informations factuelles à sa disposition[2795]. Dans un contexte transfrontalier, ceci signifie que l'expert aura vraisemblablement également à examiner des documents étrangers et aura par conséquent tout intérêt à collaborer avec les experts étrangers à ce sujet.

C. *Le contrôle du rapport d'échange*

577. Une mission fondamentale. Il ressort du texte même de la Directive Sociétés que la vérification du caractère pertinent et raisonnable du rapport d'échange est le point central du contrôle réalisé par l'expert indépendant[2796], que ce soit dans le cadre d'une scission interne[2797] ou d'une fusion interne[2798]. Le même constat s'impose à l'égard des fusions transfrontalières[2799] et des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2800] et il devrait en être de même à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. Un tel contrôle s'articule autour de deux axes, à savoir (i) la vérification des évaluations des sociétés impliquées et (ii) la vérification du calcul du rapport d'échange.

578. La vérification de l'évaluation économique des sociétés. Avant de pouvoir espérer porter un jugement sur le rapport d'échange, l'expert indépendant devra tout d'abord se pencher sur les évaluations économiques à la base de celui-ci[2801]. Cette étape est fondamentale dans un contexte transfrontalier en raison de l'absence d'harmonisation au niveau européen des méthodes utilisées pour évaluer les sociétés[2802]. Il devra en outre indiquer si l'approche

2792 Sur la possibilité de nommer un expert commun chargé d'établir un rapport unique, voir *supra* n° 571.
2793 G. ZEIDLER in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 9, n° 27.
2794 G. ZEIDLER in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 9, n° 27.
2795 Art. 2.6.1., al. 2 de la norme de l'IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021) et G. ZEIDLER in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 9, n° 29.
2796 S. HERRLER et S. SCHNEIDER, *op. cit.*, p. 799 ; G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 9, n° 23 et G. ZEIDLER in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 9, n 30.
2797 Art. 142, § 2 de la Directive Sociétés.
2798 Art. 96, § 2 de la Directive Sociétés.
2799 Art. 125, § 3, 1re phrase de la Directive Mobilité.
2800 Art. 160*septies*, § 2, 1re phrase de la Directive Mobilité.
2801 Art. 160*septies*, § 2, b) de la Directive Mobilité.
2802 À ce sujet, voir *supra* n° 450.

retenue est adéquate en l'occurrence et donner un avis sur le poids plus ou moins important donné par l'organe de gestion à chacune de ces méthodes dans la détermination de la valeur finale des entreprises[2803]. De plus, si certaines difficultés d'évaluation surviennent, celles-ci devront également figurer dans le rapport[2804].

579. La vérification du calcul du rapport d'échange. Une fois l'évaluation des entités participantes réalisée, l'expert se penchera sur la manière dont ces évaluations ont été utilisées pour aboutir au rapport d'échange. À cet égard, il attachera une importance particulière à (i) la comparabilité des méthodes d'évaluation utilisées pour chacune des sociétés impliquées et (ii) le respect des droits des associés tant majoritaires que minoritaires[2805]. En d'autres termes, l'expert s'assurera que l'opération ne se fera pas au détriment manifeste d'une catégorie d'associés.

D. *Le contrôle du montant de la soulte en espèces*

580. Un contrôle dans l'intérêt des associés minoritaires. Compte tenu du fait que le législateur européen a fait le choix d'assurer à tout le moins partiellement la protection des associés minoritaires impacté par une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés par le biais d'un droit de retrait[2806] et que la fixation du montant de la soulte en espèces incombe en premier lieu à l'organe de direction où d'administration de la société scindée qui a tout intérêt à le réduire au maximum pour limiter le potentiel impact du droit de retrait sur les liquidités de la société, le législateur européen a jugé opportun d'imposer à l'expert indépendant de vérifier le caractère adéquat de cette soulte en espèces[2807]. Une telle mission est loin d'être inédite et se retrouve notamment en droit allemand[2808] et en droit autrichien[2809] qui connaissent tous deux un droit de retrait en cas de scission interne. Les critères pour la vérification de cette soulte en espèces sont identiques à ceux utilisés dans le cadre de la vérification du caractère adéquat du rapport d'échange, ce qui correspond également à la situation en droit allemand[2810]. Un tel contrôle devrait en tout état de cause également se retrouver dans un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante dans la mesure où il constitue d'une part une garantie du caractère adéquat de la soulte en espèces et d'autre part, il dissuadera éventuellement les associés minoritaires

2803 Art. 96, § 2, al. 1er, b) et 142, § 2 de la Directive Sociétés en matière de scissions internes et art. 160*septies*, § 2, c) de la Directive Mobilité (scissions transfrontalières).
2804 Art. 160*septies*, § 2, d) de la Directive Mobilité.
2805 Art. 3.3.2. de la norme de l'IRE belge relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021).
2806 Art. 160*decies*, §§ 1 à 5 de la Directive Mobilité et pour une analyse détaillée de ce mécanisme de protection, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 5, § 3.
2807 Sur le rôle de l'expert indépendant dans le cadre de la vérification de la soulte en espèces, voir *infra* nos 1055 à 1058. Voir en faveur d'un tel contrôle : ECLE, *op. cit.*, pp. 211 et 212 ; P. Stelmaszczyk, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440 et J. Schmidt, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16.
2808 §§ 30 (2) et 125 UmwG.
2809 § 5(4), 1. SpaltG.
2810 Voir en ce sens : B. Grunewald in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 30, n° 5.

de faire abusivement usage de leur droit de contester le montant de la soulte en espèces[2811].

E. *L'incidence du caractère transfrontalier de l'opération*

581. Une mission potentiellement plus large. Tant les dispositions de la Directive Sociétés en matière de scissions internes[2812] que celles de la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2813] ne font qu'imposer un minimum à l'égard de l'étendue de la mission de l'expert indépendant qu'il est loisible aux États membres de compléter. Un catalogue national plus complet ne posera pas de problème dans le cas où un rapport distinct est établi pour chaque société participant à l'opération puisque, comme en matière de fusions transfrontalières[2814], les règles relatives à l'entendue de la mission de l'expert indépendant s'appliqueront distributivement. En revanche, la question est plus épineuse dans l'hypothèse particulière de la nomination d'un expert commun. En effet, dans ce cas, on peut s'interroger si l'expert ainsi désigné devra accomplir sa mission de contrôle en respectant le prescrit de tous les droits nationaux en présence ou si, au contraire, le choix de l'autorité administrative ou judiciaire chargée de la nomination de l'expert conjoint n'opère pas également un choix de droit applicable à la mission de l'expert. En matière de fusions transfrontalières, il a été avancé qu'il fallait privilégier le droit national de l'expert ainsi nommé et qu'une application cumulative ne se justifiait pas en l'occurrence car la Directive Sociétés a procédé à une harmonisation de l'étendue minimale de la mission de contrôle de l'expert pour éviter de devoir réaliser un tel cumul[2815]. Si cet argument va certes dans le sens d'une simplification des opérations transfrontalières, il n'en méconnaît pas moins que l'objectif du rapport de l'expert indépendant est de protéger les associés et s'inscrit *de facto* dans une dynamique de protection des associés minoritaires susceptibles de se prononcer contre l'opération de restructuration. Or, reconnaître une application distributive revient à autoriser les parties à choisir le droit qui sera applicable à la mission de l'expert et, partant, à éluder les mécanismes de protection spécifiquement prévus par certains droits nationaux, comme le droit autrichien qui impose aux experts de se prononcer également sur les méthodes utilisées pour déterminer le prix de rachat qui sera proposé aux associés ayant voté contre la scission[2816]. Il s'ensuit qu'il convient de considérer qu'un rapport d'expert unique devient un acte commun à toutes les entités impliquées et qu'il conviendra de recourir à une application cumulative de tous les droits en présence tout en privilégiant la

2811 Art. 160*decies*, §§ 4 et 5 de la Directive Mobilité et sur la possibilité de contester le montant de la soulte en espèces, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 5, § 5, E.

2812 Selon l'art. 96, § 2, 1re phrase auquel l'art. 142, § 2 de la Directive Sociétés renvoie, « [d]ans le rapport visé au paragraphe 1, les experts doivent en tout cas déclarer […] ».

2813 Selon l'art. 160*septies*, § 1er, 1re phrase de la Directive Mobilité, « [l]e rapport […] contient *en tout état de cause* […] ».

2814 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 189 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 310.

2815 G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 10 et R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 405.

2816 § 5 (4) SpaltG.

norme la plus sévère[2817]. Par souci de sécurité juridique et dans la mesure où les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante sont susceptibles de mettre en concurrence un nombre relativement important de droits nationaux potentiellement distincts à cet égard, il serait bon qu'une initiative européenne en la matière précise explicitement cette règle de conflit de lois.

F. *L'incidence des spécificités d'une scission*

582. La nécessité de contrôles additionnels en cas de scission. Dans un souci de simplification, le législateur européen a fait directement référence au régime applicable au contenu du projet de fusion interne en déterminant les normes applicables au projet de scission interne[2818]. Cependant, il n'a pas jugé utile de compléter ce régime en tenant compte des spécificités propres aux opérations de scissions. Ainsi, pour être plus conforme à son objectif d'information et de protection des associés, ce contrôle aurait également dû porter sur la méthode utilisée pour déterminer le critère de répartition des actions des sociétés bénéficiaires attribuées aux associés de la société scindée. Ce point a été très justement reconnu par le législateur autrichien[2819], ainsi que par l'Institut des réviseurs d'entreprises belge[2820] et luxembourgeois[2821], mais ne s'est malheureusement pas retrouvé dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité. Cet aspect mériterait toutefois d'être rectifié dans le cadre de la mise en place d'un régime européen plus général des scissions transfrontalières.

§7. Le contenu du rapport d'expert

583. La conclusion du contrôle. Le rapport de l'expert indépendant devra nécessairement contenir un descriptif et une justification des résultats auxquels l'expert aura abouti suite à l'accomplissement de sa mission de contrôle[2822]. Le contenu du rapport a fait l'objet d'une harmonisation minimale par le législateur européen dans le cadre des scissions[2823] et des fusions[2824] internes, mais également des fusions transfrontalières[2825] et des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2826]. À l'égard de ces dernières, le rapport

2817 D. Beutel, *op. cit.*, p. 189 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 5 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 310.
2818 Art. 142, § 2 de la Directive Sociétés.
2819 § 5 (4) SpaltG.
2820 Art. 2.6.2., al. 1er de la norme de l'IRE belge relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021).
2821 Art. 3.6.6., al. 6 de la norme professionnelle NP2018-07 du 19 juin 2018 de l'IRE luxembourgeois sur les diligences professionnelles du réviseur d'entreprises dans le cadre des opérations de fusions et scissions, www.ire.lu (01/09/2021).
2822 G. Zeidler in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 12, n° 7.
2823 Art. 142, § 2 de la Directive Sociétés.
2824 Art. 96, § 2 de la Directive Sociétés.
2825 Art. 125, § 3, al. 1er de la Directive Mobilité.
2826 Art. 160*septies*, § 2, al. 1er de la Directive Mobilité.

devra ainsi, en tout état de cause, contenir (i) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces et le rapport d'échange, (ii) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour ce faire, une indication de la valeur obtenue à l'aide de cette méthode et un avis sur l'importance relative donner à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue et (iii) une indication des difficultés d'évaluation éventuellement rencontrées et susceptibles d'avoir une incidence sur le rapport d'échange ou la soulte en espèces. Compte tenu du champ d'application limité de la Directive Mobilité[2827], le législateur européen n'a pas précisé que dans le cadre d'une scission transfrontalière l'expert indépendant devrait également inclure dans son rapport une indication sur la justification de l'utilisation de méthodes différentes si différentes méthodes étaient utilisées dans les sociétés impliquées dans l'opération, contrairement à ce qui est le cas dans le nouveau régime des fusions transfrontalières[2828]. Or, comme dans le cas d'une scission mixte ou d'une scission par absorption, il est tout à fait probable que la société scindée et la ou les société(s) bénéficiaire(s) n'applique pas nécessairement les mêmes méthodes d'évaluation, une telle indication pourrait pourtant s'avérer utile pour une meilleure information des associés. Il serait donc utile de l'inclure au sein du catalogue du contenu minimum du rapport d'expert dans le cadre de la mise en place d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. En outre, il serait utile en vue de tenir compte du caractère particulier d'une scission par rapport à une fusion, que le rapport d'expert contienne également un avis de l'expert indépendant sur le critère utilisé pour la répartition des actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée.

584. L'incidence du caractère transfrontalier. À l'instar de ce qui a été développé à propos de l'étendue de la mission de l'expert indépendant en cas de rapport unique[2829], on peut considérer que les diverses dispositions nationales relatives au contenu devront faire l'objet d'une application cumulative tout en privilégiant la norme la plus sévère[2830].

§ 8. La langue du rapport

585. Un régime variable. Le caractère commun ou individuel du rapport influera directement sur le régime linguistique qui lui sera applicable. En effet, si chacune des sociétés impliquées procède à l'établissement d'un tel rapport, les exigences linguistiques des différents États membres s'appliqueront distributivement[2831]. *A contrario*, en cas de rapport commun, il faudra recourir à une application cumulative, ce qui signifie que le rapport pourra être traduit en plusieurs langues[2832], ce qui renforce à nouveau l'intérêt de pouvoir établir celui-ci dans « une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances

2827 Art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité.
2828 Art. 125, § 3, al. 1er, c) de la Directive Mobilité.
2829 À ce sujet, voir *supra* n° 571.
2830 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 310.
2831 J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 317.
2832 *Ibidem*.

internationales »[2833][2834] tout en prévoyant la possibilité pour les destinataires du rapport d'en demander sans frais une version dans une des langues nationales des sociétés concernée.

§9. La renonciation au rapport d'expert

586. Une simplification inspirée du régime des fusions transfrontalières. Si la possibilité de renoncer au rapport d'expert indépendant était à l'origine une spécificité du régime des fusions transfrontalières[2835] absente tant du régime des fusions internes[2836] que de celui de la société européenne[2837] et laissée à l'entière discrétion des États membres en cas de scissions internes[2838], elle a par la suite été étendue aux fusions internes[2839] et rendue obligatoire en matière de scissions internes[2840]. S'il est certes vrai qu'une telle disposition profite avant tout aux sociétés à l'actionnariat peu dispersé[2841], elle permet indiscutablement de faciliter et d'accélérer le processus de restructuration tout en réduisant les coûts de manière significative[2842]. Il n'est donc pas surprenant de constater que le législateur européen ait également intégré une telle faculté de renonciation dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2843].

587. L'exigence d'une renonciation unanime. À l'égard des fusions transfrontalières, le texte de la Directive Sociétés précise qu'une renonciation à l'examen du projet commun et au rapport d'expert n'est possible qu'avec l'accord unanime des associés de chacune des sociétés impliquées[2844]. Il s'ensuit que pour pouvoir éluder cette étape du processus de restructuration, il faudra nécessairement que les associés des sociétés étrangères aient également renoncé à celle-ci[2845]. Cette exigence peut paraître lourde, *a fortiori* en cas d'actionnariat

2833 Art. 160*sexies*, § 4 de la Directive Mobilité.
2834 Voir en ce sens de manière générale : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 24.
2835 Art. 8, § 4 de la Dixième Directive.
2836 Art. 10 de la Troisième Directive.
2837 Art. 22 du Règlement sur la Société européenne.
2838 Art. 10 de la Sixième Directive.
2839 Art. 2, § 1er de la directive (CE) 2007/63 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, *J.O.*, L 300, 17 novembre 2007, pp. 47 et 48.
2840 Art. 3, § 2 de la directive (CE) 2007/63 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, *J.O.*, L 300, 17 novembre 2007, pp. 47 et 48.
2841 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 191 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 115 et G. ZEIDLER in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 9, n° 51.
2842 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 191 ; M FRISCHHUT, *op. cit.*, p. 58 et U. GROHMANN et N. GRUSCHINSKE, « Grenzüberschreitende Mobilität von Kapitalgesellschaften in Europa – Die Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *GmbHR*, 2006, p. 192.
2843 Art. 160*septies*, § 3, al. 1er de la Directive Mobilité.
2844 Art. 125, § 4 de la Directive Sociétés.
2845 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 842 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 191 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 7 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes… », *op. cit.*, p. 728 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 232 et G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 4.

fortement dispersé[2846], mais elle s'explique par le fait que la mission de l'expert indépendant s'inscrit dans une dynamique de protection des intérêts de tous les associés[2847]. Compte tenu de ces considérations, il convient de plaider en faveur d'une extension de cette condition d'unanimité internationale aux scissions transfrontalières. Or, comme le régime de la Directive Mobilité n'envisage que les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, il n'est pas surprenant de constater que le législateur européen ne mentionne que la condition d'unanimité au sein de la société scindée. Cependant, dans l'hypothèse de la mise en place d'un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, il conviendra de s'inspirer de la solution des fusions transfrontalières et de requérir l'unanimité au sein de chacune des sociétés impliquées dans l'opération.

588. La forme de la renonciation. Ni la Directive Sociétés, ni la Directive Mobilité ne prévoient de condition de forme à cette renonciation, de sorte que chaque État membre demeure en principe libre d'imposer ou non un certain formalisme. Ainsi, dans l'hypothèse d'une scission interne, (i) en droit allemand[2848], la renonciation doit nécessairement faire l'objet d'un acte notarié, (ii) en droit autrichien[2849], il suffit d'un écrit ou d'une renonciation figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale, (iii) en droit belge[2850], tout comme en droit luxembourgeois[2851], la loi est muette à ce sujet, mais dans ce dernier cas, il est fréquent en pratique de prévoir un écrit soit sous forme de renonciation individuelle soit sous forme de résolution unanime des associés passée sous seing privé. Il en découle qu'en cas de scission transfrontalière, on pourrait aisément se retrouver dans la situation où des exigences de forme différentes se verraient confrontées, comme par exemple dans le cas de la scission d'une société luxembourgeoise au profit de deux sociétés allemandes. Comme la renonciation, pour être valable, doit être unanime au sein de toutes les sociétés impliquées[2852], on pourrait en conclure qu'il s'agit là d'un acte commun à toutes les entités concernées entraînant par conséquent une application cumulative des différents droits nationaux tout en privilégiant la norme la plus sévère. Cette question a généré certaines interrogations en droit allemand à l'égard des fusions transfrontalières, notamment en raison de la formulation particulièrement générale du texte de loi imposant la forme notariée[2853]. Cependant, outre le fait qu'imposer la forme

2846 Voir en ce sens : J. RICKFORD, *op. cit.*, p. 1408.
2847 À ce sujet, voir *supra* n°s 569 et 570.
2848 §§ 8 (3), *in fine* et 125 UmwG.
2849 § 5 (6), SpaltG.
2850 Art. 12:62, § 1er, al. 6 et art. 12:78, al. 6 du CSA.
2851 Art. 1031-8, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
2852 Voir en ce sens au sujet des fusions transfrontalières : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 842 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 403 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 191 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 7 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes – Erleichterung grenzüberschreitender Verschmelzungen für deutsche Kapitalgesellschaften ? », *op. cit.*, p. 728 et G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 4.
2853 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 842 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 7 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes… », *op. cit.*, p. 728 ; H. HECKSCHEN, *op. cit.*, p. 459 et G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122f, n° 4.

notariée aux associés d'une société dont le droit national ne connaît pas cette exigence compliquerait inutilement la procédure et engendrerait des difficultés au niveau de la reconnaissance des actes notariés passés à l'étranger[2854], un tel raisonnement serait contraire, en matière de fusions transfrontalières, au principe selon lequel une telle opération reste pour chaque société impliquée soumise aux modalités de sa propre loi nationale, sauf disposition contraire figurant dans la Directive Sociétés[2855]. On doit donc en conclure que les exigences de forme s'appliquent distributivement[2856] et que, par analogie, il devra en être de même en cas de scission transfrontalière.

§10. L'exemption du rapport d'expert

589. L'exemption des sociétés unipersonnelles. Conformément à sa volonté de réduire les coûts et de simplifier la procédure pour les micro-entreprises et les petites entreprises[2857], la Proposition de la Commission excluait à l'origine les micro-entreprises et les petites entreprises[2858] de l'obligation d'établir un rapport d'expert[2859]. Bien que cette exemption fût accueillie positivement par le Comité économique et social européen[2860] ainsi que par certains auteurs[2861], elle fut remplacée dès le Premier Compromis de la Présidence par une possibilité pour les États membres d'exclure les sociétés unipersonnelles[2862] qui se retrouva en définitive dans la Directive Mobilité[2863]. S'il est certes vrai que le coût d'un rapport d'expert peut s'avérer être particulièrement lourd pour une micro-entreprise pour laquelle une scission transfrontalière constituerait néanmoins une option de restructuration intéressante, il convient de ne pas perdre de vue que le rapport d'expert sert avant tout à protéger les associés

2854 Sur cette problématique à l'égard de la forme du projet commun de scission, voir *supra* n°s 428 et 429 et Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 7.

2855 Art. 121, § 1er, lit. b de la Directive Sociétés.

2856 *Pro :* D. Beutel, *op. cit.*, p. 191 ; R. Frenzel, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 263 ; R. Frenzel, « Grenzüberschreitende Verschmelzung nach Ablauf der Umsetzungsfrist », *op. cit.*, p. 19 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 246 ; G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 4 et H.-F. Müller, « Der Schutz der Minderheitsgesellschafter bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *Der Konzern*, 2007, p. 83. *Contra :* Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122f, n° 7 et Fl. Drinhausen et A. Keinath, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes… », *op. cit.*, p. 728.

2857 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 23.

2858 Pour ce qui est de la définition de « microentreprise » et de « petite entreprise », la Proposition de la Commission opère un renvoi à l'article 2 de la Recommandation de la Commission (CE) 2003/361 du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), disponible sur http://eur-lex.europa.eu (17/06/2018), qui définit les microentreprises comme celles qui occupent « moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros » et les petites entreprises comme celles qui occupent « moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ».

2859 Art. 160*decies*, § 6 de la Proposition de la Commission.

2860 Avis CESE, pts. 1.15 et 3.6.11 où le CESE considère que « le coût d'un tel rapport constituerait une charge excessive pour ces entreprises de petite taille ».

2861 Voir en ce sens : S. Binard et L. Schummer, *op. cit.*, p. 35. *Contra* : J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, pp. 278 et 279 et H. Wicke, « Optionen und Komplikationen… (Teil I) », *op. cit.*, p. 2646.

2862 Art. 160i, § 3, 2e phrase du Premier Compromis de la Présidence.

2863 Art. 160*septies*, § 3, al. 2 de la Directive Mobilité.

minoritaires[2864]. Il est donc surprenant de considérer que ceux-ci ne requièrent pas de protection spécifique dans une micro ou petite entreprise. C'est donc à juste titre que le législateur européen a restreint la dispense du rapport d'expert indépendant aux seules entreprises unipersonnelles[2865] et c'est la solution qui devrait également prévaloir dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante.

SECTION 6. MESURES DE PUBLICITÉ

590. Plan de la section 6. Les mesures de publicité revêtent un caractère fondamental en cas de scission transfrontalière dans la mesure où elles garantissent une parfaite information des *stakeholders* sur les spécificités de l'opération envisagée. Les étudier impose en premier lieu d'aborder la question de la publication à l'ère numérique (§ 1), celle des délais applicables (§ 2), celle de l'étendue des informations à publier (§ 3), celle de la mise à disposition des documents préparatoires (§ 4) et, en dernier lieu, celle de l'obligation d'information en cas de modification importante du patrimoine actif et passif (§ 5).

§1. Publication classique et ère numérique

A. *Une étape essentielle*

591. Une publicité de principe. Le projet de scission transfrontalière, à l'instar du projet de scission interne[2866], du projet de fusion interne[2867] ou transfrontalière[2868] et du projet de transformation transfrontalière[2869], devra, suite à son approbation par les organes de gestion ou d'administration chargés de l'établir, être publié au registre au plus tard un mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale qui devra se prononcer sur l'opération[2870]. Les contours de cette publication à l'égard des fusions transfrontalières ont fait l'objet d'une refonte dans le cadre de la Directive Mobilité suite à l'adoption de la Directive Outils Numériques[2871], contrairement toutefois au régime des

2864 À ce sujet, voir *supra* n°s 569 et 570.

2865 Voir en faveur d'une telle exclusion : P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 69, n° 52.

2866 Art. 138, § 1er de la Directive Sociétés.

2867 Art. 92, § 1er de la Directive Sociétés.

2868 Art. 123, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

2869 Art. 86*octies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

2870 Art. 160*octies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

2871 Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 186, 11 juillet 2019, pp. 80–104 (ci-après la « **Directive Outils Numériques** »). Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 248 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 241 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 69, n° 56. Voir au sujet de la Directive Outils Numériques : S. ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, « Proposal regarding the use of digital tools and processes in compan law : the practitioner's perspective », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 149–189 ;

scissions[2872] et fusions[2873] internes qu'il aurait pu être utile d'harmoniser également par souci de cohérence. Dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, les règles prévues par chaque État membre à cet égard s'appliqueront distributivement[2874], ce qui signifie que chaque société impliquée dans l'opération devra procéder à une publication conformément au prescrit de la *lex societatis* à laquelle elle est soumise.

592. Une double finalité : information et délais. Cette publication constitue une étape essentielle de la procédure dans la mesure où c'est elle qui va, en principe, porter le projet de restructuration tant à la connaissance des associés que des tiers[2875]. En pratique, cette assertion doit être nuancée car un nombre considérable d'opérations de restructuration ont lieu au sein du même groupe de sociétés[2876] et sont initiées à la requête des conseils de la société-mère. Les associés sont par conséquent fréquemment déjà avertis de l'opération avant la publication du projet commun et ont en général déjà donné un accord de principe quant aux conditions essentielles de l'opération afin d'éviter tout risque de rejet au moment de l'assemblée générale. Il en va généralement de même des principaux créanciers qui jouissent généralement de mécanismes de protection conventionnels imposant aux parties de requérir leur accord en amont de toute opération de restructuration[2877]. Cette publication aura cependant toujours comme intérêt de servir de point de départ au calcul de différents délais applicables à la procédure, comme celui applicable à la tenue de l'assemblée générale[2878], aux mécanismes de protection des créanciers[2879]

J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Digitalisierung des Gesellschaftsrechts nach dem EU-Company Law Package – Zum neuen EU-Rechtsrahmen für die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften », *NZG*, 2019, pp. 601–612 ; P.-H. Conac, « Le retour du courage politique à Bruxelles : l'Odyssée du "Paquet droit des sociétés" de 2018 », *op. cit.*, pp. 31–41 ; R. Knaier, « Crossing borders, digitally… », *op. cit.*, R148 – R150 ; Fl. Möslein, « Back to the digital future ? On the EU Company Law Package's approach to digitalization », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 4 et 5 ; S. Omlor, « Digitalization and EU Company Law : innovation and tradition in tandem », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 6–12 ; J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, pp. 229–235 ; G. Spindler, « Digitalization and corporate law – A view from Germany », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 106–148.

2872 Art. 138 de la Directive Sociétés.

2873 Art. 92 de la Directive Sociétés.

2874 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : H. le Nabasque, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 2 ; U. Lennerz, *op. cit.*, p. 165 ; Fl. Parrein, *op. cit.*, p. 313 ; Th. Prüm, *op. cit.*, p. 84 ; Th. Tilquin et J.-A. Delcorde, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 45, n° 57 et Th. Tilquin, J.-A. Delcorde, Ph. Malherbe, D. Garabedian et P. Geerebaert, *op. cit.*, p. 30. *Du même avis, mais parlant alors d'application cumulative différenciée :* E. Roelofs, *op. cit.*, p. 400.

2875 58e considérant de la Directive Sociétés et Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122d, nos 2 et 3 ; M. Evrard et E. van der Vaeren, *op. cit.*, p. 114 et P. Van Ommeslaghe, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 16.

2876 Selon les données collectées par Bech-Bruun et Lexidale et en appliquant des critères très conservateurs, près de 38 % des fusions transfrontalières étudiées pouvaient être qualifiées d'opérations intra-groupes, voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 49. Compte tenu de la proximité entre les deux modes de restructuration, on peut partir du postulat qu'il en va de même en matière de scissions.

2877 Sur les mécanismes contractuels de protection des intérêts des créanciers, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 3.

2878 Art. 92, al. 1er ; art. 123, § 1er, al. 1er et art. 138, al. 1er de la Directive Sociétés.

2879 Art. R. 236-8, § 1er du Code de commerce français et § 122j UmwG et St. Reynolds, A. Scherrer et E. Truli, *op. cit.*, p. 38.

ou encore de la participation des travailleurs[2880]. Elle sera par conséquent inéluctable en matière de scissions transfrontalières.

593. Une innovation de la Directive Mobilité. Par rapport au régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés[2881], l'exigence de publicité prévue par la Directive Mobilité présente la particularité intéressante de couvrir également une notification informant les différents *stakeholders* qu'ils disposent de la possibilité de présenter des observations sur le projet de scission transfrontalière au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale[2882], ce qui devrait renforcer la transparence de la procédure[2883] tout en permettant d'assurer une prise de décision éclairée au niveau de l'assemblée générale. Dans la mesure où le rapport d'expert indépendant est susceptible de présenter un intérêt également pour des *stakeholders* autres que les associés[2884], la Directive Mobilité prévoit également que les États membres disposent de la faculté d'exiger la publication de ce dernier moyennant, le cas échéant, l'exclusion des éventuelles informations confidentielles[2885]. Étant donné qu'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante entraîne des risques accrus pour bon nombre de *stakeholders*, un régime européen en la matière intégrerait utilement ces deux mesures de publicité additionnelles. En outre, articuler certains régimes de protection spécifiques des créanciers[2886] et des associés minoritaires[2887] autour des conclusions du rapport d'expert indépendant requerra nécessairement que celui-ci soit à leur disposition. Il s'ensuit que si les solutions défendues ci-après devaient être mises en place lors d'une initiative ultérieure[2888], la publication du rapport d'expert indépendant moins les informations confidentielles devrait être rendue obligatoire, contrairement à ce qui est le cas dans le régime actuel[2889].

B. *Publication numérique*

594. La simplification par le numérique. Le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2890] conserve, en les rendant néanmoins facultatives[2891], les innovations introduites par la directive (CE) 2009/109[2892] qui

2880 Art. 133, § 2 de la Directive Sociétés.
2881 Art. 12, § 1er, al. 1er de la Directive Sociétés.
2882 Art. 160*octies*, § 1er, al. 1er, b) de la Directive Mobilité.
2883 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 358.
2884 Sur le rôle du rapport d'expert dans le cadre de la protection des créanciers, voir *infra* nos 931 et 934.
2885 Art. 160*octies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
2886 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 2, B.
2887 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1er, Section 5.
2888 À ce sujet, voir *infra* n° 934.
2889 Art. 160*octies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
2890 Art. 160*octies*, § 2 de la Directive Mobilité.
2891 Le caractère facultatif se déduit de l'emploi du verbe « peuvent » à l'art. 160*octies*, § 2 de la Directive Mobilité. Pour un point de vue critique de ce choix, voir J. SCHMIDT, EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 241.
2892 Directive (CE) 2009/109 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive (CE) 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions, *J.O.*, L 259, 2 octobre 2009, pp. 14 à 21 (ci-après « la **Directive Fusions et Scissions Electroniques** »).

avaient pour objectifs tant d'adapter le droit des sociétés à l'ère numérique que de réduire les coûts engendrés par une restructuration transfrontalière[2893]. Les États membres disposeront par conséquent de la possibilité de dispenser la société scindée des obligations classiques de publication[2894] si celle-ci préfère au contraire opter pour une mise à disposition gratuite du projet et de l'avis aux *stakeholders* sur son site internet propre pendant une période continue d'au moins un mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale[2895]. En tout état de cause, compte tenu du fait que l'utilisation des moyens numériques en vue d'assurer la publicité du projet commun va dans le sens d'une plus grande efficacité[2896], il est logique que ce type de publication soit également ouvert dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. Le caractère facultatif de cette option pour les États membres est certes déplorable[2897], *a fortiori* dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière où, compte tenu du nombre de sociétés impliquées, la réduction des coûts et la simplification qu'une publication sur le site internet auraient pu engendrer auraient été d'autant plus intéressantes et constitue possiblement une concession aux visées plus protectionnistes des États membres qui auront ainsi la possibilité, par le biais de formalités de publicité plus lourdes, de décourager un certain nombre de transactions[2898].

2893 1er et 2e considérants de la Directive Fusions et Scissions Electroniques et A. Tilleux et E. Weemaels, « Les nouvelles obligations en matière de fusions et de scissions – Le droit des sociétés se prépare à entrer dans le XXIe siècle », *J.T.*, 2 mars 2013, n° 6511, p. 145, n° 1.

2894 Il convient toutefois de relever qu'une mise à disposition des documents préparatoires sur un site internet ne dispense pas pour autant une société de toutes formalités de publication dans le registre puisqu'en application de l'art. 160*octies*, § 3 de la Directive Mobilité, lorsque la société scindée met à disposition le projet de scission transfrontalière sur son site internet, elle devra malgré tout soumettre au registre compétent, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale, les informations suivantes : « a) la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination de la ou des sociétés nouvellement créées résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leur siège statutaire ; b) le registre auprès duquel les [les principaux documents sociaux visés à l'article 14 de la Directive Sociétés] sont déposés pour la société scindée et son numéro d'immatriculation dans ce registre ; c) une indication des modalités d'exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés ; et d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d'obtenir gratuitement et en ligne le projet de scission transfrontalière, l'avis [informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l'absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière], le rapport de l'expert indépendant et les informations complètes sur les dispositions [relative aux modalités d'exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés]. Le registre met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d). ».

2895 Pour un point de vue critique d'une telle flexibilité, voir : Th. Luy, « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Company Law Package », *op. cit.*, p. 1909 ; P. Stelmaszczyk, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 69, n° 56 et Th. Wachter, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 290. Voir en faveur d'une telle flexibilité et prônant même son caractère obligatoire : J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 241.

2896 Ph. Malherbe, « Allègements et développements en matière de fusions » in *Droit des sociétés – Millésime 2011*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 351, n° 26.

2897 Voir en ce sens : J. Schmidt, EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 241.

2898 Sur la légitimation d'un éventuel retour au protectionnisme par la Directive Mobilité, voir : I. Corbisier, « Les nouvelles dispositions… », *op. cit.*, pp. 809 et 810.

595. Une étape intermédiaire. Il est toutefois également possible d'y voir une forme d'étape intermédiaire. En effet, se doutant de l'éventuelle réticence des États membres à l'égard d'une publication sur le seul site internet de la société dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, il est possible que la Commission[2899] ait préféré prévoir d'abord que celle-ci serait laissée à la discrétion des États membres pour ensuite se servir des conclusions qu'elle pourrait glaner de cette expérience pour justifier un alignement du régime des scissions transfrontalières sur celui des scissions internes[2900] lors d'une initiative ultérieure en la matière.

596. Le système d'interconnexion des registres centraux. Tirant pleinement parti de la mise en place du système d'interconnexion des registres centraux[2901], la Directive Mobilité prévoit que les différents documents devant être publiés dans le cadre de la procédure de scission transfrontalière devront également être accessibles via le système d'interconnexion des registres centraux. Ce système, opérationnel depuis juin 2017[2902], permettra d'améliorer l'information des différents stakeholders[2903], *a fortiori* dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante puisque dans cette dernière hypothèse, la publication des documents préparatoires devra être effectuée dans plus d'un État membre.

§2. Les délais applicables

597. La possibilité de renoncer au respect du délai de publication. En droit allemand, il est admis, sur la base du constat que le délai d'un mois est avant tout destiné à permettre aux associés de se préparer à l'assemblée qui se prononcera sur l'opération[2904], que les associés puissent dans un contexte interne[2905] renoncer à l'unanimité au respect de celui-ci, voire au dépôt du contrat de fusion

2899 Le caractère facultatif de la reconnaissance d'une publication sur le site internet de la société concernée remonte à la Proposition de la Commission. Voir art. 160*undecies*, § 2, al. 1er de la Proposition de la Commission.

2900 L'art. 138, al. 2 de la Directive Sociétés impose obligatoirement aux États membres de dispenser des obligations de publicité au registre compétent toute société participant à une scission et qui pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, met gratuitement à la disposition du public ce projet de scission sur son site internet.

2901 Le système d'interconnexion des registres est issu (i) de la directive (UE) 2012/17 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 156, 16 juin 2012, pp. 1–9 et (ii) du Règlement d'exécution (UE) 2015/884 de la Commission du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 144, 10 juin 2015, pp. 1–9. Il est accessible à l'adresse suivante : https://beta.e-justice.europa.eu (6/07/2020).

2902 7e considérant de la Directive Outils Numériques.

2903 Voir en ce sens : R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 615.

2904 H. DIEKMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 61, n° 5 et B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 61, n° 7.

2905 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 122d, n° 17 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 122d, n° 11 et C. KRUSE et Co. KRUSE, *op. cit.*, p. 3036.

ou de scission interne auprès du registre de commerce[2906]. Cependant, la situation ne peut être identique dans l'hypothèse d'une opération transfrontalière. En effet, à l'égard des fusions transfrontalières, le législateur européen a pris soin de préciser que cette obligation de publication était destinée à protéger les intérêts tant des tiers que des associés[2907]. Une telle interprétation est par ailleurs confortée par l'exigence d'une mention additionnelle relative spécifiquement à la protection des intérêts des créanciers et des associés minoritaires[2908] qui se retrouve également dans le régime des scissions par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité[2909]. Ceci justifie le fait que lorsqu'un État membre admet que dans le cadre d'une opération interne, il soit possible aux associés de renoncer aux formalités de publication[2910], une telle liberté ne puisse exister en matière d'opérations transfrontalières[2911]. Une telle exception se justifie d'autant plus que certains États membres, comme la France[2912], ont fait le choix en matière de fusions transfrontalières de faire dépendre certains mécanismes de protection des créanciers de la date de publication du projet commun. En ce qui concerne la possibilité pour les assemblées générales de réduire le délai devant nécessairement s'écouler entre la publication et la tenue de l'assemblée générale sans renoncer intégralement à la publication, il a été avancé en droit allemand qu'une telle réduction devait être possible[2913], comme c'est le cas en droit interne[2914]. La justification tient au fait que le droit allemand calcule le délai d'un mois à partir du dépôt du projet commun par opposition à sa publication[2915]. Si on combine cela avec le fait que les membres de l'organe de direction ou d'administration de la société absorbée ont l'obligation de

2906 H. Diekmann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 61, n° 17 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 122d, n° 11 et R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 3.

2907 58e considérant de la Directive Sociétés et Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 122d, nos 2, 3 et 9 ; M. Evrard et E. van der Vaeren, *op. cit.*, p. 114 ; H.-F. Müller, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 288 et P. Van Ommeslaghe, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 16.

2908 Art. 123, § 3, c) de la Directive Mobilité.

2909 Art. 160*octies*, § 3, c) de la Directive Mobilité.

2910 B. Grunewald in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 61, n° 7 et R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 3.

2911 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 17 ; D. Beutel, *op. cit.*, p. 168 ; R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 122d, n° 3 ; St. Klein, *op. cit.*, p. 590 ; C. Kruse et Co. Kruse, *op. cit.*, p. 3036 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 329 et H.-F. Müller, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 288.

2912 En droit français, le délai d'opposition de 30 jours dont jouissent les créanciers commence à courir à partir de la date de publication du projet commun de fusion transfrontalière. Voir art. R. 236-8 du Code de commerce français.

2913 W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 18 et Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 12.

2914 H. Diekmann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 61, n° 17 et Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 122d, n° 11.

2915 § 122d, al. 1er UmwG. Sur la contrariété de cette disposition au texte européen, voir : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 7 ; W. Bayer et J. Schmidt, « Der Referentenentwurf zum 3. UmwÄndG : Vereinfachungen bei Verschmelzungen und Spaltungen und ein neuer verschmelzungspezifischer Squeeze out », *op. cit.*, p. 962 ; D. Beutel, *op. cit.*, p. 177 ; R. Frenzel, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 232 ; S. Herrler et S. Schneider, *op. cit.*, p. 797 ; Chr. Louven, *op. cit.*, p. 2025 et R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 1.

certifier à un stade ultérieur de la procédure qu'une sûreté adéquate a bien été fournie à tous les créanciers qui y avaient droit[2916], on constate qu'une réduction du délai s'écoulant entre l'assemblée générale et la publication du projet commun, pour peu qu'elle soit couverte par l'approbation des associés, n'est pas de nature à nuire aux intérêts des créanciers et doit donc être permise[2917]. En effet, ce délai ne sert que les intérêts des associés[2918]. Si ce raisonnement est certes convaincant de prime abord, et présente l'indéniable avantage d'aller dans le sens d'une plus grande flexibilité et de permettre d'accélérer le processus, force est de constater que son applicabilité au régime des fusions transfrontalières est étroitement liée aux spécificités nationales de la transposition des dispositions de la Directive Sociétés. En d'autres termes, une telle réduction du délai n'est possible que parce que d'une part le législateur allemand a erronément transposé le texte de la Directive Sociétés en confondant dépôt et publication[2919] et d'autre part parce que le régime de protection des créanciers mis en place, malgré son caractère *ex ante*[2920], est efficace indépendamment du respect ou non du délai entre la date de publication et la tenue de l'assemblée générale[2921].

598. Quid en cas de scissions transfrontalières ? Comme les scissions transfrontalières présentent au moins autant de risques pour les créanciers qu'une fusion transfrontalière, on peut légitimement penser que la publication du projet commun se fera tant dans l'intérêt des associés, que des créanciers. Ce point est confirmé par les dispositions de la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés puisqu'elle prévoit une publication dans l'intérêt des créanciers, des travailleurs et des associés[2922]. Il s'ensuit qu'il ne pourrait en tout état de cause être possible de faire l'impasse sur la publication et ce, quand bien même elle serait couverte par une décision unanime des associés. Un raisonnement similaire s'applique également à la possibilité de réduire le délai de publication puisque cela aurait pour conséquence néfaste d'amputer une partie des délais des mécanismes de protection des *stakeholders* s'articulant autour de la date du jour de la publication du projet[2923].

§ 3. Une obligation de publication dépassant le seul projet commun

599. Les mentions additionnelles. Conformément à son objectif d'information des *stakeholders*[2924], la publication du projet commun de scission transfrontalière

2916 § 122k (1) UmwG.
2917 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 12.
2918 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 18.
2919 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 177 ; Chr. LOUVEN, *op. cit.*, p. 2025 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 1.
2920 Sur cette notion, voir *infra* n° 896.
2921 § 122k (1) UmwG.
2922 Art. 160*octies*, b) de la Directive Mobilité.
2923 Sur la nécessité d'articuler le droit de retrait des actionnaires minoritaires autour de cette date, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1er, Section 7, § 2.
2924 15e considérant de la Directive Mobilité. Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122d, nos 2, 3 et 9 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 114 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 322 et 323 ; H.-F. MÜLLER, « Die

présente la spécificité, par rapport aux scissions internes[2925], d'impliquer l'obligation pour la société concernée, pour peu qu'elle fasse usage de la faculté de mettre les documents à disposition sur son site internet propre, de déposer un certain nombre de mentions additionnelles auprès du registre compétent au moins un mois avant la date de l'assemblée générale[2926]. La société concernée devrait ainsi déposer (i) la forme juridique, le lieu du siège statutaire et la dénomination de la société scindée, ainsi que la forme juridique, la dénomination de la ou des sociétés nouvellement créées au cours de l'opération, (ii) le registre compétent pour la société scindée et son numéro d'immatriculation dans ce registre, (iii) une indication des modalités d'exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés et (iv) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d'obtenir gratuitement le projet de scission, l'avis selon lequel les *stakeholders* peuvent soumettre des observations, le rapport d'expert indépendant et les informations complètes sur les modalités d'exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés. Ces différentes informations présentent indéniablement un intérêt pour les différents *stakeholders* impactés et devraient, en toute logique, se retrouver également dans un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. Cependant, on peut s'interroger sur la nécessité de déposer auprès du registre de la société scindée l'information selon lequel ce registre est compétent ainsi que le numéro d'immatriculation dans ce registre de la société scindée[2927]. Un tel dépôt ne fait aucun sens dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés et est issu en réalité du régime des fusions transfrontalières[2928] où il est prévu que le registre compétent pour chacune des sociétés impliquées dans la fusion, ainsi que le numéro d'immatriculation respectif des sociétés impliquées devront être déposés[2929], ce qui ne présente de réelle utilité que dans l'hypothèse d'une fusion par absorption. À l'égard des scissions transfrontalières, il faut donc voir dans cette mention spécifique un nouvel indice selon lequel le législateur européen prépare déjà le terrain pour une réforme plus ambitieuse des scissions.

600. Une indication des modalités d'exercice des mécanismes de protection. Parmi les différentes mentions additionnelles, il en est une qui est susceptible de soulever davantage d'interrogations. En effet, il est clair que l'obligation d'indiquer les modalités d'exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés s'inscrit dans une dynamique de protection des *stakeholders*[2930]. Dans cette optique, il serait par conséquent erroné de l'interpréter comme excluant les porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs

grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 288 et P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 16.

2925 Ar. 138 de la Directive Sociétés.

2926 Art. 160*octies*, § 3, al. 1er de la Directive Mobilité.

2927 Art. 160*octies*, § 3, al. 1er, b) de la Directive Mobilité.

2928 L'art. 160*undecies*, § 3, b) de la Proposition de la Commission faisait par ailleurs erronément référence à « *chacune des sociétés scindées* ».

2929 Art. 123, § 3, b) de la Directive Mobilité.

2930 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 12 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122d, n° 3.

du capital social[2931]. Il est toutefois intéressant de relever que contrairement au régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés[2932], le nouveau régime de la Directive Mobilité n'impose plus de fournir également une adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur les modalités d'exercice des droits des créanciers et des associés minoritaires. Une telle suppression peut s'expliquer à tout le moins par le fait que la protection de ces deux catégories de *stakeholders* a fait l'objet d'une harmonisation *a minima* dans la Directive Mobilité[2933]. Il s'ensuit qu'une résurgence de cette mention dans le cadre de l'introduction d'un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante est improbable.

§ 4. La mise à disposition des documents préparatoires

601. Plan du § 4. Parmi les mesures de publicité, la mise à disposition des documents préparatoires vise avant tout à garantir une parfaite information des associés avant la tenue de l'assemblée générale destinée à se prononcer sur l'opération[2934]. Afin de bien saisir les enjeux derrière cette étape, il conviendra, après une brève description de son principe (A), d'étudier certains documents ainsi mis à disposition, à savoir l'état comptable intérimaire (B) et les éventuels documents étrangers (C). Une fois que ce sera fait, il importera de s'interroger sur la possibilité d'en obtenir une copie (D) ainsi que sur les modalités concrètes de mise à disposition (E).

A. *Le principe*

602. Un objectif de préparation de l'assemblée générale. Toujours dans un souci de protection des associés[2935], il est prévu, tant en matière de scissions internes[2936] que de fusions internes[2937] que ceux-ci puissent avoir accès au moins un mois avant la tenue de l'assemblée générale à certains documents préparatoires au siège social de la société dont ils détiennent une participation. Comme cette mise à disposition de documents est avant tout prévue dans l'intérêt des associés[2938], ceux-ci doivent également avoir la possibilité d'y renoncer[2939]. Une telle réglementation n'est pas explicitement prévue en matière de fusions transfrontalières ou de scissions transfrontalières par constitution de nouvelles

2931 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 122d, n°s 12 et S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 215.
2932 Art. 123, § 2, c) de la Directive Sociétés.
2933 Sur l'harmonisation *a minima* de la protection des créanciers, voir *infra* n° 954. Sur l'harmonisation *a minima* de la protection des actionnaires minoritaires, voir *infra* n° 1089.
2934 Sur cette étape de la procédure de scission transfrontalière, voir *infra* n°s 617 à 638.
2935 50e et 69e considérants de la Directive Sociétés.
2936 Art. 143, § 1er de la Directive Sociétés.
2937 Art. 97, § 1er de la Directive Sociétés.
2938 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 63, n° 1 ; H. DIEKMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 63, n° 1 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 247 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 63, n° 1 et J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 74, n° 204.
2939 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 63, n° 1 ; H. DIEKMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 63, n° 3 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 63, n° 2.

sociétés. Elle s'appliquera toutefois également à ce type d'opérations par le biais de l'application subsidiaire du droit des fusions internes pour les fusions transfrontalières[2940] et (ii) du droit des scissions internes pour les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2941]. Il devrait en toute logique en être de même dans l'hypothèse d'un régime européen des scissions transfrontalières.

603. Une liste non exhaustive de documents. Au nombre de ces documents, on comptera à tout le moins, le projet commun, les rapports de l'organe de gestion et de l'expert indépendant, les comptes annuels et les rapports de gestion pour les trois derniers exercices et, le cas échéant, un état comptable intérimaire[2942]. Certains législateurs nationaux ont choisi de compléter cette liste de documents. À titre d'illustration, on peut ainsi citer le droit autrichien qui prévoit également la mise à disposition d'un bilan de clôture si la date de prise d'effet comptable de la scission diffère de celle de la fin du dernier exercice social[2943], alors que ni le droit belge[2944], ni le droit luxembourgeois[2945] ne connaissent une telle exigence. Ces divergences ne poseront toutefois pas de difficultés particulières dans la mesure où les règles relatives aux différents documents à mettre à disposition des associés devront s'appliquer distributivement, comme en matière de fusions transfrontalières[2946].

B. *L'état comptable intérimaire*

604. Un document requis dans un cas particulier. S'il s'avère que les comptes annuels les plus récents d'une des sociétés impliquées se rapportent à un exercice social dont la date est antérieure de plus de six mois à la date du projet commun, cette société aura l'obligation de dresser un état comptable intérimaire qui ne pourra être antérieur de plus de trois mois à la date du projet commun[2947]. L'objectif de cette disposition est avant tout d'informer les associés sur la situation financière actuelle de la société[2948].

605. Les règles relatives à l'établissement de l'état comptable intérimaire. En matière de scissions et de fusions internes[2949], l'état comptable intérimaire en question devra en principe être établi de la même manière que le dernier bilan annuel. Cependant, la Directive Sociétés prévoit qu'il est loisible aux États membres de permettre aux sociétés (i) de ne pas procéder à un nouvel inventaire réel et (ii) de ne modifier les évaluations figurant au dernier bilan qu'en fonction des mouvements d'écriture, tout en tenant néanmoins compte des

2940 Art. 121, § 1er, lit. b de la Directive Sociétés et Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 4 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 247 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 338.
2941 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.
2942 Art. 97, § 1er et 143, § 1er de la Directive Sociétés.
2943 § 7 (2), 3) SpaltG.
2944 Art. 12:64, § 2 et 12:80, § 2 du CSA.
2945 Art. 1031-7, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
2946 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 338.
2947 Art. 97, § 1er, lit. c et 143, § 1er, lit. c de la Directive Sociétés.
2948 H. Diekmann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 63, n° 14 ; G. Lanfermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 63, n° 5 ; Ph. Malherbe, *op. cit.*, p. 347, n° 18 ; J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 74, n° 204 et A. Tilleux et E. Weemaels, *op. cit.*, p. 147, n° 11.
2949 Art. 97, § 2, al. 1er et 143, § 2, al. 1er de la Directive Sociétés.

amortissements et provisions intérimaires, ainsi que des changements de valeur importants n'apparaissant pas dans les mouvements d'écriture[2950]. Cette option législative a été suivie en matière de scissions internes notamment par les législateurs belge[2951], luxembourgeois[2952], autrichien[2953] et allemand[2954], mais pas par le législateur français[2955]. Il n'en résultera toutefois pas de difficultés particulières en cas de scission transfrontalière dans la mesure où les règles relatives à l'établissement du bilan intérimaire s'appliqueront distributivement[2956].

606. L'exclusion des sociétés cotées. Les sociétés cotées sont exclues de cette obligation de mise à disposition dans le cas des scissions internes[2957] et transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[2958] ainsi que des fusions internes[2959] et transfrontalières[2960] dans la mesure où elles publient des états financiers semestriels. Cette exception qui ne fait que refléter le caractère superflu de l'état comptable intérimaire en présence d'états financiers récents[2961] devra en toute logique également trouver à s'appliquer dans le cadre des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

607. La renonciation à l'état comptable intérimaire. Il est possible de renoncer à la production d'un état comptable intérimaire par un vote unanime[2962]. Cette exigence d'unanimité implique qu'une telle renonciation ne sera possible que dans une société à l'actionnariat peu dispersé[2963]. De plus, il faudra un vote unanime au niveau de chacune des entités impliquées dans l'opération puisque chaque associé dispose du droit à obtenir la totalité des informations comptables[2964]. La question de la forme de cette renonciation peut susciter certaines interrogations. En effet, les textes européens ne précisent pas s'il doit s'agir d'une décision collective des associés prise en assemblée générale ou si une simple renonciation individuelle est suffisante[2965]. Certains États membres ont résolu cette question en prévoyant qu'une telle renonciation devait faire l'objet d'un acte notarié[2966]. Il n'en découlera toutefois pas de difficulté particulière dans le cas d'une scission transfrontalière dans la mesure où les règles nationales s'appliqueront distributivement en la matière[2967].

2950 Art. 97, § 2, al. 2 et 143, § 2, al. 2 de la Directive Sociétés.
2951 Art. 12:64, § 2, al. 2 et 3 et 12:80, § 2, al. 2 et 3 du CSA.
2952 Art. 1031-7, § 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
2953 § 7 (3) SpaltG.
2954 §§ 63 (2) et 125 UmwG.
2955 Art. R-236-3, al. 1er, 4) du Code de commerce français.
2956 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 338.
2957 Art. 143, § 1er, al. 2 de la Directive Sociétés.
2958 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité et art. 143, § 1er, al. 2 de la Directive Sociétés.
2959 Art. 97, § 1er, al. 2 de la Directive Sociétés.
2960 Art. 97, § 1er, al. 2 et 121, § 1er, lit. b de la Directive Sociétés.
2961 8e considérant de la Directive Fusions et Scissions Electroniques et 77e considérant de la Directive Sociétés.
2962 Art. 1.3.6. de la norme de l'IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021).
2963 A. TILLEUX et E. WEEMAELS, *op. cit.*, p. 147, n° 11.
2964 Ph. MALHERBE, *op. cit.*, p. 348, n° 19 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 8, n° 38 et M. WAUTERS, « Fusie, splitsing en andere herstructureringen : de verslagplicht op drift ? », *T.R.V.*, 2010, p. 541, n° 15.
2965 Ph. MALHERBE, *ibidem*, p. 344, n° 10.
2966 § 8 (3) et § 125 UmwG.
2967 Au sujet de la forme de la renonciation au rapport d'expert, voir *supra* n° 588.

C. *La mise à disposition de documents étrangers*

608. L'incidence du contexte transfrontalier. Si dans le cas d'une scission interne, la question de savoir si chaque société impliquée dans l'opération a l'obligation de tenir les documents préparatoires de la scission de toutes les sociétés impliquées à la disposition de ses associés ne présente pas un intérêt considérable, tel ne sera pas le cas dans un contexte transfrontalier. En effet, si on devait considérer que cette obligation concerne les documents de toutes les sociétés impliquées, ceci signifierait que chaque société devrait nécessairement mettre des documents étrangers à disposition de ses associés. Or, dans le cas d'une scission interne, il ressort clairement du texte de la Directive Sociétés que chaque société a l'obligation de mettre les documents préparatoires de toutes les sociétés impliquées à la disposition de ses propres associés[2968]. Cette solution est par ailleurs identique en matière de fusions transfrontalières[2969]. En l'absence de norme contraire et afin de garantir une information adéquate des associés, il convient donc de considérer que cette exigence concerne également les documents relatifs aux sociétés étrangères dans le cas d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante.

609. La langue des documents étrangers. Il reste toutefois encore à examiner dans quelle langue les documents étrangers devront être rédigés. Cette question n'est pas anodine dans la mesure où la nécessité de réaliser des traductions des documents préparatoires de chacune des entités impliquées dans l'opération engendrera nécessairement des coûts importants et pourrait retarder la réalisation de la scission. En matière de fusions transfrontalières, on considère que les règles relatives à l'emploi des langues dans ces documents s'appliqueront distributivement[2970]. Cette solution est logique puisqu'à l'exception du cas particulier du rapport unique[2971] et du projet commun de scission[2972], chaque document préparatoire sera établi individuellement par chaque société impliquée. Cette solution a été rejetée par certains auteurs en matière de fusions transfrontalières en raison du fait qu'elle n'est pas nécessairement compatible avec l'objectif d'information des associés[2973]. Ce point pourrait être résolu aisément en prévoyant que ces différents documents doivent être disponibles dans la langue usuelle des affaires, ce qui est par ailleurs généralement le cas en pratique au Grand-Duché de Luxembourg, tout en précisant que les

2968 Art. 143, § 1er de la Directive Sociétés.

2969 Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 4 ; Fl. Drinhausen et H. Gesell, *op. cit.*, p. 13 ; Fl. Drinhausen et A. Keinath, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes…. », *op. cit.*, p. 729 ; Fl. Drinhausen et A. Keinath, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung… », *op. cit.*, p. 84 ; St. Klein, *op. cit.*, p. 595 ; N. Krause et N. Kulpa, *op. cit.*, p. 64 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 249 ; Chr. Louven, *ibidem*, p. 2027 ; R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 63, n° 3 et J. Mitterecker, *ibidem*, p. 338.

2970 *Pro :* Chr. Louven, *op. cit.*, p. 2027 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 338. *Contra :* Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 122g, n° 4 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 250 ; R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 63, n° 3.

2971 À ce sujet, voir *supra* n° 571.

2972 À ce sujet, voir *supra* nos 416 et 417.

2973 Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 4 ; R. Frenzel, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 275 et S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 250.

destinataires pourront en obtenir une version dans une des langues nationales sans frais et sur simple demande.

D. *La possibilité d'obtenir une copie*

610. Trois possibilités pour obtenir une copie. Face à la nécessité de garantir une information adéquate des associés, il est également prévu tant en matière de scissions internes[2974] qu'en matière de fusions internes[2975] que les associés puissent obtenir sans frais et sur simple demande une copie partielle ou intégrale des différents documents mis à leur disposition au siège social des sociétés impliquées. Ces copies ne devront pas nécessairement être remises sous forme physique, mais pourront, pour peu que l'associé ait consenti à ce mode de communication, être transmises par courrier électronique. Par ailleurs, dans le cadre de la simplification des procédures de restructuration par le numérique, il est également prévu que la possibilité de télécharger et d'imprimer les différents documents par les associés dispense de l'envoi de copies à ceux-ci en cas de scissions internes[2976] et de fusions internes[2977]. Ces diverses possibilités sont tout à fait transposables à l'hypothèse d'une scission transfrontalière et n'appellent pas de commentaire particulier.

E. *Les modalités de la mise à disposition*

611. Une mise à disposition au siège social. Les différents documents devront être mis à la disposition des associés au siège social de chacune des sociétés impliquées. Cette solution est identique tant en cas de scission interne[2978] que de fusion interne[2979]. La notion de siège social doit ici être entendue comme le siège statutaire[2980], ce qui permet de garantir une certaine prévisibilité quant au lieu où se trouveront les documents préparatoires. Si le siège réel devait différer du siège statutaire, il est généralement recommandé de mettre les documents à la disposition des associés aux deux endroits[2981]. Par souci de simplicité et de cohérence, la solution devra être identique en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante.

612. L'utilisation du site internet de la société. En vue d'une part de réduire les coûts d'une opération de restructuration et, d'autre part, de simplifier l'accès aux documents préparatoires pour les associés[2982], il est prévu, tant en matière

2974 Ar. 143, § 3 de la Directive Sociétés.
2975 Art. 97, § 3 de la Directive Sociétés.
2976 Art. 143, § 4, al. 2 de la Directive Sociétés.
2977 Art. 97, § 4, al. 2 de la Directive Sociétés.
2978 Art. 143, § 1er de la Directive Sociétés.
2979 Art. 97, § 1er de la Directive Sociétés.
2980 *Pro* : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Referentenentwurf zum 3. UmwÄndG : Vereinfachungen bei Verschmelzungen und Spaltungen und ein neuer verschmelzungspezifischer Squeeze out », *ZIP*, 2010, p. 963 ; H. DIEKMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 63, n° 9 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 63, n° 2. *Contra* : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 63, n° 3.
2981 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 63, n° 2.
2982 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 63, n° 4.

de scissions internes[2983] que de fusions internes[2984] que les sociétés puissent être dispensées de l'obligation de mise à disposition des documents au siège social si, au moins pendant un mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale, elles mettent les documents préparatoires à la disposition des associés sur leur site internet. Une telle possibilité devrait également être reconnue dans le cas d'une scission transfrontalière étant donné que la nécessité d'une facilitation de l'accès à l'information et d'une réduction des coûts liés à celle-ci se justifie d'autant plus dans un contexte transfrontalier.

§5. L'obligation d'information en cas de modification importante du patrimoine actif et passif

613. Le principe. Dans le cas d'une opération de scission interne[2985], les organes de direction ou d'administration de l'entité scindée ont, en outre, également l'obligation d'informer tant leur propre assemblée générale que les organes de direction ou d'administration des autres entités impliquées de toute modification significative du patrimoine actif et passif de leur société survenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de l'assemblée générale. Une telle obligation, qui découle de l'exécution de bonne foi du projet commun[2986], est fondamentale en cas de scission dans la mesure où elle est susceptible d'avoir une incidence soit sur le rapport d'échange, soit sur la clé de répartition des éléments d'actif et de passif prévue à l'origine dans le projet commun soit encore sur le montant de la soulte en espèces qui sera offerte aux associés souhaitant faire usage de leur droit de retrait. Au nombre de ces évolutions dont l'assemblée générale devrait être informée, on peut citer toutes les circonstances affectant la position de l'entreprise sur le marché ou ses perspectives de revenus susceptibles d'avoir une incidence sur l'évaluation de l'entreprise qui a été faite au moment de l'établissement du projet commun de scission[2987]. En tout état de cause, il est admis qu'à partir du moment où une telle modification du patrimoine est susceptible d'avoir une incidence sur le rapport d'échange ou sur le montant d'un éventuel prix de rachat de la participation des associés s'opposant à l'opération, elle devra faire l'objet d'une notification par l'organe de direction ou d'administration[2988]. Il est encore également intéressant de relever qu'il ne s'agit là que d'une obligation d'information et qu'il n'appartient pas à l'organe de direction ou d'administration de procéder à une adaptation des termes du projet commun

2983 Art. 144, § 2 de la Directive Sociétés.
2984 Art. 97, § 4 de la Directive Sociétés.
2985 Art. 141, § 3 de la Directive Sociétés.
2986 H. Diekmann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 64, n° 12 et D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 588, n° 31.
2987 H. Diekmann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 64, n° 11.
2988 H. Diekmann in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 64, n°s 10 et 11 ; B. Grunewald in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 64, n° 5 et R. Marsch-Barner et St. Oppenhoff in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 64, n° 6.

de scission, la décision de requérir le cas échéant une telle modification incombant à l'assemblée générale[2989].

614. Une obligation insuffisante en matière de scissions. Dans le cas d'une fusion interne, cette obligation d'information s'applique indistinctement aux organes de direction ou d'administration de toutes les sociétés impliquées, peu important qu'elles soient absorbées ou absorbantes[2990]. Cette solution est tout à fait logique dans la mesure où le rapport d'échange résulte de la comparaison entre les valeurs respectives de toutes les entités impliquées. On peut dès lors s'étonner que le législateur européen ait exclu les organes de direction ou d'administration des sociétés bénéficiaires de cette obligation en cas de scissions internes[2991]. Il s'agit là d'une lacune qui a été très justement identifiée par le gouvernement belge au moment de la transposition de la Sixième Directive[2992] et qui se doit d'être comblée, *a fortiori* dans un contexte transfrontalier où l'accès à l'information pour les associés est par définition plus compliqué que dans le cas d'une opération interne. Afin de garantir une prise de décision éclairée au moment de l'assemblée générale, il est par conséquent indispensable d'étendre cette obligation d'actualisation à toutes les sociétés impliquées dans une scission transfrontalière.

615. La possibilité d'une renonciation. Tant en cas de scissions internes[2993] que de fusions internes[2994], les États membres ont pu disposer de la possibilité de prévoir que les associés et porteurs d'autres titres conférant un droit de vote pouvaient, à l'unanimité, renoncer à cette obligation d'information à charge de l'organe de direction ou d'administration. Certains États membres, comme le Luxembourg[2995], la Belgique[2996] et l'Allemagne[2997] connaissent ainsi une telle faculté de renonciation unanime dans leur droit national en cas de scissions internes, alors que d'autres, comme l'Autriche[2998], ont fait le choix de ne pas reconnaître explicitement une telle possibilité. Si cela va certes dans le sens d'une simplification de la procédure de scission et d'une réduction des coûts liés à celle-ci, on pourrait, à l'instar de certains auteurs au sujet des fusions transfrontalières[2999], s'interroger sur la compatibilité de cette renonciation avec l'impératif d'une prise de décision éclairée au sein de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur l'opération. Cette crainte se justifie d'autant plus en cas de scissions transfrontalières en raison du nombre généralement plus important de sociétés et de droits nationaux impliqués, ce qui ne va indéniablement

2989 Voir en ce sens : G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, p. 126, n° 13 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 64, n° 5.
2990 Art. 95, § 2 de la Directive Sociétés.
2991 Art. 141, § 3 de la Directive Sociétés.
2992 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 26.
2993 Art. 144, § 2 de la Directive Sociétés.
2994 Art. 95, § 3 de la Directive Sociétés.
2995 Art. 1031-8, § 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
2996 Art. 12:62, § 1er, al. 6 du CSA. Il est intéressant de relever que cette solution n'a pas toujours été applicable puisque les art. 732 et 747 de l'ancien Code des Sociétés belge ne la prévoyaient pas.
2997 §§ 64 (1) *in fine* et 8 (3) UmwG.
2998 § 7 (6) SpaltG.
2999 A. TILLEUX et E. WEEMAELS, *op. cit.*, p. 149, nos 25 et 26.

pas dans le sens d'une simplification de l'accès à l'information pour les associés. Cependant, il ne faut pas surestimer l'importance d'une possible renonciation. En effet, elle ne constituera une possibilité réaliste que dans le cadre de sociétés à l'actionnariat très peu dispersé où les liens entre l'assemblée générale et l'organe de gestion sont par définition beaucoup plus étroits de sorte qu'en tout état de cause, les associés seront suffisamment informés. Compte tenu de cela et en vue de simplifier les opérations de scissions transfrontalières intra-groupes, cette faculté de renonciation devrait également être ouverte en cas de scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

616. Quid en cas de législations nationales contradictoires ? Si une telle faculté de prévoir une renonciation unanime devait être reconnue aux États membres en cas de scission transfrontalière, il reste encore à déterminer comment il convient de résoudre un éventuel conflit de lois si, par exemple, le droit applicable à la société scindée connaît une telle exception au contraire des droits nationaux applicables aux sociétés bénéficiaires. Comme il s'agit là d'un aspect de l'opération impliquant toutes les sociétés impliquées, notamment en raison de l'obligation de partage de l'information qui incombe aux conseils d'administration, il convient de plaider en faveur d'une application cumulative tout en privilégiant la norme la plus sévère.

SECTION 7. L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

617. Plan de la section 7. Pour pleinement apprécier l'étape de l'approbation de l'opération par l'assemblée générale des sociétés concernées, il importe, après quelques remarques introductives (§ 1), de s'intéresser aux délais, à l'objet et à la forme du procès-verbal (§ 2), aux conditions de présence et de majorité applicables (§ 3), à la possibilité d'assortir l'approbation de l'opération d'une condition suspensive (§ 4), à la possibilité de l'assemblée générale de modifier le projet commun (§ 5), au caractère facultatif de l'assemblée générale (§ 6) et, en définitive, à la possibilité de contestation de la décision de l'assemblée générale (§ 7).

§1. Présentation

618. Une décision éclairée. Selon la Directive Mobilité, après avoir pris connaissance à tout le moins du rapport d'experts et du ou des rapport(s) de l'organe de direction ou d'administration ainsi que, le cas échéant, des avis des représentants des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs eux-mêmes sur le rapport ou la section du rapport de l'organe de gestion à leur intention et les éventuels avis soumis par les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes, à la société concernant le projet de scission transfrontalière, l'assemblée générale de chacune des sociétés impliquées devra se prononcer sur l'opération[3000]. Cette disposition pourrait s'appliquer *mutatis mutandis* aux scissions transfrontalières impliquant

[3000] Voir art. 160*nonies*, § 1er de la Directive Mobilité.

plus d'une société préexistante et devrait dès lors viser l'assemblée générale qui se tiendra au sein de chacune des sociétés impliquées[3001], à l'instar de ce qui est le cas dans le cadre d'une scission interne[3002] ou d'une fusion transfrontalière[3003]. Il n'existe en effet pas de raison de traiter différemment les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante à cet égard.

619. Une application distributive des règles en présence. Dans la mesure où la tenue de l'assemblée générale ne requiert pas une action commune de toutes les entités impliquées dans l'opération, les règles spécifiques gravitant autour de celles-ci et relatives notamment à la convocation, à la tenue et à la forme des décisions s'appliqueront distributivement[3004], à l'instar de celles en cas de fusion transfrontalière[3005]. Cette règle de conflit de lois ne figure certes pas dans le régime des scissions de la Directive Mobilité, mais cela s'explique aisément par le fait que dans le cadre d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, il n'y aura par définition que l'assemblée générale de la société scindée qui devra être tenue.

§ 2. Délai, objet et forme du procès-verbal

620. Des délais à appliquer distributivement. L'assemblée générale ne peut, tout comme en matière de scissions internes[3006] et transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[3007] ou de fusions internes[3008] et transfrontalières[3009] en principe être tenue avant (i) l'écoulement d'un délai d'un mois suivant la publication ou la mise à disposition sur un site internet du projet commun et (ii) l'écoulement d'un délai d'un mois suivant la mise à disposition des documents préparatoires soit au siège social, soit sur le site internet des entités impliquées[3010][3011]. Comme la Directive Sociétés ne fait qu'imposer un minimum à cet égard, les exigences temporelles ont été transposées de manières divergentes par les États membres. Ainsi, en droit belge, le délai devant s'écouler entre le dépôt du projet commun de scission et la date de tenue de l'assemblée

3001 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 358.
3002 Art. 139, § 1er de la Directive Sociétés.
3003 Art. 126, § 1er de la Directive Mobilité.
3004 U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 165 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 84 et E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 415.
3005 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 5 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 1 ; St. KLEIN, *op. cit.*, p. 595 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 251 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 346 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit belge », *op. cit.*, pp. 195 et 196, n° 30 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 45, n° 57 ; D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, pp. 588 et 589, note 82 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 18 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 1.
3006 Art. 138, al. 1er et 2 de la Directive Sociétés.
3007 Art. 160*octies*, §§ 1 et 2 de la Directive Mobilité.
3008 Art. 92, al. 1er et al. 2 de la Directive Sociétés.
3009 Art. 123, §§ 1 et 2 de la Directive Mobilité.
3010 Art. 143, §§ 1er et 4 de la Directive Sociétés.
3011 Voir *supra* n° 597 pour une analyse de la possibilité d'une réduction de ce délai à l'initiative des actionnaires.

générale est de six semaines[3012], alors qu'en droit luxembourgeois[3013], tout comme en droit autrichien[3014], le délai devant s'écouler entre la publication du projet commun et la date de l'assemblée générale est d'un mois. Ces divergences ne poseront toutefois pas de difficultés particulières dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière dans la mesure où les différents délais s'appliqueront distributivement[3015], chaque assemblée générale demeurant soumise aux dispositions de son propre droit national. Les autres exigences prévues par les États membres en matière de délais, comme par exemple l'interdiction faite en droit allemand à une société anonyme de participer à une scission interne si elle n'a pas été inscrite au registre depuis au moins deux ans[3016], s'appliqueront distributivement. Tant que les diverses exigences en matière de délai seront respectées, l'ordre dans lequel les assemblées générales des différentes sociétés impliquées seront tenues est sans incidence[3017]. Néanmoins, afin d'éviter des problèmes pratiques, il est conseillé de tenir toutes les assemblées générales le même jour[3018].

621. Une décision dépassant la scission. Comme dans le cas d'une scission interne[3019] ou transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés[3020], ou encore d'une fusion interne[3021] ou transfrontalière[3022], les assemblées générales des sociétés participant à l'opération devront non seulement approuver la scission, mais également (i) les modifications statutaires rendues nécessaires par celle-ci, comme par exemple l'augmentation du capital social des sociétés absorbantes requise pour permettre l'échange d'actions et (ii) le cas échéant, les statuts des sociétés nouvellement constituées dans le cadre de l'opération ou ceux de la société scindée en cas de scission partielle. Cet aspect de la procédure devrait en toute logique être identique en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société existante puisque ce type d'opération requerra en principe également des modifications des statuts des sociétés bénéficiaires.

622. La forme du procès-verbal de scission. Alors que la Directive Sociétés précise à l'égard de la forme du procès-verbal de l'assemblée générale d'une scission interne que celui-ci ne devra nécessairement être établi sous forme authentique que si le droit national n'impose pas de contrôle judiciaire ou administratif de légalité portant sur tous les actes nécessaires à la scission

3012 Art. 12:64, §§ 1, 2 et 4 (scissions par absorption) et 12:80, §§ 1, 2 et 4 (scissions par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.
3013 Art. 1031-2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3014 § 7(1) SpaltG.
3015 Voir en ce sens à propos du régime de la Directive Mobilité : P. Stelmaszczyk, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 69, n° 58.
3016 §§ 76 (1) et 125 UmwG.
3017 N. Zimmermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 13, n° 8.
3018 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 4.
3019 Art. 139, § 1er et 93, § 3 de la Directive Sociétés.
3020 Art. 160*nonies*, § 1er de la Directive Mobilité.
3021 Art. 93, § 3 de la Directive Sociétés.
3022 Art. 121, § 1er, b) et 93, § 3 de la Directive Sociétés.

interne[3023], la Directive Mobilité ne contient aucune indication à ce sujet, que ce soit à l'égard des scissions transfrontalières[3024], des fusions transfrontalières[3025] ou encore des transformations transfrontalières[3026], contrairement au souhait du *Bundesrat* qui aurait préféré voir une référence explicite aux droits nationaux à ce sujet[3027]. Il faudra dès lors appliquer les différents droits nationaux en présence distributivement[3028], comme en matière de fusions transfrontalières[3029], tout en précisant que de nombreux États membres, comme la Belgique[3030] et le Luxembourg[3031] à l'égard des scissions internes et transfrontalières et l'Allemagne[3032] et l'Autriche[3033] à l'égard des scissions internes ont de toute façon prévu la forme notariée.

§ 3. Les conditions de présence et de majorité

623. Un mécanisme de protection des associés minoritaires. Si les conditions de présence et de majorité feront l'objet d'une étude détaillée lors de l'examen des mécanismes de protection des associés minoritaires qui doivent être mis en place dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante[3034], il convient de relever à ce stade de l'analyse qu'alors qu'à l'égard des conditions de présence et de majorité applicables aux fusions transfrontalières, le législateur européen s'en était explicitement remis aux différents législateurs nationaux dans la Directive Sociétés[3035], la Directive Mobilité consacre une position différente à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés. En effet, il y est expressément prévu que l'approbation du projet de scission transfrontalière requerra une majorité qui ne pourra être inférieure aux deux-tiers mais n'excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions soit au capital souscrit représenté à l'assemblée générale, étant entendu qu'en tout état de cause le seuil des votes ne pourra être supérieur à celui prévu par le droit national pour l'approbation des fusions

3023 Art. 102, § 1er et 148 de la Directive Sociétés.
3024 Art. 160*nonies* de la Directive Mobilité.
3025 Art. 126 de la Directive Mobilité.
3026 Art. 86*nonies* de la Directive Mobilité.
3027 Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, pp. 3 et 4.
3028 Voir en ce sens à propos du régime de la Directive Mobilité : P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 69, n° 58 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 326.
3029 *Pro* : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 6 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 84 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 415 ; D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, pp. 588 et 589, note 82 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122g, nos 10 et 12. *Contra* : M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 116 qui semble toutefois confondre le projet commun et le procès-verbal d'approbation de la fusion transfrontalière.
3030 Art. 12:68 (scissions par absorption), al. 1er et 12:84, al. 1er (scissions par acquisition) du CSA.
3031 Art. 1031-13, § 1er et 1032-1, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3032 §§ 13(3) et 125 UmwG.
3033 § 8(4) SpaltG.
3034 À ce sujet, voir *infra* nos 999 à 1008.
3035 Art. 121, § 2 de la Directive Sociétés.

transfrontalières[3036]. Une telle règle sensée[3037] serait tout à fait compatible avec un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, étant entendu que des conditions de présence et de majorité différentes d'un État membre à un autre ne poseront aucun problème dans la mesure où il conviendra de recourir à une application distributive des droits nationaux en présence[3038], comme dans l'hypothèse d'une fusion transfrontalière[3039].

§4. La possibilité d'une condition suspensive et résolutoire portant sur le régime de participation des travailleurs

624. Un principe tenant compte de la nécessité d'une prise de décision rapide. Compte tenu du caractère délicat et long du mécanisme de protection de la participation des travailleurs[3040], le régime des scissions transfrontalières de la Directive Mobilité[3041], à l'instar de celui des fusions transfrontalières[3042] et de celui de la société européenne[3043], autorise l'assemblée générale de la société scindée à prévoir que la scission transfrontalière ne sera réalisée qu'à la condition qu'elle entérine les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans les sociétés issues de l'opération. Fruit d'un compromis entre le droit des associés de faire valoir leur avis sur un point aussi essentiel que la participation des travailleurs[3044] et l'intérêt de la société qui nécessite une prise de décision rapide[3045], une telle mesure a l'avantage de ne pas empêcher l'approbation du projet de scission tout en suspendant la prise d'effet de celle-ci. Comme la question de la protection de la participation des travailleurs ne manquera pas d'être centrale dans la mise en place d'un régime cohérent des scissions transfrontalières, mais que les impératifs économiques d'une scission nécessitent une certaine rapidité pour répondre aux conditions changeantes du marché, il serait certainement utile de prévoir une mesure similaire en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. D'un point de vue purement pratique, cela permettra déjà de rassurer les associés et les investisseurs sur les chances de réussite de l'opération, ce qui est susceptible d'avoir un effet positif sur le cours des actions ou encore de faciliter l'accès à de nouvelles sources de financement. Toutefois, dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante il convient toutefois encore de préciser que cette faculté devra être ouverte à

3036 Art. 160*nonies*, § 3 de la Directive Mobilité.
3037 Voir en ce sens : J. Schmidt, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 250.
3038 Voir en ce sens à propos du régime de la Directive Mobilité : P. Stelmaszczyk, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 69, n° 58.
3039 R. Frenzel, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 276 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 251 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 347.
3040 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2.
3041 Art. 160*nonies*, § 2 de la Directive Mobilité.
3042 Art. 126, § 2 de la Directive Sociétés.
3043 Art. 23, § 2 du Règlement sur la Société européenne.
3044 W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 2 ; D. Beutel, *op. cit.*, p. 195 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 8 ; St. Klein, *op. cit.*, p. 597 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 252 ; H. le Nabasque, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 13 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 353.
3045 W. Bayer in M. Lutter (dir.), *ibidem*, § 122g, n° 2 et D. Beutel, *ibidem*, p. 195.

l'assemblée générale de chacune des sociétés impliquées dans l'opération comme en matière de fusions transfrontalières[3046]. En effet, la question de la participation des travailleurs aura à tout le moins la même importance pour chacune des sociétés impliquées.

625. L'approbation subséquente du régime de participation des travailleurs. Cette faculté implique que l'assemblée générale devra tout d'abord se prononcer sur cette condition suspensive au moment où elle se prononce sur le projet commun pour ensuite être à nouveau convoquée afin d'examiner les modalités décidées pour la participation des travailleurs. Il est intéressant de relever que le nouveau régime des scissions transfrontalières[3047], tout comme celui des fusions transfrontalières[3048] et celui de la société européenne[3049] imposent que les modalités soient entérinées « *expressément* » lors de cette seconde assemblée générale, ce qui suppose un comportement actif de la part des associés. Une simple absence de contestation pendant un certain délai ne sera donc pas suffisante à cet égard[3050]. Cette interprétation s'impose notamment au vu de la nécessité de simplifier le contrôle de légalité qui interviendra à un stade ultérieur de la procédure[3051] et qui portera également sur cette décision de confirmation de l'assemblée générale[3052].

626. Quorum et majorité. Si la possibilité d'instaurer une telle condition suspensive se retrouve certes tant dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[3053], que dans celui des fusions transfrontalières[3054], des transformations transfrontalières[3055] ou encore de la société européenne[3056], aucun n'impose de quorum de présence ou de condition de majorité spécifique, que ce soit au moment de l'adoption de celle-ci ou au moment de sa levée lors de l'approbation des modalités relatives à la participation des travailleurs. Cette question relèvera donc du droit national de chaque entité impliquée[3057], ce qui ne générera pas de conflit de lois et ne nécessiterait *a priori* donc pas une intervention du législateur européen. Néanmoins, un examen des différentes législations nationales en la matière montre que ni le législateur belge, ni les législateurs luxembourgeois, autrichien ou encore allemand n'ont traité explicitement ce cas de figure. Cette situation a par conséquent donné lieu à une certaine controverse en doctrine. En effet, certains auteurs partent du principe qu'en l'absence de règles de majorité spécifiques, il y a lieu de considérer qu'une majorité simple des votes

3046 Art. 126, § 2 de la Directive Sociétés.
3047 Art. 160*nonies*, § 2 de la Directive Mobilité.
3048 Art. 126, § 2 de la Directive Sociétés.
3049 Art. 23, § 2 du Règlement sur la Société européenne.
3050 S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 254 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 355.
3051 À ce sujet, voir *infra* n°s 657 à 659.
3052 S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 254 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 355 ; M. SCHEIFELE, *Die Gründung der Europäischen Aktiengesellschaft (SE)*, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2004, pp. 216 et 217 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 17.
3053 Art. 160*nonies*, § 2 de la Directive Mobilité.
3054 Art. 126, § 2 de la Directive Sociétés.
3055 Art. 86*nonies*, § 2 de la Directive Mobilité.
3056 Art. 23, § 2 du Règlement sur la Société européenne.
3057 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 195 ; M. HABERSACK, *op. cit.*, p. 229 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 355.

exprimés suffit tant pour imposer la condition que pour la réaliser[3058]. D'autres auteurs, en revanche, considèrent que tant l'instauration que la levée d'une telle condition sont indissociables de la décision d'approbation de la restructuration et les décisions les concernant devraient donc être prises aux conditions de présence et de majorité renforcées[3059], certains reconnaissant qu'il reste malgré tout loisible à l'assemblée générale de prévoir au moment de l'adoption de la condition suspensive que celle-ci pourra être levée à la majorité simple des voix exprimées[3060], pour autant que l'approbation du régime de participation ne nécessite pas de modification statutaire[3061]. Cette dernière interprétation ne saurait toutefois être suivie. En effet, les conditions de présence et de majorité renforcées prévues à l'origine par la Directive Sociétés tant en matière de fusions internes[3062] que de scissions internes[3063] ne visent que la décision de procéder à l'opération en tant que telle et comme elles constituent une exception au principe de la prise de décision à la majorité simple des voix exprimées, elles doivent être interprétées restrictivement. Par conséquent, elles ne doivent pas être étendues aux conditions affectant celle-ci. De plus, prévoir des conditions de présence et de majorité plus strictes pour l'adoption de la condition suspensive serait contraire à sa *ratio legis* qui n'est autre que la protection des associés[3064]. Il faut donc en conclure que seule la décision d'approbation de la restructuration devra se faire aux conditions de présence et de majorité renforcées, mais que tant l'adoption que la réalisation de la condition suspensive se feront aux conditions normales de présence et de majorité. En pratique, cette question ne constitue toutefois pas un obstacle significatif puisqu'il suffit de prévoir dans la résolution de l'assemblée générale approuvant la scission sous condition suspensive que cette dernière pourra être levée à la majorité simple des voix exprimées. Néanmoins, en vue d'une part de renforcer la sécurité juridique et d'autre part de simplifier le processus de scission transfrontalière déjà fort complexe si la société scindée connaît un régime de participation des travailleurs, il serait utile de préciser lors d'une révision du régime de la Directive Mobilité que l'entérinement des modalités relatives à la participation des travailleurs par l'assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celles-ci requièrent une modification statutaire.

627. La possibilité d'une délégation de pouvoirs. Dans les sociétés cotées, une seconde convocation de l'assemblée générale peut s'avérer très lourde

3058 D. Beutel, *ibidem*, p. 195 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 10 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 255 et M. Scheifele, *op. cit.*, p. 215.

3059 R. Frenzel, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 282 ; H. Heckschen, *op. cit.*, p. 463 ; St. Klein, *op. cit.*, p. 597 ; P. Limmer, « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Sevic-Urteil des EuGH und den Neuregelungen des UmwG (Teil II) », *ZNotP*, 2007, p. 285 ; H.-F. Müller, « Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 1085 et N. Zimmermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 20.

3060 St. Klein, *op. cit.*, p. 597 ; P. Limmer, *ibidem*, p. 285 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 256 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 357 ; H.-F. Müller, *ibidem*, p. 1085 et St. Simon et D. Rubner, « Die Umsetzung der Richtlinie über grenzüberschreitende Verschmelzungen ins deutsche Recht », *Der Konzern*, 2006, p. 839.

3061 St. Klein, *op. cit.*, p. 597.

3062 Art. 93, § 1er de la Directive Sociétés.

3063 Art. 93, § 1er et 139, § 1er de la Directive Sociétés.

3064 Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 10.

et coûteuse en pratique[3065], même en appliquant des conditions de présence et de majorité simples. Il peut donc être intéressant de déléguer le pouvoir de réaliser la condition suspensive en entérinant les modalités relatives à la participation des travailleurs à l'organe de direction ou d'administration. Une telle délégation se justifierait d'autant plus en cas de scission transfrontalière par absorption dans la mesure où les coûts et la perte de temps engendrés par la nécessité de convoquer et de tenir une seconde assemblée générale pour trois sociétés distinctes peuvent être significatifs. Cette possibilité de délégation ne fait toutefois pas l'unanimité en doctrine à l'égard des fusions transfrontalières. En effet, certains auteurs considèrent qu'une telle délégation de pouvoirs empiéterait sur la décision d'approbation de la fusion qui demeure une compétence réservée de l'assemblée générale[3066], alors que d'autres considèrent que comme il est loisible à l'assemblée générale de soumettre la décision d'approbation de l'opération à une condition suspensive, il doit également lui être possible de déléguer la levée de cette condition[3067]. Cette dernière interprétation doit être privilégiée pour deux raisons. Tout d'abord, l'opération devra de toute façon être approuvée par l'assemblée générale aux conditions de présence et de majorité renforcées juste avant l'adoption de la condition suspensive, de sorte qu'il ne sera pas porté atteinte à sa compétence réservée. Ensuite, de telles délégations de pouvoir gravitant autour de compétences réservées de l'assemblée générale, à l'instar du capital autorisé[3068] ou encore de la possibilité pour l'organe de gestion de modifier les statuts en cas de déplacement du siège social au sein du même État membre[3069], sont loin d'être inconnues du droit des sociétés. Il convient toutefois de préciser que cette délégation de pouvoirs devra être entourée de certaines garanties afin de préserver les compétences de l'assemblée générale. Ainsi, elle devra être approuvée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts[3070] et elle devra être spécifique, ce qui revient à dire qu'elle ne pourra concerner qu'une opération de scission bien déterminée qui aura déjà fait l'objet d'une résolution de l'assemblée générale.

628. La limitation de la condition suspensive aux régimes d'exception. Une autre possibilité pratique qui a parfois été avancée dans le cadre d'une fusion transfrontalière[3071] ou de la constitution d'une société européenne[3072] et qui serait également transposable en matière de scissions transfrontalières consiste à déjà approuver les nouveaux statuts de la société bénéficiaire en intégrant directement soit (i) les dispositions relatives à la participation des travailleurs

3065 St. KLEIN, *op. cit.*, p. 597 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 258 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 352 ; Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit belge », *op. cit.*, p. 197, n° 33 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 80, n° 121.

3066 R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 283 ; H.-F. MÜLLER, « Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 1085 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122g, n° 19.

3067 St. KLEIN, *op. cit.*, p. 597 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 259 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 357.

3068 Art. 7:198 du CSA et art. 420-22 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3069 Art. 450-3, § 1er, al. 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3070 S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 258 et 259 et M. SCHEIFELE, *op. cit.*, p. 259.

3071 R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 284.

3072 W. BAYER in M. LUTTER et P. HOMMELHOFF (dir.), *Die Europäische Gesellschaft – Prinzipien, Gestaltungsmöglichkeiten und Grundfragen aus der Praxis*, Köln, Otto Schmidt, 2005, p. 41.

qui trouveraient à s'appliquer par défaut, c'est-à-dire celles en vigueur dans le siège de l'État membre du siège statutaire de la société bénéficiaire[3073], soit (ii) les dispositions de référence, c'est-à-dire celles qui permettent d'atteindre l'objectif d'implication des travailleurs en favorisant le système d'implication le plus élevé[3074], pour ensuite soumettre l'opération envisagée à la condition suspensive de l'entérinement par l'assemblée générale des modalités relatives à la participation des travailleurs qui dérogeraient au régime adopté *ex ante*. Une telle solution permet d'éviter de devoir convoquer à nouveau les assemblées générales si l'issue des négociations consiste simplement à appliquer soit les dispositions du droit applicable à la société bénéficiaire concernée, soit les dispositions de référence tout en évitant l'aléa des discussions sur une possible délégation de pouvoirs à un autre organe.

629. Un régime des scissions transfrontalières. Par souci de sécurité juridique, il serait utile dans le cadre de la mise en place d'un régime européen des scissions transfrontalières de nature plus générale soit de prévoir explicitement que l'assemblée générale pourra déléguer l'entérinement des modalités relatives à la participation des travailleurs à l'organe de direction où d'administration de la société concernée soit, à tout le moins, de prévoir que cette question sera dévolue aux États membres. En effet, compte tenu du nombre de sociétés susceptibles d'être impliquées dans une scission transfrontalière par absorption, une telle solution permettant de réduire tant les coûts que les délais de la procédure s'impose d'autant plus.

§5. La possibilité pour l'assemblée générale de modifier le projet de scission

630. Une flexibilité nécessaire ? Étant donné que l'assemblée générale qui va approuver l'opération n'est pas l'organe qui est en charge de la rédaction du projet commun de scission, on peut s'interroger sur la possibilité pour cette dernière de modifier le projet commun au moment où elle est amenée à se prononcer sur l'opération. Cette question est susceptible de se poser fréquemment en pratique compte tenu du laps de temps relativement long pouvant s'écouler entre la publication du projet commun de scission et les réunions des assemblées générales des sociétés concernées.

631. Une approbation ou un rejet en bloc ? On pourrait tout d'abord considérer que la formulation restrictive (i) de la Directive Sociétés en matière de scissions internes imposant que la décision de l'assemblée générale doive nécessairement porter sur « l'approbation du projet de scission »[3075] et (ii) de la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés qui précise qu'il incombe à l'assemblée générale « d'approuver ou non le projet de scission transfrontalière »[3076] implique que les associés

[3073] Art. 133, § 1er de la Directive Sociétés et art. 7 de la Directive Participation des Travailleurs.
[3074] Art. 133, § 3, h) et § 4, a) de la Directive Sociétés et Annexe, Partie 3 de la Directive Participation des Travailleurs.
[3075] Art. 139, § 1er et 93, § 3 de la Directive Sociétés.
[3076] Art. 160*nonies*, § 1er de la Directive Mobilité.

ne peuvent qu'approuver ou rejeter le projet en bloc[3077]. Une telle interprétation est en outre confortée par la description des effets de la scission faite par la Directive Sociétés qui impose que, sauf élément d'actif ou passif oublié, cette répartition soit faite « conformément à la répartition prévue au projet de scission »[3078] et qui se retrouve également dans le régime de la Directive Mobilité[3079]. Si on combine cela avec le fait que certains mécanismes de protection des créanciers établis notamment par la France[3080] commencent déjà à courir à partir de la publication du projet commun de scission, on comprend difficilement comment il pourrait encore être loisible à l'assemblée générale d'apporter des modifications au projet de scission.

632. Une faculté de modification en cas d'opération interne. Cette position doit toutefois être fortement nuancée. En effet, tout d'abord, on comprend difficilement l'intérêt de l'obligation d'information des assemblées générales des sociétés impliquées qui pèse sur les organes de direction ou d'administration des sociétés impliquées en cas de modification importante du patrimoine actif et passif de la société scindée[3081] si celles-ci ne peuvent en tirer les conséquences sous la forme d'une adaptation du projet commun de scission. La *ratio legis* de cette obligation d'information est, outre la volonté de garantir une prise de décision éclairée au sein de l'assemblée générale[3082], d'éviter d'imposer systématiquement à l'organe de direction ou d'administration d'adapter le projet de scission au gré des évolutions importantes du patrimoine de la société scindée et de devoir repasser par les étapes de la publication et des rapports. Il faut donc en conclure que les États membres restaient libres au moment de la transposition du régime des scissions internes prévu par la Directive Sociétés de reconnaître un pouvoir de modification à l'assemblée générale, ce qui est le cas par exemple en droit belge[3083], en droit français[3084] et en droit allemand[3085].

633. La position du législateur européen dans la Directive Mobilité. De manière innovante, le législateur européen a fait le choix, dans le cadre des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, d'imposer

3077 A. SEIFERT, *op. cit.*, p. 130.

3078 Art. 151, § 1er, a), de la Directive Sociétés et Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 29.

3079 Art. 160*novodecies*, § 1er, a) de la Directive Mobilité.

3080 Art. L236-14, al. 2 et L236-21, al. 2 du Code de commerce français.

3081 Voir art. 141, § 3 de la Directive Sociétés en cas de scission interne et à ce sujet en cas de scission transfrontalière, voir *supra* nos 613 à 616.

3082 À ce sujet, voir *supra* nos 613 à 616.

3083 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 9 qui traite en particulier de la nécessité pour l'assemblée générale de corriger le rapport d'échange suite à une modification patrimoniale et S. MAQUET, *op. cit.*, p. 46 ; G. PALMAERS et A. GUBBELS, « De grensoverschrijdende fusie », *T.F.R.*, 2008/4, pp. 251et 252, n° 46 ; Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 222, n° 313 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 588, n° 31. Voir toutefois également : Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 29 qui établit qu'il n'est pas loisible à l'assemblée générale de modifier la répartition du patrimoine de la société scindée telle qu'elle figure dans le projet de scission.

3084 J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 45, n° 102.

3085 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 64, n° 10.

explicitement aux États membres de veiller à ce qu'une modification du projet de scission ne puisse être approuvée qu'à une majorité qui ne pourra être (i) ni inférieure aux deux-tiers, (ii) ni supérieure à 90 % des droits de vote attachés soit aux actions, soit au capital souscrit représenté[3086]. Cette précision a certes le mérite d'indiquer clairement les conditions applicables à une modification du projet, mais elle n'impose pas aux États membres de reconnaître explicitement un pouvoir de modification à l'assemblée générale de la société scindée[3087]. La résolution de cette question s'en trouve donc déférée aux différents États membres, ce qui ne pose aucun problème dans le cadre du champ d'application *ratione materiae* limité de la Directive Mobilité[3088] puisque la question sera exclusivement résolue par le droit national applicable à la société scindée[3089], même s'il eût été préférable d'autoriser de tels amendements *ab initio* moyennant l'accord de l'assemblée générale[3090].

634. *Quid* en cas de scission impliquant plus d'une société préexistante ? La solution de la Directive Mobilité n'est toutefois pas transposable aux scissions par acquisition ainsi qu'aux scissions mixtes puisqu'en l'occurrence, le projet de scission devra également être approuvé par les assemblées générales des sociétés bénéficiaires[3091]. À l'instar de la solution retenue en matière de fusions transfrontalières[3092], on pourrait considérer qu'il est loisible aux assemblées générales de modifier le projet commun pour autant toutefois qu'une telle modification soit autorisée par toutes les *lex societatis* en présence et qu'en définitive, toutes les sociétés impliquées approuvent le projet commun dans des termes identiques. En d'autres termes, il faudrait recourir à une application cumulative des différents droits nationaux en présence, tout en privilégiant la norme la plus sévère, c'est-à-dire celle qui s'opposerait à toute modification du projet commun ou qui prohiberait l'altération de certains éléments du projet commun jugés plus fondamentaux, comme à titre d'illustration la répartition du patrimoine de la société scindée[3093]. Cette solution doit toutefois encore être nuancée sous deux aspects. Tout d'abord, étant donné qu'il a été exposé qu'en cas de scissions transfrontalières, le rapport de l'organe de direction ou d'administration justifiant la scission et en expliquant les conséquences doit être mis à la disposition non seulement des associés, mais également des travailleurs[3094], il convient de considérer que l'assemblée générale ne peut procéder à une modification pure et simple du projet commun si celle-ci est susceptible d'avoir une incidence sur la situation des salariés des entreprises impliquées. Soutenir le contraire reviendrait en effet à priver les représentants

3086 Art. 160*nonies*, § 3 de la Directive Mobilité.
3087 Voir en ce sens : F. Bernard, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 31.
3088 Art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité.
3089 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.
3090 Voir en ce sens : S. Binard et L. Schummer, *op. cit.*, p. 35.
3091 À ce sujet, voir *supra* n° 618.
3092 S. Maquet, *op. cit.*, p. 35 ; J.-M. Moulin, *op. cit.*, p. 45, n° 102 ; Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 222, n° 313 et D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 588, n° 31.
3093 À ce sujet, voir : Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 29.
3094 À ce sujet, voir *supra* n° 556.

du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes de leur droit d'être informés des conséquences de l'opération au moins un mois avant la date de l'assemblée générale. Une telle modification impliquera que les assemblées générales devront soit approuver la scission sous la condition suspensive de la renonciation par les représentants des salariés ou des salariés eux-mêmes à leur droit de recevoir un rapport à jour, soit devront requérir auprès de l'organe de direction ou d'administration l'établissement d'un nouveau projet commun de scission qui devra faire l'objet d'une publication et de rapports. La seconde nuance concerne le fait que les modifications apportées à la scission pourraient avoir un impact sur les conditions de son approbation, par exemple en cas de transformation d'une scission symétrique en scission asymétrique, si l'unanimité n'est pas de toute façon requise pour une telle modification[3095] comme c'est le cas en droit belge[3096] et en droit allemand[3097].

§ 6. Une assemblée générale facultative

635. Une simplification de la procédure pour les sociétés bénéficiaires. Considérant qu'une scission ne présente que des risques plus limités pour les associés des sociétés bénéficiaires[3098], le législateur européen a prévu en matière de scissions internes que les États membres pouvaient rendre l'approbation de l'opération par les assemblées générales des sociétés bénéficiaires facultative en dehors de l'hypothèse d'une scission intra-groupe[3099] pour peu que certaines obligations de publicité soient remplies et que des associés minoritaires détenant un pourcentage minimal du capital social qui ne pourra être fixé à plus de cinq pourcents par les États membres disposent toujours de la possibilité de requérir la tenue d'une assemblée générale[3100]. La Directive Mobilité n'aborde pas cette question dans la mesure où elle n'a pas vocation à s'appliquer aux scissions transfrontalières où au moins une des sociétés bénéficiaires serait préexistante. Cependant, un régime similaire se retrouve également dans la Directive Sociétés à l'égard des fusions internes[3101] et transfrontalières[3102]. Contrairement au législateur luxembourgeois[3103], le législateur belge[3104] n'a pas fait usage de cette faculté. En revanche, en droit autrichien[3105], il est explicitement prévu que les scissions d'importance mineure dans lesquelles les actions à attribuer n'excèdent pas dix pourcents du capital social de la société bénéficiaire concernée, ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale. La *ratio legis* tient au fait que l'impact d'une telle opération sur

3095 À ce sujet, voir *infra* n° 1001.
3096 Art. 12:67, § 6 (scissions par absorption) et 12:83, § 6 (scissions par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.
3097 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 64, n° 10.
3098 À ce sujet, voir *infra* n°s 977 à 984.
3099 À ce sujet, voir *infra* n°s 671 à 682.
3100 Art. 140 de la Directive Sociétés.
3101 Art. 94 de la Directive Sociétés.
3102 Art. 126, § 3 et 94 de la Directive Sociétés.
3103 Art. 1031-4 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3104 Projet de loi portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2007–2008, n° 1012/001, p. 65.
3105 § 17(5) SpaltG et § 231(1), 2. öAktG. À ce sujet, voir S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 944, n° 54.

les associés des sociétés bénéficiaires est limité de sorte qu'une telle simplification de procédure se justifie[3106]. S'il est certes vrai que cette option ne présente que peu d'intérêt dans l'hypothèse où les statuts des sociétés bénéficiaires doivent de toute façon être modifiés par l'assemblée générale à la suite de l'opération[3107], tel ne sera pas le cas si (i) les actions à attribuer sont détenues en trésorerie par les sociétés bénéficiaires et (ii) aucune autre modification des statuts n'est nécessaire à la suite de l'opération. En tout état de cause, les divergences entre États membres ne sont pas de nature à poser de difficultés particulières en cas de scission transfrontalière dans la mesure où la question du caractère facultatif ou obligatoire de l'approbation de l'opération par les assemblées générales des sociétés bénéficiaires dépendra des différents droits nationaux en question qui se verront appliqués distributivement[3108].

§7. La contestation de la décision de l'assemblée générale

636. Un nouvel indice de l'habileté politique de la Commission. La Directive Mobilité prévoit explicitement que la décision d'approbation de la scission transfrontalière par l'assemblée générale ne pourra être contestée uniquement sur la base du fait que (i) le rapport d'échange des actions n'a pas été fixé correctement, (ii) la soulte en espèces dans le cadre du droit de retrait n'a pas été fixée correctement ou (iii) les informations concernant le rapport d'échange ou la soulte en espèces n'étaient pas conformes aux exigences légales[3109]. Si la troisième exclusion a été ajoutée au cours du processus législatif par le Premier Compromis de la Présidence[3110], il est toutefois intéressant de relever que la Proposition de la Commission excluait également la possibilité de contester la validité de la décision de l'assemblée générale sur la base du motif que la valeur totale des participations attribuées à un associé n'était pas équivalente à la valeur des actions détenues par celui-ci dans la société scindée. Cette dernière disposition qui n'a pas survécu au Premier Compromis de la Présidence[3111] ne fait certes qu'un sens limité dans l'hypothèse d'une scission par constitution de nouvelles sociétés puisque les sociétés bénéficiaires n'ont aucune valeur préalablement à la scission. En revanche, elle prend tout son sens dans l'hypothèse d'une scission asymétrique au profit de plusieurs sociétés bénéficiaires préexistantes où un associé minoritaire se retrouverait avec une participation exclusivement dans la société bénéficiaire s'étant vu allouer toutes les branches d'activité en perte de vitesse ou ayant un actif net négatif. Il convient donc d'y voir à nouveau un indice selon lequel la Commission entendait d'ores et déjà préparer le terrain à une réforme plus ambitieuse des scissions transfrontalières couvrant également l'hypothèse d'une opération impliquant plus d'une société préexistante.

3106 Voir en ce sens : S. Kalss in S. Kalss (dir)., *op. cit.*, p. 380, n° 3.
3107 Voir en ce sens : M. Evrard et E. van der Vaeren, *op. cit.*, p. 116.
3108 J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 360.
3109 Art. 160*nonies*, § 5 de la Directive Mobilité.
3110 Art. 160 k, § 5, c) du Premier Compromis de la Présidence.
3111 Art. 160 k, § 5 du Premier Compromis de la Présidence.

637. Une juste contrepartie. Ces exclusions bienvenues[3112] s'inscrivent dans le nouveau régime spécifique de protection des associés minoritaires mis en place par le législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité[3113] en empêchant que l'opération transfrontalière ne soit bloquée pour ces motifs[3114]. Elle vise avant tout à remédier à une insuffisance significative du régime allemand des fusions transfrontalières liée à une harmonisation insuffisante de la protection des associés minoritaires par la Directive Mobilité. En effet, cette dernière, tout en s'en remettant volontairement aux États membres pour la détermination des mécanismes spécifiques de protection des intérêts des associés minoritaires[3115], intégrait une règle de droit international privé spécifique[3116] issue du régime de la société européenne[3117] et destinée à couvrir notamment la procédure de réévaluation du rapport d'échange et le droit de retrait des associés minoritaires connus en droit allemand[3118] et en droit autrichien[3119]. Il était ainsi prévu que si le droit national applicable à une des sociétés impliquées dans la fusion transfrontalière prévoyait une procédure permettant soit d'analyser et de modifier le rapport d'échange soit d'indemniser les associés minoritaires, une telle procédure ne trouverait à s'appliquer que si les autres sociétés impliquées et soumises à un droit national ne connaissant pas ce type de procédure l'acceptaient explicitement au moment de l'approbation du projet de fusion transfrontalière[3120]. En pratique, cette règle s'est révélée être une source de considérables difficultés[3121], ne fût-ce qu'en raison du fait que les associés de la société étrangère n'étaient aucunement incités à accepter

3112 Voir en ce sens : M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 21 ; M. MENJUCQ, « Les transformations transfrontalières », *op. cit.*, p. 4 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 260 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2443 et Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 245.

3113 Voir en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2256 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 363 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 212 et 213 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 32 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 237 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 292.

3114 Voir en ce sens ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 310 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 260 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2443 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *ibidem*, p. 292.

3115 Voir en ce sens : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 428.

3116 Art. 127, § 3 de la Directive Sociétés.

3117 Art. 25, § 3 du Règlement sur la Société européenne et à ce sujet, voir : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 265.

3118 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 6 et N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2255.

3119 § 11(1) SpaltG et § 10(1) EU-VerschG.

3120 Art. 127, § 3, 1re phrase de la Directive Sociétés.

3121 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 4 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, pp. 1162 et 1163 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 781 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 26, n° 11 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 509 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 253 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 237 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2438.

de telles procédures[3122], notamment en raison du fait que les mécanismes de protection en question auraient été à sens unique[3123], et qu'une procédure de vérification du rapport d'échange était inconnue dans la grande majorité des États membres[3124]. Or, un tel refus de reconnaître ces mécanismes de protection spécifiques avait pour conséquence directe que les associés minoritaires qui en étaient privés retrouvaient leur droit de contester la validité de la décision de l'assemblée générale pour des raisons d'évaluations insuffisantes[3125]. Afin d'éluder cette conséquence néfaste affectant une opération transfrontalière d'une incertitude non négligeable, la solution prônée par la Directive Mobilité devrait également se retrouver dans un régime plus général des scissions transfrontalières moyennant toutefois la mise en place d'un système de protection efficace des associés minoritaires[3126] assurant un équilibre entre les intérêts de ces derniers et ceux de la société concernée[3127].

638. Quid en cas de scissions transfrontalières ? En droit allemand[3128] et en droit autrichien[3129] des fusions internes et transfrontalières et des scissions internes, l'impossibilité le contester la validité de la décision de l'assemblée générale sur la base d'une évaluation insuffisante ne s'applique qu'aux seuls associés de la société scindée ou absorbée. Cette position restrictive n'a pas été suivie dans le nouveau régime des fusions transfrontalières de la Directive Mobilité[3130] qui prévoit explicitement que ni les associés des sociétés bénéficiaires, ni les associés de la société absorbée ne pourront contester la validité de l'approbation de la fusion transfrontalière sur la base du seul motif que le rapport d'échange ou la soulte en espèces n'ont pas été fixés correctement ou encore que les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d'échange ou la soulte en espèces n'étaient pas conforme aux exigences légales. Ce choix du législateur européen, qui est à approuver en raison du plus haut niveau de sécurité qu'il confère à l'opération[3131], devrait également se retrouver dans un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. Ceci présuppose toutefois la mise en place de mécanismes alternatifs de protection des intérêts des associés minoritaires tant de la société scindée que des sociétés bénéficiaires suffisants[3132].

3122 W. Bayer et J. Schmidt, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 844 ; D. Beutel, *op. cit.*, p. 266 ; T. Drygala et T. von Bressensdorf, *op. cit.*, pp. 1162 et 1163 ; R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 3 et M. Noack, *op. cit.*, p. 781.

3123 B. Lecourt, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 26, n° 11 ; R. Marsch-Barner et C. Wilk in H. Kallmeyer (dir.), *ibidem*, § 122h, n° 3 et M. Noack, *ibidem*, p. 781.

3124 Voir en ce sens : W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 10 ; D. Beutel, *op. cit.*, p. 263 et Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 2.

3125 Voir en ce sens : M. Noack, *op. cit.*, p. 781.

3126 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1.

3127 Sur cet impératif d'équilibre, voir *infra* n°s 985 et 986.

3128 §§ 14(2) ; 122h et 125 UmwG.

3129 § 234b(5) öAktG ; § 9(2) SpaltG et § 11 EU-VerschG.

3130 Art. 126, § 4 de la Directive Mobilité.

3131 Voir en ce sens : P. Stelmaszczyk, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2444.

3132 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1.

SECTION 8. LE DOUBLE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

639. Plan de la section 8. Étape propre aux opérations transfrontalières, le double contrôle de légalité sera essentiel en cas de scission transfrontalière. Pour pleinement saisir les objectifs que celui-ci entend remplir, il importe en premier lieu d'exposer l'origine de ce mécanisme (§ 1), pour ensuite examiner en détail le premier contrôle (§ 2), la communication du certificat préalable (§ 3), le second contrôle (§ 4) et, en définitive, les autorités nationales compétentes pour l'accomplir (§ 5).

§ 1. Une règle de droit matériel inspirée du régime des fusions transfrontalières et de la société européenne

640. Un mécanisme en deux temps. Afin d'éviter des opérations de restructuration frauduleuses ou incorrectes[3133] tout en limitant autant que possible les cas dans lesquels la nullité de l'opération pourrait être prononcée[3134], le législateur européen a instauré un mécanisme de contrôle en deux temps inspiré de la procédure de constitution d'une société européenne[3135] et du régime des fusions transfrontalières[3136] dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité[3137]. Il s'agit là d'une norme de droit matériel justifiée par le caractère transfrontalier de l'opération[3138]. L'idée sous-jacente est qu'en raison des disparités existant entre les droits nationaux, le respect de la procédure nationale ne peut être efficacement vérifié que par une autorité relevant du même État membre[3139]. Par conséquent, chaque autorité nationale compétente contrôlera la légalité de la scission transfrontalière pour les parties de la procédure régies par son propre droit national, délivrera un certificat préalable attestant de manière incontestable de l'accomplissement correct des procédures et des formalités préalables à l'opération et transmettra celui-ci par le biais du système d'interconnexion des registres à une autorité centralisatrice qui opérera un contrôle plus général de la légalité de la partie de la procédure relative à la réalisation de l'opération. L'intérêt de ce mécanisme en deux temps est que l'autorité de contrôle final disposera des certificats nationaux attestant de la conformité de

3133 S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 265 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1905 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 378 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 589, n° 34.

3134 61e considérant de la Directive Sociétés.

3135 Art. 25 et 26 du Règlement sur la Société européenne.

3136 Art. 127 et 128 de la Directive Sociétés.

3137 Art. 160*quaterdecies* ; 160*quindecies* et 160 *sexdecies* de la Directive Mobilité et en ce sens : Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 6 ; M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 19, n° 12 et p. 22, n° 38 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 70, n° 63.

3138 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 200 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 116 ; R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 375 et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », *op. cit.*, p. 19, n° 35.

3139 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 201.

l'objet du premier contrôle aux législations nationales respectives[3140], ce qui lui évitera de devoir analyser les différentes législations nationales[3141]. Au-delà de cet aspect de simplification, ce double mécanisme présente également l'avantage de renforcer la qualité du contrôle puisque la conformité aux différents droits nationaux sera systématiquement vérifiée par l'autorité qui est la plus compétente pour ce faire[3142].

641. La nécessité d'un tel mécanisme en cas de scission transfrontalière. Ce mécanisme en deux temps est certes relativement long et contraignant[3143], mais il présente l'indéniable avantage d'une certaine sécurité juridique[3144] et s'est révélé efficace en pratique[3145]. Compte tenu de ce caractère cardinal, il est indispensable de prévoir l'application d'un mécanisme similaire aux scissions transfrontalières[3146], tout en tenant toutefois compte des spécificités de ce type d'opération qui se caractérise par une unicité de société apporteuse. Si la nécessité de prévoir l'application d'un tel mécanisme aux scissions transfrontalières a été reconnue[3147] et se retrouve effectivement dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité, on peut toutefois s'étonner de ce que la Directive Mobilité se soit limitée à reprendre la solution développée en matière de fusions transfrontalières[3148] sans tenir compte des spécificités d'une scission qui se caractérise par une unicité de société apporteuse[3149]. Cette particularité implique en effet que le second contrôle de légalité devrait être réalisé par une autorité relevant du droit de l'entité scindée et non des entités bénéficiaires. Cette inversion se justifie au regard de l'objectif centralisateur de ce second contrôle qui ne pourrait être rempli aussi efficacement s'il devait être effectué dans tous les États membres des sociétés bénéficiaires, mais également du point de vue de la solution retenue pour la date de prise d'effet de l'opération qui s'aligne sur le droit applicable à la société scindée[3150]. Cette solution n'a toutefois pas davantage été retenue par le législateur belge dans le cadre de la mise en place du régime des scissions transfrontalières par absorption[3151], mais cela tient

3140 W. Bayer et J. Schmidt, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 404 ; D. Beutel, *ibidem*, p. 200 ; M. Evrard et E. van der Vaeren, *op. cit.*, p. 116 ; H.-W. Neye et B. Timm, *op. cit.*, p. 492 et M. Scheifele, *op. cit.*, p. 272.

3141 D. Beutel, *ibidem*, p. 201 et M. Evrard et E. van der Vaeren, *op. cit.*, p. 117.

3142 D. Beutel, *ibidem*, p. 201.

3143 S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 266 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 378.

3144 S. Kulenkamp, *ibidem*, p. 265 ; J. Mitterecker, *ibidem*, p. 378 et D. Willermain, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 589, n° 34.

3145 Voir en ce sens : J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 305 et Th. Wachter, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 328.

3146 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 octobre 2015, Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, COM(2015) 550 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (04/05/2018), p. 8.

3147 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 octobre 2015, Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, COM(2015) 550 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (04/05/2018), p. 8.

3148 Art. 128, § 1er de la Directive Mobilité et art. 160*sexdecies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

3149 Voir en ce sens : F. Bernard, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 31 et 32.

3150 Art. 160*octodecies* de la Directive Mobilité.

3151 Art. 12:73, §§ 3 à 5 du CSA.

vraisemblablement au fait que le législateur belge, contrairement au législateur européen[3152], a fait le choix surprenant de faire dépendre la date de prise d'effet de l'opération du droit national applicable aux sociétés bénéficiaires[3153].

§2. Le premier contrôle ou contrôle de conformité

642. Plan du § 2. Présenter avec concision le premier contrôle ou contrôle de conformité implique de clarifier la question du droit qui lui sera applicable (A), d'identifier les entités concernées (B), de préciser l'objet du contrôle (C) et d'exposer les différentes issues du contrôle envisageables (D).

A. *Le droit applicable*

643. La primauté du droit de l'autorité. Comme l'accomplissement de ce premier contrôle de conformité ne requiert pas une action commune de toutes les entités impliquées dans l'opération, il sera, sauf pour ce qui est de certains aspects liés à la validité du certificat[3154], régi par le droit applicable à l'autorité nationale en charge de ce contrôle[3155]. Cette règle de conflit de lois est conforme au principe fondamental selon lequel la procédure de scission transfrontalière reste régie pour chaque société impliquée par son propre droit national[3156].

B. *Les entités concernées*

644. Le cas particulier de la société de l'État membre du second contrôle. Selon le texte tant de la Directive Mobilité[3157] que du Règlement sur la Société européenne[3158], le premier contrôle s'appliquera à chacune des entités participant à l'opération. En matière de fusions transfrontalières, il serait donc erroné de penser que le premier contrôle ne vise que les sociétés apporteuses et le second contrôle se rapporte à la société bénéficiaire[3159]. Toutefois, on peut s'interroger sur la nécessité de prévoir deux contrôles séparés et la délivrance d'un certificat pour cette dernière alors que c'est la même autorité nationale qui effectuera les deux contrôles. Ceci explique pourquoi certains États membres, comme l'Allemagne[3160], ont prévu la possibilité d'un contrôle unique dans le chef de la société absorbante et qu'une solution similaire ait été recommandée

3152 Art. 160*octodecies* de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *infra* n° 667.
3153 Art. 12:73, §§ 4 et 5 du CSA.
3154 À ce sujet, voir *infra* n° 648.
3155 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 1 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 66 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 1.
3156 À ce sujet, voir *supra* n° 314. Voir également : art. 160*quater* de la Directive Mobilité.
3157 Art. 127, § 1er de la Directive Mobilité.
3158 Art. 25, § 1er du Règlement sur la Société européenne.
3159 *À propos des fusions transfrontalières :* D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 201 ; D. HARITZ et B. VON WOLFF, « Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrecht – Zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *GmbHR*, 2006, p. 343 ; Chr. LOUVEN, *op. cit.*, p. 2021 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 379. *À propos de la société européenne :* M. SCHEIFELE, *op. cit.*, p. 271.
3160 § 122k (1) UmwG.

à la suite des résultats de l'étude menée par Bech-Bruun et Lexidale[3161]. L'idée d'un tel contrôle unique qui a pour objectif de simplifier une procédure déjà fort complexe mériterait indéniablement d'être considérée dans le cas d'une scission transfrontalière, à ceci près que compte tenu de l'impératif d'une date unique pour la prise d'effet de l'opération[3162], celui-ci ne devrait pas concerner la société bénéficiaire comme dans le cas d'une fusion transfrontalière, mais bien la société scindée.

C. *L'objet du contrôle*

645. Un contrôle préventif. Au-delà de la lutte contre de potentiels abus[3163], le premier contrôle s'appliquera à chacune des entités participant à l'opération et portera à tout le moins sur le respect de toutes les conditions pertinentes et de l'accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans cet État membre. On peut donc considérer que ce premier contrôle se concentre sur tous les aspects internes de l'opération et, principalement à la préparation et à la tenue de chaque assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération[3164], ainsi que sur le respect des mécanismes de protection des différents *stakeholders*[3165]. C'est ainsi que le contrôle en matière de scission transfrontalière portera, le cas échéant, sur la vérification que le projet contient bien des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités de participation des travailleurs dans les sociétés bénéficiaires[3166], ainsi que sur les options possibles pour de telles modalités de participation des travailleurs[3167] et que dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'autorité compétente examinera, selon le texte de la Directive Mobilité[3168], une indication de la société scindée selon laquelle la procédure de négociation relative à la protection de la participation des travailleurs a bien débuté. À l'égard de ce dernier élément, il appartiendra également à ces autorités de vérifier que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont bien été fixées conformément aux dispositions du droit européen[3169], puisque ces autorités seront les mieux à même de vérifier cet aspect dans la mesure où il relève majoritairement du droit national des sociétés bénéficiaires. Pour ce qui est de la protection des créanciers[3170], le contrôle pourra également porter, selon le choix des États membres, sur la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non

3161 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 84 et 85.
3162 À ce sujet, voir *infra* n°s 666 et 667.
3163 Sur l'utilisation du premier contrôle de légalité dans le cadre de la lutte anti-fraude et anti-abus, voir *supra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1, Section 2, § 4.
3164 D. Beutel, *op. cit.*, p. 202 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 2 et R. Frenzel, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 380.
3165 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : F. Garcimartín et E. Gandía, *op. cit.*, p. 39.
3166 Sur la question de l'incidence d'une scission transfrontalière sur le régime de participation des travailleurs, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2.
3167 Art. 160*quaterdecies*, § 5 de la Directive Mobilité.
3168 Art. 160*quaterdecies*, § 6, b) de la Directive Mobilité.
3169 Voir art. 160*sexdecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité qui, à l'heure actuelle, confère la vérification de cet élément à l'autorité en charge du second contrôle.
3170 Sur la question de la protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I.

pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d'exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours[3171]. Il convient également de relever qu'à aucun moment les autorités nationales n'ont à se prononcer sur l'opportunité de la décision de scission qui relève de la liberté économique des sociétés concernées[3172].

646. Les documents à fournir à l'autorité compétente. La Directive Mobilité prévoit explicitement que l'autorité compétente, en dehors des documents additionnels qui pourraient être requis par les États membres dans le cadre de la disposition anti-abus[3173], devra à tout le moins obtenir (i) le projet de scission, (ii) le cas échéant, le ou les rapports de l'organe de direction ou d'administration et l'avis des représentants des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs eux-mêmes et le rapport de l'expert indépendant, (iii) toute observation sur le projet de scission présentée par les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes sur le projet de scission et (iv) des informations sur la décision adoptée par l'assemblée générale à l'égard du projet de scission[3174]. Ces documents correspondent également à ceux requis dans le cadre d'une fusion transfrontalière[3175] et sont suffisants pour permettre à l'autorité nationale compétente de remplir sa mission de contrôle dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, peu important à cet égard qu'elle implique ou non plus d'une société préexistante.

D. *L'issue du contrôle*

1. *Présentation*

647. Quatre issues possibles. Une fois l'autorité nationale compétente saisie du contrôle de conformité, celle-ci disposera d'un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et informations pour prendre une décision quant à l'éventuelle délivrance du certificat. Quatre issues distinctes sont ainsi possibles. Tout d'abord, s'il est déterminé que l'opération envisagée remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités ont bien été accomplies, l'autorité compétente pourra décider de remettre le certificat de conformité[3176]. Alternativement, et en dehors de l'hypothèse d'une opération abusive ou frauduleuse, lorsque toutes les conditions applicables ne sont pas remplies ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n'ont pas été accomplies, l'autorité compétente refusera la délivrance du certificat, le cas échéant en laissant toutefois un délai de grâce à la société concernée pour rectifier les insuffisances[3177]. Troisièmement, s'il s'avère que l'opération est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire

3171 Art. 160*quaterdecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
3172 À propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 204 ; S. MAQUET, *op. cit.*, p. 48 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 379, n° 558. À propos de la société européenne : M. SCHEIFELE, *op. cit.*, p. 259.
3173 Art. 160*quaterdecies*, § 3, de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1, Section 2, § 4.
3174 Art. 160*quaterdecies*, § 2, al. 1er de la Directive Mobilité.
3175 Art. 127, § 2 de la Directive Mobilité.
3176 Art. 160*quaterdecies*, § 7, a) de la Directive Mobilité.
3177 Art. 160*quaterdecies*, § 7, b) de la Directive Mobilité.

au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner ou à des fins criminelles, l'autorité compétente refusera purement et simplement de délivrer le certificat[3178]. Quatrièmement, lorsque l'autorité compétente soupçonne sérieusement que l'opération est réalisée à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles, elle peut réaliser une appréciation de tous les faits et circonstances pertinents[3179], le cas échéant en réalisant des enquêtes supplémentaires ou en requérant des informations additionnelles, tout en bénéficiant d'un délai additionnel de trois mois au maximum[3180]. Il n'y a pas de raison qu'il en soit différemment dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. Comme les deux dernières hypothèses ont déjà fait l'objet d'une étude détaillée[3181], seules les deux premières seront examinées ici.

2. *La délivrance du certificat*

648. Une preuve irréfragable ? Si à l'issue du contrôle de conformité, il s'avère que l'opération envisagée tombe bien dans le champ d'application du régime national des scissions transfrontalières et que toutes les conditions, formalités et procédures ont bien été observées, l'autorité compétente délivrera alors un certificat préalable à la scission[3182]. Il découle du texte même de la Directive Mobilité qui qualifie le certificat préalable de « preuve concluante » de la conformité de la scission transfrontalière envisagée au droit national de l'État membre de la société scindée[3183], que ce dernier liera en principe l'autorité en charge du second contrôle[3184]. Ce caractère liant découle notamment du fait que les objets des différents contrôles ne se recouvrent pas[3185]. Cette pré-

3178 Art. 160*quaterdecies*, § 8 de la Directive Mobilité.
3179 Art. 160*quaterdecies*, § 9 de la Directive Mobilité.
3180 Art. 160*quaterdecies*, § 10 de la Directive Mobilité.
3181 À ce sujet, voir *supra* n°s 347 à 375.
3182 Art. 160*quaterdecies*, § 7, a) de la Directive Mobilité.
3183 Art. 160*sexdecies*, § 5 de la Directive Mobilité.
3184 Voir en ce sens : W. Bayer et J. Schmidt, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569 ; J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 359 ; J. Bormann et P. Stelmaszczyk, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 305 ; Th. Luy, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1905 ; C. Müller, *op. cit.*, p. R6 ; J. Schmidt, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 251 ; J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243. Pour un point de vue plus sceptique, voir : G. Parleani, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 16, n° 54 et O. Mörsdorf, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 144. Pour un point de vue critique de la formulation de la Proposition de la Commission qui aurait pu être plus claire à cet égard, voir : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 8.
3185 W. Bayer in M. Lutter (dir.), *op. cit.*, § 122l, n° 19 ; W. Bayer et J. Schmidt, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 404 ; W. Bayer et J. Schmidt, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *op. cit.*, p. 843 ; D. Beutel, *op. cit.*, p. 200 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122l, n° 10 ; R. Frenzel, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 384 ; St. Klein, *op. cit.*, p. 607 ; S. Kulenkamp, *op. cit.*, p. 268 ; J. Mitterecker, *op. cit.*, pp. 279 et 280 ; O. Mörsdorf, *ibidem*, p. 144 ; H.-W. Neye et B. Timm, « Die geplante Umsetzung der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften im Umwandlungsgesetz », *DB*, 2006, p. 492 et P. Stelmaszczyk, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 70, n° 64 et N. Zimmermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122l, n° 16.

cision est utile dans la mesure où il s'est avéré à l'égard du régime actuel des fusions transfrontalières que certaines autorités nationales en charge du second contrôle de légalité vérifiaient si toutes les entités impliquées avaient bien respecté le prescrit du droit national de l'autorité en question[3186], violant par là même le principe de l'application subsidiaire du droit national adopté dans la Directive Sociétés[3187]. Cependant, s'il est certes vrai qu'il n'est pas loisible à l'autorité chargée du second contrôle de remettre en cause ce qui est établi dans le certificat, il n'en demeure pas moins que si celui-ci présente des erreurs manifestes, elle devra à tout le moins avoir la possibilité de requérir l'autorité nationale compétente de renouveler son contrôle sur les points litigieux[3188]. Compte tenu du nombre potentiellement important de contrôles de conformité qui devront avoir lieu dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, cette solution, qui n'est que la conséquence logique de la division du travail entre les différentes autorités nationales compétentes, devrait également trouver à s'y appliquer.

649. La forme du certificat. En dehors de ces précisions, il est intéressant de relever que la Directive Mobilité[3189], pas plus que la Directive Sociétés[3190] ou le Règlement sur la Société européenne[3191] avant elle, ne contient de précisions sur le certificat lui-même. S'il est logique qu'aucune condition de forme explicite ne soit imposée en raison des différentes autorités susceptibles d'être chargées du contrôle de conformité, on peut déduire de l'utilisation du terme « certificat » qu'il faudra à tout le moins un écrit[3192]. Au-delà de cela, les certificats seront susceptibles de revêtir des formes très diverses[3193], ce qui est de nature à engendrer certaines difficultés pratiques. A titre d'illustration, en matière de fusions transfrontalières, on peut citer l'exemple du droit allemand en vertu duquel la notification faite par la juridiction compétente que la fusion a bien été inscrite au registre de la société absorbée constitue le certificat, sans que la délivrance d'un certificat séparé ne soit requise[3194]. Cette situation, dont la conformité à la Directive Sociétés n'est pas certaine[3195], est susceptible de

3186 Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, p. 62 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, 359 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 305 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 251 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 70, n° 64. Pour un cas d'illustration d'une telle remise en cause voir : *Re Diamonds Resorts (Europe) Ltd* [2013] B.C.C. 275.

3187 Art. 121, § 1er, b) de la Directive Sociétés.

3188 Voir pour la même problématique à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122l, n° 20 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 203, note 1048 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 268 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 279 et 280.

3189 Pour un point de vue critique, voir : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243.

3190 Art. 127 de la Directive Sociétés.

3191 Art. 25 du Règlement sur la Société européenne.

3192 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 210.

3193 J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25.

3194 § 122k (1) UmwG.

3195 Contre la conformité du régime allemand à la Directive Sociétés : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *op. cit.*, p. 843 ; Fl. DRINHAUSEN in

causer certaines difficultés à l'autorité nationale en charge du second contrôle, *a fortiori* si en vertu du droit national de cette dernière, la notification du registre ne constitue pas un certificat valable dans la mesure où elle requiert un document contenant une motivation[3196]. Afin de remédier à ces insuffisances, il avait été proposé de mettre en place un formulaire standard de certificat[3197], mais ces recommandations n'ont pas été suivies dans la Directive Mobilité. Compte tenu du fait qu'une scission transfrontalière par acquisition impliquera fréquemment pas moins de trois États membres distincts, la nécessité d'une certaine forme d'homogénéisation du certificat s'imposera d'autant plus et on ne peut plaider qu'en faveur de la mise en place d'un formulaire numérique standard au niveau européen qui puisse être aisément communiqué via le système d'interconnexion des registres et accepté sans réticences par l'autorité nationale en charge du second contrôle. Certes, le fait que cette question n'ait pas été abordée dans le nouveau régime des fusions transfrontalières de la Directive Mobilité témoigne à lui seul du caractère politiquement délicat de la question, mais il serait possible de contourner cet obstacle en imposant aux différentes autorités nationales de remplir un formulaire standard en plus du certificat usuel. Il convient toutefois encore de remarquer que dans le cadre de la Directive d'ici au 1er février 2021, la Commission aura dû adopter un acte d'exécution reprenant notamment la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l'échange d'informations entre les registres dans le cadre notamment de la transmission du certificat préalable à la scission[3198], ce qui pourrait en tout état de cause permettre de se rapprocher de l'introduction d'un formulaire standard pour le certificat préalable[3199].

650. La langue du certificat. Contrairement aux souhaits exprimés en ce sens[3200], la Directive Mobilité ne prévoit malheureusement pas que le certificat pourra être établi dans une « langue usuelle dans le domaine des affaires et de la finance internationale » et ce, ni à l'égard des fusions transfrontalières[3201], ni à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[3202]. Ceci aura pour conséquence que les différents certificats devront, le cas échéant, faire l'objet d'une traduction dans une des langues

J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 6 ; R. Frenzel, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 381 ; D. Haritz et B. von Wolff, *op. cit.*, p. 344 ; St. Klein, *op. cit.*, p. 813 ; J. Schmidt, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 252 ; J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25 ; S. Stiegler, « Zehn Jahre Internationale Verschmelzungsrichtlinie – Erreichtes, Stand und Perspektiven », *GmbHR*, 2016, p. 413 et N. Zimmermann in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 15. En faveur de la conformité du régime allemand à la Directive Sociétés, voir : S. Kulenkamp, *op. cit.*, pp. 281 et 282.

3196 W. Bayer et J. Schmidt, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *op. cit.*, p. 843 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *ibidem*, § 122k, n° 6.

3197 Voir en ce sens : St. Reynolds, A. Scherrer et E. Truli, *op. cit.*, p. 47 ; J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243 et J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25.

3198 Art. 24, al. 1er, e *bis* et al. 3 et art. 160*quindecies* de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité et la Directive Outils Numériques.

3199 Voir en ce sens : J. Schmidt, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 573 et J. Schmidt, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2019/20 », *BB*, 34/2020, p. 1796.

3200 Voir en ce sens : J. Schmidt, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 24.

3201 Art. 127 de la Directive Mobilité.

3202 Art. 160*quaterdecies* de la Directive Mobilité.

nationales de l'autorité en charge du second contrôle avant de pouvoir être remis à cette dernière[3203]. Compte tenu du nombre potentiellement important d'entités susceptibles d'être impliquées dans une scission transfrontalière par absorption, une telle flexibilité aurait indéniablement été dans le sens d'une simplification de la procédure combinée à une réduction de coûts. Compte tenu du caractère politiquement délicat de la question qui a été démontré à suffisance dans le cadre de l'étude de la question de la langue du projet de scission[3204], il est peu probable que cette solution voit le jour lors de l'introduction d'un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. Cependant, si un formulaire standard devait être prévu en sus du certificat, il serait vraisemblablement plus aisé de prévoir que celui-ci pourra être en anglais.

651. Le contenu du certificat. Ni le Règlement sur la Société européenne, ni la Directive Sociétés, ni encore la Directive Mobilité ne contient de liste de mentions qui doivent en principe se retrouver dans le certificat. On peut toutefois conclure de l'objectif poursuivi par ce document qu'il devra à tout le moins contenir une indication relative au respect des conditions imposées par le droit national applicable et de l'accomplissement des procédures et formalités pertinentes ainsi que, selon certains auteurs[3205], une motivation de la décision de conformité. Les autres mentions éventuellement nécessaires dépendront du prescrit du droit national applicable au premier contrôle. Afin de remédier à ces insuffisances, il a été proposé de mettre en place un formulaire standard de certificat[3206], ou, à tout le moins, d'en préciser le contenu[3207], ce qui aurait indéniablement pu présenter un intérêt dans l'hypothèse de scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

652. Le délai de transmission du certificat. Compte tenu du fait que la situation tant juridique qu'économique des entités impliquées dans l'opération n'est pas figée dans le temps[3208], tant le régime de la société européenne[3209] que celui de la Directive Sociétés en matière de fusions transfrontalières[3210] prévoyaient que le certificat de légalité devait être remis à l'autorité en charge du contrôle de légalité dans les six mois de sa délivrance. À l'égard des fusions transfrontalières, il est intéressant de relever à ce sujet qu'il s'agissait là d'un délai fixe qui ne pouvait être réduit ou allongé par les États membres au moment de la transposition[3211]. Le calcul de celui-ci relevait du droit applicable à l'autorité en charge du second contrôle puisque c'est à elle qu'incombe la vérification de la validité des certificats[3212]. *A contrario*, la Directive Mobilité a entendu supprimer

3203 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 414.
3204 À ce sujet, voir *supra* n°s 433 à 437.
3205 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 843 et Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 6.
3206 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 47 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 252 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25.
3207 R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 381.
3208 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 206.
3209 Art. 26, § 2 du Règlement sur la Société européenne.
3210 Art. 128, § 2 de la Directive Sociétés.
3211 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 206.
3212 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 207.

toute indication expresse relative à un délai de transmission du certificat du régime des fusions transfrontalières et n'en a pas davantage introduit à l'égard du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés. Cette suppression peut s'expliquer notamment par le fait que la transmission du certificat préalable se fera dorénavant au moyen du système d'interconnexion des registres[3213] qui entraîne en principe l'application d'un délai de 21 jours pour transcrire au registre et publier l'information concernée[3214]. Ce mode spécifique de communication et le délai particulièrement court pour ce faire sont parfaitement compatibles avec une scission transfrontalière par absorption qui se caractérise, par définition, par une pluralité de sociétés bénéficiaires et qui implique, à supposer que l'autorité nationale de l'État membre de la société scindée soit compétente pour effectuer le second contrôle, que plusieurs certificats devront être établis.

653. Un document essentiel en cas de scission transfrontalière. Les certificats de conformité constituent un élément clé de la procédure[3215] puisque ce sont eux qui font le lien entre le premier et le second contrôle. Ils seront par conséquent également inéluctables en cas de scission transfrontalière. L'exigence d'un tel certificat plaide par ailleurs en faveur d'un second contrôle réalisé par l'autorité dont relève la société scindée. En effet, si on devait confier le contrôle à l'autorité supervisant les sociétés bénéficiaires, comme en cas de fusion, on se retrouverait devant la nécessité de dupliquer le certificat afin que chaque autorité nationale des sociétés nouvelles ou absorbantes puisse remplir sa mission de contrôle. Outre la perte de l'effet centralisateur du second contrôle, une telle situation entraînerait immanquablement des difficultés pratiques en raison des traductions à fournir et de l'absence d'harmonisation du contenu du certificat.

3. *Le refus de délivrance du certificat en dehors de la disposition anti-abus*

654. Le principe. Selon le régime applicable aux scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés en vertu de la Directive Mobilité[3216], l'autorité nationale en charge du contrôle considère que (i) l'opération envisagée ne remplit pas toutes les conditions applicables ou (ii) toutes les procédures et formalités nécessaires n'ont pas été observées et que la société, après y avoir, le cas échéant, été invitée par l'autorité nationale, n'a pas rectifié les insuffisances, elle refusera d'émettre le certificat.

655. L'incidence de la liberté d'établissement. De prime abord, cette disposition semble cohérente, mais lue en conjonction avec les dispositions relatives au champ d'application limité de la Directive Mobilité, elle est susceptible

3213 Art. 127*bis* (fusions transfrontalières) et 160*quindecies* (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité et en ce sens : J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243.

3214 Art. 15, § 1er de la Directive Mobilité et en ce sens : R. Knaier, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 616 ; J. Schmidt, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 251 et J. Schmidt, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243.

3215 D. Beutel, *op. cit.*, p. 200 et J. Mitterecker, *op. cit.*, p. 399.

3216 Art. 160*quaterdecies*, § 7, b) de la Directive Mobilité.

d'être problématique à l'aune de la liberté d'établissement telle qu'interprétée par la Cour de justice. En effet, si on prend l'exemple d'une scission transfrontalière par absorption dans laquelle la société scindée est soumise au droit d'un État membre qui connaît ce type d'opération en interne mais s'est limité à une transposition stricte de la Directive Mobilité qui ne couvre que les scissions par constitution de nouvelles sociétés, l'autorité nationale en charge du contrôle de conformité devrait normalement refuser catégoriquement d'émettre un certificat préalable au motif que l'opération envisagée ne rentre pas dans le champ d'application de la mesure de transposition nationale de la Directive Mobilité. Or, une telle décision violerait le principe de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes[3217]. L'exclusion explicite des scissions par absorption du champ d'application de la Directive Mobilité ne sera en outre d'aucun secours puisqu'il est de jurisprudence constante que l'existence de règles d'harmonisation ne constitue pas une condition préalable pour la mise en œuvre de la liberté d'établissement[3218]. Une telle entrave à la liberté d'établissement ne pourra de plus n'être que très difficilement justifiée puisque la Cour de justice a déjà établi qu'un refus général d'une autorité nationale d'inscrire une fusion transfrontalière au registre de commerce ne remplissait pas le critère de proportionnalité du « *Gebhard test* »[3219]. En d'autres termes, cette disposition ne manquera pas de constituer une source de problèmes justifiant une nouvelle initiative européenne à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante et il est difficilement concevable que ce point ait échappé à la vigilance de la Commission. *A contrario*, un arrêt de la Cour de justice à cet égard, qui ne serait par ailleurs pas sans rappeler les faits à la base de l'arrêt *Sevic*, justifierait aisément une nouvelle initiative législative à l'égard des scissions transfrontalières.

§ 3. La communication du certificat

656. Communication à l'ère numérique. Selon le régime de la Directive Mobilité, en cas d'issue positive au contrôle de conformité, le certificat préalable sera partagé avec les autorités nationales en charge du contrôle de légalité au moyen du système d'interconnexion des registres[3220], étant entendu que le certificat préalable devra être disponible au moyen du système d'interconnexion des registres et que l'accès à celui-ci devrait être gratuit tant pour les autorités en charge du contrôle de légalité que pour les registres. Un tel régime de communication, dont on peut s'attendre à ce qu'il permette de réduire la durée de la procédure de restructuration[3221], est parfaitement compatible avec l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, à ceci près que, comme indiqué précédemment, l'autorité en charge du contrôle de légalité devrait être celle de l'État membre de la société scindée.

3217 Arrêt *Polbud*, pt. 43 ; arrêt *Vale*, pt. 32 et arrêt *Cartesio*, pts. 109 à 112.
3218 Arrêt *Vale*, pt. 38 et arrêt *Sevic*, pt. 26.
3219 Arrêt *Sevic*, pt. 30.
3220 À ce sujet, voir *supra* n° 596.
3221 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 616.

§4. Le second contrôle ou contrôle de légalité

A. *L'objet du contrôle*

657. Une volonté claire du législateur européen. Selon le texte de la Directive Mobilité, qui s'aligne à cet égard sur le prescrit de la Directive Sociétés[3222], le second contrôle en cas de scission transfrontalière porte plus spécifiquement sur la « réalisation » de l'opération[3223]. Sur ce point, on pourrait se demander, si le terme « réalisation » doit être entendu de manière large, c'est-à-dire comme comprenant l'ensemble du processus, et donc aussi tout ce qui fait l'objet du premier contrôle, ou si, au contraire, il doit être entendu de manière restrictive afin d'éviter tout recoupement des objets respectifs des deux contrôles. Tant à l'égard des fusions transfrontalières que des scissions transfrontalières, il conviendra indiscutablement de retenir l'interprétation restrictive[3224]. Cela se voit tout d'abord au fait que le soixantième considérant de la Directive Sociétés précise que les deux contrôles portent sur des parties différentes de la procédure[3225], mais également au choix des termes dans la Directive Mobilité qui établissent que le certificat préalable est une « preuve concluante de l'accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la scission »[3226]. Cette approche est en outre plus conforme à l'interprétation du principe d'effectivité faite par la Cour de justice dans l'arrêt *Vale* en matière de transformations transfrontalières et qui impose à l'État membre d'accueil de « tenir dûment compte, lors de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une société, des documents émanant des autorités de l'État membre d'origine attestant que cette société s'est effectivement conformée aux conditions de celui-ci, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit de l'Union »[3227].

658. La réalisation de l'opération. Le deuxième contrôle portera ainsi tout d'abord sur les aspects purement transfrontaliers de l'opération, comme par exemple, la vérification que les entités impliquées ont bien approuvé le projet commun dans les mêmes termes. Ce premier objet se justifie au vu du fait que le projet commun sera en principe rédigé dans plusieurs langues nationales[3228] et implique par ailleurs que les parties aient l'obligation de remettre à l'autorité en charge du second contrôle une version du projet commun tel qu'approuvé par l'assemblée générale[3229], accompagnée, le cas échéant, d'une version dans une des langues reconnues par l'autorité en charge du second contrôle. En cas de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, selon le

3222 Art. 128, § 1er de la Directive Sociétés.
3223 Art. 160*sexdecies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
3224 À propos des fusions transfrontalières : D. Beutel, *op. cit.*, p. 203 ; Fl. Drinhausen in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 122l, n° 10 et R. Frenzel, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 384. À propos de la société européenne : M. Scheifele, *op. cit.*, p. 203.
3225 D. Beutel, *op. cit.*, p. 202.
3226 Art. 160*sexdecies*, § 5 de la Directive Mobilité.
3227 Arrêt *Vale*, pt. 61 et à ce sujet, voir *supra* n° 208.
3228 Sur la question de la langue du projet commun de scission, voir *supra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Section 3, § 6.
3229 Art. 160*sexdecies*, § 2 de la Directive Mobilité.

texte de la Directive Mobilité, le contrôle de légalité portera également sur les aspects qui concernent le fonctionnement des nouvelles sociétés, comme les modalités relatives à la participation des travailleurs[3230] ou encore le respect des dispositions relatives à la constitution et l'immatriculation des nouvelles sociétés[3231]. Cependant, si le contrôle de légalité devait être réalisé dans l'État membre de la société scindée comme suggéré ci-dessus, ces différents aspects de l'opération seront vérifiés lors du contrôle de conformité.

659. Des pratiques divergentes au sein des États membres. Cette distinction ne semble toutefois pas claire en pratique et il s'avère que certaines autorités nationales en charge du second contrôle de légalité vérifient si toutes les entités impliquées ont bien respecté le prescrit du droit national de l'autorité en question[3232], violant par là même le principe de l'application subsidiaire du droit national adopté dans la Directive Sociétés[3233] et qu'on retrouve également dans la Directive Mobilité[3234]. Par conséquent, on ne peut que relever que si on devait suivre la suggestion du législateur européen qui vise à instaurer autant de contrôles de légalité qu'il y aura de sociétés issues de l'opération[3235], ces problèmes, qui ne disparaîtront certainement pas avec la Directive Mobilité s'en trouveraient décuplés. Par conséquent, d'un pur point de vue pragmatique, il convient de restreindre ce risque au minimum en veillant à ce que le second contrôle de légalité soit accompli par une autorité unique, à savoir celle de l'État membre de la société scindée.

B. *Les délais applicables*

660. Une formulation imprécise. Contrairement à ce qui est le cas à l'égard du contrôle de conformité[3236], le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité ne contient pas d'indication précise du délai applicable à l'accomplissement du contrôle de légalité. La seule précision à cet égard est que l'autorité nationale compétente se doit d'approuver l'opération « dès qu'elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l'État membre de destination ont été correctement accomplies »[3237]. Une telle formulation laissant *de facto* une large marge d'appréciation à l'autorité nationale est regrettable car elle va empêcher les parties d'évaluer précisément la durée de la procédure. Ce point est encore aggravé par le fait que dans l'esprit du législateur européen, ce contrôle de légalité devra être effectué au sein de l'État membre de chacune des nouvelles sociétés créées dans l'opération[3238]. Afin de réduire ce risque, ainsi que d'éluder la situation peu confortable où

3230 Art. 128, § 1er, *in fine* de la Directive Sociétés.
3231 Art. 128, § 1er, *in initio* de la Directive Sociétés.
3232 J. SCHMIDT, *op. cit.*, p. 25 ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 49.
3233 Art. 121, § 1er, b) de la Directive Sociétés.
3234 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.
3235 Art. 160*sexdecies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
3236 À ce sujet, voir *supra* nos 642 à 655.
3237 Art. 160*sexdecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
3238 Art. 160*sexdecies*, § 1er de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *supra* n° 641.

le contrôle de légalité serait accompli très rapidement dans l'État membre d'une des sociétés bénéficiaires et mettrait beaucoup plus de temps dans l'État membre de l'autre société bénéficiaire, il serait, à nouveau, préférable qu'un contrôle de légalité unique soit confié à l'autorité nationale compétente de l'État membre de la société scindée.

§5. Les autorités nationales compétentes

661. Un libre choix. La Directive Sociétés avait fait le choix de laisser une grande latitude aux États membres en ce qui concerne le choix de l'autorité nationale compétente tant pour effectuer le premier que le second contrôle. Cette absence de précision a engendré une forte disparité, même si les États membres ont en majorité opté pour le choix des registres de commerce[3239], alors que les notaires, malgré leurs moyens plus limités par rapport à une autorité judiciaire[3240], semblent avoir les faveurs des praticiens et des acteurs économiques en raison de leur disponibilité, de leur coût réduit et de leur flexibilité[3241]. En vue de simplifier la procédure, il avait été proposé de confier le contrôle exclusivement aux registres de commerce[3242], ce qui suite à la mise en place du système d'interconnexion des registres et à la volonté avérée de la Commission européenne de promouvoir l'utilisation de moyens digitaux pour simplifier les procédures relevant du droit des sociétés dans le cadre de la mise en place du marché unique numérique[3243] aurait pu se justifier dans une certaine mesure. Cependant, la Directive Mobilité a préféré laisser le choix de l'autorité compétente aux États membres, ce qui se justifie au vu des importantes disparités nationales existant en la matière, même si on ne peut que relever que certaines missions incombant à l'autorité compétente dans le cadre du premier contrôle en matière de lutte anti-abus ne sont que bien peu compatibles avec les missions traditionnellement dévolues à un notaire[3244]. Il est toutefois peu probable que cet aspect soit altéré lors d'une prochaine initiative européenne à l'égard des scissions transfrontalières.

3239 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale, 11 États membres (la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, Malte, la Norvège, le Portugal, la Roumanie et la Suède) ont opté pour le registre de commerce, 9 (l'Allemagne, l'Autriche, Chypre, la France, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne, le Royaume-Uni et la Slovénie) pour un tribunal, 7 (la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la République tchèque et la Slovaquie) pour un notaire et 3 (le Danemark, la Grèce et le Liechtenstein) pour un autre type d'autorité. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 82.

3240 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, pp. 70 et 71 et S. Maquet, *op. cit.*, p. 48.

3241 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 83.

3242 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 84.

3243 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions of April 25, 2018, Explanatory Memorandum, COM(2018) 241 final, http://eur-lex.europa.eu (04/05/2018), p. 10.

3244 À ce sujet, voir *supra* n° 369.

SECTION 9. IMMATRICULATION ET PRISE D'EFFET

662. Plan de la section 9. Ultime étape du processus de scission transfrontalière, l'immatriculation et la prise d'effet de l'opération n'en revêtent pas moins une importance considérable. Les aborder dans l'optique de l'élaboration d'un régime qui soit compatible avec tout type de scission transfrontalière implique en premier lieu de se prononcer sur la compatibilité du régime figurant actuellement dans la Directive Mobilité (§ 1), pour ensuite s'intéresser au fonctionnement des notifications entre registres (§ 2) et, en définitive, de répondre à la délicate question de la date de prise d'effet de l'opération (§ 3).

§1. Un régime compatible

663. Une règle de droit international privé simple. Tout comme à l'égard des fusions transfrontalières[3245], la Directive Mobilité pose comme règle de droit international privé que les modalités de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière seront déterminées distributivement par les différents droits nationaux en présence[3246]. Une telle approche est parfaitement compatible avec l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante et n'appelle pas de commentaire particulier.

664. Les informations à publier. Selon la Directive Mobilité, les informations essentielles sur l'opération et les entités impliquées devront à la fois être inscrites dans les registres nationaux concernés et être disponibles via le système d'interconnexion des registres[3247]. En comparant les différentes mentions imposées par la Directive Mobilité aux scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés avec celles applicables aux fusions transfrontalières[3248], on constate que celles-ci sont parfaitement compatibles avec une opération de scission par absorption ou mixte. En effet, dans de telles hypothèses, le registre de l'État membre de chacune de ces sociétés bénéficiaires préexistantes devra reprendre le numéro d'immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société scindée et des sociétés bénéficiaires.

§2. Les notifications entre registres

665. Une modification nécessaire. Suite aux insuffisances manifestes des communications entre registres en cas de fusion transfrontalière mises en lumière par l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale[3249] et conformément à l'objectif de la Commission européenne de mettre en place un marché unique numérique[3250], la

3245 Art. 130, § 1er de la Directive Mobilité.
3246 Art. 160*septdecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
3247 Art. 160*septdecies*, § 2 de la Directive Mobilité.
3248 Art. 130, § 2 de la Directive Mobilité.
3249 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 60 à 64 et à ce sujet, voir : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 24.
3250 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 12 et Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 octobre 2015, Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, COM(2015) 550 final, http://eur-lex.europa.eu (04/05/2018), pp. 5–8.

Directive Mobilité intègre un certain nombre de dispositions destinées à encadrer plus précisément cette étape de la procédure. Selon le texte de la Directive Mobilité, les registres des États membres des sociétés bénéficiaires seront ainsi dans l'obligation de notifier le fait que les sociétés bénéficiaires ont bien été immatriculées au moyen du système d'interconnexion des registres au registre de l'État membre de la société scindée. Les États membres devront en outre veiller à ce qu'en cas de scission complète la suppression ou la radiation du registre de la société scindée prenne effet immédiatement dès la réception de ces notifications[3251]. Le registre de l'État membre de la société scindée devra ensuite notifier aux registres des États membres des sociétés bénéficiaires que la scission transfrontalière a pris effet[3252]. Comme il a été défendu que la procédure de scission transfrontalière gagnerait en cohérence si le contrôle de légalité était confié à l'autorité compétente de la société scindée, cette disposition devra faire l'objet de certaines modifications. Ainsi, l'immatriculation des sociétés bénéficiaires ne devra plus faire l'objet d'une notification séparée puisque les formalités relatives à la constitution de ces dernières seront déjà couvertes par le certificat préalable[3253]. Seule la radiation de la société scindée et la prise d'effet de l'opération[3254] devront être notifiées par le registre de la société scindée aux registres des sociétés bénéficiaires, ce qui correspondrait en outre davantage au régime des fusions transfrontalières où seule la société dont le droit national détermine la prise d'effet de l'opération notifie celle-ci aux registres des sociétés apporteuses[3255]. Une telle modification serait particulièrement compatible avec un régime des scissions transfrontalières par absorption puisque dans une telle hypothèse, il ne sera, par définition, pas nécessaire de notifier l'immatriculation de nouvelles sociétés.

§ 3. La date de prise d'effet de l'opération

666. Une absence d'harmonisation. La Directive Sociétés s'en est explicitement remise aux États membres en ce qui concerne la détermination de la date de prise d'effet d'une scission interne[3256]. Il n'est dès lors pas surprenant de constater qu'il en est résulté une certaine diversité. Ainsi, en droit autrichien[3257], une scission interne prendra effet lors de l'inscription de la scission au registre des entreprises (*Firmenbuch*). En droit allemand, ce sera la date d'enregistrement de l'opération au registre du siège de la société scindée[3258], alors qu'en droit belge, ce sera la date à laquelle seront intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés concernées en cas de scission par absorption[3259] et la date à laquelle toutes les nouvelles sociétés sont constituées en cas de scission

3251 Art. 160*septdecies*, § 3 de la Directive Mobilité.
3252 Art. 160*septdecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
3253 À ce sujet, voir *infra* n°s 666 et 667.
3254 Art. 160*septdecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
3255 Art. 130, § 3 de la Directive Mobilité.
3256 Art. 149 de la Directive Sociétés.
3257 §§ 14(2) et 17 SpaltG et à ce sujet, voir S. Kalss in S. Kalss (dir.), *op. cit.*, pp. 1042 à 1071, n°s 13 à 91.
3258 §§ 131(1) et 137 UmwG, même si le contrat de scission est déjà valable *inter partes* dès l'approbation par les assemblées générales respectives. À ce sujet, voir M. Sickinger in H. Kallmeyer (dir.), *op. cit.*, § 131, n° 1 et N. Leonard in J. Semler, A. Stengel et N. Leonard (dir.), *op. cit.*, § 131, n°s 1 à 4.
3259 Art. 12:69, al. 2 du CSA.

par constitution de nouvelles sociétés[3260]. En droit luxembourgeois, la scission sera réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause[3261]. En droit français, la scission prendra effet, en cas de création d'une ou de plusieurs nouvelles sociétés, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles[3262] et, dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat de scission prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société scindée[3263].

667. La réponse de la Directive Mobilité. Contrairement au législateur luxembourgeois qui ne traite pas explicitement de la question de la date de prise d'effet d'une scission transfrontalière et au législateur belge qui a fait le choix surprenant de préciser que la date de prise d'effet de la scission transfrontalière serait déterminée par le droit national applicable aux sociétés bénéficiaires[3264], le législateur européen a fait le choix, face à l'obstacle majeur que risque de constituer le potentiel conflit entre les différents droits nationaux au sujet de la date de prise d'effet de la scission[3265], de prévoir que la date à laquelle la scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés prendrait effet serait déterminée par le droit de l'État membre de la société scindée. Cette règle de conflit de lois est complétée par une règle de droit matériel[3266] précisant que la date de prise d'effet devra nécessairement être postérieure à l'exécution des contrôles de légalité[3267]. Si on compare cette solution à celle qui prévaut en matière de fusions transfrontalières[3268], on constate que dans ce dernier cas, le législateur européen a fait le choix de prévoir que ce serait la législation de l'État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière qui déterminerait la date de prise d'effet. Si ces deux solutions paraissent *a priori* contradictoires, elles procèdent néanmoins de la même logique, à savoir la nécessité d'une date de prise d'effet unique pour l'opération, quel que soit le nombre de sociétés impliquées. En conséquence, comme une scission transfrontalière se caractérise fondamentalement par une unicité de société scindée, il est logique de faire dépendre la date de prise d'effet de l'opération de ce seul droit national[3269].

3260 Art. 12:86 du CSA.
3261 Art. 1031-14 et 1032-1, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3262 Art. L 236-4, 1° du Code de commerce français.
3263 Art. L 236-4, 2° du Code de commerce français.
3264 Art. 12:73, § 5 (scission par absorption) et 12:90, § 5 (scission par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.
3265 Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 61, n° 9 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 420.
3266 Voir en ce sens : Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 6 et 7.
3267 À ce sujet, voir *supra* n° 658.
3268 Art. 129 de la Directive Sociétés. Sur le caractère rudimentaire de cette règle, voir : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122l, n° 23.
3269 Voir : Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1909 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 147 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 268 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 280 qui considère à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés qu'il s'agit là de la seule solution sensée.

Chapitre 2
Le régime des nullités des scissions transfrontalières

668. Un régime parfaitement transposable. Alors que les scissions internes[3270], tout comme les fusions internes[3271], sont régies par un principe de limitation des cas de nullités[3272] combiné à une régularisation dès que possible, la Directive Mobilité, s'inspirant en cela des régimes des fusions transfrontalières[3273] et de la société européenne[3274], prévoit explicitement qu'une scission transfrontalière ayant pris effet ne pourra être déclarée nulle et non avenue[3275]. De manière assez intéressante, le motif avancé comme justification de ces trois régimes est celui de la sécurité juridique[3276]. Il convient donc d'en conclure que la nature plus stricte de celui des fusions transfrontalières est intimement liée à la nature internationale de ce type d'opérations et à la présence du double contrôle de légalité qui limite les cas d'opérations lacunaires ou frauduleuses[3277]. En tout état de cause, il est indéniable que cette disposition va dans le sens d'une plus grande sécurité juridique à l'égard des associés et autres *stakeholders*[3278]. En outre, d'un point de vue purement pragmatique, elle est inéluctable dans la mesure où une fusion transfrontalière demeure une opération complexe dont l'annulation *ex nunc* ou *ex tunc* s'avérerait pratiquement impossible à réaliser en pratique[3279], *a fortiori* si on ajoute à cela que la détermination des cas de nullité d'une opération transfrontalière requiert en principe un traitement unitaire[3280]. Il n'est dès lors pas surprenant de constater que le législateur européen ait consacré le même principe à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés dans la Directive Mobilité[3281]. Il est certes vrai que cette disposition ne manquera pas de soulever certaines interrogations en pratique, notamment à l'égard du sort d'une scission transfrontalière qui aurait fait l'objet d'une inscription au registre de l'État membre en charge du contrôle de légalité en l'absence d'un certificat de conformité[3282], *a fortiori* si on combine cela avec le commentaire de l'article 160*quatervicies* de la Proposition de la Commission qui indique clairement que cette validité incontestable ne vaudra que « si la procédure de scission transfrontalière a été respectée »[3283]. Il n'en demeure toutefois pas moins que si on prend en considération le fait que

3270 73e considérant et art. 153 de la Directive Sociétés. Sur le régime des nullités d'une scission interne en droit belge, voir G. HORSMANS, *op. cit.*, pp. 215 à 261 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, pp. 383 à 413, n° 562 à 614.

3271 54e considérant de la Directive Sociétés.

3272 Selon l'art. 153, § 1er, b) de la Directive Sociétés, la nullité d'une scission qui a pris effet « ne peut être prononcée si ce n'est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d'acte authentique, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national ».

3273 Art. 134 de la Directive Sociétés et en ce sens : M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 24, n° 49 et O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 147.

3274 Art. 30, § 1er du Règlement sur la Société européenne et à ce sujet : J. RICKFORD, *op. cit.*, p. 1410.

3275 Art. 160*duovicies*, al. 1er de la Directive Mobilité.

3276 54e, 61e et 73e considérants de la Directive Sociétés.

3277 D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 589, n° 36.

3278 61e considérant de la Directive Sociétés et S. MAQUET, *op. cit.*, p. 34 ; G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 17, n° 65 et P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 75, n° 90. Voir également en ce sens au sujet du régime de nullité des scissions internes : R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 140 et Th. TILQUIN, *op. cit.*, p. 383, n° 562.

3279 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122l, n° 26 et D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 220.

3280 Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, *op. cit.*, p. 46.

3281 Ar. 160*duovicies*, al. 1er de la Directive Mobilité.

3282 Sur cette problématique, voir O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 147.

3283 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 34.

selon les dires mêmes du législateur européen, les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante constituent des opérations particulièrement complexes emportant des risques additionnels pour les *stakeholders*[3284], il devrait indubitablement en aller de même pour ce type d'opérations. La règle posée par la Directive Mobilité est donc parfaitement compatible avec les spécificités des scissions par absorption et des scissions mixtes.

669. L'incidence du champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité. Si on peut aisément avancer que la solution consacrée par la Directive Mobilité est sensée[3285] et constitue la contrepartie de l'introduction d'un régime harmonisé de protection des associés minoritaires[3286], on ne peut que relever que le champ d'application foncièrement limité de la Directive Mobilité ne manquera pas d'être source d'incohérences en pratique. En effet, la Directive Sociétés a posé comme principe en matière de scissions internes que la nullité de ces dernières pouvait être prononcée pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif, soit d'acte authentique, ou encore s'il est établi que la décision de l'assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national[3287]. Ainsi, à titre d'illustration, en droit belge, il est expressément prévu que la nullité d'une scission puisse être prononcée (i) si le montant maximum de la soulte en espèces est dépassé[3288], (ii) lorsque les décisions des assemblées générales ou des organes de gestion ayant approuvé l'opération n'ont pas été constatées par acte authentique[3289], (iii) lorsque ces décisions ont été prises en l'absence des rapports de l'organe d'administration, du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe[3290] ou encore (iv) lorsque les décisions en question sont entachées d'une autre cause de nullité[3291]. De manière plus restreinte, en droit luxembourgeois, la nullité de la scission ne pourra être prononcée que pour défaut d'acte notarié ou, le cas échéant, d'acte sous seing privé, ou encore s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou l'autre assemblée générale est nulle[3292]. Or, selon le principe de non-discrimination des opérations internes par rapport aux opérations transfrontalières posé par la Cour de justice dès l'arrêt *Sevic*[3293], si une opération est permise dans l'ordre interne, elle ne peut être prohibée *ab initio* dans un contexte transfrontalier. Il s'ensuit qu'une scission transfrontalière par absorption ou mixte est en principe déjà possible pour peu que les dispositions de la Directive Sociétés en matière de scissions internes aient bien été transposées, à ceci près qu'en l'absence de norme spécifique à ce sujet, elle ne bénéficiera

3284 38e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1, Section 2, § 3, B.

3285 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 259 et 268 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2443.

3286 Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 292.

3287 Art. 153, § 1er, b) de la Directive Sociétés.

3288 Art. 12:19, al. 1er du CSA. Sur la problématique de la soulte en espèces, voir *supra* n° 454. Pour un point de vue sceptique de la conformité de cette disposition aux dispositions de la Sixième Directive, voir : G. HORSMANS, *op. cit.*, p. 231, n° 30.

3289 Art. 12:20, al. 1er du CSA.

3290 *Ibidem*.

3291 *Ibidem*.

3292 Art. 1031-18, 2° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3293 À ce sujet, voir *supra* n° 153.

pas du régime de stabilité accrue posé par le législateur européen. Une telle différence de traitement apparaît comme foncièrement contradictoire puisque ce sont justement les opérations qui présentent le plus de risque pour les *stakeholders* qui ne bénéficient pas d'un régime de nullité très strict, pourtant justement destiné à renforcer la sécurité juridique de l'opération en question à l'égard des *stakeholders*. Cette différence de traitement difficilement conciliable avec la logique ayant prévalu à l'égard des fusions transfrontalières, pourrait aisément servir à justifier une nouvelle initiative de la Commission à l'égard de des scissions impliquant plus d'une société préexistante.

670. Un pouvoir de sanction résiduel. Si la disposition de la Proposition de la Commission[3294] relative au régime de nullité n'a été altérée ni par le Premier Compromis de la Présidence[3295], ni par le Deuxième Compromis de la Présidence[3296], ni par le Compromis des Représentants Permanents[3297], et que la suggestion de la Commission des affaires juridiques qui visait à introduire la possibilité pour l'autorité compétente de prendre des sanctions effectives en cas de montage artificiel découvert par le biais de nouvelles informations dans les deux années suivant la prise d'effet de la scission transfrontalière[3298] n'a pas été reprise, vraisemblablement en raison de l'abandon de la notion de « montage artificiel » dès le Premier Compromis de la Présidence[3299], le Compromis Final est venu préciser que la stabilité d'une scission transfrontalière n'affectait pas « les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l'application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la scission transfrontalière a pris effet ». Cette précision rejoint à tout le moins en partie l'interprétation de la disposition de la Directive Sociétés régissant les nullités des fusions transfrontalières avant l'avènement de la Directive Mobilité[3300] et qui considérait que rien dans son texte ne faisait obstacle à la mise en place par les États membres d'un système de responsabilité approprié des associés fautifs entraînant le paiement de dommages et intérêts[3301]. Cette disposition destinée également à lutter contre d'éventuels comportements abusifs ou fautifs va toutefois plus loin dans la mesure où elle laisse sous-entendre qu'une sanction consistant en l'annulation de l'opération demeurerait possible dans certaines circonstances particulières[3302]. La question de savoir si cette exception

3294 Art. 160*quatervicies* de la Proposition de la Commission.
3295 Art. 160w du Premier Compromis de la Présidence.
3296 Art. 160w du Deuxième Compromis de la Présidence.
3297 Art. 160w du Compromis des Représentants Permanents.
3298 Voir l'amendement 338 de l'Avis CAJ qui visait à introduire la disposition suivante : « 1*bis*. Toutefois, si, au cours des deux années suivant la prise d'effet de la scission transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite scission, suggérant une infraction d'une des dispositions de la présente directive, sont portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières révisent leur évaluation des faits en l'espèce et sont habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels ».
3299 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1, Section 2, § 4, C.
3300 Art. 134 de la Directive Sociétés.
3301 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 220 et M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 121. Au sujet de l'art. 30 du Règlement sur la Société européenne, voir : M. SCHEIFELE, *op. cit.*, p. 300.
3302 Voir en ce sens : Fr. SCHURR, *op. cit.*, p. 543.

fait suite à une véritable nécessité[3303] ou, au contraire, ne constitue que le prix de l'adhésion de certains États membres plus sceptiques envers la mobilité transfrontalière des personnes morales[3304] peut être longuement débattue, mais il n'en demeure pas moins qu'une telle mesure est parfaitement compatible avec les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante et qu'elle est même de nature rassurer certains États membres potentiellement plus méfiants à leur égard.

3303 *Ibidem*.

3304 Sur la nécessité de tels mécanismes anti-abus pour emporter l'adhésion politique au niveau du Conseil et du Parlement, voir P.-H. CONAC, « Le retour du courage politique à Bruxelles : l'Odyssée du "Paquet droit des sociétés" de 2018 », *op. cit.*, p. 8.

Chapitre 3
Les opérations simplifiées

SECTION 1. PRÉSENTATION

671. Un enjeu non-négligeable. Si dans l'absolu, les scissions transfrontalières sont susceptibles d'avoir un impact considérable sur les différents *stakeholders*, certaines opérations seront par nature plus inoffensives. À titre d'illustration, il est évident que dans l'hypothèse d'une « *scission partielle silencieuse* »[3305], c'est-à-dire l'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine à une société bénéficiaire qui est déjà titulaire de toutes ses actions sans émission de nouvelles actions, les risques de dilution sont inexistants pour les associés minoritaires de la société bénéficiaire. Il en découle que dans de telles hypothèses, il serait judicieux en vue, d'une part, de réduire les coûts et, d'autre part, d'accélérer le processus, de simplifier la procédure de scission transfrontalière. Il est également utile de préciser que l'enjeu de cette question est loin d'être négligeable puisque l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale a permis de démontrer que les fusions transfrontalières étaient principalement utilisées en vue de procéder à des réorganisations intragroupes[3306] et que la procédure simplifiée s'était avérée particulièrement importante à cet égard[3307]. Compte tenu du fort lien de parenté entre les fusions et les scissions[3308], il y a de fortes chances que le même constat s'impose à l'égard de ces dernières de sorte qu'il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante devrait intégrer es dispositions spécifiques à leur égard. Pour ce faire, il est opportun de commencer par étudier la position du législateur européen adoptée à cet égard dans le cadre (i) des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, (ii) des fusions transfrontalières et (iii) des scissions internes (section 2), pour se pencher ensuite sur la position adoptée par les législateurs belges et luxembourgeois dans leurs régimes respectifs des scissions transfrontalières (section 3). Une fois ces différentes étapes réalisées, il sera possible d'esquisser les contours d'un futur régime des scissions transfrontalières simplifiées (section 4).

3305 Art. 12:8, 2° du CSA. Sur cette notion en droit belge, voir : S. MAQUET et D. WILLERMAIN, *op. cit.*, pp. 463–465, n° 11 et D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, pp. 331 et 332, n° 9. Voir également à ce sujet : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 300.

3306 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale et sur la base de nombres très conservateurs, au moins 38 % des fusions transfrontalières étudiées avaient pour objectif premier de réaliser une réorganisation intragroupe. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 49.

3307 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 40 et en ce sens : Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 243 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 61.

3308 Voir en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 1 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 414 ; H. LAMON, *op. cit.*, p. 125 et Th. PRÜM, *ibidem*, p. 16 ; A. REIK, *op. cit.*, p. 300 ; E. ROELOFS, *op. cit.*, p. 347 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 6, n° 9 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 27 et Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 13.

SECTION 2. LA POSITION DU LÉGISLATEUR EUROPÉEN

§1. Le régime des scissions transfrontalières

672. Le régime particulier des scissions par séparation. Suite à l'introduction des scissions par séparation[3309] dans le champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité lors du Premier Compromis de la Présidence[3310], il a été prévu que dans ce type spécifique d'opération, le projet de scission ne contiendrait pas (i) de rapport d'échange, (ii) de description des modalités d'attribution des actions des sociétés bénéficiaires, (iii) d'indication de la date à laquelle les actions représentatives du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices des sociétés bénéficiaires, (iv) de description des droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions représentatives du capital social de la société scindée, (v) d'indications concernant l'allocation aux associés de la société scindée d'actions et de titres des sociétés bénéficiaires ainsi qu'une explication du critère sur lequel cette allocation est fondée et (vi) de description des modalités d'attribution de la soulte en espèces aux associés ayant fait usage de leur droit de retrait[3311]. En outre, ni un rapport de l'organe de gestion[3312], ni un rapport de l'expert indépendant[3313] ne seront requis et les mécanismes spécifiques de protection des associés ne trouveront pas à s'appliquer[3314].

673. L'incidence du champ d'application limité. En dehors de ces simplifications liées à une opération très particulière, la Directive Mobilité n'intègre pas de dispositions spécifiques destinées à simplifier les opérations intragroupes[3315], malgré les appels faits en ce sens[3316]. Cette attitude restrictive de la part du législateur européen[3317] s'explique toutefois aisément par le champ d'application foncièrement limité de la Directive Mobilité[3318] qui exclut volontairement les opérations impliquant plus d'une société préexistante[3319], ce qui inclut nécessairement les hypothèses où les sociétés bénéficiaires sont titulaires de l'ensemble du capital social de la société scindée. Pour pouvoir apprécier ce que serait éventuellement un régime simplifié des scissions intragroupes, il

3309 Sur cette notion, voir *supra* n° 30.
3310 Art. 160b, 3), c) du Premier Compromis de la Présidence.
3311 Art. 160*vicies* de la Directive Mobilité.
3312 Art. 160*vicies* et 160*sexies* de la Directive Mobilité. Sur ce rapport, voir *supra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Section 4.
3313 Art. 160*vicies* et 160*septies* de la Directive Mobilité. Sur ce rapport, voir *supra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Section 5.
3314 Art. 160*vicies* et 160*decies* de la Directive Mobilité. Sur les différents mécanismes de protection des associés minoritaires, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 5.
3315 Pour un point de vue critique de la Proposition de la Commission à cet égard, voir : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 282.
3316 Voir en ce sens : St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 53 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 31.
3317 Pour un point de vue critique, voir : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364.
3318 Voir en ce sens également : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 270.
3319 Art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité.

est dès lors utile de se pencher sur le régime des fusions transfrontalières qui a l'avantage de déjà couvrir les opérations par absorption.

§2. Le régime des fusions transfrontalières

674. Trois hypothèses distinctes. À l'égard des fusions transfrontalières, tant l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale[3320] que la consultation publique de 2015[3321] ont mis en évidence la nécessité d'une simplification des procédures existantes en vue d'en réduire les coûts en l'absence de risques pour les *stakeholders* concernés[3322]. Dans le cadre du nouveau régime des fusions transfrontalières instauré par la Directive Mobilité, trois constellations spécifiques sont couvertes[3323], à savoir (i) lorsque la fusion transfrontalière par absorption est réalisée par la société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées (*upstream merger*)[3324], (ii) lorsque la fusion par absorption est réalisée par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n'attribue aucune action dans le cadre de la fusion (*side-step* ou *sidestream merger*)[3325] et (iii) lorsque la fusion transfrontalière par absorption est réalisée quand une société qui détient au moins 90 % ou plus, mais non la totalité, départ et les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées[3326].

675. *Upstream* et *side-step mergers*. Dans les deux premières hypothèses, un projet de fusion plus limité ne contenant pas de rapport d'échange[3327], ni de description des modalités d'attribution des titres du capital social de la société

3320 À l'égard des opérations ne présentant pas de risques pour les créanciers, voir : Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 57 et 58.

3321 Voir : Consultation publique de 2015, pp. 15 et 16.

3322 Étude d'impact, p. 21 et Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 6 et 7. Voir également à ce sujet : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 22.

3323 Ainsi que de nombreux auteurs l'ont fait remarquer, la Directive Mobilité n'intègre pas dans son régime des fusions simplifiées les opérations dans lesquelles les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent. Voir art. 119, 2., d) et 132, § 1er de la Directive Mobilité et à ce sujet : Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 844 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 30, ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 270 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 244.

3324 Art. 132, § 1er de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.

3325 Art. 132, § 1er de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 301 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 864, n° 65 R. « Unionales Umwandlungsrecht – Die Zukunft der Unternehmensmobilität im Binnenmarkt », *op. cit.*, p. 613 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 30, n° 31 et 32 ; E. SCHLUMBERGER, « Les fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 3 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 270 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243.

3326 Art. 132, § 2 de la Directive Sociétés.

3327 Art. 122, b) et 132, § 1er de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.

bénéficiaire[3328], ni d'indication de la date à laquelle les titres ou parts représentatifs du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit[3329], ni encore de description des modalités d'attribution de la soulte en espèces aux associés ayant fait usage de leur droit de retrait[3330], pourra être établi. De plus, aucun rapport d'expert indépendant ne sera nécessaire[3331], la ou les sociétés absorbées ne devront pas établir de rapport de l'organe de gestion[3332] et l'opération en question ne devra pas faire l'objet d'une approbation par l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées[3333].

676. Absorption par une société détenant au moins 90 % mais pas totalité des actions d'une société absorbée. Dans l'hypothèse de la fusion par absorption d'une société détenue au moins à 90 % mais pas entièrement par la société absorbante, il sera possible de se passer du rapport d'expert indépendant pour peu que ni la législation nationale de la société absorbante, ni la législation nationale de la ou des sociétés absorbées ne le requièrent dans un contexte interne[3334].

677. L'incidence sur les scissions transfrontalières. Dans le cadre de l'étude de l'opportunité de la mise en place d'un régime simplifié pour certaines scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, on peut en retenir que dans l'esprit du législateur européen, le seul fait que l'opération impliquait des sociétés situées dans des États membres distincts n'était pas de nature à justifier l'exclusion de toute procédure de fusion simplifiée[3335].

§ 3. Une nécessité reconnue en cas de scissions internes

678. *Upstream divisions only*. Dans l'hypothèse d'une scission interne, la Directive Sociétés prévoit explicitement que les États membres ne disposent pas de la possibilité d'imposer l'approbation de la scission par l'assemblée générale de la société scindée si les sociétés bénéficiaires sont titulaires de la totalité des actions de la société scindée et de tous les autres titres conférant un droit de vote[3336]. Trois conditions cumulatives devront toutefois être remplies.

3328 Art. 122, c) et 132, § 1er de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
3329 Art. 122, e) et 132, § 1er de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
3330 Art. 122, m) et 132, § 1er de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
3331 Art. 125 et 132, § 1er de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
3332 Art. 126, § 1er et 132, § 1er de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. Pour un point de vue critique de cette disposition, voir : P. STELMASZCZYK, « Die neue Umwandlungsrichtlinie… », *op. cit.*, p. 75, n° 91 qui relève que même dans une opération simplifiée, il ne sera possible de renoncer complètement au rapport de l'organe de gestion que dans l'hypothèse où la société concernée n'a pas de travailleurs.
Art. § 132, § 1er, deuxième tiret et 124 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
3333 Art. § 132, § 1er, deuxième tiret et 126, § 1er de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
3334 Art. 132, § 2 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
3335 Voir en ce sens également : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 263 qui considère que le caractère transfrontalier d'une opération de fusion simplifiée ne justifie pas que celle-ci soit traitée différemment d'une fusion interne simplifiée.
3336 Art. 154, al. 1er de la Directive Sociétés.

Ainsi, (i) les obligations relatives à la publicité du projet commun de scission devront être accomplies un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet et (ii) tous les associés de la société impliquée dans l'opération auront le droit un mois au moins avant la date de prise d'effet de l'opération de prendre connaissance au siège social de leur société d'un certain nombre de documents préparatoires, au nombre desquels on compte notamment le projet de scission, les rapports des organes de gestion et les rapports d'expert. De plus, l'organe de gestion sera tenu d'informer l'assemblée générale de la société scindée ainsi que les organes de gestion des sociétés bénéficiaires de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date d'établissement du projet de scission[3337]. Ceci montre que la nature particulière d'une scission, qui se caractérise par une pluralité de sociétés bénéficiaires, ne s'oppose pas à la mise en place d'un régime simplifié en cas de scission d'une filiale commune détenue intégralement par les sociétés bénéficiaires.

SECTION 3. LA SITUATION EN DROIT BELGE ET EN DROIT LUXEMBOURGEOIS

679. Le régime du CSA. Tout comme en matière de scissions internes[3338], si la société scindée est soumise au droit belge, l'assemblée générale de cette dernière ne devra pas se prononcer sur l'opération si les sociétés bénéficiaires détiennent l'ensemble des actions de la société à scinder et tous les autres titres conférant un droit de vote sont détenus par les sociétés bénéficiaires[3339], pour peu que (i) le dépôt du projet de scission ait eu lieu pour chacune des sociétés impliquées six semaines au moins avant la date de prise d'effet, (ii) tous les associés de la société impliquée dans l'opération auront eu le droit un mois au moins avant la date de prise d'effet de la scission de prendre connaissance au siège social de la société d'un certain nombre de documents préparatoires, au nombre desquels on compte notamment le projet de scission, les rapports des organes de gestion et les rapports d'expert et (iii) un ou plusieurs associés de la société scindée qui détiennent ensemble au moins cinq pourcents des actions de la société scindée auront néanmoins le droit d'obtenir la convocation de l'assemblée générale de la société scindée pour que celle-ci puisse se prononcer sur le projet de scission[3340]. Il est également précisé que les informations que l'organe de gestion de la société scindée devra fournir concerneront toutes les modifications du patrimoine actif et passif depuis la date à laquelle le projet de scission a été établi[3341]. En outre, il est intéressant de relever que

[3337] Cette disposition est destinée avant tout à clarifier le fait que l'absence d'assemblée générale au niveau de la société scindée ne dispense pas l'organe de direction ou d'administration de son obligation d'information sous prétexte que l'art. 141, § 3 de la Directive Sociétés ne mentionne que les modifications importantes du patrimoine actif et passif de la société scindée intervenues entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée.

[3338] Ar. 12:66, § 7 du CSA.

[3339] Art. 12:66, § 7 et 12:73 du CSA.

[3340] Art. 12:66, § 7 du CSA.

[3341] Art. 12:66, § 7, al. 1er, 3° du CSA.

les travaux préparatoires clarifient explicitement qu'une scission transfrontalière silencieuse peut également être réalisée de manière transfrontalière pour peu que les conditions propres à ce type d'opération soient remplies[3342].

680. Le régime de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales. De manière similaire, le législateur luxembourgeois a consacré le fait que dans le cadre d'une scission transfrontalière par acquisition, il n'était pas nécessaire de faire approuver l'opération par l'assemblée générale de la société scindée lorsque les sociétés sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions ou parts de la société scindée[3343]. La seule différence notable avec le régime belge est qu'il n'est pas prévu qu'il devrait être possible pour des associés minoritaires représentant au moins cinq pourcents de requérir que cette assemblée générale soit tenue, ce qui est logique vu que cette condition est absente du régime des scissions internes simplifiées de la Directive Sociétés[3344].

SECTION 4. *QUID* EN CAS DE SCISSION TRANSFRONTALIÈRE PAR ACQUISITION ?

681. Un régime possible. Il ressort de l'exemple des fusions transfrontalières simplifiées que le caractère transfrontalier de l'opération ne prohibe pas *ab initio* la mise en place d'un régime accéléré lorsque la société apporteuse est une filiale détenue à cent pourcents. En outre tant le législateur belge que le législateur luxembourgeois partagent cette opinion à l'égard des scissions transfrontalières par acquisition de sorte qu'il devra être possible pour le législateur européen d'instaurer un tel régime simplifié des scissions transfrontalières dans le cadre d'une initiative future en la matière[3345].

682. L'incidence de la liberté d'établissement. Il serait toutefois erroné d'arrêter là l'analyse car, loin d'être seulement possible, l'instauration d'un régime simplifié en cas de scission transfrontalière d'une filiale commune ou d'une scission partielle transfrontalière d'une filiale au profit de sa mère, est indispensable. En effet, il a été établi que les scissions transfrontalières constituaient des modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement[3346]. Or, si imposer la tenue d'une assemblée générale constitue un formalisme destiné à protéger les associés minoritaires[3347], cela n'en demeure pas moins contraignant. Il est donc particulièrement aisé d'y voir une restriction en principe prohibée à la liberté d'établissement en ce que cette exigence est de nature à « *dissuader* »[3348] un bénéficiaire de la liberté d'établissement de l'exercer. Si l'impératif de protection des intérêts des associés minoritaires a de longue

3342 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 300.
3343 Art. 1030-1, al. 3 et 1031-19 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3344 Art. 154 de la Directive Sociétés.
3345 Voir en ce sens également : St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 53 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 31.
3346 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.
3347 Sur la protection des associés minoritaires par le biais de l'exercice de droits de vote au niveau de l'assemblée générale, voir *infra* n°s 999 à 1008.
3348 Arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 45 et arrêt *Daily Mail*, pt. 16.

date été reconnu comme une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la liberté d'établissement[3349], il n'en demeure pas moins que celle-ci se doit d'être notamment proportionnée pour satisfaire le « *Gebhard test* »[3350]. Il s'ensuit qu'afin de s'assurer que la mesure ne va effectivement pas au-delà de ce qui est nécessaire, il convient de ne pas imposer d'approbation par l'assemblée générale dans les hypothèses de scission où un mécanisme de protection des intérêts des associés minoritaires par ce biais est superflu. Une initiative européenne à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante devra par conséquent nécessairement intégrer une dispense de l'assemblée générale en cas de scission d'une filiale commune.

3349 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 et arrêt *Überseering*, pt. 92.
3350 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.

Conclusion sur les contours d'un régime européen des scissions transfrontalières

683. Une réforme en marche. Il ressort de l'étude des dispositions de la Directive Mobilité applicables aux scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés que le modèle général européen pour les restructurations sur lequel ce régime est bâti[3351] est également compatible avec les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[3352]. Cependant, au-delà de cette simple compatibilité théorique, il est d'ores et déjà possible de déceler un nombre important d'indices de l'habileté politique de la Commission[3353] qui indiquent que cette dernière n'entendait pas seulement harmoniser les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, mais aspirait également à préparer le terrain à une réforme plus ambitieuse du régime des scissions. En effet, l'obligation d'indiquer dans le projet commun de scission une date à partir de laquelle le droit de participer aux bénéfices sera acquis aux associés de la société scindée[3354] ne fait pas de sens dans le cas d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, mais présente une utilité non négligeable dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. Il en va de même de la possibilité de prévoir des dates de prise d'effet comptable distinctes et de la règle sur l'emploi des langues figurant à l'origine dans la Proposition de la Commission. Dans un même ordre d'idées, la possibilité de prévoir une date de prise d'effet comptable rétroactive ne fait véritablement de sens que dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante puisque dans le cas d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, la date de prise d'effet comptable correspondra nécessairement à la date de constitution des nouvelles sociétés. Il est également possible de déceler une telle intention dans le fait que la mention relative aux garanties offertes aux créanciers dans le projet de scission ne fait pas de distinction entre les créanciers de la société scindée et ceux des sociétés bénéficiaires comme aurait pu le dicter un régime résolument limité aux scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, rendant cette mention directement compatible avec un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. On ne peut également que s'étonner de constater que le législateur européen ait imposé de déposer auprès du registre de la société scindée, l'information selon laquelle ce registre est compétent ainsi que le numéro d'immatriculation dans ce registre de la société scindée. Une telle exigence ne se comprend qu'en vue de préparer le terrain à l'introduction d'un régime applicable également aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. En outre, l'interdiction de contester la validité de la décision de l'assemblée générale approuvant l'opération transfrontalière sur la seule base que la valeur totale des participations attribuées à un associé n'est pas équivalente à la participation détenue par celui-ci dans la société scindée ne fait véritablement de sens que dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. Par ailleurs, la décision d'une

3351 W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569.
3352 Voir en ce sens : St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 25.
3353 Pour une liste détaillée des indices de l'habileté politique de la Commission européenne, voir Annexe 4.
3354 Art. 160*quinquies*, f) de la Directive Mobilité.

autorité nationale compétente de refuser d'émettre le certificat de conformité dans le cadre d'une scission transfrontalière par absorption au motif que ce type d'opération ne rentre pas dans le champ d'application de la disposition nationale ayant transposé la Directive Mobilité violerait le principe de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes si l'État membre en question reconnaît les scissions par acquisition dans l'ordre interne. Il n'est pas concevable que la Commission ait ignoré ce point qui sème les germes d'une répétition des faits à la base de l'arrêt *Sevic*[3355] dans le cadre des scissions transfrontalières et justifierait aisément une initiative législative en la matière. Pour finir, l'absence de prohibition de prononcer la nullité d'une scission transfrontalière mixte ou par acquisition ayant déjà pris effet nuit à la sécurité juridique de ce type d'opération tant pour les associés concernés que pour les autres *stakeholders* pourtant davantage exposés dans ce type d'opérations que dans une simple scission par constitution de nouvelles sociétés. Cette incohérence flagrante permettrait également de justifier une intervention de la Commission en la matière lors de la révision de la Directive Mobilité au plus tard en 2027[3356].

684. Un certain nombre de modifications nécessaires. Cependant, ces conclusions ne doivent pas être exagérées. En effet, s'il est effectivement possible d'identifier un nombre relativement important d'indices que la volonté de la Commission allait au-delà du champ d'application foncièrement limité de la Directive Mobilité, seules les fondations ont été creusées. En effet, l'analyse détaillée de la procédure de scission transfrontalière a permis de mettre en lumière le fait qu'un certain nombre de modifications demeuraient malgré tout nécessaires pour pouvoir mettre en place un régime efficace des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[3357]. Ainsi, dans l'intérêt de la sécurité juridique, il serait utile d'imposer que le projet de scission transfrontalière mentionne également les éléments intransmissibles du patrimoine de la société scindée, dans la mesure où les associés des sociétés bénéficiaires ignorent vraisemblablement les restrictions à la transmission à titre universel en vigueur dans l'État membre de la société scindée. Il s'est également avéré qu'il conviendrait de réintégrer la règle de répartition par défaut des éléments d'actif et de passif oubliés ou inconnus qui figurait à l'origine dans la Proposition de la Commission et de garder la limite obligatoire de la solidarité passive à l'actif net transféré. Compte tenu du nombre potentiellement important de juridictions impliquées, la nécessité d'intégrer une règle d'emploi des langues permettant aux parties d'établir le projet commun dans une langue usuelle de la sphère financière internationale, tout en prévoyant qu'en présence de versions dans d'autres langues nationales, la version anglaise prévaudrait, n'est

3355 Sur les faits à la base de cet arrêt, voir *supra* n° 149.

3356 Voir art. 4 de la Directive Mobilité qui précise que la Commission procédera au plus tard le 1er février 2027 à une évaluation de la Directive Mobilité et établira un rapport comprenant également une évaluation de la faisabilité de la définition de règles pour les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

3357 Pour une liste détaillée des différents aspects du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés qui nécessiteront une modification pour faire des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante une réalité au sein de l'Union européenne, voir Annexe 5.

pas contestable. De même, la question de la date de prise d'effet comptable de l'opération gagnerait à être harmonisée, le cas échéant en s'inspirant du régime figurant à l'origine dans la Proposition de la Commission. De plus, au niveau de la mention relative aux droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou aux mesures proposées à leur égard, il conviendrait également de couvrir l'impact que la scission pourrait avoir sur la situation des titulaires de droits spéciaux des sociétés bénéficiaires, à l'instar de ce qui est le cas dans l'hypothèse d'une opération interne. Imposer de mentionner les avantages perçus par l'expert indépendant dans le projet commun de scission transfrontalière comme en cas de scission interne irait également dans le sens d'une meilleure information des *stakeholders*, de même que le fait d'inclure une description des principaux éléments intransmissibles du patrimoine de la société scindée. Il semblerait également opportun de ne pas permettre aux États membres d'exiger de mentions supplémentaires dans le projet commun de scission. Par ailleurs, dans un souci d'information des associés minoritaires, l'obligation d'expliquer la répartition des actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée dans le rapport de l'organe de direction ou d'administration devrait être ajoutée. Il serait également préférable d'harmoniser le droit au secret dans le cadre de l'établissement du rapport de l'organe de direction ou d'administration, en prévoyant toutefois une obligation complémentaire de motivation en vue d'éluder les éventuels abus. De plus, dans un souci de simplification et de réduction de coûts, il serait utile qu'un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante mentionne explicitement la possibilité d'établir un rapport de l'organe de direction ou d'administration commun à toutes les sociétés impliquées. Il aurait également été appréciable dans l'intérêt de la sécurité juridique que la Directive Mobilité précise que les associés et les travailleurs disposent, à l'unanimité, de la possibilité de réduire le délai de mise à disposition du ou des rapports de l'organe de direction ou d'administration. Toujours dans une optique de réduction de coûts, et cette fois-ci à l'égard plus particulièrement du rapport d'expert indépendant, il conviendrait de prévoir une procédure de désignation d'un expert commun ainsi que la possibilité d'établir un rapport unique pour toutes les sociétés impliquées dans l'opération de scission. En vue de renforcer la sécurité juridique, il serait également préférable qu'une initiative européenne à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante prévoie explicitement qu'en cas de rapport d'expert unique, les différents droits nationaux en présence s'appliqueront de manière cumulative tout en privilégiant la norme la plus sévère. De plus, afin de mieux tenir compte des spécificités d'une scission par rapport à une fusion et de garantir une meilleure information des associés appelés à se prononcer sur l'opération au moment de l'assemblée générale, le rapport d'expert indépendant devrait également inclure une indication sur la justification de l'utilisation de méthodes d'évaluation différentes si différentes méthodes ont été utilisées dans les sociétés impliquées dans l'opération, ains qu'un avis sur le critère utilisé pour la répartition des actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée. Par ailleurs, dans l'hypothèse de la mise en place d'un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société

préexistante, il conviendrait de s'inspirer de la solution des fusions transfrontalières à l'égard d'une possible renonciation au rapport d'expert et de requérir l'unanimité au sein de chacune des sociétés impliquées dans l'opération. Il s'avère également que le mécanisme du double contrôle de légalité devrait aussi trouver à s'appliquer à l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, à ceci près que, compte tenu des spécificités des scissions qui se caractérisent par une unicité de société scindée, le second contrôle devrait être accompli par l'autorité nationale compétente de l'État membre de la société scindée. Il s'ensuivrait en toute logique que seules la radiation de la société scindée et la prise d'effet de l'opération devraient être notifiées par le registre de la société scindée aux registres des sociétés bénéficiaires. A ceci s'ajoute que le nombre important de juridictions différentes potentiellement impliquées dans une scission transfrontalière par acquisition renforce la nécessité de mettre en place un formulaire numérique standard, disponible à tout le moins en anglais, au niveau européen pour le certificat de conformité, étant entendu que les éventuelles réticences des États membres à cet égard pourraient être contournées en prévoyant que ce formulaire viendrait en sus du certificat de conformité habituellement émis. Dernièrement, une initiative européenne à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante devrait nécessairement intégrer un régime simplifié prévoyant une dispense de l'assemblée générale de la société absorbée en cas de scission d'une filiale commune, à l'instar de ce qui est d'application en cas d'opération purement interne.

Conclusion de la première partie

685. Une étape de plus dans la construction européenne. L'apparente simplicité de la notion de « *scission transfrontalière* » dissimule une réalité beaucoup plus complexe. Recouvrant à la fois les scissions par constitution de nouvelles sociétés, les scissions par absorption, les scissions mixtes, les scissions partielles, les scissions par séparation et les scissions silencieuses, elle regroupe en réalité un très vaste éventail d'opérations distinctes. Ce caractère disparate est toutefois loin d'être une faiblesse dans la mesure où il permet aux différents acteurs économiques de l'adapter à leurs besoins concrets et de l'intégrer dans une stratégie bien déterminée. S'il est vrai qu'elles ne sont ni dénuées d'inconvénients, ni infaillibles, il a été établi qu'elles présentaient une utilité économique indéniable, en priorité pour les associés majoritaires, mais également pour les autres *stakeholders*, justifiant l'intérêt de la possibilité de réaliser de telles opérations au sein de l'Union européenne. Malgré un nombre important de précieux enseignements en la matière, la liberté d'établissement et son interprétation par la Cour de justice souffrent de certaines limites intrinsèques rendant illusoire une construction purement prétorienne d'un droit européen des scissions transfrontalières. En revanche, par son vaste champ d'application ainsi que par son rôle de garde-fou, elle complèterait avantageusement une norme de droit dérivé en la matière. Pour ce qui est de la libre circulation des capitaux, s'il semble incontestable que les scissions transfrontalières en constituent également des modalités particulières d'exercice, son intérêt s'avère très limité en pratique. En outre, compte tenu de l'impact considérable qu'une scission transfrontalière est susceptible d'avoir sur de nombreux *stakeholders*, force est de constater qu'elle n'est pas adaptée à ce type d'opération. Face à ces insuffisances des libertés fondamentales, ni les différentes théories développées en droit international privé, ni une application par analogie du régime pourtant éprouvé des fusions transfrontalières, ni encore des initiatives bienveillantes de législateurs nationaux favorables à la mobilité transfrontalière ne parviennent à apporter une réponse satisfaisante. Cet état de fait justifie pleinement l'intervention du législateur européen sous la forme de l'adoption de la Directive Mobilité. Cependant, si la Directive Mobilité constitue indubitablement un succès en soi, elle n'en est pas pour autant suffisante. En effet, l'absence d'harmonisation préalable des scissions internes, un champ d'application *ratione personae* et *ratione materiae* foncièrement insuffisants, une disposition anti-abus critiquable à maints égards ainsi que des différences de traitement injustifiées entre des opérations transfrontalières pourtant aisément interchangeables sont autant d'éléments ne permettant pas de clore le sujet des scissions transfrontalières au sein du marché intérieur. Une nouvelle initiative européenne en la matière est donc inéluctable, l'exemple des fusions transfrontalières combiné aux insuffisances des méthodes dérivées, à une insécurité juridique persistante et à l'omniprésente nécessité de protéger les *stakeholders* démontrant à suffisance sa nécessité pour faire des scissions transfrontalières une réalité. À cet égard, l'exemple des fusions transfrontalières a permis de démontrer que l'intégration européenne en matière de mobilité transfrontalière était un processus par étapes et que le meilleur moyen de contourner les éventuelles réticences des États membres à l'encontre d'un plus haut degré d'harmonisation consistait à leur faire accepter un premier régime peu intrusif pour ensuite mettre en exergue, de façon incontestable,

la nécessité de remédier aux insuffisances de ce régime par une harmonisation plus ambitieuse. Si ce *modus operandi* est bien celui adopté par la Commission, une nouvelle initiative devrait effectivement voir le jour au plus tard en 2027[3358] et devrait s'inspirer du modèle général européen pour les restructurations sur lequel la Directive Mobilité est bâtie[3359] et dont l'étude détaillée a permis d'une part de mettre en lumière qu'il était compatible, dans son principe, avec les spécificités d'une scission impliquant plus d'une société préexistante et d'autre part d'identifier un nombre considérable d'indices que la Commission avait déjà à l'esprit la préparation du terrain à une réforme plus ambitieuse du régime des scissions. L'étude détaillée des dispositions de la Directive Mobilité a toutefois permis d'établir qu'une simple application *mutatis mutandis* du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés était loin d'être une solution satisfaisante et qu'un nombre important de modifications s'imposait malgré tout.

[3358] Art. 4, § 1er de la Directive Mobilité.
[3359] W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2569.

Partie II
Les scissions transfrontalières sous l'angle des principaux *stakeholders*

SOMMAIRE

Introduction de la deuxième partie 559
Titre I. La protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière 563
Titre II. La protection des autres stakeholders dans le cadre d'une scission transfrontalière 813
Conclusion de la deuxième partie 955

Introduction de la deuxième partie

686. Un impact considérable sur les *stakeholders*. S'il est établi que les scissions transfrontalières sont nécessaires d'un point de vue économique pour permettre aux sociétés de s'adapter plus facilement aux conditions changeantes d'un marché de plus en plus globalisé, il ne faut pas perdre de vue que les effets d'une telle opération ne sont pas limités aux seules sociétés impliquées et que leurs répercussions vont largement au-delà des seuls associés de contrôle. En effet, une telle opération, à l'instar des fusions transfrontalières[3360] et des transformations transfrontalières, risque d'avoir un impact considérable sur tous les *stakeholders*[3361], et principalement sur les créanciers, les associés minoritaires et les travailleurs[3362]. Par conséquent, toute initiative européenne à l'égard des scissions transfrontalières ne devra pas uniquement être concernée par le bien-être des sociétés impliquées, mais devra nécessairement également offrir une protection efficace aux *stakeholders*[3363]. Ce constat s'impose d'autant plus si on prend en considération le fait que lors de la consultation publique de 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés, plus de 50 % des personnes s'étant prononcées sur les objectifs du droit européen des sociétés ont indiqué que le renforcement de la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des travailleurs devait être une des priorités du droit européen des sociétés[3364] et que lors de la consultation publique de 2015, la moitié des questions posées à l'égard des fusions transfrontalières concernaient directement les *stakeholders*[3365]. Parmi ces derniers, les créanciers seront la catégorie qui fera l'objet des plus longs développements dans la mesure où une scission entraîne des risques spécifiques à leur égard[3366][3367] (titre I). L'impact tant sur les associés minoritaires que sur le régime de participation des travailleurs sera ensuite étudié (titre II). L'objectif de cette deuxième partie est double et consiste (i) à déterminer si le régime déjà existant en matière de scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés serait compatible avec les spécificités d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante et (ii) à identifier les insuffisances à cet égard et déterminer la meilleure manière d'y remédier efficacement. Pour y parvenir, la méthode utilisée, bien que requérant systématiquement certaines adaptations liées aux spécificités de chaque catégorie de *stakeholders*, s'articulera autour de trois points cardinaux, à savoir (i) l'identification des enjeux d'une scission transfrontalière pour chaque catégorie de *stakeholders*, (ii) l'examen de la manière dont il a été répondu à ces différents enjeux par le législateur européen à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés et (iii) la détermination des modifications qui s'avèrent nécessaires en vue de faire de

3360 Voir en ce sens : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 308.
3361 Par « *stakeholder* » on entend « tout individu ou groupe sur lequel les activités de la société ont un impact, en ce compris les travailleurs, les consommateurs et la communauté locale ». Voir : Chr. A. MALLIN, *op. cit.*, p. xix.
3362 Étude d'impact, p. 5.
3363 Étude d'impact, p. 6.
3364 Feedback statement – Summary of responses to the public consultation on the future of European company law, July 2012, disponible sur http://ec.europa.eu (15/06/2016), p. 4.
3365 Consultation publique de 2015, pp. 4 à 18.
3366 Voir en ce sens : G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *op. cit.*, p. 72.
3367 Pour une étude détaillée des risques encourus par les créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière, voir *infra* n°s 696 et 704.

tout type de scission une réalité au sein de l'Union européenne en tirant pleinement parti de l'expérience glanée en matière de fusions transfrontalières, ainsi que des solutions développées par les différents législateurs nationaux connaissant déjà un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

687. L'ombre omniprésente de la Cour de justice. À titre préliminaire, il convient de préciser d'ores et déjà qu'il découle de l'applicabilité de la liberté d'établissement aux scissions transfrontalières que les différents mécanismes de protection des *stakeholders* devront en tout état de cause respecter tant le principe d'équivalence, que le principe d'effectivité[3368]. Le principe d'équivalence impose que les mesures de protection nationales applicables à une scission transfrontalière ne soient pas moins favorables que celles régissant les scissions internes[3369] et le principe d'effectivité impose que ces mêmes mesures de protection ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice de la liberté d'établissement[3370]. Toute entrave à la liberté d'établissement, pour peu qu'elle ne soit pas directement discriminatoire, devra nécessairement respecter les conditions du « *Gebhard test* », c'est-à-dire (i) être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, (ii) être propre à garantir l'objectif en cause et (iii) ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif[3371]. Or, à cet égard, il est de jurisprudence constante que la protection des créanciers, des associés minoritaires et des travailleurs constitue une telle raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la liberté d'établissement[3372]. Tout au long de l'analyse des différents mécanismes de protection des *stakeholders*, il conviendra dès lors de garder à l'esprit que ceux-ci pourront certes constituer une entrave à la liberté d'établissement, mais devront en tout état de cause demeurer tant adéquats que proportionnés.

3368 Voir *supra* n° 132.
3369 Arrêt *Vale*, pts. 48 et 54.
3370 Arrêt *Vale*, pt. 48.
3371 Voir notamment : arrêt *Polbud*, pt. 52 ; C.J., gde ch., arrêt *National Grid Indus BV c. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam*, 29 novembre 2011, C-371/10, EU:C:2011:785, pt. 42 ; arrêt *Vale*, pt. 39 et arrêt *Sevic*, pts 28 et 29.
3372 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 ; arrêt *Überseering*, pt. 92 et arrêt *Inspire Art*, pt. 132 (pour les créanciers uniquement). Voir également plus spécifiquement pour la protection des travailleurs : C.J., gde ch., arrêt *Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) c. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis*, 21 décembre 2016, EU:C:2016:972, pt. 73.

TITRE I
La protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière

SOMMAIRE

Introduction du titre I 565
Chapitre 1. Aspects généraux de la protection des créanciers 569
Chapitre 2. Les contours de la protection des créanciers dans les scissions transfrontalières 625
Conclusion sur la protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière 809

Introduction du titre I

688. Délimitation. La question de la protection des créanciers est un sujet sensible pour de nombreux législateurs nationaux[3373] et son étendue considérable va bien au-delà de la seule problématique de la mobilité transfrontalière des personnes morales. Elle constitue non seulement un point d'intersection entre différentes branches du droit telles que le droit des sociétés, le droit comptable, le droit des obligations ou encore le droit de l'insolvabilité et le droit pénal[3374], mais nécessite également de solides connaissances en sciences économiques pour pouvoir être appréhendée dans son entièreté, ce qui irait bien au-delà des objectifs de la présente étude qui vise avant tout à déterminer les enjeux d'une scission transfrontalière pour les créanciers des sociétés impliquées et la manière d'y répondre de manière adéquate. Ainsi, seuls les créanciers directs des sociétés impliquées dans l'opération feront l'objet d'une analyse détaillée, à l'exclusion des créanciers indirects tels que les créanciers d'un associé lésé dans le cadre d'une scission. Enfin, l'analyse se concentrera sur les mécanismes de protection à mettre spécifiquement en place en cas de scission transfrontalière à l'exclusion des mécanismes de protection institutionnels[3375] relevant du droit général des sociétés, à l'instar du capital social minimum[3376] ou des limites aux distributions faites aux associés[3377], qui ont pour particularité d'être applicables indépendamment de toute opération transfrontalière.

3373 Étude d'impact, p. 69.

3374 P. MÜLBERT, *A synthetic view of different concepts of creditor protection – or a high-level framework for corporate creditor protection*, ECGI – Law Working Paper n° 60, 2006, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 7 et 8 et M. SIEMS, L. HERZOG et Er. ROSENHAGER, « The protection of creditors of a European private company (SPE), *EBOR*, 2011, vol. 12(1), pp. 151 et 152.

3375 Sur cette notion, voir *infra* n° 754.

3376 Au sujet de l'échec du capital social minimum pour la protection des créanciers, voir notamment : J. ARMOUR, « Legal capital : an outdated concept ? », *EBOR*, 2006, pp. 5–27 ; H. CULOT, « La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée », *RDC-TBH*, 2018/9, pp. 968 et 969, n° 4 et 5 ; H. CULOT et P.-Y. THOUMSIN, « Contrôle et maintien du capital : une réforme sans audace », *J.T.*, 2009/6, pp. 93–94, n° 2-4 ; H. CULOT et M. VAN BUGGENHOUT, « Droit européen des sociétés : vers une réforme du « capital » ? », *J.D.E.*, 2007/7, n° 141, pp. 193–200 ; L. ENRIQUES et L. MACEY, « Creditors versus capital formation : the case against the European legal capital rules », *Cornell Law Review*, 2001, pp. 1165–1204 ; J. FONTEYN, « Ne dites plus "capital", dites "capitaux propres" », *RPS-TRV*, 2019/3, pp. 272 et 273 ; A. NAVEZ, « Chapitre 4 – La société à responsabilité limitée » in E.-J. NAVEZ (dir.), *Le Code des sociétés et associations*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 102 et 103, n° 224–225 ; P. SANTELLA, « Capital maintenance in the EU : is the Second Company Law Directive really that restrictive ? », *EBOR*, 2008, vol. 9(3), pp. 431–435 et Chr. TEICHMANN, *Binnenmarktkonformes Gesellschaftsrecht*, Berlin, De Gruyter Recht, October 2006, pp. 469–472. Voir également sur l'importance d'un capital social minimum pour la protection des créanciers : F. DIAS SIMOES, « Legal capital rules in Europe : is there still room for creditor protection », *I.C.C.L.R.*, 2013, 24(4), pp. 166–172. Voir également : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 12 : « Le concept de capital est actuellement dépassé et ne répond plus à la réalité économique. Il n'offre pas aux créanciers la protection efficace qui en était attendue, tout en confrontant les sociétés à des frais et à des procédures bureaucratiques. C'est la raison pour laquelle il est remplacé par une approche plus réaliste et plus économique tout en restant attentive à la recherche d'un juste équilibre entre la protection des tiers et la liberté contractuelle ».

3377 À ce sujet, voir notamment : H. CULOT, *ibidem*, pp. 976 et 977, n° 27–30 ; J. RICKFORD, « Legal approaches to restricting distributions to shareholders : balance sheet tests and solvency tests », *EBOR*, 2006, vol 7(1), pp. 135–179 ; J. RICKFORD, « Reforming Capital – Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance », *EBLR*, 2004, pp. 919–1027 et P. SANTELLA, *ibidem*, pp. 446–460.

689. Plan du titre I. Pour parvenir à porter un jugement éclairé sur les contours que devrait revêtir un régime de protection efficace et équilibré des créanciers en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante (chapitre 2), certains aspects généraux de la protection des créanciers doivent être précisés au préalable (chapitre 1). En effet, examiner au microscope les différents mécanismes mis en place par le législateur européen pour assurer une protection adéquate des intérêts des créanciers en cas d'opération transfrontalière se révélerait être un exercice particulièrement vain s'il ne se trouvait pas précédé d'une étude détaillée des particularités de la protection de cette catégorie de *stakeholders* dépassant le seul cadre des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés.

Chapitre 1
Aspects généraux de la protection des créanciers

INTRODUCTION DU CHAPITRE 1

690. Plan du chapitre 1. Par le biais de l'identification (i) des différents créanciers impactés par une scission transfrontalière (section 1), (ii) des enjeux de la protection des créanciers (section 2) ainsi que (iii) des principes de droit international privé applicables à cette matière (section 3), il sera possible de déterminer si les créanciers nécessitent une protection accrue en raison de la nature transfrontalière de l'opération (section 4), ainsi que si les créanciers d'une société scindée nécessitent davantage de protection que les créanciers des sociétés bénéficiaires (section 5). Cette manière de procéder permettra d'aborder l'étude des différents mécanismes de protection des créanciers en percevant continuellement les enjeux sous-jacents en filigrane.

SECTION 1. NOTION DE CRÉANCIER

691. Créanciers, associés et travailleurs. Qu'entend-on exactement par la notion *a priori* simple de « créancier » ? Ce dernier peut être généralement défini comme toute personne bénéficiant d'un droit de créance « permettant à son titulaire de réclamer d'une personne déterminée l'accomplissement d'une prestation »[3378]. Cette définition, particulièrement large, recouvre inévitablement également les deux autres catégories de *stakeholders* que sont les associés et les salariés. Cependant, les spécificités de la situation dans laquelle ceux-ci se trouvent justifient un examen séparé. En effet, si les premiers constituent bien des créanciers de la société en ce qu'ils détiennent un certain nombre de droits à l'encontre de celle-ci[3379], le fait que, contrairement à tous les autres créanciers, ils maîtrisent l'opération de scission transfrontalière, génère des besoins de protection spécifiques. En ce qui concerne les seconds, bien qu'ils constituent également des créanciers *stricto sensu*[3380], leur étroite dépendance envers la société ainsi que l'existence d'un régime juridique spécifiquement dédié à réglementer les différents aspects de leur relation de travail nécessitent une étude à part. Il convient toutefois de préciser que si cette distinction entre créanciers, associés et travailleurs est utile d'un point de vue théorique, elle n'implique toutefois pas que ces qualités soient exclusives les unes des autres. Il est en effet fréquent en pratique d'être confronté à des créanciers hybrides[3381] comme des associés ayant consenti un prêt à la société dont ils détiennent les actions ou encore des travailleurs détenant une faible participation dans la société qui les emploie.

3378 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 19, n° 6.
3379 J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 17 et 18, n° 28 et 29.
3380 27e considérant de la Proposition du Parlement qui prévoit que les créanciers à protéger dans le cadre d'une opération transfrontalière pourraient être « des travailleurs, en activité ou non, disposant de droits à pension professionnelle acquis et des personnes touchant des prestations de pension professionnelle ». Voir également en ce sens : G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, « Der Gläubigerschutz im Gesellschaftsrecht nach Inspire Art », *RIW*, 2004, p. 14 et J. SCHMEIDLER, *ibidem*, p. 20, n° 32.
3381 H. MERKT, « Creditor protection through mandatory disclosure », *EBOR*, 2006, p. 107.

692. Une catégorie hétérogène de *stakeholders*. Malgré ces premières exclusions, il convient d'ores et déjà de préciser que, loin de constituer une catégorie homogène de *stakeholders*, les créanciers concernés sont susceptibles d'être dans des situations très diverses[3382]. Il est ainsi possible de distinguer les créanciers en fonction de la nature de la créance qu'ils détiennent à l'encontre de la société, celle-ci pouvant être tant contractuelle que délictuelle[3383] ou encore tant volontaire qu'involontaire[3384]. À titre d'exemple de créanciers contractuels, on peut citer un fournisseur de la société et à titre d'exemple de créancier délictuel, on peut citer les personnes physiques ayant subi un dommage environnemental causé par la société en question. En ce qui concerne, les créanciers volontaires, on peut citer d'exemple d'une banque ayant consenti une ligne de crédit et le meilleur exemple de créancier involontaire est celui de l'État par le biais de son administration fiscale. Il est également possible de distinguer les créanciers en fonction de l'existence ou non de sûretés[3385]. En effet, les premiers jouissent généralement d'une position privilégiée par rapport aux seconds dans la mesure où ils disposent de garanties additionnelles de la bonne exécution de la dette par le débiteur. Les créanciers peuvent être également répartis entre créanciers privés qui jouissent à l'encontre du débiteur d'un droit subjectif dont ils peuvent librement disposer et créanciers publics[3386], tels que l'administration fiscale ou un organisme de perception de cotisations sociales[3387], dont la marge de manœuvre est plus limitée en raison de l'existence d'un cadre légal plus strict[3388]. Pour finir, il est également possible de distinguer les créanciers en fonction de leur taille et de leurs connaissances[3389]. Certains créanciers, tels que les établissements de crédit, disposent ainsi généralement de nombreux débiteurs dans un souci de diversification des risques, ont accès à des conseils spécialisés et sophistiqués leur permettant de sauvegarder leurs intérêts et sont généralement en position de force par rapport à leurs débiteurs. D'autres, en revanche, comme les petits fournisseurs, seront de moindre importance et fréquemment en position de faiblesse par rapport à leur débiteur.

693. Créanciers chirographaires et créanciers privilégiés. Même si les créanciers chirographaires se trouvent, par définition, dans une situation généralement plus précaire que les créanciers privilégiés, il serait erroné de penser qu'une scission transfrontalière ne risque pas d'impacter négativement cette dernière catégorie de *stakeholders*. À titre d'illustration, et pour se convaincre du danger latent encouru par les créanciers privilégiés, il est intéressant de se pencher brièvement sur la jurisprudence française récente en matière de

3382 H. MERKT, *ibidem*, p. 107 ; G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, *op. cit.*, p. 14 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 16–20, n°s 26–33.
3383 G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, *ibidem*, p. 14.
3384 H. MERKT, *op. cit.*, p. 109 et P. MÜLBERT, *op. cit.*, p. 11.
3385 J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 20, n° 33.
3386 Par « créancier public », on entend « les services chargés du recouvrement d'une dette qui trouve son origine dans l'application de dispositions légales ou réglementaires établissant un prélèvement à charge du débiteur ». Voir à ce sujet : D. PATARD, « Notion de créancier public », *Rép. not.*, tome XIII, La procédure notariale, Livre 4/12, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, n° 171.
3387 D. PATARD, *ibidem*, n° 171.
3388 *Ibidem*.
3389 H. MERKT, *op. cit.*, p. 107.

circulation du cautionnement général garantissant les obligations d'une société débitrice faisant par après l'objet d'une scission[3390]. Dans une telle hypothèse, la solution généralement retenue par la jurisprudence est que l'obligation de règlement[3391] demeure alors que l'obligation de couverture[3392] s'éteint[3393]. Cette solution est justifiée par le caractère *intuitu personae* du contrat de cautionnement[3394] ainsi que par un principe d'interprétation stricte du cautionnement[3395]. En effet, dans la mesure où la personne du débiteur est un élément déterminant de l'engagement de la caution à couvrir les dettes futures de ce dernier[3396], il ne peut être inféré de son engagement qu'elle a pu vouloir couvrir les dettes futures d'une autre personne morale si le débiteur vient à se faire absorber dans le cadre d'une fusion ou d'une scission. Ceci explique également pourquoi cette solution sera écartée si la caution a manifestement exprimé son intention de garantir toutes les dettes des sociétés bénéficiaires de l'opération[3397] ou encore, en cas de scission frauduleuse destinée à permettre à une société d'éluder, ou à tout le moins de réduire son engagement

3390 À ce sujet, voir : C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 100, n° 226 ; C. COUPET, « Fusion ou scission de la société créancière ou débitrice : même sort pour la caution », note sous Cass. com., 8 mars 2017, *Droit des sociétés*, n° 10, octobre 2017, pp. 23 et Ph. DELEBECQUE et Ph. SIMLER, « Droit des sûretés », *La Semaine Juridique Édition Générale*, n° 42, 17 octobre 2001, doctr. 356, disponible sur www.lexis360.fr (10/12/2019), pp. 5 et 6, n°s 17–20.

3391 Par « obligation de règlement », on entend l'obligation « par laquelle la caution est tenue de payer chacune des dettes du débiteur entrant dans le champ de la couverture, nées et non acquittées par le débiteur ». À ce sujet, voir : M. BOURASSIN, V. BREMOND et M.-N. JOBARD-BACHELLIER, *Droit des sûretés*, 7e éd., Paris, Sirey, 2020, p. 92, n° 147.

3392 Par « obligation de couverture », on entend l'obligation « par laquelle la caution s'engage à couvrir, c'est-à-dire à garantir, les dettes à venir du débiteur principal ». À ce sujet, voir : M. BOURASSIN, V. BREMOND et M.-N. JOBARD-BACHELLIER, *ibidem*, p. 92, n° 147.

3393 C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 100, n° 226 ; Ph. DELEBECQUE et Ph. SIMLER, *op. cit.*, p. 5, n° 20 ; C. COUPET, *op. cit.*, p. 23 ; D. HOUTCIEFF, « Le sort du cautionnement garantissant le bail en cas de fusion-absorption de la société créancière ou débitrice », *La Semaine Juridique Édition Générale*, n° 49, 7 décembre 2005, p. 10170, disponible sur www.lexis360.fr (10/12/2019), p. 4 ; D. LEGEAIS, « Sort du cautionnement garantissant le bail en cas de fusion-absorption de la société créancière ou débitrice », note sous Cass. com., 8 novembre 2005 et Cass. com., 8 novembre 2005, *La Semaine Juridique – Entreprise et Affaires*, n° 1, 5 janvier 2006, p. 1000, disponible sur www.lexis360.fr (10/12/2019), p. 6 ; N. MORELLI, « Le sort du cautionnement dans les opérations de fusion », *BJS*, juillet 2004, p. 932, disponible sur www.lextenso.fr (07/01/2020), p. 6 et R. MARTY, « Cautionnement de dettes futures et fusion-absorption de sociétés », *La Semaine Juridique – Entreprises et Affaires*, n° 22, 31 mai 2018, p. 38. Pour des cas d'illustration en matière de fusions, voir : Cass. com., 21 janvier 2003, n° 97-13.027, *Bull. civ.*, 2003, IV, n° 9 et Cass., 3e civ., 16 février 2000, *Droit des sociétés*, n° 5, mai 2000, comm. 78.

3394 C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *ibidem*, p. 100, n° 226 ; C. COUPET, *ibidem*, p. 23 ; D. HOUTCIEFF, *ibidem*, p. 4 ; D. LEGEAIS, *ibidem*, p. 6 ; R. MARTY, *op. cit.*, p. 38 et A. PRÜM, « Fusions de banques et survie des cautionnements consentis en faveur des établissements absorbés », *Revue de droit bancaire et financier*, n° 1, janvier 2006, alerte 1.

3395 D. LEGEAIS, *ibidem*, p. 6.

3396 A.-S. BARTHEZ et D. HOUTCIEFF, *Les sûretés personnelles*, Paris, L.G.D.J., Lextenso éditions, 2010, p. 84, n° 98 ; P. LE CANNU, « Cautions et fusions ; l'aubaine se fait plus rare », *BJS*, mars 2006, p. 345, disponible sur www.lextenso.fr (07/01/2020), p. 2 ; N. MORELLI, *op. cit.*, p. 6 et X. VAMPARYS, « Fusions et transmissibilité des conventions conclues *intuitu personae* », *BJS*, mai 2006, p. 591, disponible sur www.lextenso.fr (07/01/2020), p. 2.

3397 C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 100, n° 226 et C. COUPET, *op. cit.*, p. 23 et Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-12.018, *Bull. Joly*, 1997, p. 643 et Cass. com., 17 juillet 1990, n° 89-11.059, *Rev. Soc.*, 1991, p. 67.

de caution[3398]. Si cette solution présente une certaine logique, on constate aisément que la situation du créancier bénéficiaire du cautionnement risque d'être significativement altérée par l'opération dans la mesure où seules les obligations de la société débitrice antérieures à la réalisation de l'opération[3399] feront l'objet de l'obligation de couverture de la caution[3400]. Cette solution, identique en droit belge[3401] et qu'on retrouve sous une forme similaire en droit allemand[3402], illustre à quel point la situation des créanciers peut être rendue précaire, même en présence d'une sûreté personnelle garantissant le remboursement d'une créance.

694. La nécessité d'un mécanisme flexible. Compte tenu du caractère particulièrement hétérogène de la catégorie de *stakeholders* que constituent les créanciers des sociétés impliquées dans une scission transfrontalière, il n'est pas surprenant que leurs besoins de protection soient à géométrie variable. Un mécanisme efficace de protection des intérêts des créanciers devra dès lors nécessairement pouvoir, sur la base du principe « *one size fits all* », s'adapter à la situation spécifique de chacune de ces différentes catégories.

SECTION 2. LES ENJEUX DE LA PROTECTION DES CRÉANCIERS

695. Plan de la section 2. Afin d'aborder les enjeux de la protection des créanciers en cas de scission transfrontalière, il importe, en premier lieu, d'identifier les différents risques qu'une telle opération présente pour les créanciers (§ 1), pour ensuite se pencher sur le délicat équilibre entre tous les intérêts en présence qu'un régime de protection des intérêts des créanciers efficace devra atteindre (§ 2).

3398 C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *ibidem*, pp. 100 et 101, n° 226 ; R. MARTY, *op. cit.*, p. 40 et A. PRÜM, « Fusions de banques et survie des cautionnements consentis en faveur des établissements absorbés », *op. cit.*, alerte 1 et Cass. com., 10 octobre 1995, n° 93-15.619, *Bull. Joly*, 1995, p. 1058.

3399 Il suffit que les dettes en question soient nées antérieurement à l'opération sans qu'elles ne doivent nécessairement être déjà exigibles. Voir en ce sens : Th. BONNEAU, « Cautionnement », note sous Cass. com., 17 juillet 2001, *Droit des sociétés*, n° 11, novembre 2001, comm. 157 et A. PRÜM, *op. cit.*, alerte 1 et Cass. com. 17 juillet 2001, *Juris-Data*, n° 010686.

3400 C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, pp. 100, n° 226 ; D. LEGEAIS, « Dettes nées après la fusion-absorption », note sous Cass. com., 17 mai 2017, *Revue de droit bancaire et financier*, juillet – août 2017, comm. 162 et D. LEGEAIS, « Sort du cautionnement garantissant le bail en cas de fusion-absorption de la société créancière ou débitrice », *op. cit.*, p. 6.

3401 Fl. GEORGE, « La cession des contrats dans les transmissions d'universalité en droit belge » in *La transmission des obligations en droit français et en droit belge : approches de droit comparé.*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 1212 et 1213, n° 40 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 120 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 304, n° 446 et Bruxelles, 21 juin 2016, *RDC-TBH*, 2017, pp. 544–549. Voir également H. DE WULF, « Borgtocht en fusie, enkele opmerkingen », *RDC-TBH*, 2017/5, pp. 549–551 qui limite la portée de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 21 juin 2016.

3402 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 34 ; N. LEONARD et St. SIMON in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 14 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 23.

§1. Une opération potentiellement au détriment des créanciers

696. Six catégories de risques. Une scission transfrontalière est susceptible d'être la source de nombreux risques pour les créanciers. Si certains sont propres aux créanciers de la société scindée, d'autres sont communs à tous les créanciers des sociétés impliquées dans l'opération. De même, certains risques se manifesteront tant dans un contexte interne que dans un contexte transfrontalier, alors que d'autres sont propres aux seules opérations transfrontalières. Pour la suite de l'analyse, et afin de parvenir à répertorier de manière suffisamment précise ces différents risques, il est opportun d'opérer une classification en fonction de leur origine. Une distinction sera ainsi opérée entre (i) le risque lié à l'aléa économique de l'opération, (ii) les risques liés à la transmission à titre universel du patrimoine, (iii) les risques liés à la nature transfrontalière de l'opération communs avec les fusions transfrontalières, (iv) les risques liés à la pérennité économique d'une des sociétés impliquées, (v) les risques liés à l'érosion financière des sociétés bénéficiaires et (vi) les risques liés aux spécificités d'une scission qui se caractérise par une pluralité de sociétés bénéficiaires.

697. Un risque lié à l'aléa économique de l'opération. Le premier risque posé par une scission transfrontalière est celui du risque d'échec économique de l'opération[3403]. En effet, si une scission transfrontalière est certes susceptible de renforcer ou de préserver une entreprise en perte de vitesse[3404], le résultat n'en est pas pour autant garanti et elle pourrait même se révéler être une mauvaise décision stratégique. S'il est évident que ce risque affectera en priorité les associés des sociétés impliquées, ce dernier, une fois que les pertes excéderont les capitaux propres de la société concernée, ne manquera pas d'affecter également les créanciers sociaux à la fois de la société scindée et des sociétés bénéficiaires[3405], *a fortiori* si on prend en compte la hausse massive du financement par dette externe des entreprises en réaction à la pandémie[3406].

698. Un double risque lié à la transmission à titre universel du patrimoine de la société scindée. Une opération de scission transfrontalière aura nécessairement un double impact direct sur les créanciers sociaux de la société scindée par le biais de la transmission à titre universel de patrimoine dont elle s'accompagne. Ainsi, ceux-ci pourront voir leur situation se détériorer par le fait qu'une scission entraîne tout d'abord une substitution de débiteur sans leur accord[3407].

3403 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 50.

3404 Sur l'intérêt économique des scissions, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2.

3405 J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 71, n° 144 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 50.

3406 D. GUINOT, « Covid-19, l'endettement des entreprises, une menace pour les banques », *Le Figaro*, 23 juin 2020, disponible sur https://www.lefigaro.fr/ (28/10/2020) ; E. LEDERER et E. BENHAMOU, « Covid-19, en deux mois, l'endettement des entreprises a bondi de 90 milliards d'euros », *Les Echos*, 29 mai 2020, disponible sur https://www.lesechos.fr/ (28/10/2020) et Fr. ROLLIN, « La hausse de l'endettement va-t-elle nous précipiter dans une seconde récession ? », *Capital*, 21 octobre 2020, disponible sur https://www.capital.fr (28/10/2020).

3407 Voir en ce sens au sujet des fusions : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 274 ; G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 60 ; B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 1 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n° 848 ; L. L. HANSEN, *op. cit.*, p. 192 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 334, n° 4 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *ZGR*, 1/2009, p. 76 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 309 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 1 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 470 ; J. SCHMEIDLER,

Bien que d'un point de vue historique cette caractéristique n'ait pas toujours été évidente[3408], il est à présent établi que l'opération aura pour conséquence que les créanciers sociaux de la société scindée se retrouveront avec un nouveau débiteur qu'ils n'auront pas choisi au moment de contracter avec la société scindée. S'il est toutefois évident que la confusion des patrimoines ne mettra pas nécessairement en cause la capacité des sociétés bénéficiaires à désintéresser tous les créanciers sociaux[3409], il convient de compenser l'absence d'accord exprès des créanciers à la substitution de débiteur qui leur est imposée dans le cadre de la scission en cas de risque que leur créance ne soit pas remboursée à terme[3410]. Ceci s'imposera tout particulièrement lorsque le passif d'une des sociétés bénéficiaires excède l'actif de la fraction du patrimoine de la société scindée qui lui sera attribuée[3411], en cas de « scission silencieuse »[3412] où une filiale transfère à sa société mère une fraction de son patrimoine ayant un actif net négatif ou encore en cas de passif inconnu ou dissimulé de la société absorbée au moment de la réalisation de l'opération[3413]. À ce premier risque propre aux créanciers de la société scindée s'ajoute, dans l'hypothèse d'une scission au profit d'une ou de plusieurs sociétés préexistantes, le risque d'une mise en concurrence avec les créanciers des sociétés bénéficiaires[3414]. S'il est vrai que ce risque, négligeable en cas d'opération n'impliquant que des sociétés en bonne

op. cit., pp. 73 et s. ; F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 203, n° 35 ; A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 111 et M. WINNER, « Creditor protection in mergers in Europe » in Er. KOVÁCS et M. WINNER (dir.), *Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues*, Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 50. Voir également à propos des scissions transfrontalières : Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 86 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 322 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 49. Voir également à propos des scissions internes : P. STOCKENHUBER, « Das österreichische Spaltungsgesetz », *RIW*, 1994, p. 285.

3408 Avant la transposition de la troisième directive en droit belge, on considérait qu'une fusion ne libérait pas la société absorbée de son passif en raison du fait qu'une substitution de débiteur n'était possible qu'avec l'accord des créanciers, de sorte qu'à leur égard la fusion leur fournissait la société bénéficiaire comme débiteur additionnel. Voir à ce sujet : G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *ibidem*, p. 60 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *ibidem*, n° 848 et Mons, 17 mai 1988, *J.L.M.B.*, 1988, p. 1314 pour un cas d'application de la survie passive de la société absorbée pour répondre des actions des créanciers.

3409 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 99.

3410 G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 60 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 309 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 470.

3411 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, « Creditor protection in cross-border mergers ; unfinished business », *Utrecht Law Review*, vol. 4, 2008/1, p. 34.

3412 Par « scission partielle silencieuse », on vise « l'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes ses parts ou actions et autres titres conférant le droit de vote » et qui ne s'accompagne par conséquent pas de l'attribution d'actions additionnelles de la société bénéficiaire. Voir art. 12:8, 2° du CSA ; Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 300 et D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, pp. 331 et 332, n° 9.

3413 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. PASSARGE et M. STARK, « Gläubigerschutz bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *GmbHR*, 2007, pp. 806 et 807 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 75 et 76.

3414 Voir en ce sens à propos des fusions : D. BEUTEL, *ibidem*, p. 274 ; G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *op. cit.*, p. 60 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n° 848 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 334, n° 4 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 76 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 309 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 470 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, pp. 534 et 535 ; A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 110 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 52.

santé financière[3415], concerne tant les créanciers de la société scindée que ceux des sociétés bénéficiaires[3416], il n'empêche que la situation de ces derniers est toutefois moins problématique dans la mesure où les fractions du patrimoine de la société scindée, du fait de l'émission des nouvelles actions dont s'accompagne nécessairement l'opération de scission, auront en principe une valeur positive[3417]. Cependant, dans l'hypothèse de la scission d'une société financée de manière très conservative au profit de deux sociétés bénéficiaires financées par des tiers de manière beaucoup plus agressive, force est de constater que la situation des créanciers de la société financée de manière plus prudente se détériorera du fait de la scission, ne fût-ce qu'au regard du fait que les créanciers des sociétés largement financées de manière agressive par des capitaux externes auront veillé à se prémunir efficacement contre le risque accru au moyen de taux d'intérêt plus élevés ou de conditions d'octroi de crédit plus strictes[3418]. En effet, dans une telle hypothèse, la qualité de la créance des créanciers de la société scindée se verra réduite du fait de l'opération, alors que celle des créanciers des sociétés bénéficiaires s'en trouvera renforcée. Ces deux risques ont pour particularité d'être communs avec les fusions transfrontalières et de se retrouver tant dans un contexte interne que dans un contexte transfrontalier.

699. Un risque lié à la nature transfrontalière de l'opération. Si du point de vue des créanciers des sociétés bénéficiaires, il importe peu que l'opération soit interne ou transfrontalière[3419], il n'en va pas nécessairement de même pour les créanciers de la société scindée. En effet, si ces derniers souhaitent faire valoir leurs droits postérieurement à la réalisation de la scission, ils devront s'en remettre aux mécanismes du droit national des sociétés bénéficiaires, celui-ci pouvant s'avérer moins protecteur tant en matière de droit des sociétés qu'en matière de procédures d'insolvabilité[3420] ou simplement fort différent d'un point de vue procédural[3421] ou

3415 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 50.

3416 Voir en ce sens à propos des fusions : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 2 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 309 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 83, n° 169 et M. WINNER, *ibidem*, p. 50.

3417 À ce sujet, voir *supra* n°s 118 à 120 et P. HAINAUT – HAMENDE, *op. cit.*, n° 848. *Contra* au sujet des fusions : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 22, n° 2 qui envisage explicitement le cas où le passif de la société absorbée excédera son actif net. Une telle situation ne se conçoit toutefois que dans l'hypothèse d'une opération ne s'accompagnant pas de l'émission d'actions ou en cas de sous-évaluation du passif ou de passif inconnu.

3418 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 50 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 52.

3419 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. WINNER, « Creditor protection… », *ibidem*, p. 61.

3420 F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 28 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 81 et 471 ; M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, pp. 809 et 810 ; M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 51 et M. WINNER, *ibidem*, p. 61.

3421 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, COM (84) 727 final, 23 janvier 1985, p. 9 ; Étude d'impact, p. 22 et T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 27, n° 14 ; G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 15, n° 43 ; M. PASSARGE et M. STARK, *ibidem*, p. 809 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 322 et M. WINNER, *ibidem*, p. 61. Pour un point de vue critique de ce risque voir : Chr. LOUVEN, « Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie », *op. cit.*, p. 2028 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 19 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *ibidem*, p. 51. Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 28.

de ses mécanismes de protection[3422]. À titre d'illustration, à l'égard du droit des sociétés, ce risque se manifestera notamment lorsque les règles relatives au capital social minimum ainsi qu'au maintien de celui-ci applicables dans l'État membre des sociétés bénéficiaires s'avéreront moins protectrices que celles de l'État membre de la société scindée[3423] ou encore lorsque les règles limitant les distributions faites aux associés sont plus souples dans l'État membre des sociétés bénéficiaires que dans celui de la société scindée[3424]. Pour ce qui est des règles relatives à l'insolvabilité, on mentionne traditionnellement le fait que les conditions pour engager la responsabilité des dirigeants sont susceptibles d'être plus restrictives dans l'État membre des sociétés bénéficiaires[3425]. En ce qui concerne les aspects procéduraux, l'opération pourra avoir pour conséquence que le domicile de la société scindée sera transféré d'un État membre à un autre. Or, selon l'art. 4, § 1er du Règlement Bruxelles I*bis*[3426], la règle par défaut en matière de compétence judiciaire est que les juridictions compétentes sont déterminées par le domicile du défendeur, ce qui pour une personne morale correspond à son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement[3427]. De même, à l'égard des procédures d'insolvabilité, le Règlement Insolvabilité[3428] prévoit que les juridictions compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité sont celles de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le « centre des intérêts principaux du débiteur », ce dernier étant présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire pour peu que celui-ci n'ait pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Du point de vue des créanciers, ceci signifie, qu'à moins de tomber dans un des cas de compétences spéciales prévus par le Règlement Bruxelles I*bis*[3429] ou d'avoir prévu contractuellement une clause attributive de juridiction[3430], ils encourront un risque du fait de la scission transfrontalière, à titre d'illustration, lorsque les procédures judiciaires sont beaucoup plus longues dans l'État membre des

3422 C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, « Cross-border reincorporations in the European Union, the case for comprehensive harmonisation », *Journal of Corporate Law Studies*, 2018, vol 18, p. 2 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 471 ; M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 809 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 242 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 322 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *ibidem*, p. 51.

3423 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 9 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 28 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 320 et 321 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 ; J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 471 et M. PASSARGE et M. STARK, *ibidem*, p. 809.

3424 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 51 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 61 qui cite l'exemple des règles restrictives applicables en droit autrichien aux distributions faites par une société à responsabilité limitée à ses associés.

3425 R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 471 ; M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 809 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 109, n° 225.

3426 Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), *J.O.*, L 351, 20 décembre 2012, pp. 1–32 (ci-après le « **Règlement Bruxelles I*bis*** »).

3427 Art. 63, § 1er du Règlement Bruxelles I*bis*.

3428 Art. 3, § 1er du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, *J.O.*, L 141, 5 juin 2015 (ci-après le « **Règlement Insolvabilité** »).

3429 Art. 7 et s. du Règlement Bruxelles I*bis*.

3430 Art. 25 du Règlement Bruxelles I*bis*.

sociétés bénéficiaires[3431] ou encore si les frais de justice demeurent à charge du demandeur même lorsqu'il obtient gain de cause[3432]. Si ce risque est parfois présent à l'esprit des législateurs nationaux au moment de l'adoption de normes introduisant une certaine flexibilité en termes de mobilité transfrontalière au sein du marché intérieur[3433], ce n'est pas forcément le cas[3434]. En tout état de cause, à l'égard des scissions transfrontalières, il convient de remarquer qu'il n'impactera pas tous les créanciers impliqués. En effet, seuls les créanciers de la société scindée dont la créance est transférée à une société bénéficiaire relevant du droit d'un État membre distinct de celui de la société scindée y seront exposés. En outre, il convient de remarquer que ce risque affectera davantage les petits créanciers ne disposant que de peu de moyens ou de temps, alors que les créanciers importants d'une part, seront plus habitués à des procédures internationales et d'autre part, par la force de négociation dont ils jouissent, pourront se prémunir efficacement contre ce risque[3435].

700. Un risque lié à la pérennité économique d'une des sociétés impliquées. Ce risque, commun aux opérations internes et transfrontalières[3436], est susceptible de se manifester à la fois au niveau tant de la société scindée que des sociétés bénéficiaires. En ce qui concerne tout d'abord la société scindée, la Directive Sociétés permet explicitement aux États membres d'autoriser la scission interne par le biais de l'absorption d'une société faisant l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue[3437]. À l'égard des scissions transfrontalières n'impliquant pas une société bénéficiaire préexistante, la Proposition de la Commission prévoyait à l'origine l'exclusion pure et simple des sociétés faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de liquidation ou d'insolvabilité[3438], d'une mesure préventive de restructuration en raison de la probabilité d'insolvabilité[3439], ainsi que celles qui se trouvent en état de cessation de paiements[3440], les sociétés faisant l'objet d'une mesure nationale préventive afin d'éviter une des trois situations d'exclusion précédentes[3441] ainsi que celles qui font l'objet de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive

3431 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7.

3432 *Ibidem*.

3433 Voir au sujet de la société européenne : Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Europäischen Gesellschaft (SEEG), exposé des motifs, *BT-Drs.*, 2004, n° 15/3405, p. 35. Voir au sujet des scissions transfrontalières : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 311.

3434 Voir au sujet des fusions transfrontalières : Projet de loi portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2007–2008, n° 1012/001, pp. 52 à 69 où ce risque n'est mentionné à aucune reprise.

3435 M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 808.

3436 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 ; FL. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 9 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 318 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 et M. PASSARGE et M. STARK, *ibidem*, p. 807.

3437 Art. 87, § 3 et 135, § 4 de la Directive Sociétés.

3438 Art. 160*quinquies*, § 2, (a) de la Proposition de la Commission.

3439 Art. 160*quinquies*, § 2, (b) de la Proposition de la Commission.

3440 Art. 160*quinquies*, § 2, (c) de la Proposition de la Commission.

3441 Art. 160*quinquies*, § 2, (e) de la Proposition de la Commission.

2014/59/UE[3442][3443], mais le législateur européen a, en définitive, préféré tempérer ce choix en laissant aux législateurs nationaux le choix d'exclure ou non les sociétés soumises à des procédures d'insolvabilité ou des cadres de restructuration préventifs[3444], celles soumises à des procédures de liquidation mais n'ayant pas encore commencé la répartition de leurs actifs à leurs associés[3445] et celles faisant l'objet de mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, § 1er de directive 2014/59/UE[3446][3447]. Or, une scission impliquant une société en proie à des difficultés financières et dont la situation risque de se détériorer davantage risque de nuire sensiblement à la solvabilité des sociétés saines et ce, au détriment des créanciers préexistants de celle-ci[3448]. Si ce problème, susceptible de survenir principalement dans le cadre d'opérations intragroupes[3449], concerne certes les créanciers des sociétés bénéficiaires qui viendraient à absorber une fraction du patrimoine d'une société en proie à des difficultés financières, la situation inverse est également envisageable car l'absorption d'une société en bonne santé financière par des sociétés dont la solvabilité est douteuse, par exemple en raison de pertes importantes ou de manque de liquidités[3450], présente un risque considérable pour les créanciers de la société scindée[3451][3452].

701. Le risque lié à l'érosion financière engendrée par la scission. Un risque supplémentaire provient du fait qu'une scission est susceptible d'engendrer des obligations de paiement additionnelles et immédiatement exigibles au profit des associés ou des porteurs de titres des sociétés bénéficiaires[3453], comme (i) le paiement d'une soulte en espèces en complément des nouvelles actions[3454], (ii) l'exercice de droits de retrait permettant aux associés de faire

3442 Directive (UE) 2014/59 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive (CEE) 82/891 du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil (CE) 2001/24, (CE) 2002/47, (CE) 2004/25, (CE) 2005/56, (CE) 2007/36, (UE) 2011/35, (UE) 2012/30 et (UE) 2013/36 et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 1093/2010 et (UE) 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 173, 12 juin 2014, pp. 190 à 348.

3443 Art. 160*quinquies*, § 2, (d) de la Proposition de la Commission.

3444 Art 160*bis*, § 5, (a) de la Directive Mobilité.

3445 Art 160*bis*, § 5, (b) de la Directive Mobilité.

3446 Art 160*bis*, § 5, (c) de la Directive Mobilité.

3447 Sur ces évolutions du champ d'application de la Directive Mobilité, voir *supra* nos 337 à 340.

3448 Étude d'impact, p. 22 et S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 77 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 37 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 74 et 75 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 203, n° 35.

3449 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMEIDLER, *ibidem*, pp. 85 et 86, n° 174.

3450 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 39 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 275 ; R. FRENZEL, *op. cit.*, pp. 364 et 365 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 807.

3451 Voir en ce sens à propos des fusions : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 52 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n° 848 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 318 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122j, n° 7.

3452 Pour un cas d'application en matière de fusions transfrontalières qui concernait la fusion par le biais de l'absorption par une société britannique insolvable de 14 filiales espagnoles dont 13 étaient en bonne santé financière, voir *Re Diamonds Resorts (Europe) Ltd* [2013] B.C.C. 275.

3453 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 334, n° 4 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 77 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 53.

3454 À ce sujet voir *supra* n° 453.

racheter leurs actions[3455] ou encore (iii) les indemnités à verser aux associés lésés si le rapport d'échange s'avère avoir été incorrectement fixé[3456]. Du point de vue des créanciers, de tels paiements s'assimilent à des distributions aux associés venant éroder leur gage commun[3457]. Dans un même ordre d'idées, les mécanismes spécifiques de protection de la participation des travailleurs[3458] et les négociations potentiellement prolongées avec le groupe spécial de négociation sont susceptibles de générer des coûts additionnels pour la société et difficilement prévisibles. En outre, certains mécanismes de protection individuels, telle que la possibilité pour un créancier de demander une garantie adéquate en cas de risque concret pour le remboursement de sa créance, vont certes profiter au créancier isolé qui aura accompli toutes les démarches nécessaires à cet effet, mais viendront également encore aggraver la situation des autres créanciers[3459].

702. Un risque lié aux spécificités d'une scission. Au-delà de ces premiers risques communs avec les fusions transfrontalières, les scissions transfrontalières emportent en sus un risque additionnel lié à l'éclatement du patrimoine de la société scindée, c'est-à-dire du gage commun des créanciers de celle-ci, et sa répartition entre plusieurs sociétés bénéficiaires telle que décidée par les associés[3460]. En effet, les associés jouissent d'une grande liberté pour déterminer la répartition des éléments d'actif et de passif entre les différentes sociétés bénéficiaires, ce qui leur laisse une certaine marge de manœuvre pour agir dans leur propre intérêt au détriment des créanciers. En d'autres termes, une scission transfrontalière est susceptible d'entraîner une forme d'expropriation des créanciers de la société scindée en ce que les associés qui décideront à terme de l'allocation des fractions de patrimoine aux différentes sociétés bénéficiaires pourraient être tentés de répartir celles-ci de manière que le remboursement de certaines créances soit compromis, ou à tout le moins rendu plus aléatoire par le fait même de l'opération.

703. Des créanciers impactés différemment. La première conclusion qui ressort clairement de cette analyse des risques est que si tous les créanciers des sociétés impliquées sont susceptibles de voir leur position se détériorer du fait d'une opération librement décidée par les associés, l'opération présente certains risques accrus propres aux créanciers de la société scindée[3461]. En effet, le double risque lié à la transmission à titre universel du patrimoine de la société scindée, le risque lié à la nature transfrontalière de l'opération ainsi

3455 À ce sujet voir *infra* n°s 1009 à 1054.
3456 À ce sujet voir *infra* n°s 1059 à 1083.
3457 Voir en ce sens à propos des fusions : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 52.
3458 À ce sujet voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2.
3459 Voir en ce sens à propos des fusions : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 334, n° 4.
3460 Étude d'impact, p. 68 ; Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, www.lachambre.be (16/02/2018), p. 30 et G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 72 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 77 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 7 ; P. STOCKENHUBER, *op. cit.*, p. 285 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 51.
3461 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. WINNER, « Protection of creditors… », *ibidem*, p. 52 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 51.

que le risque lié à l'allocation des fractions du patrimoine de la société scindée librement décidée par les associés touchent soit exclusivement, soit principalement, les créanciers des sociétés absorbées.

704. Des risques de natures différentes. La deuxième conclusion que l'on peut tirer est que la nature des risques encourus par les créanciers n'est pas uniforme[3462]. En effet, le risque lié à l'aléa économique de l'opération, le double risque lié à la transmission à titre universel du patrimoine de la société scindée, le risque lié à la pérennité économique d'une des sociétés impliquées, le risque lié à l'érosion financière engendrée par la scission et le risque lié aux spécificités d'une scission ont pour point commun d'être intimement liés à la situation patrimoniale des sociétés bénéficiaires et sont donc d'une nature davantage économique. *A contrario*, le risque lié à la nature transfrontalière de l'opération est essentiellement juridique[3463]. Lors de l'examen des différents mécanismes de protection des créanciers[3464], il conviendra dès lors de vérifier si cette différence de nature est susceptible d'avoir un impact sur leur efficacité.

§ 2. Un juste équilibre à trouver

705. Plan du § 2. Pour pouvoir apprécier l'exigence d'un double équilibre qui s'impose à tout mécanisme de protection des intérêts des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière, il importe de se pencher en premier lieu sur l'incidence de la nécessité économique des scissions transfrontalières (A.) pour, en second lieu, s'intéresser à l'impact de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement (B.).

A. *La nécessité économique des scissions transfrontalières*

706. La nécessité d'un régime flexible. Un mécanisme de protection des créanciers efficace doit correspondre à un équilibre entre la nécessité d'éviter que l'opération de scission transfrontalière ne détériore sensiblement la situation des créanciers tout en veillant à ne pas condamner les entreprises en leur refusant une opération qui peut s'avérer vitale d'un point de vue économique pour garantir leur pérennité[3465]. Cette exigence, qui n'a pas échappé au législateur européen dans le cadre de la mise en place d'une procédure efficace de scission transfrontalière[3466], implique que le régime de protection devra nécessairement faire preuve d'une certaine flexibilité pour s'accommoder des

3462 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 52.
3463 *Ibidem*.
3464 Voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1.
3465 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 11 et F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 27 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 28, n° 47 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 322 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 45.
3466 Le 6e considérant de la Proposition du Parlement prévoit ainsi qu' « [u]n cadre juridique harmonisé contribuerait à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement tout en garantissant une protection adéquate aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les associés ». À ce sujet, voir également : M. WINNER, *ibidem*, p. 45.

spécificités propres à chaque cas d'espèce. À titre d'illustration, en adoptant son régime de protection dérogatoire pour protéger les créanciers de la société absorbée dans le cadre d'une fusion-émigration, le législateur allemand a prévu que celui-ci ne trouverait à s'appliquer que si les créanciers sociaux parvenaient à établir que l'opération représentait un risque pour le paiement de leur créance, cette condition devant permettre aux juridictions compétentes de disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour leur permettre de développer des critères à même d'atteindre ce délicat point d'équilibre entre intérêts des créanciers et intérêts de la société[3467]. Cette nécessité de pondérer les différents intérêts en jeu explique également pourquoi tous les types de risques subis par les créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière ne peuvent pas nécessairement donner lieu à une mesure de protection. Il a ainsi pu être avancé que le rôle d'un régime de protection des créanciers optimal était de protéger les créanciers contre les risques qu'un créancier parfaitement informé et rationnel n'accepterait pas au moment de contracter, à l'exception du risque économique inhérent au principe de la responsabilité limitée[3468]. C'est ainsi, à titre d'illustration, qu'à l'égard du régime allemand des fusions transfrontalières, la grande majorité des auteurs considère que le fait que les règles en vigueur dans l'État membre de la société bénéficiaire soient moins strictes en matière de capital social minimum et de maintien de celui-ci ne suffit pas à établir que les créanciers de la société absorbée soumise à des règles plus sévères encourent un risque concret du fait de l'opération leur ouvrant un droit à l'obtention de garanties[3469]. En revanche, il est indispensable de mettre en place des mécanismes de protection suffisamment protecteurs aux yeux des créanciers car à défaut, il y a un risque d'une augmentation des taux d'intérêt imposés par les créanciers ou, tout simplement, d'augmenter les coûts d'un financement au moyen de capitaux tiers[3470]. En effet, les études économiques réalisées en la matière ont établi que des mécanismes de protection des créanciers renforcés étaient généralement liés à une plus grande disponibilité

3467 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, exposé des motifs, *BT-Drs.*, 2006, n° 16/2919, p. 17.

3468 Selon les termes de P. Mülbert, « *creditors are to be protected against those risks that a fully informed rational creditor would not accept voluntarily when contracting the claim in question – except for the risk of business misfortune, since the essence of the principle of limited liability company is to burden creditors with this risk* ». Voir P. MÜLBERT, *op. cit.*, p. 15.

3469 *Pro* : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 9 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7. Voir également W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 qui, de manière plus nuancée, considère toutefois que les divergences nationales à cet égard peuvent constituer un risque concret pour les créanciers dans des cas extrêmes. Voir également S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 321 et J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, p. 166 qui considèrent qu' (i) une telle différence de règles ne met pas concrètement en péril le remboursement de la créance si l'opération concerne des sociétés anonymes ou des sociétés européennes en raison de l'harmonisation opérée par la directive et (ii) de telles différences entre législations d'États membres peuvent être à l'origine d'un risque concret pour les créanciers justifiant une intervention en leur faveur si les sociétés impliquées sont des sociétés de capitaux autres que des sociétés anonymes et des sociétés européennes. Voir également R. FRENZEL, *op. cit.*, p. 364 qui, en partant de l'exemple de la fusion transfrontalière par absorption d'une société allemande par une *private company limited by shares* anglaise considère que les seules divergences entre règles nationales relatives au maintien du capital social ne suffisent pas à justifier l'octroi d'une garantie aux créanciers allemands.

3470 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 12.

de dette externe[3471]. En outre, on ne peut que relever le caractère fictionnel et irréaliste de la conception du créancier en tant qu' « individu calculateur, rationnel et intéressé »[3472] évoquant l' « *homo oeconomicus* » de la doctrine contractarienne néoclassique de la firme[3473]. En effet, alors que ce modèle pourrait dans certaines circonstances convenir aux grands créanciers que sont les banques, force est de constater qu'il est foncièrement inadapté aux petits créanciers que sont, par exemple, les fournisseurs. En outre, compte tenu de l'efficacité de certains mécanismes contractuels développés par la pratique[3474], il s'avère qu'un tel créancier idéal ne nécessiterait aucune protection spécifique puisqu'il se sera dès l'origine prémuni contre les risques encourus du fait d'une scission transfrontalière au moyen de clauses adéquates. Pour finir, ce modèle de référence n'est que d'un maniement malaisé à l'égard des créanciers délictuels qui, par définition, n'ont conclu aucun contrat avec la société et ne sont, en toute vraisemblance, pas prêts à accepter le moindre risque. Il serait dès lors préférable de lui substituer un autre critère de référence, plus à même de tenir compte du caractère foncièrement hétérogène de la notion de créancier. Ainsi, en s'inspirant du régime de la société européenne[3475], le critère devrait être que la scission transfrontalière ne doit pas sensiblement augmenter les risques encourus par les créanciers par rapport à la situation dans laquelle aucune scission ne serait accomplie[3476]. En d'autres termes, l'idéal serait que l'opération demeure à tout le moins neutre du point de vue des créanciers en empêchant les associés de recourir à une scission pour tenter de les exproprier[3477].

B. *L'incidence de la liberté d'établissement*

707. Les enseignements de la Cour de justice. Cette trame de fond, déjà complexe, doit encore être complétée par les enseignements de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement. En effet, si la protection des intérêts des créanciers a, de longue date, été reconnue comme une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la liberté d'établissement[3478], les contours de celle-ci tels que dessinés par la jurisprudence de la Cour de justice demeurent fragmentaires. Compte tenu du fait que les scissions transfrontalières constituent des « *modalités particulières d'exercice de*

[3471] Voir en ce sens : J. ARMOUR, G. HERTIG et H. KANDA, « Transactions with creditors », *op. cit.*, p. 109 ; S. DJANKOV, O. HART, C. MACLIESH et A. SHLEIFER, « Debt enforcement around the world », *Journal of Political Economy*, 2008, vol. 116(6), pp. 1105–1149 et R. HASELMANN, K. PISTOR et V. VIG, « How law affects lending », *Review of Financial Studies*, 2010, vol 23(2), pp. 549–580.

[3472] L'expression est empruntée à J. E. Stiglitz qui y recourt pour critiquer l' « *homo oeconomicus* » à la base de la doctrine contractarienne néoclassique de la firme. Voir : J.E. STIGLITZ, *Le triomphe de la cupidité*, Paris, LLL, 2010, p. 397. Voir également à ce sujet : I. CORBISIER, *La société : contrat ou institution*, *op. cit.*, p. 397.

[3473] Pour un exposé détaillé de cette doctrine, voir : I. CORBISIER, *ibidem*, pp. 256 à 300. Pour une étude des critiques de cette doctrine, voir : I. CORBISIER, *ibidem*, pp. 301 à 340.

[3474] À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 3.

[3475] Selon le 24e considérant du Règlement sur la Société européenne qui vise plus particulièrement l'hypothèse du transfert de siège, l'opération « ne doit pas affecter les droits nés avant le transfert ».

[3476] Voir en ce sens : Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 180.

[3477] Voir en ce sens à propos des fusions : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 51.

[3478] Arrêt *Centros*, pt. 39 ; arrêt *Überseering*, pt. 92 ; arrêt *Inspire Art*, pt. 132 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; et arrêt *Polbud*, pt. 54.

la liberté d'établissement »[3479], un bref examen de la jurisprudence de la Cour de justice permettra d'isoler certains principes découlant des articles 49 et 54 du TFUE et applicables de manière générale à tout régime de protection des créanciers.

708. L'arrêt *Centros*. Ainsi, dans l'arrêt *Centros*[3480], la Cour de justice a considéré que le refus d'immatriculation par l'administration danoise de la succursale de la *limited company* britannique des époux Bryde au motif que ceux-ci cherchaient en réalité à éluder les règles danoises sur la constitution et la libération du capital social minimum ne remplissait pas les conditions du « *Gebhard test* » et ne pouvait être justifié par la raison impérieuse d'intérêt général de protection des intérêts des créanciers[3481]. En effet, d'une part la mesure n'est pas propre à garantir une protection efficace des créanciers puisque si la *limited company* avait exercé une activité au Royaume-Uni, l'administration danoise aurait accepté l'immatriculation de sa succursale sans autre considération pour les créanciers[3482]. Ensuite, comme la société Centros Ltd. se présente comme une société de droit britannique, les créanciers sont directement avertis de ce qu'ils traitent avec une société de droit étranger et peuvent s'en remettre à certaines règles de droit communautaire destinées à protéger leurs intérêts[3483]. À titre d'illustration de ces règles de droit communautaire, la Cour cite ainsi la quatrième directive[3484], ainsi que (ii) la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État[3485][3486]. Pour finir, la Cour insiste sur le fait que le refus pur et simple d'immatriculation ne respecte pas davantage le principe de proportionnalité en ce qu'il existe des mesures moins intrusives vis-à-vis des libertés fondamentales pour garantir une protection efficace des créanciers telles que « la possibilité légale aux créanciers publics de prendre les garanties nécessaires »[3487]. Ces réponses de la Cour sont précieuses pour l'étude de la protection des

[3479] Voir en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 3 ; H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 55 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1161 ; T. DRYGALA, *op. cit.*, p. 26 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 19 ; V. GEYRHALTER et Th. WEBER, *op. cit.*, p. 150 ; L. HANSEN, *op. cit.*, p. 195 ; S. HERRLER, *op. cit.*, pp. 298 et 299 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, pp. 226 et 234 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 45 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 416 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, pp. 165 et 166 ; W. MEILICKE et D. E. RABBACK, *op. cit.*, pp. 126 et 127 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 320 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 236 ; J. SEDEMUND, *op. cit.*, p. 521 ; M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 314 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 358 ; Chr. TEICHMANN et R. KNAIER, *op. cit.*, p. 1319 et S. WEISS et H.-T. WÖHLERT, *op. cit.*, pp. 584 et 585.

[3480] Au sujet des faits à la base de cet arrêt, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1, Section 4, § 3, B., 2., 2.1.

[3481] Arrêt *Centros*, pts. 32–39.

[3482] Arrêt *Centros*, pt. 35.

[3483] Arrêt *Centros*, pt. 36.

[3484] Quatrième directive (CEE) 78/660 du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, § 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, *J.O.*, L 222, 14 août 1978, pp. 11–31.

[3485] Onzième directive (CEE) 89/666 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État, *J.O.*, L 395, 30 décembre 1989, pp. 36–39.

[3486] Arrêt *Centros*, pt. 36.

[3487] Arrêt *Centros*, pt. 37.

créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière et, par le biais d'une application par analogie, il est possible d'en tirer trois enseignements distincts. Tout d'abord, l'accent semble être mis sur la vigilance des créanciers qui, dès qu'ils ont connaissance de l'opération envisagée, devraient adapter leur comportement en conséquence. Bien que la Cour ne le précise pas, il convient de relever qu'une mesure de protection préventive par le biais d'une information en temps utile des créanciers ne peut, par définition, n'être efficace qu'à l'égard des seuls créanciers volontaires. En effet, un créancier délictuel n'a que peu de chances de pouvoir adapter son comportement suite à l'annonce de l'opération, *a fortiori* si celui-ci n'a pas encore connaissance de sa qualité de créancier. Ensuite, la Cour semble s'appuyer sur l'existence d'un cadre juridique communautaire plutôt large pour relativiser la nécessité de devoir recourir à des mécanismes de protection spécifiquement liés à un certain type d'opérations[3488]. Du point de vue des scissions transfrontalières, ceci signifie qu'il conviendra d'examiner dans quelle mesure le cadre juridique général de protection des créanciers, composé entre autres du Règlement Insolvabilité, viendra relativiser la nécessité de prévoir des mécanismes de protection spécifiques aux scissions transfrontalières[3489]. Pour finir, la suggestion de la Cour de permettre aux créanciers publics de prendre les garanties nécessaires[3490] semble indiquer qu'une mesure de protection par ce moyen serait plus conforme au principe de proportionnalité.

709. L'arrêt *Inspire Art*. L'arrêt *Inspire Art*[3491], rendu quelques années plus tard, apporte un certain nombre de précisions additionnelles sur les caractéristiques que devrait revêtir un régime adéquat de protection des créanciers. Ainsi, il est tout d'abord intéressant de relever que la Commission, ignorant en cela la situation des petits créanciers et des créanciers involontaires, plaide en faveur d'une responsabilisation des créanciers limitant la nécessité de les protéger puisque « [s]i les assurances que leur donne le droit anglais ne leur suffisent pas, ils pourraient soit insister pour obtenir des garanties complémentaires, soit renoncer à contracter avec une société de droit étranger »[3492]. Ce point a été suivi par la Cour qui a jugé que les créanciers étaient suffisamment informés du fait que la société était soumise au droit anglais et que partant, l'application d'un régime d'exception n'était pas nécessaire pour les protéger davantage[3493]. Ce raisonnement a été fortement critiqué par certains auteurs dans la mesure où (i) en cas de responsabilité délictuelle de la société étrangère, les créanciers nationaux n'auront pas choisi la société débitrice[3494] et (ii) les travailleurs nationaux de la société risquent fort de se retrouver dans une position moins favorable[3495]. En outre, la Cour s'est à nouveau référée à l'existence

3488 Arrêt *Centros*, pt. 36.
3489 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 3.
3490 Arrêt *Centros*, pt. 37.
3491 Au sujet des faits à la base de cet arrêt, voir *supra* n° 190.
3492 Arrêt *Inspire Art*, pt. 125.
3493 Arrêt *Inspire Art*, pt. 135. Voir à ce sujet : H. MERKT, *op. cit.*, p. 105.
3494 *Voir en ce sens* : St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *op. cit.*, p. 63, n° 32 ; G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, *op. cit.*, p. 14 et D. ZIMMER, « Wie es Euch gefällt? Offene Fragen nach dem Überseering-Urteil des EuGH », *op. cit.*, p. 63, n° 32.
3495 St. LEIBLE in S. HEIDINGER, L. MICHALSKI, St. LEIBLE et J. SCHMIDT (dir.), *ibidem*, p. 63, n° 32.

de règles communautaires de nature plus générale et garantissant un certain niveau de protection pour relativiser la nécessité d'une mesure de protection spécifique des intérêts des créanciers en cas d'opération transfrontalière[3496]. À l'égard des scissions transfrontalières, l'arrêt *Inspire Art* ne permet pas de tirer de conclusions additionnelles par rapport à l'arrêt *Centros*, mais confirme les enseignements de ce dernier.

710. **Les arrêts *Überseering*, *Sevic* et *Vale*.** Dans l'arrêt *Überseering*[3497], la Cour a simplement considéré qu'un déni pur et simple de la capacité juridique ne saurait être justifié par la protection des intérêts des créanciers car cela équivaut à la « négation même de la liberté d'établissement »[3498]. En d'autres termes, la condition de proportionnalité imposée par le « *Gebhard test* »[3499] n'est pas remplie en l'occurrence. Cet angle d'attaque est identique à celui auquel la Cour de justice a eu recours dans l'arrêt *Sevic* en considérant que le refus général d'inscrire une fusion transfrontalière va au-delà de ce qui est nécessaire en ce qu'elle empêche la réalisation de ce type d'opérations même lorsque les intérêts, entre autres, des créanciers ne sont pas menacés[3500]. Dans la suite logique de l'arrêt *Sevic*, la Cour de justice a considéré dans l'arrêt *Vale*[3501] que le refus général par un État membre de reconnaître les transformations transfrontalières, alors même que les intérêts des créanciers ne s'en trouveraient pas menacés va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une protection efficace de ces derniers[3502]. À l'égard de l'étude des scissions transfrontalières, on peut en déduire qu'une exclusion générale des scissions transfrontalières en vue de protéger les intérêts des créanciers a très peu de chances d'être considérée comme une mesure proportionnée justifiant l'entrave à la liberté d'établissement qui en résulterait.

711. **L'arrêt *Polbud*.** Dans l'arrêt *Polbud*[3503], la deuxième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi concernait explicitement la possible justification de l'obligation en vertu du droit polonais de procéder à la liquidation d'une société souhaitant se transformer en une société de droit étranger et partant, de désintéresser les créanciers ou de constituer des sûretés en leur faveur, pouvait constituer « une mesure appropriée, nécessaire et proportionnée au regard de la sauvegarde de l'intérêt général digne de protection que constitue la préservation de l'intérêt des créanciers, des actionnaires minoritaires et des salariés de la société migrante »[3504]. Ce raisonnement n'a toutefois pas été suivi par la Cour qui a considéré qu'une obligation générale de liquidation ne

3496 Arrêt *Inspire Art*, pt. 135.
3497 Au sujet des faits à la base de cet arrêt, voir *supra* n°s 186 et 187.
3498 Arrêt *Überseering*, pt. 93.
3499 Voir à ce sujet : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 71 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 67 et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 267 et arrêt *Polbud*, pt. 52 ; arrêt *Sevic*, pt. 23 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Caixa Bank France c. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*, 5 octobre 2004, C-442/02, EU:C:2004:586, pt. 17 ; C.J.C.E., arrêt *Ciola c. Land Vorarlberg*, 29 avril 1999, C-224/97, EU:C:1999:212, pt. 16 ; arrêt *Gebhard*, pt. 37 et arrêt *Kraus*, pt. 32.
3500 Arrêt *Sevic*, pt. 30.
3501 Au sujet des faits à la base de cet arrêt, voir *supra* n° 200.
3502 Arrêt *Vale*, pt. 40.
3503 Au sujet des faits à la base de cet arrêt, voir *supra* n° 211.
3504 Arrêt *Polbud*, pt. 18.

respecte pas le principe de proportionnalité et que les intérêts des créanciers, en ce compris les créanciers publics, pouvaient être protégés de manière adéquate et moins intrusive par le biais de garanties bancaires ou de garanties équivalentes[3505]. Certains auteurs ont relativisé la portée de cette assertion de la Cour en se référant à un arrêt plus ancien[3506] pour préciser que l'État d'origine dispose d'une marge de manœuvre limitée à cet égard puisque la Cour a considéré, en matière de recouvrement d'impôts, que l'obligation de constituer une garantie bancaire ne pouvait être imposée que si une évaluation a établi un risque réel de non-recouvrement de l'impôt[3507]. Quoi qu'il en soit, il semble que la possibilité de demander des garanties soit le moyen de protection de prédilection de la Cour de justice en raison de sa proportionnalité.

SECTION 3. LES PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ APPLICABLES À LA PROTECTION DES CRÉANCIERS

712. Une application distributive de principe. Selon le régime de droit international privé applicable aux constitutions de sociétés européennes par voie de fusion[3508], aux fusions transfrontalières[3509], aux transformations transfrontalières[3510] ainsi qu'aux scissions transfrontalières[3511], les mécanismes de protection des créanciers s'appliquent distributivement[3512], de sorte que les créanciers de la société absorbée demeurent soumis au droit national applicable à celle-ci, comme s'il s'agissait d'une opération interne. Cette solution, qui découle de celle prônée par la *Vereinigungstheorie*[3513], est également celle consacrée par la Directive Mobilité[3514] tant à l'égard des scissions transfrontalières[3515] que des transformations transfrontalières[3516]. En effet, cette dernière prévoit que les « procédures et formalités à respecter », ce qui inclut les mécanismes de protection des créanciers[3517], avant l'émission du certificat de conformité seront régies par le droit de la société scindée, alors que l'autre partie suivant la réception du certificat de conformité sera régie par le droit des États membres des sociétés bénéficiaires. Cette règle de conflit de lois présente une certaine logique dans la mesure où les créanciers dont la créance est née

3505 Arrêt *Polbud*, pt. 58.
3506 M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 372.
3507 C.J.U.E., arrêt *DMC Beteiligungsgesellschaft mbH c. Finanzamt Hamburg-Mitte*, 23 janvier 2014, C-164/12, EU:C:2014:20, pts. 65–69.
3508 Art. 24, § 1er du Règlement sur la Société européenne.
3509 Art. 121, § 1er, b) et § 2 de la Directive Sociétés et 3e considérant de la Dixième Directive.
3510 A. FRANCK, *op. cit.*, p. 192.
3511 *Pro* : Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 86. *Contra* : R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 427 qui plaide en faveur d'une application cumulative.
3512 Voir en ce sens : L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556 ; U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 230 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 124–126, nos 262–268 ; Th. TILQUIN, « L'arrêt KA Finanz AG : la fusion transfrontalière et la protection des créanciers », *RDC-TBH*, 2018/1, p. 66, note 25 ; D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 583 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 59 et arrêt *KA Finanz*, pt. 61.
3513 Voir en ce sens : A. FRANCK, *op. cit.*, p. 192.
3514 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 55.
3515 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.
3516 Art. 86*quater* de la Directive Mobilité.
3517 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 55.

antérieurement à la publication du projet commun se sont fiés aux mécanismes de protection du droit national de la société scindée pour contracter avec cette dernière[3518]. L'argument selon lequel cette règle de conflit de lois s'impose également en raison du fait que les créanciers sont majoritairement localisés dans l'État membre de la société débitrice[3519] doit cependant être appréhendé avec une certaine circonspection dans la mesure où l'essor des nouvelles technologies et des contrats à distance implique potentiellement une dispersion des créanciers à travers de nombreux États membres. En outre, il convient de relever que cette règle de conflit de lois, si elle peut être adaptée aux transformations et aux fusions transfrontalières, s'avère trop simpliste à l'égard des scissions transfrontalières pour deux raisons. Tout d'abord, une référence directe au régime applicable aux scissions internes telle que celle prônée par la Directive Mobilité[3520] présuppose l'existence d'un tel régime, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la mesure où, contrairement à ce qui fut le cas en matière de fusions internes[3521], les États membres n'ont pas eu l'obligation de reconnaître obligatoirement la figure de la scission[3522]. Ensuite, plus fondamentalement, certains mécanismes de protection des créanciers nécessitent par définition une application cumulative pour être efficaces. Ce dernier point est mieux illustré par la solution appliquée par le législateur belge dans son nouveau régime des scissions transfrontalières dans la mesure où ce dernier s'applique à tous types de scissions transfrontalières[3523], alors que le régime de la Directive Mobilité exclut *ab initio* toute opération impliquant l'absorption d'une société préexistante[3524].

713. La solution plus nuancée du CSA. De prime abord, les dispositions du CSA, en prévoyant que chaque société participant à la scission devra se conformer « aux dispositions et formalités de sa législation nationale qui lui sont applicables ainsi qu'à ses titulaires de titres, organes d'administration et de contrôle, travailleurs et créanciers »[3525] semble privilégier une application distributive de principe des différents droits nationaux en présence[3526], à l'instar

[3518] Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 310. Voir également en ce sens à propos des transformations transfrontalières : A. FRANCK, *op. cit.*, p. 192.

[3519] Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : A. FRANCK, *ibidem*, p. 192.

[3520] Art. 160*quater* de la Directive Mobilité.

[3521] Selon l'art. 88 de la Directive Sociétés, « [l]es États membres organisent pour les sociétés relevant de leur législation, la fusion par absorption d'une ou plusieurs sociétés par une autre société et la fusion par constitution d'une nouvelle société ».

[3522] Selon le texte de l'art. 15, §§ 1 à 3 de la Directive Sociétés, ce n'est que « lorsque les États membres permettent » la scission par absorption, la scission par constitution de nouvelles sociétés et la scission mixte qu'ils ont l'obligation de soumettre celles-ci aux dispositions de la Directive Sociétés.

[3523] Art. 12:70 (scission par absorption) ; 12:90 (scission par constitution de nouvelles sociétés) et 12:91 (scission mixte) du CSA.

[3524] Art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité et 8e considérant de la Directive Mobilité qui justifie cette position par le fait que de telles opérations par absorption se révèlent « très complexes, nécessitant la participation d'autorités compétentes de plusieurs États membres et entraînant des risques supplémentaires en termes de contournement des règles de l'Union et des règles nationales ». Au sujet du champ d'application *ratione materiae* limité de la Directive Mobilité, voir *supra* : Première partie, Titre IV, Chapitre 1er, Section 2, § 3, B.

[3525] Art. 12:73, § 1er, 2° (scission par absorption) et 12:90, § 1er, 2° (scission par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.

[3526] Voir en ce sens : D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, p. 336.

de ce qui est prévu pour les fusions transfrontalières[3527]. Cependant, certains mécanismes de protection des créanciers ne peuvent fonctionner efficacement que par le biais d'une application cumulative[3528]. Ainsi, à l'égard du régime de responsabilité solidaire pour (i) les dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participation à la scission qui sont transférées à une autre société bénéficiaire ainsi que (ii) les dettes pour lesquelles une action en justice a été introduite par le créancier avant l'acte constatant la scission, l'article 12:17 du CSA prévoit explicitement que ce sont « les sociétés bénéficiaires » qui en seront tenues, sans faire de distinction entre opération interne et transfrontalière. Il en va de même de la possibilité pour un créancier d'une société belge d'exiger une sûreté puisque la demande en question pourra être adressée à une société bénéficiaire soumise à un autre droit national ou encore de la possibilité pour la société bénéficiaire d'écarter une demande de sûreté en payant la créance à sa valeur[3529], peu important qu'elle soit nationale ou étrangère[3530].

714. Le libre choix du mécanisme le plus favorable. Avant de conclure sur les règles de droit international privé applicables aux scissions transfrontalières, il est utile de se pencher brièvement sur la possibilité de laisser les créanciers décider à la majorité de choisir le mécanisme de protection qui leur serait applicable parmi ceux prévus par les droits des sociétés fusionnantes. Il s'agit là indéniablement d'une solution favorable aux créanciers mais qui ne peut être retenue en ce qu'elle rompt l'équilibre entre les différents intérêts en présence. En d'autres termes, comme l'objectif est que l'opération soit autant que possible neutre sur la situation des créanciers, laisser ces derniers choisir le mode de protection le plus favorable serait contraire à cet objectif en ce que certains créanciers pourraient se trouver mieux lotis avant l'opération qu'après. À titre d'illustration, ce sera notamment le cas lorsque les conditions pour l'octroi de garanties sont plus souples dans un des États membres impliqués que dans

3527 Art. 113 du Code de droit international privé belge et Th. TILQUIN et J.-A. DELCORDE, « La fusion transfrontalière… », *op. cit.*, p. 44, n° 56 et 57 ; D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *ibidem*, p. 336 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 581, n° 6. Voir également : Th. TILQUIN, « L'arrêt KA Finanz AG : la fusion transfrontalière et la protection des créanciers », *op. cit.*, p. 66, note 25 qui nuance son propos en précisant que cette application distributive ne concerne que les créanciers de la société absorbée.

3528 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 310.

3529 Art. 12:15, § 1er, al. 2 du CSA.

3530 Voir en ce sens : D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, pp. 336 et 337. Il est également intéressant de relever que c'est en ce sens que vont les travaux préparatoires. En effet, il y est précisé que « [l]a procédure de scission devra, en principe, être appliquée de manière distributive, de sorte que chaque société satisfasse aux dispositions et formalités de la législation nationale qui lui sont applicables. En ce qui concerne la société belge, il s'agit en particulier des dispositions du présent code, pour autant que l'article 12:73 n'y déroge pas. Cependant, certaines dispositions exigeront, de par leur nature, une application cumulative. Il conviendra en particulier d'être attentif aux dispositions belges visant à protéger les porteurs de titres, les travailleurs et les créanciers. Ainsi, un créancier d'une société belge scindée pourra, conformément à l'article 12:15, exiger une sûreté de la société bénéficiaire étrangère si les conditions prévues à cet article sont remplies. De même, le régime de responsabilité spécifique relatif aux scissions, prévu à l'article 12:17, pourra être applicable à une société étrangère. Ainsi, une société bénéficiaire étrangère sera solidairement tenue des dettes transférées à une autre société bénéficiaire si les conditions prévues à cet article sont remplies. ». Voir : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 310.

l'autre. En outre, une telle règle complexifierait sensiblement l'opération en ce que la protection des créanciers d'une même société est susceptible de varier considérablement en fonction du droit applicable aux autres sociétés concernées et aura pour principale conséquence d'inciter les conseillers des sociétés concernées à privilégier d'autres moyens de restructuration potentiellement plus longs, mais moins affectés d'un tel aléa juridique.

715. Conclusion intermédiaire. Il découle de ce qui précède que si une application distributive des différentes *lex societatis* en matière de protection des créanciers doit être le point de départ, cette dernière ne suffit pas à régler les différents conflits de lois susceptibles de survenir dans le cadre d'une scission transfrontalière. Cette application distributive de principe doit donc être complétée par une application cumulative des différents droits nationaux en présence lorsque l'efficacité du mécanisme de protection le requiert. Si cette solution est préférable à celle de laisser les créanciers choisir le régime de protection qui leur convient le mieux à la majorité, il reste à relever qu'elle est susceptible de complexifier significativement la procédure de scission transfrontalière. Il n'est dès lors pas surprenant de constater que lors de la consultation publique de 2015 sur les fusions transfrontalières, près de 80 % des personnes ayant répondu étaient en faveur d'une harmonisation de la protection des créanciers[3531].

SECTION 4. LA NÉCESSITÉ D'UN RÉGIME RENFORCÉ EN CAS D'OPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ?

716. Plan de la section 4. Une question importante à laquelle il convient d'apporter une réponse avant de poursuivre plus en avant l'analyse est celle de savoir si le risque engendré par la nature transfrontalière de l'opération justifie une protection renforcée par rapport à une opération purement interne à l'égard des créanciers de la société scindée. À titre liminaire, un tel régime s'imposerait en raison du fait que par l'effet de l'opération, ces créanciers se retrouveront potentiellement soumis à un droit national distinct moins protecteur à leur égard[3532] ou plus difficile à mettre en œuvre d'un point de vue procédural[3533]. Pour apporter une réponse adéquate à cette question, il convient tout d'abord d'examiner comment il y a été répondu dans le cadre des fusions transfrontalières (§ 1) ainsi que dans les régimes des scissions transfrontalières

3531 Étude d'impact, p. 20 et Consultation publique de 2015, pp. 5 et 6.

3532 F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 28 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 81 et 471 ; M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, pp. 809 et 810 ; Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 86 ; M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 51 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 61.

3533 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, COM (84) 727 final, 23 janvier 1985, p. 9 ; Étude d'impact, p. 22 et M. PASSARGE et M. STARK, *ibidem*, p. 809 et M. WINNER, « Creditor protection… », *ibidem*, p. 61. Pour un point de vue critique de ce risque voir : Chr. LOUVEN, « Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie », *op. cit.*, p. 2028 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 19 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *ibidem*, p. 51. Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *ibidem*, p. 28.

instaurés par les législateurs belge et luxembourgeois (§ 2) et européen (§ 3) pour ensuite se pencher sur l'incidence de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement sur cette question (§ 4). Cette analyse sera complétée par une étude plus détaillée des difficultés liées à la mise en œuvre des moyens de protection des créanciers suite à la réalisation d'une scission transfrontalière (§ 5) ainsi que de l'incidence d'une scission transfrontalière sur le droit applicable au contrat entre la société scindée et son créancier (§ 6). Une relativisation de l'argument classique selon lequel le droit national applicable à la société scindée à la suite de l'opération serait potentiellement moins protecteur (§ 7) devrait permettre de déterminer si une initiative européenne en matière de scissions transfrontalières devrait ou non intégrer des dispositions spécifiques pour les créanciers de la société scindée en cas de scission-émigration (§ 8).

§1. Le régime des fusions transfrontalières

A. *Perspective historique*

717. La position stricte de la proposition de directive de 1985. Avant de s'interroger sur le régime actuel des fusions transfrontalières, il est intéressant de relever que les rédacteurs de la proposition de dixième directive de 1985 avaient déjà considéré que, compte tenu de l'harmonisation des fusions internes, « il convient de considérer que les créanciers trouveront leur meilleure protection dans le fait de bénéficier du même système de protection que celui applicable dans le cas d'une fusion interne »[3534], cette dernière proposition prohibant par ailleurs explicitement la mise en place d'un système de protection différent de celui applicable à l'hypothèse d'une fusion purement nationale[3535]. Il s'ensuit qu'au moment de l'élaboration de cette proposition de directive, une protection renforcée des créanciers de la société absorbée dans le cadre d'une fusion transfrontalière apparaissait comme superflue.

B. *Le régime de la Directive Sociétés*

718. La réponse ambiguë de la Directive Sociétés. Contrairement à la position claire de la proposition de directive de 1985, il convient de relever que le principe de l'application subsidiaire du droit national à l'égard des mécanismes de protection des créanciers figurant dans la Directive Sociétés est formulé de manière ambiguë. En effet, celui-ci semble, tout en insistant sur le fait que le régime de protection des créanciers relève du droit national applicable à

[3534] Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, exposé des motifs, COM (84) 727 final, présentée par la Commission au Conseil le 14 janvier 1985, *J.O.*, n° C 23/11, 23 janvier 1985, p. 9.

[3535] Art. 9, § 2 de la Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, exposé des motifs, COM (84) 727 final, présentée par la Commission au Conseil le 14 janvier 1985, *J.O.*, n° C 23/11, 23 janvier 1985.

la société débitrice, imposer de tenir compte du caractère transfrontalier de l'opération. Selon l'article 121, § 1er, b) de la Directive Sociétés, chaque société participant à une fusion transfrontalière se doit ainsi de se conformer « aux dispositions et aux formalités de la législation nationale dont elle relève », ce qui en vertu de l'article 121, § 2 de la Directive Sociétés inclut « compte tenu de la nature transfrontalière de l'opération, la protection des créanciers qui fusionnent ». En revanche, l'article 121, § 2 *in fine* ne prévoit explicitement la possibilité d'introduire un régime de protection spécifique que pour une seule catégorie de *stakeholders*, à savoir les associés minoritaires sans mentionner les créanciers[3536]. Ces dispositions ont ainsi donné lieu à trois interprétations divergentes. Ainsi, premièrement, la mention explicite des associés minoritaires à l'article 121, § 2 *in fine* a pu être comprise comme signifiant qu'*a contrario*, les États membres ne disposaient pas de la possibilité d'introduire des mécanismes de protection des créanciers spécifiques aux fusions transfrontalières et totalement inconnus en cas de fusion interne[3537]. Deuxièmement, à la lumière du fait que ces dispositions ont été introduites dans la Dixième Directive lors des discussions au niveau du Conseil et que ces dernières sont fortement politisées et ne sont pas en priorité concernées par la logique purement juridique des textes, il a été avancé que l'article 121, § 2 de la Directive Sociétés devait être compris comme autorisant les États membres à adopter des régimes de protection dérogatoires tenant compte du caractère transfrontalier de l'opération[3538]. Troisièmement, et de manière plus nuancée, il a également été avancé que cette disposition devait s'interpréter comme permettant uniquement d'adapter le régime de protection existant en droit interne aux risques additionnels engendrés par le caractère transfrontalier de l'opération et de passer, à titre d'illustration, d'un régime de protection *ex post*[3539] à un régime de protection *ex ante*[3540] en cas de fusion transfrontalière[3541]. Compte tenu de ces interprétations divergentes et du manque de clarté des textes européens, il n'est guère surprenant de constater que l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale ait mis en évidence le fait que si de nombreux États membres appliquaient des mécanismes de protection des créanciers identiques aux fusions internes et

3536 Selon l'art. 122, § 2 *in fine* de la Directive Sociétés, « [u]n État membre peut adopter, pour les sociétés participant à une fusion transfrontalière et relevant de sa législation, des dispositions destinées à assurer une protection appropriée aux associés minoritaires qui se sont prononcés contre la fusion transfrontalière. ». À ce sujet, voir *infra* nos 1086 à 1088.

3537 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz bei (grenzüberschreitenden) Verschmelzungen », *ZIP*, 2016, pp. 846 et 847 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 405 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 274 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163 ; B. GRUNEWALD, *op. cit.*, p. 107 ; D. HARITZ et B. VON WOLFF, *op. cit.*, p. 343 ; L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 233 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 311 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 17 et 18.

3538 Voir en ce sens : N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 75 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 473 ; H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 289 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, pp. 803 et s. ; J. RICKFORD, *op. cit.*, pp. 1408 et 1409 ; A. UGLIANO, *op. cit.*, pp. 607 et 608 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, pp. 62 et 63.

3539 Sur cette notion, voir *infra* n° 896.

3540 *Ibidem*.

3541 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drucksache 16/2919 – Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, *BT-Drs.*, 2007, n° 16/4193, p. 5 et H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, p. 233 et S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 314 et 315.

transfrontalières[3542], d'autres avaient fait explicitement le choix d'introduire des dispositions plus strictes en cas de fusion-émigration[3543].

719. Le régime d'exception des §§ 122j et 122k UmwG. À titre d'illustration, on peut citer le régime allemand applicable aux fusions transfrontalières qui comprend des dispositions protectrices d'exception applicables exclusivement en cas de fusion-émigration (*Hinausverschmelzung*). En effet, dans l'hypothèse d'une fusion-immigration[3544], tout comme dans le cas d'une fusion purement interne[3545], le principe est celui de l'application d'un mécanisme de protection *ex post* s'articulant autour de la possibilité de demander une sûreté pour les créances non encore échues dans les six mois de l'inscription de la fusion, pour autant que le créancier demandant une telle sûreté parvienne à démontrer que la fusion représente une menace pour le remboursement de sa créance. En revanche, dans l'hypothèse où ce serait la société allemande qui se ferait absorber, on passe d'un système de protection *ex post* à un mécanisme de protection *ex ante* en vertu duquel les créanciers existants de la société absorbée, pour peu (i) qu'ils ne disposent pas de la possibilité de demander le remboursement immédiat de leur créance, (ii) qu'ils aient fait connaître par écrit l'existence de leur créance, en ce compris la raison et le montant, dans les deux mois suivant la publication du projet commun de fusion, (iii) qu'ils parviennent à rendre crédible le fait que l'opération menace le paiement de leur créance et (iv) que la créance en question ne soit pas née moins de quinze jours avant la date de publication du projet commun de fusion, disposent de la possibilité d'exiger une sûreté[3546]. Si ces différentes conditions sont remplies, la société absorbante devra fournir une sûreté avant la prise d'effet de la fusion et les membres de l'organe de gestion devront en outre garantir à la juridiction en charge du contrôle de conformité que les sûretés nécessaires ont bien été fournies[3547] et ce, sous peine de sanctions pénales[3548]. En outre, la juridiction compétente ne pourra délivrer de certificat de conformité en l'absence d'une telle déclaration de la part de l'organe de gestion[3549]. Le caractère a priori surprotecteur de ce régime doit toutefois être nuancé par le fait qu'il est généralement admis que le seul caractère transfrontalier de l'opération ne suffit pas à établir que l'opération met en péril le remboursement d'une créance préexistante[3550]. À en croire

3542 Voir à titre d'exemples : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 268 pour la Belgique ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 369 pour le Danemark ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 429 pour la France ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 670 pour le Luxembourg et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 348 pour la République tchèque.

3543 Voir à titre d'exemples : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 453 pour l'Allemagne ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 245 pour l'Autriche ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 477 pour la Grèce et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 539 pour l'Irlande.

3544 § 22 (1) UmwG.

3545 § 122a (2) UmwG.

3546 § 122j UmwG.

3547 § 122k (1), *in fine* UmwG.

3548 § 314a UmwG.

3549 § 122k (2), 3e phrase UmwG.

3550 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 274 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 9 ; R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, op. cit.*, pp. 362 et 363 ; B. GRUNEWALD, *op. cit.*, p. 107 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 317 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 et J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, p. 165.

la justification avancée par le législateur allemand, ce régime dérogatoire a été mis en place car un mécanisme de protection *ex post* a été jugé comme insuffisamment protecteur à l'égard des intérêts des créanciers allemands[3551]. D'aucuns l'ont également justifié en avançant qu'en tout état de cause, un régime de protection *ex post* en cas de fusion-émigration serait dénué d'intérêt dans la mesure où la société absorbante ne serait pas liée par les mécanismes de protection prévu par le droit national de la société absorbée[3552].

C. *L'interprétation de la Cour de justice dans l'arrêt* KA Finanz

720. La clarification de l'arrêt *KA Finanz*. Cependant, cette interprétation permissive de l'article 121, § 2 de la Directive Sociétés a été de longue date rejetée par une partie de la doctrine[3553] et n'a pas été suivie l'Étude Bech-Bruun et Lexidale[3554]. La Cour de justice a finalement eu à se pencher sur cette question dans l'arrêt *KA Finanz* dans lequel, suivant en cela l'avis de l'avocat général Yves Bot[3555], elle a considéré qu'il découle du cinquante-sixième considérant ainsi que de l'article 121 de la Directive Sociétés (anciens troisième considérant et article 4 de la Dixième Directive) qu' « une société participant à une fusion transfrontalière reste soumise, en ce qui concerne notamment la protection de ses créanciers, aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable dans le cadre d'une fusion nationale »[3556]. En d'autres termes, en se référant directement au régime de protection applicable en cas d'opération interne, sans envisager l'hypothèse de l'existence d'un éventuel régime d'exception justifié par le caractère transfrontalier de l'opération, la

[3551] Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, exposé des motifs, *BT-Drs.*, 2006, n° 16/2919, p. 17 et voir et à ce sujet : D. BEUTEL, *ibidem*, p. 274 ; L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122j, n° 1 ; H.-W. NEYE et B. TIMM, « Die geplante Umsetzung der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften im Umwandlungsgesetz », *op. cit.*, p. 492 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, pp. 808 et 809.

[3552] Voir en ce sens : B. GRUNEWALD, *op. cit.*, p. 107 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 125 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 315 ; J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, p. 165 et M. PASSARGE et M. STARK, *ibidem*, p. 805.

[3553] W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *ZIP*, 2016, pp. 846 et 847 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 405 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *op. cit.*, p. 843 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 260 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes… », *op. cit.*, p. 732 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 121, n° 253.

[3554] Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, p. 31.

[3555] Au point 49 de ses conclusions, l'avocat général avait considéré notamment qu' « [e]n vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/56, une société participant à une fusion transfrontalière se conforme aux dispositions et aux formalités de la législation nationale dont elle relève, ces dispositions et ces formalités concernant, notamment, la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent. Dans la mesure où les États membres doivent se conformer aux articles 13 à 15 de la troisième directive 78/855 concernant la protection des créanciers dans le cadre d'une fusion nationale, nous en déduisons que la directive 2005/56 renvoie à ces dispositions et que les créanciers, dans le cadre d'une fusion transfrontalière, doivent jouir de la même protection que les créanciers concernés par une fusion nationale. ». Voir Av. gén., Y. BOT, concl. préc. C.J., arrêt *KA Finanz AG c. Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group*, 7 avril 2016, C-483/14, EU:C:2015:757, pt. 49.

[3556] C.J., arrêt *KA Finanz AG c. Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group*, 7 avril 2016, C-483/14, EU:C:2016:205 (ci-après l' « **arrêt *KA Finanz*** »), pts. 60–62.

Cour laisse à penser que le législateur européen n'avait aucunement voulu autoriser les États membres à adopter des régimes d'exception similaires au § 122j UmwG[3557]. Malgré cela, il a pu être avancé par M. Winner qu'il découlait du point 62 de la décision selon lequel « [d]ans la mesure où les États membres, dans le cadre d'une fusion nationale, doivent se conformer aux articles 13 à 15 de la directive 78/855 en ce qui concerne la protection des créanciers, ils sont, partant, tenus de respecter ces dispositions également dans le cadre d'une fusion transfrontalière », que la Cour de justice n'a pas tenu à se prononcer sur la question de l'admissibilité de régimes dérogatoires en matière de protection des créanciers dans l'hypothèse d'une fusion transfrontalière[3558]. Cependant, outre la délicate réconciliation de cette interprétation avec les points 60 et 61 de l'arrêt *KA Finanz* à laquelle l'auteur en question ne répond pas et qui pourtant fondent la conclusion au point 62[3559], il convient de relever que la Cour exprime très clairement que les dispositions applicables à une fusion nationale seront également applicables à une opération transfrontalière sans émettre de réserve quant à l'existence d'éventuels régimes dérogatoires. On peut certes déplorer que le dispositif de l'arrêt *KA Finanz* ne fasse que reprendre cette conclusion sans autres précisions[3560], mais elle n'est que la conséquence logique de l'interprétation restrictive de l'article 121, § 2 de la Directive Sociétés opérée par la Cour.

721. L'incidence sur les régimes d'exception. En conséquence de l'arrêt *KA Finanz*, la balance semble fortement pencher en faveur des auteurs qui avançaient que le texte de la Directive Sociétés applicable aux fusions transfrontalières n'était aucunement destiné à permettre aux États membres d'instaurer un régime de protection des créanciers radicalement distinct de celui applicable à une opération interne[3561]. Cette solution est logique ne fût-ce qu'à la lumière (i) de la seconde phrase de l'article 121, § 2 de la Directive Sociétés qui autorise explicitement les États membres à adopter des dispositions spécifiques

3557 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, pp. 844 et 846 et s. ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 3 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 17 et 18 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, pp. 238 et 239.

3558 M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 63, note 48.

3559 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, p. 846.

3560 Le deuxième tiret du point 1) du dispositif de l'arrêt *KA Finanz* énonce que « les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société ».

3561 *Pro :* W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, pp. 846 et 847 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 405 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *NZG*, 2006, p. 843 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 274 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir), *op. cit.*, § 122j, n° 3 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163 ; B. GRUNEWALD, *op. cit.*, p. 107 ; D. HARITZ et B. VON WOLFF, *op. cit.*, p. 343 ; L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 3 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 121, n° 253 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 17 et 18. *Contra :* R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 379 et 380 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 328 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 75 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 473 ; H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 289 ; M. PASSARGE et M. STARK, « Gläubigerschutz bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *GmbHR*, 2007, pp. 803 et s. ; J. RICKFORD, *op. cit.*, pp. 1408 et 1409 ; A. UGLIANO, *op. cit.*, pp. 607 et 608 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, pp. 62 et 63.

destinées à protéger les associés minoritaires s'étant prononcés contre l'opération[3562] et (ii) des dispositions de la proposition de directive de 1985 sur les fusions transfrontalières[3563] dans laquelle le législateur européen n'avait pas jugé opportun de prévoir de mécanisme de protection spécifique en raison de la nature transfrontalière de l'opération[3564]. Il en découle que les différents régimes d'exception adoptés par les législateurs nationaux sont contraires au droit secondaire de l'Union européenne et, partant, ne devraient dès lors plus être appliqués[3565]. Il n'en demeure pas moins que ces incertitudes ont contribué à l'émergence d'une multitude de systèmes divergents dont le caractère dérogatoire au régime applicable en cas d'opération interne a nui à la lisibilité de la procédure[3566].

§2. Analyse de droit comparé en matière de scissions transfrontalières

722. Intérêt d'une étude de droit comparé. Compte tenu du fait que certains législateurs nationaux ont fait le choix d'introduire une procédure de scission transfrontalière en l'absence d'une initiative directe de la part du législateur européen, il est intéressant d'aller voir si ces législateurs nationaux ont spontanément fait le choix ou non de prévoir des mécanismes de protection dérogatoires en cas d'opération transfrontalière. Pour ce faire, il conviendra tout d'abord de se pencher sur le nouveau régime des scissions transfrontalières introduit par le CSA pour ensuite examiner comment le législateur luxembourgeois a, à travers le prisme de son attitude foncièrement libérale[3567], traité cette question.

723. Le régime d'exception prévu par le CSA. Contrairement à ce qui est le cas pour les fusions transfrontalières pour lesquelles une procédure spécifique est explicitement prévue par le CSA[3568], la procédure de scission transfrontalière est directement calquée sur celle applicable en cas de scission interne[3569].

3562 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *ibidem*, p. 847 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *ibidem*, p. 405 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes… », *op. cit.*, p. 732 ; D. HARITZ et B. VON WOLFF, *ibidem*, p. 343 et S. HERRLER, *op. cit.*, p. 297.

3563 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, p. 847.

3564 Voir art. 9 de la proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, exposé des motifs, COM (84) 727 final, présentée par la Commission au Conseil le 14 janvier 1985, *J.O.*, n° C 23/11, 23 janvier 1985, et plus spécifiquement le § 2 selon lequel « [l]e système de protection ne peut être différent de celui prévu pour la protection des intérêts des créanciers en cas de fusion de sociétés relevant toutes de la législation de l'État membre concerné ».

3565 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, p. 847 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 276 et L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 557. *Contra* : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 63.

3566 Voir en ce sens : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 53 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18.

3567 Voir en ce sens : I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 18 et I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *RPS-TRV*, 2017, pp. 418 et 419.

3568 Titre 6 du livre 12 du CSA intitulé « *Règles spécifiques concernant les fusions transfrontalières et opérations assimilées* ».

3569 Art. 12:73, § 1er, 2° (scission par absorption) et 12:90, § 1er, 2° (scission par constitution de nouvelles sociétés) du CSA. Sur le caractère pertinent de cette différence de traitement d'un point de vue légistique, voir E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, « Chapitre 12 – Les réorganisations de personnes morales »,

Cependant, cette spécificité n'a pas empêché le législateur belge d'introduire un régime de protection renforcé pour les créanciers lorsque la société scindée est une société belge. Ainsi, bien que la protection des créanciers en cas de scission transfrontalière soit, comme en cas de scission interne, régie par l'art. 12:15 du CSA, l'articulation de cette dernière disposition avec les aspects procéduraux relatifs à l'émission du certificat de conformité en cas de scission-émigration aboutit à un renforcement du régime de protection des créanciers en cas de scission transfrontalière. En effet, le mécanisme de protection de base consacré par le CSA tant en matière de fusion que de scission est celui de la possibilité pour les créanciers de chacune des sociétés participant à l'opération d'exiger une sûreté dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l'opération pour les créances (i) certaines avant cette publication mais non-exigibles ou (ii) qui ont fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant l'opération[3570]. Or, si en cas de scission interne, ce mécanisme est à qualifier de régime *ex post*[3571] en raison du fait qu'il n'entre en jeu qu'après la date de prise d'effet de l'opération et ne retarde par conséquent pas la prise d'effet de celle-ci[3572], il en va autrement en cas de scission transfrontalière dans laquelle la société scindée est soumise au droit belge. En effet, dans cette dernière hypothèse, le notaire instrumentant ne pourra délivrer le certificat de conformité établissant que tous les actes et formalités préalables à l'opération ont bien été accomplis qu'une fois que les créanciers exigeant une sûreté auront, soit obtenu satisfaction, soit vu leurs prétentions rejetées par une décision judiciaire exécutoire[3573]. Or, ces derniers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la réalisation de l'opération pour faire valoir leurs prétentions[3574]. Il s'ensuit que contrairement à ce qui se passe en cas de scission interne[3575] et de fusions transfrontalières[3576], la demande introduite dans les temps par un créancier aura un effet suspensif[3577] puisque la scission transfrontalière, lorsque la société scindée est soumise au droit belge, ne pourra prendre effet qu'une fois que le notaire instrumentant aura délivré le certificat de conformité[3578]. De plus, la procédure de scission-émigration sera d'office plus longue étant donné que le notaire instrumentant ne pourra délivrer son certificat qu'au plus

in E.-J. NAVEZ (dir.), *Le Code des sociétés et associations*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 338, n° 938 selon lesquels ce choix du législateur belge pourrait s'expliquer par la volonté d'attendre l'entrée en vigueur de la Directive Mobilité.

3570 Art. 12:15, § 1er, al. 1er du CSA.

3571 Sur cette notion, voir *infra* n° 896.

3572 Selon l'art. 12:69, al. 2 du CSA, une scission par absorption prend effet « lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées » et selon l'art. 12:86 du CSA, une scission par constitution de nouvelles sociétés prend effet « lorsque toutes les nouvelles sociétés sont constituées ».

3573 Art. 12:73, § 3, 2e phrase (scission par absorption) et 12:90, § 3, 2e phrase (scission par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.

3574 Art. 12:15, § 1er, al. 1er du CSA.

3575 Art. 12:15, § 1er ; 12:69, al. 2 et 12:86 du CSA.

3576 Art. 12:15 ; 12:106, al. 1er ; 12:117 et 12:119 du CSA.

3577 I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 27 ; E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *op. cit.*, p. 340, n° 941 et D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, p. 337.

3578 Art. 12:73, § 5 du CSA.

tôt après l'expiration du délai de deux mois dont les créanciers disposent pour faire valoir leurs droits[3579]. En d'autres termes, dans le but de « protéger les créanciers de la société belge »[3580], on passe d'un système de protection *ex post* en cas de scission interne à un système de protection *ex ante*[3581] en cas de scission transfrontalière. Un tel choix législatif ne peut que démontrer que le législateur belge a considéré qu'une scission-émigration présentait des risques accrus par rapport à une opération purement interne.

724. L'absence de disposition spécifique en droit luxembourgeois. Ayant adopté une attitude résolument libérale[3582] qu'il est aisé de qualifier de bienveillante à l'égard des opérations transfrontalières[3583], le législateur luxembourgeois s'est simplement contenté d'étendre le régime des scissions internes aux scissions transfrontalières[3584]. Il s'ensuit que les créanciers disposant d'une créance antérieure à la date de publication des actes constatant la scission bénéficieront de la possibilité de demander la constitution de sûretés pour des créances échues ou non-échues, dans les deux mois suivant cette publication, au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, pour peu qu'ils parviennent à démontrer de manière crédible que la scission présente un risque pour l'exercice de leurs droits[3585]. Si ce mécanisme de protection ressemble très fort au régime belge, la différence fondamentale est que l'introduction d'une demande par un créancier n'a pas d'effet suspensif sur l'opération et que le notaire n'est pas tenu de vérifier l'état d'avancement des demandes des créanciers avant de passer l'acte de scission. En d'autres termes, le législateur luxembourgeois n'a pas jugé opportun d'instaurer de mécanisme de protection des créanciers additionnel en raison de la nature transfrontalière de l'opération.

3579 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 311.

3580 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 311.

3581 Sur cette notion, voir *infra* n° 896.

3582 Projet de loi relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital et portant transposition : (i) de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ; (ii) de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital et (iii) de la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855(CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2007–2008, n° 5829, p. 13 selon lequel les modalités des fusions transfrontalières telles que transposées « *sont inspirées d'un esprit de libéralisme économique caractéristique de la matière du droit luxembourgeois des sociétés* ». Voir également en ce sens : I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 18 et I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *op. cit.*, p. 418.

3583 Voir en ce sens : I. CORBISIER et F. BERNARD, *ibidem*, p. 18.

3584 Art. 1030-1, al. 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3585 Art. 1031-10, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

§ 3. Analyse de la Directive Mobilité

725. Un régime plus uniforme. Afin d'éclaircir la situation et de remédier à l'ambiguïté dont était affecté l'article 121, § 2 de la Directive Sociétés[3586], la Directive Mobilité clarifie ce dernier en supprimant toute référence à la fois (i) à la protection des créanciers, des obligataires et des porteurs de titres ou parts et (ii) à la nécessité de tenir compte de la nature transfrontalière de l'opération[3587] et introduit un système de protection distinct pour chaque type d'opération[3588]. Cette évolution sera bienvenue dans la mesure où malgré les enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *KA Finanz*, les règles applicables aux opérations internes continueront toutefois à s'appliquer dans toutes les hypothèses où le régime spécifique n'aura pas prévu une solution *ad hoc*[3589], comme par exemple à l'égard de la protection des obligataires[3590]. Si le législateur européen ne semble avoir souhaité introduire qu'un régime de protection minimal tout en laissant aux États membres le loisir de renforcer cette protection[3591], force est de constater que le régime de protection en matière de fusions transfrontalières ne fait aucune distinction entre les créanciers soumis à un changement de *lex societatis* et les autres[3592]. Cette même approche se retrouve à l'égard des scissions transfrontalières[3593], mais cette assertion mérite une précision. Tout d'abord, il convient de relever que l'exclusion des

3586 À ce sujet, voir *supra* n[os] 718 et 719.

3587 Art. 121, § 2 de la Directive Mobilité.

3588 Art. 86*undecies* de la Directive Mobilité pour les transformations transfrontalières ; art. 126*ter* de la Directive Mobilité pour les fusions transfrontalières et art. 160*undecies* de la Directive Mobilité pour les scissions transfrontalières.

3589 Art. 86*quater* de la Directive Mobilité pour les transformations transfrontalières ; art. 121, § 1[er], b) de la Directive Sociétés qui n'est pas modifié par la Directive Mobilité pour les fusions transfrontalières et art. 160*quater* de la Directive Mobilité pour les scissions transfrontalières.

3590 Art. 160*quater* de la Directive Mobilité et art. 146, § 5 de la Directive Sociétés relatif à la protection des obligataires en cas de scission interne. Voir également à ce sujet : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 55.

3591 Proposition de la Commission, exposé des motifs, pp. 21 et 22 où la Commission rappelle que « [c]oncernant la protection des créanciers, l'analyse d'impact a comparé l'option 0 (scénario de base), consistant à garder telles quelles les règles actuelles sur les fusions transfrontalières et à n'introduire aucune règle européenne sur la protection des créanciers dans le cadre de transformations et scissions transfrontalières, à l'option 1, qui entend introduire des règles harmonisées pour protéger les créanciers, et à l'option 2, qui introduirait les mêmes règles harmonisées que l'option 1 mais permettrait aux États membres de prévoir des garanties supplémentaires. L'option 2, privilégiée, offrirait le meilleur équilibre entre la réduction des coûts, un niveau élevé de protection et la flexibilité pour les États membres. Les options 1 et 2 réduiraient considérablement les coûts et charges pour les entreprises par rapport au scénario de base, car les règles harmonisées sur la protection des créanciers assureraient une plus grande sécurité juridique et réduiraient le besoin de conseils juridiques pour toute opération transfrontalière. L'option 1 générerait les plus grandes réductions de coûts pour les entreprises ; dans l'option 2, ces réductions de coûts pourraient être moins importantes parce que les États membres pourraient instaurer des garanties supplémentaires qui pourraient être coûteuses ou lourdes pour certaines entreprises (par exemple, la nécessité de fournir des garanties à tous les créanciers). En termes de protection offerte aux créanciers, l'option 2 assurerait une protection plus complète et plus ciblée que l'option 1 en raison de la possibilité accordée aux États membres d'évaluer les spécificités nationales de la protection des créanciers et d'introduire des garanties supplémentaires ». Sur le choix peu clair du législateur européen de privilégier une harmonisation minimale combinée à la possibilité pour les États membres de compléter le régime, voir *infra* n° 954.

3592 Art. 126*ter* de la Directive Mobilité.

3593 Art. 160*undecies* de la Directive Mobilité.

opérations de scission impliquant plus d'une société préexistante[3594] complexifie l'analyse dans la mesure où, par définition, seuls les créanciers de la société scindée seront impactés par l'opération et nécessiteront une protection. En effet, les nouvelles sociétés bénéficiaires ne seront constituées que suite à la prise d'effet de l'opération[3595], donc à un moment où les créanciers seront parfaitement avertis de la réussite de l'opération et ne nécessiteront pas de protection spécifique à cet égard. Comme dans l'hypothèse classique de la scission transfrontalière d'une société soumise au droit d'un État membre A au profit de deux nouvelles sociétés situées dans un État membre B, tous les créanciers de la société scindée seront nécessairement exposés à un changement de *lex societatis*, il pourrait être avancé qu'il est impossible de tirer des conclusions du régime de protection des créanciers figurant actuellement dans la Directive Mobilité en raison de l'absence de créanciers non soumis à un changement de *lex societatis*. Cependant, il s'agit là d'une interprétation erronée. En effet, tout d'abord, le législateur européen, s'il a fait le choix d'exclure les scissions par absorption et les scissions mixtes, a indiscutablement autorisé les scissions partielles[3596]. Or, dans une scission partielle transfrontalière, les créanciers dont la créance n'est pas transférée à la nouvelle société soumise au droit d'un autre État membre ne seront par définition pas affectés par un changement de *lex societatis* alors que les créanciers dont la créance est transférée à la société bénéficiaire se retrouveront avec un débiteur soumis à un droit national distinct de celui applicable à leur débiteur d'origine. En d'autres termes, dans ce type assez particulier d'opération transfrontalière, on sera en présence à la fois de créanciers soumis à un changement de *lex societatis* et de créanciers non soumis à un changement de *lex societatis* et ce, malgré le fait que l'opération ne puisse être réalisée qu'au bénéfice d'une société nouvellement créée. Or, dans cette hypothèse, tous les créanciers de la société scindée disposeront de la même protection en vertu des dispositions de la Directive Mobilité, indépendamment de tout changement de *lex societatis*. En outre, on peut partir du postulat que si le législateur européen avait effectivement souhaité instaurer un régime dérogatoire plus protecteur à l'égard des créanciers de la société scindée soumis à un changement de droit national applicable à leur débiteur, il aurait vraisemblablement étendu le mécanisme de la *perpetuatio fori* prévu pour les transformations transfrontalières[3597] aux scissions et aux fusions transfrontalières[3598], ne fût-ce qu'en raison de son caractère proportionné[3599]. Par ailleurs, tant le régime de protection des créanciers applicable en cas de fusion transfrontalière que celui applicable en cas de scission transfrontalière sont

[3594] Art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité.
[3595] Art. 160*novovicies*, §§ 1 et 2 de la Directive Mobilité.
[3596] Art. 160*ter*, 4), b) de la Directive Mobilité.
[3597] Art. 86*undecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
[3598] Si ce choix aurait pu se justifier dans la mesure où une *perpetuatio fori* permet de protéger les créanciers contre l'aléa lié à l'obligation de devoir agir devant des juridictions étrangères dont les règles procédurales peuvent s'avérer fort différentes ou plus désavantageuses tout en étant relativement peu intrusive, il convient toutefois de remarquer qu'à l'égard de la société européenne, ce mécanisme de protection n'est disponible qu'en cas de transfert de siège et pas en cas de fusion transfrontalière. Voir art. 8, § 16 du Règlement sur la Société européenne.
[3599] À ce sujet, voir *infra* n[os] 790 à 792.

largement inspirés du régime applicable dans un contexte purement interne[3600]. En conclusion, il est possible de déduire (i) d'une comparaison avec le nouveau régime des fusions transfrontalières, (ii) de l'application uniforme du régime de protection des créanciers spécifiquement prévu par la Directive Mobilité aux scissions transfrontalières ainsi que (iii) du choix du législateur européen de ne pas étendre la *perpetuatio fori* aux fusions et scissions transfrontalières et (iv) de l'inspiration du régime applicable aux opérations internes, que le législateur européen n'a pas jugé opportun de prévoir de protection renforcée pour les créanciers soumis à un changement de *lex societatis*. Cependant, en l'absence d'une prise de position claire et univoque de la part du législateur européen en ce sens, que ce soit dans la Directive Mobilité, dans une des diverses versions ayant jalonné son processus d'adoption ou encore dans l'Étude d'impact, cette conclusion demeure affectée d'une certaine incertitude.

§4. L'incidence de la liberté d'établissement

726. La position ambiguë de la Cour de justice. Comme les scissions transfrontalières constituent des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »[3601], il s'ensuit que le principe fondamental de non-discrimination posé par la Cour de justice de l'Union européenne devra également trouver à s'appliquer en l'occurrence[3602]. Par conséquent, des mécanismes de protection des créanciers spécifiquement liés à la nature transfrontalière de l'opération et totalement inexistants dans le cas d'une opération interne constitueront immanquablement une entrave à la liberté d'établissement[3603]. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, il sera très difficile à un État membre de justifier que des mesures de protection additionnelles et dérogatoires au régime applicable aux opérations purement internes remplissent la condition de proportionnalité applicable à toute justification à une entrave à la liberté d'établissement[3604]. Il a également été considéré que par le biais

3600 Art. 99 de la Directive Sociétés pour les fusions internes et art. 146, §§ 1 à 3 de la Directive Sociétés pour les scissions internes. Voir également en ce sens à propos du Premier Compromis de la Présidence : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 55. Voir également au sujet de la Proposition de la Commission : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 263 et 264.

3601 Arrêt *Sevic*, pt. 19 et en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 3 ; H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 55 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1161 ; T. DRYGALA, *op. cit.*, p. 26 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 19 ; V. GEYRHALTER et Th. WEBER, *op. cit.*, p. 150 ; S. HERRLER, *op. cit.*, pp. 298 et 299 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, pp. 226 et 234 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 45 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 416 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, pp. 165 et 166 ; W. MEILICKE et D. E. RABBACK, *op. cit.*, pp. 126 et 127 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 320 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *ibidem*, p. 236 ; J. SEDEMUND, *op. cit.*, p. 521 ; M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 314 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 358 ; Chr. TEICHMANN et R. KNAIER, *op. cit.*, p. 1319 et S. WEISS et H.-T. WÖHLERT, *op. cit.*, pp. 584 et 585.

3602 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 275 et 276 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 806.

3603 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *ibidem*, pp. 275 et 276 et G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, *op. cit.*, p. 13.

3604 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 381 et F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 33.

du principe de responsabilisation des créanciers et la référence faite par la Cour de justice dans l'arrêt *Inspire Art* à l'existence de règles communautaires offrant une protection de nature plus générale aux créanciers[3605], la Cour de justice était partie du postulat que les systèmes nationaux de protection des créanciers étaient équivalents, même si l'efficacité concrète d'un moyen particulier est susceptible de varier en fonction du cas d'espèce[3606]. En poussant ce raisonnement un peu plus loin, cela signifie qu'un État membre ne pourrait « imposer des protections supplémentaires, que cela soit au niveau matériel ou au niveau conflictualiste »[3607] en cas d'opération transfrontalière. Cependant, il semble plus avisé d'adopter une position plus réservée en la matière. En effet, dans l'arrêt *Sevic*, la Cour de justice semble malgré tout avoir laissé une porte ouverte en rappelant que, bien qu'il existe des règles harmonisées applicables aux fusions internes, les fusions transfrontalières posent des « problèmes spécifiques »[3608] et qu'il ne saurait être exclu que dans certaines circonstances et sous certaines conditions, la protection des intérêts des créanciers puisse justifier une restriction à la liberté d'établissement[3609]. Un raisonnement similaire se retrouve également dans l'arrêt *Polbud* où la Cour rappelle, à l'égard des transformations transfrontalières, que la liberté d'établissement ne s'oppose pas à ce qu'un État membre adopte des mesures destinées à sauvegarder les intérêts des créanciers en cas d'opération transfrontalière[3610], pour peu que celles-ci soient efficaces et proportionnées[3611]. En d'autres termes, même si la Cour semble partir du principe qu'il sera difficile de justifier une mesure de protection dérogatoire destinée à tenir compte du caractère transfrontalier de l'opération, elle ne l'exclut pas *ab initio*. Il n'est donc pas possible d'apporter une réponse définitive à cette question par le biais de la seule analyse de la jurisprudence de la Cour de justice, même s'il est évident qu'une mesure dérogatoire ne sera que très difficilement justifiable.

727. Illustration : la liberté d'établissement et le régime d'exception du droit allemand. Afin d'illustrer les difficultés liées à l'appréciation de la conformité d'une mesure de protection dérogatoire à la liberté d'établissement, il est utile de s'intéresser brièvement aux auteurs ayant examiné cette question à l'égard du régime d'exception consacré par le droit allemand[3612]. À cet égard, un premier groupe d'auteurs a avancé que le seul passage d'un mécanisme de protection des créanciers *ex post* à un mécanisme *ex ante* en cas de fusion émigration[3613], en faveur duquel Ursula Lennerz avait plaidé bien avant l'adoption de la Dixième Directive[3614], constituait certes une entrave à la liberté d'établissement, mais que celle-ci était à la fois proportionnée et nécessaire

3605 Arrêt *Inspire Art*, pt. 135.
3606 J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 61 et 62, nos 121 et 122.
3607 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMEIDLER, *ibidem*, p. 62, n° 122.
3608 Arrêt *Sevic*, pt. 27.
3609 Arrêt *Sevic*, pt. 28 et à ce sujet J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 123.
3610 Arrêt *Polbud*, pt. 55.
3611 Arrêt *Polbud*, pt. 56.
3612 Pour une description de ce régime, voir *supra* n° 719.
3613 § 122j UmwG.
3614 U. LENNERZ, *op. cit.*, pp. 227 et 228.

à la protection des créanciers[3615], alors que l'exigence d'une déclaration de l'organe de gestion que les garanties nécessaires ont bien été fournies assortie de sanctions pénales personnelles[3616] allait au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une protection adéquate des créanciers en cas de fusion-émigration[3617]. En revanche, un second groupe a rejeté de manière plus générale la conformité du régime d'exception aux articles 49 et 54 du TFUE[3618], ne fût-ce qu'en raison du fait que la responsabilité pénale personnelle qu'il fait peser sur les membres de l'organe de gestion[3619], ainsi que les inconvénients en matière de trésorerie qu'il impose à la société absorbée[3620] constituent une entrave disproportionnée à la liberté d'établissement des entités impliquées. Si par son arrêt *KA Finanz*[3621], la Cour de justice a significativement relativisé l'importance de ce débat en donnant raison aux auteurs qui ne voyaient pas dans l'article 121, § 2 de la Directive Sociétés d'incitation pour les législateurs nationaux à adopter des régimes de protection dérogatoires en cas d'opération transfrontalière[3622], il n'en demeure pas moins qu'il est impossible d'en tirer des conséquences définitives sur l'éventuelle conformité du régime allemand à la liberté d'établissement, même si à la lumière de l'attitude bienveillante

3615 Voir en ce sens : H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 289 ; M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 806 et A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 113.

3616 § 122k, (1) *in fine* UmwG.

3617 Voir en ce sens : M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 806 et A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 113. *Contra* : S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 329 et 330.

3618 T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 276 et D. HARITZ et B. VON WOLFF, *op. cit.*, p. 343.

3619 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *ibidem*, p. 276 et D. HARITZ et B. VON WOLFF, *ibidem*, p. 343.

3620 Voir en ce sens D. BEUTEL, *ibidem*, p. 276 qui s'appuie sur les enseignements de l'arrêt *Metallgesellschaft e. a.* dans lequel la Cour de justice a considéré qu'une législation nationale imposant un désavantage de trésorerie aux sociétés dont la société mère n'est pas située dans le même État membre constituait une entrave à la liberté d'établissement. Voir C.J., arrêt *Metallgesellschaft Ltd e. a., Hoechst AG et Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) c. Commissioners of Inland Revenue et HM Attorney General*, 8 mars 2001, C-397/98 et C-410/98, EU:C:2001:134, pts. 54 et 75.

3621 À ce sujet, voir *supra* n° 720.

3622 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, pp. 844 et 846 et s. ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 3 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 17 et 18 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, pp. 238 et 239. *Contra* : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 63, n° 49 qui considère que la Cour de justice n'a pas explicitement prohibé les régimes d'exception applicables aux fusions transfrontalières. *Pro :* W. BAYER et J. SCHMIDT, *ibidem*, pp. 846 et 847 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Die neue Richtlinie… », *op. cit.*, p. 405 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 843 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 274 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir), *op. cit.*, § 122j, n° 3 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163 ; B. GRUNEWALD, *op. cit.*, p. 107 ; D. HARITZ et B. VON WOLFF, *op. cit.*, p. 343 ; L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122j, n° 3 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 121, n° 253 et J. SCHMIDT, *ibidem*, pp. 17 et 18. *Contra :* R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 379 et 380 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 328 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 75 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 473 ; H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *op. cit.*, p. 289 ; M. PASSARGE et M. STARK, « Gläubigerschutz bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *GmbHR*, 2007, pp. 803 et s. ; J. RICKFORD, *op. cit.*, pp. 1408 et 1409 ; A. UGLIANO, *op. cit.*, pp. 607 et 608 et M. WINNER, *ibidem*, pp. 62 et 63.

de la Cour de justice à l'égard des opérations de mobilité transfrontalière[3623], la balance pencherait vraisemblablement en faveur d'une entrave injustifiée.

§5. Les difficultés liées à la mise en œuvre des mécanismes de protection des créanciers

728. Un argument insuffisant. Une des raisons susceptibles de justifier une protection accrue des créanciers de la société scindée en cas de scission-émigration est liée aux éventuelles difficultés procédurales découlant du changement de droit national applicable suite à la réalisation de l'opération[3624]. Or, un tel argument se doit d'être très fortement relativisé, notamment en raison des dispositions spécifiques du Règlement Bruxelles I*bis*[3625]. En effet, dans un nombre important de situations, les juridictions de l'État membre de la société scindée demeureront compétentes pour traiter une demande des créanciers de celle-ci. Ce sera notamment le cas lors du maintien d'une succursale ou d'un établissement dans l'État membre de la société scindée[3626] ou encore lorsque le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande se trouve dans l'État membre de la société scindée[3627]. En outre, dans notre monde économique globalisé, force est de constater que les procédures transfrontalières visant à obtenir le paiement d'une créance sont loin d'être exceptionnelles[3628]. S'il est vrai que ce type de procédure peut s'avérer plus longue et plus coûteuse en pratique[3629], on peut toutefois douter de la nécessité de mettre en place un régime de protection renforcé des créanciers de la société scindée pour ce seul fait.

3623 Pour une étude détaillée de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1er.

3624 Voir à propos des fusions transfrontalières : Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, exposé des motifs, COM (84) 727 final, p. 9 et S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 119 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, pp. 808 et 809. Voir au sujet de la société européenne : Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Europäischen Gesellschaft (SEEG), exposé des motifs, *BT-Drs.*, 2004, n° 15/3405, pp. 33 et 35 et A. FRANCK, *op. cit.*, p. 192.

3625 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in J. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 4 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 278 ; DAV, « Handelsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *NZG*, 2006, p. 742 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163 ; L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 2 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 19.

3626 Art. 7, point 5 du Règlement Bruxelles I*bis* et à ce sujet à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *op. cit.*, p. 843 ; D. BEUTEL, *ibidem*, p. 276 ; DAV, *ibidem*, p. 742 ; FL. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 9 ; B. GRUNEWALD, *op. cit.*, 107 ; D. HARITZ et B. VON WOLFF, *op. cit.*, p. 343 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 319 ; Chr. LOUVEN, *op. cit.*, p. 2028 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 808.

3627 Art. 7, point 1 du Règlement Bruxelles I*bis* et à ce sujet à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 276 et M. PASSARGE et M. STARK, *ibidem*, p. 808.

3628 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. PASSARGE et M. STARK, *ibidem*, p. 808.

3629 *Ibidem*.

§ 6. L'incidence d'une scission transfrontalière sur le droit applicable au contrat

729. Un argument potentiellement en faveur d'un régime dérogatoire. En matière de contrats de prêt, que ceux-ci soient externes ou intragroupes, il est très fréquent que les parties déterminent par une clause spécifique le droit qui sera applicable à leur relation contractuelle. En vertu du Règlement Rome I[3630], un tel choix est en principe valable, mais on peut s'interroger sur l'incidence d'une scission transfrontalière sur le choix éventuellement opéré par les parties quant au droit applicable à l'interprétation, l'exécution et l'extinction d'un tel contrat. En effet, en vertu de l'article 1er, § 2, f) du Règlement Rome I, les dispositions de ce dernier ne sont pas applicables aux questions relevant du droit des sociétés, telles que notamment la constitution, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés. Un bref examen de certains faits à la base de l'arrêt *KA Finanz* permet d'appréhender l'incidence de cette question sur les scissions transfrontalières.

730. Les emprunts subordonnés de Kommunalkredit International Bank Ltd. En 2005, Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, une société de droit autrichien, avait souscrit deux emprunts subordonnés émis par Kommunalkredit International Bank Ltd, une société de droit chypriote. Selon les conditions de ces emprunts subordonnés, (i) la forme, le contenu, ainsi que tous les droits et obligations tant du titulaire que de l'émettrice étaient soumis au droit allemand et (ii) un remboursement de la valeur nominale de ces titres, ainsi qu'un éventuel paiement d'intérêts n'étaient possibles que si ce versement n'impliquait pas que les capitaux propres de l'émettrice descendraient en dessous des seuils fixés dans les lignes directrices applicables de la banque centrale de Chypre sur le calcul des fonds propres des banques. Cette condition n'ayant plus été remplie à partir de la fin de l'année 2008, la société *Kommunalkredit* a cessé de verser des intérêts. En 2010, Kommunalkredit a été absorbée par KA Finanz AG, une société de droit autrichien, dans le cadre d'une fusion transfrontalière. Suite à cela, Kommunalkredit a réclamé à KA Finanz le paiement des intérêts dus sur les deux emprunts pour les années 2009 et 2010 et, à titre subsidiaire, l'obtention de droits équivalents au sens du § 226 (3) öAktG[3631]. Face à ces demandes, KA Finanz a avancé qu'au 31 décembre 2008, KA Finanz affichait des fonds propres négatifs de près d'un milliard d'euros de sorte que ces deux emprunts subordonnés avaient perdu toute valeur et que c'est donc à juste titre qu'elle y a mis fin en application du § 226 (3) öAktG sans octroyer de compensation, étant donné que cette dernière disposition légale présente la particularité en droit autrichien d'être interprétée comme permettant à la société émettrice ou à la société absorbante de choisir soit d'octroyer des droits équivalents soit de modifier ou de mettre fin purement et simplement aux obligations et titres participatifs en versant une compensation adéquate[3632]. Bien que tant le

[3630] Art. 3, § 1er du Règlement Rome I.

[3631] Selon cette disposition du droit autrichien, « [i]l convient d'accorder des droits équivalents aux titulaires d'obligations et de titres participatifs ou de leur verser une compensation adéquate pour la modification des droits ou le droit lui-même ».

[3632] W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, p. 848.

Handelsgericht Wien en première instance que l'*Oberlandesgericht Wien* en deuxième instance aient jugé que le § 226 (3) öAktG n'était pas applicable aux prêts subordonnés dans la mesure où ceux-ci ne constituaient pas des titres participatifs au sens de ladite disposition, on voit aisément que la ligne de défense de KA Finanz AG reposait sur la reconnaissance que le droit applicable devait être le droit autrichien, c'est-à-dire le droit applicable à la société absorbante, et non pas le droit allemand pourtant choisi contractuellement par les parties[3633].

731. La réponse de la Cour de justice. Suite aux questions préjudicielles posées par l'*Oberster Gerichtshof* devant lequel le litige a fini par atterrir, la Cour de justice a eu notamment à se prononcer sur la délicate question du droit applicable. Pour y répondre de manière adéquate, la Cour de justice, procédant en cela à une reformulation des première, quatrième et cinquième questions préjudicielles, a choisi de distinguer entre (i) la question du droit applicable à la suite d'une fusion transfrontalière, à l'interprétation, à l'exécution et aux modes d'extinction d'un contrat d'emprunt et (ii) le droit applicable à la demande par laquelle un créancier entend se prévaloir des mécanismes de protection prévus par l'ancien article 15 de la Troisième Directive (actuellement l'article 101 de la Directive Sociétés)[3634]. En ce qui concerne la première partie de la question, la Cour commence par se prononcer sur l'applicabilité de la Convention de Rome[3635] dont l'article 1er, § 2, e) excluait de son champ d'application toutes les questions relevant du droit des sociétés, en ce compris, selon le rapport établi par les professeurs Giuliano et Lagarde, les fusions de sociétés[3636], en ce qu'elles sont liées à la dissolution des sociétés[3637]. En revanche, (i) comme les sociétés Sparkassen Versicherung et Kommunalkredit relevaient du champ d'application de la Convention de Rome avant la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière et qu'elles ont donc valablement opté pour le droit allemand comme droit applicable aux deux contrats d'emprunt et (ii) vu qu'une fusion transfrontalière entraîne par définition, par le biais du transfert de patrimoine dont elle s'accompagne, la substitution sans novation de la société absorbante à la société absorbée comme partie à l'ensemble des contrats conclus par cette dernière, la loi applicable à un contrat avant la réalisation de l'opération demeurera celle applicable à ce même contrat à la suite de la fusion[3638]. En d'autres termes, une fusion transfrontalière est sans incidence sur la validité d'une clause de droit applicable contenue dans un contrat conclu avant la fusion. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, la Cour constate que « les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société »[3639], c'est-à-dire pour la

3633 Pour le détail des faits, voir : arrêt *KA Finanz*, pts. 19–39.
3634 Arrêt *KA Finanz*, pt. 47.
3635 Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (version consolidée), *J.O.*, C 027, 26 janvier 1998, pp. 34–46 (ci-après la « **Convention de Rome** »).
3636 Arrêt *KA Finanz*, pt. 51 et Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l'université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l'université de Paris I, *J.O.*, C 282, 31 octobre 1980, p. 12.
3637 Arrêt *KA Finanz*, pt. 52.
3638 Arrêt *KA Finanz*, pts. 49–59.
3639 Point 1, deuxième tiret du dispositif et pt. 61 de l'arrêt *KA Finanz*. Pour une analyse détaillée de ce volet de l'arrêt *KA Finanz*, voir *supra* nos 720 et 721.

société Kommunalkredit, ceux prévus par le droit chypriote[3640], et non ceux du droit autrichien comme l'avait estimé l'*Oberlandesgericht Wien*[3641].

732. Les conséquences sur les scissions transfrontalières. Il découle de ces enseignements de la Cour de justice qu'une fusion transfrontalière ne peut être utilisée pour (i) écarter le choix de la loi applicable opéré par les parties dans un contrat ou encore (ii) permettre au débiteur absorbé de bénéficier de la législation potentiellement plus favorable de l'absorbante et d'opposer les mécanismes de celle-ci à ses débiteurs préexistants. À cet égard, il est utile de préciser que même si dans l'arrêt *KA Finanz*, la Cour s'est exclusivement prononcée sur l'interprétation de l'article 1er, § 2, e) de la Convention de Rome en raison du fait que les deux contrats d'emprunt avaient été conclus sous l'empire de celle-ci[3642], la solution sous le Règlement Rome I étant venu remplacer ladite convention doit être identique dans la mesure où celui-ci n'est que le résultat de la modernisation et de la transformation en règlement de l'ancienne convention[3643]. Par ailleurs, une telle interprétation se justifie également à la lumière du fait que le texte de l'article 1er, § 2, e) de la Convention de Rome est pratiquement identique à celui de l'article 1er, § 2, f) du Règlement Rome I. En ce qui concerne plus spécifiquement les scissions transfrontalières, bien que la Cour de justice ait rejeté la première question préjudicielle en raison du fait que celle-ci portait sur l'interprétation de la Convention de Rome au regard des scissions de sociétés alors que les faits à la base du litige au principal concernaient une fusion par absorption[3644], on peut partir du principe qu'en raison du fort lien de parenté existant entre fusions et scissions, la solution aurait été identique dans l'hypothèse d'une scission[3645]. Cette solution est en outre confortée par le texte du rapport établi par les professeurs Giuliano et Lagarde sur la Convention de Rome sur lequel la Cour de justice s'est basée. En effet, celui-ci prévoit que la dissolution d'une société comprend notamment « la disparition de la société par fusion ou par un autre mode semblable »[3646], ce qui devrait en toute logique inclure les scissions. On peut donc déduire de ce qui précède qu'une scission transfrontalière n'aura aucun effet sur la loi applicable à un contrat conclu entre un créancier et une des sociétés impliquées dans la scission, ce dernier étant soumis à la loi choisie par les parties[3647] ou, à défaut, par la loi déterminée en fonction de facteurs de rattachement spécifiques[3648]. Il s'ensuit qu'une protection renforcée en cas d'opération transfrontalière ne se justifie pas davantage à ce titre.

3640 Arrêt *KA Finanz*, pts. 60 et 61.
3641 Arrêt *KA Finanz*, pt. 32.
3642 Arrêt *KA Finanz*, pt. 43.
3643 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, p. 845 et M. LEHMANN et St. LEIBLE, « Die Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ("Rom I") », *RIW*, 2008, p. 529.
3644 Arrêt *KA Finanz*, pt. 44.
3645 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, p. 846.
3646 Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l'université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l'université de Paris I, *J.O.C.E.*, C282, 31 octobre 1980, p. 12.
3647 Art. 3, § 1er du Règlement Rome I.
3648 Art. 4, § 1er du Règlement Rome I.

§7. Un droit national potentiellement moins protecteur

733. Une nécessaire relativisation. Un des arguments susceptibles de justifier la mise en place d'un régime de protection renforcée des créanciers de la société scindée en cas d'opération transfrontalière est que le droit des sociétés applicable aux sociétés bénéficiaires étrangères est susceptible d'être moins protecteur à leur égard[3649], l'exemple classique étant que les règles relatives au montant du capital social et à son maintien sont susceptibles de diverger d'un État membre à un autre[3650]. À titre d'illustration, on peut citer le fait que le capital social d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois doit s'élever au minimum à douze mille euros[3651] alors qu'une société à responsabilité limitée de droit belge n'est plus soumise à une exigence de capital social minimum[3652]. Sans prendre position sur l'intérêt du capital social pour la protection des créanciers[3653] à l'instar de la Cour de justice[3654], cette affirmation mérite d'être nuancée sous trois angles distincts. Tout d'abord, de nombreux droits nationaux tels que les droits belges[3655], luxembourgeois[3656], allemand[3657] et autrichien[3658] autorisent les scissions hétérogènes. Il s'ensuit qu'à titre d'illustration, en cas de scission par absorption d'une société anonyme de droit luxembourgeois qui doit avoir un capital minimum de trente mille euros[3659] au bénéfice de deux sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui doivent avoir chacune un capital social minimum d'au moins douze mille euros[3660], les règles relatives au montant du capital social minimum seront inévitablement moins strictes au sein des sociétés bénéficiaires

3649 Voir *supra* n° 699.

3650 Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 9 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 28 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 320 et 321 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 471 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 809.

3651 Art. 710-5, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3652 Art. 5:1 du CSA.

3653 À ce sujet voir notamment : J. ARMOUR, G. HERTIG et H. KANDA, « Transactions with creditors », *op. cit.*, pp. 124–127 ; J. ARMOUR, « Share capital and creditor protection : efficient rules for a modern company law », *Modern Law Review*, 2000, pp. 355–378 ; J. ARMOUR, « Legal capital : an outdated concept ? », *op. cit.*, pp. 5–27 ; H. CULOT, *op. cit.*, pp. 968 et 969 ; H. CULOT et P.-Y. THOUMSIN, *op. cit.*, pp. 93–94, nos 2–4 ; H. CULOT et M. VAN BUGGENHOUT, *op. cit.*, pp. 193–200 ; F. DIAS SIMOES, *op. cit.*, pp. 166–172 ; L. ENRIQUES et J. MACEY, *op. cit.*, pp. 1165–1204 ; J. FONTEYN, *op. cit.*, pp. 272 et 273 ; M. LUTTER, *Legal capital in Europe*, 2006 ; A. NAVEZ, *op. cit.*, pp. 102 et 103, nos 224–225 ; M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 809 ; P. SANTELLA, *op. cit.*, pp. 431–435 et W. SCHÖN, « The future of legal capital », *EBOR*, 2004, vol. 5(3), pp. 429–448. Voir également : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 12 :

3654 Arrêt *Inspire Art*, pt. 135.

3655 Voir art. 12:1, § 1er, al. 1er du CSA en vertu duquel toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique peuvent réaliser une scission.

3656 Voir art. 1030-1, al. 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales en vertu duquel toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique et les groupements d'intérêt économique peuvent procéder à une scission.

3657 Voir § 1(1), 2. UmwG en vertu duquel toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique et ayant leur siège en Allemagne peuvent réaliser une scission interne.

3658 Voir § 1(1) SpaltG selon lequel toutes les sociétés de capitaux peuvent procéder à une scission interne.

3659 Art. 420-1, § 1er, 1° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3660 Art. 710-5, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

même dans un contexte purement interne. On ne comprend dès lors que difficilement pourquoi le même risque justifierait une protection accrue dans un contexte transfrontalier[3661]. Ensuite, deuxièmement, afin de réaliser la liberté d'établissement, le Conseil de l'Union européenne a, en application de l'article 50, § 2, g) du TFUE (ancien article 44, § 2, g) du Traité CE), adopté un certain nombre de directives en vue de coordonner « dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers »[3662]. Au nombre de celles-ci, on compte notamment (i) la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers[3663] et (ii) la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital[3664]. Ces deux directives, dont les dispositions modifiées figurent à l'heure actuelle au sein de la Directive Sociétés[3665], assurent une équivalence minimale dans la protection des créanciers des sociétés anonymes au sein de l'Union européenne[3666] de sorte qu'une scission transfrontalière homogène impliquant des sociétés anonymes situées dans des États membres différents n'entraînera pas nécessairement une baisse significative du niveau de protection des créanciers en vertu du droit des sociétés[3667].

3661 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, pp. 809 et 810.

3662 Arrêt *Inspire Art*, pts. 6 à 12.

3663 Première directive (CEE) 68/151 du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, *J.O.*, L 065, du 14 mars 1968, pp. 8–12. Cette première directive a par la suite été abrogée par la directive (CE) 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'E.E.E.), *J.O.*, L 258, 1er octobre 2009, pp. 11–19, elle-même abrogée par la Directive Sociétés.

3664 Deuxième directive (CEE) 77/91 du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, *J.O.*, L 26 du 31 janvier 1997, pp. 1–13. Cette deuxième directive a par la suite été abrogée par la directive (UE) 2012/30 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 315 du 14 novembre 2012, elle-même abrogée par la Directive Sociétés.

3665 Titre I de la Directive Sociétés.

3666 3e considérant de la Directive Sociétés.

3667 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 321 et J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, p. 166.

Troisièmement, l'éventuelle diminution du niveau de protection des créanciers ne doit pas être appréciée à l'aune d'une mesure isolée du droit des sociétés telle que celles relatives aux distributions faites aux associés ou à la libération du capital social, mais en fonction de la protection des créanciers, offertes par un ordre juridique déterminé pris dans son ensemble[3668] et regroupant des matières aussi diverses que le droit de l'insolvabilité, le droit des obligations, le droit des sociétés ou encore le droit comptable et le droit pénal[3669]. Il s'ensuit que l'exercice visant à comparer l'éventuel niveau de protection des créanciers d'une personne morale dans deux États membres distincts est particulièrement délicat, ne fût-ce qu'en raison du fait qu'une protection plus faible des créanciers par le biais du droit des sociétés peut être compensée par un droit de l'insolvabilité plus sévère. Conclure à la nécessité d'une protection renforcée des créanciers au titre d'un droit national potentiellement moins protecteur serait par conséquent beaucoup trop simpliste, en plus du fait que le droit national applicable aux créanciers de la société scindée pourrait fort bien s'avérer moins protecteur que celui applicable aux sociétés bénéficiaires.

§8. Conclusion sur la nécessité d'un régime renforcé en cas d'opération transfrontalière

734. Une protection des créanciers calquée sur celle applicable en cas d'opération interne. Malgré une formulation ambiguë de l'article 121 de la Directive Sociétés ayant abouti à l'émergence de régimes de protection renforcés des créanciers de la société absorbée en cas de fusion-émigration, comme, par exemple, le régime de protection *ex ante* consacré en droit allemand par les §§ 122j et 122k UmwG, une analyse du régime des fusions transfrontalières préalablement à l'entrée en vigueur de la Directive Mobilité et tel qu'interprété dans une perspective historique ainsi qu'à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt *KA Finanz* aboutit à la conclusion que les régimes de protection applicables aux fusions internes sont, tant aux yeux du législateur européen que de la Cour de justice, suffisants pour garantir une protection adéquate des intérêts des créanciers de la société absorbée en cas d'opération transfrontalière (§ 1). En revanche, une étude de droit comparé sur la question ne permet pas d'aboutir à une conclusion satisfaisante puisque les deux droits nationaux examinés ont apporté des réponses différentes à cette problématique. En effet, si le droit luxembourgeois n'a pas jugé nécessaire de prévoir de régime dérogatoire pour protéger les créanciers de la société scindée en cas de scission-émigration, cette position n'a pas été adoptée par le législateur belge (§ 2). Par contre, l'examen des dispositions de la Directive Mobilité en matière de fusions et de scissions transfrontalières permet d'aboutir à deux conclusions importantes. Tout d'abord, le législateur européen, tout en supprimant l'ambiguïté dont était affecté l'article 121 de la Directive Sociétés et en introduisant

3668 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 810 et H.-W. NEYE et B. TIMM, « Die geplante Umsetzung der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften im Umwandlungsgesetz », *op. cit.*, p. 493.

3669 P. MÜLBERT, *op. cit.*, pp. 7 et 8 et M. SIEMS, L. HERZOG et Er. ROSENHAGER, *op. cit.*, pp. 151 et 152. Voir en ce sens également : C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, pp. 5 et 6.

un régime de protection minimal des intérêts des créanciers dans le cadre des fusions transfrontalières, n'a pas introduit de mécanisme spécifique destiné à protéger les intérêts des créanciers de la société absorbée. Ensuite, le fait que la Directive Mobilité ne prévoit pas, en matière de scission transfrontalière partielle, de protection renforcée pour les créanciers de la société scindée soumis à un changement de droit national applicable à leur débiteur permet de conclure, malgré l'exclusion du champ d'application de la Directive Mobilité des opérations impliquant plus d'une société préexistante, que le législateur européen a adopté la même position à l'égard des scissions transfrontalières. Ces deux conclusions sont confortées à la fois par le fait que le régime par défaut est largement inspiré de celui applicable en cas de fusion ou de scission interne ainsi que par le fait que le mécanisme de protection de la *perpetuatio fori* prévu en matière de transformations transfrontalières n'a pas été étendu aux autres opérations (§ 3). S'il ressort des enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement que celle-ci se montrerait plus que vraisemblablement très circonspecte à l'égard d'une législation nationale ne respectant pas le principe de non-discrimination des opérations internes par rapport aux opérations transfrontalières en imposant des mesures de protection additionnelle dans l'intérêt des créanciers soumis à un changement de *lex societatis*, il n'est toutefois pas possible de conclure *ab initio* à l'impossibilité d'une justification d'une telle mesure. Cette limite est illustrée par les débats en droit allemand sur la conformité du régime d'exception de l'UmwG applicable en cas de fusion transfrontalière aux articles 49 et 54 du TFUE qui démontrent bien qu'en l'absence d'une décision de la Cour de justice en la matière, toute conclusion reste affectée d'un certain aléa (§ 4). La réfutation de l'argument selon lequel une protection accrue des créanciers soumis à un changement de *lex societatis* se justifierait en raison des difficultés procédurales auxquelles ceux-ci seraient confrontés en cas de scission transfrontalière à la lumière tant des règles de compétence applicables en vertu du Règlement Bruxelles I*bis* que de la fréquence des procédures transfrontalières, permet d'écarter une des principales causes de justification d'un régime dérogatoire (§ 5). Il en va de même de l'analyse de l'incidence d'une scission transfrontalière sur le droit applicable au contrat conclu entre un créancier et la société scindée qui, mise en perspective par les faits à la base de l'arrêt *KA Finanz*, montre qu'une telle opération n'a aucune incidence sur celui-ci (§ 6). En définitive, même l'argument selon lequel une protection renforcée se justifierait en raison du caractère moins protecteur du droit national applicable aux sociétés bénéficiaires par rapport à celui de la société scindée peut être écarté en raison d'une part de l'harmonisation des différents droits des sociétés nationaux par le législateur européen et, d'autre part, en raison de son caractère beaucoup trop simpliste (§ 7). En conclusion, le raisonnement tenu par de nombreux auteurs à l'égard des fusions transfrontalières selon lequel le caractère transfrontalier de l'opération ne justifie pas un niveau de protection plus élevé que dans le cas d'une opération purement interne[3670] trouve également à s'appliquer aux scissions transfrontalières.

[3670] Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 74 ; Fl. DRINHAUSEN et A. KEINATH, « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes… », *op. cit.*, p. 732 et A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 111. *Contra* : S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 314 et 315 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 472.

SECTION 5. LA NÉCESSITÉ D'UNE PROTECTION RENFORCÉE DES CRÉANCIERS DE LA SOCIÉTÉ SCINDÉE

§1. Position de la question

735. Une situation foncièrement plus risquée. S'il découle de la section précédente qu'une protection accrue des créanciers en cas de scission transfrontalière ne se justifie pas par rapport à une scission interne, il convient encore d'examiner si la nature particulière d'une scission n'impose pas de protéger davantage les créanciers de la société scindée que ceux de la société absorbante. En effet, si l'analyse des risques engendrés par une telle opération a permis de mettre en lumière le fait que les créanciers des sociétés bénéficiaires préexistantes sont susceptibles d'être également impactés par une scission dans la mesure où ils se retrouveront par l'effet de l'opération en concurrence avec les créanciers de la société scindée, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la solvabilité de leur débiteur[3671], il n'en demeure pas moins que les créanciers de la société scindée seront les principaux impactés par l'opération[3672]. En effet, d'une part, seuls les créanciers de la société scindée seront confrontés à une substitution de débiteur sans leur accord[3673] et d'autre part, le fait que l'éclatement du patrimoine de la société scindée soit une composante essentielle de toute scission et que les associés des sociétés impliquées jouissent d'une grande liberté au niveau de la répartition de ce dernier est source de grande insécurité pour les créanciers de la société scindée[3674]. Contrairement à la section précédente qui s'articulait autour de la distinction entre opération transfrontalière et opération interne, la présente section se concentrera donc sur les différences existant entre la situation des créanciers de la société absorbée et ceux des sociétés bénéficiaires, indépendamment de la nature interne ou transfrontalière de l'opération. En analysant comment cette question a été traitée tant par le législateur européen (§ 2) que par différents législateurs nationaux (§ 3) et en se penchant sur la délicate question de l'attribution des éléments oubliés ou inconnus du patrimoine de la société scindée (§ 4), il sera

3671 Voir en ce sens à propos des fusions internes : R. MARSCH-BARNER in KALLMEYER, (dir.), *op. cit.*, pp. 325 et 326, n° 1 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 203, n° 35.

3672 Voir *supra* n° 703 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 86 et G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 37.

3673 Voir au sujet de ce risque en cas de fusion : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 274 ; G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 60 ; B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 1 ; L. L. HANSEN, *op. cit.*, p. 192 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 334, n° 4 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 76 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 309 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 1 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 470 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 73 et s. ; F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 203, n° 35 ; A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 111 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 50. Voir également à propos des scissions transfrontalières : Th. PRÜM, *ibidem*, p. 86 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 49.

3674 Étude d'impact, p. 68 ; Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 30 et G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, *ibidem*, p. 72 ; S. KALSS, *ibidem*, p. 77 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 7 et M. WINNER, *ibidem*, p. 51.

possible de tirer une conclusion sur la nécessité d'une telle protection renforcée dans un éventuel régime européen des scissions transfrontalières (§ 5).

§ 2. La position du législateur européen

736. Présentation. Afin de déterminer dans quelle mesure les risques additionnels encourus par les créanciers de la société scindée justifient la mise en place d'un régime de protection renforcée, il convient tout d'abord d'analyser dans quelle mesure le législateur européen, à la fois dans le Directive Sociétés et la Directive Mobilité, a jugé opportun d'introduire des mécanismes de protection additionnels destinés à sauvegarder les intérêts de ces derniers.

737. La Directive Sociétés. À l'égard des fusions internes, l'exposé des motifs de la Troisième Directive insistait sur le fait que la situation des créanciers de l'absorbée n'était en rien comparable à celle des créanciers de la société absorbante dans la mesure où ces derniers ne se voient pas imposer de nouveau débiteur[3675], de sorte que même s'il ressort clairement du texte de la Directive Sociétés que tant les créanciers de la société absorbée que ceux de la société absorbante doivent être protégés[3676], une protection renforcée pour les créanciers de la société absorbée est possible[3677]. Cette position, qui figurait également dans la proposition de dixième directive de 1985[3678], se retrouve à l'égard de scissions internes[3679]. En outre, si le législateur européen a prévu un régime de protection minimum par le biais de l'octroi de garanties s'appliquant de prime abord uniformément aux créanciers de toutes les sociétés impliquées, il serait erroné d'en déduire qu'il considérait que tous les créanciers des sociétés impliquées nécessitaient une protection uniforme[3680]. En effet, le système de l'octroi des garanties présuppose notamment que le créancier demandeur parvienne à établir que la situation financière tant de la société scindée que de la société à laquelle cette obligation sera transférée rend cette protection nécessaire[3681]. Or, une telle preuve, en raison de l'éclatement du patrimoine de la société scindée et de la nécessité que chaque fraction ait un actif net positif[3682], sera par définition plus aisée à apporter par le créancier de la

[3675] Proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, paragraphe 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes du 5 juin 1970, COM (70) 633, p. 31.

[3676] Art. 91, § 1er de la Directive Sociétés et S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 83 et M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 142.

[3677] Art. 99, § 3 de la Directive Sociétés qui prévoit explicitement que « [l]a protection peut être différente pour les créanciers de la société absorbante et ceux de la société absorbée ».

[3678] Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, exposé des motifs, COM (84) 727 final, présentée par la Commission au Conseil le 14 janvier 1985, *J.O.C.E.*, n° C 23/11, 23 janvier 1985, p. 9.

[3679] Art. 146, § 4 de la Directive Sociétés qui renvoie à l'art. 99, § 3 de la Directive Sociétés.

[3680] *Contra* : M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 142 qui en se basant sur l'art. 12, § 1er et 2 de la sixième directive (actuellement art. 146, § 1er et 2 de la Directive Sociétés) considère que le législateur européen n'a pas souhaité faire une telle distinction.

[3681] Art. 146, § 2 de la Directive Sociétés.

[3682] À ce sujet, voir *supra* nos 118 à 120.

société scindée. En outre, afin de parer ces risques additionnels[3683], la Directive Sociétés[3684] prévoit dans son régime par défaut que si un des créanciers de la société scindée n'obtient pas satisfaction de la société à laquelle sa créance a été transférée, les sociétés bénéficiaires seront tenues solidairement pour cette obligation, tout en précisant que les États membres peuvent (i) limiter cette responsabilité solidaire à l'actif net attribué à chacune des sociétés autres que celle à laquelle l'obligation a été transférée ou encore (ii) exclure cette solidarité si la scission est soumise au contrôle d'une autorité judiciaire et qu'une majorité des créanciers représentant les trois quarts du montant des créances, soit global, soit d'une catégorie spécifique, de la société scindée y a renoncé lors d'une assemblée générale. En outre, les États membres peuvent également (i) simplement se contenter de prévoir une responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires pour les dettes de la société scindée[3685] ainsi que (ii) combiner la protection par le biais de l'octroi de garanties avec une responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires, tout en ayant alors la possibilité de limiter cette solidarité à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés[3686].

738. La Directive Mobilité. Compte tenu du champ d'application limité de la Directive Mobilité et de l'exclusion des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[3687], la question de la nécessité d'une protection renforcée des créanciers de la société scindée ne se pose que dans une moindre mesure[3688]. Il est toutefois intéressant de relever que le régime de protection des créanciers de la société scindée s'articulera essentiellement autour de l'octroi de garanties. Ainsi, il est prévu que les créanciers de la société scindée disposant de créances nées antérieurement à la publication du projet de scission et non encore échues au moment de cette publication, insatisfaits des garanties proposées dans le projet de scission, pourront saisir une autorité judiciaire ou administrative dans les trois mois suivant la publication du projet de scission pour demander des garanties adéquates s'ils parviennent à démontrer de manière crédible que la scission compromet le recouvrement de leurs créances et qu'ils ne disposent pas déjà de garanties satisfaisantes à cet égard[3689]. S'il s'avère qu'un créancier n'obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette a été transférée, toutes les autres sociétés bénéficiaires en seront tenues conjointement et solidairement, cette solidarité étant toutefois obligatoirement limitée à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, de l'actif net attribué à chacune des sociétés[3690]. Cette solidarité passive, en ce qu'elle ne bénéficiera par définition qu'aux créanciers

3683 Voir en ce sens : W. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 58 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 1.
3684 Art. 146, § 3 de la Directive Sociétés.
3685 Art. 146, § 6 de la Directive Sociétés.
3686 Art. 146, § 7 de la Directive Sociétés.
3687 À ce sujet, voir *supra* n°s 341 à 346.
3688 Voir 38e considérant de la Proposition de la Commission où cette limitation du champ d'application *ratione materiae* est justifiée par le fait que les scissions transfrontalières impliquant une société préexistante sont « très complexes, nécessitant la participation d'autorités compétentes de plusieurs États membres et entraînant des risques supplémentaires en termes de fraude et de contournement de ces règles ».
3689 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
3690 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.

de la société scindée, traduit un souci particulier du législateur européen à leur égard. Il est cependant intéressant de relever que le régime de protection des créanciers en cas de fusions transfrontalières ne prévoit pas[3691], contrairement au régime applicable aux fusions internes en vertu de la Directive Sociétés[3692], que la protection des créanciers de la société absorbée peut être différente de celle des créanciers de la société bénéficiaire. Cette omission est toutefois sans conséquence en raison de l'application subsidiaire du régime applicable aux fusions internes[3693].

739. Un besoin de protection supplémentaire. Il ressort indiscutablement de cette analyse de la position du législateur européen tant dans la Directive Sociétés que dans la Directive Mobilité, que ce dernier a jugé que les risques spécifiques engendrés par une scission pour les créanciers des sociétés absorbées justifiaient des mesures de protection additionnelles.

§ 3. Analyse de droit comparé

740. Présentation. Compte tenu de la marge de manœuvre laissée par le législateur européen aux différents États membres dans la Directive Sociétés, il est intéressant de se pencher sur la manière dont les législateurs nationaux ont traité la question de la situation plus défavorable du créancier de la société scindée. Un bref examen de droit comparé en la matière permettra de voir si les États membres ont préféré se limiter à un renforcement minimal de la protection des intérêts des créanciers de la société scindée ou si, au contraire, à la lumière des risques encourus par cette catégorie spécifique de créanciers, leur régime de protection a été significativement revu à la hausse par rapport aux autres créanciers. À cet égard, il paraît opportun d'examiner tout d'abord les droits allemands et autrichiens dans la mesure où l'existence d'un régime de protection dérogatoire en cas d'opération transfrontalière[3694] démontre que ces législateurs nationaux sont particulièrement concernés par la situation des créanciers et, d'autre part, les droits belges[3695] et luxembourgeois[3696] qui reconnaissent tous deux déjà les scissions transfrontalières.

741. La protection asymétrique du droit autrichien. En cas de scission interne soumise au droit autrichien, le § 15(1) SpaltG prévoit que toutes les sociétés bénéficiaires seront tenues solidairement des dettes de la société scindée nées antérieurement à la publication de la scission, cette solidarité étant limitée à l'actif net attribué à chacune des sociétés autres que celle à laquelle l'obligation a été transférée en vertu du projet de scission. En outre, en vertu du § 15(2) SpaltG, seuls les créanciers de la société scindée peuvent, pour peu qu'ils ne puissent réclamer le paiement de leur créance, demander une garantie auprès des sociétés bénéficiaires (i) s'ils introduisent cette demande dans les six mois suivant la publication de l'inscription de la scission et (ii) s'ils parviennent à

3691 Art. 126*ter* de la Directive Mobilité.
3692 Art. 99, § 3 de la Directive Sociétés.
3693 Art. 121, § 1er, b) de la Directive Sociétés.
3694 Voir *supra* n° 719.
3695 Art. 12:73, § 1er et 12:90, § 1er du CSA.
3696 Art. 1030-1, al. 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

rendre crédible que la scission met en péril le paiement de leur créance. Si une telle garantie leur est fournie, la solidarité de principe des sociétés bénéficiaires tombe[3697]. En revanche, si la garantie est réclamée devant la juridiction compétente dans le délai susmentionné, toutes les sociétés impliquées seront tenues solidairement et de manière illimitée de la dette en question, et ce, jusqu'à ce qu'une garantie ait été fournie ou la demande rejetée[3698]. En d'autres termes, le législateur autrichien a considéré que seuls les créanciers de la société scindée nécessitaient une protection spécifique. Cette position est d'autant plus surprenante qu'en matière de fusions internes, la possibilité de demander des garanties était ouverte tant aux créanciers de la société absorbée qu'aux créanciers de la société bénéficiaire[3699], ce qui a pu être justifié par le fait que les créanciers ne sont pas en position de décider quelle sera la société absorbée et quelle sera la société absorbante[3700].

742. La protection asymétrique du droit allemand. À l'égard des scissions internes, le § 133 UmwG opte en premier lieu pour une responsabilité solidaire (« *gesamtschuldnerische Haftung* ») à charge des sociétés bénéficiaires de l'opération. Ce choix, expressément laissé à la discrétion des États membres par la Directive Sociétés[3701], est justifié selon les travaux préparatoires par la grande liberté dont jouissent les associés dans la répartition des éléments d'actif et de passif du patrimoine de la société scindée[3702]. En sus de cette première protection, tous les créanciers des sociétés impliquées disposent, dans un délai de six mois suivant le jour de la publication de la scission dans le registre du siège de leur débiteur de la possibilité de demander des garanties, pour autant qu'ils ne puissent en réclamer le paiement et qu'ils parviennent à démontrer de manière crédible que l'opération compromet le paiement de leur créance[3703].

743. Le régime de protection renforcé du CSA. En droit belge, tant les créanciers de la société scindée que ceux des sociétés bénéficiaires disposent de la possibilité de demander l'octroi d'une sûreté dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de l'acte constatant la scission pour peu (i) que leur créance soit certaine avant cette publication mais pas encore exigible ou (ii) que leur créance ait fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant la scission[3704]. À défaut d'accord, ou si le créancier n'a pas obtenu sa sûreté, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice, siégeant en référé[3705]. Ce dernier, s'il estime qu'une sûreté doit être fournie, fixera celle-ci ainsi que le délai dans lequel elle doit

3697 § 15 (1) *in fine* SpaltG.
3698 § 15 (3) SpaltG.
3699 § 226(1) öAktG.
3700 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 336, n° 10.
3701 Art. 146, § 6 de la Directive Sociétés.
3702 Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 122 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 1.
3703 § 133(1), 2e phrase UmwG qui renvoie au § 22 UmwG.
3704 Art. 12:15, § 1er, al. 1er du CSA.
3705 Art. 12:15, § 1er, al. 3 du CSA.

être fournie[3706]. Si malgré cela, la sûreté n'est pas fournie dans les temps, la créance deviendra immédiatement exigible et les sociétés bénéficiaires seront tenues solidairement de cette obligation[3707]. Ce régime général s'adressant à tous les créanciers des sociétés impliquées dans une scission est combiné à un mécanisme de protection additionnel des créanciers de la société scindée étant donné que le législateur belge a prévu que les sociétés bénéficiaires, en ce compris la société scindée en cas d'opération assimilée à la scission[3708], demeureraient solidairement tenues (i) des dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participation à une scission, ainsi que (ii) des dettes pour lesquelles une action a été introduite en justice ou par voie d'arbitrage par le créancier avant l'acte constatant la scission[3709]. Cette solidarité est toutefois limitée, pour les sociétés bénéficiaires auxquelles la dette en question n'a pas été transférée, à l'actif net attribué à celles-ci[3710]. Il est intéressant de relever que cette solidarité par défaut ne figurait pas dans la transposition originale de la Sixième Directive dans les anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales car le législateur belge, tout en reconnaissant clairement la nécessité de protéger davantage les créanciers de la société scindée[3711] avait préféré articuler la protection des créanciers autour de l'octroi de sûretés comme en matière de fusions. Selon les travaux préparatoires[3712], ce choix s'explique par le manque de souplesse d'une solidarité sans réserve ainsi que par le fait qu'un système articulé autour de l'octroi de garanties permet de fixer plus rapidement les obligations de chacune des sociétés impliquées. Cependant, par une loi du 13 avril 1995[3713], un paragraphe 3 a été ajouté à l'article 174/38 des anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour prévoir une solidarité passive limitée et ce, « afin d'éviter le recours abusif à la scission »[3714]. Ceci montre bien que le législateur belge, malgré son souhait initial de préserver une certaine flexibilité dans le cadre des scissions, a constaté qu'une protection renforcée des créanciers de la société scindée était inéluctable.

744. Le régime de protection renforcé du droit luxembourgeois. En droit luxembourgeois, tout comme en droit belge, le régime de protection des créanciers s'articule en priorité autour de la demande de garanties. Il est ainsi tout

3706 Art. 12:15, § 1er, al. 4 du CSA.
3707 Art. 12:15, § 1er, al. 5 du CSA.
3708 Art. 12:17, al. 2 du CSA.
3709 Art. 12:17, al. 1er, 1re phrase du CSA.
3710 Art. 12:17, al. 1er, 2e phrase du CSA.
3711 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 30 où il est fait mention « de la situation peu favorable du créancier qui, en cas de scission, se voit imposer un changement de débiteur, avec la conséquence que le patrimoine de son débiteur initial, qui constituait son gage général, est réparti entre plusieurs sociétés ».
3712 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 30.
3713 Art. 69 de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, disponible sur www.ejustice.just.fgov.be (26/09/2019).
3714 Proposition de loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, commentaires des articles, *Doc.*, Ch., 1992–1993, 1005/1, disponible sur www.lachambre.be (26/09/2019), p. 14.

d'abord prévu que tous les créanciers des sociétés impliquées dans une scission dont la créance est antérieure à la date de publication des actes constatant la scission disposent de la possibilité de demander la constitution de sûretés au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, pour peu qu'ils parviennent à démontrer, de manière crédible, que l'opération constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société débitrice ne leur a pas fourni de garanties adéquates[3715]. En outre, si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance deviendra immédiatement exigible[3716]. Cette première protection est combinée à une responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires, limitée à l'actif net attribué à chacune d'entre elles, dès lors que le créancier de la société scindée n'a pas eu satisfaction de la part de la société à laquelle l'obligation a été transférée conformément au projet commun de scission[3717]. Si le commentaire de l'article ne fait pas mention d'une quelconque nécessité de protéger davantage les créanciers de la société scindée et se contente de se référer aux dispositions de la Sixième Directive[3718], il n'empêche que ces derniers, par le biais de la solidarité passive des sociétés bénéficiaires en cas de défaut de la société à laquelle l'obligation a été transférée, bénéficieront d'une protection additionnelle par rapport aux créanciers des sociétés bénéficiaires.

745. Conclusion. Cette analyse de droit comparé a permis de démontrer que dans l'esprit des législateurs nationaux, les créanciers de la société scindée nécessitent une protection additionnelle par rapport aux créanciers des sociétés bénéficiaires. À cet égard, l'exemple belge est particulièrement éloquent puisque dans un second temps, le législateur est venu renforcer la protection des créanciers de la société scindée.

§4. La question des éléments oubliés ou inconnus du patrimoine de la société scindée

746. Présentation. S'il est indéniable que les créanciers de la société scindée encourent un risque général lié au fait que les associés peuvent librement déterminer la répartition des éléments d'actif et de passif de la société scindée entre les sociétés bénéficiaires[3719], ce risque se manifeste tout particulièrement à l'égard des éléments oubliés ou inconnus. En effet, malgré l'exigence d'une

3715 Art. 1031-10, § 1er, al. 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3716 Art. 1031-10, § 1er, al. 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3717 Art. 1031-10, § 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3718 Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Commentaire des articles, *Doc.*, Ch. des députés, 1984–1985, n° 2897, disponible sur https://chd.lu (26/09/2019), pp. 31 et 32.
3719 Étude d'impact, p. 68 ; Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 30 et G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 72 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 77 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 7 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 51.

répartition précise et *a priori* exhaustive des éléments du patrimoine de la société scindée dans le projet de scission[3720], il est toujours possible qu'un élément ait été oublié, soit volontairement soit involontairement ou ait tout simplement été inconnu au moment de la rédaction du projet commun. À titre d'illustration, ce sera tout particulièrement le cas en présence d'une responsabilité du fait d'un produit défectueux mis sur le marché par la société scindée avant la réalisation de l'opération[3721] ou d'une responsabilité pour dégâts environnementaux[3722]. Si dans le cas d'un élément d'actif, la situation est peu problématique, il n'en va pas de même en cas d'élément de passif oublié ou inconnu puisqu'*a priori* aucune des sociétés ne souhaitera spontanément en assumer la charge. Il s'ensuit qu'un créancier de la société scindée risque d'en pâtir et un certain nombre de litiges risquent de survenir[3723].

747. La nécessité d'un ensemble de règles de répartition par défaut. Dans pareille hypothèse, le régime des scissions internes prévoit qu'il conviendra dans un premier temps de voir si une interprétation du projet commun ne permettrait pas de résoudre la question de l'allocation de l'élément en question, et ce peu importe qu'il s'agisse d'un élément d'actif ou de passif[3724]. Allant encore un peu plus loin, la Directive Mobilité prévoit en outre qu'en cas de scission transfrontalière n'impliquant pas de société bénéficiaire préexistante, le projet de scission devra inclure des dispositions réglant le sort des éléments d'actif ou de passif qui n'auraient pas été explicitement alloués[3725]. Une telle obligation existe déjà en droit autrichien à l'égard de tous types de scissions[3726] et ne peut qu'être approuvée dans la mesure où elle permet une meilleure information des créanciers sur l'impact de la scission sur leur situation. À cet égard, une ventilation du patrimoine de la société scindée en respectant l'intégrité des branches d'activités[3727] ou faisant preuve d'une certaine cohérence est indéniablement de nature à fournir une clé d'interprétation du projet commun facilitant l'allocation d'un élément oublié[3728], même si une telle répartition n'est pas en soi suffisante dans la mesure où les créanciers de la société scindée ne

3720 Art. 137, §2, h) de la Directive Sociétés et art. 160*quinquies*, l) de la Directive Mobilité.

3721 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, Commentaire, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 25 et S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 827, n° 67 ; G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, p. 128 ; K. MERTENS, « Zur Universalsukzession in einem neuen Umwandlungsrecht », *AG*, 1994, p. 70 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 84 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 9.

3722 K. MERTENS, *ibidem*, p. 70 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 827, n° 67 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 133, n° 84 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 133, n° 9.

3723 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, Commentaire, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 24.

3724 Art. 137, § 3, al. 1 et 2 de la Directive Sociétés et au sujet de l'application de cette règle en droit allemand, voir : H. SCHRÖER in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n°s 79 et 80 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n°s 64 à 66.

3725 Art. 160*quinquies*, l) de la Directive Mobilité.

3726 § 2(1), n° 11 SpaltG.

3727 À ce sujet, voir *infra* n°s 884 à 888.

3728 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 827, n° 66 ; R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 175, n° 210 ; H. SCHRÖER in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n°s 79 et 80 ; St. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 88 ; M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 66 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 335, n° 502.

sont pas forcément au courant de la branche d'activités à laquelle leur créance appartient[3729] et ne peut être érigée en condition d'une scission car trop restrictive[3730]. Cependant, il est des cas où l'interprétation seule du projet commun de scission ne permet pas de résoudre la question de l'allocation d'un élément oublié. Une solution par défaut est dès lors inéluctable. Il est certes possible de considérer que dans le cas d'une scission partielle, lorsque l'interprétation du projet de scission ne permet pas de déterminer à quelle société une dette a été attribuée, tous les éléments qui n'auront pas été transférés à la société bénéficiaire demeureront dans le patrimoine de la société scindée[3731 3732], mais cette solution ne règle pas la question de la scission totale et ne se retrouve ni dans la Directive Sociétés, ni dans la Directive Mobilité. Face à cette situation, dans un contexte interne, le législateur européen a prévu que chacune des sociétés bénéficiaires en sera solidairement responsable[3733]. Cette solidarité s'étendra, en fonction de l'option choisie par les États membres au moment de la transposition de la Directive Sociétés, soit sur la totalité du patrimoine des sociétés bénéficiaires, soit uniquement sur l'actif net attribué à chacune d'elles dans le cadre de l'opération[3734]. À cet égard, il est intéressant de relever que le législateur luxembourgeois[3735], contrairement aux législateurs belge[3736], allemand[3737] et autrichien[3738], a explicitement fait le choix d'introduire cette limite de l'actif net. Ce choix du législateur luxembourgeois n'est pas avantageux pour les créanciers et a surtout pour conséquence que la situation du créancier dont la créance a été oubliée sera moins favorable que celle des créanciers dont la créance a été clairement allouée car ces derniers bénéficieront toujours d'un débiteur principal dont la responsabilité ne sera pas limitée à l'actif net qui lui aura été attribué dans le cadre de l'opération[3739]. Dans le cadre de la Directive Mobilité, le législateur européen a prévu qu'en cas d'élément de passif oublié ou inconnu que l'interprétation du projet de scission ne permet pas d'attribuer, cet élément sera réparti entre toutes les sociétés issues de la scission proportionnellement à l'actif net attribué à chacune de celles-ci[3740], de sorte que le créancier se retrouvera nécessairement avec plusieurs débiteurs principaux chaque fois pour une quote-part de sa créance, étant entendu qu'en

3729 Voir en ce sens : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 827, n° 66.
3730 *Contra* : R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 175 et 176. À ce sujet, voir *infra* n°s 884 à 888.
3731 Voir en ce sens en droit allemand : St. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 87 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 37. *Contra* en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 828, n° 67.
3732 En droit allemand, cette solution qui consiste à présumer que la société scindée conserve les dettes inconnues ou oubliées qu'il n'est pas possible d'attribuer au moyen d'une interprétation du projet de scission ne prive pas les créanciers en question de la possibilité d'agir contre la ou les sociétés bénéficiaires, puisque le législateur allemand a opté pour une solidarité passive de principe pour garantir la protection des droits des créanciers dont la créance est antérieure à la prise d'effet de la scission (§ 133(1) UmwG).
3733 Art. 137, § 3, al. 2, 1re phrase de la Directive Sociétés.
3734 Art. 137, § 3, al. 2, 2e phrase de la Directive Sociétés.
3735 Art. 1031-1, § 3, al. 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3736 Art. 12:76, al. 2 du CSA.
3737 Voir à ce sujet : H. SCHRÖER in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 80 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 131, n° 29.
3738 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 827 et 828, n° 67.
3739 Art. 1031-10, §§ 1 et 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3740 Art. 160*novodecies*, § 4 de la Directive Mobilité.

cas de défaut d'une des sociétés à laquelle une quote-part de la dette a été attribuée, il bénéficiera de la solidarité des autres sociétés, limitée toutefois à l'actif net qui leur aura été transféré[3741].

748. Conclusion. L'étude de la question du sort des éléments de dette du patrimoine de la société scindée oubliés ou inconnus montre à quel point la situation des créanciers de la société scindée peut se révéler précaire. Ce risque, auquel ne sont par définition pas confrontés les créanciers des sociétés bénéficiaires, ne fait que renforcer la nécessité de protéger davantage les créanciers de la société scindée, ce qui a été fait par le législateur européen tant dans la Directive Sociétés[3742] que dans la Directive Mobilité[3743].

§ 5. Conclusion sur la nécessité d'une protection renforcée des créanciers de la société scindée

749. La nécessité d'une protection renforcée. Si dans le cadre des fusions transfrontalières, il a pu être avancé qu'une protection accrue des créanciers de la société absorbée ne se justifiait pas au seul titre de la substitution de débiteur engendrée par l'opération dans la mesure où celle-ci est neutre à leur égard car elle peut s'avérer soit positive soit négative[3744], force est de constater que dans le cadre des scissions transfrontalières, la grande marge de manœuvre dont jouissent les associés au niveau de la répartition du patrimoine de la société scindée entraîne la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection spécifiques dans l'intérêt des créanciers de la société scindée. Ce point n'a échappé ni au législateur européen (§ 2), ni aux différents législateurs nationaux étudiés (§ 3) qui ont tous adopté des mesures si pas toujours spécifiquement, à tout le moins principalement, destinées à la défense des créanciers de la société scindée. En outre, l'examen de la question du sort des éléments de passif inconnus ou oubliés du patrimoine de la société scindée ne fait que renforcer la nécessité de protéger tout particulièrement les créanciers de la société scindée (§ 4).

SECTION 6. CONCLUSION SUR LES ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA PROTECTION DES CRÉANCIERS

750. Les balises d'un régime efficace de protection des créanciers. Comme les créanciers constituent une catégorie foncièrement hétérogène de *stakeholders*, le premier enjeu d'un mécanisme efficace de protection des créanciers, sera d'être suffisamment polyvalent pour pouvoir répondre efficacement aux six risques distincts auxquels les créanciers risquent d'être confrontés dans le cadre d'une scission transfrontalière. Le deuxième enjeu sera de garantir un juste équilibre entre les intérêts des associés à réaliser une opération et ceux

3741 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.
3742 Art. 137, § 3 de la Directive Sociétés.
3743 Art. 160*undecies*, § 2 et 160*novodecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
3744 Voir en ce sens à propos des fusions : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 52.

des créanciers à ne pas se voir indûment lésés par les associés. Le troisième enjeu sera d'intégrer correctement les enseignements de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d'établissement (i) en mettant l'accent sur la vigilance et la responsabilisation des créanciers, (ii) en examinant dans quelle mesure le cadre juridique général de protection des créanciers, composé entre autres du Règlement Insolvabilité, viendra relativiser la nécessité de prévoir des mécanismes de protection spécifiques aux scissions transfrontalières, (iii) en considérant qu'une exclusion générale des scissions transfrontalières ou une obligation de liquidation de la société scindée en vue de protéger les intérêts des créanciers ne constitueraient pas des mesures proportionnées justifiant l'entrave à la liberté d'établissement ainsi générée et (iv) en gardant à l'esprit que la possibilité de demander des garanties adéquates constitue le mécanisme de protection privilégié de la Cour de justice en raison de sa proportionnalité. En outre, il conviendra également de prendre en compte le fait que la règle de conflit de lois qui devra être applicable sera celle d'une application distributive des différentes *lex societatis* en matière de protection des créanciers complétée, le cas échéant, par une application cumulative des différents droits nationaux en présence lorsque l'efficacité du mécanisme de protection le requiert. La complexité de cette règle plaide en faveur d'un niveau d'harmonisation suffisamment élevé des mécanismes de protection des créanciers pour réduire autant que possible l'insécurité juridique qui y est liée. En ce qui concerne la délicate question de savoir si la nature transfrontalière de l'opération serait de nature à justifier la mise en place d'un mécanisme plus protecteur en cas d'opération transfrontalière qu'en cas d'opération interne, l'analyse tant du régime des fusions transfrontalières avant l'entrée en vigueur de la Directive Mobilité à l'aune des enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *KA Finanz* que du nouveau régime instauré par la Directive Mobilité plaident contre un tel renforcement. Si (i) cette conclusion n'est que partiellement confortée par l'examen de la position tant du législateur luxembourgeois que du législateur belge et (ii) même s'il est indéniable que la Cour de justice se montrerait très réservée à l'égard de la conformité à la liberté d'établissement d'une telle violation du principe d'équivalence, il est impossible de conclure *ab initio* à l'impossibilité de justifier une telle entrave. Il n'en demeure pas moins que l'argument selon lequel une protection accrue des créanciers soumis à un changement de *lex societatis* se justifierait en raison des difficultés procédurales auxquelles ceux-ci seraient confrontés en cas de scission transfrontalière a pu être réfuté. Dans un même ordre d'idées, il a été établi qu'une scission transfrontalière était sans incidence sur le droit applicable au contrat conclu entre un créancier et la société scindée et l'argument selon lequel une protection renforcée se justifierait en raison du caractère moins protecteur du droit national applicable aux sociétés bénéficiaires par rapport à celui de la société scindée a été battu en brèche en raison d'une part de l'harmonisation des différents droits des sociétés nationaux par le législateur européen et, d'autre part, en raison de son caractère beaucoup trop simpliste. Il en découle qu'un régime efficace de protection des intérêts des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière devra nécessairement largement s'inspirer du régime applicable aux opérations internes et que le seul caractère transfrontalier de l'opération ne justifie pas qu'on fasse pencher la balance en faveur des intérêts

des créanciers. Cependant, la grande marge de manœuvre dont jouissent les associés au moment de la répartition du patrimoine actif et passif de la société scindée justifie que les créanciers de la société scindée bénéficient d'une protection accrue, ce que confirme tout particulièrement la problématique des éléments de passif inconnus ou oubliés.

Chapitre 2
Les contours de la protection des créanciers dans les scissions transfrontalières

INTRODUCTION DU CHAPITRE 2

751. Plan du chapitre 2. Maintenant que les balises générales de la protection des créanciers dans le cadre des scissions transfrontalières ont pu être établies, il conviendra de porter un jugement sur les différents mécanismes de protection envisageables (section 1) ainsi que sur les aspects temporels de la protection des créanciers (section 2). Suite à une relativisation de l'intérêt de la question de la protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière à l'aune des derniers développements en matière de droit de l'insolvabilité (section 3), il sera nécessaire de s'intéresser à l'intérêt de mettre en place une « *fast track procedure* » permettant de raccourcir la durée des procédures de scissions transfrontalières ne présentant pas de danger pour les créanciers (section 4) ainsi qu'à l'articulation entre les mécanismes de protection des créanciers et les mécanismes de protection des titulaires de titres autres que des actions (section 5). Ce tour d'horizon permettra par la suite de porter un jugement éclairé sur le type d'harmonisation à privilégier dans le cadre d'une initiative européenne applicable à tout type de scission (section 6).

SECTION 1. LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES CRÉANCIERS

§1. Présentation

752. Plan de la section 1. Toujours dans l'objectif de déterminer les caractéristiques que devrait revêtir un régime général de protection des créanciers dans tout type de scission transfrontalière, il convient à présent de s'intéresser concrètement aux mécanismes permettant de préserver les différents intérêts en présence tout en ne perdant de vue ni la protection des scissions transfrontalières par la liberté d'établissement[3745] restreignant la marge de manœuvre des législateurs nationaux, ni le nécessaire objectif de neutralité de l'opération sur la situation des créanciers[3746]. En analysant les différents mécanismes de protection prévus par les législateurs nationaux et européens (§ 2), les mécanismes de protection conventionnels permettant aux parties d'aménager librement les conséquences d'une scission sur leur relation contractuelle (§ 3) et l'intérêt d'une éventuelle ventilation du patrimoine de la société scindée par branches d'activité (§ 4), il sera possible d'identifier par quels moyens les intérêts des créanciers doivent être sauvegardés dans le cadre d'une scission transfrontalière (§ 5).

§2. Les mécanismes de protection prévus par les législateurs

753. Plan du § 2. Dans le cadre de ce tour d'horizon des différents mécanismes de protection des intérêts des créanciers prévus par les législateurs et afin de pouvoir porter un jugement éclairé sur ceux-ci (D), il importe d'étudier successivement, après un bref rappel de la distinction entre mécanismes de

[3745] À ce sujet, voir *supra* n[os] 707 à 711.
[3746] À ce sujet, voir *supra* n° 706.

protection individuels et institutionnels (A), les mécanismes spécifiquement introduits par le législateur européen (B) et ceux introduits spontanément par différents législateurs nationaux (C).

A. *Mécanismes de protection individuels et institutionnels*

754. Typologie. Parmi les différents mécanismes de protection susceptibles d'être mis en place, il est possible de distinguer (i) les mécanismes de protection institutionnels qui interviennent indépendamment de toute action des créanciers et ne sont pas directement liés aux droits subjectifs des différents créanciers et (ii) les mécanismes de protection individuels dont la mise en œuvre requiert l'intervention des créanciers[3747]. Si les mécanismes de protection institutionnels présentent l'avantage de protéger indistinctement les créanciers actifs et passifs[3748] et ce, qu'ils aient ou non conscience de leur qualité de créancier, ils ont généralement un coût plus élevé dans la mesure où ils s'appliqueront sans distinction à toutes les transactions, indépendamment du fait qu'elles présentent ou non un risque concret pour les créanciers[3749]. Si cette typologie présente un indéniable intérêt en ce qu'elle permet une classification aisée des différents mécanismes de protection des créanciers, il convient toutefois de préciser que ces différents mécanismes de protection sont fréquemment liés dans la mesure où les mécanismes de protection institutionnels assurant une information adéquate des créanciers sont une condition nécessaire à l'exercice efficace de certains mécanismes de protection individuels[3750].

B. *Les mécanismes de protection prévus par le législateur européen*

755. Plan du point B. Au sein des divers mécanismes de protection envisagés par le législateur européen, on compte l'information des créanciers (1), la déclaration de l'organe de direction ou d'administration (2), la possibilité de demander une garantie adéquate (3), la solidarité des sociétés bénéficiaires de l'opération (4) et la *perpetuatio fori* (5).

1. *L'information des créanciers*

1.1. Présentation

756. La nécessaire correction de l'asymétrie d'information. D'un point de vue économique, il a été démontré que l'asymétrie d'information existant entre un débiteur et son créancier est propice à l'émergence d'un phénomène d'agence

[3747] S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 123 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 23, n° 38 ; K. SCHMIDT, « Gläubigerschutz bei Umstrukturierungen – Zum Referentenentwurf eines Umwandlungsgesetzes », *ZGR*, 1993, pp. 367 et 368 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 473 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, pp. 55 et 56.

[3748] Voir en ce sens : M. WINNER, *ibidem*, pp. 55 et 56.

[3749] Voir en ce sens : M. WINNER, *ibidem*, p. 56.

[3750] Voir en ce sens : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 335, n° 5 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 123 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 473.

et que ce dernier risque de se traduire par une « sélection adverse »[3751][3752]. En d'autres termes, le fait que les débiteurs soient mieux informés sur leur situation personnelle, et plus particulièrement sur leur solvabilité et leurs motivations, que les créanciers va inciter ces derniers à se prémunir contre ce risque additionnel, par exemple en augmentant les taux d'intérêt sur la base d'une évaluation moyenne des risques encourus. Il s'ensuit que les débiteurs solvables s'abstiendront de recourir à des financements externes en raison du coût prohibitif de ceux-ci par rapport au risque qu'ils engendrent pour leurs créanciers, alors que les débiteurs peu solvables y recourront massivement en raison du coût proportionnellement faible d'un financement externe par rapport au risque qu'ils représentent. Pour contrer ce phénomène de sélection adverse, il peut être intéressant d'intervenir en amont du problème en corrigeant autant que faire se peut l'asymétrie d'information existant entre un créancier et son débiteur dans le cadre d'une scission transfrontalière. Et ce, d'autant plus qu'il a été démontré par le biais de l'analyse d'un marché monopolistique dans lequel les acheteurs peuvent acquérir des informations sur le bien qu'ils comptent acheter, qu'au plus l'information est bon marché, au plus on s'approche de la situation dans laquelle les prix deviennent parfaitement révélateurs[3753]. Il s'ensuit que le coût de la dette externe devrait parfaitement refléter la solvabilité du débiteur et que les capitaux disponibles seraient alloués de manière efficace[3754].

757. Un mécanisme peu intrusif. La Cour de justice semble elle-même favorable à la protection des créanciers par ce moyen[3755] qui n'est pas sans rappeler la jurisprudence *Cassis de Dijon* en matière de libre circulation des

[3751] Par « sélection adverse » ou « *adverse selection* » en anglais, on entend « *precontractual opportunism where one contracting party uses his private information to the counterparty's disadvantage. For example, the adverse selection problem can arise when a woman planning a pregnancy purchases health insurance, when a car rental customer secretly planning a trip through a Golan Heights minefield buys comprehensive insurance on the car, or when a pyromaniac purchases fire insurance. In all three cases, the agent (insured or customer) has private information with respect to the higher anticipated costs of the insurance coverage or lease, but pays a "pooling" premium for the incident or casualty coverage. Obviously, this private information affects the behavior of insurers and other insured clients, in what might otherwise be taken to be a suboptimal manner, referred to as the adverse selection problem.* », voir : J. L. TEALL, *Financial trading and investing*, 2nd ed., London, Academic Press, 2018, p. 147. À ce sujet, voir également : G. AKERLOF, « Market for "lemons": quality uncertainty and the market mechanism », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, 1970, pp. 488–500.

[3752] Voir en ce sens : J. ARMOUR, « Share capital and creditor protection : efficient rules for a modern company law », *op. cit.*, p. 359 et H. MERKT, *op. cit.*, p. 99. Voir également : G. AKERLOF, *ibidem*, pp. 488–500 qui en se basant sur une analyse du marché des voitures d'occasion a démontré que si le marché est affecté par une asymétrie d'information, seuls des biens inférieurs, ou dans un cas extrême, aucun bien, ne feront l'objet d'un échange sur le marché. Voir également F. HERWEG et D. MÜLLER, « Overconfidence in the markets for lemons », *Scandinavian Journal of Economics*, 2016, vol. 118(2), pp. 354–371 qui en partant du constat empirique que, contrairement à ce qui avait été prédit par Akerlof, le nombre de véhicules d'occasion vendus sur eBay Motors aux États-Unis était relativement élevé, ont démontré que la présence d'acheteurs excessivement confiants en leurs capacités permettait d'éviter une situation de sélection adverse totale, mais excluait de ce fait les acheteurs rationnels du marché et incitait les vendeurs à cacher d'autant plus les qualités réelles des biens vendus.

[3753] H. BESTER et K. RITZBERGER, « Strategic pricing, signalling, and costly information acquisition », International *Journal of Industrial Organization*, 2001, vol. 19, issue 9, pp. 1347–1361 et F. HERWEG et D. MÜLLER, *op. cit.*, p. 256.

[3754] Voir en ce sens : H. MERKT, *op. cit.*, p. 100.

[3755] Voir *supra* n° 708.

marchandises[3756], ne fût-ce qu'en raison de son caractère peu intrusif et, par conséquent plus conforme au principe de proportionnalité. Il ressort ainsi de l'arrêt *Inspire Art*[3757] qu'un niveau de transparence accru devrait être suffisant pour protéger à tout le moins les grands créanciers contractuels[3758], tels que les banques. Il n'est dès lors pas surprenant de constater que parmi les mécanismes de protection institutionnels adoptés par le législateur européen, on retrouve toutes les réglementations destinées à faciliter l'exercice des droits individuels dont le principe n'est autre que l'information des créanciers. En effet, en se penchant sur la procédure de scission interne et de fusion interne et transfrontalière consacrée par la Directive Sociétés, on constate que le législateur européen est parti du principe qu'une information adéquate était indispensable pour garantir la protection des créanciers[3759] et que de nombreuses étapes jalonnant le processus de restructuration sont destinées à assurer une information étendue des créanciers. À titre d'illustration, il en est ainsi de l'exigence d'établissement d'un projet commun[3760] dont le contenu minimum, au niveau des scissions internes, comprend notamment la description et la répartition précise des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires[3761] ainsi que de l'exigence de publicité subséquente[3762]. Cette tendance se retrouve au niveau de la Directive Mobilité[3763], et ce, dans une mesure encore plus importante puisque, à titre d'illustration, dans le cas d'une scission transfrontalière, le projet de scission devra en sus intégrer une règle par défaut pour l'allocation des éléments d'actif ou de passif inconnus à la date d'établissement du projet de scission ou simplement oubliés[3764] ainsi

3756 Chr. TEICHMANN, *Binnenmarktkonformes Gesellschaftsrecht*, *op. cit.*, p. 459 et C.J.C.E., arrêt *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, 20 février 1979, C-120/78, EU:C:1979:42, pt. 13 où la Cour a considéré qu' « on ne saurait cependant aller jusqu'à considérer la fixation impérative de taux minima d'alcoolisation comme étant une garantie essentielle de la loyauté des transactions commerciales, alors qu'il est facile d'assurer une information convenable de l'acheteur par l'exigence d'une indication de la provenance et du titre alcoométrique sur l'emballage des produits ».

3757 Voir en ce sens : H. MERKT, *op. cit.*, p. 118.

3758 Voir en ce sens : P. BEHRENS, « Gemeinschaftsrechtliche Grenzen der Anwendung inländischen Gesellschaftsrechts auf Auslandsgesellschaften nach Inspire Art », *IPRax*, 2004, p. 25 et G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, *op. cit.*, p. 13. Voir également J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 61, n° 121 qui ne limite pas les enseignements de l'arrêt *Inspire Art* aux seuls créanciers contractuels.

3759 52e (fusions internes), 58e (fusions transfrontalières) et 71e (scissions internes) considérants de la Directive Sociétés où le législateur européen insiste sur l'importance de l'exigence de publicité pour protéger les intérêts des tiers.

3760 Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 311 ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 4 et 5 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 140, n° 308 ; Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 174, n° 227 ; P. VAN OMMESLAGHE, « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive européenne du 26 octobre 2005 », *op. cit.*, p. 14 et D. WILLERMAIN, « Les fusions transfrontalières de sociétés », *op. cit.*, p. 586.

3761 Art. 137, § 2, h) de la Directive Sociétés.

3762 Art. 138 de la Directive Sociétés.

3763 12e et 15e considérants de la Directive Mobilité et Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 30. À ce sujet, voir également : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364 ; G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 13, n° 30 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 et J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 262.

3764 Art. 160*quinquies*, I) de la Directive Mobilité.

que les garanties offertes aux créanciers, s'il y en a[3765]. Au sujet de ce dernier élément, il convient de relever que si la Proposition de la Commission n'était pas claire à cet égard[3766], il ressortait clairement du texte de la Proposition du Parlement que les parties à une scission transfrontalière n'étaient en aucun cas dans l'obligation de systématiquement fournir de telles garanties[3767]. On ne peut que déplorer que la version finale de la Directive Mobilité se soit abstenue de conserver cette précision et en soit revenue à la situation ambiguë de la Proposition de la Commission en se contentant d'y adjoindre deux exemples de garanties[3768].

1.2. Limites

758. Un mécanisme indispensable, mais limité. Compte tenu de l'importance de ce moyen de protection et de son caractère indispensable à d'autres moyens de protection tels que l'octroi de garanties[3769], on pourrait se risquer à avancer que la Commission n'a même pas jugé utile, dans le cadre de ses consultations publiques[3770], d'interroger les différents *stakeholders* sur sa nécessité. Cependant, ce mécanisme institutionnel[3771] par excellence souffre de certaines limites. Tout d'abord, il ne profitera qu'aux seuls créanciers vigilants, à l'exclusion des créanciers ne consultant que peu le site internet de leur société débitrice ou le site des registres de commerce ou des créanciers ignorant l'existence de leur créance comme les victimes d'un produit défectueux ou de dégâts environnementaux. En outre, même en présence d'un créancier vigilant, il est généralement difficile pour un créancier d'évaluer les risques d'une opération transfrontalière pour le remboursement de sa créance[3772]. Par ailleurs, même si un créancier vigilant constate que sa société débitrice envisage de réaliser une scission transfrontalière et qu'il n'a aucun doute quant au fait que cette opération présente certains risques pour le remboursement de sa créance, encore faut-il qu'il jouisse d'un certain pouvoir de négociation vis-à-vis de sa société débitrice pour que l'information lui soit d'une quelconque utilité. Ceci signifie que l'information, à elle seule, aussi complète soit-elle, ne profitera

[3765] Art. 160*quinquies*, q) de la Directive Mobilité.

[3766] L'art. 160*sexies*, r) de la Proposition de la Commission mentionnait uniquement « les garanties offertes aux créanciers », ce qui pouvait prêter à confusion, même si l'art. 160*sexies*, § 3, (b) de la Proposition de la Commission semble indiquer que l'offre spontanée de telles garanties était facultative. Voir à ce sujet : ECLE, *op. cit.*, p. 206.

[3767] Art. 160*sexies*, q) de la Proposition du Parlement qui prévoyait que le projet devait inclure « *les garanties, telles que les cautionnements et les gages, lorsqu'elles sont offertes aux créanciers* ».

[3768] Art. 160*sexies*, q) de la Directive Mobilité qui prévoit simplement que le projet devra inclure « les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ».

[3769] Au sujet de ce moyen de protection, voir *infra* n[os] 767 à 779.

[3770] Consultation publique de 2015, pp. 5–9 ou bien que les différentes personnes interrogées n'aient pas eu à se prononcer sur la nécessité d'un droit à l'information, ce dernier ait été spontanément mentionné par certaines personnes ayant répondu aux questions sur la protection des créanciers. Voir également : Consultation publique de 2017, p. 7 où la question de la protection des créanciers par le biais de l'information n'est pas abordée.

[3771] S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 335, n° 5 et S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 123.

[3772] Voir en ce sens : P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », in M. LUTTER (Ed.), *Legal capital in Europe*, Berlin, De Gruyter Recht, 2006, p. 404 et J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, p. 166.

pas aux « *non-adjusting creditors* », c'est-à-dire à la catégorie de créanciers sociaux dans l'incapacité d'adapter les conditions de leur créance au risque effectif qu'ils encourent[3773]. En d'autres termes, une protection des intérêts des créanciers par le biais d'une information adéquate et en temps utile telle que prônée par la Cour de justice dans l'arrêt *Inspire Art*[3774] ne constituera, à elle seule, un moyen de défense efficace que pour les grands créanciers en position de force et à même d'exiger des garanties de leur débiteur. En revanche, les plus petits créanciers[3775] ainsi que les créanciers délictuels ou publics[3776] ne seront pas en mesure de s'en servir efficacement pour se défendre en l'absence d'autres mécanismes de protection. Il s'ensuit que l'information n'est pas à elle seule un moyen de protection suffisant en cas d'opération transfrontalière[3777].

2. *La déclaration de l'organe de direction ou d'administration*

2.1. Présentation

759. L'incitation du législateur européen. La Proposition de la Commission[3778] a introduit la possibilité pour les États membres d'exiger que dans le cadre d'une scission transfrontalière, l'organe de direction ou d'administration de la société scindée fournisse une déclaration reflétant fidèlement la situation financière de la société dans le cadre du projet commun et établissant que sur la base des informations à la disposition de l'organe de direction ou d'administration de la société à la date de la déclaration et après avoir fait des recherches raisonnables, l'organe de direction ou d'administration n'a connaissance d'aucune raison pour laquelle toute société bénéficiaire et, en cas de scission partielle, la société faisant l'objet de la scission, ne seraient, une fois que la scission aura pris effet, pas en mesure de s'acquitter à l'échéance des engagements qui lui sont dévolus dans le cadre du projet de scission transfrontalière. Cette mesure, également prévue pour les fusions transfrontalières[3779] et pour les transformations transfrontalières[3780], a été conservée au cours du processus législatif tant par le Premier Compromis de la Présidence[3781] que par la Proposition du Parlement[3782] et la Directive Mobilité[3783], le Comité des affaires économiques et monétaires ayant même suggéré de la rendre obligatoire[3784]. Elle a pour objectif d'offrir une protection additionnelle aux créanciers. En effet, au-delà de l'objectif évident de limiter le recours abusif aux scissions transfrontalières dans

3773 Sur cette notion, voir : J. ARMOUR, G. HERTIG et H. KANDA, « Transactions with creditors », *op. cit.*, p. 115.
3774 Arrêt *Inspire Art*, pt. 135.
3775 Voir en ce sens : G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, *op. cit.*, p. 14.
3776 Voir en ce sens : J. ARMOUR, G. HERTIG et H. KANDA, *op. cit.*, p. 115 et G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, *ibidem*, p. 14.
3777 Voir en ce sens : Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 359 et A. WENG, *op. cit.*, p. 108.
3778 Art. 160*quaterdecies*, § 1er de la Proposition de la Commission.
3779 Art. 126*ter*, § 1er de la Proposition de la Commission.
3780 Art. 86*duodecies*, § 1er de la Proposition de la Commission.
3781 Art. 160m, § 3 du Premier Compromis de la Présidence.
3782 Art. 160*quaterdecies*, § 3 de la Proposition du Parlement.
3783 Art. 86*undecies*, § 2 ; 126*ter*, § 2 et 160*undecies*, § 3 de la Directive Mobilité.
3784 Avis CAEM, p. 96, amendement 188.

un but d'expropriation des créanciers, le législateur européen sous-entend que cette déclaration de solvabilité est également destinée à rendre les membres de l'organe de gestion personnellement responsables de l'exactitude de la déclaration à l'égard des créanciers en cas d'insolvabilité des sociétés bénéficiaires à la suite de la réalisation de l'opération[3785]. En d'autres termes, cette mesure est destinée d'une part à offrir des débiteurs additionnels aux créanciers de la société scindée en la personne des membres de l'organe de gestion de celle-ci et, d'autre part, à dissuader les membres de l'organe de gestion de poursuivre une opération transfrontalière volontairement réalisée en vue d'exproprier les créanciers au profit des associés. À titre d'illustration, on peut aisément imaginer que l'épée de Damoclès que représente une telle responsabilité personnelle découlant d'une déclaration inexacte ou volontairement lacunaire va dissuader les membres de l'organe de gestion d'envisager une scission pour tenter de mettre à l'abri certains actifs alors qu'une procédure d'insolvabilité se profile à l'horizon.

760. La déclaration de l'organe de gestion en droit allemand. L'utilisation d'une déclaration de l'organe de gestion pour renforcer la protection des créanciers dans le cadre d'une opération transfrontalière n'est cependant pas une mesure inédite et se retrouve, à titre de comparaison et de manière beaucoup plus limitée, dans le régime allemand des fusions transfrontalières[3786]. Ce régime d'exception, inexistant en cas de fusion interne[3787] et inspiré par le régime de la société européenne[3788], prévoit que le certificat de fusion ne sera émis par l'autorité compétente que si les membres de l'organe de gestion certifient que tous les créanciers (i) disposant d'une créance non encore échue née au plus tard quinze jours après la publication du projet commun, (ii) ayant notifié l'origine et le montant de leur créance dans un délai de deux mois suivant la publication du projet commun et (iii) étant parvenus à démontrer que l'opération représentait, de manière crédible, un risque pour le remboursement de leur créance ont bien obtenu une garantie adéquate[3789]. Il s'ensuit que cette déclaration ne pourra en tout état de cause être faite qu'après l'écoulement du délai de deux mois imparti aux créanciers pour faire valoir leurs droits[3790]. En d'autres termes, cette exigence de déclaration fait de l'octroi de garanties adéquates aux créanciers une véritable condition de l'enregistrement de l'opération[3791] et risque par conséquent de retarder considérablement la réalisation

3785 Considérants 17, 34 et 49 de la Proposition de la Commission.

3786 § 122k (1) *in fine* et (2) UmwG.

3787 La conformité de cette disposition d'exception tant à la liberté d'établissement qu'aux dispositions de la Directive Sociétés est discutée. Voir à ce sujet : D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 212 et pp. 275 et 276 ; D. HARITZ et B. VON WOLFF, *op. cit.*, p. 343 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 806 qui considèrent qu'une telle mesure est contraire tant au droit primaire qu'au droit secondaire. *Contra* : R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 379 et 380 et S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 329 et 330. Au sujet de la possibilité de prévoir des régimes d'exception justifiés en raison du caractère transfrontalier de l'opération, voir *supra* : Deuxième partie, Chapitre 1, Section 4.

3788 §§ 8 et 53(3), n° 1 SEAG. Voir également à ce sujet : M. PASSARGE et M. STARK, *ibidem*, pp. 803 et 804.

3789 § 122k (1) *in fine* et (2) UmwG.

3790 Voir en ce sens : W. BAYER in J. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 16 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 8.

3791 Voir en ce sens : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 324 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 804.

de celle-ci. Ce dernier point se doit toutefois d'être nuancé dans la mesure où il est possible de certifier que la société n'a pas de créanciers ou pas de créanciers en droit d'exiger des garanties additionnelles[3792].

2.2. Limites

761. Les abus des créanciers. Bien qu'intéressante dans son principe[3793], ne fût-ce qu'en raison de l'information additionnelle qu'elle fournit sur la situation financière de la société et de responsabilisation de l'organe de direction ou d'administration, cette mesure prête néanmoins le flanc à la critique sur certains points. En effet, en cas de discussions sur les risques engendrés par la scission sur le remboursement de certaines créances, l'organe de gestion pourrait se retrouver dans l'obligation de fournir une garantie injustifiée à des créanciers dans le seul but de ne pas retarder la réalisation d'une opération essentielle à la survie économique de l'entreprise[3794] ou encore de limiter les risques d'une éventuelle responsabilité personnelle. S'il est clair que la déclaration de l'organe de gestion a un rôle intéressant à jouer en matière d'information des créanciers[3795], il est, assez paradoxalement, nécessaire de limiter l'étendue de l'obligation à charge des membres de l'organe de gestion de manière à ce que ces derniers ne soient pas tentés de systématiquement concéder des garanties au détriment de la société et des associés en vue d'éviter de voir leur responsabilité personnelle engagée. Ce point ne semble pas avoir échappé au législateur européen puisqu'on peut aisément déduire du texte de la Directive Mobilité que l'organe de gestion n'assume qu'une obligation de moyens à cet égard. En effet, il est clairement précisé, que ce soit à l'égard des fusions transfrontalières[3796], des transformations transfrontalières[3797] et des scissions transfrontalières[3798] que l'organe de gestion n'est tenu de se prononcer que sur la base des informations dont il dispose et après avoir fait des recherches raisonnables.

3792 W. BAYER in J. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 16 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 8.

3793 Voir en ce sens : G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 13, n° 31 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 584 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 263 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239. Voir également : B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 27, n° 17 qui considère que le principal intérêt de cette déclaration est de fournir une information additionnelle sur la situation financière de la société débitrice. *Contra* : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 312 ; H. BUNGERT et T. WANSLEBEN, *op. cit.*, p. 2102 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860, n° 33 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 294.

3794 W. BAYER in J. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 4 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 2. Voir également en ce sens à propos de la société européenne : J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, p. 165.

3795 B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 27, n° 17.

3796 Art. 126*ter*, § 2 de la Directive Mobilité.

3797 Art. 86*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.

3798 Art. 160*undecies*, § 3 de la Directive Mobilité.

762. La question de la limitation dans le temps. Il est intéressant de relever que dans les différents droits nationaux où cette déclaration de solvabilité est déjà connue, cette déclaration est parfois assortie d'une limitation temporelle. Ainsi, par exemple, en droit chypriote, à l'égard des transformations transfrontalières, il est prévu que les administrateurs certifient dans la déclaration de solvabilité qu'ils n'ont pas connaissance de circonstances susceptibles d'affecter la solvabilité de la société pendant une période de trois ans[3799]. Une telle limitation de durée, qui ne se retrouve pas dans la Directive Mobilité[3800], pose la question du sort des circonstances susceptibles d'affecter la solvabilité de la société à long terme, tels que les éventuels dégâts environnementaux connus et vient, le cas échéant, encore relativiser l'intérêt d'une telle déclaration.

763. La nécessité d'une sanction adéquate. La Directive Mobilité ne contient aucune sanction spécifique pour une déclaration inexacte ou trompeuse et ce, en raison des divergences existant entre les traditions juridiques des États membres à l'égard de l'utilisation des déclarations de solvabilité[3801]. À titre d'illustration, en droit allemand, l'efficacité de la déclaration de l'organe de gestion en tant que mesure de protection des intérêts des créanciers est renforcée par le fait qu'une fausse déclaration est assortie de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement[3802]. Selon le législateur allemand[3803], l'efficacité pratique d'une telle sanction a été démontrée par l'expérience glanée en matière de sociétés européennes[3804], cette mesure de protection spécifique des créanciers ayant été introduite en droit allemand à la suite d'une proposition du *Bundesrat* au moment de l'introduction du régime de la société européenne[3805]. Cependant, on peut se demander s'il ne conviendrait pas de privilégier une sanction civile sous la forme, à titre d'illustration, d'un régime de responsabilité renforcé des administrateurs, au regard des articles 49 et 54 du TFUE. En effet, d'une part la présence de sanctions pénales à un effet dissuasif sur les bénéficiaires de la liberté d'établissement[3806], et d'autre part, la possibilité de prévoir des sanctions civiles fait que les sanctions pénales, plus lourdes, ont moins de chances de remplir la condition de proportionnalité du « *Gebhard test* ». *A contrario*, en droit autrichien, où dans le cadre d'une fusion-émigration, l'organe de direction ou d'administration de la société absorbée est également dans l'obligation d'établir que les créanciers ont obtenu les garanties nécessaires et de fournir une déclaration qu'en dehors des créanciers payés ou auxquels une garantie a été consentie, aucun créancier ne s'est manifesté dans le délai imparti[3807], une fausse déclaration

3799 Art. 354L, (b) of the Cypriot Companies Law, disponible sur www.fbscyprus.com (10/10/2019).
3800 Art. 160*quaterdecies*, § 3 de la Proposition du Parlement.
3801 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239.
3802 § 314a UmwG.
3803 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, exposé des motifs, *BT-Drs.*, 2006, n° 16/2919, p. 20. Voir également à ce sujet : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 325.
3804 § 53 (3), n° 2 SEAG.
3805 Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Europäischen Gesellschaft, zu Art. 1 (§§ 8, 13 SEAG), *BT-Drs.*, 2004, n° 15/3656, pp. 4 et 9. Voir également à ce sujet : R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 378.
3806 Voir en ce sens : G. SPINDLER et O. B. GÖTTINGEN, *op. cit.*, p. 15.
3807 § 14(1), n° 9 EU-VerschG.

n'est assortie ni d'une sanction pénale, ni explicitement d'une responsabilité civile personnelle des membres de l'organe de direction ou d'administration[3808]. Cependant, la nécessité d'une sanction adéquate pour garantir la véracité de la déclaration par l'organe de direction ou d'administration[3809] n'a pas échappé au législateur européen qui mentionne explicitement la possibilité pour les États membres d'une part de rendre les membres de l'organe de gestion en question personnellement responsable de l'exactitude de sa déclaration et, d'autre part, de tirer les conséquences qui s'imposent en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, entre autres par le biais de « sanctions et responsabilités efficaces et proportionnées »[3810]. Cependant, compte tenu (i) de l'influence que ne manqueront pas d'exercer les acteurs économiques, à commencer par l'industrie du *private equity*[3811] et (ii) de la présence d'administrateurs indépendants de plus en plus professionnalisés et organisés risquant de se montrer particulièrement rétifs à l'idée de se voir imposer une telle responsabilité[3812], on peut émettre certains doutes sur l'efficacité d'une telle incitation[3813]. En tout état de cause, il demeure que cette déclaration de l'organe de gestion, si utile soit-elle *a priori* pour l'information des créanciers[3814], sera privée d'une partie de son intérêt si elle ne permet pas en sus d'agir personnellement contre les membres de l'organe de gestion.

764. Un mécanisme potentiellement coûteux, voire dissuasif. Si la mise en place d'une sanction adéquate permettrait aux créanciers de se prémunir plus aisément contre les déclarations inexactes ou trompeuses, une telle déclaration de l'organe de gestion aura nécessairement pour conséquence d'augmenter sensiblement le coût de l'opération en raison des honoraires des conseillers juridiques qui seront mobilisés par la société pour rédiger celle-ci et confirmer l'analyse de l'organe de gestion[3815]. Dans le pire des cas, il y a également un risque que l'organe de gestion abandonne purement et simplement l'idée d'une scission transfrontalière et préfère proposer des méthodes alternatives à l'assemblée générale qui ne mettraient pas la responsabilité personnelle des administrateurs ou gérants en cause[3816]. A titre de comparaison, en droit luxembourgeois[3817] et en

3808 G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 740, n° 22.
3809 Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 843.
3810 25e considérant de la Directive Mobilité.
3811 Au sujet de l'influence des praticiens actifs dans l'industrie du *private equity* sur le législateur luxembourgeois, voir : I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 18 et I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *op. cit.*, pp. 418 et 419.
3812 Pour apprécier correctement l'enjeu de cette question, il est utile de relever que l'exposé des motifs du CSA mentionne que « [d]'un point de vue politique, le projet estime en outre devoir prendre en compte le fait que dans le contexte de la globalisation, où les sociétés rivalisent sur le plan international pour recruter les administrateurs les plus talentueux, il n'est pas heureux que les risques liés à l'exercice d'un mandat d'administrateur soient plus élevés en Belgique que dans les pays voisins ». Voir : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 67.
3813 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 54.
3814 B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 27, n° 17.
3815 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311.
3816 *Ibidem*.
3817 À ce sujet, voir I. CORBISIER et D. BURBI, *Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 – Regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé*, Bruxelles, Larcier 2011, p. 71.

droit belge[3818], il a été relevé à l'égard de la possibilité de se passer d'un rapport d'expert indépendant dans certaines circonstances en cas d'apport en nature dans une société anonyme[3819] que malgré l'existence d'exceptions légales, il n'en était que rarement fait usage en pratique et qu'une des explications de ce phénomène pouvait tenir à la frilosité des membres du conseil d'administration à assumer une responsabilité supplémentaire du fait de cette renonciation.

765. Le délai de la déclaration. Selon le législateur européen[3820], la déclaration ne pourra être faite qu'au plus tôt un mois avant la publication du projet de scission transfrontalière. Ceci signifie cependant qu'au moment où la déclaration sera faite, l'organe de direction ou d'administration est dans l'incapacité d'évaluer avec un niveau de précision suffisant l'érosion financière qui sera potentiellement engendrée par l'opération elle-même et due, à titre d'illustration, à l'exercice du droit de retrait par un nombre important d'associés minoritaires[3821] ou encore à des négociations prolongées sur la participation des travailleurs au sein des sociétés bénéficiaires[3822]. Il s'ensuit que les informations fournies aux créanciers par le biais de la déclaration ne refléteront pas précisément l'impact de la scission sur la situation économique de la société débitrice.

766. La conformité à la liberté d'établissement. Le fait d'imposer à l'organe de gestion de fournir une déclaration de solvabilité constitue indéniablement une entrave à la liberté d'établissement de la société impliquée dans la mesure où ce mécanisme de protection fait partie des « mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de cette liberté »[3823]. Si une telle mesure est susceptible d'être justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général que constitue la protection des créanciers[3824] et est à même de garantir un certain niveau d'efficacité, on peut nourrir certains doutes quant à la proportionnalité de la mesure, *a fortiori* si elle est assortie de sanctions pénales. En effet, imposer l'exigence pour l'organe de gestion d'établir une déclaration de solvabilité interdit *de facto* les opérations dans lesquelles les sociétés encourent déjà des difficultés à faire face au remboursement de leurs dettes et pour lesquelles un assainissement par le biais d'une opération transfrontalière pourrait s'avérer salutaire. À titre d'illustration, on peut aisément imaginer que les membres de l'organe de gestion feront, au mieux, preuve d'une certaine méfiance à l'égard d'une scission transfrontalière dictée par la nécessité de se débarrasser d'une branche d'activités en perte de vitesse et compromettant la solvabilité de la

3818 À ce sujet, voir M. WESTRADE, « L'apport en nature : quelques réflexions relatives à son déroulement pratique », *C.J.*, 4/2009, p. 102.

3819 Art. 420-10, §§ 4–6 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et art. 7:7, § 2 du CSA. Pour l'origine européenne de ces exceptions, voir : art. 50 de la Directive Sociétés.

3820 Art. 160*undecies*, § 3 de la Directive Mobilité.

3821 Au sujet du droit de retrait des actionnaires minoritaires, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1er, Section 5, § 3.

3822 Au sujet de la durée des négociations sur le régime de participation des travailleurs, voir *infra* n° 1125.

3823 Arrêt *Polbud*, pt. 46 ; C.J., arrêt *Euro Park Service*, pt. 59 ; C.J., gde ch., arrêt *National Grid Indus*, pt. 35 ; arrêt *Cartesio*, pt. 36 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Caixa Bank France c. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*, 5 octobre 2004, C-442/02, EU:C:2004:586, pt. 11 ; C.J.C.E., arrêt *Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA et ADP GSI SA*, 17 octobre 2002, C-79/01, EU:C:2002:592, pt. 26 ; C.J.C.E., arrêt *Mac Quen, Pouton, Godts, Antoun c. Grandvision Belgium SA*, 1er février 2001, C-108/96, EU:C:2001:67, pt. 26 et arrêt *Gebhard*, pt. 37.

3824 Arrêt *Centros*, pt. 39 ; arrêt *Überseering*, pt. 92 ; arrêt *Inspire Art*, pt. 132 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 ; arrêt *Vale*, pt. 39 et arrêt *Polbud*, pt. 52.

totalité de l'entreprise[3825] dans la mesure où le succès économique d'une telle opération n'est pas automatique[3826]. En outre, la protection des créanciers par le biais de l'octroi de garanties adéquates assure une protection suffisante des intérêts des créanciers attentifs susceptibles d'être protégés par la mesure en question, tout en étant moins intrusive[3827].

3. *La possibilité de demander une garantie*

3.1. Le principe

767. Un mécanisme de protection très fréquent. Dans le cadre de la Directive Sociétés, à l'égard des scissions internes[3828], des fusions internes[3829] et des fusions transfrontalières[3830], le législateur européen a certes prévu que les États membres étaient libres d'instaurer le régime de protection qu'ils jugeaient adéquat pour garantir la protection des intérêts des créanciers dont la créance est (i) antérieure à la publication du projet commun et (ii) non encore échue à ce moment, mais ils sont dans l'obligation de prévoir que ces derniers doivent à tout le moins avoir le droit d'obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés impliquées rend cette protection nécessaire et qu'ils ne disposent pas encore de telles garanties. Cette possibilité légale pour un créancier de demander des sûretés, dont l'origine remonte au *Companies Act* britannique de 1867[3831], n'est pas sans rappeler celle applicable en cas de réduction de capital social[3832] et se retrouve également dans le nouveau régime des fusions[3833], scissions[3834] et transformations[3835] transfrontalières prévu par la Directive Mobilité. En outre, elle semble avoir les faveurs de la Cour de justice qui l'a citée à plusieurs reprises comme exemple de mesure moins intrusive que celles prônées par certains États membres pour protéger les créanciers[3836][3837] ainsi que celles du Parlement

3825 Sur l'utilité économique d'une scission dans ce type de situation, voir *supra* n°s 53 à 55.
3826 Sur ce risque, voir *supra* n° 697.
3827 Au sujet de la conformité à la liberté d'établissement de la déclaration de l'organe de gestion en droit allemand : G. LEUTNER et Th. WAGNER, *op. cit.*, p. 34 et H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung… », *op. cit.*, p. 1795 qui se révèlent sceptiques quant à la proportionnalité de la mesure prévue par les §§ 122k (1) *in fine* et 314a UmwG en raison du fait que la vérification effective par la juridiction compétente pour la tenue du registre qu'une garantie a bien été fournie serait moins intrusive. *Contra* : S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 329 et 330 qui considère au contraire que la mesure est proportionnée notamment en raison du fait qu'imposer à la juridiction compétente de vérifier systématiquement le bon octroi des garanties serait trop lourd en pratique.
3828 Art. 146, § 2 de la Directive Sociétés.
3829 Art. 99 de la Directive Sociétés.
3830 Art. 121, § 1er, point b et § 2 de la Directive Sociétés.
3831 Voir en ce sens : S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 308 et 309.
3832 Art. 75, § 1er de la Directive Sociétés et G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 61 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, pp. 202 et 203, n° 34.
3833 Art. 126*ter*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
3834 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
3835 Art. 86*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
3836 Arrêt *Centros*, pt. 37 et arrêt *Polbud*, pt. 58.
3837 Voir également à ce sujet : Chr. TEICHMANN, *Binnenmarktkonformes Gesellschaftsrecht*, *op. cit.*, p. 458 qui insiste sur le fait que la Cour de justice ne se prononce pas en faveur d'un mécanisme de protection en raison de son efficacité, mais en raison de son caractère peu intrusif au regard des libertés fondamentales.

européen qui, lors des discussions sur une éventuelle 14e directive relative au transfert du siège statutaire, s'était déjà prononcé en faveur de ce moyen de protection[3838]. De même, lors de la consultation publique de 2015, ce moyen de protection est celui qui a remporté le plus d'adhérents[3839]. Il n'est dès lors pas étonnant de constater que ce régime ait été très fréquemment adopté par les différents législateurs nationaux, le cas échéant moyennant certains aménagements spécifiques[3840]. À titre d'illustration il se retrouve ainsi dans (i) le régime luxembourgeois des fusions internes[3841] et transfrontalières[3842] et des scissions internes[3843] et transfrontalières[3844], à la fois pour des créances échues et non échues, (ii) le régime belge des fusions internes[3845] et transfrontalières[3846] et des scissions internes[3847] et transfrontalières[3848] pour toute créance certaine mais non encore exigible avant la date de publication des actes constatant l'opération ou ayant fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant l'opération, (iii) le régime allemand des fusions internes[3849] et transfrontalières[3850] et des scissions internes[3851] pour les créances non encore échues et (iv) le régime autrichien des fusions internes[3852] et transfrontalières[3853] et des scissions internes[3854] pour les créances non encore échues.

768. La question de l'effet suspensif. Un des aspects fondamentaux de la protection des créanciers par le biais de l'octroi de garanties adéquates qui ne se trouve explicitement réglé ni dans la Directive Sociétés, ni dans la Directive Mobilité est celui de la question de l'effet suspensif d'une demande de garantie introduite par un créancier dans l'hypothèse où le droit de demander des garanties lui est ouvert avant la date de prise d'effet de l'opération[3855]. On pourrait avancer qu'il découle de l'obligation générale qu'ont les États membres de veiller à ce que les garanties octroyées aux créanciers dépendent de la

3838 Voir 6e recommandation de l'annexe à la Résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire (2011/2046(INI)), P7_TA(2012)0019, 2 février 2012. Voir C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, p. 12 à ce sujet.

3839 81 % des personnes interrogées en faveur d'une harmonisation de la protection des créanciers ont opté pour un régime de protection axé autour de l'obtention de garanties. Voir : Consultation publique de 2015, p. 7.

3840 Selon les données collectées par Bech-Bruun et Lexidale, 29 des 30 États membres étudiés ont transposé ce régime optionnel pour les fusions transfrontalières. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 52.

3841 Art. 1020-1, al. 3 et 4 et art. 1021-9, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3842 Art. 1020-9, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3843 Art. 1031-10, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3844 Art. 1031-1, al. 3 et art. 1031-10, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3845 Art. 12:15, § 1er du CSA.

3846 Art. 12:15, § 1er et 12:106 du CSA.

3847 Art. 12:15, § 1er du CSA.

3848 Art. 12:15, § 1er et 12:73, § 1er et du CSA.

3849 § 22 (1) UmwG.

3850 § 122j UmwG.

3851 §§ 22 et 133 (1) UmwG.

3852 § 226 öAktG et S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 338, n° 14.

3853 § 13(1) EU-VerschG et G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 723, n° 9.

3854 § 15(2) SpaltG et S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 1105, n° 66.

3855 Voir au sujet de la Proposition de la Commission : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 qui plaide en faveur d'une règlementation de cet aspect au cours du processus législatif.

prise d'effet de la scission[3856] que celles-ci devront nécessairement avoir été octroyées auparavant. Il est également possible de considérer que la procédure relative à l'obtention d'une garantie adéquate fait partie intégrante des « procédures et formalités »[3857] dont la vérification incombe à l'autorité en charge du premier contrôle de légalité[3858], ce que tendraient à confirmer les dernières modifications apportées par la Proposition du Parlement qui précisent que ces procédures et formalités comprennent « la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d'exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours »[3859]. Cependant, malgré ces deux arguments, force est de constater que la position du législateur européen sur la question demeure incertaine, d'autant plus qu'il ressort du trente-septième considérant de la Directive Mobilité que le législateur européen semble avoir voulu laisser délibérément cette question à la libre appréciation des États membres. En effet, selon ce dernier, « [l]es États membres devraient être en mesure de préciser les conséquences sur la délivrance du certificat préalable à l'opération que les procédures engagées par des associés et des créanciers conformément à la présente directive pourraient avoir »[3860]. Du point de vue du droit interne, en prenant l'exemple du droit belge à titre d'illustration, alors que dans le cadre des fusions transfrontalières, une demande de garantie n'aura aucun effet suspensif[3861], on constate qu'en cas de scission transfrontalière dans laquelle la société scindée est une société belge, il est explicitement prévu que le notaire instrumentant devra s'abstenir de délivrer le certificat de conformité s'il s'avère qu'un créancier ayant exigé une sûreté n'a pas obtenu satisfaction, à moins que les prétentions de celui-ci n'aient été rejetées par une décision judiciaire exécutoire[3862]. En d'autres termes, en cas de scission-émigration, la demande introduite dans les temps par un créancier aura un effet suspensif. Si l'objectif du législateur de renforcer la protection des créanciers de la société nationale en cas de scission-émigration[3863] s'en trouve certes rempli, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une option particulièrement intrusive et susceptible de retarder significativement la réalisation d'une opération essentielle à la survie économique d'une entreprise. De plus, force est de constater qu'il existe des mesures de protection moins restrictives et tout aussi efficaces, telle que la solidarité supplétive prônée par la Directive Sociétés en matière de scissions internes[3864] ou la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières[3865]. Il s'ensuit qu'assortir la possibilité de demander des garanties pour

3856 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 3 de la Directive Mobilité.
3857 Art. 160*quaterdecies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
3858 Voir en ce sens à propos du régime des fusions transfrontalières selon la Proposition de la Commission : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239.
3859 Art. 160*quaterdecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
3860 37e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité.
3861 Art. 12:15 ; 12:106, al. 1er ; 12:117 et 12:119 du CSA.
3862 Art. 12:73, § 3 et 12:90, § 3 du CSA.
3863 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 311.
3864 Art. 146, § 3 de la Directive Sociétés.
3865 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.

les créanciers d'un effet suspensif serait à tout le moins hasardeux du point de vue du respect de la liberté d'établissement des sociétés impliquées, ne fût-ce qu'au regard de l'exigence de proportionnalité qui s'impose à toute entrave[3866].

769. Le destinataire de la demande de constitution de garanties. La possibilité de demander une sûreté peut se décliner de plusieurs manières différentes. Il est ainsi possible soit de prévoir que la société devra fournir une sûreté à la requête d'un créancier, soit encore d'autoriser les créanciers à agir devant une autorité nationale en vue de l'obtention d'une telle sûreté[3867]. En ce qui concerne l'autorité compétente, la situation est susceptible de varier entre une décision judiciaire rendue par une cour ou un tribunal[3868] et une décision administrative rendue par le registre compétent[3869]. À titre d'illustration, dans le régime luxembourgeois des scissions transfrontalières, la demande de constitution de sûretés doit être adressée au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé[3870]. Dans le régime belge des scissions transfrontalières, un créancier doit, sous peine d'irrecevabilité, adresser sa requête par écrit à la fois à la société débitrice et au notaire instrumentant mentionné dans le projet de scission et, à défaut d'accord ou s'il n'a pas obtenu satisfaction, soumettre la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice, siégeant en référé[3871]. Dans la grande majorité des cas, de telles divergences procédurales ne sont pas problématiques et cet aspect de la protection des créanciers peut être laissé à l'appréciation des États membres, ce qui est l'option explicitement choisie par le législateur européen dans le cadre des fusions et scissions internes[3872]. Cependant, dans le cas particulier d'un système de protection *ex ante* dans lequel (i) l'opération ne peut prendre effet tant que la demande du créancier n'a pas été satisfaite ou rejetée par une décision exécutoire et (ii) la procédure contentieuse ne recourt pas au référé, une scission transfrontalière nécessaire à la survie économique d'une entreprise pourrait se retrouver bloquée par un créancier peu diligent dont la position ne serait pas mise en péril. Pour limiter tout risque de ce type, il est par conséquent nécessaire que l'autorité en charge d'ordonner la constitution d'une garantie ou de trancher une contestation au sujet d'une créance soit à même de rendre une décision dans de brefs délais.

3866 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 71 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 67 ; Th. PAPADOPOULOS, « EU regulatory approaches… », *op. cit.*, p. 79 et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 267 et arrêt *Polbud*, pt. 52 ; arrêt *Sevic*, pt. 23 ; C.J.C.E., gde ch., arrêt *Caixa Bank France c. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*, 5 octobre 2004, C-442/02, EU:C:2004:586, pt. 17 ; C.J.C.E., arrêt *Ciola c. Land Vorarlberg*, 29 avril 1999, C-224/97, EU:C:1999:212, pt. 16 ; arrêt *Gebhard*, pt. 37 et arrêt *Kraus*, pt. 32.

3867 Fusions et scissions transfrontalières – Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), disponible sur http://www.europarl.europa.eu (27/09/2017), p. 6.

3868 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale en matière de fusions transfrontalières, c'est le cas notamment en France, au Luxembourg, en Pologne, au Portugal, en République Tchèque et en Slovaquie. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 57.

3869 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale en matière de fusions transfrontalières, c'est le cas en Finlande, en Norvège et en Suède. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 57.

3870 Art. 1031-1, al. 3 et 1031-10, § 1er de la Loi sur les sociétés commerciales.

3871 Art. 12:15, § 1er, al. 1er et 3 et 12:90, § 3 du CSA.

3872 Art. 99, § 2 et 146, § 2, al. 2 de la Directive Sociétés.

Cette précision, absente du régime des scissions, fusions et transformations transfrontalières prévu tant par la Proposition de la Commission[3873] que par la Directive Mobilité[3874], gagnerait malgré tout à être ajoutée s'il ne devait être politiquement possible de priver toute demande de garantie adéquate d'effet suspensif.

770. Les créanciers visés. Ni la Directive Sociétés, ni la Directive Mobilité n'introduisent de limites quant aux catégories de créanciers susceptibles de bénéficier de ce régime de protection, et ce, qu'il s'agisse d'une scission interne[3875] ou transfrontalière[3876], d'une fusion interne[3877] ou transfrontalière[3878] ou encore d'une transformation transfrontalière[3879]. Il en découle que tous les créanciers doivent en principe pouvoir y recourir, peu important que leur créance soit d'origine légale ou contractuelle[3880]. Ceci n'a toutefois pas empêché certains législateurs nationaux, tels que le législateur allemand[3881] et le législateur autrichien[3882] en matière de scissions internes, d'exclure d'emblée certains créanciers dont la situation n'est pas aggravée par l'opération, tels que les créanciers disposant, en cas de procédure d'insolvabilité de leur société débitrice, d'un privilège découlant d'une disposition légale et couvert par une masse contrôlée par les autorités. En droit autrichien, ce sont même tous les créanciers des sociétés bénéficiaires qui se voient exclus du mécanisme de protection[3883].

771. Les créances antérieures à la publication du projet commun. Selon à la fois le texte de la Directive Sociétés applicable aux fusions internes[3884] et transfrontalières[3885], ainsi qu'aux scissions internes[3886] et le texte de la Directive Mobilité applicable aux scissions transfrontalières[3887], aux transformations transfrontalières[3888] et aux fusions transfrontalières[3889], seuls les créanciers disposant d'une créance née antérieurement à la publication du projet doivent nécessairement pouvoir bénéficier d'un mécanisme de protection. Or, le point de référence de la publication du projet commun n'a pas été transposé avec la même

3873 Art. 86*duodecies*, § 2 (transformations) ; 126*ter*, § 2 (fusions) et 160*quaterdecies*, § 2 (scissions) de la Proposition de la Commission.
3874 Art. 86*undecies*, § 1er, al. 2 (transformations) ; 126*ter*, § 1er, al. 2 (fusions) et 160*undecies*, § 1er, al. 2 (scissions) de la Directive Mobilité.
3875 Art. 146 de la Directive Sociétés.
3876 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
3877 Art. 99 de la Directive Sociétés.
3878 Art. 126*ter*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
3879 Art. 86*duodecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
3880 Voir en ce sens à propos du régime allemand des fusions internes : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 4 ; G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 6 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 2. Voir également en ce sens à propos du régime autrichien des scissions internes : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1105, n° 65.
3881 §§ 22 (2) et 125 UmwG.
3882 § 15 (4) SpaltG.
3883 § 15 (1) SpaltG et à ce sujet : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1105, n° 65.
3884 Art. 99, § 1er de la Directive Sociétés.
3885 Art. 99, § 1er et 121, § 1er, b) et § 2 de la Directive Sociétés.
3886 Art. 146, § 1er de la Directive Sociétés.
3887 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
3888 Art. 86*undecies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
3889 Art. 126*ter*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

rigueur par tous les législateurs nationaux[3890]. Ainsi, le législateur allemand a prévu en matière de fusions[3891] et de scissions internes[3892] que les régimes de protection s'appliquaient à toutes les créances antérieures à l'opération, ce qui est interprété par certains auteurs comme fixant la date d'inscription de l'opération au registre de commerce compétent[3893] et par d'autres, comme faisant référence à la date de publication de l'inscription de l'opération[3894]. En cas de fusion transfrontalière, la situation est plus complexe puisqu'en cas de fusion-émigration, le mécanisme de protection s'appliquera également aux créanciers titulaires d'une créance née jusqu'à quinze jours après la date de publication[3895]. Selon les travaux préparatoires[3896], cette extension surprenante de prime abord se justifie au regard du § 15 HGB selon lequel les faits inscrits et publiés au registre de commerce compétent ne sont pas opposables aux tiers à l'égard des actes juridiques accomplis dans les quinze jours suivant la publication, pour peu que le tiers parvienne à prouver qu'il n'en avait ni ne pouvait en avoir connaissance. Une telle différence de traitement ne convainc pas dans la mesure où dans le cas d'une fusion transfrontalière, un créancier n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'il ignorait de bonne foi la réalisation de la fusion[3897]. En droit autrichien, si les régimes de protection *ex post* des fusions internes[3898] et des scissions internes[3899] utilisent la date d'inscription de l'opération comme point de référence temporel, le régime de protection *ex ante* des fusions transfrontalières recourt à la date de publication du projet commun[3900]. De manière similaire, si en droit belge on recourt la date de publication des actes constatant l'opération en matière de fusions et scissions internes[3901] tout comme en cas de fusion[3902] ou de scission transfrontalière[3903], en matière de transformations transfrontalières[3904], on utilise la date de publication du projet de transformation. En revanche, de telles distinctions à l'égard de la notion d'antériorité ne se retrouvent pas dans le régime luxembourgeois des fusions[3905] et scissions internes et transfrontalières[3906] qui se réfère explicitement à la date de publication des actes constatant l'opération.

3890 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 56.
3891 § 22 (1) UmwG et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 3.
3892 §§ 22 et 125 UmwG.
3893 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 7 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 12 qui précise toutefois que l'opération ne pourra être opposable aux tiers qui n'en avaient pas connaissance avant la publication.
3894 Voir en ce sens : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 3.
3895 § 122 (j) UmwG.
3896 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, exposé des motifs, *BT-Drs.*, 2006, n° 16/2919, p. 17.
3897 § 122 (j) (2) UmwG.
3898 § 226 (1) öAktG.
3899 § 15 (2) SpaltG.
3900 § 13 (1) EU-VerschG.
3901 Art. 12:15, § 1er, al. 1er du CSA.
3902 Art. 12:15, § 1er, al. 1er et 12:106 du CSA.
3903 Art. 12:15, § 1er, al. 1er ; 12:73, § 1er et 12:90, § 1er du CSA.
3904 Art. 14:19, al. 1er du CSA.
3905 Art. 1020-1, al. 3 et 1021-9, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3906 Art. 1030-1, al. 3 et 1031-10, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

772. Créances échues ou non encore échues ? Les dispositions européennes en matière de fusions[3907] et de scissions internes[3908] précisent explicitement que seules les créances non encore échues au moment de la publication du projet commun doivent bénéficier d'une protection. Cette limite, qui se retrouve également dans la Directive Mobilité à l'égard des scissions[3909], des fusions[3910] et des transformations[3911] transfrontalières, n'a pas systématiquement été transposée par les États membres. Ainsi, si à l'égard des fusions et scissions internes, tout comme des fusions transfrontalières, tant le législateur allemand[3912] que le législateur autrichien[3913] ont limité le mécanisme de protection aux seules créances non encore échues, ce ne fut pas le cas du législateur luxembourgeois qui a explicitement précisé en matière de fusions[3914] et de scissions[3915] que la possibilité de demander des garanties devait s'appliquer à la fois aux créances échues et non échues au moment de la publication des actes constatant la réalisation de l'opération. Les travaux préparatoires justifient cette extension par le fait que les titulaires de créances échues ne sont pas toujours en mesure d'obtenir immédiatement le remboursement de leur créance, raison pour laquelle ils doivent également avoir la possibilité de demander des garanties[3916]. Cependant, cette justification ne convainc pas. En effet, on ne comprend pas pourquoi tous les titulaires de créances échues devraient être protégés alors que le législateur entendait uniquement protéger les titulaires de créances *sub iudice*[3917]. La solution du législateur belge qui tant en matière de fusions que de scissions internes et transfrontalières[3918] ouvre la possibilité de demander des garanties tant aux titulaires de créances certaines mais pas encore exigibles qu'aux titulaires de créances ayant fait « l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant la fusion ou la scission » semble préférable. Cette précision n'est pas superflue car en droit allemand, où aucune mention spécifique ne figure dans la loi, la question de savoir si le droit de demander des garanties est également ouvert aux titulaires d'une créance faisant l'objet d'une contestation est débattue[3919] et

3907 Art. 99, § 1er *in fine* de la Directive Sociétés.
3908 Art. 146, § 1er *in fine* de la Directive Sociétés.
3909 Art. 160*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
3910 Art. 126*ter*, § 1er de la Directive Mobilité. Cette précision était toutefois absente de l'art. 126*ter*, § 2 de la Proposition de la Commission.
3911 Art. 86*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
3912 §§ 22 (1) (fusions internes) ; 122j (fusions transfrontalières) et 125 (scissions internes) UmwG.
3913 § 15 (2) SpaltG (scissions internes).
3914 Art. 1021-9, § 1er de la Loi sur les sociétés commerciales.
3915 Art. 1031-10, § 1er de la Loi sur les sociétés commerciales.
3916 Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1984–1985, n° 2897, p. 14.
3917 Par « créances *sub iudice* », on entend « les créances faisant l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage ». Voir à ce sujet : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 301.
3918 Art. 12:15 du CSA. Voir également : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, pp. 301 et 302.
3919 *Pro* : G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 37. *Contra* : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 11 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 8.

en droit autrichien, on considère que les créances *sub iudice* sont exclues[3920]. Ceci étant, on est en droit de s'interroger sur la nécessité de prévoir un régime spécifique pour les créances *sub iudice* absent de la Directive Sociétés. En effet, l'exclusion des créances échues pourrait s'expliquer aisément par le fait que leur titulaire peut s'en prévaloir et en exiger le paiement avant la prise d'effet de l'opération[3921] et d'autre part, par le fait que ces créanciers sont, dans le cadre d'une scission, de toute façon protégés par la solidarité des sociétés bénéficiaires[3922] et ce, de manière moins intrusive. Or, si un créancier dont la créance échue est contestée introduit une procédure à l'encontre de la société scindée, il devra, avant toute autre chose, établir l'existence de sa créance. S'il y parvient, la créance n'est plus litigieuse et il pourra en réclamer le paiement si elle est exigible, le cas échéant en sus de mesures conservatoires, de sorte que la possibilité de demander des garanties est sans intérêt pour lui[3923].

773. Un risque crédible. Cependant, afin de préserver le délicat équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des associés et d'éviter qu'une scission ne soit rendue excessivement complexe par les demandes de nombreux créanciers[3924], il est indispensable de limiter l'octroi de garanties aux seuls créanciers dont la position se retrouve potentiellement compromise du fait de l'opération. Cette assertion, indiscutable dans un contexte interne, l'est d'autant plus dans un contexte transfrontalier, en raison de la nécessité de respecter le principe de proportionnalité applicable à toute entrave à la liberté d'établissement d'une société[3925]. C'est pourquoi tant (i) la Directive Sociétés à l'égard des fusions[3926] et des scissions internes[3927] que la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières[3928], des fusions transfrontalières[3929] et des transformations transfrontalières[3930], prévoient que les créanciers doivent établir de manière crédible que l'opération engendre un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas encore fourni de garanties adéquates. À cet égard, il est utile de préciser que suite à l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I*bis*, le seul caractère transfrontalier de l'opération ne suffit pas à justifier la nécessité de l'octroi d'une garantie[3931], mais qu'au contraire il convient d'établir que les circonstances de l'opération entraînent un risque concret pour le remboursement

3920 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1105, n° 65.
3921 Voir en ce sens : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 861.
3922 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 8.
3923 Voir en ce sens à propos des fusions internes : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 11.
3924 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1106, n° 68 et K. MERTENS, « Zur Universalsukzession in einem neuen Umwandlungsrecht », *op. cit.*, p. 70.
3925 À ce sujet, voir *supra* n°s 707 à 711.
3926 Art. 99, § 2, al. 2 de la Directive Sociétés.
3927 Art. 146, § 2, al. 2 de la Directive Sociétés.
3928 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
3929 Art. 126*ter*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
3930 Art. 86*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
3931 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 275 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 9 ; R. FRENZEL *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 362 et 363 ; B. GRUNEWALD, *op. cit.*, p. 197 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 317 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 ; H.-W. NEYE et B. TIMM, « Mehr Mobilität für die GmbH in Europa – Das neue Recht der grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *GmbHR*, 2007,

de la créance en question[3932] qui, contrairement à ce qui a pu être avancé[3933], va au-delà d'une simple baisse de solvabilité de la société débitrice. Selon le texte de la Directive Mobilité, l'autorité nationale en charge de se prononcer sur la demande de garantie introduite par un créancier mécontent devra examiner si la créance détenue après la réalisation de l'opération est « d'une valeur au moins équivalente et d'une qualité de crédit comparable à la créance antérieure à l'opération transfrontalière et si le droit à cette créance peut être exercé dans la même juridiction »[3934]. En d'autres termes, l'analyse d'un risque concret pour les créanciers de la société scindée semble de prime abord aller plus loin que dans un contexte purement interne où il suffit de comparer la situation financière de la société scindée avec celle de la société à laquelle la créance est transférée[3935]. À titre d'illustration, un risque concret pourra être présent tant dans un contexte interne que transfrontalier en cas de transfert d'actifs importants de l'État membre de la société scindée vers celui d'une des sociétés bénéficiaires[3936], lorsque les frais de justice dans l'État membre de la société bénéficiaire doivent être supportés par le demandeur, même en cas de jugement favorable[3937] et que ce n'est pas le cas dans l'État membre de la société scindée, ou encore en cas de scission transfrontalière d'une société solvable au profit de plusieurs sociétés en situation de difficultés financières[3938] ou en cas de doute sur les liquidités de la société bénéficiaire à laquelle la dette a été transférée[3939]. À cet égard, il est intéressant de relever qu'au moment de l'introduction du régime de la société européenne, le *Bundestag* allemand avait proposé d'introduire une liste d'exemples de situations dans lesquelles une fusion transfrontalière présente un risque crédible pour les intérêts des créanciers[3940], ce qui aurait permis de renforcer la sécurité juridique de la mesure de protection en question. Cette suggestion a toutefois été rejetée par après

p. 564 et J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, p. 165. Voir également en ce sens à propos des transformations transfrontalières : J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 583.

3932 Voir en ce sens à propos du régime allemand des fusions transfrontalières : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 122j, n° 9 ; R. FRENZEL, *ibidem*, p. 363 ; S. KULENKAMP, *ibidem*, p. 317 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122j, n° 7 ; M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, pp. 806 et 810 et M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 133, n° 92.

3933 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 314, n° 464.

3934 23e considérant de la Directive Mobilité.

3935 Voir en ce sens en droit autrichien : RV EU-GesRÄG 1996 32, commentaire des articles, BlgNR 20. GP, disponible sur https://www.parlament.gv.at (11/10/2019), p. 125.

3936 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : *Pro* : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 9 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 et J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, p. 165. *Contra* : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 318 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 807 qui justifient leur position en avançant qu'un débiteur dispose de la possibilité de transférer des parties importantes de son patrimoine à l'étranger en dehors d'une fusion transfrontalière et ce, sans que ses créanciers ne bénéficient du droit de demander des garanties.

3937 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7.

3938 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 318 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122j, n° 7 et M. PASSARGE et M. STARCK (dir.), *op. cit.*, p. 810.

3939 R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122j, n° 9 et W. NEYE et B. TIMM, « Mehr Mobilität für die GmbH in Europa – Das neue Recht der grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 564.

3940 Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Europäischen Gesellschaft, zu Art. 1 (§§ 8, 13 SEAG), *BT-Drs.*, 2004, n° 15/3656, p. 4.

par le *Bundesrat* qui a estimé qu'une telle liste exemplative n'était ni réalisable en raison de la grande diversité des situations susceptibles de se présenter, ni nécessaire au vu du fait que le régime identique prévu en matière de fusions internes depuis 1995 n'avait pas été source de difficultés à ce sujet[3941]. Quoi qu'il en soit, dans un contexte européen et compte tenu de l'existence du Règlement Bruxelles I*bis*, on comprend difficilement en quoi une scission qui dans un contexte purement interne ne générerait pas de risque crédible pour les créanciers en créerait du seul fait d'un changement de compétence juridictionnelle. On peut tout au plus envisager (i) l'hypothèse où les frais de justice seraient systématiquement laissés à charge du demandeur dans la nouvelle juridiction alors que ce n'est pas le cas dans la juridiction de départ ou encore (ii) la charge que représente l'obligation d'agir devant des juridictions étrangères inconnues et éloignées pour les plus petits créanciers, mais il s'agit là de cas marginaux qui de toute façon à eux seuls ont très peu de chances de justifier l'octroi de garanties même sous l'empire de la Directive Mobilité. Il est en revanche intéressant de relever qu'en droit suisse, contrairement à ce qui est prévu par la Directive Sociétés[3942] et la Directive Mobilité[3943], le législateur a fait le choix de faire peser la charge de la preuve non pas sur le créancier, mais sur la société elle-même[3944]. En effet, au lieu d'imposer au créancier de démontrer l'existence d'un risque crédible, ce qui pourrait s'avérer délicat en raison de l'asymétrie d'information existant entre les sociétés bénéficiaires et ses créanciers quant à leur capacité financière à faire face aux dettes de la société scindée[3945], il est prévu que la société débitrice est dans l'obligation de fournir une garantie demandée par un créancier, à moins qu'elle ne parvienne à prouver que « la scission ne compromet pas l'exécution de la créance »[3946]. Un tel choix législatif est effectivement plus sensé que celui du législateur européen pour deux raisons. Tout d'abord, les sociétés impliquées dans l'opération sont mieux placées que les créanciers individuels pour fournir des informations quant à leur solvabilité, ce qui permettra à la juridiction compétente de rendre une décision en pleine connaissance de cause. Ensuite, plus fondamentalement, un tel renversement de la charge de la preuve devrait avoir un impact positif sur l'apathie rationnelle[3947] des créanciers, alors qu'obliger de surcroît ces derniers

3941 Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Europäischen Gesellschaft, zu Art. 1 (§§ 8, 13 SEAG), *BT-Drs.*, 2004, n° 15/3656, p. 9.

3942 Art. 99, § 2, al. 2 (fusions internes) et 146, § 2, al. 2 (scissions internes) de la Directive Sociétés.

3943 Art. 86*undecies*, § 1er, al. 2 (transformations transfrontalières) ; 126ter, § 1er, al. 2 (fusions transfrontalières) et 160*undecies*, § 1er, al. 2 (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

3944 Art. 25 §§ 1 et 3 (fusions internes) et 46, §§ 1 et 2 (scissions internes) de la Loi suisse sur les fusions et scissions.

3945 Selon le Conseil fédéral suisse à propos du nouveau régime des fusions qui prévoit un mécanisme identique, « [c]ette solution a été retenue car seule la société reprenante dispose de l'ensemble des informations concernant sa situation financière. En effet, il serait très difficile pour les créanciers d'apporter eux-mêmes la preuve, ou du moins de rendre vraisemblable que la fusion met en danger le remboursement de leurs créances. ». Voir : message du conseil fédéral suisse concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 13 juin 2000, n° 00.052, disponible sur https://www.admin.ch (12/12/2019), p. 4080.

3946 Art. 46, § 2 de la Loi suisse sur les fusions et scissions.

3947 Par « apathie rationnelle », on vise la situation dans laquelle un acteur économique est rationnellement incité à rester inactif. Dans l'hypothèse d'un créancier, cela visera notamment le cas dans lequel le coût d'une action pour obtenir le remboursement d'une créance excède le montant de la créance elle-même. Voir à ce sujet : P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of

à établir l'existence d'un risque crédible ne ferait que les dissuader davantage de recourir à ce mécanisme de protection pour garantir leurs droits.

774. Un libre choix de garanties ? Ni la Directive Sociétés à l'égard des fusions internes[3948] et transfrontalières[3949] et des scissions internes[3950], ni la Directive Mobilité à l'égard des transformations[3951], fusions[3952] et scissions[3953] transfrontalières ne contiennent d'indication quant à la forme que doit revêtir la garantie qui sera fournie aux créanciers[3954]. Ceci permet à la société débitrice de bénéficier d'une certaine flexibilité à cet égard dans la mesure où elle pourra *a priori* opter pour la garantie de son choix sous le contrôle de l'autorité compétente[3955] alors que l'introduction d'une « *white list* » des garanties présumées adéquates n'aurait fait que restreindre inutilement le pouvoir d'appréciation des juridictions concernées[3956]. La garantie fournie pourra ainsi revêtir des formes très diverses, allant de la consignation d'une somme d'argent ou de valeurs mobilières en passant par le gage, l'hypothèque ou encore le cautionnement par un tiers[3957], pour peu qu'il ne s'agisse pas d'une des autres entités impliquées dans l'opération[3958]. Cette liberté de choix, qui ressort notamment des travaux préparatoires des mesures nationales ayant transposé les dispositions de la Directive Sociétés[3959] est indispensable car elle permet au débiteur de l'obligation de s'adapter en fonction du patrimoine qu'il a à sa disposition. En effet, l'obligation pour une société de consigner une somme d'argent alors qu'elle manque de liquidités l'obligerait, au mieux, à réaliser certains de ses actifs ou à contracter d'autres prêts et, au pire, aboutirait dans une impasse. Le seul critère est que l'étendue de la garantie soit suffisante à l'aune de la créance qu'elle entend protéger[3960], c'est-à-dire en prenant en considération non seulement le montant de la créance, mais également les spécificités de

a company and their interests ? », *op. cit.*, p. 399 ; S. SEPE, « Corporate agency problems and equity contracts », *Journal of Corporation Law*, 2010, vol 36(1), p. 138, note 27 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 53, note 38.

3948 Art. 99, § 2 de la Directive Sociétés.

3949 Art. 99, § 2 et 121, § 1er, b) de la Directive Sociétés.

3950 Art. 146, § 2 de la Directive Sociétés.

3951 Art. 86*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.

3952 Art. 126*ter*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.

3953 Art. 160*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.

3954 Voir au sujet de la Directive Mobilité : Th. MASTRULLO, « La protection des créanciers dans la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », *op. cit.*, p. 2.

3955 Voir en droit luxembourgeois : Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1984–1985, n° 2897, p. 14 qui précise que la demande d'un créancier peut être satisfaite « par la fourniture tant d'une garantie ou sûreté d'ordre personnel que par la garantie ou une sûreté d'ordre réel ». Voir en ce sens en droit allemand : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 12 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 52.

3956 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 207 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 68.

3957 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER et St. OPPENHOFF (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 12 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 22, n° 52.

3958 Voir en ce sens : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 22, n° 12.

3959 En droit luxembourgeois : Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1984–1985, n° 2897, p. 14.

3960 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 7 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 12 ; G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 48 et R.-Chr. STRATZ in J. SCHMITT, R. HÖRTNAGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 21.

celle-ci telle que l'existence d'un droit de rétention ou d'autres garanties pour une partie[3961]. À cet égard, il est intéressant de relever que le droit autrichien des scissions internes comprend une disposition spécifique plafonnant le montant de la garantie fournie au montant à laquelle la créance en question est évaluée au moment de l'inscription de la scission selon les règles comptables applicables[3962].

775. Un mécanisme de protection éprouvé. Cette méthode de protection, bien qu'elle ait pu être qualifiée d' « épée relativement émoussée »[3963], est considérée comme offrant un niveau de protection adéquat[3964] et, en toute vraisemblance conforme à la liberté d'établissement[3965]. Elle est en outre celle qui compte le plus d'adhérents dans le cadre des fusions transfrontalières[3966] et permet de parvenir à une situation d'équilibre entre (i) les intérêts de la société et de ses associés à la réalisation rapide d'une scission transfrontalière nécessaire d'un point de vue économique et (ii) la nécessité de veiller à ce que la situation des créanciers antérieurs ne se détériore pas du fait de l'opération[3967]. L'efficacité de cette mesure a en outre été confirmée par la pratique[3968].

3.2. Les limites

776. Une situation d'équilibre difficile à atteindre. Si de prime abord le mécanisme de protection par le biais de l'octroi de garanties semble propre à garantir la neutralité de l'opération sur la situation des créanciers, la nécessaire évaluation des besoins de protection des créanciers dans le cadre de la détermination de l'étendue de la garantie à fournir peut s'avérer très délicate en pratique de sorte que le délicat équilibre entre intérêts des créanciers et intérêts des associés n'est pas toujours atteint. En d'autres termes, les aspects variables de ce système peuvent avoir pour conséquence indésirable que le créancier se retrouve paradoxalement dans une situation plus favorable à la suite de l'opération[3969]. Ce sera tout particulièrement le cas si une demande d'octroi de garanties a un effet suspensif sur l'opération.

3961 G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 22, n° 48.
3962 § 15 (2), 2e phrase SpaltG.
3963 H. HECKSCHEN, « Inhalt und Umfang der Gesamtrechtsnachfolge – sog. Vertrauensstellungen und Mitgliedschaften », *GmbHR*, 2014, p. 627.
3964 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18.
3965 Arrêt *Polbud*, pt. 57 et arrêt *Centros*, pts. 36 et 37.
3966 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale à cet égard, dans 29 des 30 États étudiés, la possibilité d'octroyer des garanties spécifiques aux créanciers constitue le mécanisme de protection privilégié. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 56.
3967 Voir en ce sens à propos des conversions transfrontalières : A. FRANK, *op. cit.*, p. 195. Voir également à propos des scissions internes : Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 121. Voir également en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 130, n° 281.
3968 Voir en ce sens à propos de la même mesure en cas de scission interne : Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 121.
3969 Voir en ce sens : G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 49.

777. L'information des créanciers. Au-delà de cette première limite, on peut également relever que ce régime de protection ne peut être mis en œuvre qu'à l'initiative d'un créancier, de sorte que son efficacité sera directement liée à l'information adéquate et en temps utile de ceux-ci. Si tant la Directive Sociétés relatives aux scissions internes[3970] que la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières[3971] veillent à ce que les créanciers soient informés de manière adéquate par le biais du projet commun de l'opération projetée, cela ne s'adresse qu'aux créanciers ayant pleine connaissance de leur qualité de créancier de la société scindée et disposant des moyens et de la volonté d'agir pour garantir leurs intérêts[3972]. À l'égard des créanciers ignorant la dette de la société scindée envers eux et ne la découvrant qu'après l'écoulement du délai légal pour demander une garantie, cette protection est inefficace. Cette question est particulièrement importante en matière de responsabilité environnementale ou du fait de produits défectueux[3973]. Dans un même ordre d'idées, ce type de protection s'adresse en priorité aux créanciers d'une certaine importance qui disposent de moyens suffisants pour faire valoir leurs droits et qui, de manière assez paradoxale, sont déjà suffisamment protégés par des mécanismes contractuels particuliers[3974]. Ces premières limites montrent déjà à elles seules à quel point un régime axé autour de la seule possibilité de demander des garanties est insuffisant.

778. Trois risques liés au patrimoine limité des sociétés impliquées. À ces premières limites s'ajoutent encore trois risques intimement liés à la situation patrimoniale de la société débitrice. Tout d'abord, assez paradoxalement, l'octroi d'une garantie à un créancier en faisant la demande risque de détériorer la situation des autres créanciers en érodant davantage le gage commun, voire même de compromettre le remboursement de créances pour lesquelles l'opération ne présentait aucun danger auparavant[3975]. Ce risque est d'autant plus accru qu'on ne tient généralement pas compte des autres garanties octroyées aux créanciers dans le cadre d'une scission pour déterminer dans quelle mesure cette dernière représente un risque concret pour les créanciers[3976] et ce, afin d'éviter un cercle vicieux obligeant sans cesse la société débitrice à octroyer de nouvelles garanties[3977]. Le second risque concerne le fait que la société débitrice n'a à sa disposition qu'un nombre limité de garanties à octroyer aux créanciers, de sorte que tous ne pourront être protégés de manière adéquate[3978]. Le troisième et dernier risque est qu'en cas de nombreuses demandes de garanties initiées par des créanciers mécontents, l'opération, potentiellement nécessaire à la survie économique de l'entreprise, ne s'en trouve soit fortement compromise,

3970 Art. 137, §§ 1 et 2 de la Directive Sociétés.
3971 Art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité.
3972 Voir en ce sens : Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 246 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 53.
3973 M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, 133, n° 9.
3974 Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 246.
3975 S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 78 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 31.
3976 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 7 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 22, n° 31.
3977 G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 22, n° 31.
3978 H. HAHN, *op. cit.*, p. 254.

soit complètement bloquée[3979]. En d'autres termes, une action de concert d'un nombre important de créanciers pour la situation desquels l'opération présente un risque concret est susceptible d'aboutir dans les faits au même résultat qu'un droit de veto. Si ce risque est atténué par la condition que seuls les créanciers à mêmes d'établir l'existence d'un risque crédible pour le remboursement de leur créance peuvent réclamer des garanties[3980], il n'en a pas pour autant disparu.

779. La nécessité d'une solidarité complémentaire. Si dans le cadre des fusions transfrontalières, on peut considérer qu'une protection des créanciers articulée autour de la possibilité pour ceux-ci de demander des garanties constitue une solution éprouvée[3981], il convient toutefois de remarquer qu'une scission, de par l'éclatement du patrimoine de la société scindée et la répartition entre les sociétés bénéficiaires telle que décidée par les associés qu'elle implique, emporte des risques additionnels pour les créanciers[3982]. Pour s'en convaincre, il convient d'envisager la situation dans laquelle les deux activités principales d'une société scindée sont réparties entre deux sociétés bénéficiaires distinctes et où, postérieurement à la réalisation de la scission, l'une des activités périclite de manière inattendue au point que la société bénéficiaire en question se retrouve insolvable. Dans une telle hypothèse, les créanciers ne se seront vraisemblablement pas vus accorder de garanties dans la mesure où préalablement à la réalisation de l'opération ou immédiatement après la réalisation de celle-ci, ces derniers n'encouraient pas de risque prévisible, mais il n'en demeure pas moins que l'opération n'aura pas été neutre à leur égard. Il s'ensuit que la protection des créanciers par le biais de la possibilité de demander des garanties n'est pas à même de protéger, à elle seule, les créanciers de la société scindée contre les éventuels effets d'une scission et que par conséquent, le recours à d'autres moyens de protection complémentaires s'impose. À cet égard, il a été avancé que seule la solidarité des sociétés bénéficiaires permettait de protéger efficacement les créanciers dans le cadre d'une scission dans la mesure où elle permet de pallier les insuffisances d'un régime de protection limité à la possibilité de demander une garantie[3983]. Il est également intéressant de relever que c'est ce même constat qui a poussé le législateur belge à compléter le régime de protection des créanciers en cas de scission interne par la solidarité des sociétés bénéficiaires pour les dettes de la société scindée[3984].

3979 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 320.

3980 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1106, n° 68 et K. MERTENS, « Zur Universalsukzession in einem neuen Umwandlungsrecht », *op. cit.*, p. 70.

3981 Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 56 qui établit que ce mécanisme de protection a été instauré dans 29 des 30 États membres étudiés.

3982 Au sujet de ce risque, voir : Étude d'impact, p. 68 ; Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 30 et G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 72 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 77 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 7 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 51.

3983 Voir en ce sens : H. HAHN, *op. cit.*, pp. 254 et 255 et Ol. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, pp. 145 et 146.

3984 Proposition de loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, commentaires des articles, *Doc.*, Ch., 1992–1993, 1005/1, disponible sur www.lachambre.be (26/09/2019), p. 14.

4. *La solidarité des sociétés bénéficiaires de la scission*

4.1. Le principe

780. Un juste équilibre. À l'égard des scissions internes, la Directive Sociétés envisage trois hypothèses distinctes de solidarité au profit uniquement des créanciers de la société scindée dont deux sont obligatoires et l'une est facultative. Tout d'abord, afin de protéger les créanciers de la société scindée en cas d'éléments de passif oubliés ou inconnus, les États membres qui ont fait le choix de reconnaître la scission ont l'obligation d'en rendre les sociétés bénéficiaires solidairement responsables si l'interprétation du projet de scission ne permet pas de résoudre la situation[3985]. Ensuite, afin de protéger les créanciers de la société scindée de manière plus générale, les États membres disposent de la possibilité de prévoir que les sociétés bénéficiaires seront tenues solidairement des obligations de la société scindée[3986] et doivent, en tout état de cause, prévoir que si un des créanciers de la société scindée n'a pas eu satisfaction de la part de la société à laquelle l'obligation a été transférée, les sociétés bénéficiaires en seront tenues solidairement[3987]. Dans un même ordre d'idées et se basant sur ce mécanisme de protection éprouvé[3988], la Directive Mobilité prévoit qu'en cas de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, si un créancier de la société scindée n'a pas eu satisfaction de la part de la société bénéficiaire à laquelle cette dette a été attribuée, les autres sociétés en seront tenues solidairement et conjointement[3989]. Le recours fréquent à la solidarité pour garantir la protection des créanciers s'explique par le fait que cette solidarité doit être considérée comme la contrepartie de la liberté dont les associés jouissent à l'égard de la répartition des éléments composant le patrimoine de la société scindée[3990] et permet de limiter les risques d'émergence de comportements opportunistes de la part des associés visant à augmenter la valeur de l'entreprise au détriment des créanciers[3991]. En effet, l'opération par laquelle les associés décideraient de concentrer les dettes et les activités à faible potentiel de croissance au sein d'une des sociétés bénéficiaires, tout en parvenant à un actif net à peine positif de la fraction de

3985 Art. 137, § 3, al. 2 de la Directive Sociétés.
3986 Art. 146, § 6 de la Directive Sociétés.
3987 Art. 146, § 3 de la Directive Sociétés.
3988 Voir en ce sens : P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2445 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281.
3989 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.
3990 Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 122 et J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *op. cit.*, p. 364 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1083, n° 7 ; Ol. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, pp. 145 et 146 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 264 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 12 ; G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 1 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 2.
3991 Proposition de loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, commentaires des articles, *Doc.*, Ch., 1992–1993, 1005/1, disponible sur www.lachambre.be (26/09/2019), p. 14.

patrimoine allouée à celle-ci[3992], en vue de réserver les activités les plus prometteuses à l'autre société bénéficiaire perd tout son intérêt en cas de solidarité des sociétés issues de l'opération[3993]. En conséquence, la solidarité des sociétés bénéficiaires devrait inciter les parties, à commencer par les organes de gestion en charge de la rédaction du projet de scission, à veiller à ce que la société à laquelle la créance sera transférée, sera bien en mesure de s'en acquitter à terme[3994]. En termes d'analyse économique, cette solidarité constitue un moyen efficace de limiter le conflit d'agence susceptible de survenir entre d'une part les associés et les membres de l'organe de gestion et d'autre part les créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière. En outre, cette solution se justifie également au regard du fort lien de parenté existant entre scission et fusion puisque dans cette dernière, il n'y a, par définition, plus qu'une société débitrice unique une fois l'opération réalisée[3995]. Ces caractéristiques font qu'il a été avancé que ce régime représente la solution la plus simple et la plus efficace pour que l'opération de scission demeure neutre à l'égard des créanciers[3996].

781. Un mécanisme très protecteur. Cette solution, qui revient dans les faits à supprimer les effets de l'éclatement du patrimoine de la société scindée à l'encontre des créanciers de la société scindée[3997], est particulièrement avantageuse pour les créanciers dans la mesure où elle leur évite de devoir engager une procédure contre chacune des sociétés impliquées dans l'opération en leur permettant de choisir la plus solvable[3998]. Elle constitue en outre la juste contrepartie de la liberté dont jouissent les associés au moment de la répartition du patrimoine de la société scindée[3999]. Ce caractère protecteur est reflété par le fait que les États membres ayant opté pour la mise en place d'une telle solidarité en cas de scission interne se retrouvent dispensés de l'obligation de prévoir un régime additionnel permettant aux créanciers de réclamer des garanties[4000]. En outre, elle permet de pallier les insuffisances du mécanisme de protection par le biais de l'octroi de garanties en offrant une protection

3992 Sur la nécessité d'avoir des fractions de patrimoine dont l'actif net est positif, voir *supra* n°s 118 à 120.

3993 Voir Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 122 où le législateur allemand fait référence à la situation dans laquelle tout l'actif serait attribué à une des sociétés bénéficiaires et tout le passif à l'autre.

3994 Voir en ce sens : K. SCHMIDT, *op. cit.*, p. 389 et M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n°s 13 et 14.

3995 Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 122.

3996 RV EU-GesRÄG 1996 32, commentaire des articles, BlgNR 20. GP, disponible sur https://www.parlament.gv.at (11/10/2019), p. 124.

3997 M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 11 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 4.

3998 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 26.

3999 Voir en ce sens : Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 122 et J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *op. cit.*, p. 364 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1083, n° 7 ; Ol. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, pp. 145 et 146 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 264 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), § 133, p. 1860, n° 12 ; G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 1 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 2.

4000 Art. 146, § 6 de la Directive Sociétés.

adéquate des petits créanciers ne disposant pas nécessairement des moyens ou de la volonté d'agir en justice pour garantir la protection de leurs intérêts, ainsi que des créanciers délictuels et des créanciers ignorant encore l'existence de leur créance au moment de la scission.

782. Un mécanisme de simplification. Un des autres avantages non négligeables de la solidarité passive est que cette dernière permet d'alléger sensiblement le régime de protection des créanciers articulé autour de l'octroi de garanties adéquates et par conséquent de limiter l'érosion du patrimoine des sociétés impliquées en raison de l'octroi répété de garanties aux créanciers. En effet, en examinant si la scission transfrontalière présente un risque pour le remboursement des différents créanciers concernés, le juge pourra tenir compte des garanties dont disposent déjà les créanciers, ce qui inclut la solidarité légale[4001]. À cet égard, le régime autrichien des scissions internes est particulièrement éloquent. Celui-ci prévoit en effet que tout créancier de la société scindée disposant de créances non-échues peut, dans les six mois suivant la date à laquelle la scission devient opposable aux tiers, se manifester auprès d'une des sociétés bénéficiaires et lui demander l'octroi d'une garantie s'il parvient à établir que la scission met le remboursement de sa créance en péril[4002]. Ce qui est intéressant, c'est que si la société et le créancier ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la garantie à octroyer dans un délai de neuf mois suivant la date à laquelle la scission devient opposable aux tiers, toutes les sociétés bénéficiaires seront tenues solidairement et de manière illimitée de la dette en question[4003]. En d'autres termes, il n'est pas possible aux créanciers de la société scindée d'agir en justice pour obtenir une garantie[4004]. Il convient toutefois de préciser que les sociétés bénéficiaires concernées disposeront malgré tout de la possibilité d'écarter la solidarité soit en fournissant la garantie soit en introduisant une procédure judiciaire en vue d'établir que les prétentions du créancier ne sont pas fondées[4005]. En d'autres termes, le régime autrichien, tout en garantissant une protection adéquate des créanciers, s'assure que les sociétés disposent d'une certaine flexibilité[4006] et ne se retrouvent pas empêtrées dans de multiples procédures initiées par les créanciers.

783. L'exclusion des seules créances postérieures à la scission. Il est important de préciser que cette solidarité des sociétés bénéficiaires ne peut porter que sur des dettes de la société scindée antérieures à la prise d'effet de l'opération et non pas, contrairement à ce qui est le cas pour le droit de demander des garanties[4007], antérieures à la publication du projet de scission.

4001 Voir en ce sens : M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 21. Voir également : K. SCHMIDT, *op. cit.*, p. 383 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 92 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 121 qui considèrent que la limitation temporelle de la solidarité passive en droit allemand est susceptible de constituer un risque pour les créanciers justifiant, le cas échéant, l'octroi de garanties adéquates.

4002 § 15 (2), 1re phrase SpaltG.

4003 § 15(3) SpaltG.

4004 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1104, n° 62.

4005 § 15(3) SpaltG.

4006 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1104, n° 62.

4007 Art. 160*undecies*, § 1er de la Proposition du Parlement pour les scissions transfrontalières et art. 146, § 3 de la Directive Sociétés pour les scissions internes.

Cette précision est textuellement absente tant de la Directive Sociétés[4008] que de la Directive Mobilité[4009], mais peut se déduire du fait que les dispositions en question s'appliquent indistinctement aux obligations transférées conformément au projet de scission indépendamment du fait qu'elles soient nées avant ou après la publication du projet de scission. En vue d'éviter tout doute sur la question, cet aspect de la solidarité passive des sociétés issues de l'opération été complété par certains législateurs nationaux, tel le législateur allemand[4010] qui a prévu que la solidarité était limitée aux seules créances nées avant la prise d'effet de la scission. Dans un même ordre d'idées, le législateur belge a restreint celle-ci aux dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participer à la scission[4011]. À cet égard, il convient toutefois de remarquer que dans le cas particulier d'une scission-émigration où la société scindée est une société belge, cette règle aboutit à un régime moins favorable aux créanciers que celui de la Directive Mobilité. En effet, cette dernière protège tous les créanciers dont la créance est antérieure à la date de prise d'effet de l'opération, alors qu'une scission-émigration belge ne prendra pas effet au moment de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participer à l'opération, mais au moment déterminé par le droit national applicable aux sociétés bénéficiaires[4012], étant entendu que ce moment devra nécessairement être postérieur à l'émission du certificat de conformité par le notaire compétent[4013]. Or, le notaire attendra en principe l'écoulement d'un délai de deux mois suivant la publication des actes constatant la scission avant d'émettre son certificat puisqu'il lui incombe de s'abstenir de le délivrer tant qu'un créancier exigeant une sûreté n'aura pas obtenu satisfaction ou n'aura pas vu sa demande rejetée par une décision judiciaire exécutoire[4014]. Il s'ensuit que les créanciers dont la créance sera devenue certaine et exigible[4015] après la publication des actes constatant la scission mais avant l'émission du certificat de conformité ne bénéficieront pas de la solidarité des sociétés bénéficiaires, et ce, malgré le fait que leur créance soit antérieure à la date de prise d'effet de l'opération. Afin de garantir une certaine uniformité entre scissions internes et transfrontalières, il vaudrait dès lors mieux prévoir que la solidarité couvrira toutes les créances antérieures à la date de prise d'effet de la scission. Il convient en outre de remarquer qu'il est important de ne pas apprécier cette condition d'antériorité de manière trop restrictive afin d'éviter de pénaliser des créanciers qui ne viendraient à découvrir le dommage qui leur aura été causé par la société scindée que bien après la prise d'effet de l'opération. À titre d'illustration, c'est pour cela qu'en droit allemand, on considère en matière de responsabilité environnementale et du fait des produits défectueux

4008 Art. 159 et 146, § 3 de la Directive Sociétés.
4009 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.
4010 § 133 (1) UmwG.
4011 Art. 12:17, al. 1er du CSA.
4012 Art. 12:73, § 5, 1re phrase et 12:90, § 5, 1re phrase du CSA.
4013 Art. 12:73, § 5, 2e phrase et 12:90, § 5, 2e phrase du CSA.
4014 Art. 12:73, § 3, 2e phrase et 12:90, § 3, 2e phrase du CSA.
4015 Il est utile de préciser que la Cour de cassation belge a considéré qu' « une obligation qui résulte d'un jugement susceptible d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ne peut être considérée comme certaine et exigible ». Voir Cass., 1re ch., 14 octobre 2011, *J.L.M.B.*, 2012/4, p. 161.

qu'il suffit que l'évènement à l'origine du dommage ait eu lieu avant la prise d'effet de la scission pour que la créance en résultant soit considérée comme une créance antérieure bénéficiant de la solidarité des sociétés impliquées dans l'opération[4016].

784. La question de la limitation à l'actif net. Selon les dispositions de la Directive Sociétés applicables en matière des scissions internes, si un État membre a opté pour une combinaison entre possibilité de demander une garantie et responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires pour les obligations de la société scindée, il dispose de la possibilité de limiter cette solidarité à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés[4017]. En matière de scissions internes, ce choix n'a pas été fait par le législateur allemand[4018] en raison des risques liés à une répartition arbitraire des éléments d'actif et de passif de la société scindée dans le cadre d'une scission[4019], alors que les législateurs autrichien[4020], belge[4021] et luxembourgeois[4022] ont choisi de l'introduire. Malgré cette marge de manœuvre laissée par la Directive Sociétés, la Directive Mobilité rend cette limite de l'actif net obligatoire[4023]. Ce point a fait l'objet de certaines critiques dans la mesure où une telle limite serait contraire à l'esprit même de la solidarité[4024] et affaiblirait la protection des créanciers[4025] puisque ce sont précisément les cas où cette limite de l'actif net sera invoquée par les sociétés concernées qui sont susceptibles d'engendrer une expropriation indue des créanciers de la société scindée[4026]. Cependant, une telle limite se justifie pleinement pour deux raisons. Tout d'abord, à l'aune de l'objectif de neutralité de la scission sur la situation des créanciers, il est indispensable de veiller également à ce que ces derniers ne soient pas mieux lotis suite à la réalisation de l'opération et ce, au détriment des sociétés bénéficiaires, ce qui risque d'être d'autant plus le cas dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. Or, c'est exactement ce qui risque de résulter d'une solidarité illimitée dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant deux sociétés bénéficiaires préexistantes et solvables,

4016 H. FLEISCHER et M. EMPT, « Gesellschaftsrechtliche Durchgriffs- und Konzernhaftung und öffentlichrechtliche Altlastenverantwortlichkeit », *ZIP*, 2000, pp. 911 et 912 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 84 ; G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 18 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 9.

4017 Art. 146, § 7 de la Directive Sociétés.

4018 § 133 UmwG et M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 7.

4019 Voir en ce sens : Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 121 et M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 133, n° 7.

4020 § 15(1) SpaltG.

4021 Art. 12:17, al. 1er, 2e phrase du CSA.

4022 Art. 1031-10, § 2, al. 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

4023 Art. 160*undecies*, § 2, 2e phrase de la Directive Mobilité.

4024 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2445 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht. Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, p. 330.

4025 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 364 ; H. BUNGERT et T. WANSLEBEN, *op. cit.*, p. 2102 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 867, n° 103 et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2445.

4026 Voir en ce sens : Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *op. cit.*, pp. 330 et 331.

puisque le créancier de la société scindée bénéficiera ainsi d'un accès direct et illimité aux patrimoines de celles-ci[4027]. En outre, une responsabilité solidaire illimitée risquerait de restreindre excessivement la liberté d'établissement des sociétés bénéficiaires en cas de scission par absorption transfrontalière dans la mesure où elle ne respecterait pas la condition de proportionnalité imposée par le « *Gebhard test* ».

785. La question de la limitation dans le temps. S'il a fait le choix de ne pas transposer la limite de l'actif net[4028], le législateur allemand a, de manière inédite, prévu qu'en cas de scission interne, la solidarité des sociétés bénéficiaires pour les dettes qui ne leur auront pas été allouées dans le projet de scission sera limitée aux dettes venant à échéance avant l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de la date de la publication de la scission et (i) constatées par un jugement ayant force de chose jugée (*rechtskräftiges Urteil*), un règlement exécutoire (*vollstreckbarer Vergleich*), un instrument exécutoire (*vollstreckbare Urkunde*), dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité (*Insolvenzverfahren*)[4029] ou (ii) reconnue par écrit par le débiteur solidaire[4030]. Toutefois, en ce qui concerne les obligations de pension en vertu de la loi allemande sur les pensions d'entreprises (*Betriebsrentengesetz*), ce délai sera porté à dix ans[4031] et un projet de loi envisage d'introduire une solidarité illimitée en matière d'énergie nucléaire[4032]. Cette limitation est à mettre en relation avec la limitation de la responsabilité d'un associé d'une société de personnes en cas de fusion par absorption de celle-ci au profit d'une société dont les associés ne sont responsables que de manière limitée[4033] et qui a pour objectif d'éviter une responsabilité sans fin en cas d'obligation à exécution successive conclue avant la date de prise d'effet de l'opération[4034]. Si la conformité de cette limite temporelle aux dispositions relatives aux scissions internes de la Directive Sociétés a pu soulever certaines interrogations, la majorité des auteurs considère qu'il découle de la possibilité offerte par la Directive Sociétés de limiter la solidarité à l'actif net attribué dans le cadre de l'opération[4035] que d'autres limitations peuvent être admises, pour peu que le mécanisme de protection dans son ensemble offre un niveau de protection adéquat[4036]. Or, en plus de la solidarité de principe pour les dettes de la société scindée antérieures à la

4027 Voir en ce sens également à propos des scissions internes : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1081, n° 3.
4028 § 133 UmwG et M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 7.
4029 § 133 (3) *in initio* UmwG et à ce sujet : M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 18.
4030 § 133 (5) UmwG.
4031 § 133 (3) *in fine* UmwG.
4032 Entwurf eines Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbau- und Entsorgungskosten im Kernenergiebereich (Rückbau- und EntsorgungskostennachhaftungsG), exposé des motifs, *BT-Drs.*, 2015, n° 18/6615, pp. 7 et 8 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 18.
4033 § 45 UmwG et Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 122.
4034 Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 122 et Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 171.
4035 Art. 186, § 7 de la Directive Sociétés.
4036 Voir en ce sens : Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 171 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 8 ; G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 7. *Contra* : M. HEIDENHAIN, « Fehlerhafte Umsetzung der Spaltungsrichtlinie », *EuZW*, 1995, p. 327.

date de prise d'effet prévue par le législateur allemand[4037], les créanciers disposent également de la possibilité de demander une garantie[4038] qui devra être octroyée par la société à laquelle la dette correspondante aura été allouée[4039]. En outre, à défaut pour la société en question de fournir la garantie nécessaire, le créancier disposera fréquemment de la possibilité de résilier le contrat[4040] et toutes les sociétés impliquées seront tenues solidairement des dettes correspondantes, tout en précisant que cette solidarité ne sera pas limitée à l'actif net transféré[4041]. Il s'ensuit que le régime de protection des créanciers mis en place par le législateur allemand offre un niveau de protection adéquat tout en palliant les inconvénients liés à une limitation temporelle relativement courte de la solidarité passive des sociétés bénéficiaires. Dans un contexte transfrontalier, bien que la Directive Mobilité soit muette sur ce sujet[4042], il a été avancé que les États membres demeuraient libres d'instaurer une limite temporelle à la solidarité passive. Ce point est indéniable au vu de la liberté d'appréciation laissée aux États membres par le législateur européen[4043] et on peut en outre relever qu'assortir la solidarité d'une limite temporelle en sus de la limite matérielle de la solidarité passive renforce la proportionnalité de la mesure à l'aune de la liberté d'établissement.

786. Solidarité uniquement en cas de défaut de la société à laquelle la créance a été transférée. Selon le régime de la Directive Mobilité[4044], la solidarité des sociétés bénéficiaires n'intervient que si le créancier de la société scindée n'a pas obtenu satisfaction de la part de la société à laquelle la dette a été transférée. Ce point a fait également l'objet de certaines critiques générales en ce qu'il serait contraire au principe de la solidarité[4045] et réduirait le niveau de protection des créanciers[4046]. Cependant, force est de constater que cette exigence correspond au régime applicable en cas de scissions internes en vertu de la Directive Sociétés pour peu que l'État membre en question ait également prévu la possibilité pour les créanciers de demander la constitution de garanties adéquates[4047] et découle de la transmission à titre universel des fractions du patrimoine de la société scindée qui constitue l'essence d'une scission[4048]. En outre, on conçoit difficilement en quoi cette exigence viendrait réduire le niveau de protection des créanciers, ne fût-ce que parce qu'elle n'impacte pas l'efficacité de la solidarité.

787. Solidarité et scissions partielles. L'obligation d'agir en priorité contre la société à laquelle la créance a été transférée combinée à la solidarité passive des autres sociétés bénéficiaires mérite toutefois quelques précisions en cas de

4037 § 133 (1) UmwG.
4038 §§ 22 et 125 UmwG.
4039 § 133 (1) *in fine* UmwG.
4040 G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 55.
4041 G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 133, n° 7.
4042 P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2445.
4043 À ce sujet, voir *infra* n°s 1089 à 1091.
4044 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.
4045 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2445.
4046 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 364 et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2445.
4047 Art. 146, § 3 de la Directive Sociétés.
4048 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 4, Section 2.

scission partielle puisque, dans une telle hypothèse, la société scindée survit à l'opération et il est tout à fait possible que la créance en question demeure au sein du patrimoine de la société scindée. Face à cette situation, la Directive Sociétés prévoit simplement que les États membres qui autorisent la scission partielle devront lui appliquer le régime de protection des créanciers applicable en cas de scission classique[4049]. *A contrario*, la Directive Mobilité traite directement et spécifiquement cette question dans la disposition relative à la protection des créanciers en prévoyant que si la société survit à l'opération, elle sera tenue conjointement et solidairement avec les autres sociétés bénéficiaires d'une dette pour laquelle un créancier n'a pas obtenu satisfaction de la part de la société à laquelle l'obligation a été attribuée[4050]. Cette formulation prête cependant le flanc à la critique dans la mesure où en assimilant automatiquement la société scindée survivante aux autres sociétés bénéficiaires, elle n'envisage pas la situation dans laquelle la dette en question demeure dans le patrimoine de la société scindée. Certes, dans une telle hypothèse, le créancier n'est pas soumis à une substitution de débiteur sans son consentement, mais il n'en demeure pas moins que le patrimoine de la société scindée se trouvera amoindri dans le cadre de l'opération. Un constat similaire s'impose à l'égard du régime luxembourgeois des scissions partielles transfrontalières puisque le régime de protection des créanciers prévoit que si un créancier n'a pas obtenu satisfaction « de la part de la société à laquelle l'obligation a été transférée conformément au projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement de cette obligation »[4051]. Si on peut aisément considérer que la notion de « sociétés bénéficiaires » doit recouvrir également la société scindée en cas de scission partielle, l'exigence d'un transfert conformément au projet de scission semble exclure *de facto* les créanciers de la société scindée dont la créance demeure dans le patrimoine de celle-ci du bénéfice de la solidarité passive. Cette situation fâcheuse se doit d'être rectifiée, *a fortiori* si on conçoit la solidarité passive des sociétés issues de la scission comme la contrepartie de la liberté dont jouissent les associés au moment de la répartition du patrimoine de la société scindée[4052]. Une telle correction ne peut se faire en procédant à une assimilation générale des scissions partielles aux scissions complètes, comme ce fut le choix tant dans le régime des scissions internes de la Directive Sociétés[4053] que dans le régime des scissions transfrontalières prévu par le législateur luxembourgeois[4054], car cela ne manquera pas de générer certaines imprécisions et incertitudes liées à toute application par assimilation.

4049 Art. 159 de la Directive Sociétés.
4050 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.
4051 Art. 1031-10, § 1er, al. 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
4052 Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 122 et J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 1083, n° 7 ; Ol. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, pp. 145 et 146 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 264 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 12 ; G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 1 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 2.
4053 Art. 159 de la Directive Sociétés.
4054 Art. 1030-3, § 1er et art. 1032-1, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Alternativement, et de préférence, il serait plus opportun, notamment du point de vue de la sécurité juridique, de se tourner vers la solution prônée par le législateur belge[4055] en précisant directement le régime de protection des créanciers en indiquant que dans le cadre particulier de la scission partielle, la société scindée ne doit être assimilée aux « autres sociétés bénéficiaires » que si la dette en question a été transférée dans le cadre de l'opération.

4.2. Les limitations

788. L'exclusion des créanciers des sociétés bénéficiaires. Si une solidarité de principe pour les obligations de la société scindée permet de garantir une protection efficace des créanciers en ce qu'elle équivaut à rendre la répartition du patrimoine de la société scindée inopposable à leur encontre[4056], force est de constater que cette solution n'est par conséquent pas du tout adaptée à la protection des créanciers des sociétés bénéficiaires. En effet, prévoir qu'en cas de scission par absorption transfrontalière, les créanciers des sociétés bénéficiaires bénéficieront d'une solidarité passive de toutes les sociétés bénéficiaires en cas de défaut de la société débitrice, même limitée à l'actif net, romprait le délicat équilibre entre les intérêts des sociétés concernées et les intérêts des créanciers des sociétés bénéficiaires en ce que la situation de ces derniers s'améliorerait considérablement suite à la réalisation de l'opération par l'adjonction d'au moins un débiteur additionnel. Cependant, il est indéniable qu'une scission transfrontalière par absorption présente également des risques pour les créanciers des sociétés bénéficiaires[4057], même si ceux-ci sont généralement moindres que ceux encourus par les créanciers des sociétés bénéficiaires[4058]. Or, comme il s'avère que la solidarité des sociétés bénéficiaires n'est pas à même de garantir une protection efficace de leurs droits tout en respectant l'objectif de neutralité, il s'ensuit que d'autres moyens de protection, comme la possibilité de demander des garanties adéquates[4059] ou encore la déclaration de solvabilité de l'organe de gestion[4060], seront inéluctables. La protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière ne peut donc graviter autour de la seule solidarité des sociétés bénéficiaires comme mécanisme de protection.

789. Un régime trop rigide. S'il est vrai qu'un mécanisme de protection institutionnel intervenant de manière automatique est plus à même de protéger les intérêts des petits créanciers ainsi que des créanciers passifs de la société scindée[4061], force est de constater que ce régime manque de souplesse en ce qu'il impose une solidarité aux sociétés bénéficiaires même lorsque le

4055 Art. 12:17 du CSA. Voir également : D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, p. 334, n° 11 qui évoque comme alternative générale pour la scission transfrontalière, la possibilité d'introduire un ensemble de règles spécifiques pour les scissions partielles.

4056 Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 122.

4057 À ce sujet, voir *supra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 1.

4058 Th. PRÜM, *op. cit.*, p. 86 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 37 et M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 142.

4059 À ce sujet, voir *supra* n°s 767 à 779.

4060 À ce sujet, voir *supra* n°s 759 à 766.

4061 M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 54.

remboursement du créancier n'est pas mis en danger par l'opération car celui-ci dispose déjà de sûretés adéquates[4062]. Si cet inconvénient a été écarté par le législateur européen dans la Directive Mobilité en imposant d'abord aux créanciers de la société scindée d'agir contre la société à laquelle leur créance a été attribuée[4063], ce régime crée une certaine insécurité pour les sociétés issues de l'opération dans la mesure où la solidarité potentielle les empêche de déterminer directement les obligations auxquelles elles seront tenues[4064]. Il s'ensuit qu'une solidarité de principe risque de significativement impacter la capacité de la société en question à avoir accès à des capitaux externes[4065]. En outre, ces incertitudes se répercuteront également sur les tiers qui viendraient à contracter avec la société après la réalisation de l'opération puisque la solidarité passive, bien que devant normalement apparaître dans l'annexe en tant qu'engagements hors bilan dans la mesure où elle est susceptible d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de la société[4066], n'apparaîtra pas nécessairement au passif des sociétés auxquelles la créance n'aura pas été transférée[4067]. Pour finir, malgré ses avantages indéniables, force est de constater que ce régime est particulièrement intrusif en ce qu'il revient dans les faits à réduire à néant la répartition du patrimoine de la société scindée telle que décidée par les associés et la transmission à titre universel dont elle s'accompagne[4068]. Si dans un contexte purement interne, une solidarité pure et simple telle que laissée à la libre appréciation des États membres par la Directive Sociétés peut se concevoir, il en va autrement dans un contexte transfrontalier où les exigences de la liberté d'établissement imposent que les restrictions introduites en vue de protéger les intérêts des créanciers soient, entre autres, proportionnées[4069]. Ce point n'a pas échappé au législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité puisque ce dernier l'a assortie de conditions strictes et a fait le choix de l'articuler autour de la possibilité de demander des garanties adéquates[4070].

4062 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 30 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 59.

4063 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.

4064 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 30 et G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 73.

4065 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 59.

4066 Voir en ce sens en droit allemand : M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 85 ; G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 14 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 69. Voir également : Commission des Normes Comptables belge, *Annuaire 2020 CNC*, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 1224–1266 et spécialement p. 1226 où il est relevé que ces engagements hors bilan comprennent « les engagements et recours corrélatifs éventuels pouvant résulter pour l'entreprise de litiges, de responsabilités, de dispositions légales ».

4067 Voir en ce sens en droit allemand : M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 133, n° 85 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 133, n° 69. Voir également : G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 133, n° 13 qui insiste sur le fait que la solidarité ne doit faire l'objet d'une inscription au passif que s'il y a un risque réel que les créanciers concernés en fassent usage.

4068 RV EU-GesRÄG 1996 32, commentaire des articles, BlgNR 20. GP, disponible sur https://www.parlament.gv.at (11/10/2019), p. 124 et M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 133, n° 11.

4069 Au sujet de l'incidence de la liberté d'établissement sur la protection des créanciers, voir *supra* n°s 707 à 711.

4070 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.

5. *La compétence des juridictions de l'État de la société scindée*

5.1. Le principe

790. Le Règlement sur la Société européenne. Le mécanisme de la *perpetuatio fori*, qui revient à maintenir fictivement la compétence des juridictions de l'État membre d'origine pendant un certain laps de temps, se retrouve dans le régime de la société européenne[4071], mais uniquement à l'égard des transferts de siège. Fruit d'un compromis politique[4072], ce mécanisme prévoit que toute société européenne qui procèderait à un transfert de son siège statutaire d'un État membre à un autre, serait considérée aux fins de tout litige survenant avant la date de prise d'effet du transfert dans l'ordre interne, comme ayant son siège statutaire dans l'État membre où la société européenne était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la société européenne après le transfert[4073]. L'objectif est donc de pallier les incertitudes liées à la nécessité d'agir devant des juridictions étrangères dont se retrouveront affectés les créanciers de l'entité transférée[4074] et revient, dans les faits, à annuler l'effet des dispositions du Règlement Bruxelles I*bis* qui aboutiraient à une compétence de principe des juridictions de l'État membre de destination[4075]. Elle est donc essentiellement destinée à protéger les créanciers de la société scindée exposés à un changement de droit national applicable contre le risque légal qu'ils encourent, et plus précisément, contre les risques de nature procédurale tels qu'un arriéré judiciaire important[4076] ou encore le fait que les juridictions de l'État membre de destination aient pour pratique de laisser les frais de justice à charge du demandeur même en cas de décision favorable[4077]. En outre, un tel maintien de la compétence dans l'État membre d'origine permet, dans une certaine mesure, de limiter le phénomène d'apathie rationnelle des petits créanciers qui aurait risqué de s'amplifier en présence de l'obligation d'introduire une procédure à l'étranger, potentiellement avec un régime linguistique distinct.

791. Le droit suisse. La *perpetuatio fori* n'est toutefois pas l'apanage du seul Règlement sur la Société européenne et est susceptible de se retrouver également au sein de différents droits nationaux. Ainsi, en droit suisse, le régime des scissions et des fusions transfrontalières prévoit explicitement qu'en matière de protection des créanciers, le for suisse demeurera tant que les créanciers et les titulaires de parts n'auront pas été désintéressés ou que leurs créances

4071 Art. 8, § 16 du Règlement sur la Société européenne.

4072 Voir en ce sens : J. OECHSLER, « Die Sitzverlegung der Europäischen Aktiengesellschaft nach Art. 8 SE-VO », *AG*, 2005, p. 378 qui déduit cela d'une part de la faculté de révision de la *perpetuatio fori* figurant à l'art. 69, c) du Règlement sur la Société européenne et, d'autre part, d'une incohérence du régime qui prévoit que la *perpetuatio fori* s'éteint au moment de la date de prise d'effet interne du transfert de siège conformément à l'article 8, § 10 du Règlement sur la Société européenne et non au moment où le transfert de siège devient opposable aux tiers conformément à l'art. 8, § 13 du Règlement sur la Société européenne.

4073 Art. 8, §§ 10 et 16 du Règlement sur la Société européenne.

4074 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Europäischen Gesellschaft (SEEG), exposé des motifs, *BT-Drs.*, 2004, n° 15/3405, p. 35.

4075 Art. 4, § 1er et 63, § 1er du Règlement Bruxelles I*bis*.

4076 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7.

4077 *Ibidem*.

n'auront pas été garanties[4078]. Ce mécanisme permet ainsi aux créanciers de la société scindée suisse de ne pas être affectés par un éventuel changement de compétence juridictionnelle qui découlerait de l'opération tant que leurs droits n'auront pas été adéquatement protégés. Si le fait que l'extension de compétence cesse lorsque des garanties adéquates ont été attribuées a pu faire l'objet de certaines critiques en ce que cette protection de nature juridictionnelle aurait pu continuer à présenter un certain intérêt pour les créanciers concernés même après l'octroi d'une garantie adéquate[4079], il convient de relever que cette mesure est avant tout destinée à protéger les petits créanciers faisant preuve d'apathie rationnelle qui n'auront vraisemblablement pas pris soin de se prémunir contre les éventuels effets de la scission.

792. *Perpetuatio fori* et Directive Mobilité. Cette solution, qui avait été recommandée par le Parlement européen dans le cadre des travaux sur la proposition de quatorzième directive concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société[4080], s'est toutefois retrouvée sous une forme surprenante dans la Proposition de la Commission et ce, aussi bien pour les transformations transfrontalières[4081] que pour les fusions transfrontalières[4082] et les scissions transfrontalières[4083]. En effet, loin de prévoir une *perpetuatio fori* pour les créances dont l'origine était antérieure à l'opération comme on aurait pu s'y attendre, la Commission a fait du maintien de la compétence du for compétent préalablement à la réalisation de l'opération une des composantes de la présomption réfragable[4084] selon laquelle les créanciers de la société transformée, absorbée ou scindée sont présumés ne pas être lésés par l'opération lorsqu'ils se voient offrir un droit de paiement additionnel. En effet, pour que la présomption naisse, ce droit de paiement additionnel consenti soit à l'encontre d'un garant tiers, soit à l'encontre d'une des sociétés issues de l'opération, devra, cumulativement, être d'une valeur au moins équivalente à la créance initiale, être d'une qualité de crédit au moins comparable à la créance initiale et relever de la même juridiction que la créance initiale[4085]. Cette adaptation originale n'a toutefois pas survécu au Compromis de la Présidence qui a préféré revenir à une conception plus classique limitée aux seules transformations transfrontalières[4086]. Il est toutefois

4078 Art. 164a de la Loi suisse sur le droit international privé.

4079 Voir en ce sens : J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 359 et 360, n° 843.

4080 Recommandation 6, al. 2 de la Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société (2008/2196(INI)), P6_TA(2009)0086, 10 mars 2009.

4081 Art. 86*duodecies*, § 3, (b) de la Proposition de la Commission.

4082 Art. 126*ter*, § 3, (b) de la Proposition de la Commission.

4083 Art. 160*quaterdecies*, § 3 (b) de la Proposition de la Commission.

4084 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 33 et J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 843 ; I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 28 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 34 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 27 ; Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 5 et G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 15, n° 44. Voir également : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 861, n° 36 qui relève que le caractère réfragable des présomptions en question devrait apparaître dans le texte même de la Proposition de la Commission et pas uniquement dans les considérants.

4085 Art. 160*quaterdecies*, § 3 (b) de la Proposition de la Commission.

4086 Art. 86k, § 4 du Premier Compromis de la Présidence.

intéressant de relever que le Compromis de la Présidence a rejeté la solution qui aurait consisté à prévoir que la société transformée devait être considérée comme ayant son siège statutaire dans l'État membre d'origine pour tout litige naissant avant la transformation et ce, pour une durée de trois ans suivant la date de prise d'effet de l'opération pour un mécanisme plus modéré destiné à protéger exclusivement les créanciers titulaires d'une créance antérieure à la publication du projet de transformation et non encore échue au moment de cette publication et ce, toujours pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de l'opération[4087]. Souhaitant apparemment réduire encore davantage l'impact de ce mécanisme de protection, la Proposition du Parlement a ensuite encore réduit le délai d'action à deux ans à compter de la publication du projet de transformation[4088] et c'est ce dernier délai qui se retrouve dans le régime des transformations transfrontalières consacré par la Directive Mobilité[4089]. Il ressort ainsi de l'analyse de la Directive Mobilité que ce mécanisme, présent à l'origine sous une forme atypique et édulcorée, a fait sa réapparition au cours du processus législatif dans une forme plus similaire à celle existant dans le Règlement sur la Société européenne[4090], pour ensuite être de plus en plus réduit. C'est ainsi que la Directive Mobilité prévoit, bien qu'uniquement à l'égard des transformations transfrontalières[4091], que les créanciers disposant d'une créance antérieure à la publication du projet jouiront de la possibilité d'engager des poursuites dans l'État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date de prise d'effet de l'opération, ce for d'exception venant explicitement s'ajouter à ceux désignés par une clause attributive de juridiction ainsi que ceux désignés par le Règlement Bruxelles I*bis*[4092].

5.2. Les limites

793. Deux limites inhérentes. Si, de manière générale, la préservation de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine présente une certaine logique pour protéger les créanciers de la société scindée des risques liés justement à un changement de compétence juridictionnelle à la suite d'une scission transfrontalière, cette assertion se doit d'être fortement nuancée sous deux angles distincts. Le premier concerne le risque contre lequel la *perpetuatio fori* entend protéger les créanciers et le second, concerne la proportionnalité de la mesure.

794. Un mécanisme fréquemment superflu en cas de scissions transfrontalières. Si les risques liés à un changement de juridictions compétentes ont pu être mis en exergue par certains auteurs dans le cadre de l'étude des fusions transfrontalières[4093], force est de constater que dans un nombre important de

4087 Art. 86k, § 4 du Premier Compromis de la Présidence.
4088 Art. 85*duodecies*, § 4 de la Proposition du Parlement.
4089 Art. 86*undecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
4090 Art. 8, § 16 du Règlement sur la Société européenne.
4091 Art. 86*undecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
4092 24e considérant et art. 86*undecies*, § 4 de la Directive Mobilité. Voir à ce sujet : J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 585 qui considère que ce for additionnel s'ajoute même aux fors exclusifs du Règlement Bruxelles I*bis*.
4093 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7.

situations, les juridictions de l'État membre de la société scindée demeureront de toute façon compétentes[4094] et ce, indépendamment de la prise d'effet de l'opération transfrontalière. À titre d'illustration, on peut citer la compétence de la juridiction (i) du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en matière contractuelle[4095] et (ii) du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire en matière délictuelle ou quasi-délictuelle[4096]. Il s'ensuit que si on avait pu avancer que la *perpetuatio fori* présentait un intérêt pour les créanciers délictuels ne découvrant leur dommage que postérieurement à la réalisation de l'opération, les règles attributives de juridiction du Règlement Bruxelles I*bis* imposent de significativement nuancer cette considération. En effet, s'il est indéniable que la règle par défaut est que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre seront en principe attraites devant les juridictions de cet État membre[4097], les règles de compétence spéciales instaurées par le Règlement Bruxelles I*bis* permettent d'éluder cet inconvénient dans maintes situations[4098]. En outre, tant le Premier Compromis de la Présidence[4099] que la Proposition du Parlement[4100] et la Directive Mobilité[4101] précisent explicitement que le mécanisme de la *perpetuatio fori* s'applique sans préjudice des règles de compétence découlant d'un accord contractuel. Il s'ensuit que ce mécanisme sera sans intérêt pour tous les créanciers ayant pris soin d'assortir leur créance d'une clause d'*electio fori*, ce qui sera généralement le cas des banques et des grands créanciers[4102]. Certes, cette limite ne s'appliquera pas aux petits créanciers pour lesquels il a été défendu que ce mécanisme présentait un intérêt non négligeable[4103], mais on voit difficilement en quoi la *perpetuatio fori* permettrait de remédier de façon plus efficace à l'apathie rationnelle des petits créanciers que la possibilité de demander des garanties adéquates, de sorte que même ce dernier avantage se voit battu en brèche. Si on ajoute à ces différents éléments encore le fait que les procédures transfrontalières visant à obtenir le remboursement d'une créance sont loin d'être extraordinaires à l'heure actuelle[4104], que les évolutions technologiques ont permis de réduire sensiblement le coût de telles procédures[4105] et que le Règlement Bruxelles I*bis* garantit en outre aux créanciers d'une société soumise au droit d'un État membre la possibilité d'exiger le paiement de leur créance au travers toute l'Union européenne[4106], on en arrive à la conclusion que le risque contre lequel la *perpetuatio fori* entend prémunir les créanciers est, si pas inexistant, à tout le moins très limité au sein de l'Union européenne.

4094 Voir en ce sens : A. FRANCK, *op. cit.*, p. 204 et F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 34.
4095 Art. 7, § 1er, a) du Règlement Bruxelles I*bis*.
4096 Art. 7, § 1er, b) du Règlement Bruxelles I*bis*.
4097 Art. 4, § 1er du Règlement Bruxelles I*bis*.
4098 Art. 7 du Règlement Bruxelles I*bis*.
4099 Art. 86k, § 4 du Premier Compromis de la Présidence.
4100 Art. 86*duodecies*, § 4 de la Proposition du Parlement.
4101 Art. 86*undecies*, § 4 de la Directive Mobilité.
4102 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 60.
4103 Voir en ce sens : M. WINNER, *ibidem*, p. 60.
4104 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 808.
4105 Voir en ce sens : A. FRANCK, *op. cit.*, p. 204.
4106 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *op. cit.*, p. 843 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 19 et Chr. LOUVEN, « Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie », *op. cit.*, p. 2028.

795. Une mesure potentiellement disproportionnée. S'il a pu être avancé que perpétuer la compétence des juridictions de l'État de la société scindée était un moyen moins intrusif que de prévoir le passage d'un mécanisme de protection *ex post* en cas d'opération interne à un mécanisme de protection *ex ante* en cas d'opération transfrontalière[4107], force est de constater que ce régime demeure foncièrement plus intrusif que d'autres mécanismes de protection comme la possibilité de demander des garanties adéquates[4108]. En effet, le mécanisme de la *perpetuatio fori* présente la particularité d'intervenir indépendamment de l'existence d'un risque concret pour les créanciers, ce qui revient à considérer que le seul caractère transfrontalier de l'opération représente un risque pour les créanciers contre lequel il convient de les prémunir. Or, il est établi de longue date dans le cadre du mécanisme de protection des créanciers par le biais de l'octroi de garanties adéquates que le seul caractère transfrontalier de l'opération ne suffit pas à établir l'existence d'un risque concret justifiant l'octroi d'une garantie[4109]. Il s'ensuit que le maintien de la compétence des juridictions de l'État membre de la société scindée dans le cadre d'une scission transfrontalière encourt le risque d'être considéré comme une entrave disproportionnée à la liberté d'établissement de la société scindée.

796. Une mesure à bannir du régime des scissions transfrontalières. Il découle de ce qui précède qu'on ne peut que comprendre pourquoi cette mesure n'a été intégrée dans le régime des scissions transfrontalières ni par la Proposition de la Commission, ni par le Premier Compromis de la Présidence, ni encore par la Directive Mobilité. En outre, il convient de relever que l'argument selon lequel le législateur européen aurait choisi de réserver la *perpetuatio fori* aux seules transformations transfrontalières au motif que celles-ci sont exceptionnellement dangereuses pour les créanciers dans la mesure où la société dispose de la possibilité de changer de *lex societatis* sans procéder à un déplacement concomittant des actifs de la société[4110] ne tient pas la route car une scission transfrontalière permet d'aboutir exactement au même résultat tout en éclatant en plus le gage commun des créanciers[4111]. Ce mécanisme de protection, dont l'efficacité dans le cadre du régime de la société européenne a déjà été remise en cause par certains auteurs[4112] ainsi que par la Commission

4107 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : A. FRANCK, *op. cit.*, p. 198.

4108 *Contra* : J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 359, n° 843 qui considère qu'il s'agit là d' « une mesure de protection efficace et proportionnée ».

4109 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 275 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 9 ; R. FRENZEL *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 362 et 363 ; B. GRUNEWALD, *op. cit.*, p. 197 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 317 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 7 ; H.-W. NEYE et B. TIMM, « Mehr Mobilität für die GmbH in Europa – Das neue Recht der grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *GmbHR*, 2007, p. 564 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 330 et J. OECHSLER, « Die Richtlinie 2005/56/EG… », *op. cit.*, p. 165.

4110 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors », *op. cit.*, p. 60.

4111 Voir également : ECLE, *op. cit.*, p. 208 qui partent du principe que les transformations transfrontalières présentent moins de risques pour les créanciers dans la mesure où elles ne s'accompagnent ni d'une modification du patrimoine de la société débitrice, ni d'un agrandissement du cercle des créanciers.

4112 Voir J. OECHSLER, « Die Sitzverlegung der Europäischen Aktiengesellschaft nach Art. 8 SE-VO », *op. cit.*, p. 378 qui fait remarquer qu'en raison de l'obligation consacrée par l'art. 64 du Règlement

européenne dans le cadre de son étude sur l'application du Règlement sur la Société européenne[4113], n'a, en conséquence de ce qui précède, pas sa place dans un régime européen des scissions transfrontalières.

C. *Les autres moyens de protection prévus par les législateurs nationaux*

797. Plan du point C. Suite à ce tour d'horizon des principaux mécanismes de protection mis en place par le législateur européen, il convient encore de s'intéresser aux mécanismes de protection plus spécifiques qui ont pu être adoptés au sein de différents États membres. Parmi ceux-ci, l'action paulienne (1), le droit de veto (2), le contrôle par une autorité nationale (3), le droit d'opposition optionnel du droit français (4), la théorie de l'imprévision (5), la gestion séparée des patrimoines (6) et la responsabilité solidaire des membres de l'organe de gestion de la société scindée (7) feront successivement l'objet d'une étude détaillée.

1. *L'action paulienne*

1.1. Le principe

798. Définition et effets. Alors qu'en principe un débiteur demeure libre de gérer son patrimoine comme bon lui semble, y compris lorsqu'il en résulte son propre appauvrissement[4114], les créanciers disposent d'une action visant à les protéger explicitement des actes commis en fraude de leurs droits et existant dans de nombreux États membres[4115]. Cette action, dénommée action paulienne, remonte au droit au romain[4116] et est issue de la fusion par Justinien de la *restitutio in integrum ob fraudem creditorum*, de l'interdit fraudatoire et

sur la Société européenne de transférer concomitamment son administration centrale et son siège statutaire, tout transfert de siège entraînera nécessairement un transfert de patrimoine vers l'étranger contre lequel la fiction juridique s'avérera impuissante. Voir également : H.-J. PRIESTER, « EU-Sitzverlegung – Verfahrensablauf », *ZGR*, 1999, pp. 43 et 44.

4113 Selon la Commission européenne, « [o]n peut également se demander si cette règle apporte quoi que ce soit aux règles de compétence existantes prévues dans le Règlement Bruxelles I, qui permettent déjà de saisir les tribunaux de l'État membre dans lequel, par exemple, un contrat est exécuté, ou un préjudice causé ou subi ». Voir Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), (COM(2010) 676 final – SEC(2010) 1391), 17 novembre 2010, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (25/10/2019), pp. 9 et 10.

4114 R. LIBCHABER, « Les équilibres propres à l'action paulienne », *RDC*, 2019/1, p. 54, n° 3 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 942, n° 935.

4115 Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790, pt. 2 et Av. gén. M. D. R.-J. COLOMER, concl. préc. C.J., arrêt *Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH c. Deko Marty Belgium NV*, 16 octobre 2008, C-339/07, EU:C:2008:575, pt. 26. À titre d'illustration, on peut citer l'art. 1167 du Code civil en droit belge, l'art. 1167 du Code civil en droit luxembourgeois ; l'article 1341-2 du Code civil en droit français et l'art. 2901 du *Codice civile* en droit italien.

4116 Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790, pt. 1.

de *l'exceptio fraudis*[4117]. Sa dénomination originale a longtemps été attribuée au préteur Paulus, inconnu à ce jour, mais est plus vraisemblablement issue de la glose byzantine[4118]. Si les contours de cette action en droit romain sont mal connus[4119], il est bien établi que l'action actuelle est destinée à permettre à un créancier insatisfait d'obtenir que les actes du débiteur lui soient déclarés inopposables[4120], ce qui permet de préserver le patrimoine de ce dernier en vue du paiement de sa dette[4121] puisque le créancier qui sera parvenu à établir la fraude paulienne bénéficiera d'un droit de préférence sur les biens transférés par la société scindée[4122]. En d'autres termes, ce mécanisme de protection permet à un créancier de sauvegarder ses droits, sans toutefois prohiber purement et simplement l'opération à l'instar d'un droit de veto, ni remettre en cause la validité de l'opération en tant que telle[4123]. Il s'agit d'un mécanisme de protection relevant du droit général des obligations qui constitue une application particulière du principe général de droit « *fraus omnia corrumpit* »[4124] et qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection du créancier. Il est intéressant de relever qu'en droit belge, avant l'adoption de la loi du 29 juin 1993[4125] ayant transposé la Sixième Directive, les droits des créanciers en cas de scission étaient essentiellement préservés par le biais de la possibilité qui leur était laissée de recourir à l'action paulienne[4126]. Cependant, même après la transposition de la Sixième Directive, les auteurs s'accordent à dire que la procédure de constitution d'une sûreté prévue dans le régime spécifique des scissions internes ne prive pas les créanciers de la possibilité de recourir à l'action paulienne[4127] et ce, malgré la disparition du

4117 W. DROSS, « ART. 1341-2 – Fasc. unique : Régime général des obligations », *Juris-Classeur Code civil*, 1er novembre 2016, n° 3.

4118 *Ibidem*.

4119 *Ibidem*.

4120 S. NOTARNICOLA, « À propos de l'action paulienne : quand le créancier poursuit la condemnation du tiers acquéreur au paiement des sommes dues par le débiteur indélicat », note sous Anvers, 3 janvier 2005, *R.G.D.C.*, 2008, pp. 169 et 170 ; R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 128, n° 141 ; Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 327, n° 485M ; P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, pp. 542 et 543 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 942, n° 935.

4121 P. WÉRY, *ibidem*, p. 872, n° 935. Voir également : C.J., arrêt *Feniks sp. z o.o. c. Azteca Products & Services SL*, 4 octobre 2018, C-337/17, EU:C:2018:805, pt. 40 où la Cour de justice a considéré que « [l]'action paulienne trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier à l'égard de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second ».

4122 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 331, n° 492.

4123 Avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1993, il était considéré en droit belge, qu'un créancier disposait de la possibilité de faire annuler une fusion ou une scission réalisée en fraude de ses droits. Voir : A. DELAHAYE, « La scission d'une société », *RPS*, 1985, p. 141 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 327, n° 487 et Cass., 5 juin 1902, *Pas.*, 1902, I, p. 264.

4124 P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, p. 2201, n° 1530 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, p. 554, n° 608.

4125 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 25.

4126 A. DELAHAYE, « La scission d'une société », *RPS*, 1985, p. 145, n° 16 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 327, n° 487 et Bruxelles, 4e ch., 11 octobre 1999, n° 6804, *RPS*, 2000/2, pp. 151 et 152, n° 2.

4127 G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 72 ; Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1233, n° 70 ; D. GIBRILA et H. AZARIAN, « Fasc. 1109 : Sociétés. – Transformation, fusion, scission et prorogation de la société », *Juris-Classeur Commercial*,

débiteur en cours d'opération[4128]. Cette position, partagée également en droit français[4129], se retrouve aussi dans les travaux préparatoires belges de la loi du 29 juin 1993 ayant transposé la Sixième Directive[4130] et, en droit allemand, les hypothèses de transmission universelle sont explicitement couvertes par la législation sur l'action paulienne[4131]. Cependant, le recours à l'action paulienne en matière de scissions ne semble pas pour autant évident car « sa mise en œuvre concurrence les instruments dédiés de protection des créanciers prévus par le droit de l'Union, et semble pouvoir, dans une certaine mesure, remettre en cause la pérennité d'une opération de restructuration déjà effective »[4132].

799. Illustration de l'intérêt de l'action paulienne pour les scissions : les faits à l'origine de l'arrêt *I.G.I. Srl.* De prime abord, il peut paraître surprenant de se pencher sur un mécanisme de protection des intérêts des créanciers relevant du droit général des obligations alors que lors de la transposition des dispositions de la Sixième Directive, les États membres ont instauré des mécanismes de protection des créanciers particuliers tenant compte des spécificités de ce type d'opérations. Pour le comprendre, il est utile de se pencher sur les faits à l'origine de la question préjudicielle de la *Corte di appello di Napoli*[4133] dans l'*arrêt I.G.I. Srl*[4134]. Dans cette affaire, la société de droit italien Construzioni Ing. Iandolo Srl avait, à la suite d'une scission partielle, transféré une fraction de son patrimoine à la société I.G.I. Srl. Cette opération ne s'est pas avérée être du goût des créanciers de la société scindée et ceux-ci ont estimé que l'opération avait sérieusement érodé le patrimoine de leur débitrice. Ne recourant pas au droit d'opposition que les créanciers sont en droit d'exercer dans un délai de soixante jours à compter de la dernière inscription de la décision au registre

1er septembre 2018, n° 98 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n° 848 et Th. TILQUIN, *ibidem*, p. 333, n° 496. Voir également en droit belge : F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 206, n° 39 qui envisagent spécifiquement l'application de l'action paulienne pour sanctionner une répartition frauduleuse du passif de la société scindée.

4128 Voir en ce sens en droit français : R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 120, n° 131.

4129 Voir en ce sens : W. DROSS, *op. cit.*, n° 89 ; D. GIBRILA et H. AZARIAN, « Fasc. 1109 : Sociétés. – Transformation, fusion, scission et prorogation de la société », *Juris-Classeur Commercial*, 1er septembre 2018, n° 98 ; T. V.-N. NGUYEN, *La protection des créanciers sociaux dans les opérations emportant transmission universelle de patrimoine,* thèse, Paris II, 2003, pp. 109 à 116, nos 144 à 155 ; R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 119, n° 128 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 425, n° 996.

4130 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 25.

4131 § 15 AnfG et à ce sujet : L. HAERTLEIN in J. KINDL, C. MELLER-HANNICH et H.-J. WOLF (dir.), *Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung*, 3e éd., Baden-Baden, Nomos, 2015, § 15, n° 7.

4132 Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790, pt. 4.

4133 Arrêt *I.G.I. Srl*, pts 25 à 37.

4134 Au sujet de cet arrêt, voir : H. HECKSCHEN, « Gläubigerschutz bei Spaltungen », *GWR*, 2020, p. 175 ; N. DE NICOLA, « Actio pauliana and divisions (IGI v. Cicenia, C-394/18): not everything that is done, is well done », *ECLJ*, 2020, vol. 17, issue 3, pp. 97–101 ; J. SCHMIDT, « Die Entscheidung des EuGH in der Rs. I.G.I. », *EuZW*, 2020, pp. 372–374 ; P. SCHULTZ, « Zur Anfechtung (actio pauliana) der Spaltung einer Gesellschaft durch ihre Gläubiger mit dem Ziel der Unwirksamerklärung der Spaltung ihnen gegenüber („I.G.I.") », *EWiR*, 2020, pp. 357 et 358 et S. STIEGLER, Gläubigeranfechtung und Spaltungsrecht – Zugleich Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 30.1.2020 – C-394/18, GmbHR 2020, 418 », *GmbHR*, 2020, pp. 405–411.

des entreprises[4135], ceux-ci ont intenté une action paulienne pour laquelle un délai de prescription quinquennal courant à compter de l'accomplissement de l'acte trouve à s'appliquer[4136]. Ayant obtenu gain de cause en premier instance, le transfert des biens résultant de la scission a été déclaré sans effet à leur égard. Les sociétés issues de l'opération ont ensuite interjeté appel au motif que l'opposition prévue spécifiquement dans le régime des scissions et des fusions était la seule voie de droit que les créanciers pouvaient exercer pour protéger leurs droits. La juridiction de renvoi, relevant qu'un des objectifs de la Sixième Directive est de garantir la sécurité juridique, fut d'avis que le régime de protection mis en place par cette même directive pouvait être interprété comme excluant l'exercice de toute autre voie de recours visant le même objectif si les créanciers n'ont pas fait usage des moyens de protection spécifiquement prévus. En outre, si l'action paulienne devait être considérée comme entraînant une nullité au sens de la Sixième Directive, la limitation du régime des nullités telle que prévue dans la Sixième Directive pourrait impliquer que l'action paulienne ne pourrait plus être exercée une fois que la scission aura pris effet. Cependant, une telle exclusion ne ressort pas clairement du texte de la Sixième Directive et, en droit interne italien, il existe des différences entre une action en nullité et une action paulienne. Sur la base de ces considérations, la *Corte di appello di Napoli* a préféré surseoir à statuer et interroger la Cour de justice sur l'articulation entre l'action paulienne et le régime de protection des créanciers prévu par la Sixième Directive, ainsi que sur l'interprétation de la notion de nullité au sens de la Sixième Directive[4137]. À l'égard de la première question préjudicielle, la Cour de justice, suivant en cela l'avis de l'avocat général Szpunar[4138], en se fondant sur le fait que la Sixième Directive n'a procédé qu'à une harmonisation *a minima* de la protection des créanciers[4139] et rappelant que la Sixième Directive ne s'oppose pas à une protection des créanciers de la société scindée différente de celle des créanciers des sociétés bénéficiaires[4140], a considéré que rien ne s'opposait à ce qu'un État membre maintienne la protection générale des créanciers conférée par l'action paulienne en plus des régimes de protection spécifiques applicables en cas de scission[4141]. En outre, suivant en cela à nouveau l'avis de

4135 Art. 2503 et 2506*ter* du *Codice civile* italien.

4136 Art. 2903 du *Codice civile* italien.

4137 Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790, pt. 34 et arrêt *I.G.I. Srl*, pt. 37.

4138 Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790, pt. 70.

4139 Arrêt *I.G.I. Srl*, pt. 67.

4140 Arrêt *I.G.I. Srl*, pt. 73.

4141 Arrêt *I.G.I. Srl*, pt. 75 où la Cour de justice a considéré qu' « [e]u égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 12 de la sixième directive, lu en combinaison avec les articles 21 et 22 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, après la réalisation d'une scission, les créanciers de la société scindée, dont les droits sont antérieurs à cette scission et qui n'ont pas fait usage des instruments de protection des créanciers prévus par la réglementation nationale en application dudit article 12, puissent intenter une action paulienne afin de faire déclarer que ladite scission ne produit pas d'effets à leur égard et de former des actions exécutoires ou conservatoires sur les biens transférés à la société nouvellement constituée ».

l'avocat général Szpunar[4142], elle a considéré que le régime strict des nullités de la scission consacré par la Sixième Directive ne s'oppose pas à l'introduction d'une action paulienne en ce que cette dernière entraîne une inopposabilité et non une nullité[4143].

800. L'incidence des aspects temporels. Contrairement aux mécanismes de protection des créanciers institués dans le cadre des scissions qui sont généralement soumis à des délais d'action très courts[4144], l'action paulienne présente l'indéniable avantage de bénéficier de délais de prescription relativement longs. Ainsi, à titre d'illustration, en droit autrichien, le délai pour intenter l'action paulienne est de dix ans en cas de collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur[4145], de deux ans lorsque le tiers acquéreur aurait dû avoir connaissance de l'intention frauduleuse du débiteur[4146] et de deux ans si le tiers acquéreur est une personne proche du débiteur, indépendamment de la connaissance de toute intention frauduleuse[4147]. En droit belge, qui présente l'intérêt de connaître un régime spécifique des scissions transfrontalières[4148], les créanciers de la société scindée disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la scission pour exiger une sûreté[4149], alors que l'action paulienne, que la Cour de cassation belge a fait le choix de rattacher à la matière extracontractuelle[4150], bien qu'il semble plus opportun d'y voir une action de fraude fondée sur le principe général « *fraus omnia corrumpit* »[4151], se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable[4152] et, en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où le fait qui a causé le dommage s'est produit[4153]. Il s'ensuit que l'action paulienne présente un intérêt non négligeable pour tous les créanciers ayant omis d'exercer les mécanismes

4142 Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790, pt. 80.

4143 Arrêt *I.G.I. Srl*, pt. 88 où la Cour de justice a considéré que « l'article 19 de la sixième directive, lu en combinaison avec les articles 21 et 22 de cette directive, qui prévoit le régime des nullités de la scission, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'introduction, après la réalisation d'une scission, par des créanciers de la société scindée, d'une action paulienne qui ne porte pas atteinte à la validité de cette scission, mais permet seulement de rendre celle-ci inopposable à ces créanciers ».

4144 À ce sujet, voir *infra* n°s 907 à 909.

4145 § 2(1) AnfO.

4146 § 2(2) AnfO.

4147 § 2(3) AnfO.

4148 Art. 12:73 et 12:90 du CSA.

4149 Art. 12:15 du CSA.

4150 Cass., 26 avril 2013, *Pas.*, 2012/4, p. 925. Voir à ce sujet : C. ALTER, S. BAR et F. ROZENBERG, « Les effets du contrat », *Obligations. Traité théorique et pratique*, Bruxelles, Kluwer, septembre 2005, II.1.7 -157 ; P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, p. 542, n° 591 et P. WÉRY, « L'action paulienne, sa nature juridique et ses rapports avec la réparation en nature en matière extra-contractuelle », note sous Cass., 26 avril 2013, *R.C.J.B.*, 2015/1, pp. 66–102. Voir également au sujet de l'action paulienne prévue en cas de faillite : Cass., 25 janvier 2013, *Pas.*, 2013/1, p. 238.

4151 Voir en ce sens : P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 946, n° 937 qui y abandonne la conception qu'il défendait dans la deuxième édition du même ouvrage.

4152 Art. 2262*bis*, § 1er, al. 2 du Cod. civ. belge.

4153 Art. 2262*bis*, § 1er, al. 3 du Cod. civ. belge.

de protection spécifiques du régime des scissions destinés à protéger leurs intérêts dans les délais imposés par la loi[4154].

801. Les conditions de l'action paulienne. Le caractère proportionné de l'action paulienne se retrouve également au niveau des nombreuses conditions qui s'imposent au créancier souhaitant intenter celle-ci. Pour pouvoir apprécier tant le caractère adéquat que proportionné de l'action paulienne, il est utile d'analyser chacune des cinq conditions à la lumière des spécificités d'une scission transfrontalière et ce, en se concentrant sur la situation des créanciers les plus vulnérables, à savoir ceux de la société scindée[4155] :

- premièrement, comme l'action paulienne doit être considérée comme une mesure exécutoire[4156], seuls les titulaires d'une créance née à tout le moins dans son principe au moment où l'acte frauduleux est posé et exigible au moment où l'action est intentée pourront se prévaloir de l'action paulienne[4157], excluant de ce fait les créanciers sous condition suspensive et à terme[4158][4159]. Dans le cas particulier de l'étude des scissions transfrontalières, la date charnière sera par conséquent la date de prise d'effet de l'opération[4160] et non la date à laquelle l'assemblée générale de la société débitrice se prononce sur l'opération puisque cette dernière ne suffit pas, à elle seule, à réaliser l'opération et, partant, à matérialiser la fraude. On constate d'emblée que les bénéficiaires de l'action paulienne seront nécessairement moins nombreux que ceux disposant de la possibilité de demander des garanties. En effet, pour ce dernier mécanisme de protection, on constate tant en droit belge[4161] qu'en droit luxembourgeois[4162], qu'il n'est pas nécessaire que la créance soit exigible pour pouvoir introduire une action judiciaire ;
- deuxièmement, il faut un appauvrissement du débiteur résultant d'un acte juridique[4163]. Dans le cadre d'une scission transfrontalière, qui constitue un acte juridique[4164], la preuve de cet appauvrissement devrait être plus

4154 Voir en ce sens : B. LECOURT, « De l'utilité de l'action paulienne en droit des sociétés », *Aspects actuels du droit des affaires. Mélanges en l'honneur de Yves Guyon*, Dalloz, Paris, 2003, p. 628 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 431, n°s 1008 et 1009.

4155 Au sujet de la position plus défavorable des créanciers de la société scindée : Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 52 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 51.

4156 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 533, n° 580. *Contra* : P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, p. 2206, n° 1535.

4157 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 126, n° 137 ; P. VAN OMMESLAGHE, *ibidem*, p. 2206, n° 1535 ; P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, pp. 943 et 944, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *Rép. not.*, Tome IV, Les obligations, Livre 1/1, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 925, n° 936 et Cass., 20 mars 2008, *Pas.*, 2008, p. 776 et Cass., 5 janvier 2006, *Pas.*, 2006, p. 48.

4158 P. WÉRY, *ibidem*, pp. 943 et 944, n° 936 et P. WÉRY, *ibidem*, pp. 925, n° 936.

4159 Cette exclusion des créanciers à terme ne fait toutefois pas l'unanimité au sein des États membres connaissant l'action paulienne puisque l'art. 2901 du *Codice civile* italien précise explicitement que l'action paulienne est également ouverte aux créanciers titulaires d'une créance conditionnelle ou à terme.

4160 Voir en ce sens : T.-V.-N. NGUYEN, *op. cit.*, p. 102, n° 133.

4161 Art. 12:15, § 1er, al. 1er du CSA.

4162 Art. 1031-10 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

4163 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 944, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 926, n° 936.

4164 Sur la nature juridique de la scission transfrontalière, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 3.

simple à apporter que dans le cas d'une fusion ou d'une transformation transfrontalière puisque par définition, la scission implique un fractionnement du patrimoine de la société scindée[4165]. Il convient toutefois encore de préciser que, comme l'éclatement du patrimoine inhérent à une scission a été consacré par la Sixième Directive, l'appauvrissement devra principalement être recherché dans la répartition inégale des actifs et passifs de la société scindée entre les sociétés bénéficiaires[4166]. Il est en outre intéressant de relever que les évolutions de l'action paulienne ont permis d'inclure dans la notion d'appauvrissement, les actes de transformation altérant le patrimoine du débiteur de façon à compliquer le recouvrement d'une créance[4167], ce qui se rapproche de très près des effets d'une scission. Par ailleurs, la preuve de l'appauvrissement du débiteur sera particulièrement aisée en cas de scission partielle transfrontalière puisque dans cette hypothèse particulière, l'opération revient dans les faits à amputer une partie du patrimoine de la société débitrice[4168] ;

- troisièmement, l'acte frauduleux commis par le débiteur doit être préjudiciable au créancier[4169]. La preuve de ce préjudice, qui s'apprécie à l'aune de la situation qui aurait été celle du créancier si l'acte frauduleux n'avait pas été posé[4170], pourrait s'avérer beaucoup plus délicate à rapporter en pratique. Certes, une scission présente un nombre considérable de risques pour les créanciers susceptibles de détériorer leur situation[4171], mais dans de nombreux cas, il s'agit également d'une décision économiquement rationnelle destinée à assainir la situation financière d'une société[4172] et par ricochet, de profiter à terme aux créanciers. Il est donc malaisé de juger du caractère préjudiciable d'une scission transfrontalière sans risquer de porter un jugement d'opportunité économique sur l'opération ;
- quatrièmement, il faut que le débiteur ait posé son acte juridique en fraude des droits de son créancier, c'est-à-dire en étant conscient que par cet acte, son créancier allait être préjudicié, sans qu'une intention de nuire ne soit requise pour autant[4173]. Cette condition de fraude est remplie à partir du moment où l' « acte litigieux a un caractère anormal et que

4165 Voir en ce sens : Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 331, n° 492.
4166 Voir en ce sens : Th. TILQUIN, *ibidem*, p. 331, n° 492.
4167 Voir en droit français : R. LIBCHABER, *op. cit.*, p. 54, n° 3. Voir en droit belge : W. DROSS, *op. cit.*, n° 44 ; P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, p. 2202, n° 1531 ; P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 874, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 926, n° 936.
4168 Voir en ce sens à propos de l'apport partiel d'actifs soumis au régime de la scission : R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 120 et 121, n° 132.
4169 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 944, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 926, n° 936.
4170 P. WÉRY, *ibidem*, p. 944, n° 936 et P. WÉRY, *ibidem*, p. 926, n° 936.
4171 À ce sujet, voir *supra* n°s 696 à 704.
4172 Sur l'utilité économique des scissions, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2.
4173 P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, pp. 2209 et 2210, n° 1537 ; P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 944, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 926, n° 936.

le débiteur savait qu'il causerait ainsi un préjudice à ses créanciers »[4174]. L'ignorance fautive par le débiteur du préjudice qu'il cause à ses créanciers est en outre assimilée à la situation dans laquelle le débiteur pose l'acte litigieux en pleine connaissance de cause[4175]. À nouveau, cette condition s'avérera difficile à remplir en pratique[4176] car même si une scission constitue indéniablement un acte de restructuration lourd de conséquences, elle n'en est pas pour autant une opération économique et juridique anormale. En outre, cette preuve de fraude sera d'autant plus difficile à rapporter en présence d'un rapport d'expert indépendant sur l'opération[4177] dans la mesure où l'intervention de ce « *gatekeeper* » est avant tout destinée à empêcher de telles fraudes[4178]. S'il a certes pu être avancé que le caractère frauduleux serait établi si l'opération n'était pas justifiée d'un point de vue économique[4179], il est difficile d'imaginer un juge se hasarder à de telles considérations en pratique. De même, si la preuve d'une fraude sera plus aisée à apporter si la scission ne se fait pas dans le respect de l'intégrité de chaque branche d'activités[4180], une telle répartition ne sera pas suffisante à elle seule ; et

- cinquièmement, le tiers doit être complice de la fraude du débiteur[4181], c'est-à-dire qu'il savait ou aurait dû savoir que l'acte juridique litigieux serait préjudiciable au créancier[4182], sauf si l'acte juridique posé par le débiteur est un acte gratuit[4183]. En toute logique, en cas d'acte juridique unilatéral, comme la scission par constitution de nouvelles sociétés[4184], cette condition n'est pas non plus requise[4185]. Cette dernière condition ne devrait, pour sa part, pas être trop délicate à établir en raison des nombreux documents et échanges d'informations qui jalonnent le processus de scission et qui font que les autres parties à l'opération, en dehors des cas où certaines informations auraient été volontairement dissimulées, ne pourront que difficilement passer à côté d'une fraude.

Il ressort de l'étude de ces différentes conditions à travers le prisme d'une scission transfrontalière que celles-ci ne seront pas simples à remplir, *a fortiori*

4174 Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 327, n° 485 et Cass., 26 octobre 1989, *Pas.*, 1990, I, n° 125, p. 248 ; Cass., 11 janvier 1988, *Pas.*, 1988, I., n° 286, p. 558 et Bruxelles, 4e ch., 11 octobre 1999, n° 6804, *RPS*, 2000/2, p. 152, n° 3.

4175 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, p. 359, n° 585.

4176 Voir en ce sens à propos des opérations emportant transmission universelle de patrimoine : R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 126 et 127, n° 139.

4177 Pour un cas d'espèce où la Cour se réfère directement au rapport établi par un réviseur d'entreprise agréé pour rejeter le caractère frauduleux d'une scission : Bruxelles, 4e ch., 11 octobre 1999, n° 6804, *RPS*, 2000/2, p. 153, n° 3.

4178 Sur le rôle de l'expert indépendant dans le cadre d'une scission transfrontalière, voir *supra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Section 5.

4179 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 127, n° 139.

4180 R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 129.

4181 P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, pp. 2212 et 2213, n° 1538 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, p. 540, n° 587 ; P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, pp. 944 et 945, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 926, n° 936.

4182 P. WÉRY, *ibidem*, p. 540, n° 587.

4183 P. WÉRY, *ibidem*, pp. 540 et 541, n° 588 ; P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, pp. 944 et 945, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 926, n° 936.

4184 À ce sujet, voir *supra* nos 823 à 831.

4185 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 127, n° 140.

si on les compare à celles applicables à d'autres mécanismes de protection tels que la possibilité de demander des garanties[4186] ou la solidarité de principe des sociétés bénéficiaires[4187]. Malgré cela, lorsque les mécanismes de protection spécifiques des créanciers figurant dans le régime des scissions sont affectés de conditions très strictes nuisant à leur efficacité, comme c'est le cas du droit d'opposition consacré par le Code de commerce français[4188], l'action paulienne conservera un attrait indéniable[4189].

802. Action paulienne et droit international privé. Si les conditions de l'action paulienne semblent déjà délicates à remplir dans l'ordre purement interne, il convient de relever encore que l'action paulienne suscite certaines difficultés additionnelles dans un contexte transfrontalier en raison de l'inexistence d'un contrat entre le créancier et le tiers-complice[4190]. Ces difficultés sont parfaitement illustrées par les faits à l'origine de l'arrêt *Feniks*[4191]. Dans cette affaire, la société de droit polonais Feniks avait conclu un contrat de travaux de construction avec la société de droit polonais Coliseum en lien avec un projet d'investissement immobilier situé à Gdansk. Pour exécuter ce contrat, Coliseum a eu recours à un certain nombre de sous-traitants mais a omis de payer une partie de ceux-ci. En application des dispositions du Code civil polonais en matière de responsabilité solidaire de l'investisseur, Feniks a ainsi été contrainte de payer ces sous-traitants et est ainsi devenue *de facto* créancière de Coliseum. Cependant, Coliseum s'est débarrassée de son principal actif, un immeuble situé en Pologne, en cédant celui-ci à Azteca, une société de droit espagnol tout en procédant à une compensation entre le prix de cession et des créances antérieures détenues par Azteca à l'encontre de Coliseum. Il est utile de préciser qu'au moment de l'opération litigieuse, le président de l'organe de gestion de Coliseum était également le représentant de la personne morale étant l'unique membre de l'organe de gestion d'Azteca. Feniks a ensuite tenté de faire déclarer la vente en question inopposable à son égard en application des dispositions polonaises sur l'action paulienne et, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, s'est fondée sur l'art. 7, point 1, sous a) du Règlement Bruxelles I*bis* qui prévoit qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée

4186 À ce sujet, voir *supra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 2, B, 3.

4187 À ce sujet, voir *supra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 2, B, 4.

4188 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 2, C, 4.

4189 B. LECOURT, « Adoption de la directive sur les fusions transcommunautaires », *Rev. Soc.*, 2005, p. 923, disponible sur www.dalloz.fr (06/12/2019), p. 3 ; B. LECOURT, « L'avenir du droit français des sociétés », *Rev. Soc.*, 2004, p. 223, disponible sur www.dalloz.fr (06/12/2019), p. 4, n° 18 et B. LECOURT, « De l'utilité de l'action paulienne en droit des sociétés », *op. cit.*, p. 615.

4190 Pour une étude des différentes théories relatives au rattachement de l'action paulienne avant l'arrêt *Feniks*, voir J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 433, n°s 1013 et 1014.

4191 C.J., arrêt *Feniks sp. z o.o. c. Azteca Products & Services SL*, 4 octobre 2018, C-337/17, EU:C:2018:805 (ci-après l' « **arrêt *Feniks*** »). Voir à ce sujet : G. CROISANT, « Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 10/07/2019 », *RDC-TBH*, 2019/5, p. 701 ; B. HAFTEL, « Revirement et extension du champ de la « matière contractuelle » dans les relations à trois personnes », *RDC*, 2019/1, pp. 85–89 ; J. HOFFMANN, « Gläubigeranfechtungsklagen und Zuständigkeit nach Angabe der EuGVVO – Anmerkung zu EuGH, Urt. V. 4.10.2018 – C-337/17- Feniks », *GPR*, 2019, pp. 168–173 ; R. JAFFERALI, « Arrêt « Feniks » : action paulienne et compétence internationale à la lumière du règlement Bruxelles I*bis* », *J.D.E.*, 2019, pp. 252 et 253 ; C. KLEINER, « L'action paulienne peut relever du for contractuel », *Gaz. Pal.*, 19 février 2019, n° 7, pp. 77 et 78 ; R. LIBCHABER, *op. cit.*, pp. 53–55 ; T. LUTZI, *op. cit.*, pp. 252–258 et Al. TENENBAUM, « Action paulienne et détachement des travailleurs : nouveautés jurisprudentielle et législative », *RDC*, 2019/1, pp. 154–158.

sur le territoire d'un État membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, pour assigner Azteca devant les juridictions polonaises. Cette compétence a été contestée par Azteca qui considérait au contraire que seules les juridictions espagnoles étaient compétentes en application de la règle générale de l'art. 4 du Règlement Bruxelles I*bis* selon laquelle les juridictions de l'État membre du domicile du défendeur sont compétentes, en raison du fait que l'action paulienne ne pouvait être qualifiée de relevant de la matière contractuelle au sens de l'art. 7, point 1, sous a) du Règlement Bruxelles I*bis*. Face à cette situation, le tribunal régional polonais a préféré interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur la question de savoir si une action paulienne constituait ou non un litige « *en matière contractuelle* » au sens du Règlement Bruxelles I*bis*[4192]. Rappelant tout d'abord que les règles de compétence spéciale du Règlement Bruxelles I*bis* sont d'interprétation stricte[4193] et que la notion de « *matière contractuelle* » doit faire l'objet d'une interprétation autonome[4194], la Cour a considéré que l'action paulienne trouvait son fondement dans le droit de créance détenu par le créancier à l'encontre de son débiteur[4195] et que la cause de cette action réside « essentiellement, dans la méconnaissance des obligations que le débiteur a consenties à l'égard du créancier »[4196]. Il s'ensuit qu' « une action paulienne, par laquelle le titulaire d'un droit de créance issu d'un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l'acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l'article 7, point 1, sous a » du Règlement Bruxelles I*bis*[4197]. Cette jurisprudence inattendue[4198], confirmée par la suite par la Cour de justice dans l'arrêt *Reitbauer*[4199], a fait l'objet d'un certain nombre de critiques en doctrine en raison (i) du choix de la Cour de rattacher l'action paulienne au contrat initial entre le créancier et le débiteur dans la mesure où le tiers n'y est pas partie et n'a, de prime abord, ni prévu, ni accepté l'éventualité d'une action paulienne[4200] et (ii) de la cohérence

4192 Arrêt *Feniks*, pts. 14–26.
4193 Arrêt *Feniks*, pt. 37.
4194 Arrêt *Feniks*, pt. 38.
4195 Arrêt *Feniks*, pt. 40.
4196 Arrêt *Feniks*, pt. 43.
4197 Arrêt *Feniks*, pt. 49.
4198 Voir également : B. HAFTEL, *op. cit.*, p. 85 qui parle d'un véritable revirement de jurisprudence de la Cour de justice par rapport à la conception stricte de la « matière contractuelle » prônée dans l'arrêt *Handte*.
4199 C.J., arrêt *Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egge, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH c. Enrico Casamassima*, 10 juillet 2019, C-722/17, EU:C:2019:577 (ci-après l' « **arrêt *Reitbauer*** »), pt. 61 où la Cour a considéré qu' « [i]l serait, par conséquent, loisible aux titulaires de droits de créance issus d'un contrat d'introduire une action paulienne devant la juridiction du « lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande », ce for étant celui qui est autorisé en vertu de l'article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 ». Voir à ce sujet : G. CROISANT, *op. cit.*, p. 701.
4200 Voir en ce sens : G. CROISANT, *ibidem*, p. 701 ; B. HAFTEL, *op. cit.*, pp. 88 et 89 ; J. HOFFMANN, « Gläubigeranfechtungsklagen und Zuständigkeit nach Angabe der EuGVVO – Anmerkung zu EuGH, Urt. V. 4.10.2018 – C-337/17- Feniks », *op. cit.*, p. 170 ; R. JAFFERALI, *op. cit.*, p. 253, n° 7 ; R. LIBCHABER, *op. cit.*, pp. 53 et 54, n° 2 et T. LUTZI, *op. cit.*, p. 256.

avec sa jurisprudence antérieure[4201] et, plus précisément, l'arrêt *Handte* où elle avait jugé que l'action directe exercée par le sous-acquéreur d'une chose contre le fabricant, ne relevait pas de la matière contractuelle[4202], laquelle « ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre »[4203]. À l'égard de l'étude des scissions transfrontalières, cette jurisprudence présente néanmoins un intérêt non négligeable en ce qu'elle renforce l'attrait de l'action paulienne comme mécanisme de protection des créanciers. En effet, le créancier lésé victime d'une fraude paulienne réalisée par le biais d'une scission transfrontalière aura ainsi la possibilité d'agir devant les juridictions du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle conclue avec la société scindée, ce qui sera dans un nombre considérable de cas l'État membre de la société scindée. En d'autres termes, le rattachement à la matière contractuelle opéré par la Cour de justice dans les arrêts *Feniks* et *Reitbauer* permet à un créancier d'éviter l'aléa lié au fait de devoir agir devant des juridictions étrangères soumises à des règles procédurales différentes ou potentiellement moins favorables au demandeur. En outre, cette règle de rattachement présente deux avantages additionnels. Tout d'abord, comme en l'absence d'un droit de veto[4204], le choix de la ou des sociétés bénéficiaires échappe à tout contrôle des créanciers, prévoir la compétence exclusive des juridictions du domicile du défendeur aurait tout simplement permis aux associés d'opter pour le for de leur choix par le biais de l'élection du domicile des sociétés bénéficiaires. Ensuite, contrairement à l'archétype de la fraude paulienne qui envisage la situation où il n'y a qu'un tiers complice, une scission transfrontalière, en dehors de l'hypothèse particulière de la scission partielle, se caractérise par une pluralité de sociétés bénéficiaires et, *de facto*, par une pluralité de défendeurs ayant potentiellement leur domicile dans des États membres distincts. En autorisant le rattachement au lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, la Cour de justice permet tout simplement d'éluder cette difficulté. Il est également utile de préciser qu'un tel rattachement sera particulièrement avantageux dans le cas de scissions en cascade puisque peu importe le nombre de sous-acquéreurs successifs, la compétence juridictionnelle pourra nécessairement être déterminée par le lieu d'exécution de l'obligation originale entre le débiteur et le créancier. En résumé, les règles de droit international privé applicables à l'action paulienne, loin de constituer un inconvénient[4205], renforcent l'intérêt de celle-ci en cas de scission transfrontalière et aboutissent dans de nombreuses situations à une forme de *perpetuatio fori societatis scissae*.

4201 Voir en ce sens : B. HAFTEL, *op. cit.*, pp. 86 et 87 ; J. HOFFMANN, « Gläubigeranfechtungsklagen und Zuständigkeit nach Angabe der EuGVVO – Anmerkung zu EuGH, Urt. V. 4.10.2018 – C-337/17-Feniks », *op. cit.*, p. 170 ; R. JAFFERALI, *op. cit.*, p. 253, n° 6 et T. LUTZI, *op. cit.*, p. 256.

4202 C.J., arrêt *Jakob Handte & Co. GmbH c. Traitements mécano-chimiques des surfaces SA*, 17 juin 1992, C-26/91, EU:C:1992:268 (ci-après l' « **arrêt *Handte*** »), pts. 14 à 21.

4203 Arrêt *Handte*, pt. 15.

4204 À ce sujet, voir *infra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 1, § 2, C., 2.

4205 *Contra* : B. HAFTEL, *op. cit.*, p. 87 qui voit dans la possibilité pour le demandeur de saisir le tribunal du lieu d'exécution de son contrat sans devoir tenir compte de la relation unissant le débiteur et le tiers un inconvénient de la nouvelle approche de la Cour de justice.

803. Une action répandue au sein de l'Union européenne. Dans le cadre d'une approche paneuropéenne de la protection des créanciers, l'action paulienne présente indéniablement l'avantage d'être très répandue dans les différents États membres[4206]. Pour reprendre les termes de l'avocat général Colomer[4207], « [m]algré les différences entre les ordres juridiques des États membres, il existe un code génétique commun aux solutions qu'ils offrent en réponse aux actes de disposition patrimoniaux réalisés en fraude des droits des créanciers ». Elle se retrouve ainsi notamment, en dehors de l'hypothèse d'une faillite, en droit français[4208], en droit allemand[4209], en droit autrichien[4210], en droit polonais[4211], en droit italien[4212], en droit belge[4213] et en droit luxembourgeois[4214].

804. Une certaine souplesse. Le régime de l'action paulienne présente l'avantage de faire preuve d'une certaine flexibilité pour le tiers. Celui-ci disposera ainsi de la possibilité de forcer le créancier à saisir en priorité les biens du débiteur en recourant au bénéfice de discussion[4215], ce qui pourrait s'avérer fort utile en cas de scission partielle transfrontalière puisque dans ce type d'opération, la société scindée débitrice ne disparaît pas. En outre, le tiers pourra également écarter l'action paulienne intentée par un créancier en payant tout simplement ce dernier[4216], l'exemple classique à cet égard étant la situation dans laquelle le tiers souhaite conserver le bien litigieux en raison de sa valeur supérieure à celle de la créance[4217]. Dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, cette possibilité pourrait présenter une utilité indéniable, notamment si l'objet en question constitue un élément indispensable à la poursuite de l'activité économique de la société bénéficiaire.

805. L'absence de concours avec les créanciers du tiers complice. Si l'action paulienne aboutit, il convient encore de régler la question de savoir si le créancier paulien se retrouvera ou non en situation de concours avec les créanciers du tiers complice. À cet égard, en droit belge, la doctrine majoritaire considère que le créancier paulien échappe à tout concours[4218]. Cette position, qui se

4206 Voir en ce sens : T. LUTZI, *op. cit.*, p. 252 et Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790, pt. 2 et Av. gén. M. D. R.-J. COLOMER, concl. préc. C.J., arrêt *Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH c. Deko Marty Belgium NV*, 16 octobre 2008, C-339/07, EU:C:2008:575, pt. 26.

4207 Av. gén. M. D. R.-J. COLOMER, concl. préc. C.J., arrêt *Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH c. Deko Marty Belgium NV*, 16 octobre 2008, C-339/07, EU:C:2008:575, pt. 26.

4208 Art. 1341-2 du Code civil français.

4209 §§ 1–20 AnfG.

4210 §§ 1–20 AnfO.

4211 Art. 527 à 533 du Code civil polonais. Voir à ce sujet : arrêt *Feniks*, pts. 8–13.

4212 Art. 2901 du *Codice civile* italien.

4213 Art. 1167 du Code civil belge.

4214 Art. 1167 du Code civil luxembourgeois.

4215 H. DE PAGE, *Traité élémentaire de droit civil belge*, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1967, p. 242 ; P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, p. 2209, n° 1536 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, p. 545, n° 596.

4216 *Ibidem*.

4217 *Ibidem*.

4218 Voir en ce sens : D. DEVOS, « La réparation du préjudice du créancier demandeur à l'action paulienne », *R.C.J.B.*, 1995, p. 327 ; S. LOOSVELD, « L'action paulienne : une institution séculaire en pleine vogue »,

retrouve également en droit français[4219], renforce considérablement l'intérêt de ce mécanisme de protection dans le cas d'une scission transfrontalière par absorption où les créanciers des sociétés bénéficiaires complices sont susceptibles d'être particulièrement nombreux.

806. Scissions successives et action paulienne. Il est intéressant de relever que l'action paulienne est également susceptible d'être intentée par le créancier à l'encontre d'un tiers sous-acquéreur[4220]. Elle pourrait par conséquent se révéler utile en cas de scissions successives dans le cadre de la réorganisation d'un groupe de sociétés, avec l'importante limite toutefois que le créancier parvienne à établir que les conditions de l'action paulienne sont remplies tant à l'égard du tiers acquéreur que du tiers sous-acquéreur[4221]. Compte tenu du fait qu'en pratique, cette preuve est délicate à rapporter même en l'absence d'une sous-cession[4222], l'action paulienne en cas de scissions en cascade sera cependant réservée aux hypothèses de fraude les plus manifestes.

1.2. Les limites

807. Effet relatif et apathie rationnelle. Quand bien même un créancier parviendrait à établir l'existence d'une fraude paulienne, il convient de relever que l'action paulienne, en dehors du cas particulier de la faillite[4223] n'aura qu'un effet relatif[4224] de sorte que le fractionnement et la transmission à titre universel dont s'accompagne une scission ne seront inopposables qu'au seul créancier qui aura intenté l'action en question et à ceux qui s'y seront joints[4225]. Ceci signifie que même si l'action paulienne permet aux créanciers victimes d'une fraude

note sous Bruxelles, 19 octobre 1998, *R.G.D.C.*, 2001, p. 166 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, p. 547, n° 599. *Contra* : C. ALTER, S. BAR et F. ROZENBERG, *op. cit.*, II.1.7 -156, Pour une position plus nuancée, voir S. NOTARNICOLA, *op. cit.*, pp. 169 et 170 qui plaide en faveur d'une distinction en fonction de ce que le créancier vise à obtenir la restitution d'un corps certain, auquel cas il échapperait au concours, ou, au contraire, le paiement d'une somme d'argent.

4219 B. LECOURT, « De l'utilité de l'action paulienne en droit des sociétés », *op. cit.*, p. 643 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 432, n° 1011.

4220 P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, p. 2214, n° 1539 ; P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, pp. 548 et 549, n° 601 et Cass., 9 février 2006, *Pas.*, 2006/2, p. 340. Voir également en droit français : B. LECOURT, *ibidem*, p. 643 et J. SCHMEIDLER, *ibidem*, p. 432, n° 1011.

4221 P. WÉRY, *ibidem*, pp. 548 et 549, n° 601 et Cass., 9 février 2006, *Pas.*, 2006/2, p. 340.

4222 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 943, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 925, n° 936.

4223 Voir à titre d'illustration en droit belge : Art. XX.111 ; XX.112 ; XX.113 et XX.114 du Code de droit économique belge et au sujet des art. 17 à 20 de la loi abrogée du 8 août 1997 sur les faillites : P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, pp. 549–551, n°s 603–605. Voir également à titre d'illustration en droit luxembourgeois : art. 445 à 448 du Code de commerce luxembourgeois. Voir également : Av. gén. M. D. R.-J. COLOMER, concl. préc. C.J., arrêt *Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH c. Deko Marty Belgium NV*, 16 octobre 2008, C-339/07, EU:C:2008:575, pt. 26–29 pour une analyse de l'évolution de l'action paulienne en action révocatoire dans le cadre de l'insolvabilité.

4224 H. DE PAGE, *op. cit.*, pp. 253 et 254 ; T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, p. 116, n° 154 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 432, n° 1011 ; P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, pp. 2215 et 2216, n° 1541 ; P. WÉRY, *ibidem*, p. 546, n° 598 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 875, n° 937.

4225 P. WÉRY, *ibidem*, p. 875, n° 937. *Contra* : Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions*, *op. cit.*, p. 331, n° 492 qui considère que le créancier qui parvient à établir la fraude paulienne demeurera en situation de concours avec les autres créanciers dont la créance a été transférée dans le cadre de l'opération.

de bénéficier d'une protection renforcée, elle ne permet pas de résoudre le problème de l'apathie rationnelle dont sont affectés tous les mécanismes de protection individuels, tout au plus le créancier indécis bénéficiera-t-il d'une plus longue période de réflexion.

808. Difficulté pour les créanciers des sociétés bénéficiaires. Comme d'une part, l'établissement d'une fraude paulienne requiert la preuve d'un appauvrissement de la société débitrice ou, à tout le moins, une altération du patrimoine du débiteur compliquant le recouvrement d'une créance[4226] et d'autre part, hors circonstances particulières, les fractions de patrimoine apportées à chacune des sociétés bénéficiaires devront, sauf cas particulier, avoir un actif net positif[4227], il s'ensuit que les créanciers des sociétés bénéficiaires ne pourront que très difficilement y recourir pour protéger leurs droits[4228]. En conséquence, si l'action paulienne présente un indéniable intérêt dans le cadre de la protection des créanciers de la société scindée, elle est beaucoup moins intéressante à l'égard des créanciers des sociétés bénéficiaires alors que ceux-ci encourent malgré tout certains risques dans le cadre de l'opération, comme ceux liés à la pérennité économique de la fraction du patrimoine transférée à leur débitrice ou encore l'érosion financière générée par la scission elle-même.

809. La nécessité d'une fraude du débiteur. L'étude des conditions de la fraude paulienne à l'aune de l'acte juridique particulier que constitue une scission a mis en lumière le fait qu'il sera délicat pour un créancier de parvenir à toutes les remplir[4229]. Le principal obstacle à cet égard est lié à la condition de l'existence d'une fraude de la part du débiteur[4230], fraude qui devra en outre exister au moment où l'acte litigieux est accompli[4231]. Dans le cadre d'une scission transfrontalière, la preuve de cette fraude sera difficile à rapporter dans la mesure où dans de nombreuses circonstances, la décision de réaliser une telle opération s'avérera être économiquement sensée[4232], à tout le moins *a priori*. Il s'ensuit qu'en dehors des cas de fraude manifeste où une scission est sciemment utilisée par un débiteur pour organiser sa propre insolvabilité[4233], un créancier éprouvera de nombreuses difficultés à établir une fraude du débiteur et il est aisé d'imaginer qu'un juge s'avérera généralement réticent à se livrer à ce qui s'apparenterait de très près à un jugement d'opportunité économique. Dans la même veine et de manière plus générale, on peut relever que les conditions d'exercice de l'action paulienne sont difficiles à remplir, raison pour laquelle en pratique cette action n'aboutit que rarement[4234].

4226 Voir en droit français : R. LIBCHABER, *op. cit.*, p. 54, n° 3. Voir en droit belge : W. DROSS, *op. cit.*, n° 44 ; P. WÉRY, *ibidem*, p. 874, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 926, n° 936.

4227 Sur cette condition, voir *supra* n°s 118 à 120.

4228 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 122, n° 133 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 330, n° 490.

4229 À ce sujet, voir *supra* n° 800.

4230 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 2, *op. cit.*, pp. 538 et 539, n° 585 ; P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 945, n° 937 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 926, n° 936.

4231 P. WÉRY, *ibidem*, p. 539, n° 585.

4232 Au sujet de l'intérêt économique des scissions, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2.

4233 Pour un cas d'illustration, voir : arrêt *I.G.I Srl*, pts. 25 à 37.

4234 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 943, n° 936 et P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », *op. cit.*, p. 925, n° 936.

810. Un mécanisme nécessaire, mais pas suffisant. Si les avantages du mécanisme de la fraude paulienne, à commencer par ses délais de prescription étendus, font de cette dernière, au-delà d'un simple « mécanisme subsidiaire »[4235] de protection des créanciers susceptible de jouer un « rôle palliatif »[4236], une véritable mesure de protection supplémentaire des créanciers[4237] qui, si elle est nécessairement moins adaptée que les mécanismes de protection *ad hoc* consacrés par le législateur européen en cas de scission, ce qui a été mis en lumière à suffisance par l'étude des différentes conditions de l'action paulienne[4238] et le fait que celle-ci n'est pas à même de protéger efficacement les créanciers des sociétés bénéficiaires[4239], permet de tenir compte de la circonstance particulière d'une fraude du débiteur justifiant un délai de prescription plus long. Elle constitue par conséquent un mécanisme de protection nécessaire, mais en aucun cas suffisant, en cas de scission transfrontalière.

2. *Le droit de veto*

2.1. Le principe

811. Le droit de veto des créanciers. Un moyen particulièrement efficace de garantir la protection des créanciers dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière serait de consentir un droit de veto aux créanciers leur permettant de bloquer temporairement ou définitivement l'opération soit de manière générale, soit en présence de certaines conditions spécifiques. Cette approche, qui peut être qualifiée de « *veto rights approach* »[4240], se retrouve sous une forme ou sous une autre dans de nombreux États membres en matière de fusions transfrontalières[4241] et de transformations transfrontalières[4242], mais existe

4235 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 125.

4236 Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790, pt. 82, note 23. Voir en ce sens également : B. LECOURT, « De l'utilité de l'action paulienne en droit des sociétés », *op. cit.*, p. 617 ; R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 125 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 430 et 431, n°s 1008 et 1009.

4237 Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790, pt. 64 selon lequel l'action paulienne « est une mesure de protection supplémentaire des intérêts des créanciers ».

4238 À ce sujet, voir *supra* n° 801.

4239 À ce sujet, voir *supra* n° 808.

4240 M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 58.

4241 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale, de tels droits de veto se retrouvent dans 14 États membres au nombre desquels on compte l'Autriche, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovénie, la Suède, la Finlande, l'Italie, la Lituanie, le Portugal et la Roumanie, alors que 15 États membres au nombre desquels on compte l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la France, la Hongrie, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie n'en ont expressément pas prévu. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 54–56. Voir également : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1166 ; Étude d'impact, pp. 10 et 143 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 261 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239.

4242 Selon l'étude de droit comparé réalisée par C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, de tels droits de veto sont connus en matière de transformations transfrontalières à Chypre, en Espagne et à Malte. Voir C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, p. 19.

également en matière de scissions transfrontalières. Ainsi, à titre d'illustration, en droit belge, dans l'hypothèse d'une scission émigration, la conjonction entre la nécessité d'obtenir un certificat de conformité de la part du notaire belge pour que l'opération puisse prendre effet avec l'interdiction faite au notaire de délivrer un tel certificat tant qu'un créancier ayant réclamé une sûreté n'aura pas obtenu satisfaction ou que ses prétentions n'auront pas été rejetées par une décision judiciaire exécutoire[4243] aboutit *de facto* à conférer un droit de veto temporaire aux créanciers de la société scindée[4244].

812. Illustration : l'ancien régime britannique des fusions transfrontalières[4245]. S'il ressort de l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale que sur les trente États membres étudiés, vingt-neuf ont fait le choix d'articuler la protection des créanciers en cas de fusions transfrontalières autour de la possibilité de réclamer des garanties adéquates, le Royaume-Uni, souhaitant en cela s'aligner sur son régime des fusions internes[4246] et allant consciemment au-delà de la Dixième Directive[4247], avait fait le choix d'instaurer un mécanisme unique centré sur la tenue d'une assemblée générale des créanciers[4248]. Ainsi, la principale protection des créanciers dans le cadre d'une fusion transfrontalière, mais également dans le cas d'une scission interne[4249] et d'une fusion interne[4250], résidait dans la possibilité pour ces derniers de réclamer auprès de la juridiction compétente que cette dernière procède à la convocation d'une assemblée générale des créanciers soit tous ensemble, soit répartis en différentes classes en fonction de leurs droits respectifs[4251]. Cette juridiction, à moins qu'elle n'estime que l'opération envisagée n'impacte pas négativement les différents créanciers[4252], était chargée de définir les modalités de convocation de ces assemblées générales de créanciers[4253] et veillait à ce que ces derniers bénéficient d'une information adéquate leur permettant de voter en pleine connaissance de cause sur l'opération projetée[4254]. En outre, la juridiction vérifiait également que les différentes

4243 Art. 12:73, § 3 et 12:90, § 3 du CSA.

4244 À ce sujet, voir *supra* n° 819.

4245 À la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la règlementation applicable aux fusions transfrontalières a été intégralement révoquée en application des sections 2 et 5 de The Companies, Limited Liability Partnerships and Partnerships (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, disponible sur www.legislation.gov.uk (18/13/2021) et ce, avec effet au jour de la sortie du Royaume-Uni, soit le 31 janvier 2020. Pour une étude détaillée des effets du Brexit sur le droit européen des sociétés, voir : J. SCHMIDT, « Brexit : Implikationen des EU-UK TCA im Bereich des Gesellschaftsrechts », *GmbHR*, 2021, pp. 229–240.

4246 Voir en ce sens : P. DAVIES, *Principles of modern company law*, 8th ed., Sweet & Maxwell, London, 2008, p. 1068 ; Explanatory Memorandum to The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, S.I. 2007 N°. 2974, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019), p. 3 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 183.

4247 Explanatory Memorandum to The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, S.I. 2007 N°. 2974, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019), p. 3.

4248 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 56 et sections 11 et 14 of The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019), (ci-après « **The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations** »).

4249 Section 901 (1) & (2) of the Companies Act 2006, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019).

4250 Section 901 (1) & (3) of the Companies Act 2006, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019).

4251 Section 11 (1) (b) of The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations.

4252 J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 183.

4253 J. PAYNE, « The role of the court in debt restructuring », *C.L.J.*, 2018, 77(1), p. 135.

4254 J. PAYNE, *ibidem*, p. 135 et *Re Indah Kiat International Finance Co. BV* [2016] B.C.C. 418, pt. 29.

classes avaient valablement été constituées[4255]. La fusion transfrontalière ne pouvait ensuite avoir lieu que si le projet commun de fusion transfrontalière était approuvé par une majorité en nombre des créanciers présents et votants, lesquels devaient également représenter 75 % de la valeur des créances[4256]. Le respect de ces différentes conditions était par la suite vérifié par la juridiction compétente dans le cadre du contrôle de conformité[4257].

2.2. Les limites

813. Un mécanisme surprotecteur. Si l'octroi d'un droit de veto aux créanciers protège efficacement les intérêts des créanciers actifs et a suscité un certain intérêt de la part des *stakeholders* interrogés dans le cadre de la consultation de 2015[4258], force est de constater qu'il s'agit là d'un moyen de protection particulièrement intrusif[4259], voire excessif car cela revient à conférer aux créanciers un droit similaire à celui des associés[4260] alors que, contrairement à ces derniers, ils ne sont pas soumis à une subordination de principe en cas de faillite et jouissent nécessairement d'une responsabilité limitée. Dans le cas du régime britannique étudié ci-dessus, il est intéressant de relever que la législation relative aux « *schemes of arrangement* »[4261] s'appliquant aux fusions internes[4262] et ayant servi de modèle à la législation relative aux fusions transfrontalières[4263] trouve son origine dans le *Joint Stock Companies Arrangement Act 1870* qui imposait la dissolution de la société débitrice[4264] et est fréquemment utilisée à l'heure actuelle dans les situations où une société est en situation de difficulté financière et souhaite négocier un compromis avec ses créanciers[4265]. Or, dans une fusion, pas plus que dans une scission, la société apporteuse n'est nécessairement en situation financière délicate. Ce caractère surprotecteur explique en outre pourquoi dans le cadre de la Directive Mobilité, certains auteurs ont considéré que l'abandon d'un tel mécanisme de protection constituait déjà une réussite en soi[4266]. De plus, conférer un tel droit permettrait à un créancier d'empêcher la société de procéder à une opération de restructuration indispensable à sa survie économique et, par conséquent, de nuire aux intérêts de tous les autres *stakeholders*, à commencer par les travailleurs. Si on combine ce risque avec le fait que les créanciers d'une société commerciale sont loin de

4255 J. PAYNE, *ibidem*, p. 135.
4256 Sections 11 et 14 of The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations.
4257 Section 6 of The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations.
4258 Voir : Consultation publique de 2015, p. 7, 40 % des personnes ayant exprimé un avis sur le moyen de protection des créanciers à adopter se sont prononcées en faveur d'une assemblée des créanciers.
4259 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 55 ; R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 418 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18.
4260 Voir en ce sens : Fr. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, pp. 27 et 28 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18.
4261 Part 26 Arrangements and reconstructions of the Companies Act 2006, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019). Voir à ce sujet : P. DAVIES, *op. cit.*, pp. 1059–1082, n°s 29-1–29-16.
4262 P. DAVIES, *ibidem*, p. 1061, n° 29-2.
4263 *Ibidem*.
4264 *Ibidem*.
4265 *Ibidem*.
4266 Voir en ce sens : T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1167.

former une catégorie homogène[4267] et que leurs intérêts sont, par conséquent, fort susceptibles de diverger, on aboutit à la situation où certains créanciers n'encourant qu'un risque limité, mais formant, le cas échéant, une classe de créanciers séparée, pourraient bloquer une opération vitale pour la pérennité de l'activité économique de la société scindée. À titre d'illustration, des créanciers contractuels à long terme seront davantage intéressés par la survie à long terme de l'entreprise garantissant le remboursement de leur créance, alors que les petits créanciers délictuels préféreront voir leur préjudice réparé le plus vite et le plus simplement possible et ne se sentiront pas concernés par l'activité économique de leur société débitrice. Dans cet exemple, il est aisé d'imaginer les premiers voter en faveur de l'opération et les seconds voter contre. Par ailleurs, un créancier mal intentionné pourrait aisément recourir à un usage abusif d'un tel mécanisme de protection pour améliorer sa position[4268], par exemple en exigeant des garanties additionnelles de la part de la société en échange de son approbation. Ce caractère excessif explique pourquoi ce mécanisme de protection est loin de faire l'unanimité dans le cadre des fusions transfrontalières. Il s'est même avéré être le moins populaire parmi les différents acteurs économiques et juridiques interrogés[4269]. Toutefois, ce tableau doit être relativisé car s'il apparaît de prime abord excessif, le droit de veto dont jouissent les créanciers se trouve limité par la possibilité dont jouit la société débitrice d'écarter celui-ci en soldant sa dette auprès du créancier opposé à la scission, le cas échéant en procédant à son refinancement préalablement à la réalisation de l'opération[4270]. À titre d'illustration, cette possibilité est expressément prévue en droit italien en matière de scissions internes[4271]. Malgré cela, compte tenu du fait que les scissions transfrontalières constituent des modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement[4272], on peut émettre de sérieux doutes quant à la proportionnalité d'un mécanisme de protection conférant un droit de veto aux créanciers[4273], ne fût-ce qu'en raison de l'existence de mécanismes beaucoup moins intrusifs tels que l'octroi de garanties adéquates[4274] ou la solidarité passive des sociétés issues de l'opération.

814. Un mécanisme délicat à mettre en œuvre en pratique. Même atténué en n'imposant que l'approbation de la scission au sein d'une assemblée générale à une majorité qualifiée, ou même à une majorité simple, ce système de protection prête le flanc à la critique. En effet, compte tenu du nombre considérable de créanciers d'une société commerciale, il est déjà particulièrement délicat

4267 À ce sujet, voir *supra* n° 692.
4268 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 60.
4269 Fusions et scissions transfrontalières – Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), disponible sur http://www.europarl.europa.eu (27/09/2017), p. 6. Voir également : Consultation publique de 2015, p. 7 qui rapporte que sur les 93 % des personnes s'étant prononcées sur la question de la protection des créanciers, seuls 12 % étaient en faveur d'un droit de veto, certains étant même allés jusqu'à indiquer que les créanciers ne devaient pas bénéficier d'un tel droit.
4270 Voir en ce sens : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 58.
4271 Art. 2503 et 2506-ter,§3 du *Codice Civile*, disponible sur www.altalex.com (18/07/2019).
4272 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.
4273 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 60 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18.
4274 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 18.

d'identifier avec précision tous les créanciers dont l'accord est requis ou qui devront être convoqués à une assemblée générale[4275]. En outre, l'exemple du régime britannique des fusions transfrontalières montre à quel point un tel système est affecté de limites intrinsèques complexifiant sa mise en œuvre. Ainsi, imposer des conditions de majorité calculées sur la base de la valeur des créances des différents créanciers implique nécessairement de parvenir à évaluer chacune des créances détenues à l'encontre de la société, ce qui peut se révéler un exercice particulièrement hasardeux en pratique[4276]. De plus, il convient de ne pas perdre de vue que d'un pur point de vue logistique, ce mécanisme de protection pourrait s'avérer particulièrement lourd à mettre en place. En effet, si la société apporteuse compte de très nombreux créanciers, tant leur convocation que leur information préalable risquent de s'avérer fastidieuses et coûteuses.

815. Un risque d'abus entre créanciers. À partir du moment où le droit de veto est levé dès que l'opération est approuvée par une certaine majorité, même élevée, des créanciers, il y a un risque inhérent d'abus au détriment d'une minorité de créanciers susceptible d'entraîner un transfert de richesse des premiers vers les seconds[4277]. Ce risque n'a pas échappé au législateur britannique dans le cadre des « *schemes of arrangement* » qui a tenté d'y remédier, d'une part en imposant la constitution de classes séparées regroupant des créanciers ayant les mêmes droits combinée avec des conditions de majorité spécifiques à remplir au sein de chaque classe[4278] et, d'autre part, en prévoyant que la constitution des différentes classes serait vérifiée par la juridiction compétente[4279]. À cet égard, il est intéressant de relever que les juridictions anglaises tendent à l'heure actuelle à privilégier la constitution de vastes classes de créanciers[4280] en n'utilisant non pas la similarité des intérêts des créanciers comme critère déterminant, mais celle de leurs droits respectifs[4281]. Or, au plus les classes sont vastes, au plus les minoritaires encourent le risque de subir un abus[4282]. De plus, force est de constater que dans l'hypothèse d'une société ayant de

[4275] Voir en ce sens à propos des fusions : S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 81.

[4276] Voir en ce sens : P. DAVIES, *op. cit.*, p. 1068, note 1045 et *British Aviation Insurance Co Ltd, Re* [2006] 1 B.C.L.C. 665.

[4277] Voir en ce sens : J. PAYNE, *op. cit.*, p. 129.

[4278] Section 896 of the Companies Act 2006, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019). Le principe de base utilisé pour la répartition des créanciers en différentes classes est le « *Dodd test* » établi par Bowen LJ dans *Sovereign Life Assurance Co v. Dodd* [1892] 2 Q.B. 573, 583 et selon lequel « [i]*t seems plain that we must give such meaning to the term « class » as will prevent the section being so worked as to result in confiscation and injustice and that it must be confined to those persons whose rights are not so dissimilar as to make it impossible for them to consult together with a view to their common interest.* ». Voir à ce sujet : J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 184 et Ch. ZHEN QU, « Sanctioning schemes of arrangement: the need for granting the court a curative power », *J.B.L.*, 2016, 1, pp. 15 et 16.

[4279] Voir en ce sens : J. PAYNE, *op. cit.*, p. 129.

[4280] J. PAYNE, *ibidem*, p. 135.

[4281] J. PAYNE, *ibidem*, p. 135 et *Re Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privat bank"* [2015] EWHC 3299 (Ch) ; *Re Codere Finance (UK) Ltd.* [2015] EWHC 3778 (Ch) et *Re Indah Kiat International Finance Co. BV* [2016] B.C.C. 418.

[4282] J. PAYNE, *ibidem*, p. 135.

très nombreux créanciers, la détermination des différentes classes s'avérera être un exercice pour le moins complexe[4283].

816. Un mécanisme trop limité. Au-delà de ces premières considérations, force est de constater à nouveau que ce mécanisme de protection ne s'adresse qu'aux seuls créanciers conscients de l'existence de leur créance et ayant à la fois les moyens et la volonté de s'opposer à l'opération projetée. En effet, à titre d'illustration, en matière de responsabilité environnementale, on voit difficilement comment les créanciers involontaires dont le dommage peut être causé préalablement à l'opération mais découvert après la réalisation de celle-ci pourraient être correctement protégés par le seul octroi d'un droit de veto.

3. *Le contrôle par une autorité nationale*

3.1. Le principe

817. Un mécanisme institutionnel par excellence. Afin de garantir que les intérêts des créanciers ne soient pas indûment préjudiciés par une opération transfrontalière, certains législateurs nationaux tels que les législateurs allemand[4284], belge[4285] et autrichien[4286], ont prévu un rôle spécifique pour l'autorité nationale en charge du contrôle de conformité[4287]. Il s'agit là d'un mécanisme de protection institutionnel par excellence dans la mesure où le contrôle réalisé par l'autorité nationale en question interviendra indépendamment de toute initiative de la part d'un créancier. Parmi ces différents mécanismes de protection articulés autour d'une intervention d'une autorité administrative ou judiciaire dans le processus de scission, il est possible de distinguer entre (i) ceux fondés sur des règles générales du droit des sociétés, telles que celles relatives au maintien du capital social[4288] et (ii) ceux fondés sur des règles propres aux opérations de restructuration comme la disposition anti-abus prévue à l'origine par la Proposition de la Commission[4289] ou encore l'obligation en droit allemand pesant sur l'autorité en charge du contrôle de conformité en cas de fusion-émigration de ne délivrer le certificat qu'en présence d'une attestation de la part de l'organe de gestion de la société absorbée que les créanciers ayant droit à l'octroi d'une garantie en vertu du § 122j UmwG[4290] l'ont bien obtenue[4291]. Afin d'apprécier les avantages et inconvénients de ce mécanisme

4283 Voir en ce sens : P. DAVIES, *op. cit.*, p. 1065, n° 29-6 ; D. MILMAN, « Schemes of arrangement and other restructuring regimes under UK company law in context », *Co. L.N.*, 2011, 3101, p. 2 et Ch. ZHEN QU, *op. cit.*, p. 13.

4284 § 122k (2), 4e phrase UmwG en matière de fusions transfrontalières. Voir à ce sujet : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122k, nos 15 et 16 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 12 ; R. HÖRTNAGL in J. SCHMITT, R. HÖRTNAGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 27 et N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 8.

4285 Art. 14:26, 2e phrase du CSA en matière de transformations transfrontalières.

4286 § 14 (1), pt. 9 Eu-VerschG en matière de fusions transfrontalières. Voir à ce sujet : G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 740, n° 22 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 391.

4287 Sur cette étape de la procédure de scission transfrontalière, voir *supra* nos 640 à 661.

4288 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 53.

4289 Art. 86*quater*, § 3 de la Proposition de la Commission pour les transformations transfrontalières et art. 160*quinquies*, § 3 de la Proposition de la Commission pour les scissions transfrontalières.

4290 Sur ce mécanisme spécifique de protection des créanciers, voir *supra* n° 719.

4291 § 122k (2), 4e phrase UmwG.

de protection, dont l'admissibilité de principe dans une procédure de scission transfrontalière est confirmée par la Directive Mobilité[4292], il est utile d'examiner un exemple de chacune de ces deux sous-catégories.

818. Illustration d'un mécanisme relevant du droit général des sociétés : les règles relatives au maintien du capital social. Un excellent exemple de ce type de mécanisme de protection se trouve en droit autrichien à l'égard des « *down-stream mergers* »[4293] dans l'hypothèse où à la suite d'un « *leveraged buy-out* »[4294] par le biais d'un « *special purpose vehicle* » contractant une dette auprès d'un tiers afin de financer l'acquisition de la cible, cette même cible absorbe le « *special purpose vehicle* » dont le patrimoine ne contient, à l'actif, que la participation dans la fille et, au passif, que la dette externe. Compte tenu d'une particularité du droit autrichien prévoyant que lorsque la société absorbée détient des actions dans le capital de la société absorbante, ces actions doivent en priorité être distribuées aux associés de la société absorbée[4295], une telle opération ne s'accompagne pas nécessairement d'une augmentation de capital de la société absorbante et ne nécessite donc pas que l'actif net de la société absorbée soit positif[4296]. Dans une telle hypothèse de « *debt push down* »[4297], le créancier ayant financé l'acquisition acquiert un accès direct aux actifs de la cible et sa position s'en trouve renforcée. En revanche, les créanciers de la cible vont se retrouver en concurrence avec la banque et leur société débitrice acquiert, par l'effet même de l'opération, une dette qui n'est pas dans son intérêt social[4298]. En d'autres termes, cela revient à ce que la société cible finance sa propre acquisition[4299]. Or, une telle opération est considérée comme équivalent à un remboursement prohibé de l'apport

4292 Selon le 39e considérant, 1re phrase de la Directive Mobilité, « [a]fin de garantir que la société qui procède à l'opération transfrontalière ne lèse pas ses créanciers, l'autorité compétente devrait avoir la possibilité de contrôler, notamment, si la société a rempli ses obligations vis-à-vis de ses créanciers publics et si ses éventuelles obligations en cours sont suffisamment garanties ».

4293 Par « *down-stream merger* », on entend l'opération de fusion par absorption d'une société mère par sa fille détenue à 100 %. Voir sur cette notion : T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 139 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 160, n° 31 ; G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 24, n° 39 ; K. MERTENS, « Aktuelle Fragen zur Verschmelzung von Mutter- auf Tochtergesellschaften – down stream merger », *AG*, 2005, p. 785 et Fr. MOZKA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 24, n° 48.

4294 Par « *leveraged buy-out* », on vise « un type d'acquisition lors duquel une partie substantielle du prix d'acquisition est financée au moyen d'emprunts, tout en utilisant les actifs de la cible comme garantie ». Voir S. SINGHAL, « Financing of leveraged buy-outs », *Comp. Law.*, 2008, 29(12), p. 355. Pour une étude sur la protection des créanciers dans le cadre d'un « *leveraged buy-out* », voir M. TASMA, *Leveraged Buyout und Gläubigerschutz*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012.

4295 § 224 (3) öAktG. Ce mécanisme est communément dénommé « *Durchschleusung* ». Voir à ce sujet : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 159–163, §§ 27–34.

4296 Au sujet de l'exigence d'un actif net positif des fractions du patrimoine de la société scindée attribuées aux sociétés bénéficiaires dans le cadre d'une scission, voir *supra* nos 118 à 120.

4297 Par « *debt push down* », on entend l'opération fréquente à la suite d'un *leveraged buy-out* par laquelle la société cible se retrouve, en raison de sa fusion *upstream* ou *downstream* avec la société acquéreuse, débitrice du financement nécessaire à sa propre acquisition. Voir à ce sujet : T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 5, n° 139.

4298 M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 56.

4299 G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 24, n° 40 ; K. MERTENS, *op. cit.*, p. 786 et M. WINNER, *ibidem*, p. 56.

à l'associé par les juridictions autrichiennes[4300] et le tribunal compétent pour l'enregistrement de l'opération peut refuser celle-ci, l'empêchant *de facto* de prendre effet en vertu du droit autrichien[4301]. Ces considérations se retrouvent également en droit allemand où de telles opérations sont appréciées avec méfiance et il est ainsi considéré (i) qu'à l'égard d'une société à responsabilité limitée (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) de telles opérations ne sont possibles que si la perte engendrée par une telle opération pour la société absorbée est susceptible d'être absorbée par les capitaux propres de cette dernière sans entamer le capital social[4302] et qu'à l'égard d'une société anonyme (*Aktiengesellschaft*) une telle opération constitue un remboursement prohibé des apports[4303]. Si ces considérations ont été essentiellement analysées par la doctrine dans le cadre des fusions internes[4304], des problèmes similaires sont susceptibles de se produire également dans le cadre d'une scission. En reprenant l'exemple du droit autrichien, il est admis que le mécanisme spécifique consistant à attribuer directement les actions détenues par la société apporteuse dans la société bénéficiaire aux associés de la société apporteuse s'applique également en cas de scission dans l'hypothèse où le projet de scission prévoit l'attribution des actions dans une des sociétés bénéficiaires à cette même société bénéficiaire[4305].

819. Illustration d'un mécanisme propre aux scissions transfrontalières : le contrôle du notaire selon le CSA. En cas de scission transfrontalière par absorption ou mixte lors de laquelle une des sociétés participantes est soumise au droit belge[4306] ou en cas de scission par constitution de nouvelles sociétés lors de laquelle la société scindée est soumise au droit belge[4307], il est prévu que le notaire instrumentant devra délivrer un certificat de conformité à la demande de cette même société. Ce procédé, qui a pour but de permettre à la société de bénéficier d'un certificat attestant de manière incontestable de l'accomplissement des actes et formalités préalables à la réalisation de

4300 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 172 et 173, n° 57 ; M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 56 et Oberster Gerichtshof Österreichs, 11 nov. 1999, 6Ob4/99b, disponible sur www.ris.bka.gv.at (18/07/2019), pp. 1–9 pour un cas d'application.

4301 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, pp. 172 et 173, n° 57 et M. WINNER, « Creditor protection… », *ibidem*, p. 56.

4302 § 30 GmbHG et G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 24, n° 40 ; K. MERTENS, *op. cit.*, pp. 786 et 787 ; Fr. MOZKA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 24, n° 48 et H.-J. PRIESTER et J. HENNRICHS in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 24, n° 62.

4303 § 57(3) AktG et Chr. LOUVEN et A. WENG, « Die Ausgliederung von Pensionsverbindlichkeiten – neue Optionen bei Unternehmensverkäufen », *BB*, 2006, p. 623 ; Fr. MOZKA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 24, n° 48, note 94 ; K. MERTENS, *ibidem*, p. 786 et H.-J. PRIESTER in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 24, n° 62, note 4 ; En faveur d'une approche plus nuancée : G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 24, n° 40. *Contra* : V. BOCK, « Institutioneller Gläubigerschutz nach § 30 Abs. 1 GmbHG beim Down-stream-merger nach einem Anteilskauf ? », *GmbHR*, 2005, pp. 1025 et s. et F. ENNEKING et H. HECKSCHEN, « Gesellschafterhaftung beim down-stream merger », *DB*, 2006, p. 1100.

4304 Voir notamment : V. BOCK, *ibidem*, pp. 1023–1030 ; G. LANFERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 24, n° 40 ; K. MERTENS, *ibidem*, pp. 786 et 787 ; Fr. MOZKA in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 24, n° 48–51 ; H.-J. PRIESTER in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 24, n°s 61–63 ; M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 53 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 56.

4305 Voir en ce sens : S. KALSS, *op. cit.*, pp. 1069 et 1070, n° 85.

4306 Art. 12:73, § 3, 1re phrase du CSA.

4307 Art. 12:90, § 3, 1re phrase du CSA.

l'opération[4308], n'est pas sans rappeler celui applicable à une fusion transfrontalière[4309], mais il diffère cependant de celui-ci en ce que le notaire devra s'abstenir d'émettre le certificat aussi longtemps que les créanciers exigeant une sûreté conformément à la procédure prévue par le CSA[4310] n'auront pas obtenu satisfaction, sauf si leurs prétentions ont été rejetées par une décision judiciaire exécutoire[4311]. Afin de rendre ce mécanisme possible, il est en outre prévu que (i) le projet de scission devra mentionner le nom et la résidence du notaire instrumentant devant lequel l'acte de scission devra être passé[4312] et (ii) par dérogation au régime applicable en cas de scission interne, le créancier souhaitant obtenir une sûreté devra adresser sa demande à la fois à la société et au notaire instrumentant, sous peine d'irrecevabilité[4313]. Cette mesure de protection additionnelle, ouvertement instaurée en vue de « protéger les créanciers de la société belge »[4314], a en elle-même un effet suspensif sur l'opération en ce que le certificat de conformité ne pourra être délivré qu'au plus tôt après l'expiration du délai de deux mois à compter de la publication de l'acte portant approbation de l'opération dont les créanciers disposent pour introduire leur demande[4315]. Cependant, au-delà de ce premier délai, force est de constater qu'une demande adressée par un créancier en temps utile aura également un effet suspensif[4316] puisque le notaire devra attendre soit que le créancier ait obtenu la sûreté requise, soit que ses prétentions aient été rejetées par une décision exécutoire. Cet effet dilatoire est d'autant plus important qu'il ne sera possible de réduire cette période de protection de deux mois qu'avec le consentement unanime de tous les créanciers[4317] ou en payant tous les créanciers ayant le droit de réclamer une sûreté, déduction faite de l'escompte[4318] ou encore en leur octroyant d'office une sûreté.

820. Deux avantages limités. En ce qui concerne l'efficacité de ce mécanisme de protection des créanciers, on peut tout d'abord relever qu'un tel mécanisme est susceptible de garantir une protection de tous les créanciers quelle que soit leur importance et peu important qu'ils soient actifs ou passifs, volontaires ou involontaires, privilégiés ou chirographaires. Ainsi, le régime autrichien, en s'articulant autour des règles relatives au maintien du capital social, vise à protéger tous les créanciers sans exception. En outre, la présence d'un contrôle effectué par une autorité nationale prenant en considération les intérêts des créanciers

4308 À ce sujet, voir *supra* n°s 648 à 653.
4309 Art. 12:117 du CSA.
4310 Art. 12:15 du CSA.
4311 Art. 12:73, § 3, 2e phrase et 12:90. § 3, 2e phrase du CSA.
4312 Art. 12:73, § 3, 3e phrase et 12:90. § 3, 3e phrase du CSA.
4313 Art. 12:73, § 3, 4e phrase et 12:90. § 3, 4e phrase du CSA.
4314 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 311.
4315 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 311.
4316 Voir en ce sens : E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *op. cit.*, p. 340, n° 941 et D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, p. 337.
4317 I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 27 et, au sujet des transformations transfrontalières : Kr. MARESCEAU, « De invoering van de statutaire zetelleer en de procedure tot grensoverschrijdende omzetting », in *Le projet de Code des sociétés et associations – Het ontwerp Wetboek van vennootschapen en verenigingen*, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 64, n° 24.
4318 Art. 12:15, § 1er, al. 2 du CSA.

soit, comme dans l'exemple autrichien, réduit la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection individuels[4319] soit, comme dans l'exemple belge, permet d'en renforcer l'efficacité.

3.2. Les limites

821. Un mécanisme lourd et coûteux. Cependant, au-delà de ces avantages, force est de constater que ce mécanisme de protection entraîne un nombre relativement important d'inconvénients. Tout d'abord, sa mise en œuvre et les éventuelles contestations qui s'ensuivront sont susceptibles de retarder considérablement la réalisation d'une scission potentiellement essentielle à la survie économique de l'entreprise. À titre d'illustration, dans un cas d'espèce en droit autrichien, la demande d'enregistrement de la fusion a été introduite le 25 septembre 1998 et la décision de la juridiction suprême autrichienne en la matière n'a été rendue que le 11 novembre 1999[4320]. Le même constat s'impose à l'égard du mécanisme allemand en ce que dans certains cas, l'organe de gestion de la société absorbée ne sera en mesure de fournir une déclaration que les créanciers ayant droit à l'octroi d'une garantie l'ont bien obtenue qu'après l'écoulement du délai de deux mois dont les créanciers disposent pour faire valoir leurs droits[4321]. En outre, dans la mesure où une fausse déclaration est assortie de sanctions pénales[4322], l'organe d'administration ne sera certainement pas enclin à prendre des risques en la matière. À ce premier inconvénient s'ajoute le fait qu'un tel mécanisme de protection ne fonctionne correctement que si l'autorité nationale compétente dispose des moyens nécessaires pour effectuer un tel contrôle, ce qui ne sera pas nécessairement le cas lorsque la mission du contrôle de légalité aura été confiée à un notaire comme dans l'exemple belge[4323]. Ensuite, si un tel mécanisme de protection institutionnel présente certes l'avantage de protéger aussi bien les créanciers actifs que les autres, il convient toutefois de remarquer qu'il entraîne un coût significatif puisqu'il implique que l'autorité en charge du contrôle aura l'obligation d'examiner toutes les opérations, même les plus inoffensives[4324].

822. Une insuffisance plus fondamentale. Au-delà de ces premiers reproches, force est de constater que ce mécanisme n'est pas sans rappeler la disposition anti-abus figurant à l'origine dans la Proposition de la Commission[4325] et qui permettait à l'autorité compétente de l'État membre de la société scindée

4319 Voir en ce sens : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 56.

4320 Oberster Gerichtshof Österreichs, 11 nov. 1999, 6Ob4/99b, disponible sur www.ris.bka.gv.at (18/07/2019), p. 2.

4321 Voir en ce sens : N. ZIMMERMANN in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 8. Pour une obligation de respecter le délai d'attente dans tous les cas, voir : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 15 et R. HÖRTNAGL in J. SCHMITT, R. HÖRTNAGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 27. Voir également : C. KRUSE et Co. KRUSE, « Grenzüberschreitende Konzernverschmelzungen – Vorgaben und Vereinfachungen der §§ 122a ff. UmwG », *BB*, 2010, p. 3038.

4322 § 314a UmwG.

4323 Art. 12:73, § 3 et 12:90, § 3 du CSA.

4324 Voir en ce sens : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 56.

4325 Art. 86*quater*, § 3 de la Proposition de la Commission pour les transformations transfrontalières et art. 160*quinquies*, § 3 de la Proposition de la Commission pour les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés.

de ne pas autoriser la scission transfrontalière si, après examen, elle s'avérait être « un montage artificiel visant à obtenir des avantages fiscaux indus ou à porter indûment atteinte aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés »[4326]. Or, la conformité à la liberté d'établissement de cette disposition était à tout le moins douteuse au regard du principe de proportionnalité[4327]. Un raisonnement similaire est susceptible de s'appliquer également à certains mécanismes nationaux de protection des créanciers par le biais du contrôle de conformité. Ainsi, à l'égard de l'exemple belge, on pourrait arguer que la possibilité de demander des sûretés[4328] combinée à (i) une exigibilité immédiate de la dette et (ii) une solidarité des sociétés bénéficiaires si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé[4329] protège déjà suffisamment les créanciers actifs et vigilants sans qu'il ne soit nécessaire d'impliquer en plus le notaire en charge du contrôle de conformité. En d'autres termes, l'entrave à la liberté d'établissement dressée par ce mécanisme de protection institutionnel ne serait pas justifiée en ce qu'elle va au-delà de ce qui est nécessaire et, par conséquent, ne remplit pas la condition de proportionnalité du « *Gebhard test* »[4330].

4. *Le droit d'opposition optionnel du droit français*

4.1. Le principe

823. Un mécanisme en cascade. En droit français, en cas de scission, les créanciers de la société scindée sont protégés par défaut par la solidarité des sociétés bénéficiaires de l'opération[4331]. Cependant, de manière originale, les sociétés impliquées dans l'opération disposent de la possibilité de prévoir que chacune des sociétés bénéficiaires ne sera tenue que de la partie du passif de la société scindée qui lui aura été transférée[4332]. Dans une telle hypothèse, les créanciers non obligataires des sociétés, peu importante qu'ils soient créanciers des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée[4333] ou encore qu'ils soient chirographaires ou privilégiés[4334], participant à une opération de scission interne et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de scission disposent d'un mécanisme de protection *ex ante* leur ouvrant la possibilité

4326 Pour une étude détaillée de cette disposition anti-abus, voir *supra* n°s 347 à 375.

4327 W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport Europäisches Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2571 ; F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 35–36 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 240 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 15.

4328 Art. 12:15, § 1er, al. 1er du CSA.

4329 Art. 12:15, § 1er, al. 5 du CSA.

4330 I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 27.

4331 Art. L-236-20 du Code de commerce français.

4332 Art. L236-21, al. 1er du Code de commerce français.

4333 *Pro* : J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 66, n° 172 et T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, p. 28, n° 31. *Contra* : R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 106–110, n°s 117–119 qui considère que les créanciers des sociétés bénéficiaires sont suffisamment protégés par l'action paulienne et que le droit d'opposition, en ce qu'il vient protéger les créanciers contre la disparition de leur droit de gage du fait de la confusion des patrimoines, devrait être réservé aux seuls créanciers de la société scindée.

4334 Voir en ce sens : J.-M. MOULIN, *ibidem*, p. 66, n° 172.

de former opposition contre celui-ci[4335] dans un délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de scission sur le site internet de chacune des sociétés impliquées[4336]. Malgré une terminologie trompeuse, cette opposition, contrairement à celle applicable en cas de dissolution-confusion[4337], est dénuée d'effet suspensif[4338]. Elle donnera simplement lieu à une décision de justice qui soit rejettera l'opposition, soit ordonnera le remboursement de la créance en question ou la constitution de garanties pour peu que la société absorbante en offre et qu'elles soient jugées suffisantes[4339]. À défaut de constitution de garanties ou de remboursement des créances, la scission sera inopposable à ce créancier[4340], ce qui implique qu'il bénéficiera d'un droit préférentiel sur les éléments de patrimoine actifs apportés aux sociétés bénéficiaires[4341]. Ce mécanisme de protection inédit dont, l'origine remonte à 1966[4342] et articulé autour de la sanction ultime de l'inopposabilité de l'opération, mérite un examen à part car il semble, de prime abord, déroger aux mécanismes de protection des créanciers prévus par défaut par la Directive Sociétés, d'une part en ce qu'il permet à la juridiction compétente de choisir entre un remboursement anticipé et la constitution de garanties adéquates et, d'autre part, en ce qu'il ne prévoit pas une responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires, potentiellement limitée à l'actif net transféré, mais une inopposabilité de l'opération.

824. Le choix entre garanties adéquates et remboursement de la créance. Contrairement à la Directive Sociétés en matière de scissions[4343] et de fusions[4344] et à la Directive Mobilité en matière de scissions[4345], de transformations[4346] et de fusions[4347] transfrontalières qui n'envisagent pas la possibilité pour l'autorité nationale compétente en charge de se prononcer en faveur d'un remboursement immédiat de la créance, le tribunal de commerce compétent[4348] disposera d'un choix entre ordonner le remboursement de la créance, et imposer la constitution de garanties si la société en offre et que ces dernières sont jugées suffisantes[4349], peu important à cet égard qu'il s'agisse de sûretés réelles

4335 Art. L236-14, al. 2 et L236-21, al. 2 du Code de commerce français.
4336 Art. R236-8, § 1er du Code de commerce français.
4337 Selon les termes de l'art. 1844-5, al. 3 *in fine* du Code civil français, « [l]a transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
4338 Art. L236-14, al. 4 et L236-21, al. 2 du Code de commerce français et M. COZIAN, Al. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, *Droit des sociétés*, 34e éd., Paris, LexisNexis, 2021, p. 818, n° 2268 et p. 836, n° 2325.
4339 Art. L236-14, al. 2 et L236-21, al. 2 du Code de commerce français.
4340 *Ibidem*.
4341 Voir en ce sens à propos des fusions : J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 67, n° 173.
4342 Art. 381 de la loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr (29/11/2019) et M. GERMAIN, « L'opposition en droit des sociétés », *LPA*, 4 avril 2007, p. 21, disponible sur www.lextenso.fr (05/12/2019), pp. 1 et 2.
4343 Art. 146, § 2 de la Directive Sociétés.
4344 Art. 99, § 2 de la Directive Sociétés.
4345 Ar. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité.
4346 Art. 86*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
4347 Art. 126*ter*, § 1er de la Directive Mobilité.
4348 Selon l'art. R236-8, al. 3 du Code de commerce français, le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société débitrice est compétent.
4349 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 114, n° 123.

ou personnelles[4350]. Un des aspects les plus originaux du droit d'opposition consacré par le Code de commerce français est donc de ne pas permettre au tribunal d'ordonner la constitution de garanties, contrairement à ce qui est le cas en Belgique[4351], au Luxembourg[4352], en Allemagne[4353] et en Autriche[4354] et ce, afin d'éviter un « *interventionnisme excessif* » de la part des juridictions compétentes[4355].

825. La sanction de l'inopposabilité de l'opération. Inspiré par le bénéfice de séparation du patrimoine[4356] consacré par l'ancien article 878 du Code civil français[4357], le droit d'opposition consacré par le Code de commerce français dénote en ce qu'il confère un droit de préférence aux créanciers de la société scindée sur les éléments du patrimoine actif transférés par rapport aux créanciers des sociétés bénéficiaires[4358] qui n'est pas sans rappeler le droit de préférence consacré en droit successoral[4359]. L'inopposabilité dont il est assorti peut être rapprochée de la protection archaïque des créanciers en cas de fusion développée par la jurisprudence française et qui tendait à considérer que la fusion était inopposable aux créanciers de la société absorbée car leur consentement exprès était requis pour qu'il puisse y avoir novation par changement de débiteur[4360]. Dans une perspective plus moderne, l'inopposabilité revient en essence à atténuer les effets de la transmission à titre universel de patrimoine dont s'accompagne l'opération de scission en protégeant le créancier de la société scindée ou d'une des sociétés bénéficiaires contre le concours avec les créanciers des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée sur les fractions de patrimoine transmises[4361], sans altérer les droits de préférence dont les créanciers de la société débitrice jouissaient avant la réalisation de l'opération[4362].

4.2. Les limites

826. Les limites prétoriennes. Malgré le caractère a priori général de la formulation du droit d'opposition dans le Code de commerce[4363], la jurisprudence est venue imposer des conditions additionnelles à l'exercice du droit d'opposition.

4350 *Ibidem*.
4351 Art. 12:15, § 1er du CSA.
4352 Art. 1031-10, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
4353 §§ 22, 125 et 133(1) UmwG.
4354 § 15 (2) SpaltG.
4355 M. GERMAIN, *op. cit.*, p. 3.
4356 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 100, n° 110.
4357 Selon cet article, modifié le 1er janvier 2007, les créanciers du défunt « peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier ».
4358 Voir en ce sens à propos des fusions : P. LE CANNU et Br. DONDERO, *Droit des sociétés*, 5e éd., Paris, LGDJ – Lextenso éditions, 2013, p, 1013, n° 164 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 67, n° 173 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 116, n° 125.
4359 Voir art. 878 du Code civil français. Voir également T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, p. 53, n° 74 et R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 116, n° 125 qui la rapprochent du privilège de séparation des patrimoines de l'ancien article 878 du Code civil français.
4360 M. GERMAIN, *op. cit.*, p. 2.
4361 Voir en ce sens : T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, p. 52, n° 71 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 116, n° 125.
4362 T.N.V. NGUYEN, *ibidem*, p. 52, n° 71.
4363 Voir à ce sujet : J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 66, n° 172.

Ainsi, seuls les créanciers disposant d'une créance certaine, liquide et exigible antérieure à la publication régulière du projet de scission pourront s'en prévaloir[4364]. L'exigence d'antériorité se justifie par le fait que les créanciers ayant contracté avec la société après la publication du projet de scission l'ont fait en pleine connaissance de cause[4365], mais, ce faisant, elle occulte totalement la situation délicate des créanciers délictuels subissant un dommage causé par la société entre la publication du projet de scission et la date de prise d'effet de l'opération. Cette exclusion critiquable a incité à plaider en faveur d'une exclusion des créances délictuelles de cette condition d'antériorité[4366]. En tout état de cause, on peut relever qu'une telle approche aurait l'avantage de la cohérence car les créanciers délictuels de la dernière heure ne sont pas exclus du bénéfice de la solidarité par défaut des sociétés bénéficiaires consacré par l'article L236-20 du Code de commerce français. Pour ce qui est de la condition d'exigibilité, il a été remarqué à juste titre qu'elle vidait le droit d'opposition de tout intérêt puisque les titulaires de créances exigibles disposent déjà d'autres voies d'exécution[4367]. En outre, un arrêt de la Cour de cassation a strictement limité le droit d'opposition aux titulaires d'une créance de somme d'argent[4368], excluant *de facto* tous les créanciers d'une obligation de donner et de faire[4369]. Cette dernière restriction découle d'une interprétation restrictive du terme « rembourser » figurant à l'article L236-14 du Code de commerce français[4370]. Elle a en outre fait l'objet d'une tentative de justification sur la base du fait que la violation d'une obligation de faire entraîne en principe une exécution forcée en nature qui, par essence, n'est pas affectée par une modification du patrimoine de la société débitrice[4371]. Cependant, force est de constater qu'une telle position ne saurait être tenue dans un contexte transfrontalier dans la mesure où le changement de *lex societatis* qui en découle pourrait indiscutablement affecter le créancier d'une obligation de faire, par exemple si l'exécution forcée en nature n'est pas la solution privilégiée par le droit de l'État membre d'accueil ou encore si les frais de justice sont habituellement laissés à la charge du demandeur. Par ailleurs, ces restrictions ne se retrouvent pas dans les dispositions de la Directive Sociétés relatives aux fusions[4372] et

4364 El. ALFANDARI et M. JEANTIN, « Fusion de coopératives. Domaine d'application du droit d'opposition », *RTD com.*, 1993, p. 335, disponible sur www.dalloz.fr (06/12/2019), p. 1 ; P. LE CANNU et Br. DONDERO, *op. cit.*, pp. 1012 et 1013, n° 1642 ; B. LECOURT, « Décret n° 2006-448 du 14 avril 2006 relatif à la société européenne », *Rev. Soc.*, p. 439, disponible sur www.dalloz.fr (06/12/2019), p. 2 ; B. LECOURT, « Adoption de la directive sur les fusions transcommunautaires », *op. cit.*, p. 3 ; B. LECOURT, « L'avenir du droit français des sociétés », *op. cit.*, p. 4, n° 18 ; T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, p. 38, n° 42 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 112–114, n° 122 et Cass. com, 21 janvier 2004, n° 00-14.549, *RJDA*, 6/04, n° 712 et Cass. com., 16 juillet 1985, *Bull. civ. IV*, n° 218.

4365 T.N.V. NGUYEN, *ibidem*, p. 34, n° 38 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 112, n° 122.

4366 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 112, n° 122.

4367 M. GERMAIN, *op. cit.*, p. 2 et R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 113, n° 122.

4368 El. ALFANDARI et M. JEANTIN, *op. cit.*, p. 1 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 66, n° 172 ; T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, p. 34, n° 39 et R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 110, n° 121 et Cass. com., 12 juillet 1992, *Bull. Joly*, 1992, p. 1111.

4369 El. ALFANDARI et M. JEANTIN, *ibidem*, p. 1 ; J.-M. MOULIN, *ibidem*, p. 66, n° 172 et T.N.V. NGUYEN, *ibidem*, pp. 34–38, n°s 39–41.

4370 El. ALFANDARI et M. JEANTIN, *ibidem*, p. 1 ; M. GERMAIN, *op. cit.*, p. 2 ; T.N.V. NGUYEN, *ibidem*, p. 36, n° 40 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 111, n° 121.

4371 R. RAFFRAY, *ibidem*, pp. 110–112, n° 121.

4372 Art. 99 de la Directive Sociétés.

aux scissions internes[4373], de sorte qu'on est en droit de s'interroger sur leur conformité au droit européen[4374]. Le même constat vaut à l'égard des dispositions de la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières[4375], de fusions transfrontalières[4376] et de transformations transfrontalières[4377]. Malgré tout, force est de constater que ces restrictions n'en sont pas moins appliquées par les cours et tribunaux, anéantissant dès lors tout intérêt du droit d'opposition pour diverses catégories de créanciers.

827. Une mesure judiciaire *ab initio*. Au-delà des limites spécifiques développées par la jurisprudence française, l'opposition, en ce qu'elle doit dans tous les cas être portée devant le tribunal de commerce[4378], présente une certaine lourdeur[4379]. *A contrario*, en droit belge, les créanciers adressent en priorité leur demande à la société et ce n'est qu'en cas de désaccord ou si le créancier n'a pas obtenu satisfaction que la contestation pourra être soumise au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice[4380]. Si cet aspect de la procédure d'opposition française a pu être expliqué par la volonté du législateur de limiter l'opposition en vue de faciliter les opérations de restructuration[4381], il est indéniable qu'il nuit à l'efficacité de cette mesure et, en augmentant d'office le coût par rapport à une procédure où le juge n'intervient qu'en cas de désaccord entre la société et le créancier, il amplifie le phénomène d'apathie rationnelle.

828. La nécessité d'intervenir à bref délai. Le droit d'opposition ne pourra être exercé que dans un délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de scission sur le site internet de chacune des sociétés impliquées[4382]. En outre, une inscription irrégulière empêchera le délai de courir pour peu que l'irrégularité en question ait eu pour effet direct d'empêcher le créancier de faire usage de son droit d'opposition[4383]. Ce délai d'action, particulièrement bref, s'il s'explique par la volonté de régler rapidement toutes les contestations relatives à une scission[4384], a pour conséquence de nuire considérablement à la protection des créanciers en rendant le recours au droit d'opposition « *presque illusoire* »[4385].

829. Une inopposabilité relative. Contrairement à la solidarité par défaut des sociétés bénéficiaires pour les dettes de la société scindée[4386], l'inopposabilité

4373 Art. 146 de la Directive Sociétés.
4374 Voir en ce sens : M. GERMAIN, *op. cit.*, p. 2 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 66, n° 172 ; T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, p. 40, n° 44 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 113, n° 122.
4375 Art. 160*undecies* de la Directive Mobilité.
4376 Art. 126*ter* de la Directive Mobilité.
4377 Art. 86*undecies* de la Directive Mobilité.
4378 Art. R236-8 du Code de commerce français.
4379 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 101, n° 111.
4380 Art. 12:15, § 1er, al. 1–3 du CSA.
4381 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 101, n° 111.
4382 Art. R236-8, § 1er du Code de commerce français.
4383 Cass. com., 4 juin 1996, *Bull. Joly*, 1996, p. 932 pour l'hypothèse de la mention erronée du siège social.
4384 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 103, n° 113.
4385 *Ibidem*.
4386 Art. L236-20 du Code de commerce français.

ne profitera qu'au seul créancier qui aura fait usage de son droit d'opposition[4387]. Il s'ensuit que seuls les créanciers actifs, vigilants et disposant de moyens suffisants pourront en bénéficier, ce qui réduit considérablement l'intérêt de ce mécanisme. En effet, ce dernier ne protégera efficacement que les grands créanciers contractuels qui auront de toute façon généralement pris soin de se mettre à l'abri au moyen de mécanismes de protection contractuels[4388].

830. Une mesure potentiellement disproportionnée. Si la faculté dont jouit le tribunal d'ordonner le remboursement de la créance litigieuse par la société débitrice présente une certaine originalité, on peut émettre de sérieux doutes quant à son caractère proportionné sous trois angles distincts. En effet, tout d'abord, à l'égard du délicat équilibre à réaliser entre les intérêts de la société et les intérêts des créanciers, il convient de relever que prononcer le remboursement immédiat de la créance fait pencher la balance dans le sens des créanciers en ce que cela améliore potentiellement leur situation. Cette conséquence négative du droit d'opposition a poussé la Cour de cassation française à estimer que seuls les créanciers titulaires d'une créance exigible pouvaient en bénéficier[4389], mais ce faisant, elle a généré une inégalité de traitement difficilement défendable entre les créanciers à terme ou sous condition et les titulaires de créances exigibles[4390]. Ensuite, une telle mesure entraînera nécessairement un *cash-out* pour les sociétés impliquées dans l'opération. Or, cette perte de liquidités aggravera nécessairement la situation des créanciers ayant choisi de ne pas faire usage de leur droit d'opposition ou ignorant tout simplement leur qualité de créancier, comme par exemple dans le cas de dégâts environnementaux uniquement décelables après la réalisation de la scission. Si on ajoute à cela que ces créanciers potentiellement lésés sont généralement les petits créanciers et les créanciers contractuels, c'est-à-dire ceux qui justement nécessitent davantage de protection, on aboutit au constat que cette mesure est foncièrement contre-productive. Pour finir, il est indéniable que le droit d'opposition tel que consacré par le droit français est de nature « dissuader »[4391] un bénéficiaire de la liberté d'établissement d'en faire usage et constitue par conséquent une entrave en principe prohibée[4392]. Il s'ensuit que pour être admise, elle devra remplir les conditions du « *Gebhard test* »[4393] et en particulier l'exigence de proportionnalité. Or à cet égard, force est de constater que l'existence de mesures moins intrusives, tel que l'octroi de garanties adéquates ordonné même en l'absence d'une proposition en ce sens par la société concernée, et qui n'impliquent pas une perte de liquidités immédiate, génère de sérieux doutes quant à la compatibilité du régime du droit d'opposition avec la liberté d'établissement telle qu'interprétée par la Cour de justice.

831. Un bilan mitigé. L'étude du droit d'opposition tel qu'il existe en droit français ainsi que la mise en lumière de ses différentes limites expliquent

4387 Voir en ce sens : T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, p. 45, n° 57 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 117, n° 125.
4388 Sur les différents mécanismes contractuels qui peuvent être mis en place, voir *infra* n°s 849 à 882.
4389 T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, p. 39, n° 43 et Cass. com, 21 janvier 2004, n° 00-14.549, *RJDA*, 6/04, n° 712 et Cass. com., 16 juillet 1985, *Bull. civ. IV*, n° 218.
4390 M. GERMAIN, *op. cit.*, p. 2 et T.N.V. NGUYEN, *ibidem*, p. 39, n° 43.
4391 Arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 45 et arrêt *Daily Mail*, pt. 16.
4392 À ce sujet, voir *supra* n° 131.
4393 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.

pourquoi l'opposition n'est que rarement mise en œuvre en pratique[4394] et a été fortement critiquée par la doctrine française[4395]. Malgré ses insuffisances manifestes, le mécanisme d'opposition en droit français présente un aspect intéressant à l'égard de l'élaboration d'un régime efficace de protection des créanciers dans le cadre des scissions transfrontalières, à savoir la possibilité pour les sociétés impliquées d'écarter la solidarité dans le projet commun de scission moyennant la mise en place d'autres mécanismes de protection[4396]. Il est indéniable que le droit d'opposition existant en droit français et qui vient combler le vide laissé par l'écartement de la solidarité est foncièrement insuffisant à protéger efficacement les petits créanciers, mais l'idée d'introduire une certaine flexibilité pour les sociétés impliquées peut présenter un certain intérêt. En effet, l'existence du seul risque d'une solidarité passive pour une des sociétés bénéficiaires peut lui porter préjudice non seulement à elle, mais également à ses associés. À titre d'illustrations, on peut tout à fait concevoir que ce risque de solidarité aura potentiellement un impact négatif sur l'accès de la société en question aux capitaux externes et, en cas de vente de la société, sera nécessairement mise en lumière dans le cadre de l'exercice de *due diligence* et aura un impact sur le prix de cession.

5. *La théorie de l'imprévision*

5.1. Le principe

832. Une théorie qui ne fait pas l'unanimité. L'imprévision peut être définie comme « un concept qui autorise la révision du contrat en cas de survenance, postérieurement à la conclusion du contrat, de circonstances présentant les caractéristiques suivantes : (i) être non imputables à la partie qui s'en prévaut, (ii) être imprévisibles et (iii) avoir pour effet le bouleversement de l'économie contractuelle »[4397]. En d'autres termes, la théorie de l'imprévision a pour objectif de remédier, à un « profond déséquilibre de l'économie du contrat »[4398] rendant la poursuite de celui-ci soit « plus onéreuse », soit « plus difficile » pour l'une des parties[4399] et constitue une dérogation au principe de la convention-loi[4400].

4394 Voir en ce sens : M. COZIAN, Al. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, *op. cit.*, pp. 818 et 819, n° 2268.

4395 El. ALFANDARI et M. JEANTIN, *op. cit.*, p. 1 ; B. LECOURT, « Décret n° 2006-448 du 14 avril 2006 relatif à la société européenne », *op. cit.*, p. 2 ; B. LECOURT, « Adoption de la directive sur les fusions transcommunautaires », *op. cit.*, p. 3 ; B. LECOURT, « L'avenir du droit français des sociétés », *op. cit.*, p. 4, n° 18 ; J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 66, n° 172 ; T.N.V. NGUYEN, *op. cit.*, pp. 27–55, n° 28–77 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 100–118, n°s 110–127.

4396 Art. L236-21 du Code de commerce français.

4397 O. CLEVENBERGH, *op. cit.*, p. 10, n° 12 ; Fl. GEORGE et J.-B-. HUBIN, « Chapitre 3 – La protection de la personne en situation de vulnérabilité par le droit des obligations et des contrats dans l'environnement numérique », in *Vulnérabilités et droits dans l'environnement numérique*, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 79 ; D. PHILIPPE, « À propos du déséquilibre du contrat et de l'obligation de renégociation », note sous Mons, 30 mai 2013, *J.L.M.B.*, 2014/23, p. 1087 ; D. PHILIPPE, « La force majeure et le hardship » in *Les principes UNIDROIT relatifs aux contrats de commerce international (Ed. 2010) et l'arbitrage / De UNIDROIT-principes inzake internationale handelscontracten (editie 2010) en arbitrage*, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 100 et D. PHILIPPE, « L'imprévision », *J.T.*, 2007/35, p. 738.

4398 Fl. GEORGE et J.-B-. HUBIN, *ibidem*, p. 79.

4399 Fr. GLANSDORFF, « La force majeure », *J.T.*, 2019, p. 355.

4400 L. BÖTTCHER in B. GRUNEWALD, G. MAIER-REIMER et K. P. WESTERMANN (dir.), *Bürgerliches Gesetzbuch*, 15e éd., Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 2017, p. 1410, n° 16.

En droit belge, la théorie de l'imprévision est traditionnellement rejetée[4401], malgré certaines brèches dans la jurisprudence de la Cour de cassation[4402] et bien qu'il ait été avancé qu'elle ait pu trouver à s'appliquer par le biais d'une interprétation plus permissive de la force majeure[4403]. Cependant, tout ceci est sur le point de changer dans la mesure où le législateur prévoit, dans le cadre de la création d'un nouveau Code civil belge, de reconnaître explicitement la théorie de l'imprévision[4404]. En droit français, la théorie de l'imprévision était en principe rejetée par la Cour de cassation[4405] et appliquée par le Conseil d'État[4406]. Cet état de fait a été bouleversé en 2016 par la reconnaissance de la théorie de l'imprévision dans le Code civil[4407], laquelle a été considérée comme « l'une des innovations majeures de la réforme opérée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 »[4408], même si on reste en droit de s'interroger sur son caractère véritablement opérationnel d'une part en raison de l'exigence de ses conditions d'application[4409] et d'autre part, en raison de son caractère supplétif

4401 Fl. GEORGE et J.-B-. HUBIN, *op. cit.*, pp. 80 et 81 ; S. GOLDMANN et S. LAGASSE, « Comment appréhender le déséquilibre contractuel en droit commun ? », in R. JAFFERALI (coord.), *Le droit commun des contrats. Questions choisies*, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 115, n° 54 et Fr. GLANSDORFF, *op. cit.*, p. 355 et Cass., 19 mai 1921, *Pas.*, 1921, I, p. 380 ; Cass. 14 avril 1994, *Pas.*, 1994, I, p. 365 et Cass., 20 avril 2006, *Pas.*, 2006, p. 884.

4402 Fl. GEORGE et J.-B-. HUBIN, *ibidem*, p. 81 et S. GOLDMANN et S. LAGASSE, *ibidem*, pp. 122 à 124, n°s 61 à 63 et Cass., 19 juin 2009, *Pas.*, 2009, p. 1590 ; Cass., 14 octobre 2010, *Pas.*, 2010, p. 2648 et Cass., 12 avril 2013, *R.G.D.C.*, 2013, p. 478. Voir plus spécifiquement à ce sujet : C. BIQUET-MATHIEU, « Soubresauts en matière d'imprévision. Les arrêts des 19 juin 2009 et 14 octobre 2010 », *Rev. Dr. ULg.*, 2012, pp. 239–257 et D. PHILIPPE, « À propos du déséquilibre du contrat et de l'obligation de renégociation », *op. cit.*, pp. 1083–1094.

4403 Fl. GEORGE et J.-B-. HUBIN, *ibidem*, pp. 80 et 81 ; Fr. GLANSDORFF, *ibidem*, p. 355 et S. GOLDMANN et S. LAGASSE, *ibidem*, pp. 117 et 118, n° 57. Pour un cas d'illustration, voir : Gand, 2 avril 2012, *N.J.W.*, 2013, p. 32.

4404 Voir Proposition de loi portant le Livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc. parl., *Ch.*, 2020–2021, n° 55-1806/001, pp. 84 à 86, art. 5.74 et Proposition de loi portant insertion du livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil, *Doc.*, Ch., 2018–2019, n° 54-3709/001, pp. 84 à 86, art. 5.74. Voir à ce sujet : M. DE POTTER DE TEN BROECK, « De imprevisieleer : de rechter met de pen in de hand », *RW*, 2 juin 2018, n° 40, pp. 1563–1575 ; Fl. GEORGE et J.-B-. HUBIN, *ibidem*, pp. 84 et 86 et D. PHILIPPE, « L'introduction de l'imprévision en droit belge », in *Le droit des affaires en évolution – Le droit civil en mouvement / Tendensen in het bedrijfsrecht – Het burgerlijk recht in beweging*, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 55–68.

4405 P. ANCEL, *op. cit.*, pp. 568 et 569, n° 486 et D. PHILIPPE, « L'imprévision », *op. cit.*, p. 739 et Cass. civ., 6 mars 1876, *Recueil Dalloz*, 1876, I, p. 193.

4406 P. ANCEL, *ibidem*, pp. 568 et 569, n° 486 et D. PHILIPPE, *ibidem*, p. 739 et C.E. France, 30 mars 1916, *Recueil Lebon*, p. 143.

4407 L'art. 1195 du Code civil français prévoit ainsi que « [s]i un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

4408 Ch.-E. BUCHER, « Les clauses portant sur l'imprévision », *Contrats Concurrence Consommation*, n° 3, mars 2019, form. 3, disponible sur www.lexis360.fr (08/01/2020), p. 1.

4409 J.-S. BORGHETTI, « Fixation et révision du prix », *RDC*, hors-série juin 2018, p. 25, disponible sur www.lextenso.fr (08/01/2020), p. 8 selon lequel « *l'article 1195 aura sans doute très peu l'occasion d'être appliqué* ». Voir également : Ph. STOFFEL-MUNCK, « L'imprévision et la réforme des effets du contrat », *RDC*, hors-série avril 2016, p. 30, disponible sur www.lextenso.fr (08/01/2020), pp. 3–5

entraînant son exclusion conventionnelle fréquente en pratique[4410]. En droit luxembourgeois, la position est celle qui était traditionnellement adoptée par la Cour de cassation française[4411], même si un arrêt de la Cour de cassation semble avoir amorcé un changement[4412]. En revanche, une évolution législative à cet égard se fait encore attendre[4413]. Si la reconnaissance de la théorie de l'imprévision dans les pays de tradition civiliste semble pour le moins laborieuse, elle est en revanche explicitement reconnue de longue date dans d'autres droits nationaux, tels que le droit allemand[4414] où la théorie de l'imprévision y a été reconnue à la suite de la Première Guerre Mondiale et des fluctuations monétaires qui s'en sont suivi[4415]. À titre d'illustration, il en est également ainsi en droit italien[4416] ou encore en droit anglais[4417]. Il est dès lors intéressant de se pencher sur la question de savoir si une fusion ou une scission pourrait, soit globalement, soit dans certains cas particuliers, être considérée comme un bouleversement de circonstances justifiant une adaptation du contrat initial, voire l'octroi au créancier impacté d'un droit à résiliation unilatéral en se concentrant sur l'exemple allemand qui a l'indéniable avantage d'être très élaboré.

833. « *Störung der Geschäftsgrundlage* » et restructurations en droit allemand. En droit allemand, il est ainsi possible pour une partie à un contrat de réclamer l'adaptation de la convention si les circonstances ayant servi de base au contrat subissent une modification substantielle et que les parties n'auraient pas conclu de contrat ou n'auraient pas conclu aux mêmes conditions si elles avaient pu prévoir ce changement, pour autant qu'il ne puisse être attendu d'une partie qu'elle continue d'exécuter le contrat inchangé en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas d'espèce et en particulier de la répartition contractuelle ou légale des risques[4418]. En outre, si une adaptation du contrat n'est pas possible ou ne peut être attendue d'une partie, dans ce cas

et L. VOGEL et J. VOGEL, « Possibilités, limites et exclusions du recours à la théorie de l'imprévision dans la crise du Covid-19 », *AJ contrat*, 2020, p. 275, disponible sur www.dalloz.fr (04/11/2020), pp. 4 et 5.

4410 Voir en ce sens : J.-S. BORGHETTI, *ibidem*, p. 8 et D. HOUTCIEFF, « La révision pour imprévision résiste-t-elle au droit des contrats spéciaux ? », *Gaz. Pal.*, 7 avril 2020, n° 14, p. 36, disponible sur www.lextenso.fr (08/01/2020), p. 1.

4411 P. ANCEL, *op. cit.*, p. 570, n° 487 ; D. SPIELMANN et H. DUPONG, « Quelques réflexions sur la théorie de l'imprévision », in *Le bicentenaire du Code civil : une contribution luxembourgeoise*, Luxembourg, Portalis, 2008, pp. 150 et 151 et A. PRÜM, « Faut-il réformer le droit luxembourgeois des contrats ? - Contribution pour les Mélanges en l'honneur du professeur Claude Witz », Luxembourg Faculty of Law, Economics and Finance, *Law working paper series*, Paper number 2018-005, 2 mai 2018, disponible sur https://papers.ssrn.com (14/01/2020), p. 12.

4412 Cass., 24 octobre 2013, n° 64/13, *Pas.*, 36, p. 393, note P. ANCEL et, en ce sens, P. ANCEL, *ibidem*, p. 570, n° 487 et A. PRÜM, *ibidem*, p. 12.

4413 Voir à ce sujet la lettre d'André PRÜM au gouvernement luxembourgeois du 12 novembre 2018, disponible sur https://gouvernement.lu (11/01/2019) et, de manière plus générale, A. PRÜM, *ibidem*, pp. 1–23.

4414 § 313 BGB.

4415 Sur l'origine ancienne de la théorie de l'imprévision en droit allemand qui remonte au début du XXe siècle, voir P. ANCEL, *op. cit.*, pp. 566 et 567, n° 484 et L. BÖTTCHER in B. GRUNEWALD, G. MAIER-REIMER et K. P. WESTERMANN (dir.), *op. cit.*, pp. 1406–1408, n°s 1–5.

4416 Art. 1467 du *Codice civile* italien.

4417 Cette reconnaissance de la théorie de l'imprévision se fait par le biais de la « *frustration* ». Voir à ce sujet : P. ANCEL, *op. cit.*, pp. 566 et 567, n° 484 ; D. PHILIPPE, « L'imprévision », *op. cit.*, p. 739 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 364 et 365, n° 855.

4418 § 313(1) BGB.

la partie désavantagée disposera de la possibilité de se retirer du contrat[4419]. L'application de cette disposition à l'hypothèse d'une fusion ou d'une scission est généralement admise[4420].

834. Une scission transfrontalière : un bouleversement de l'économie contractuelle ? Il restera toutefois encore à vérifier si en l'occurrence, les conditions de l'imprévision selon le § 313(1) BGB seront bien réunies[4421]. Or à cet égard, pour que ce dernier trouve à s'appliquer à une relation contractuelle, il faudra :

(i) une modification substantielle de l'économie du contrat, ce qui sera généralement le cas si on ne peut raisonnablement remettre en cause le fait qu'une des parties n'aurait pas conclu ou n'aurait pas conclu aux mêmes conditions si elle avait connu l'existence de ces circonstances[4422]. À l'égard des scissions transfrontalières, cette première condition serait aisément remplie en raison des nombreux risques qu'une telle opération fait peser sur les créanciers de la société scindée[4423] ;

(ii) cette modification substantielle de l'économie du contrat ne tombe pas dans la sphère des risques acceptés par la partie qui s'en prévaut. Cette condition implique également qu'une partie ne pourra en principe pas se prévaloir d'un bouleversement de circonstances dont elle est à l'origine[4424]. *A contrario*, le fait que le bouleversement de circonstances soit imputable à une des parties pourra jouer en faveur de l'autre partie[4425]. En outre, une modification substantielle ne sera pas prise en compte s'il s'avère qu'elle était prévisible[4426]. Or, à cet égard, force est de constater que les modifications structurelles susceptibles d'impacter une personne morale font partie des risques habituels liés aux contrats impliquant des personnes morales[4427], comme en témoigne la grande diversité de clauses développées par la pratique pour s'en prémunir[4428]. En conséquence, il peut être défendu que le risque qu'une contrepartie procède à une scission transfrontalière est prévisible[4429], ce qui exclurait l'application de la théorie de l'imprévision. La question devra certainement être examinée au cas par cas, étant entendu qu'il sera beaucoup plus difficile d'argumenter qu'une

4419 § 313(3) BGB.

4420 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 9 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 1 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 10 ; St. SIMON in B. DAUNER-LIEB et St. SIMON (dir.), *Kölner Kommentar zum UmwG*, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2009, p. 444, n° 1 et M. WINTER in J. SCHMITT, R. HÖRTNAGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 37.

4421 Sur les conditions générales de la théorie de l'imprévision en droit allemand, voir : L. BÖTTCHER in B. GRUNEWALD, G. MAIER-REIMER et K. P. WESTERMANN (dir.), *op. cit.*, pp. 1409–1416, n°s 11–39 et St. LORENZ in H.G. BAMBERGER, W. HAU, R. POSECK et H. ROTH (dir.), *Bürgerliches Gesetzbuch – Kommentar*, 4e éd., 2019, pp. 2164–2178, n°s 23–81.

4422 St. LORENZ in H.G. BAMBERGER, W. HAU, R. POSECK et H. ROTH (dir.), *ibidem*, p. 2164, n° 23.

4423 À ce sujet, voir *supra* n°s 695 à 704.

4424 St. LORENZ in H.G. BAMBERGER, W. HAU, R. POSECK et H. ROTH (dir.), *op. cit.*, p. 2165, n° 27.

4425 *Ibidem*.

4426 L. BÖTTCHER in B. GRUNEWALD, G. MAIER-REIMER et K. P. WESTERMANN (dir.), *op. cit.*, pp. 1412 et 1413, n° 24 et St. LORENZ in H.G. BAMBERGER, W. HAU, R. POSECK et H. ROTH (dir.), *ibidem*, p. 2165, n° 28.

4427 Voir en ce sens : N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 8.

4428 Sur les aménagements conventionnels, voir *infra* n°s 849 à 882.

4429 Voir en ce sens à propos des fusions et scissions internes : N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 8.

scission était imprévisible si la société s'est déjà livrée à des opérations de restructuration internes ou transfrontalières par le passé et que la partie qui se prévaut de l'imprévision a omis de se protéger au moyen de clauses contractuelles adéquates[4430] ; et

(iii) qu'imposer à une partie de poursuivre l'exécution de la convention telle qu'initialement prévue aboutirait à un résultat inacceptable aux yeux du droit et de l'équité en faisant peser une charge excessivement onéreuse sur une des parties[4431]. Cette appréciation dépendra fondamentalement des circonstances propres à chaque cas d'espèce, mais il est néanmoins intéressant de relever que lors de ce délicat exercice, il faudra également tenir compte des éventuels avantages qu'une partie tire des circonstances nouvelles ayant bouleversé l'équilibre contractuel. Dans le cas particulier des scissions transfrontalières, compte tenu du fait qu'elles sont susceptibles de permettre à une société d'assainir sa situation financière[4432], cette mise en balance des avantages et inconvénients s'avérera particulièrement délicate à réaliser.

Si ces différentes conditions ne sont certes pas aisées à remplir, la théorie de l'imprévision est malgré tout susceptible de présenter une utilité non négligeable lorsqu'il s'avère que la protection par le biais de l'octroi d'une garantie adéquate n'est pas suffisante pour protéger un créancier[4433]. En effet, dans une telle hypothèse, l'octroi d'un droit à résiliation unilatérale sur la base de la théorie de l'imprévision pourra s'avérer être une solution plus satisfaisante[4434].

835. L'imprévision, une arme à double tranchant ? Si dans certaines circonstances, le recours à la théorie de l'imprévision pour garantir la protection des créanciers d'une société impliquée dans une scission transfrontalière peut être retenu, il convient de ne pas perdre de vue qu'une société bénéficiaire pourrait potentiellement également l'invoquer à l'encontre d'un créancier de la société scindée. En droit allemand, le § 22 UmwG prévoit ainsi expressément que si à la suite de l'opération, des obligations de retrait ou d'approvisionnement ou des obligations similaires issues de contrats synallagmatiques qui n'ont pas encore été exécutés par aucune des parties au moment de l'opération devaient se rencontrer, et qu'elles s'avéraient incompatibles ou que leur exécution commune représentait une lourde iniquité pour la société bénéficiaire, dans ce cas, l'étendue des obligations qui pèseront sur la société bénéficiaire se déterminera selon des considérations d'équité en tenant compte des droits contractuels de toutes les sociétés impliquées. Cette application particulière de la théorie de l'imprévision consacrée de manière générale par le § 313 BGB[4435] vise

4430 Sur l'acceptation du risque du fait de l'absence d'aménagement conventionnel des conséquences d'une opération sur le contrat : St. LORENZ in H.G. BAMBERGER, W. HAU, R. POSECK et H. ROTH (dir.), *op. cit.*, p. 2165, n° 28.

4431 St. LORENZ in H.G. BAMBERGER, W. HAU, R. POSECK et H. ROTH (dir.), *ibidem*, p. 2166, n° 31.

4432 À ce sujet, voir *supra* n°s 53 à 55 et 700.

4433 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 54 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 11.

4434 *Ibidem*.

4435 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 2 et St. SIMON in B. DAUNER-LIEB et St. SIMON (dir.), *op. cit.*, p. 444, n° 1. *Contra* : M. WINTER in J. SCHMITT, R. HÖRTNAGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 1.

principalement à simplifier la réalisation d'une fusion ou d'une scission[4436] et à protéger la société bénéficiaire contre des engagements de non-concurrence ainsi que contre des obligations de livraison ou d'approvisionnement exclusifs qu'il lui serait impossible ou excessivement onéreux de respecter[4437]. Au niveau du champ d'application de cette disposition spécifique, il est utile de préciser que la condition de similitude aux obligations de livraison ou de retrait qui semble avoir été posée ne doit pas être appréciée trop rigoureusement[4438]. Il s'ensuit qu'un tiers pourrait voir les obligations de son nouveau débiteur allégées à la suite d'une scission. Il convient toutefois de remarquer qu'il a été avancé que comme l'opération tombait dans la sphère des risques de la société bénéficiaire, ses intérêts devaient être moins pris en compte que ceux du tiers impacté[4439]. En outre, la preuve de l'incompatibilité ou de l'iniquité sévère incombera à la société bénéficiaire qui s'en prévaut[4440]. Si les conditions sont réunies, la société bénéficiaire procédera aux modifications nécessaires et les notifiera au créancier impacté[4441]. Toutefois, si le créancier impacté ne juge pas celles-ci équitables, il disposera de la possibilité de les contester devant la juridiction compétente[4442]. En dehors du champ d'application particulier de ce mécanisme spécifique, il convient encore de relever qu'une société bénéficiaire disposera également de la possibilité de se prévaloir de la théorie générale de l'imprévision reposant sur le § 313 BGB[4443], tout en précisant que la tâche sera relativement ardue dans la mesure où la scission est un risque que la société bénéficiaire doit assumer[4444].

5.2. Les limites

836. Un mécanisme de protection exceptionnel. Au-delà des limites évidentes liées à sa difficile reconnaissance au sein des différents droits nationaux des État membres, la théorie de l'imprévision souffre de certaines insuffisances additionnelles qui ne manqueront pas d'impacter son efficacité dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière. Ainsi, tout d'abord, le recours à ce mécanisme de protection présuppose un comportement actif de la part de créanciers, ce qui est à nouveau propice à l'émergence d'un phénomène d'apathie rationnelle.

4436 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 21, n° 5.
4437 N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 3 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 4 et M. WINTER in J. SCHMITT, R. HÖRTNAGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 3.
4438 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 4 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 21, n° 4 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 21, n° 4 et St. SIMON in B. DAUNER-LIEB et St. SIMON (dir.), *op. cit.*, p. 445, n° 6.
4439 Voir en ce sens : St. SIMON in B. DAUNER-LIEB et St. SIMON (dir.), *ibidem*, p. 446, n° 11. Voir également N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 7 qui insiste sur la nécessité de protéger les intérêts du tiers impacté.
4440 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 5 et M. WINTER in J. SCHMITT, R. HÖRTNAGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 9.
4441 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 21, n° 7.
4442 *Ibidem*.
4443 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 4 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 21, n° 8 et St. SIMON in B. DAUNER-LIEB et St. SIMON (dir.), *op. cit.*, p. 446, n° 13.
4444 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 21, n° 9.

Ensuite, cette théorie, en ce qu'elle repose sur la volonté des parties[4445], ne se conçoit que dans le cadre de l'existence d'une relation contractuelle[4446], ce qui exclut de pouvoir protéger par ce moyen les créanciers délictuels potentiellement impactés par une scission transfrontalière. En outre, si l'application de la théorie de l'imprévision à l'hypothèse d'une scission transfrontalière est tout à fait concevable[4447], les conditions de celle-ci, telles que l'exclusion des risques prévisibles et le seuil élevé du déséquilibre contractuel, font qu'elle ne trouvera à s'appliquer que dans des cas exceptionnels[4448].

6. La gestion séparée des patrimoines

6.1. Le principe

837. Aux origines des scissions. Une solution additionnelle qui permettrait de remplir de prime abord l'objectif de neutralité de l'opération à l'égard des créanciers consiste à imposer aux sociétés bénéficiaires de gérer séparément leur propre patrimoine et la fraction de celui de la société scindée qui lui a été apportée soit jusqu'à ce que les créanciers de la société scindée soient payés, soit jusqu'à l'écoulement d'un délai déterminé. Loin d'être originale, cette solution était assez fréquente par le passé. À titre d'illustration, un tel mécanisme de gestion séparée existait en droit autrichien avant l'entrée en vigueur de l'AktG 1937[4449][4450]. Cette solution rappelle en outre le régime applicable en droit belge aux fusions et scissions avant l'adoption de la loi du 29 juin 1993[4451] qui prévoyait que la transmission universelle ou à titre universel dont s'accompagne ce type d'opérations n'emportait pas transmission des dettes sans l'accord du créancier, avec pour corollaire le fait que le créancier conservait la société absorbée comme débitrice pendant une durée de cinq ans suivant sa liquidation[4452]. Elle se retrouvait également sous une forme assez élaborée en droit suisse en matière de fusions[4453] avant l'adoption de la Loi suisse sur la fusion et la scission[4454]. Il était alors prévu que l'actif de la société dissoute ferait l'objet d'une administration séparée par la société reprenante jusqu'au moment où les créanciers auraient été payés ou auraient reçu des sûretés et ce, sous la responsabilité personnelle et solidaire des membres du conseil d'administration

4445 L. BÖTTCHER in B. GRUNEWALD, G. MAIER-REIMER et K. P. WESTERMANN (dir.), *op. cit.*, pp. 1409, n° 11.
4446 Voir à ce sujet à propos du § 313 BGB : L. BÖTTCHER in B. GRUNEWALD, G. MAIER-REIMER et K. P. WESTERMANN (dir.), *ibidem*, pp. 1409–1410, n°s 11–15.
4447 Voir en ce sens à propos des fusions et scissions internes : M. WINTER in J. SCHMITT, R. HÖRTNAGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 37.
4448 Voir en ce sens : N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 21, n° 9.
4449 Art. 160*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
4450 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 333, n° 2.
4451 Message du conseil fédéral suisse concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 13 juin 2000, n° 00.052, disponible sur https://www.admin.ch (12/12/2019), p. 4000.
4452 P. HAINAUT-HAMENDE, *op. cit.*, n° 848. Pour des cas d'application, voir : Mons, 17 mai 1988, *J.L.M.B.*, 1988, p. 1314 ; Liège 30 juin 1989, *RPS*, 1990, p. 173 et Liège, 5 octobre 1989, *RPS*, 1990, p. 176.
4453 Art. 748 du Code des obligations suisse dans sa version en vigueur au 25 juin 2002, disponible sur https://www.admin.ch (12/12/2019).
4454 Les art. 25 et 46 de la Loi suisse sur les fusions et scissions ont abandonné la gestion séparée des patrimoines comme mécanisme de protection des créanciers.

de la société reprenante, étant entendu que le for de la société dissoute subsistait pour toute la durée de l'administration séparée. Cet actif administré séparément était encore considéré comme celui de la société dissoute dans les rapports des créanciers de cette dernière, ceux de la société bénéficiaire et la société bénéficiaire elle-même. En outre, il formait, en cas de faillite, une masse distincte exclusivement employée à désintéresser les créanciers de la société dissoute[4455]. Cette forme de protection des créanciers n'appartient toutefois pas qu'au passé et existe encore en droit polonais à l'égard des fusions transfrontalières. Il y est ainsi prévu que lorsque la société absorbante est une société polonaise, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de prise d'effet de l'opération disposent de la possibilité dans un délai de six mois suivant la publication de la réalisation de l'opération de demander le paiement de leur créance et que le patrimoine de chacune des sociétés absorbées devra être géré séparément par la société bénéficiaire jusqu'à ce que les créanciers en question aient été payés ou aient obtenu une garantie[4456].

6.2. Les limites

838. Une mesure de protection dépassée. S'il est indéniable que ce mécanisme de la gestion séparée du patrimoine de la société scindée présente une certaine logique dans le cadre de la protection des créanciers en ce qu'il suspend la confusion des fractions du patrimoine de la société scindée avec les patrimoines des sociétés bénéficiaires, il prête néanmoins le flanc à la critique sous trois angles distincts. Tout d'abord, il s'agit d'une protection archaïque remontant au temps où les frontières de la notion de scission étaient floues et difficiles à appréhender et qui, dans les faits, revient à supprimer le principal effet de la scission. Du point de vue des personnes morales concernées, il s'agit d'une mesure particulièrement intrusive de nature à les dissuader de réaliser une scission transfrontalière. Compte tenu d'une part, de la protection de ces dernières par la liberté d'établissement[4457] et, d'autre part, de l'existence de moyens de protection moins intrusifs, tels que la possibilité de demander des garanties adéquates, on peut sérieusement douter de la compatibilité de la gestion séparée des patrimoines avec la liberté d'établissement. Ensuite, compte tenu des divergences entre les normes comptables appliquées dans les différents États membres[4458], se posera inévitablement la question des normes comptables à appliquer à la fraction du patrimoine de la société scindée. Faudra-t-il lui appliquer les règles potentiellement divergentes des sociétés bénéficiaires ou, au contraire, s'en tenir aux normes appliquées par la société scindée ? Cette question montre à quel point une gestion séparée des patrimoines est une mesure

[4455] Art. 758, n° 5 du Code des obligations suisse dans sa version en vigueur au 25 juin 2002, disponible sur https://www.admin.ch (12/12/2019).

[4456] Art. 495 et 496 du Code des associations et des sociétés commerciales polonais, version anglaise disponible sur https://supertrans2014.files.wordpress.com (18/07/2019) et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 57, ainsi que pp. 768 et 769 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 59.

[4457] À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.

[4458] Sur l'impact des divergences entre les règles comptables appliquées par les différents États membres en cas de fusions transfrontalières, voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 65 et 66.

de protection inadéquate dans un contexte transfrontalier[4459]. Troisièmement et dernièrement, cette solution n'est pas adaptée aux opérations en chaîne. Ainsi, dans l'hypothèse de la scission d'une société bénéficiaire d'une première scission, les sociétés qui recueilleront une fraction du patrimoine de celle-ci seront dans l'obligation de gérer séparément non seulement les fractions du patrimoine de la société scindée qu'elles recueilleront, mais également les fractions de patrimoine déjà gérées séparément par la société scindée. La complexité de ce mécanisme de protection, déjà élevée dans l'hypothèse d'une scission isolée, s'intensifie donc encore davantage en cas d'opérations successives. Le maintien fictif de la société scindée qui se retrouve à errer dans les limbes soit jusqu'à l'écoulement d'un délai particulier, soit jusqu'à la satisfaction des créanciers n'est par conséquent pas une solution satisfaisante, ne fût-ce qu'en raison des difficultés pratiques qu'elle engendre[4460], ce qui explique au moins en partie le manque d'enthousiasme à son égard dans le cadre des fusions transfrontalières de la part des différents *stakeholders* interrogés lors de la consultation de 2015[4461]. Dans le cadre de l'élaboration d'un régime efficace de protection des créanciers en cas de scission transfrontalière, un tel mécanisme de protection obsolète n'a donc plus sa place.

7. *La responsabilité solidaire des membres de l'organe de gestion de la société scindée*

7.1. Le principe

839. Un régime de responsabilité spécifique. Tant en matière de fusions internes[4462] que de scissions internes[4463], la Directive Sociétés prévoit l'obligation pour les États membres d'organiser un régime de responsabilité civile des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société absorbée ou scindée pour les fautes commises lors de la préparation et de la réalisation de l'opération envers les seuls associés. Cependant, bien avant l'introduction de ce régime particulier, certains États membres, comme l'Autriche[4464] et l'Allemagne[4465], connaissaient déjà un régime de protection spécifique

4459 Des problèmes similaires seraient susceptibles d'apparaître également dans un contexte purement interne dès l'instant où les sociétés disposent d'un choix entre différentes normes comptables, comme en droit luxembourgeois où les sociétés peuvent établir leurs comptes en Lux GAAP, en LUX GAAP avec l'option juste valeur ou en IFRS. Voir art. 51, § 1er, 64*bis*, 64*sexies* et 72*bis* de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, disponible en version coordonnée sur www.lbr.lu (07/11/2021).

4460 Message du conseil fédéral suisse concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 13 juin 2000, n° 00.052, disponible sur https://www.admin.ch (12/12/2019), p. 4079.

4461 Dans le cadre de la consultation de 2015 sur les fusions et scissions transfrontalières, seuls 26 % des personnes s'étant prononcées sur cette question se sont prononcées en faveur de la gestion séparée des actifs et passifs comme mesure de protection des intérêts des créanciers dans le cadre d'une fusion transfrontalière. Voir : Consultation publique de 2015, p. 7.

4462 Art. 106 de la Directive Sociétés.

4463 Art. 152 de la Directive Sociétés.

4464 § 227 öAktG (fusions internes) et § 3(5) SpaltG.

4465 §§ 25, 125 et 135(1) UmwG.

des créanciers inconnu en droit belge[4466] et en droit luxembourgeois[4467] et permettant à ces derniers d'engager la responsabilité des dirigeants sociaux ainsi que des membres de l'organe de surveillance de la société apporteuse pour les dommages subis en raison d'une fusion[4468] ou d'une scission[4469] en procédant par le biais de la fiction de la continuation de la société apporteuse[4470] pour en exclure les créanciers et associés de la ou des sociétés bénéficiaires[4471]. En droit allemand, ce régime est en outre explicitement applicable aux sociétés nationales impliquées dans une fusion transfrontalière[4472]. Dans le cadre de l'étude des mécanismes de protection des créanciers contre les risques engendrés par une scission transfrontalière, il est dès lors intéressant de se pencher sur l'efficacité de ce régime de responsabilité.

840. Le régime de responsabilité solidaire du droit allemand et du droit autrichien. Dispositif de protection dont l'origine remonte à l'AktG 1937[4473], l'objectif de ce régime est d'éviter que la dissolution de la société scindée ou absorbée n'empêche les créanciers de cette dernière d'agir contre les membres de l'organe de direction ou d'administration de celle-ci[4474]. Contrairement au droit commun des sociétés[4475], ces différents *stakeholders* peuvent ainsi agir directement contre les membres de l'organe de direction ou d'administration. Dans le cadre d'une opération de fusion ou de scission, il est établi que les dirigeants doivent faire preuve d'une certaine diligence non seulement au niveau de la conclusion du contrat de fusion ou de scission, mais également au niveau de l'évaluation des fractions de patrimoine transférées ainsi que de la solvabilité financière de la ou des sociétés bénéficiaires[4476]. Ce régime de responsabilité spécifique est donc susceptible de trouver application dans l'hypothèse potentiellement dangereuse pour les créanciers de l'absorption par une société à la santé financière incertaine[4477]. L'aspect le plus intéressant

4466 Art. 12:18 du CSA qui ne prévoit un régime de responsabilité des administrateurs qu'à l'égard des seuls associés.

4467 Art. 1021-18 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales qui, comme en droit belge, ne prévoit un régime de responsabilité des administrateurs qu'à l'égard des seuls associés.

4468 En droit allemand, ce régime de responsabilité spécifique s'applique à l'identique tant aux fusions internes qu'aux scissions internes. Voir §§ 25, 125 et 135(1) UmwG.

4469 En droit autrichien, le § 3(5) SpaltG n'ouvre pas cette action en responsabilité aux créanciers dans le cadre d'une scission interne, contrairement à ce qui est le cas dans le régime des fusions internes prévu par le § 227 öAktG.

4470 Voir en droit allemand : § 25(2) UmwG et B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 1 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 1. Voir en droit autrichien : § 227(2) öAktG et S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 354, n° 10.

4471 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 352, n° 3 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 25, n° 1.

4472 §§ 25(1) et 122a (2) UmwG.

4473 Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 352, n° 2.

4474 Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 352, n° 3.

4475 En vertu du droit commun des sociétés allemand, les actions à l'encontre des membres de l'organe de direction ou d'administration devraient être exercées par la société bénéficiaire en sa qualité d'ayant droit à titre universel de la société apporteuse. Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 2 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 1.

4476 Voir en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 9 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 6. Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 352, n° 5. *Contra* en droit allemand : N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 25, n° 16.

4477 Au sujet de ce risque, voir *supra* n° 700.

de ce régime de protection spécifique est qu'il repose sur une présomption de responsabilité des membres de l'organe de direction ou d'administration[4478]. Il suffit donc au demandeur d'établir l'existence de son dommage et d'un lien causal entre ce dommage et l'opération pour que la présomption opère[4479]. À l'égard des créanciers, ce dommage sera généralement réalisé si la fusion ou la scission conduit à l'insolvabilité de la société débitrice[4480] ou à un affaiblissement significatif de sa capacité de remboursement[4481]. Il n'est d'ailleurs pas requis que le mandat des membres de l'organe de direction ou d'administration continue jusqu'à la date de prise d'effet de l'opération pour que ces derniers risquent de voir leur responsabilité engagée, mais il suffit qu'ils aient participé aux préparatifs dommageables de l'opération pour qu'ils encourent ce risque de responsabilité spécifique[4482]. En outre, l'approbation régulière subséquente de la fusion ou de la scission par l'assemblée générale n'aura pas pour effet de couvrir une éventuelle négligence[4483]. Cependant, malgré le caractère *a priori* favorable aux créanciers de ce régime, les membres de l'organe de direction ou d'administration n'en sont pas pour autant démunis et disposent de la possibilité de s'exonérer de toute responsabilité en établissant qu'ils ont rempli leur devoir de diligence[4484]. En revanche, s'ils ne parviennent pas à renverser la présomption, ils encourront une responsabilité solidaire à l'égard des créanciers et associés ayant intenté l'action[4485].

841. Une mise en œuvre particulière de l'action en responsabilité. Il serait toutefois erroné de voir dans cette action en responsabilité une action susceptible d'être exercée individuellement par tout créancier mécontent. En effet, afin d'éviter une multitude de décisions potentiellement divergentes en la matière ainsi qu'une forme de « *race to the courthouse* » de la part des créanciers[4486], les législateurs allemands et autrichiens ont expressément prévu que tout créancier souhaitant exercer cette action devra, avant tout, requérir la nomination d'un

[4478] Voir en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 12 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 8 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 6. Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 353, n° 7.

[4479] Voir en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 12 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 25, n° 8 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 6. Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 353, n° 7.

[4480] Voir en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 16 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 5. Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 355, n° 13.

[4481] Voir en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 16 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 25, n° 16. Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 355, n° 13.

[4482] Voir en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 5 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 25, n° 6 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 5. Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 352, n° 4.

[4483] Voir en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 19 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 7 et 7a. Voir en droit autrichien : § 227(1) *in fine* öAktG et S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, pp. 352 et 353, n° 6.

[4484] § 25(1) *in fine* UmwG et § 227(1) öAktG.

[4485] § 25(1) UmwG et § 227(1) öAktG.

[4486] Voir en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 26, n° 3 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 26, n° 1. Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 357, n° 3.

représentant spécial (« *besonderer Vertreter* ») par la juridiction compétente du lieu du siège de la société apporteuse[4487]. Par ailleurs, cette demande ne pourra être introduite que par des créanciers qui ne peuvent obtenir l'exécution de leur créance[4488] ou l'octroi d'une garantie de la part de la société bénéficiaire[4489] ou encore ceux que la garantie octroyée par la société bénéficiaire ne suffit pas à désintéresser[4490]. Ce représentant sera ensuite chargé d'inciter, au moyen d'une publication *ad hoc*, les différents créanciers de la société scindée, à lui notifier leurs prétentions en vertu du régime de responsabilité spécifique dans un délai limité qui, sauf circonstances exceptionnelles[4491], ne pourra être inférieur à un mois[4492]. Toute réparation obtenue par ce représentant spécial dans le cadre d'une action intentée par les créanciers sera, déduction faite de ses frais et de sa rémunération, directement versée par celui-ci aux différents demandeurs[4493]. Si les fonds ainsi obtenus ne suffisent pas à dédommager tous les demandeurs, ils feront l'objet d'une répartition au prorata[4494], étant entendu qu'en tout état de cause, seuls les créanciers ayant fait connaître leur créance dans le délai imparti pourront y prétendre[4495].

7.2. Les limites

842. Un mécanisme subsidiaire. Si ce régime est certes intéressant d'un point de vue théorique, il est d'une faible utilité pratique[4496] et a suscité un certain scepticisme par son caractère dérogatoire au droit commun de la responsabilité des dirigeants[4497]. En outre, il a été avancé que ce mécanisme était superflu[4498] dans la mesure où les intérêts des créanciers de la société apporteuse qu'il entend protéger, sont déjà suffisamment préservés par d'autres mécanismes, comme la possibilité de demander des garanties[4499] ou la solidarité passive des sociétés bénéficiaires[4500]. Du point de vue de l'articulation entre les différents mécanismes de protection des créanciers, ceci signifie que les créanciers de la société apporteuse devront obligatoirement exercer en priorité l'action leur

4487 § 26(1) UmwG et § 228(1) öAktG.
4488 § 26(1) UmwG et § 228(1) *in fine* öAktG.
4489 § 228(1) *in fine* öAktG.
4490 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 26, n° 8 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 26, n° 6 et R. MARSCH-BARNER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 26, n° 8.
4491 Voir en ce sens : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 360, n° 14 qui cite l'exemple d'un délai raccourci en vue d'éviter une prescription. Voir également : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 26, n° 22 qui avance que le délai peut être plus court, pour peu qu'il demeure adéquat.
4492 § 26(2) UmwG et § 228(2) öAktG.
4493 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 26, n° 25 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 27, n° 15.
4494 Voir en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 26, n° 25 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 27, n° 15. Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 361, n° 18.
4495 N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 27, n° 15 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 26, n° 8.
4496 Voir en ce sens en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 352, n° 3.
4497 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 8 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 1.
4498 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 8.
4499 §§ 22 et 125 UmwG. Sur l'efficacité de ce mécanisme, voir *supra* n°s 767 à 779.
4500 § 133 UmwG. Sur l'efficacité de ce mécanisme, voir *supra* n°s 780 à 789.

permettant d'obtenir des garanties adéquates avant de tenter d'engager la responsabilité des membres de l'organe de gestion[4501], sous peine de se voir opposer le fait qu'ils ont eux-mêmes contribué à la réalisation de leur dommage[4502]. Il en découle que l'efficacité de ce régime de responsabilité sera *de facto* exposée aux limites affectant un mécanisme de protection des créanciers par le biais de la possibilité de demander des garanties adéquates[4503], telle que l'apathie rationnelle. Il reste néanmoins que si les sociétés bénéficiaires devaient être dans l'impossibilité de fournir les garanties adéquates, les créanciers de la société scindée disposeraient malgré tout de la possibilité d'agir contre les membres de l'organe de gestion[4504]. Si cet avantage semble *a priori* justifié, force est de constater qu'il est battu en brèche par un examen plus approfondi des limites affectant ce mécanisme de protection.

843. La limite du dommage réparable. Malgré une formulation relativement large[4505], le régime de responsabilité spécifique du droit allemand et du droit autrichien ne vise pas à réparer tout le dommage qu'un créancier pourrait subir des suites d'une scission, mais uniquement le dommage qui est en lien causal avec la violation du devoir de diligence des membres de l'organe de direction[4506]. Or, la disparition de la société débitrice n'est qu'une conséquence de l'opération et non un dommage en lien causal avec une négligence de la part des membres de l'organe de direction[4507]. Il s'ensuit que ce régime spécifique de responsabilité est incapable de protéger les créanciers contre la substitution automatique de débiteur à laquelle ils sont confrontés et ce, *a fortiori* dans la mesure où une réparation en nature sous la forme d'une nullité de l'opération est exclue[4508].

844. L'incidence de la limitation de la responsabilité des administrateurs. En élargissant l'angle d'appréciation au-delà des régimes spécifiques des fusions et scissions, on constate que certaines règles plus générales du droit des sociétés viennent relativiser encore davantage l'intérêt de ce type de mécanisme de protection dans le cadre des scissions transfrontalières. Il en est ainsi du choix fait par le législateur belge de plafonner les indemnités dues en cas de responsabilité des administrateurs[4509] à cinq seuils spécifiques dépendant

4501 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 16 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 16.

4502 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 16 et § 26, n° 8 qui relève en outre que, compte tenu de la complexité de la procédure en question, la probabilité qu'un créancier tente d'y recourir avant d'exercer l'action plus simple consacrée par le § 22 UmwG est particulièrement faible.

4503 Sur ces limites, voir *supra* n°s 776 à 779.

4504 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 16 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 16.

4505 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 17.

4506 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 17 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 17 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 25, n°s 8 et 9.

4507 Voir en ce sens : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 8.

4508 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 17 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 17.

4509 Ce régime de responsabilité s'applique à chaque membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière, ainsi qu'à toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu effectivement le pouvoir de gérer la personne morale. Voir art. 2:51 et 2:56 du CSA. Par souci de clarté, ces différentes personnes seront par la suite regroupées sous le vocable d' « **administrateurs** ».

du niveau du chiffre d'affaires moyen hors taxes sur la valeur ajoutée et du total du bilan[4510]. Si ce plafonnement impératif[4511], considéré comme une des innovations majeures du CSA[4512], est notamment destiné à faciliter l'assurabilité du risque encouru par les administrateurs[4513] et, par conséquent, faciliter l'indemnisation des tiers[4514], il convient de relever que les montants sont loin d'être excessivement élevés et vont de 125 000 euros à 12 millions d'euros[4515]. En outre, cette limitation s'applique non seulement à tous les membres du conseil d'administration pris dans leur ensemble, mais également par fait ou par ensemble de faits pouvant entraîner une responsabilité, indépendamment du nombre de demandeurs ou d'actions[4516]. En d'autres termes, le plafond n'est multiplié ni par le nombre d'administrateurs, ni par le nombre de demandeurs ou d'actions[4517]. S'il est important de relever que le plafonnement des indemnités ne s'applique notamment pas en cas de faute légère habituelle, de faute grave ou d'intention frauduleuse[4518], ce qui selon certains auteurs, revient à vider la limitation de responsabilité d'une grande partie de sa substance[4519], il n'en demeure pas moins que ce plafonnement combiné aux coûts engendrés par une telle procédure nuira considérablement à son attractivité et risque de renforcer le phénomène d'apathie rationnelle. De manière plus cynique, il convient également de relever qu'organiser un système de protection des créanciers autour d'une éventuelle responsabilité des dirigeants afin de se prémunir contre d'éventuels comportements opportunistes de la part de ces derniers risque d'inciter ces derniers à mettre leur patrimoine à l'abri par

4510 Art. 2:57, § 1er et 2:58 du CSA. Voir à ce sujet : X. DIEUX et P. DE WOLF, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : Capita Selecta », *J.T.*, 2019, pp. 511 et 512, nos 63–67.

4511 Voir en ce sens : X. DIEUX et P. DE WOLF, *ibidem*, p. 512, n° 66.

4512 E. POTTIER et F. LEFÈVRE, « La responsabilité des organes » in A. PIERRE, A. DUMONT et Th. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 174, n° 5.

4513 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, pp. 63 et 67 et E. POTTIER et F. LEFÈVRE, *ibidem*, p. 186, n° 24, qui se montrent circonspects à l'égard de cet argument, notamment en raison du fait que les assureurs plafonnent systématiquement le montant maximal d'indemnisation et E. MASSET, « Avec le nouveau Code des sociétés et des associations, la responsabilité des administrateurs est adaptée », *La semaine fiscale*, n° 378, mai 2019, p. 2.

4514 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, pp. 63 et 67.

4515 Art. 2:57, § 1er du CSA. L'existence de ces différents seuils est justifiée par le fait que les grandes entreprises engendrent une responsabilité sociale plus importante. Voir à ce sujet : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 68 et E. POTTIER et F. LEFÈVRE, *op. cit.*, pp. 187 et 188, n° 26. Il est intéressant de relever que ce critère avait été critiqué par le Conseil d'État en raison de son imprécision. Voir : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/002, pp. 12–18.

4516 Art. 2:57, § 2 du CSA. Ce point a également fait l'objet d'une critique de la part du Conseil d'État qui n'a pas été suivie par le législateur, ce qui est regrettable notamment en matière environnementale. Voir : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/002, pp. 12–18 et E. POTTIER et F. LEFÈVRE, *op. cit.*, pp. 188 et 189, n° 27.

4517 Voir en ce sens : D. DEVLEESCHOUWER, « Le Nouveau Code des Sociétés et des Associations – Aperçu de quelques nouveautés convenant la gouvernance des sociétés anonymes », *IN FORO*, n° 62, 01/2019, p. 20.

4518 Art. 2:57, § 3 du CSA.

4519 Voir en ce sens : E. POTTIER et F. LEFÈVRE, *op. cit.*, p. 195, n° 36.

d'autres moyens, comme par exemple en transférant la propriété de certains biens à des proches, pour réduire *de facto* le montant disponible pour une éventuelle réparation[4520].

845. Appréciation marginale et « *business judgement rule* ». La possibilité pour les membres de l'organe de direction ou d'administration d'échapper à leur responsabilité en établissant qu'ils ont rempli leur devoir de diligence combinée avec l'équivalent de la « *business judgement rule* »[4521] appliquée par les juridictions allemandes[4522], vient en outre considérablement relativiser l'intérêt de ce mécanisme de protection. Un constat similaire s'appliquerait à de nombreuses autres juridictions comme la Belgique[4523] et le Luxembourg[4524] qui connaissent tous deux un principe d' « appréciation marginale » conférant une large marge de manœuvre aux dirigeants. En effet, en ce qui concerne spécifiquement la décision de participer à l'opération en question, il est généralement admis que les membres de l'organe de direction ou d'administration jouissent d'une large marge d'appréciation[4525]. En d'autres termes, une opération de scission au profit d'une ou de plusieurs sociétés bénéficiaires en situation financière précaire n'est pas de nature à entraîner, à elle seule, une responsabilité des membres de l'organe de gestion et ce, à juste titre, car une scission peut s'avérer être un mécanisme d'assainissement financier efficace[4526]. Encore faudrait-il que les membres de l'organe de gestion aient fait preuve de

4520 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », *op. cit.*, p. 398.

4521 Par « *business judgement rule* » on entend la règle applicable en droit américain qui prohibe aux cours et tribunaux de porter *a posteriori* un jugement sur l'opportunité de décisions économiques. Voir à ce sujet : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 66 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 9, note 15 et E. POTTIER et F. LEFÈVRE, *ibidem*, pp. 187, n° 25.

4522 § 93(1) AktG, deuxième phrase et B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 9 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 25, n° 9 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 6.

4523 Voir à titre d'illustration en droit belge le principe de l'appréciation marginale à présent consacré à l'art. 2:56 du CSA selon lequel les administrateurs « ne sont toutefois responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente ». Voir à ce sujet : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 59 et E. POTTIER et F. LEFÈVRE, *op. cit.*, pp. 177 et 178, nos 9–11.

4524 I. RIASSETTO, « Les dirigeants de sociétés » in G. RAVARANI, (dir.), *La responsabilité civiles des personnes privées et publiques*, Luxembourg, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, p. 648, n° 629 ; A. STEICHEN, *op. cit.*, pp. 305 et 306, n° 389 et J.-P. WINANDY, *Manuel de droit des sociétés*, Bertrange, Legitech, 2019, pp. 602 et 603 et T.A. Luxembourg, 25 avril 2018, n°s 181613, 184874 et 186633 et C.A. Luxembourg, 1er octobre 1997, n°s 12583, 12771, 12859, 12896 et 20243.

4525 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 9 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n°s 9 et 10 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 6. Pour une illustration, voir : LG Stuttgart, 8 mars 1994, 4 KfH O 6/94, *AG*, 1994, p. 567 où, dans le cadre d'une fusion, la société absorbante avait pris à sa charge tous les coûts de la fusion. Voir également : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, pp. 59 et 60 où le législateur belge insiste sur le fait que « [n]ombre de décisions de gestion importantes, par exemple en matière d'investissements ou de désinvestissements stratégiques, relèvent de ce type de décisions pour lesquelles l'organe d'administration dispose d'une large marge d'appréciation ».

4526 Sur l'intérêt économique des scissions, voir *supra* n°s 35 à 84.

négligence dans l'évaluation du patrimoine des sociétés bénéficiaires[4527], tout en précisant qu'ils n'assument à cet égard qu'une obligation de moyens[4528]. D'un point de vue pratique, on voit directement que pour écarter ce risque de responsabilité, il est utile de réaliser une *due diligence* en bonne et due forme sur les autres sociétés impliquées[4529]. En outre, ce mécanisme sera inutile en cas d'opération intragroupe où la situation financière des sociétés impliquées est, par définition, bien connue *ab initio*.

846. Un délai de prescription atypique. Le régime de responsabilité spécifique en droit allemand[4530] et en droit autrichien[4531] prévoit également un délai de prescription particulier de cinq ans qui, contrairement à ce qui est le cas en droit commun[4532], prend cours au jour de la publication de l'inscription de l'opération dans le registre compétent des sociétés bénéficiaires et ce, quand bien même le créancier ne serait en mesure d'avoir connaissance de son dommage que plus tard[4533]. Cette prescription privilégiant la sécurité juridique[4534] vient éroder encore davantage l'intérêt de ce mécanisme pour la protection des créanciers, *a fortiori* si on le compare à d'autres mécanismes tels que l'action paulienne qui bénéficient de délais de prescription plus longs[4535].

D. *Conclusion sur les mécanismes de protection prévus par les législateurs*

847. Mécanismes de protection individuels et institutionnels prévus par le législateur européen. Parmi les mécanismes de protection institutionnels privilégiés par le législateur européen, l'information adéquate en temps utile des créanciers occupe, à juste titre, une place de choix en raison à la fois de sa capacité à corriger une éventuelle asymétrie d'information entre les créanciers et la société débitrice et de la proportionnalité de l'entrave qu'elle génère à la liberté d'établissement des sociétés concernées. Elle est toutefois loin d'être suffisante pour garantir une protection adéquate des intérêts des créanciers en ce qu'elle ne profite qu'aux seuls créanciers vigilants ayant connaissance de leur créance, à même d'apprécier l'impact d'une opération transfrontalière sur la capacité de remboursement de leur société débitrice et jouissant d'une force de négociation suffisante envers la société débitrice leur permettant d'adapter les conditions de leur créance en conséquence. Le mécanisme de la déclaration

4527 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 16.
4528 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 9 et R. PÖLLATH et Chr. PHILIPP, « Unternehmenskauf und Verschmelzung : Pflichten und Haftung von Vorstand und Geschäftsführer », *DB*, 2005, p. 1505 qui indiquent que les membres de l'organe de gestion sont uniquement tenus de vérifier la plausibilité des informations financières qui leur sont fournies.
4529 Voir en ce sens également : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 9 et N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 9.
4530 § 25(3) UmwG.
4531 § 227(3) öAktG.
4532 § 199 BGB et à ce sujet : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 22.
4533 Voir en ce sens en droit allemand : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 22 ; N. LEONARD in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 31 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 25, n° 15. Voir en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 353, n° 8.
4534 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 25, n° 22 et S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 353, n° 8.
4535 À ce sujet, voir *supra* n° 799.

de solvabilité vient partiellement compléter ces insuffisances. Il a pour objectif d'offrir une protection additionnelle aux créanciers en limitant le recours abusif aux scissions transfrontalières dans un but d'expropriation des créanciers et en rendant, le cas échéant, les membres de l'organe de gestion personnellement responsables de l'exactitude de la déclaration à l'égard des créanciers en cas d'insolvabilité des sociétés bénéficiaires à la suite de la réalisation de l'opération. Cependant, ce mécanisme, même s'il ne fait peser qu'une obligation de moyens sur l'organe de gestion, risque dangereusement de rompre le délicat équilibre entre intérêts des créanciers et intérêts de la société en incitant les membres de l'organe de gestion à fournir trop aisément une garantie adéquate pour se mettre à l'abri d'une éventuelle action en responsabilité de la part des créanciers. En outre, une éventuelle limitation de la garantie de solvabilité à moyen terme par les États membres, l'absence de sanction précise, la chronologie de la déclaration qui l'empêche de tenir compte de l'érosion financière engendrée par la scission transfrontalière, son coût potentiellement élevé pour la société concernée et une éventuelle contrariété à la liberté d'établissement viennent sensiblement relativiser sa pertinence. Mécanisme très fréquent ayant les faveurs tant de la Cour de justice que des législateurs européens et nationaux, la possibilité pour les créanciers d'obtenir des garanties adéquates s'ils parviennent à démontrer, de manière crédible, que l'opération compromet le recouvrement de leur créance et qu'ils ne disposent pas encore de garanties satisfaisantes permet de sauvegarder efficacement les intérêts des créanciers tout en respectant l'équilibre des intérêts en présence et la condition de proportionnalité du « *Gebhard test* », pour peu qu'il ne soit pas assorti d'un effet suspensif. Cette possibilité de demander des garanties adéquates devrait être ouverte à tous les créanciers titulaires d'une créance née antérieurement à la publication du projet de scission et non encore échue à ce moment. Cependant, l'asymétrie d'information existant entre les créanciers et la société concernée et le risque d'apathie rationnelle impliquent qu'il serait préférable d'imposer à la société concernée de prouver que l'opération de scission ne compromet pas le remboursement de la créance à terme ou que le créancier demandeur a déjà obtenu suffisamment de garanties plutôt que de requérir de la part du créancier en question qu'il parvienne à établir que l'opération présente un risque crédible pour le remboursement à terme de sa créance. Malgré le fait que l'efficacité de ce mécanisme de protection semble établie, il n'en est pas pour autant exempt de limites. Ainsi, l'objectif de neutralité de l'opération est particulièrement délicat à atteindre par le biais de ce mécanisme et il s'adresse en priorité aux créanciers vigilants et disposant de suffisamment de moyens qui, assez paradoxalement, sont ceux qui sont généralement déjà suffisamment protégés par des mécanismes contractuels particuliers. En outre, ce moyen de protection (i) entraîne une érosion additionnelle du patrimoine de la société concernée susceptible d'aggraver la situation des autres créanciers, (ii) est intimement lié à la capacité de la société concernée à fournir des garanties adéquates et (iii) risque d'aboutir dans les faits au même résultat qu'un droit de veto privant une société d'une opération potentiellement essentielle à sa survie économique. Plus fondamentalement, il s'avère de plus que la possibilité de demander des garanties adéquates n'est pas à même de protéger efficacement les créanciers de la société scindée contre les risques auxquels ces derniers

sont exposés en cas de scission. Il s'ensuit que ce mécanisme de protection doit nécessairement être complété par une solidarité passive des sociétés issues de l'opération qui est seule susceptible de compenser la liberté dont jouissent les associés au niveau de la répartition du patrimoine de la société scindée entre les sociétés bénéficiaires. Cette solidarité passive, qui présente le double avantage d'être particulièrement protectrice de tous les créanciers et de limiter l'érosion du patrimoine des sociétés impliquées en raison de l'octroi répété de garanties aux créanciers, doit toutefois être limitée à l'actif net transféré à chacune des sociétés issues de l'opération et peut, au choix des États membres, être limitée dans le temps et ce, afin de remplir l'objectif de neutralité de l'opération sur la situation tant des créanciers que de la société et de générer une entrave plus proportionnelle à la liberté d'établissement des sociétés concernées. En outre, elle ne pourra intervenir qu'en cas de défaut de la société à laquelle la créance a été transférée et devrait également, en cas de scission partielle, profiter aux créanciers de la société scindée dont la créance est restée dans le patrimoine de la société scindée. Si elle est certes indéniablement efficace, cette solidarité passive n'est toutefois pas du tout adaptée à la protection des intérêts des créanciers des sociétés bénéficiaires préexistantes et se révèle particulièrement intrusive et inflexible, raison pour laquelle elle ne peut intervenir qu'en combinaison avec la possibilité de demander des garanties adéquates et ce, à titre subsidiaire. Le mécanisme de la *perpetuatio fori*, qui revient à maintenir fictivement la compétence des juridictions de l'État membre d'origine pendant un certain laps de temps, ne présente aucun d'intérêt dans l'hypothèse des scissions transfrontalières, d'une part parce qu'il s'avérera fréquemment superflu et d'autre part, parce qu'il est plus intrusif du point de vue de la liberté d'établissement que d'autres mécanismes tels que la possibilité de demander des garanties adéquates.

848. Les autres moyens de protection prévus par les législateurs nationaux. Cependant, les mécanismes de protection spécifiquement mis en place par le législateur dans le cadre du régime des scissions transfrontalières sont loin d'être les seuls mécanismes auxquels les créanciers peuvent recourir pour sauvegarder leurs droits. Ainsi, l'action paulienne présente l'indéniable avantage de bénéficier de délais de prescription beaucoup plus longs et, en raison du rattachement de l'action paulienne à la matière contractuelle opéré par la Cour de justice dans les arrêts *Feniks* et *Reitbauer*, de permettre à un créancier d'agir dans un nombre important de cas devant les juridictions de l'État membre de la société scindée et d'éviter ainsi l'aléa lié à l'obligation d'agir devant des juridictions étrangères soumises à des règles procédurales différentes ou potentiellement moins favorables au demandeur. En outre, l'action paulienne présente l'avantage (i) d'être particulièrement répandue au sein des États membres, (ii) d'être flexible en ce que le tiers concerné peut se prévaloir du bénéfice de discussion ou écarter l'action paulienne intentée par un créancier en payant tout simplement ce dernier, (iii) d'éluder tout concours avec les créanciers du tiers complice et (iv) de pouvoir être intentée à l'encontre d'un tiers sous-acquéreur en cas de scissions successives. Pour utile qu'elle puisse être dans certaines circonstances, l'action paulienne n'en est pas pour autant un mécanisme de protection suffisant. Ainsi, il ressort de l'étude des différentes conditions de l'action paulienne par le prisme d'une scission transfrontalière

que ces dernières ne seront pas simples à remplir, *a fortiori* si on les compare à celles applicables à d'autres mécanismes de protection tels que la possibilité de demander des garanties ou la solidarité de principe des sociétés bénéficiaires. En outre, en raison de son effet relatif, elle n'est pas à même de résoudre le problème d'apathie rationnelle qui affectera certains créanciers et elle n'est pas en mesure d'offrir une protection efficace aux créanciers des sociétés bénéficiaires. Elle n'en constitue cependant pas moins un mécanisme de protection supplémentaire venant compléter l'arsenal des mécanismes de protection à disposition des créanciers en cas de scission transfrontalière et révélant tout son intérêt en présence d'une fraude de la part du débiteur. *A contrario*, il ne semble pas opportun d'assurer la protection des créanciers par le biais de l'octroi d'un droit de veto, même sous une forme atténuée, car cela se révélerait particulièrement intrusif et romprait le délicat équilibre entre les intérêts en présence, sans parler du risque d'usage abusif par certains créanciers, de son caractère disproportionné rendant sa conformité à la liberté d'établissement particulièrement douteuse et de son inutilité pour les créanciers involontaires ne découvrant leur dommage que postérieurement à la réalisation de l'opération. Mécanisme de protection institutionnel par excellence, l'instrumentalisation du contrôle de conformité en vue de protéger les créanciers présente le double avantage d'une part, de protéger toutes les catégories de créanciers et d'autre part, soit de réduire la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection individuels spécifiques, soit d'en renforcer l'efficacité. En revanche, ce mécanisme (i) risque de retarder considérablement la réalisation de l'opération, (ii) ne pourra fonctionner efficacement que si l'autorité nationale compétente dispose de moyens suffisants pour remplir sa mission, (iii) entraîne un coût potentiellement significatif et (iv) génère une entrave à la liberté d'établissement de la société concernée qui n'est potentiellement pas justifiée à l'aune du « *Gebhard test* ». Le droit d'opposition tel qu'il existe en droit français ne s'avère pas être un mécanisme de protection satisfaisant et ce, en raison des limites prétoriennes qui y ont été adjointes, de son caractère judiciaire *ab initio*, de la nécessité d'intervenir à bref délai, du caractère relatif de l'inopposabilité qui vient le sanctionner et de son caractère potentiellement disproportionné. En revanche, l'idée d'introduire une certaine flexibilité pour les sociétés impliquées peut présenter un certain intérêt en écartant l'épée de Damoclès que celle-ci fait peser sur les sociétés issues de l'opération. La théorie de l'imprévision, pour sa part, pourrait présenter une utilité non négligeable lorsqu'il s'avère que la protection par le biais de l'octroi d'une garantie adéquate n'est pas suffisante pour protéger un créancier et que la reconnaissance d'un droit à résiliation unilatérale représenterait une solution plus satisfaisante. Malgré cela, la théorie de l'imprévision est susceptible de se révéler être une arme à double tranchant en ce qu'une des sociétés bénéficiaires pourrait, le cas échéant, également s'en prévaloir. En outre, elle est affectée de limites intrinsèques confinant son utilité à des cas exceptionnels dans la mesure où (i) elle requiert un comportement actif de la part du créancier, (ii) ses différentes conditions ne sont pas aisées à remplir et (iii) elle n'est pas applicable aux créanciers délictuels pourtant également impactés par une opération de scission. La gestion séparée du patrimoine de la société scindée et des patrimoines des sociétés bénéficiaires constitue en revanche un mécanisme de protection

dépassé très difficilement compatible avec (i) les enseignements de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement, (ii) les divergences existant entre les normes comptables appliquées au sein des différents États membres et (iii) les fractionnements successifs du patrimoine de la société scindée en cas de scissions transfrontalières en chaîne. Un régime de responsabilité spécifique des membres de l'organe de direction ou d'administration ne présente pas davantage d'intérêt dans la mesure où (i) il est sujet à un phénomène d'apathie rationnelle et (ii) la limite du dommage réparable, le plafonnement impératif des indemnités dues en cas de responsabilité des administrateurs, l'incidence de la « *business judgement rule* » ainsi que d'éventuels délais de prescription privilégiant la sécurité juridique relativisent sensiblement son utilité.

§ 3. Les mécanismes de protection conventionnels

A. *Présentation*

849. Intérêt de la question. Au-delà des mécanismes légaux explicitement prévus, qu'ils soient institutionnels ou individuels, la pratique contractuelle a vu se développer un nombre important et particulièrement varié de clauses spécifiques destinées à protéger les créanciers contre les décisions des associés susceptibles d'entraîner une expropriation des derniers au profit des premiers, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'une opération interne ou d'une opération transfrontalière. L'opportunité de privilégier les mécanismes conventionnels peut s'expliquer par le postulat que dans une situation de concurrence parfaite sur les marchés de capitaux et en présence de parties parfaitement informées et où le coût intrinsèque des contrats est nul, une intervention du législateur pour protéger les créanciers s'avère superflue dans la mesure où les conditions des financements externes, tels que les taux d'intérêt ou les garanties requises, sont parfaitement déterminées par le marché et, par conséquent, tout à fait adaptée aux risques encourus par les créanciers[4536]. Cette approche découlant du courant « *law and economics* »[4537][4538] implique que les intérêts des créanciers

[4536] J. ARMOUR, *op. cit.*, p. 357 ; L. ENRIQUES et L. MACEY, *op. cit.*, pp. 1184 et 1185 et W. SCHÖN, *op. cit.*, p. 439. Pour un point de vue plus critique, voir P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », *op. cit.*, p. 395.

[4537] Par « *law and economics* », on entend une discipline développée aux États-Unis dans les années 1970 et qui consiste « à utiliser les instruments et concepts de la science économique pour analyser les phénomènes juridiques et judiciaires - telles les règles de droit, les décisions judiciaires, l'organisation de la justice, etc. ». Voir à ce sujet : S. DELABRUYÈRE, « Réflexions économiques sur l'Europe juridique et judiciaire », *Recueil Dalloz*, 2005, p. 1652, disponible sur www.dalloz.fr (02/01/2019), p. 1. Pour une étude détaillée de ce courant appliqué au droit des sociétés et des critiques qui peuvent être formulées à son encontre, voir : I. CORBISIER, *La société : contrat ou institution*, *op. cit.*, pp. 249 à 340. Voir également : Al. BERNARD, « Law and Economics: une science idiote? », *Recueil Dalloz*, 2008, p. 2806, disponible sur www.dalloz.fr (02/01/2020), p. 1 ; Al. MARCIANO, *Law and economics : a reader*, London, Routledge, 2009 ; N. MERDURO (dir.), *Law and economics: critical concepts in law*, London, Routledge, 2007 et R.-A. POSNER, « Utilianarism, economics and legal theory », *The Journal of Legal Studies*, janvier 1979, vol. 8(1), pp. 103–140.

[4538] Voir en ce sens : P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », *op. cit.*, pp. 394 et 395.

sont généralement mieux protégés par les créanciers eux-mêmes[4539]. Même en adoptant une approche plus nuancée qui n'aurait pas pour objectif d'exclure les mécanismes de protection institutionnels, mais plutôt de les compléter[4540], force est de constater que les mécanismes de protection conventionnels présentent l'indéniable avantage d'être plus flexibles et de s'adapter au mieux aux besoins individuels de chaque créancier[4541]. En considérant qu'il est loisible aux parties à un contrat de déroger à la transmission à titre universel qui pourrait affecter le patrimoine de l'une d'elles à la suite d'une scission[4542][4543], il est intéressant de s'interroger sur l'efficacité des clauses contractuelles dans le cadre d'une scission transfrontalière et en présence d'un environnement concurrentiel imparfait. En effet, s'il devait s'avérer que les différentes clauses développées par la pratique offrent une protection suffisante aux créanciers en mesure de les imposer à leurs débiteurs, ceci permettrait à tout le moins de pouvoir les exclure du mécanisme général de protection des créanciers qui devrait être instauré par le législateur et, par conséquent, de limiter les inconvénients liés à un mécanisme trop général fondé sur le principe du « *one size fits all* » (D). Pour ce faire, il conviendra de procéder en deux temps : il sera ainsi tout d'abord indispensable d'examiner certains types de clauses fréquentes en pratique pour pouvoir porter un jugement éclairé sur leur efficacité (B) et ensuite de s'intéresser aux limites inhérentes aux mécanismes conventionnels (C).

B. *Une multitude de clauses distinctes*

1. *Typologie*

850. Une classification double. Si l'autonomie de la volonté dont jouissent les parties au moment de la conclusion d'un contrat leur permet d'élaborer une multitude de clauses diverses destinées à aménager l'incidence d'une opération de réorganisation transfrontalière, il est possible de les répartir en deux catégories distinctes en fonction de ce qu'elles visent à permettre au créancier de mettre fin à la relation contractuelle (2) ou, au contraire, ne visent qu'à aménager les conséquences de l'opération sur l'équilibre contractuel et la position du créancier (3).

4539 J. ARMOUR, *op. cit.*, p. 373 ; L. ENRIQUES et L. MACEY, *op. cit.*, pp. 1184 et 1185 et W. SCHÖN, *op. cit.*, p. 439.

4540 Voir en faveur de cette approche : P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », *op. cit.*, p. 409 ; J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 448 et s. et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 53.

4541 J. SCHMEIDLER, *ibidem*, p. 448.

4542 Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1223, n° 52 ; B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 14 ; J.-M. MOULIN, C. CATHIARD et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 91, n° 208 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 114 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 398, n° 508.

4543 En droit français, il a été avancé que « l'affirmation législative du principe de transmission universelle du patrimoine a conféré à cette règle un caractère d'ordre public », empêchant dès lors d'y déroger par le biais d'une simple stipulation contractuelle. Voir en ce sens : M. JEANTIN, *op. cit.*, pp. 298 et 299, n°s 32 et 33. Voir également sur ce sujet : M. DUBERTRET, *op. cit.*, p. 2 ; Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1223, n° 52 et D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 114.

2. *Les clauses destinées à mettre fin au contrat*

2.1. La clause d'intransmissibilité

851. Exemple de clause d'intransmissibilité :

Except as otherwise provided herein, no Party may assign this Agreement or all or part of its rights and obligations under this Agreement to any third party (through a sale, a contribution, a donation or any other transaction, including the sale or contribution of a division ("branche d'activités") or of a business as a whole ("universalité"), a merger, a split or a partial split) without the prior written consent of the other Party. As long as such consent has not been obtained, the assigning Party shall continue to be liable for all obligations that it intended to assign (without prejudice to any other right or remedy that the other Party may have for breach of this Clause).

852. Notion. La clause d'intransmissibilité vise à interdire purement et simplement à une partie de transférer ses droits et obligations en vertu d'un contrat sans l'accord exprès et préalable de l'autre partie. En d'autres termes, elle permet à une partie contractante d'éluder les effets de la transmission à titre universel[4544]. En cas de violation de cette obligation, il est possible de prévoir la résiliation automatique du contrat[4545] ou, au contraire, une simple faculté de résiliation unilatérale pour l'autre partie[4546], auquel cas, la clause d'intransmissibilité se rapprochera d'une clause d'agrément[4547]. Une telle clause, parfaitement licite[4548], se distingue de la clause d'incessibilité en ce qu'elle n'est pas limitée à l'hypothèse d'une cession[4549], qui, en l'absence d'autres précisions, ne couvre pas l'hypothèse d'une scission[4550], mais vise également les situations dans lesquelles la dette serait transférée par le biais d'une transmission universelle ou à titre universel.

853. Efficacité de la clause. En droit belge[4551], tout comme en droit luxembourgeois[4552], en droit allemand[4553], en droit autrichien[4554] et en droit

4544 Voir en ce sens à propos des fusions : G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 66.
4545 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 413, n° 530.
4546 Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1223, n° 54 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 311, n° 458.
4547 Sur ce type de clause, voir *infra* n°s 863 à 865.
4548 Voir en ce sens : D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 114 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 310 et 311, n° 458. *Contra* : R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 415 et 416, n° 532.
4549 Sur la distinction entre les notions de « *transmission* » et de « *cession* », voir Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1184.
4550 Voir en ce sens : Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1223, n° 53 ; R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 407, n° 522 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 307, n° 451.
4551 G. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *op. cit.*, p. 246 ; FL. GEORGE, *op. cit.*, p. 1223, n° 52 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *Les sociétés anonymes*, *op. cit.*, pp. 438 et 439, n° 844 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 114 ; Th. TILQUIN, *ibidem*, pp. 310 et 311, n° 458 ; F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 189, n° 22 et P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, p. 1991, n° 1381.
4552 Al. STEICHEN, *op. cit.*, p. 427, n° 550.
4553 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 20, n°s 14 et 53 ; H. HECKSCHEN, « Die umwandlungsrechtliche Universalsukzession und ihre haftungsrechtliche Kompensation », *GmbHR*, 2017, p. 959 et S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 81.
4554 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 221, n° 40.

français[4555], la validité de principe d'une clause d'intransmissibilité conventionnelle en cas de scission ne fait aucun doute. En cas de scission, le contrat affecté d'une clause d'intransmissibilité sera dissous[4556] *ex nunc*, impliquant que la dissolution ne produira ses effets que pour l'avenir et que les sociétés bénéficiaires demeureront tenues des dettes nées antérieurement à l'opération[4557]. Il est toutefois également possible de l'assortir d'une faculté de résiliation permettant aux parties, le cas échéant, de préserver leur contrat[4558]. En revanche, une clause prohibant purement et simplement tout transfert entraîne pour certains davantage de circonspection dans la mesure où leur proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi n'est pas évidente[4559] alors que pour d'autres elles doivent être admises, la société étant libre de déterminer sa propre gestion économique[4560]. En tout état de cause, la transmission à titre universel dont s'accompagne une scission n'étant pas d'ordre public[4561], il doit être loisible aux parties d'y déroger conventionnellement par le biais d'une telle clause[4562]. Cependant, compte tenu du fait que le principe consacré par le législateur est celui de la transmission à titre universel, toute clause y dérogeant ne pourra être interprétée que restrictivement[4563], justifiant dès lors le soin apporté à leur rédaction en pratique. En outre, elle ne pourra jamais être appliquée que dans les limites de l'abus de droit[4564]. Au niveau de l'efficacité de cette clause à l'égard de la protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière, le spectre de la résiliation unilatérale d'un contrat économiquement important pour la survie de l'entreprise, comme un contrat de crédit significatif ou un contrat de distribution commerciale, incitera le plus souvent les parties à entamer des négociations au stade de la préparation du projet commun, soit avant même le début du processus de restructuration en tant que tel. Lorsque le contrat a une certaine importance, cette clause permettra donc indirectement au créancier de renégocier les conditions de son engagement tout en jouissant d'une position privilégiée vis-à-vis de la société débitrice.

4555 M. DUBERTRET, *op. cit.*, p. 10 ; M. MOULIN, C. CATHIARD et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 91, n° 208 ; R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 413, n° 530 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 454 et 455, n° 1071.

4556 Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1223, n° 54 ; Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scission, op. cit.*, p. 311, n° 459 ; F. T'KINT et I. CORBISIER, *ibidem*, p. 189, n° 22 et P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge, op. cit.*, p. 1991, n° 1381.

4557 Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1223, n° 54 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *ibidem*, p. 189, n° 22.

4558 Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1223, n° 54 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 311, n° 458.

4559 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 418, n° 536.

4560 T.-V.-N. NGUYEN, *op. cit.*, p. 375.

4561 *Pro* : Al. STEICHEN, *op. cit.*, p. 427, n° 550 ; M. DUBERTRET, *op. cit.*, p. 2 ; Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1223, n° 52 ; J.-M. MOULIN, C. CATHIARD et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 91, n° 208 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 114 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 398, n° 507. *Contra* : M. JEANTIN, « La transmission universelle du patrimoine d'une société », *Les activités et les biens de l'entreprise – Mélanges J. Derruppé*, Paris, Joly et Litec, pp. 298 et 299, n°s 32 et 33.

4562 M. DUBERTRET, *ibidem*, p. 2 ; Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1223, n° 52 ; J.-M. MOULIN, C. CATHIARD et J.-L. NAVARRO, *ibidem*, p. 91, n° 208 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *ibidem*, p. 114 et R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 398, n° 507.

4563 Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1223, n° 53 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 307, n° 451.

4564 Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1224, n° 56 et Th. TILQUIN, *ibidem*, pp. 307 et 308, n° 453.

2.2. La clause d'*intuitu personae*

854. Exemple de clause d'*intuitu personae* :

> *Les Parties reconnaissent que les qualités propres à l'Emprunteur ont été déterminantes dans le chef de la Banque et que le présent Contrat de Crédit est dès lors conclu en considération de (intuitu personae) la personne de l'Emprunteur.*

855. Présentation. Selon la définition de H. De Page, un contrat est qualifié d'*intuitu personae* quand « la considération de la personne de l'un des cocontractants est pour l'autre partie un élément déterminant du contrat »[4565]. En d'autres termes, c'est la confiance qu'inspire la personne du cocontractant, que ce soit par ses qualités, sa compétence, sa solvabilité ou encore son expérience qui a poussé l'autre partie à conclure[4566]. Si certains contrats sont par nature qualifiés d'*intuitu personae*, comme le mandat dans le chef du mandataire[4567] ou encore les contrats de distribution commerciale[4568], ce caractère peut également résulter d'une stipulation contractuelle expresse[4569]. Cette dernière hypothèse est, au demeurant, fréquente en droit des affaires[4570].

856. Notion. Si, compte tenu des spécificités de la doctrine et de la jurisprudence françaises à l'égard du sort des contrats conclus *intuitu personae* en cas d'opération emportant transmission universelle ou à titre universel de patrimoine[4571], la clause d'*intuitu societatis* a pu être définie comme la clause par laquelle les parties ont décidé que « la transmission universelle mettra fin au contrat, de manière automatique ou à l'initiative du « cédé » »[4572], la rapprochant dès lors d'une clause d'intransmissibilité, il est proposé pour les besoins de la présente étude et dans une perspective plus internationale, de retenir une définition plus restreinte. Sera dès lors considérée comme clause d'*intuitu personae*, la clause par laquelle les parties précisent que leur contrat a été conclu en considération de la personne du cocontractant[4573]. En d'autres termes, elle permettra soit de clarifier la nature *intuitu personae* d'un contrat, soit encore de conférer un tel caractère à une convention qui en est en principe dépourvue.

4565 H. DE PAGE, *op. cit.*, p. 431. Sur cette notion, voir également : F. MOURLON BEERNAERT, « *Intuitus personae* et sociétés », *RPS-TRV*, 2017/3, p. 274 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, pp. 102–105, n° 68.

4566 H. DE PAGE, *ibidem*, p. 431. Sur cette notion, voir également : F. MOURLON BEERNAERT, *ibidem*, p. 274 et P. WÉRY, *ibidem*, pp. 102–105, n° 68.

4567 F. MOURLON BEERNAERT, *ibidem*, p. 274 et P. WÉRY, *ibidem*, p. 102, n° 68.

4568 L. DU JARDIN, « L'*intuitu personae* et la sélection des intermédiaires commerciaux », note sous Anvers, 21 février 2008, *RDC*, 2008, p. 918 et s. et F. MOURLON BEERNAERT, *ibidem*, p. 274 et P. WÉRY, *ibidem*, p. 103, n° 68.

4569 F. MOURLON BEERNAERT, *ibidem*, p. 274 ; R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 414, n° 530 et P. WÉRY, *ibidem*, p. 104, n° 68.

4570 P. HAINAUT-HAMENDE, *Les sociétés anonymes*, *op. cit.*, p. 438, n° 844.

4571 À ce sujet, voir *infra* n° 857.

4572 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 413, n° 530.

4573 Voir en ce sens également : J.-M. MOULIN, C. CATHIARD et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 91, n° 208 ; F. MOURLON BEERNAERT, *op. cit.*, p. 274 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 104, n° 68.

857. Une spécificité française. Alors que les contrats *intuitu personae* ne sont pas transmis aux ayants cause du *de cujus* en cas de décès d'une personne physique[4574], la situation est loin d'être aussi limpide à l'égard de la transmission à titre universel dont s'accompagne une scission. Ainsi, en droit français, tant la doctrine[4575] que la jurisprudence[4576] considèrent, en l'absence de disposition légale spécifique en la matière, que le caractère *intuitu personae* de certaines conventions est une cause de caducité en cas de transmission à titre universel de patrimoine. Cette caducité, qui reposait autrefois sur l'ancien article 1122 du Code civil français[4577][4578] découle, suite à la réforme du droit des contrats de 2016[4579], de l'article 1186, al. 1er du Code civil[4580][4581]. La clause par laquelle le créancier stipule que le contrat est conclu en considération de la personne de son débiteur ne lui permettra certes pas de s'opposer à l'opération envisagée, mais lui confèrera une faculté de résiliation unilatérale. La jurisprudence française est particulièrement abondante en la matière et, à titre d'illustration de contrats *intuitu personae* qui ne seront pas couverts par la transmission universelle dont s'accompagne une scission ou une fusion, on peut citer les contrats de distribution sélective[4582], les contrats de franchise[4583], les contrats de concession automobile[4584] et les conventions de crédit[4585]. Si cette exception a pu faire l'objet de certaines critiques en raison des contours incertains de la notion d'*intuitu personae*, de son caractère artificiel à l'égard des personnes morales ainsi que son effet indésirable sur les opérations emportant transmission universelle de patrimoine[4586], force est de constater qu'elle demeure d'actualité[4587]. Il convient malgré tout de relever que la position en droit français n'est pas si claire qu'il y paraît à ce sujet et il est ainsi prévu que les contrats

4574 Art. 1122 du Code civil belge et du Code civil luxembourgeois et D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 92 et P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, p. 1981.

4575 M. COZIAN, Al. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, *op. cit.*, p. 821, n° 2278 ; J.-M. MOULIN, C. CATHIARD et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 92, n° 211 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 362, n° 464.

4576 Pour une vue d'ensemble de la jurisprudence en matière de contrats *intuitu personae*, voir : M. COZIAN, Al. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, *ibidem*, p. 821, n° 2278.

4577 Selon cet ancien art. 1122 du Code civil français, toujours en vigueur en droit belge et en droit luxembourgeois, « [o]n est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ».

4578 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 361, n° 463 ; P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, pp. 1988 et 1989, n° 1379 et P.-Y. BÉRARD, « Les fusions à l'épreuve de l'*intuitus personae* », *RTD com.*, 2007, p. 279, disponible sur www.dalloz.fr (09/01/2020), p. 2, n° 4.

4579 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, disponible sur www.legifrance.gouv.fr (06/01/2020).

4580 Selon l'art. 1186, al. 1er du Code civil français, « [u]n contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ».

4581 J.-M. MOULIN, C. CATHIARD et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 92, n° 211.

4582 Cass. com., 7 janvier 2014, n° 10-18.319, *RJDA*, 3/2014, n° 223. *Contra* : Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, *RJDA*, 5/2013, n° 410.

4583 Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-16.428, *RJDA*, 4/2010, n° 371 et Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-18.007, *Recueil Dalloz*, 2008, p. 1623.

4584 Cass. com., 13 décembre 2005, *BJS*, 2006, p. 591.

4585 C.A. Pau, 31 décembre 2012, *Rev. Sociétés*, 2013, p. 482.

4586 Voir en ce sens : M. DUBERTRET, « L'*intuitu personae* dans les fusions », *Rev. Soc.*, 2006, p. 721, disponible sur www.dalloz.fr, pp. 12–21 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 360 à 398, nos 463–507.

4587 Pour un exemple de jurisprudence récente en la matière, voir C.A. Bordeaux, 4e ch., 18 février 2019, n° 17/03333, disponible sur www.lexis360.fr (07/01/2020), p. 6 au sujet d'une garantie à première demande.

de travail, malgré leur caractère *intuitu personae*[4588], ne sont pas couverts par cette exception[4589][4590].

858. Une position isolée. Cette interprétation du droit français venant restreindre la portée du principe de la transmission universelle et à titre universel consacré par le législateur européen demeure isolée au sein de l'Union européenne[4591] et n'apparaît qu'à l'égard de la France dans le cadre de l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale[4592]. Elle n'est d'ailleurs pas exempte de critiques en ce qu'elle pèche par excès d' « anthropomorphisme »[4593]. Ainsi, en droit belge, on considère depuis la loi de 1993 ayant transposé la Troisième Directive que la transmission universelle dont s'accompagne une fusion s'applique également aux contrats *intuitu personae*[4594]. Cette position est essentiellement basée sur le fait que (i) le texte de la Directive Sociétés[4595] ne prévoit aucune exception à cet égard[4596], pas plus que la Directive Mobilité qui précise même que la transmission universelle porte sur « tous les contrats, crédits, droits et obligations »[4597], (ii) l'*intuitu personae* n'existe à l'égard des sociétés que sous une forme atténuée[4598], qualifiée d'*intuitu firmae*[4599], c'est-à-dire que la personnalité du cocontractant en considération de laquelle la convention

4588 P. LE CANNU et Br. DONDERO, *op. cit.*, p. 1021, n° 1638.

4589 Art. L. 1224-1 du Code du travail français et M. DUBERTRET, *op. cit.*, p. 3.

4590 Cette exception peut toutefois s'expliquer par le fait que le régime de transfert des contrats de travail en cas de fusion et scission a été harmonisé par la Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, *J.O.*, L 61, 5 mars 1977, pp. 26–28, abrogée par la Directive 2001/23/CEE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, *J.O.*, L 82, 22 mars 2001, pp. 16–20.

4591 M. DUBERTRET, *op. cit.*, p. 2.

4592 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 194.

4593 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 360, n° 462.

4594 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 14 et G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 65 ; Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1214, n° 44 ; G. KEUTGEN, « La directive européenne sur les fusions nationales », *RPS*, 1979, p. 114 ; S. MAQUET et D. WILLERMAIN, *op. cit.*, p. 502 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 92 ; F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 179, n° 18 et P. VAN OMMESLAGHE, Les principes généraux relatifs à la fusion et à la scission selon les directives et selon la loi nouvelle, *op. cit.*, pp. 43–48.

4595 Art. 89, § 1er ; 90, § 1er et 105, §§ 1 et 3 de la Directive Sociétés pour les fusions internes, art. 119, § 2 et 131, §§ 1 à 3 de la Directive Sociétés pour les fusions transfrontalières et art. 136, § 1er ; 151, §§ 1er et 3 et 155, § 1er de la Directive Sociétés pour les scissions internes.

4596 M. DUBERTRET, *op. cit.*, pp. 2 et 3 ; Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1215, n° 44 ; P. HAINAUT-HAMENDE, *Les sociétés anonymes*, *op. cit.*, pp. 434 et 435, n° 842 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 92 ; P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, p. 1989, n° 1379 et P. VAN OMMESLAGHE, Les principes généraux relatifs à la fusion et à la scission selon les directives et selon la loi nouvelle, *op. cit.*, p. 44. Pour une position plus nuancée à cet égard, voir F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 181, n° 19.

4597 Art. 131, § 1, point a) et § 2, point a) de la Directive Mobilité pour les fusions transfrontalières et art. 160*ter*, point 4) et 160*novodecies* § 1er, point a), § 2, point a) et § 3, point a) pour les scissions transfrontalières.

4598 F. MOURLON BEERNAERT, *op. cit.*, p. 274 et P. VAN OMMESLAGHE, Les principes généraux relatifs à la fusion et à la scission selon les directives et selon la loi nouvelle, *op. cit.*, p. 47.

4599 F. MOURLON BEERNAERT, *ibidem*, p. 274 ; Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 290 et 291, nos 427 et 428 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 181, n° 19.

a été conclue « ne constitue qu'une garantie d'exécution »[4600], (iii) une scission est davantage à analyser comme une opération de transformation que comme une véritable transmission de contrats[4601], la personnalité juridique de la société absorbée étant continuée par les sociétés bénéficiaires[4602] et (iv) l'insécurité juridique qui en résulte[4603]. À l'appui de cette position vient encore s'ajouter le fait que les dispositions du CSA[4604] ne consacrent pas davantage d'exceptions pour cette catégorie spécifique de contrats. En outre, il a été défendu que le régime des fusions et scissions devait s'analyser comme une atteinte volontaire du législateur à l'*intuitu personae* dictée par la nécessité de préserver l'efficacité de ce type d'opérations et compensée par la mise en place d'un régime de protection des créanciers institutionnels[4605]. En droit luxembourgeois, la position n'est pas limpide et s'il a pu être avancé tant en doctrine[4606] que lors d'une ancienne décision de jurisprudence[4607] se référant en cela à la doctrine française, que l'exception des contrats *intuitu personae* devait également trouver à s'appliquer, cette position n'a généralement pas été suivie par la jurisprudence[4608]. Cette solution s'impose également compte tenu de la position du législateur luxembourgeois dans les travaux préparatoires où celui-ci a considéré, à l'égard des fusions, que « tous les autres droits non énumérés [au paragraphe 2 de l'article 1021-17 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales] passent automatiquement de la société absorbée à la société absorbante même vis-à-vis des tiers sans

4600 F. T'KINT et I. CORBISIER, *ibidem*, p. 176, n° 14.

4601 Voir en ce sens : Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 58, n° 72 et pp. 91 et 92, n° 111. Pour un point de vue critique, voir P. HAINAUT-HAMENDE, *Les sociétés anonymes*, *op. cit.*, p. 438, n° 844 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *ibidem*, pp. 165–170, n°s 6 et 183, n° 19.

4602 Voir en ce sens à propos des fusions : P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, *op. cit.*, p. 1990, n° 1379.

4603 Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1216 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 181, n° 18.

4604 Art. 12:13, al. 1er, 3° du CSA.

4605 F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 184, n° 20.

4606 A. SCHMITT, « Regards sur les transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité (articles 308*bis*-1 à 5 de la loi sur les sociétés commerciales), *ACE,* 2014/3, p. 21.

4607 T.A. Luxembourg, 8 avril 1987, n° 35197 où le tribunal d'arrondissement avait retenu que « [c]omme l'absorption et la fusion entraînent transmission universelle du partrimoine d'une société à une autre, avec son actif et son passif, il est admis en particulier que la société absorbante doit continuer les contrats de la société absorbée qui ne sont pas conclus *intuitu personae* ».

4608 Voir C.A. Luxembourg, 15 janvier 2014, n°s 38858 et 39595 où la Cour d'appel a rejeté l'argumentation d'un des appelants qui arguait qu'en vertu du caractère *intuitu personae* du contrat bancaire, la convention de prêt signée avec la banque ne pouvait être transférée à l'intimée par voie de scission sans l'accord donné à l'avance par les emprunteurs, donnant raison à l'intimée qui avançait qu'il résulte implicitement des dispositions sur les effets de la scission de la loi sur les sociétés commerciales que même les contrats *intuitu personae* pouvaient être transférés automatiquement aux sociétés bénéficiaires. Voir également C.A. Luxembourg, 1er février 2012, n°s 33072 et 33104 où la Cour a considéré que « [l]e fait que le contrat d'entreprise peut être conçu comme étant « *intuitu personae* », impliquant que l'entrepreneur doit personnellement l'exécution du contrat, ne signifie pas que l'entrepreneur ne peut transférer dans le cadre d'une cession du patrimoine d'une société à une autre les contrats d'entreprise […] s'agissant d'un transfert d'une universalité de droits et obligations d'une société vers une autre, et non du transfert d'un contrat isolé, l'accord du cédé n'est pas nécessaire ni pour le transfert des créances ni pour le transfert des dettes ainsi transmises ».

autre formalité »[4609], ce qui inclut les contrats *intuitu personae*, absents de l'énumération en question.

859. L'incidence d'une clause d'*intuitu personae* sur la transmission à titre universel. S'il est clair qu'en droit français, le seul caractère *intuitu personae* de la convention devrait à lui seul s'opposer à la transmission à titre universel du contrat en question, il serait erroné de postuler *ab initio* que l'adjonction d'une clause d'*intuitu personae* serait sans incidence en droit belge ou en droit luxembourgeois. En effet, la notion d'*intuitu personae* est « faussement claire »[4610] et son étendue est susceptible de varier considérablement au gré de la commune intention des parties[4611]. La limite entre la clause d'incessibilité et d'*intuitu firmae* peut ainsi s'avérer délicate à tracer en pratique, les deux catégories faisant preuve d'une certaine perméabilité[4612]. Ces limites floues incitent ainsi à procéder à un examen séparé de chaque convention conclue *intuitu personae* en faisant prévaloir la commune intention des parties pour déterminer si elle est, ou non, transmissible en cas de scission transfrontalière[4613]. Le principe étant que si la clause d'*intuitu societatis* devait en réalité s'analyser davantage comme une clause d'intransmissibilité, le contrat en question ne pourrait être couvert automatiquement par la transmission à titre universel[4614]. *A contrario*, en droit belge, une simple clause d'*intuitu personae* se bornant à indiquer qu'une convention a été conclue *intuitu personae* est sans incidence sur l'étendue de la transmission universelle[4615]. À titre d'illustration, une clause rédigée comme suit : « les Parties reconnaissent que le présent Contrat est conclu en considération de (*intuitu personae*) la personne de la Partie 2 et ne pourra en conséquence être transmis en cas (i) de fusion, (ii) de scission, (iii) d'apport partiel d'actifs, de branche d'activités ou d'universalité ou (iv) de toute autre opération de restructuration emportant transmission universelle ou à titre universel sans l'accord écrit et préalable de la Partie 2 », devrait être interprétée comme empêchant le transfert automatique du contrat en question. Dans un contexte transfrontalier, il est intéressant de relever que des situations plus subtiles sont susceptibles de survenir. Ainsi, un contrat affecté d'une clause d'*intuitu personae* précisant uniquement la nature de celui-ci, mais soumis au droit français devrait s'interpréter comme une clause d'intransmissibilité en cas de scission en raison des conséquences particulières attachées par le droit français à ce type de contrats.

4609 Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1984–1985, n° 2897, p. 16.

4610 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 103, n° 68.

4611 Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1215, n° 44 ; F. MOURLON BEERNAERT, *op. cit.*, p. 274 et P. WÉRY, *ibidem*, p. 103, n° 68. Voir également : Cass., 4 février 2013, *R.G.D.C.*, 2016/7, pp. 412–414 où la Cour de cassation belge a précisé que « [l]e juge apprécie en fait si un contrat qui, par nature, ne revêt pas un caractère *intuitu personae*, a été conclu en considération de la personne de l'un des cocontractants ».

4612 P. HAINAUT-HAMENDE, *Les sociétés anonymes*, *op. cit.*, p. 438, n° 844 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 178, n° 17.

4613 Voir en faveur d'une telle analyse au cas par cas : P. HAINAUT-HAMENDE, *ibidem*, p. 439, n° 844 et R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 361 à 398, n°s 463 à 507.

4614 Voir en ce sens également : F. MOURLON BEERNAERT, *op. cit.*, p. 274.

4615 Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1216, n° 44 et P. HAINAUT-HAMENDE, *Les sociétés anonymes*, *op. cit.*, p. 439.

2.3. La clause d'exigibilité immédiate ou « acceleration clause »

860. Exemple d' « *acceleration clause* » :

Merger:
The Borrower shall not (and the Borrower shall ensure that no other member of the Group will) enter into any amalgamation, demerger, merger, sale or contribution of all its assets and liabilities or of one of its branches of activities or other corporate reconstruction.
Event of Default
Each of the events or circumstances set out in this Clause is an Event of Default:
[…]
The Borrower or a Third Party Pledgor does not comply with any provision of the Finance Documents.
Acceleration
On and at any time after the occurrence of an Event of Default the Agent may, and shall if so directed by the Lenders, by notice to the Borrower:
a) cancel the Total Commitments whereupon they shall immediately be cancelled ;
b) declare that all or part of the Utilisations, together with accrued interest, and all other amounts accrued or outstanding under the Finance Documents be immediately due and payable, whereupon they shall become immediately due and payable ; and/or
c) declare that all or part of the Utilisations be payable on demand, whereupon they shall immediately become payable on demand by the Agent on the instructions of the Majority Lenders.

861. Un aménagement contractuel fréquent. Cette clause, fréquente en pratique[4616] et parfaitement licite[4617], est explicitement reconnue en droit français en cas de fusions[4618]. Se rapprochant de la clause d'intransmissibilité au point de pratiquement se confondre avec cette dernière lorsqu'elle aboutit à une déchéance du terme pure et simple, elle permet au créancier d'une société d'exiger immédiatement certaines prestations du débiteur en cas de survenance de certains évènements prédéfinis, tels qu'une fusion ou une scission[4619] et ce, quel qu'ait été le terme convenu à l'origine. La seule différence entre les deux types de clause réside dans le fait que l'élément déclencheur dans le cas de la clause d'intransmissibilité est la transmission à titre universel dont s'accompagne la scission, c'est-à-dire un effet de celle-ci, alors que dans le cas de la clause d'exigibilité immédiate, l'élément déclencheur est l'opération en tant que telle.

4616 Voir en ce sens : C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 98, n° 222 et J.-M. MOULIN, *op. cit.*, p. 64, n° 167. Pour un point de vue plus critique, mais isolé, voir R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 415, n° 532 qui émet certains doutes sur la licéité d'une telle clause en ce qu' « elle contrarie directement la possibilité pour le contractant de se restructurer, si le contrat est stratégique pour l'entreprise, ce qui pourrait être considéré comme disproportionné au regard de la nécessaire protection du cocontractant ».

4617 D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 114 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 310 et 311, n° 458.

4618 Art. L236-14 du Code de commerce français.

4619 D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 114 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, pp. 310 et 311, n° 458.

862. Efficacité de la clause. Ce mécanisme de protection contractuel est susceptible d'être particulièrement efficace lorsque les montants en jeu sont considérables. En effet, le fait qu'une dette dont le montant excède la capacité immédiate de remboursement de la société impliquée dans l'opération devienne immédiatement exigible impliquera la nécessité de procéder à un refinancement préalablement ou immédiatement après l'opération, ce dernier ayant de grandes chances d'être obtenu à des conditions moins favorables[4620].

2.4. La clause d'agrément

863. Exemple de clause d'agrément :

> *Each Party may assign or delegate all or part of its rights and obligations under this Agreement to any third party (through a sale, a capital contribution, a donation or any other transaction, including the sale or contribution of a division ("branche d'activités") or of a business as a whole ("universalité"), or a merger, spin-off or split-up) with the prior written consent of the other Party (such consent not to be unreasonably withheld, conditioned or delayed).*

864. Notion. La clause d'agrément[4621], qui peut être définie comme la clause par laquelle le cocontractant cédé se réserve le droit de se prononcer sur le choix du cessionnaire sans altérer la cessibilité du contrat[4622] est destinée à permettre au créancier de jouir d'un certain contrôle sur une opération qui a priori lui échappe. Il lui sera ainsi loisible soit d'approuver soit de récuser le nouveau contractant en cas de transmission du contrat[4623]. Dans le second cas, le refus entraînera la disparition du contrat *ex nunc* et le débiteur perdra le bénéfice du terme[4624]. Il est également intéressant de relever que la clause d'agrément ne doit pas nécessairement directement aboutir à la résiliation du contrat, mais qu'au contraire, il est possible de conditionner l'agrément à la fourniture d'une sûreté adéquate préalablement à la réalisation de l'opération[4625]. En d'autres termes, cette clause bénéficie d'une flexibilité accrue par rapport à une clause d'intransmissibilité assortie d'une résiliation automatique[4626], mais se rapproche très fort d'une clause d'intransmissibilité assortie d'une faculté de résiliation en ce qu'elle n'est pas purement prohibitive. La seule faible distinction qui subsiste est une question de degré. La clause d'agrément, contrairement à la clause d'intransmissibilité avec faculté de résiliation unilatérale, laisse davantage d'espoir quant à la poursuite de la relation contractuelle suite à la réalisation de l'opération[4627].

865. Une efficacité assortie de certaines limites. Cependant, les clauses d'agrément connaissent certaines limites amenuisant leur efficacité pratique. Ainsi, si

---

4620 M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 54.
4621 Sur l'incidence d'une clause d'agrément portant sur les transferts de titres d'une des sociétés bénéficiaires sur une scission transfrontalière, voir *infra* n°s 1005 à 1008.
4622 Voir en ce sens : Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1192, n° 18 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 476, n° 1128.
4623 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 400.
4624 J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 476, n° 1128.
4625 Voir en ce sens : J. SCHMEIDLER, *ibidem*, p. 455, n° 1073.
4626 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *op. cit.*, pp. 398 et 399, n° 510 et J. SCHMEIDLER, *ibidem*, p. 476, n° 1128.
4627 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 416, n° 533.

elles sont licites dans leur principe[4628], elles ne peuvent être insérées dans un contrat dont la transmissibilité est d'ordre public, comme le bail commercial en France par exemple[4629]. Qui plus est, selon certains auteurs[4630], l'application d'une telle clause ne saurait être discrétionnaire. En outre, il convient de relever que l'efficacité concrète de la clause en question dépendra fortement du soin qui aura été accordé à sa rédaction[4631] afin de veiller à ce que son applicabilité dans l'hypothèse d'une scission ne laisse planer aucun doute. En effet, une clause d'agrément peut aisément être interprétée comme une clause destinée à conférer un caractère *intuitu personae* à une convention qui en est en principe dépourvue[4632], avec toutes les difficultés d'application en cas d'opération emportant transmission universelle ou à titre universel qui en découlent[4633]. En outre, il est fréquent de prévoir en pratique que l'agrément ne peut être refusé de manière déraisonnable[4634]. Le caractère raisonnable ou non d'un refus d'agrément relèvera *in fine* de l'appréciation souveraine du juge du fonds, mais il est logique de penser que si le nouveau débiteur offre des garanties de solvabilité suffisante, un refus ne sera que difficilement défendable[4635]. Dans cette hypothèse, on peut néanmoins légitimement s'interroger sur le sort à réserver à un refus d'agrément motivé par la seule nature transfrontalière de l'opération en cas de scission transfrontalière par absorption en avançant que le législateur européen s'est abstenu de réglementer ce type d'opération en raison des risques accrus qu'elles présentent pour les *stakeholders*[4636]. La réponse finale à cette question dépendra évidemment de l'interprétation à conférer à la commune intention des parties, mais en l'absence d'autres précisions, un refus d'agrément d'une société offrant des garanties de solvabilité plus que suffisantes ne devrait pas être considéré comme raisonnable sur la base du seul motif qu'elle est soumise à une *lex societatis* distincte de celle du débiteur d'origine.

2.5. La clause de changement de contrôle

866. Exemple de clause de changement de contrôle :

If the Ultimate Beneficial Owner ceases to own (directly or indirectly) 90 per cent. or more of the legal and beneficial interest in the Borrower or the Shareholder, then:

a. the Borrower shall promptly notify the Agent upon becoming aware of that event ;

4628 R. RAFFRAY, *ibidem*, pp. 399 et 400, n° 511.
4629 R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 399, n° 511.
4630 Voir en ce sens : R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 413, n° 529 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 455, n° 1072.
4631 Voir Cass. civ., 27 mai 1997, n° 95-12.386, *RJDA*, 1997, n° 1163 où la Cour a refusé d'étendre une clause d'agrément visant l'apport partiel d'actif à l'hypothèse d'une fusion. Voir en ce sens également : R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 400, n° 511.
4632 Pour un exemple d'un auteur qui plaide en faveur d'une telle interprétation de la clause d'agrément, voir : R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 409, n° 524.
4633 Sur ces limites, voir *supra* n°s 856 à 858.
4634 C'est le sens de la locution « *such consent not to be unreasonably withheld* » qu'on retrouve fréquemment dans les contrats anglo-saxons.
4635 *Voir en ce sens :* S. P. ROBERT-TISSOT, « Consent not to be unreasonably withheld », *Comp. Law*, 1997, 18(4), p. 118.
4636 Voir 7e considérant de la Directive Mobilité.

b. a Lender shall not be obliged to fund a Utilisation ; and

c. if a Lender so requires and notifies the Agent, the Agent shall, by not less than 10 Business Days' notice to the Borrower, cancel the Available Commitment of that Lender and declare the participation of that Lender in the Loan, together with accrued interest, and all other amounts accrued or outstanding under the Finance Documents immediately due and payable, whereupon the Available Commitment of that Lender will be immediately cancelled, any Commitment of that Lender shall immediately cease to be available for further utilisation and all such outstanding participations in the Loan of that Lender, accrued interest and amounts will become immediately due and payable.

867. Notion et utilité en cas de scission transfrontalière. La clause de changement de contrôle est une clause importée du droit américain[4637]. Elle peut se définir comme une clause attachant certaines conséquences spécifiques à un changement de contrôle d'une des parties contractantes et destinée à en protéger le caractère *intuitu personae*[4638]. Elle pourra s'analyser comme une clause de résiliation unilatérale lorsqu'en cas de changement de contrôle, elle donnera le pouvoir à une des parties de mettre fin unilatéralement au contrat[4639], mais rien n'empêche les parties d'attacher d'autres conséquences à un tel changement de contrôle comme une obligation de renégociation[4640] ou l'extinction automatique du contrat[4641]. Elle présente la particularité de lier l'éventuelle disparition du contrat à la survenance d'un événement objectif[4642]. Ces clauses sont parfaitement licites[4643], mais ne peuvent toutefois être exercées que dans les limites de la bonne foi[4644] et ne peuvent contrevenir à des dispositions impératives ou d'ordre public[4645]. Si la notion de contrôle fait généralement

4637 Voir en ce sens : Al. LÄNGSFELD, « (Un-)Wirksamkeit von Change-of-Control-Klauseln – Zum neuen § 225 a IV 3 InsO », *NZI*, 2014, p. 735.

4638 Voir en ce sens : G. RUE, « Les clauses de changement de contrôle », *B.J.S.*, 2011/459, p. 15 ; C.-A. LEUNEN, T. L'HOMME et J. FILBICHE, « Augmentations de capital dans les sociétés cotées, clauses de changement de contrôle et assistance financière » in *L'impact du nouveau droit des sociétés sur la gouvernance des institutions financières et sur les transactions financières - De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de governance van financiële instellingen en op financiële transacties*, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 220 et 221 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 469, n° 1109.

4639 Al. LÄNGSFELD, *op. cit.*, p. 135 ; J. MAIDL, « Rechtsbeziehungen des Zielunternehmens in der M&A Transaktion – Change of Control Klausel als neue Spaltungsbremse? », *NZG*, 2018, p. 727 ; G. RUE, *ibidem*, p. 15 et J. SCHMEIDLER, *ibidem*, p. 469, n° 1109.

4640 Voir en ce sens : J. MAIDL, *ibidem*, p. 727.

4641 *Ibidem*.

4642 Voir en ce sens : P. WÉRY, « b) Les clauses qui lient la dissolution du contrat à la survenance de certains événements objectifs. », *Rép. not.*, Tome IV, Les obligations, Livre 1/1, La théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 1006.

4643 Il est utile de relever que ces clauses peuvent malgré tout tomber sous le coup de législations spécifiques, comme à titre d'illustration en droit belge, l'article 7:151 du CSA qui prévoit que « [d]ans les sociétés cotées, seule l'assemblée générale peut conférer à des tiers des droits affectant substantiellement le patrimoine de la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement substantiel à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement du contrôle exercé sur elle. Sous peine de nullité, la décision est déposée préalablement à la réception par la société de la communication visée à l'article 7:152 conformément à l'article 2:8, et est publiée conformément à l'article 2:14, 4. ». Voir également : Al. LÄNGSFELD, *op. cit.*, p. 735.

4644 Voir en ce sens : G. RUE, *op. cit.*, p. 15.

4645 P. WÉRY, « b) Les clauses qui lient la dissolution du contrat à la survenance de certains événements objectifs. », *op. cit.*, n° 1006.

l'objet d'une définition contractuelle, faisant notamment varier le pourcentage au-delà duquel les parties estiment être en présence d'un changement de contrôle[4646], on ne peut que relever qu'une scission transfrontalière, en ce que les nouvelles actions des sociétés bénéficiaires qui seront attribuées aux associés de la société scindée en échange de leurs actions de la société scindée ne manqueront pas d'altérer le pourcentage de détention des associés dans les différentes sociétés impliquées, sera susceptible de permettre à un créancier de mettre fin unilatéralement à sa relation contractuelle avec la société. De telles clauses sont fréquentes en pratique[4647], notamment dans les contrats de crédit[4648], et sont efficaces pour limiter les effets de la transmission à titre universel ou l'émission de nouvelles actions dont s'accompagne une scission[4649].

3. *Les clauses destinées à aménager les conséquences de l'opération sur le contrat*

3.1. La clause attributive de juridiction en vertu du Règlement Bruxelles I*bis*

868. Exemple de clause attributive de juridiction :

The Courts of Luxembourg shall have exclusive jurisdiction to hear and decide any dispute arising out or in connection with this Agreement.

869. Notion. La clause attributive de juridiction ou d'*electio fori* est celle par laquelle « les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé »[4650]. Elle permet aux parties concernées d'opter pour une juridiction qui n'aurait pas nécessairement été compétente en vertu des règles de rattachement classiques, auquel cas il s'agira d'une prorogation de compétence ou, au contraire, d'exclure la compétence d'une juridiction normalement compétente, ce qui entraînera une dérogation de compétence[4651]. Son objectif est donc d'éviter l'aléa lié à la détermination du juge compétent en désignant *ab initio* la juridiction qui aurait à connaître d'un éventuel litige. Elle permet ainsi d'atteindre une certaine prévisibilité à cet égard et a pour but d'enrayer toute tentative de *forum shopping*[4652]. La possibilité pour les parties à un contrat de déterminer conventionnellement le for compétent pour connaître de tout litige en lien avec une relation contractuelle spécifique est explicitement prévue par l'article 25 du Règlement Bruxelles I*bis* et découle de la liberté contractuelle[4653]. La notion

4646 À titre d'exemple de la définition de la notion de « contrôle », on peut citer la clause suivante : « *Control means the ownership of a majority stake, or the right to exercise in any given company or entity the majority of the voting rights, or the right to appoint the majority of the members of the management body of such company or entity, either pursuant to the applicable laws, its constitutional documents or agreements reached with third parties* ».

4647 Voir en ce sens : C.-A. LEUNEN, T. L'HOMME et J. FILBICHE, *op. cit.*, p. 220, n° 43.

4648 *Ibidem*.

4649 Voir en ce sens : J. MAIDL, *op. cit.*, p. 727.

4650 Art. 25, § 1er du Règlement Bruxelles I*bis*.

4651 H. DÖRNER in I. SAENGER (dir.), *Zivilprozessordnung : ZPO*, 8e éd., 2019, Baden-Baden, Nomos, Art. 25, n° 7.

4652 Voir en ce sens : J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 478, n° 1133.

4653 Voir en ce sens : H. DÖRNER in I. SAENGER (dir.), *op. cit.*, Art. 25, n° 7.

de « convention attributive de juridiction » au sens de ce dernier y reçoit une interprétation autonome[4654], de sorte qu'il suffit que la volonté des parties d'opter pour un for compétent soit claire et précise[4655], mais pas nécessairement explicite[4656]. Cependant, pour pouvoir bénéficier du régime du Règlement Bruxelles I*bis*, une clause d'élection de for devra nécessairement satisfaire à certaines conditions d'applicabilité, de fond et de forme.

870. Une condition d'applicabilité dans l'espace. L'art. 25 du Règlement Bruxelles I*bis* n'a vocation à s'appliquer que dans un contexte international[4657], puisque dans un contexte purement interne, la validité d'une clause attributive de juridiction devra être mesurée à l'aune du droit national[4658]. Cependant, le caractère international requis sera présent dès que deux parties ayant leur domicile dans le même État membre optent pour les juridictions d'un autre État membre ou encore lorsque les deux parties n'ont pas leur domicile au sein du même État membre[4659]. Pour peu qu'on se trouve dans un contexte international, le Règlement Bruxelles I*bis* sera applicable[4660] dès qu'une ou plusieurs juridictions d'un État membre auront été choisies par les parties, sans considération du domicile de celles-ci[4661]. En outre, il est intéressant de relever que les parties disposent de la possibilité non seulement d'opter pour les juridictions d'un État membre déterminé, mais également d'un lieu spécifique, comme dans l'exemple ci-dessus[4662].

871. Une condition de fond. Pour être valable, la clause attributive de juridiction devra nécessairement répondre à certaines conditions de fond et de forme. Ainsi, la convention en question devra nécessairement remplir une condition de fond, à savoir se rapporter à « des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé »[4663], ce qui sera nécessairement le cas lorsque le

4654 C.J.C.E., arrêt *Powell Duffryn c. Wolfgang Petereit*, 10 mars 1992, C-214/89, EU:C:1992:115, pt. 11.

4655 M. DECHAMPS, *op. cit.*, p. 10 et H. DÖRNER in I. SAENGER (dir.), *op. cit.*, Art. 25, n° 10 et C.J., arrêt *Profit Investment SIM SpA c. Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, Profit Holding SpA, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore et E3 SA*, 20 avril 2016, C-366/13, EU:C:2016:282, pt. 27.

4656 H. DÖRNER in I. SAENGER (dir.), *ibidem*, Art. 25, n° 10 et C.J., arrêt *Höszig Kft. c. Alstom Power Thermal Services*, 7 juillet 2016, C-222/15, EU:C:2016:525, pt. 43 où la Cour de justice a considéré qu'il est « suffisant que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître ». Voir également : C.J.C.E., arrêt *Coreck Maritime GmbH c. Handelsveem BV e.a.*, 9 novembre 2000, C-387/98, EU:C:2000:606, pt. 15.

4657 H. DÖRNER in I. SAENGER (dir.), *ibidem*, Art. 25, n° 5.

4658 H. DÖRNER in I. SAENGER (dir.), *ibidem*, Art. 25, n° 6 et C.J., arrêt *Refcomp SpA c. Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network et Climaveneta SpA*, 7 février 2013, C-543/10, EU:C:2013:62, pt. 17.

4659 H. DÖRNER in I. SAENGER (dir.), *ibidem*, Art. 25, n° 6.

4660 La Cour de justice a précisé qu'il ne s'agissait là que d'une condition d'applicabilité et non d'une condition de validité. Voir à ce sujet : M. Dechamps, « L'actualité de la prorogation volontaire de compétence en matière civile et commerciale : jurisprudence Brexit », *RDC-TBH*, 2018/1, p. 9 et C.J., arrêt *Refcomp SpA c. Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network et Climaveneta SpA*, 7 février 2013, C-543/10, EU:C:2013:62, pt. 17.

4661 Art. 25, § 1er, 1re phrase du Règlement Bruxelles I*bis*.

4662 H. DÖRNER in I. SAENGER (dir.), *op. cit.*, Art. 25, n° 21 et C.J., arrêt *Höszig Kft. c. Alstom Power Thermal Services*, 7 juillet 2016, C-222/15, EU:C:2016:525, pt. 49.

4663 Art. 25, § 1er, 1re phrase du Règlement Bruxelles I*bis* et C.J., arrêt *Höszig Kft. c. Alstom Power Thermal Services*, 7 juillet 2016, C-222/15, EU:C:2016:525, pt. 33 ; C.J., arrêt *Profit Investment SIM SpA c. Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli,*

litige trouve son origine dans le contrat qui contient une clause d'*electio fori*[4664]. Il convient encore de préciser que les clauses attributives de juridiction impliquant un travailleur, un consommateur ou concernant la matière d'assurances font l'objet de conditions spécifiques[4665] justifiées par la qualité des parties impliquées[4666]. De plus, il n'est pas possible de déroger par convention aux compétences exclusives instituées par l'art. 24 du Règlement Bruxelles I*bis*[4667], ce qui est sans incidence sur les contrats de crédit ou les contrats de distribution commerciale auxquels la société scindée sera éventuellement partie.

872. Les conditions de forme. Les conditions de forme, d'interprétation stricte[4668], visent, tout comme la condition de fond, à établir la réalité du consentement des parties[4669]. Il est ainsi prévu que la clause attributive de juridiction devra être conclue (i) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite[4670], (ii) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles[4671], ou encore (iii) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée[4672]. Il est en outre précisé que toute transmission par voie électronique permettant de consigner durablement la convention sera considérée comme revêtant une forme écrite[4673].

873. Efficacité de la clause attributive de juridiction dans le cas d'une scission transfrontalière. Une fois valablement convenue, la clause ne sera pas affectée par une modification ultérieure de circonstances factuelles ou juridiques[4674] et, sauf convention contraire[4675], la juridiction ainsi désignée sera seule compétente. En outre, il est intéressant de relever que la Cour de justice fait preuve d'une certaine souplesse au niveau de l'application des conditions de forme et elle a ainsi considéré que celles-ci étaient remplies par (i) une clause d'élection de for figurant dans des conditions générales directement

Francesco Redi, Profit Holding SpA, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore et E3 SA, 20 avril 2016, C-366/13, EU:C:2016:282, pt. 23 et C.J., Arrêt *Refcomp SpA c. Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA*, 7 février 2013, C-543/10, EU:C:2013:62, pt. 25.

4664 C.J., arrêt *Höszig Kft. c. Alstom Power Thermal Services*, 7 juillet 2016, C-222/15, EU:C:2016:525, pt. 34.

4665 Art. 25, § 4 du Règlement Bruxelles I*bis*.

4666 Voir en ce sens : M. DECHAMPS, *op. cit.*, p. 10.

4667 Art. 25, § 4 *in fine* du Règlement Bruxelles I*bis*.

4668 C.J.C.E., arrêt *F. Berghoefer GmbH & Co. KG c. ASA SA*, 11 juillet 1985, C-221/84, EU:C:1985:337, pt. 13.

4669 C.J., arrêt *Profit Investment SIM SpA c. Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, Profit Holding SpA, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore et E3 SA*, 20 avril 2016, C-366/13, EU:C:2016:282, pt. 27 et C.J., arrêt *Höszig Kft. c. Alstom Power Thermal Services*, 7 juillet 2016, C-222/15, EU:C:2016:525, pt. 32.

4670 Art. 25, § 1er, point a) du Règlement Bruxelles I*bis*.

4671 Art. 25, § 1er, point b) du Règlement Bruxelles I*bis*.

4672 Art. 25, § 1er, point c) du Règlement Bruxelles I*bis*.

4673 Art. 25, § 2 du Règlement Bruxelles I*bis*.

4674 H. DÖRNER in I. SAENGER (dir.), *op. cit.*, Art. 25, n° 7.

4675 Art. 25, § 1er, 2e phrase du Règlement Bruxelles I*bis*.

annexées au contrat[4676] et (ii) une décision d'élection de for figurant dans des conditions générales acceptées par clic sur internet[4677]. En tout état de cause, ce type de clause permet ainsi de protéger efficacement le créancier contre le risque lié à la nature transfrontalière de l'opération[4678] qui se manifestera notamment lorsque les procédures judiciaires sont beaucoup plus longues dans l'État membre des sociétés bénéficiaires[4679] ou encore si les frais de justice demeurent à charge du demandeur même lorsqu'il obtient gain de cause[4680]. D'un point de vue pratique, il est possible, par le biais d'une telle clause, d'aboutir à un résultat similaire à celui de la *perpetuatio fori* du Règlement sur la Société européenne[4681] ou de la Directive Mobilité en matière de transformations transfrontalières[4682], avec toutefois une flexibilité accrue dans la mesure où les parties ne sont pas cantonnées au choix des juridictions de l'État membre de départ et qu'aucune limitation temporelle ne s'applique au choix[4683]. D'un point de vue plus pragmatique, cette clause permet au créancier en position de force, comme une banque ouvrant une ligne de crédit ou un franchiseur concédant une franchise exclusive de s'assurer que les juridictions compétentes pour traiter d'un éventuel litige avec une société bénéficiaire d'une scission transfrontalière seront celles qui lui seront les plus favorables.

3.2. La clause d'adaptation générale, de renégociation ou de hardship

874. Exemple de clause de *hardship* :

> *Les Parties conviennent de se réunir, dans un délai de 30 Jours Ouvrables à compter de la réception de la demande écrite de l'une d'elles, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, si l'évolution exceptionnelle des circonstances économiques, politiques, monétaires, juridiques, nationales ou internationales bouleverse l'économie du contrat au point de rendre gravement préjudiciable à l'une des parties l'exécution de ses obligations (ci-après un « **Évènement de Hardship** »).*
>
> *Pour les besoins de cette clause, toute opération entraînant un transfert universel ou à titre universel des droits et obligations d'une des parties en vertu du présent Contrat, en ce compris, de manière non limitative, toute fusion, scission, apport partiel d'actifs, de branche d'activités ou d'universalité, sera irrévocablement considérée comme un Évènement de Hardship entraînant l'application de la procédure ci-dessous.*

4676 C.J., arrêt *Höszig Kft. c. Alstom Power Thermal Services*, 7 juillet 2016, C-222/15, EU:C:2016:525, pt. 39.

4677 C.J., Arrêt *Jaouad El Madjoub c. CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH*, 21 mai 2015, C-322/14, EU:C:2015:334, pt. 31. Pour un point de vue critique de cet arrêt, voir : M. DECHAMPS, *op. cit.*, pp. 14 et 15.

4678 Voir en ce sens : J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 480, n° 1140.

4679 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122k, n° 7.

4680 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 122j, n° 14 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122k, n° 7.

4681 Art. 8, § 16 du Règlement sur la Société européenne.

4682 Art. 86*undecies*, § 4 de la Directive Mobilité.

4683 Selon l'art. 86*undecies*, § 4 de la Directive Mobilité, la *perpetuatio fori* en matière de transformation transfrontalière est limitée à une durée de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation prend effet.

Les Parties s'engagent alors à renégocier les conditions financières du contrat dans un esprit de collaboration et d'équité en vue de se replacer dans une situation d'équilibre comparable à celle qui existait lors de la conclusion du Contrat.

Pendant cette période de renégociation qui ne pourra dépasser 30 Jours Ouvrables à compter de la première réunion des Parties (la ***Période de Renégociation****), le Contrat sera suspendu sans indemnités.*

À défaut d'accord à l'issue de la Période de Négociation, le présent Contrat pourra être résilié dans un délai de 60 Jours Ouvrables, sans indemnité, par la partie lésée par l'Évènement de Hardship (la ***Partie Lésée****). Pour éviter tout doute, en cas d'opération entraînant un transfert universel ou à titre universel des droits et obligations d'une des Parties en vertu du présent Contrat, la Partie Lésée sera uniquement celle ne prenant pas part à l'opération en question* »[4684].

875. Précisions terminologiques. Dans les contrats à prestations successives s'inscrivant dans la durée[4685] ainsi que dans les contrats à prestations différées dans le temps[4686], il est fréquent que les circonstances initiales sur lesquelles les parties se sont basées pour négocier leur accord se trouvent radicalement altérées par la suite. Il est aisé de concevoir qu'une scission transfrontalière constitue un tel bouleversement de circonstances rendant l'exécution de certaines obligations, comme une obligation de non-concurrence, particulièrement malaisée, voire impossible[4687]. Face à cette situation, et compte tenu de l'aléa affectant la théorie de l'imprévision[4688][4689], il est loisible aux parties d'intégrer *ab initio* une clause d'adaptation, de renégociation ou de *hardship* dans leur contrat en vue de leur permettre de restaurer l'équilibre contractuel en temps utile[4690]. D'un point de vue terminologique, la clause d'adaptation générale prévoit simplement à charge des parties une obligation d'adaptation des stipulations contractuelles en cas d'altération de l'environnement contractuel d'origine[4691]. La clause de renégociation, pour sa part, va plus loin, et engendre une obligation de renégociation à charge des parties en cas de survenance de

4684 Cet exemple de clause a été rédigé en se basant sur le modèle de R. BONHOMME et M. BOUTEILLE, « Fasc. F-250 : Clauses de variation de prix. – Guide de rédaction et exemples. – Formules », *Juris-Classeur Contrats-Distribution*, 15 septembre 2012, pp. 13 et 14.

4685 O. CLEVENBERGH, « Les changements significatifs défavorables ('Material Adverse Change') dans les contrats de cession d'actions ou d'actifs en droit belge », *RDC-TBH*, 2011/1, p. 10, n° 12 et D. PHILIPPE, « Chapitre 6 – Les clauses relatives au changement de circonstances dans les contrats à long terme », in *La rédaction des contrats internationaux*, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 143.

4686 P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 602, n° 589.

4687 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 455, n° 1074.

4688 Sur l'application de la théorie de l'imprévision aux scissions transfrontalières, voir *supra* n°s 832 à 836.

4689 Voir à ce sujet : A. M. GARRO, « Force majeure, hardship and other excuses », *RDIDC*, 2015/2, pp. 223–227 ; Al. NICOLAS, « Hardship : prévoir l'imprévisible », *C.J.*, 2013/3, pp. 92 et 93 et D. PHILIPPE, « Chapitre 6 – Les clauses relatives au changement de circonstances dans les contrats à long terme », *op. cit.*, pp. 143–149.

4690 Voir en ce sens : M. ALBERTINI, « Bouleversement du contrat par la crise : quelles clauses pour négocier ? », *Aides Pratiques et Ingénierie Sociétaire*, n° 111, Mai 2010, p. 5, disponible sur www.lexis360.fr (08/01/2020), p. 3 ; S. GOLDMANN et S. LAGASSE, *op. cit.*, p. 116, n° 55 ; Al. NICOLAS, *op. cit.*, pp. 93 et 94 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 456 et 457, n° 1077.

4691 Voir en ce sens : S. GOLDMANN et S. LAGASSE, *ibidem*, p. 116, n° 55 et J. SCHMEIDLER, *ibidem*, p. 459, n° 1085.

certains évènements généralement prédéterminés dans le contrat. La clause de *hardship*, parfois également dénommée « clause de sauvegarde », « clause d'imprévision » ou encore « clause de révision »[4692] est celle par laquelle les parties anticipent les conséquences de la survenance d'une situation d'imprévision sur leur relation contractuelle[4693 4694]. Contrairement aux deux premières, elle présuppose par conséquent une véritable rupture de l'équilibre contractuel[4695]. La licéité de ces clauses n'est pas discutée[4696] et elles sont fréquentes en pratique[4697].

876. Une efficacité potentiellement redoutable. À l'égard des clauses de renégociation, il a été avancé qu'en cas de fusion, leur efficacité était limitée car elles n'engendrent à charge des parties qu'une obligation de moyens[4698]. Cependant, il est erroné de porter un jugement d'efficacité sur cette seule base dans la mesure où celle-ci dépendra très fréquemment de la qualité de rédaction de la clause en question. En effet, dans l'hypothèse d'un contrat de crédit vital pour la continuation de l'entreprise et si la clause de renégociation prévoit *ab initio* (i) les hypothèses faisant naître à charge des parties une obligation de renégociation, (ii) la procédure de renégociation en tant que telle et (iii) une faculté de résiliation concédée à la partie qui n'est pas à l'origine de l'évènement ayant justifié l'obligation de renégociation, il y a fort à parier que la partie impliquée dans une scission transfrontalière déploiera tous les efforts nécessaires pour aboutir à une solution satisfaisante et ce, afin d'éviter les conséquences potentiellement dramatiques liées à une déchéance du terme. Le même constat s'applique aux clauses de *hardship* qui, correctement rédigées, envisagent également la situation dans laquelle les négociations ne devraient pas aboutir tout en prévoyant alors une faculté de résiliation pour la partie lésée ou les deux parties, ou encore de mandater un tiers qui sera chargé de procéder à l'adaptation du contrat[4699]. À cet égard, on peut débattre de la question de savoir si une scission transfrontalière constitue un véritable bouleversement de l'économie du contrat en dehors de toute autre précision

4692 R. BONHOMME et M. BOUTEILLE, *op. cit.*, pp. 11 et 12.

4693 E.-Ch. BUCHER, *op. cit.*, p. 3 et S. GOLDMANN et S. LAGASSE, *op. cit.*, p. 116, n° 55.

4694 Selon la définition figurant à l'art. 6.2.2 des Principes d'UNIDROIT (version de 2016), disponibles sur https://www.unidroit.org (03/01/2020), « [i]l y a hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l'équilibre des prestations, soit que le coût de l'exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué, et a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après la conclusion du contrat ; b) que la partie lésée n'a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement prendre de tels événements en considération ; c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée ; et d) que le risque de ces événements n'a pas été assumé par la partie lésée ».

4695 J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, pp. 457 et 458, n°s 1079 et 1080 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 602, n° 589.

4696 S. GOLDMANN et S. LAGASSE, *op. cit.*, p. 116, n° 55 ; Al. NICOLAS, *op. cit.*, p. 93 et P. WÉRY, *ibidem*, p. 602, n° 589.

4697 Al. NICOLAS, *ibidem*, p. 93 et P. WÉRY, *ibidem*, p. 602, n° 589. Pour de nombreux exemples de telles clauses, voir D. PHILIPPE, « Chapitre 6 – Les clauses relatives au changement de circonstances dans les contrats à long terme », *op. cit.*, pp. 149–168.

4698 J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 459, n° 1084.

4699 E.-Ch. BUCHER, *op. cit.*, p. 4 ; Al. NICOLAS, *op. cit.*, p. 94 ; D. PHILIPPE, « Chapitre 6 – Les clauses relatives au changement de circonstances dans les contrats à long terme », *op. cit.*, p. 155 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 603, n° 589.

contractuelle[4700]. Considérer qu'une scission transfrontalière constitue d'office un bouleversement grave de l'économie du contrat serait excessif dans la mesure où, s'il est vrai qu'une telle opération est susceptible de générer un nombre important de risques pour les créanciers[4701], ce n'est pas forcément le cas. Cependant, correctement rédigées[4702], les clauses de *hardship* font preuve d'une certaine précision et peuvent intégrer *ab initio* des évènements que les parties ont conventionnellement choisi d'intégrer[4703] en allant jusqu'à retenir une définition plus large de l'imprévision[4704]. En conséquence, il suffit d'intégrer les « opérations emportant transmission universelle ou à titre universel de patrimoine affectant l'une ou l'autre partie » dans la définition de la clause pour que le mécanisme de renégociation trouve à s'appliquer en cas de scission transfrontalière, ou encore pour qu'une des parties puisse mettre fin unilatéralement à la relation contractuelle[4705]. Ce type de clause est donc également susceptible d'être utilisée par la partie confrontée à la scission transfrontalière de son débiteur et, dans une telle hypothèse, s'avérera particulièrement efficace pour préserver l'équilibre contractuel[4706].

C. *Les insuffisances des mécanismes de protection conventionnels*

877. Une protection inadéquate pour certaines catégories de créanciers. Si ce tour d'horizon de certaines clauses susceptibles d'être rencontrées montre qu'il est tout à fait possible de protéger efficacement les intérêts des créanciers par ce moyen, force est de constater que ce type de protection ne s'adresse qu'à une catégorie limitée de créanciers, que l'on peut qualifier d' « *adjusting creditors* »[4707], ayant tout d'abord l'expérience, les moyens et le pouvoir de négociation nécessaires pour imposer celles-ci à leurs débiteurs[4708] et ensuite connaissance de leur qualité de créancier avant la réalisation de l'opération[4709]. À titre d'illustration, ce sera fréquemment le cas lorsqu'une banque consentira une ligne de crédit à une petite entreprise[4710]. *A contrario*, tant les créanciers en position faible qui ne sont pas en mesure d'imposer leurs conditions à la société impliquée dans une scission que les créanciers involontaires tels que ceux dont la créance découle de la responsabilité délictuelle de la société en question ne peuvent être protégés de manière adéquate par ces différents

4700 *Contra* : J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 462, n° 1092. Pour une position plus nuancée, voir : P. HAINAUT-HAMENDE, *Les sociétés anonymes*, *op. cit.*, p. 440, n° 844.
4701 À ce sujet, voir *supra* n°s 696 à 704.
4702 Selon les termes de A. M. GARRO, « [d]*rafting such clauses, however, calls for a certain level of craft* ». Voir A. M. GARRO, *op. cit.*, p. 220.
4703 E.-Ch. BUCHER, *op. cit.*, p. 3 ; R. BONHOMME et M. BOUTEILLE, *op. cit.*, p. 12 et S. GOLDMANN et S. LAGASSE, *op. cit.*, p. 116, n° 55.
4704 E.-Ch. BUCHER, *ibidem*, p. 3 et S. GOLDMANN et S. LAGASSE, *ibidem*, p. 116, n° 55.
4705 D. PHILIPPE, « Chapitre 6 – Les clauses relatives au changement de circonstances dans les contrats à long terme », *op. cit.*, p. 153 qui souligne la rareté, en pratique, de clauses permettant la résiliation du contrat sans procédure de renégociation préalable.
4706 Al. NICOLAS, *op. cit.*, p. 94 et A. M. GARRO, *op. cit.*, p. 220.
4707 Voir en ce sens : C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, p. 38.
4708 Voir en ce sens : H. MERKT, *op. cit.*, p. 108 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 53.
4709 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 53.
4710 Voir en ce sens : J. ARMOUR, *op. cit.*, p. 358.

mécanismes de protection[4711]. Dans le cas de ces derniers, il serait en effet particulièrement dommageable de leur imposer de négocier avec la société débitrice car, contrairement aux grands créanciers contractuels comme par exemple une banque ayant consenti une ligne de crédit, un petit créancier délictuel n'a, par définition, pas choisi d'entrer en relation avec son débiteur sur la base de critères rationnels[4712]. A cela s'ajoute d'une part, que ces créanciers délictuels ne sont susceptibles d'avoir connaissance de leur qualité de créancier que postérieurement à la réalisation de la scission et, d'autre part, que la société sera en position de force pour négocier le montant de la réparation à la baisse[4713]. Un constat similaire s'impose pour le plus grand créancier qu'est l'État, que ce soit par le biais de l'administration fiscale ou de l'organisme de sécurité sociale[4714], bien que dans cette hypothèse, il dispose d'autres moyens de protection, comme par exemple un traitement préférentiel en cas d'insolvabilité[4715]. En outre, la position de ces créanciers involontaires est d'autant plus précaire que les créanciers contractuels en position de force passeront avant eux et se réserveront en priorité certains actifs de la société. En d'autres termes, lorsqu'une banque réclame une garantie comme un gage sur compte ou une hypothèque en contrepartie d'un taux d'intérêt plus favorable à la société débitrice, cela revient à faire supporter une partie du risque aux créanciers involontaires qui ne disposeront plus que d'un accès subordonné aux éléments du patrimoine de la société débitrice en question[4716]. La situation n'est pas plus encourageante à l'égard des petits créanciers contractuels que sont, à titre d'illustration, les consommateurs et les petits fournisseurs. En effet, bien que ces derniers aient à un moment choisi volontairement d'entrer en relation avec la société débitrice, ils ne disposaient pas de la force de négociation nécessaire pour imposer des mécanismes contractuels permettant une défense efficace de leurs droits[4717].

878. Surveillance et apathie rationnelle. Au-delà de cette première limite liée au pouvoir de négociation dont jouit un créancier au moment de l'entrée en relation d'affaires, il convient encore de relever que l'efficacité de nombreuses mesures contractuelles de protection est intrinsèquement liée aux moyens de surveillance qui seront déployés par les créanciers ainsi qu'à leur niveau d'information[4718]. En d'autres termes, seuls les créanciers déployant les moyens nécessaires pour surveiller leur société débitrice et décidés à utiliser cette information pourront tirer pleinement parti des clauses destinées à protéger leurs intérêts, ce qui vient encore réduire le champ des créanciers efficacement protégés par ce mécanisme contractuel. S'il est certes vrai que le processus

4711 Voir en ce sens à propos des fusions : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 53. Voir également en ce sens à propos de l'exigence d'un capital social minimum : P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », *op. cit.*, pp. 395 et 396 et W. SCHÖN, *op. cit.*, p. 440.

4712 Voir en ce sens : H. EIDENMÜLLER et A. ENGERT, « Rechtsökonomik des Mindestkapitals im GmbH-Recht », *GmbHR*, 2005, p. 436 et P. MANKOWSKI, *ibidem*, p. 396.

4713 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI, *ibidem*, pp. 395 et 396.

4714 P. MANKOWSKI, *ibidem*, p. 396.

4715 À ce sujet, voir *infra* n°s 912 à 925.

4716 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », *op. cit.*, pp. 396 et 397.

4717 P. MANKOWSKI, *ibidem*, pp. 397 et 400.

4718 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI, *ibidem*, p. 404.

de scission transfrontalière est jalonné d'étapes destinées à assurer la bonne information des *stakeholders*, il n'en demeure pas moins que les créanciers devront en outre être décidés à utiliser cette information pour protéger leurs droits, ce qui constitue à nouveau un terrain propice à l'émergence d'un phénomène d'apathie rationnelle.

879. Une situation d'équilibre difficile à atteindre. La protection des créanciers par le biais de mécanismes contractuels librement négociés entre parties prête également le flanc à la critique sous l'angle de la situation d'équilibre qui doit être atteinte entre les intérêts de la société à réaliser une opération importante pour sa survie économique et la nécessaire protection des intérêts des créanciers contre une décision qui échappe a priori à leur contrôle[4719]. En effet, en pratique, le postulat selon lequel les mécanismes de protection conventionnels et le taux d'intérêt applicables au crédit reflètent adéquatement le risque encouru par le créancier est loin de se vérifier systématiquement[4720]. Cela sera d'autant plus le cas que les grands créanciers auront tendance à adopter une position plus défensive tout en jouant sur leur position de force au moment des négociations pour imposer des conditions disproportionnées sur la base du principe « *take it or leave it* »[4721].

D. *Conclusion sur les mécanismes de protection conventionnels*

880. Une protection potentiellement efficace. Il ressort de l'analyse qui précède que des solutions négociées au cas par cas par les parties intéressées sont indéniablement de nature à garantir une protection plus adéquate de certains créanciers dans la mesure où elles tiennent davantage compte des spécificités de chaque situation[4722]. Ainsi, tant les clauses destinées à permettre au créancier de mettre fin à la relation contractuelle, telles que les clauses d'intransmissibilité, d'*intuitu personae*, d'exigibilité immédiate et d'agrément que les clauses destinées simplement à aménager les conséquences de l'opération sur la relation contractuelle préexistante telles que la clause attributive de juridiction et la clause de *hardship* font preuve d'une efficacité redoutable pour les parties capables de les imposer. En outre, s'il est indéniable que ce type de protection est principalement destiné à protéger les intérêts des grands créanciers, au nombre desquels les banques ayant consenti des lignes de crédit figurent au premier plan, cela n'empêchera toutefois pas les petits créanciers de bénéficier par ricochet de certaines clauses négociées par des créanciers plus importants[4723], comme par exemple dans le cas d'une clause d'agrément. En effet, dans ce dernier cas, le créancier important a peu de chance d'autoriser

4719 Sur cet équilibre, voir *supra* n[os] 705 à 711.

4720 P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », *op. cit.*, p. 405.

4721 *Ibidem*.

4722 Voir en ce sens : W. SCHÖN, *op. cit.*, p. 441 ; M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 52 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 53.

4723 Voir en ce sens : H. MERKT, *op. cit.*, pp. 108 et 109 qui avance que les créanciers importants jouent un rôle de « *factual trustee* » pour les petits créanciers. *Contra* : P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », *op. cit.*, pp. 401 et 402 qui avance que les grands créanciers poursuivent leur propre agenda sans considération pour le bien commun.

une scission transfrontalière si celle-ci devait avoir un impact négatif significatif sur la situation patrimoniale de la société débitrice, ce qui évitera également aux autres créanciers de devoir en subir les conséquences.

881. Certaines limites à prendre en compte. En tout état de cause, il serait erroné de considérer de manière générale que les créanciers sont les mieux placés pour garantir leur protection au moyen de mécanismes d'ordre privé[4724]. En effet, les créanciers contractuels en position de faiblesse par rapport à la société, comme les petits fournisseurs, les créanciers délictuels, comme ceux ayant subi un dommage du fait d'un produit défectueux, et les créanciers étatiques, comme l'administration fiscale, ne sont pas en mesure d'imposer de tels mécanismes conventionnels à une société. En outre, l'efficacité de ce mécanisme est à relativiser encore au vu du fait qu'elle dépend étroitement des moyens de surveillance déployés par le créancier intéressé ainsi que de son éventuelle apathie rationnelle. D'un point de vue davantage global, il convient également de relever que ce type de protection risque aisément de faire pencher la balance entre la nécessité de permettre à une société de se restructurer et la nécessaire protection des intérêts des créanciers en faveur de cette dernière.

882. Une nécessaire articulation entre mécanismes privés et publics. Ces insuffisances expliquent pourquoi le législateur européen a fait le choix d'introduire des mécanismes spécifiques tant dans la Directive Sociétés en cas de scission interne[4725] que dans la Directive Mobilité en cas de scission transfrontalière[4726] spécifiquement destinés à la protection des créanciers[4727]. En d'autres termes, si les mécanismes contractuels sont certes efficaces et facilement adaptables aux spécificités de chaque situation, ils ne peuvent suffire à eux seuls à protéger efficacement les intérêts de toutes les catégories de créanciers. Ils devront dès lors nécessairement être complétés par des mécanismes individuels ou institutionnels instaurés par le législateur mais protégeant également les petits créanciers ainsi que les créanciers passifs[4728]. Ceci étant, il est toutefois également indispensable qu'un régime européen des scissions transfrontalières ne vienne pas remettre en cause les mécanismes de protection conventionnels librement négociés par les parties par le biais de la transmission à titre universel. Une telle articulation est, à titre d'illustration, explicitement prévue en droit français[4729]. Il est en outre possible d'interpréter la récente modification du régime des effets des fusions transfrontalières introduite par la

4724 Voir en ce sens de manière générale : J. ARMOUR, *op. cit.*, p. 373 ; L. ENRIQUES et L. MACEY, *op. cit.*, pp. 1184 et 1185 et W. SCHÖN, *op. cit.*, p. 439. *Contra* : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 52.

4725 Art. 146 de la Directive Sociétés.

4726 Art. 160*undecies* de la Directive Mobilité.

4727 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 52.

4728 Voir en ce sens : M. WINNER, *ibidem*, p. 53. D'un point de vue plus général à l'égard de la nécessité d'imposer un capital social minimum en droit des sociétés, voir P. MANKOWSKI, « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? », *op. cit.*, p. 409 et W. SCHÖN, *op. cit.*, p. 440.

4729 Art. L236-14, al. 5 du Code de commerce français qui prévoit explicitement que le droit d'opposition consacré par le droit français ne fait pas « obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société ».

Directive Mobilité comme une manifestation de la part du législateur européen d'une volonté de préserver, si ce n'est d'encourager, les solutions conventionnelles. En effet, alors que l'art. 131 de la Directive Sociétés précisait uniquement que la fusion transfrontalière impliquait que « *l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée* » était transféré à la société bénéficiaire, le nouvel article 131 introduit par la Directive Mobilité précise dorénavant que cette transmission inclut « *tous les contrats, crédits, droits et obligations* ». Il est ainsi possible de voir dans cette disposition une transmissibilité de principe des contrats conclus par la société scindée destinée à clore les débats au sein des différents États membres sur les éventuelles limites à la transmission universelle de patrimoine[4730], comme, à titre d'illustration, en droit français à l'égard des contrats *intuitu personae*[4731]. Par ricochet, cela devrait inciter les parties à prévoir *ab initio* le sort du contrat en cas d'opération transfrontalière si elles souhaitent aménager celui-ci. En tout état de cause, une telle position se doit d'être encouragée et il convient de laisser une certaine marge de manœuvre afin de permettre aux parties de négocier des solutions au cas par cas.

§4. Les autres moyens de protection envisageables

883. Les mécanismes de protection alternatifs. Avant de pouvoir porter un jugement sur la forme que devrait revêtir un système de protection efficace des créanciers, il convient encore d'analyser deux mécanismes de protection alternatifs, à savoir l'obligation de préserver l'intégrité des branches d'activité de la société scindée (A) et l'annulation de l'opération de scission (B) qui, bien qu'ils ne se retrouvent ni au niveau des normes européennes, ni au niveau des droits nationaux, méritent quelques développements.

A. *Le respect de l'intégrité des branches d'activités dans le projet commun de scission combiné à une solidarité des entités issues de la scission*

884. Une nécessaire ventilation par branche d'activités. Ni la Directive Sociétés en matière de scissions internes[4732], ni la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières[4733] n'imposent de limites précises au sujet de la répartition des éléments d'actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires. Celle-ci sera dès lors librement décidée par les associés[4734] sous réserve de certaines

4730 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 306 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 616 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 25, n° 4 ; E. SCHLUMBERGER, « Les fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 6, n° 28 et 29 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 243.

4731 À ce sujet, voir *supra* n° 107. Au sujet plus spécifiquement de la circulation du contrat de cautionnement, voir *supra* n° 693.

4732 Art. 136, § 1er, 137, § 2, point h) et 155, § 1er de la Directive Sociétés.

4733 Art. 160*ter*, § 4 et 160*quinquies*, point l) de la Directive Mobilité.

4734 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 823 et 824, n° 59 ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 55 et M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 19.

limites restreintes[4735]. Cette marge de manœuvre génère un risque propre aux scissions pour les créanciers[4736]. Afin notamment de protéger les créanciers en garantissant la pérennité de l'activité économique sous-jacente et la possibilité d'accroître le volet actif du patrimoine des sociétés concernées qui en découle[4737], il a été proposé d'imposer que la répartition doive nécessairement respecter l'intégrité de chaque branche d'activités[4738].

885. Notion. La notion de branche d'activités existe de longue date en droit fiscal[4739] et y est définie comme « l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens »[4740]. Cette définition se rapproche de celle figurant dans le CSA[4741] et la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales[4742], bien que la définition relevant du droit des sociétés soit considérée comme davantage contraignante en ce qu'elle ne permet pas, dans le cadre d'un apport de branche d'activités, d'en exciper certains éléments[4743]. Il n'en demeure pas moins que les enseignements en matière fiscale sont utiles pour appréhender la portée de cette notion[4744]. Or, à cet égard, la Cour de justice a eu l'occasion de préciser que « le fonctionnement autonome de l'exploitation doit être apprécié en premier lieu d'un point de vue fonctionnel — les actifs transférés doivent pouvoir fonctionner comme une entreprise autonome sans avoir besoin, à cet effet, d'investissements ou d'apports supplémentaires — et seulement en second lieu d'un point de vue financier »[4745]. Il n'est donc pas surprenant qu'en matière sociétaire, le rattachement de certains éléments d'actif

4735 Sur ces limites, voir n°s 492 à 495.

4736 Étude d'impact, pp. 68 et 69 ; Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 30 et G.-A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 », *op. cit.*, p. 72 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 77 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 25 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 7 ; P. STOCKENHUBER, *op. cit.*, p. 285 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 51.

4737 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 175, n° 210.

4738 *Ibidem*.

4739 P. HAINAUT-HAMENDE et G. RAUCQ, « La société anonyme. Première partie : constitution et fonctionnement », *Rép. Not.*, Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 3/1, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 237, n° 147 et J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *op. cit.*, p. 1090, n° 1610. Sur l'interprétation de la notion de « *branche d'activité* » en droit fiscal, voir notamment : L. DEKLERCK et Th. BLOCKERYE, *Plus-values et moins-values*, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 211–216 et A. SCHUMACHER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, Anh. § 151, n° 11–20.

4740 Art. 2, point j) de la Directive Fiscale.

4741 Selon l'art. 12:11 du CSA, « [u]ne branche d'activités est un ensemble qui, d'un point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens ».

4742 Art. 1040-3, al. 3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales qui définit une branche d'activités comme « un ensemble qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens ».

4743 Voir en ce sens : P. HAINAUT-HAMENDE et G. RAUCQ, *op. cit.*, p. 239, n° 147 et Th. TILQUIN, « Le transfert d'une universalité ou d'une branche d'activité », *J.T.*, 1996, p. 501.

4744 Voir en ce sens : Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1235, n° 74 et P. HAINAUT-HAMENDE et G. RAUCQ, *op. cit.*, p. 239, n° 147.

4745 C.J.C.E., arrêt *Andersen og Jensen ApS c. Skatteministeriet*, 15 janvier 2002, C-43/00, EU:C:2002:15, pt. 35.

ou de passif à une branche d'activités doive se faire de manière objective[4746] sur la base d'une appréciation factuelle[4747]. On considère toutefois que les parties conservent malgré tout un certain pouvoir d'appréciation pour allouer certains éléments du patrimoine d'une société à l'une ou l'autre branche d'activités[4748]. Il sera certes loisible aux créanciers de contester le cas échéant la répartition décidée par les parties, mais le contrôle ainsi opéré devra demeurer marginal[4749].

886. Une justification par la cause de la scission. La reconnaissance d'une telle exigence de préservation de l'intégrité de chaque branche d'activités comme condition à la transmission à titre universel de patrimoine résultant de l'opération de scission découle, selon son défenseur, de la cause même de la scission[4750]. Cette dernière peut s'analyser comme la volonté de rendre indépendante la gestion d'une certaine activité économique afin soit d'en préparer la cession ultérieure (cas de déconcentration suivie de concentration ultérieure) ou d'en maximiser la valeur sur les marchés (cas de déconcentration pure et simple).

887. Certains avantages indéniables. À cet égard, une ventilation du patrimoine de la société scindée en respectant l'intégrité des branches d'activité ou faisant preuve d'une certaine cohérence est indéniablement de nature à fournir une clé d'interprétation du projet commun facilitant l'allocation d'un élément oublié[4751] et renforçant la sécurité juridique[4752]. En outre, elle limite les effets néfastes pour les créanciers liés à leur expropriation partielle en évitant la concentration de dettes indépendantes dans une des sociétés bénéficiaires redoutée par certains législateurs nationaux[4753] et elle simplifierait le recours à l'action paulienne, la preuve d'une fraude étant plus simple à rapporter en cas de non-respect de l'intégrité des différentes branches d'activités[4754].

888. Une exigence à rejeter. Cependant, une telle exigence se doit d'être rejetée pour trois raisons distinctes. Ainsi, tout d'abord, force est de constater qu'elle ne se retrouve ni dans le texte de la Directive Sociétés relatif aux scissions internes[4755], ni dans celui de la Directive Mobilité relatif aux scissions transfrontalières[4756]. Il aurait pu être avancé que cette omission traduisait simplement une volonté du législateur européen de laisser cette question à la

4746 Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1236, n° 75 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 100 et Th. TILQUIN, « Le transfert d'une universalité ou d'une branche d'activité », *op. cit.*, p. 501.

4747 Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1236, n° 75.

4748 Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1236, n° 75 ; P. HAINAUT-HAMENDE et G. RAUCQ, *op. cit.*, p. 239, n° 147 et Th. TILQUIN, « Le transfert d'une universalité ou d'une branche d'activité », *op. cit.*, p. 501.

4749 Voir en ce sens : Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1236, n° 75 ; D.-E. PHILIPPE et D. PHILIPPE, *op. cit.*, p. 100 et Th. TILQUIN, *ibidem*, p. 501. Voir également P. HAINAUT-HAMENDE et G. RAUCQ, *op. cit.*, p. 237, n° 147, ce « contrôle marginal » implique que « ce qui importe surtout est de savoir si l'apporteur ou les parties ont raisonnablement pu considérer que le transfert portait sur une branche d'activités ».

4750 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 175, n° 210.

4751 *Ibidem* ; H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 79 ; M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 126, n° 66 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 335, n° 502.

4752 R. RAFFRAY, *ibidem*, p. 175, n° 210.

4753 Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), commentaire des articles, *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699, p. 121.

4754 R. RAFFRAY, *op. cit.*, p. 175, n° 210.

4755 Art. 136, § 1er, 137, § 2, point h) et 155, § 1er de la Directive Sociétés.

4756 Art. 160*ter*, § 4 et 160*quinquies*, point l) de la Directive Mobilité.

libre appréciation des différents législateurs nationaux. Cependant, une telle limite contreviendrait à la définition même de la notion de *scission* en vertu de la Directive Sociétés[4757] et de la Directive Mobilité[4758] qui fait fi d'une telle limite. De plus, l'Étude d'impact, en mettant en lumière la liberté dont jouissent les associés au moment de la répartition du patrimoine de la société scindée pour justifier l'existence de mesures plus protectrices dans le cadre des scissions que dans le cadre des fusions montre clairement que le législateur européen n'avait pas envisagé de laisser les États membres instaurer de telles limites générales. Ensuite, une telle exigence ne respecterait pas l'impératif d'équilibre entre les intérêts de la société à se restructurer et la nécessaire protection des créanciers et priverait injustement du bénéfice potentiel d'une scission, une société ne disposant que d'une seule branche d'activités[4759] ou en présence d'un financement externe délicat à répartir entre plusieurs branches d'activités[4760]. Troisièmement, l'argument de la sécurité juridique se doit d'être fortement relativisé en raison du caractère imprécis de la notion de « *branche d'activités* » et des contestations qui pourraient potentiellement résulter du fait qu'il s'agit avant tout d'une question factuelle[4761] pour laquelle les parties conservent une certaine marge d'appréciation[4762], raison pour laquelle il a été avancé qu'une telle exigence serait source d'insécurité et de retards dans le processus de scission en raison d'éventuelles contestations de la part de tiers intéressés[4763].

B. *L'annulation de l'opération de scission*

889. Une solution en cas d'opération abusive. Faut-il permettre à un créancier dont les intérêts sont gravement mis en danger par l'opération, mais qui ne le découvre que postérieurement à la réalisation de celle-ci, de requérir l'annulation de la scission transfrontalière[4764] ? Une telle solution pourrait présenter un certain intérêt, notamment en matière de responsabilité environnementale ou nucléaire où les dommages ne sont pas immédiatement décelables et où une société pourrait abusivement recourir à une scission transfrontalière pour nuire aux intérêts des créanciers.

4757 Art. 136, § 1er et 155, § 1er de la Directive Sociétés.
4758 Art. 160*ter*, § 4 de la Directive Mobilité.
4759 Voir en ce sens : Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1235, n° 73 qui relève à propos de l'apport d'une branche d'activité en droit belge que celui-ci « suppose donc que la société apporteuse exerce une autre activité que celle transmise ».
4760 Voir en ce sens : Fl. GEORGE, *ibidem*, p. 1236, n° 75 et M. F. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 15.
4761 À titre d'illustration, voir à propos de la notion de « branche d'activité » en matière fiscale : C.J.C.E., arrêt *Andersen og Jensen ApS c. Skatteministeriet*, 15 janvier 2002, C-43/00, EU:C:2002:15, pts. 34–38.
4762 Fl. GEORGE, *op. cit.*, p. 1236, n° 75 ; P. HAINAUT-HAMENDE et G. RAUCQ, *op. cit.*, p. 239, n° 147 et Th. TILQUIN, « Le transfert d'une universalité ou d'une branche d'activité », *op. cit.*, p. 501.
4763 M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 15.
4764 Sur la question plus générale des cas de nullité des scissions transfrontalières, voir *supra* nos 668 à 670.

890. La position ambiguë du législateur européen. Si tant le régime des scissions internes[4765] que celui des fusions internes[4766] en vertu de la Directive Sociétés prévoient certaines hypothèses dans lesquelles la nullité d'une telle opération pourrait être prononcée, la question est plus tranchée dans le régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés où il est explicitement prévu que la nullité d'une telle opération ne peut être prononcée[4767]. Cependant, si dans la Directive Sociétés, le législateur européen s'était clairement prononcé à l'encontre de la possibilité de demander la nullité d'une fusion transfrontalière au nom de la sécurité juridique en affirmant que « [d]ans un souci de sécurité juridique, il convient d'interdire de prononcer la nullité d'une fusion transfrontalière après la date à laquelle la fusion transfrontalière a pris effet »[4768], il semble avoir adopté une position plus nuancée dans le cadre de la Directive Mobilité. En effet, dans cette dernière, il énonce qu' « il ne devrait pas être possible de prononcer la nullité d'une opération transfrontalière qui a pris effet conformément à la procédure prévue dans la présente directive »[4769]. Il va même plus loin en précisant que cette limitation est sans préjudice « des pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l'application de la loi conformément aux législations nationales, en particulier dans les cas où l'autorité compétente ou d'autres autorités pertinentes établissent, notamment à partir de nouvelles informations substantielles, après la prise d'effet de l'opération transfrontalière, que l'opération transfrontalière a été réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles »[4770]. Cette porte ouverte, qui se retrouve tant dans le régime des transformations transfrontalières[4771] que dans le régime des scissions transfrontalières[4772] et a été ajoutée dans le régime des fusions transfrontalières[4773] lors du Compromis Final[4774], mais qui était absente de la Proposition de la Commission[4775], du Premier Compromis de la Présidence[4776], du Deuxième Compromis de la Présidence[4777] ainsi que du Compromis des Représentants Permanents[4778], montre à quel point la position du législateur européen a évolué sur cette question. En effet, dès l'avis de la Commission des affaires juridiques, il a été proposé d'ajouter un paragraphe 1*bis* à l'article 160*quatervicies* stipulant que « [t]outefois, si, au cours des deux années suivant la prise d'effet de la scission transfrontalière, de nouvelles informations sur ladite scission, suggérant une infraction d'une des dispositions de la présente directive, sont

[4765] Art. 153 de la Directive Sociétés.
[4766] Art. 108 de la Directive Sociétés.
[4767] Art. 134 de la Directive Sociétés.
[4768] 61e considérant de la Directive Sociétés.
[4769] 50e considérant de la Directive Mobilité.
[4770] 50e considérant de la Directive Mobilité.
[4771] Art. 86*unvicies*, al. 2 de la Directive Mobilité.
[4772] Art. 160*duovicies*, al. 2 de la Directive Mobilité.
[4773] Art. 134, al. 2 de la Directive Mobilité.
[4774] Art. 86u, al. 2 ; 134, al. 2 et 160w, al. 2 du Compromis Final.
[4775] Art. 86*duovicies* et 160*quatervicies* de la Proposition de la Commission.
[4776] Art. 86u et 160w du Premier Compromis de la Présidence.
[4777] Art. 86u et 160w du Deuxième Compromis de la Présidence.
[4778] Art. 86u et 160w du Compromis des Représentants Permanents.

portées à la connaissance des autorités compétentes, ces dernières révisent leur évaluation des faits en l'espèce et sont habilitées à prendre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas de montages artificiels »[4779] et ce dans l'optique de lutter contre les montages artificiels en exigeant que les sociétés exercent une activité économique effective dans l'État membre de destination[4780]. C'est ainsi également dans une optique de lutte anti-abus[4781] que le Compromis Final[4782], la Proposition du Parlement[4783] et la Directive Mobilité[4784] ont intégré une exception anti-abus à l'impossibilité de déclarer la nullité d'une scission transfrontalière ayant valablement pris effet. En conséquence, il n'est pas possible d'affirmer que l'introduction d'une procédure permettant aux créanciers d'obtenir la nullité d'une scission transfrontalière en cas d'atteinte excessive à leurs droits serait nécessairement contraire à la volonté du législateur européen. Pour autant, on peut néanmoins s'interroger sur la question de savoir si un tel régime serait souhaitable.

891. Une solution à rejeter. Cependant, la protection des créanciers en leur donnant accès à une action en nullité d'une scission transfrontalière doit être rejetée *ab initio*. Tout d'abord, force est de constater qu'un tel régime serait foncièrement contraire à la liberté d'établissement et que l'atteinte qu'il porterait à cette dernière n'aurait que très peu d'espoir de remplir les conditions du « *Gebhard test* »[4785], ne fût-ce qu'en raison de l'existence d'autres moyens de protection moins intrusifs, comme la possibilité de demander des garanties, ayant les faveurs de la Cour de justice[4786]. Ensuite, on ne peut qu'adhérer au point de vue selon lequel la nullité d'une opération transfrontalière est une sanction inadaptée[4787], notamment en raison des difficultés pratiques liées à un détricotage d'une telle opération[4788] et de l'insécurité juridique qui en résulterait[4789]. Il est également utile de préciser qu'une nullité *ex nunc* est à rejeter au même titre qu'une nullité *ex tunc* d'une part en raison de l'impact que cela

4779 Art. 160*quatervicies*, § 1*bis* de l'Avis CAJ.
4780 Avis CAJ, exposé des motifs, pp. 216 et 217.
4781 50e considérant du Compromis Final ; 50e considérant de la Proposition du Parlement et 50e considérant de la Directive Mobilité. Le 50e considérant de la Directive Mobilité prévoit ainsi qu' « afin de garantir la sécurité juridique, il ne devrait pas être possible de prononcer la nullité d'une opération transfrontalière qui a pris effet conformément à la procédure prévue dans la présente directive. Cette restriction est sans préjudice des pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l'application de la loi conformément aux législations nationales, en particulier dans les cas où l'autorité compétente ou d'autres autorités pertinentes établissent, notamment à partir de nouvelles informations substantielles, après la prise d'effet de l'opération transfrontalière, que l'opération transfrontalière a été réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. À cet égard, les autorités compétentes pourraient également examiner si le seuil national de déclenchement de la participation des travailleurs applicable dans l'État membre de la société qui procède à l'opération transfrontalière a été atteint ou dépassé dans les années suivant l'opération transfrontalière ».
4782 Art. 86u, al. 2 ; 134, al. 2 et 160w, al. 2 du Compromis Final.
4783 Art. 86*duovicies*, al. 2 ; 134, al. 2 et 160*quatervicies*, al. 2 de la Proposition du Parlement.
4784 Art. 86*unvicies*, al. 2 ; 134, al. 2 et 160*duovicies*, al. 2 de la Directive Mobilité.
4785 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.
4786 À ce sujet, voir *supra* n° 766.
4787 Voir en ce sens : C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 75, n° 165.
4788 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 219 et 220 et J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 151, n° 344.
4789 G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 17, n° 19 et S. MAQUET, *op. cit.*, p. 36.

ne manquerait pas d'avoir sur les tiers ayant, dans l'intervalle, contracté avec la société issue de l'opération[4790] et d'autre part, parce que certains éléments du patrimoine de la société dissoute auront disparu ou, qu'au contraire, de nouveaux éléments auront fait leur apparition[4791]. Ces difficultés, encore renforcées dans un contexte transfrontalier[4792], incitent à rejeter l'idée de protéger les intérêts des créanciers au moyen d'une éventuelle action en nullité. À cet égard, force est de constater que les dégâts causés par une opération abusive aux créanciers pourraient très bien être réparés par l'octroi de dommages et intérêts[4793] au paiement duquel toutes les sociétés bénéficiaires seraient tenues. Dans un même ordre d'idées, un mécanisme spécifique de responsabilité des membres de l'organe de gestion[4794] ne remettant pas en cause la validité de l'opération serait de loin préférable[4795], tout en ayant l'avantage d'être potentiellement plus efficace[4796].

§5. Conclusion sur les mécanismes de protection des créanciers

892. Une nécessaire articulation entre mécanismes institutionnels et mécanismes individuels. Le premier constat qui ressort de l'étude des mécanismes de protection qui précède est que les mécanismes de protection individuels, peu important à cet égard qu'ils aient été institués par le législateur ou, au contraire, qu'ils aient été contractuellement négociés, reposant sur un comportement actif des créanciers ne sont, à eux seuls, pas suffisants pour garantir la neutralité de l'opération de scission transfrontalière sur la situation des créanciers. En effet, ces mécanismes s'adressent exclusivement aux créanciers actifs, bien informés et ayant les moyens d'agir en temps utile[4797]. *A contrario*, les petits créanciers ont davantage tendance à faire preuve d'apathie rationnelle de sorte que leur protection doit être assurée par des mécanismes institutionnels. Cependant, le deuxième constat qui s'impose est que s'en remettre aux seuls mécanismes institutionnels serait excessif, en ce sens que ces derniers, étant donné qu'ils s'appliquent automatiquement et indépendamment d'un risque réel pour les créanciers, constituent une entrave plus importante à la liberté d'établissement des sociétés impliquées. À titre d'illustration, une solidarité illimitée des sociétés issues de la scission est indéniablement un moyen efficace de protéger tant les créanciers importants que les plus petits créanciers ou les créanciers involontaires. Cependant, il s'agit là d'un moyen particulièrement intrusif et beaucoup plus restrictif que, par exemple, la possibilité pour les créanciers de demander des garanties additionnelles en cas de risque concret

4790 Voir en ce sens : 54e considérant de la Directive Sociétés et D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 220 et C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 75, n° 165 et B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 78.

4791 Voir en ce sens à propos des fusions internes : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 20, n° 78.

4792 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 220. En ce sens également à propos du régime de la société européenne : M. SCHEIFELE, *op. cit.*, p. 299.

4793 D. BEUTEL, *ibidem*, p. 220.

4794 Sur l'efficacité d'un tel mécanisme de protection des créanciers, voir *supra* nos 839 à 846.

4795 Voir en ce sens : C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 75, n° 165.

4796 Sur l'efficacité d'un tel mécanisme de protection des créanciers, voir *supra* nos 839 à 846.

4797 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 53.

pour le remboursement de leur créance. En effet, ce dernier mécanisme de protection ne trouvera à s'appliquer que si l'opération présente un véritable danger pour les créanciers et ne restreindra pas la liberté d'établissement des sociétés impliquées dans une scission transfrontalière n'impliquant que des sociétés largement solvables. En d'autres termes, les mécanismes de protection individuels sont davantage conformes au principe de proportionnalité du « *Gebhard test* », raison pour laquelle la possibilité de demander des garanties a les faveurs de la Cour de justice[4798]. Si on ajoute à cela que les différents mécanismes de protection envisagés isolément ne permettent pas d'aboutir à une solution satisfaisante, on aboutit à la conclusion qu'il convient d'apprécier la manière dont ces différents moyens s'articulent ensemble pour atteindre un niveau de protection efficace[4799]. En d'autres termes, au lieu d'imposer un mécanisme unique permettant de protéger les créanciers, il conviendra de développer un système incorporant divers mécanismes où les avantages des uns pallieront les inconvénients des autres et vice versa.

893. Une défense en profondeur[4800]**.** Il s'ensuit que la protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière devra nécessairement s'articuler autour d'une défense élastique en profondeur. L'étude de quelques mécanismes de protection conventionnels a démontré que ces derniers présentaient à la fois une grande souplesse permettant de les adapter à des situations très précises et une efficacité significative pour les créanciers en mesure de les imposer. A ces avantages s'ajoute qu'une opération transfrontalière n'aura aucune incidence sur le droit applicable au contrat, ne fût-ce qu'en raison du fait que les contrats en question contiennent, sauf rare exception, une clause désignant le droit applicable indépendamment des facteurs de rattachement relevant du droit des sociétés. En conséquence, le système de protection à mettre en place en matière de scissions transfrontalières devra nécessairement promouvoir en priorité des solutions contractuelles, ce qui suppose cependant la mise en place d'un mécanisme de protection institutionnel par le biais d'obligations d'information étendues. En effet, ces dernières permettront aux créanciers de réagir en temps utile et, le cas échéant, de se prévaloir de leurs prérogatives contractuelles avant que l'opération n'ait pris effet. Cette première ligne de défense montre toutefois rapidement ses limites face aux risques engendrés par une scission transfrontalière pour les créanciers involontaires, les créanciers n'ayant pas connaissance de leur qualité ou encore les petits créanciers en position plus faible et dans l'incapacité d'imposer des mécanismes de

4798 Arrêt *Centros*, pt. 37 et arrêt *Polbud*, pt. 58.

4799 Voir en ce sens à propos des fusions : S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 80.

4800 Le terme « défense en profondeur » est emprunté au vocabulaire militaire et désigne une stratégie défensive indirecte et élastique s'appuyant sur la profondeur qui consiste à entourer les biens à défendre par plusieurs lignes de défense participant toutes à la défense globale, mais autonomes (la perte d'une ligne de défense n'entraîne pas la chute de la totalité du système défensif) et ayant chacune un rôle spécifique à jouer (affaiblir l'attaque, retarder l'ennemi, etc.). Ce terme a par la suite également été utilisé dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la sécurité des systèmes d'information. À ce sujet, voir : Mémento sur la défense en profondeur appliquée aux systèmes d'information du Secrétariat général de la défense nationale français du 19 juillet 2004, disponible sur https://www.ssi.gouv.fr (23/11/2020) et H. COUTEAU-BÉGARIE, *Traité de stratégie*, Economica, Paris, 1997, p. 332, n° 171.

protection contractuels. La deuxième ligne de défense fera intervenir les mécanismes de protection individuels aussi bien propres au régime des scissions transfrontalières, comme la possibilité de demander des garanties adéquates, que relevant du droit des obligations, comme l'action paulienne et la théorie de l'imprévision. Cependant, ces mesures défensives seront dans l'incapacité de résoudre le problème de l'apathie rationnelle et ne seront d'aucune utilité pour les créanciers ne découvrant leur dommage que postérieurement à la réalisation de l'opération. C'est à ce stade que la troisième ligne de défense, composée de mécanismes de protection institutionnels par définition plus intrusifs du point de vue de la liberté d'établissement, comme la solidarité passive des sociétés bénéficiaires pour les dettes de la société scindée ou encore l'instrumentalisation de l'autorité compétente pour le contrôle de conformité devront entrer en jeu. Cette stratégie défensive indirecte[4801] présente le double avantage d'une part d'être proportionnelle en ce que les mécanismes de protection les plus intrusifs n'entrent en scène que lorsque *res ad triarios rediit*, mais également de tenir compte des avantages et des limites des mécanismes individuels et des mécanismes institutionnels.

SECTION 2. LES ASPECTS TEMPORELS DE LA PROTECTION DES CRÉANCIERS

§1. Présentation

894. Au-delà des aspects matériels. L'efficacité d'un régime de protection des créanciers ne dépend toutefois pas exclusivement du choix des mécanismes destinés à préserver les intérêts de ces derniers. En effet, d'autres facteurs, au nombre desquels on compte les aspects temporels, auront une influence considérable sur celle-ci. L'élaboration d'un régime de protection équilibré nécessite en effet de déterminer, d'une part, à partir de quand la protection commence à courir (§ 2), et, d'autre part, pour combien de temps celle-ci sera disponible pour les créanciers (§ 3).

§2. Le point de départ de la protection

895. Plan du § 2. Pour pouvoir émettre un avis éclairé sur le choix du législateur européen à l'égard du point de départ des mécanismes de protection des créanciers et son éventuelle compatibilité avec les exigences d'un régime plus vaste des scissions transfrontalières (E), il convient en premier lieu d'étudier les différents régimes qui existent au sein des États membres (A), pour ensuite examiner méthodiquement les avantages et inconvénients tant d'un système de protection *ex ante* (B) que d'un système de protection *ex post* (C), ainsi que les inconvénients liés à la coexistence de différents mécanismes de protection justifiant une harmonisation à l'échelle européenne (D).

[4801] H. COUTAU-BÉGARIE, *ibidem*, pp. 332 et 333.

A. *Une grande diversité au sein des États membres*

896. Mécanismes de protection *ex ante* et *ex post*. De manière assez schématique, on distingue les régimes de protection *ex ante* des régimes de protection *ex post*[4802]. Les premiers ont pour caractéristique d'avoir leur point de départ avant la date de prise d'effet de l'opération, alors que les seconds ne trouvent à s'appliquer qu'une fois que l'opération a pris effet[4803].

897. Une précision absente du régime scissions internes. Les dispositions de la Directive Sociétés relatives à la protection des créanciers en matière de scissions internes ne précisent pas la date à partir de laquelle les créanciers peuvent agir et demander l'octroi de garanties de nature à assurer le paiement de leurs créances. Comme il appartient dès lors aux États membres de déterminer le point de départ de la période de protection, il n'est pas surprenant de constater que celui-ci diffère fortement d'un État membre à un autre. À titre d'illustration, le point de départ des mécanismes de protection des créanciers sera (i) la publication des actes constatant la scission interne ou transfrontalière en droit luxembourgeois[4804] (régime de protection *ex post*), (ii) la publication de l'inscription de la scission interne en droit autrichien[4805] (régime de protection *ex post*), (iii) la publication de l'inscription de la scission interne au registre compétent pour la société débitrice en droit allemand[4806] (régime de protection *ex post*), (iv) la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la scission interne en droit belge[4807] (régime de protection *ex post*), (v) la dernière insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou, le cas échéant, au Bulletin des annonces légales obligatoires ou la mise à disposition du public du projet commun sur le site internet de chacune des sociétés en droit français[4808] (régime de protection *ex ante*) et (vi) l'inscription de la dernière décision de l'assemblée générale de procéder à la scission en droit italien[4809] (régime de protection *ex ante*).

898. Fusions transfrontalières et société européenne. De même, à l'égard des fusions transfrontalières, ni les dispositions de la Directive Sociétés[4810], ni celles du Règlement sur la Société européenne[4811] n'expriment de préférence

4802 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 19 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 535 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 35 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 38 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 18 ; M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 54 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 57. Voir également : J. SCHMEIDLER, *op. cit.*, p. 170, n° 391 qui distingue entre les mécanismes *a priori* et les mécanismes *a posteriori* selon que le mécanisme en question est disponible avant ou après la date de prise d'effet de l'opération.

4803 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 200 ; Th. PAPADOPOULOS, *ibidem*, p. 535 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *ibidem*, p. 35 ; J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 18 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *ibidem*, p. 54. Voir également : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 19 et M. WINNER, *ibidem*, p. 57 qui considèrent en revanche que la date charnière est celle de la tenue de l'assemblée générale.

4804 Art. 1031-10, § 1er de la Loi du 10 août 1915.

4805 § 15(2) SpaltG.

4806 §§ 22 (1) et 133 (1) UmwG.

4807 Art. 12:15, § 1er du CSA.

4808 Art. R236-8, al. 1er du Code de commerce français.

4809 Art. 2503 du Codice civile.

4810 Art. 99 et 121, § 1, b) et § 2 de la Directive Sociétés.

4811 Art. 24, § 1er du Règlement sur la Société européenne.

pour l'un ou l'autre système de protection. Ceci explique la grande diversité existant entre les États membres à cet égard[4812]. Il demeure que cette absence d'harmonisation est considérée par beaucoup comme un obstacle significatif à la réalisation d'une fusion transfrontalière[4813] et dans le cadre de la consultation de 2015, 86 % des personnes ayant exprimé un avis sur la question de l'harmonisation de la date de départ de la période de protection des créanciers ont exprimé le souhait de voir cet aspect des fusions transfrontalières harmonisé, tout en privilégiant un mécanisme de protection *ex ante*[4814].

B. *Avantages et inconvénients d'un système de protection* ex ante

899. Un régime plus protecteur ? Un système de protection *ex ante*, c'est-à-dire un mécanisme dont le point de départ se situe avant la date de prise d'effet de l'opération[4815], présente indiscutablement l'avantage de permettre aux créanciers de la société scindée d'agir directement contre leur débiteur d'origine sans avoir à se soucier des sociétés bénéficiaires soumises à un droit étranger[4816]. Un régime de protection *ex ante* offre un niveau de protection élevé pour peu qu'il soit combiné avec une information adéquate et en temps utile des créanciers[4817]. En outre, comme il permet de clarifier la situation des créanciers avant la prise d'effet de l'opération, il devient possible d'éviter un risque d'érosion de la solvabilité des sociétés bénéficiaires après la prise d'effet de l'opération en raison de l'obligation de fournir des sûretés additionnelles à certains créanciers[4818].

900. Un certain nombre d'inconvénients. L'argument selon lequel un système de protection *ex ante* est plus avantageux car il évite aux créanciers de la

4812 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale, l'Allemagne, l'Autriche, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Roumanie et la Slovénie appliquent un régime de protection *ex ante*, alors que la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, la République tchèque, la Slovaquie et la Suède appliquent un régime de protection *ex post*. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 54.

4813 T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1166 ; ECLE, *op. cit.*, p. 200 ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, *op. cit.*, pp. 53 et 54 ; R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 420 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 18 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, pp. 245 et 246 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 54.

4814 Fusions et scissions transfrontalières – Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), http://www.europarl.europa.eu (27/09/2017), p. 8 et Consultation publique de 2015, p. 8.

4815 Consultation publique de 2015, p. 8 et Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 535 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 37 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 18 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 54. Voir également : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 19 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 57.

4816 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Chr. LOUVEN, « Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie », *op. cit.*, p. 2028 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *ibidem*, p. 37 et J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 18. Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : A. FRANCK, *op. cit.*, p. 197.

4817 Voir en ce sens à propos des fusions : S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 111 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 535 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 57.

4818 Voir à ce sujet à propos des fusions : S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 111.

société scindée d'agir devant des juridictions étrangères se doit toutefois d'être relativisé car le Règlement Bruxelles I*bis* garantit aux créanciers d'une société soumise au droit d'un État membre la possibilité d'exiger le paiement de leur créance au travers toute l'Union européenne[4819]. De plus, un système de protection *ex ante* n'est pas exempt d'inconvénients car il ne protégera efficacement que les créanciers vigilants. Il serait certes possible d'imposer une obligation de consultation de tous les créanciers pour y parer, cependant, en présence de nombreux créanciers, cela impliquerait un fastidieux et coûteux exercice[4820] qui viendrait en outre limiter les avantages de la transmission à titre universel dont s'accompagne une opération de scission. À ce premier inconvénient s'ajoute celui qu'un tel système, en imposant une nécessaire période de protection avant la date de prise d'effet de l'opération, risque de retarder considérablement et inutilement la réalisation des scissions qui ne posent pas de dangers pour les créanciers[4821], voire de compromettre purement et simplement l'opération[4822]. Ce désavantage peut être limité d'une part en réduisant la période de protection au strict minimum, mais cela renforce la problématique liée à la vigilance des créanciers et, d'autre part, en permettant aux créanciers de réduire contractuellement la durée de cette protection, comme c'est le cas par exemple en droit allemand dans le régime de protection des créanciers en cas de fusion ou de scission interne[4823]. À ces premiers défauts s'ajoute encore le fait qu'un système de protection *ex ante*, *a fortiori* s'il est assorti d'un droit de veto, est susceptible d'être utilisé abusivement par certains créanciers en vue d'améliorer leur position[4824].

C. *Avantages et inconvénients d'un système* ex post

901. Un régime plus favorable aux sociétés impliquées. Contrairement au système de protection *ex ante*, un système de protection *ex post*, c'est-à-dire un régime de protection dont le point de départ se situe après la date de prise d'effet de l'opération[4825], présente l'indéniable avantage de ne pas retarder la

4819 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *op. cit.*, p. 843 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 19 et Chr. LOUVEN, « Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie », *op. cit.*, p. 2028.

4820 Voir à ce sujet à propos des fusions : S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 111.

4821 Voir à ce sujet à propos des fusions : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 58 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 37 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 535 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 19 ; S. KALSS, *ibidem*, p. 111 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 57.

4822 Voir à ce sujet à propos des fusions : J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 19.

4823 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 59 ; B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 19 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 5 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 39.

4824 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 60.

4825 Voir en ce sens : Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 535 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 35 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 54. Voir également : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 19 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 57 qui considèrent en revanche que la date charnière est celle de la tenue de l'assemblée générale.

scission[4826]. Ceci signifie qu'une telle opération pourra être réalisée à plus brève échéance et, par conséquent, permettra aux entreprises de s'adapter plus rapidement aux éventuelles conditions changeantes du marché. Ce mécanisme est donc plus favorable à la mobilité transfrontalière des personnes morales qu'un mécanisme *ex ante*[4827]. En outre, il permet également de prévoir des délais de protection plus longs pour les créanciers que ne le permettrait un mécanisme *ex ante* assorti d'un effet suspensif[4828].

902. Un régime moins protecteur ? Cependant, comme un tel régime ne permet pas aux créanciers de réagir avant la réalisation de l'opération, la situation de ces derniers demeure incertaine au moment de la prise d'effet de l'opération[4829]. Ceci implique que dans certains cas, comme par exemple en cas de scission au profit d'une société en mauvaise santé financière, il sera potentiellement trop tard pour leur venir en aide[4830]. En outre, comme les créanciers de la société scindée n'auront d'autre choix que d'agir contre les sociétés bénéficiaires, ils se retrouveront par la force des choses soumis à l'aléa d'un droit étranger qui leur est potentiellement inconnu[4831]. Si ce dernier risque se doit d'être fortement relativisé[4832], il n'en demeure pas moins que les coûts de recouvrement risquent de s'en ressentir dans la mesure où les honoraires des conseils impliqués seront nécessairement plus élevés en cas de procédure transfrontalière qu'en cas de procédure interne.

903. Un régime plus conforme aux principes de proportionnalité et de neutralité. Dans la mesure où une scission transfrontalière est à analyser comme une modalité particulière d'exercice de la liberté d'établissement[4833], toute entrave à cette dernière pour une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des intérêts des créanciers[4834], devra nécessairement être conforme aux principes d'effectivité et de proportionnalité. Or, si un mécanisme de protection *ex ante* est indéniablement de nature à protéger efficacement les intérêts des créanciers, *a fortiori* s'il est assorti d'un droit de veto, force est de constater qu'un régime de protection *ex post* remplit également cet objectif tout en étant moins intrusif du point de vue de la liberté d'établissement. On peut donc en conclure qu'un régime de protection *ex ante* pourrait aisément être considéré comme une entrave injustifiée à la liberté d'établissement par

4826 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 59 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *ibidem*, pp. 37 et 38 ; Th. PAPADOPOULOS, *ibidem*, p. 535 et M. WINNER, « Creditor protection… », *ibidem*, p. 57.

4827 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 59 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 18 et 19 et M. WINNER, *ibidem*, p. 57.

4828 Voir en ce sens : R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 429.

4829 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 59 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 536 et G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, pp. 37 et 38.

4830 Voir à ce sujet à propos des fusions : S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, pp. 111 et 112 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 57.

4831 Sur ce risque pour les créanciers de la société scindée, voir *supra* n° 699.

4832 Sur ce point, voir *supra* n°s 716 à 734.

4833 Sur ce point, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.

4834 Arrêt *Centros*, pt. 39 ; arrêt *Überseering*, pt. 92 ; arrêt *Inspire Art*, pt. 132 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; et arrêt *Polbud*, pt. 52.

la Cour de justice[4835]. En outre, en ce qu'il ne permet pas aux créanciers des sociétés impliquées de profiter de l'opération pour améliorer leur position, comme par exemple en retardant excessivement une opération importante pour la survie économique d'une entreprise dans le but de lui faire accepter de nouvelles conditions de prêt, un régime de protection *ex post* est également davantage conforme à l'objectif de neutralité[4836].

D. *Inconvénients de la coexistence de différents mécanismes de protection*

904. Un risque commun à tous les créanciers des sociétés impliquées. Dans un contexte transfrontalier, l'éventuelle nécessité d'articuler le cas échéant un système de protection *ex ante* avec un système de protection *ex post* est susceptible de générer certaines difficultés qui ne se présenteraient pas dans un contexte purement interne[4837]. En effet, dans l'hypothèse où le régime de protection applicable à la société scindée intervient *ex post*, alors que celui applicable aux sociétés bénéficiaires s'applique *ex ante*, tant les créanciers de la société scindée que ceux des sociétés bénéficiaires sont susceptibles de se retrouver dans une situation délicate. En ce qui concerne les premiers, le risque provient de ce que les créanciers des sociétés bénéficiaires auront eu tout le loisir de demander une sûreté avant la prise d'effet de l'opération ce qui, à supposer que les sociétés bénéficiaires soient en difficultés financières, risque d'aggraver encore la situation des créanciers de la société scindée qui ne seront à même de faire valoir leurs droits qu'après la prise d'effet de l'opération. Du point de vue des créanciers des sociétés bénéficiaires, le risque provient de ce qu'ils se retrouveront confrontés suite à la prise d'effet de l'opération à un mécanisme de protection soumis à un droit étranger dont les conséquences ne sont que difficilement prévisibles au moment où ils sont en mesure d'invoquer leur propre régime de protection[4838]. La situation inverse, c'est-à-dire celle dans laquelle le régime de protection des créanciers de la société scindée intervient *ex ante* alors que les régimes de protection des créanciers des sociétés bénéficiaires interviennent *ex post* s'avère également problématique[4839]. En effet, les créanciers de la société scindée risquent de se retrouver confrontés à des mécanismes de protection inattendus après la prise d'effet de l'opération dont seuls les créanciers des sociétés bénéficiaires pourront profiter. Ceci signifie que dans cette hypothèse, la situation des créanciers de la société scindée, bien qu'étant par définition la plus délicate en cas de scission transfrontalière[4840], se retrouvera encore aggravée. Ces deux hypothèses suffisent amplement à

4835 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 60. *Contra* : A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 113.
4836 À ce sujet, voir *supra* n° 706.
4837 G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, pp. 37 et 38 ; St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 38 ; R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 419 et Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 245.
4838 Voir en ce sens : Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 536 et R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 420.
4839 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 38.
4840 À ce sujet, voir *supra* n°s 735 à 749.

démontrer les risques pour les créanciers des sociétés impliquées découlant de l'absence d'harmonisation du point de départ des mécanismes de protection des créanciers dans le cadre d'une opération transfrontalière, mais il convient encore de remarquer que comme une scission transfrontalière implique, à l'exception du cas particulier de la scission partielle, une pluralité de sociétés bénéficiaires, il est tout à fait concevable que les créanciers des sociétés bénéficiaires ne soient pas soumis au même type de régime de protection, une première société bénéficiaire pouvant être soumise à un régime *ex post* alors que la deuxième se verra appliquer un régime *ex ante*. La situation est susceptible d'être particulièrement complexe pour les créanciers confrontés à une telle opération et les conséquences de cette dernière sur leur situation personnelle s'avéreront impossibles à déterminer avec certitude.

905. Le risque de comportements opportunistes. En outre, la coexistence de différents régimes de protection laisse une marge de manœuvre aux sociétés leur permettant d'adopter un comportement opportuniste de nature à exacerber les risques pour les créanciers. En d'autres termes, au-delà des risques liés à la seule absence d'harmonisation du point de départ de la protection des créanciers, il y a encore un risque que certaines sociétés au sein d'un même groupe ne réalisent une opération de scission transfrontalière que dans le but de privilégier certains créanciers ou, au contraire, de nuire à d'autres[4841].

E. *La position de la Directive Mobilité*

906. La consécration d'un régime *ex ante*. Consciente de la nécessité de procéder à une harmonisation de cet aspect de la protection des créanciers[4842] et ne suivant pas en cela les recommandations faites dans une des études préliminaires selon laquelle, compte tenu des inconvénients significatifs d'un système de protection *ex ante*, un système de protection *ex post* semble préférable ne fût-ce qu'en raison du fait qu'il permet une période de protection plus longue sans compromettre la réalisation de l'opération[4843], la Proposition de la Commission introduit un régime de protection *ex ante* à l'égard des scissions transfrontalières[4844], et ce, alors même que certains auteurs pensaient que la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt *KA Finanz* allait induire un mouvement progressif vers les régimes de protection *ex post*[4845]. Il y était ainsi prévu, d'une part, que le projet de scission devrait inclure « les détails des garanties offertes aux créanciers »[4846], étant entendu que ceci ne signifiait pas que des garanties devaient nécessairement être offertes aux créanciers[4847], et d'autre part, que les créanciers insatisfaits de la protection offerte spontanément par la société dans le projet commun pouvaient demander des garanties

4841 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 30.
4842 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, pp. 37 et 38 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 65.
4843 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 19 et 30.
4844 Voir en ce sens : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 66.
4845 Voir en ce sens : T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1166.
4846 Art. 160*sexies*, § 1er, point (r) de la Proposition de la Commission.
4847 Voir en ce sens : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 66.

adéquates à l'autorité judiciaire ou administrative compétente dans le mois suivant la publication du projet. Cette solution, qu'on retrouvait également à l'égard des fusions transfrontalières[4848] et des transformations transfrontalières[4849], n'a été altérée ni par le Premier Compromis de la Présidence[4850], ni par la Proposition du Parlement[4851], ni par la Directive Mobilité[4852] qui ont toutefois étendu le délai applicable à trois mois. Le principal inconvénient d'un système de protection *ex ante*, à savoir l'éventuel retard de la réalisation des opérations ne présentant pas de dangers pour les créanciers[4853], a toutefois été écarté car le mécanisme de protection des créanciers n'a pas d'effet suspensif[4854]. En effet, l'assemblée générale pourra se prononcer sur le projet de scission transfrontalière dès qu'un délai d'un mois suivant la publication du projet de scission se sera écoulé[4855]. Il s'ensuit qu'au moment où un créancier mécontent introduira sa demande, l'opération pourra déjà avoir pris effet[4856]. De plus, à supposer qu'un créancier ait introduit une demande avant la date de prise d'effet de l'opération, la Directive Mobilité[4857] n'impose pas que celle-ci ait un effet suspensif comme dans le cas du régime belge[4858]. Il ressort toutefois du trente-septième considérant de la Directive Mobilité que les États membres demeurent libres d'y attacher de tels effets[4859], ce qui est regrettable du point de vue tant de la liberté d'établissement[4860] que du principe de neutralité de l'opération[4861].

§ 3. La durée de la protection

907. Un aspect non réglé par la Directive Sociétés. En l'absence de précisions spécifiques relatives à la durée du mécanisme de protection des créanciers, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un système *ex post* ou *ex ante*, dans les dispositions de la Directive Sociétés relatives aux scissions internes, il n'est pas

4848 Art. 126*ter*, § 2 de la Proposition de la Commission.
4849 Art. 86*duodecies*, § 2 de la Proposition de la Commission.
4850 Art. 160m, § 2 du Premier Compromis de la Présidence.
4851 Art. 160*quaterdecies*, § 1er de la Proposition du Parlement.
4852 Art. 160*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
4853 Voir à ce sujet à propos des fusions : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 58 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 37 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 535 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 19 ; S. KALSS, « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *op. cit.*, p. 111 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 57.
4854 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 56.
4855 Art. 160*undecies*, § 1er de la Proposition du Parlement.
4856 Art. 160*unvicies* de la Proposition du Parlement. Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 56.
4857 Art. 160*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
4858 Art. 12:73, § 3, 2e phrase (scission par absorption) et 12:90, § 3, 2e phrase (scission par constitution de nouvelles sociétés) du CSA et E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *op. cit.*, p. 340, n° 941 et D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, p. 337.
4859 Selon le 37e considérant, 2e phrase de la Proposition du Parlement, « [l]es États membres devraient être en mesure de préciser les conséquences sur la délivrance du certificat préalable à l'opération que les procédures engagées par des associés et des créanciers conformément à la présente directive pourraient avoir ».
4860 Sur l'incidence d'un effet suspensif sur le caractère proportionné d'une mesure de protection, voir *supra* n° 903.
4861 Sur cet aspect de la protection des créanciers, voir *supra* nos 705 à 711.

étonnant de constater que la durée de la protection soit susceptible de varier fortement d'un État membre à un autre. Ainsi, elle sera de deux mois pour les scissions internes et transfrontalières en droit luxembourgeois[4862], de six mois pour les scissions internes en droit autrichien[4863], de six mois également pour les scissions internes en droit allemand[4864], de deux mois en droit belge[4865] pour les scissions internes et transfrontalières, de trente jours en droit français[4866] pour les scissions internes et de soixante jours en droit italien[4867] pour les scissions internes. Selon l'Étude d'impact[4868], la législation danoise applicable aux scissions transfrontalières prévoit que les créanciers peuvent demander à être protégés jusqu'à quatre semaines après la date de l'assemblée générale et les règles tchèques en la matière autorisent les créanciers à agir dans les six mois suivant la date de prise d'effet de la scission, ce délai étant réduit à trois mois si la société bénéficiaire a son siège à l'étranger.

908. Un enjeu non négligeable. Cependant, l'absence d'harmonisation à cet égard est susceptible d'engendrer des différences de traitement significatives des créanciers de la société scindée par rapport à ceux de la société bénéficiaire si, à titre d'illustration, les premiers disposent d'une période de deux mois pour demander des sûretés additionnelles à partir de la publication du projet commun de scission alors que les seconds ne disposent que d'un délai d'un mois à partir de cette même date. Cette source de difficultés n'est pas propre aux scissions transfrontalières et a également été mise en lumière dans l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale à l'égard des fusions transfrontalières[4869]. La complexification de l'opération engendrée par la nécessité de devoir jouer avec des délais de protection différents renforce l'insécurité juridique et la durée de la procédure[4870].

909. La Directive Mobilité. Face à ces difficultés, la Proposition de la Commission a fait le choix d'imposer un délai de protection d'une durée d'un mois à compter de la publication du projet commun et ce, tant en cas de scission transfrontalière[4871] qu'en cas de fusion[4872] et de transformation transfrontalière[4873]. Cependant ce délai n'est pas resté inchangé au cours du processus législatif. Après avoir fait l'objet de critiques de la part du *Bundesrat* allemand[4874], il s'est

4862 Art. 1031-10, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
4863 § 15 (1) SpaltG.
4864 §§ 22 (1) et 133 (1) UmwG.
4865 Art. 12:15, § 1er du CSA.
4866 Art. R-236-8, al. 1er du Code de commerce français.
4867 Art. 2503, al. 2 du Codice civile.
4868 Étude d'impact, p. 163.
4869 Selon l'étude Bech-Bruun et Lexidale, la durée de protection des créanciers dans le cadre d'une fusion transfrontalière varie entre un mois, comme au Danemark, en France, en Grèce ou en Hongrie, six mois, comme en République Tchèque, en Bulgarie ou en Slovaquie, et pas de durée spécifique, comme en Lituanie et au Royaume-Uni (pré-Brexit). Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 54 et 55. Voir également Étude d'impact, p. 143.
4870 Étude d'impact, p. 143 et St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, *op. cit.*, p. 38.
4871 Art. 160*quaterdecies*, § 2 de la Proposition de la Commission.
4872 Art. 126*ter*, § 2 de la Proposition de la Commission.
4873 Art. 86*duodecies*, § 2 de la Proposition de la Commission.
4874 Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende

vu allongé à trois mois pour les trois opérations[4875] dès le Premier Compromis de la Présidence, et n'a été modifié ni par la Proposition du Parlement[4876], ni par la Directive Mobilité[4877]. S'il est vrai qu'un délai d'un mois est excessivement court compte tenu du fait que la demande de garantie doit être adressée à une autorité appropriée et non simplement à la société débitrice[4878], le porter à trois mois n'est véritablement acceptable du point de vue de la proportionnalité de la mesure que si la demande d'une garantie adéquate par un créancier n'est pas assortie d'un effet suspensif. Or, cet aspect a justement été laissé à la discrétion des États membres par le législateur européen[4879], ce qui ne manquera pas de générer de nombreuses interrogations quant à la conformité au droit primaire de ce mécanisme.

§4. Conclusion sur les aspects temporels de la protection des créanciers

910. Un régime de protection *ex ante* strictement encadré. Les risques engendrés par la coexistence de différents régimes de protection sont considérables de sorte que cet aspect devait nécessairement faire l'objet d'une harmonisation dans la Directive Mobilité. À cet égard, s'il est clair qu'un régime de protection *ex post* semble plus conforme à la liberté d'établissement ainsi qu'à l'objectif de neutralité de l'opération sur la situation des créanciers, tout en permettant une protection efficace par le biais d'une durée plus longue que celle d'un régime de protection *ex ante*, on est en droit de s'interroger sur la nécessité d'attendre la date de prise d'effet de l'opération pour permettre aux créanciers d'agir. En effet, le mécanisme de protection de loin le plus concerné par le caractère *ex ante* ou *ex post* du régime est celui articulé autour de l'octroi de garanties adéquates aux créanciers dont la situation est mise en péril par l'opération. Or, ce mécanisme s'adresse en priorité, si pas exclusivement, aux créanciers actifs, vigilants, bien informés et peu affectés par un phénomène d'apathie rationnelle[4880]. En d'autres termes, il s'agit d'une catégorie de créanciers qui aura connaissance de l'opération envisagée bien avant la publication des actes constatant sa réalisation. Ce sera d'autant plus le cas que le processus de scission transfrontalière tel qu'il a été déterminé dans la première partie du présent travail est jalonné de mesures de publicité[4881]. Si on ajoute à cela le fait que lors de l'étude de la protection des créanciers par le biais d'un mécanisme d'octroi de garanties adéquates, il a été établi que ce dernier faisait peser une certaine incertitude non seulement sur les sociétés bénéficiaires, mais également sur les autres créanciers, il est dans l'intérêt de

Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 10 où, à l'égard des transformations transfrontalières, le *Bundesrat* allemand a demandé que ce délai soit porté à au moins deux mois.

4875 Art. 86k, § 2 (transformations transfrontalières), 126b, § 2, al. 2 (fusions transfrontalières) et 160m, § 2 (scissions transfrontalières) du Premier Compromis de la Présidence.

4876 Art. 86*duodecies*, § 1er (transformations transfrontalières), 126*ter*, § 1er, al. 2 (fusions transfrontalières) et 160*quaterdecies*, § 1er (scissions transfrontalières) de la Proposition du Parlement.

4877 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

4878 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.

4879 37e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité.

4880 Sur cette notion, voir *supra* n° 773.

4881 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1.

la proportionnalité de la mesure que celle-ci commence le plus tôt possible. Le choix du législateur européen d'opter pour une protection *ex ante*[4882] est donc rationnel sous cet angle. Cependant, le revers de la médaille est qu'il a été établi qu'un mécanisme de protection *ex ante* présentait un nombre important d'inconvénients parmi lesquels on compte essentiellement le fait de retarder la réalisation de l'opération lorsqu'il est assorti d'un effet suspensif, le risque d'abus de la part de certains créanciers et une éventuelle contrariété tant à la liberté d'établissement qu'à l'impératif de neutralité. S'il est possible de remédier à ces défauts en privant une demande introduite par un créancier d'effet suspensif pour l'opération, la faculté laissée par la Directive Mobilité aux États membres à cet égard[4883] est une grave erreur. En effet, il est assez aisé de concevoir qu'un régime de protection *ex ante* assorti d'un effet suspensif est plus intrusif du point de vue de la liberté d'établissement que le même régime non assorti d'un effet suspensif sans qu'il soit possible de démontrer pour autant que ce dernier est inefficace. En d'autres termes, un tel régime de protection ne remplirait pas les conditions du « *Gebhard test* »[4884]. Un régime efficace de protection des créanciers en cas de scission transfrontalière gagnerait dès lors à intégrer une disposition inspirée du droit français des scissions internes[4885] et précisant clairement que l'exercice du droit d'opposition est dénué d'effet suspensif.

911. La nécessité d'une durée suffisante. Un mécanisme de protection des créanciers reposant sur un comportement actif de ces derniers, comme la possibilité de demander des garanties adéquates, nécessite que les créanciers disposent d'un délai d'action suffisant pour pouvoir faire valoir leurs prétentions. À cet égard, le délai d'un mois prévu à l'origine par la Proposition de la Commission[4886] apparaissait comme insuffisant[4887] et c'est à juste titre qu'il a été prolongé à trois mois dans la Directive Mobilité[4888]. Cependant, l'exigence de conformité à la liberté d'établissement et le respect du principe de neutralité commandent qu'un tel délai prolongé ne soit pas assorti d'un effet suspensif. La marge de manœuvre laissée aux États membres par la Directive Mobilité à cet égard[4889] apparaît par conséquent à nouveau comme injustifiée.

4882 Art. 86*undecies*, § 1er, al. 2 (transformations transfrontalières), 126*ter*, § 1er, al. 2 (fusions transfrontalières) et 160*undecies*, § 1er, al. 2 (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.
4883 37e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité.
4884 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.
4885 Selon l'art. L236-14, al. 4 du Code de commerce français, l' « opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion ». Cette disposition est applicable aux opérations de scission en vertu de l'art. L236-16 du Code de commerce français.
4886 Art. 160*quaterdecies*, § 2 de la Proposition de la Commission.
4887 Voir en ce sens : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 10.
4888 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
4889 37e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité.

SECTION 3. L'INCIDENCE DU DROIT INTERNATIONAL DE L'INSOLVABILITÉ

§1. Présentation

912. Un entrelacs de normes. La question de la protection des créanciers dans leurs relations avec une personne morale a pour particularité de ne pas constituer l'apanage du seul droit des sociétés. En effet, le droit de l'insolvabilité, le droit des obligations, le droit comptable, mais également le droit administratif et le droit pénal sont susceptibles d'intégrer des mesures destinées spécifiquement à sauvegarder les intérêts des différents créanciers[4890]. Compte tenu du fait que le rapport entre ces différents droits est principalement fonction des préférences des États membres, il s'ensuit, d'une part, qu'il serait erroné de juger de l'efficacité des mécanismes de protection d'un État membre sur la base des seules mesures de son droit des sociétés et, d'autre part, qu'une comparaison entre les niveaux de protection offerts par les droits nationaux des différents États membres s'avère être un exercice particulièrement complexe[4891]. Sur la base de ce constat, et dans le cadre de l'étude des mécanismes de protection des créanciers contre les risques engendrés par une scission transfrontalière, il est utile de se pencher brièvement sur la question de l'incidence du droit international de l'insolvabilité, et notamment du Règlement Insolvabilité, sur la protection des créanciers dans le cadre des scissions transfrontalières. Ce bref examen devrait permettre d'analyser dans quelle mesure la protection de ces derniers contre certains risques engendrés par l'opération devrait être organisée en dehors d'une éventuelle directive européenne sur le sujet. Pour ce faire, il conviendra tout d'abord d'examiner dans quelle mesure la position de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement diffère de celle en matière d'insolvabilité (§ 2), pour ensuite procéder à un examen des dispositions du Règlement Insolvabilité destinées à lutter contre le « *forum-shopping* »[4892] à l'aune des spécificités d'une scission transfrontalière (§ 3) ainsi qu'à une analyse des dispositions de certains droits nationaux et de la Directive Mobilité relatives à l'insolvabilité (§ 4).

§2. Le délicat équilibre entre « lex societatis » et « lex fori concursus »

913. Les enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Kornhaas*. S'il ressort de l'examen de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement que les barrières dressées par l'État d'accueil en matière de droit des sociétés n'ont que très peu de chance d'être justifiées[4893], l'arrêt

4890 P. MÜLBERT, *op. cit.*, pp. 7 et 8 et M. SIEMS, L. HERZOG et Er. ROSENHAGER, *op. cit.*, pp. 151 et 152. Voir en ce sens également : Étude d'impact, p. 67 ; M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 366 ; C. GERNER-BEUERLE et E. SCHUSTER, « The costs of separation : friction between company and insolvency law in the single market », *Journal of Corporate Law Studies*, octobre 2014, p. 318 et C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, pp. 5 et 6.

4891 Voir en ce sens : P. MÜLBERT, *op. cit.*, p. 8.

4892 Sur cette notion, voir *infra* n° 917.

4893 À ce sujet, voir *supra* n°s 178 à 197 et L. BERNARDEAU, *op. cit.*, p. 110 qui considère la possibilité de justification d'une telle entrave comme « *purement rhétorique* ».

Kornhaas[4894] a mis en lumière que les mesures de protection spécifiques relevant du droit de l'insolvabilité pouvaient être admises beaucoup plus facilement[4895]. Les faits à la base de cet arrêt[4896] concernaient une « *private company limited by shares* » britannique qui exerçait l'essentiel de ses activités au moyen de sa succursale établie en Allemagne. Bien que le siège d'incorporation de la société se soit trouvé au Royaume-Uni, le centre des intérêts principaux[4897] se trouvait donc en Allemagne, raison pour laquelle une procédure d'insolvabilité a pu y être ouverte sur la base de l'art. 4, § 1er de l'Ancien Règlement Insolvabilité. Au cours de la procédure, il s'est avéré que la dirigeante avait effectué un certain nombre de paiements plus de trois semaines après la survenance de l'insolvabilité, ouvrant dès lors la porte à une action en remboursement pour les sommes ainsi versées à l'encontre de la dirigeante en vertu de la loi allemande relative aux sociétés à responsabilité limitée[4898]. Condamnée à un tel remboursement en première instance et en appel, un recours en révision a été intenté devant le *Bundesgerichtshof*. Ce dernier a estimé que, bien que la disposition fondant l'action en remboursement figurât formellement dans une loi relevant du droit des sociétés allemand, elle relevait en réalité du droit de l'insolvabilité en ce qu'elle visait avant tout à éviter une diminution des actifs avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vue d'un meilleur désintéressement des créanciers. L'enjeu de cette qualification n'était pas des moindres car si la *lex societatis* applicable à la *limited* en question n'est autre que la loi britannique, la *lex fori concursus* applicable à la procédure d'insolvabilité en vertu de l'art. 4, § 1er de l'Ancien Règlement Insolvabilité est la loi de l'État d'ouverture, soit l'Allemagne. Cependant, au vu (i) des enseignements de la Cour de justice dans les arrêts *Überseering*[4899] et *Inspire Art*[4900] ainsi que (ii) de l'existence d'une controverse en droit allemand sur l'applicabilité du régime de responsabilité spécifique aux dirigeants de sociétés régies par le

4894 C.J., arrêt *Simona Kornhaas c. Thomas Dithmar*, 10 décembre 2015, C-594/14, EU:C:2015:806 (ci-après l' « **arrêt *Kornhaas*** »). Sur cet arrêt, voir notamment : L. D'AVOUT, « Suites de la jurisprudence Centros : les sociétés off shore rattrapées par le droit local de l'insolvabilité », note sous C.J.U.E., 10 décembre 2015, aff. C-594/14, Kornhaas, *La Semaine Juridique Édition Générale*, n° 11, 14 mars 2016, p. 304, disponible sur www.lexis360.fr (14/01/2020), pp. 1–8 ; M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 369 ; L. IDOT, « Règlement « procédures d'insolvabilité » - Domaine de la lex fori concursu », note sous C.J.U.E., 10 décembre 2015, aff. C-594/14, Kornhaas, *Revue Europe*, février 2016, p. 1 ; Th. MASTRULLO, « Champ d'application matériel : première rencontre entre le droit européen des procédures d'insolvabilité et le droit d'établissement des sociétés », note sous C.J.U.E., 10 décembre 2015, aff. C-594/14, Kornhaas, *Revue des procédures collectives*, n° 6, novembre 2016, comm. 171, disponible sur www.lexis360.fr (14/01/2020), pp. 1–6 ; S. MOCK, « Zur Qualifikation der insolvenzrechtlichen Gläubigerschutzinstrument des Kapitalgesellschaftsrechts », *IPRax*, 2016, pp. 237–243 ; W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, pp. 270–279 ; A. SCHALL, « The forthcoming ECJ decision of the Kornhaas case – The final chapter of the European Traveller's Tales ? », *ECFR*, 2015, pp. 280–298 ; A. SCHALL, « Das Kornhaas-Urteil gibt grünes Licht für die Anwendung des § 64 GmbHG auf eine Limited mit Sitz in Deutschland – Alles klar dank EuGH! », *ZIP*, 2016, pp. 289–295 et E. SCHLUMBERGER, « Droit européen des sociétés (octobre 2015 – mars 2016) », *Rev. Soc.*, juillet 2016, pp. 11–13.

4895 Arrêt *Kornhaas*, pts. 22 à 29.

4896 Voir arrêt *Kornhaas*, pts. 6 à 13.

4897 Sur la notion de « *centre des intérêts principaux* » ou « *COMI* » en droit de l'insolvabilité, voir *infra* n° 918.

4898 § 64 (1) et (2) GmbHG et arrêt *Kornhaas*, pt. 5.

4899 Sur les enseignements de la Cour de justice dans cet arrêt, voir *supra* nos 188 et 189.

4900 Sur les enseignements de la Cour de justice dans cet arrêt, voir *supra* nos 191 et 192.

droit des sociétés d'un autre État membre mais ayant leur centre des intérêts principaux en Allemagne[4901], la juridiction de renvoi a préféré surseoir à statuer et interroger la Cour de justice d'une part sur la question de savoir si le régime de responsabilité spécifique relevait bien de la *lex fori concursus* au sens de l'art. 4, § 1er de l'Ancien Règlement Insolvabilité et, d'autre part, sur la conformité à la liberté d'établissement d'un tel régime de responsabilité[4902]. Face à ces questions, la Cour de justice a tout d'abord considéré que le régime de responsabilité spécifique du dirigeant consacré par le droit allemand, en ce qu'il « contribue à la réalisation d'un objectif qui est intrinsèquement lié, mutatis mutandis, à toute procédure d'insolvabilité, à savoir la prévention de possibles diminutions de la masse avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vue d'un désintéressement égalitaire des créanciers »[4903] relevait bien de la *lex fori concursus* au sens de l'Ancien Règlement Insolvabilité[4904] et s'est ainsi rangée à l'avis de la doctrine allemande majoritaire[4905]. Ensuite, bien que dans l'arrêt *Inspire Art* elle avait considéré qu'un régime de responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs applicable lorsque le capital n'atteint pas le montant minimal prévu par la législation nationale ou tombe en dessous de ce montant en cours d'existence de la société était contraire à la liberté d'établissement[4906], la Cour a considéré que le régime de responsabilité spécifique consacré par le droit allemand ne violait pas la liberté d'établissement en ce qu'il « *ne concerne aucunement la constitution d'une société dans un État membre donné ni son établissement ultérieur dans un autre État membre* »[4907].

914. L'incidence de l'arrêt *Kornhaas* sur les mécanismes de protection des créanciers en cas de scission transfrontalière. S'il ressort de l'examen de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement que les barrières dressées par l'État d'accueil en matière de droit des sociétés n'ont que très peu de chance d'être justifiées[4908], l'arrêt *Kornhaas* a mis en lumière que les mesures de protection spécifiques relevant du droit de l'insolvabilité

4901 Sur cette controverse, voir M. FISCHER, « Die Verlagerung des Gläubigerschutzes vom Gesellschafts- in das Insolvenzrecht nach „Inspire Art" », *ZIP*, 2004, pp. 1481 et 1482 ; W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, p. 272 et A. SCHALL, « The forthcoming ECJ decision of the Kornhaas case – The final chapter of the European Traveller's Tales ? », *op. cit.*, pp. 285 et 286.

4902 Arrêt *Kornhaas*, pt. 13.

4903 Arrêt *Kornhaas*, pt. 20.

4904 Arrêt *Kornhaas*, pt. 21. Pour un point de vue critique de cette solution, voir : W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, pp. 273 et 274.

4905 W.-G. RINGE, *ibidem*, p. 272 et A. SCHALL, « The forthcoming ECJ decision of the Kornhaas case – The final chapter of the European Traveller's Tales ? », *op. cit.*, p. 286.

4906 Arrêt *Kornhaas*, pt. 24 et arrêt *Inspire Art*, pt. 141. Voir également : P. MANKOWSKI, « Insolvenzrecht gegen Gesellschaftsrecht 2:0 im europäischen Spiel um § 64 GmbHG », *op. cit.*, p. 285 et W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, pp. 275 et 276 qui y voient un parallèle avec la doctrine Keck en matière de libre circulation des marchandises et A. SCHALL, « Das Kornhaas-Urteil gibt grünes Licht für die Anwendung des § 64 GmbHG auf eine Limited mit Sitz in Deutschland – Alles klar dank EuGH! », *op. cit.*, p. 292 qui, au contraire, considère que la Cour de justice a préféré ne pas s'y référer.

4907 Arrêt *Kornhaas*, pts. 28 et 29. Pour un point de vue critique de cette décision au motif qu'elle est difficilement conciliable avec les enseignements de l'arrêt *Inspire Art*, voir : W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, pp. 276 et 277.

4908 À ce sujet, voir *supra* nos 178 à 197 et L. BERNARDEAU, *op. cit.*, p. 110 qui considère la possibilité de justification d'une telle entrave comme « purement rhétorique ».

pouvaient être admises[4909]. Bien que la portée de cet arrêt ne doive pas être exagérée au vu de sa faible importance aux yeux de la Cour de justice[4910], force est de constater que cet arrêt fait du droit de l'insolvabilité une sorte de « *safe harbour* » pour les mécanismes de protection des créanciers face à l'utilisation des « *pseudo-foreign companies* »[4911]. Il a ainsi été considéré comme « le principal antidote aux pathologies résultant de l'arrêt *Centros* »[4912]. Il y a donc un enjeu non négligeable à déterminer si une mesure de protection applicable à une scission transfrontalière relève de la *lex societatis* ou, au contraire, de la *lex fori concursus*[4913]. Ce traitement *a priori* plus favorable par la Cour de justice a poussé certains auteurs à argumenter que les mesures protectrices gagneraient à être sorties du droit des sociétés et à être intégrées dans le droit de l'insolvabilité[4914]. Il a en outre été avancé qu'il était possible de pallier les déficiences du droit des sociétés en lien avec la liberté d'établissement en matière de protection des créanciers, et plus particulièrement l'utilisation de « *pseudo-foreign companies* », par le biais d'un droit de l'insolvabilité renforcé[4915]. C'est également la position qui a été suivie par le droit belge lors de l'abandon de la théorie du siège réel au profit de la théorie du siège statutaire au moment de l'adoption du CSA[4916]. Par ailleurs, tant dans l'arrêt *Centros*[4917] que dans l'arrêt *Inspire Art*[4918], la Cour de justice avait déjà semblé vouloir

4909 Arrêt *Kornhaas*, pts. 22 à 29 et L. D'AVOUT, *op. cit.*, p. 7 ; P. MANKOWSKI, « Insolvenzrecht gegen Gesellschaftsrecht 2:0 im europäischen Spiel um § 64 GmbHG », pp. 284–286 ; W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, p. 278 et A. SCHALL, « Das Kornhaas-Urteil gibt grünes Licht für die Anwendung des § 64 GmbHG auf eine Limited mit Sitz in Deutschland – Alles klar dank EuGH! », *op. cit.*, pp. 292–296.

4910 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI, *ibidem*, p. 285 qui relève que l'arrêt n'a été rendu que par la troisième chambre et sans conclusions d'un Avocat général.

4911 Voir en ce sens : A. SCHALL, « The forthcoming ECJ decision of the Kornhaas case – The final chapter of the European Traveller's Tales ? », *op. cit.*, pp. 281 et 282.

4912 L. D'AVOUT, *op. cit.*, p. 4, n° 1. Voir en ce sens également : P. MANKOWSKI, « Insolvenzrecht gegen Gesellschaftsrecht 2:0 im europäischen Spiel um § 64 GmbHG », *op. cit.*, p. 284 ; Th. MASTRULLO, « Champ d'application matériel : première rencontre entre le droit européen des procédures d'insolvabilité et le droit d'établissement des sociétés », *op. cit.*, p. 6 et E. SCHLUMBERGER, « Droit européen des sociétés (octobre 2015 – mars 2016) », *op. cit.*, p. 11, n° 1.

4913 Voir en ce sens de manière plus générale à propos des transformations transfrontalières : M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 366, note 99.

4914 J. ARMOUR, H. HANSMANN, R. KRAAKMAN et M. PARGENDLER, *op. cit.*, p. 17 ; A. COTIGA, *op. cit.*, p. 379 et M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 374. Voir également : M. FISCHER, *op. cit.*, p. 1478 qui plaide en faveur d'une telle évolution à la suite des enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Inspire Art*.

4915 Voir en ce sens W. SCHÖN, *op. cit.*, p. 447 selon lequel « [n]*ot only could one counter the import of inadequately capitalised pseudo-foreign companies by means of a vigorous insolvency law that applies to both domestic and foreign business organisations, but the use of domestic organizational forms would likely increase* ».

4916 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, pp. 341 et 342 où le législateur belge insiste sur le fait que « l'introduction de la doctrine du siège statutaire n'occasionnera aucun préjudice aux créanciers belges ou au fisc belge. Le droit de l'insolvabilité et le droit fiscal appliquent d'autres critères permettant de déterminer le droit applicable et le critère du centre des intérêts principaux joue toujours un rôle déterminant. En outre, l'applicabilité du droit belge de l'insolvabilité à des entreprises étrangères actives en Belgique sera renforcée. Ainsi, les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite et pour non-paiement de cotisations ONSS et de contributions TVA, notamment, ont été intégrées au droit de l'insolvabilité ».

4917 Arrêt *Centros*, pt. 36.

4918 Arrêt *Inspire Art*, pt. 135.

indiquer que la présence d'un cadre juridique communautaire destiné à garantir, de manière générale, la protection des créanciers, relativisait la nécessité d'introduire des mécanismes de protection additionnels spécifiquement liés à une opération particulière. S'il paraît séduisant de prime abord, un tel raisonnement ne saurait toutefois être soutenu à l'égard des scissions transfrontalières car il convient de ne pas perdre de vue qu'au moment où interviennent les mécanismes de protection relevant du droit de l'insolvabilité, il est souvent déjà trop tard pour désintéresser complètement les créanciers. Ainsi, à titre d'illustration, le mécanisme de responsabilité spécifique du dirigeant mis en lumière dans l'arrêt *Kornhaas* n'intervient qu'une fois que la société est insolvable[4919]. En d'autres termes, les mécanismes de protection des créanciers relevant du droit de l'insolvabilité ont une fonction curative, alors que la prise en compte adéquate des intérêts des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière requiert des mesures préventives[4920]. Or, l'objectif d'un mécanisme de protection efficace des créanciers en cas de scission transfrontalière vise en priorité à garantir une neutralité de l'opération sur la situation des créanciers tant de la société scindée que des sociétés bénéficiaires[4921], ce qui va au-delà de la simple répartition égalitaire des actifs d'une société insolvable. Il serait donc foncièrement insuffisant de n'organiser la protection des créanciers qu'au moyen du seul droit de l'insolvabilité[4922] et ce, d'autant plus que l'article 50 du TFUE lui-même, autorisant le Parlement et le Conseil à statuer par voie de directives en vue de réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée[4923], impose à ces organes d'exercer leurs prérogatives en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées des sociétés pour assurer la protection des intérêts tant des associés que des tiers[4924], ce qui inclut les créanciers. Ceci n'exclut toutefois pas de compléter les mécanismes de protection propres au droit des sociétés, comme la possibilité de demander des garanties[4925] ou la solidarité passive des sociétés bénéficiaires[4926] par des mécanismes de protection qui pourraient être considérés comme plus intrusifs au regard de la liberté d'établissement, mais également plus protecteurs dans un contexte d'insolvabilité comme à titre d'illustration, des mécanismes de responsabilité spécifiques pour aveu tardif[4927].

4919 § 64 GmbHG.
4920 Sur cette distinction, voir : L. D'AVOUT, *op. cit.*, p. 6, n° 2.
4921 Sur la nécessité d'un tel équilibre, voir *supra* n°s 705 à 711.
4922 Voir en ce sens et de manière plus générale : C. GERNER-BEUERLE et E. SCHUSTER, *op. cit.*, pp. 331 et 332.
4923 Art. 50, § 1er du TFUE.
4924 Art. 50, § 2, point g) du TFUE.
4925 Sur ce moyen de protection, voir *supra* n°s 767 à 779.
4926 Sur ce moyen de protection, voir *supra* n°s 780 à 789.
4927 Voir § 823 (2) BGB et 15a de l'*Insolvenzordnung* du 5 octobre 1994, disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021) (ci-après « **InsO** ») en droit allemand et sur le rattachement de ce mécanisme au droit de l'insolvabilité : P. MANKOWSKI, « Insolvenzrecht gegen Gesellschaftsrecht 2:0 im europäischen Spiel um § 64 GmbHG », *op. cit.*, p. 286 ; S. MOCK, *op. cit.*, pp. 241 et 242 ; A. SCHALL, « Das Kornhaas-Urteil gibt grünes Licht für die Anwendung des § 64 GmbHG auf eine Limited mit Sitz in Deutschland – Alles klar dank EuGH! », p. 293 et W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, p. 277.

Une telle approche tiendrait en outre davantage compte de l' « interdépendance fonctionnelle »[4928] entre le droit des sociétés et le droit de l'insolvabilité.

915. Une incitation en ce sens dans la Directive Mobilité ? Une des innovations de la Directive Mobilité en matière de protection des créanciers réside dans la possibilité pour les États membres d'exiger de la part des sociétés impliquées, qu'elles fournissent une déclaration de solvabilité[4929]. Or, une des lacunes de ce mécanisme est que la Directive Mobilité ne contient aucune sanction pour une déclaration incomplète ou inexacte[4930]. Loin d'être un oubli, cette omission combinée à l'incitation pour les États membres à décider « des conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, qui devraient inclure des sanctions et responsabilités efficaces et proportionnées conformément au droit de l'Union »[4931], ainsi que la référence directe aux procédures d'insolvabilité dans l'explication de la *ratio legis* de cette déclaration[4932] pourrait être volontaire et destinée à inciter les États membres à prévoir des sanctions relevant, non pas du droit des sociétés, mais du droit de l'insolvabilité en cas d'insolvabilité des sociétés issues de l'opération dans un certain délai suivant celle-ci. Une telle approche, outre son attrait pour les États membres farouchement opposés au « *forum shopping* », tirerait pleinement parti de la jurisprudence *Kornhaas* en éludant un examen peu prometteur à l'aune de la liberté d'établissement. Les transpositions nationales qui suivront sous peu montreront si les États membres choisiront, ou non, de s'engouffrer dans cette porte entrouverte.

916. Une protection des créanciers articulée autour de deux pôles. Dans le cadre de la protection des créanciers dans le cas spécifique des scissions transfrontalières, il peut dès lors être particulièrement avantageux d'adopter une approche systémique tenant d'avantage compte de l'interdépendance fonctionnelle entre le droit des sociétés et le droit de l'insolvabilité. En effet, tout d'abord, se contenter d'une approche isolationniste visant à organiser la protection des créanciers par le seul biais du droit des sociétés méconnaîtrait le besoin de protection renforcée des créanciers en cas d'insolvabilité suivant de près une scission et justifiant l'existence de régimes particuliers tels que le régime de responsabilité spécifique consacré par le § 64 (1) et (2) GmbHG examiné par la Cour de justice dans l'arrêt *Kornhaas*. Ensuite, l'arrêt *Kornhaas*, dont la portée n'est pas remise en cause par l'adoption du Règlement Insolvabilité[4933], a démontré que des mécanismes de protection relevant du droit de l'insolvabilité ne sont pas à apprécier à l'aune de la

[4928] Sur cette notion d' « interdépendance fonctionnelle » entre le droit des sociétés et le droit de l'insolvabilité, voir C. GERNER-BEUERLE et E. SCHUSTER, *op. cit.*, pp. 287–332. Voir également en ce sens : L. ENRIQUES et M. GELTER, « Regulatory competition in European company law and creditor protection », *EBOR*, 2006, p. 436 et W.-G. RINGE, *ibidem*, p. 277.

[4929] Art. 86*undecies*, § 2 (transformations transfrontalières), 126*ter*, § 2 (fusions transfrontalières) et 160*undecies*, § 3 (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

[4930] Sur cette limite, voir *supra* n[os] 763 et 915.

[4931] 25[e] considérant de la Directive Mobilité.

[4932] Selon le 25[e] considérant de la Directive Mobilité, cette déclaration de solvabilité est destinée à « protéger les créanciers contre le risque d'insolvabilité de la société à la suite d'une opération transfrontalière ».

[4933] Voir en ce sens : P. MANKOWSKI, « Insolvenzrecht gegen Gesellschaftsrecht 2:0 im europäischen Spiel um § 64 GmbHG », *op. cit.*, p. 286.

liberté d'établissement et ne sont donc pas tenus de respecter les conditions, appréciées généralement de manière très stricte, voire restrictive par la Cour de justice[4934], du « *Gebhard test* ». La protection des créanciers dans le cadre des scissions transfrontalières gagnerait dès lors en s'articulant autour de deux pôles. Le premier, relevant du droit des sociétés, serait soumis à un impératif strict de neutralité de l'opération sur la situation des créanciers en veillant à préserver l'équilibre entre les intérêts des créanciers et les intérêts de la société et de ses associés et aurait vocation à s'appliquer à toutes les scissions transfrontalières. Le deuxième, relevant du droit de l'insolvabilité, privilégierait une protection renforcée des créanciers, au détriment de la mobilité de la société. À titre d'illustration, si la solidarité passive des sociétés bénéficiaires limitée à l'actif net[4935] constitue un moyen de protection tout à fait adapté à toutes les hypothèses de scissions[4936], il serait envisageable de faire tomber cette limite dans une règlementation relative à l'insolvabilité et ne trouvant à s'appliquer que dans le cas d'une insolvabilité suivant de très près la scission. De cette manière, les créanciers de la société scindée, particulièrement exposés en cas de scission de la société débitrice au profit d'au moins une société en difficultés financières[4937] ou en cas de scission partielle transfrontalière visant exclusivement à isoler les activités en bonne santé au sein d'une nouvelle société avec le moins possible de dettes, bénéficieront d'au moins un autre débiteur plein et entier, ce qui renforcera la probabilité de leur désintéressement. Il pourrait être objecté qu'un tel mécanisme risque, en revanche, d'impacter négativement la situation des créanciers existants de la société bénéficiaire qui ne jouira plus de la limitation de la solidarité, cependant ce risque sera confiné aux seules scissions partielles simplifiées où il n'est pas requis que la fraction de patrimoine transférée ait un actif net positif[4938].

§ 3. Le Règlement Insolvabilité et la lutte contre le « forum shopping » abusif

917. Scissions transfrontalières et « *forum shopping* » abusif. L'étude des risques engendrés par une scission transfrontalière a montré qu'un des dangers auquel les créanciers de la société scindée étaient exposés était lié à l'application, à la suite de la réalisation de l'opération, d'un droit national potentiellement moins protecteur, notamment en matière d'insolvabilité[4939]. En effet, comme une scission transfrontalière permet aux associés de déplacer le siège de la société scindée sans nécessairement avoir l'accord de leurs créanciers, sauf dans l'hypothèse particulière où ces derniers jouissent d'un droit de veto, elle pourrait leur permettre, dans les faits, de choisir une juridiction et un droit plus favorables à leurs intérêts et ce, potentiellement au

4934 À ce sujet, voir *supra* n°s 178 à 197. Voir également : L. BERNARDEAU, *op. cit.*, p. 110.
4935 Art. 160*undecies*, § 2, 2e phrase de la Directive Mobilité.
4936 Sur l'efficacité de ce mécanisme de protection, voir *supra* n°s 780 à 789.
4937 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 725, n° 10 qui y voit le plus grand risque pour les créanciers de la société absorbée. Sur ce risque, voir également *supra* n° 700.
4938 Sur cette limite, voir *supra* n°s 118 à 120.
4939 Sur ce risque, voir *supra* n° 699.

détriment des créanciers[4940]. En d'autres termes, une scission transfrontalière pourrait servir de vecteur au « *forum shopping* »[4941] en jouant notamment sur les profondes divergences[4942] existant entre les droits nationaux de l'insolvabilité au sein de l'Union européenne[4943][4944]. Or, à cet égard, face à l'échec de l'Ancien Règlement Insolvabilité[4945] à enrayer ce phénomène[4946], le Règlement Insolvabilité intègre un certain nombre de mécanismes susceptibles de trouver à s'appliquer dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière. Plusieurs de ces mécanismes méritent d'être brièvement exposés afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure une forte protection par le biais du droit de l'insolvabilité viendrait réduire la nécessité de mécanismes de protection des créanciers en droit des sociétés.

918. La clarification de la notion de COMI[4947]**.** Sous l'empire de l'Ancien Règlement Insolvabilité, la juridiction compétente pour les procédures d'insolvabilité était déterminée par le centre des intérêts principaux du débiteur, ce dernier étant présumé, jusqu'à preuve contraire, correspondre avec le lieu du siège statutaire[4948] et la loi applicable à la procédure d'insolvabilité ainsi qu'à ses effets était celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure avait été ouverte[4949]. La notion de COMI était non seulement fondamentale en ce qu'elle permettait de déterminer la juridiction compétente et le droit applicable[4950], mais également le

4940 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 52 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 471.

4941 Par « *forum shopping* » dans le cadre du Règlement Insolvabilité, on entend le fait pour les parties de « déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d'un État membre à un autre en vue d'améliorer leur situation juridique au détriment de la masse des créanciers ». Voir 5e considérant du Règlement Insolvabilité. Sur cette notion, voir également : L. ENRIQUES et M. GELTER, *op. cit.*, pp. 442–449 ; V. MARQUETTE, « Le règlement n° 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité : les principales innovations en matière d'insolvabilité communautaire », *RDC-TBH*, p. 10, n° 3 et W.-G. RINGE, « Forum shopping under the EU Insolvency Regulation », *EBOR*, 2008, pp. 581 et 582.

4942 Pour un aperçu de ces différences, voir la récente étude de l'OECD sur le sujet : OECD, *Policies for productivity : the design of insolvency regimes across countries*, 2018, disponible sur www.oecd.org (16/01/2020).

4943 Voir en ce sens : V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 20, n° 27. Voir toutefois également : H. EIDENMÜLLER, « The rise and fall of regulatory competition in corporate insolvency law in the European Union », *EBOR*, 2019, p. 548 qui insiste sur les efforts déployés par le législateur européen pour harmoniser les divergences entre les différents droits nationaux de l'insolvabilité.

4944 Ces divergences devraient être réduites, bien que de manière limitée, suite à la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), disponible sur http://eur-lex.europa.eu (16/01/2020) qui doit intervenir pour le 17 juillet 2021.

4945 Règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, *J.O.*, L 160, 30 juin 2000, pp. 1–18 (ci-après l' « **Ancien Règlement Insolvabilité** »).

4946 Voir en ce sens : H. EIDENMÜLLER, « The rise and fall of regulatory competition in corporate insolvency law in the European Union », *op. cit.*, p. 548 et pp. 554–556 qui relève que ce Règlement a permis au Royaume-Uni d'émerger en tant que « *market leader* » du marché européen de l'insolvabilité.

4947 « *COMI* » est l'abréviation communément utilisée pour « *center of main interests* », soit le centre des intérêts principaux en droit de l'insolvabilité.

4948 Art. 3, § 1er de l'Ancien Règlement Insolvabilité.

4949 Art. 4, § 1er de l'Ancien Règlement Insolvabilité.

4950 M. FALLON et M. WAUTELET, « Le nouveau droit européen de l'insolvabilité – Le règlement Insolvabilité II, pour une efficacité accrue des procédures transfrontières à la lumière de l'acquis », *J.T.*, 2017, p. 592 et V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 19, n° 25.

champ d'application territorial de l'Ancien Règlement Insolvabilité[4951]. Si dans la plupart des cas le COMI est assez simple à déterminer[4952], force est de constater que la notion de COMI peut s'avérer être ambiguë[4953] et n'est pas définie dans le texte même de l'Ancien Règlement Insolvabilité[4954]. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait dû faire l'objet de clarifications par la Cour de justice[4955]. Ceci explique également pourquoi certains auteurs ont plaidé en faveur de l'adoption d'une définition du COMI se rapprochant de la notion de siège statutaire ou de siège d'incorporation[4956], suivant en cela les évolutions de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement[4957] et ce, afin de renforcer la sécurité juridique et mieux tenir compte de l'interdépendance fonctionnelle existant entre le droit des sociétés et le droit de l'insolvabilité[4958]. Prenant en considération le caractère fondamental de la notion de COMI[4959], le Règlement Insolvabilité est venu préciser cette notion en intégrant les enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière[4960]. La détermination du COMI d'une personne morale selon l'art. 3, § 1er du Règlement Insolvabilité s'opère

4951 14e considérant du Règlement Insolvabilité et V. MARQUETTE, *ibidem*, p. 19, n° 25.

4952 Voir en ce sens : M. FISCHER, *op. cit.*, p. 1485.

4953 W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, p. 277 selon lequel « *COMI thus remains an ill-defined and contentious concept, prone to attract arbitrage and litigation* ». Voir également en ce sens : M. FALLON et M. WAUTELET, *op. cit.*, p. 593 ; C. GERNER-BEUERLE et E. SCHUSTER, *op. cit.*, p. 306 ; H. EIDENMÜLLER, « Free choice in international company insolvency law in Europe », *EBOR*, 2005, p. 428 et V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 19, n° 25.

4954 La définition légale de la notion de COMI figurait au 13e considérant de l'Ancien Règlement Insolvabilité selon lequel « [l]e centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers ».

4955 C.J.C.E., gde ch., arrêt *Eurofood IFSC Ltd.*, 2 mai 2006, C-341/04, EU:C:2006:281 (ci-après l' « **arrêt *Eurofood*** »), pts. 31 à 37 et C.J., arrêt *Interedil Srl, en liquidation c. Fallimento Interedil Srl et Intesa Gestione Crediti SpA*, 20 octobre 2011, C-396/09, EU:C:2011:671 (ci-après l' « **arrêt *Interedil*** »), pts. 47 à 53. Sur l'arrêt *Eurofood*, voir notamment : Th. BACHNER, « The battle over jurisdiction in European insolvency law », *ECFR*, 2006/3, pp. 310–329 ; H.-C., DUURSMA-KEPPLINGER, « Aktuelle Entwicklungen zur internationalen Zuständigkeit für Hauptinsolvenzverfahren – Erkenntnisse aus Staubitz-Schreiber und Eurofood », *ZIP*, 2007, pp. 896–903 ; P. MANKOWSKI, « Klärung von Grundfragen des europäischen Internationalen Insolvenzrechts durch die Eurofood Entscheidung? », *BB*, 2006, pp. 1753–1759 ; J.-P. RÉMERY, « L'application à une filiale du règlement communautaire relatif aux procédures d'insolvabilité », *Rev. Soc.*, 2006, pp. 371–381 et J. SCHMIDT, « Eurofood – Eine Leitentscheidung und ihre Rezeption in Europa und den USA », *ZIP*, 2007, pp. 405–410. Sur l'arrêt *Interedil*, voir notamment : Th. MASTRULLO, « Critères et date d'appréciation du centre des intérêts principaux : les précisions de l'arrêt Interedil Srl », *Rev. Soc.*, 2012, pp. 120–122 ; F. MUCCIARELLI, « The hidden voyage of a dying Italian company, from the Mediterranean Sea to Albion », *ECFR*, 4/2012, pp. 571–579 ; J. SCHMIDT, Bestimmung des COMI des Insolvenzschuldners durch wertende Gesamtbetrachtung des Einzelfalls ("Interedil") », *EWiR*, 2011, pp. 345 et 346 et U. WOLF, « Der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen bei Gesellschaften - eine Anmerkung zu der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Interedil (C-396/09) », *GPR*, 2012 pp. 149–153.

4956 Voir en ce sens : H. EIDENMÜLLER, « Free choice in international company insolvency law in Europe », *op. cit.*, p. 447 ; W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, p. 277 et W.-G. RINGE, « Forum shopping under the EU Insolvency Regulation », *EBOR*, 2005, pp. 614–616.

4957 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.

4958 Voir en ce sens : W.-G. RINGE, « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *op. cit.*, p. 277 et W.-G. RINGE, « Forum shopping under the EU Insolvency Regulation », *op. cit.*, pp. 614–616. Voir également à ce sujet : V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 19, n° 25.

4959 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *Europäische Insolvenzordnung 2015 – Kommentar*, 1re éd., München, Beck, 2016, art. 3, n° 1 et V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 19, n° 25.

4960 Art. du Règlement Insolvabilité et V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 20, n° 26 et arrêt *Eurofood*, pts. 29, 33 et 37 et arrêt *Interedil*, pt. 43.

ainsi en deux temps. Il est ainsi tout d'abord présumé de manière réfragable correspondre au lieu du siège statutaire de la société, à moins qu'il ne soit possible de démontrer que le « lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers »[4961] se trouve dans un autre État membre en établissant que « l'administration centrale de la société est située dans un État membre autre que celui de son siège statutaire et si une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permet d'établir, d'une manière vérifiable par des tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre »[4962][4963]. Cette notion incorpore à la fois des éléments de la théorie du siège réel et de la théorie du siège d'incorporation[4964], même si, de manière assez générale, on peut relever que contrairement au droit des sociétés qui semble, à la suite de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement[4965], être de plus en plus enclin à favoriser la théorie du siège d'incorporation[4966], le facteur de rattachement appliqué à l'égard des règles relatives à l'insolvabilité se rapproche davantage de critères associables à la théorie du siège réel[4967]. Un tel choix se justifie également par le fait que le siège réel représente le lieu de convergence des principaux intérêts des créanciers[4968]. Il s'ensuit que cette règle de rattachement, qui attache en outre une importance particulière aux créanciers et à la perception que ces derniers ont du lieu où leur débiteur gère ses intérêts[4969], limite drastiquement les possibilités de « *forum shopping* » pour les « *pseudo-foreign companies* »[4970]. Ainsi, l'utilisation d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés pour bénéficier d'une législation plus favorable en matière d'insolvabilité dans l'État membre d'accueil[4971], bien que parfaitement valable du point de vue du droit des sociétés, sera sans effet sur la compétence en matière d'insolvabilité et, par ricochet, le droit applicable à la procédure en question, si l'essentiel de l'activité économique et la gestion de celles-ci continuent à être exercés dans l'État membre de départ au moyen de succursales[4972].

4961 28e considérant du Règlement Insolvabilité.
4962 30e considérant du Règlement Insolvabilité.
4963 La possibilité de renverser la présomption avait déjà été admise par la Cour de justice avant l'adoption du Règlement Insolvabilité. Voir à ce sujet : A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, « Chapitre 3 – La lutte contre le forum shopping et le traitement de l'insolvabilité des groupes de sociétés », in *Le nouveau droit européen des faillites internationales*, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 95.
4964 Voir en ce sens : C. GERNER-BEUERLE et E. SCHUSTER, *op. cit.*, p. 307.
4965 À ce sujet, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1.
4966 À ce sujet, voir : projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, pp. 15 et 16.
4967 30e considérant et art. 3 du Règlement Insolvabilité et J. ARMOUR, H. HANSMANN, R. KRAAKMAN et M. PARGENDLER, « What is Corporate Law ? », *The Anatomy of Corporate Law – A Comparative and Functional Approach*, 3e éd., Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 21 et H. EIDENMÜLLER, « The rise and fall of regulatory competition in corporate insolvency law in the European Union », *op. cit.*, p. 551 et arrêt *Eurofood*, pt. 33 et arrêt *Interedil*, pt. 59.
4968 Voir en ce sens : M. FISCHER, *op. cit.*, p. 1481.
4969 28e considérant du Règlement Insolvabilité.
4970 Voir en ce sens : V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 20, n° 27 et A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, *op. cit.*, p. 95.
4971 Pour un exemple en matière de fusions transfrontalières, voir : H. EIDENMÜLLER, « The rise and fall of regulatory competition in corporate insolvency law in the European Union », *op. cit.*, p. 549.
4972 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, p. 16.

919. L'exclusion de la présomption en cas de restructuration tardive. Si on combine la présomption de coïncidence entre le COMI et le siège statutaire et le fait que la Cour de justice a précisé que l'appréciation de la localisation du COMI devait avoir lieu à la date de la demande d'ouverture de procédure et non à celle de la décision d'ouverture[4973], faisant ainsi en sorte qu'un déplacement subséquent du COMI soit sans incidence[4974], on voit aisément que s'ouvre une possibilité de « *forum shopping* » de dernière minute par laquelle la société en difficultés financières opèrerait un transfert de siège dans un autre État membre en vue de profiter de la présomption dans cet État membre d'accueil juste avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité[4975][4976]. Alors que l'Ancien Règlement Insolvabilité ne contenait aucune disposition à ce sujet et que la Cour de justice avait affirmé dans l'arrêt *Interedil* que « dans le cas d'un transfert du siège statutaire d'une société débitrice avant l'introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci »[4977], le Règlement Insolvabilité prévoit explicitement que la présomption de coïncidence ne trouvera pas à s'appliquer si le siège statutaire a fait l'objet d'un transfert au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité[4978]. Cette disposition est destinée à enrayer une tentative de « *forum shopping* » de dernière minute[4979], malgré un délai de trois mois particulièrement court[4980]. La brièveté du délai peut néanmoins s'expliquer par le fait qu'une société opérationnelle ne parviendra de toute façon pas à déplacer son siège réel rapidement, contrairement aux sociétés *holding* qui constituent la cible première de cette disposition[4981]. Cette mesure n'implique toutefois pas qu'il soit impossible de modifier le facteur de rattachement pendant la période suspecte (ou « *look back period* »), mais uniquement que la

4973 M. FALLON et M. WAUTELET, *op. cit.*, p. 593 ; P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *op. cit.*, art. 3, n° 28 et V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 20, n° 27 et C.J.C.E., gde ch., arrêt *Susanne Staubitz-Schreiber*, C-1/04, 17 janvier 2006, EU:C:2006:39, pts. 24 à 29.

4974 P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 3, n° 28 et P. KINDLER, « Sitzverlegung und internationales Insolvenzrecht », *IPRax*, 2006, pp. 115 et 116 et C.J.C.E., gde ch., arrêt *Susanne Staubitz-Schreiber*, C-1/04, 17 janvier 2006, EU:C:2006:39, pt. 26.

4975 30e considérant du Règlement Insolvabilité et A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, *op. cit.*, p. 103 ; P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 3, n° 33 et V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 20, n° 27.

4976 Pour un cas d'application, voir C.J., ord. *Leonmobili Srl, Gennaro Leone c. Homag Holzbearbeitungssyteme GmbH, Custela del Fallimento Leonmobili Srl, ICO Srl, Arturo Salice SpA, Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino, Deutsche Bnk SpA, Fida Srl et Elica SpA*, 24 mai 2016, C-353/15, EU:C:2016:374 qui concernait le cas d'un transfert de dernière minute du siège d'une société de l'Italie vers la Bulgarie peu avant l'introduction d'une demande en déclaration de faillite par huit de ses créanciers en Italie.

4977 Arrêt *Interedil*, pt. 59.

4978 Art. 3, § 1er, al. 2 du Règlement Insolvabilité.

4979 A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, *op. cit.*, pp. 103 et 104 ; D. LATELLA, « The "COMI" concept in the revision of the European Insolvency Regulation », *ECFR*, 4/2014, p. 490 ; P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *op. cit.*, art. 3, n° 34 et V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 21, n° 27.

4980 Voir en ce sens : D. LATELLA, *ibidem*, p. 494 ; P. KINDLER et S. SAKKA, « Die Neufassung der Europäischen Insolvenzordnung », *EuZW*, 2015, p. 462 et P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 3, n° 34.

4981 P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 3, n° 34.

présomption ne trouvera pas à jouer dans cette hypothèse[4982], aboutissant *de facto* à un renversement de la charge de la preuve[4983]. La société désireuse d'abuser ses créanciers en modifiant son siège statutaire devra dès lors faire preuve de prévoyance et s'y prendre assez tôt[4984]. Ceci signifie qu'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés dans un État membre à la législation plus favorable juste avant l'introduction d'une procédure d'insolvabilité ne permettra pas de bénéficier de la présomption de coïncidence entre le siège statutaire et le COMI.

920. L'obligation de vérification et de motivation à charge de la juridiction saisie combinée à la possibilité de contestation par des tiers. Toujours dans l'optique de lutter contre le « *forum shopping* »[4985], la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité devra d'office examiner sa compétence à l'aune des critères de rattachement fixés par l'art. 3 du Règlement Insolvabilité[4986]. Cette obligation est destinée à enrayer la pratique de certains États membres qui se basent exclusivement sur les informations fournies par le demandeur pour fonder leur compétence sans autre forme de vérification[4987]. En outre, en cas de doutes quant à sa compétence, la juridiction disposera de la possibilité d'exiger du demandeur qu'il fournisse des éléments de preuve additionnels, comme par exemple, en cas de déplacement du COMI, la preuve que les créanciers ont été informés en temps utile du nouveau lieu à partir duquel il gère ses intérêts[4988], et, si la *lex fori concursus* le permet, de donner aux créanciers du débiteur l'occasion de donner leur point de vue sur la compétence de la juridiction en question[4989]. Par ailleurs, si à l'issue de cette phase de vérification, la juridiction saisie se déclare compétente, elle aura l'obligation de motiver sa décision[4990]. Cette obligation de motivation, qui ne doit pas faire l'objet d'une appréciation très sévère[4991] et pour laquelle il n'est pas prévu qu'elle doive être factuellement correcte[4992], est avant tout destinée à simplifier le contrôle juridictionnel qui peut notamment être initié par tout créancier[4993], quel que soit le montant ou le rang de sa créance ou

4982 A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, *op. cit.*, p. 104 et P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 3, n° 37.
4983 Voir en ce sens : V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 21, n° 77.
4984 A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, *op. cit.*, p. 104 ; L. ENRIQUES et M. GELTER, *op. cit.*, p. 439 et P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *op. cit.*, art. 3, n° 29.
4985 A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, *ibidem*, p. 106 ; H. EIDENMÜLLER, « The rise and fall of regulatory competition in corporate insolvency law in the European Union », *op. cit.*, p. 558 ; M. FALLON et M. WAUTELET, *op. cit.*, p. 594 et P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 4, n° 5.
4986 Art. 4, § 1er, 1re phrase du Règlement Insolvabilité.
4987 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *op. cit.*, art. 4, n° 5 et V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 22, n° 31.
4988 28e considérant du Règlement Insolvabilité et, en ce sens : A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, *op. cit.*, p. 106.
4989 32e considérant du Règlement Insolvabilité.
4990 Art. 4, § 1er, 2e phrase du Règlement Insolvabilité.
4991 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *op. cit.*, art. 4, n° 15 qui déduit cela de la version suédoise du Règlement Insolvabilité.
4992 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 4, n° 12 et Chr. THOLE, « Die Reform der Europäischen Insolvenzverordnung », *ZEuP*, 2014, p. 57.
4993 Art. 5, § 1er du Règlement Insolvabilité.

encore son lieu de résidence[4994]. La possibilité de contestation de toute décision d'ouverture d'une procédure principale découle d'une disposition du droit matériel de l'Union[4995] et est notamment destinée à remédier aux conséquences néfastes de la jurisprudence de la Cour de justice qui avait décidé que la possibilité de contester une décision de compétence relevait du droit national de l'État membre d'ouverture de la procédure principale[4996][4997]. Bien que cette possibilité de contestation soit affectée de certaines lacunes notables, comme l'indication explicite de la juridiction compétente pour connaître d'une telle demande[4998], l'absence de description concrète de la procédure applicable[4999], d'effet suspensif[5000] ou encore de délais[5001], pour lesquelles il conviendra de se tourner vers la *lex fori concursus*[5002] ce qui, assez paradoxalement ouvre une porte au « *forum shopping* »[5003], elle représente un mécanisme de lutte intéressant contre le recours abusif aux scissions transfrontalières en vue de bénéficier d'une législation en matière d'insolvabilité plus favorable.

921. Une protection efficace des créanciers par le biais de la lutte contre le « *forum shopping* » abusif. Les exemples de dispositions destinées à enrayer le phénomène du « *forum shopping* » et susceptibles de trouver à s'appliquer dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière sont nombreux dans le Règlement Insolvabilité. On pourrait ainsi également citer (i) les règles de compétence juridictionnelle pour les actions découlant directement de la procédure d'insolvabilité et qui y sont étroitement liées[5004], comme par exemple les actions en responsabilité des administrateurs[5005], (ii) la possibilité d'ouvrir une procédure secondaire dans l'État membre où ne se trouve que le siège social du débiteur[5006] en cas de transfert effectif du COMI[5007] ou encore (iii) les nouvelles règles relatives à l'insolvabilité des groupes de sociétés[5008]. Cette constatation n'est pas surprenante si on prend en compte le fait que la lutte contre le « *forum shopping* » était un des objectifs principaux du législateur européen lors de

4994 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÌN, « The EU Insolvency Regulation recast, scope, jurisdiction and applicable law », *ZEuP*, 2015, p. 709 et P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *op. cit.*, art. 5, n° 8.

4995 P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 5, n° 1.

4996 Arrêt *Eurofood*, pt. 43.

4997 Voir en ce sens : P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *op. cit.*, art. 5, n° 1.

4998 Voir à ce sujet : M. FALLON et M. WAUTELET, *op. cit.*, p. 594 et V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 22, n° 31 qui établissent qu'il ne peut s'agir que d'une juridiction appartenant au même État que la juridiction dont émane la décision d'ouverture.

4999 P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *op. cit.*, art. 5, n° 10.

5000 P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 5, n° 12 et 14.

5001 P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 5, n° 10.

5002 34e considérant et art. 7 du Règlement Insolvabilité et P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 5, n° 19.

5003 P. MANKOWSKI in P. MANKOWSKI, M. MÜLLER et J. SCHMIDT, *ibidem*, art. 5, n° 19.

5004 Art. 6 du Règlement Insolvabilité et à ce sujet : M. FALLON et M. WAUTELET, *op. cit.*, pp. 594 et 595.

5005 V. MARQUETTE, *op. cit.*, p. 22.

5006 24e considérant du Règlement et V. MARQUETTE, *ibidem*, p. 25, n° 39.

5007 Sur ce type particulier de *forum shopping*, voir H. EIDENMÜLLER, « The rise and fall of regulatory competition in corporate insolvency law in the European Union », *op. cit.*, p. 550.

5008 Chapitre V du Règlement Insolvabilité. Voir à ce sujet : A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, *op. cit.*, pp. 94–100 et M. FALLON et M. WAUTELET, *op. cit.*, pp. 603–604. Voir toutefois également : H. EIDENMÜLLER, « The rise and fall of regulatory competition in corporate insolvency law in the European Union », *op. cit.*, p. 557 selon lequel : « [t]*he new provisions are not very useful: the coordination mechanism is bureaucratic, and it will be cumbersome to use it* ».

l'adoption du Règlement Insolvabilité[5009]. Il ressort toutefois des trois exemples de mécanismes étudiés ci-dessus que les dispositifs du Règlement Insolvabilité destinés à enrayer tout recours abusif à la libre mobilité des personnes morales au sein du marché intérieur en vue de bénéficier d'une législation plus favorable en matière d'insolvabilité semblent pour le moins prometteurs[5010][5011]. Du point de vue de l'étude de la protection des créanciers dans le cadre des scissions transfrontalières, il est possible d'en déduire trois enseignements. Tout d'abord, il serait erroné de vouloir concevoir un régime de protection des créanciers dans un régime des scissions transfrontalières relevant du seul droit des sociétés et opérant en totale autarcie par rapport aux autres branches du droit. Certains risques engendrés par une telle opération de restructuration, comme le risque de « *forum shopping* » abusif, dépassent le seul cadre de celle-ci et s'inscrivent dans une problématique plus vaste et relevant du droit international de l'insolvabilité. Par souci de sécurité juridique et de cohérence, sans parler du bénéfice de l'applicabilité directe de toutes les dispositions du Règlement Insolvabilité[5012], il est donc préférable que les mécanismes de protection destinés à garantir les intérêts des créanciers face à ce type de comportements y figurent. En effet, ces législations spécifiques sont davantage à même d'appréhender les spécificités d'éventuels abus qu'un régime général relatif à la mobilité transfrontalière des personnes morales. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les diverses dispositions anti-abus figurant dans le Règlement Insolvabilité qui se caractérisent toutes par un certain niveau d'élaboration et la disposition anti-abus figurant dans la Proposition de la Commission caractérisée par son caractère particulièrement vague et laconique[5013]. Ensuite, l'existence de ces mécanismes anti-abus issus d'autres branches du droit et qui relèvent davantage d'une approche systémique de la protection des créanciers dans les opérations transfrontalières viennent renforcer le constat qu'une protection renforcée des créanciers au sein d'un régime européen des scissions transfrontalières au seul motif du caractère transfrontalier de l'opération ne s'impose pas[5014]. Troisièmement et, *a contrario*, l'existence de tels régimes anti-abus dans d'autres branches du droit renforce la nécessité de mettre en place un régime de protection spécifique des créanciers propre aux scissions transfrontalières qui tienne plus particulièrement compte des risques engendrés par ce type d'opération pour les créanciers. À titre d'illustration, le Règlement Insolvabilité, s'il intègre un nombre important de mécanismes élaborés destinés à protéger les créanciers contre un éventuel « *forum shopping* » abusif, ne contient aucune disposition contre les risques, bien réels, liés à l'éclatement du patrimoine de la société scindée et à la substitution de débiteur.

5009 5e considérant du Règlement Insolvabilité.

5010 Voir en ce sens : A. COTIGA-RACCAH et N. LAUGIER, *op. cit.*, p. 107 ; M. FALLON et M. WAUTELET, *op. cit.*, p. 605 et V. MARQUETTE, *op. cit.*, pp. 32 et 33, nos 58 et 59.

5011 On peut toutefois relever que les « *schemes of arrangement* » britanniques, pourtant fréquemment utilisés en matière de « *forum shopping* » en droit de l'insolvabilité tombaient hors du champ d'application du Règlement Insolvabilité. Voir à ce sujet : 16e considérant, art. 1, § 1er, dernière phrase et annexe A du Règlement Insolvabilité et H. EIDENMÜLLER, « The rise and fall of regulatory competition in corporate insolvency law in the European Union », *op. cit.*, p. 557.

5012 M. FALLON et M. WAUTELET, *op. cit.*, p. 590.

5013 Sur le caractère inapproprié de cette disposition anti-abus, voir *supra* nos 347 à 375.

5014 Sur ce point, voir *supra* nos 716 à 734.

§4. Dispositions relatives à l'insolvabilité dans le régime des scissions transfrontalières

922. Une relation réciproque. S'il découle de ce qui précède que le droit de l'insolvabilité entretient certains liens étroits avec le droit de la mobilité internationale des personnes morales en vue de neutraliser les conséquences potentiellement négatives pour les créanciers de déplacements précédant une procédure d'insolvabilité, les régimes de restructuration mis en place par les différents droits nationaux ainsi que par la Directive Mobilité tiennent également compte de certaines spécificités du droit de l'insolvabilité tels que le désintéressement prioritaire de certains créanciers privilégiés ou encore la participation d'une société en proie à une procédure d'insolvabilité ou qui risque de l'être sous peu à une scission transfrontalière.

923. Une exclusion utile en droit allemand et autrichien. Cette nécessaire articulation entre droit des restructurations et droit de l'insolvabilité n'a, à titre d'illustration, pas échappé au législateur autrichien qui a explicitement prévu qu'en matière de scissions internes[5015], de fusions internes[5016] et de fusions transfrontalières[5017], les créanciers disposant, en cas de procédure d'insolvabilité de leur société débitrice, d'un privilège découlant d'une disposition légale et couvert par une masse contrôlée par les autorités ne devaient pas bénéficier du droit de demander des garanties additionnelles[5018]. Une telle exclusion se retrouve également en droit allemand en matière de fusions[5019] et de scissions internes[5020], mais son applicabilité en cas de fusions transfrontalières est controversée[5021]. À titre d'exemples de tels créanciers, on peut citer notamment les titulaires d'obligations hypothécaires (*Hypothekenpfandbriefe*)[5022] ou encore les créanciers dont les prétentions découlent d'un assurance-vieillesse, d'une assurance-maladie ou encore d'une assurance-accident[5023]. Elle se justifie fondamentalement par le fait que de tels créanciers sont déjà suffisamment protégés[5024]. Il convient en effet de relever que seuls les créanciers qui parviennent à démontrer de manière crédible que l'opération constitue un risque pour

5015 § 15 (4) SpaltG.
5016 § 226 (2) öAktG.
5017 § 13 (1), dernière phrase EU-VerschG.
5018 § 15 (4) SpaltG.
5019 § 22 (2) UmwG.
5020 §§ 22 (2) et 125 UmwG.
5021 *Pro* : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 18 ; R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, p. 366 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 804. *Contra* : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 323 et 324 ; Chr. LOUVEN, « Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie », *op. cit.*, p. 2028 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 6.
5022 § 30 Pfandbriefgesetz (PfandBG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (17/01/2020) et à ce sujet : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 26 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 22, n° 9 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 22, n° 59.
5023 §§ 77 et 79 Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehment (VAG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (17/01/2020) et B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 22, n° 26 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 22, n° 9 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 22, n° 59.
5024 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 22, n° 26.

l'exercice de leurs droits et qui ne jouissent pas déjà de garanties adéquates peuvent réclamer une garantie[5025]. Or, dans l'hypothèse de créanciers bénéficiant déjà d'un régime de protection efficace en cas d'insolvabilité, cette preuve sera d'autant plus difficile à apporter[5026]. Cette précision n'en est pas pour autant superflue et mériterait de se retrouver dans un régime européen des scissions transfrontalières pour deux raisons. Tout d'abord, elle dispense l'autorité nationale en charge de décider de l'attribution d'une garantie adéquate de procéder à un examen du risque concret encouru par ces créanciers spécifiques en raison de l'opération. Comme ce dernier peut s'avérer être un exercice délicat, tout particulièrement dans un contexte transfrontalier, le recours à de telles exclusions va dans le sens d'une simplification et renforce en outre la proportionnalité de la protection des créanciers par le biais de l'octroi de garanties adéquates aux yeux de la liberté d'établissement. Ensuite, elle permet de renforcer la prévisibilité des conséquences de l'opération sur la situation patrimoniale des sociétés bénéficiaires dans la mesure où ces dernières peuvent être sûres qu'elles ne devront pas faire face à une demande imprévue de garantie de la part de ces créanciers.

924. L'exclusion des sociétés en situation de difficultés financières. La Directive Mobilité prévoit une exclusion obligatoire (i) des sociétés en liquidation et ayant commencé à distribuer leurs actifs entre les associés[5027] et (ii) des sociétés soumises aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59[5028 5029] ou au titre V du Règlement (UE) 2021/23[5030]et facultative (i) des sociétés qui font l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou d'un cadre de restructuration préventif[5031], (ii) de celles qui font l'objet d'une procédure de liquidation, mais qui n'ont pas encore commencé à distribuer leurs actifs entre les associés[5032] et (iii) de celles soumises à des mesures de

5025 § 122j (1) UmwG.

5026 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 18 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 14 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 323 et 324 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 6.

5027 Art. 86*bis*, § 3, point a) (transformations transfrontalières), 120, § 4, point a) (fusions transfrontalières) et 160*bis*, § 4, point a) (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

5028 Directive (UE) 2014/59 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive (CEE) 82/891 du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil (CE) 2001/24, (CE) 2002/47, (CE) 2004/25, (CE) 2005/56, (CE) 2007/36, (UE) 2011/35, (UE) 2012/30 et (UE) 2013/36et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 1093/2010 et (UE) 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 173, 12 juin 2014, pp. 190–348.

5029 Art. 86*bis*, § 3, point b) (transformations transfrontalières), 120, § 4, point b) (fusions transfrontalières) et 160*bis*, § 4, point b) (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

5030 Cette modification du texte de la Directive Mobilité découle de l'article 92, point 5), point a) du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 22, 22 janvier 2021, pp. 1–102.

5031 Art. 86*bis*, § 4, point a) (transformations transfrontalières), 120, § 5, point a) (fusions transfrontalières) et 160*bis*, § 5, point a) (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

5032 Art. 86*bis*, § 4, point b) (transformations transfrontalières), 120, § 5, point b) (fusions transfrontalières) et 160*bis*, § 5, point b) (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

prévention de crise au sens de l'art. 2, § 1er, point 101) de la directive (UE) 2014/59[5033][5034] ou à l'art. 2, point 48) du Règlement (UE) 2021/23[5035]. Cette position tranche avec celle de la Proposition de la Commission qui prévoyait une exclusion obligatoire pour toutes ces sociétés[5036], à l'exception de celles visées par le Règlement (UE) 2021/23 dans la mesure où ce dernier n'est apparu qu'ultérieurement. Cette position d'origine a en effet été tempérée dès le Premier Compromis de la Présidence[5037] en laissant une plus grande latitude aux États membres pour les sociétés en proie à des mesures préventives ou soumises à des procédures autres que la liquidation de sociétés insolvables, la Commission des affaires juridiques étant même allée jusqu'à proposer de supprimer purement et simplement cette seconde catégorie d'exclusions[5038]. Ce choix, qui demeure plus strict que celui applicable en cas d'opération purement interne[5039], s'avère plus judicieux car, s'il est indéniable qu'il convient d'éviter que des scissions transfrontalières ne soient utilisées abusivement pour échapper à des procédures d'insolvabilité au détriment des créanciers[5040] ou tenter de changer le droit applicable à une telle procédure ou encore le juge compétent[5041], il est tout aussi indispensable de ne pas perdre de vue qu'une scission transfrontalière peut également se révéler être un instrument d'assainissement particulièrement efficace[5042]. En outre, on aurait pu émettre des doutes quant à la proportionnalité de l'entrave à la liberté d'établissement générée par une exclusion pure et simple des sociétés en proie à des mesures préventives en raison de l'existence de mécanismes moins intrusifs[5043], comme les mesures de sauvegarde figurant dans le Règlement Insolvabilité[5044].

5033 Art. 86*bis*, § 4, point c) (transformations transfrontalières), 120, § 5, point c) (fusions transfrontalières) et 160*bis*, § 5, point c) (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité.

5034 Sur ces exclusions, voir également 9e considérant de la Directive Mobilité.

5035 Cette modification du texte de la Directive Mobilité découle de l'article 92, point 5), point b) du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 22, 22 janvier 2021, pp. 1–102.

5036 Art. 86*quater*, § 2 (transformations transfrontalières), 120, § 4 (fusions transfrontalières) et 160*quinquies*, § 2 (scissions transfrontalières) de la Proposition de la Commission.

5037 Art. 86c, §§ 2 et 2a (transformations transfrontalières), 120, §§ 4 et 4a (fusions transfrontalières) et 160c, §§ 4 et 5 (scissions transfrontalières) du Premier Compromis de la Présidence.

5038 Avis CAJ, pp. 78 (transformations transfrontalières), 126 et 127 (fusions transfrontalières) et 169 (scissions transfrontalières).

5039 Art. 87, §§ 3 et 4 et 135, § 4 de la Directive Sociétés.

5040 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, pp. 301 et 302 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, pp. 612, 613 et 617 ; J. SCHMIDT, « Cross-border mergers, divisions and conversions: Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 236 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1), *op. cit.*, p. 239.

5041 Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, pp. 3 et 4 et G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 11, n° 14.

5042 Fr. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 23 et J. SCHMIDT, « Cross-border mergers, divisions and conversions: Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 236.

5043 Voir en ce sens : Fr. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *ibidem*, p. 23.

5044 Sur ces mesures de protection, voir *supra* nos 917 à 921.

§5. Conclusion sur l'incidence du droit international de l'insolvabilité

925. La nécessité d'une relation symbiotique entre droit des sociétés et droit de l'insolvabilité. L' « *interdépendance fonctionnelle* » existant entre le droit des sociétés et le droit de l'insolvabilité se manifeste de multiples façons à l'égard de la protection des créanciers dans le cadre des scissions transfrontalières. Cette relation particulière implique qu'un régime de protection efficace des créanciers ne peut être l'apanage du seul droit des sociétés. Les créanciers seront ainsi mieux protégés contre certains risques spécifiques, à commencer par le « *forum shopping* » abusif en matière d'insolvabilité, par le biais de mécanismes relevant de cette dernière branche du droit. Ce constat est étayé d'une part par une position plus tolérante de la Cour de justice à l'égard de la conformité à la liberté d'établissement de tels mécanismes et, d'autre part, par l'efficacité des garde-fous déployés par le Règlement Insolvabilité en la matière. En revanche, une protection relevant du seul droit de l'insolvabilité ne sera pas suffisante pour deux raisons. Tout d'abord, les scissions transfrontalières engendrent des risques allant au-delà du seul « *forum shopping* » abusif, comme par exemple la substitution de débiteur ou encore l'éclatement du patrimoine de la société scindée. Ensuite, un régime général des scissions transfrontalières se doit de respecter un objectif d'équilibre entre intérêts de la société à se restructurer et la nécessaire protection des créanciers, ce qui n'est pas le cas du droit de l'insolvabilité où la balance penche davantage en faveur des créanciers. Ceci étant, cette indispensable articulation entre droit des sociétés et droit de l'insolvabilité requerra également que le régime des scissions transfrontalières intègre certaines dispositions destinées à assurer une meilleure articulation avec le droit de l'insolvabilité, notamment par le biais de l'exclusion de certains créanciers suffisamment protégés du droit de demander des garanties adéquates et un champ d'application *ratione personae* n'excluant pas *ab initio* les sociétés faisant l'objet d'une mesure de restructuration préventive ou encore d'une procédure d'insolvabilité en déférant ces points spécifiques au droit de l'insolvabilité. Un tel choix s'avérera en outre bénéfique car il renforcera la proportionnalité du régime général des scissions transfrontalières à l'aune de la liberté d'établissement.

SECTION 4. LA NÉCESSITÉ D'UNE CERTAINE FLEXIBILITÉ POUR LES SOCIÉTÉS IMPLIQUÉES

§1. Présentation

926. Enjeu de la question. Certains mécanismes de protection des créanciers tels que la possibilité de demander des garanties adéquates et les incertitudes qui y sont liées sont susceptibles de dissuader les sociétés de réaliser une opération transfrontalière pourtant nécessaire à leur développement économique en raison des coûts et des retards susceptibles d'être engendrés par les créanciers lors d'une telle opération[5045]. Afin de permettre aux sociétés de

[5045] Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 58.

se restructurer plus rapidement[5046], il est indispensable de prévoir une certaine marge de manœuvre pour les opérations transfrontalières ne présentant pas de risques pour les créanciers, comme par exemple dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière intragroupe sans créanciers tiers. Une étude de droit comparé portant sur différents mécanismes destinés à rendre le régime de protection des créanciers plus facilement adaptable (§ 2) suivie de l'analyse des deux présomptions qui figuraient dans la Proposition de la Commission (§ 3) devrait permettre de tirer des conclusions sur la nécessité de prévoir une certaine flexibilité dans un régime européen général des scissions transfrontalières (§ 4).

§ 2. Analyse de droit comparé

927. La possibilité d'écarter la demande d'un créancier. Alors que ni le droit allemand[5047], ni le droit autrichien[5048] ne contiennent de disposition explicitement destinée à permettre d'écarter une demande de garantie émanant d'un créancier, tant le droit belge que le droit luxembourgeois contiennent une disposition assez minimaliste permettant d'éviter le contretemps et le surcoût générés par une demande intempestive d'un créancier qui tenterait de profiter de l'opération pour améliorer sa situation. En droit belge, il est ainsi explicitement prévu que si un créancier exige une sûreté[5049], la société bénéficiaire à laquelle l'obligation en question a été transférée, ce qui inclut la société scindée en cas de scission partielle[5050], et, le cas échéant, la société dissoute disposent de la possibilité d'écarter cette demande en payant la dette « à sa valeur, après déduction de l'escompte »[5051]. Cette faculté de remboursement anticipé ne peut être refusée par les créanciers concernés, même s'ils sont créanciers à terme[5052]. Une solution identique se retrouve en droit luxembourgeois[5053], étant entendu qu'il est tout à fait possible que ce soit une société autre que la société débitrice qui paie le créancier en vue de décharger la société débitrice[5054]. Si cette option est intéressante en termes de flexibilité,

5046 À cet égard, il est intéressant de relever que lors de la Consultation de 2015, 58 % des personnes ayant exprimé leur avis sur la question de savoir dans quelles conditions une procédure « *fast track* » de fusion transfrontalière devait être ouverte ont estimé que cela devrait être le cas lorsque l'opération n'a aucun impact sur les créanciers. Voir : Consultation publique de 2015, p. 16.

5047 §§ 22 (fusions internes) ; 122j (fusions transfrontalières) ; 125 et 133 (scissions internes) UmwG.

5048 § 226 öAktG (fusions internes) ; § 13 EU-VerschG (fusions transfrontalières) et § 15 SpaltG. Il convient toutefois de relever que les conditions pour l'obtention d'une garantie adéquate sont délicates à remplir de sorte que de telles demandes sont rares en pratique. Voir en ce sens à propos des fusions internes : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 339, n° 17.

5049 Art. 12:15, § 1er, al. 1er du CSA.

5050 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 299.

5051 Art. 12:15, § 1er, al. 2 du CSA.

5052 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 16.

5053 Art. 1021-9, § 1er, al. 1er, 3e phrase (fusions) et 1031-10, § 1er, al. 1er, 3e phrase (scissions) de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

5054 Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1984–1985, n° 2897, p. 14 et projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avis de la Chambre de commerce sur la fusion des sociétés anonymes, *Doc.*, Ch., 1984–1985, n° 2897, p. 3.

force est de constater qu'elle demeure foncièrement limitée dans la mesure où, d'une part, elle oblige le débiteur souhaitant éviter un litige à payer la dette, quand bien même l'opération de restructuration ne remettrait pas en cause sa solvabilité et ensuite, elle ne se conçoit que pour des obligations de payer une somme d'argent[5055].

928. La solidarité optionnelle du droit français. En droit français[5056], la protection par défaut des créanciers en cas de scission réside dans la solidarité illimitée de sociétés bénéficiaires. Cependant, il est loisible aux parties à la scission d'écarter cette solidarité dans le projet de scission, auquel cas les créanciers sociaux jouiront d'un droit d'opposition, leur permettant d'obtenir, selon la décision du juge compétent, le remboursement de leur créance ou la constitution de garanties, sous peine d'inopposabilité de la scission à leur égard[5057]. Compte tenu des insuffisances de chacun de ces deux mécanismes de protection[5058], insérer une telle flexibilité par ce moyen n'est toutefois pas souhaitable car cela revient à méconnaître fondamentalement le risque d'apathie rationnelle engendré par le droit d'opposition.

929. La « *gatekeeper approach* » de certains États membres. En droit italien[5059], en cas de scission interne, les créanciers des sociétés impliquées jouissent en principe d'un droit d'opposition[5060]. Pour garantir l'efficacité de celui-ci, il est prévu que l'opération ne pourra prendre effet avant l'écoulement d'un délai de soixante jours à compter de la dernière inscription de la décision de participer à l'opération au registre des entreprises. Cependant, pour permettre d'accélérer la prise d'effet dans le cadre des scissions ne présentant pas de risques additionnels pour les créanciers, il est également prévu que ce délai tombera si (i) l'accord des créanciers des sociétés impliquées antérieurs à l'inscription ou à la publication du projet commun a été obtenu, (ii) les créanciers n'ayant pas donné leur accord ont été payés, (iii) les sommes nécessaires au paiement des créanciers n'ayant pas donné leur accord ont été déposées auprès d'une banque ou (iv) le rapport d'expert indépendant a été établi par la même société de révision pour toutes les sociétés impliquées et que cette société de révision établit, sous sa propre responsabilité, que la situation patrimoniale et financière des sociétés impliquées dans l'opération est telle que des garanties additionnelles ne sont pas nécessaires à la protection des créanciers[5061]. Si les trois premières exceptions ne sont pas surprenantes, la dernière présente une certaine originalité. En effet, en vue d'assurer la protection des créanciers, l'Italie a adopté une position qu'on qualifie généralement

5055 Voir en ce sens : Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 317, n° 468.

5056 Art. L236-20 (sociétés par actions) et L236-23 (S.à r.l.) du Code de commerce français et à ce sujet, voir : C. CATHIARD, J.-M. MOULIN et J.-L. NAVARRO, *ibidem*, p. 111, n° 257.

5057 Art. L236-21 (sociétés par actions), L236-23 (S.à r.l.) et L236-14 (droit d'opposition) du Code de commerce français.

5058 À ce sujet, voir *supra* n°s 776 à 779 et n°s 788 et 789.

5059 Sur le régime de protection des créanciers applicable en Italie, voir : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 57 ; Étude d'impact, p. 145 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 58.

5060 Art. 2503, § 1er et 2506-ter, § 3 du Codice Civile, disponible sur www.altalex.com (18/07/2019).

5061 Sur cette exception en matière de fusions transfrontalières, voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 57.

de « *gatekeeper approach* »[5062][5063] et qui repose sur l'intervention d'un expert indépendant, jugé plus à même de déterminer si les créanciers encourent un quelconque risque additionnel du fait de l'opération[5064]. Du point de vue de la théorie de l'agence, cela équivaut à ce que le principal délègue la surveillance de l'agent à un tiers plus compétent pour le faire[5065]. Une telle position n'est toutefois pas unique en Europe, et se retrouve également au Danemark où, en cas de scission interne, les risques posés par l'opération pour les créanciers font l'objet d'une évaluation par un expert indépendant[5066]. Elle se retrouve également dans l'*Europen Model Companies Act*[5067]. Il y est ainsi prévu que les mécanismes de protection des créanciers sont directement liés aux résultats du rapport d'expert indépendant. Il est toutefois intéressant de relever que le régime italien ne permet de recourir à cette exception que lorsque les sociétés impliquées dans l'opération on fait le choix de nommer un expert unique. Cette précision n'est pas sans importance car seul un expert ayant analysé la situation de chacune des sociétés impliquées sera à même de déterminer si une opération présente ou non un risque pour les créanciers.

§ 3. Le régime de la Proposition de la Commission

930. Deux présomptions réfragables. En vue notamment d'éviter de pénaliser excessivement les sociétés en instaurant un régime de protection *ex ante*[5068] mais également afin de favoriser la mobilité transfrontalière dans les situations ne présentant que peu de risques pour les créanciers[5069], la Proposition de la Commission présentait l'originalité d'instaurer deux présomptions que l'opération projetée ne lésait pas les créanciers[5070]. Si l'instauration de telles présomptions apparaît de prime abord être dans l'intérêt de la société scindée, il est toutefois utile de préciser que d'une part, les deux présomptions étaient susceptibles de preuve contraire[5071] et que d'autre part, la Proposition de la

[5062] Par « *gatekeeper approach* » ou « *gatekeeper control* », on vise le recours à des acteurs extérieurs à la société, tels que des comptables ou des avocats, en vue de surveiller la conduite des acteurs intérieurs à la société. À ce sujet, voir J. ARMOUR, H. HANSMANN et R. KRAAKMAN, *op. cit.*, p. 42.

[5063] Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 207 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 57. Sur le rôle de « *gatekeepers* » dans le cadre de la protection des créanciers, voir : J. ARMOUR, G. HERTIG et H. KANDA, *op. cit.*, pp. 122 et 123 et J. KRAAKMAN, « Gatekeepers : the anatomy of a third-party enforcement strategy », *Journal of Law, Economics and Organization*, 1986, Vol. 2(1), pp. 53–104.

[5064] J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 206 et 207 et Étude d'impact, p. 68.

[5065] J. ARMOUR, H. HANSMANN et R. KRAAKMAN, *op. cit.*, pp. 42 et 43.

[5066] Art. 277 (fusions transfrontalières) et 297 (scissions transfrontalières) du Danish Companies Act, disponible sur https://danishbusinessauthority.dk (10/10/2019). Sur le régime de protection des créanciers applicable au Danemark, voir : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 57 ; Étude d'impact, p. 145 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 58.

[5067] Voir à propos des fusions transfrontalières : art. 13:28 de l'European Model Companies Act, 1st ed., 2017, disponible sur https://papers.ssrn.com (18/10/2019). Voir en ce sens également : Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 246.

[5068] Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 293.

[5069] 18e, 35e et 50e considérants de la Proposition de la Commission et ECLE, *op. cit.*, p. 206.

[5070] Art. 86*duodecies*, § 3 (transformations transfrontalières), 126*ter*, § 3 (fusions transfrontalières) et 160*quaterdecies*, § 3 (scissions transfrontalières) de la Proposition de la Commission.

[5071] Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 33 et J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 843 ;

Commission prévoyait explicitement que si un créancier de la société scindée dont la créance est transférée n'obtient pas satisfaction de son nouveau débiteur, toutes les sociétés issues de l'opération se retrouveraient conjointement et solidairement responsables[5072]. Cette responsabilité devait toutefois être limitée pour chaque entité concernée à la valeur des actifs nets attribués à celles-ci au jour de la date de prise d'effet de l'opération[5073].

931. Une extension de la « *gatekeeper approach* ». La première présomption vise l'hypothèse dans laquelle la société publie en même temps que le projet de scission un rapport (i) établi par un expert indépendant remplissant les mêmes critères que l'expert chargé d'examiner le projet de scission et nommé comme ce dernier[5074] et (ii) qui aboutit à la conclusion « qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable que les droits des créanciers soient indûment lésés »[5075]. Cette première présomption semble inspirée de la solution adoptée à l'égard des fusions et scissions en droit italien[5076] ou encore du régime danois applicable aux fusions et scissions transfrontalières[5077]. Elle est certes utile tout d'abord en ce que l'expert indépendant est vraisemblablement la personne la plus à même de déterminer si une opération présente ou non un risque pour la situation des créanciers[5078] et ensuite, en ce qu'elle offre aux sociétés une possibilité de limiter les risques de recours de la part des créanciers[5079], mais compte tenu du coût d'un tel rapport d'expert, elle s'adresse surtout aux scissions de sociétés d'une certaine taille et ayant un nombre important de créanciers internationaux[5080]. En outre, s'il a pu être avancé que lier la protection des créanciers au rapport d'expert indépendant pouvait s'avérer à la fois utile et innovant en ce que cela permettra à la fois aux créanciers et à la société de disposer d'une évaluation solide de l'impact de l'opération sur leur situation[5081], une telle assertion se doit d'être fortement relativisée en présence de créances encore inconnues ou impossibles à évaluer au moment de l'opération, comme par exemple en cas de responsabilité environnementale ou nucléaire. Cette limite explique pourquoi la présomption doit nécessairement être réfragable. A cela s'ajoute

I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 28 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 34 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 27 ; Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 5 et G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 15, n° 44. Voir également : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU) in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM (2018) 241 », *op. cit.*, p. 861, n° 36 qui relève que le caractère réfragable des présomptions en question devrait apparaître dans le texte même de la Proposition de la Commission et pas uniquement dans les considérants.

5072 Art. 160*quaterdecies*, § 4, *in initio* de la Proposition de la Commission.

5073 Art. 160*quaterdecies*, § 4, *in fine* de la Proposition de la Commission.

5074 À ce sujet, voir *supra* n°s 564 à 566.

5075 Art. 86*duodecies*, § 3, a) (transformations transfrontalières), 126*ter*, § 3, a) (fusions transfrontalières) et 160*quaterdecies*, § 3, a) (scissions transfrontalières) de la Proposition de la Commission.

5076 Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, p. 36.

5077 Art. 277 (fusions transfrontalières) et 297 (scissions transfrontalières) du Danish Companies Act, disponible sur https://danishbusinessauthority.dk (10/10/2019).

5078 Voir en ce sens : Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 246.

5079 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 206 et 207 et Étude d'impact, p. 68.

5080 Voir en ce sens également : S. BINARD et L. SCHUMMER, *op. cit.*, p. 36.

5081 Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 9.

que dans la mesure où la Proposition de la Commission ne précise pas les qualifications de l'expert en question, la qualité du rapport risque de varier d'un État membre à un autre[5082], même si la Proposition de la Commission tempère ce risque en prévoyant que l'expert en question devra être désigné ou agréé par l'autorité compétente et devra également présenter certaines garanties d'indépendance par rapport à la société scindée[5083]. En outre, en prévoyant, dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière par absorption, que la présomption ne jouera que si les parties ont fait le choix de faire établir un rapport unique pour toutes les sociétés impliquées[5084], comme en droit italien[5085], il sera possible de renforcer l'indépendance de l'expert puisque celui-ci sera, comme en matière de fusions transfrontalières[5086], nommé par une autorité judiciaire ou administrative. Par ailleurs, on peut déplorer l'imprécision des termes « probabilité raisonnable » et « indûment lésés » utilisés par la Proposition de la Commission[5087]. Si la version allemande de la Proposition de la Commission est un peu plus précise en parlant de « détérioration excessive » (« *übermäßige Beeinträchtigung* »), on peut également s'interroger également sur la raison pour laquelle la présomption devrait jouer lorsque les créanciers sont lésés par l'opération mais pas excessivement[5088]. Laisser une telle marge d'appréciation à un expert mandaté par la société risque d'être source de dangereux abus. En conséquence, il aurait mieux valu limiter le jeu de la présomption aux seules hypothèses dans lesquelles, de l'avis de l'expert indépendant, la scission transfrontalière ne compromet pas le remboursement à terme des dettes de la société scindée. Il est important également de relever que la présomption aurait gagné en efficacité et permis d'économiser certains coûts additionnels s'il avait été précisé que l'expert indépendant ainsi visé pouvait être celui intervenant également dans le processus de scission transfrontalière[5089][5090], comme c'est le cas en droit italien[5091].

932. L'octroi d'un droit de paiement de qualité équivalente. La seconde présomption concerne le cas dans lequel les créanciers se voient offrir un droit de

5082 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 207 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 57.

5083 Art. 86*duodecies*, § 3, a) (transformations transfrontalières), 126*ter*, § 3, a) (fusions transfrontalières) et 160*quaterdecies*, § 3, a) (scissions transfrontalières) de la Proposition de la Commission.

5084 Sur la nécessité de prévoir la possibilité d'un tel rapport unique dans le cadre de la procédure de scission transfrontalière, voir *supra* n° 571.

5085 Art. 2503, al. 1er du *Codice civile* italien.

5086 Art. 125, § 2 de la Directive Sociétés.

5087 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311 ; T. BRANDI, *op. cit.*, p. 2632, note 74 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2443. Voir également de manière générale sur le manque de clarté des présomptions de la Proposition de la Commission : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 10.

5088 DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 861, n° 37 et 867, n° 102 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2708.

5089 Sur le rôle de l'expert indépendant, voir *supra* nos 562 à 589.

5090 DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 861, n° 37 et 867, n° 102 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2708.

5091 Art. 2503, al. 1er du *Codice civile* italien.

paiement à l'encontre soit d'un garant tiers, soit des sociétés bénéficiaires, en ce compris la société scindée en cas de scission partielle transfrontalière, d'une valeur au moins équivalente à leur créance initiale, relevant de la même juridiction que la créance initiale et d'une qualité de crédit au moins comparable à la créance initiale immédiatement après la prise d'effet de la scission[5092]. Les hypothèses ainsi visées sont très larges et auraient permis aux praticiens de faire preuve d'imagination pour éviter toute procédure en amont de l'opération en recourant par exemple à une garantie à première demande donnée par une société du même groupe que la société scindée sous condition suspensive de la réalisation de la scission. Si elle paraît certes utile de prime abord, force est de constater que cette deuxième présomption n'est pas claire. En effet, on peut s'interroger sur l'identité de la personne chargée d'évaluer la qualité au moins équivalente du droit de paiement ainsi offert[5093]. On pourrait considérer qu'il doit s'agir de l'expert indépendant, voire même que la deuxième présomption ainsi prévue par la Proposition de la Commission vise en réalité uniquement à préciser les critères à prendre en compte par l'expert indépendant pour déterminer si les intérêts des créanciers sont lésés par l'opération[5094]. Cependant cette dernière interprétation doit être rejetée dans la mesure où elle n'est pas conciliable avec la formulation de l'exposé des motifs qui distingue clairement deux hypothèses[5095]. Dans un même ordre d'idées, on peut également s'interroger sur les critères à prendre en compte pour déterminer une telle équivalence. Faut-il en effet s'attacher à la valeur historique de la créance ou, au contraire, s'adonner à un délicat exercice d'évaluation de la juste valeur de la créance ? C'est en tout cas vers cette deuxième solution, qui semble en outre plus équitable et plus conforme à l'objectif de neutralité de l'opération, que s'orientait la Commission des affaires juridiques en proposant de remplacer cette condition d'équivalence par une condition d'égalité à la valeur réelle de la créance initiale[5096]. Cette deuxième présomption a également fait l'objet de certaines critiques au motif qu'elle était excessivement onéreuse à partir du moment où l'intervention d'un tiers garant est requise[5097]. Il est certes vrai qu'une telle garantie additionnelle pourrait sensiblement améliorer la situation du créancier en question et revient à imposer une charge significative à un tiers à l'opération. Cependant, il convient de ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'un choix laissé à la discrétion tant de la société scindée que du tiers garant éventuel, de sorte que si ces derniers décident de leur plein gré d'octroyer une telle garantie, c'est qu'ils y trouvent également leur avantage en accélérant la réalisation de l'opération et en économisant les coûts liés à un éventuel litige avec le créancier en question. Pour finir, il a également été avancé, en cas de

5092 Art. 86*duodecies*, § 3, b) (transformations transfrontalières), 126*ter*, § 3, b) (fusions transfrontalières) et 160*quaterdecies*, § 3, b) (scissions transfrontalières) de la Proposition de la Commission.

5093 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 207.

5094 Voir en ce sens : ECLE, *ibidem*, p. 207. Voir également à ce sujet : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 67.

5095 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 7.

5096 Avis CAJ, p. 195. Voir en ce sens également : G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 15, n° 44.

5097 Voir en ce sens : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 861, n°s 39 et 867, n° 102.

transformations transfrontalières[5098], que la présomption n'était pas justifiée lorsque le droit de paiement équivalent était consenti par la société issue de l'opération dans la mesure où elle demeure débitrice de la dette d'origine après l'opération et qu'un simple dédoublement de celle-ci n'est pas de nature à améliorer la situation des créanciers, la seule différence étant la compétence des juridictions d'origine. Une telle remarque n'est pas fondée à l'égard des scissions transfrontalières car le texte même de la Proposition de la Commission précise que le droit de paiement doit être consenti à l'encontre de toutes les sociétés issues de l'opération, ce qui comprend nécessairement celle qui ne recueillera pas la dette en question dans son patrimoine. Il en résultera l'équivalent d'une solidarité des sociétés bénéficiaires mais qui ne sera pas soumise à la limite des actifs nets transférés, ce qui représente en tout état de cause une amélioration significative de la situation des créanciers qui bénéficieront en outre d'une *perpetuatio fori*[5099] pour le deuxième droit de paiement[5100]. Par souci de clarté à cet égard, il aurait été avantageux de reformuler la deuxième présomption en prévoyant qu'elle jouerait soit en cas de droit de paiement équivalent octroyé par un tiers garant, soit en cas de solidarité non limitée aux actifs nets transférés des sociétés bénéficiaires pour les dettes de la société scindée.

933. L'abandon dans le Premier Compromis de la Présidence. Considéré par certains comme l'aspect le plus innovant de la Proposition de la Commission[5101], ce régime composé de deux présomptions réfragables, a disparu dès le Premier Compromis de la Présidence[5102] et n'est réapparu ni dans la Proposition du Parlement[5103], ni dans la Directive Mobilité[5104], bien qu'en contrepartie, les conditions auxquelles les créanciers peuvent obtenir des garanties adéquates aient été modifiées pour imposer à ceux-ci de démontrer, de manière crédible,

5098 DAV, *ibidem*, p. 861, n° 39.

5099 Sur ce mécanisme de protection des créanciers, voir *supra* n[os] 790 à 796.

5100 Cette forme de *perpetuatio fori* découle de l'exigence que le droit de paiement ainsi consenti relève de la même juridiction que la créance initiale. Voir art. 160*quaterdecies*, § 3, a) de la Proposition de la Commission.

5101 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 57 au sujet de la présomption reposant sur un rapport d'expert indépendant. Voir également en faveur de ce régime de protection : S. BINARD et L. SCHUMMER, *op. cit.*, p. 36 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311 ; Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 843 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects of the EU Commission's Company Law Package: or 'The Good, the Bad and the Ugly' », *op. cit.*, p. 18 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2708. Voir également en faveur de la première présomption uniquement : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, pp. 861, n[os] 39 et 867, n° 102 ; ECLE, *op. cit.*, pp. 206 et 207 ; G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 15, n° 44 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2443. Pour un point de vue plus sceptique de ce régime dans le cadre des transformations transfrontalières, voir : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 34. Voir également : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 10 qui recommande à la Commission de supprimer ces deux présomptions en raison de leur manque de clarté.

5102 Art. 160m du Premier Compromis de la Présidence.

5103 Art. 160*quaterdecies* de la Proposition du Parlement.

5104 Art. 160*undecies* de la Directive Mobilité.

que la scission transfrontalière compromet le remboursement de leurs créances et qu'ils n'ont pas obtenu de garanties satisfaisantes de la part de la société[5105]. Si on peut certes remarquer le fait que ces présomptions aient été principalement adressées aux groupes de sociétés d'une certaine importance, on ne peut que déplorer leur abandon[5106]. Ces présomptions auraient en effet permis de simplifier les scissions transfrontalières ne présentant que peu de risques pour les créanciers en évitant les coûts et les retards liés aux demandes de multiples créanciers[5107]. En outre, elles présentaient l'avantage de renforcer la proportionnalité du mécanisme général de protection des créanciers consacré par la Proposition de la Commission au regard de la liberté d'établissement. Il est en effet beaucoup plus aisé d'avancer que celui-ci ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la protection des intérêts des créanciers si les sociétés disposent elles-mêmes d'une possibilité d'écarter les demandes des créanciers *ab initio*. Pour finir, elles permettaient d'éviter que des créanciers n'abusent des mécanismes de protection mis en place par les États membres pour améliorer leur situation. À titre d'illustration, si on prend l'exemple d'une société qui souhaite réaliser une scission transfrontalière essentielle à sa survie économique dès que possible mais qui est située dans un État membre, comme la Belgique[5108], qui attache un effet suspensif à une demande de garantie introduite par un créancier, il y a un risque qu'un créancier n'utilise la situation pour améliorer sa position en faisant planer la menace d'une action introduite juste avant l'écoulement du délai et ce, au détriment tant de la société que des autres créanciers. En d'autres termes, ces deux présomptions étaient destinées à préserver le délicat équilibre entre les intérêts en présence, ce qui ressort clairement de la réponse de la Commission[5109] au *Bundesrat* allemand qui lui avait demandé de les supprimer[5110]. Dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la prévisibilité de l'impact de la protection des créanciers sur la société scindée, il aurait pu être utile au contraire de les préciser encore davantage[5111].

5105 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 *in fine* de la Directive Mobilité. Voir à ce sujet : P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2443.

5106 Voir en ce sens : Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 246 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 58.

5107 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 311 et Étude d'impact, p. 68.

5108 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., 2017–2018, n° 54-3119/001, p. 1311 et I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 27 ; E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *op. cit.*, p. 340, n° 941 et D. WILLERMAIN, « Restructuration de sociétés… », *op. cit.*, p. 337.

5109 Stellungnahme der Europäischen Kommission zu dem Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen c(201) 114 final, zu *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 5.

5110 Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 10.

5111 Voir en ce sens également : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 263 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects of the EU Commission's Company Law Package: or 'The Good, the Bad and the Ugly' », *op. cit.*, p. 18 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 58.

§ 4. Conclusion sur la nécessité d'une certaine flexibilité pour les sociétés impliquées

934. La nécessité d'un régime de protection adaptable. Chaque scission transfrontalière présente ses spécificités et peut s'avérer totalement inoffensive pour les créanciers, comme par exemple dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière intragroupe n'impliquant que des sociétés en excellente santé financière ou, au contraire, particulièrement dommageable, comme par exemple dans l'hypothèse d'une scission-assainissement où une société solvable est scindée au profit de deux sociétés en situation précaire dans l'espoir de leur éviter la faillite. Il serait donc foncièrement erroné de vouloir traiter toutes ces situations par le biais d'un régime de protection figé. En effet, un tel régime s'avérerait tantôt insuffisant, tantôt excessif en fonction des spécificités de chaque opération, ce qui poserait des questions non seulement du point de vue de l'objectif de neutralité d'un tel régime, mais également du point de vue de la proportionnalité de la mesure à l'aune de la liberté d'établissement. Il est donc indispensable qu'un mécanisme de protection efficace des créanciers intègre un régime de base très protecteur pour les créanciers destiné avant tout à préserver les intérêts des créanciers dans les situations à risque, combiné à certaines possibilités d'assouplissement en cas de risques moindres ou inexistants pour les créanciers. À cet égard, il ressort de l'analyse qui précède que les deux présomptions de la Commission auraient pu s'avérer utiles si elles avaient fait l'objet de plus d'attention au cours du processus législatif.

SECTION 5. L'ARTICULATION AVEC LA PROTECTION DES TITULAIRES DE TITRES, AUTRES QUE DES ACTIONS, AUXQUELS SONT ATTACHÉS DES DROITS SPÉCIAUX

§ 1. Présentation

935. Plan de la section 5. À ce stade de l'analyse, il est utile de s'intéresser brièvement à une catégorie particulière de créanciers[5112] que sont les « *porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux* » spécifiquement visés par la Directive Sociétés tant dans l'hypothèse des scissions internes[5113] que des fusions internes[5114]. Afin de pouvoir tirer certaines conclusions sur un régime européen plus général des scissions transfrontalières à cet égard (§ 8), il conviendra, après avoir apporté quelques précisions terminologiques (§ 2), d'étudier la mesure dans laquelle ces titulaires nécessitent une protection spécifique (§ 3) ainsi que la réponse apportée par le législateur européen à cette question (§ 4). Comme dans le cas de la protection générale des créanciers, il sera ensuite nécessaire de voir à quel point il est important que la société émettrice bénéficie d'une certaine flexibilité (§ 5) et

[5112] Voir arrêt *KA Finanz*, pt. 64 où la Cour de justice semble considérer que les porteurs de titres sont bien une catégorie particulière de créanciers.
[5113] Art. 147 de la Directive Sociétés.
[5114] Art. 101 de la Directive Sociétés.

si les parties concernées disposent de la possibilité de prévoir certains aménagements conventionnels (§ 6). Pour finir, il sera indispensable de clarifier l'articulation de ce régime de protection très spécifique avec celui, plus général, des créanciers (§ 7).

§2. Les instruments visés

936. La notion de « titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux ». Selon la Cour de justice, les titres ainsi visés sont « entre autres titres, les obligations échangeables contre des actions, les obligations assorties de droits de souscription préférentiels au capital social, les obligations participant aux bénéfices ainsi que les droits de souscription »[5115] ou, en termes plus généraux[5116], les titres qui « confèrent à leurs porteurs des droits plus étendus qu'un simple remboursement des créances et des intérêts convenus »[5117] et, plus particulièrement, « des titres qui reconnaissent à leurs porteurs le droit de les échanger contre des actions ou le droit de participer aux bénéfices de la société émettrice »[5118]. Si on considère généralement que les parts bénéficiaires[5119] tombent dans cette catégorie et que les contrats de travail ou de mandat prévoyant des mécanismes de rémunération liés aux résultats de l'entreprise, tels que des tantièmes, sont exclus[5120], d'autres instruments hybrides sont susceptibles de poser certaines questions. Qu'en est-il ainsi par exemple des *preferred equity certificates* fréquents en droit luxembourgeois, ayant les caractéristiques d'un instrument de dette mais dont l'intérêt est calculé non pas en fonction du montant principal, mais des bénéfices générés par un investissement sous-jacent dont l'acquisition a partiellement été financée par l'émission de ceux-ci ? La réponse à cette question dépendra nécessairement de l'appréciation souveraine des juridictions nationales[5121], mais il est toutefois intéressant de relever que, contrairement à la proposition de troisième directive sur les fusions internes de 1970 qui énumérait explicitement un certain nombre d'instruments[5122], la Directive Sociétés reste vague, vraisemblablement

5115 Arrêt *KA Finanz*, pt. 65.

5116 Voir en ce sens : Th. TILQUIN, « L'arrêt KA Finanz AG : la fusion transfrontalière et la protection des créanciers », *op. cit.*, p. 69.

5117 Arrêt *KA Finanz*, pt. 66.

5118 *Ibidem*.

5119 G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, p. 136, n° 30 ; Th. TILQUIN, « L'arrêt KA Finanz AG : la fusion transfrontalière et la protection des créanciers », *op. cit.*, p. 69 et Th. TILQUIN, « Traité des fusions et scissions », *op. cit.*, p. 139, n° 182.

5120 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 20 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER, *op. cit.*, § 23, n° 3.

5121 Th. TILQUIN, « L'arrêt KA Finanz AG : la fusion transfrontalière et la protection des créanciers », *op. cit.*, p. 69.

5122 Voir art. 13 et 14 de la proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, paragraphe 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes, COM (70)633, 14 juillet 1970, *J.O.C.E.*, n° C 89/20 qui mentionnent respectivement « les porteurs d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions, d'obligations assorties de droits de souscription préférentiels au capital social, d'obligations participant aux bénéfices ainsi que les titulaires de droits de souscription » et « les porteurs de parts bénéficiaires non représentatives du capital social et les porteurs d'actions de jouissance ou de « *Genusscheine* » de la société absorbée ».

de manière à pouvoir s'adapter plus facilement aux spécificités nationales[5123] ainsi qu'aux évolutions du droit des sociétés. On peut néanmoins déduire de cette interprétation ainsi que du texte de l'article 147 de la Directive Sociétés que seuls des droits économiques spéciaux sont visés par cette disposition[5124].

§ 3. La nécessité d'une protection accrue des titulaires

937. Un risque de dilution économique. En cas de scission transfrontalière, les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux au sein de la société scindée encourent un risque de dilution[5125] sans même avoir la possibilité de voter sur l'opération[5126]. En d'autres termes, cette catégorie spécifique de créanciers encourt des risques similaires à ceux des associés sans toutefois bénéficier du même droit de vote sur l'opération envisagée[5127].

938. Un risque lié à la nature d'une scission. Si ces deux risques[5128] se retrouvent aussi bien dans une fusion que dans une scission, la situation est davantage complexe dans ce dernier cas. En effet, les scissions se caractérisent en principe par une pluralité de sociétés bénéficiaires de sorte que les droits spéciaux pourraient se retrouver éparpillés dans plusieurs sociétés bénéficiaires, voire demeurer au sein de la société scindée en cas de scission partielle. Ce dernier point n'a pas été explicitement traité par le législateur européen mais est néanmoins logique du point de vue de la *ratio legis* puisque l'objectif de cette mesure de protection est d'éviter que les titulaires de droit spéciaux n'aient à souffrir d'une érosion de leurs droits en raison de l'opération[5129] et que celui-ci sera tout aussi bien rempli en cas de maintien des droits au sein de la société scindée, le cas échéant moyennant modification afin de s'assurer que ceux-ci demeurent à tout le moins équivalents[5130].

5123 Voir en ce sens : L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556.

5124 Voir en ce sens : S. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 2 ; S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 8 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 2.

5125 Proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, paragraphe 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes, COM (70)633, 14 juillet 1970, p. 32 et B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 23, n° 2 ; L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556 ; S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 23, n° 1 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 23, n° 1 et M. WINTER in J. SCHMITT, R. HORTNÄGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 1.

5126 L. HÜBNER, *ibidem*, p. 556 ; S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 23, n° 1 et M. WINTER in J. SCHMITT, R. HORTNÄGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *ibidem*, § 23, n° 4.

5127 Voir en ce sens : S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *ibidem*, § 23, n° 11.

5128 Sur le risque engendré par un rapport d'échange inadéquat, voir *infra* n° 979. Sur le risque engendré par le fait de se faire imposer une opération, voir *infra* n° 980.

5129 Proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, paragraphe 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes, COM (70) 633, 12 juin 1970, p. 32 et 4e considérant de la Sixième Directive et B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 2 ; L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556 ; S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 1 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 1 et M. WINTER in J. SCHMITT, R. HORTNÄGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 1.

5130 M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 133, n° 130.

§4. La protection consacrée par le législateur européen

939. Le régime des scissions internes. Le régime de protection des porteurs de titres consacré par les dispositions de la Directive Sociétés prévoit que ces derniers devront jouir au sein des sociétés bénéficiaires de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient au sein de la société scindée, à moins que la modification des droits en question n'ait été approuvée par une assemblée des porteurs de titres ou, si la loi nationale n'en prévoit pas, par les porteurs de titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres[5131].

940. La notion de « droits au moins équivalents ». Bien que la Directive Sociétés ne contienne aucune précision sur ce qu'il convient d'entendre par « droits au moins équivalents », il est généralement admis que l'équivalence doit être appréciée en termes économiques et non d'un point de vue purement juridique[5132]. En outre, il n'est pas requis que les droits ainsi offerts soient identiques à ceux qui disparaissent dans le cadre de l'opération[5133]. Cette flexibilité est particulièrement importante dans un contexte transfrontalier dans la mesure où elle permet de pallier l'absence de droits identiques dans la juridiction d'accueil, même si elle impose de se livrer, le cas échéant, à un délicat exercice de comparaison.

941. Le texte ambigu de la Directive Sociétés. Le régime de protection des titulaires de droits spéciaux dans le cadre d'une scission interne ayant été calqué sur celui applicable en cas de fusion interne[5134], le législateur européen s'est contenté d'adapter le texte applicable aux fusions internes à l'existence de plusieurs sociétés bénéficiaires sans autre forme de précisions[5135]. Ce point est regrettable car ce faisant, il laisse entendre que les titulaires de titres autres que des actions devraient jouir de droits spéciaux dans chacune des sociétés bénéficiaires et que la somme de ceux-ci devrait correspondre à des droits au moins équivalents à ceux dont ils disposaient dans la société scindée. Une telle interprétation, bien qu'*a priori* conforme au texte de l'article 147 de la Directive Sociétés, est toutefois beaucoup trop restrictive et n'a pas été suivie par bon nombre de législateurs nationaux. Ainsi, à titre d'illustration, alors que tant le législateur belge[5136] que le législateur luxembourgeois[5137] laissent planer un doute sur la nécessité que des droits soient nécessairement attribués par toutes les sociétés bénéficiaires[5138], le législateur autrichien indique simplement que les titulaires de droits spéciaux doivent disposer de droits équivalents ou

5131 Art. 147 de la Directive Sociétés.
5132 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz… », *op. cit.*, p. 849 ; B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 16 ; S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 12 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 346 et 347, n° 35 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 8.
5133 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 346, n° 35.
5134 Art. 101 de la Directive Sociétés et 4e considérant de la Sixième Directive qui implique que la procédure de scission interne a été alignée sur celle des fusions internes.
5135 Art. 101 et 147 de la Directive Sociétés.
5136 Art. 12:59, al. 1er, 6° et 12:75, al. 1er, 6° du CSA.
5137 Art. 1031-12, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
5138 Art. 12:59, al. 1er, 6° et 12:75, al. 1er, 6° du CSA.

bénéficier d'une compensation financière pour la modification de leurs droits ou leurs droits en tant que tels[5139] et en droit allemand, la disposition, qui renvoie directement au régime applicable aux fusions internes[5140], est majoritairement interprétée par la doctrine comme laissant le choix aux parties à la scission de déterminer librement quelle société devra consentir des droits équivalents[5141].

942. Une insécurité juridique en cas de scission transfrontalière. Si cette imprécision de la part du législateur européen ne pose pas de problème dans un contexte purement interne si les législateurs nationaux ont pris soin de la clarifier, il n'en va pas de même dans l'hypothèse d'une opération transfrontalière. En effet, on conçoit aisément les difficultés pratiques qui seraient engendrées dans le cas d'une scission partielle où la société scindée serait soumise à un droit national prônant une obligation pour toutes les sociétés issues de la scission de fournir des droits équivalents, alors que tel n'est pas le cas en vertu du droit national applicable à la société bénéficiaire qui, au contraire, comptait sur le maintien des droits spéciaux au sein de la société scindée moyennant modification de ceux-ci. Dans un souci de sécurité juridique et de simplification des procédures transfrontalières en vue d'en réduire le coût, il serait utile d'harmoniser ce point dans le sens d'une certaine flexibilité pour les parties. En effet, l'objet de la disposition est uniquement d'éviter un amoindrissement des droits des détenteurs de titres autres que des actions[5142], ce qui ne nécessite pas forcément que des droits soient consentis dans toutes les sociétés bénéficiaires.

943. L'absence d'indication dans le Directive Mobilité. Malgré ces incertitudes, il n'y a aucune disposition dans la Directive Mobilité qui consacre spécifiquement la protection des porteurs de titres autres que des actions par le biais de droits au moins équivalents et ce, que ce soit à l'égard des scissions transfrontalières, des fusions transfrontalières ou des transformations transfrontalières. Néanmoins, leur sort n'a pas été totalement oublié puisqu'il est prévu que le projet devra mentionner, entre autres, les droits accordés aux porteurs de titres ou les mesures proposées à leur égard[5143]. Il conviendra dès lors d'appliquer le droit interne sur ce point[5144] conformément également aux enseignements

5139 § 15(5) SpaltG.

5140 §§ 125 et 23 UmwG.

5141 *Pro* : R. HÖRTNAGL in J. SCHMITT, R. HÖRTNAGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 27 ; M. SCHWAB in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 129 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 73. *Contra* : M. SICKINGER in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 125, n° 34 et O. VOSSIUS in S. WIDMANN et M. MAYER (dir.), *op. cit.*, § 133, n° 26.

5142 Proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, paragraphe 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes, COM (70) 633, 12 juin 1970, p. 32 et quatrième considérant de la Sixième Directive et S. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 2 ; L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 556 ; S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 1 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 1 et M. WINTER in J. SCHMITT, R. HORTNÄGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 1.

5143 Art. 86*quinquies*, point e) (transformations transfrontalières) et art. 160*quinquies*, point i) (scissions transfrontalières) de la Directive Mobilité et art. 122, g) de la Directive Sociétés (fusions transfrontalières).

5144 Pour les scissions par constitution de nouvelles sociétés et pour les scissions partielles au profit d'une ou de plusieurs nouvelle(s) société(s), voir art. 160*quater* de la Directive Mobilité.

de la Cour de justice[5145]. Cependant, si à l'égard des fusions transfrontalières, cette solution est viable, elle l'est beaucoup moins à l'égard des scissions transfrontalières en raison du champ d'application plus limité des dispositions de la Directive Mobilité à l'égard des scissions internes qui ne couvre que les sociétés anonymes[5146], contrairement aux dispositions sur les scissions transfrontalières[5147], et de la reconnaissance facultative de la figure de la scission[5148].

§5. La nécessité d'une certaine flexibilité pour l'émettrice

944. La nécessité d'une porte de sortie pour la société émettrice ? S'il est indéniable que les titulaires de titres nécessitent une protection spécifique, on peut s'interroger s'il convient malgré tout de permettre à la société émettrice de bénéficier d'une certaine latitude quant au choix des mécanismes de protection des titulaires de droits spéciaux. En effet, comme l'art. 147 de la Directive Sociétés prévoit en matière de scissions internes que les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir de droits au moins équivalents au sein des sociétés bénéficiaires, sauf si la modification des termes et conditions de leurs droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, par les porteurs de ces titres individuellement ou encore si ces porteurs ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres, on peut se demander si cette disposition doit être interprétée dans le sens qu'il est loisible à la société émettrice de procéder au rachat des titres pour éviter aux sociétés bénéficiaires de se livrer à l'exercice potentiellement délicat de l'octroi de droits au moins équivalents. Afin d'apporter une réponse à cette question, il convient tout d'abord d'analyser la réponse qui y a été apportée en matière de fusions transfrontalières, pour ensuite mettre celle-ci en perspective avec les spécificités d'une scission transfrontalière.

945. Le régime applicable aux fusions transfrontalières. Le régime de protection des porteurs de titres, autres que des actions, applicable en matière de fusions transfrontalières a été clarifié par la Cour de justice dans l'arrêt *KA Finanz*[5149]. Ce dernier portait notamment sur l'interprétation, en droit autrichien, du § 226 (3) öAktG qui transpose l'art. 101 de la Directive Sociétés. Cette disposition légale était en effet interprétée par la majorité de la doctrine comme permettant à la société absorbée de choisir librement entre (i) conférer des droits aux moins équivalents aux porteurs de titres autres que des actions, (ii) compenser une éventuelle réduction des droits par un paiement ou encore (iii) procéder au rachat des titres en question[5150]. Cette position ressortait en outre explicitement des travaux préparatoires[5151], mais avait

5145 Arrêt *KA Finanz*, pt. 72.
5146 Art. 135, § 1er de la Directive Sociétés qui renvoie à l'annexe I.
5147 Art. 160*ter*, § 1er de la Directive Mobilité qui renvoie à l'annexe II.
5148 Art. 135, § 2 de la Directive Sociétés.
5149 Sur les faits à la base de cet arrêt, voir *supra* n° 730.
5150 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz bei « grenzüberschreitenden » Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 848 ; L. HÜBNER, *op. cit.*, p. 557 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 345, n° 31 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 494 et Th. TILQUIN, « L'arrêt KA Finanz AG : la fusion transfrontalière et la protection des créanciers », *op. cit.*, p. 69.
5151 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 332.

fait l'objet de certaines critiques dans la mesure où elle permettait à une société-émettrice de se prévaloir d'une fusion insignifiante pour procéder au rachat des titres[5152]. Cependant, la Cour de justice, après avoir clarifié que les dispositions protectrices applicables à une fusion nationale devaient également trouver à s'appliquer dans l'hypothèse d'une opération transfrontalière[5153], n'a laissé planer aucun doute sur le fait qu'une telle interprétation n'était pas conforme à l'article 15 de la Troisième Directive (actuel article 101 de la Directive Sociétés) qui ne confère aucun droit à l'émettrice[5154]. Il faut toutefois relever que la Cour de justice va trop loin en considérant que l'article 101 de la Directive Sociétés ne confère pas de droits à l'émettrice[5155]. En effet, celle-ci pourra convoquer une assemblée générale des porteurs de titres ou, si la loi nationale applicable ne prévoit pas une telle assemblée, elle pourra demander individuellement l'autorisation des différents porteurs de titres pour procéder à la modification de leurs droits respectifs. De plus, s'il s'avère impossible de conférer des droits au moins équivalents aux porteurs de titres en raison, par exemple, des spécificités de la législation nationale applicable à la société bénéficiaire, la société émettrice pourra exceptionnellement procéder au versement d'une compensation pécuniaire aux différents titulaires afin de ne pas devoir renoncer à une opération potentiellement essentielle à sa survie économique[5156]. A la lumière des enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *KA Finanz* et dans la mesure où les auteurs ayant plaidé en faveur d'une telle interprétation la justifient à la lumière du principe « *impossibilium nulla est obligatio* »[5157], un tel rachat devra néanmoins être réservé aux situations d'impasse.

946. L'incidence de la liberté d'établissement sur les scissions transfrontalières. Si on part du principe (i) que le fait pour un État membre d'imposer aux personnes morales impliquées dans une scission transfrontalière de fournir des droits équivalents constituerait en toute probabilité une entrave à la liberté d'établissement de la société scindée en ce qu'une telle mesure est de nature à la dissuader de faire usage de sa liberté d'établissement[5158], mais que (ii) la « *rule of reason* » permet de tolérer une telle entrave pour peu (a) qu'elle soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, comme la protection des intérêts des créanciers[5159], (b) qu'elle soit propre à réaliser cet objectif et (c) qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre[5160], on peut également se demander si le principe de proportionnalité ne serait pas

5152 Voir en ce sens : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 345, n° 30 qui plaide en faveur d'une limitation de cette faculté de rachat aux seules hypothèses où les porteurs de titres encourent un risque de dilution du fait de l'opération.

5153 Arrêt *KA Finanz*, pt. 60.

5154 Arrêt *KA Finanz*, pt. 70.

5155 *Ibidem*.

5156 Sur l'importance économique des scissions transfrontalières, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 2.

5157 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Gläubigerschutz bei « grenzüberschreitenden » Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 848.

5158 À cet égard, il est utile de rappeler que « toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de cette liberté » sont en principe prohibées. À ce sujet, voir *supra* n° 131.

5159 Arrêt *Centros*, pt. 39 ; arrêt *Überseering*, pt. 92 ; arrêt *Inspire Art*, pt. 132 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; et arrêt *Polbud*, pt. 52.

5160 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 71 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 67 et P. VAN CLEYNENBREUGEL, *op. cit.*, p. 267 et arrêt *Polbud*, pt. 52 ; arrêt *Sevic*, pt. 23 ; arrêt *Gebhard*, pt. 37 et arrêt *Kraus*, pt. 32.

mieux respecté s'il était permis à la société scindée de bénéficier d'une porte de sortie en procédant au rachat des titres litigieux.

§6. Une possible dérogation contractuelle ?

947. Une large marge de manœuvre. Si les contours du régime de protection des porteurs de titres autres que des actions sont à présent mieux définis, il convient encore de déterminer dans quelle mesure, il devrait être permis aux parties intéressées d'y déroger contractuellement. S'il est clair qu'une dérogation générale dans le projet commun de scission transfrontalière n'est pas acceptable[5161] dans la mesure où elle permettrait à la société scindée d'éluder trop facilement les dispositions protectrices, qu'en est-il en revanche d'une dérogation *ex ante* convenue contractuellement entre la société et le titulaire de titres autres que des actions ? À titre d'illustration, on pourrait songer aux conditions d'émission de *warrants*[5162] ou de *convertible preferred equity certificates*[5163] prévoyant qu'en cas de scission transfrontalière, la société émettrice pourra procéder au rachat de ceux-ci à un prix prédéterminé et à leur annulation subséquente par le biais du simple envoi d'une notification et du paiement du prix correspondant. En d'autres termes, on peut se demander si la disposition de la Directive Sociétés est une disposition d'ordre public[5164], une disposition impérative[5165] ou une disposition purement supplétive n'ayant vocation à s'appliquer qu'en l'absence de dispositions contractuelles contraires[5166]. En nuançant encore davantage, on peut également se demander si la disposition en question ne relèverait pas de l'ordre public sociétaire[5167] ou encore de

5161 Voir en ce sens : S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 3 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER, *op. cit.*, § 23, n° 9.

5162 Par « *warrant* », on entend des « obligations avec droit de souscription d'actions ». À ce sujet, voir L. DABIN, « Régime juridique des marchés financiers et des valeurs mobilières », *Rép. not.*, Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 11, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 104.

5163 Par « *convertible preferred equity certificates* » on vise, en droit luxembourgeois, des instruments émis à l'initiative de l'assemblée générale ou de l'organe de gestion dans les limites du capital autorisé portant un intérêt généralement calculé en fonction du revenu généré par un investissement spécifique financé partiellement par l'émission de ceux-ci moins une marge et qui, par rapport au « *preferred equity certificates* », présentent notamment la particularité d'être convertibles en actions sous certaines conditions spécifiques.

5164 Les dispositions d'ordre public « touchent aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité ou fixent dans le droit privé les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique et social de la société ». À ce sujet, voir V. SIMONART, « L'ordre public et le droit des sociétés » in J.-F. ROMAIN, *L'ordre public : concept et applications*, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 87 et P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, p. 317, n° 308 et Cass., 9 décembre 1948, *Pas.*, 1948, I., p. 699.

5165 Une disposition impérative est une disposition qui « a pour objet principal de protéger les intérêts particuliers d'une catégorie de personnes considérées comme faibles : elle s'impose aux parties nonobstant leur volonté contraire ». À ce sujet, voir : P. WÉRY, *Droit des obligations*, vol. 1, *op. cit.*, pp. 322 et 323, n° 312. Voir également à ce sujet : V. SIMONART, *ibidem*, p. 87.

5166 Une disposition supplétive est une disposition qui ne trouve à s'appliquer que « dans le silence des parties ». À ce sujet, voir : V. SIMONART, *ibidem*, p. 87.

5167 Une disposition d' « *ordre public sociétaire* » se caractérise par le fait qu'elle « réglemente le fonctionnement de la société, intéresse la collectivité mouvante des associés, actionnaires et participants et met en cause l'intérêt collectif conçu comme l'intérêt de la société ». À ce sujet, voir : V. SIMONART, *ibidem*, pp. 122 et 123.

l'ordre public économique[5168]. Si elle n'est certes pas d'ordre public classique en ce que les intérêts qu'elle protège sont d'ordre privé et qu'elle ne relève pas davantage de l'ordre public économique en ce que les titulaires de titres autres que des actions ne peuvent être considérés comme tiers à la société, on peut se demander si, en protégeant les intérêts de la collectivité des associés, elle ne relèverait pas de l'ordre public sociétaire ou s'il ne conviendrait pas de lui conférer un caractère impératif prohibant toute disposition contractuelle contraire *ex ante*. En effet, le texte de l'article 101 de la Directive Sociétés en matière de fusions internes et de l'article 147 de la Directive Sociétés en matière de scissions internes ne sont pas limpides sur le sujet et se bornent à poser un principe d'équivalence[5169], tout en précisant toutefois qu'une dérogation à ce principe n'est possible que si (i) cette dernière a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, (ii) lorsque les porteurs de ces titres y ont consenti individuellement, ou encore (iii) lorsque ces porteurs ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres. S'il en découle certes qu'une renonciation individuelle sur la base des conditions de l'opération figurant dans le projet commun doit être possible, il n'est pas possible d'affirmer qu'une renonciation *ex ante* générale à ce droit doit nécessairement être admise[5170]. Afin de clarifier cette situation, il serait utile de modifier l'article en précisant que les États membres pourront déterminer que ce principe s'appliquera en l'absence de dispositions contractuelles contraires, de manière à permettre aux États membres de faire le choix politique soit de protéger davantage les titulaires de titres, soit de privilégier la flexibilité et les solutions conventionnelles.

§7. L'articulation avec les mécanismes généraux de protection des créanciers

948. Un régime dérogatoire. Le régime de protection spécifique des titulaires de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doit être compris comme une évolution du régime de protection général des créanciers destiné à tenir compte de la situation particulière de ces créanciers qui encourent, du fait de la scission, un risque allant au-delà du seul changement de débiteur[5171]. En d'autres termes, les deux régimes de protection entretiennent un rapport de loi spéciale à loi générale[5172] et n'ont pas vocation

[5168] Une disposition d' « *ordre public économique* » se caractérise par le fait qu'elle concerne « *tous les tiers qui traitent avec la société et met en cause l'intérêt social* ». À ce sujet, voir : V. SIMONART, *ibidem*, pp. 122 et 123.

[5169] Voir en ce sens : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 9.

[5170] Voir en faveur de la possibilité d'une telle renonciation générale dans les conditions des titres autres que des actions en droit allemand : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 23, n° 9. *Contra* : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 24 et S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 3.

[5171] Voir à ce sujet à propos de la relation entretenue par les §§ 22 et 23 UmwG : S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 1 et M. WINTER in J. SCHMITT, R. HORTNÄGL et R.-Chr. STRATZ (dir.), *op. cit.*, § 22, n°s 1–3.

[5172] Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 6 ; S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 23, n° 1 et S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 349, n° 41.

à s'appliquer cumulativement[5173]. Il en découle qu'un régime général de protection des créanciers applicable aux scissions transfrontalières n'aura pas vocation à protéger ces titulaires de droits spéciaux et qu'en présence d'un titulaire d'un instrument de dette, il conviendra tout d'abord d'analyser dans quelle mesure ce titulaire devrait bénéficier de la protection spécifique accordée en principe aux porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux. Ce n'est que s'il ne rentre pas dans le champ d'application de ce régime spécifique qu'il conviendra de protéger ses intérêts par le biais du mécanisme plus général de protection des intérêts des créanciers[5174]. Une telle interprétation est confortée par le texte même de la Directive Sociétés qui, en matière de scissions internes, contrairement à ce qui est le cas pour les obligataires[5175], n'ouvre pas la possibilité de demander des garanties adéquates aux porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux[5176].

§8. Conclusion sur l'articulation avec la protection des titulaires de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux

949. Une exclusion du régime général de protection des créanciers. L'examen des risques encourus par les titulaires de titres, autres que des actions auxquels sont attachés des droits spéciaux et la spécificité de ces derniers nécessitent un mécanisme particulier de protection tenant pleinement compte du fait que cette catégorie spécifique de *stakeholders* se rapproche davantage des associés sans avoir nécessairement la possibilité de se prononcer sur l'opération. L'analyse de la manière dont ces difficultés ont été traitées par le législateur européen ainsi que la détermination du niveau de flexibilité dont jouissent les parties concernées permettent d'établir que le régime de protection des porteurs de titres autres que des actions revêt un caractère autonome. Ce régime doit donc être indépendant du régime général de protection des créanciers en cas de scission transfrontalière. Il s'ensuit que la notion de « créancier » utilisée dans le cadre d'un régime des scissions transfrontalières devra être exclusive des porteurs de titres bénéficiant déjà d'une protection spécifique. Cette relation particulière mériterait toutefois d'être clarifiée.

5173 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122j, n° 23 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 344, n° 27 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 313 et G. SEULEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 6. Voir toutefois également : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 122j, n° 6 qui considère à l'égard des fusions internes que la protection par le biais de l'octroi de garanties adéquates doit trouver à s'appliquer si le mécanisme de protection spécifique des porteurs de titres s'avère insuffisant.

5174 Voir en ce sens en droit autrichien : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 344, n° 28.

5175 Art. 146, § 5 de la Directive Sociétés.

5176 Art. 147 de la Directive Sociétés.

SECTION 6. L'HARMONISATION AU NIVEAU EUROPÉEN

§ 1. Présentation

950. Suite de l'analyse. À présent que les principaux contours de la protection générale des créanciers en cas de scission transfrontalière ont été déterminés, il convient de s'intéresser à la question de la nature que devrait revêtir une intervention du législateur européen en la matière pour atteindre un niveau de protection et de sécurité juridique satisfaisant. S'il est clair que le Parlement européen et le Conseil disposent de la compétence pour adopter une directive en vue, notamment, de coordonner « dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers »[5177], étant entendu que cette notion de tiers recouvre également les créanciers[5178], il reste à déterminer l'étendue de cette harmonisation. Pour ce faire, il est tout d'abord nécessaire de se pencher sur les choix qui ont été faits par le législateur européen en la matière par le passé (§ 2), pour ensuite s'intéresser à la nécessité d'instaurer un régime uniforme pour les scissions internes et les scissions transfrontalières (§ 3) et finir par étudier les avantages et inconvénients des différents types d'harmonisation envisageables (§ 4).

§ 2. Les choix du législateur européen

951. Plan du § 2. Pour pouvoir apprécier à leur juste valeur les choix faits par le législateur européen en matière d'harmonisation de la protection des créanciers, il importe de procéder en trois étapes. En partant des choix faits dans la Directive Sociétés (A) et en analysant les réactions à ces choix dans les consultations publiques (B), il sera possible de tirer certaines conclusions sur les options retenues par le législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité (C).

A. *Le régime de la Directive Sociétés*

952. Un régime peu intrusif. Les règles relatives à la protection des créanciers présentes dans la Directive Sociétés que ce soit en matière de fusions internes[5179] ou de scissions internes[5180] ont l'originalité d'imposer aux États membres de mettre en place « un système adéquat de protection des intérêts des créanciers ». Cette formulation *a priori* surprenante a l'avantage d'une part d'empêcher un « *race to the bottom* »[5181] tout en permettant aux États

5177 Art. 50, § 2, g) du TFUE.
5178 Voir en ce sens : Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 536.
5179 Art. 99, § 1er de la Directive Sociétés.
5180 Art. 146, § 1er de la Directive Sociétés.
5181 Sur cette notion, voir *supra* n° 137.

membres de s'adapter aux spécificités de leur droit des sociétés national[5182] et d'être plus conforme au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3 du TFUE[5183]. En revanche, en laissant une marge de manœuvre aussi importante aux États membres, cette option retenue de la part du législateur européen a engendré des mécanismes de protection des créanciers disparates et parfois contradictoires au sein des États membres[5184]. Si dans un contexte purement interne, il n'en résulte pas de difficultés particulières, il en va autrement dans un contexte international. Ce point n'avait d'ailleurs pas échappé au législateur européen qui dès la proposition de dixième directive de 1985 avait estimé que les fusions transfrontalières requerraient « une harmonisation plus poussée par rapport à celle atteinte pour la fusion interne » en matière de protection des créanciers[5185]. En effet, l'exemple des fusions transfrontalières démontre à suffisance que ces différences entre États membres ont pour conséquences d'allonger les procédures et d'en augmenter sensiblement le coût[5186]. À tel point que cette absence d'harmonisation est considérée comme une des lacunes les plus importantes du régime actuel des fusions transfrontalières[5187] et a été mise clairement en lumière par l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale à ce sujet[5188] ainsi que par de nombreux auteurs[5189]. Ces insuffisances ont même poussé à plaider contre une application par analogie du régime de protection des créanciers reconnu en matière de fusions transfrontalières aux scissions transfrontalières[5190].

B. *Le résultat des consultations publiques de 2015 et 2017*

953. Le verdict des consultations publiques. Lors de la première consultation publique réalisée par la Commission en 2015, la sous-harmonisation des règles relatives à la protection des créanciers a été identifiée comme un des principaux inconvénients du régime des fusions transfrontalières et près de 80 % des personnes ayant exprimé un avis sur la question se sont prononcées en faveur

5182 M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 59.
5183 M. WINNER, *ibidem*, p. 59.
5184 Voir en ce sens : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 10 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 310 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 37 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 535 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18 et M. WINNER, *ibidem*, p. 65.
5185 Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, COM (84) 727 final, 23 janvier 1985, p. 7.
5186 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 10.
5187 Étude d'impact, p. 68.
5188 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 52–60 ; G. RAAIJMAKERS et Th. OLTHOFF, *op. cit.*, p. 39 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, pp. 238 et 239.
5189 Voir en ce sens : T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, pp. 1166 et 1167 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 536 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 310 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 65.
5190 Voir en ce sens : R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 428.

d'une harmonisation des mécanismes de protection des créanciers[5191]. De plus, 70 % de ces personnes s'étant prononcées en faveur de l'harmonisation et ayant exprimé un avis quant aux modalités d'une telle harmonisation ont exprimé une préférence pour une harmonisation complète par rapport à un choix entre deux options et un libre choix des États membres[5192]. Cette tendance s'est confirmée lors de la consultation publique de 2017 au cours de laquelle 80 % des autorités nationales ayant fourni une réponse se sont prononcées en faveur d'une harmonisation des mesures de protection des créanciers[5193], ainsi que dans la résolution du Parlement européen du 13 juin 2017[5194]. Cette réaction découle nécessairement de la coexistence d'une multitude de régimes de protection nationaux qui est source d'insécurité juridique et de coûts pour les créanciers désireux de protéger leurs droits[5195].

C. *Le régime de la Directive Mobilité*

954. Une harmonisation minimale combinée à une incitation. Alors qu'il ressort clairement du texte même de la Proposition de la Commission[5196], du Premier Compromis de la Présidence[5197], de la Proposition du Parlement[5198] et de la Directive Mobilité[5199] qu'à l'égard de la protection des associés minoritaires, le législateur européen a opté pour une harmonisation minimale et que les États membres demeurent libres d'introduire des mécanismes de protection additionnels, la situation est moins claire à l'égard des créanciers[5200]. En effet, alors que tant la Directive Mobilité[5201] que l'exposé des motifs de la Proposition de la Commission[5202] mentionnent explicitement le fait que l'absence de cadre harmonisé génère une protection suboptimale des créanciers, ce qui aurait pu servir de prélude à une harmonisation avancée de la matière, il ressort de l'exposé des motifs que le législateur européen a opté pour l'introduction de certaines règles harmonisées tout en permettant aux États membres d'imposer certaines garanties supplémentaires en ce que cette solution offre « le meilleur équilibre entre la réduction des coûts, un niveau élevé de protection et la flexibilité pour les États membres »[5203]. Cette position se reflète également

5191 Étude d'impact, p. 20 et Consultation publique de 2015, pp. 5–7. Voir à ce sujet : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 65.
5192 Consultation publique de 2015, p. 7.
5193 Étude d'impact, p. 20 et Consultation publique de 2017, p. 7.
5194 Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pts. 10 et 18.
5195 J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 310 ; M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 47 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 65.
5196 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 21.
5197 20e considérant du Premier Compromis de la Présidence.
5198 45e considérant de la Proposition du Parlement.
5199 17e considérant de la Directive Mobilité.
5200 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 47.
5201 5e considérant de la Directive Mobilité.
5202 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, pp. 21 et 22.
5203 *Ibidem*.

dans la Directive Mobilité[5204]. D'un point de vue purement pragmatique, cette approche restrictive et plus vague a vraisemblablement permis d'emporter plus facilement l'adhésion des États membres au niveau du Conseil[5205] et tient compte de la réalité de la politique européenne en partant du principe que cette solution imparfaite prévaut sur un « *no deal* »[5206], mais elle a peu de chances de supprimer les difficultés liées à la coexistence de différents régimes de protection au sein de l'Union européenne[5207]. Par ailleurs, si telle est effectivement l'option retenue par la Commission, on peut s'étonner du fait que la Proposition de la Commission prévoit comme mécanisme de protection facultatif la possibilité pour les États membres d'exiger une déclaration de la part de l'organe de gestion sur la situation financière de la société scindée[5208], le cas échéant assortie de sanctions pénales[5209]. La seule explication possible est qu'il faut y voir une incitation aux États membres d'introduire un tel système de protection[5210], même si compte tenu de l'influence que ne manqueront pas d'exercer les acteurs économiques, à commencer par l'industrie du *private equity*[5211] et les administrateurs indépendants professionnalisés[5212], on peut émettre certains doutes sur l'efficacité d'une telle incitation[5213].

§ 3. La nécessité d'une harmonisation des scissions transfrontalières et des scissions internes

955. Une approche nouvelle, mais insuffisante. Contrairement à la Directive Sociétés en matière de fusions transfrontalières qui avait opéré un renvoi au régime applicable en cas d'opération interne[5214], la Directive Mobilité intègre certaines dispositions spécifiquement destinées à harmoniser la protection des créanciers en cas de scission transfrontalière[5215], de fusion transfrontalière[5216] et de transformation transfrontalière[5217]. Ce choix est surprenant, d'autant plus que le régime ainsi mis en place à l'égard des scissions transfrontalières diffère de celui applicable en cas de cas de scissions internes en vertu de la Directive

5204 24e considérant, 1re phrase de la Directive Mobilité qui précise qu' « [i]l convient que les États membres garantissent une protection adéquate des créanciers qui ont noué une relation avec la société avant que celle-ci n'ait rendu publique son intention de procéder à une opération transfrontalière ».

5205 Voir en ce sens : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 66 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 48.

5206 Selon les termes de M. WINNER, « *an imperfect deal in this context seems to be better than no deal at all* ». Voir M. WINNER, « Protection of creditors… », *ibidem*, p. 48.

5207 Voir en ce sens : M. WINNER, *ibidem*, p. 57.

5208 25e considérant et art. 160*undecies*, § 3 de la Directive Mobilité et au sujet de ce mécanisme particulier de protection, voir *supra* nos 759 à 766. Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 206.

5209 Voir en ce sens : M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 69.

5210 Voir en ce sens : M. WINNER, *ibidem*, p. 66.

5211 Au sujet de l'influence des praticiens actifs dans l'industrie du private equity sur le législateur luxembourgeois, voir : I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 18 et I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *op. cit.*, pp. 418 et 419.

5212 À ce sujet, voir *supra* n° 763.

5213 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 54.

5214 Art. 121, § 1er, b) de la Directive Sociétés.

5215 Art. 160*undecies* de la Directive Mobilité.

5216 Art. 126*ter* de la Directive Mobilité.

5217 Art. 86*undecies* de la Directive Mobilité.

Sociétés[5218]. À titre d'illustration, on peut citer le choix fait par le législateur européen d'opter pour un régime de protection *ex ante* sans effet suspensif dans la Directive Mobilité alors que la question avait été laissée à la libre appréciation des États membres dans la Directive Sociétés[5219] ou encore la limite de la solidarité des sociétés bénéficiaires de l'opération à l'actif net transféré qui est passée de facultative dans un contexte interne[5220] à obligatoire dans un contexte transfrontalier[5221]. Ce choix législatif suscite des interrogations sous deux angles distincts. Tout d'abord, il a été établi que le principe de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes reconnu par la Cour de justice à l'égard des fusions transfrontalières s'appliquait également aux scissions transfrontalières[5222] et que le caractère transfrontalier de l'opération ne justifiait pas la mise en place d'une mesure de protection renforcée des créanciers[5223]. En conséquence, un régime national qui imposerait une déclaration de solvabilité en cas de scission transfrontalière en suivant en cela la suggestion du législateur européen dans la Directive Mobilité[5224], mais n'en imposerait pas dans un contexte interne respecterait certes le prescrit de la Directive Mobilité, mais violerait le principe de non-discrimination entraînant potentiellement les foudres de la Cour de justice en raison de l'entrave à la liberté d'établissement qui en découlerait. Ensuite, le champ d'application foncièrement limité de la Directive Mobilité qui n'a pas vocation à s'appliquer aux opérations impliquant au moins une société bénéficiaire préexistante[5225] risque d'aboutir à une différence de traitement difficilement justifiable entre les scissions transfrontalières impliquant au moins une société bénéficiaire préexistante et celles n'en impliquant pas. En effet, les premières se verront appliquer le régime des scissions internes par application des règles de droit international privé, alors que les secondes seront soumises au régime spécifique prévu par la Directive Sociétés.

956. Une indispensable harmonisation des scissions internes. Il découle de ce qui précède que le choix opéré par le législateur européen dans la Directive Mobilité n'est pas le plus judicieux. Si une harmonisation de la protection des créanciers était certes indispensable[5226], elle aurait dû passer par (i) une réforme du droit des scissions internes en renforçant le degré d'harmonisation[5227] et (ii) une règle de droit international privé renvoyant aux différents droits nationaux

5218 Art. 147 de la Directive Sociétés.
5219 Art. 146, § 1er de la Directive Mobilité.
5220 Art. 146, § 3, al. 2 de la Directive Mobilité.
5221 Art. 160*undecies*, § 2, 2e phrase de la Directive Mobilité.
5222 Sur ce point, voir *supra* n° 153.
5223 Sur ce point, voir *supra* nos 716 à 734.
5224 Art. 160*undecies*, § 3 de la Directive Mobilité.
5225 8e considérant et art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité. Sur cette insuffisance, voir *supra* nos 341 à 346.
5226 Voir en ce sens à propos du régime des fusions transfrontalières : T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, pp. 1166 et 1167 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 536 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 310 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 65.
5227 Voir en ce sens également : R. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 428 et 429 qui plaidait en faveur d'une harmonisation de la protection des créanciers dans la Sixième Directive.

pour ce qui est de la protection des créanciers pour tous types de scissions et inspirée de celle du régime des fusions transfrontalières[5228].

§4. Le type d'harmonisation à privilégier

957. Plan du § 4. Afin de pouvoir tirer certaines conclusions sur le type d'harmonisation à privilégier dans le cadre spécifique de la protection des créanciers en cas de scission transfrontalière, il convient d'étudier tour à tour les quatre méthodes d'harmonisation envisageables, à savoir l'harmonisation complète (A), le choix fermé entre plusieurs options (B), le libre choix entre plusieurs options (C) et l'harmonisation a minima (D).

A. *L'harmonisation complète*

958. Une nécessité dictée par la nature d'une scission. Compte tenu du fait qu'une scission transfrontalière présente le risque de mettre en concurrence au moins deux ordres juridiques distincts, et potentiellement bien d'avantage, il est préférable d'éviter autant que possible des divergences entre les mécanismes de protection des créanciers, sous peine de risquer soit de voir des sociétés réaliser une telle opération dans le seul but d'éroder les droits de leurs créanciers[5229], soit, au contraire, de restreindre excessivement la mobilité transfrontalière des personnes morales au sein de l'Union européenne en imposant des coûts excessifs aux entreprises. En d'autres termes, l'objectif de neutralité de l'opération sur la situation des créanciers et des sociétés impliquées dicte de ne pas laisser la question de la protection des intérêts des créanciers à la libre appréciation des États membres. Face à ce constat, la solution la plus évidente serait de procéder à une harmonisation complète de la protection des créanciers pour les opérations transfrontalières[5230]. Cette option est vraisemblablement la plus avantageuse en termes de sécurité juridique et de réduction des coûts liés à une scission transfrontalière[5231]. En outre, elle permettrait d'offrir un niveau de protection des créanciers élevé indépendamment des préférences politiques de chaque État membre, tout en veillant à ne pas entraver de manière disproportionnée la liberté d'établissement des personnes morales concernées.

959. Un nombre important d'inconvénients. Si l'harmonisation complète présente indéniablement un nombre important d'avantages, elle n'est pas nécessairement réalisable en raison des différences fondamentales existant entre les différents systèmes juridiques au sein de l'Union européenne[5232]. En outre, elle méconnaît le fait que le choix d'introduire des mécanismes plus ou moins protecteurs des créanciers dépend également des choix politiques opérés au

[5228] Art. 121, § 1er, b) et § 2 de la Directive Sociétés.
[5229] J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 30.
[5230] Voir en faveur d'une telle harmonisation complète : R. ROELOFS, *op. cit.*, p. 577, n° 25.
[5231] Voir en ce sens : Étude d'impact, p. 70 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 10.
[5232] Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 10.

sein des différents États membres[5233], de sorte qu'un régime sur la base du « *one size fits all* » pourrait ne convenir ni aux États membres souhaitant privilégier les intérêts des créanciers, ni aux États membres souhaitant, au contraire, avantager les entreprises. Au-delà de ces premières considérations, on est également en droit de s'interroger sur la conformité d'une telle approche avec le principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3 du TFUE. En dernier lieu, si une harmonisation complète semble *a priori* attrayante du point de vue de la sécurité juridique, ce point de vue doit être relativisé au vu du fait que la protection des créanciers en cas d'opération transfrontalière ne relève pas du seul droit des sociétés mais se situe à l'intersection entre le droit des sociétés, le droit de l'insolvabilité, le droit comptable, mais également le droit administratif et le droit pénal[5234] de sorte que, compte tenu du fait que ces différents droits ne sont pas harmonisés au niveau européen, la simplicité qui découlerait d'une harmonisation complète au niveau européen ne se révélerait rapidement n'être qu'une apparence trompeuse[5235]. Quoi qu'il en soit, compte tenu du fait que les différents États membres sont généralement jaloux de leur indépendance législative, il est fort peu probable qu'une harmonisation intégrale de la protection des créanciers en cas de scission transfrontalière soit acceptée au niveau du Conseil européen[5236].

B. *Le choix fermé entre plusieurs options*

960. Les enseignements des fusions transfrontalières. Suite au constat que les différences entre les systèmes de protection des créanciers dépendaient principalement du choix opéré par les États membres entre (i) un régime plus protecteur afin de privilégier les intérêts des créanciers et (ii) un régime moins protecteur en vue, au contraire, d'avantager les sociétés, mais qu'au sein de ces deux catégories, les différences étaient plus limitées[5237], la solution recommandée suite à l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale à l'égard des fusions transfrontalières, désignée comme la « *fixed menu approach* »[5238] ou encore la « *two-option approach* »[5239], consiste à permettre aux États membres de choisir entre deux solutions harmonisées leur permettant de privilégier, au choix, l'une ou l'autre catégorie de *stakeholders* tout en évitant les coûts et les incertitudes liés à la coexistence d'une multitude de régimes distincts[5240]. Elle présente en outre l'avantage d'être plus conforme au principe de subsidiarité[5241] et d'être, par conséquent, plus facilement acceptable d'un point de vue politique qu'une harmonisation complète.

5233 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 12.
5234 P. MÜLBERT, *op. cit.*, pp. 7 et 8 et M. SIEMS, L. HERZOG et Er. ROSENHAGER, *op. cit.*, pp. 151 et 152. Voir en ce sens également : C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, pp. 5 et 6.
5235 Sur l' « interdépendance fonctionnelle » des mécanismes de protection des créanciers, voir *supra* n°s 913 à 916.
5236 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 48.
5237 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 12.
5238 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 10.
5239 Consultation publique de 2015, p. 5.
5240 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 12.
5241 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 59.

961. Une option à abandonner. Malgré ses avantages, cette solution n'est toutefois pas satisfaisante et c'est sans grande surprise qu'elle a été de loin moins populaire que l'harmonisation complète lors de la consultation de 2015[5242]. Elle n'a de plus pas été considérée par la Commissions lors des travaux sur la récente Directive Mobilité[5243]. La raison en est très simple : l' « *interdépendance fonctionnelle* » existant entre différentes branches du droit à l'égard de la protection des créanciers ne se laisse pas résumer à deux options distinctes en fonction de la partie à privilégier. En outre, on peut émettre certains doutes sur l'acceptabilité politique d'un tel mécanisme.

C. *Le libre choix entre plusieurs options*

962. Une flexibilité encadrée. Également envisagée dans le cadre de l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale à l'égard des fusions transfrontalières, l' « *open menu approach* » consiste à proposer un certain nombre de mécanismes de protection que les États membres pourront choisir à leur guise, tout en leur permettant de panacher entre ceux-ci[5244]. Cette solution présente le double avantage d'être à la fois très peu intrusive dans la mesure où elle laisse une grande marge d'appréciation aux États membres, tout en limitant les coûts liés aux divergences entre régimes de protection existants entre États membres en restreignant les options des États membres[5245].

963. Une option à rejeter. Compte tenu des insuffisances du régime actuel des fusions transfrontalières[5246], la solution consistant à proposer un nombre limité d'options aux États membres manque à nouveau de flexibilité en ne permettant d'adapter les règles de protection des créanciers relevant du droit des sociétés que de manière limitée aux spécificités nationales tout en engendrant toujours une multitude de régimes différents. En outre, la rédaction de plusieurs options potentiellement cumulables, mais tenant suffisamment compte des spécificités nationales du système général de protection des créanciers dans lequel ces dernières s'inscrivent s'avérerait être une tâche particulièrement délicate. C'est donc sans grande surprise qu'elle n'a pas été examinée lors de la rédaction de la Proposition de la Commission[5247] et qu'elle a été la moins populaire lors de la consultation de 2015[5248].

5242 Seuls 17 % des personnes ayant exprimé un avis sur la forme que devait revêtir l'harmonisation se sont prononcées en faveur de la « *two option approach* » contre 80 % pour l'harmonisation complète. Voir Consultation publique de 2015, p. 6.

5243 Étude d'impact, pp. 68–72.

5244 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 10 et Consultation publique de 2015, p. 5.

5245 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 60.

5246 Voir en ce sens : T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, pp. 1166 et 1167 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 536 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 310 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 239 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 18 et M. WINNER, « Creditor protection… », *op. cit.*, p. 65.

5247 Étude d'impact, pp. 68–72.

5248 Seuls 13 % des personnes s'étant prononcées sur la forme que devait revêtir une éventuelle harmonisation se sont prononcées en faveur de cette méthode. Voir : Consultation publique de 2015, p. 6.

D. *L'harmonisation* a minima

964. Une flexibilité accrue. La dernière solution, qui est celle adoptée par le législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité[5249] et une des plus populaires lors de la consultation de 2017[5250], consiste à imposer aux États membres d'introduire un mécanisme identique offrant un niveau de protection minimum, ce qui, tout en laissant une large marge d'appréciation aux États membres, permet d'éviter une « *race to the bottom* »[5251] en matière de protection des créanciers.

965. Avantages et inconvénients. Par rapport à l'harmonisation complète, cette possibilité laissée aux États membres de jouir d'une certaine flexibilité est moins avantageuse en termes de coûts dans la mesure où l'impact des mesures de protection sur le coût de l'opération variera en fonction des régimes additionnels imposés par les différents États membres[5252]. Cependant, en termes d'effectivité, cette solution est préférable dans la mesure où elle impose un niveau de protection minimal identique au sein de l'Union européenne avec la possibilité d'un éventuel renforcement en fonction des spécificités nationales[5253]. En effet, l'Étude d'impact a mis en lumière non seulement l'importance de la question de la protection des créanciers pour les différents États membres, mais également le fait que celle-ci était susceptible de s'inscrire dans une stratégie plus vaste dépassant de loin le seul cadre du droit des sociétés et, *a fortiori*, celui de la mobilité transfrontalière[5254]. Ce constat impose, selon la Commission, de laisser une certaine flexibilité pour les États membres de compléter le régime existant par des mesures nationales propres[5255]. En outre, cette solution, bien que potentiellement plus onéreuse pour les sociétés impliquées en raison des mesures de protection plus intrusives susceptibles d'être adoptées par les États membres, présente l'indéniable avantage d'être plus facilement acceptable politiquement[5256]. Il convient en outre de préciser que l'inconvénient lié au risque d'émergence d'une multitude de régimes distincts de protection des créanciers doit être relativisé par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement[5257]. En effet, toute mesure de protection des créanciers introduite par un État membre devra nécessairement remplir les conditions du « *Gebhard test* »[5258], à savoir (i) s'appliquer de manière non-discriminatoire, (ii) être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, ce qui sera nécessairement le cas puisque la protection des créanciers a été reconnue comme telle par la Cour de justice[5259], (iii) être adéquate et (iv) être

5249 Étude d'impact, p. 72 et à ce sujet, voir *supra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 6, § 4, D.
5250 Consultation publique de 2017, p. 9.
5251 Sur cette notion, voir *supra* n° 137.
5252 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 22 et Étude d'impact, p. 71.
5253 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 22 et Étude d'impact, p. 72.
5254 Étude d'impact, p. 69.
5255 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, p. 22 et Étude d'impact, p. 69.
5256 Étude d'impact, p. 72 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 48.
5257 Au sujet de l'incidence de la liberté d'établissement sur la protection des créanciers, voir *supra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 2, B.
5258 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.
5259 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 et arrêt *Überseering*, pt. 92.

proportionnée[5260]. Malgré cela, les États membres vont disposer d'une large marge d'appréciation[5261] avec peu d'indications sur ce qui est admissible ou non à l'aune de la liberté d'établissement.

§5. Conclusion sur l'harmonisation au niveau européen

966. Une harmonisation minimale combinée à des régimes facultatifs. S'il est indéniable qu'un certain degré d'harmonisation de la protection des créanciers en cas de scission transfrontalière est nécessaire pour, d'une part, renforcer la sécurité juridique d'une scission transfrontalière et, d'autre part, réduire les coûts liés à ce type d'opérations[5262], l'examen des différentes possibilités d'harmonisation réalisé ci-dessus fait clairement ressortir qu'aucune solution n'est exempte d'inconvénients. Une harmonisation complète est lourde, difficilement compatible avec les spécificités nationales et politiquement infaisable, la « *fixed menu approach* » est trop rigide, l' « *open menu approach* » se rapproche trop de la situation actuelle peu satisfaisante en termes de sécurité juridique et l'harmonisation minimale risque, d'une part, d'aboutir à l'adoption d'une multitude de régimes distincts et, d'autre part, d'engendrer un certain contentieux au niveau de la liberté d'établissement. Cependant, il est possible de tirer un plusieurs conclusions permettant d'aboutir à une solution qui, à terme, pourrait s'avérer satisfaisante sans devoir nécessairement plaider en faveur d'une utopique harmonisation exhaustive[5263]. En effet, il est clair qu'une certaine flexibilité pour les États membres est indispensable, tant pour faciliter l'adhésion politique à une initiative européenne visant à harmoniser le régime des scissions transfrontalières que pour tenir compte du fait que la protection des créanciers s'inscrit dans une stratégie globale transcendant le seul droit des sociétés et impliquant d'autres branches du droit encore faiblement harmonisées. Un tel procédé se rapproche très fort de celui adopté par le législateur européen dans la Directive Mobilité, à ceci près qu'il n'est pas utile de le combiner avec des régimes purement facultatifs comme celui du mécanisme de la déclaration de solvabilité par l'organe de gestion[5264] qui ne vont qu'encourager la diversité au sein des États membres. Par souci de sécurité juridique, il est préférable de s'en tenir à une harmonisation poussée d'un régime cohérent de protection des créanciers identique en cas de scission interne et de scission transfrontalière, tout en concédant aux États membres la possibilité de le compléter par des mesures spécifiques.

5260 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 47.
5261 Voir en ce sens : M. WINNER, *ibidem*, p. 47.
5262 Proposition de la Commission, Exposé des motifs, pp. 21 et 22.
5263 *Contra* : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 48 qui qualifie l'harmonisation complete de « *conceptually superior option* ». Voir également : R. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 427 à 429 en faveur d'une harmonisation exhaustive.
5264 À ce sujet, voir *supra* n°s 759 à 766.

SECTION 7. CONCLUSION SUR LES CONTOURS DE LA PROTECTION DES CRÉANCIERS DANS LES SCISSIONS TRANSFRONTALIÈRES

967. Les mécanismes de protection des créanciers. Le constat des insuffisances tant des mécanismes institutionnels que des mécanismes individuels de protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière implique que la protection de leurs intérêts requerra la mise en place d'une stratégie plus élaborée et axée sur une défense en profondeur, seule à même de tenir compte tant (i) des avantages et des limites des divers mécanismes de protection susceptibles de s'appliquer à une scission transfrontalière que (ii) de la nécessité de parvenir à une position d'équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des sociétés concernées. La première ligne de défense sera ainsi centrée sur les mécanismes contractuels susceptibles d'être adaptés à la situation spécifique de chaque créancier et combinés à la mise en place d'un mécanisme de protection institutionnel par le biais d'obligations d'information étendues. La deuxième ligne de défense fera intervenir les mécanismes de protection individuels comme, à titre d'illustration, la possibilité de demander des garanties adéquates ou l'action paulienne. La troisième ligne de défense, composée de mécanismes de protection institutionnels par définition plus intrusifs du point de vue de la liberté d'établissement, comme la solidarité passive des sociétés bénéficiaires pour les dettes de la société scindée n'entrera en jeu qu'en ultime recours.

968. Les aspects temporels de la protection. La comparaison des avantages d'un régime de protection *ex ante* par rapport à un régime de protection *ex post* à la suite de l'examen des divergences existant à cet égard dans le régime des scissions internes et le régime des fusions transfrontalières issu de la Directive Mobilité ont permis d'établir que le choix d'un régime de protection *ex ante* par le législateur européen dans la Directive Mobilité[5265] était judicieux. Dans un même ordre d'idées, le choix de porter la durée du délai imparti aux créanciers pour introduire leur demande de garantie adéquate d'un mois[5266] à trois mois[5267] va indéniablement dans le sens d'une meilleure efficacité du mécanisme de protection en question. En revanche, on ne peut que déplorer le fait que ces choix ne se soient pas accompagnés de l'interdiction aux États membres d'assortir la demande de garantie adéquate introduite par un créancier d'un effet suspensif[5268]. Cette option législative ne manquera pas d'engendrer de délicates questions au regard de la conformité du régime de protection des créanciers à la liberté d'établissement et gagnerait à être rectifiée au plus vite.

969. Une quatrième ligne de défense. La lutte contre le *forum shopping* et, par ricochet, le *law shopping* abusifs dépasse de loin le cadre des seules scissions transfrontalières et s'inscrit davantage dans un cadre général de protection des créanciers en matière d'insolvabilité internationale. Si la première conclusion

5265 Art. 86*undecies*, § 1er (transformations transfrontalières), 126*ter*, § 1er (fusions transfrontalières) et 160*undecies*, § 1er de la Directive Mobilité.
5266 Art. 160*quaterdecies*, § 2 de la Proposition de la Commission.
5267 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
5268 37e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité.

qu'on pourrait en tirer est qu'il serait indéniablement erroné d'observer les enjeux de la protection des créanciers en cas de mobilité transfrontalière des personnes morales par le seul prisme du droit des sociétés, il est possible d'en tirer d'autres précieux enseignements. Tout d'abord, en dépit de sa position actuelle particulièrement restrictive en matière d'entraves à la liberté d'établissement, il ressort de l'étude de l'arrêt *Kornhaas*, que la Cour de justice est plus tolérante à l'égard des mécanismes de protection des créanciers relevant du droit de l'insolvabilité. Pour autant, il serait erroné d'avancer que ce traitement *a priori* plus favorable justifierait que la protection des créanciers soit exclusivement organisée par le droit de l'insolvabilité, ne fût-ce qu'en raison d'une divergence d'objectifs entre les deux. En effet, l'objectif du droit de la mobilité transfrontalière tel qu'organisé par le droit des sociétés est de préserver un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux de la personne morale, alors que le droit de l'insolvabilité vise avant tout à protéger les intérêts des créanciers et à assurer leur traitement égalitaire. En revanche, comme les risques pour les créanciers sont plus importants en situation d'insolvabilité, il serait particulièrement intéressant de compléter le régime de protection équilibré et relevant du droit des sociétés par des mesures plus intrusives au regard de la liberté d'établissement, mais également plus protectrices à l'égard des créanciers. Cette position, qu'on retrouve dans l'incitation de la Directive Mobilité aux États membres d'instaurer un régime de responsabilité spécifique des membres de l'organe de direction ou d'administration en cas de déclaration de solvabilité inexacte ou incomplète, pourrait se traduire par un abandon de la limite de l'actif net à l'égard de la solidarité passive des sociétés bénéficiaires en cas d'insolvabilité suivant de très près la scission. L'étude de certains mécanismes de protection instaurés par le Règlement Insolvabilité, tels que le recours à une notion de COMI intégrant l'acquis jurisprudentiel en la matière, l'exclusion de la présomption simple de coïncidence entre le COMI et le siège statutaire en cas de restructuration tardive ou encore l'obligation pour la juridiction saisie de vérifier et de motiver sa compétence combinée à une possibilité de contestation par les tiers, constituent des mécanismes de protection efficaces des intérêts des créanciers. Compte tenu du fait que la lutte contre le « *forum shopping* » abusif dépasse de loin les questions de la seule mobilité transfrontalière des personnes morales et que le Règlement Insolvabilité bénéficie d'une, il est préférable que les mécanismes destinés à protéger les créanciers contre ce risque y figurent. Cependant, compte tenu du caractère général de ce dernier et de son incapacité à appréhender toutes les spécificités d'une scission transfrontalière, il devra nécessairement être complété par un régime spécial prenant en compte les risques atypiques engendrés par une telle opération pour les créanciers. *A contrario*, il est toutefois indispensable qu'un régime efficace des scissions transfrontalières tienne également compte de la situation spécifique d'une société soit approchant de l'insolvabilité, soit se trouvant déjà dans une situation d'insolvabilité. À cet égard, la solution retenue en droit allemand et en droit autrichien et qui consiste à exclure les créanciers disposant, en cas de procédure d'insolvabilité de leur société débitrice, d'un privilège découlant d'une disposition légale et couvert par une masse contrôlée par les autorités de la possibilité de demander des garanties additionnelles fait sens. Dans un même ordre d'idées, un régime européen des scissions

transfrontalières ne devrait en aucun exclure purement et simplement de son champ d'application les sociétés en proie à des procédures d'insolvabilité, même si certaines limites s'imposent à cet égard. On peut donc en conclure que le droit de l'insolvabilité et les mesures particulièrement protectrices des créanciers qui s'y trouvent devraient jouer le rôle d'une quatrième ligne de défense dans le cadre de la protection des créanciers en entraînant l'application de mesures davantage intrusives au regard de la liberté d'établissement et tirant pleinement part de la jurisprudence de l'arrêt *Kornhaas*.

970. La nécessité d'une certaine flexibilité. Dans la mesure où les risques engendrés pour les créanciers par une scission transfrontalière sont susceptibles de varier considérablement au gré des spécificités de l'opération en question, tant l'objectif de neutralité de l'opération que l'exigence de proportionnalité de l'entrave générée à la liberté d'établissement commandent qu'un régime de protection efficace des créanciers intègre un régime de base très protecteur combiné à certaines possibilités d'assouplissement en cas de risques moindres ou inexistants pour les créanciers, le cas échéant en réintégrant, moyennant modification, les deux présomptions qui figuraient à l'origine dans la Proposition de la Commission.

971. L'articulation avec la protection des titulaires de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux. Bien que les titulaires de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits économiques spéciaux relèvent de la catégorie très vaste de *stakeholders* que sont les créanciers, ils encourent un risque de dilution spécifique du fait d'une scission transfrontalière les rapprochant des associés. Cependant, contrairement à ces derniers, ils ne disposent *a priori* pas de la possibilité de se prononcer sur l'opération envisagée. Pour néanmoins protéger adéquatement les intérêts de ces porteurs de titres, le législateur européen recourt en priorité à l'exigence de prévoir des droits au moins équivalents pour ces derniers dans les sociétés bénéficiaires. Si le texte de la Directive Sociétés à l'égard des scissions internes fait preuve d'une certaine ambiguïté au niveau de l'identité de l'émettrice de ces droits au moins équivalents en laissant sous-entendre qu'ils devraient être émis par chacune des sociétés bénéficiaires, la Directive Mobilité ne fait rien pour clarifier la situation. Cette dernière se contente en effet d'un simple renvoi aux dispositions nationales avec les incertitudes additionnelles qui découlent du champ d'application limité des dispositions sur les scissions internes de la Directive Sociétés. Une ambiguïté additionnelle se retrouve à l'égard des mécanismes de protection de ces porteurs de titres dans la mesure où l'art. 147 de la Directive Sociétés semble mettre sur un pied d'égalité l'octroi de droits équivalents, l'approbation de la modification des droits par une assemblée des porteurs de titres et le rachat des titres. Cette dernière ambiguïté a néanmoins fait l'objet d'une clarification par la Cour de justice dans l'arrêt *KA Finanz* qui a considéré que la société émettrice ne bénéficiait pas d'une faculté de rachat. Cet enseignement doit toutefois être relativisé d'une part dans les situations d'impasse et d'autre part, dans les situations où il est impossible ou excessivement onéreux d'octroyer des droits au moins équivalents. Cette exception est également dictée par la nécessité de renforcer la proportionnalité de la mesure au regard de la liberté d'établissement. Une certaine flexibilité doit également

se retrouver à un niveau purement contractuel et il doit être permis aux parties concernées de déroger aux mécanismes de protection spécifiquement prévus par le législateur européen sans que l'octroi de droits au moins équivalents ne constitue un seuil en deçà duquel il ne serait pas possible d'aller. Il ressort de l'analyse des mécanismes de protection des titulaires de titres autres que des actions que ceux-ci font partie d'un régime de protection à part et dérogatoire par rapport au régime général de protection des créanciers. Cette relation particulière mériterait toutefois d'être clarifiée.

972. Le type d'harmonisation à privilégier. Malgré les insuffisances intrinsèques d'une harmonisation partielle, il s'avère qu'une certaine flexibilité est indispensable, tant pour faciliter l'adhésion politique des États membres que pour tenir compte du fait que la protection des créanciers s'inscrit dans une stratégie globale transcendant le seul droit des sociétés et impliquant d'autres branches du droit encore faiblement harmonisées. À l'égard de la protection des créanciers, il convient donc de s'en tenir à une harmonisation poussée d'un régime cohérent de protection des créanciers identique en cas de scission interne et de scission transfrontalière, tout en concédant aux États membres la possibilité de le compléter par des mesures spécifiques.

Conclusion sur la protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière

973. Le système de défense des créanciers. Catégorie foncièrement hétérogène de *stakeholders*, les créanciers d'une société impliquée dans une procédure de scission sont susceptibles d'encourir jusqu'à six risques distincts du fait de l'opération[5269]. Si la nécessité de les protéger contre ceux-ci ne fait aucun doute, tout l'enjeu sera d'élaborer une stratégie défensive parvenant à instituer un délicat équilibre entre les intérêts des créanciers à ne pas se voir spoliés et ceux de la société et de ses associés majoritaires à réaliser une opération potentiellement essentielle à la survie économique de l'entreprise, tout en respectant l'impératif de proportionnalité qui s'applique à toute entrave à la liberté d'établissement. De plus, si une protection renforcée ne s'impose pas en raison du seul caractère transfrontalier de l'opération, les créanciers de la société scindée nécessiteront une attention particulière en raison de leur position particulièrement exposée. Une stratégie en profondeur composée de quatre lignes de défense successives graduellement plus intrusives du point de vue de la liberté d'établissement[5270] s'avère être la meilleure solution à cet égard, étant entendu que les titulaires de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux nécessiteront une protection différente tenant mieux compte du risque de dilution qu'ils encourent. La première ligne de défense sera celle des mécanismes contractuels susceptibles d'être adaptés à la situation spécifique de chaque créancier et combinés à la mise en place d'un mécanisme de protection institutionnel par le biais d'obligations d'information étendues. La deuxième ligne de défense, qui sera également la ligne de résistance principale, sera celle du mécanisme de protection individuel que constitue la possibilité de demander des garanties adéquates combinée à des mécanismes plus généraux du droit des obligations tels que l'action paulienne ou la théorie de l'imprévision et ayant tous en commun de nécessiter un comportement actif de la part du créancier concerné pour être efficaces. Cette ligne de défense, qui interviendra *ex ante* pour une durée de trois mois à compter de la publication du projet commun tout en étant dénuée d'effet suspensif, devra nécessairement faire preuve d'une certaine élasticité par le biais de deux présomptions que l'opération ne lèse pas les créanciers en présence et ce, pour éviter le dommage collatéral que constituerait la prohibition d'une opération potentiellement mutuellement profitable ou inoffensive. La troisième ligne de défense sera celle de la solidarité passive des sociétés bénéficiaires pour les dettes de la société scindée limitée à l'actif net transféré qui constitue le mécanisme institutionnel par excellence permettant de surmonter l'obstacle de l'apathie rationnelle et seule capable de protéger efficacement les créanciers involontaires ou ceux ignorant encore l'existence de leur créance au moment de la réalisation de l'opération. L'ultime ligne de défense, qui n'entrera en jeu que si les trois premières lignes ont été percées, tirera pleinement parti de l'interdépendance fonctionnelle existant entre le droit des sociétés et le droit de l'insolvabilité et sera composée de mécanismes relevant du droit de l'insolvabilité. Cette dernière ligne de résistance sera caractérisée par une rupture de l'équilibre en faveur des créanciers ainsi que par un caractère particulièrement

[5269] Sur ces six risques, voir *supra* n[os] 696 à 704.

[5270] Pour un schéma illustrant le système de défense en profondeur des intérêts des créanciers articulé autour de quatre lignes de défense, voir Annexe 3.

intrusif du point de vue de la liberté d'établissement tirant pleinement parti de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt *Kornhaas*. Cette stratégie défensive ne devra toutefois pas faire l'objet d'une mise en place uniforme par le biais d'une harmonisation exhaustive mais requerra une certaine flexibilité pour s'adapter aux terrains forts différents que constituent les régimes généraux de protection des créanciers des États membres et tenir pleinement compte du fait que cette question transcende le seul droit des sociétés et implique d'autres branches du droit encore faiblement harmonisées. Une harmonisation avancée de la protection des créanciers identique en cas de scission interne et de scission transfrontalière combinée à la possibilité pour les États membres de la compléter par des mesures spécifiques semble dès lors être la solution idéale.

TITRE II
La protection des autres *stakeholders* dans le cadre d'une scission transfrontalière

SOMMAIRE

Introduction du titre II 815
Chapitre 1. Les enjeux de la protection des associés minoritaires 819
Chapitre 2. Les enjeux d'une scission transfrontalière pour la participation des travailleurs 915
Conclusion sur la protection des autres stakeholders dans le cadre d'une scission transfrontalière 951

Introduction du titre II

974. Plan du titre II. Si les créanciers des sociétés impliquées dans une scission transfrontalière sont tout particulièrement exposés, ils n'en constituent pas pour autant la seule catégorie de *stakeholders* encourant un risque du fait de cette opération. En effet, tant les associés minoritaires (chapitre 1) que les travailleurs (chapitre 2) pourraient voir leur situation foncièrement altérée.

Chapitre 1
Les enjeux de la protection des associés minoritaires

SECTION 1. PRÉSENTATION.

975. Une approche originale. Considérée majoritairement comme moins importante que la problématique de la protection des créanciers dans le cadre d'une opération transfrontalière lors des consultations publiques de 2017[5271] et de 2015[5272], la question de la protection des associés minoritaires dans le cadre d'une scission transfrontalière n'en revêt pas moins une importance certaine[5273]. Une étude des scissions transfrontalières se doit dès lors indiscutablement d'aborder cette question. Cependant, au lieu de réutiliser la grille d'analyse développée pour la question de la protection des intérêts des créanciers et de superposer les analyses répétitives des mêmes questions pour chaque catégorie de *stakeholder*, il est proposé d'aborder la protection des associés minoritaires de manière innovante en l'observant à travers deux prismes distincts. Le premier sera celui de la protection des créanciers et se justifie par le fait que les mécanismes de protection développés pour les autres *stakeholders* sont susceptibles d'impacter négativement la situation patrimoniale de la société impliquée dans l'opération de scission et, de ce fait, d'éroder davantage le gage commun des créanciers[5274]. Il peut certes être objecté qu'aborder cette question sous cet angle revient immanquablement à privilégier les créanciers par rapport aux associés minoritaires, mais cette objection peut être renversée en précisant que les risques auxquels sont exposés ces derniers feront l'objet d'une analyse détaillée et qu'il sera veillé à ce que tout aménagement de la protection des associés minoritaires dicté par la nécessité de sauvegarder efficacement les intérêts des créanciers offre malgré tout une ligne de défense suffisamment efficace contre les risques engendrés par une scission transfrontalière pour les associés minoritaires. Le deuxième sera celui de l'habileté politique du législateur européen[5275] et aura pour objectif de mettre en exergue les aspects de la Directive Mobilité dont l'insuffisance *ab initio* laisse apparaître en filigrane la nécessité d'une nouvelle initiative européenne en la matière.

976. Plan du chapitre. Pour parvenir à délimiter les contours d'un régime de protection des associés minoritaires dans le cadre des scissions transfrontalières, peu important qu'elles impliquent une ou plusieurs sociétés préexistantes (section 8), il est tout d'abord nécessaire d'identifier avec précision les enjeux que représente une telle opération pour cette catégorie de *stakeholders* (section 2) ainsi que l'incidence que la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement ne manquera pas d'avoir (section 3). Compte tenu du fait que la nature transfrontalière de l'opération aura nécessairement

5271 Étude d'impact, p. 75 et Consultation publique de 2017, p. 7. Voir en ce sens également : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 61.

5272 Lors de la consultation publique de 2015, 59 % des personnes s'étant prononcées sur le sujet ont considéré que la protection des actionnaires minoritaires était un des principaux obstacles aux scissions transfrontalières contre 68 % pour la protection des créanciers. Voir : Consultation publique de 2015, p. 23.

5273 18e considérant de la Directive Mobilité ; Étude d'impact, p. 22 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 31 ; Fr. SCHURR, *op. cit.*, p. 543 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, pp. 61 et 62.

5274 Sur ce risque, voir *supra* n° 701.

5275 À ce sujet, voir *supra* n° 404.

un impact sur la situation des associés minoritaires, il conviendra également de répondre à la question de savoir si ce caractère transfrontalier justifie la mise en place d'un régime de protection renforcé (section 4). Il sera ensuite possible de parcourir en détail les différents mécanismes de protection envisageables et de mettre en évidence leurs principaux avantages ainsi que leurs limites intrinsèques (section 5). Une fois cet exercice accompli, il sera opportun, toujours dans l'optique d'une éventuelle révision de la Directive Mobilité, d'analyser dans quelle mesure l'approche restrictive et résolument a minima du législateur européen est suffisante (section 6) et d'analyser en détail les enjeux posés par les aspects temporels de la protection des associés minoritaires (section 7).

SECTION 2. LES ENJEUX D'UNE SCISSION TRANSFRONTALIÈRE POUR LES ASSOCIÉS MINORITAIRES

977. Plan de la section 2. Afin d'aborder précisément les enjeux que pose une scission transfrontalière pour les associés minoritaires, il convient tout d'abord d'identifier les risques que pose une telle opération pour leurs intérêts (§ 1), pour ensuite se pencher sur le double équilibre que tout mécanisme de protection devra remplir (§ 2).

§1. Une opération potentiellement au détriment des associés minoritaires

978. Une multitude de risques. « Je n'ai pas livré l'homme d'un sicle à la merci de l'homme d'une mine »[5276]. Par cette phrase tirée du Code du roi sumérien Ur-Namma âgé de plus de quatre millénaires[5277], il est possible de résumer tout l'enjeu de la protection des associés minoritaires dans le cadre d'une scission transfrontalière. En effet, si par rapport aux créanciers, les associés minoritaires disposent de la possibilité de se prononcer sur l'opération, ils n'en sont pas moins à la merci des majoritaires susceptibles de décider de procéder à une scission transfrontalière à des conditions potentiellement défavorables pour les minoritaires. Si cet argument semble logique, la nécessité de protéger les associés minoritaires n'en est pas pour autant évidente. Il a ainsi été avancé à l'égard des fusions transfrontalières que la question de leur protection était davantage liée à une tendance actuelle à protéger cette catégorie de *stakeholders* et ne répondait pas à un réel besoin en la matière[5278]. L'enjeu de cette question n'est toutefois pas neutre car s'il devait s'avérer que les associés minoritaires encourent des risques significatifs en cas de scission transfrontalière, l'absence de protection adéquate risque d'impacter la capacité des

[5276] Une mine sumérienne, d'un poids d'environ 500 gr, se divisait en 60 sicles. À ce sujet, voir : N. T. BELAIEW, « Au sujet de la valeur probable de la mine sumérienne », *Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale*, 1929, vol. 26, n° 3, pp. 115–132.

[5277] S. DÉMARE-LAFONT, « Les inégalités sociales en Mésopotamie : quelques précautions de vocabulaire », *Droit et cultures*, 69/2015-1, https://journals.openedition.org (28/03/2019) p. 3, n° 4.

[5278] Voir à ce sujet : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 70. Voir en ce sens : M. WYCKAERT et K. GEENS, « Cross-border mergers and minority protection – An open-ended harmonization », *Utrecht Law Review*, mars 2008, vol. 4, n° 1, pp. 49 à 51.

sociétés à lever des capitaux[5279]. Il est donc indispensable, à titre liminaire, de déterminer avec précision les risques auxquels ces derniers sont exposés dans le cadre d'une scission transfrontalière. À cet égard, il est possible d'identifier cinq risques distincts.

979. Le risque lié à un rapport d'échange inadéquat. Si le rapport d'échange n'a pas été fixé de manière adéquate, les associés d'une des sociétés impliquées dans l'opération subiront une dilution excessive de leur participation[5280]. Ce risque ne concerne toutefois que les scissions impliquant plus d'une société préexistante puisque dans une scission par constitution de nouvelles sociétés, les associés de la société scindée ne sauraient être dilués[5281]. Il est également intéressant de relever que ce risque de dilution concerne aussi bien les associés de la société scindée que ceux des sociétés bénéficiaires[5282].

980. Le risque de se faire imposer une opération. Les associés minoritaires encourent en outre le risque de se faire imposer une opération aux conséquences particulièrement lourdes, et qu'ils ne souhaitent aucunement, par les associés majoritaires[5283]. Ce risque est commun à tout type de scission, peu important en outre qu'il s'agisse d'une opération interne ou transfrontalière.

981. Le risque lié aux scissions asymétriques. Dans le cadre d'une scission asymétrique[5284], les actions des sociétés bénéficiaires ne sont pas allouées aux associés de la société scindée proportionnellement à leur participation dans la société scindée. Ce raisonnement peut être poussé à l'extrême et il est ainsi possible d'aller jusqu'à une asymétrie totale[5285]. Il s'ensuit que si la répartition des actions des sociétés bénéficiaires est décidée par les associés majoritaires, les associés minoritaires risquent de se retrouver isolés au sein de la société bénéficiaire à laquelle toutes les activités en perte de vitesse auront été allouées[5286], voire de se faire exclure[5287]. Ce risque est donc d'autant plus présent que l'assemblée générale est dominée par un groupe d'associés en mesure d'imposer ses décisions aux associés minoritaires[5288]. Il pourrait

5279 Voir en ce sens : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 70.

5280 Étude d'impact, p. 22 et F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 44 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 15, n° 1 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 427 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 145 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20.

5281 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 62.

5282 F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 44 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308. M. WINNER, *ibidem*, p. 62.

5283 16e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité et Étude d'impact, p. 22.

5284 Sur cette notion, voir *supra* n° 111.

5285 *Ibidem*.

5286 Voir en ce sens : Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 28 et Message du Conseil fédéral suisse concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 13 juin 2000, 00.052, disponible sur https://www.admin.ch (02/12/2019), p. 4013 et ECLE, *op. cit.*, p. 215 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 63.

5287 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 31 qui parle de l'utilisation d'une scission transfrontalière pour réaliser un véritable *squeeze-out* des minoritaires.

5288 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 63.

être éliminé très simplement en imposant une condition de proportionnalité, comme le faisait à l'origine le texte initial de la Sixième Directive[5289], mais cette solution a été rejetée de longue date en raison de son manque de flexibilité[5290]. Il s'ensuit que les associés minoritaires seront immanquablement confrontés à ce risque commun aux opérations internes et transfrontalières.

982. Les risques liés à la nature transfrontalière de l'opération. Une scission transfrontalière, par le fait qu'elle emporte un changement du droit applicable aux associés de la société scindée, est susceptible d'être dommageable pour les associés minoritaires[5291]. Ce risque ne concerne donc que les associés de la société scindée exposés à un changement de *lex societatis*[5292]. En effet, comme la protection des associés minoritaires varie sensiblement d'un État membre à un autre[5293], le droit national des sociétés bénéficiaires peut s'avérer fort différent et même moins protecteur à leur égard[5294]. Ce sera notamment le cas si les règles en matière (i) de quorums de présence et de vote, (ii) de convocation des assemblées générales ou (iii) de modification du capital social, des statuts ou des droits attachés aux titres sont moins strictes ou encore si les conditions pour faire reconnaître un abus de majorité ou mettre en cause la responsabilité des administrateurs sont plus strictes dans l'État d'accueil que dans l'État d'origine[5295]. En outre, toute contestation de la validité d'une décision ultérieure de l'assemblée générale pour abus de majorité devra être introduite dans l'État membre du siège des sociétés bénéficiaires[5296], ce qui ne manquera pas d'avoir un effet dissuasif sur les très petits associés minoritaires[5297].

5289 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1, p. 28.

5290 *Ibidem*.

5291 21e considérant du Premier Compromis de la Présidence et Étude d'impact, p. 27 ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 68 et F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 29 ; S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *op. cit.*, p. 21 ; O MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 146 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20 ; E. SCHOLLMEYER, « Der Verschmelzungs-, Spaltungs- und Formwechselbericht… », *op. cit.*, p. 546 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 63 et Av. gén., J. KOKOTT, concl. préc. C.J., gde ch., arrêt *Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., en liquidation*, 4 mai 2017, C-106/16, EU:C:2017:351, pt. 62.

5292 M. WINNER, *ibidem*, p. 63.

5293 Pour une étude détaillée des différents mécanismes de protection des actionnaires minoritaires au sein de l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni, voir l'étude dirigée par TGS Baltic pour la Commission européenne sur le sujet : Study on minority shareholders protection, TGS Baltic, janvier 2018, disponible sur https://op.europa.eu (10/06/2020) (ci-après l' « **Étude TGS Baltic** »). Voir également : B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés – Les droits des actionnaires minoritaires au sein de l'Union européenne », *Rev. Soc.*, novembre 2018, n° 11, pp. 677 à 684.

5294 21e considérant du Premier Compromis de la Présidence ; Étude d'impact, p. 27 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 68 et C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, p. 2 ; Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, pp. 536 et 537 ; M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 63 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 284 et arrêt *Überseering*, pt. 88.

5295 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 29, note 40 et M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 371. Pour un point de vue très restrictif de ce risque, voir K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 50.

5296 Art. 24, § 2 du Règlement Bruxelles I*bis*.

5297 Sur ce risque, voir : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 63.

983. Le risque d'échec économique. Tout comme dans le cas des créanciers[5298], il n'y a aucune garantie que l'opération sera un succès économique. Ce risque, bien que commun à tous les associés des sociétés impliquées dans l'opération[5299] présente la particularité de devoir être supporté en priorité par les associés ayant pris la décision de procéder à la scission[5300]. En effet, contrairement aux créanciers, les associés disposent de la possibilité de se prononcer sur l'opération et, le cas échéant, de s'y opposer.

984. Des risques à relativiser. S'il est indéniable que les associés encourent un nombre de risques relativement important du fait d'une scission transfrontalière, ces risques se doivent d'être malgré tout relativisés. En effet, l'Étude Bech-Bruun et Lexidale a permis d'établir qu'un nombre important de fusions transfrontalières étaient réalisées dans un contexte intra-groupe[5301], donc n'impliquant généralement pas d'associés minoritaires[5302], et il serait logique que cette tendance se confirme également à l'égard des scissions transfrontalières. *A contrario*, il convient toutefois également de relever qu'il est possible que le faible nombre d'opérations impliquant des associés minoritaires s'explique également par l'absence de régime harmonisé de protection des intérêts de ces derniers[5303], mais il n'en demeure pas moins que dans bon nombre de situations, la question de la protection des associés minoritaires ne constituera pas un obstacle à la réalisation d'une scission transfrontalière.

§2. Un juste équilibre à trouver

985. Equilibre entre associés majoritaires et minoritaires. Ainsi qu'il en est à l'égard des créanciers[5304], un régime de protection des intérêts des associés minoritaires doit aboutir à un compromis équilibré entre d'une part, la nécessité de protéger de manière efficace les intérêts des associés minoritaires impliqués dans l'opération et d'autre part, la nécessité de ne pas empêcher une entreprise de réaliser à brève échéance une opération économiquement importante pour son développement, voire essentielle à sa survie[5305]. En effet, introduire un mécanisme de protection excessif pourrait engendrer une certaine méfiance des acteurs économiques face aux opérations de scission transfrontalière

5298 Sur ce risque dans le cadre de la protection des créanciers, voir *supra* n° 697.
5299 Voir en ce sens : M. WINNER ; « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 62.
5300 Pour une position moins nuancée, voir M. WINNER, *ibidem*, p. 62 qui considère que ce risque doit être supporté par tous les associés.
5301 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 49 qui établit que sur la base d'une approche très conservative, au moins 38 % des fusions transfrontalières étudiées concernaient des réorganisations de groupe.
5302 Voir également en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 200 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 61.
5303 À ce sujet, voir : M. WINNER, *ibidem*, p. 61.
5304 À ce sujet, voir *supra* : Deuxième partie. Titre I, Chapitre 1, Section 2, § 2.
5305 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, pp. 27 et 28. Voir en ce sens également à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 69 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 427. Voir en ce sens à propos des fusions, scissions et transformations transfrontalières : Avis CESE, pt. 3.6.1. et N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2255 ; ECLE, *op. cit.*, p. 209 ; M. FUENTES NAHARRO, *op. cit.*, p. 34 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 45.

et cantonner celles-ci aux opérations de restructuration intragroupes[5306]. La recherche de cet équilibre est rendue encore plus délicate par le fait que la règle de la majorité est un des fondements du droit des sociétés[5307] et qu'il ne convient d'y déroger que dans le cadre de la protection des intérêts légitimes des associés minoritaires[5308]. Ceci implique qu'un régime de protection des associés minoritaires ne peut constituer un frein excessif à la mobilité transfrontalière des sociétés, mais doit en même temps limiter les risques de comportements opportunistes de la part des associés majoritaires tentés d'utiliser l'opération pour nuire aux intérêts des associés minoritaires[5309]. En d'autres termes, il convient d'éviter à la fois qu'une scission transfrontalière ne puisse être utilisée comme un moyen de spoliation des associés minoritaires et qu'une telle opération ne fournisse un moyen d'extorsion aux associés minoritaires[5310].

986. Equilibre entre créanciers et associés minoritaires. Comme de nombreux mécanismes de protection des associés minoritaires, tels qu'un droit de retrait contre une soulte en espèces adéquate ou encore une possibilité de contestation du rapport d'échange, sont susceptibles d'avoir un impact non négligeable sur la situation patrimoniale des sociétés issues de l'opération, il est indispensable de veiller à ce que le mécanisme de protection des associés minoritaires n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une protection adéquate afin d'éviter une érosion excessive du gage commun des créanciers de ce fait[5311].

SECTION 3. L'INCIDENCE DE LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

987. Des enseignements très limités. Compte tenu du fait que les scissions transfrontalières constituent des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »[5312], un régime de protection des intérêts des associés minoritaires devra nécessairement également tenir compte des enseignements

5306 Voir en ce sens à propos du droit de retrait en cas de fusion transfrontalière : T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163.

5307 N. NOHLEN, *Binnenmarktkonformer Minderheitenschutz bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung von Aktiengesellschaften*, Baden-Baden, Nomos, 2012, p. 29.

5308 Voir en ce sens : K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 40.

5309 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 28. Voir également en ce sens : Fusions et scissions transfrontalières – Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), disponible sur http://www.europarl.europa.eu (27/09/2017), p. 9.

5310 M. FUENTES NAHARRO, *op. cit.*, p. 34.

5311 Au sujet de ce risque pour les créanciers, voir *supra* n° 701.

5312 Voir en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 3 ; H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 55 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1161 ; T. DRYGALA, *op. cit.*, p. 26 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 19 ; V. GEYRHALTER et Th. WEBER, *op. cit.*, p. 150 ; L. HANSEN, *op. cit.*, p. 195 ; S. HERRLER, *op. cit.*, pp. 298 et 299 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, pp. 226 et 234 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 45 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 416 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, pp. 165 et 166 ; W. MEILICKE et D. E. RABBACK, *op. cit.*, pp. 126 et 127 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 320 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 236 ; J. SEDEMUND, *op. cit.*, p. 521 ; M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 314 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 358 ; Chr. TEICHMANN et R. KNAIER, *op. cit.*, p. 1319 et S. WEISS et H.-T. WÖHLERT, *op. cit.*, pp. 584 et 585.

de la Cour de justice en la matière[5313]. En effet, il est indéniable qu'un régime de protection des associés minoritaires serait de nature à « dissuader »[5314] les sociétés de faire usage de leur liberté d'établissement, ne fût-ce qu'en raison du risque de retard ou de blocage de l'opération ou encore de l'impact potentiel sur les liquidités de la société. Celui-ci constituera donc systématiquement une entrave à la liberté d'établissement des sociétés concernées. Il en découle que l'entrave qu'un régime de protection efficace des intérêts des associés minoritaires ne manquera pas de générer devra nécessairement remplir les conditions du « *Gebhard test* »[5315] pour être admissible. Avant de poursuivre l'analyse, il est dès lors nécessaire de se pencher brièvement sur les enseignements de la Cour de justice en la matière afin de déterminer s'il est possible d'en isoler certains principes utiles dans la détermination d'un régime efficace et proportionné de protection des associés minoritaires dans le cadre des scissions transfrontalières. En effet, si la protection des intérêts des associés minoritaires a été reconnue de longue date comme une raison impérieuse d'intérêt général[5316], la Cour de justice ne s'est jamais prononcée avec précision sur les contours exacts d'un régime de protection des associés minoritaires conforme aux prescrits de la liberté d'établissement. Il est toutefois possible d'identifier certains enseignements laconiques dans sa jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt *Überseering*[5317], la Cour a considéré qu'un déni pur et simple de la capacité juridique ne saurait être justifié notamment par la protection des intérêts des associés minoritaires car cela équivalait à la « négation même de la liberté d'établissement »[5318]. L'arrêt *Sevic* permet d'établir qu'un refus général d'enregistrement d'une fusion transfrontalière dans l'État membre de la société bénéficiaire ne constitue pas davantage une mesure de protection proportionnée des intérêts des associés minoritaires[5319]. Dans l'arrêt *Vale*[5320], la Cour de justice a établi que le refus général par un État membre de reconnaître les transformations transfrontalières, alors même que les intérêts des associés minoritaires ne s'en trouveraient pas menacés, va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une protection efficace de ces derniers[5321]. Pour finir, il découle de l'arrêt *Polbud* qu'une obligation de liquidation de la société scindée en vue de protéger les intérêts des associés minoritaires, outre le fait qu'elle serait contraire à la notion même de scission transfrontalière qui implique par définition une dissolution sans liquidation[5322], serait contraire aux prescrits des articles 49 et 54 du TFUE[5323].

988. Une importance considérable. Malgré le fait que les enseignements de la Cour de justice en la matière soient particulièrement limités, il n'en demeure

5313 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Th. PAPADOPOULOS, « The magnitude of EU fundamental freedoms… », *op. cit.*, p. 539.
5314 Arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 45 et arrêt *Daily Mail*, pt. 16.
5315 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.
5316 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 et arrêt *Überseering*, pt. 92.
5317 Au sujet des faits à la base de cet arrêt, voir *supra* n°s 186 et 187.
5318 Arrêt *Sevic*, pt. 93.
5319 Arrêt *Sevic*, pt. 30.
5320 Au sujet des faits à la base de cet arrêt, voir *supra* n° 200.
5321 Arrêt *Vale*, pts. 39 et 40.
5322 À ce sujet, voir *supra* n° 97.
5323 Arrêt *Polbud*, pt. 58.

pas moins que tout régime de protection des associés minoritaires dans le cadre d'un régime consacré aux scissions transfrontalières devra nécessairement remplir les conditions du « *Gebhard test* »[5324] et, en particulier, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif[5325]. En outre, comme le caractère transfrontalier de l'opération entraîne des risques additionnels pour les associés minoritaires confrontés à un changement de *lex societatis*[5326], il serait logique que ceux-ci bénéficient d'une protection accrue en cas d'opération transfrontalière par rapport à une opération interne. Cependant, un tel mécanisme violerait le principe de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes posé dès l'arrêt *Sevic*[5327]. Il est donc rigoureusement indispensable qu'il n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une protection adéquate aux associés minoritaires, ce qui signifie, notamment, que le nombre des bénéficiaires devra être limité au strict minimum.

SECTION 4. LA NÉCESSITÉ D'UN RÉGIME RENFORCÉ EN CAS D'OPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

989. Une situation différente par rapport à celle des créanciers. Si une scission transfrontalière est susceptible d'avoir un impact sur tous les associés minoritaires des sociétés impliquées, les associés minoritaires exposés à un changement de *lex societatis* encourent du fait de l'opération un risque additionnel par rapport aux autres associés qui ne sont exposés qu'à une modification de la structure de l'entreprise[5328]. En effet, alors qu'à l'égard de la protection des créanciers, il a pu être établi qu'un régime renforcé ne s'imposait pas notamment en raison du fait qu'une scission transfrontalière n'aura aucun effet sur la loi applicable à un contrat conclu entre un créancier et une des sociétés impliquées dans la scission, ce dernier étant soumis à la loi choisie par les parties[5329] ou, à défaut, par la loi déterminée en fonction de facteurs de rattachement spécifiques[5330][5331], il en va différemment à l'égard des associés minoritaires. En effet, les mécanismes de protection dont ceux-ci jouissent, tels que des conditions de majorité renforcées[5332], un droit de retrait[5333]ou encore le droit de contester le rapport d'échange en cas de fusion ou de scission[5334], relèvent de la *lex societatis*. Or, à l'égard des associés de la société scindée, une scission transfrontalière aura nécessairement pour effet d'altérer la *lex societatis*

[5324] Sur cette notion, voir *supra* n° 132.
[5325] Fusions et scissions transfrontalières – Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), http://www.europarl.europa.eu (27/09/2017), p. 9.
[5326] À ce sujet, voir *supra* n° 982.
[5327] À ce sujet, voir *supra* n° 153.
[5328] F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 20.
[5329] Art. 3, § 1er du Règlement Rome I.
[5330] Art. 4, § 1er du Règlement Rome I.
[5331] À ce sujet, voir *supra* nos 729 à 732.
[5332] Sur ce mécanisme de protection, voir *infra* nos 999 à 1008.
[5333] Sur ce mécanisme de protection, voir *infra* nos 1009 à 1054.
[5334] Sur ce mécanisme de protection, voir *infra* nos 1059 à 1083.

applicable, ne fût-ce qu'en raison du fait qu'elle emporte une dissolution sans liquidation[5335].

990. La position des différents législateurs nationaux. Ni le droit luxembourgeois[5336], ni le droit belge[5337] ne prévoient de mécanismes spécifiques de protection des intérêts des associés minoritaires en raison de la seule nature transfrontalière de la scission, même s'il a longtemps été considéré qu'une opération transfrontalière altérant la nationalité d'une société ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord unanime des associés[5338]. Une telle unanimité demeure par ailleurs de mise à l'égard des transformations transfrontalières en droit français en l'absence d'une convention internationale favorable[5339] dans la mesure où les associés ont un « droit individuel au maintien de la loi ayant présidé à la conclusion de leur engagement avec la société »[5340]. En droit autrichien, alors que le régime des scissions internes impose déjà un droit de retrait pour les associés minoritaires de la société scindée s'étant opposés à une scission asymétrique[5341] et que le régime des fusions internes prévoit également un tel droit de sortie lorsque la société absorbante ou la nouvelle société issue de l'opération a une forme sociale distincte de celle de la société absorbée[5342], le régime des fusions transfrontalières prévoit explicitement un droit de retrait de nature plus générale[5343] pour les associés minoritaires de la société absorbée dans l'hypothèse où la société absorbante serait soumise à une *lex societatis*

5335 Sur cette caractéristique, voir *supra* n° 97.

5336 À l'égard des fusions transfrontalières, voir : Projet de loi relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital et portant transposition : (i) de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ; (ii) de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital et (iii) de la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855(CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, exposé des motifs, Ch. des députés, 2007–2008, n° 5829, pp. 19 et 20.

5337 À l'égard des fusions transfrontalières, voir : Projet de loi portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2007–2008, n° 1012/001, pp. 66 et 67 où le législateur belge a explicitement fait le choix de ne pas introduire de droit de retrait.

5338 Sur l'abandon de la théorie des éléments essentiels en droit belge, voir *supra* n° 315. Voir également : M. COIPEL, « La défunte théorie des éléments essentiels », *Rep. not.*, Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 4, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Bruxelles, Larcier, 2008, n° 395-1 ; D. PASTEGER, « Arrêt *Cartesio* : nouvelles précisions sur les modalités de transfert du siège social au regard de la liberté d'établissement », *J.T.*, 2009, p. 798 et Th. TILQUIN, « La fusion transfrontalière des sociétés de capitaux en droit belge après la transposition de la directive 2005/56/CE », *op. cit.*, pp. 33–37, n°s 41–48. En droit luxembourgeois, voir : I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *op. cit.*, p. 448, n° 49.

5339 À ce sujet, voir : C. KLEINER, « Le transfert de siège social en droit international privé », *Journal du droit international privé*, n° 2, avril 2010, disponible sur www.lexis360.fr (06/11/2020), p. 10, n° 34 ; B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés », *op. cit.*, p. 362 ; B. LECOURT, « Evénement historique en droit européen des sociétés : adoption de la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », *op. cit.*, p. 1 ; Th. MASTRULLO, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 5, n° 16 et E. SCHLUMBERGER, « Le sort des associés dans les opérations de mobilité transfrontalière », *op. cit.*, p. 1, n° 2.

5340 M. MENJUCQ, « Les opérations transfrontalières de rapprochement et de mobilité à l'épreuve de la diversité des droits nationaux », *op. cit.*, p. 7.

5341 § 9(1) SpaltG.

5342 § 234b öAktG.

5343 Voir en ce sens : J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 433 et 434.

distincte[5344]. La *ratio legis* tient à la volonté de ne pas imposer de changement de droit applicable à un associé minoritaire sans son accord[5345] et il y est considéré que l'impact significatif qu'un changement de droit national applicable est susceptible d'avoir sur la position des associés minoritaires justifie pleinement l'octroi d'un tel droit de retrait[5346]. En droit allemand, en cas de fusion interne, les associés minoritaires de la société absorbée disposent d'un droit de sortie lorsque la société absorbante a une forme sociale distincte[5347] ou encore en cas d'absorption d'une société cotée par une société non cotée[5348]. En revanche, en cas de fusion transfrontalière, ce droit de retrait existe en tout état de cause dès que la société absorbante est soumise à un droit national distinct[5349], donc même, à titre d'illustration, en cas de fusion homogène entre deux sociétés anonymes. Cet aspect du droit allemand des fusions transfrontalières n'est toutefois pas considéré comme contraire à la liberté d'établissement en raison de la nécessité de protéger les associés minoritaires contre les conséquences potentiellement défavorables d'un changement de *lex societatis*[5350].

991. La position du législateur européen. Les dispositions de la Directive Sociétés à l'égard de la protection des associés minoritaires dans le cadre des fusions transfrontalières sont foncièrement très limitées, mais il est toutefois prévu qu'un État membre pourra adopter des dispositions particulières destinées à protéger les associés minoritaires d'une société relevant de son propre droit national et s'étant prononcés contre la fusion transfrontalière[5351]. Le législateur européen s'en est donc ouvertement remis aux différents législateurs nationaux pour organiser la protection des associés minoritaires[5352] et laisse même sous-entendre que des mécanismes spécifiques n'existant pas dans un contexte purement interne seraient envisageables[5353]. Une telle interprétation est confortée par la solution adoptée en définitive dans la Directive Mobilité puisque le législateur européen y organise un régime de protection des associés minoritaires très élaboré qui s'articule principalement autour (i) d'une information adéquate et en temps utile des associés minoritaires[5354], (ii) du droit de se prononcer sur l'opération au moment de l'assemblée générale à des conditions de majorité et de présence strictes[5355], (iii) d'un droit de sortie[5356] et (iv) d'un droit de contester le caractère adéquat du rapport

5344 § 10(1) EU-VerschG.
5345 Voir en ce sens : G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 679, n° 2 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 431.
5346 G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 680, n° 4 et J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 434.
5347 § 29 UmwG et à ce sujet, voir : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 29, n° 2 et D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 270.
5348 § 29 UmwG et à ce sujet, voir : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 29, n° 3.
5349 § 122i(1) UmwG et à ce sujet : R. FRENZEL, *op. cit.*, pp. 343 et 344.
5350 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 271 et N. NOHLEN, *op. cit.*, pp. 231 à 239.
5351 Art. 121, § 2, 2e phrase de la Directive Sociétés.
5352 En ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, nos 1 et 2 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 429 et N. NOHLEN, *op. cit.*, p. 231.
5353 Voir en ce sens : A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 115.
5354 Art. 160*quinquies* (établissement du projet de scission) ; 160*sexies* (rapport de l'organe de gestion) et 160*septies* (rapport de l'expert indépendant) de la Directive Mobilité.
5355 Art. 160*nonies*, § 3 de la Directive Mobilité.
5356 Art. 160*decies*, §§ 1 à 5 de la Directive Mobilité.

d'échange[5357]. Or, en comparaison avec le régime des scissions internes figurant dans la Directive Sociétés, il est évident que le législateur européen a opté pour un régime de protection des associés minoritaires fortement renforcé dans le cadre des scissions transfrontalières. En effet, dans le cadre des scissions internes, un droit de retrait pour les associés minoritaires n'est envisagé que dans l'hypothèse des scissions asymétriques et l'introduction de celui-ci est laissée à l'entière discrétion des États membres[5358]. *A contrario*, dans la Directive Mobilité, l'introduction d'un tel droit de retrait est obligatoire, indépendamment du caractère symétrique ou non de l'opération[5359]. Dans un même ordre d'idées, les dispositions de la Directive Sociétés sur les scissions internes n'intègrent pas de possibilité de contester le caractère adéquat du rapport d'échange, alors que la Directive Mobilité introduit une procédure spécifique à cet égard[5360]. Cette position favorable à un régime *a priori* renforcé est en ligne avec l'insistance du législateur européen sur les risques encourus par les associés minoritaires de la société apporteuse en raison du fait qu'à la suite de la réalisation d'une opération transfrontalière, ils se retrouveront nécessairement associés d'une société régie par un autre droit national[5361].

992. Incidence de la liberté d'établissement. Comme les scissions transfrontalières constituent des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »[5362], il s'ensuit que le principe fondamental de non-discrimination posé par la Cour de justice de l'Union européenne devra également trouver à s'appliquer en l'occurrence[5363]. Par conséquent, des mécanismes de protection des associés minoritaires spécifiquement liés à la nature transfrontalière de l'opération et renforcés par rapport à ceux existants dans le cas d'une opération interne constitueront immanquablement une entrave à la liberté d'établissement[5364]. Cependant, compte tenu du risque additionnel supporté par les associés minoritaires de la société scindée[5365], le législateur européen considère que des mécanismes inédits de protection des intérêts des associés puissent se justifier, ce qui n'empêche pas que les conditions d'effectivité et de proportionnalité du « *Gebhard test* » devront toujours être remplies par chaque mécanisme de protection. Il convient toutefois encore de remarquer

5357 Art. 160*decies*, §§ 6 et 7 de la Directive Mobilité.
5358 Art. 139, § 2, 1re phrase de la Directive Sociétés.
5359 Art. 160*decies*, § 1er de la Directive Mobilité.
5360 Art. 160*decies*, §§ 6 et 7 de la Directive Mobilité.
5361 18e considérant de la Directive Mobilité et Étude d'impact, p. 22.
5362 Arrêt *Sevic*, pt. 19 et en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 3 ; H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 55 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1161 ; T. DRYGALA, *op. cit.*, p. 26 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 19 ; V. GEYRHALTER et Th. WEBER, *op. cit.*, p. 150 ; S. HERRLER, *op. cit.*, pp. 298 et 299 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, pp. 226 et 234 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 45 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 416 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, pp. 165 et 166 ; W. MEILICKE et D. E. RABBACK, *op. cit.*, pp. 126 et 127 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 320 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 236 ; J. SEDEMUND, *op. cit.*, p. 521 ; M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 314 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 358 ; Chr. TEICHMANN et R. KNAIER, *op. cit.*, p. 1319 et S. WEISS et H.-T. WÖHLERT, *op. cit.*, pp. 584 et 585.
5363 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 275 et 276 et M. PASSARGE et M. STARK, *op. cit.*, p. 806.
5364 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *ibidem*, p. 271 et N. NOHLEN, *op. cit.*, pp. 232 à 234.
5365 À ce sujet, voir *supra* n° 981.

que l'attitude résolument plus protectrice des intérêts des associés minoritaires du législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité pourrait également trouver à s'expliquer sous l'angle de l'habileté politique du législateur européen. Ce dernier aurait ainsi pu volontairement générer une discordance entre le régime des scissions internes et celui des scissions transfrontalières en vue de justifier une révision plus étendue du régime des scissions tant internes que transfrontalières et passer plus facilement outre les éventuelles réticences des États membres à cet égard.

SECTION 5. LES DIFFÉRENTS MÉCANISMES DE PROTECTION DES ASSOCIÉS MINORITAIRES

993. Plan de la section 5. Pour esquisser les contours d'un régime cohérent de protection des associés minoritaires en cas de scission transfrontalière (§ 6), il convient, en partant de la position du législateur européen sur les différents mécanismes composant un tel système (§ 1), de passer en revue le droit de s'opposer à la scission (§ 2), le droit de retrait (§ 3), le rôle joué à cet égard par l'expert indépendant (§ 4) et le droit de contester le rapport d'échange (§ 5).

§1. La position du législateur européen

994. Plan du paragraphe 1er. Pour pouvoir déterminer avec précision la position du législateur européen à l'égard de la protection des associés minoritaires, il convient d'analyser tour à tour les choix faits à l'origine à l'égard des fusions transfrontalières (A), le régime des scissions internes (B) et le régime des scissions transfrontalières de la Directive Mobilité (C).

A. *Le régime des fusions transfrontalières avant l'adoption de la Directive Mobilité*

995. Un régime très limité. Préalablement à l'adoption de la Directive Mobilité, la protection des associés minoritaires dans la Directive Sociétés se limitait à (i) une information adéquate et en temps utile au cours du processus de fusion[5366] et (ii) l'exercice du droit de vote au moment de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion[5367], tout en laissant aux États membres le soin d'organiser des mécanismes de protection additionnels[5368],

[5366] Cette information adéquate était principalement assurée par (i) le projet de fusion transfrontalière (art. 122 de la Directive Sociétés), (ii) les mesures de publicité (art. 123 de la Directive Sociétés), (iii) le rapport de l'organe de direction ou d'administration (art. 124 de la Directive Sociétés) et (iv) le rapport de l'expert indépendant (art. 125 de la Directive Sociétés).

[5367] Art. 126 de la Directive Sociétés.

[5368] Art. 121, § 2, 2e phrase de la Directive Sociétés et à ce sujet : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2255 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1162 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 253 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 236 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2438.

à l'instar de ce qui avait été fait dans le régime de la société européenne[5369]. Une certaine diversité en a résulté[5370], allant du droit de sortie[5371] aux conditions de majorité renforcée[5372] en passant par le droit de contester le rapport d'échange[5373] ou encore un droit d'investigation[5374]. Certains États membres[5375] ont également choisi de ne pas faire usage de la marge de manœuvre laissée dans la Directive Sociétés. De manière générale, l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale a permis d'établir que, malgré la latitude laissée aux États membres par la Directive Sociétés, les mécanismes de protection étaient relativement similaires et s'articulaient essentiellement autour de droits de sortie et de procédures de réévaluation[5376].

996. Une règle de droit international privé peu satisfaisante. Bien qu'elle s'en soit remise volontairement aux États membres pour la détermination des mécanismes spécifiques de protection des intérêts des associés minoritaires[5377], la Directive Sociétés intégrait une règle de droit international privé spécifique[5378] issue du régime de la société européenne[5379] et destinée à couvrir notamment la procédure de réévaluation du rapport d'échange et le droit de retrait des associés minoritaires connus en droit allemand[5380] et en droit autrichien[5381]. Il était ainsi prévu que si le droit national applicable à une des sociétés impliquées dans la fusion transfrontalière prévoyait une procédure permettant soit d'analyser et de modifier le rapport d'échange, soit d'indemniser les associés minoritaires, une telle procédure ne trouverait à s'appliquer que si les autres sociétés impliquées et soumises à un droit national ne connaissant pas ce type de procédure l'acceptaient explicitement au moment de l'approbation du projet de fusion transfrontalière[5382]. Cette règle *a priori* surprenante fut intégrée

5369 Art. 24, § 2 du Règlement sur la Société européenne.

5370 Étude d'impact, pp. 143 et 144 ; Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 69 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 43 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 146 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 253 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, pp. 236 et 237 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 19 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2438 ; Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 8 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 245 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 61.

5371 À titre d'illustration, on peut citer, l'Allemagne, l'Irlande et les Pays-Bas. Voir Étude d'impact, pp. 143 et 144.

5372 À titre d'illustration, on peut citer le Royaume-Uni (pré-Brexit), l'Irlande et l'Allemagne. Voir Étude d'impact, p. 144.

5373 À titre d'illustration, on peut citer l'Allemagne. Voir Étude d'impact, p. 144.

5374 À titre d'illustration, on peut citer les Pays-Bas. Voir Étude d'impact, p. 144.

5375 Au nombre de ces États, on compte la Belgique, la Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg et la Suède. Voir Étude d'impact, p. 144.

5376 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 69.

5377 Voir en ce sens : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 428.

5378 Art. 127, § 3 de la Directive Sociétés.

5379 Art. 25, § 3 du Règlement sur la Société européenne et à ce sujet, voir : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 265.

5380 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 6 et N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2255.

5381 § 11(1) SpaltG et § 10(1) EU-VerschG.

5382 Art. 127, § 3, 1re phrase de la Directive Sociétés.

à l'instigation de l'Allemagne et de l'Autriche[5383]. En pratique, elle s'est toutefois révélée être une source de considérables difficultés[5384], ne fût-ce qu'en raison du fait que les associés de la société étrangère n'étaient aucunement incités à accepter de telles procédures[5385], notamment en raison du fait que les mécanismes de protection en question auraient été à sens unique[5386], et qu'une procédure de vérification du rapport d'échange était inconnue dans la grande majorité des États membres[5387]. Il n'est dès lors pas surprenant qu'elle ait fait l'objet de vives critiques[5388].

B. *Le régime des scissions internes*

997. La réticence du législateur européen. En dehors des mécanismes de protection par le biais d'une information en temps utile des associés[5389], de la possibilité de se prononcer sur le projet de scission lors de l'assemblée générale[5390] et de la possibilité de faire prononcer la nullité de la scission sous certaines conditions[5391], la Directive Sociétés n'intègre pratiquement pas d'autres dispositions relatives à la protection des associés minoritaires dans le régime des scissions. Il y est juste encore prévu qu'en cas de répartition non proportionnelle des actions des sociétés bénéficiaires aux actionnaires de la société scindée, les États membres disposent de la possibilité de conférer un droit de retrait à ces actionnaires et que la contrepartie devra (i) correspondre à la valeur de ces actions et, (ii) au besoin, pouvoir être déterminée par un tribunal[5392]. Sur cette trame de fond, il n'est pas surprenant de constater que les mécanismes de protection en cas de scission asymétrique varient fortement d'un État membre à un autre[5393].

5383 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 265 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 429.

5384 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 4 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, pp. 1162 et 1163 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 781 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 26, n° 11 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *op. cit.*, p. 509 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 253 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 237 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2438.

5385 W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 844 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 266 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, pp. 1162 et 1163 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 3a et M. NOACK, *ibidem*, p. 781.

5386 B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 26, n° 11 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 122h, n° 3 et M. NOACK, *ibidem*, p. 781.

5387 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 10 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 263 et Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 2.

5388 Voir en ce sens : M. KYRIAKIDES et Fr. FOURNARI, *op. cit.*, p. 216 ; J. MUKWIRI, *op. cit.*, p. 498 et Al. SERETAKIS, « Appraisal rights in the US and the EU » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, p. 71.

5389 Art. 137 (établissement d'un projet de scission) ; 138 (publicité du projet de scission) ; 141 (rapport de l'organe d'administration ou de direction) ; 142 (rapport d'expert) et 143 (mise à disposition des documents pour leur consultation par les associés) de la Directive Sociétés.

5390 Art. 139, § 1er de la Directive Sociétés.

5391 Art. 153 de la Directive Sociétés.

5392 Art. 139, § 2 de la Directive Sociétés.

5393 Voir Étude d'impact, pp. 144 et 145 et *infra* n° 1001.

C. *Le régime de la Directive Mobilité*

998. Le régime de la Directive Mobilité. Afin de remédier aux insuffisances du régime antérieur des fusions transfrontalières et de ne pas répéter les mêmes erreurs à l'égard des scissions transfrontalières, la Directive Mobilité intègre un certain nombre de mécanismes de protection spécifiques. La protection des associés minoritaires y est ainsi assurée par une information adéquate et en temps utile[5394], la nécessité d'approuver l'opération de scission à des conditions de présence et de majorité renforcées[5395], l'instauration d'un droit de retrait obligatoire[5396], l'intervention d'un expert indépendant[5397] et la possibilité de contester le rapport d'échange[5398]. De manière générale, le régime de la Directive Mobilité est considéré comme « *transaction friendly* » en ce qu'il ne bloque pas la réalisation d'une opération transfrontalière[5399]. En outre, le législateur européen a volontairement opté pour une harmonisation *a minima* de la protection des associés minoritaires[5400], de manière à permettre aux différents États membres d'adapter le régime de protection aux spécificités de leur droit national[5401].

§2. Un droit de s'opposer à la scission

999. Plan du § 2. Pour pouvoir porter un jugement sur l'intérêt de protéger les associés minoritaires par le biais d'un droit de s'opposer à la scission, il est opportun de commencer par en analyser le principe et les limites (A), pour ensuite se pencher sur l'articulation entre ce mécanisme et les clauses d'agrément (B).

5394 L'information est ainsi assurée par le biais (i) du projet de scission transfrontalière (art. 160*quinquies* de la Directive Mobilité), (ii) le rapport de l'organe d'administration ou de direction (art. 160*sexies* de la Directive Mobilité), (iii) le rapport de l'expert indépendant (art. 160*septies* de la Directive Mobilité) et (iv) de mesures de publicité (art. 160*octies* de la Directive Mobilité). Sur ces différentes étapes du processus de scission transfrontalière, voir *supra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Sections 3, 4, 5 et 6.

5395 Art. 160*nonies*, §§ 3 et 4 de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *infra* n°s 999 à 1008.

5396 Art. 160*decies*, §§ 1 à 5 de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *infra* n°s 1009 à 1054.

5397 Art. 160*septies* de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *infra* n°s 1055 à 1058.

5398 Art. 160*decies*, §§ 6 et 7 de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *infra* n°s 1059 à 1083.

5399 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 65.

5400 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 21 et 17e considérant de la Directive Mobilité et à ce sujet : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 363 ; ECLE, *op. cit.*, p. 200 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 254 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439.

5401 Étude d'impact, pp. 72 et 73.

A. *Principes et limites*

1000. Un mécanisme potentiellement surprotecteur. S'il a pu être défendu à l'égard des fusions transfrontalières qu'elles constituaient un des types de restructuration les plus démocratiques qui soient[5402], un constat similaire s'impose à l'égard des scissions transfrontalières. Le premier et principal moyen d'assurer une certaine protection aux associés minoritaires est de prévoir que les scissions transfrontalières ne pourront être approuvées qu'à des conditions de quorum et de majorité dépassant largement la majorité simple des voix attachées aux actions représentées[5403]. À titre d'illustration, c'est pour cela qu'en droit belge, une scission doit être approuvée à une majorité des trois-quarts des voix[5404], alors que la Directive Sociétés n'imposait qu'une majorité des deux tiers des voix afférentes aux titres représentés[5405]. Cependant, ce moyen de protection ne peut pas être exagéré dans la mesure où imposer des conditions de majorité plus strictes est généralement considéré comme étant plus intrusif du point de vue de la liberté d'établissement que l'octroi d'un droit de retrait[5406]. En outre, de telles conditions restrictives pourraient potentiellement bloquer une opération essentielle à la survie économique de l'entreprise sous-jacente[5407], raison pour laquelle ce mécanisme de protection a été le moins plébiscité lors de la consultation publique de 2015[5408]. En d'autres termes, le risque que ce mécanisme de protection ne soit utilisé abusivement par les associés minoritaires est excessif car cela revient à leur conférer un moyen d'extorsion redoutable[5409], *a fortiori* si l'unanimité est de mise pour réaliser une opération transfrontalière[5410].

1001. L'exemple de la scission asymétrique au sein des États membres. Malgré ces inconvénients, il s'agit là d'une stratégie fréquemment utilisée par les États membres pour assurer une protection adéquate des intérêts des associés minoritaires dans le cadre des scissions asymétriques[5411], allant jusqu'à conférer l'équivalent d'un véritable droit de veto aux associés minoritaires en requérant une décision unanime[5412]. Ainsi, en droit allemand, en cas de scission asymétrique interne, l'unanimité sera requise lors de l'assemblée générale de la société scindée[5413], contrairement à ce qui est le cas pour une scission

5402 Voir en ce sens : K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 46.
5403 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 209 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 146 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, pp. 63 et 64.
5404 Art. 12:67, § 1er, 2°, a) du CSA.
5405 Art. 139, § 1er et 93, § 1er de la Directive Sociétés. Voir en ce sens : G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, p. 143, n° 42.
5406 Voir en ce sens : S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *op. cit.*, p. 21 ; U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 175 et A. WENG, *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, *op. cit.*, p. 115.
5407 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : Étude d'impact, pp. 33 et 34.
5408 Lors de la consultation publique de 2015, seuls 15 % des personnes s'étant prononcées sur la forme du mécanisme de protection des associés minoritaires ont exprimé une préférence en faveur d'un droit de bloquer l'opération. Voir : Consultation publique de 2015, p. 10.
5409 Voir en ce sens : M. FUENTES NAHARRO, *op. cit.*, p. 34.
5410 À titre d'illustration, un changement de nationalité requiert l'unanimité en droit français. Voir art. L223-30 du Code de commerce français.
5411 Étude d'impact, p. 145 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 31 et C. GERNER-BEUERLE, F. MUCCIARELLI, E. SCHUSTER et M. SIEMS, *op. cit.*, p. 18.
5412 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *ibidem*, p. 31.
5413 § 128 UmwG.

symétrique interne où une majorité renforcée suffit[5414]. Il en sera de même en droit belge[5415]. En droit français, la protection des associés minoritaires en cas de scission non-proportionnelle est assurée par le biais de la possibilité d'écarter une résolution affectée d'un abus de majorité[5416] ainsi que par une exigence d'unanimité en cas de rupture de l'égalité entre associés[5417]. En droit autrichien, alors que l'approbation d'une scission interne symétrique requiert, en l'absence de dispositions statutaires plus strictes, une majorité des trois-quarts du capital représenté dans une société anonyme (*Aktiengesellschaft*, *AG*) et une majorité des trois quarts des voix émises dans une société à responsabilité limitée (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, *GmbH*)[5418], la décision d'approbation d'une scission asymétrique requerra une majorité des neuf dixièmes du capital social de la société scindée[5419]. En outre, lorsque les parts sociales de l'une ou de plusieurs des sociétés impliquées sont majoritairement ou exclusivement allouées à des associés qui ensemble ne représentent pas plus d'un dixième du capital social de la société scindée[5420], ou lorsqu'une ou plusieurs des sociétés impliquées, auxquelles des associés ne détenant pas plus d'un dixième du capital social de la société scindée participeront à la suite de l'opération, n'obtiennent principalement que des titres, des éléments liquides ou d'autres éléments de patrimoine non susceptibles d'être exploités par une entreprise, l'opération requerra l'unanimité des associés de la société scindée[5421]. En droit luxembourgeois, aucune disposition spécifique n'envisage explicitement la scission asymétrique[5422], ce qui avait fait l'objet de certaines critiques de la part de la Chambre de commerce lors de la transposition de la Sixième Directive[5423]. Celles-ci n'en demeurent pas moins possibles en pratique,

5414 En l'absence de dispositions statutaires plus strictes, l'approbation de la scission symétrique interne requerra les ¾ des votes émis dans une GmbH et les ¾ du capital social représenté dans une AG. Voir §§ 50(1) et 65(1), 1re phrase UmwG et à ce sujet : H.-J. PRIESTER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 128, n° 6.

5415 Art. 12:67, § 6 (scission par absorption) et 12:83, § 6 (scission par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.

5416 Étude d'impact, p. 145. Au sujet des limites de ce moyen de protection en droit français, voir : B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés – Les droits des actionnaires minoritaires au sein de l'Union européenne », *op. cit.*, p. 682.

5417 J.-M. MOULIN, C. CATHIARD et J.-L. NAVARRO, *op. cit.*, p. 115, n° 269 et art. L236-2, al. 2 du Code de commerce français.

5418 § 8(1) SpaltG.

5419 § 8(3), 1re phrase SpaltG.

5420 § 8(3), pt. 1 SpaltG.

5421 § 8(3), pt. 2 SpaltG.

5422 Voir art. 1031-3, § 1er de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales qui n'envisage pas la question d'une répartition non proportionnelle des actions des sociétés bénéficiaires.

5423 Selon la Chambre de commerce, « [i]l est à noter que l'article 5 de la 6e directive contient, contrairement à l'article 7 de la 3e directive, un paragraphe 2 qui réglemente l'hypothèse de l'attribution des actions des sociétés bénéficiaires non proportionnelle à leurs droits aux actionnaires de la société scindée. Le texte proposé du projet de loi ne transpose pas cette disposition. Une telle transposition pourrait cependant être utile, alors que l'omission de transposer cette disposition en droit luxembourgeois pourrait être interprétée comme signifiant qu'en droit luxembourgeois, une telle répartition non proportionnelle serait interdite. ». Voir : Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avis de la Chambre de commerce relatif aux scissions des sociétés anonymes, Ch. des députés, 1984–1985, n° 2897/02, p. 3.

même si l'accord unanime des associés de la société scindée est requis par le notaire instrumentant pour passer l'acte[5424].

1002. La position du législateur européen. Dans le cadre des scissions internes, le législateur européen a uniquement prévu que les conditions de quorum et de majorité requises pour l'approbation de la décision de procéder à la scission seraient déterminées par les législateurs nationaux, étant entendu que les États membres étaient dans l'obligation de prévoir qu'une telle décision requerrait à tout le moins une majorité ne pouvant être inférieure aux deux-tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté[5425]. Les États membres demeuraient toutefois libres de prévoir que lorsque la moitié au moins du capital souscrit était représentée, une majorité simple des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté pouvait suffire[5426], étant entendu que, le cas échéant, les règles relatives à la modification des statuts s'appliqueraient également[5427]. Alors qu'à l'égard des conditions de présence et de majorité applicables aux fusions transfrontalières, le législateur européen s'en était explicitement remis aux différents législateurs nationaux dans la Directive Sociétés[5428], la Directive Mobilité consacre un changement de position, notamment à l'égard des scissions transfrontalières, puisqu'il y est expressément prévu que l'approbation du projet de scission transfrontalière requerra une majorité qui ne pourra être inférieure aux deux-tiers mais n'excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions soit au capital souscrit représenté à l'assemblée générale, étant entendu qu'en tout état de cause le seuil des votes ne pourra être supérieur à celui prévu par le droit national pour l'approbation des fusions transfrontalières[5429]. Par cette exigence qui, malgré une erreur rédactionnelle dans la Proposition de la Commission[5430], n'a pas varié par la suite au cours du processus législatif[5431], le législateur européen a ouvertement voulu s'assurer que la décision de procéder à l'opération serait prise par une majorité suffisamment solide[5432], mais en se référant directement aux régimes nationaux applicables aux fusions transfrontalières pour lesquelles l'unanimité n'est pas de mise en raison du principe de non-discrimination des opérations internes par rapport aux opérations transfrontalières[5433],

5424 À ce sujet voir le projet de scission du 13 septembre 2020 de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois TRANSLATE 4 U au profit de la société à responsabilité limitée de droit belge TRANSLATE 4U2, disponible sur https://www.lbr.lu (13/10/2020).

5425 Art. 93, § 1er, al. 1er et 139, § 1er de la Directive Sociétés.

5426 Art. 93, § 1er, al. 2, 1re phrase et 139, § 1er de la Directive Sociétés.

5427 Art. 93, § 1er, al. 2, 2e phrase et 139, § 1er de la Directive Sociétés.

5428 Art. 121, § 2 de la Directive Sociétés.

5429 Art. 160*nonies*, § 3 de la Directive Mobilité.

5430 Art. 160*duodecies*, § 3 de la Proposition de la Commission qui omettait erronément de couvrir l'approbation de l'opération. Voir à ce sujet : Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 244, note 44.

5431 Art. 160k, § 3 du Premier Compromis de la Présidence ; art. 160k, § 3 du Deuxième Compromis de la Présidence ; art. 160k, § 3 du Compromis des Représentants Permanents ; art. 160k, § 3 du Compromis final et art. 160k, § 3 de la Proposition du Parlement.

5432 16e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité.

5433 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 191 ; M. EVRARD et E. VAN DER VAEREN, *op. cit.*, p. 116 ; S. KULENKAMP, *op. cit.*, p. 251 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 347 ; H.-F. MÜLLER, « Die grenzüberschreitende Verschmelzung… », *op. cit.*, p. 1794 et Th. TILQUIN, « Fusions et scissions – Aspects transfrontaliers », *op. cit.*, p. 15, n° 29.

le législateur européen a du même coup sonné le glas des mécanismes de protection des associés minoritaires en cas de scissions asymétriques articulés autour d'une exigence d'unanimité[5434]. La seule exception concerne l'hypothèse dans laquelle une clause du projet de scission ou une modification des statuts de la société scindée entraînerait une augmentation des engagements économiques d'un associé à l'égard de la société ou de tiers et où l'associé en question ne disposerait pas d'un droit de retrait ou du droit de contester le caractère correct du rapport d'échange[5435]. Dans une telle hypothèse, les États membres disposent de la possibilité d'exiger l'accord exprès de l'associé concerné. Si en raison du fait que le droit de retrait est ouvert à tous les associés de la société scindée ayant voté contre l'opération[5436] et que tous les associés n'ayant pas eu ou n'ayant pas exercé le droit de céder leurs actions disposent du droit de contester le rapport d'échange[5437], les hypothèses visées par cette disposition, introduites par le Compromis des Représentants Permanents[5438], seront foncièrement limitées[5439], elle a néanmoins le mérite de démontrer à nouveau que dans l'esprit du législateur européen, l'exigence d'approbation unanime de l'opération transfrontalière ne doit rester que l'*ultima ratio*.

1003. L'incidence de la liberté d'établissement. Il est généralement admis qu'imposer une condition d'unanimité pour procéder à une opération transfrontalière est plus intrusif du point de vue de la liberté d'établissement que d'organiser la protection des associés minoritaires autour d'une condition de majorité combinée à un droit de retrait pour les associés minoritaires s'étant opposés à l'opération[5440]. Cette position est tout à fait logique car si des seuils de majorité renforcée, voir l'exigence d'unanimité au sein de l'assemblée générale de la société scindée soumise à un changement de *lex societatis*, seraient indéniablement de nature à protéger efficacement les intérêts des associés

5434 Voir en ce sens de manière plus générale et sans relever directement l'implication pour les scissions asymétriques : Th. MASTRULLO, *op. cit.*, p. 5, n° 16 et M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 21, n° 30 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 279 ; Fr. SCHURR, *op. cit.*, p. 543 ; Chr. SCHULTE, *op. cit.*, p. 144 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 244 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 330. Voir également en ce sens à propos de l'exigence d'unanimité en cas de transformation transfrontalière : B. LECOURT, « Chronique de droit européen des sociétés – Evènement historique : adoption de la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », *op. cit.*, p. 362 et G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 12, n° 18 et p. 14, n° 39. *Contra* : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 358 qui ne relève pas toutes les implications de la référence au régime des fusions transfrontalières figurant dans la Directive Mobilité et qui recommande simplement au législateur allemand de s'en remettre au régime applicable aux scissions internes lors de la transposition du régime des scissions transfrontalières de la Directive Mobilité.

5435 Art. 160*nonies*, § 4 de la Directive Mobilité.

5436 Art. 160*decies*, § 1er de la Directive Mobilité.

5437 Art. 160*decies*, § 6 de la Directive Mobilité.

5438 Art. 160k, § 3a du Compromis des Représentants Permanents.

5439 On pourrait, à titre d'illustration, envisager que cela s'applique aux titulaires d'actions sans droit de vote qui se verraient priver d'un dividende préférentiel à la suite de la réalisation de la scission transfrontalière.

5440 Voir en ce sens : S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *op. cit.*, p. 21 ; U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 175 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 434 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktsmobilität von Gesellschaften nach Sevic », *op. cit.*, p. 359 et A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 114.

minoritaires contre une opération transfrontalière qui leur serait imposée, ces mécanismes de protection sont plus dissuasifs que de pouvoir se passer de leur accord moyennant l'octroi d'un droit de retrait contre une soulte en espèces adéquate. En effet, dans l'hypothèse de sociétés à l'actionnariat fortement dispersé, un tel mécanisme de protection aurait pour principale conséquence de rendre la réalisation d'une scission transfrontalière asymétrique illusoire[5441], alors qu'autoriser l'opération sous condition de l'octroi d'un droit de retrait, même si elle avait potentiellement un impact non négligeable sur les liquidités de la société, ne bloquerait pas l'opération.

1004. Appréciation critique. Si la référence aux conditions de majorité applicables aux fusions transfrontalières dans la Directive Mobilité peut s'expliquer partiellement par le fait que la Directive Sociétés n'impose pas une reconnaissance obligatoire des scissions internes[5442], il est également possible d'y voir un exemple de l'habileté politique de la Commission. En effet, prohiber l'exigence d'unanimité en cas de scission asymétrique[5443] en contrepartie de la concession d'un droit de retrait contre soulte en espèces adéquate[5444] moins intrusif au regard de la liberté d'établissement[5445] emportera plus facilement l'adhésion des États membres, comme le Luxembourg[5446], traditionnellement pro-majoritaires et généralement plus sceptiques à l'égard du droit de retrait[5447]. En effet, la méfiance additionnelle de certains États membres à l'encontre des scissions transfrontalières aurait aisément pu se traduire par une hausse des conditions de quorum et de majorité requises. Dans cette optique, des conditions de quorum et de majorité identiques à celles applicables en cas de fusion transfrontalière assorties d'un droit de retrait semblent être une solution de loin préférable dans la mesure où elle ne permet pas directement à une faible minorité de bloquer une opération potentiellement vitale à la survie économique de la société en question. Il est également à relever qu'une telle position se justifie du point de vue des créanciers qui ont un intérêt à ce que leur société débitrice ne se retrouve pas engluée dans des procédures de négociation avec des associés minoritaires hostiles à une opération économiquement rationnelle.

5441 U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 177 ; H. SCHRÖER in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 128, n° 3 et A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 114.

5442 Art. 135, § 1er de la Directive Sociétés et en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 29.

5443 Art. 160*nonies*, §§ 3 et 4 de la Directive Mobilité.

5444 Art. 160*decies*, §§ 1 à 5 de la Directive Mobilité.

5445 Voir en ce sens : S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *op. cit.*, p. 21 ; U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 175 ; J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 434 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktsmobilität von Gesellschaften nach Sevic », *op. cit.*, p. 359 et A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 114.

5446 Voir au sujet du caractère libéral et traditionnellement pro-majoritaire du droit luxembourgeois des sociétés : I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 18 et I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *op. cit.*, pp. 418 et 419.

5447 Sur l'échec de l'introduction d'un droit de retrait au Luxembourg lors de la réforme de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 2016, voir : I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *op. cit.*, pp. 445 à 447.

B. *L'incidence des clauses d'agrément*

1005. Exemple de clause d'agrément :

> *Tout transfert d'actions à titre particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort est soumis à l'agrément de l'unanimité des actionnaires, déduction faite des actions dont la cession est proposée*[5448].

1006. Trois points de friction. À l'égard des cessions de titres d'une société, une clause d'agrément peut être définie comme la clause par laquelle « la décision de céder les actions est soumise à l'agrément d'un organe de la société – le conseil d'administration ou l'assemblée générale – ou à un comité ou encore à une personne désignée dans le pacte syndicataire »[5449]. Dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, l'existence d'une clause d'agrément est susceptible de générer des frictions dans trois hypothèses distinctes[5450], à savoir (i) lorsque la société absorbée a dans son patrimoine des titres dont la cessibilité fait l'objet d'une clause d'agrément, (ii) lorsque les titres de la société scindée qui disparaîtront dans le cadre de l'opération font l'objet d'une clause d'agrément et (iii) lorsque les titres d'une des sociétés absorbantes qui seront attribués aux associés de la société scindée en conséquence de la scission font l'objet d'une clause d'agrément. À l'égard de la première question, on considère en droit belge que la clause d'agrément devra en principe trouver à s'appliquer[5451 5452], mais dans la mesure où il s'agit d'avantage d'une question traitant de l'étendue de la transmission à titre universel de patrimoine dont s'accompagne une scission[5453], il n'est pas utile d'y consacrer de longs développements dans le cadre de la protection des associés minoritaires. En revanche, les deux autres questions méritent un examen plus approfondi.

1007. Clause d'agrément relative aux titres de la société scindée. À l'égard de la deuxième question, l'existence d'une clause d'agrément ne pose en principe guère de problèmes dans la mesure où à aucun moment, les sociétés

5448 Exemple de clause d'agrément portant sur les actions d'une société à responsabilité limitée de droit belge tiré de : A.-P. DUMONT, « Les titres et leur transfert », *Le nouveau droit des sociétés et des associations*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 313, n° 26.

5449 A. COIBION, *Les conventions d'actionnaires en pratique*, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 59, n° 83.

5450 Pour une étude détaillée de ces questions, voir : P. HAINAUT-HAMENDE, « La société anonyme. Deuxième partie : Opérations sur le capital. Émissions publiques. Transformation. Fusion - Scission », *op. cit.*, n° 836 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, pp. 185–188, n° 21.

5451 Voir en ce sens : P. HAINAUT-HAMENDE, « La société anonyme. Deuxième partie : Opérations sur le capital. Émissions publiques. Transformation. Fusion - Scission », *op. cit.*, n° 836 ; J. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, pp. 121 et 122, n° 6 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *ibidem*, p. 188, n° 21. Voir également : J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE et H. CULOT, *op. cit.*, pp. 848 et 849, n° 1536.

5452 En droit allemand, la question est plus délicate et on considère généralement qu'une telle clause d'agrément ne trouvera pas à s'appliquer, mais il est néanmoins possible pour les actionnaires de la société cédée de prévoir dans les statuts que la société bénéficiaire en cas de scission sera dans l'obligation de rétrocéder ses actions aux actionnaires de la société cédée. À ce sujet, voir : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 7 et N. LEONARD et St. SIMON in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 20, n° 22. Voir également : S. BLASCHE, « Vinkulierungsklauseln in GmbH-Gesellschaftsverträgen », *RNotZ*, 2013, p. 518.

5453 Au sujet de cet élément caractéristique des scissions, voir *supra* : Première partie, Titre I, Chapitre 4, Section 2.

bénéficiaires ne deviendront associées de la société scindée[5454]. Cette solution, si elle apparaît certes logique, fait parfois l'objet de certains tempéraments au sein des États membres puisqu'à titre d'illustration, en droit allemand, il est expressément prévu que si le transfert des titres de la société absorbée dépend de l'agrément de certains associés en particulier, la décision de scission requerra nécessairement l'approbation de ces associés[5455]. Cette position particulière s'explique par la volonté du législateur allemand de ne pas permettre l'altération d'un droit spécial sans l'accord de son titulaire[5456]. Il convient toutefois de relever que lorsqu'un tel agrément appartient à l'assemblée générale statuant à une majorité qualifiée[5457] ou à l'unanimité[5458], ou à un autre organe de la société[5459], il ne trouvera pas à s'appliquer. En conséquence, une telle clause d'agrément n'est que d'une utilité limitée dans le cadre de la protection des associés minoritaires de la société scindée qui sont pourtant les plus vulnérables[5460].

1008. Clause d'agrément relative aux titres d'une société bénéficiaire. La troisième hypothèse est plus épineuse dans la mesure où on pourrait parfaitement imaginer la situation dans laquelle un transfert des titres d'une des sociétés bénéficiaires requerrait l'approbation de l'assemblée générale à une plus forte majorité que la décision de scission elle-même. Pourrait-on dès lors envisager que les associés minoritaires bénéficiant de cette clause puissent bloquer l'opération de scission par le biais d'une telle clause d'agrément ? Si la clause en question ne vise que la cession des titres de la société bénéficiaire, il est généralement admis qu'elle ne devra pas trouver à s'appliquer à l'hypothèse d'une scission[5461] dans la mesure où (i) l'attribution des parts de la société bénéficiaire ne s'apparente pas à une cession[5462] et (ii) le processus décisionnel spécifique de la scission, en tant que loi spéciale, l'emporte sur « les mécanismes généraux régissant la vie sociétaire »[5463], comme les clauses d'agrément[5464]. Toutefois deux tempéraments doivent être apportés à cette solution logique : (i) dans certaines hypothèses, le législateur lui-même a prévu certains tempéraments, comme à titre d'illustration en droit belge en prévoyant qu' « une société ne peut absorber une autre société que si les associés ou les actionnaires de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou actionnaire de la société absorbante »[5465] et

5454 Voir en ce sens : F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 187, n° 21 et J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE et H. CULOT, *op. cit.*, p. 849, n° 1536.
5455 §§ 13(2) et UmwG.
5456 T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 13, n° 28.
5457 T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 13, n° 30.
5458 T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 13, n° 32.
5459 T. DRYGALA in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 13, n° 30.
5460 À ce sujet, voir *supra* n°s 978 à 984.
5461 P. HAINAUT-HAMENDE, « La société anonyme. Deuxième partie : Opérations sur le capital. Émissions publiques. Transformation. Fusion - Scission », *op. cit.*, n° 836 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 246, n° 350.
5462 P. HAINAUT-HAMENDE, *ibidem*, n° 836 et Th. TILQUIN, *ibidem*, p. 246, n° 350.
5463 F. T'KINT et I. CORBISIER, *op. cit.*, p. 186, n° 21.
5464 Voir en ce sens : P. HAINAUT-HAMENDE, « La société anonyme. Deuxième partie : Opérations sur le capital. Émissions publiques. Transformation. Fusion - Scission », *op. cit.*, n° 836 et F. T'KINT et I. CORBISIER, *ibidem*, p. 186, n° 21.
5465 Art. 12:29, § 1er du CSA.

(ii) lorsque la clause d'agrément figurant dans les statuts vise explicitement l'hypothèse de l'attribution d'actions dans le cas d'une scission, elle devra en tout état de cause être respectée[5466]. Une telle clause est donc susceptible de présenter un intérêt pour protéger certains associés minoritaires, par exemple lorsque ces derniers disposent de suffisamment de force de négociation pour imposer l'insertion d'une clause d'agrément visant spécifiquement la scission, mais ces situations devraient demeurer limitées dans la mesure où il sera peu fréquent qu'un associé majoritaire concède un tel droit.

§ 3. Un droit de retrait

1009. Plan du § 3. Pour pouvoir se prononcer sur l'efficacité du droit de retrait en tant que mécanisme de protection permettant de répondre de manière adéquate aux différents enjeux posés par une scission transfrontalière pour les associés minoritaires, il importe d'en exposer le principe et les limites intrinsèques (A), d'identifier quels associés minoritaires parmi ceux potentiellement impactés par une scission transfrontalière doivent en bénéficier (B), de se prononcer sur la nature de la soulte en espèces qui devra être offerte en contrepartie (C) ainsi que sur la nécessité d'une information préalable (D), la nécessité d'une procédure de vérification du prix de rachat (E) et la nécessité d'une règle de droit international privé qui lui serait spécifiquement applicable (F). Il conviendra également de s'intéresser à la personne de l'acheteur (G), à la nécessaire requalification de l'associé minoritaire exerçant son droit de retrait en créancier chirographaire (H) et à l'éventuelle exclusion des sociétés cotées du champ d'application du droit de retrait (I).

A. *Principe et limites*

1. *Un mécanisme* a priori *efficace*

1010. Un mécanisme proportionné. Suivant en cela les recommandations d'une des études préalables[5467], les résultats de la consultation publique de 2015 à l'égard du régime des fusions transfrontalières[5468] et la recommandation du Parlement européen dans sa résolution de 2017[5469], la Directive Mobilité impose aux États membres d'octroyer un droit de retrait à tout le moins aux associés de la société scindée qui ont voté contre l'approbation du projet de

5466 *Pro* : P. HAINAUT-HAMENDE, « La société anonyme. Deuxième partie : Opérations sur le capital. Émissions publiques. Transformation. Fusion - Scission », *op. cit.*, n° 836 et Th. TILQUIN, *Traité des fusions et scissions, op. cit.*, p. 246, n° 350. *Contra* : J. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, p. 120, n° 5. Voir en droit allemand : H. SCHRÖER et G. GREITEMANN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 4, n° 20.

5467 J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 31. Voir également à ce sujet : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 254.

5468 Lors de la consultation publique de 2015, parmi 94 % des personnes s'étant prononcées en faveur d'une harmonisation, 70 % ont plaidé en faveur d'un droit de retrait. Voir : Consultation publique de 2015, p. 10.

5469 Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pt. 11.

scission[5470]. Ce mécanisme de protection se devinait déjà dans la règle de droit international privé applicable à la protection des associés minoritaires figurant dans le Règlement sur la Société européenne[5471] et est considéré comme un mécanisme particulièrement efficace pour protéger les intérêts des associés minoritaires[5472]. Son introduction par le législateur européen a été accueillie favorablement par de nombreux auteurs[5473] et l'Avocate générale Juliane Kokott, en s'inspirant de la législation applicable en matière d'offres publiques d'acquisition[5474], avait déjà défendu cette possibilité de rachat automatique de la participation des associés minoritaires s'étant prononcés contre l'opération dans ses conclusions précédant l'arrêt *Polbud*[5475] en estimant qu'il s'agissait là d'une mesure proportionnée au regard de la liberté d'établissement[5476]. Bien que la Cour de justice n'ait pas encore eu l'occasion de se prononcer sur cette question, il est indéniable qu'il s'agit là d'une mesure plus proportionnée que le fait de requérir l'unanimité pour réaliser une telle opération[5477], même si le fait que ce mécanisme intervienne indépendamment d'un risque concret pour les associés minoritaires, comme dans l'hypothèse d'une opération transfrontalière où la juridiction d'accueil offre un niveau de protection identique ou supérieur aux associés minoritaires[5478], a pu soulever certaines interrogations[5479].

1011. Un mécanisme fréquent. L'octroi d'un droit de sortie aux associés minoritaires est loin d'être un mécanisme de protection des intérêts des associés minoritaires inconnu et existe, sous une forme ou sous une autre, dans bon

5470 Art. 160*decies*, §§ 1 à 5 de la Directive Mobilité.

5471 Art. 25, § 3 du Règlement sur la Société européenne et en ce sens : K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 42 et S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *op. cit.*, p. 21.

5472 Voir en ce sens : K. GEENS et M. WYCKAERT, *ibidem*, p. 47 ; P.-H. CONAC, *op. cit.*, p. 8 ; S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *ibidem*, p. 21 et R. ROELOFS, *op. cit.*, pp. 577 et 578.

5473 Pour un point de vue positif, voir : St. BARTMANN, *op. cit.*, p. 140 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860 ; Th. MASTRULLO, *op. cit.*, p. 5, n° 18 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 ; Fr. SCHURR, *op. cit.*, p. 543 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 71.

5474 Art. 16, § 2 de la directive (CE) 2005/25 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, *J.O.*, L 142, 30 avril 2004 (ci-après la « **Directive OPA** »), pp. 12–23.

5475 Sur cet arrêt, voir *supra* n[os] 211 et 212.

5476 Av. gén., J. KOKOTT, concl. préc. C.J., gde ch., arrêt *Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., en liquidation*, 4 mai 2017, C-106/16, EU:C:2017:351, pt. 62. Voir également en ce sens : J. MITTERECKER, *op. cit.*, pp. 432 et 433 ; U. LENNERZ, *op. cit.*, p. 175 et Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 362.

5477 Voir en ce sens : S. FRAZZANI, C. ANGELICI, J. HOFFMANN, S. MEDICI et F. SCIAUDONE, *op. cit.*, p. 21 ; U. LENNERZ, *ibidem*, p. 175 ; J. MITTERECKER, *ibidem*, p. 434 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktsmobilität von Gesellschaften nach Sevic », *op. cit.*, p. 359 et A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 114.

5478 Du point de vue du droit belge, on pourrait être tenté d'y voir une forme de survivance de la théorie des éléments essentiels puisque contrairement à l'hypothèse du droit de retrait pour justes motifs consacré par l'article 2:68 du CSA, il n'est pas nécessaire de disposer de « justes motifs » pour bénéficier du droit de retrait consacré par le législateur européen, comme si la simple altération de la nationalité et la soumission à une autre *lex societatis* justifiaient celui-ci. Sur cette théorie des éléments essentiels, voir *supra* n[os] 315 et 990.

5479 G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 681, n° 4 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 435 qui concluent toutefois à la conformité de la mesure à la liberté d'établissement. Voir également en ce sens : S. KULENKAMP, *op. cit.*, pp. 355 et 356.

nombre d'États membres[5480], comme l'Allemagne[5481] et l'Autriche[5482]. Il est également envisagé dans le *Model Companies Act*[5483] et apparaît dans les dispositions de la Directive Sociétés à l'égard des scissions internes[5484] et des fusions internes[5485], ainsi que dans la Directive OPA[5486] et la Directive OPCVM en cas de fusion tant interne que transfrontalière[5487]. En outre, cette option s'est avérée être de loin la plus populaire lors de la consultation publique de 2015, mais ce résultat a indéniablement été influencé par le nombre important de réponses fournies par des personnes soumises au droit allemand[5488] qui connaît un tel mécanisme de protection[5489]. Cependant, cette attitude ne fait pas l'unanimité et certains États membres comme la Belgique[5490], le Luxembourg[5491] et la France[5492] ont fait le choix de ne pas intégrer un tel mécanisme de protection dans leur régime de fusion ou de scission[5493]. En droit belge, ce choix peut s'expliquer par l'existence d'un droit de retrait pour justes motifs de droit commun[5494] applicable aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, à l'exception des sociétés cotées[5495]. En effet, bien que la question de son applicabilité à l'hypothèse d'une scission ou d'une fusion ne semble pas

5480 Voir Étude TGS Baltic, p. 42 établissant que des droits de sortie existent dans 23 États membres. Voir également ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20.

5481 §§ 29 et 122i UmwG.

5482 § 234b öAktG ; § 10 (1) EU-VerschG et § 11 SpaltG.

5483 Art. 13.17 de l'European Model Companies Act, 1st ed., 2017, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/06/2020).

5484 Art. 139, § 2 de la Directive Sociétés.

5485 Art. 114, al. 1er de la Directive Sociétés.

5486 Art. 16, § 2 de la Directive OPA.

5487 Art. 45, § 1er de la directive (CE) 2009/65 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), version consolidée disponible sur https://eur-lex.europa.eu (07/11/2021) (ci-après la « **Directive OPCVM** »).

5488 Consultation publique de 2015, p. 3.

5489 §§ 29 et 122i UmwG.

5490 Projet de loi portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2007–2008, n° 1012/001, pp. 66 et 67 où il est simplement précisé que « [l]a Belgique ne connaît toutefois pas de droit de rachat. ».

5491 Projet de loi relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital et portant transposition : (i) de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ; (ii) de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital et (iii) de la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855 (CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, exposé des motifs, Ch. des députés, 2007–2008, n° 5829, pp. 19 et 20.

5492 Voir à ce sujet : F. SCHLUMBERGER, *op. cit.*, p. 5, n° 22.

5493 D. CARREAU et H. LETRÉGUILLY, « Offres publiques : OPA, OPE, OPR », *Répertoire de droit commercial*, juin 2012, n° 479. Voir également : S. DARIOSECQ et N. MÉTAIS, « Les clauses d'exclusion, solution à la mésentente entre associés », *BJS*, septembre 1998, n° 9, p. 908, disponible sur www.lextenso.fr (04/11/2020), p. 1 et M. PARIENTE, « Qu'est-ce qu'un actionnaire ? », *Rev. Sociétés*, 1999, p. 805, disponible sur www.dalloz.fr (04/11/2020), pp. 3–5).

5494 Selon l'article 2:68, § 1er du CSA, « [t]out actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l'origine de ces justes motifs reprennent tous ses titres. ». À ce sujet, voir : J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE et H. CULOT, *op. cit.*, pp. 329–338.

5495 Art. 2:60 du CSA.

avoir encore été tranchée par la jurisprudence et dépendrait, en tout état de cause, des faits spécifiques à la base du litige, compte tenu notamment de la grande diversité de justes motifs déjà admis en jurisprudence[5496], en ce compris le transfert de substance de la société vers une autre structure[5497], il est indéniable qu'une scission transfrontalière pourrait potentiellement être admise comme juste motif « d'une telle nature que l'on ne peut attendre de l'associé qui [l'invoque] qu'il reste associé »[5498]. Il convient toutefois de relever qu'elle ne le sera que dans des cas relativement rares dans la mesure où (i) la loi de la majorité doit rester la norme[5499], les tribunaux ne pouvant intervenir que s' « il est manifeste que les actionnaires majoritaires s'avantagent eux-mêmes en spoliant la société »[5500] et (ii) l'intérêt social devra également être, au moins à titre subsidiaire, pris en compte[5501]. Compte tenu de ces spécificités du droit de retrait de droit commun, il n'est pas étonnant de constater que le législateur belge se soit montré réticent à intégrer un droit de retrait détaché en quelque sorte d'un juste motif en cas de fusion ou de scission. Il n'en demeure toutefois pas moins que l'introduction d'un droit de retrait spécifique aux opérations transfrontalières permettrait, par application du principe *lex specialis legi generali derogat* d'éluder toute interférence avec la procédure d'exclusion-retrait de droit commun. En droit luxembourgeois, cette hostilité par rapport au droit de retrait peut s'expliquer par la volonté de préserver les mécanismes contractuels réservant un traitement peu favorable aux associés minoritaires et dont l'efficacité se trouverait potentiellement affaiblie par l'octroi d'un droit de retrait[5502]. Enfin, en droit français, la procédure du retrait obligatoire a suscité de vives controverses dans la mesure où elle a pu être qualifiée d' « expropriation pour cause d'utilité privée » ou encore de « contraire à l'idée même de société qui repose sur le droit de chaque associé d'y participer »[5503].

5496 Pour une analyse des justes motifs de retrait admis en jurisprudence, voir : R. AYDOGDU et O. CAPRASSE, *Les conflits entre actionnaires – Prévention et résolution*, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 297 à 304, n°s 571 à 582 ; H. CULOT, L. CULOT, Y., DE CORDT, J.-M. GOLLIER, A. HANNOUILLE, N. KONINGS, F. MAGNUS, G. PARISIS, G. DE PIERPONT, K. VAN DE VELDEN et S. WOLFF, *Société anonyme*, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 584–587, n° 775 et J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE et H. CULOT, *op. cit.*, pp. 333 à 335, n° 635.

5497 R. AYDOGDU et O. CAPRASSE, *ibidem*, p. 299, n° 275 et Comm. Bruges (prés.), 13 juin 2001, *D.A. O.R.*, 2001, p. 280 et Liège, 12 septembre 2005, *J.L.M.B.*, 2007/23, p. 986.

5498 Cass., 16 mars 2009, *RDC*, 2009, p. 956.

5499 J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE et H. CULOT, *op. cit.*, p. 332, n° 634 et Comm. Hasselt (réf.), 16 juillet 1997, *T.R.V.*, p. 331 et Comm. Tongres (réf.), 8 juillet 1997, *T.R.V.*, 1999, p. 335.

5500 J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE et H. CULOT, *ibidem*, pp. 332 et 333, n° 634.

5501 R. AYDOGDU et O. CAPRASSE, *op. cit.*, p. 293, n°s 564 et 565 et J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE et H. CULOT, *ibidem*, pp. 332 et 333, n° 634 et Liège, 12 septembre 2005, *J.L.M.B.*, 2007/23, p. 986.

5502 Pour une étude détaillée de cette question, voir I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *op. cit.*, pp. 445 à 447, n° 47. Voir également : Procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2015 de la sous-commission « Modernisation du droit luxembourgeois des sociétés » de la Commission juridique, *Doc.*, Ch. des députés, 2014–2015, n° 5730, disponible sur https://chd.lu (26/09/2019), pp. 4 et 5.

5503 Pour un exposé de ces controverses, voir : D. CARREAU et H. LETRÉGUILLY, *op. cit.*, n° 479. Voir également sur les clauses d'exclusion : S. DARIOSECQ et N. MÉTAIS, « Les clauses d'exclusion, solution à la mésentente entre associés », *BJS*, septembre 1998, n° 9, p. 908, disponible sur www.lextenso.fr (04/11/2020), p. 1 et M. PARIENTE, « Qu'est-ce qu'un actionnaire ? », *Rev. Sociétés*, 1999, p. 805, disponible sur www.dalloz.fr (04/11/2020), pp. 3–5.

2. *Un nombre important d'inconvénients*

1012. Les limites du droit de retrait. Malgré sa fréquence et ses avantages, l'octroi d'un droit de retrait aux associés minoritaires opposés à l'opération n'en constitue pas pour autant nécessairement un mécanisme exempt d'inconvénients. Il est ainsi possible d'identifier pas moins de cinq impacts négatifs dont un tel droit de retrait s'accompagne.

1013. L'impact sur les liquidités de la société. Comme remarqué dès l'Étude d'impact[5504], même lorsque l'opération s'avère parfaitement rationnelle d'un point de vue économique, à partir du moment où l'actionnariat des sociétés impliquées sera dispersé, il y aura, si pas toujours, à tout le moins très fréquemment des associés minoritaires opposés. Il s'ensuit qu'une scission transfrontalière impliquera l'obligation pour les sociétés concernées de disposer de suffisamment de liquidités pour pouvoir racheter les participations des associés minoritaires opposés à l'opération[5505]. Cet aspect du droit de retrait des associés minoritaires risque de poser problème non seulement dans le cadre d'une scission transfrontalière réalisée en vue d'assainir la situation financière d'une des sociétés impliquées dans l'opération, mais également lors de la scission transfrontalière d'une société économiquement viable mais ne disposant que d'une faible trésorerie ou de peu d'actifs liquides. S'il a pu être avancé que cet inconvénient du droit de retrait ne devait pas être surestimé dans la mesure où ce mécanisme de protection des associés minoritaires est essentiellement destiné à avoir un effet dissuasif sur les associés majoritaires[5506], il n'en demeure pas moins que cette limite du droit de retrait est très fréquemment mise en lumière en droit allemand[5507] où une expérience non négligeable a pu être recueillie en la matière.

1014. L'impact sur le patrimoine de la société. Compte tenu des conditions de majorité spécifiques fixées par la Directive Mobilité en matière de scissions transfrontalières, l'impact sur le patrimoine de la société concernée est loin d'être négligeable[5508], a fortiori en présence d'une société cotée où un rachat ne fût-ce que de quelques pourcents s'avérerait particulièrement coûteux[5509]. Ceci explique pourquoi en droit allemand, il a été avancé que les sommes qui allaient devoir être versées en contrepartie de l'exercice du droit de retrait par certains associés minoritaires devaient être prises en compte pour déterminer le risque encouru par les créanciers du fait de l'opération et potentiellement justifier l'octroi d'une garantie adéquate[5510].

5504 Étude d'impact, p. 74 et ECLE, *op. cit.*, p. 210.

5505 Étude d'impact, p. 74 et W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 6 ; P.-H. CONAC, *op. cit.*, p. 8 ; A. FRANCK, *op. cit.*, p. 229 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 245 ; J. VETTER, *op. cit.*, p. 623 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 68.

5506 Voir en ce sens : P.-H. CONAC, *ibidem*, p. 8.

5507 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 844 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 622.

5508 Voir en ce sens : Étude d'impact, p. 159 ; ECLE, *op. cit.*, p. 210 ; M. FUENTES NAHARRO, *op. cit.*, p. 37 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 27, n° 13 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 432.

5509 Voir en ce sens : G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, p. 146, n° 51.

5510 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 13 et G. SEULEN in J. SEMLER et A STENGEL (dir.), *op. cit.*, p. 316, n° 30.

1015. Des problèmes d'évaluation de la « soulte en espèces adéquate ». La détermination du montant de la soulte en espèces adéquate peut s'avérer hasardeuse et l'expérience glanée au sein de différents États membres en la matière démontre à suffisance que cet aspect du droit de retrait des associés minoritaires peut être source de litiges extrêmement longs[5511].

1016. Un potentiel usage abusif. Si dans l'esprit du législateur européen, le droit de retrait a, en priorité, été instauré pour protéger les associés minoritaires contre un changement de *lex societatis* potentiellement dommageable[5512], rien ne garantit que les associés minoritaires y recourront effectivement pour cette raison[5513]. À titre d'illustration, des associés minoritaires qui bénéficieraient d'un droit national plus protecteur à la suite d'une scission transfrontalière pourraient malgré tout recourir au droit de retrait pour se débarrasser d'une participation peu liquide tout en engendrant par là même un *cashflow* injustifié pour les sociétés issues de l'opération. Ce risque peut toutefois être limité en prévoyant que la scission transfrontalière est soumise à la condition suspensive que des associés minoritaires représentant moins d'un certain pourcentage du capital social de la société scindée n'exercent leur droit de retrait[5514], avec toutefois l'inconvénient de risquer de bloquer une opération économiquement intéressante pour l'entreprise. En tout état de cause, il est nécessaire de limiter ce droit de retrait au strict nécessaire sous peine, à l'instar de ce qui a été avancé à l'égard des fusions transfrontalières[5515], d'engendrer une certaine méfiance des acteurs économiques face aux scissions transfrontalières et cantonner celles-ci aux opérations intragroupes.

1017. Des délais prolongés. Le dernier inconvénient significatif de ce droit de retrait est lié aux délais applicables. En effet, en cas de contestation du caractère adéquat de la soulte en espèces proposée dans le projet commun, la société concernée peut se retrouver engluée dans des procédures longues et coûteuses[5516] qui ne manqueront pas d'engendrer une certaine insécurité tant pour la société que pour ses créanciers.

B. *Les associés minoritaires jouissant du droit de retrait*

1018. Plan du point B. Pour pouvoir déterminer quels associés minoritaires impliqués dans une scission transfrontalière devraient bénéficier d'un droit de retrait, il convient d'examiner tour à tour la question de la limitation aux associés de la société scindée (1), la question de l'exigence d'un changement de *lex societatis* (2), la question de l'exigence d'une opposition formelle au projet de scission (3) et la question de l'exigence d'une période de détention minimale (4).

5511 Voir en ce sens : G. SEULEN in J. SEMLER et A STENGEL (dir.), *ibidem*, p. 316, n° 30 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 68.
5512 18e considérant de la Directive Mobilité et M. WINNER, *ibidem*, p. 71.
5513 Voir en ce sens : M. WINNER, *ibidem*, p. 71.
5514 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 210 et M. WINNER, *ibidem*, p. 71.
5515 T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163.
5516 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 210.

1. *La limitation aux associés de la société scindée*

1019. L'exclusion des associés autres que ceux de la société scindée. À l'égard du droit de retrait des associés minoritaires dans le cadre de la mise en place d'un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, on peut tout d'abord s'interroger sur l'opportunité d'ouvrir ce droit à tous les associés des sociétés impliquées ou, au contraire, de limiter celui-ci aux seuls associés de la société scindée. Dans la mesure où seuls ces derniers vont se retrouver associés d'une société qu'ils n'auront pas choisie à l'origine, il semble logique *a priori* de limiter ce droit aux seuls associés de la société scindée[5517]. Cette limitation, qu'on retrouve également en droit allemand[5518] et en droit autrichien[5519], permet certes de limiter l'impact du droit de retrait sur la situation patrimoniale et les liquidités des sociétés impliquées, mais n'en est pas pour autant évidente. En effet, il a été argumenté qu'une opération transfrontalière pouvait être tout aussi bouleversante pour les associés des sociétés bénéficiaires[5520] et que l'extension du droit de retrait à tous les associés minoritaires des sociétés impliquées était en outre plus conforme au principe d'égalité des associés[5521]. Pour pouvoir trancher cette question à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, il est utile de se pencher sur les évolutions, au cours du processus législatif, du droit de retrait consacré par la Directive Mobilité dans le cadre des fusions transfrontalières[5522].

1020. L'enseignement du régime des fusions transfrontalières. La Proposition de la Commission prévoyait à l'origine d'octroyer un droit de retrait tant aux associés minoritaires de la société absorbée qu'à ceux de la société absorbante[5523]. Ce vaste champ d'application, correspondant aux nombreux appels fait en ce sens à l'égard du droit allemand des fusions transfrontalières[5524], a

5517 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 49. Voir également en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 69 ; ECLE, *ibidem*, p. 210 et M. NOACK, *op. cit.*, p. 781. *Contra* à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238.

5518 §§ 29 et 125 UmwG.

5519 § 9(1) UmwG et à ce sujet : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 955 et 956, n° 12.

5520 J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 255 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238. Voir également en ce sens à propos du régime allemand des fusions transfrontalières : W. BAYER in W. BAYER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 4 et p. 1321, n° 5. Voir également en faveur d'une telle extension : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 5 et N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2257. *Contra* : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439.

5521 J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, p. 255 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *ibidem*, p. 237. Voir également en ce sens à propos du régime allemand des fusions transfrontalières : W. BAYER in W. BAYER (dir.), *ibidem*, § 122h, n° 4 et § 122i, n° 5. Voir également en faveur d'une telle extension : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *ibidem*, p. 2257.

5522 Art. 126*bis*, § 1er, al. 1 et 2 de la Directive Mobilité.

5523 Art. 126*bis*, § 1er de la Proposition de la Commission.

5524 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 5 et R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 613.

été accueilli favorablement par certains auteurs[5525] et vivement critiqué par d'autres[5526]. Le Premier Compromis de la Présidence est ensuite venu limiter le bénéfice du droit de retrait aux seuls associés de la société absorbée[5527], tout en prévoyant la possibilité pour les États membres d'étendre ce droit à d'autres associés « de la société »[5528]. Cette dernière disposition manquait de clarté dans la mesure où il n'était pas certain que ces termes ne visassent pas exclusivement la société absorbée, interdisant de ce fait à un État membre d'étendre le droit de sortie aux associés minoritaires de la société absorbante. Fort heureusement, ce point a été clarifié dès le Deuxième Compromis de la Présidence qui est venu préciser que les États membres disposaient de la faculté d'étendre le bénéfice du droit de retrait aux associés de toute société fusionnante, peu important à cet égard qu'elle soit absorbée ou absorbante[5529]. Cette position s'est ensuite retrouvée inchangée dans le Compromis des Représentants Permanents[5530], le Compromis Final[5531], la Proposition du Parlement[5532] et la Directive Mobilité[5533]. Si on ajoute à cela que le législateur européen a résolument opté pour une harmonisation *a minima* dans le cadre de la protection des associés minoritaires[5534], il en découle que, de son point de vue, dans le cadre d'une opération transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, le droit de sortie doit être ouvert à tout le moins aux associés de la société absorbée et il ne semble pas impératif de l'ouvrir également aux associés de la société bénéficiaire.

1021. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. Le principal risque auquel les associés des sociétés bénéficiaires préexistantes sont exposés dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante est celui de la dilution excessive qu'ils auraient à subir en cas de rapport d'échange insuffisant[5535]. Or, ces derniers sont suffisamment protégés contre ce risque par le biais de la procédure de contestation du rapport d'échange[5536]. Si on ajoute à cela que les enseignements de la Cour de justice en matière

[5525] W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; R. KNAIER, *ibidem*, p. 613 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238.

[5526] Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 842 ; ECLE, *op. cit.*, p. 210 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 781 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 69.

[5527] Art. 126a, § 1er, al. 1er du Premier Compromis de la Présidence.

[5528] Art. 126a, § 1er, al. 2 du Premier Compromis de la Présidence.

[5529] Art. 126a, § 1er, al. 2 du Deuxième Compromis de la Présidence.

[5530] Art. 126a, § 1er, al. 1 et 2 du Compromis des Représentants Permanents.

[5531] Art. 126a, § 1er, al. 1 et 2 du Compromis Final.

[5532] Art. 126*bis*, § 1er, al. 1 et 2 de la Proposition du Parlement.

[5533] Art. 126*bis*, § 1er, al. 1 et 2 de la Directive Mobilité.

[5534] Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 21 et 17e considérant de la Directive Mobilité et à ce sujet : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 363 ; ECLE, *op. cit.*, p. 200 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 254 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439.

[5535] Sur ce risque, voir *supra* n° 978 et en ce sens : P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2439.

[5536] Voir en ce sens : P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2439.

de liberté d'établissement imposent de limiter le droit de retrait au strict minimum[5537], il en découle qu'un nouveau régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante ne devrait ouvrir un tel droit de retrait qu'aux seuls associés de la société scindée, sans laisser de possibilité pour les États membres d'étendre ce droit de sortie aux associés des sociétés bénéficiaires.

2. *L'exigence d'un changement de* lex societatis

1022. Enjeux de la question. S'il a pu être déterminé que seuls les associés minoritaires de la société scindée devaient bénéficier d'un droit de retrait[5538], il serait toutefois erroné de s'arrêter là et ce, car il convient encore de répondre à trois questions distinctes. Tout d'abord, dans le cadre d'une scission partielle asymétrique, il se peut que certains associés de la société scindée conservent la totalité de leurs actions dans la société scindée sans en obtenir d'autres, de sorte qu'à l'issue de l'opération, leur participation dans la société scindée demeurera inchangée. Faut-il dès lors également leur ouvrir un droit de retrait ? Dans un même ordre d'idées, dans le cadre d'une scission transfrontalière partielle, il est tout à fait possible qu'un associé de la société scindée obtienne des actions dans la société bénéficiaire et conserve une partie de ses actions dans la société scindée. S'il doit bénéficier d'un droit de retrait, celui-ci doit-il également couvrir les actions dans la société scindée qui ne seront pas échangées contre des actions d'une des sociétés bénéficiaires ? Pour finir, une scission transfrontalière se caractérise par une pluralité de sociétés bénéficiaires. Il est donc tout à fait concevable que l'opération ne soit que partiellement transfrontalière et, dans le cadre d'une répartition asymétrique des actions des sociétés bénéficiaires, que tous les associés de la société scindée ne soient pas confrontés à un changement de droit national applicable. Faut-il malgré tout les protéger alors même que le régime des scissions internes ne prévoit pas de droit de retrait[5539] ? Pour répondre à ces différentes questions, il est tout d'abord utile de se pencher sur la manière dont le législateur européen a choisi d'y répondre dans le cadre de la Directive Mobilité.

1023. Le critère du changement de *lex societatis*. La Proposition de la Commission prévoyait à l'origine purement et simplement que tous les associés de la société scindée devaient pouvoir bénéficier d'un droit de sortie contre juste rémunération[5540]. L'octroi d'un droit de retrait à tous les associés minoritaires d'une société scindée dans le cadre d'une scission partielle semble excessif dans la mesure où seuls les associés de celle-ci se voyant octroyer des actions dans la ou les sociétés bénéficiaires sont exposés à un changement de *lex societatis* potentiellement dommageable[5541]. Cette position a fait l'objet d'un revirement significatif lors de l'adoption du Premier Compromis

5537 À ce sujet, voir *supra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 3.
5538 À ce sujet, voir *supra* n°s 1018 à 1021.
5539 Sur la position du législateur européen à l'égard des opérations internes, voir *supra* n° 996.
5540 48e considérant et art. 160*terdecies*, § 1er de la Proposition de la Commission.
5541 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; ECLE, *op. cit.*, p. 210 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 19 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer

de la Présidence qui a explicitement lié le bénéfice du droit de sortie à l'exigence d'un changement de droit national applicable du fait de l'opération[5542], tout en prévoyant une possibilité pour les États membres d'étendre ce droit à d'autres associés minoritaires[5543]. Cette position s'est ensuite retrouvée dans le Deuxième Compromis de la Présidence[5544], le Compromis des Représentants Permanents[5545], le Compromis Final[5546], la Proposition du Parlement[5547] et la Directive Mobilité[5548]. Ainsi, les États membres ne devront introduire un droit de retrait contre juste rémunération que pour les seuls associés qui, par le fait de l'opération, « acquièrent des actions dans les sociétés bénéficiaires qui seraient régies par la législation d'un autre État membre que celui de la société scindée ». Cette nouvelle approche, jugée plus conforme au principe de proportionnalité[5549], se retrouve tant à l'égard du régime des scissions transfrontalières[5550] qu'à l'égard de celui des fusions transfrontalières[5551].

1024. La situation en droit allemand et en droit autrichien. Cette exigence de changement de *lex societatis* correspond en outre à la situation existante dans différents droits nationaux. Ainsi, en matière de fusions transfrontalières, il est prévu tant en droit allemand[5552] qu'en droit autrichien[5553] que les associés minoritaires de la société absorbée ne disposeront d'un droit de retrait que si la société absorbante est soumise au droit d'un autre État membre. Une telle exigence correspond à la *ratio legis* de ces dispositions qui est d'éviter qu'un associé minoritaire ne se voit imposer un changement de droit national applicable contre son gré[5554].

1025. Une complexité additionnelle liée à la nature des scissions. Si on s'en tient à une interprétation littérale du texte de la Directive Mobilité[5555], on en aboutit à la conclusion que la condition est remplie lorsqu'un associé de la société scindée acquiert des actions dans des sociétés bénéficiaires soumises à une *lex societatis* distincte de celle de la société scindée, peu important dans

Richtlinie… », *op. cit.*, p. 146 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 69. *Contra* : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 255 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 237.

5542 21e considérant et art. 160l, § 1er, al. 1er du Premier Compromis de la Présidence.

5543 Art. 160l, § 1er, al. 2 du Premier Compromis de la Présidence.

5544 21e considérant et art. 160l, § 1er, al. 1 et 2 du Deuxième Compromis de la Présidence.

5545 21e considérant et art. 160l, § 1er, al. 1 et 2 du Compromis des Représentants Permanents.

5546 16e considérant et art. 160l, § 1er, al. 1 et 2 du Compromis Final.

5547 16e considérant et art. 160*terdecies*, § 1er, al. 1 et 2 de la Proposition du Parlement.

5548 18e considérant et art. 160*decies*, § 1er, al. 1 et 2 de la Directive Mobilité.

5549 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, pp. 19–21. Voir également en ce sens à propos du régime autrichien des fusions transfrontalières : G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 680, n° 3 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 431.

5550 Art. 160*terdecies*, § 1er, al. 1er de la Proposition du Parlement européen.

5551 Art. 126*bis*, § 1er, al. 1er de la Proposition du Parlement européen.

5552 § 122i (1), 1re phrase UmwG.

5553 § 10 (1) EU-VerschG.

5554 Voir en ce sens en droit autrichien : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 431 et G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 679, n° 2. Voir en ce sens en droit allemand : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 6 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 2 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 2 et H.-W. NEYE et B. TIMM, « Mehr Mobilität für die GmbH in Europa – Das neue Recht der grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 564.

5555 Art. 160*decies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

quelle proportion. Cependant, l'usage des termes « *les sociétés bénéficiaires* qui seraient régies par la législation d'un autre État membre »[5556] semble *a priori* exclure à la fois les scissions partielles transfrontalières où il n'y aurait qu'une seule société bénéficiaire[5557] et les scissions transfrontalières où une société bénéficiaire serait régie par un droit national distinct de celui de la société scindée et l'autre société bénéficiaire relèverait de la même *lex societatis* que la société scindée, alors même que ce type d'opération entre dans la définition de la notion de « *scission transfrontalière* » consacrée par la Directive Mobilité[5558]. Tel ne peut évidemment être le cas et ce, pour trois raisons. Tout d'abord, prôner une telle interprétation permettrait trop facilement d'éluder le droit de retrait des associés minoritaires, non seulement dans le cas d'une scission transfrontalière, mais également dans le cas d'une fusion[5559] ou d'une transformation transfrontalière[5560]. En effet, à titre d'illustration, dans ce dernier cas, il suffirait de procéder à une scission partielle transfrontalière au profit d'une société nouvellement constituée dans l'État membre de destination en vidant la société scindée, suivie de la liquidation de celle-ci peu de temps après pour émousser considérablement le tranchant du droit de retrait en cas de transformation transfrontalière. Ensuite, il ne s'agit pas là du seul exemple où le législateur européen fait négligemment usage du pluriel dans le cadre d'une scission partielle et un exemple se retrouve même dans la définition de la notion de scission partielle de la Directive Mobilité[5561]. Troisièmement, si on se penche sur le processus législatif de la Directive Mobilité, on constate que le document de travail modifié par le Premier Compromis de la Présidence envisageait explicitement l'hypothèse d'une société bénéficiaire unique et prévoyait que le droit de retrait trouverait à s'appliquer dès que les associés minoritaires de la société scindée acquerraient du fait de la scission des actions dans une société soumise à un droit national distinct de celui de la société scindée[5562]. Il s'ensuit qu'en cas de scission transfrontalière partielle asymétrique totale, les associés de la société scindée qui ne se verraient pas attribuer d'actions dans la société bénéficiaire ne devraient pas bénéficier de droit de retrait. Cette solution est logique puisque de leur point de vue, l'opération ne

5556 Art. 160*decies*, § 1er, al. 1er *in fine* de la Directive Mobilité.

5557 L'art. 160*ter,* 4), b) de la Directive Mobilité autorise explicitement les scissions transfrontalières partielles dans lesquelles il n'y a qu'une société bénéficiaire.

5558 L'art. 160*bis*, § 1er de la Directive Mobilité prévoit qu'il suffit qu' « *au moins deux* des sociétés de capitaux impliquées dans la scission [soient] régies par le droit d'États membres différents ».

5559 Un tel droit de retrait en cas de fusion transfrontalière est instauré par l'art. 126*bis*, §§ 1 à 5 de la Directive Mobilité.

5560 Un tel droit de retrait en cas de transformation transfrontalière est instauré par l'art. 86*decies*, §§ 1 à 5 de la Directive Mobilité.

5561 L'art. 160*ter,* 4), b) de la Directive Mobilité, malgré le fait qu'il envisage notamment l'hypothèse d'une scission partielle transfrontalière avec une seule société bénéficiaire, prévoit cependant que les associés de la société scindée se verront allouer des titres ou actions « dans *les sociétés bénéficiaires* ».

5562 Voir art. 160l du document de travail 14872/18 que le Premier Compromis de la Présidence entendait modifier et qui prévoyait ce qui suit : « […] *provided that as a result of the division they would acquire shares in* a recipient company *which is governed by the law of a Member State other than the company being divided* », ce qui a été remplacé par : « *provided that, as a result of the division, they would acquire shares in* the recipient companies *which would be governed by the law of a Member State other than the company being divided* ». Voir art. 160l du Premier Compromis de la Présidence.

se distinguera pas d'une scission purement interne. En revanche, la Directive Mobilité ne contient aucune limitation une fois la condition remplie. Dès lors, dès qu'un associé minoritaire obtient des actions dans une société bénéficiaire soumise à une *lex societatis* distincte, il bénéficiera en principe d'un droit de sortie applicable à l'intégralité de sa participation dans la société scindée et ce, indépendamment de la clé de répartition des actions prévues dans le projet de scission. Par conséquent, en cas de scission partielle transfrontalière, un associé se voyant attribuer des nouvelles actions de la société bénéficiaire et en conservant certaines dans la société scindée pourra exercer un droit de retrait à l'égard de la totalité de sa participation dans la société scindée. Cette solution est critiquable car du point de vue de la participation dans la société scindée, la situation n'est pas distincte de celle d'une scission interne. Si le droit de retrait a effectivement été instauré dans la Directive Mobilité pour protéger les associés minoritaires contre un changement de *lex societatis*[5563], il aurait fallu prévoir que dans une telle hypothèse le droit de retrait ne concernerait que les actions dans la société scindée qui seraient échangées contre des actions émises par la société bénéficiaire soumise à une *lex societatis* distincte. Cette solution aurait en outre été plus conforme au principe de proportionnalité. Dans un même ordre d'idées, la formulation de la Directive Mobilité, combinée à la définition de la notion de « scission transfrontalière » qui requiert uniquement qu'une seule des sociétés bénéficiaires soit soumise à un droit national distinct de celui de la société scindée[5564] implique que dans l'hypothèse d'une scission totale par constitution de nouvelles sociétés partiellement transfrontalière dans laquelle la répartition des actions des sociétés bénéficiaires se fait de manière parfaitement symétrique, les associés minoritaires de la société bénéficiaire pourront théoriquement exercer leur droit de retrait pour l'intégralité de leurs actions dans la société scindée et ce, malgré le fait que l'opération aura des conséquences identiques à une scission interne pour une partie des actions de la société scindée.

1026. La nécessité d'un régime plus nuancé. Cette solution est suboptimale en ce que l'érosion financière du gage commun des créanciers qu'elle risque d'engendrer va au-delà de ce qui est nécessaire. Si on part du principe que le droit de retrait instauré par le législateur européen a pour objectif de protéger les associés minoritaires contre un changement de *lex societatis*[5565], une telle solution prête le flanc à la critique tant sous l'angle de son impact sur la situation des créanciers que sous l'angle du caractère disproportionné qu'elle génère à l'égard de la liberté d'établissement des entités concernées. Le droit de retrait devrait dès lors se limiter aux seules actions destinées à faire l'objet d'un échange contre des actions de la société bénéficiaire soumise à un droit national distinct. Il est à espérer que ces nuances seront bien intégrées au plus tard lors de la révision du régime de la Directive Mobilité.

5563 18e considérant de la Directive Mobilité et en ce sens : ECLE, *op. cit.*, pp. 210 et 211 ; Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 9 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 69.

5564 18e considérant de la Directive Mobilité et en ce sens : M. WINNER, *ibidem*, p. 69.

5565 Art. 160*bis*, § 1er de la Directive Mobilité.

3. *L'exigence d'une opposition formelle au projet de scission*

1027. La nécessité d'un vote négatif. Compte tenu des inconvénients significatifs de la concession d'un droit de retrait aux associés minoritaires[5566], il est apparu nécessaire au législateur européen d'en restreindre le bénéfice aux seuls associés minoritaires ayant voté contre l'approbation du projet de scission transfrontalière[5567]. En outre, afin de restreindre encore davantage ce droit de retrait[5568], les États membres disposent de la possibilité d'exiger que l'opposition au projet de scission transfrontalière et/ou l'intention de faire usage du droit de retrait fassent l'objet d'un enregistrement au plus tard lors de l'assemblée générale se prononçant sur le projet de scission[5569]. En d'autres termes, le législateur européen exclut du bénéfice du droit de sortie les associés passifs[5570], ainsi que les associés sans droit de vote[5571] ou encore les titulaires d'autres instruments, comme les parts bénéficiaires[5572], susceptibles de conférer un droit de vote[5573], même si les États membres demeurent libres d'étendre le droit de retrait à ces catégories de porteurs de titres[5574].

1028. L'évolution au cours du processus législatif. Cet aspect du droit de retrait a fortement évolué au cours du processus d'adoption de la Directive Mobilité. La Proposition de la Commission prévoyait à l'origine que tous les associés ayant des actions sans droit de vote[5575] et tous les associés ayant des actions avec droit de vote et n'ayant pas voté en faveur de l'opération[5576] devaient pouvoir en bénéficier. Cela signifiait que non seulement les associés ayant voté contre la scission lors de l'assemblée générale devaient en profiter, mais également les associés s'étant abstenus de voter[5577] et ceux ne s'étant pas présentés à l'assemblée générale[5578]. Cette approche de la Proposition de la Commission a fait l'objet de certaines critiques en raison de son vaste

5566 À ce sujet, voir *supra* n°s 1012 à 1017.
5567 Art. 160*decies*, § 1e, al. 1er de la Directive Mobilité.
5568 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 69.
5569 Art. 160*decies*, § 1er, al. 3 de la Directive Mobilité.
5570 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 69.
5571 Ce point ressort clairement du 18e considérant de la Directive Mobilité, malgré le fait que dans certaines circonstances, les titulaires d'actions sans droit de vote recouvrent celui-ci. Voir art. 430-1 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales qui précise que « [l]es actions sans droit de vote disposent d'un droit de vote lorsque la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier les droits attachés aux actions sans droit de vote ainsi que dans toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital social ou sur la dissolution anticipée de la société ». Voir également : art. 5:47, § 1er du CSA qui prévoit notamment que les actions sans droit de vote donneront néanmoins droit à une voix par action en cas de transformation transfrontalière, de fusion transfrontalière ou de déplacement transfrontalier du siège, sans toutefois mentionner explicitement l'hypothèse des scissions transfrontalières pourtant explicitement autorisées.
5572 À ce sujet, voir : I. CORBISIER et F. BERNARD, *op. cit.*, p. 27.
5573 Art. 7:58 et 7:59 du CSA et art. 430-1, § 1er, al. 2 (S.A.) ; 710-5, § 1er, al. 2 (S. à r.l.) et 812-9, al. 1er (sociétés coopératives) de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
5574 18e considérant et art. 160*decies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
5575 Art. 160*terdecies*, § 1er, b) de la Proposition de la Commission.
5576 Art. 160*terdecies*, § 1er, a) de la Proposition de la Commission.
5577 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 782 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439.
5578 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 307 ; M. NOACK, *ibidem*, p. 782 et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2439.

champ d'application[5579] et dès le Premier Compromis de la Présidence, l'exigence d'un vote négatif a été introduite[5580], de même que la possibilité pour les États membres (i) d'exiger que l'opposition explicite au projet de scission et/ou l'intention des associés concernés d'exercer leur droit de retrait soient documentées au plus tard lors de l'assemblée générale[5581] et (ii) de considérer que l'enregistrement de l'objection au projet de scission constituait une preuve suffisante d'une opposition explicite[5582]. La Commission des affaires juridiques avait, pour sa part, suggéré d'intégrer également l'exigence d'un vote négatif, tout en prévoyant également que les associés n'ayant pas participé à l'assemblée générale, mais ayant à la fois exprimé leur intention avant l'assemblée de voter contre le projet et d'exercer leur droit de retrait pouvaient également en bénéficier[5583]. Elle avait également prévu que les actionnaires détenant des actions sans droit de vote devaient malgré tout manifester leur intention d'exercer leur droit de retrait lors de l'assemblée générale pour pouvoir en bénéficier[5584]. Cette dernière solution est logique car dans le cas contraire, des actionnaires minoritaires disposant à la fois d'actions avec et sans droit de vote auraient très bien pu voter en faveur de l'opération lors de l'assemblée générale et, malgré tout, disposer de leurs actions sans droit de vote[5585]. La position du Premier Compromis de la Présidence s'est retrouvée sans altération dans le Deuxième Compromis de la Présidence[5586]. En revanche, le Compromis des Représentants Permanents a vu la suppression des détenteurs d'actions sans droit de vote du champ obligatoire du droit de retrait[5587]. Ni le Compromis Final[5588], ni la Proposition du Parlement[5589] n'ont altéré cette position qui s'est retrouvée en définitive dans la Directive Mobilité[5590].

1029. Une précision utile en droit allemand et en droit autrichien. En droit allemand[5591] et en droit autrichien[5592] des fusions et scissions, on considère

[5579] Voir en ce sens : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, pp. 8 et 9 et Al. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 843 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 31 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 et M. NOACK, *ibidem*, p. 782. *Contra* : ECLE, *op. cit.*, p. 210 qui insiste sur le fait que l'exigence d'un vote négatif risque de bloquer l'opération et M. FUENTES NAHARRO, *op. cit.*, p. 36.

[5580] Art. 160l, § 1er, al. 1er, a) du Premier Compromis de la Présidence.

[5581] Art. 160l, § 1er, al. 2, 1re phrase du Premier Compromis de la Présidence.

[5582] Art. 160l, § 1er, al. 2, 2e phrase du Premier Compromis de la Présidence.

[5583] Amendement 301 de l'Avis CAJ.

[5584] Amendement 302 de l'Avis CAJ. Voir également en faveur d'une telle modification : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860.

[5585] Voir en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 43.

[5586] Art. 160l, § 1er du Deuxième Compromis de la Présidence.

[5587] Art. 160l, § 1er du Compromis des Représentants Permanents.

[5588] Art. 160l, § 1er du Compromis Final.

[5589] Art. 160*terdecies*, § 1er de la Proposition du Parlement.

[5590] Art. 160*terdecies*, § 1er de la Directive Mobilité.

[5591] §§ 29 ; 122i, § 1er, 1re phrase et 125 UmwG et en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 9 et B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 29, nos 11 et 12.

[5592] § 234b(3) öAktG (fusions internes) ; § 10(1) EU-VerschG (fusions transfrontalières) et § 9(1) SpaltG (scissions) et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 436.

généralement que seuls les associés minoritaires ayant voté contre l'opération et ayant manifesté leur intention d'exercer le droit de retrait lors de l'assemblée générale pourront s'en prévaloir. Une telle condition est jugée comme essentielle dans la mesure où en l'absence d'une telle exigence, il se pourrait qu'un nombre important d'associés votent en faveur de l'opération pour ensuite exercer le droit de retrait au point que l'impact qui en découlerait sur les liquidités de la société priverait l'opération d'intérêt économique[5593]. Il est en outre intéressant de relever qu'en droit allemand, il est également prévu que la condition d'une opposition à l'opération est également remplie lorsque (i) un associé n'a pu comparaître à l'assemblée générale parce qu'il n'y a indûment pas été admis, (ii) l'assemblée générale n'a pas été convoquée correctement ou (iii) l'objet de l'assemblée n'a pas été annoncé correctement[5594]. De telles précisions, qui se retrouvent également en droit autrichien[5595], auraient pu avoir leur utilité dans le régime de la Directive Mobilité et mériteraient de se retrouver dans un régime européen général des scissions transfrontalières.

1030. Le cas particulier des scissions asymétriques. Si dans le cadre des fusions transfrontalières, l'exigence d'un vote négatif permet d'éviter la situation où un nombre important d'associés minoritaires auraient voté en faveur de l'opération pour ensuite exercer leur droit de retrait[5596], cet aspect mérite quelques développements additionnels dans le cadre particulier des scissions asymétriques. En effet, compte tenu des risques spécifiques engendrés par ce type d'opération pour les associés de la société scindée[5597], de nombreux États membres, comme la Belgique[5598], le Luxembourg[5599] et l'Allemagne[5600] ont prévu qu'une telle opération ne pourrait être approuvée qu'à l'unanimité et d'autres, comme l'Autriche[5601], ont prévu des conditions de majorité renforcées. Dans de telles hypothèses, imposer aux associés minoritaires souhaitant faire usage de leur droit de retrait de voter contre l'opération aurait pour conséquence directe d'empêcher celle-ci, alors même que les associés minoritaires disposeraient d'un mécanisme de protection adéquat par le biais d'un droit de retrait. Compte tenu de l'impératif de proportionnalité de toute mesure protectrice des associés minoritaires[5602], une telle exigence d'un vote négatif ne se comprend que dans l'hypothèse où une scission transfrontalière asymétrique ne requiert pas de quorum de présence et de majorité spécifiques[5603]. Cet aspect du droit de retrait montre à nouveau que le législateur européen a voulu supprimer les exigences de majorité spécifiques applicables aux scissions

5593 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 9.
5594 § 29(2) UmwG.
5595 § 196(1) öAktG et § 41 öGmbHG. Voir : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 438.
5596 Sur ce risque, voir : M. NOACK, *op. cit.*, p. 782.
5597 Sur ce risque, voir *supra* n° 1028.
5598 Art. 12:67, § 6 (scissions par absorption) et 12:83, § 6 (scission par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.
5599 Voir *supra* n° 1001.
5600 § 128 UmwG.
5601 § 8(3), 1re phrase SpaltG.
5602 À ce sujet, voir *supra* nos 987 et 988.
5603 À ce sujet, voir *supra* n° 1001.

asymétriques, ce qui est plus conforme à l'exigence de proportionnalité de la mesure engendrée par l'incidence de la liberté d'établissement[5604].

1031. La preuve de l'opposition. La Directive Mobilité prévoit explicitement la possibilité pour les États membres d'exiger que l'opposition expresse au projet de scission et/ou l'intention des associés minoritaires d'exercer leur droit de sortie soient enregistrées au plus tard le jour de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération[5605]. À titre d'illustration, une telle exigence d'enregistrement existe en droit allemand[5606] et en droit autrichien[5607] des fusions transfrontalières et a à plusieurs avantages. Tout d'abord, comme il est également loisible aux titulaires d'actions sans droit de vote de procéder à un tel enregistrement d'opposition formelle[5608], cette exigence permet de résoudre facilement la question des actions sans droit de vote[5609] dont les titulaires ne se prononceront pas nécessairement lors de l'assemblée générale. En outre, elle permet également à la société concernée d'évaluer plus facilement l'impact que l'exercice du droit de retrait aura sur ses liquidités[5610] et ce, au moment de l'approbation de l'opération. Pour finir, comme il n'existe pas nécessairement en droit national d'obligation légale de documenter le vote émis par chaque associé, la preuve pour un associé minoritaire qu'il a voté contre le projet de scission peut s'avérer délicate à rapporter[5611]. Ce dernier avantage explique également pourquoi la Directive Mobilité intègre une disposition spécifique introduite lors du Premier Compromis de la Présidence[5612] et prévoyant que les États membres disposent de la possibilité de permettre de considérer l'enregistrement de l'opposition au projet de scission comme justificatif adéquat d'un vote négatif[5613].

1032. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. La formulation restrictive du législateur européen dans la Directive Mobilité[5614] exigeant une opposition formelle au projet de scission transfrontalière et les règles permettant d'établir une telle opposition sont parfaitement compatibles avec un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. En outre, une telle approche du droit de retrait est davantage conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle en limite l'effet dissuasif et est de plus dans l'intérêt des créanciers car elle restreint l'incidence du droit de retrait sur les liquidités de la société. Certaines précisions relatives à des irrégularités

5604 À ce sujet, voir *supra* n° 1003.
5605 Art. 160*decies*, § 1er, al. 3 de la Directive Mobilité.
5606 § 122i(1) UmwG.
5607 § 10(1) EU-VerschG.
5608 Voir en ce sens : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 781 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439.
5609 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307.
5610 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 307 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 782 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2707.
5611 Voir en ce sens en droit allemand : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 307 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439 ; M. NOACK, *op. cit.*, 782 et H. WICKE, *ibidem*, p. 2707.
5612 Art. 160l, § 1er, al. 2, 2e phrase du Premier Compromis de la Présidence.
5613 Art. 160*decies*, § 1er, al. 3 de la Directive Mobilité.
5614 Art. 160*decies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

affectant l'assemblée générale et l'éventuelle impossibilité pour un associé minoritaire d'y voter contre l'opération qui se retrouvent en droit allemand[5615] et en droit autrichien[5616] mériteraient toutefois d'être intégrées.

4. *L'exigence d'une période de détention minimale*

1033. Une exclusion utile. Lors de la consultation publique de 2015, les syndicats se sont fermement opposés à une harmonisation de la protection des associés minoritaires au motif que ces associés étaient fréquemment des investisseurs à court terme ne méritant pas d'être protégés[5617]. Sans tomber dans un tel extrême, il convient de relever que comme le projet de scission fera l'objet d'une publication au moins un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération[5618], tout associé qui deviendrait titulaire d'actions dans la future société scindée à la suite de cette publication, que ce soit par souscription ou par acquisition, le deviendrait en connaissance de cause et devrait dès lors être exclu du bénéfice du droit de retrait. Une telle exclusion ne se retrouve pas dans la Directive Mobilité, mais présenterait l'indéniable avantage de limiter l'impact du droit de sortie sur les liquidités des sociétés bénéficiaires et correspondrait en outre à la volonté du législateur européen d'encourager l'actionnariat à long terme[5619]. Une limite semblable, quoique plus restreinte, existe déjà en droit allemand où on considère que lorsqu'un associé minoritaire ayant fait part de son intention d'exercer son droit de retrait acquiert des actions additionnelles de la société apporteuse après la tenue de l'assemblée générale mais avant la prise d'effet de l'opération, il ne pourra exercer son droit de retrait à l'égard de ces actions nouvellement acquises[5620]. Cette exclusion est logique car au moment de l'acquisition additionnelle, l'associé acquéreur était pleinement informé de l'opération[5621]. Pour finir, une telle exclusion se justifierait également d'une part, à l'aune de l'impératif de protection des créanciers puisqu'elle limite l'impact du droit de retrait sur les liquidités de la société débitrice et d'autre part, au regard de la liberté d'établissement puisqu'elle renforce la proportionnalité de la mesure. Il s'ensuit que dans le cadre d'un régime européen général des scissions transfrontalières, il serait opportun de prévoir qu'un associé minoritaire ne pourra exercer son droit de retrait qu'à l'égard des seules actions détenues au jour

5615 §§ 29 ; 122i(1), 1re phrase et 125 UmwG et en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 9 et B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 29, nos 11 et 12.

5616 § 234b(3) öAktG (fusions internes) ; § 10(1) EU-VerschG (fusions transfrontalières) et § 9(1) SpaltG (scissions) et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 436.

5617 Consultation publique de 2015, p. 9.

5618 Art. 160*octies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.

5619 Voir directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/3/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 132, 20 mai 2017, pp. 1–25 et Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 12 décembre 2012, Plan d'action : droit européen des sociétés et gouvernance d'entreprise - un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), COM(2012) 740 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (11/06/2020).

5620 B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 29, n° 13.

5621 *Ibidem*.

de la publication du projet commun de scission dans l'État membre de la société scindée.

C. *La nature de la soulte*

1034. La nécessité d'une interprétation large. L'utilisation des termes « *soulte en espèces adéquate* » dans la Directive Mobilité laisse penser que la soulte doit nécessairement prendre la forme d'un paiement en espèces et qu'un paiement en nature ne serait pas envisageable. Une telle interprétation n'est toutefois pas satisfaisante au regard de l'objectif d'un juste équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des associés minoritaires. En effet, le principal inconvénient du droit de retrait n'est autre que son impact sur les liquidités de la société concernée. Afin de minimiser celui-ci, ainsi que son potentiel impact sur la situation des créanciers, il est indispensable de permettre également à la société scindée de payer cette soulte adéquate (i) au moyen d'un paiement en nature moyennant l'accord exprès de l'associé minoritaire concerné[5622] et (ii) par le biais d'une compensation entre la créance détenue par l'associé minoritaire sortant à l'encontre de la société bénéficiaire du fait de l'exercice de ce droit de retrait et toute créance potentiellement détenue par la société bénéficiaire à la suite de la scission à l'encontre de l'associé en question. À titre de comparaison, une telle flexibilité est loin d'être inédite puisque la Directive OPCVM prévoit que les porteurs de parts disposent, non seulement du droit d'exiger le rachat ou le remboursement de leurs parts, mais également, lorsque c'est possible, la conversion de leurs parts en celles d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte[5623]. Une telle interprétation est, en outre, plus conforme à la liberté d'établissement dans la mesure où elle respecte davantage le principe de proportionnalité. En effet, permettre à une société souhaitant réaliser une scission transfrontalière de bénéficier de davantage de flexibilité au niveau du paiement de la soulte aura indéniablement un effet moins dissuasif sur cette dernière que l'obligation de payer nécessairement cette soulte en espèces. Une telle flexibilité est d'autant plus évidente en présence d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante où un *cash-out* au niveau des sociétés bénéficiaires impactera également les créanciers préexistants de celle-ci. En outre, une telle interprétation large est loin d'être inédite puisqu'en droit autrichien des fusions transfrontalières, bien que le texte de loi mentionne explicitement une soulte en espèces (« *Barabfindung* »)[5624], on considère que la soulte en question peut également être payée en nature, comme par exemple par le biais de l'octroi d'actions dans une autre société, à la condition toutefois

[5622] Voir en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 43 et M. FUENTES NAHARRO, *op. cit.*, p. 39 qui relève qu'en droit espagnol, un tel paiement en nature est admis en cas de rachat d'actions pour peu que cette possibilité soit explicitement prévue par les statuts.

[5623] Art. 45, § 1er de la Directive OPCVM.

[5624] § 10(1) EU-VerschG.

que chaque associé minoritaire sortant y ait consenti ou que le paiement en nature soit présenté comme une faculté laissée à la discrétion des associés minoritaires concernés[5625]. Il est dès lors nécessaire d'interpréter les termes de la Directive Mobilité comme imposant à la société scindée de faire une offre de prix exprimée dans la même devise que le capital social de la société scindée, tout en autorisant le recours à d'autres mécanismes de paiement potentiellement moins dommageables tant à la société débitrice qu'à ses créanciers[5626], mais les dispositions de la Directive Mobilité gagneraient à être précisées à cet égard.

D. *La nécessité d'une information préalable*

1035. Une mention indispensable. Afin de garantir une certaine efficacité au droit de retrait, le législateur européen a prévu que le projet de scission devait nécessairement intégrer une description des « modalités d'attribution de la soulte en espèces » à verser aux associés minoritaires pouvant se prévaloir d'un droit de retrait[5627]. Cette disposition, qui laisse sous-entendre que l'offre *qualitate qua* ne doit pas nécessairement être incluse dans le projet de scission, ne peut être interprétée en ce sens[5628]. En effet, les dispositions relatives au droit de retrait précisent clairement que la soulte en espèces doit être mentionnée dans le projet de scission transfrontalière[5629]. Une telle solution s'impose également au regard de la nécessité de protéger les créanciers puisque le délai dont ils disposent pour demander une garantie adéquate commence à courir dès la publication du projet commun de scission[5630] et qu'ils doivent en être informés pour pouvoir, le cas échéant, se prévaloir de l'impact du droit de retrait pour justifier l'octroi d'une garantie[5631]. Une telle solution serait plus à même de garantir le délicat équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des associés minoritaires[5632]. Il s'ensuit que lors de la révision de la Directive Mobilité, le législateur européen serait bien avisé de clarifier cet aspect du projet de scission, *a fortiori* si le champ d'application doit également être étendu aux scissions impliquant plus d'une société préexistante puisque dans une telle hypothèse, les créanciers des sociétés bénéficiaires auront également un intérêt à être parfaitement informés du montant de la soulte qui sera éventuellement versée aux associés de la société scindée.

5625 G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 690, n° 23 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 447.
5626 Voir en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 43.
5627 Art. 160*quinquies*, q) de la Directive Mobilité.
5628 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 69.
5629 Art. 160*quinquies*, § 3 de la Directive Mobilité.
5630 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
5631 Sur la prise en compte des sommes versées dans le cadre de l'exercice du droit de retrait en droit allemand des fusions internes pour justifier l'octroi d'une garantie adéquate aux créanciers, voir : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 13 et G. SEULEN in J. SEMLER et A STENGEL (dir.), *op. cit.*, p. 316, n° 30.
5632 À ce sujet, voir *supra* n° 986.

E. *La nécessité d'une procédure de vérification du prix de rachat*

1036. Plan du point E. Pour pouvoir porter un jugement sur les contours d'une procédure de vérification du prix de rachat (6), il importe en premier lieu de préciser la notion de soulte en espèces adéquate (1), pour ensuite se pencher sur les limites d'une possibilité de contestation (2), ainsi que sur l'effet de la décision de l'autorité compétente en la matière (3). Il conviendra également de s'intéresser à la question du caractère nécessairement favorable aux associés d'une éventuelle révision de la soulte en espèces (4) et à l'opportunité d'assortir une telle procédure de contestation d'un effet suspensif (5).

1. *La notion de soulte en espèces adéquate selon le législateur européen*

1037. Une notion floue. La Directive Mobilité prévoit que la cession doit se faire contre une « soulte en espèces adéquate »[5633]. Cette terminologie se retrouvait déjà dans la Proposition de la Commission[5634] et n'a pratiquement pas évolué au cours du processus législatif[5635]. L'exigence d'adéquation a été interprétée comme signifiant que la soulte en espèces devait nécessairement représenter l'intégralité de la valeur des actions[5636], mais la disposition sur le droit de retrait des associés minoritaires ne contient pas d'autres précisions à cet égard. Cependant, les règles sur l'intervention de l'expert indépendant[5637] permettent d'établir que l'évaluation devra tenir compte du prix de marché des actions dans la société scindée avant l'annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l'effet de la scission envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées[5638]. Ces précisions ont été interprétées comme signifiant qu'une soulte en espèces couvrant uniquement la valeur d'inventaire ou la valeur comptable ne constituait pas une soulte en espèces adéquate[5639]. Par ailleurs, l'exclusion explicite de l'impact de la scission est logique puisque si un associé minoritaire s'oppose à l'opération, il n'y a aucune raison de lui concéder le droit de bénéficier d'évaluations potentiellement favorables tenant compte, à titre d'illustration, de la future suppression de synergies négatives[5640] générées par la scission transfrontalière[5641]. En dehors de ces quelques précisions, il faudra s'en remettre aux différentes pratiques nationales. Pourtant, la question de la détermination du prix de rachat des actions en question est particulièrement délicate[5642] et s'est, à titre d'illustration,

5633 Art. 160*decies*, § 1er de la Directive Mobilité.
5634 Art. 160*terdecies*, § 1er de la Proposition de la Commission.
5635 Seule la Commission de l'emploi et des affaires sociales avait proposé de recourir à la notion de « soulte appropriée » au lieu de « soulte adéquate ». Voir amendement 111 de l'Avis CEAS.
5636 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 70.
5637 Sur le rôle de l'expert indépendant dans le cadre de la protection des associés minoritaires, voir *infra* nos 1055 à 1058.
5638 Art. 160*septies*, § 2 de la Directive Mobilité.
5639 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 211 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 70.
5640 Sur cette notion et l'utilité des scissions transfrontalières à leur égard, voir *supra* nos 43 à 46.
5641 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, pp. 47 qui plaident en faveur d'une « neutralisation de l'impact positif de la fusion » dans le cadre de la détermination du prix de rachat. Voir également en ce sens : M. NOACK, *op. cit.*, p. 783 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 70.
5642 Voir en ce sens : K. GEENS et M. WYCKAERT, *ibidem*, p. 47.

révélée être particulièrement épineuse à l'égard du droit de retrait pour justes motifs en droit belge[5643] avant de faire l'objet de précisions dans le CSA[5644]. La logique voudrait qu'on utilise la même évaluation que celle à laquelle il a été recouru pour déterminer le rapport d'échange[5645]. Cependant, si la raison pour laquelle les associés minoritaires se sont opposés à l'opération tient justement à une évaluation inappropriée des entités impliquées, une telle détermination du prix ne s'avérera que peu satisfaisante[5646].

2. *La possibilité limitée de contester le montant de la soulte en espèces*

1038. Une juste contrepartie. Dans la mesure où les associés minoritaires ne peuvent contester la validité de la décision de l'assemblée générale approuvant la scission transfrontalière au seul motif que la soulte en espèces n'a pas été fixée correctement[5647], les associés ayant fait part de leur décision d'exercer le droit de retrait disposent de la possibilité de réclamer une soulte supplémentaire s'ils estiment que la soulte en espèces n'a pas été fixée correctement[5648]. Une telle possibilité est loin d'être inédite et existe notamment en droit allemand[5649] et en droit autrichien[5650].

1039. Un mécanisme strictement encadré. Compte tenu du fait qu'une réévaluation de la soulte en espèces ne manquera pas d'impacter significativement les conditions de la scission transfrontalière, le législateur européen a très strictement encadré la procédure de contestation. Ainsi, seuls les associés actifs ayant fait part de leur intention d'exercer leur droit de retrait pourront y recourir, ce qui, compte tenu des conditions restrictives en la matière[5651], limitera déjà considérablement les possibilités d'action. Cette limite est similaire à celle qu'on retrouve en droit allemand puisque seuls les associés s'étant opposés à l'opération pourront s'en prévaloir[5652], même si contrairement à ce qui est le cas dans la Directive Mobilité[5653], il n'est pas requis qu'ils aient d'ores et déjà manifesté leur intention d'exercer leur droit de retrait et il suffit qu'ils se soient opposés à l'opération[5654]. Compte tenu du fait que le droit de retrait

5643 Pour une analyse détaillée de cette problématique : R. AYDOGDU, « Les procédures de résolution des conflits internes » in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et Th. TILQUIN, *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 289–297, n° 18 à 23 et R. AYDOGDU et O. CAPRASSE, *op. cit.*, pp. 326 à 329, n°s 633 à 640.

5644 Art. 2:69 du CSA et à ce sujet, voir : R. AYDOGDU, *ibidem*, pp. 298 à 302, n°s 24 à 32.

5645 K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 47.

5646 *Ibidem*.

5647 Art. 160*nonies*, § 5, b) de la Directive Mobilité.

5648 Art. 160*decies*, § 4, al. 1er de la Directive Mobilité.

5649 § 34 UmwG.

5650 § 234b(5), 2e phrase öAktG (fusions internes) ; § 11(2) EU-VerschG (fusions transfrontalières) et § 9(2), 2e phrase SpaltG (scissions internes).

5651 À ce sujet, voir *supra* n°s 1017 à 1032.

5652 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 34, n° 2 et S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 34, n° 12.

5653 Selon l'art. 160*decies*, § 4, al. 1er, 1re phrase de la Directive Mobilité, « tout associé ayant fait part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions » pourra réclamer une soulte en espèces supplémentaires.

5654 En droit allemand, on considère qu'un actionnaire ayant accepté l'offre de soulte adéquate ne dispose plus de la possibilité de contester celle-ci. Voir à ce sujet : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 34, n° 2 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 35, n° 3 et S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 34, n° 11.

instauré par une mesure européenne applicable aux scissions transfrontalières devra nécessairement respecter l'impératif de proportionnalité imposé par le « *Gebhard test* », il est indispensable que celui-ci soit limité au strict nécessaire[5655]. En conséquence, il serait préférable que seuls les associés ayant irrévocablement fait usage de leur droit de retrait puissent contester le caractère adéquat de la soulte en espèces, au risque de voir certains associés minoritaires réserver l'exercice de leur droit de retrait au moment où la soulte en espèces aura été déterminée par la juridiction compétente ce qui, compte tenu des délais assez longs pour une telle procédure[5656], mettra tant les sociétés concernées que leurs créanciers dans une situation d'incertitude quant à l'impact du droit de retrait sur la situation patrimoniale des sociétés issues de l'opération.

3. *L'effet de la décision de l'autorité nationale compétente*

1040. Une large marge de manœuvre pour les États membres. La Directive Mobilité autorise explicitement les États membres à prévoir que la décision rendue par la juridiction compétente sur l'octroi d'une éventuelle soulte additionnelle aura un effet *erga omnes*, en ce sens que tous les associés minoritaires ayant exprimé leur décision d'exercer leur droit de retrait pourront en bénéficier[5657]. Une telle possibilité était absente de la Proposition de la Commission[5658], ce qui avait fait l'objet de certaines critiques notamment en raison du risque de décisions divergentes[5659] ou de considérations liées à l'égalité des associés[5660]. Elle a ensuite fait son apparition dans le Premier Compromis de la Présidence[5661] et est restée dans le Deuxième Compromis de la Présidence[5662], le Compromis des Représentants Permanents[5663], le Compromis Final[5664], la Proposition du Parlement[5665] et la Directive Mobilité[5666]. En outre, à aucun moment le législateur européen ne mentionne la délicate question de l'allocation des coûts d'une telle procédure de contestation. Il s'ensuit qu'il incombera aux différents États membres de décider s'il devrait incomber à la société concernée de supporter le coût d'une telle procédure ou si, au contraire, celui-ci devrait partiellement ou exclusivement affecter les associés minoritaires. L'enjeu de cette question n'est pas anodin car il est évident qu'imposer aux associés minoritaires de supporter l'intégralité du coût d'une procédure à l'encontre de la société aura un fort effet dissuasif et inversement[5667].

5655 Sur ce point, voir *supra* n° 988.
5656 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 31, n° 2.
5657 Art. 160*decies*, § 4, al. 2 de la Directive Mobilité.
5658 Art. 160*terdecies*, § 5 de la Proposition de la Commission.
5659 Voir en ce sens : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16.
5660 R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 614.
5661 24e considérant du Premier Compromis de la Présidence.
5662 Art. 160l, § 3a, al. 2 du Deuxième Compromis de la Présidence.
5663 Art. 160l, § 3a, al. 2 du Compromis des Représentants Permanents.
5664 Art. 160l, § 3a, al. 2 du Compromis Final.
5665 Art. 160*terdecies*, § 4, al. 2 de la Proposition du Parlement.
5666 Art. 160*decies*, § 4, al. 2 de la Directive Mobilité.
5667 ECLE, *op. cit.*, p. 212.

1041. Les enseignements du droit allemand et du droit autrichien. En droit autrichien, la décision rendue par la juridiction compétente aura un effet *erga omnes* et profitera, le cas échéant, à tous les associés ayant exercé leur droit de retrait[5668]. La position en droit allemand est la même[5669]. Cette position se justifie d'une part, en ce qu'elle préserve l'égalité des associés[5670] et, d'autre part, en ce qu'elle évite à la société d'être confrontée à une multitude de demandes séparées[5671]. En outre, il a été avancé qu'elle correspondait au prescrit de la Directive Sociétés qui requiert que la décision prise à l'issue de la procédure sur le droit de retrait ou le droit de contester le rapport d'échange lie l'ensemble des associés[5672]. En revanche, elle renforce l'impact négatif du droit de retrait sur les liquidités et la situation patrimoniale de la société concernée[5673].

1042. Appréciation critique. Une telle option devrait être appréciée avec la plus grande circonspection car la procédure de révision du montant de la soulte par une autorité judiciaire compétente risque de s'avérer longue et incertaine[5674]. En outre, si la soulte en espèces est revue à la hausse, une érosion additionnelle du gage commun des créanciers s'ensuivra et ce, à un moment où il ne leur sera plus possible de demander des garanties adéquates. S'il est certes vrai que l'octroi d'une soulte additionnelle à certains associés ayant fait usage de leur droit de retrait et non à d'autres peut sembler surprenant, il se justifie également par le fait que seuls les associés ayant fait le choix de prendre le risque d'initier des procédures judiciaires et d'en supporter le coût devraient en bénéficier[5675]. Cette position correspond en outre davantage à l'intention du législateur européen qui, dans le cadre de l'élaboration du droit de retrait, a volontairement voulu privilégier les associés actifs[5676] et préserve davantage le double équilibre entre (i) les intérêts des associés minoritaires et ceux de la société[5677] et (ii) les intérêts des associés minoritaires et ceux des créanciers[5678]. En dernier lieu, il convient de remarquer qu'une révision n'ayant un effet qu'*inter partes* sera nécessairement plus proportionnée au regard de l'entrave à la liberté d'établissement qu'elle génère qu'un mécanisme de protection ayant un effet *erga omnes*.

5668 § 9(2) SpaltG (scissions internes) ; §§ 234b(5) et 225i(1) öAktG (fusions internes) ; § 11(2) VerschG (fusions transfrontalières). À ce sujet, voir : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 469 et G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 706, n° 29.
5669 § 13, 2e phrase SpruchG.
5670 M. NOACK, *op. cit.*, p. 785.
5671 *Ibidem*.
5672 Art. 127, § 3, 4e phrase de la Directive Sociétés et en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 29.
5673 M. NOACK, *op. cit.*, p. 785.
5674 DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860.
5675 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 210.
5676 À ce sujet, voir *supra* nos 1027 et 1028.
5677 Sur cet équilibre, voir *supra* n° 985.
5678 Sur cet équilibre, voir *supra* n° 986.

4. *Une révision nécessairement en faveur des associés minoritaires ?*

1043. Quid de la *reformatio in peius* ? Une question intéressante à l'égard de cette procédure en révision du montant de la soulte en espèces est celle de savoir si la juridiction compétente pourrait également décider de revoir le montant de la soulte en espèces à la baisse. À cet égard, la Proposition de la Commission prévoyait exclusivement que les associés minoritaires mécontents pouvaient exiger « un nouveau calcul de la soulte en espèces »[5679], ce qui laissait supposer que la juridiction compétente aurait très bien pu réduire le montant de la soulte en espèces. Cette formulation a été altérée dès le Premier Compromis de la Présidence qui mentionne uniquement le droit pour les associés minoritaires de réclamer « une soulte en espèces supplémentaires »[5680], mais mentionne que la juridiction nationale compétente rendra une décision sur « le caractère adéquat de la soulte en espèces »[5681]. Le Deuxième Compromis de la Présidence est ensuite venu abandonner cette dernière formulation et a précisé que la juridiction nationale compétente rendrait une décision à l'égard de « la soulte en espèces supplémentaire »[5682]. De même, tant le Compromis des Représentants Permanents[5683], que le Compromis Final[5684], la Proposition du Parlement[5685] et la Directive Mobilité[5686] ne mentionnent plus que la possibilité d'une « soulte en espèces supplémentaire », ce qui laisse sous-entendre qu'une révision à la baisse du montant de la soulte en espèces ne serait pas possible.

1044. La solution en droit allemand et en droit autrichien. En droit allemand[5687], la soulte en espèces ne peut être revue à la baisse[5688], quand bien même la juridiction compétente estimerait que la soulte en espèces ainsi offerte est excessive[5689]. Cette interdiction fait l'objet de certaines critiques dans la mesure où elle inciterait la société concernée à systématiquement fournir une première soulte en espèces insuffisante puisque cette dernière constituera irrémédiablement une sorte de seuil absolu en dessous duquel la soulte en espèces ne pourra de toute façon plus tomber[5690]. En droit autrichien, il est également explicitement prévu que la juridiction compétente ne pourra revoir le montant de la soulte en espèces qu'à la hausse[5691].

1045. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. Dans un contexte transfrontalier, une prohibition d'une *reformatio in peius* serait difficilement

5679 Art. 160*terdecies*, § 5 de la Proposition de la Commission.
5680 Art. 160l, § 3a du Premier Compromis de la Présidence.
5681 24e considérant du Premier Compromis de la Présidence.
5682 Art. 160l, § 3a, al. 2 du Deuxième Compromis de la Présidence.
5683 Art. 160l, § 3a du Compromis des Représentants Permanents.
5684 Art. 160l, § 3a du Compromis Final.
5685 Art. 160*terdecies*, § 4 de la Proposition du Parlement.
5686 Art. 160*decies*, § 4 de la Directive Mobilité.
5687 § 11 SpruchG.
5688 À ce sujet, voir M. NOACK, *op. cit.*, p. 785 et P. MENNICKE in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 11 SpruchG, n° 2.
5689 P. MENNICKE in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 11 SpruchG, n° 2.
5690 M. NOACK, *op. cit.*, p. 785.
5691 § 234b(5), 2e phrase (fusions internes) ; § 11(2), 1re phrase EU-VerschG (fusions transfrontalières) et § 9(2), 2e phrase SpaltG (scissions internes). À ce sujet, voir : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 461 et 462, n° 87 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 469.

justifiable à l'aune de l'entrave qu'elle génère à la liberté d'établissement des sociétés concernées[5692]. Il serait en effet très difficile d'argumenter qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une protection adéquate aux associés minoritaires concernés puisque même en l'absence de celle-ci, les associés minoritaires disposent d'un mécanisme les protégeant contre une soulte en espèces fixée abusivement par les associés majoritaires, sans mentionner le fait que la soulte en question fera, en tout état de cause, l'objet d'un contrôle par l'expert indépendant intervenant au cours de la procédure de scission[5693]. *A contrario*, prohiber toute revue à la baisse du montant de la soulte en espèces revient, au contraire, à inciter les associés minoritaires à tenter leur chance en initiant malgré tout une procédure. Ceci ne manquerait pas d'avoir, en présence de nombreux associés minoritaires très actifs, un effet dissuasif sur la société concernée, sans que cela ne soit nécessaire pour assurer une protection adéquate aux associés minoritaires. Il en découle qu'il serait préférable de prévoir que le montant de la soulte en espèces pourra être revu par la juridiction compétente, sans prohiber une éventuelle revue à la baisse, de manière à dissuader les associés minoritaires souhaitant profiter de l'opération pour extorquer davantage de liquidités à la société, ce qui ne manquerait pas de nuire, par ricochet, aux intérêts des créanciers de la société concernée.

5. *L'effet suspensif d'une procédure de contestation sur la procédure de scission*

1046. L'absence d'effet suspensif. Si le trente-septième considérant de la Directive Mobilité s'en remet clairement aux différents États membres pour la détermination des conséquences sur la délivrance du certificat préalable à la réalisation de la scission qu'une procédure engagée par les associés minoritaires devrait avoir, il est clair que dans l'esprit du législateur européen, la procédure de vérification du prix de rachat n'a, *a priori*, pas d'effet suspensif. Ceci correspond par ailleurs à la solution consacrée à l'origine dans le régime des fusions transfrontalières[5694] et se voit au fait que pour la délivrance du certificat de conformité, l'autorité compétente a uniquement besoin de la preuve que la procédure de révision a débuté[5695], et non de celle que la procédure a été clôturée. Cette position, bien qu'elle n'ait pu être imposée aux différents États membres, est indéniablement plus conforme à l'exigence de proportionnalité et à la nécessité de parvenir à un délicat équilibre entre les intérêts de la société et des associés minoritaires. En effet, s'il a pu être avancé qu'un effet suspensif était souhaitable en raison du fait qu'à défaut, les associés minoritaires seraient contraints de prendre la décision de quitter la société concernée sans connaître le montant final de la soulte en espèces qui leur sera allouée[5696], il convient de ne pas perdre de vue que l'objectif du droit de retrait est exclusivement de permettre aux associés opposés à l'opération de quitter la société

[5692] Voir en ce sens : M. NOACK, *op. cit.*, p. 785.
[5693] Art. 160*septies*, § 2 de la Directive Mobilité.
[5694] Art. 127, § 3, 2e phrase de la Directive Sociétés.
[5695] Art. 160*quaterdecies*, § 6, b) de la Directive Mobilité.
[5696] DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860.

contre une juste rémunération, et non de leur permettre de décider si la soulte en espèces qui leur est offerte est économiquement intéressante ou non. En outre, permettre aux associés minoritaires de bloquer une opération potentiellement essentielle à la survie de la société, ou à tout le moins importante pour son développement économique, pendant une durée indéterminée, irait indéniablement au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur protection, et risquerait même d'aboutir à des comportements abusifs. Par ailleurs, lors de la consultation de 2015, l'octroi aux associés minoritaires du droit de bloquer une fusion transfrontalière a été très largement rejeté[5697]. Il serait donc particulièrement surprenant de réintroduire un tel droit indirectement par le biais de l'effet suspensif d'une procédure de contestation du montant de la soulte en espèces et une telle solution est en tout état de cause à bannir d'un régime européen applicable aux scissions transfrontalières.

6. Appréciation critique

1047. Une approche nécessairement restrictive. La procédure de contestation envisagée par la Directive Mobilité laisse une large marge de manœuvre aux États membres pour limiter considérablement l'impact de celle-ci[5698]. Il s'agit là de la position qui devrait être suivie par les États membres pour éviter autant que possible qu'une révision du montant de la soulte en espèces ne vienne excessivement affaiblir la position des créanciers de la société scindée. En effet, la seule raison d'être de cette procédure est d'éviter qu'un rapport d'expert négatif sur le montant de la soulte en espèces soit sans conséquences pour les sociétés impliquées et, par conséquent, de garantir une certaine équité quant au montant proposé pour les autres associés. Une approche restrictive à cet égard s'impose d'autant plus en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante dans la mesure où une révision du montant de la soulte en espèces affectera non seulement la position des créanciers de la société scindée mais également, le cas échéant, celle des créanciers existants des sociétés bénéficiaires. En vue d'une part, d'éviter des procédures abusives de la part d'associés minoritaires souhaitant bénéficier d'une porte de sortie à des conditions plus avantageuses que celles du marché et, d'autre part, de ne pas encourager les associés majoritaires à spolier les associés minoritaires par le biais d'une opération transfrontalière, il aurait en outre été bon de préciser davantage l'articulation entre le rapport d'expert indépendant et la procédure de révision de la soulte en espèces en indiquant qu'en présence d'un rapport d'expert positif, la soulte en espèces figurant dans le projet de scission sera présumée adéquate jusqu'à preuve du contraire et inversement en cas de rapport d'expert négatif[5699]. De telles présomptions assureraient indubitablement un meilleur équilibre entre les intérêts de la société et ceux des associés minoritaires et justifieraient en outre davantage le coût engendré par l'obligation

[5697] Consultation publique de 2015, p. 10 et en faveur d'un tel rejet : T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1167.

[5698] M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 70.

[5699] Sur le rôle de l'expert indépendant dans le cadre de la protection des associés minoritaires, voir *infra* n°s 1055 à 1058.

de faire examiner le montant de la soulte en espèces par l'expert indépendant[5700]. Il convient toutefois encore de préciser qu'en attendant une nouvelle initiative du législateur européen en la matière, les États membres demeurent libres d'instaurer de telles présomptions en raison (i) du caractère résolument *a minima* de l'harmonisation prônée par le législateur européen en matière de protection des associés minoritaires[5701] et (ii) du fait que ces présomptions, par leur caractère réfragable, ne diminueraient en rien le niveau de protection des associés minoritaires. En outre, l'instauration de telles présomptions aurait également pour avantage de renforcer la proportionnalité de l'entrave générée à la liberté d'établissement par l'octroi d'un droit de retrait[5702].

F. *La nécessité d'une règle de droit international privé*

1048. Une règle logique. Tant la Proposition de la Commission[5703], que le Premier Compromis de la Présidence[5704], le Deuxième Compromis de la Présidence[5705], le Compromis des Représentants Permanents[5706], le Compromis Final[5707], la Proposition du Parlement[5708] et la Directive Mobilité[5709] prévoient que le droit de l'État membre de la société scindée devra trouver à s'appliquer à l'exercice du droit de retrait, en ce compris le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire et que les juridictions de l'État membre de la société scindée disposeront à cet égard d'une compétence exclusive. La remarque faite par certains auteurs à l'encontre de la Proposition de la Commission[5710] selon laquelle il aurait été bon de prévoir qu'il s'agissait là d'une compétence exclusive[5711] a été prise en compte dès le Premier Compromis de la Présidence[5712]. Cette règle appropriée[5713] est logique dans la mesure où le droit de sortie a été instauré par le législateur européen en vue de protéger les associés minoritaires contre un éventuel changement de droit national applicable[5714]. En outre, la règle de conflit de lois évite en tout état de cause que les associés majoritaires ne se soustraient trop aisément au droit national applicable à la société

5700 Art. 160*septies*, § 2, al. 1er de la Directive Mobilité.
5701 À ce sujet, voir *infra* nos 1089 à 1091.
5702 Au sujet de l'incidence de la liberté d'établissement sur la protection des associés minoritaires, voir *supra* nos 987 et 988.
5703 Art. 160*terdecies*, § 6 de la Directive Mobilité.
5704 Art. 160l, § 6 du Premier Compromis de la Présidence.
5705 Art. 160l, § 6 du Deuxième Compromis de la Présidence.
5706 Art. 160l, § 6 du Compromis des Représentants Permanents.
5707 Art. 160l, § 6 du Compromis Final.
5708 Art. 160*terdecies*, § 5 de la Proposition du Parlement.
5709 Art. 160*decies*, § 5 de la Directive Mobilité.
5710 Art. 160*terdecies*, § 6 de la Proposition de la Commission.
5711 Voir en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, pp. 2257 et 2258.
5712 Art. 160l, § 6 de la Proposition de la Commission.
5713 Voir en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2257 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 309 ; ECLE, *op. cit.*, p. 213 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 581 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 257 et 258 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 293.
5714 Voir en ce sens : ECLE, *ibidem*, p. 213 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 70.

scindée, ainsi qu'aux mécanismes de protection consacrés par ce dernier[5715]. La règle de compétence se justifie d'une part par le fait que la protection des associés minoritaires concerne avant tout un problème interne à la société[5716] et, d'autre part, par l'avantage que le juge compétent applique son propre droit national[5717]. Elle correspond en outre à la jurisprudence récente de la Cour de justice à l'égard du contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie dans le cadre d'une procédure d'éviction des actionnaires minoritaires[5718]. De plus, elle est parfaitement compatible avec un régime des scissions transfrontalières par acquisition ou mixtes et correspond à la règle applicable en cas de fusion par acquisition[5719].

G. *La personne de l'acheteur*

1049. La position flexible de la Commission. La Proposition de la Commission prévoyait à l'origine que le rachat des participations de l'associé minoritaire sortant pouvait être effectué tant par la société scindée elle-même que par les associés restants de cette société ou même des tiers, pour peu que cela soit en accord avec la société scindée[5720]. Cette solution particulièrement flexible avait été accueillie très favorablement par bon nombre d'auteurs[5721]

5715 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2257.

5716 *Ibidem* ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 257 et 258 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2441.

5717 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *ibidem*, p. 2257 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 309 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, pp. 257 et 258 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *ibidem*, p. 238 et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2441.

5718 C.J., arrêt *E. ON Czech Holding AG c. Michael Dědouch, Petr Streitber et Pavel Suda*, 7 mars 2018, C-560/16, EU:C:2018:167, pt. 45 dans lequel la Cour de justice a considéré que « l'article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 [actuel article 24, point 2 du Règlement Bruxelles I*bis*] doit être interprété en ce sens qu'un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet le contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l'actionnaire principal d'une société est tenu de verser aux actionnaires minoritaires de celle-ci en cas de transfert obligatoire de leurs actions à cet actionnaire principal, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'état membre sur le territoire duquel cette société est établie ». Voir en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *ibidem*, p. 2257 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 309 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 581 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *ibidem*, pp. 257 et 258 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *ibidem*, p. 238 et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2441.

5719 Art. 126*bis*, § 5 de la Directive Mobilité et en ce sens à propos des fusions transfrontalières : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *ibidem*, pp. 2257 et 2258.

5720 Art. 160*terdecies*, § 2 de la Proposition de la Commission selon lequel : « [l]es États membres veillent à ce que les associés visés au paragraphe 1 puissent disposer de leurs participations, en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée, une fois que la scission transfrontalière a pris effet conformément à l'article 160*unvicies* vis-à-vis des parties suivantes : (a) la société scindée ; (b) les associés restants de cette société ; (c) les tiers, en accord avec la société scindée ».

5721 Voir également en faveur d'une telle extension : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2257 ; F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 44 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 256 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von

et se justifiait notamment en raison du fait que la personne de l'acquéreur est sans importance pour l'associé minoritaire exerçant son droit de retrait[5722]. À travers le prisme de la protection des créanciers, une telle latitude s'impose également. En effet, prévoir que les participations d'associés minoritaires sortants puissent être rachetées également par les associés souhaitant rester dans la société et les tiers permet d'éviter que ce mécanisme de protection des intérêts des associés minoritaires n'entraîne une érosion du gage commun des créanciers. Malheureusement, cette flexibilité, qui aurait en outre permis de mieux tenir compte des différences existant entre les traditions juridiques des États membres à cet égard[5723], a disparu dès le Premier Compromis de la Présidence[5724] et n'est pas réapparue par la suite[5725]. Cependant, rien n'empêchera un État membre de la réintroduire au moment de la transposition nationale de la Directive Mobilité[5726]. À titre d'illustration, une telle flexibilité existe en droit autrichien des fusions transfrontalières où il est expressément prévu que la soulte en espèces adéquate peut également être offerte par un tiers[5727].

1050. Une énumération alternative ou cumulative ? À l'égard des dispositions de la Proposition de la Commission, il a été relevé qu'il n'était pas clair s'il

Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 237. Pour un point de vue plus sceptique, voir : ECLE, *op. cit.*, p. 211 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440 et M. NOACK, *op. cit.*, p. 782.

5722 Voir en ce sens : G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 14, n° 41.

5723 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308.

5724 Art. 160l, § 2 du Premier Compromis de la Présidence.

5725 Les dispositions l'article 160*decies*, §§ 1–4 de la Directive Mobilité relatives au droit de retrait prévoient ainsi uniquement que : « [l]es États membres veillent à ce qu'au moins les associés d'une société scindée qui ont voté contre l'approbation du projet de scission transfrontalière aient le droit de céder leurs actions en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, à condition qu'à la suite de la scission transfrontalière, ils acquièrent des actions des sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d'un autre État membre que celui de la société scindée. Les États membres peuvent également prévoir que d'autres associés de la société scindée bénéficient du droit visé au premier alinéa.
Les États membres peuvent exiger que l'opposition expresse au projet de scission transfrontalière, l'intention des associés d'exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l'assemblée générale visée à l'article 160*nonies*. Les États membres peuvent permettre que l'enregistrement de l'opposition au projet de scission transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d'un vote négatif.
2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société scindée leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l'assemblée générale visée à l'article 160*nonies*. Les États membres veillent à ce que la société scindée fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique.
3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de scission transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d'effet de la scission transfrontalière conformément à l'article 160*octodecies*.
4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n'a pas été fixée correctement ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l'autorité ou de l'organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire ».

5726 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308.

5727 § 10(1) EU-VerschG.

s'agissait d'une énumération cumulative ou alternative[5728]. Il est possible de résoudre cette question par le biais du prisme de la protection des créanciers. En effet, compte tenu de l'érosion financière que le droit de retrait est susceptible d'engendrer, il serait logique de privilégier la solution limitant autant que faire se peut cet impact. Il s'ensuit que le rachat par la société scindée ne devrait constituer qu'une solution d'ultime recours. Par ailleurs, une telle flexibilité renforcerait la proportionnalité de la mesure au regard de la liberté d'établissement. En outre, afin d'éviter les limites liées à d'éventuelles restrictions légales[5729] ou conventionnelles[5730] applicables aux cessions d'actions à des tiers, il serait logique de privilégier la cession aux associés existants. De plus, afin de limiter encore davantage l'érosion patrimoniale engendrée par le droit de retrait, il serait utile que dans le cadre d'une scission impliquant plus d'une société préexistante, les actions des associés sortants de la société scindée puissent également être rachetées par les associés des sociétés bénéficiaires. Il est certes possible d'inclure ces derniers parmi les potentiels tiers acquéreurs, cependant, compte tenu de leur caractère interne à l'opération, il serait logique de les faire bénéficier d'un droit de priorité. En conséquence, une révision de la Directive Mobilité en vue d'intégrer un régime spécifique applicable aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante devrait établir un ordre hiérarchique parmi les personnes autorisées à acquérir les actions des associés minoritaires de la société scindée faisant usage de leur droit de retrait. Ainsi, les actions en question devraient être offertes en priorité aux associés de la société scindée, puis aux associés des sociétés bénéficiaires, ensuite à d'éventuels tiers acquéreurs et, à défaut, obligatoirement rachetées par la société scindée. En effet, étant donné qu'il n'est pas concevable de forcer les associés restants[5731] ou des tiers[5732] à procéder à un tel rachat, il est logique que seule la société scindée assume une véritable obligation d'achat.

1051. Une précision utile. En droit autrichien des fusions transfrontalières, il est expressément prévu que des restrictions statutaires à la libre cessibilité des actions ne sont pas opposables à l'associé s'étant opposé à l'opération entre la date de l'assemblée générale s'étant prononcée sur la fusion et la date d'écoulement du délai d'exercice du droit de retrait[5733]. Une telle précision se retrouve également en droit allemand[5734]. Du point de vue des associés sortants, cette disposition est avantageuse car elle leur permet de céder leurs actions à des tiers pour un prix déterminé librement et, par conséquent,

[5728] Voir à ce sujet et en faveur d'une énumération cumulative : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2257 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 782 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 237.

[5729] À titre d'illustration, voir art. 5:63 du CSA et art. 710-12 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales pour ce qui est de l'exigence d'un agrément en cas de cession à des tiers de parts sociales d'une SRL / S. à r.l.

[5730] À titre d'illustration, ce serait le cas en présence d'un pacte d'actionnaires contenant une clause de premier refus ou d'incessibilité. Sur la licéité de telles clauses, voir notamment art. 5:67 et art. 7:78 à 7:81 du CSA et art. 430-1, § 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

[5731] K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 48.

[5732] N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2257.

[5733] § 10(3) EU-VerschG.

[5734] § 33 UmwG.

potentiellement supérieur à la soulte en espèces figurant dans le projet commun[5735]. Du point de vue de la société et des créanciers, augmenter ainsi la liquidité des actions permet (i) de renforcer les chances que les associés minoritaires sortants n'aient pas à faire racheter leurs actions par la société concernée et (ii) de limiter l'impact du droit de retrait sur les créanciers de la société concernée. Une telle exclusion aurait dès lors indéniablement un certain intérêt dans un régime européen général des scissions transfrontalières.

H. *La requalification de l'associé minoritaire sortant en créancier chirographaire*

1052. Un élément de passif à allouer. La Directive Mobilité précise que l'offre de soulte en espèces doit être faite par la société scindée[5736] puisque c'est à cette dernière que les associés sortants doivent déclarer leur intention d'exercer leur droit de sortie[5737]. En revanche, au niveau du délai de paiement du prix de rachat, la Directive Mobilité vient préciser que les États membres fixeront celui-ci, mais qu'il devra en tout état de cause prendre fin au plus tard deux mois après la date de prise d'effet de l'opération[5738]. Il s'ensuit que la dette devra être allouée aux sociétés issues de l'opération conformément à la clé de répartition prévue dans le projet de scission[5739] ou, à défaut, conformément à la règle applicable aux éléments oubliés ou inconnus[5740]. En d'autres termes, dans l'esprit du législateur européen, à la date de prise d'effet de l'opération, le droit de rachat aura déjà dû être exercé, de sorte que les associés sortants seront devenus, au moment de la date de prise d'effet de l'opération, des créanciers de la société scindée[5741] bénéficiant, le cas échéant, de la solidarité passive des sociétés bénéficiaires de l'opération[5742] et même potentiellement du droit de demander une garantie adéquate[5743] puisque le délai pour ce faire est de trois mois à compter de la publication du projet de scission[5744]. À cet égard, il est intéressant de relever qu'en droit autrichien des fusions transfrontalières, une garantie doit obligatoirement être fournie à l'actionnaire sortant exerçant son droit de retrait et cette garantie doit couvrir non seulement le montant de la soulte en espèces, mais également les coûts liés au rachat d'actions[5745]. Cette volonté du législateur européen de transformer les associés minoritaires en créanciers chirographaires de la société scindée s'identifie clairement par trois indices distincts. Tout d'abord, dans le cadre de la description des effets

5735 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 460.
5736 Voir en ce sens à propos du Premier Compromis de la Présidence : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 70.
5737 Art. 160*decies*, § 2 de la Directive Mobilité.
5738 Art. 160*decies*, § 3 de la Directive Mobilité.
5739 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 70.
5740 Art. 160*novodecies*, § 4 de la Directive Mobilité et sur le traitement spécifique des éléments du patrimoine de la société scindée oubliés ou inconnus, voir *supra* n°s 496 à 498.
5741 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 70.
5742 Art. 160*undecies*, § 2 de la Directive Mobilité et sur ce mécanisme de protection des créanciers, voir *supra* n°s 780 à 789.
5743 Sur ce mécanisme de protection des créanciers, voir *supra* n°s 767 à 779.
5744 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
5745 § 10(1), 5e phrase EU-VerschG.

de la scission transfrontalière, il est clairement précisé que les associés de la société scindée deviendront associés des sociétés bénéficiaires, « à moins qu'ils n'aient cédé leurs actions comme visé à l'art. 160*decies*, paragraphe 1er »[5746]. En d'autres termes, s'ils font usage de leur droit de sortie, les associés minoritaires verront leurs actions rachetées nécessairement avant la date de prise d'effet de la scission. Deuxièmement, cette volonté se distingue également dans l'articulation des différents délais prévus par la Directive Mobilité[5747]. En effet, les associés doivent déclarer au plus tard un mois après la date de l'assemblée générale leur intention d'exercer leur droit de sortie[5748] et l'autorité nationale compétente pour le contrôle de conformité dispose d'un délai de base de trois mois à compter de la date de réception des documents et informations concernant l'approbation de la scission transfrontalière par l'assemblée générale pour effectuer son contrôle[5749]. Ceci implique que la société scindée sera en mesure d'effectuer le rachat bien avant la fin du contrôle de conformité. Troisièmement, dans le cadre de la disposition anti-abus, il est précisé que pour garantir que l'opération transfrontalière ne lèse pas les créanciers de la société, l'autorité compétente devrait avoir la possibilité de contrôler que les obligations en cours de la société scindée sont suffisamment garanties[5750], sans mentionner la nécessité de veiller à ce que l'opération ne lèse pas abusivement ou frauduleusement les intérêts des associés minoritaires. Cette omission est toutefois logique si on considère qu'au moment du contrôle, les associés minoritaires sortants sont à considérer comme des créanciers de la société scindée et l'obligation de verser la soulte en espèces est à considérer comme une obligation en cours. En définitive, il est également intéressant de relever que cette interprétation est la seule qui soit véritablement conforme à la *ratio legis* du droit de retrait. En effet, comme celui-ci vise avant tout à protéger les associés minoritaires contre un changement de *lex societatis* qui leur serait imposé par les associés majoritaires[5751], il est logique que ceux-ci ne soient pas exposés à des règles relatives à l'acquisition d'actions propres relevant d'un droit national distinct[5752]. Un tel choix se justifie d'autant plus en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante puisque dans une telle hypothèse les associés minoritaires sortant de la société scindée pourraient se retrouver confrontés à plusieurs droits nationaux distincts potentiellement plus restrictifs et être face à des sociétés bénéficiaires ayant un actif net négatif, contrairement à ce qui serait le cas dans l'hypothèse d'une scission n'impliquant qu'une seule société préexistante.

5746 Art. 160*novodecies*, § 1er, b) de la Directive Mobilité. Voir également : art. 160*novodecies*, § 2, b) de la Directive Mobilité pour les scissions partielles.
5747 Sur les aspects temporels de la protection des associés minoritaires, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section 7.
5748 Art. 160*decies*, § 2, 2e phrase de la Directive Mobilité.
5749 Art. 160*quaterdecies*, § 7 de la Directive Mobilité.
5750 39e considérant, 1re phrase de la Directive Mobilité.
5751 Sur ce risque, voir *supra* n° 982.
5752 Sur cette problématique en droit autrichien, voir : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 454.

I. *L'exclusion des sociétés cotées*

1053. Une liquidité de principe. En droit allemand, où un tel droit de sortie pour les associés minoritaires existe[5753], la question de la nécessité d'offrir une soulte en espèces adéquate dans le cadre d'une fusion transfrontalière impliquant une société cotée en tant que société absorbée s'est posée dans la mesure où les actions en question bénéficient d'une liquidité de principe[5754]. En outre, l'obligation de racheter même un faible pourcentage de l'actionnariat d'une société cotée est susceptible d'avoir un impact considérable sur les liquidités de celle-ci[5755]. Il a ainsi été avancé qu'un droit de retrait ne devrait pas trouver à s'appliquer dans l'hypothèse d'une fusion transfrontalière d'une société cotée au profit d'une autre société[5756]. Compte tenu de l'impact positif qu'une telle cession sur le marché aurait pour les liquidités des sociétés concernées et, par ricochet, la situation des créanciers, une telle solution se doit d'être encouragée si le législateur européen ne devait pas faire preuve de flexibilité à l'égard de l'identité de l'acquéreur des actions de l'associé sortant[5757]. Cependant, cette dernière solution ne prévaut pas en droit allemand et les sociétés cotées n'ont pas fait l'objet d'une exclusion[5758]. En effet, le principe applicable à la matière est le *Meistbegünstigungsprinzip* selon lequel (i) le cours de bourse constitue la valeur plancher et (ii) la soulte en espèces attribuée, généralement supérieure au cours de bourse, est déterminée sur la base de la valeur de rendement[5759].

1054. La position du législateur européen. Une telle exception pour les sociétés cotées n'apparaît pas dans la Directive Mobilité. Cependant, dans un souci de protection des intérêts des créanciers en limitant autant que possible l'impact sur les liquidités des sociétés concernées du droit de retrait pour les associés minoritaires, il serait indéniablement utile de prévoir que les actionnaires d'une société cotée ne pourront en bénéficier. À titre d'illustration, une telle exclusion se retrouve en droit belge à l'égard de la procédure d'exclusion-retrait[5760]. En outre, il convient de relever qu'à l'aune de la liberté d'établissement, on peut s'interroger tant sur la nécessité de protéger les associés minoritaires dans une telle hypothèse que sur le caractère proportionné d'un droit de retrait octroyé aux actionnaires minoritaires d'une société cotée alors qu'une cession sur le marché est en tout état de cause beaucoup moins intrusive[5761].

5753 §§ 29 et 122i UmwG.
5754 Voir à ce sujet : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 6 et T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1162.
5755 Voir en ce sens : G. KEUTGEN et J.-F. TOSSENS, *op. cit.*, p. 146, n° 51.
5756 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 6 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 844 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 781 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 623.
5757 Sur la nécessité d'une telle flexibilité, voir *supra* n°s 1049 à 1051.
5758 À ce sujet, voir R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 2 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440.
5759 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2440.
5760 Art. 2:60 du CSA.
5761 Voir en ce sens : N. NOHLEN, *op. cit.*, p. 235.

§ 4. L'intervention de l'expert indépendant

1055. L'intervention de l'expert indépendant. Comme la Directive Mobilité interdit strictement aux États membres de permettre aux associés minoritaires de contester la validité de la décision de l'assemblée générale de procéder à la scission transfrontalière sur la base du motif que le rapport d'échange[5762] ou encore la soulte en espèces[5763] n'ont pas été fixés correctement, ou encore que les informations concernant le rapport d'échange ou la soulte en espèces ne sont pas conformes au prescrit légal[5764], le législateur européen a eu recours à une « *gatekeeper approach* »[5765] en imposant à l'expert indépendant de se prononcer sur le caractère adéquat tant du rapport d'échange que de la soulte en espèces[5766]. Cette approche, que l'on retrouve dans le régime des scissions internes consacré par la Directive Sociétés à l'égard du rapport d'échange[5767], attribue un rôle important à l'expert indépendant puisque celui-ci devra nécessairement vérifier que le rapport d'échange tel qu'établi dans le projet commun n'entraîne pas un net désavantage d'un des associés[5768]. Pour ce qui est du contrôle du montant de la soulte en espèces, une telle fonction est également attribuée à l'expert indépendant en droit allemand[5769] et en droit autrichien[5770].

1056. Une insuffisance de la Proposition de la Commission. Il est intéressant de relever qu'à l'origine, la Proposition de la Commission ne prévoyait une intervention de l'expert indépendant au niveau de la vérification du montant de la soulte en espèces que dans le cadre des fusions transfrontalières[5771]. Ce point avait été vivement critiqué par la doctrine[5772] et a, fort heureusement, été rectifié dès le Premier Compromis de la Présidence[5773] pour ne plus changer au cours du processus législatif[5774].

5762 Art. 160*nonies*, § 5, a) de la Directive Mobilité.
5763 Art. 160*nonies*, § 5 b) de la Directive Mobilité.
5764 Art. 160*nonies*, § 5 c) de la Directive Mobilité.
5765 Sur cette notion dans le cadre de la protection des créanciers, voir *supra* n° 929.
5766 Art. 160*septies*, § 2 de la Directive Mobilité.
5767 Art. 96, §§ 2 et 3 et art. 142 de la Directive Sociétés.
5768 Art. 2.4.6. de la norme de l'IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, https://www.ibr-ire.be (01/09/2021).
5769 §§ 30 (2) ; 122i (1) et 125 UmwG et à ce sujet : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 237 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440.
5770 § 220b(2) öAktG (fusions internes) ; § 5(4) SpaltG (scissions internes) et § 7(3) EU-VerschG (fusions transfrontalières).
5771 Art. 86*octies* (transformations transfrontalières) ; 126*bis*, § 5 (fusions transfrontalières) et 160*decies* (scissions transfrontalières) de la Proposition de la Commission.
5772 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 363 ; ECLE, *op. cit.*, p. 212 ; M. FUENTES NAHARRO, *op. cit.*, p. 39 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 257 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2707.
5773 Art. 160i, § 2 du Premier Compromis de la Présidence.
5774 Art. 160i, § 2 du Deuxième Compromis de la Présidence ; art. 160i, § 2 du Compromis des Représentants Permanents ; art. 160i, § 2 du Compromis Final ; art. 160*decies*, § 2 de la Proposition du Parlement et art. 160*septies*, § 2 de la Directive Mobilité.

1057. L'incidence du régime de responsabilité de l'expert indépendant. L'efficacité du régime de protection des associés minoritaires par le biais de l'intervention de l'expert indépendant est en outre renforcée par (i) le régime de responsabilité spécifique de l'expert indépendant[5775] prôné par le législateur européen dans la Directive Mobilité[5776], ainsi que (ii) l'obligation pour les États membres de mettre en place certaines règles garantissant l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité de l'expert indépendant[5777].

1058. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. Du point de vue de la protection des associés minoritaires, l'intervention de l'expert indépendant permettra non seulement d'informer en temps utile les associés minoritaires sur un rapport d'échange ou une soulte en espèces incorrects, mais également d'inciter les associés majoritaires à privilégier les solutions équitables[5778]. Ce mécanisme de protection présente à la fois l'avantage d'être proportionné car très peu intrusif et d'être indirectement dans l'intérêt des créanciers[5779] puisqu'il est susceptible de permettre d'éviter que trop d'associés minoritaires ne fassent usage de leur droit de retrait. Dans un même ordre d'idées, l'intervention de l'expert indépendant permettra de limiter les incertitudes liées à des procédures initiées par des associés minoritaires mécontents du rapport d'échange ou de la soulte en espèces adéquate, puisque le caractère approprié de ces derniers sera nécessairement plus délicat à contester en présence d'un rapport d'expert positif[5780]. Il s'ensuit que l'intervention de l'expert indépendant permet, dans une certaine mesure, de renforcer la proportionnalité d'autres mécanismes de protection des associés minoritaires.

§5. Le droit de contester le rapport d'échange

1059. Plan du § 5. Afin de pouvoir tirer une conclusion sur l'utilité de prévoir une possibilité pour les associés minoritaires de contester le caractère adéquat du rapport d'échange en cas de scission transfrontalière (I), il convient, après avoir présenté le principe et les limites intrinsèques à ce mécanisme de protection (A), de clarifier la notion de rapport d'échange qui, dans le cas particulier des scissions, est susceptible de recouvrir également la répartition des actions nouvellement émises au cours de l'opération (B), de s'interroger sur le champ d'application *ratione personae* de ce droit (C) ainsi que sur l'éventuel effet *erga omnes* d'un jugement rendu en la matière (D) et sur la possibilité d'une révision potentiellement défavorable aux associés minoritaires demandeurs (E). Il sera ensuite nécessaire de se pencher sur la nécessité d'introduire une certaine flexibilité au niveau de la méthode de compensation d'un rapport d'échange jugé inadéquat (F), ainsi que sur l'incidence de l'absence d'harmonisation des

5775 Voir en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2256.
5776 Art. 160*unvicies*, § 1er de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *supra* n° 564.
5777 Art. 160*unvicies*, § 2 de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *supra* n° 564.
5778 Voir en ce sens : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 68 et 69, n° 3. Sur le rôle général de l'expert indépendant, voir *supra* nos 572 à 582.
5779 Voir en ce sens : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, pp. 68 et 69, n° 5.
5780 Sur les présomptions qui devraient découler d'un rapport d'expert positif ou négatif, voir *supra* n° 1047.

règles d'évaluation au sein des États membres (G) et sur la nécessité d'assortir ce mécanisme de protection d'une règle de droit international privé (H).

A. *Principe et limites*

1. *Un mécanisme connu*

1060. L'impact d'un rapport d'échange inadéquat. S'il s'avère que le rapport d'échange a été fixé de manière inadéquate, une catégorie d'associés sera nécessairement excessivement diluée[5781]. Si ce risque est moindre dans le cadre d'une scission par constitution de nouvelles sociétés dans la mesure où les sociétés bénéficiaires ne disposent pas d'un actionnariat existant, la question se posera de manière beaucoup plus aiguë dans le cadre d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante[5782]. En effet, dans le cadre de cette dernière, plusieurs groupes d'associés distincts risquent d'encourir une certaine forme de spoliation du fait d'un rapport d'échange fixé de manière inadéquate. Face à ce risque, le législateur européen, tenant en cela compte de la préférence du Parlement européen dans sa résolution de 2017[5783], a introduit un droit pour les associés minoritaires de contester le rapport d'échange prévu dans le projet de scission en raison de son insuffisance auprès d'une autorité nationale et de réclamer une soulte en espèces additionnelle[5784].

1061. Un mécanisme existant en droit allemand et autrichien. Ce mécanisme de protection, bien que peu répandu parmi les différents États membres[5785], est toutefois loin d'être inédit et existe notamment en droit allemand[5786] et en droit autrichien[5787]. Il est la contrepartie directe de l'impossibilité de contester la validité de la décision de l'assemblée générale au seul motif que le rapport d'échange n'a pas été fixé de manière appropriée[5788], et va dès lors dans le sens d'un renforcement de la sécurité juridique.

1062. Un mécanisme proportionné. S'il est intéressant de relever que la Cour de justice n'a pas encore eu à traiter de la possible justification d'une entrave à la liberté d'établissement dans un souci de protection de tous les associés d'une personne morale[5789], il est foncièrement improbable qu'un tel droit de contester le caractère approprié du rapport d'échange soit contraire à la liberté

5781 Voir en ce sens : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 389 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 785 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20.

5782 Sur ce risque, voir *supra* n° 979.

5783 Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pt. 11.

5784 Art. 160*decies*, § 6 de la Directive Mobilité.

5785 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 6 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 263 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 2 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 2.

5786 §§ 15 ; 122h et 125 UmwG.

5787 § 225c et s. öAktG (fusions internes) ; § 9 SpaltG (scissions internes) et § 12 EU-VerschG (fusions transfrontalières).

5788 §§ 14(2) ; 122h et 125 UmwG. À ce sujet, voir : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n°s 14 et 15 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 369.

5789 Voir en ce sens : A. WENG, « Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen », *op. cit.*, p. 118.

d'établissement. En effet, s'il est certes vrai qu'il peut s'avérer dissuasif à l'égard des sociétés concernées en raison du risque pour les liquidités de celles-ci, en protégeant tous les associés, il n'en poursuit pas moins la raison impérieuse d'intérêt général qu'est la protection des intérêts des associés minoritaires[5790]. En outre, il est adéquat en ce qu'il permet un rééquilibrage des conditions de l'opération et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif puisqu'il est explicitement prévu qu'il n'aura pas d'effet suspensif sur l'opération[5791].

2. *Limites*

1063. Un certain nombre d'inconvénients. Un tel mécanisme de protection va engendrer des procédures longues et coûteuses pour les sociétés concernées[5792]. Ceci explique pourquoi en droit allemand, ce mécanisme n'est pas fréquemment plébiscité[5793], car même s'il fait preuve d'une certaine efficacité[5794], il souffre de délais de procédure excessivement longs[5795]. En outre, ce mécanisme de protection des associés minoritaires emporte, tout comme le droit de sortie, un risque significatif pour les liquidités de la société susceptible de nuire à sa capacité de rembourser ses créanciers[5796]. Il est également intéressant de relever qu'en droit allemand, cet impact négatif pour la société concernée est amplifié par la prohibition d'une *reformatio in peius* à l'égard des associés minoritaires[5797] et par la possibilité pour la juridiction compétente de faire peser l'intégralité des coûts de la procédure sur la société défenderesse[5798].

B. *Quid de la répartition des actions des sociétés bénéficiaires ?*

1064. Une interprétation large de la notion de rapport d'échange. À l'égard du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, il a été avancé que le droit de contester le caractère adéquat du rapport d'échange[5799] emportait également le droit de contester la répartition asymétrique des actions des sociétés bénéficiaires[5800]. Une telle interprétation se justifie par le fait que la Directive Mobilité ne couvre que les scissions

5790 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 et arrêt *Überseering*, pt. 92.
5791 Art. 160*decies*, § 6, 2e phrase de la Directive Mobilité.
5792 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 65. Voir également en ce sens à propos du régime allemand : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 263.
5793 N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2256.
5794 Voir en ce sens : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860.
5795 *Ibidem*.
5796 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 4 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 3a et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 65.
5797 § 11 SpruchG. À ce sujet, voir : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 266 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, pp. 1162 et 1163 et P. MENNICKE in M. LUTTER (dir.), *ibidem*, § 11 SpruchG, n° 2.
5798 § 15(2) SpruchG. À ce sujet, voir : D. BEUTEL, *ibidem*, p. 267.
5799 Art. 160*decies*, § 6 de la Directive Mobilité.
5800 DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 866 ; ECLE, *op. cit.*, p. 215 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 64.

transfrontalières n'impliquant qu'une seule société préexistante[5801] et pour lesquelles, par définition, la détermination du rapport d'échange au sens strict ne présente pas d'aléa[5802]. Cependant, si une telle interprétation permet certes d'accommoder la procédure de contestation du rapport d'échange au champ d'application *ratione materiae* excessivement limité de la Directive Mobilité, force est de constater que le risque encouru par les associés minoritaires du fait d'une répartition foncièrement asymétrique décidée par les majoritaires va au-delà de la seule dilution contre laquelle la procédure de réévaluation du rapport d'échange entend les protéger. Une répartition asymétrique totale pourrait effectivement être utilisée par des associés majoritaires en vue d'isoler les associés minoritaires au sein d'une société qui ne récolterait que les activités en perte de vitesse de la société scindée. Ce risque supérieur explique également pourquoi parmi les pays européens qui connaissent une telle procédure de réévaluation, la protection des associés minoritaires contre ce risque est assurée par une condition d'unanimité à l'assemblée générale[5803]. On peut donc *a priori* s'étonner de la présence de cette procédure dans la Directive Mobilité. Cependant, si on prend en compte le fait qu'en matière de scissions transfrontalières, le législateur européen cherche fondamentalement à préparer le terrain pour une mesure d'harmonisation de plus grande envergure, il apparaît clairement qu'il s'agit là davantage d'une démonstration d'habileté politique par le biais de laquelle le législateur européen introduit un mécanisme de protection qui ne prendra son véritable sens qu'au moment de l'introduction d'un régime couvrant tous les types de scissions.

C. *La question des titulaires de ce droit*

1065. Plan du point C. Pour pouvoir identifier avec précision à quels associés minoritaires il serait opportun d'ouvrir la possibilité de contester le caractère adéquat du rapport d'échange, il importe de s'interroger en premier sur la nécessité de réserver ce droit aux seuls associés ayant voté contre l'opération (1), pour ensuite se pencher sur l'articulation entre ce mécanisme et le droit de retrait (2), ainsi que sur l'exigence d'un vote favorable à l'opération pour pouvoir en bénéficier (3) et, en définitive, sur l'intérêt d'ouvrir ce droit aux associés des sociétés bénéficiaires dans le cadre des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante (4).

1. *Une condition superflue*

1066. Quid de l'opposition à l'opération ? Bien que cela eût pu se justifier[5804], la Directive Mobilité n'impose pas aux associés insatisfaits des conditions de l'opération de voter contre celle-ci[5805], contrairement à ce qui est le cas pour

5801 Sur le champ d'application *ratione materiae* limité de la Directive Mobilité, voir *supra* n°s 341 à 346.
5802 DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 866.
5803 § 128 UmwG en droit allemand et § 9(3) SpaltG en droit autrichien.
5804 ECLE, *op. cit.*, p. 214 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 65.
5805 Art. 160*decies*, § 6 de la Directive Mobilité.

le droit de retrait[5806]. Une telle condition aurait pu se justifier par différents arguments. Tout d'abord, elle aurait permis une évaluation plus simple du risque encouru par les sociétés bénéficiaires. Ce faisant, on aurait également permis aux créanciers d'estimer plus aisément l'impact probable de l'opération sur la situation patrimoniale de leur débiteur. Le cas échéant, cela aurait également simplifié le travail de l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour octroyer une garantie adéquate en ce qu'il aurait été plus aisé de déterminer si l'érosion financière générée par la scission transfrontalière était de nature à compromettre le recouvrement par les créanciers de leurs créances[5807]. Cependant, en imposant une telle condition, on aurait forcé les associés minoritaires qui considéraient que l'opération était sensée d'un point de vue économique, mais souhaitaient uniquement revoir les conditions de celle-ci, à potentiellement bloquer une opération nécessaire pour sauvegarder leurs droits[5808]. Cette position correspond en outre à la situation en droit allemand[5809] et en droit autrichien[5810] où il n'est pas requis que les associés minoritaires faisant usage de leur droit de contester le rapport d'échange aient au préalable voté contre l'opération. De plus, une telle condition aurait rendu la mesure plus intrusive du point de vue de la liberté d'établissement alors qu'obliger les associés minoritaires à agir à bref délai après la publication du projet de scission[5811] permet de restreindre efficacement l'impact patrimonial et les incertitudes pour les sociétés bénéficiaires engendrés par une telle procédure. C'est donc à juste titre que le législateur européen s'est abstenu d'imposer une telle condition[5812] et une telle solution devrait également prévaloir à l'égard d'un régime plus général des scissions transfrontalières.

2. *Un mécanisme alternatif*

1067. L'exclusion des associés minoritaires ayant fait usage de leur droit de retrait. Le texte de la Directive Mobilité exprime très clairement le fait que seuls les associés minoritaires n'ayant pas fait usage de leur droit de retrait ou n'en ayant pas bénéficié pourront, le cas échéant, contester le rapport d'échange et réclamer une soulte en espèces supplémentaire[5813]. En d'autres termes, dans l'esprit du législateur européen, les deux mécanismes de protection des associés minoritaires s'appliquent de manière alternative[5814]. Cet aspect du régime européen des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés

5806 À ce sujet, voir *supra* n°s 1027 à 1032.
5807 Sur ce mécanisme de protection des créanciers, voir *supra* n°s 767 à 779.
5808 Voir en ce sens à propos du régime allemand des fusions internes : Chr. DECHER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 15, n° 3.
5809 §§ 15 ; 122h et 125 UmwG et à ce sujet : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 15, n° 5.
5810 § 225c et s. öAktG (fusions internes) ; § 9 SpaltG (scissions internes) et § 12 EU-VerschG (fusions transfrontalières).
5811 À ce sujet, voir *infra* n°s 1108 à 1110.
5812 *Contra* : ECLE, *op. cit.*, p. 214 qui plaident en faveur soit d'une restriction aux seuls actionnaires ayant voté contre l'opération soit d'une ouverture à tous les actionnaires indépendamment de leur vote.
5813 Art. 160*decies*, § 6, 1re phrase de la Directive Mobilité.
5814 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 210 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 65.

se retrouvait déjà dans la Proposition de la Commission[5815] et est resté constant tout au long du processus législatif[5816]. Une telle articulation correspond à celle applicable en droit allemand[5817] et s'impose par la nécessité d'assurer un équilibre entre les intérêts de la société concernée et ceux des associés minoritaires[5818]. En effet, l'objectif du législateur européen n'est pas de permettre aux associés minoritaires de bénéficier d'un véritable arsenal, mais plutôt de limiter les atteintes à la liberté d'établissement de la société scindée au strict minimum nécessaire pour assurer une protection adéquate des intérêts des associés minoritaires. De telles considérations devraient également prévaloir dans le cadre d'un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante de sorte que le caractère alternatif des mécanismes de protection s'y justifie également.

3. *L'exigence d'un vote positif*

1068. L'exigence de voter en faveur de l'opération. La Proposition de la Commission prévoyait à l'origine que seuls les associés de la société scindée qui ne s'opposaient pas à la scission pourraient bénéficier du droit de contester le caractère adéquat du rapport d'échange[5819]. Ceci signifiait que seuls les associés ayant voté en faveur du projet de scission ainsi que ceux s'étant abstenus d'exercer leur droit de vote, soit explicitement, soit en ne participant pas à l'assemblée générale, auraient pu contester le rapport d'échange. Cet aspect a subi une évolution au cours du processus législatif puisque dès le Premier Compromis de la Présidence, il a été prévu que seuls les associés n'ayant pas exercé le droit de retrait pourraient en bénéficier[5820]. Cette formulation a fait l'objet de certaines critiques[5821] en ce qu'elle sous-entendait que seuls les associés disposant en premier lieu du droit de retrait pouvaient bénéficier du droit de contester le caractère adéquat du rapport d'échange et ce, alors même qu'un rapport d'échange inadéquat affecte tous les associés minoritaires de la société concernée[5822]. Le 25e considérant du Premier Compromis de la Présidence permettait de corriger cette interprétation trop restrictive en ce qu'il précisait que tant les associés n'ayant pas bénéficié d'un droit de retrait ou ne l'ayant pas exercé devaient pouvoir contester le rapport d'échange[5823]. Le Deuxième Compromis de la Présidence a gardé la même formulation ambiguë[5824], mais tant le Compromis des Représentants Permanents[5825] que

5815 Art. 160*terdecies*, § 7 de la Proposition de la Commission.
5816 Art. 160l, § 7 du Premier Compromis de la Présidence ; art. 160l, § 7 du Deuxième Compromis de la Présidence ; art. 160l, § 7 du Compromis des Représentants Permanents ; art. 160l, § 7 du Compromis Final et art. 160*terdecies*, § 6 de la Directive Mobilité.
5817 § 3 SpruchG et à ce sujet : P. MENNICKE in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 3 SpruchG, n° 6.
5818 Sur cet équilibre, voir *supra* n° 984.
5819 Art. 160*terdecies*, § 7 de la Proposition de la Commission.
5820 Art. 160l, § 7 du Premier Compromis de la Présidence.
5821 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 65.
5822 *Ibidem*.
5823 25e considérant du Premier Compromis de la Présidence et en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 214 et M. WINNER, *ibidem*, p. 65.
5824 Art. 160l, § 7 du Deuxième Compromis de la Présidence.
5825 Art. 160l, § 7 du Compromis des Représentants Permanents.

le Compromis Final[5826] et la Proposition du Parlement[5827] l'ont rectifiée en adoptant la formulation qui s'est retrouvée en définitive dans la Directive Mobilité[5828]. Ainsi, tous les associés de la société scindée, à l'exception de ceux ayant exercé leur droit de retrait[5829], peuvent contester le rapport d'échange. Cependant, pour utile qu'elle soit, cette précision n'en est pas pour autant suffisante. En effet, la *ratio legis* de ce droit de contester le caractère adéquat du rapport d'échange découle à tout le moins de la volonté de protéger les associés minoritaires qui considèrent que la scission transfrontalière est une décision économiquement rationnelle pour le développement de l'entreprise, mais à l'égard desquels le rapport d'échange fixé par les associés majoritaires est incorrect[5830]. En outre, il découle du texte même de la Directive Mobilité que, dans l'esprit du législateur européen, le fait d'intenter une telle procédure ne devait pas empêcher l'enregistrement de la scission transfrontalière[5831]. En conséquence, il eût été logique d'imposer que les associés minoritaires susceptibles de bénéficier d'un droit de retrait s'ils s'étaient opposés à la scission transfrontalière lors de l'assemblée générale conformément au prescrit de la Directive Mobilité[5832] votassent en faveur de l'opération pour pouvoir bénéficier du droit de contester le caractère adéquat du rapport d'échange[5833]. Une telle solution serait en outre plus conforme à l'exigence de proportionnalité de l'entrave générée à la liberté d'établissement de la société concernée puisque dans le cas contraire, cela signifierait qu'un associé minoritaire pourrait très bien voter contre l'opération, ne pas exercer son droit de sortie, et de ce fait potentiellement bloquer l'opération, pour ensuite contester le rapport d'échange et ainsi essayer de forcer les associés majoritaires à lui octroyer des conditions plus favorables. Il en découle qu'un nouveau régime des scissions transfrontalières devrait imposer aux associés minoritaires susceptibles d'entrer dans le champ d'application *ratione personae* du droit de retrait de voter en faveur de l'opération lors de l'assemblée générale pour pouvoir contester le rapport d'échange.

4. *La situation des associés des sociétés bénéficiaires*

1069. Quid des associés minoritaires des sociétés bénéficiaires ? La question de la protection des associés minoritaires des sociétés bénéficiaires qui seraient potentiellement impactés par le rapport d'échange négatif n'est évidemment pas traitée par la Directive Mobilité puisque celle-ci n'envisage volontairement

5826 Art. 160l, § 7 du Compromis Final.
5827 Art. 160*terdecies*, § 6 de la Proposition du Parlement.
5828 Selon l'art. 160*decies*, § 6 de la Directive Mobilité, « les associés de la société scindée qui n'ont pas eu ou n'ont pas exercé le droit de céder leurs actions » peuvent contester le rapport d'échange.
5829 Sur les conditions qu'un associé de la société scindée doit remplir pour bénéficier d'un droit de retrait, voir *supra* n°s 1018 à 1033.
5830 Voir en ce sens à propos du régime allemand des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 18.
5831 Art. 160*decies*, § 6, 2e phrase de la Directive Mobilité.
5832 Art. 160*decies*, § 1er, al. 1er de la Directive Mobilité.
5833 *Contra* : Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 245 qui considère que le principe d'égalité entre actionnaires impose d'ouvrir également le droit de contester le rapport d'échange aux actionnaires minoritaires ayant voté contre l'opération, mais n'ayant pas fait usage de leur droit de retrait.

pas le cas des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[5834]. Cependant, dans le cadre de la construction d'un régime paneuropéen des scissions transfrontalières par acquisition et mixtes, il est intéressant de se pencher sur la question de savoir si les associés minoritaires des sociétés bénéficiaires devraient également disposer de la possibilité de contester le rapport d'échange. Pour résoudre cette question, il faut se pencher sur le régime des fusions transfrontalières consacré par la Directive Mobilité. Or, à l'égard de ces dernières, la Directive Mobilité prévoit explicitement que les associés de la société absorbante disposent également de la possibilité de contester le rapport d'échange[5835]. Une telle solution n'est pas évidente car, à titre d'illustration, en droit allemand[5836] des fusions transfrontalières, contrairement à ce qui est prévu en droit autrichien des fusions transfrontalières[5837], seuls les associés de la société absorbée peuvent contester ce rapport d'échange. Compte tenu du fait que, contrairement au droit de retrait[5838], la possibilité de contester le rapport d'échange est destinée, d'une part, à protéger les associés minoritaires contre un risque commun à tous les associés minoritaires impliqués dans l'opération de scission, à savoir celui d'un rapport d'échange excessivement défavorable qui leur serait imposé par un associé majoritaire et qui aboutirait à une dilution de leur participation[5839] et d'autre part, à compenser le fait qu'il n'est pas loisible aux minoritaires de contester la validité de la décision d'approbation de la scission transfrontalière par l'assemblée générale sur la base du fait que le rapport d'échange n'aurait pas été fixé correctement[5840], il serait logique, dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, de l'ouvrir également aux associés des sociétés bénéficiaires[5841].

D. *La délicate question de l'effet* erga omnes

1070. La position changeante du législateur européen. Contrairement à ce qui est le cas pour les fusions transfrontalières[5842], la Directive Mobilité ne prévoit pas explicitement que la décision rendue par l'autorité nationale

5834 Sur le champ d'application *ratione materiae* limité de la Directive Mobilité, voir *supra* n°s 341 à 346.
5835 Art. 126*bis*, § 6 de la Directive Mobilité.
5836 § 122h UmwG et pour un point de vue critique : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 4 ; W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 844 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 625.
5837 § 12(1) EU-VerschG.
5838 À ce sujet, voir *supra* n°s 1018 à 1033.
5839 Voir en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 44 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 146. M. NOACK, *op. cit.*, pp. 785 et 786 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2441.
5840 Voir en ce sens : F. BERNARD, *ibidem*, p. 44.
5841 Voir en ce sens également : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 65. Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 4 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 309 ; ECLE, *op. cit.*, p. 214 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 146 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 786 ; J. SCHMIDT, « Coming soon: „Company Law Package Part 2 - Implementation" », *op. cit.*, p. 802 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 258 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2441.
5842 Art. 126*bis*, § 6, al. 2 de la Directive Mobilité.

compétente puisse avoir un effet *erga omnes*[5843]. En d'autres termes, une décision favorable aux demandeurs et établissant l'obligation pour les sociétés issues de l'opération de verser une soulte en espèces additionnelle en raison d'un rapport d'échange inadéquat ne profitera *a priori* qu'aux seuls associés actifs dans la procédure. Ce choix, qui se retrouvait déjà dans la Proposition de la Commission[5844], a fait l'objet de certaines critiques très tôt au cours du processus législatif[5845] et été rectifié dans le Deuxième Compromis de la Présidence qui a introduit un effet *erga omnes* obligatoire[5846]. Le Compromis des Représentants Permanents est ensuite partiellement revenu sur cette position en prévoyant que la question de l'effet *erga omnes* de la décision rendue par la juridiction compétente serait laissée à la discrétion des États membres[5847]. Cet ajout a ensuite disparu du Compromis Final[5848] et n'est réapparu ni dans la Proposition du Parlement[5849], ni dans la Directive Mobilité[5850]. Malgré cela, comme la Directive Mobilité établit clairement qu'elle ne vise qu'une harmonisation *a minima* à l'égard de la protection des associés minoritaires[5851], il reste loisible aux États membres de prévoir que la décision ainsi rendue aura un effet *erga omnes*[5852], pour peu que cela soit conforme au regard de la liberté d'établissement[5853].

1071. La situation en droit allemand et en droit autrichien. En droit allemand des fusions transfrontalières, la décision rendue sur le caractère adéquat du rapport d'échange aura nécessairement un effet *erga omnes*[5854]. Il s'ensuit que la décision rendue par la juridiction compétente impactera tous les associés même si ceux-ci n'étaient pas parties à la procédure de contestation du rapport d'échange[5855]. Un tel effet était jugé conforme au prescrit de la Directive

5843 Art. 160*decies*, § 6 de la Directive Mobilité.
5844 Art. 160*terdecies*, § 8 de la Proposition de la Commission.
5845 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 214 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 258 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238.
5846 L'art. 160l, § 7, 2e phrase du Deuxième Compromis de la Présidence prévoyait que : « [t]*he decision shall be binding on the recipient companies and, in case of a partial division, also on the company being divided, and all their members* ».
5847 L'art. 160l, § 7, al. 2 du Compromis des Représentants Permanents prévoyait que : « *Member States may also provide that the share exchange ratio as established in the decision is valid for those members of the company being divided who did not have or did not exercise the right to dispose of their shares* ».
5848 Art. 160l, § 7 du Compromis Final.
5849 Art. 160*terdecies*, § 6 de la Proposition du Parlement.
5850 Art. 160*decies*, § 6 de la Directive Mobilité.
5851 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 21 et 17e considérant de la Directive Mobilité et à ce sujet : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 363 ; ECLE, *op. cit.*, p. 200 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 254 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439.
5852 M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 65.
5853 Sur l'incidence de la liberté d'établissement, voir *supra* nos 986 et 987.
5854 § 13 SpruchG et à ce sujet : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 24 et R. MARSCH-BARNER (dir.), *op. cit.*, p. 794, n° 6.
5855 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 24.

Sociétés[5856] selon laquelle « l'issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l'ensemble de ses associés »[5857]. Il en est de même en droit autrichien[5858].

1072. Appréciation critique. Malgré les appels faits en ce sens par certains auteurs[5859], notamment en vue de respecter l'égalité entre associés[5860], on peut s'interroger sur l'intérêt de prévoir un tel effet *erga omnes*. S'il est effectivement vrai que l'absence d'effet *erga omnes* risque de nuire à l'égalité entre associés, *a fortiori* si certains associés minoritaires reçoivent des actions additionnelles et d'autres non[5861], on est en droit de se demander s'il est effectivement opportun de permettre aux associés minoritaires passifs de bénéficier des risques encourus par d'autres[5862]. En effet, prévoir un effet *erga omnes* ne manquera pas d'aggraver les conséquences négatives d'une soulte en espèces additionnelle sur les liquidités et la situation patrimoniale de la société concernée. De plus, l'incidence de la liberté d'établissement impose que l'effet dissuasif généré par une mesure protectrice destinée à sauvegarder les intérêts des associés minoritaires n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif[5863]. Or, dans la mesure où une action ne profitant qu'à la partie l'ayant initiée remplit l'objectif de protection des associés minoritaires de manière adéquate et aura un effet dissuasif moindre sur la société concernée qu'une action ayant un effet *erga omnes*, on peut émettre certains doutes sur la conformité à la liberté d'établissement d'une mesure nationale qui adjoindrait un tel effet *erga omnes* à la décision rendue sur le caractère adéquat du rapport d'échange. Pour finir, il a été avancé dans le cadre des fusions transfrontalières, qu'en présence de multiples sociétés absorbées, l'absence d'effet *erga omnes* allait poser problème dans la mesure où la révision du rapport d'échange entre la société absorbante et une des sociétés absorbées allait nécessairement impacter également les rapports d'échange entre la société absorbante et les autres sociétés absorbées[5864]. Compte tenu du fait que les scissions transfrontalières se caractérisent par définition par une pluralité de sociétés bénéficiaires, un tel raisonnement pourrait également faire son chemin à l'égard d'un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société bénéficiaire préexistante. Cependant, tenir un tel raisonnement revient à perdre de vue le fait que l'objectif de la possibilité de contester le rapport d'échange n'est pas de

5856 Art. 127, § 3, 4e phrase de la Directive Sociétés.

5857 Voir en ce sens : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 24 et R. FRENZEL, *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, *op. cit.*, pp. 334 et 335.

5858 § 225i öAktG et § 12 EU-VerschG et à ce sujet : G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 706, n° 29 et S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 311 et 312, n° 8.

5859 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 259 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2442.

5860 J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 259.

5861 ECLE, *op. cit.*, p. 214 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238.

5862 ECLE, *ibidem*, p. 214.

5863 Sur les conditions applicables à la justification d'une entrave à la liberté d'établissement, voir *supra* n° 132.

5864 Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1907 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2442.

procéder à un rééquilibrage équitable des conditions de la scission transfrontalière, tâche en tout état de cause particulièrement ardue en l'absence d'harmonisation des règles d'évaluation au sein de l'Union européenne[5865], mais de protéger les associés minoritaires actifs contre une expropriation abusive de la part des majoritaires ainsi que de compenser le fait qu'il est explicitement prohibé aux associés minoritaires de contester la validité de la décision de procéder à la scission sur la seule base que le rapport d'échange n'a pas été fixé de manière correcte[5866]. Il s'ensuit que lors d'une révision ultérieure de la Directive Mobilité en vue de procéder à l'harmonisation de tous les types de scissions transfrontalières, il serait préférable d'indiquer que la décision rendue par la juridiction compétente en la matière sera dénuée d'effet *erga omnes*.

E. *La* reformatio in peius

1073. Une limite à proscrire. Il a été avancé que contrairement aux droits allemand[5867] et autrichien[5868], le législateur européen n'excluait pas la possibilité d'une révision du rapport potentiellement défavorable à une certaine catégorie d'associés[5869]. Cette position découle du fait que, dans le cadre d'une fusion transfrontalière, les associés de toutes les sociétés impliquées disposent de la possibilité de contester le rapport d'échange[5870] et il devrait en être de même dans le cadre d'un régime plus général des scissions transfrontalières. En effet, le mécanisme de contestation du rapport d'échange vise en priorité à protéger les associés minoritaires tant de la société scindée que des sociétés bénéficiaires d'une part contre une dilution excessive liée à un rapport d'échange incorrect[5871] et d'autre part contre une répartition inéquitable des actions des sociétés bénéficiaires entre les associés de la société scindée[5872]. Il s'ensuit que si plusieurs associés minoritaires à la fois de la société scindée et d'une des sociétés bénéficiaires introduisent une procédure de contestation du caractère correct du rapport d'échange, une révision en faveur des uns aura nécessairement un impact négatif à l'encontre des autres. Une telle prohibition d'une *reformatio in peius* ne fait donc pas de sens[5873]. A cela s'ajoute que l'expérience du régime allemand a montré que certains associés minoritaires avaient tendance à initier la procédure de contestation simplement dans l'espoir de

5865 Sur cette problématique, voir *supra* n°s 304 et 450.
5866 Art. 160*nonies*, § 5, a) de la Directive Mobilité.
5867 § 11 SpruchG et à ce sujet : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 4 ; R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 3a et P. MENNICKE in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 11 SpruchG, n° 2.
5868 § 234b(5), 2e phrase (fusions internes) ; § 11(2), 1re phrase EU-VerschG (fusions transfrontalières) et § 9(2), 2e phrase SpaltG (scissions internes). À ce sujet, voir : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 461 et 462, n° 87 et J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 469.
5869 N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2258 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 310 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2441.
5870 N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *ibidem*, p. 2258 et J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 310.
5871 Sur ce risque, voir *supra* n° 979.
5872 Sur ce risque, voir *supra* n° 981.
5873 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : M. NOACK, *op. cit.*, p. 788 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2443.

bénéficier d'un rapport d'échange plus favorable dû à l'intervention d'un expert différent de celui s'étant prononcé au cours de la procédure normale de fusion ou de scission[5874]. Ne pas prohiber une *reformatio in peius* aurait un effet dissuasif sur ce genre de comportement de nature à décourager les sociétés concernées de faire usage de leur liberté d'établissement et cet aspect de la contestation du rapport d'échange mériterait d'être énoncé explicitement par le législateur européen lors de l'introduction d'un régime plus général des scissions transfrontalières.

F. *La nécessité d'une certaine flexibilité*

1074. Une possibilité d'atténuation de l'impact sur les créanciers. Dans la mesure où le versement d'une soulte en espèces additionnelle en vue de compenser un rapport d'échange inadéquat entraînerait une érosion supplémentaire du gage commun des créanciers et de potentiels problèmes de liquidités pour la société concernée[5875], la Directive Mobilité autorise explicitement les États membres à prévoir que la société issue de la scission concernée, c'est-à-dire (i) celle dont l'actif net reçu excède la valeur des actions échangées de la société scindée en contrepartie des actions émises dans cette nouvelle société[5876] ou (ii) le cas échéant, en cas de scission partielle, la société scindée s'il s'avère que la société scindée a conservé trop d'actifs nets par rapport à la valeur de ses actions qui ont été échangées[5877], pourra offrir « des actions ou une autre compensation au lieu d'une soulte en espèces »[5878].

5874 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 15, n° 2.

5875 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 309 ; ECLE, *op. cit.*, p. 214 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 258 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2442.

5876 À titre d'illustration, ce sera le cas dans l'exemple chiffré suivant : la Société A a un actif net d'un montant de 100 000 EUR et un capital social de 50 000 EUR représenté par 50 actions ayant une valeur nominale de 1 000 EUR chacune. La Société A a deux actionnaires, l'un, l'Actionnaire A, disposant de 40 actions et l'autre, l'Actionnaire B, de 10. Il est décidé de procéder à une scission asymétrique totale par constitution de deux nouvelles sociétés en vue d'isoler les deux principales branches d'activité de la Société A. En conséquence de l'opération, une branche d'activité représentant un actif net de 95 000 EUR est transférée à la première société bénéficiaire dont l'Actionnaire A sera seul actionnaire, alors que la deuxième société bénéficiaire dont l'Actionnaire B sera seul actionnaire n'obtiendra que 5 000 EUR. En d'autres termes, alors que la participation de B dans la Société A représentait une valeur de 20 000 EUR (soit 10/50 x 100 000 EUR), ses nouvelles actions dans la deuxième société bénéficiaire ne représenteront plus qu'une valeur de 5 000 EUR.

5877 À titre d'illustration, ce sera le cas dans l'exemple chiffré suivant : la Société A a un actif net d'un montant de 100 000 EUR et un capital social de 50 000 EUR représenté par 50 actions ayant une valeur nominale de 1 000 EUR chacune. La Société A a deux actionnaires, l'un, l'Actionnaire A, disposant de 40 actions et l'autre, l'Actionnaire B, de 10. Il est décidé de procéder à une scission asymétrique partielle par constitution d'une nouvelle société. En conséquence de l'opération, la nouvelle société recevra une branche d'activités ayant un actif net d'un montant de 12 000 EUR et la société scindée conservera un actif net d'un montant de 88 000 EUR. Cependant, au cours de l'opération, les 10 actions de l'Actionnaire B dans la société scindée seront échangées contre 10 actions de la société bénéficiaire et 2 actions de l'Actionnaire A dans la société scindée seront échangées contre 2 actions de la nouvelle société. À la suite de l'opération, les 10 actions de l'Actionnaire B ne représenteront plus qu'un actif net de 10 000 EUR (soit 10/12 x 12 000 EUR), alors qu'avant l'opération, elles représentaient un actif net de 20 000 EUR (soit 10/50 x 100 000 EUR).

5878 Art. 160*decies*, § 7 de la Directive Mobilité.

1075. Les évolutions au cours du processus législatif. La Proposition de la Commission prévoyait à l'origine que la juridiction compétente pour trancher la question du caractère adéquat ou non du ratio d'échange disposait de la possibilité, sur demande expresse de l'un des demandeurs à l'action, d'octroyer des actions supplémentaires aux associés lésés en lieu et place d'un paiement en espèces[5879]. Cette possibilité a par la suite été supprimée dans le Premier Compromis de la Présidence dans lequel il est exclusivement mentionné que la juridiction compétente pourra enjoindre à la société concernée de verser une compensation aux associés ayant valablement contesté le rapport d'échange, sans préciser en quoi cette compensation consisterait[5880]. Le Deuxième Compromis de la Présidence a fort heureusement réintroduit la possibilité pour les États membres de prévoir que les sociétés issues de l'opération pourraient allouer des actions additionnelles aux associés concernés et ce, de commun accord avec ceux-ci[5881]. Le Compromis des Représentants Permanents a supprimé la nécessité d'obtenir l'accord préalable des associés concernés et a introduit une flexibilité additionnelle en permettant à la société concernée d'allouer également une autre forme de compensation en lieu et place d'actions additionnelles ou d'une soulte en espèces supplémentaire[5882]. Cette solution est également celle qui se retrouve dans le Compromis Final[5883] et la Proposition du Parlement[5884].

1076. La situation en droit allemand et en droit autrichien. En droit allemand, seule une soulte espèces additionnelle peut être versée[5885]. Une compensation au moyen de l'octroi d'actions supplémentaires ou de droits spécifiques n'est pas admissible[5886]. Ce manque de flexibilité a fait l'objet de nombreuses critiques[5887] en raison de l'impact négatif sur les liquidités de la société que ne manquerait pas d'avoir l'obligation de verser une soulte additionnelle obligatoirement en espèces. Au contraire, en droit autrichien, la société bénéficiaire issue de l'opération dispose de la possibilité de demander à la juridiction compétente de lui permettre d'allouer des actions supplémentaires aux associés lésés au lieu de leur verser une soulte en espèces additionnelle[5888].

5879 Art. 160*terdecies*, § 8 de la Proposition de la Commission.

5880 Art. 160l, § 8 du Premier Compromis de la Présidence et, pour un point de vue critique, voir : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 258.

5881 Art. 160l, § 8a du Deuxième Compromis de la Présidence.

5882 Art. 160l, § 8 du Compromis des Représentants Permanents.

5883 Art. 160l, § 8 du Compromis Final.

5884 Art. 160*terdecies*, § 7 de la Proposition du Parlement.

5885 W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 16 et Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122h, n° 9.

5886 Voir en ce sens : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 15, n° 6.

5887 Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2258 ; R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *ibidem*, § 15, n° 6 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 786 ; J. SCHMIDT, « Coming soon: „Company Law Package Part 2 - Implementation" », *op. cit.*, p. 802 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20, note 91.

5888 §§ 225e (3) et 225j (2) öAktG et à ce sujet : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, pp. 316 à 318, n°s 8 à 14.

1077. Appréciation critique. Cette solution présente l'indéniable avantage de limiter à la fois le risque d'érosion subséquente du patrimoine d'une des sociétés issues de la scission transfrontalière et le risque de liquidités[5889], ce qui n'est pas sans conséquence sur la situation des créanciers[5890]. En outre, une telle flexibilité bénéficie d'une certaine logique puisqu'elle aboutit à la situation à laquelle les parties elles-mêmes auraient abouti si le rapport d'échange avait été fixé correctement *ab initio*[5891]. Pour finir, elle permettrait d'éviter qu'une scission transfrontalière ne soit utilisée comme mécanisme d'exclusion des associés minoritaires contre rémunération[5892]. Ces différents avantages font qu'elle a été accueillie favorablement par de nombreux auteurs[5893], certains ayant même argumenté qu'il conviendrait de faire de l'octroi d'actions supplémentaires la règle de base et de l'octroi d'une soulte en espèces additionnelle, l'exception[5894]. En effet, une telle solution mériterait de se retrouver dans un régime européen des scissions transfrontalières car, au-delà des considérations relatives à la situation patrimoniale des sociétés impliquées, il convient de relever que l'octroi d'une soulte en espèces additionnelle ne constitue pas un remède adéquat à la dilution excessive subie par les associés minoritaires du fait de l'opération[5895]. En d'autres termes, ne prévoir que la possibilité d'une soulte en espèces additionnelle pour compenser un rapport d'échange inadéquat ouvre la porte à d'éventuels abus car elle permet une expropriation partielle d'associés minoritaires contre rémunération[5896]. Il s'ensuit que le paiement d'une soulte en espèces additionnelle ne devrait intervenir que (i) pour résoudre la problématique d'éventuels rompus[5897] à l'instar de la soulte en espèces dans le cadre de la détermination du rapport d'échange[5898] ou (ii) lorsqu'il s'avère impossible d'attribuer de nouvelles actions[5899]. On est également en droit de

[5889] Voir en ce sens : W. BAYER et J. SCHMIDT, « Der Regierungsentwurf… », *op. cit.*, p. 843 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 309 ; ECLE, *op. cit.*, p. 214 ; S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 316, n° 8 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 258 ; J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2442 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 625.

[5890] M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, pp. 67 et 68.

[5891] ECLE, *op. cit.*, p. 214.

[5892] Voir en ce sens : M. NOACK, *op. cit.*, p. 786 qui met en garde contre le fait que permettre à la société bénéficiaire de compenser un rapport d'échange incorrect en priorité par un paiement en espèces rend la dilution irréversible.

[5893] W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 309 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2442.

[5894] Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 309 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 786 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439.

[5895] Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, pp. 309 et 310 et M. NOACK, *ibidem*, p. 786.

[5896] Voir en ce sens : M. NOACK, *ibidem*, p. 786.

[5897] J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 310 ; M. NOACK, *ibidem*, p. 786 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2442.

[5898] À ce sujet, voir *supra* n° 112.

[5899] Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 310 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 786 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2442.

se demander si l'octroi d'une soulte en espèces additionnelle portant le montant total de la soulte en espèces attribuée dans le cadre de l'opération à un montant supérieur à dix pour cent de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable des nouvelles actions attribuées, ce qui est explicitement autorisé en droit allemand[5900], ne compromettrait pas également le traitement fiscal de l'opération. En effet, la Directive Fiscale conditionne le bénéfice de la neutralité fiscale à l'octroi d'une soulte en espèces ne dépassant pas cette limite[5901]. En conséquence de ce qui précède, bien que ce mécanisme de protection des créanciers ait pour principal inconvénient d'aboutir à un rapport d'échange distinct de celui sur lequel l'assemblée générale s'est prononcée[5902], un régime européen des scissions transfrontalières devrait intégrer une obligation pour les États membres de faire de l'octroi d'actions supplémentaires, le remède principal à un rapport d'échange inadéquat, tout en reléguant la possibilité d'une soulte en espèces additionnelle à un rôle subsidiaire.

G. *L'incidence de l'absence d'harmonisation des méthodes d'évaluation*

1078. Une insuffisance significative. Les méthodes d'évaluation à la base de l'établissement du rapport d'échange n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation au sein de l'Union européenne de sorte qu'il existe de fortes divergences entre les États membres[5903] en la matière. Cet état de fait a été notamment mis en lumière par l'Étude Bech-Bruun et Lexidale[5904]. Or, en l'absence d'une méthode d'évaluation uniforme, le travail de l'autorité compétente pour trancher la question d'une éventuelle inadéquation du rapport d'échange risque d'être particulièrement délicat, *a fortiori* dans l'hypothèse d'une scission par absorption transfrontalière si les États membres concernés n'appliquent pas les mêmes méthodes[5905]. Ce problème, existant déjà de manière limitée dans un contexte interne[5906], ne manquera pas d'engendrer des difficultés pratiques considérables nuisant à l'efficacité de ce mécanisme de protection des associés minoritaires[5907], à moins qu'il ne soit imposé aux parties à l'opération d'opter pour une méthode d'évaluation uniforme et de la mentionner dans le projet commun[5908]. Le choix du législateur européen en faveur d'une possibilité de

5900 § 15(1), 1re phrase UmwG.
5901 Art. 2, b) de la Directive Fiscale.
5902 ECLE, *op. cit.*, p. 214 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, pp. 67 et 68.
5903 Sur cette problématique, voir *supra* nos 304 et 450.
5904 Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 66 à 68. Voir également à ce sujet : T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1163 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 23.
5905 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 66 et 67 et N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2255 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 66.
5906 N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *ibidem*, p. 2257.
5907 O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 146 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, pp. 65 et 68.
5908 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2257 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 310 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 788 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2443.

contester le rapport d'échange comme mécanisme de protection des intérêts des associés minoritaires renforce d'autant plus la nécessité d'une harmonisation des méthodes d'évaluation.

H. *La nécessité d'une règle de droit international privé*

1079. Une compétence exclusive ? Compte tenu du caractère transfrontalier de l'opération, ainsi que du risque d'avoir des décisions divergentes si la procédure de réévaluation du rapport d'échange pouvait être intentée tant dans les États membres des sociétés bénéficiaires que dans celui de la société scindée[5909], *a fortiori* si on prend en compte le fait qu'une scission transfrontalière est susceptible d'impliquer un nombre important de sociétés bénéficiaires, la Directive Mobilité intègre une règle de compétence internationale. Il est ainsi prévu que toute contestation du rapport d'échange sera nécessairement du ressort de l'autorité ou de l'organe compétent de l'État membre de la société scindée[5910]. Cette solution appropriée[5911] se justifie non seulement en raison de l'unicité de la société scindée dans le cadre d'une scission transfrontalière, mais également tout particulièrement au vu du champ d'application restreint de la Directive Mobilité qui ne vise que les scissions n'impliquant qu'une seule société préexistante[5912] puisque seuls les associés de cette dernière sont, par définition, susceptibles d'être lésés. La logique de l'unicité de la société scindée voudrait qu'une règle identique s'impose à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, mais avant de se prononcer sur ce point, il est utile de se pencher sur les évolutions du nouveau régime des fusions transfrontalières au cours du processus d'adoption de la Directive Mobilité. Le recours à cette comparaison se justifie dans la mesure où le régime des fusions transfrontalières, contrairement à celui des scissions transfrontalières[5913], couvre déjà les opérations par absorption[5914].

1080. La solution des fusions transfrontalières. Bien que la possibilité de contester le caractère adéquat du rapport d'échange dans le cadre d'une fusion transfrontalière figurât déjà dans la Proposition de la Commission[5915], les dispositions n'intégraient aucune règle de compétence, contrairement à ce qui était le cas à l'égard d'une contestation du montant de la soulte en espèces dans le cadre du droit de retrait[5916]. Il était uniquement précisé que l'obligation de verser une soulte en espèces additionnelle ou d'attribuer des actions supplémentaires relevait de la législation nationale applicable à la société

5909 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 67.
5910 Art. 160*decies*, § 6, 2e phrase de la Directive Mobilité.
5911 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 257 et 258 et J. SCHMIDT, « The mobility aspects… », *op. cit.*, p. 16.
5912 Sur le champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité, voir *supra* nos 341 à 346.
5913 Art. 160*ter* de la Directive Mobilité.
5914 Art. 119, § 2 de la Directive Mobilité.
5915 Art. 126*bis*, §§ 8 à 10 de la Proposition de la Commission.
5916 L'art. 126*bis*, § 7, 1re phrase de la Proposition de la Commission prévoyait que cette procédure était régie pour chaque société qui fusionne par le droit national de l'État membre qui lui est applicable et que les juridictions de cet État membre étaient compétentes.

issue de la fusion transfrontalière[5917]. Cette approche n'a pas été fondamentalement modifiée lors du Premier Compromis de la Présidence[5918], mais il a toutefois été précisé que les juridictions de l'État membre de la société issue de la fusion transfrontalière étaient seules compétentes pour traiter des litiges concernant l'obligation de verser une soulte en espèces additionnelle ou de fournir des actions supplémentaires. Cette absence de précision a donné lieu à des interprétations divergentes, certains ayant estimé que la demande en révision du rapport d'échange devait nécessairement être introduite devant les juridictions de l'État membre de la société issue de la fusion transfrontalière[5919], alors que d'autres ont considéré que cela signifiait au contraire que les juridictions nationales de chacune des sociétés impliquées dans la fusion étaient compétentes[5920]. Cette dernière position l'a emporté dès le Deuxième Compromis de la Présidence qui est venu préciser que la procédure devait être introduite devant « les autorités ou les organes compétents habilités par le droit national de l'État membre auquel une société fusionnante est soumise »[5921]. Le Compromis des Représentants Permanents est venu préciser que le droit national en question est celui de « la société qui fusionne concernée »[5922]. Ces précisions se sont retrouvées dans le Compromis Final[5923], ainsi que dans la Directive Mobilité[5924 5925]. Cette règle de rattachement peut surprendre de prime abord en ce qu'elle ne désigne pas une juridiction unique[5926] et, si on part du principe que chaque juge national appliquera son propre droit[5927], un droit national unique pour régir toutes les demandes en révision du rapport d'échange. Néanmoins, elle se justifie sous trois angles distincts. Tout d'abord, elle correspond à la règle de rattachement prévue explicitement en matière de contestation du montant de la soulte en espèces dans le cadre de l'exercice du droit de retrait[5928]. Ensuite, elle permet d'intenter l'action en révision avant que la fusion transfrontalière n'ait pris effet puisque le législateur européen a explicitement prévu qu'une telle procédure n'empêchait pas l'enregistrement de la fusion transfrontalière[5929]. Ceci présente l'indéniable avantage de clarifier

5917 Art. 126*bis*, § 10 de la Proposition de la Commission.
5918 Art. 126a, § 10 du Premier Compromis de la Présidence.
5919 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 310 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 787 ; ECLE, *op. cit.*, p. 215 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 67.
5920 J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 258 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238.
5921 Traduction française de la version anglaise de l'art. 126a, § 8, 1re phrase du Deuxième Compromis de la Présidence.
5922 Traduction française de la version anglaise de l'art. 126a, § 8, 2e phrase du Compromis des Représentants Permanents.
5923 Art. 126a, § 8, 2e phrase du Compromis Final.
5924 Art. 126*bis*, § 6 de la Directive Mobilité.
5925 La version française de l'art. 126*bis*, § 6, 2e phrase de la Proposition du Parlement omet erronément le terme « *concernée* », alors que la version anglaise utilise le terme « *respective* ».
5926 Voir DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 865 qui plaide en faveur de la désignation d'une juridiction unique pour éviter d'éventuelles décisions contradictoires.
5927 Voir en ce sens : P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2443.
5928 Art. 126*bis*, § 7 de la Proposition de la Commission. Voir en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2259 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 238.
5929 Art. 126*bis*, § 6, 2e phrase de la Directive Mobilité.

la situation le plus rapidement possible et est donc notamment dans l'intérêt des créanciers dans la mesure où ceux-ci pourront plus rapidement déterminer l'impact d'une éventuelle décision de révision sur la situation patrimoniale de leur société débitrice. En outre, du point de vue de la protection des associés minoritaires, elle permet aux associés minoritaires d'agir devant la juridiction compétente de l'État membre du siège de la société dont ils sont associés, ce qui implique qu'ils ne seront pas affectés par le changement de droit applicable, *a fortiori* dans la mesure où la décision sera contraignante pour la société issue de l'opération transfrontalière[5930].

1081. Quid en cas de scissions transfrontalières mixtes ou par acquisition ? En conséquence, et pour ces mêmes raisons, un nouveau régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante devrait, non pas reprendre telle quelle la règle de compétence prévue dans le régime des scissions transfrontalières et qui envisage la compétence exclusive des juridictions habilitées par le droit de l'État membre de la société scindée, mais s'inspirer du nouveau régime des fusions transfrontalières.

I. *Un mécanisme inutile ?*

1082. Un seuil de tolérance assez élevé. Si le droit de contester le caractère adéquat du rapport d'échange peut sembler équilibré[5931], il convient de ne pas en exagérer l'utilité pratique. En effet, en présence d'un rapport d'expert positif, on ne peut que s'interroger sur les chances de succès d'une action intentée par des associés minoritaires mécontents, de sorte que ce mécanisme est déjà émoussé avant même d'avoir pu être utilisé. En effet, l'intervention de la juridiction nationale devrait consister en un processus en trois étapes distinctes[5932]. La première étape consiste à vérifier si le rapport d'échange n'est pas insuffisant, Et ce n'est que si elle conclut au caractère déraisonnable du rapport d'échange que la juridiction compétente devra procéder à un nouveau calcul du rapport d'échange et, le cas échéant, à l'octroi d'une compensation additionnelle. Il s'ensuit qu'en l'absence de fraude de la part de l'expert indépendant, seuls les cas d'abus les plus manifestes devraient être sanctionnés. L'expérience allemande[5933] et autrichienne[5934] en la matière a montré que des variations de l'ordre de 10 % entre l'évaluation des parties et celle d'un expert nommé par la juridiction compétente n'étaient fréquemment pas corrigées.

1083. L'incidence du rapport d'expert. Il est évident que dans le cadre de l'appréciation du caractère correct du rapport d'échange par l'autorité nationale compétente, le rapport d'expert jouera un rôle primordial. Afin de limiter

[5930] Art. 126*bis*, § 6, 3e phrase de la Directive Mobilité. L'art. 160*decies*, § 6, 3e phrase de la Directive Mobilité prévoit une règle similaire à l'égard des scissions transfrontalières en prévoyant que la décision ainsi rendue est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, également pour la société scindée.

[5931] Voir en ce sens : F. BERNARD, « L'avènement des scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 44 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 237 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 65.

[5932] J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 310.

[5933] Voir en ce sens : R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 15, n° 8.

[5934] Voir en ce sens : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 262, n° 21.

les incertitudes liées à une procédure de contestation du rapport d'échange, il serait utile de prévoir, à l'instar de ce qui a été défendu à l'égard du montant de la soulte en espèces[5935], qu'en présence d'un rapport d'expert positif, le rapport d'échange sera présumé correct jusqu'à preuve du contraire et inversement. Aller encore plus loin en adoptant la solution suggérée lors de la consultation publique de 2015 qui consistait à n'ouvrir le droit de contestation du rapport d'échange qu'en cas de rapport d'expert négatif[5936] ne semble toutefois pas opportun en raison des limites intrinsèques à l'intervention de l'expert indépendant susceptibles de nuire à son objectivité[5937].

§6. Conclusion sur les différents mécanismes de protection des associés minoritaires

1084. Une position plus favorable à la mobilité qu'il n'y paraît. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser de prime abord, il ressort de l'analyse des différents mécanismes de protection des associés minoritaires consacrés par le législateur européen dans la Directive Mobilité que l'approche de ce dernier est beaucoup moins restrictive qu'il n'y paraît. Certes, l'introduction d'un droit de retrait obligatoire pour les associés minoritaires s'étant opposés à l'opération ne manquera pas de constituer un bouleversement pour nombre d'États membres, comme la Belgique et le Luxembourg, ignorant ce type de protection dans le cadre d'une scission ou d'une fusion transfrontalière. Cependant, l'étude détaillée des différents mécanismes de protection des intérêts des associés minoritaires a permis d'établir que la solution adoptée par le législateur européen n'en était pas pour autant excessivement intrusive du point de vue de la liberté d'établissement. En outre, si du point de vue du droit luxembourgeois, elle va à l'encontre d'une position traditionnellement pro-majoritaire[5938], du point de vue du droit belge, elle permettrait d'éluder aisément toute interférence de la procédure générale de retrait-exclusion[5939]. En ce qui concerne l'introduction d'un régime européen applicable à tous les types de scissions transfrontalières, il est également apparu que le législateur européen avait déjà habilement préparé le terrain puisque le droit de contester le rapport d'échange ne fait vraiment de sens qu'à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. Ceci étant, il s'est avéré que le régime consacré par le législateur européen dans la Directive Mobilité n'était pas transposable tel quel aux scissions mixtes et aux scissions par acquisition et nécessitait malgré tout quelques adaptations, comme à l'égard de la règle de compétence internationale applicable aux contestations du rapport d'échange. Sous l'angle de la protection des créanciers potentiellement impactés par l'opération, il est indéniable qu'un certain nombre d'améliorations seraient souhaitables, à commencer par une certaine flexibilité à l'égard de l'identité de l'acheteur des participations d'un associé minoritaire faisant usage de son

5935 À ce sujet, voir *supra* n° 1047.
5936 Voir : Consultation publique de 2015, p. 10.
5937 Sur les limites de la « *gatekeeper approach* », voir *supra* n° 931.
5938 À ce sujet, voir *supra* n° 1004.
5939 À ce sujet, voir *supra* n° 1011.

droit de retrait et de l'allocation prioritaire d'actions supplémentaires en vue de compenser un rapport d'échange inadéquat. Compte tenu de ces insuffisances, il convient à présent de se pencher sur la technique d'harmonisation en la matière dans le cadre d'une initiative européenne couvrant tous les types de scissions transfrontalières.

SECTION 6. L'HARMONISATION AU NIVEAU EUROPÉEN

1085. Plan de la section 6. Afin de porter un jugement éclairé sur la méthode d'harmonisation à privilégier à l'égard de la protection des associés minoritaires dans le cadre d'une initiative européenne visant à faire de tout type de scission transfrontalière une réalité au sein de l'Union européenne (§ 3), il convient d'étudier tant l'approche ayant prévalu préalablement à l'adoption de la Directive Mobilité (§ 1) que celle prônée dans la Directive Mobilité (§ 2).

§ 1. Le régime antérieur à l'adoption de la Directive Mobilité

1086. Le régime des scissions internes de la Directive Sociétés. Contrairement à la question de la protection des créanciers pour laquelle la Directive Sociétés prévoyait certains mécanismes harmonisés[5940], aucun mécanisme n'est prévu à l'égard de la protection des associés minoritaires en dehors de l'information[5941] et du droit de voter sur l'opération à l'occasion de l'assemblée générale[5942]. La Directive Sociétés envisageait certes l'octroi d'un droit de retrait pour les associés minoritaires, mais uniquement dans l'hypothèse des scissions asymétriques et l'introduction de celui-ci était laissée à l'entière discrétion des États membres[5943].

1087. Les régimes nationaux des scissions transfrontalières. Il s'ensuit que les règles nationales sur la protection des associés minoritaires en cas de scissions internes divergent fortement[5944]. Ainsi, à titre d'illustration, en matière de scissions asymétriques, les mécanismes de protection comprennent notamment un droit de sortie contre juste rémunération[5945], des conditions de majorité renforcées[5946] ou encore un contrôle préalable des conditions de la scission par une autorité judiciaire[5947]. Une telle diversité[5948] est immanquablement source d'insécurité juridique[5949].

5940 Art. 146 de la Directive Sociétés.
5941 Cette information adéquate était principalement assurée par (i) le projet de scission (art. 137 de la Directive Sociétés), (ii) les mesures de publicité (art. 138 de la Directive Sociétés), (iii) le rapport de l'organe de direction ou d'administration (art. 141 de la Directive Sociétés) et (iv) le rapport de l'expert indépendant (art. 142 de la Directive Sociétés).
5942 Art. 139 de la Directive Sociétés.
5943 Art. 139, § 2, 1re phrase de la Directive Sociétés.
5944 Étude d'impact, p. 27.
5945 À titre d'illustration, on peut citer le Danemark, l'Irlande, l'Italie et la Pologne. Voir Étude d'impact, p. 145.
5946 À titre d'illustration, on peut citer l'Autriche et le Danemark. Voir Étude d'impact, p. 145.
5947 À titre d'illustration, on peut citer le Royaume-Uni. Voir Étude d'impact, p. 145.
5948 Pour une étude des différents mécanismes de protection des associés minoritaires en droit belge, luxembourgeois, français, allemand et autrichien, voir *supra* n° 1001.
5949 Voir en ce sens : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, pp. 19, 20 et 31.

1088. L'enseignement des fusions transfrontalières. Une des insuffisances du régime des fusions transfrontalières à l'égard de la protection des associés minoritaires avant l'adoption de la Directive Mobilité concernait le fait qu'en dehors d'une protection limitée par le biais de l'information[5950] et de l'exercice du droit de vote à l'occasion de l'assemblée générale[5951], la Directive Sociétés, à l'instar du Règlement sur la Société européenne[5952], s'en remettait exclusivement aux États membres pour la détermination d'autres mécanismes de protection des associés minoritaires[5953], sans préciser toutefois quels associés minoritaires devaient être protégés, ni la nature de la protection[5954]. En effet, en essence, la Directive Sociétés se contentait (i) de préciser que les différents États membres disposaient de la possibilité de mettre en place des régimes de protection pour les associés minoritaires des sociétés relevant de leur droit national qui se sont prononcés contre la fusion transfrontalière[5955] et (ii) d'indiquer que lorsque le droit national d'une des sociétés impliquées dans l'opération prévoyait une procédure de révision du rapport d'échange ou une procédure d'indemnisation des associés minoritaires, une telle procédure ne trouverait à s'appliquer que si elle était explicitement approuvée lors de l'assemblée générale par les autres sociétés impliquées et soumises à des droits nationaux ignorant de telles procédures[5956]. En outre, les dispositions applicables aux fusions internes ne contenaient pas, à l'exception du cas très limité[5957] de l'absorption d'une filiale détenue à 90 % ou plus, mais pas totalement[5958], de mécanisme spécifique à l'instar de ce qui était le cas pour les créanciers[5959]. Cette approche restrictive a engendré une protection des associés minoritaires à géométrie variable à travers les différents États membres[5960]. Ainsi, six États membres ont fait le choix de ne pas introduire de mécanismes de protection spécifiques destinés à protéger les intérêts des associés minoritaires[5961]. En outre, dans certains États membres, les associés minoritaires disposent d'un droit de sortie contre juste rémunération, alors que dans d'autres, ils ne sont protégés que de manière marginale[5962]. Ces divergences

5950 Étude d'impact, pp. 152 et 153.
5951 Art. 126 de la Directive Sociétés.
5952 Art. 24, § 2 du Règlement sur la Société européenne et, à ce sujet, voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 68.
5953 Art. 121, § 2, 2e phrase de la Directive Sociétés et Étude d'impact, pp. 20, 152 et 153 et voir en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2255 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 48.
5954 Sur ces insuffisances du régime des fusions transfrontalières de la Dixième Directive, voir : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 307 ; M. FUENTES NAHARRO, *op. cit.*, p. 34 et K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 43.
5955 Art. 121, § 2, 2e phrase de la Directive Sociétés.
5956 Art. 127, § 3 de la Directive Sociétés.
5957 Voir en ce sens : K. GEENS et M. WYCKAERT, *op. cit.*, p. 41.
5958 Art. 114, al. 1er de la Directive Sociétés.
5959 Voir art. 99 de la Directive Sociétés.
5960 Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 68 et 69 et en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, pp. 2255 et 2256 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20.
5961 Selon l'Étude Bech-Bruun et Lexidale, il s'agit de la Belgique, de la Hongrie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Norvège et de la Suède. Voir Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 118. Il est toutefois intéressant de relever que le schéma utilisé pour illustrer ce constat ne reprend pas les mêmes chiffres et considère que sept États membres n'ont pas eu recours à cette faculté.
5962 Étude d'impact, p. 22.

engendrent des difficultés additionnelles dans la mesure où, en dehors de l'évidente insécurité juridique et de la potentielle inégalité de traitement des associés minoritaires dans le cadre d'une même opération transfrontalière[5963] qui en découlent, les associés minoritaires, s'ils souhaitent faire valoir leurs droits, devront nécessairement recourir à des conseils légaux spécialisés. Or, le coût engendré par de tels conseils les met *ab initio* hors de portée d'un certain nombre d'associés minoritaires[5964]. Cette insuffisance a été particulièrement mise en lumière lors de la consultation publique de 2015[5965]. En outre, l'Étude Bech-Bruun et Lexidale a permis de mettre en évidence le fait que les incertitudes liées à la protection des associés minoritaires et l'incidence que les différents mécanismes de protection sont susceptibles d'avoir sur la trésorerie des sociétés impliquées dans une fusion transfrontalière poussaient tout simplement les acteurs économiques à s'en abstenir dès qu'il y avait un risque que des associés minoritaires se prévalent de leur droit de retrait et qu'il n'était pas possible de régler cet aspect en amont de la transaction[5966].

§ 2. Le choix du législateur européen lors de l'adoption de la Directive Mobilité

1089. Une harmonisation *a minima*. Face à cette situation, et tout particulièrement face à l'évident échec de la délégation pure et simple aux États membres prônée par la Directive Sociétés en matière de fusions transfrontalières[5967], le législateur européen a souhaité accroître le degré d'harmonisation de la protection des associés minoritaires. Une telle intervention correspond au souhait des différents *stakeholders* mis en lumière lors de la consultation publique de 2015[5968]. Cependant, contrairement à ce qui avait été souhaité lors de cette consultation publique[5969] ainsi que dans la résolution du Parlement européen de 2017[5970], le législateur européen a très explicitement opté pour une harmonisation *a minima* à l'égard de la protection des associés minoritaires impliquant que les États membres seront libres d'intégrer des mécanismes de protection additionnels[5971].

5963 Étude d'impact, p. 22 et en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, pp. 2255 et 2256.

5964 Étude d'impact, p. 22.

5965 Lors de la consultation publique de 2015, 65 % des personnes s'étant prononcées sur le sujet ont exprimé leur préférence pour une harmonisation de la protection des associés minoritaires. Voir : Étude d'impact, p. 20 et Consultation publique de 2015, p. 9.

5966 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 69.

5967 Voir en ce sens : N. BENZ, L. HÜBNER et A. ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 2256 et J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 254 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20.

5968 Lors de la consultation publique de 2015, 65 % des personnes s'étant prononcées sur le sujet ont exprimé une préférence pour l'harmonisation de la protection des actionnaires minoritaires. Voir : Consultation publique de 2015, p. 9.

5969 Lors de la consultation publique de 2015, 71 % des personnes s'étant prononcées sur le sujet ont exprimé une préférence pour une harmonisation complète de la protection des actionnaires minoritaires. Voir : Consultation publique de 2015, p. 9.

5970 Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017, pt. 3.

5971 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 21 et 17e considérant de la Directive Mobilité et à ce sujet : W. BAYER et J. SCHMIDT, « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum

1090. Un choix justifié de prime abord. Si une harmonisation s'imposait d'une part en vue de réduire tant l'insécurité juridique que les coûts qui en résultent pour les sociétés[5972] et d'autre part, en raison du fait que les risques encourus par les associés minoritaires sont similaires à travers les États membres[5973], on peut s'étonner du choix du législateur européen de recourir à une telle approche restrictive[5974]. Ce choix s'explique pour deux raisons. Tout d'abord, la protection des associés minoritaires dépasse le seul cadre spécifique de la mobilité tant nationale que transfrontalière et s'inscrit de manière plus générale dans le droit des sociétés et la gouvernance d'entreprise de chaque État membre[5975]. Il s'ensuit que les traditions varient fortement à cet égard[5976] et qu'il est donc plus avisé de permettre aux États membres de bénéficier d'une certaine marge de manœuvre afin de s'assurer que leur régime de protection des associés minoritaires en cas de scission transfrontalière s'accommode au mieux des spécificités des différents droits des sociétés nationaux[5977]. En outre, s'il n'a certes pas échappé au législateur européen qu'une harmonisation *a minima* serait susceptible d'entraîner un coût pour les sociétés qui soit supérieur à une harmonisation pure et simple, ce dernier a estimé que bon nombre d'États membres ne recourraient pas à la marge de manœuvre laissée par la Directive Mobilité dans la mesure où la protection des associés minoritaires offerte par celle-ci était élevée et intégrait les principaux mécanismes en la matière[5978]. Au-delà de ces deux arguments rationnels, il convient toutefois de relever que de manière très réaliste, et non sans une pointe de résignation, l'Étude d'impact mentionne clairement que comme la protection des associés minoritaires s'insère dans un cadre plus vaste, un degré d'harmonisation supérieur à une harmonisation *a minima* ne semble pas politiquement faisable à l'heure actuelle[5979].

1091. Une justification critiquable. S'il est indéniable que l'harmonisation opérée par la Directive Mobilité renforcera la sécurité juridique et permettra de réduire les coûts engendrés par la délicate question de la protection

Europäischen Unternehmensrecht 2017/18 », *op. cit.*, p. 2568 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 307 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 363 ; ECLE, *op. cit.*, p. 200 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 254 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2439.

5972 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 69 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20.

5973 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 69.

5974 Voir en ce sens également : ECLE, *op. cit.*, p. 200 ; O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 145 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 47.

5975 Étude d'impact, p. 73.

5976 *Ibidem*. Voir également : Étude TGS Baltic pour une étude détaillée des différents mécanismes de protection des associés minoritaires au sein des États membres.

5977 Étude d'impact, p. 73.

5978 Étude d'impact, pp. 73 à 75.

5979 Selon l'Étude d'impact, « [a]*s the system of minority shareholders protection is often part of the core company law, it does not seem politically feasible to provide for rules which would not leave enough flexibility to MS* ». Voir Étude d'impact, p. 75. Voir en ce sens également : ECLE, *op. cit.*, p. 200 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 47 qui sous-entendent que le choix de l'harmonisation *a minima* s'explique par cette dimension politique.

des associés minoritaires dans le cadre d'une scission transfrontalière[5980] et s'il est vrai qu'une harmonisation exhaustive en la matière n'est pas forcément souhaitable en raison des positions divergentes des États membres à l'égard des associés minoritaires[5981], il n'en demeure pas moins que l'harmonisation *a minima* se doit d'être suffisante pour que les bénéfices escomptés, à savoir une réduction des coûts et une augmentation de la sécurité juridique[5982], puissent effectivement être réalisés. En d'autres termes, pour pouvoir résoudre les insuffisances du régime des fusions transfrontalières par le biais d'une harmonisation *a minima*, il est indispensable d'introduire un système de protection des associés minoritaires suffisamment cohérent et efficace limitant considérablement l'intérêt de régimes nationaux spécifiques[5983]. Or, le régime de protection des associés minoritaires laisse une large marge de manœuvre aux États membres[5984] puisque ceux-ci pourront, (i) désigner les associés qui pourront bénéficier du droit de retrait[5985], (ii) exiger l'enregistrement exprès de l'opposition au projet de scission transfrontalière ou de l'intention d'exercer le droit de retrait ou les deux au plus tard lors de l'assemblée générale[5986], (iii) déterminer le délai de déclaration à la société de la décision d'exercer le droit de retrait[5987], (iv) déterminer le délai de versement de la soulte en espèces[5988], (v) fixer la date limite pour réclamer une soulte en espèces supplémentaire, (vi) choisir d'assortir ou non la décision rendue sur la soulte en espèces supplémentaire d'un effet *erga omnes*[5989] et (vii) ouvrir la possibilité pour la société scindée d'offrir des actions ou une autre compensation au lieu d'une soulte en espèces si le rapport d'échange est jugé insuffisant[5990]. On ne peut donc que se demander si l'harmonisation sera effectivement suffisante.

§ 3. Un nouvel exemple de l'habileté politique de la Commission

1092. Un résultat prévisible. L'harmonisation limitée prônée par le législateur européen ainsi que la large marge de manœuvre laissée aux États membres, bien que dictées par les négociations politiques au niveau du trilogue[5991], ne permettront certainement pas de résoudre tous les problèmes posés par la coexistence de multiples régimes de protection nationaux[5992]. Ainsi, il est pratiquement certain que l'évaluation de la Directive Mobilité qui aura lieu au plus tard le 1er février 2027 mettra en lumière l'insuffisance de l'harmonisation de la protection des associés minoritaires. En revanche, ce choix contraint

5980 Étude d'impact, p. 75. Pour un point de vue positif, voir également : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 253.
5981 Étude d'impact, p. 73.
5982 17e considérant de la Directive Mobilité et Étude d'impact, p. 58.
5983 Voir en ce sens : M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 48.
5984 Voir en ce sens : Fr. SCHURR, *op. cit.*, p. 543.
5985 Art. 160*decies*, § 1er, al. 1 et 2 de la Directive Mobilité.
5986 Art. 160*decies*, § 1er, al. 3 de la Directive Mobilité.
5987 Art. 160*decies*, § 2, 1re phrase de la Directive Mobilité.
5988 Art. 160*decies*, § 4, al. 1er, 2e phrase de la Directive Mobilité.
5989 Art. 160*decies*, § 4, al. 2 de la Directive Mobilité.
5990 Art. 160*decies*, § 7 de la Directive Mobilité.
5991 Fr. SCHURR, *op. cit.*, p. 543.
5992 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 200 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 71.

s'accompagne de deux avantages significatifs. Tout d'abord, ce moindre degré d'harmonisation a indéniablement simplifié le processus législatif ayant conduit à l'adoption de la Directive Mobilité puisque du point de vue des États membres disposant déjà d'une législation élaborée en la matière, le régime de la Directive Mobilité, est peu intrusif. Ensuite, plus subrepticement, ce choix restrictif permettra lors de l'adoption de la révision de la Directive Mobilité d'établir l'insuffisance d'une harmonisation *a minima* et la nécessité d'aller un pas plus loin dans l'harmonisation, soit en proposant un nombre limité d'options comme recommandé dans une des études préalables[5993], soit en procédant à une harmonisation complète comme souhaité à l'égard du régime des fusions transfrontalières lors de la consultation publique de 2015[5994]. Il s'ensuit qu'il est possible de voir dans cette attitude restrictive un autre exemple de l'habileté politique du législateur européen qui prépare le terrain pour une mesure de plus grande envergure.

SECTION 7. LES ASPECTS TEMPORELS DE LA PROTECTION DES ASSOCIÉS MINORITAIRES

1093. Plan de la section 7. Après une brève présentation de la problématique des aspects temporels de la protection des associés minoritaires (§ 1), il conviendra d'étudier méthodiquement les aspects temporels du droit de retrait (§ 2), les aspects temporels du droit de contester le montant de la soulte en espèces (§ 3) et les aspects temporels du droit de contester le rapport d'échange (§ 4). Pour chacun de ces trois pans, l'analyse se fera systématiquement dans l'optique de déterminer les caractéristiques que devra revêtir un régime européen plus général des scissions transfrontalières.

§1. Présentation

1094. Le point de départ de la protection avant l'adoption de la Directive Mobilité. La Directive Sociétés ne prévoit pas d'indication quant au point de départ des mécanismes de protection des associés minoritaires qui auraient pu être mis en place par les différents États membres. Il s'ensuit que celui-ci varie d'un droit national à un autre, mais dans une moindre mesure que dans le cas de la protection des créanciers[5995]. À l'égard des fusions transfrontalières, le mécanisme de protection peut intervenir au moment de la décision de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération ou à la date d'enregistrement ou de publication de l'opération au registre compétent[5996]. Il n'y a donc pas la même distinction qu'à l'égard des créanciers entre mécanismes *ex ante* et *ex*

[5993] Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 20.
[5994] Consultation publique de 2015, p. 9.
[5995] Sur cet aspect de la protection des créanciers, voir *supra* : Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section 2, § 2.
[5996] Étude d'impact, p. 157 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 69.

post[5997] puisque tous les mécanismes seront *ex post*[5998]. Malgré cette différence par rapport au régime de protection des créanciers, dans le cadre de la consultation publique de 2015, les trois quarts des personnes se sont prononcés en faveur d'une harmonisation du point de départ de la durée de protection[5999].

1095. La durée de la protection avant l'adoption de la Directive Mobilité. Tout comme à l'égard du point de départ de la protection, la Directive Mobilité ne contient pas d'indications précises au sujet de la durée du mécanisme de protection. À l'égard du régime des fusions transfrontalières existant avant l'adoption de la Directive Mobilité, il s'est avéré que la durée de la protection des associés minoritaires variait considérablement d'un État membre à un autre et pouvait aller d'une dizaine de jours à trois mois[6000]. Face à cette diversité et aux incertitudes qui en résultent, il n'est pas surprenant de constater que lors de la consultation publique de 2015, une majorité des personnes s'étant prononcées sur la question ont exprimé une préférence pour une harmonisation de la durée de la protection[6001].

§ 2. Aspects temporels de l'exercice du droit de retrait

1096. Plan du § 2. À l'égard des aspects temporels de l'exercice du droit de retrait, deux aspects particuliers nécessitent d'être étudiés successivement. Il s'agit en premier lieu du délai d'acceptation de l'offre de retrait (A) et en deuxième lieu du délai de paiement de la soulte en espèces (B).

A. *Le délai d'acceptation de l'offre de retrait*

1097. L'évolution au cours du processus législatif. La Proposition de la Commission prévoyait à l'origine que les États membres devraient fixer le délai pour l'acceptation de la soulte en espèces adéquate, étant entendu que ce délai ne pourrait excéder un mois après la date de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération[6002]. Bien que cette solution correspondît parfaitement aux résultats de la consultation publique de 2015[6003], ce délai a fait l'objet de certaines critiques en doctrine d'une part en raison de son caractère particulièrement court qui aurait contraint les associés minoritaires à prendre la décision de quitter la société très tôt dans le processus de scission[6004] et d'autre part,

5997 À ce sujet, voir *supra* n° 896.
5998 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 69.
5999 Consultation publique de 2015, p. 10.
6000 Étude d'impact, p. 143 et Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 69.
6001 Sur 85 % des personnes s'étant prononcées sur le sujet, 69 % étaient en faveur d'une harmonisation de la durée de la protection. Voir : Consultation publique de 2015, p. 12.
6002 Art. 160*terdecies*, § 3, 2e phrase de la Proposition de la Commission.
6003 Lors de la consultation de 2015, la majorité des personnes ayant émis une opinion à ce sujet s'étaient prononcées en faveur d'un délai d'un mois prenant cours le jour de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération. Voir : Consultation publique de 2015, pp. 8 à 12.
6004 Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU) in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 »,

en raison du fait que cela supposait que les associés minoritaires disposassent pratiquement simultanément d'une information sur le résultat du vote[6005]. Il est cependant resté identique dans le Premier Compromis de la Présidence[6006], le Deuxième Compromis de la Présidence[6007], le Compromis des Représentants Permanents[6008], le Compromis Final[6009] et la Proposition du Parlement[6010]. C'est ainsi que la Directive Mobilité prévoit que le délai pour déclarer la décision d'exercer le droit de retrait à la société concernée ne peut excéder un mois après la date de l'assemblée générale[6011].

1098. La situation en droit allemand et en droit autrichien. En droit allemand des fusions transfrontalières, le délai d'acceptation de l'offre sera de deux mois à compter de la date à laquelle la fusion transfrontalière aura été enregistrée et publiée au registre de la société bénéficiaire étrangère[6012]. Ce délai correspond à celui applicable en cas d'opération interne[6013]. En outre, il est également prévu que lorsqu'un associé a contesté le caractère adéquat du montant de la soulte en espèces devant une juridiction compétente, le délai d'acceptation de l'offre sera de deux mois à compter de la publication de la décision[6014]. En revanche, la question de la possibilité d'accepter l'offre avant la date de prise d'effet de l'opération est débattue[6015]. Ces délais particulièrement longs ont pour conséquence directe que ce n'est bien souvent que longtemps après que l'opération aura pris effet qu'il sera possible de déterminer avec précision quels associés feront effectivement usage de leur droit de retrait[6016]. En droit autrichien des fusions transfrontalières[6017], le délai d'acceptation de l'offre est d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale de la société concernée. Ce délai plus court qu'en cas d'opération interne[6018], où un délai de deux mois à compter de la date d'opposabilité de l'opération prévaut, s'explique par le caractère transfrontalier de l'opération[6019].

op. cit., p. 860 ; M. NOACK, *op. cit.*, pp. 782 et 783 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2707. Voir également en ce sens : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 9. *Contra* : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, pp. 256 et 257 et Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 245.

6005 DAV, *ibidem*, p. 860.

6006 Art. 160l, § 2a, 2e phrase du Premier Compromis de la Présidence.

6007 Art. 160l, § 2a, 2e phrase du Deuxième Compromis de la Présidence.

6008 Art. 160l, § 2a, 2e phrase du Compromis des Représentants Permanents.

6009 Art. 160l, § 2a, 2e phrase du Compromis Final.

6010 Art. 160*terdecies*, § 2, 2e phrase de la Proposition du Parlement.

6011 Art. 160*decies*, § 2 de la Directive Mobilité.

6012 § 122i(1), 3e phrase UmwG. Voir à ce sujet : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 17 ; Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 9 et R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 5.

6013 § 31 UmwG.

6014 §§ 31, 2e phrase et 122i(1) UmwG.

6015 *Pro* : Fl. DRINHAUSEN in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 9. *Contra* : R. MARSCH-BARNER et C. WILK in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 5 et J. VETTER, *op. cit.*, p. 623. Voir également : W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 17 qui ne prend pas position.

6016 Voir en ce sens : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 31, n° 2.

6017 § 10(1), 2e phrase EU-VerschG.

6018 § 9(1), 4e phrase SpaltG et § 234b(3), 2e phrase öAktG.

6019 Voir en ce sens : J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 441.

1099. La situation en droit belge et luxembourgeois. Tant en droit belge qu'en droit luxembourgeois, dans le cadre de la scission interne ou transfrontalière d'une société coopérative au profit de sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme, il est expressément prévu que les associés de la société coopérative pourront exercer leur droit de démissionner par le biais d'une notification à la société par lettre recommandée déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée[6020].

1100. L'impact de la participation des travailleurs. Tout comme le législateur autrichien[6021], le législateur belge[6022] et le législateur luxembourgeois[6023], et contrairement au législateur allemand[6024], le législateur européen a fait le choix d'articuler le délai d'acceptation autour de la date de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération[6025]. Cependant, dans le cadre d'une opération transfrontalière où le régime de protection de la participation des travailleurs devrait trouver à s'appliquer[6026], certaines interrogations sont susceptibles de se présenter. En effet, le régime des scissions transfrontalières consacré par la Directive Mobilité prévoit explicitement que l'assemblée générale peut subordonner la réalisation de la scission transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités relatives à la participation des travailleurs[6027]. En conséquence, dans une telle hypothèse où une seconde assemblée générale sera tenue[6028], on peut se demander si le délai d'exercice du droit de retrait devrait être calculé à compter de la première assemblée générale ou de la seconde. En droit autrichien des fusions transfrontalières, on considère que le délai d'acceptation commencera à courir à compter de la date de la seconde assemblée générale[6029]. Cette dernière solution est logique, ne fût-ce qu'en raison de la durée potentiellement très longue des mécanismes de négociation destinés à assurer la protection de la participation des travailleurs[6030], mais elle mériterait d'être clarifiée par le législateur européen.

1101. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. Prévoir un point de départ du délai antérieur à la date de prise d'effet de l'opération permet aux sociétés concernées d'évaluer plus précisément le coût potentiellement engendré par l'exercice du droit de retrait par les différents associés

6020 Art. 12:66, § 2 (scission par absorption) et 12:82, § 2 (scission par constitution de nouvelles sociétés) du CSA et art. 1031-9, § 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
6021 § 10(1), 2e phrase EU-VerschG.
6022 Art. 12:66, § 2 (scission par absorption) et 12:82, § 2 (scission par constitution de nouvelles sociétés) du CSA.
6023 art. 1031-9, § 2 de la Loi luxembourgeoises sur les sociétés commerciales.
6024 § 122*i*(1), 3e phrase UmwG.
6025 Art. 160*decies*, § 2, 2e phrase de la Directive Mobilité.
6026 Sur ce mécanisme de protection, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2.
6027 Art. 160*nonies*, § 2 de la Directive Mobilité.
6028 Sur la possibilité de déléguer l'entérinement des modalités relatives à la participation des travailleurs à l'organe de gestion, voir *supra* n° 627.
6029 J. MITTERECKER, *op. cit.*, p. 441.
6030 Art. 160*terdecies*, § 3, c) de la Directive Mobilité et art. 5 de la Directive Participation des Travailleurs qui prévoit une durée maximale des négociations de six mois, prolongeable de commun accord jusqu'à un an.

minoritaires[6031], ainsi que l'impact de celui-ci sur leurs liquidités[6032]. Si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, il serait plus logique de prévoir qu'au plus tard au moment de la tenue de l'assemblée générale, les associés minoritaires sortants auront dû faire part de leur intention de quitter la société. En effet, un tel délai raccourci permettrait à l'assemblée générale de prendre une décision en pleine connaissance de cause. En outre, compte tenu du fait que (i) l'offre de soulte en espèces doit déjà figurer dans le projet commun de scission[6033], (ii) le projet de scission doit être publié au moins un mois avant la date de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur l'opération[6034], (iii) le rapport ou la partie du rapport à l'intention des associés contenant notamment une explication de la soulte en espèces et de la méthode utilisée pour la déterminer[6035] doit être mis à la disposition des associés au moins six semaines avant la date de l'assemblée générale[6036] et (iv) le rapport de l'expert indépendant se prononçant sur le caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l'évaluation de la soulte en espèces[6037] doit nécessairement être mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale[6038], les associés minoritaires disposent très tôt dans le processus de scission transfrontalière de l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée quant à l'éventuel exercice de leur droit de sortie. Par ailleurs, lorsque l'assemblée générale de la société scindée aura fait le choix d'approuver la scission sous la condition suspensive qu'elle entérine expressément les modalités relatives à la participation des travailleurs[6039], il conviendra de prévoir que c'est à la date de la seconde assemblée que le délai d'acceptation de la soulte en espèces prendra fin. Pour finir, prévoir un droit de retrait exerçable dès la publication du projet de scission et exerçable au plus tard lors de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération semble également indispensable du point de vue de la protection des créanciers. En effet, compte tenu du risque significatif que le droit de retrait fait peser sur les liquidités de la société[6040], le droit de demander une garantie adéquate pour les créanciers devra nécessairement s'étendre au-delà du délai d'exercice du droit de retrait de manière à permettre aux créanciers de justifier l'octroi de garanties adéquates sur la base de l'érosion financière engendrée par l'exercice du droit de retrait[6041].

6031 17e considérant de la Directive Mobilité et à ce sujet : Th. LUY, « Die Austrittserklärung des Minderheitsgesellschafters nach dem Company Law Package », *op. cit.*, p. 1106.

6032 Th. LUY, « Die Austrittserklärung des Minderheitsgesellschafters nach dem Company Law Package », *ibidem*, p. 1106.

6033 Art. 160*quinquies*, point p) de la Directive Mobilité.

6034 Art. 160*octies*, § 1er, a) de la Directive Mobilité.

6035 Art. 160*sexies*, § 3, a) de la Directive Mobilité.

6036 Art. 160*sexies*, § 6 de la Directive Mobilité.

6037 Art. 160*septies*, § 2, c) de la Directive Mobilité.

6038 Art. 160*septies*, § 1er, 2e phrase de la Directive Mobilité.

6039 Art. 160*nonies*, § 2 de la Directive Mobilité.

6040 Voir en ce sens : Étude d'impact, p. 74 et W. BAYER in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 122i, n° 6 ; P.-H. CONAC, *op. cit.*, p. 8 ; A. FRANCK, *op. cit.*, p. 229 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 245 ; J. VETTER, *op. cit.*, p. 623 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 68.

6041 Sur la prise en compte des sommes versées dans le cadre de l'exercice du droit de retrait en droit allemand des fusions internes pour justifier l'octroi d'une garantie adéquate aux créanciers, voir : B. GRUNEWALD in M. LUTTER (dir.), *op. cit.*, § 22, n° 13 et G. SEULEN in J. SEMLER et A STENGEL (dir.), *op. cit.*, p. 316, n° 30.

Du point de vue de l'étude de la protection des créanciers, il est possible d'en tirer deux précieux enseignements. Tout d'abord, il est indispensable de prévoir un délai de protection des créanciers supérieur à celui de la protection des associés minoritaires, puisque les mécanismes de protection de ces derniers impacteront les premiers. Ceci devrait être le cas sous l'empire de la Directive Mobilité puisque le délai pour demander une garantie adéquate est de trois mois à compter de la publication du projet de scission transfrontalière[6042], que la publication du projet commun de scission doit avoir lieu au moins un mois avant la date de l'assemblée générale et que le droit de retrait est exerçable au plus tard un mois après la date de l'assemblée générale[6043], ce qui laisse au mieux un mois de battement aux créanciers pour demander une garantie adéquate. Ce sera d'autant plus le cas si le *dies ad quem* pour l'exercice du droit de retrait est fixé au jour de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération comme suggéré ci-dessus. Cependant, comme le délai susceptible de s'écouler entre la publication du projet de scission et la tenue de l'assemblée générale est susceptible d'être beaucoup plus long qu'un mois, il est indispensable d'élaborer davantage le délai de protection des créanciers en précisant qu'en tout état de cause, celui-ci ne prendra fin qu'au plus tard un mois après la date de l'assemblée générale si cette dernière constitue la date limite d'exercice du droit de retrait. Ensuite, dans un même ordre d'idées, il serait utile et dans l'intérêt de la sécurité juridique de préciser que lorsque l'assemblée générale a fait le choix de subordonner la réalisation de l'opération à la condition qu'elle entérine expressément les modalités relatives à la participation des travailleurs[6044], c'est cette dernière date qu'il conviendra de prendre en compte pour le calcul des différents délais.

B. *Le délai de paiement de la soulte en espèces*

1102. La position du législateur européen. Selon le texte de la Directive Mobilité, le délai pour le versement de la soulte en espèces mentionnée dans le projet de scission sera déterminé par les États membres, étant entendu que ce délai prendra fin au plus tard deux mois après la date de prise d'effet de la scission transfrontalière[6045]. La Proposition de la Commission prévoyait à l'origine un délai déterminé par les États membres mais ne pouvant en tout état de cause dépasser un délai d'un mois à compter de la date de prise d'effet de l'opération[6046]. Ce délai est passé à deux mois dès le Premier Compromis de la Présidence[6047] et le Deuxième Compromis de la Présidence a tenté de supprimer la latitude laissée aux États membres à l'égard de la détermination du délai[6048]. Cette dernière position ne se retrouve toutefois ni dans le Compromis

6042 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
6043 Art. 10*decies*, § 2, 2e phrase de la Directive Mobilité.
6044 Art. 160*nonies*, § 2 de la Directive Mobilité.
6045 Art. 160*decies*, § 3 de la Directive Mobilité.
6046 Ar. 160*terdecies*, § 4, 2e phrase de la Directive Mobilité.
6047 Art. 160l, § 3 du Premier Compromis de la Présidence.
6048 Art. 160l, § 3 du Deuxième Compromis de la Présidence.

des Représentants Permanents[6049], ni dans le Compromis Final[6050], ni dans la Proposition du Parlement[6051] qui prévoient systématiquement que le délai de paiement de la soulte en espèces sera déterminé par les États membres, mais que celui-ci ne pourra en tout état de cause excéder un délai de deux mois après la date de prise d'effet de l'opération.

1103. La situation en droit allemand et en droit autrichien. En droit allemand, le paiement de la soulte en espèces est exigible dès que l'associé sortant quitte la société[6052], mais des aménagements conventionnels demeurent admissibles[6053]. En outre, la soulte en espèces additionnelle portera intérêt à compter de la date de la publication de l'enregistrement de la fusion au registre du siège de la société bénéficiaire[6054] afin d'éviter que la société concernée ne fasse durer excessivement la procédure[6055]. De même, en droit autrichien des fusions transfrontalières, le paiement de la soulte en espèces est exigible dès la date de prise d'effet de la fusion en vertu du droit étranger[6056].

1104. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. S'il découle de la formulation large du législateur européen dans la Directive Mobilité que les États membres disposeront de la possibilité d'imposer un délai de paiement plus court[6057], on peut s'interroger si un délai maximum de deux mois serait compatible avec l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. En effet, dans le cadre d'une scission par constitution de nouvelles sociétés, sauf cas particulier[6058], chacune des fractions de patrimoine devra avoir un actif net positif. Il s'ensuit que chacune des nouvelles sociétés issues de l'opération aura nécessairement également un actif net positif lui permettant de faire plus aisément face à certains éléments de passif. Cependant, ce ne sera pas nécessairement le cas dans le cadre d'une scission par acquisition où il se pourrait très bien que même après la scission, les deux sociétés bénéficiaires se retrouvent avec un actif net négatif les mettant dans l'impossibilité de s'acquitter de la soulte en espèces à brève échéance. On pourrait dès lors se demander s'il ne conviendrait pas de prévoir un délai de paiement plus élaboré en fonction de l'identité de l'acheteur, et ce, afin d'éviter d'entraver excessivement des sociétés souhaitant réaliser une scission-assainissement dont les bénéfices ne se ressentiront que quelque temps après la réalisation de l'opération. En effet, lorsque les actions sont rachetées par les associés de la société scindée, les associés des sociétés bénéficiaires ou encore des tiers, un délai par défaut de deux mois est tout à fait suffisant,

6049 Art. 160l, § 3 du Compromis des Représentants Permanents.
6050 Art. 160l, § 3 du Compromis Final.
6051 Art. 160*terdecies*, § 3, 2e phrase de la Proposition du Parlement.
6052 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 ; S. KALSS in J. SEMLER, A. STENGEL et N. LEONARD (dir.), *op. cit.*, § 31, n° 9 et R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 29, n° 23.
6053 Voir en ce sens : M. NOACK, *op. cit.*, p. 785 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440.
6054 §§ 15(2), 1re phrase ; 122h et 125 UmwG.
6055 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 15, n° 9.
6056 § 10(1), 3e phrase EU-VerschG et à ce sujet : G. ECKERT in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 691, n° 27.
6057 Voir en ce sens : P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440.
6058 À ce sujet, voir *supra* nos 118 à 120.

étant entendu que comme en droit allemand[6059], les parties pourraient y déroger conventionnellement en cas de besoin. En revanche, lorsque la soulte en espèces doit être versée par les sociétés bénéficiaires, il serait préférable de prévoir un délai de paiement plus long, et ce pour deux raisons. Premièrement, imposer un délai trop court risque de dissuader les sociétés bénéficiaires de faire usage de leur liberté d'établissement par le biais d'une scission par acquisition et nuirait dès lors à la proportionnalité de la mesure de protection à l'aune du « *Gebhard test* ». Ensuite, autoriser un étalement plus long dans le temps permet de limiter l'impact du droit de retrait sur les créanciers tant de la société scindée que des sociétés bénéficiaires et restreint du même coup les hypothèses où l'octroi d'une garantie adéquate pourrait être justifié par l'érosion financière engendrée par les mécanismes de protection des associés minoritaires[6060]. Autoriser les États membres à prévoir deux délais distincts serait donc une évolution bienvenue qui s'imposerait d'autant plus en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante.

§ 3. Aspects temporels du droit de contester le montant de la soulte en espèces

1105. L'évolution au cours du processus législatif. La Proposition de la Commission prévoyait à l'origine que les associés ayant accepté l'offre de soulte en espèces pouvaient exiger un nouveau calcul de celle-ci devant un tribunal national dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de l'offre[6061]. Ce point de départ avait fait l'objet de certaines critiques en raison du fait qu'il aurait été variable en fonction de chaque associé[6062], raison pour laquelle il a pu être recommandé de faire coïncider celui-ci avec la date d'écoulement du délai d'acceptation de l'offre de retrait[6063]. Dans un même ordre d'idées, la durée de ce délai avait été contestée dans la mesure où (i) elle était excessivement courte[6064] et (ii) elle contraignait les associés à agir en justice à un moment où la restructuration n'avait pas encore pris effet et où l'existence de la créance de l'associé minoritaire à l'encontre de la société n'était pas encore fixée[6065]. Dès le Premier Compromis de la Présidence[6066], il a été prévu de laisser les États

6059 Voir en ce sens : M. NOACK, *op. cit.*, p. 785 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440.

6060 Sur ce risque pour les créanciers, voir *supra* n° 701.

6061 Art. 160*terdecies*, § 5 de la Proposition de la Commission.

6062 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 309 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860 et M. NOACK, *op. cit.*, p. 784. *Contra* : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 257.

6063 DAV, *ibidem*, p. 860. *Contra* : J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 258.

6064 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 309 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2441. *Contra* : J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 258.

6065 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 309 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 784 et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2441. *Contra* : J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 258.

6066 Art. 160l, § 3a, 2e phrase du Premier Compromis de la Présidence.

membres déterminer le délai applicable à cette demande et cette position n'a plus changé au cours du processus législatif[6067].

1106. La situation en droit allemand et autrichien. Le délai prévu en droit allemand pour contester le caractère adéquat de la soulte en espèces est de trois mois à compter de la publication de la réalisation de l'opération au registre du siège de la société bénéficiaire en cas de fusion transfrontalière[6068] et de trois mois à compter de l'enregistrement de l'opération au registre compétent en cas de scission et de fusion internes[6069]. En droit autrichien, le délai est d'un mois après la date de la prise de décision à l'assemblée générale en cas de fusion transfrontalière[6070] et d'un mois à partir de la date de publication de l'enregistrement de l'opération en cas de fusion[6071] et de scission[6072] internes.

1107. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. Si certains auteurs ont pu plaider en faveur de l'adoption du régime allemand par le législateur européen[6073], il convient de formuler deux remarques. Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que le montant de la soulte en espèces fera l'objet d'une vérification par l'expert indépendant de sorte que la procédure en vérification du montant de celle-ci ne doit jouer le rôle que d'un garde-fou en cas d'insuffisances affectant l'expert indépendant ou encore lorsque le rapport de celui-ci est négatif[6074]. Il s'ensuit que le délai pour contester le rapport d'échange ne devrait pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remplir cet objectif. Ensuite, le risque d'une contestation du montant de la soulte en espèces fait peser une certaine insécurité tant sur la société concernée que sur les créanciers de celle-ci. Ce constat s'impose d'autant plus dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière par acquisition où une révision à la hausse du montant de la soulte en espèces impactera non seulement les sociétés impliquées, mais également potentiellement tous les créanciers de celle-ci. Si on ajoute à cela que l'objectif avéré du législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité est notamment de renforcer la sécurité juridique[6075], un délai court commençant à s'écouler dès que possible semble préférable et renforcerait la proportionnalité de la mesure à l'aune de la liberté d'établissement. Il en découle que malgré les critiques formulées à son encontre[6076], le délai

6067 Art. 160l, § 3a, al. 1er, 2e phrase du Deuxième Compromis de la Présidence ; art. 160l, § 3a, al. 1er, 2e phrase du Compromis des Représentants Permanents ; art. 160l, § 3a, al. 1er, 2e phrase du Compromis Final ; art. 160*terdecies*, § 4, al. 1er, 2e phrase de la Proposition du Parlement et art. 160*decies*, § 4, al. 2 de la Directive Mobilité.

6068 § 4 (1), n° 5 SpruchG.

6069 § 4 (1), n° 4 SpruchG.

6070 § 11(2), 1re phrase EU-VerschG.

6071 §§ 225e(2) et 234b(5) öAktG.

6072 § 225e(2) öAktG et § 11(2) SpaltG.

6073 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 308 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 784 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2440.

6074 À ce sujet, voir *supra* n° 1047.

6075 17e considérant de la Directive Mobilité et Étude d'impact, p. 58.

6076 Pour une vision critique, voir : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 309 ; DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 860 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 784 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2441.

de la Proposition de la Commission qui était d'un mois à compter de la date d'acceptation de l'offre[6077] était tout à fait adapté et mériterait de se retrouver dans un régime plus général des scissions transfrontalières.

§ 4. Aspects temporels du droit de contester le rapport d'échange

1108. L'évolution au cours du processus législatif. Alors que la Directive Mobilité prévoit que le délai applicable à la contestation du rapport d'échange sera déterminé par le droit national applicable[6078], la Proposition de la Commission prévoyait que l'action en question devait être introduite dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur de la scission transfrontalière[6079]. Ce délai avait fait l'objet de certaines critiques car il avait été jugé excessivement court[6080]. Il a ainsi été laissé à la discrétion des États membres dès le Premier Compromis de la Présidence[6081] et n'a plus été altéré par la suite[6082].

1109. La situation en droit allemand et en droit autrichien. En droit allemand, la demande en vue de l'obtention d'une soulte en espèces additionnelle destinée à compenser un rapport d'échange incorrect doit être formulée (i) dans les trois mois suivant l'enregistrement de la fusion transfrontalière au registre étranger dans l'hypothèse d'une fusion-émigration[6083] et (ii) dans les trois mois suivant l'enregistrement de l'opération au registre de commerce compétent en cas de fusion ou de scission interne[6084]. En droit autrichien des fusions internes[6085] et des scissions internes[6086], le délai pour contester le caractère adéquat du rapport d'échange est d'un mois à compter de la publication de l'enregistrement de l'opération, étant entendu que les associés qui (i) étaient associés entre la décision de l'assemblée générale et l'introduction de la demande et (ii) qui n'ont pas renoncé à l'attribution d'actions supplémentaires ou d'une soulte en espèces additionnelle disposent d'un délai d'un mois supplémentaire. En pratique, en tenant compte des différents délais susceptibles de s'écouler entre les étapes de la procédure, il s'ensuit que les associés disposent fréquemment d'un délai de quatre mois pour agir[6087].

1110. Un nouveau régime des scissions transfrontalières. Si certains ont pu plaider en faveur de l'adoption du long délai applicable en droit allemand[6088], il convient de prendre trois éléments distincts en considération dans le cadre

6077 Art. 160*terdecies*, § 5 de la Directive Mobilité.
6078 Art. 160*decies*, § 6, 2e phrase de la Directive Mobilité.
6079 Ar. 160*terdecies*, § 7 de la Proposition de la Commission.
6080 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 310 ; M. NOACK, *op. cit.*, p. 787 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2442.
6081 Art. 160l, § 7 du Premier Compromis de la Présidence.
6082 Art. 160l, § 7 du Deuxième Compromis de la Présidence ; art. 160l, § 7 du Compromis des Représentants Permanents ; art. 160l, § 7 du Compromis Final ; art. 160*terdecies*, § 6, 2e phrase de la Proposition du Parlement et art. 160*decies*, § 6, 2e phrase de la Directive Mobilité.
6083 § 4(1), pt. 5 SpruchG et à ce sujet : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 267.
6084 § 4(4) SpruchG.
6085 § 225e (2) öAktG.
6086 § 9 SpaltG et à ce sujet : S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 975, n° 81.
6087 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *ibidem*, p. 271.
6088 Voir en ce sens : M. NOACK, *op. cit.*, p. 787 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2442.

de la détermination des aspects temporels du droit de contester le rapport d'échange. Le premier concerne la date à laquelle la juridiction compétente va apprécier le caractère correct du rapport d'échange. Cet aspect est absent de la Directive Mobilité, mais revêt néanmoins une importance considérable. En effet, (i) comme le rapport d'échange est fixé sur la base de la valeur des différentes sociétés impliquées dans l'opération à un moment déterminé nécessairement antérieur à l'établissement du projet de commun de scission[6089] et (ii) étant donné qu'en fonction de la méthode d'évaluation utilisée, la valeur des sociétés risque de fluctuer entre la date d'établissement du rapport d'échange et la date de prise d'effet de l'opération, un rapport d'échange qui pourrait s'avérer tout à fait correct au moment de la publication du projet commun pourrait se révéler foncièrement déséquilibré au moment de la tenue de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération. En droit allemand, qui n'ouvre un tel droit de contester le rapport d'échange qu'aux seuls associés minoritaires de la société scindée[6090] ou absorbée[6091], cette question a été résolue en considérant que le caractère correct du rapport d'échange devait être apprécié au moment où la décision de procéder à l'opération a été prise au sein de la société concernée[6092]. La solution est la même en droit autrichien[6093]. Dans la mesure où la liberté d'établissement impose que le mécanisme de protection des intérêts des associés minoritaires n'aille pas au-delà du nécessaire, il serait logique de faire débuter ce délai le plus tôt possible. En conséquence, le point de départ du droit de contester le caractère adéquat du rapport d'échange devrait être la date à laquelle le caractère adéquat de celui-ci sera apprécié, à savoir la date de tenue de l'assemblée générale, ce qui correspond au point de départ souhaité lors de la consultation publique de 2015[6094]. Le deuxième élément concerne le fait que dans le cadre des fusions transfrontalières, le législateur européen a, contrairement au législateur allemand[6095], fait le choix d'ouvrir le droit de contester le rapport d'échange à la fois aux associés de la société absorbée et aux associés de la société absorbante[6096] et qu'il a été établi qu'une telle solution devait également prévaloir à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[6097]. Il s'ensuit que si on adopte la date de la tenue de l'assemblée générale comme point de départ de la protection, celui-ci variera vraisemblablement en fonction de chaque société impliquée. Ce point n'est toutefois pas problématique à partir du moment où on prévoit que les juridictions compétentes pour connaître d'une contestation du rapport d'échange seront, pour chaque société concernée, les juridictions compétentes en vertu du droit national, ce qui correspond à la

6089 Sur la détermination du rapport d'échange dans le cadre d'une scission transfrontalière, voir *supra* : Première partie, Titre V, Chapitre 1, Section 3, § 7, B., 2.
6090 §§ 15(1) et 125 UmwG.
6091 §§ 15 et 122h(1) UmwG.
6092 R. MARSCH-BARNER et St. OPPENHOFF in H. KALLMEYER (dir.), *op. cit.*, § 15, n° 2.
6093 S. KALSS in S. KALSS (dir.), *op. cit.*, p. 262, n° 21.
6094 Lors de la consultation publique de 2015, § 73 % des personnes s'étant prononcées sur le sujet ont estimé que le délai de protection des associés minoritaires devait débuter au jour de l'assemblée générale. Voir : Consultation publique de 2015, pp. 10 et 11.
6095 §§ 15 et 122h UmwG.
6096 Art. 126*bis*, § 6, al. 1er de la Directive Mobilité.
6097 À ce sujet, voir *supra* n° 1069.

règle de compétence qui devrait trouver à s'appliquer à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[6098]. Le troisième aspect concerne plus spécifiquement le délai dont les associés minoritaires doivent disposer pour pouvoir contester le rapport d'échange. Compte tenu de l'incidence de la liberté d'établissement en la matière, ce délai devra nécessairement être le plus court possible sans pour autant compromettre l'efficacité de ce mécanisme de protection. À cet égard, le délai de trois mois prévu par le législateur allemand semble excessif et il serait préférable de privilégier un délai d'un mois comme ce qui avait été souhaité lors de la consultation publique de 2015[6099]. Un tel délai raccourci s'impose également à travers le prisme de la protection des créanciers. En effet, comme ceux-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du projet de scission[6100] pour demander une garantie adéquate[6101] et que l'assemblée générale ne peut se tenir au plus tôt qu'un mois après la date de publication du projet de scission[6102], les créanciers actifs et vigilants pourront, le cas échéant, se prévaloir de l'éventuelle érosion financière générée par la nécessité de compenser un rapport d'échange incorrect pour justifier l'octroi d'une garantie. Il s'ensuit qu'un délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale constitue un délai approprié pour l'introduction d'une demande en réévaluation du rapport d'échange.

SECTION 8. CONCLUSION SUR LES ENJEUX DE LA PROTECTION DES ASSOCIÉS MINORITAIRES

1111. Conclusion intermédiaire. Confrontés à une scission transfrontalière, les associés minoritaires des sociétés concernées encourent jusqu'à cinq risques distincts. Les protéger efficacement contre ces risques afin d'éviter un impact négatif sur l'accès des sociétés aux capitaux requiert toutefois d'aboutir à un délicat équilibre entre (i) les intérêts des associés minoritaires et les intérêts de la société et (ii) les intérêts des associés minoritaires et les intérêts des créanciers de la société concernée, tout en ne négligeant pas le fait que tout mécanisme de protection constituera également une entrave à la liberté d'établissement des sociétés concernées et devra, par conséquent, respecter les conditions du « *Gebhard test* »[6103]. A cela s'ajoute que les enjeux posés par la protection des associés minoritaires sont plus aigus dans une opération transfrontalière que dans une opération interne car un changement de *lex societatis* constitue un risque réel pour ceux-ci. L'analyse des mécanismes de protection des associés minoritaires instaurés par le législateur européen à travers le double prisme de la liberté d'établissement et de la protection des intérêts des créanciers tout

6098 À ce sujet, voir *supra* n°s 1079 à 1081.
6099 Lors de la consultation publique de 2015, 67 % des personnes s'étant prononcées sur le sujet avaient exprimé une préférence pour un délai d'un mois. Voir : Consultation publique de 2015, pp. 11 et 12.
6100 Art. 160*undecies*, § 1er, al. 2 de la Directive Mobilité.
6101 Sur ce mécanisme de protection des créanciers, voir *supra* n°s 767 à 779.
6102 Art. 160*octies*, § 1er de la Directive Mobilité.
6103 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.

en les comparant aux mécanismes de deux juridictions moins protectrices des intérêts des associés minoritaires en matière de mobilité, à savoir la Belgique et le Luxembourg, et de deux juridictions disposant des régimes parmi les plus élaborés en la matière, à savoir l'Allemagne et l'Autriche, a permis de mettre en lumière le fait que le régime prôné par le législateur européen demeure relativement proportionné et va même, dans une certaine mesure, dans le sens d'un renforcement de la mobilité transfrontalière. Ce point ressort tout particulièrement de l'analyse d'un renforcement des conditions de quorum et de majorité pour garantir une protection adéquate des intérêts des associés minoritaires[6104]. Il ressort également de cette analyse que le régime de protection des associés minoritaires consacré par la Directive Mobilité serait dans une très large mesure parfaitement compatible avec un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. Ce point est particulièrement saillant à l'égard de la possibilité de contester le rapport d'échange et de réclamer une soulte en espèces adéquate[6105] étant donné que ce mécanisme de protection ne fait vraiment de sens que dans l'hypothèse où au moins une des sociétés bénéficiaires existe déjà. Il est donc à nouveau possible de constater que le législateur européen a préparé le terrain pour une réforme plus ambitieuse du régime des scissions transfrontalières. Cependant, l'étude des différents mécanismes a également montré qu'un nombre relativement important d'aspects mériteraient d'être revus afin de mieux tenir compte des impératifs de la liberté d'établissement et de la protection des intérêts des créanciers. Le même constat s'impose suite à l'examen de l'harmonisation résolument *a minima* prônée par le législateur européen qui ne peut aboutir à une solution satisfaisante, mais constitue un préalable nécessaire pour rendre une harmonisation plus ambitieuse politiquement acceptable. Il en est de même à l'égard des aspects temporels de la protection des associés minoritaires qui, bien que compatibles avec un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, présentent certaines lacunes, tant en termes d'harmonisation, qu'en termes de respect des intérêts des créanciers et du prescrit de la liberté d'établissement.

6104 À ce sujet, voir *supra* n°s 999 à 1004.
6105 Sur ce mécanisme de protection, voir *supra* n°s 1059 à 1083.

Chapitre 2
Les enjeux d'une scission transfrontalière pour la participation des travailleurs

SECTION 1. PRÉSENTATION

1112. L'impact d'un changement de *lex societatis*. Une scission transfrontalière est susceptible d'avoir de nombreux impacts sur la situation des travailleurs des sociétés concernées[6106]. Cependant, il serait erroné de tenter de régir chacune des éventuelles conséquences sociales d'une scission transfrontalière dans une initiative européenne en la matière dans la mesure où cette dernière s'intégrera nécessairement dans le cadre légal existant et destiné à sauvegarder les intérêts des travailleurs[6107]. Cependant, il y a un aspect de droit social qui est tout particulièrement susceptible d'être impacté par une scission transfrontalière et qui, contrairement à ce qui est généralement le cas[6108], ne dépend pas d'un rattachement au droit du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail[6109], mais d'un rattachement à la *lex societatis* applicable. Cet aspect n'est autre que le droit de participation des travailleurs[6110]. Or, comme par définition, une scission transfrontalière est susceptible d'altérer la *lex societatis* à laquelle les travailleurs se retrouveront confrontés, il est indispensable de consacrer quelques développements à la question particulièrement épineuse[6111] de la préservation de la participation des travailleurs. Selon l'Étude d'impact, la préservation de la participation des travailleurs dans le cadre d'une scission transfrontalière doit en effet être considérée comme une partie intégrante de l'acquis social destiné à protéger les travailleurs dans le cadre d'une opération transfrontalière[6112] et repose sur le socle européen des droits sociaux[6113], et plus particulièrement sur le huitième principe qui tend à préserver le dialogue social et la participation des travailleurs[6114].

6106 Voir en ce sens : J. ROEST, *op. cit.*, p. 84.

6107 Ce cadre légal existant est composé essentiellement de (i) la directive (CE) 2009/38 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'E.E.E.), *J.O.*, L 122, 16 mai 2009, pp. 28–44 ; (ii) la directive (CE) 2002/14 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, *J.O.*, L 80, 23 mars 2002, pp. 29–34 ; (iii) la directive (CE) 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, *J.O.*, L 82, 22 mars 2001, pp. 16–20 et (iv) la directive (CE) 98/59 du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, *J. O.*, L 225, 12 août 1998, pp. 16–21.

6108 Voir en ce sens : D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 88 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 246 et Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, pp. 10 et 11.

6109 Art. 8, § 2 du Règlement Rome I et Étude d'impact, p. 39.

6110 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 35 ; Fr. SCHURR, *op. cit.*, p. 544 et Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, pp. 10 et 11.

6111 Sur le caractère politiquement délicat de cette question, voir *infra* n° 1119.

6112 Étude d'impact, p. 10.

6113 *Ibidem*.

6114 Les vingt principes clés du socle européen des droits sociaux, 8. Le dialogue social et la participation des travailleurs, disponible sur https://ec.europa.eu (29/03/2019) selon lequel : « Les partenaires sociaux sont consultés sur la conception et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et de l'emploi, conformément aux pratiques nationales. Ils sont encouragés à négocier et à établir des conventions collectives sur des sujets qui les concernent, dans le respect de leur autonomie et de leur droit à l'action collective. Le cas échéant, des accords entre les partenaires

1113. Plan du chapitre 2. En identifiant au préalable les différents enjeux posés à cet égard par une scission transfrontalière (section 2), en prenant en compte la dimension éminemment politique de cette question (section 3) ainsi que la nécessité pour un régime de protection applicable aux scissions transfrontalières de réaliser un délicat équilibre entre les intérêts des parties en présence (section 4) et en intégrant les enseignements de la Cour de justice en la matière (section 5), il conviendra de porter un jugement sur la compatibilité du régime de la Directive Mobilité avec un régime plus vaste des scissions transfrontalières (section 6), tout en ne négligeant pas la question de la conformité de ce régime particulièrement intrusif à la liberté d'établissement (section 7).

SECTION 2. UNE OPÉRATION POTENTIELLEMENT AU DÉTRIMENT DE LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

1114. Un régime fragmentaire. La participation des travailleurs, entendue comme « l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société (i) en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou (ii) en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer »[6115], est un enjeu fondamental de toute opération transfrontalière[6116], ce qui explique pourquoi on retrouve des dispositions relatives à celle-ci tant dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[6117] que dans celui des transformations transfrontalières[6118], des fusions transfrontalières[6119], de la société européenne[6120] et de la société coopérative européenne[6121]. Sans entrer trop dans les détails d'une question particulièrement complexe qui a déjà fait l'objet d'un grand nombre d'études[6122], on peut résumer la problématique

sociaux sont mis en œuvre au niveau de l'Union et de ses États membres. Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit d'être informés et d'être consultés, en temps opportun, sur les questions qui les intéressent, en particulier sur le transfert, la restructuration et la fusion d'entreprises et les licenciements collectifs. Il convient d'encourager le renforcement de la capacité des partenaires sociaux à promouvoir le dialogue social ».

6115 Art. 2, k) de la Directive Participation des Travailleurs.

6116 Voir en ce sens : J. ROEST, *op. cit.*, p. 76.

6117 Art. 160*terdecies* de la Directive Mobilité.

6118 Art. 86*terdecies* de la Directive Mobilité.

6119 Art. 133 de la Directive Sociétés.

6120 Art. 12, § 3 du Règlement sur la Société européenne.

6121 Art. 11, § 2 du Règlement sur la Société coopérative européenne.

6122 Voir notamment : D. BEUTEL, *op. cit.*, pp. 221–255 ; C. DUPIN, *op. cit.*, pp. 17–82 ; Ol. KISKER, « Unternehmerische Mitbestimmung in der Europäischen Gesellschaft, der Europäischen Genossenschaft und bei grenzüberschreitender Verschmelzung im Vergleich », *RdA*, 2006, pp. 206–212 ; H. LUNK et L. HINRICHS, « Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach dem MgVG », *NZA*, 2007, pp. 773–780 ; T. NIKOLEYCZIK et Th. FÜHR, « Mitbestimmungsgestaltung im grenzüberschreitenden Konzern unter besonderer Berücksichtigung der SE und grenzüberschreitender Verschmelzungen », *DStR*, 2010, pp. 1743–1750 ; Cl. SCHUBERT, « Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitender Verschmelzung », *RdA*, pp. 9–17 et E. TROST, *Mitbestimmungsgestaltung bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen*, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2016.

en indiquant qu'au sein de l'Union européenne, un certain nombre d'États membres connaissent un régime de participation[6123], alors qu'il est totalement inconnu dans d'autres[6124]. A cela s'ajoute que même au sein des États membres connaissant un tel régime de participation, ce dernier est loin d'être harmonisé et varie considérablement[6125]. En effet, dans nombre d'États membres, seules les sociétés anonymes sont concernées par cette obligation[6126], alors que dans d'autres, les sociétés à responsabilité limitée et d'autres formes sociales sont également impactées[6127]. En outre, les seuils au-delà desquels la mise en place d'un régime obligatoire de participation des travailleurs devient obligatoire varient fortement d'un État membre à un autre[6128], de même que la proportion des représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration ou de surveillance[6129].

1115. L'incidence d'une scission transfrontalière. Comme cela a pu être remarqué, la plus grande faiblesse des régimes de participation des travailleurs réside dans leur caractère disparate au sein des États membres[6130] auquel les échecs successifs (i) de la Proposition de Cinquième Directive[6131] qui aurait partiellement remédié à ces différences en introduisant un régime de

6123 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale, 19 États membres connaissent un système de participation des travailleurs. Voir : Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 70 et 71. L'Etude d'impact cite l'Autriche, la République tchèque, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l'Espagne et la Suède. Voir : Annexe 10 de l'Étude d'impact.

6124 Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, pp. 49 et 50. C'est le cas notamment de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de l'Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte et du Royaume-Uni. Voir : Annexe 10 de l'Étude d'impact et J. ROEST, *op. cit.*, p. 78.

6125 Voir en ce sens : Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 71 et 72 ; Étude d'impact, p. 198 et A. SEIFERT, « Employee participation in the board and corporate restructuring – The perspective of EU Law » in Er. KOVÁCS et M. WINNER (dir.), *Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues*, Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 134.

6126 Voir à titre d'illustration : art. L. 225-27 et s. du Code de commerce français et art. 426-1 du Code du travail luxembourgeois disponible sur http://data.legilux.public.lu (07/11/2021) (ci-après le « **Code du travail luxembourgeois** »).

6127 § 1(1), 1. du Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (MitbestG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021) (ci-après le « **MitbestG** ») et § 1(1) du Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (ci-après le « **DrittelbG** »). Voir également § 110(1) et (5) de l'Arbeitsverfassungsgesetz (ArVG) autrichien, disponible sur www.jusline.at (25/07/2020).

6128 En droit luxembourgeois, en dehors des cas où l'entreprise bénéficie d'une participation financière d'au moins 25 % ou d'une concession de l'État portant sur l'activité principale, le seuil sera de mille salariés au moins au cours des trois dernières années (art. L. 426-1 du Code du travail luxembourgeois). En droit allemand, hors cas particuliers, le seuil sera de 500 travailleurs pour la représentation au sein du conseil de surveillance (§ 1(1) DrittelbG).

6129 En droit luxembourgeois, au-delà du seuil de mille salariés, un tiers des administrateurs ou des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance devra représenter le personnel de l'entreprise. En droit allemand, hors cas particuliers, au-delà du seuil de 500 travailleurs, un tiers du conseil de surveillance devra être composé de représentants des travailleurs (§§ 1(1) et 4(1) DrittelbG) et dans les entreprises dépassant le seuil de 2 000 travailleurs, la moitié du conseil de surveillance devra être composée de représentants des travailleurs (§§ 1 et 7 MitbestG).

6130 Voir en ce sens : A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 135.

6131 Proposition d'une cinquième directive tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés, au sens de l'article 58 paragraphe 2 du traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers en ce qui concerne la structure des sociétés anonymes ainsi que les pouvoirs et obligations de leurs organes du 9 octobre 1972, COM(72) 887 final, *J.O.*, C 131, 13 décembre 1972, pp. 49–61 (ci-après la « **Proposition de Cinquième Directive** ») et Proposition modifiée d'une cinquième directive fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE,

participation harmonisé dans toutes les sociétés anonymes dépassant un seuil de 500 travailleurs[6132] et (ii) de la Proposition Modifiée de Cinquième Directive qui visait à imposer aux États membres de prévoir que dans les sociétés anonymes employant en moyenne un nombre de travailleurs qui ne peut être fixé à plus de 1000 par les États membres, les travailleurs de la société pourraient nommer au moins un tiers et au plus la moitié des membres de l'organe de surveillance[6133], n'ont pas permis de remédier. Dans le contexte particulier d'une scission transfrontalière, la crainte est donc grande que l'opération ne soit utilisée pour éluder un régime de participation jugé trop contraignant par les associés majoritaires[6134]. Un tel objectif pourrait être atteint de trois manières différentes, ce qui explique pourquoi les syndicats se sont montrés particulièrement sceptiques à l'égard d'une initiative en la matière[6135].

1116. Le recours à une scission hétérogène. Tout comme dans le cas d'une scission interne[6136] ou d'une fusion interne ou transfrontalière, il est tout d'abord possible de veiller à ce que les sociétés issues de la scission soient d'une forme sociale distincte de celle de la société scindée pour laquelle le droit national applicable n'impose pas la mise en place d'un régime de participation des travailleurs[6137]. À titre d'illustration, la scission d'une *Aktiengesellschaft* allemande ayant plus de 2000 travailleurs[6138] au profit de deux sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois devrait, en l'absence de mesure de sauvegarde spécifique, aboutir à l'extinction du régime de participation[6139].

1117. La migration dans un pays sans système de participation. Comme toute autre opération transfrontalière, une scission peut également être utilisée pour déplacer la société scindée dans un État membre qui ne connaît pas de régime de participation des travailleurs[6140]. À titre d'illustration, ce sera le cas de la scission transfrontalière d'une société anonyme de droit luxembourgeois ayant 4 500 travailleurs[6141] au profit de deux sociétés anonymes de droit

concernant la structure des sociétés anonymes et les pouvoirs et obligations de leurs organes du 19 août 1983, COM(83) 185 final, *J.O.*, C 240, 9 septembre 1983, pp. 2–38 (ci-après la « **Proposition Modifiée de Cinquième Directive** »).

6132 Art. 4, §§ 1 et 2 de la Proposition de Cinquième Directive.

6133 Art. 4 et 4 b) de la Proposition Modifiée de Cinquième Directive.

6134 En application des §§ 1(1) et 4(1) DrittelbG, ce n'est qu'au-delà du seuil de 500 travailleurs qu'un tiers du conseil de surveillance devra être composé de représentants des travailleurs.

6135 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 19.

6136 Voir en ce sens : A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 138.

6137 Sur cette problématique en droit luxembourgeois, voir A. SEIFERT, *ibidem*, p. 138 et A. SEIFERT, « Comment recodifier le dialogue social au sein de l'entreprise ? », *J.T.L.*, 17/2011, p. 121.

6138 En application des §§ 1 et 7 MitbestG, la moitié du conseil de surveillance de cette société anonyme devrait être composée de représentants des travailleurs.

6139 Les sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois n'entrent pas dans le champ d'application du régime de participation des travailleurs. Voir art. L. 426-1, § 1er du Code du travail luxembourgeois.

6140 Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 246 et Chr. TEICHMANN, « Grenzüberschreitende Umwandlungen: EU erweitert die Palette – Neuregelung im Spannungsfeld von Gestaltungsfreiheit und Missbrauchsgefahren », *op. cit.*, p. M4. Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 28. Voir en ce sens à propos des fusions transfrontalières : Fr. SCHURR, *op. cit.*, p. 544.

6141 En application de l'art. L. 426-3, § 1er du Code du travail luxembourgeois, un tiers des membres du Conseil d'administration d'une telle société devra être composé de représentants des travailleurs.

belge[6142], ce qui, en l'absence de régime de protection spécifique aurait pour conséquence l'extinction des droits de participation des travailleurs de l'entité luxembourgeoise.

1118. L'évitement des seuils. Tant une scission interne qu'une scission transfrontalière peuvent également être utilisées pour réduire le nombre global de travailleurs occupés habituellement et ainsi, soit éviter de dépasser le seuil légal au-delà duquel la mise en place d'un système de participation des travailleurs devient obligatoire, soit encore redescendre en dessous de ce seuil[6143]. Si les deux premiers mécanismes d'évitement de la participation peuvent très bien s'articuler autour d'une transformation transfrontalière ou d'une fusion transfrontalière, il convient de relever qu'une scission, en ce qu'elle implique la répartition du patrimoine de la société scindée entre au moins deux sociétés bénéficiaires, représente l'instrument idéal pour mettre en œuvre cette troisième stratégie. À titre d'illustration, on peut citer l'hypothèse de la scission transfrontalière d'une société anonyme de droit luxembourgeois occupant habituellement 1 800 travailleurs dans trois branches d'activités distinctes, chacune occupant 400 travailleurs au profit de trois sociétés anonymes de droit allemand recueillant chacune une branche d'activités distincte et 400 travailleurs.

SECTION 3. UNE DIMENSION POLITIQUE SIGNIFICATIVE

1119. Un enjeu politique considérable. Face aux divergences entre les États membres au niveau de la participation des travailleurs, il n'est pas surprenant de constater que celle-ci constitue un enjeu politique considérable pour un grand nombre d'entre eux[6144]. De manière assez schématique, certains États membres ne connaissent pas de régime de participation et y sont généralement opposés[6145], tandis que d'autres, à commencer par l'Allemagne, disposent d'un régime de participation très élaboré et sont farouchement opposés à toute érosion de celui-ci[6146]. La question de la protection de la participation des

6142 En droit belge, un régime de participation obligatoire des travailleurs n'existe que dans le cas d'une société européenne (Convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004 concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne, disponible sur www.cnt-nar.be (21/07/2020)) et dans le cas particulier des fusions transfrontalières (Convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008 concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, disponible sur www.cnt-nar.be (21/07/2020)).

6143 Voir en ce sens : Étude d'impact, p. 28.

6144 Voir en ce sens : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 10 ; ECLE, *op. cit.*, p. 216 ; J. ROEST, *op. cit.*, p. 76 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 244 ; M. SELENT, *op. cit.*, pp. 1171 et 1172 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 246 ; Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 10 et Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, p. 294.

6145 Ce fut tout particulièrement le cas du Royaume-Uni à l'égard de la Proposition de Cinquième Directive et de la Proposition Modifiée de Cinquième Directive. Voir à ce sujet : A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 136.

6146 Voir à ce sujet : A. SEIFERT, *ibidem*, p. 136 qui relève que l'échec de la Proposition de Cinquième Directive et de la Proposition Modifiée de Cinquième Directive est principalement dû à l'opposition du gouvernement allemand qui craignait de voir le régime allemand affaibli.

travailleurs s'est dès lors révélée être un obstacle majeur à la mobilité transfrontalière des personnes morales au sein de l'Union européenne et ce, tant dans le cadre de l'adoption du Règlement sur la Société européenne[6147] que de la Dixième Directive à l'égard des fusions transfrontalières[6148]. De même, à l'égard de la Directive Mobilité, on s'attendait à ce que les discussions sur la participation des travailleurs retardent considérablement le processus législatif[6149], ce qui ne fut pas le cas en définitive[6150].

1120. Un enjeu à relativiser. Malgré cette importance politique cardinale, il convient toutefois de relever que la question de la participation des travailleurs est loin de concerner toutes les sociétés de capitaux potentiellement susceptibles de réaliser une scission transfrontalière au sein de l'Union européenne. En effet, la participation des travailleurs est généralement l'apanage des grandes sociétés[6151]. Or, sur les plus de vingt millions de sociétés de capitaux que compte l'Union européenne[6152], 99 % de celles-ci sont de petites ou moyennes entreprises et 93 % d'entre elles comptent moins de dix travailleurs et ne connaissent pas de système de participation[6153]. Si on ajoute à cela qu'au sein de l'Union européenne, deux travailleurs sur trois sont employés par une PME[6154], on constate que l'impact des règles sur la participation des travailleurs est moindre que ce qu'il ne pourrait sembler de prime abord, même si cela n'érode en rien l'importance politique de la question.

SECTION 4. LA NÉCESSITÉ D'UN JUSTE ÉQUILIBRE

1121. Un équilibre délicat. Un régime efficace des scissions transfrontalières devra dès lors nécessairement parvenir à un délicat équilibre entre d'une part, les intérêts des associés à la réalisation d'une opération de restructuration potentiellement essentielle à la survie économique de l'entreprise et les intérêts des travailleurs à ce qu'une telle opération n'entraîne pas une érosion abusive de leurs droits de participation au profit des associés majoritaires[6155]. Cependant, compte tenu des préférences politiques variables des États membres à l'égard de la participation des travailleurs, il est évident que ce point d'équilibre sera particulièrement délicat à déterminer.

6147 Voir en ce sens : L. L. HANSEN, *op. cit.*, p. 184.
6148 Voir en ce sens : A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 138.
6149 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 216 ; R. KNAIER, « Crossing borders, digitally… », *op. cit.*, p. R149 ; R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 622 et M. WINNER, « Protection of creditors… », *op. cit.*, p. 46.
6150 Sur le caractère expéditif du processus législatif de la Directive Mobilité, voir *supra* n° 327.
6151 Selon l'Étude d'impact, le seuil le plus faible au sein des États membres est celui de la Suède qui est de 25 travailleurs. Voir Étude d'impact, p. 200.
6152 Étude d'impact, p. 89.
6153 Étude d'impact, p. 94.
6154 *Ibidem*.
6155 Voir en ce sens : A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 135. Voir en ce sens également à propos des transformations transfrontalières : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, pp. 28 et 29.

SECTION 5. L'INCIDENCE DE LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

1122. Des enseignements très limités. Comme les scissions transfrontalières constituent des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »[6156], il importe de ne pas perdre de vue qu'un régime de protection des droits de participation des travailleurs sera en toute vraisemblance de nature à « *dissuader* »[6157] les sociétés de faire usage de leur liberté d'établissement, ne fût-ce qu'en raison de la durée potentiellement excessive de la procédure de négociation[6158]. Celui-ci constituera donc systématiquement une entrave à la liberté d'établissement des sociétés concernées et cette dernière devra nécessairement remplir les conditions du « *Gebhard test* »[6159] pour être admissible. Avant de poursuivre l'analyse, il est dès lors nécessaire de se pencher brièvement sur les enseignements de la Cour de justice en la matière. Cependant, si la protection des intérêts des salariés a été reconnue de longue date comme une raison impérieuse d'intérêt général[6160], la Cour de justice ne s'est jamais prononcée avec précision sur les contours exacts d'un régime de protection de leurs intérêts conforme aux prescrits de la liberté d'établissement. Il est toutefois possible d'identifier certains enseignements laconiques dans sa jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt *Überseering*[6161], la Cour a considéré qu'un déni pur et simple de la capacité juridique ne saurait être justifié notamment par la protection des intérêts des salariés car cela équivaut à la « négation même de la liberté d'établissement »[6162] et ce, alors même que le gouvernement allemand avait tenté de justifier sa position par la nécessité de protéger les salariés « au travers d'une cogestion de l'entreprise dans les conditions fixées par la loi »[6163]. L'arrêt *Sevic* permet d'établir qu'un refus général d'enregistrement d'une fusion transfrontalière dans l'État membre de la société bénéficiaire ne constitue pas davantage une mesure de protection proportionnée des intérêts

6156 Voir en ce sens : L. ATHLAN et St. TORCK, *op. cit.*, p. 3 ; H. BUNGERT, *op. cit.*, p. 55 ; T. DRYGALA et T. VON BRESSENSDORF, *op. cit.*, p. 1161 ; T. DRYGALA, *op. cit.*, p. 26 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 19 ; V. GEYRHALTER et Th. WEBER, *op. cit.*, p. 150 ; L. HANSEN, *op. cit.*, p. 195 ; S. HERRLER, *op. cit.*, pp. 298 et 299 ; H. KALLMEYER et St. KAPPES, *op. cit.*, pp. 226 et 234 ; N. KRAUSE et N. KULPA, *op. cit.*, p. 45 ; H. LE NABASQUE, « Les fusions et scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 416 ; St. LEIBLE et J. HOFFMANN, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach SEVIC », *op. cit.*, pp. 165 et 166 ; W. MEILICKE et D. E. RABBACK, *op. cit.*, pp. 126 et 127 ; Fl. PARREIN, *op. cit.*, p. 320 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 236 ; J. SEDEMUND, *op. cit.*, p. 521 ; M. SIEMS, « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *op. cit.*, p. 314 ; Chr. TEICHMANN, « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften… », *op. cit.*, p. 358 ; Chr. TEICHMANN et R. KNAIER, *op. cit.*, p. 1319 et S. WEISS et H.-T. WÖHLERT, *op. cit.*, pp. 584 et 585.

6157 Arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 45 et arrêt *Daily Mail*, pt. 16.

6158 Art. 160*terdecies*, § 3, c) de la Directive Mobilité et art. 5 de la Directive Participation des Travailleurs qui prévoit une durée maximale des négociations de six mois, prolongeable de commun accord jusqu'à un an.

6159 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.

6160 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; C.J., gde ch., arrêt *Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) c. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis*, 21 décembre 2016, C-201/15, EU:C:2016:972, pt. 73 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 et arrêt *Überseering*, pt. 92.

6161 Sur les faits à la base de cet arrêt, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1, Section 4, § 3, B, 3., 3.1.

6162 Arrêt *Sevic*, pt. 93.

6163 Arrêt *Überseering*, pt. 89.

des salariés[6164]. Dans l'arrêt *Vale*[6165], la Cour de justice a établi que le refus général par un État membre de reconnaître les transformations transfrontalières, alors même que les intérêts des salariés ne s'en trouveraient pas menacés va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une protection efficace de ces derniers[6166]. Pour finir, il découle de l'arrêt *Polbud* qu'une obligation de liquidation de la société scindée en vue de protéger les intérêts des salariés, serait contraire aux prescrits des articles 49 et 54 du TFUE[6167].

1123. Une ombre persistante. Si les enseignements de la Cour de justice en la matière demeurent laconiques, il convient de ne pas perdre de vue que tout mécanisme de protection des droits de cogestion des salariés dans le cadre d'un régime consacré aux scissions transfrontalières devra nécessairement remplir les conditions du « *Gebhard test* »[6168] et, en particulier, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif[6169]. En outre, comme le caractère transfrontalier de l'opération entraîne un risque additionnel pour les salariés[6170], il serait logique que ceux-ci bénéficient d'une protection accrue en cas d'opération transfrontalière par rapport à une opération interne. Cependant, un tel mécanisme violerait le principe de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes posé dès l'arrêt *Sevic*[6171]. Il est donc rigoureusement indispensable qu'il n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une protection adéquate aux salariés.

SECTION 6. LA COMPATIBILITÉ DU RÉGIME DE LA DIRECTIVE MOBILITÉ AVEC LES SCISSIONS MIXTES ET PAR ABSORPTION

1124. Plan de la section 6. Afin de pouvoir apporter une réponse satisfaisante à la question de la compatibilité du régime consacré par le législateur européen dans le cadre des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés avec les spécificités d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, il convient tout d'abord d'analyser quelle a été l'attitude générale du législateur européen face à cette problématique particulièrement délicate dans le cadre de la Directive Mobilité (§ 1) pour ensuite se pencher brièvement sur les quelques modifications du régime existant des fusions transfrontalières introduites par la Directive Mobilité dans la mesure où ce dernier présente l'indéniable avantage de couvrir également les opérations impliquant plus d'une société préexistante (§ 2). Une telle démarche préalable se justifie par le fait que le régime des fusions transfrontalières a nécessairement servi de base au législateur européen pour l'élaboration du régime de protection de la

6164 Arrêt *Sevic*, pt. 30.
6165 Sur les faits à la base de cet arrêt, voir *supra* : Première partie, Titre II, Chapitre 1, Section 5, § 2, A.
6166 Arrêt *Vale*, pts. 39 et 40.
6167 Arrêt *Polbud*, pt. 58.
6168 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.
6169 Fusions et scissions transfrontalières – Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), http://www.europarl.europa.eu (27/09/2017), p. 9.
6170 À ce sujet, voir *supra* n° 1117.
6171 À ce sujet, voir *supra* n° 153.

participation des travailleurs applicable en cas de scission transfrontalière[6172]. Avant de porter un jugement sur ce dernier, il convient dès lors d'adopter le même cheminement. Il conviendra par après de comparer le régime des fusions transfrontalières à celui des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés pour en tirer certains enseignements à l'égard des scissions transfrontalières mixtes et par absorption (§ 3).

§1. Un régime très similaire

1125. L'incidence de la nature politique. L'entrelacs de règles composant cette matière est le fruit d'un fragile compromis politique[6173]. Ceci explique pourquoi, la Directive Mobilité n'a modifié le régime actuellement applicable à une fusion transfrontalière que sur certains points limités en vue d'assurer un certain degré de cohérences entre les différents modes de restructuration[6174]. De manière très schématique, le régime, reposant sur le « *before-after regime* »[6175] instauré à l'égard de la société européenne[6176], prévoit que la participation au sein des sociétés bénéficiaires sera en principe régie par le droit national applicable à celles-ci[6177], sauf, et ce afin d'éviter une certaine forme de « *forum shopping* » à cet égard[6178], si (i) la société scindée occupe un nombre de travailleurs supérieur à un certain seuil pendant les six mois précédant la publication du projet de fusion[6179] ou (ii) si le droit national applicable à la société issue de la fusion transfrontalière ne prévoit pas le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s'applique aux sociétés qui fusionnent concernées[6180] ou encore (iii) si le droit national applicable à la société issue de la fusion transfrontalière ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d'autres États membres pourront bénéficier des mêmes droits de participation que les travailleurs employés dans l'État membre du siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière[6181]. Dans ces trois hypothèses, il conviendra de former un groupe spécial de négociation qui sera chargé pendant une durée de base de six mois[6182], mais prolongeable à

6172 J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364 et A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 145. Voir en faveur d'une telle approche : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 31.

6173 J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 21.

6174 Voir en ce sens : L. PÜTZ, *op. cit.*, p. 121.

6175 Voir en ce sens : F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 35 ; L. PÜTZ, *ibidem*, p. 120 ; A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 141 et Chr. TEICHMANN, « Company Law Package – Content and State of Play », *op. cit.*, p. 11.

6176 F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 35.

6177 Art. 133, § 1er de la Directive Sociétés.

6178 Voir en ce sens : Étude d'impact, p. 20.

6179 Art. 133, § 2 de la Directive Mobilité.

6180 Art. 133, § 2, a) de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. Ce niveau de participation est apprécié « en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans ces sociétés, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs ».

6181 Art. 133, § 2, b) de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.

6182 Art. 133, § 3, c) de la Directive Sociétés et art. 5, § 1er de la Directive Participation des Travailleurs.

un an[6183], de négocier avec l'organe de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent. Ces négociations devront en principe aboutir (i) soit à un accord sur mesure sur les modalités de la participation des travailleurs au sein des sociétés bénéficiaires[6184], (ii) soit à la décision d'appliquer les dispositions de référence[6185], c'est-à-dire les dispositions qui prévoient le niveau de participation le plus élevé[6186]. Il existe toutefois deux hypothèses dans lesquelles les négociations n'auront pas lieu, à savoir (i) lorsque les organes compétents des sociétés qui fusionnent décident de choisir sans négociation préalable d'être directement soumis aux dispositions de référence telles que fixées par les droits de l'État Membre dans lequel est établi le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière[6187] et (ii) lorsque l'organe spécial de négociation décide, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi[6188]. En outre, si les négociations n'aboutissent pas dans le délai imparti de six mois[6189] ou lorsque les parties en conviennent ainsi[6190] les dispositions de référence trouveront en principe à s'appliquer. Ces dispositions de référence reposent sur le principe avant-après et consacrent le plus haut niveau de participation appliqué dans une des sociétés impliquées préalablement à l'opération[6191].

1126. Une approche légistique discutable. Loin d'intégrer un régime exhaustif relatif à la participation des travailleurs, la Directive Mobilité[6192], tout comme la Directive Sociétés[6193] avant elle, fonctionne par le biais de renvois à la réglementation applicable à la participation des travailleurs dans une société européenne. Si cette approche laissait déjà à désirer à l'égard des fusions transfrontalières en ce qu'elle nuisait à la lisibilité générale de la procédure, ce sera encore davantage le cas à l'égard des scissions transfrontalières qui ne sont pas envisagées dans le régime de la société européenne et obligent à se livrer à un délicat exercice d'adaptation des dispositions de la Directive Participation

6183 Art. 133, § 3, c) de la Directive Sociétés et art. 5, § 2 de la Directive Participation des Travailleurs.
6184 Art. 133, § 3, b) de la Directive Sociétés et art. 4, § 1er de la Directive Participation des Travailleurs.
6185 Art. 133, § 3, e) de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité et art. 7, § 1er, a) de la Directive Participation des Travailleurs.
6186 Art. 133, § 3, h) de la Directive Sociétés et partie 3, b) de l'annexe de la Directive Participation des Travailleurs.
6187 Art. 133, § 4, a) de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
6188 Art. 133, § 4, b) de la Directive Sociétés.
6189 Art. 133, § 3, a) de la Directive Sociétés et art. 7, § 1er, b) de la Directive Participation des Travailleurs.
6190 Art. 133, § 3, a) de la Directive Sociétés et art. 7, § 1er, a) de la Directive Participation des Travailleurs.
6191 Voir en ce sens : A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 141. Selon la partie 3, point b) de l'annexe de la Directive Participation des Travailleurs à laquelle l'art. 133, § 3, h) de la Directive Sociétés renvoie « […] les travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la SE égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la SE. […] ».
6192 Art. 86*terdecies* ; 133 et 160*terdecies* de la Directive Mobilité.
6193 Art. 133 de la Directive Sociétés.

des Travailleurs. Prévoir un régime propre à chaque type d'opération transfrontalière serait indéniablement préférable[6194].

§2. Les principales réformes du régime des fusions transfrontalières

1127. Plan du § 2. Les principales réformes du régime des fusions transfrontalières introduites par la Directive Mobilité s'articulent autour de trois points cardinaux, à savoir un seuil d'occupation plus flexible (A), un principe de protection du régime de participation des travailleurs pendant quatre ans (B) et une information étendue des travailleurs (C), qui méritent tous un bref examen dans le cadre de l'étude des caractéristiques que devrait revêtir un régime plus général des scissions transfrontalières à l'égard de la protection de la participation des travailleurs.

A. *Un seuil d'occupation plus flexible*

1128. Une règle anti-abus. La première modification du régime des fusions transfrontalières concerne la détermination du seuil au-delà duquel il conviendra en principe d'écarter la règle de base de l'application du droit national des sociétés bénéficiaires. En effet, alors que préalablement à la Directive Mobilité, le régime des fusions transfrontalières fixait ce seuil à cinq cents travailleurs[6195], le nouveau régime des fusions transfrontalières prévoit que ce seuil sera de quatre cinquièmes du seuil prévu par le droit national de la société qui fusionne au-delà duquel un régime de participation doit être mis en place[6196]. L'adoption d'un seuil plus flexible permettra indéniablement d'adapter le régime de la Directive Mobilité aux spécificités des différents régimes de participation existant au sein des États membres et qui ont recours à des seuils très différents les uns des autres[6197]. En revanche, cela va dans le sens d'un renforcement de cette première exception[6198] dans la double mesure où (i) seuls quatre cinquièmes du seuil doivent être atteints et (ii) les seuils appliqués par les États membres en la matière sont susceptibles d'être bien inférieurs à cinq cents travailleurs[6199]. Il est intéressant de relever que cette modification était absente du régime des

6194 Voir en ce sens également : J. ROEST, *op. cit.*, p. 93.
6195 Art. 133, § 2 de la Directive Mobilité.
6196 Art. 133, § 2 de la Directive Mobilité.
6197 Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings* p. 50. Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364 ; A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 146 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281 ; M. SELENT, *op. cit.*, p. 1173 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2446.
6198 Voir en ce sens : Avis CAJ, exposé des motifs qui relève à propos du régime des fusions transfrontalières de la Proposition de la Commission que « [c]ontrairement aux transformations et aux scissions transfrontalières, les droits de participation des travailleurs n'ont pas été modifiés, en conséquence de quoi ils se retrouvent inférieurs à ceux prévus pour les transformations et les scissions. ». Voir également en ce sens : Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 et J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 588.
6199 Selon l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale, ces seuils vont de 25 à plus de 500 employés. Voir : Étude Bech-Bruun et Lexidale, *Main Findings*, p. 50.

fusions transfrontalières de la Proposition de la Commission[6200], mais apparaissait déjà dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés de la Proposition de la Commission[6201]. Compte tenu du caractère aisément substituable des opérations transfrontalières, l'Avis de la CAJ contenait une proposition de modification du régime des fusions transfrontalières en vue d'introduire ce seuil des quatre cinquièmes[6202], la Commission de l'emploi et des affaires sociales ayant même suggéré d'abaisser ce seuil aux deux tiers[6203]. Ce seuil flexible n'a toutefois été intégré que dans le Compromis Final[6204] et s'est retrouvé ainsi dans la Directive Mobilité[6205]. Une telle disposition se justifie également par la volonté de lutter contre des opérations de mobilité transfrontalière par lesquelles une société tenterait de se soustraire abusivement à un régime de participation des travailleurs dans la vicinité d'un franchissement des seuils[6206][6207], mais on ne peut que relever qu'il ne s'agit là que d'un « tigre de papier »[6208]. En effet, dans une telle hypothèse, les seuils entraînant l'application du régime de participation n'ont pas encore été franchis de sorte qu'aucun régime de participation n'est effectivement en place au sein des sociétés concernées. Il s'ensuit que la menace de l'application des dispositions de référence[6209] serait totalement inexistante[6210]. Il a été proposé de remédier à cette insuffisance en imposant l'application du régime de participation de l'État membre d'origine en cas d'échec des négociations et si les seuils applicables sont franchis dans un certain délai suivant la réalisation de l'opération[6211]. Une telle règle renforcerait encore davantage le régime de participation

6200 Art. 133 de la Proposition de la Commission.
6201 Art. 160*quindecies*, § 2 de la Proposition de la Commission.
6202 Amendement 233 de l'Avis CAJ.
6203 Amendement 81 de l'Avis CEAS.
6204 Art. 133, § 2 du Compromis Final.
6205 Art. 133, § 2 de la Directive Mobilité.
6206 31e considérant de la Directive Mobilité et en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364 ; ECLE, *op. cit.*, p. 218 ; F. GARCIMARTÍN et E. GANDÍA, *op. cit.*, p. 36 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 ; A. PÜTZ, *op. cit.*, p. 119 ; J. ROEST, *op. cit.*, p. 90 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281 ; M. SELENT, *op. cit.*, p. 1173 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2446 ; Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, p. 11 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2709.
6207 Sur l'utilisation d'une fusion transfrontalière pour éluder les règles de participation des travailleurs allemandes, voir : C. GÖTZE, Th. WINZER et Chr. ARNOLD, « Unternehmerische Mitbestimmung – Gestaltungsoptionen und Vermeidungsstrategien », *ZIP*, 2009, p. 249. Sur l'utilisation de la société européenne pour éluder les règles de participation des travailleurs allemandes, voir : Étude d'impact, pp. 66 et 67 ; W. BAYER, « Die Erosion der deutschen Mitbestimmung », *NJW*, 2016, p. 1933 et Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, pp. 246 et 247.
6208 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 119 ; M. HABERSACK, *op. cit.*, p. 502 ; M. GÖTTE et P. MÜCKL, *op. cit.*, p. 2040 ; A. PÜTZ, *op. cit.*, p. 119 ; J. ROEST, *op. cit.*, p. 90 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 588 ; P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2446 ; Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 247 ; Chr. TEICHMANN, « The Company Law Package… », *op. cit.*, pp. 11 et 12 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2709.
6209 Sur cette notion, voir *supra* n° 1125.
6210 Voir en ce sens : M. GÖTTE et P. MÜCKL, *op. cit.*, p. 2040 ; A. PÜTZ, *op. cit.*, p. 119 et J. ROEST, *op. cit.*, p. 90.
6211 Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende

des travailleurs et ne serait que difficilement acceptable pour les États membres qui y sont moins favorables, sans parler des éventuelles interrogations qu'elle ne manquerait pas de souligner à l'aune de la liberté d'établissement[6212]. En outre, force est de constater que ce seuil est difficilement compatible avec le principe avant-après ou « *no escape but no extension* »[6213] sous-tendant tout le régime de protection des travailleurs de la Directive Mobilité[6214]. En effet, ce principe qui trouve son origine dans le régime de la société européenne a pour objectif premier d'éviter une érosion du régime de participation en vigueur dans la société concernée préalablement à l'opération. Pour finir, on ne peut que relever que ce seuil méconnaît le fait que le nombre de travailleurs n'est pas le seul critère utilisé par les États membres pour rendre un système de participation obligatoire[6215]. Il convient dès lors de plaider en faveur de la solution qui se retrouvait dans le Premier Compromis de la Présidence et qui prévoyait l'application du seuil des cinq cents travailleurs du régime de la Directive Sociétés tant pour les fusions transfrontalières[6216] que pour les scissions transfrontalières[6217] et les transformations transfrontalières[6218]. On ne peut par conséquent que regretter que cette position ait été abandonnée lors du Compromis Final[6219][6220].

B. *La protection du régime de participation pendant quatre ans*

1129. Une règle de permanence. Afin d'éviter que les sociétés bénéficiaires ne tentent d'éluder le régime de participation mis en place dans le cadre d'une fusion transfrontalière par le biais d'une opération de fusion ultérieure,

Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 10 ; J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, p. 364 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2446. Voir en ce sens également à propos des transformations transfrontalières : ECLE, *op. cit.*, p. 218, note 103. Voir également : Chr. TEICHMANN, « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts… », *op. cit.*, p. 247 qui plaide en faveur d'une obligation de négociation en cas de dépassement subséquent des seuils en vigueur dans l'État membre de départ.

6212 Sur l'incidence de la liberté d'établissement, voir *infra* : Deuxième partie, Titre II, Chapitre II, Section 5.

6213 ECLE, *op. cit.*, p. 217.

6214 Voir en ce sens : DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 861, n° 40.

6215 Voir en ce sens : J. ROEST, *op. cit.*, pp. 90 et 91 qui cite l'exemple des Pays-Bas où le régime de participation ne s'applique qu'après une période transitionnelle de trois ans et ne vise que les sociétés qualifiées de « grandes », ce qui implique notamment que la somme du capital et des réserves de la société en question excède 16 millions EUR.

6216 Art. 133 du Premier Compromis de la Présidence qui n'altère pas cet aspect de la Directive Mobilité.

6217 Art. 160n, § 2 du Premier Compromis de la Présidence qui prévoyait en outre que le seuil des 500 travailleurs ne jouerait un rôle que si la société scindée connaissait déjà un régime de participation des travailleurs.

6218 Art. 86l, § 2 du Premier Compromis de la Présidence qui prévoyait en outre que le seuil des 500 travailleurs ne jouerait un rôle que si la société concernée connaissait déjà un régime de participation des travailleurs.

6219 Art. 160n, § 2 du Compromis Final.

6220 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, pp. 364 et 365 et DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2017/1132/(EU)… », *op. cit.*, p. 861, n° 40. *Contra* : ECLE, *op, cit.*, p. 218.

le régime des fusions transfrontalières de la Directive Mobilité pose une règle de permanence selon laquelle si la société issue de la fusion transfrontalière est régie selon un système de participation des travailleurs, cette dernière devra répéter le mécanisme de protection des travailleurs en cas de fusion nationale subséquente dans les trois ans après que la fusion nationale ait pris effet[6221]. Dans la mesure où il eût été très facile de contourner cette règle en recourant à un autre mécanisme de restructuration, la Directive Mobilité a étendu cette règle aux autres formes de restructuration que sont les transformations, fusions ou scissions nationales ou transfrontalières et a porté la durée de cette obligation à quatre ans après que la fusion transfrontalière ait pris effet[6222]. Si l'extension du champ des opérations nationales subséquentes couvertes est logique[6223], on peut s'interroger sur la nécessité de mentionner les autres fusions, scissions et transformations transfrontalières qui bénéficient déjà d'un régime de protection propre[6224]. En effet, il aurait été utile de préciser, dans la mesure où les différents régimes de protection de la participation des travailleurs ne sont pas identiques[6225], qu'en cas d'opération transfrontalière subséquente régie par la Directive Mobilité, la question de la préservation de la participation des travailleurs serait régie par les règles propres à chaque type d'opération[6226]. Ainsi, à titre d'illustration, en cas de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés suivant une fusion transfrontalière, la logique voudrait que la possibilité pour l'organe de la société scindée de décider spontanément d'appliquer les dispositions de référence telle qu'elle existe dans le régime des fusions transfrontalières[6227] ne soit pas ouverte[6228]. Il est toutefois également possible d'expliquer ce choix par le biais du champ d'application *ratione materiae* limité de la Directive Mobilité en matière de scissions. En effet, comme une application par analogie de la procédure prévue pour les fusions transfrontalières et la société européenne aux scissions transfrontalières par absorption et mixtes n'est que difficilement justifiable en l'absence de droit secondaire[6229], mais que les scissions transfrontalières sont protégées par la liberté d'établissement, le législateur européen a pu vouloir éviter par là qu'il ne soit trop aisé de recourir à une scission transfrontalière subséquente pour éluder le régime de participation des travailleurs.

6221 Art. 133, § 7 de la Directive Sociétés.
6222 Art. 133, § 7 de la Directive Mobilité.
6223 Voir en ce sens : A. BUTTERSTEIN, *op. cit.*, p. 844.
6224 Voir en ce sens : B. LECOURT, « Le nouveau régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 29.
6225 À ce sujet, voir *infra* n°s 1131 à 1148.
6226 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 312 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 244 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2447.
6227 Art. 133, § 4, a) de la Directive Sociétés.
6228 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 312.
6229 Voir en ce sens de manière générale sur les scissions transfrontalières préalablement à l'adoption de la Directive Mobilité : Chr. TEICHMANN et R. KNAIER, *op. cit.*, p. 1321.

C. *L'information des travailleurs*

1130. Une obligation d'information incertaine. Il est également prévu que toute société doive communiquer à ses travailleurs si elle choisit d'appliquer les dispositions de référence ou si elle initie la procédure de négociation[6230]. Dans cette dernière hypothèse, la société sera tenue d'informer les travailleurs ou leurs représentants du résultat des négociations[6231]. Si cette disposition va certes dans le sens d'une meilleure information des travailleurs, on peut s'interroger sur le choix du débiteur de cette obligation dans la mesure où les travailleurs disposent déjà de représentants directement impliqués dans la procédure de négociation. En outre, il aurait été utile d'indiquer la forme que doit revêtir cette communication[6232], comme par exemple une publication sur le site internet de la société ou encore un courrier électronique, et de prévoir un délai plus précis pour remplir cette obligation[6233].

§ 3. Éléments de comparaison entre le régime des fusions transfrontalières et celui des scissions transfrontalières

1131. Plan du § 3. Dans le cadre de la comparaison entre le régime des fusions transfrontalières et celui des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés de la Directive Mobilité en vue d'en isoler certains éléments qui devraient se retrouver dans un régime plus général des scissions transfrontalières, dix points seront étudiés successivement, à savoir le caractère plus protecteur du régime des scissions transfrontalières (A), l'exclusion apparente de la possibilité d'appliquer les dispositions de référence sans négociations préalables (B), l'absence d'une condition de représentation transfrontalière au sein du groupe spécial de négociation (C), le cas particulier de la scission partielle (D), la question des hypothèses d'application des dispositions de référence (E), la question de la scission partielle au profit d'une société sans travailleurs (F), l'hypothèse de l'instauration d'un régime de participation transitoire (G), l'incidence divergente de la règle de permanence (H), la question de la composition du groupe spécial de négociation (I) et le cas particulier de la réduction des droits de participation (J).

A. *Un régime très protecteur*

1132. Un renforcement significatif. Le régime de protection de la participation des travailleurs adopté par le législateur européen à l'égard des scissions

6230 Art. 133, § 8, 1re phrase de la Directive Mobilité.
6231 Art. 133, § 8, 2e phrase de la Directive Mobilité.
6232 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *op. cit.*, p. 312 et J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *op. cit.*, p. 244.
6233 Pour un point de vue critique de ce délai, voir : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Verschmelzungen… », *ibidem*, p. 312 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *ibidem*, p. 244 et A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 142.

transfrontalières[6234], à l'instar de celui applicable aux transformations transfrontalières[6235], offre un niveau de protection de la participation des travailleurs renforcé[6236]. Ceci devrait satisfaire les syndicats qui avaient réclamé un régime plus protecteur en matière de scissions[6237], mais ne va certainement pas aller dans le sens d'une simplification de la procédure, *a fortiori* dans la mesure où le législateur européen s'est foncièrement limité à reprendre les dispositions applicables aux transformations transfrontalières sans nécessairement tenir compte des spécificités d'une scission qui se caractérise par une pluralité de sociétés bénéficiaires[6238]. Si la justification tient au fait qu'une scission, contrairement à une fusion, permet de réduire le nombre de travailleurs afin d'éviter de franchir les seuils au-delà desquels la mise en place d'un régime de participation devient obligatoire[6239], on ne peut que relever qu'en raison de la substituabilité des opérations, un tel régime renforcé est aisément contournable[6240], sans parler du recours à une scission par absorption qui n'entre pas dans le champ d'application du régime renforcé de la Directive Mobilité[6241]. Si on adhère à la conception que les scissions transfrontalières présentent des dangers additionnels pour la participation des travailleurs[6242] et que celle-ci se doit d'être protégée, il convient d'en tirer d'ores et déjà deux conséquences. Tout d'abord, les régimes de protection de toutes les opérations transfrontalières devraient être alignés à cet égard de manière à ne pas inciter les praticiens inventifs à recourir à une superposition d'opérations pour éluder un régime jugé trop protecteur[6243]. Ensuite, toutes les « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement », en ce compris tout particulièrement les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, devraient tomber dans le champ de ces mécanismes de protection sous peine de les priver d'une bonne partie de leur effet utile. En d'autres termes, ceci plaide une fois de plus en faveur d'une intervention plus ambitieuse du législateur européen à l'égard des scissions transfrontalières.

6234 Art. 160*terdecies* de la Directive Mobilité.
6235 Art. 86*terdecies* de la Directive Mobilité.
6236 Étude d'impact, p. 64 et en ce sens : Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 ; L. PÜTZ, « Die Unternehmensmitbestimmung nach dem „Company Law Package"der EU – Erste Überlegungen zur Umsetzung der neugefassten Mobilitäts-Richtlinie (EU) 2017/1132 in das deutsche Recht », *AG*, 2020, p. 118 ; J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 265 et M. SELENT, *op. cit.*, p. 1175. Voir toutefois : M. FALLON et E. NAVEZ, *op. cit.*, p. 371 qui plaidaient en faveur d'une application du régime des fusions transfrontalières aux transformations transfrontalières. *Contra* : M. MENJUCQ, « Les scissions transfrontalières », *op. cit.*, p. 22, n° 34 qui considère que les règles applicables aux scissions transfrontalières ne sont qu'un « copier-coller » des dispositions applicables aux fusions transfrontalières et O. MÖRSDORF, « Der Entwurf einer Richtlinie… », *op. cit.*, p. 145 qui parle de « *geringe Modifikationen* ».
6237 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 19. *Contra* : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 31 qui avait plaidé en faveur d'un alignement des différents régimes.
6238 Voir en ce sens : R. KNAIER, « Unionales Umwandlungsrecht… », *op. cit.*, p. 624 et L. PÜTZ, *op. cit.*, p. 121.
6239 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 22 ; Étude d'impact, p. 62 et en ce sens également : J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 265.
6240 J. SCHMIDT, *ibidem*, p. 265.
6241 Art. 160*ter*, 3) de la Directive Mobilité.
6242 Voir en ce sens : Étude d'impact, p. 62.
6243 J. SCHMIDT, « Accomplishments and deficits… », *op. cit.*, p. 265.

B. *L'exclusion apparente de la possibilité d'appliquer les dispositions de référence sans négociations préalables*

1133. Un manque de flexibilité inexplicable. Sous prétexte de protéger les travailleurs contre les risques accrus en cas de scission transfrontalière[6244], la Directive Mobilité ne reprend pas dans le régime des scissions transfrontalières la possibilité pour l'organe de la société scindée de décider spontanément d'appliquer les dispositions de référence telle qu'elles existent dans le régime des fusions transfrontalières[6245]. Ce point est regrettable car, comme la constitution de l'organe spécial de négociation et les négociations nécessitent un certain temps[6246] et n'est pas sans difficultés[6247], cette exception, fréquemment utilisée en pratique[6248], permet d'accélérer et de réduire les coûts d'une opération transfrontalière tout en garantissant un niveau de protection élevé. Un tel constat s'impose d'autant plus si on prend en compte le fait que les négociations ne peuvent débuter que suite à la publication du projet[6249]. Il est certes vrai que cela va dans le sens d'un renforcement de la négociation[6250], ce qui compte tenu du fait que les solutions négociées en matière de participation des travailleurs peuvent se révéler plus adaptées aux besoins spécifiques d'une société[6251], peut s'avérer bénéfique, mais on ne distingue pas son intérêt immédiat[6252]. De plus, exclure une telle disposition ne fait que peu de sens dans la mesure où une société qui souhaite y recourir n'aurait qu'à opter pour une fusion transfrontalière suivie d'une scission interne en lieu et place d'une scission transfrontalière pour pouvoir en bénéficier[6253]. Il convient donc de plaider en faveur de l'extension de cette possibilité de ne pas ouvrir de négociations aux scissions transfrontalières, ce qui présenterait en outre le double avantage

6244 Étude d'impact, p. 62.

6245 Art. 133, § 4, a) de la Directive Sociétés.

6246 Voir en ce sens : St. BRANDES, « Mitbestimmungsvermeidung mittels grenzüberschreitender Verschmelzungen », *ZIP*, 2008, p. 2195 ; T. BRANDI, *op. cit.*, p. 2632 ; J. ROEST, *op. cit.*, p. 93 ; E. SCHLUMBERGER, *op. cit.*, p. 5, n° 23 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2446. Voir également en ce sens : Th. MASTRULLO. *op. cit.*, p. 6 qui relève en outre que les longs délais de négociation ne sont pas compatibles avec le calendrier d'une scission.

6247 Voir en ce sens : St. BRANDES, *ibidem*, p. 2195 ; B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 29 ; J. ROEST, *ibidem*, p. 93 et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2446.

6248 M. GÖTTE et P. MÜCKL, *op. cit.*, p. 2040 ; J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », *op. cit.*, p. 588 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281 et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, p. 2446.

6249 Art. 160*terdecies*, § 3, a) de la Directive Mobilité et art. 3, § 1er de la Directive Participation des Travailleurs et en ce sens : B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 29.

6250 Voir en ce sens : A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 146.

6251 Voir en ce sens : ECLE, *op. cit.*, p. 220 Voir toutefois : H. EIDENMÜLLER, L. HORNULF et M. REPS, « Contracting Employee Involvement: An Analysis of Bargaining over Employee Involvement Rules for Societas Europaea », *Journal of Corporate Law Studies*, 12 (2012), p. 201.

6252 Pour un point de vue critique, voir : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, « Grenzüberschreitende Spaltungen… », *op. cit.*, pp. 364 et 365 ; T. BRANDI, *op. cit.*, p. 2632 ; M. GÖTTE et P. MÜCKL, *op. cit.*, p. 2040 ; J. ROEST, *op. cit.*, p. 93 ; J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 281 ; Th. WACHTER, « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I)… », *op. cit.*, pp. 294 et 295 et H. WICKE, « Optionen und Komplikationen… (Teil II) », *op. cit.*, p. 2709.

6253 Voir en ce sens : J. BORMANN et P. STELMASZCZYK, *ibidem*, pp. 364 et 365.

(i) d'aboutir à un meilleur équilibre entre les intérêts des associés majoritaires à réaliser à brève échéance une opération économiquement importante pour l'entreprise et l'intérêt des travailleurs à voir leur droit de participation préservé et (ii) de renforcer la proportionnalité de l'entrave à la liberté d'établissement générée par le mécanisme de protection de la participation des travailleurs[6254].

C. *L'absence de la condition de représentation transfrontalière*

1134. Une condition absente. Tant le régime des fusions transfrontalières que celui des scissions transfrontalières prévoient que l'organe spécial de négociation dispose de la possibilité de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir des négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de l'opération sera établi[6255]. Cependant, le régime des scissions transfrontalières ne prévoit pas que cette majorité des deux tiers des membres de l'organe spécial de négociation représentant au moins deux tiers des travailleurs devra également comprendre « les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents ». Bien que l'exposé des motifs de la Proposition de la Commission ne le mentionne pas, cette omission est vraisemblablement liée au champ d'application *ratione materiae* limité de la Directive Mobilité qui ne couvre que les scissions n'impliquant qu'une société préexistante et où, par conséquent, il est beaucoup moins probable d'avoir des travailleurs dans au moins deux États membres différents[6256]. Ceci étant, cette condition de représentation des travailleurs mériterait d'être réinstaurée dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, ne fût-ce que par souci de cohérence avec le régime des fusions transfrontalières[6257].

D. *Scission partielle et « société issue de la scission transfrontalière »*

1135. Une notion incertaine. Les dispositions de la Directive Mobilité relatives à la protection du régime de participation des travailleurs dans le cadre d'une scission transfrontalière s'appliquent aux « sociétés issues de la scission transfrontalière »[6258]. Il a été relevé à cet égard qu'il n'était pas clair si, dans l'hypothèse d'une scission partielle, la société scindée devait également être visée par cette notion[6259]. Si on peut effectivement avancer que ce ne devrait pas être le cas dans la mesure où le caractère national ou transfrontalier de

6254 À ce sujet, voir *infra* n° 1153.
6255 Art. 133, § 4, b) de la Directive Sociétés et art. 160*terdecies*, § 4, a) de la Directive Mobilité.
6256 A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 146 qui y voit une omission fautive de la part du législateur européen.
6257 *Contra* : J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 282 qui y voit une simplification pratique bienvenue de la procédure.
6258 Art. 160*terdecies*, § 3 de la Directive Mobilité.
6259 Voir en ce sens : A. PÜTZ, *op. cit.*, p. 122.

l'opération devrait être sans incidence sur la participation au sein de la société scindée qui devrait demeurer sous l'emprise du droit national applicable à la société scindée[6260], il n'en demeure pas moins que cette incertitude due à une reprise du régime applicable aux transformations transfrontalières[6261] mériterait d'être clarifiée.

E. *L'application des dispositions de référence*

1136. Plan du point E. Au niveau de l'application des dispositions de référence, deux aspects méritent d'être brièvement étudiés dans le cadre de la comparaison entre le régime des fusions transfrontalières et celui des scissions transfrontalières couvertes par la Directive Mobilité. Le premier concerne la définition de la notion de dispositions de référence qui n'est pas identique dans les deux opérations (1) et le deuxième concerne une limitation des cas où un régime de participation pourrait être imposé de force aux seules hypothèses où l'opération risque de porter atteinte aux droits acquis par un nombre suffisamment important de travailleurs qui ne se retrouve pas dans le régime des scissions transfrontalières (2).

1. *Une double définition*

1137. Les dispositions de référence dans une fusion transfrontalière. Dans le cadre des fusions transfrontalières[6262], le régime de la Directive Sociétés, inaltéré à cet égard par la Directive Mobilité[6263], s'en remet au régime applicable au cas de constitution d'une société européenne autrement que par transformation[6264] qui stipule que lorsque les dispositions de référence trouvent à s'appliquer, « les travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la SE égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la SE ». En d'autres termes, ce sont les dispositions nationales les plus favorables à la participation des travailleurs qui trouveront à s'appliquer.

1138. Les dispositions de référence dans une scission transfrontalière. *A contrario*, le régime de la Directive Mobilité applicable aux scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[6265] renvoie au régime applicable en cas de constitution d'une société européenne par voie de transformation[6266]. Or, ce dernier prévoit en substance l'application des règles de participation de l'État membre d'origine.

6260 *Ibidem*.
6261 Voir art. 86*terdecies*, § 3 de la Directive Mobilité qui fait référence à « la société issue de la transformation transfrontalière ».
6262 Art. 133, § 3, h) de la Directive Sociétés.
6263 Art. 133 de la Directive Mobilité.
6264 Annexe, partie 3, b) du Règlement sur la Société européenne.
6265 Art. 160*terdecies*, § 3, g) de la Directive Mobilité.
6266 Annexe, partie 3, a) du Règlement sur la Société européenne.

1139. Enjeu de la question. Une telle différence de traitement est foncièrement insatisfaisante dans la mesure où on voit difficilement ce qui justifie de traiter différemment les fusions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés et les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés. En outre, si dans le cadre de la formation d'une société européenne par voie de transformation d'une société anonyme nationale, cette règle ne pose pas de difficulté particulière dans la mesure où l'opération ne s'accompagne pas d'un changement de *lex societatis* concomitant[6267], il n'en va pas de même en cas de scission transfrontalière. En effet, dans le cadre de cette dernière hypothèse, la *lex societatis* de la société scindée sera par définition[6268] différente de la *lex societatis* applicable à au moins une des sociétés bénéficiaires. Il s'ensuit que cette règle permet, de manière assez surprenante, d'éluder l'application du régime de participation potentiellement plus contraignant de l'État membre de destination[6269].

1140. Illustration. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre l'hypothèse de la scission transfrontalière d'une société anonyme de droit luxembourgeois occupant 900 travailleurs au profit de deux sociétés de droit allemand dont l'une recueillera 500 travailleurs et l'autre 450. Comme le droit luxembourgeois prévoit qu'un régime de participation ne doit être mis en place dans une société anonyme qu'au-delà d'un seuil de 1 000 travailleurs[6270], la société scindée ne connaissait pas de régime de participation des travailleurs. Cependant, le seuil des quatre cinquièmes posé par la Directive Mobilité[6271] est franchi, de sorte que la règle par défaut qui consacre l'application de principe des règles de participation en vigueur dans l'État membre du siège statutaire[6272] s'en trouve écartée. Il conviendra dès lors de procéder à la formation d'un groupe spécial de négociation qui sera chargé de négocier le régime de participation avec l'organe compétent de la société scindée. Comme ce dernier n'est nullement incité à faire des concessions à cet égard[6273], il y a de fortes chances que les négociations échouent au bout du délai imparti de six mois[6274]. Or, dans une telle hypothèse, le législateur européen a prévu que c'étaient les dispositions de référence qui devaient trouver à s'appliquer[6275], c'est-à-dire en l'occurrence les règles applicables en vertu du droit luxembourgeois. Il s'ensuivrait en toute logique qu'aucun régime de participation de travailleurs ne devrait trouver à s'appliquer dans les sociétés bénéficiaires de droit allemand et ce, alors

6267 Art. 37, § 3 du Règlement sur la Société européenne et à ce sujet, voir : J. HOFFMANN, « Mitbestimmungsfreie Gesellschaften deutschen Rechts durch grenzüberschreitenden Formwechsel », *op. cit.*, p. 786.

6268 Art. 160*bis*, § 1er de la Directive Mobilité qui prévoit que le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés ne trouve à s'appliquer que « si au moins deux des sociétés de capitaux dans la scission sont régies par le droit d'États membres différents ».

6269 Voir en ce sens : Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 et M. SELENT, *op. cit.*, p. 1175.

6270 Art. L. 426-1, § 1er du Code du travail luxembourgeois.

6271 Art. 160*terdecies*, § 2 de la Directive Mobilité et à ce sujet, voir *supra* n° 1128.

6272 Art. 160*terdecies*, § 1er de la Directive Mobilité.

6273 Sur cette problématique, voir *supra* n° 1128.

6274 Art. 160*terdecies*, § 3, c) de la Directive Mobilité et art. 5, § 1er de la Directive Participation des Travailleurs.

6275 Art. 160*terdecies*, § 3, e) de la Directive Mobilité et art. 7, § 1er de la Directive Participation des Travailleurs.

même qu'en vertu de ce dernier, un tiers du conseil de surveillance devrait être composé de représentants des salariés dès que le seuil de 500 travailleurs est franchi[6276]. Certes, dans pareille hypothèse, l'organe spécial de négociation serait bien avisé de clore les négociations et de s'en remettre aux règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre de chaque société bénéficiaire[6277], mais il n'en demeure pas moins que cette incohérence du régime des scissions transfrontalières permet d'éluder le régime de participation applicable dans l'État membre de destination[6278].

1141. Une révision indispensable. Il découle de ce qui précède qu'une scission transfrontalière pourrait, assez paradoxalement, être utilisée pour constituer une société sans régime de participation des travailleurs dans un État membre ayant pourtant un régime très protecteur à cet égard. Le même constat s'imposerait *mutatis mutandis* à l'égard d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante pour laquelle cette définition des dispositions de référence s'avère foncièrement inappropriée. Un régime européen plus général des scissions transfrontalières devrait dès lors nécessairement recourir à la définition des dispositions de référence prévalant à l'égard des fusions transfrontalières[6279], et non à celle applicable à une société européenne constituée par transformation.

2. *Une condition nécessaire en cas de scission transfrontalière*

1142. Le régime des fusions transfrontalières. À l'égard des fusions transfrontalières, les dispositions de référence trouveront à s'appliquer (i) si les négociations entre l'organe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés fusionnantes échouent dans le délai imparti[6280], (ii) si l'organe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés qui fusionnent en décident ainsi[6281] ou encore (iii) si les organes compétents des sociétés qui fusionnent préfèrent accélérer la procédure et décident spontanément d'appliquer les dispositions de référence[6282]. Cependant, cette règle par défaut est considérablement émoussée dans l'hypothèse des fusions transfrontalières dans la mesure où ces dispositions de référence ne pourront trouver à s'appliquer que si, avant l'immatriculation de la fusion transfrontalière, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins un tiers du nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des sociétés participantes[6283]. Cette disposition a fait l'objet de

6276 (§§ 1(1) et 4(1) DrittelbG.
6277 Art. 160*terdecies*, § 4, a) de la Directive Mobilité.
6278 Voir en ce sens à propos des transformations transfrontalières : J. HOFFMANN, « Mitbestimmungsfreie Gesellschaften deutschen Rechts durch grenzüberschreitenden Formwechsel », *op. cit.*, p. 786.
6279 Art. 133, § 3, h) de la Directive Sociétés et Annexe, partie 3, b) de la Directive Participation des Travailleurs.
6280 Art. 133, § 3, e) de la Directive Sociétés et art. 7, § 1er, b) de la Directive Participation des Travailleurs.
6281 Art. 133, § 3, e) de la Directive Sociétés et art. 7, § 1er, a) de la Directive Participation des Travailleurs.
6282 Art. 133, § 4, a) de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité.
6283 Art. 133, § 3, e) de la Directive Sociétés et art. 7, § 2, b), 1er tiret de la Directive Participation des Travailleurs.

certaines critiques[6284] dans la mesure où il n'est pas compréhensible pourquoi un régime moins favorable à la participation des travailleurs devrait s'appliquer en cas de fusion transfrontalière par rapport à une fusion transfrontalière en vue de la constitution d'une société européenne[6285]. Elle n'en a pas pour autant été altérée par la Directive Mobilité et force est de constater qu'elle est néanmoins logique dans la mesure où elle limite les cas où un régime de participation pourrait être imposé de force aux seules hypothèses où l'opération risque de porter atteinte aux droits acquis par un nombre suffisamment important de travailleurs[6286].

1143. Un régime des scissions transfrontalières distinct. Le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, pour sa part, ne prévoit pas d'aménagement similaire à cette règle par défaut, ce qui s'explique aisément par le fait qu'il n'y a qu'une seule société préexistante impliquée. Cependant, dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, il est tout à fait probable que le nombre de travailleurs bénéficiant du régime de participation soit négligeable par rapport au nombre total de travailleurs concernés par l'opération. Ceci signifie qu'une règle similaire à celle applicable aux fusions transfrontalières et requérant qu'un pourcentage suffisamment élevé de travailleurs soient exposés à une réduction de leur droit de participation ferait tout son sens et renforcerait en outre la proportionnalité de la mesure de protection en question au regard de la liberté d'établissement[6287].

F. *La scission partielle au profit d'une société sans travailleurs*

1144. Une spécificité des scissions. Compte tenu du fait qu'une scission partielle peut être réalisée au profit d'une société soit nouvellement créée, soit préexistante qui n'aurait aucun travailleur, on peut s'interroger sur ce qu'il conviendrait de faire en pareille hypothèse. En effet, si une société anonyme luxembourgeoise régie selon un système de participation des travailleurs se scinde au profit d'une nouvelle société belge sans que l'opération ne s'accompagne d'aucun transfert de contrat de travail vers la société belge, il ne pourrait y avoir de négociations préalables ou d'accord sur la participation au sein de la société bénéficiaire faute de travailleurs[6288]. À cet égard, il a été avancé que de telles opérations devaient être considérées comme abusives et que

6284 Voir en ce sens : A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, pp. 141 et 142. *Contra* : S. NABER et Ul. SITTARD in H. KIEL, St. LUNK et H. OETKER (dir.), *Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht*, vol. 4, 4e éd., München, C.H. BECK, 2018, § 386, n° 81 qui justifient cette exception par le fait que la règle par défaut en matière de fusions transfrontalières est l'application du droit national et que dans ce cas, l'application du droit national n'aboutit pas à ce que la société issue de l'opération ne connaisse pas de système de participation.

6285 Dans le régime de la société européenne, ce seuil est fixé à 25 %. Voir art. 7, § 2, b), premier tiret de la Directive Participation des Travailleurs.

6286 St. BRANDES, *op. cit.*, p. 2197 et S. NABER et Ul. SITTARD in H. KIEL, St. LUNK et H. OETKER (dir.), *op. cit.*, § 386, n° 81.

6287 À ce sujet, voir *infra* n° 1153.

6288 Voir en ce sens : A. PÜTZ, *op. cit.*, p. 123.

l'autorité compétente devrait s'abstenir de délivrer un certificat de conformité[6289]. Cependant, on peine à voir le caractère foncièrement abusif d'une telle opération puisqu'elle n'affectera pas les droits de participation des travailleurs au sein de la société scindée. En outre, on peut émettre de sérieux doutes quant à la proportionnalité d'une mesure nationale prohibant *ab initio* ce type d'opération à l'aune de la liberté d'établissement. Il n'en demeure pas moins que cette lacune mériterait d'être rectifiée dans l'intérêt de la sécurité juridique afin d'éviter de devoir attendre une éventuelle décision de la Cour de justice en la matière. Il conviendrait ainsi de prévoir qu'en l'absence de travailleurs affectés par un changement de *lex societatis*, le régime spécifique de protection des droits de participation des travailleurs ne devrait pas trouver à s'appliquer.

G. *L'instauration d'un régime de participation transitoire*

1145. Une règle de faible intérêt. Afin de garantir une protection ininterrompue des droits de participation des travailleurs, la Directive Mobilité prévoit que les États membres auront dorénavant également l'obligation de garantir que les règles de participation applicables à la société scindée continueront de s'appliquer jusqu'à la date d'application de toutes règles convenues d'un commun accord ultérieurement ou en l'absence de telles règles jusqu'à l'application des dispositions de référence[6290]. Cette règle, absente du régime des fusions transfrontalières et directement reprise du régime des transformations transfrontalières[6291] vise à éviter une éventuelle interruption du régime de participation des travailleurs[6292]. Bien que compréhensible dans son principe, elle ne présente que peu d'intérêt[6293], ne fût-ce qu'en raison du fait que son application pratique ne sera pas aisée[6294], a fortiori dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. On peut également se demander si cette disposition ne poursuit pas également un objectif politique en visant à rassurer les États membres et les syndicats demeurant sceptiques à l'égard des scissions transfrontalières. Ceci expliquerait en tout cas pourquoi elle ne se retrouve pas dans le régime des fusions transfrontalières.

H. *La surprenante incidence de la règle de permanence*

1146. Une nouvelle preuve de la nécessité d'une intervention du législateur européen. Tout comme dans le cas des fusions transfrontalières[6295], le régime des scissions transfrontalières de la Directive Mobilité par constitution de nouvelles sociétés intègre une règle de permanence selon laquelle en cas

6289 *Ibidem*.
6290 Art. 160*terdecies*, § 4, c) de la Directive Mobilité.
6291 Art. 86*terdecies*, § 4, c) de la Directive Mobilité.
6292 J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 282.
6293 Voir en ce sens : A. SEIFERT, « Employee participation… », *op. cit.*, p. 147.
6294 J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 282.
6295 À ce sujet, voir *supra* n° 1129.

de transformation, scission ou fusion transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après la date de prise d'effet de la scission initiale, la société est tenue de protéger les droits en matière de participation des travailleurs en appliquant le régime de protection prévu en matière de scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[6296]. À cet égard, il convient tout d'abord de remarquer que s'il a pu être argumenté qu'il s'agissait là en réalité d'une erreur de rédaction de la part du législateur européen[6297] et qu'il ressortait de l'exposé des motifs de la Proposition de la Commission que seules les opérations nationales devaient en réalité être visées[6298], ne fût-ce qu'en raison du fait que les autres opérations transfrontalières disposent déjà d'un régime propre de protection de la participation des travailleurs, il y a néanmoins une hypothèse dans laquelle cette extension aux opérations transfrontalières se justifie pleinement. En effet, dans la mesure où les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante n'entrent pas dans le champ d'application de la Directive Mobilité[6299], ces dernières ne disposent pas d'un régime propre de protection de la participation de travailleurs. Or, comme le régime de protection applicable aux fusions transfrontalières présente certaines différences par rapport au régime applicable tant aux fusions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés qu'aux transformations transfrontalières, on en aboutit à la conséquence assez surprenante que le régime de protection de la participation des travailleurs en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante variera au gré de l'opération transfrontalière la précédant. Ainsi, à titre d'illustration, en cas de scission transfrontalière par absorption d'une société scindée connaissant un régime de participation et issue d'une fusion transfrontalière, les organes compétents des sociétés impliquées dans l'opération disposeront du droit de choisir sans négociation préalable d'être directement soumis aux dispositions de référence relatives à la participation[6300]. *A contrario*, la même opération dans laquelle la société scindée connaissant le régime de participation est issue d'une scission transfrontalière par constitution d'une nouvelle société n'entraînera pas la possibilité pour les organes compétents des sociétés impliquées de choisir sans négociation préalable d'être directement soumis aux dispositions de référence. Le même constat s'impose à l'égard de la définition des dispositions de référence[6301] qui est susceptible de varier en fonction de l'opération transfrontalière ayant précédé la scission transfrontalière par absorption. Une telle situation est illogique et inévitablement source d'insécurité juridique, de

6296 Art. 160*terdecies*, § 7 de la Directive Mobilité.
6297 Voir en ce sens : B. LECOURT, « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *op. cit.*, p. 29.
6298 Proposition de la Commission, exposé des motifs, p. 30 où il est indiqué que « [l]'article 133, paragraphe 7, qui dispose que pendant les trois ans suivant la fusion transfrontalière, la société ne pourra pas effectuer une fusion nationale subséquente qui entraînerait une sape du système de participation des travailleurs, est modifié pour couvrir *toutes les opérations nationales subséquentes* possibles (c'est-à-dire fusions, scissions et transformations) et pas uniquement les fusions nationales ». Voir en ce sens : B. LECOURT, *ibidem*, p. 29.
6299 Sur le champ d'application *ratione materiae* excessivement limité de la Directive Mobilité, voir *supra* n°s 341 à 346.
6300 Art. 133, § 4, a) de la Directive Sociétés.
6301 Sur cette problématique, voir *supra* n°s 1136 à 1141.

sorte qu'elle justifierait une intervention du législateur européen à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante.

I. *La composition du groupe spécial de négociation*

1147. Une représentation équitable. À l'égard de la constitution du groupe spécial de négociation tant le régime des fusions transfrontalières[6302] que celui des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[6303] se réfère directement au régime applicable à la société européenne. En conséquence, lors de la formation de ce groupe spécial de négociation qui représentera les travailleurs des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés[6304], il y aura lieu de veiller, lors de l'élection des membres, à ce que les membres soient élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre, un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente dix pourcents du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des États membres concernés, ou une fraction de cette tranche[6305]. Cette règle s'applique uniformément tant en cas de fusion transfrontalière[6306] que de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés[6307], à ceci près qu'en cas de fusion transfrontalière, il est également précisé que lors de l'élection des membres du groupe spécial de négociation, il y aura également lieu de veiller à ce que d'autres membres supplémentaires de chaque État membre concerné soient présents dans la mesure nécessaire pour garantir que le groupe spécial de négociation comprenne au moins un membre représentant chaque société participante qui est immatriculée et emploie des travailleurs dans cet État membre et qui suite à la réalisation de la fusion sera dissoute sans liquidation, pour autant que le nombre de ses membres supplémentaires n'excède pas vingt pourcents du nombre des membres désignés conformément à la règle de base et que la composition du groupe spécial de négociation n'implique pas une double représentation des travailleurs concernés. Cette règle vise en priorité à assurer que chaque société dissoute et concernée par l'opération soit dûment représentée au sein du groupe spécial de négociation[6308]. Si l'exclusion de cette règle tant en matière de transformation que de scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés se justifie par le fait qu'il n'y a jamais qu'une seule société impliquée[6309], il en va fondamentalement différemment dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus

6302 Art. 133, § 3, a) de la Directive Sociétés et art. 3, § 2 de la Directive Participation des Travailleurs.
6303 Art. 160*terdecies*, § 3, a) de la Directive Mobilité et art. 3, § 2, point a), i) et point b) de la Directive Participation des Travailleurs.
6304 Art. 3, § 2 de la Directive Participation des Travailleurs.
6305 Art. 3, § 2, a), i) de la Directive Participation des Travailleurs.
6306 Art. 133, § 3, a) de la Directive Sociétés et art. 3, § 2 de la Directive Participation des Travailleurs.
6307 Art. 160*terdecies*, § 3, a) de la Directive Mobilité et art. 3, § 2, a), i) de la Directive Participation des Travailleurs.
6308 Voir en ce sens : M. GÖTTE et P. MÜCKL, *op. cit.*, p. 2039 et H. OETKER in M. LUTTER, P. HOMMELHOFF et Chr. TEICHMANN (dir.), *SE Kommentar*, 2e éd., Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 2015, § 5SEBG, n° 11.
6309 Voir au sujet des transformations transfrontalières : M. GÖTTE et P. MÜCKL, *ibidem*, p. 2039 qui relèvent que dans une telle opération, aucune société ne se trouve dissoute.

d'une société préexistante. En effet, dans une telle hypothèse, l'application par analogie du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés aurait pour conséquence que les travailleurs de la société scindée, qui sont pourtant les seuls concernés par une éventuelle perte de leurs droits de participation, ne seront pas nécessairement représentés au sein du groupe spécial de négociation. Afin d'éviter ce cas de figure, un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante devrait également intégrer l'exception prévue en matière de fusions transfrontalières et veiller à une représentation obligatoire de la société scindée.

J. *Le cas particulier de la réduction des droits de participation*

1148. Un régime difficilement compatible. Dans le cas d'une fusion transfrontalière[6310], il est expressément prévu qu'alors que les décisions du groupe spécial de négociation sont en principe prises à la majorité absolue des membres, à condition que cette majorité représente la majorité absolue des travailleurs, des conditions de majorité renforcées s'appliquent à une décision approuvant une éventuelle réduction des droits de participation, si la participation concerne au moins vingt-cinq pourcents du nombre total de travailleurs employés par les sociétés participantes. En effet, une telle décision requerra une majorité des deux tiers des voix des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs et incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres. Cette règle ne trouve pas à s'appliquer dans le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[6311] qui, en revanche, adopte la même solution que dans l'hypothèse d'une transformation transfrontalière[6312]. Il prévoit ainsi que l'accord conclu devra nécessairement prévoir un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société préalablement à sa transformation. Dans l'hypothèse des scissions transfrontalières, cette règle surprend à double titre. Tout d'abord, elle n'a aucun intérêt dans l'hypothèse du dépassement du seuil des quatre cinquièmes puisque par définition, il n'y a pas de régime de participation en vigueur dans la société scindée. Ensuite, plus spécifiquement dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, l'impossibilité de réduire le niveau de participation aboutirait à une complexification significative des négociations. En effet, sans altération, la règle qui prévaut à l'heure actuelle à l'égard des scissions transfrontalières impliquerait tout simplement que dans l'hypothèse dans l'hypothèse d'une scission par acquisition où les salariés de la société scindée ne représenteraient qu'un très faible pourcentage du nombre total de travailleurs impactés par l'opération, il ne sera pas possible de consentir à une réduction en vue d'obtenir un accord. Il ne serait dès lors pas étonnant de constater que

6310 Art. 133, § 3, a) de la Directive Sociétés et art. 3, § 4, 1er al., premier tiret de la Directive Participation des Travailleurs.

6311 Art. 160*terdecies*, § 3, b) de la Directive Mobilité et art. 4, § 4 de la Directive Participation des Travailleurs.

6312 Art. 86*terdecies*, § 3, b) de la Directive Mobilité et art. 4, § 4 de la Directive Participation des Travailleurs.

les négociations n'aboutissent pas dans une telle hypothèse. En conséquence, à l'égard des scissions transfrontalières par acquisition et mixtes, il convient de plaider en faveur de l'application de la solution développée à l'égard des fusions transfrontalières et qui autorise une éventuelle réduction des droits de participation, le cas échéant à des conditions de majorité renforcées.

SECTION 7. LA CONFORMITÉ DU RÉGIME DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

1149. Plan de la section 7. Pour pouvoir se prononcer sur la conformité du régime de participation des travailleurs à la liberté d'établissement, il convient de procéder en deux étapes successives, à savoir établir que ce régime de protection constitue bien une entrave à la liberté d'établissement des sociétés concernées (§ 1) et examiner si cette entrave pourrait être justifiée (§ 2).

§1. Une entrave à la liberté d'établissement

1150. Un indéniable caractère dissuasif. Compte tenu de la complexité du mécanisme de protection de la participation des travailleurs et de la durée potentiellement excessive des négociations, il n'est pas difficile de voir dans le régime de la Directive Mobilité une mesure de nature à « *dissuader* »[6313] une société de faire usage de sa liberté d'établissement en procédant à une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés[6314]. À cela s'ajoute qu'à l'égard du régime de la société européenne, il a été clairement établi que la complexité de la réglementation applicable à la participation des travailleurs décourageait les acteurs économiques à recourir à cette forme sociale[6315]. Le même constat ressort de l'Étude Bech-Bruun et Lexidale au sujet des fusions transfrontalières[6316] et s'imposerait d'autant plus dans l'hypothèse d'une scission par absorption au profit de deux sociétés bénéficiaires préexistantes situées dans un État membre ignorant tout mécanisme de participation des travailleurs si les règles de la Directive Mobilité devaient être étendues à ces dernières. En effet, le cas échéant, ces dernières pourraient se voir contraintes de mettre en place un système de participation, mais en plus, elles ne seront plus libres dans le choix de leur forme sociale[6317] et devront réitérer le même long et fastidieux processus de négociation pour toute opération nationale ou transfrontalière subséquente et ce, pendant une durée de quatre ans à

6313 Arrêt *Lasteyrie du Saillant*, pt. 45 et arrêt *Daily Mail*, pt. 16.
6314 Voir en ce sens : G. PARLEANI, « Les propositions concernant… », *op. cit.*, p. 15, n° 46.
6315 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), (COM(2010) 676 final – SEC(2010) 1391), 17 novembre 2010, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (25/10/2019), p. 5 et J. ROEST, *op. cit.*, p. 82.
6316 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 73 qui cite l'exemple de la fusion entre une société cotée grecque et une société espagnole qui a dû être abandonnée à cause de la question de la participation des travailleurs.
6317 Art. 160*terdecies*, § 6 de la Directive Mobilité.

compter de la date de prise d'effet de l'opération[6318]. Il est dès lors évident qu'il existe une tension entre la liberté d'établissement et les règles sur la participation des travailleurs[6319] et il est particulièrement aisé de démontrer que ces dernières constituent une entrave nécessitant une justification à l'aune du « *Gebhard test* »[6320][6321].

§ 2. La justification objective de l'entrave

1151. Une raison impérieuse d'intérêt général. Si la protection des intérêts des salariés a de longue date été reconnue par la Cour de justice comme raison impérieuse d'intérêt général[6322], il reste encore à déterminer si la protection de la participation des travailleurs est susceptible d'être considérée comme une raison impérieuse d'intérêt général. Pour pouvoir répondre à cette question, il convient d'aller voir quelle est la *ratio legis* des systèmes de participation mis en place dans les États membres. Pour ce qui est du *Mitbestimmungsgesetz* allemand, le *Bundesverfassungsgericht* a précisé que ce dernier associait les salariés au processus de décision interne afin de réduire les risques liés au fait que dans les grandes entreprises, la plupart des décisions stratégiques étaient prises à l'étranger[6323]. Il est ainsi généralement considéré que celui-ci répond effectivement à un souci de protection des intérêts des salariés[6324], ce qui, selon certains auteurs, est confirmé par les mesures législatives européennes en vue de le préserver[6325]. Au vu de cela, on peut considérer qu'une disposition de droit dérivé destinée à protéger le système de participation mis en place dans une société répond effectivement à un souci de protection des intérêts des salariés[6326].

1152. Une mesure adéquate. Peut-on à présent considérer que le mécanisme particulièrement complexe mis en place par le législateur européen est propre à atteindre cet objectif ? Si on part du principe que le but avéré est la protection du *status quo ante*, on peut considérer que celui-ci est effectivement rempli adéquatement puisqu'en l'absence de solution négociée, les règles en vigueur dans l'État membre de la société scindée trouveront à s'appliquer[6327].

6318 Art. 160*terdecies*, § 7 de la Directive Mobilité.
6319 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 75.
6320 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.
6321 Voir en ce sens : W. MEILICKE et D. E. RABBACK, *op. cit.*, p. 126.
6322 Arrêt *Polbud*, pt. 54 ; C.J., gde ch., arrêt *Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) c. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis*, 21 décembre 2016, C-201/15, EU:C:2016:972, pt. 73 ; arrêt *Vale*, pt. 39 ; arrêt *Sevic*, pt. 28 et arrêt *Überseering*, pt. 92.
6323 BVerfG, Urteil v. 1. März 1979, *NJW*, 1979, p. 593 et à ce sujet : W. BAYER, « Auswirkungen der Niederlassungsfreiheit nach den EuGH-Entscheidungen Inspire Art und Überseering auf die deutsche Unternehmensmitbestimmung », *AG*, 2004, p. 537 et G. THÜSING, « Deutsche Unternehmensmitbestimmung und europäische Niederlassungsfreiheit », *ZIP*, 2004, p. 385.
6324 Voir en ce sens : W. BAYER, *ibidem*, p. 537 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 151 ; Cl. SCHUBERT, « Beteiligung von Arbeitnehmern in ausländischen Betrieben und Tochtergesellschaften an der Unternehmensmitbestimmung in deutschen Konzernen », *AG*, 2017, p. 373 et G. THÜSING, *ibidem*, p. 385.
6325 W. BAYER, *ibidem*, p. 537.
6326 Voir en ce sens : W. BAYER, *ibidem*, p. 537 ; D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 151 et G. THÜSING, *op. cit.*, p. 385.
6327 Art. 160*terdecies*, § 3, e) de la Directive Mobilité et art. 7, § 1er, al. 2, b) de la Directive Participation des Travailleurs.

Certes, on pourrait relever que la possibilité de réaliser une scission transfrontalière peu avant le franchissement des seuils et l'ineffectivité de la combinaison entre seuil des quatre cinquièmes et application des dispositions de référence en cas d'échec des négociations à remédier à ce problème[6328], si tant est qu'il en soit un, pourrait venir relativiser cette conclusion, mais il n'en demeure pas moins que, compte tenu du caractère particulièrement délicat d'un point de vue politique de la question[6329], ce mécanisme semble malgré tout adéquat dans la mesure où il garantit généralement un maintien des droits de participation en vigueur pendant une durée de quatre ans[6330].

1153. Une mesure proportionnée ? Le régime de protection la participation des travailleurs de la Dixième Directive a pu sembler proportionné[6331], même si l'étude réalisée par Bech-Bruun et Lexidale a démontré à suffisance que les règles en la matière étaient perçues comme excessivement complexes[6332]. En effet, un tel régime est en tout état de cause plus proportionné qu'une prohibition pure et simple des opérations transfrontalières ou qu'un mécanisme de protection *ad aeternitatem*. Cependant, le régime prôné par le législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité va dans le sens d'un renforcement des règles protectrices de la participation des travailleurs et ce, non seulement pour les scissions transfrontalières, mais également pour les fusions transfrontalières[6333]. À titre d'illustration, cela ressort très clairement de l'extension de l'exception du seuil des quatre cinquièmes[6334] et de la prolongation de la durée de la règle de permanence de trois à quatre ans[6335]. Un tel renforcement est surprenant dans la mesure où, malgré les critiques formulées à son encontre par les sociétés[6336] et les syndicats[6337], les règles relatives à la participation des travailleurs en cas de fusion transfrontalière de sociétés, bien que compliquées, fonctionnaient en pratique[6338] et qu'il aurait dès lors tout à fait pu être

6328 À ce sujet, voir *supra* n°s 1128 et 1136 à 1141.

6329 À ce sujet, voir *supra* n° 1125.

6330 Art. 86*terdecies*, § 7 ; 133, § 7 et 160*terdecies*, § 7 de la Directive Mobilité.

6331 D. BEUTEL, *op. cit.*, p. 253. *Contra* : Consultation publique de 2015, p. 18 qui relève qu'une des personnes interrogées semblait émettre de sérieux doutes quant à la conformité à la liberté d'établissement d'une telle mesure.

6332 Étude Bech-Bruun et Lexidale, p. 73 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 21.

6333 Voir en ce sens : Avis CAJ, exposé des motifs, p. 216 ; ECLE, *op. cit.*, p. 218 ; Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 ; M. GÖTTE et P. MÜCKL, *op. cit.*, p. 2043 ; J. ROEST, *op. cit.*, pp. 95 et 96 ; E. SCHLUMERGER, *op. cit.*, p. 5, n° 23 et P. STELMASZCZYK, « Der materielle Stakeholderschutz… », *op. cit.*, p. 2447.

6334 Art. 133, § 7 de la Directive Mobilité.

6335 Art. 133, § 2 de la Directive Mobilité. À ce sujet, voir : J. ROEST, *op. cit.*, p. 104 qui relève que la durée de trois ans était relativement courte. Voir également : ETUC letter on the proposal for a directive on the company law package to Commissioner Thyssen du 22 mai 2018, disponible sur https://www.etuc.org (23/07/2020) dans laquelle la confédération européenne des syndicats avance que « [t]*he Commission proposal offers only the temporary 'survival' of existing national regulations. This is clearly insufficient* ».

6336 Étude d'impact, p. 22 qui indique que les sociétés considèrent ce régime comme trop complexe et entraînant des coûts et des retards superflus. Voir également en ce sens : Étude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 72 et 73.

6337 Étude d'impact, pp. 20 et 23 qui indique que les syndicats considèrent que ce régime n'offre pas une protection suffisante.

6338 Voir en ce sens : Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906 ; J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 21 et J. ROEST, *op. cit.*, p. 89.

envisageable d'étendre ces règles aux autres opérations transfrontalières[6339]. S'il est certes possible de justifier l'intégration d'un régime de protection des travailleurs pour les fusions et les scissions transfrontalières par le fait que les différentes opérations transfrontalières sont aisément substituables[6340], cela n'explique pas pourquoi le régime des fusions transfrontalières présente encore autant de différences par rapport au régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés[6341]. Une question similaire se pose à l'égard de la possibilité pour les organes compétents de ne pas ouvrir de négociations et de décider d'appliquer directement les dispositions de référence[6342]. En effet, est-ce qu'une mesure qui ne permet pas d'éluder la constitution d'un groupe spécial de négociation en présence d'une des trois situations déclenchant le mécanisme de protection, et ce alors que le choix d'appliquer les dispositions de référence garantirait un niveau de protection particulièrement élevé[6343], ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif ?

1154. L'incidence de la nature politique. S'il est permis d'émettre certains doutes quant à la proportionnalité de l'entrave générée à la liberté d'établissement par le nouveau régime de protection de la participation des travailleurs, il convient de préciser que la dimension éminemment politique de la matière rend particulièrement malaisé l'exercice qui consiste à déterminer ce qui va au-delà du nécessaire pour garantir une protection adéquate. Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher brièvement sur la délicate question de la durée de la règle de permanence[6344] à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés. En effet, alors que la Proposition de la Commission[6345], le Premier Compromis de la Présidence[6346], le Deuxième Compromis de la Présidence[6347] et le Compromis des Représentants Permanents[6348] envisageaient une durée de trois ans, la Commission de l'emploi et des affaires sociales[6349], tout comme la Commission des affaires juridiques avaient plaidé en faveur d'une durée de six ans[6350], le Compromis Final[6351] tout comme la Proposition du Parlement[6352] et la Directive Mobilité[6353] se sont arrêtés sur une durée de quatre ans, le Bundesrat allemand s'était prononcé en faveur d'une durée de dix ans[6354] et la confédération européenne des syndicats réclamait une

6339 Voir en ce sens : M. GÖTTE et P. MÜCKL, *op. cit.*, p. 2043.
6340 Voir en ce sens : Th. LUY, « Grenzüberschreitende Umwandlungen… », *op. cit.*, p. 1906.
6341 À ce sujet, voir *supra* n°s 1131 à 1148.
6342 À ce sujet, voir *supra* n° 1133.
6343 Sur la problématique de la définition des « dispositions de référence », voir *supra* n°s 1136 à 1141.
6344 Sur cette règle, voir *supra* n° 1129.
6345 Art. 160*quindecies*, § 7 de la Proposition de la Commission.
6346 Art. 160n, § 7 du Premier Compromis de la Présidence.
6347 Art. 160n, § 7 du Deuxième Compromis de la Présidence.
6348 Art. 160n, § 7 du Compromis des Représentants Permanents.
6349 Amendement 112 de l'Avis CEAS.
6350 Amendement 316 de l'Avis CAJ.
6351 Art. 160n, § 7 du Compromis Final.
6352 Art. 160*quindecies*, § 7 de la Proposition du Parlement.
6353 Art. 160*terdecies*, § 7 de la Directive Mobilité.
6354 Voir également : Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18, p. 10 qui réclame une durée d'au moins cinq ans pour la règle de permanence.

durée minimale de dix ans[6355]. Une telle diversité rend la tâche de déterminer ce qui est proportionné ou non en la matière particulièrement délicate. De manière purement pragmatique, il est également peu probable que la Cour de justice puisse se décider à réduire à néant les efforts de plusieurs décennies de négociation nécessaires pour parvenir à un compromis politique sur la participation des travailleurs.

SECTION 8. CONCLUSION SUR LES ENJEUX D'UNE SCISSION TRANSFRONTALIÈRE POUR LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

1155. Conclusion intermédiaire. Foncièrement fragmentaire entre les différents États membres et réticente à toute harmonisation, la participation des travailleurs constitue un enjeu non négligeable d'une scission transfrontalière. Ce sera tout particulièrement le cas si (i) la ou les société(s) bénéficiaire(s) relève(nt) d'une forme sociale pour laquelle la législation nationale applicable ne prévoit pas de régime de participation de travailleurs, (ii) la *lex societatis* qui détermine l'existence et les conditions du régime de participation se trouve altérée au profit d'une autre *lex societatis* affaiblissant le régime en vigueur ou le supprimant purement et simplement, et (iii) la scission transfrontalière est utilisée pour redescendre en dessous des seuils au-delà desquels l'instauration d'un régime de participation des travailleurs devient obligatoire en vertu du droit national applicable à la société scindée ou éviter *in extremis* de les dépasser. Bien que ne concernant qu'un faible pourcentage de sociétés de capitaux au sein de l'Union européenne, l'expérience glanée à l'égard de la société européenne et des fusions transfrontalières démontre à suffisance que la dimension politique de la question ne doit en aucun cas être sous-estimée et que cette dernière rend une situation d'équilibre entre les différents intérêts en présence particulièrement difficile à atteindre. Cette trame de fond déjà complexe se voit encore complétée par le fait que tout régime destiné à protéger les droits de participation des travailleurs constituera immanquablement une entrave à la liberté d'établissement des sociétés préexistantes concernées. Ce caractère intrinsèquement délicat explique pourquoi le régime des fusions transfrontalières consacré par la Directive Sociétés n'a été modifié que ponctuellement. Ces altérations limitées vont toutefois dans le sens d'un renforcement, même si on ne peut que relever que le seuil des quatre cinquièmes consacré par le législateur européen est dénué de véritable intérêt pratique et devrait être délaissé, que la règle de permanence manque de clarté et que la règle relative à l'information des travailleurs gagnerait à être précisée d'avantage. En outre, lorsqu'on compare ce régime à celui mis en place par le législateur européen à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, on constate que le régime de ces dernières est plus strict, ce qui amène à deux conclusions. Premièrement, ce manque de cohérence affaiblit l'efficacité du régime des scissions transfrontalières dans la mesure où les différentes

[6355] ETUC letter on the proposal for a directive on the company law package to Commissioner Thyssen du 22 mai 2018, disponible sur https://www.etuc.org (23/07/2020).

opérations sont aisément substituables. Deuxièmement, les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, devraient tomber dans le champ d'application des mécanismes de protection sous peine de les priver d'une bonne partie de leur effet utile puisque leur protection par le biais de la liberté d'établissement n'est pas tributaire de la mise en place d'un régime de protection spécifique. Ensuite, par le biais de cette comparaison, il est possible de mettre en évidence certaines spécificités qu'un régime plus général des scissions transfrontalières devrait revêtir s'il devait s'inspirer du régime mis en place par la Directive Mobilité tant à l'égard des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés que des fusions transfrontalières, à savoir (i) permettre aux organes compétents des sociétés impliquées dans la scission de décider spontanément d'appliquer les dispositions de référence, (ii) la décision de l'organe spécial de négociation de ne pas ouvrir des négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre de chaque société bénéficiaire devrait être prise à la majorité des deux tiers des membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, y compris les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents, (iii) en cas de scission partielle, la société scindée qui survit à l'opération ne devrait pas être concernée par le mécanisme de protection de la participation des travailleurs en cas de scission transfrontalière, (iv) la définition des dispositions de référence devrait être celle qui prévaut à l'égard des fusions transfrontalières, et non celle applicable à une société européenne constituée par transformation, (v) les dispositions de référence ne devraient trouver à s'appliquer que si, avant l'immatriculation de la scission transfrontalière, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins un tiers du nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des sociétés participantes, (vi) en cas de scission partielle au profit d'une société qui ne recueillera aucun travailleur dans l'opération, le régime spécifique de protection des droits des travailleurs ne devrait pas trouver à s'appliquer, (vii) la mesure transitoire prévoyant que les règles de participation applicables à la société scindée continueront de s'appliquer jusqu'à la date d'application de toutes règles convenues d'un commun accord ultérieurement ou, en l'absence de telles règles, jusqu'à l'application des dispositions de référence devrait être bannie, (viii) les règles relatives à la composition du groupe spécial de négociation devraient garantir, à l'instar de ce qui est le cas *mutatis mutandis* dans le régime des fusions transfrontalières, la représentation de la société scindée au sein du groupe spécial de négociation et (ix) le groupe spécial de négociation doit avoir la possibilité de consentir à une éventuelle réduction des droits de participation, le cas échéant aux conditions de majorité renforcées posées à cet égard dans le cadre des fusions transfrontalières. Par ailleurs, à la suite de cette analyse, on peut également relever que le fait que la règle de permanence aboutisse à l'application d'un régime de protection de la participation des travailleurs à une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante qui variera au gré de l'opération transfrontalière l'ayant précédée dans un délai de moins de quatre ans plaide indéniablement en faveur d'une intervention de la part du législateur européen en la matière. À cela s'ajoute que la longue et complexe procédure destinée à sauvegarder

les droits de participation des travailleurs est de nature à dissuader un bénéficiaire de la liberté d'établissement d'en faire usage. Il s'ensuit que les mécanismes mis en place par le législateur européen à cet égard devront remplir les différentes conditions de la « *rule of reason* »[6356]. Or, si ceux-ci, en ce qu'ils aspirent à sauvegarder les droits de participation, poursuivent effectivement la raison impérieuse d'intérêt général que constitue la protection des intérêts des salariés et sont, de prime abord, suffisamment convaincants et propres à atteindre cet objectif, ils soulèvent néanmoins certaines interrogations au niveau de la condition de proportionnalité. Cependant, la dimension politiquement délicate de la matière rend l'exercice particulièrement difficile. Au vu de cette complexité, du caractère politiquement sensible et des incohérences existant entre les différents régimes, il n'est pas surprenant de constater qu'il ait d'ores et déjà été plaidé en faveur d'une réforme plus globale du régime de participation des travailleurs[6357]. Cependant, une telle réforme de grande envergure est loin d'être indispensable à la mise en place d'un régime des scissions transfrontalières couvrant plus d'une société préexistante et il a été démontré que moyennant un certain nombre d'adaptations inspirées du régime des fusions transfrontalières, le régime consacré par la Directive Mobilité à l'égard des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante pourrait leur être adapté.

6356 Sur cette notion, voir *supra* n° 132.

6357 J. SCHMIDT, « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *op. cit.*, p. 285 et J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…*, *op. cit.*, p. 21. *Contra* : M. SELENT, *op. cit.*, p. 1176.

Conclusion sur la protection des autres *stakeholders* dans le cadre d'une scission transfrontalière

1156. Une compatibilité limitée. À l'instar des créanciers, tant les associés minoritaires que les travailleurs encourent du fait d'une scission transfrontalière un certain nombre de risques significatifs. À l'égard de ces deux catégories de *stakeholders*, la dimension transfrontalière de l'opération les expose à des risques additionnels justifiant une protection spécifique qui devra correspondre à un triple équilibre, à savoir (i) être suffisamment protectrice mais ne pas empêcher une société de réaliser une opération de restructuration potentiellement essentielle à sa survie, (ii) être suffisamment protectrice mais ne pas affaiblir excessivement la position des créanciers en raison de l'érosion du patrimoine des sociétés impliquées qui serait induite par les différents mécanismes de protection ou en retardant excessivement la réalisation de l'opération et (iii) être proportionnée à l'aune des exigences du « *Gebhard test* » pour que l'entrave à la liberté d'établissement des sociétés concernées engendrée par les mécanismes de protection puisse être justifiée. L'étude des moyens de protection développés par le législateur européen à la lumière tant du régime éprouvé des fusions transfrontalières qui a l'indéniable avantage de couvrir également les fusions impliquant plus d'une société existante que des régimes de protection consacrés par les législateurs belge, luxembourgeois, allemand et autrichien a permis d'aboutir à la conclusion que le régime de protection des associés minoritaires et celui de la participation des travailleurs consacré par le législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité sont, dans une très large mesure, compatibles avec les spécificités une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante. Une extension pure et simple du champ d'application de la Directive Mobilité n'en constitue pas pour autant une solution satisfaisante. En effet, un certain nombre de modifications s'imposent, même si pour ce qui est de la protection de la participation des travailleurs, s'il est certes vrai que le régime en place souffre d'un nombre assez important d'incohérences et d'insuffisances, on peut émettre des doutes quant à l'opportunité politique de réviser encore les dispositions à cet égard dans la mesure où la tendance semble être celle d'un renforcement général et excessif de leur protection que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'aidera certainement pas à endiguer. Lors de l'étape suivante du long processus de consécration de la mobilité transfrontalière des personnes morales au sein de l'Union européenne et qui verra, idéalement au plus tard en 2027[6358], la consécration d'un régime applicable aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, il serait dès lors vraisemblablement préférable de ne pas encore y envisager de réforme du régime de participation des travailleurs[6359].

6358 Art. 4, § 1er de la Directive Mobilité.

6359 Voir en ce sens à propos de la révision des dispositions de la Directive Sociétés relatives aux fusions transfrontalières préalablement à l'adoption de la Directive Mobilité : J. SCHMIDT, *Cross-border mergers and divisions…, op. cit.*, p. 21.

Conclusion de la deuxième partie

1157. Un régime de protection à améliorer. À ce stade de l'analyse, il est possible de tirer deux conclusions fondamentales. Tout d'abord, il serait erroné d'aborder la protection des différents *stakeholders* pris isolément dans la mesure où il y a une véritable interdépendance entre les régimes de protection des créanciers, des associés minoritaires et des travailleurs. En effet, l'efficacité du système défensif des créanciers dépend également de la proportionnalité des mécanismes de protection des associés minoritaires et des travailleurs qui ne peuvent ni entraîner une érosion financière excessive du fait de la scission, ni constituer un obstacle démesuré à la réalisation d'une opération importante pour le développement de l'entreprise économique sous-jacente dont pourrait dépendre le désintéressement ultime des créanciers. Inversement, il s'ensuit qu'un régime efficace de protection des créanciers devra nécessairement tenir compte également de l'impact des autres régimes de protection sur la situation des créanciers. Deuxièmement, s'il s'avère que le régime général prévu actuellement par le législateur européen dans la Directive Mobilité est majoritairement compatible avec les spécificités d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante et qu'il est d'ores et déjà possible de discerner ici et là certains indices que la Commission avait déjà à l'esprit une réforme plus ambitieuse en la matière, il n'en demeure pas moins que le régime est suboptimal. Tirant pleinement parti des insuffisances et des solutions identifiées lors de l'étude des différents enjeux de la protection de chaque catégorie de *stakeholder*, les modifications suivantes peuvent ainsi être suggérées à l'égard de la protection des associés et des créanciers[6360] :

Texte actuel de l'art. 160*decies* de la Directive Mobilité	Proposition de nouvel art. 160*decies* de la Directive Mobilité
Protection des associés	Protection des associés
1. Les États membres veillent à ce qu'au moins les associés d'une société scindée qui ont voté contre l'approbation du projet de scission transfrontalière aient le droit de céder leurs actions en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, à condition qu'à la suite de la scission transfrontalière, ils acquièrent des actions des sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d'un autre État membre que celui de la société scindée.	1. Les États membres veillent à ce qu'au moins les associés d'une société scindée qui ont voté contre l'approbation du projet de scission transfrontalière aient le droit de céder leurs actions détenues au jour de la publication du projet de scission conformément à l'article 160*octies* et qui sont destinées à être échangées contre des actions d'une société bénéficiaire régie par le droit d'un autre État membre que celui de la société scindée en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 8.
Les États membres peuvent également prévoir que d'autres associés de la société scindée bénéficient du droit visé au premier alinéa.	Les États membres peuvent également prévoir que d'autres associés de la société scindée exposés à un changement de *lex societatis* bénéficient du droit visé au premier alinéa.

[6360] Les dispositions relatives à la participation des travailleurs sont exclues de cette proposition car l'opportunité politique et la faisabilité d'un allègement de ce régime en 2027 sont improbables.

Les États membres peuvent exiger que l'opposition expresse au projet de scission transfrontalière, l'intention des associés d'exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l'assemblée générale visée à l'article 160*nonies*. Les États membres peuvent permettre que l'enregistrement de l'opposition au projet de scission transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d'un vote négatif.	Les États membres peuvent exiger que l'opposition expresse au projet de scission transfrontalière, l'intention des associés d'exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l'assemblée générale visée à l'article 160*nonies*. Les États membres peuvent permettre que l'enregistrement de l'opposition au projet de scission transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d'un vote négatif. Les États membres peuvent prévoir que la condition d'opposition expresse au projet de scission transfrontalière prévue au paragraphe 1 sera considérée comme remplie lorsque (i) un associé n'a pu comparaître à l'assemblée générale parce qu'il n'y a indûment pas été admis, (ii) l'assemblée générale n'a pas été convoquée correctement ou (iii) l'objet de l'assemblée n'a pas été annoncé correctement.
	2. Les États membres veillent à ce que les associés visés au paragraphe 1 puissent céder leurs participations en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée conformément au paragraphe 5 aux parties suivantes : (a) en priorité aux associés existants de la société scindée ; (b) à défaut, aux associés existants de la ou des sociétés bénéficiaires, s'il y en a ; (c) à défaut, à des tiers ; et (d) à défaut et obligatoirement dans ce dernier cas, à la société scindée.
	3. Les dispositions statutaires limitant la libre cessibilité des actions sont inopposables aux associés sortants ayant manifesté leur intention d'exercer leur droit de retrait et ce, pour toute la durée de validité de celui-ci conformément au paragraphe 4.

2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société scindée leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l'assemblée générale visée à l'article 160*nonies*. Les États membres veillent à ce que la société scindée fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique.	4. Le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société scindée leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions détenues au jour de la publication du projet de scission transfrontalière conformément à l'article 160*octies* commence le jour de cette publication et prendra fin le jour de l'assemblée générale visée à l'article 160*nonies*. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 160*nonies*, § 2, le délai prendra fin le jour de l'assemblée générale entérinant expressément les modalités visées à l'article 160*terdecies*. Les États membres veillent à ce que la société scindée fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique.
3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de scission transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d'effet de la scission transfrontalière conformément à l'article 160*octodecies*.	5. Les États membres fixent le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de scission transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d'effet de la scission transfrontalière conformément à l'article 160*octodecies* dans les hypothèses visées à l'article 160*decies*, § 2, points (a) à (c). Lorsque conformément à l'article 160*decies*, § 2, point (d), les actions de l'associé sortant sont acquises par la société scindée, les États membres peuvent fixer un délai de paiement plus long.
	6. Les États membres veillent à ce que la soulte en espèces puisse également être payée soit au moyen d'un paiement en nature moyennant l'accord exprès de l'associé minoritaire concerné, soit par le biais d'une compensation entre la créance détenue par l'associé minoritaire sortant à l'encontre de la société bénéficiaire du fait de l'exercice de ce droit de retrait et toute créance potentiellement détenue par la société bénéficiaire à la suite de la scission à l'encontre de l'associé en question.

4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n'a pas été fixée correctement ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l'autorité ou de l'organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire. Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société scindée qui ont fait part de leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.	7. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait irrévocablement part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions conformément au paragraphe 1 mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n'a pas été fixée correctement ait le droit de réclamer une réévaluation de cette soulte en espèces auprès de l'autorité ou de l'organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire, laquelle ne peut être supérieure à un mois à compter de la date d'exercice du droit de retrait. La soulte en espèces figurant dans le projet de scission sera présumée adéquate jusqu'à preuve contraire en cas de rapport d'expert positif et inversement en cas de rapport d'expert négatif. Une telle procédure n'aura pas d'effet suspensif sur la scission transfrontalière. Les États membres ne peuvent pas prévoir que la décision finale relative à la réévaluation de la soulte en espèces est valable pour tous les associés de la société scindée qui ont fait part de leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 4.
5. Les États membres veillent à ce que le droit de l'État membre d'une société scindée régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d'éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l'État membre de la société scindée.	8. Les États membres veillent à ce que le droit de l'État membre d'une société scindée régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 7 et à ce que la compétence exclusive pour régler d'éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l'État membre de la société scindée.

6. Les États membres veillent à ce que les associés de la société scindée qui n'ont pas eu ou n'ont pas exercé le droit de céder leurs actions, mais qui considèrent que le rapport d'échange des actions figurant dans le projet de scission transfrontalière est insuffisant, puissent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès de l'autorité ou l'organe compétent habilité par le droit de l'État membre de la société scindée, dans le respect des délais fixés par ce droit national et cette procédure n'empêche pas l'enregistrement de la scission transfrontalière. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, elle l'est également pour la société scindée.	9. Les États membres veillent à ce que (i) les associés de la société scindée qui auraient bénéficié du droit de céder leurs actions conformément au § 1, mais qui ont fait le choix de voter en faveur de l'opération et (ii) les associés de la société scindée et des sociétés bénéficiaires qui n'ont pas eu le droit de céder leurs actions, mais qui considèrent que le rapport d'échange des actions figurant dans le projet de scission transfrontalière est insuffisant, puissent contester ledit rapport et réclamer l'attribution additionnelle d'actions de la société issue de la scission concernée et, si nécessaire, d'une soulte en espèces supplémentaire. Cette procédure est intentée auprès de l'autorité ou l'organe compétent habilité par le droit de l'État membre auquel est soumise la société participant à la scission concernée, dans le respect des délais fixés par ce droit national et cette procédure n'empêche pas l'enregistrement de la scission transfrontalière. La décision est contraignante pour les sociétés issues de la scission transfrontalière et n'a d'effet qu'à l'égard des seuls associés l'ayant initiée.
7. Les États membres peuvent également prévoir que la société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée puissent offrir des actions ou une autre compensation au lieu d'une soulte en espèces.	10. Les États membres prévoient que la société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée offrent en priorité des actions ou une autre compensation au lieu d'une soulte en espèces.

Texte actuel de l'art. 160*undecies* de la Directive Mobilité	Proposition de nouvel art. 160*undecies* de la Directive Mobilité
Protection des créanciers	Protection des créanciers (disposition commune aux scissions internes et transfrontalières)
1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication.	1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers, autres que les porteurs de titres auxquels sont attachés des droits spéciaux visés à l'article 147, dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication.

Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière visées à l'article 160*quinquies*, point q), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de scission transfrontalière visée à l'article 160*octies*, saisir l'autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que lesdits créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu'ils n'ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes.	Les États membres veillent à tout le moins à ce que les créanciers, à l'exclusion de ceux qui disposent, en cas d'insolvabilité de leur société débitrice, d'un privilège découlant d'une disposition légale et couvert par une masse contrôlée par les autorités, qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière visées à l'article 160*quinquies*, point q), puissent, dès la publication du projet de scission transfrontalière visée à l'article 160*octies*, et au plus tard dans le mois suivant la date de l'assemblée générale visée à l'article 160*nonies*, étant entendu que s'il a été fait usage de la faculté prévue à l'article 160*nonies*, paragraphe 2, il conviendra de prendre en compte la date de la dernière assemblée générale, saisir l'autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates. L'octroi de telles garanties sera refusé si la société concernée parvient à démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière ne compromet pas le recouvrement de leurs créances ou que les créanciers en question ont déjà obtenu de la société des garanties satisfaisantes. Les États membres veillent à ce qu'une telle saisine émanant de la part d'un créancier n'ait pas pour effet de suspendre l'opération. Les États membres veillent à ce que les sociétés concernées puissent écarter toute demande d'un créancier, soit en payant ou en faisant payer par un tiers la dette litigieuse, même non encore échue, à sa valeur, après déduction de l'escompte, soit encore en consignant ou en faisant consigner par un tiers les sommes nécessaires pour ce faire auprès d'une banque.
Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d'effet de la scission transfrontalière conformément à l'article 160*octodecies*.	Les États membres veillent en outre à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d'effet de la scission transfrontalière conformément à l'article 160*octodecies*.

	2. Les créanciers des sociétés impliquées dans la scission sont présumés, jusqu'à preuve contraire, ne pas être lésés par l'opération si les conditions de l'une ou l'autre des deux exceptions suivantes sont remplies : a) lorsque les sociétés ont fait le choix de demander la nomination d'un ou de plusieurs experts indépendants en vue de l'établissement d'un rapport unique pour toutes les sociétés conformément à l'article 160*septies* et que ce rapport d'expert indépendant conclut qu'il découle de la situation patrimoniale et financière des sociétés impliquées que l'opération envisagée n'empêchera pas les sociétés bénéficiaires de faire face à leurs obligations envers les créanciers une fois celles-ci arrivées à échéance ; et b) lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement soit à l'encontre d'un garant tiers, soit à l'encontre d'au moins une des sociétés résultant de la scission transfrontalière d'une valeur au moins équivalente à leur créance initiale, qui relève de la même juridiction que leur créance initiale et qui est d'une qualité de crédit au moins comparable à la créance initiale du créancier immédiatement après la fin de l'opération tel que confirmé par un expert indépendant.
2. Lorsqu'un créancier de la société scindée n'obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d'une scission partielle ou d'une scission par séparation, la société scindée, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets attribués à cette société.	3. Lorsqu'un créancier de la société scindée n'obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, en ce compris la société scindée en cas de scission partielle, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d'une scission partielle ou d'une scission par séparation, la société scindée, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets attribués à cette société. Les États membres pourront toutefois ne pas appliquer cette limite dans l'hypothèse où la société débitrice principale deviendrait insolvable moins de six mois après la date de prise d'effet de la scission transfrontalière conformément à l'article 160*octodecies*. Les États membres peuvent en outre limiter cette solidarité dans le temps.

3. Les États membres peuvent exiger que l'organe d'administration ou de direction de la société scindée fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date de la déclaration qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l'organe d'administration ou de direction de la société scindée à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d'administration ou de direction n'a connaissance d'aucune raison pour laquelle toute société bénéficiaire et, en cas de scission partielle, la société scindée ne seraient, une fois que la scission aura pris effet, pas en mesure de s'acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées dans le cadre du projet de scission transfrontalière. La déclaration est publiée en même temps que le projet de scission transfrontalière, conformément à l'article 160*octies*.	4. L'organe d'administration ou de direction de la société scindée fournira une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date de la déclaration qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l'organe d'administration ou de direction de la société scindée à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d'administration ou de direction n'a connaissance d'aucune raison pour laquelle toute société bénéficiaire et, en cas de scission partielle, la société scindée ne seraient, une fois que la scission aura pris effet, pas en mesure de s'acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées dans le cadre du projet de scission transfrontalière. La déclaration est publiée en même temps que le projet de scission transfrontalière, conformément à l'article 160*octies*. Les États membres organisent un système de responsabilité adéquat des membres de l'organe d'administration ou de direction en cas d'insolvabilité survenant moins de trois mois après la date de prise d'effet de l'opération conformément à l'article 160*octodecies*.
	5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice ni d'autres arrangements négociés entre les créanciers et une des sociétés participant à la scission, ni d'autres mécanismes de protection existant en vertu du droit commun ou du droit de l'insolvabilité.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l'application du droit de l'État membre de la société issue de la scission transfrontalière en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.	6. Les paragraphes 1 à 5 sont sans préjudice de l'application du droit de l'État membre de la société issue de la scission transfrontalière en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.

Conclusion générale

1158. Position de la question. Bénéficiant d'un nouvel engouement dont l'arrêt *Polbud*, la Directive Mobilité et la récente initiative de l'*European Law Institue* visant à aboutir à un nouveau Règlement Rome IV sur le droit applicable aux sociétés[6361] ne constituent que des épiphénomènes, la mobilité transfrontalière des personnes morales demeure plus que jamais un sujet d'actualité. Il serait cependant erroné d'y voir la manifestation d'une volonté unanime de construction du marché intérieur où les frontières s'évaporeraient progressivement pour les sociétés. Au contraire, tant la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement que la lente et fragmentaire construction du droit européen de la mobilité transfrontalière illustrent parfaitement à quel point toute évolution dans ce domaine se retrouvera nécessairement tiraillée entre méfiance, voire protectionnisme, de certains États membres soucieux de l'impact d'une mobilité effrénée sur les différents *stakeholders* et, au contraire, bienveillance et libéralisme d'autres États membres qui espèrent en faire profiter leur économie nationale. C'est au cœur de cette dichotomie que s'inscrit la présente étude sur un mécanisme encore peu exploré de mobilité transfrontalière. Plus précisément, l'objet est de répondre à la question, d'apparence simple, de comment faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne tout en tenant compte des différents enjeux posés par ce type d'opération pour les *stakeholders*.

1159. Intérêt de la question. L'attention portée à cette question se justifie pleinement à la lumière de l'intérêt économique des scissions transfrontalières. Opérations de déconcentration parmi d'autres, ces dernières constituent un mécanisme particulièrement souple susceptible de s'insérer tant dans le cadre d'une stratégie défensive ayant pour objectif d'éviter une perte de valeur de l'entreprise, que dans le cadre d'une stratégie plus offensive visant à accroître la valeur de celle-ci. Ainsi, si une scission permet notamment à une entreprise de se recentrer sur son *core business* en corrigeant une erreur de jugement, en supprimant des synergies négatives ou encore, en procédant à une véritable réorientation stratégique dictée notamment par une récession économique ou par les résultats financiers décevants d'une branche d'activités en perte de vitesse, elle permet également de limiter les effets de la décote de diversification dont souffrent les conglomérats, de corriger une éventuelle asymétrie d'information existant entre les dirigeants de l'entreprise et le marché des capitaux externes ou encore de répondre aux besoins en capitaux d'une branche d'activités prometteuse ou du conglomérat en lui-même. De manière originale, une scission transfrontalière peut également servir de mesure de défense anti-OPA ou encore remplir certains objectifs purement juridiques tels que l'adaptation aux exigences du droit de la concurrence, l'obtention d'un régime fiscal ou réglementaire plus avantageux ou encore la limitation du risque de responsabilité civile engendré par certaines activités. Il ressort également de l'analyse économique des scissions que si l'augmentation de la valeur de l'entreprise pour les associés (*shareholder value*) est au centre de la décision, l'opération ne se fera pas nécessairement au détriment des

[6361] Pour une description détaillée de cette initiative, voir : https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibility-studies-and-other-activities/feasibility-studies/eu-laws-for-companies/ (09/10/2020).

autres *stakeholders* et pourra même s'avérer bénéfique à leur égard, pour peu qu'elle prenne adéquatement en compte les intérêts de ces autres parties intéressées. Bien que susceptibles d'être particulièrement avantageuses, les scissions n'en sont pas pour autant infaillibles. Ainsi, la ou les sociétés issues de l'opération peuvent s'avérer être trop petites et souffrir par conséquent d'une décote de liquidité ou, au contraire, être davantage exposées aux risques d'une offre publique d'acquisition hostile. Une scission risque également de rendre les entités qui en sont issues moins attrayantes pour les investisseurs dans la mesure où leurs activités sont généralement moins diversifiées. Cependant, les principaux inconvénients d'une scission demeurent la complexité de sa mise en œuvre et la durée de sa préparation. Un régime efficace des scissions transfrontalières devra par conséquent (i) d'une part ne pas négliger les intérêts des *stakeholders* tout en privilégiant les opérations bénéfiques tant aux associés majoritaires qu'aux créanciers, aux associés minoritaires et aux travailleurs et (ii) d'autre part, réduire au strict nécessaire les coûts, la durée et la complexité d'une telle opération.

1160. Précision du sujet d'étude. Or, la mise en place d'un tel régime nécessite en premier lieu de définir avec précision l'opération elle-même. De nature juridique polymorphe, une scission peut être analysée comme une opération de restructuration pouvant revêtir tantôt la forme d'un contrat *sui generis*, tantôt la forme d'un acte juridique unilatéral et se caractérisant en principe par (i) une dissolution atypique ne s'accompagnant pas d'une liquidation, celle-ci étant toutefois absente dans les cas de la scission partielle et de la scission par séparation, (ii) une transmission à titre universel des fractions du patrimoine de la société scindée aux sociétés bénéficiaires, (iii) l'attribution, symétrique ou non, d'actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée, ou à la société scindée elle-même dans le cas particulier de la scission par séparation, avec ou sans soulte en espèces supplémentaire, sauf dans l'hypothèse d'une scission silencieuse et (iv) un élément d'extranéité bien déterminé.

1161. L'incidence des libertés fondamentales. Si elle est certes utile en ce qu'elle permet de délimiter avec une certaine précision la scission des autres opérations de restructuration, cette vaste définition n'en permet pas pour autant de faire des scissions une réalité concrète. Elle permet en revanche de les examiner sous l'angle particulier de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux et ce, afin d'isoler certains enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière qui permettent de jeter les fondations d'un régime européen des scissions transfrontalières. Ainsi, l'étude des enseignements de la Cour de justice à l'égard des fusions transfrontalières, des transferts de siège et des transformations transfrontalières permet d'établir notamment que les scissions transfrontalières constituent des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement »[6362]. En conséquence, les principes d'équivalence et d'effectivité impliquent que tant l'État membre d'origine que les États membres d'accueil, pour peu qu'ils connaissent la figure de la scission en droit interne, ne peuvent traiter les scissions transfrontalières moins favorablement que les opérations internes, ni les rendre impossibles en

[6362] Arrêt *Sevic*, pt. 19.

pratique ou excessivement difficiles par le biais de leur législation nationale. En outre, une entrave à la liberté d'établissement ne pourra être admise que si elle remplit les conditions du « *Gebhard test* ». À cet égard, la lutte contre le recours abusif à la liberté d'établissement, la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux ou de la loyauté des transactions commerciales et la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires, des salariés ou encore du fisc constituent des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une entrave. Il est ainsi possible d'en inférer que la règle de conflit de lois applicable aux scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés devra entraîner l'application du droit de l'État membre de la société scindée pour la partie de la procédure jusqu'à l'émission du certificat de conformité, alors que le reste de la procédure devra en principe être régie par le droit des États membres des nouvelles sociétés. En outre, il en découle également que l'adoption d'une norme de droit dérivé régissant spécifiquement les scissions transfrontalières ne peut justifier un refus de la part des États membres de reconnaître ce type d'opérations s'ils reconnaissent les scissions internes. Malgré ces précieux enseignements, les cinq limites inhérentes aux avancées prétoriennes en matière de liberté d'établissement que sont (i) l'insécurité juridique liée à l'absence de décision portant spécifiquement sur une scission transfrontalière, (ii) l'inexistence d'un régime clair offrant un niveau de sécurité juridique suffisant, (iii) le fait que la Cour de justice n'ait en essence posé qu'un principe de non-discrimination dont l'application est conditionnée par la reconnaissance des scissions dans l'ordre interne alors que la Directive Sociétés n'a pas imposé la reconnaissance des scissions nationales, (iv) l'incertitude tout d'abord quant à la compatibilité de certaines entraves indispensables à la protection des *stakeholders* avec la liberté d'établissement et ensuite quant à la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection renforcés en raison de la nature transfrontalière de l'opération et (v) la réticence des États membres à reconnaître spontanément les avancées de la Cour de justice en matière de mobilité transfrontalière, viennent sensiblement restreindre leur portée. Le constat n'est pas plus encourageant à l'égard de la libre circulation des capitaux car si cette dernière est effectivement en mesure de trouver à s'appliquer aux scissions transfrontalières, l'étude des limites inhérentes à cette autre liberté fondamentale tant dans un contexte purement européen que dans une situation impliquant également des États tiers est venue démontrer que celle-ci ne présente aucun intérêt pratique pour les scissions transfrontalières. Il en découle que l'harmonisation négative opérée par la Cour de justice par le biais de sa jurisprudence en matière de liberté d'établissement n'est pas, à elle seule, en mesure de faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne, mais doit nécessairement s'accompagner de normes de droit positif adoptées soit par les différents législateurs nationaux et articulées au moyen de règles de droit international privé, soit au moyen d'une norme de droit dérivé adoptée par le législateur européen.

1162. Théories de droit international privé et initiatives nationales. Pour ce qui est de la première méthode, l'étude des différentes théories de droit international privé développées en matière de scissions transfrontalières permet d'établir que ces dernières montrent rapidement leurs limites. Il est cependant clair que la forte proximité entre les fusions et les scissions implique que

la procédure de scission transfrontalière devra nécessairement s'inspirer très largement du régime applicable aux fusions transfrontalières, tout en respectant les spécificités d'une scission qui, à l'opposé d'une fusion, se caractérise fondamentalement par une pluralité de sociétés bénéficiaires et une unicité de société apporteuse. Cependant, pour ce faire, et si les scissions transfrontalières doivent effectivement être régies en s'inspirant du régime applicable aux fusions transfrontalières, il conviendra au préalable de rendre leur reconnaissance par les États membres obligatoire dans un contexte purement interne afin de pouvoir en toute quiétude articuler le régime des scissions transfrontalières autour du principe de l'application subsidiaire du régime applicable aux scissions internes. De plus, il n'est pas envisageable de s'en remettre exclusivement aux législateurs nationaux en la matière en raison du fait que d'une part, les approches nationales à l'égard des scissions transfrontalières risquent de diverger sensiblement d'un État membre à un autre et de générer des frictions, ce qui a pu être établi à suffisance par l'étude des régimes belge et luxembourgeois et d'autre part, que certains États membres plus protectionnistes et moins bienveillants à l'égard de la mobilité transfrontalière ne manqueraient pas de s'abstenir purement et simplement d'introduire un quelconque régime.

1163. *Company law package* et nécessité d'une nouvelle initiative européenne. Compte tenu de ces insuffisances, c'est en toute logique que le législateur européen a procédé à l'adoption de la Directive Mobilité qui introduit pour la première fois une procédure de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés au sein de l'Union européenne. Si cette dernière constitue certes une avancée significative vers la consécration d'un régime européen des scissions transfrontalières, elle n'en est pas pour autant exempte d'inconvénients et souffre de quatre insuffisances majeures impliquant que la délicate question de la concrétisation des scissions transfrontalières au sein de l'Union européenne est loin d'avoir été close. Ainsi (i) l'absence d'harmonisation préalable du régime des scissions internes et les incohérences générales qui en découlent, (ii) un champ d'application *ratione personae* limité aux sociétés de capitaux et privant certaines sociétés en situation précaire d'un mécanisme d'assainissement potentiellement efficace et un champ d'application *ratione materiae* excluant toutes les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, (iii) une vague disposition anti-abus certes compréhensible dans son principe, mais risquant d'aboutir aisément à des pratiques divergentes et possiblement abusives de la part d'États membres plus protectionnistes et dont la conformité à la liberté d'établissement laisse sceptique et (iv) des différences de traitement injustifiées entre les fusions et les scissions transfrontalières, au désavantage de ces dernières, laissent présager de beaux jours pour le rôle de la Cour de justice dans le cadre de la concrétisation prétorienne de la liberté d'établissement. Ces insuffisances, combinées (i) aux enseignements des fusions transfrontalières dont l'exemple permet d'établir qu'un niveau de sécurité juridique élevé issu d'une directive et permettant de limiter significativement les coûts habituellement liés à ce type d'opération tout en réduisant le délai nécessaire pour les réaliser agit comme catalyseur des opérations transfrontalières, (ii) à l'inadéquation des méthodes dérivées pour aboutir à un résultat identique à celui d'une scission par acquisition, (iii) à l'effet dissuasif de l'insécurité juridique persistante dont

sont affectées les scissions tombant hors du champ d'application de la Directive Mobilité et (iv) à la nécessité de protéger les *stakeholders* de manière adéquate dans le cadre des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante dans la mesure où ces dernières sont, en essence, potentiellement plus dommageables à leur égard que les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, rendent une nouvelle intervention du législateur européen en matière de scissions transfrontalières inéluctable. L'attitude de la Commission dans le cadre de la Directive Mobilité ne peut dès lors que laisser perplexe car elle n'est, *a priori*, pas conciliable avec le choix fait par celle-ci de ne réglementer que les scissions transfrontalières n'impliquant qu'une seule société préexistante. Une explication possible est que celle-ci a préféré limiter sa première initiative législative aux catégories de scission les moins susceptibles de générer d'appréhension des États membres plus frileux à l'égard de la mobilité transfrontalière des sociétés et ce, en vue d'établir qu'une scission transfrontalière est une opération de restructuration économiquement importante qui doit nécessairement figurer au sein de l'arsenal des acteurs économiques du marché intérieur en misant sur une hausse conséquente de ces opérations suite à la transposition nationale de la Directive Mobilité. Il s'ensuit qu'une nouvelle initiative européenne en la matière est inéluctable et que cette dernière revêtira nécessairement la forme d'une directive dans la mesure où (i) l'art. 50 du TFUE impose cette forme pour supprimer progressivement les restrictions à la liberté d'établissement et pour assurer une protection efficace des *stakeholders* dans ce cadre, (ii) nombre de procédures de restructuration sont déjà réglementées dans une directive de sorte que, par souci de cohérence et de cohésion du droit des sociétés européen, ce choix s'impose naturellement et (iii) le processus législatif éclair de la Directive Mobilité a démontré à suffisance l'acceptabilité politique du fait de procéder par le biais de cette mesure législative en vue d'encadrer et de renforcer la mobilité transfrontalière des personnes morales au sein de l'Union européenne. Cependant, les insuffisances intrinsèques d'une directive telles que (i) la nécessité d'aboutir à un compromis politique laissant malgré tout une certaine marge de manœuvre aux législateurs nationaux et (ii) une complexité excessive de la matière due à tout le moins en partie à l'impératif de préserver certains particularismes nationaux font que l'harmonisation négative par la Cour de justice au moyen de sa jurisprudence en matière de liberté d'établissement demeurera nécessaire, tout comme une modification du Règlement sur la Société européenne et du Règlement sur la Société Coopérative européenne qui n'envisagent pas encore la constitution de ces formes sociales atypiques par le biais d'une scission transfrontalière.

1164. Un régime européen des scissions transfrontalières. L'attitude ambiguë et restrictive du législateur européen à l'égard des scissions transfrontalières soulève certaines interrogations et on ne peut que se demander si, dès l'origine, la Commission européenne, pressentant les réticences de certains États membres, n'a pas fait le choix stratégique de procéder en deux étapes successives pour faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne. En d'autres termes, il est tout à fait possible que dans l'esprit de la Commission, la nécessité de procéder à l'harmonisation des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante n'ait jamais fait l'ombre d'un doute, mais que le meilleur moyen qui lui soit apparu pour surmonter la

frilosité de certains États membres et tenir compte du scepticisme des syndicats à leur égard ait été de procéder d'abord par le biais d'une harmonisation asymétrique tout en habituant en même temps les États membres aux scissions par constitution de nouvelles sociétés, en essence moins litigieuses, par le biais d'une adaptation de la procédure des fusions transfrontalières à laquelle ils sont coutumiers. Sur cette base, il est dès lors intéressant de se pencher sur le régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés mis en place par le législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité pour déterminer dans quelle mesure celui-ci est également compatible avec les scissions transfrontalières mixtes et par acquisition tout en identifiant les indices étayant le fait que la Directive Mobilité n'est qu'une étape préliminaire à une initiative de plus grande envergure et en tentant de résoudre les éventuelles incompatibilités en tirant pleinement parti du régime des scissions transfrontalières que l'on retrouve en droit belge et en droit luxembourgeois, ainsi que d'éléments de comparaison avec les droits allemand, autrichien, français et italien. Cette analyse détaillée du modèle général européen pour les restructurations constitué de sept étapes distinctes, à savoir (i) le projet commun de scission, (ii) le ou les rapport(s) de l'organe de gestion ou d'administration, (iii) le rapport d'expert, (iv) les mesures de publicité, (v) l'approbation de l'assemblée générale, (vi) le double contrôle de légalité et (vii) l'immatriculation et la prise d'effet et sur lequel le régime des scissions par constitution de nouvelles sociétés consacré par le législateur européen dans la Directive Mobilité repose, a permis de démontrer que celui-ci était également compatible dans son principe avec les spécificités d'une scission transfrontalière par acquisition ou mixte. Cependant, il serait erroné d'en conclure qu'une simple extension du champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité suffirait à faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne et l'analyse a permis de mettre en lumière la nécessité de procéder à un nombre significatif de modifications dont (i) l'intégration d'une règle relative à la langue du projet commun, (ii) la nécessité d'harmoniser la question de la date de prise d'effet comptable, (iii) l'ajout de l'obligation d'expliquer la répartition des actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée dans le rapport de l'organe de direction ou d'administration, (iv) l'introduction de la possibilité d'établir un rapport de l'organe de direction ou d'administration commun à toutes les sociétés impliquées, (v) la nécessité de prévoir une procédure de désignation d'un expert commun ainsi que la possibilité d'établir un rapport unique pour toutes les sociétés impliquées dans l'opération de scission, (vi) l'attribution de la charge du contrôle de légalité à l'autorité nationale compétente de l'État membre de la société scindée et (vii) la mise en place d'un régime simplifié prévoyant une dispense de l'assemblée générale de la société absorbée en cas de scission d'une filiale commune ne sont que quelques illustrations[6363]. Ce constat renforce encore le caractère inéluctable d'une nouvelle intervention du législateur européen à l'égard des scissions transfrontalières.

[6363] Pour une liste détaillée des différents aspects du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés nécessitant d'être modifiés en vue de faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne, voir Annexe 5.

1165. Une réforme latente. Au-delà de la démonstration de la compatibilité de principe du modèle européen des opérations transfrontalières et de l'identification des aspects de la procédure nécessitant encore une adaptation aux spécificités d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante, l'analyse détaillée du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés consacré par la Directive Mobilité permet également de mettre en évidence un nombre significatif d'indices de l'habileté politique de la Commission étayant la thèse que cette dernière n'entendait pas seulement harmoniser les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés, mais aspirait également à préparer le terrain à une réforme plus ambitieuse du régime des scissions[6364]. Il en va ainsi notamment (i) de la règle relative à la langue du projet de scission qui figurait à l'origine dans la Proposition de la Commission, (ii) de l'obligation d'indiquer dans le projet de scission la date à partir de laquelle les actions des sociétés bénéficiaires attribuées au cours de l'opération donnent le droit de participer aux bénéfices ou encore (iii) de la possibilité de prévoir des dates de prise d'effet comptable rétroactives. En outre, plus fondamentalement, la Commission n'a pu ignorer le fait que la décision d'une autorité nationale compétente de refuser d'émettre le certificat de conformité dans le cadre d'une scission transfrontalière par absorption au motif que ce type d'opération ne rentrait pas dans le champ d'application de la disposition nationale ayant transposé la Directive Mobilité violait le principe de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes posé dès l'arrêt *Sevic* par la Cour de justice. Il s'ensuit qu'une extension du régime actuel aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante lors de la révision de la Directive Mobilité au plus tard en 2027 serait parfaitement justifiable.

1166. Un spectre élargi. Si, du point de vue des sociétés impliquées, les fondations de la reconnaissance des scissions transfrontalières semblent déjà creusées, il serait erroné d'arrêter là l'analyse. En effet, loin de ne concerner que les seules sociétés et leurs associés majoritaires, une scission transfrontalière est également susceptible d'impacter significativement la situation des autres *stakeholders* et principalement les créanciers, les associés minoritaires et les travailleurs. Il est dès lors indispensable d'élargir le champ de l'analyse de manière à prendre en compte de manière adéquate les enjeux d'une scission transfrontalière pour ces différentes parties prenantes dans la mesure où la concrétisation des scissions transfrontalières au sein de l'Union européenne n'est pas concevable sans la mise en place d'un régime de protection adéquat de leurs intérêts. Pour progresser davantage dans la quête d'une réponse à la question de recherche, il convient dès lors (i) d'analyser dans quelle mesure les mécanismes de protection consacrés par le législateur européen dans la Directive Mobilité seraient compatibles avec les spécificités d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante et (ii) d'identifier la meilleure manière de remédier aux éventuelles insuffisances de ces derniers. La méthode utilisée, bien que requérant systématiquement certaines adaptations

[6364] Pour une liste détaillée des différents aspects du régime des scissions transfrontalières laissant présager que la Commission avait, dès l'origine, l'intention de procéder en deux étapes pour faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne, voir Annexe 4.

liées aux spécificités de chaque catégorie de *stakeholders*, s'articule autour de trois pôles, à savoir (i) l'identification des enjeux d'une scission transfrontalière pour chaque catégorie de *stakeholder*, (ii) l'examen de la manière dont il a été répondu à ces différents enjeux par le législateur européen dans la Directive Mobilité et (iii) la détermination des modifications qui s'avèrent nécessaires en vue de faire de tout type de scission une réalité au sein de l'Union européenne tout en ne sacrifiant pas les intérêts des autres parties prenantes et ce, en ne perdant pas de vue l'incidence de la liberté d'établissement sur la matière. Cette dernière implique que tout mécanisme de protection devra nécessairement respecter tant le principe d'équivalence que le principe d'effectivité et toute entrave à la liberté d'établissement générée par la mise en place de mécanismes spécifiques de protection devra nécessairement respecter les conditions du « *Gebhard test* ».

1167. Enjeux et balises d'un régime efficace de protection des créanciers en cas de scission transfrontalière. Catégorie foncièrement hétérogène de *stakeholder*, les créanciers d'une société impliquée dans une procédure de scission transfrontalière sont susceptibles d'encourir jusqu'à six risques distincts du fait de l'opération. Parmi ceux-ci, le double risque lié à la transmission à titre universel du patrimoine de la société scindée, le risque lié à la nature transfrontalière de l'opération ainsi que le risque lié à l'allocation des fractions du patrimoine de la société scindée librement décidée par les associés touchent soit exclusivement, soit principalement, les créanciers des sociétés absorbées. Si on ajoute à cela qu'une harmonisation des mécanismes de protection au niveau européen est de loin préférable en vue tant de renforcer la sécurité juridique des scissions transfrontalières que d'en réduire les coûts qui y sont associés, le premier enjeu d'un régime efficace de protection des intérêts des créanciers en cas de scission transfrontalière sera d'être suffisamment flexible que pour s'adapter efficacement aux risques variables encourus par les différents créanciers impactés par l'opération. Le deuxième enjeu sera d'élaborer une stratégie défensive parvenant à instituer un délicat équilibre entre les intérêts des créanciers à ne pas se voir spoliés et ceux de la société et de ses associés majoritaires à réaliser une opération potentiellement essentielle à la survie économique de l'entreprise. Le troisième enjeu sera d'intégrer correctement les enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement (i) en mettant l'accent sur la vigilance et la responsabilisation des créanciers, (ii) en examinant dans quelle mesure le cadre juridique général de protection des créanciers, composé entre autres du Règlement sur l'Insolvabilité, relativise la nécessité de prévoir des mécanismes de protection spécifiques aux scissions transfrontalières, (iii) en considérant qu'une exclusion générale des scissions transfrontalières ou une obligation de liquidation de la société scindée en vue de protéger les intérêts des créanciers ne constitueraient pas des mesures proportionnées justifiant l'entrave à la liberté d'établissement ainsi générée et (iv) en gardant à l'esprit que la possibilité de demander des garanties adéquates constitue le mécanisme de protection privilégié par la Cour de justice en raison de sa proportionnalité. En outre, l'analyse tant du régime des fusions transfrontalières avant l'entrée en vigueur de la Directive Mobilité à l'aune des enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *KA Finanz* que du nouveau régime instauré par la Directive

Mobilité plaident contre un renforcement des mécanismes de protection des créanciers en raison de la seule nature transfrontalière de l'opération. Si cette conclusion n'est que partiellement confortée par l'examen de la position tant du législateur luxembourgeois que du législateur belge et même s'il est indéniable que la Cour de justice se montrerait très réservée à l'égard de la conformité à la liberté d'établissement d'une telle violation du principe d'équivalence, il est impossible de conclure *ab initio* à l'impossibilité de justifier l'entrave qui en résulterait. En revanche, l'argument selon lequel une protection accrue des créanciers soumis à un changement de *lex societatis* se justifiait en raison des difficultés procédurales auxquelles ceux-ci seraient confrontés en cas de scission transfrontalière a pu être réfuté et il a été établi qu'une scission transfrontalière était sans incidence sur le droit applicable au contrat conclu entre un créancier et la société scindée. De plus, l'argument selon lequel une protection renforcée se justifierait en raison du caractère moins protecteur du droit national applicable aux sociétés bénéficiaires par rapport à celui de la société scindée a été battu en brèche en raison, d'une part, de l'harmonisation partielle des différents droits des sociétés nationaux par le législateur européen et, d'autre part, en raison de son caractère beaucoup trop simpliste. Il en découle qu'un régime efficace de protection des intérêts des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière devra nécessairement largement s'inspirer du régime applicable aux opérations internes et que le seul caractère transfrontalier de l'opération ne justifie pas qu'on fasse pencher la balance en faveur des intérêts des créanciers. Cependant, les créanciers de la société scindée nécessiteront une attention particulière en contrepartie de la grande liberté dont jouissent les associés au niveau de la répartition des éléments du patrimoine actif et passif de la société scindée combinée à la substitution de débiteur qui leur est imposée sans leur consentement.

1168. Les contours de la protection des créanciers en cas de scission transfrontalière. L'étude détaillée des différents mécanismes de protection individuels et institutionnels mis en place tant par le législateur européen – comme l'obligation d'information des créanciers, la déclaration de l'organe de direction ou d'administration, la possibilité de demander une garantie adéquate, la solidarité passive des sociétés bénéficiaires de la scission ou encore la compétence des juridictions de l'État membre de la société scindée – que par les différents législateurs nationaux – comme l'action paulienne, un éventuel droit de veto, le contrôle préalable par une autorité nationale, le droit d'opposition optionnel du droit français, la théorie de l'imprévision, la gestion séparée des patrimoines ou encore la responsabilité solidaire des membres de l'organe de gestion de la société scindée – montrent tous certaines insuffisances et se révèlent incapables, pris isolément, de remplir adéquatement les enjeux identifiés au préalable. Il en va de même des mécanismes de protection conventionnels permettant aux créanciers tantôt de mettre fin à la relation contractuelle, comme les clauses d'intransmissibilité, d'*intuitu personae*, d'exigibilité immédiate et d'agrément, tantôt simplement d'aménager les conséquences de l'opération sur la relation contractuelle préexistante telles que la clause attributive de juridiction et la clause de *hardship*. Il en découle qu'une protection efficace des intérêts des créanciers (autres que les associés, les travailleurs et les titulaires de titres autres que des actions auxquels sont attachés des droits spéciaux)

en cas de scission transfrontalière doit nécessairement s'articuler autour d'une défense en profondeur composée de quatre lignes de défense successives graduellement plus intrusives du point de vue de la liberté d'établissement :

- La première ligne de défense sera celle des mécanismes contractuels. L'étude de ces derniers a en effet démontré qu'ils présentaient à la fois une grande souplesse permettant de les adapter à des situations très précises et une efficacité significative pour les créanciers vigilants en mesure de les imposer. Afin de garantir leur efficacité, il conviendra toutefois de mettre également en place un mécanisme de protection institutionnel par le biais d'obligations d'information étendues. En effet, ces dernières permettront aux créanciers de réagir en temps utile et, le cas échéant, de se prévaloir de leurs prérogatives contractuelles avant que l'opération n'ait pris effet. Cependant, cette première ligne de défense est loin d'être suffisante pour garantir une protection adéquate des intérêts des créanciers en ce qu'elle ne profite qu'aux seuls créanciers vigilants ayant connaissance de leur créance, à même d'apprécier l'impact d'une opération transfrontalière sur la capacité de remboursement de leur société débitrice et jouissant d'une force de négociation suffisante envers la société débitrice leur permettant d'adapter les conditions de leur créance.
- La deuxième ligne de défense, qui sera également la ligne de résistance principale, s'articulera autour du mécanisme de protection individuel que constitue la possibilité de demander des garanties adéquates. Ce mécanisme, prôné tant par les législateurs nationaux et européens que par la Cour de justice et permettant aux créanciers d'obtenir des garanties additionnelles s'ils parviennent à démontrer, de manière crédible, que l'opération compromet le recouvrement de leur créance et qu'ils ne disposent pas encore de garanties satisfaisantes, permet de sauvegarder efficacement les intérêts des créanciers tout en respectant l'équilibre des intérêts en présence et la condition de proportionnalité du « *Gebhard test* », pour peu qu'il ne soit pas assorti d'un effet suspensif. Ce mécanisme spécifique, qui interviendra *ex ante* pour une durée de trois mois à compter de la publication du projet commun, tout en étant dénué d'effet suspensif, devra nécessairement faire preuve d'une certaine élasticité par le biais de deux présomptions simples que l'opération ne lèse pas les créanciers, à savoir (i) en présence d'un rapport d'expert concluant et (ii) en cas d'octroi d'un droit de paiement de qualité équivalente et ce, pour éviter le dommage collatéral que constituerait la prohibition d'une opération potentiellement mutuellement profitable ou inoffensive. Les flancs seront gardés par des mécanismes plus généraux du droit des obligations au nombre desquels on comptera en premier lieu l'action paulienne qui présente l'indéniable avantage de bénéficier de délais de prescription beaucoup plus longs et de permettre à un créancier d'agir dans un nombre important de cas devant les juridictions de l'État membre de la société scindée et d'éviter ainsi l'aléa lié à l'obligation d'agir devant des juridictions étrangères soumises à des règles procédurales différentes ou potentiellement moins favorables au demandeur. En outre, l'action paulienne, tout en étant largement représentée

au sein des États membres, (i) jouit d'une certaine flexibilité en ce que le tiers concerné peut se prévaloir du bénéfice de discussion ou écarter l'action paulienne intentée par un créancier en payant tout simplement ce dernier, (ii) permet d'éluder tout concours avec les créanciers du tiers complice et (iii) peut être intentée à l'encontre d'un tiers sous-acquéreur en cas de scissions successives. Au niveau des flancs, on retrouvera également l'octroi d'un droit à résiliation unilatérale sur la base de la théorie de l'imprévision qui pourrait présenter une utilité non négligeable lorsqu'il s'avère que la protection par le biais de l'octroi d'une garantie adéquate n'est pas suffisante pour protéger un créancier. Cette ligne de défense est, tout comme la première, insuffisante en ce qu'elle s'adresse en priorité aux créanciers vigilants, ayant connaissance de leur créance et disposant de suffisamment de moyens pour protéger leurs droits. En outre, tant l'action paulienne que la théorie de l'imprévision présentent des conditions qui ne sont pas aisées à remplir et qui les réservent à des situations plus exceptionnelles.

- Une troisième ligne de défense articulée autour de la solidarité passive des sociétés bénéficiaires pour les dettes de la société scindée limitée à l'actif net transféré devra être mise en place. Ce mécanisme institutionnel par excellence permet de surmonter les obstacles de l'apathie rationnelle et de l'asymétrie d'information existant entre les créanciers et les sociétés concernées. En outre, il est à même tant de protéger efficacement les créanciers involontaires ou ceux ignorant encore l'existence de leur créance au moment de la réalisation de l'opération que de compenser la liberté dont jouissent les associés au niveau de la répartition du patrimoine de la société scindée entre les sociétés bénéficiaires. Cette solidarité ne pourra toutefois intervenir qu'en cas de défaut de la société à laquelle la créance a été transférée et devra également, en cas de scission partielle, profiter aux créanciers de la société scindée dont la créance est restée dans le patrimoine de la société scindée.
- L'ultime ligne de défense, qui n'entrera en jeu que si les trois premières lignes ont été percées, tirera pleinement parti de l'interdépendance fonctionnelle existant entre le droit des sociétés et le droit de l'insolvabilité et sera composée de mécanismes relevant du droit de l'insolvabilité. Cette dernière ligne de résistance sera caractérisée par une rupture de l'équilibre en faveur des créanciers ainsi que par un caractère particulièrement intrusif du point de vue de la liberté d'établissement tirant pleinement parti tant de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt *Kornhaas* que des garde-fous déployés par le Règlement Insolvabilité.

Cette stratégie défensive ne devra toutefois pas faire l'objet d'une mise en place uniforme par le biais d'une harmonisation exhaustive mais requerra une certaine flexibilité pour s'adapter aux terrains forts différents que constituent les régimes généraux de protection des créanciers des États membres et au fait que les mécanismes les composant transcendent le seul droit des sociétés et impliquent d'autres branches du droit encore faiblement harmonisées. L'étude des différentes possibilités d'harmonisation a en effet permis d'établir qu'une harmonisation avancée de la protection des créanciers identique en cas de scission interne et de scission transfrontalière, combinée à la possibilité

pour les États membres de la compléter par des mesures spécifiques était la solution idéale.

1169. Les enjeux de la protection des associés minoritaires. Bien que moins saillante *a priori* que la question de la protection des créanciers, la question de la protection des intérêts des associés minoritaires dans le cadre d'une scission transfrontalière n'en revêt pas moins une certaine importance et impose de répondre de manière adéquate à pas moins de quatre enjeux différents. En effet, une scission transfrontalière engendre jusqu'à cinq risques distincts pour les associés minoritaires dont trois (le risque lié à un rapport d'échange inadéquat, le risque de se faire imposer une opération par les majoritaires et le risque d'échec économique) sont communs aux associés de la société scindée et de la société bénéficiaire et deux (le risque lié aux scissions asymétriques et le risque lié à la nature transfrontalière de l'opération) sont propres aux associés de la société scindée. Le premier enjeu d'un régime efficace de protection des intérêts des associés minoritaires est par conséquent de répondre de manière adéquate à ces risques afin d'éviter un impact négatif sur l'accès des sociétés aux capitaux. Le deuxième enjeu est d'aboutir à un double équilibre. En premier lieu, un régime efficace de protection des intérêts des associés minoritaires ne doit ni permettre aux associés majoritaires d'exproprier abusivement les associés minoritaires, ni constituer un obstacle trop important à la réalisation d'une opération économiquement indispensable à la continuation de l'entreprise. En deuxième lieu, il ne doit ni entraîner une érosion excessive du patrimoine ou des liquidités de la société concernée qui pourrait se révéler potentiellement dommageable pour les créanciers, ni indûment sacrifier les intérêts des associés minoritaires susceptibles de se voir imposer une opération transfrontalière contre leur gré. Le troisième enjeu sera de ne pas négliger le fait que tout mécanisme de protection constituera également une entrave à la liberté d'établissement des sociétés concernées et devra, par conséquent, respecter les conditions du « *Gebhard test* ». Le quatrième et dernier enjeu sera de tenir compte du fait que contrairement aux créanciers, les associés minoritaires encourent un risque significatif additionnel du fait de la nature transfrontalière de l'opération dans la mesure où elle entraîne un changement de la *lex societatis* qui leur est applicable.

1170. Les contours de la protection des associés minoritaires en cas d'opération transfrontalière. L'analyse des mécanismes de protection des associés minoritaires instaurés par le législateur européen à travers le double prisme de la liberté d'établissement et de la protection des intérêts des créanciers tout en les comparant aux mécanismes de deux juridictions moins protectrices des intérêts des associés minoritaires en matière de mobilité, à savoir la Belgique et le Luxembourg, et de deux juridictions disposant des régimes parmi les plus élaborés en la matière, à savoir l'Allemagne et l'Autriche, a permis d'aboutir à la conclusion que le régime prôné par le législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité demeurait relativement proportionné et allait même, dans une certaine mesure, dans le sens d'un renforcement de la mobilité transfrontalière. Pour ce qui est plus spécifiquement des mécanismes de protection des intérêts des associés minoritaires, l'exigence d'unanimité au sein de l'assemblée générale de la société scindée, bien que fréquemment mise en place par les législateurs nationaux en cas de scission asymétrique, se doit d'être

rejetée non seulement en raison de son caractère particulièrement intrusif du point de vue de la liberté d'établissement, mais également en raison du fait que l'octroi d'un tel droit de veto risque de sacrifier l'intérêt des créanciers de la société scindée à voir une opération économiquement rentable être réalisée. L'octroi d'un droit de retrait aux associés minoritaires constitue une mesure plus proportionnée à l'aune des conditions du « *Gebhard test* », mais elle demeure affectée de cinq désavantages significatifs, à savoir (i) un impact sur les liquidités des sociétés concernées, (ii) une érosion du patrimoine des sociétés concernées, (iii) des problèmes d'évaluation de la soulte en espèces, (iv) un potentiel usage abusif et (v) une insécurité liée à des délais prolongés en cas de contestation. L'étude détaillée de ce droit de retrait a toutefois permis d'identifier un certain nombre de balises destinées à encadrer un droit de retrait dans le cadre d'un régime européen des scissions transfrontalières et permettant de s'assurer que ce dernier remplira adéquatement les différents enjeux posés par ces opérations. Ce premier mécanisme de protection devra ensuite être complété par le droit pour les associés minoritaires de toutes les sociétés impliquées de contester le caractère adéquat du rapport d'échange, tout en insistant sur le fait que droit de retrait et droit de contester le rapport d'échange devraient être exclusifs l'un de l'autre. Cependant, si l'analyse des différents mécanismes de protection des associés minoritaires consacrés par le législateur européen dans la Directive Mobilité a permis de démontrer que l'approche de ce dernier est beaucoup moins restrictive qu'il n'y paraît de prime abord et que ce régime de protection serait dans une très large mesure parfaitement compatible avec un régime européen des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante, il serait erroné de considérer que le régime de protection consacré par la Directive Mobilité est transposable purement et simplement aux scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante. En effet, de nombreux aspects mériteraient d'être revus afin de mieux tenir compte des impératifs de la liberté d'établissement et de la protection des intérêts des créanciers. En outre, le choix du législateur européen d'opter pour une harmonisation résolument *a minima* à l'égard de la protection des associés minoritaires ne peut que se révéler insuffisante à long terme. Cependant, il est possible de voir dans ces choix législatifs un préalable nécessaire pour rendre une harmonisation plus ambitieuse politiquement acceptable.

1171. Les enjeux de la protection de la participation des travailleurs. Réticente à toute harmonisation et politiquement très sensible, la question de la préservation de la participation des travailleurs constitue un enjeu non négligeable d'une scission transfrontalière dans la mesure où ce type d'opération pourrait aisément être utilisé pour l'éluder. L'étude détaillée des dispositions de la Directive Mobilité en la matière et la comparaison avec le régime des fusions transfrontalières tant avant qu'après l'adoption de la Directive Mobilité a permis de mettre en lumière le fait que la tendance était à un renforcement des mécanismes de protection et que le régime des scissions transfrontalières était plus strict que celui applicable aux fusions transfrontalières. Cet exercice a également permis de dresser les contours qu'un régime plus général des scissions transfrontalières devrait revêtir s'il devait s'inspirer du régime mis en place par la Directive Mobilité tant à l'égard des scissions transfrontalières par

constitution de nouvelles sociétés que des fusions transfrontalières et d'isoler les éléments nécessitant une modification. En examinant toutefois le régime de la Directive Mobilité à l'aune de la liberté d'établissement, on ne peut que s'interroger sur sa compatibilité avec le principe de proportionnalité et sur la nécessité d'une réforme plus globale de ce régime, même s'il ne s'agit pas là d'un préalable nécessaire à la consécration d'un régime plus général de participation des travailleurs.

1172. Une délicate articulation entre les mécanismes de protection. L'étude détaillée du régime de protection tant des associés minoritaires que des travailleurs a également permis de mettre en lumière le fait qu'il existe une véritable interdépendance entre les régimes de protection des associés minoritaires, des travailleurs et des créanciers. En effet, l'efficacité du système défensif de ces derniers est intimement liée à la proportionnalité des mécanismes de protection des associés minoritaires et des travailleurs qui ne peuvent ni entraîner une érosion financière excessive, ni constituer un obstacle démesuré à la réalisation d'une opération dont pourrait dépendre le désintéressement ultime des créanciers. Sur la base de ce constat, il a ainsi été possible d'identifier certains aspects du régime actuel des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés qui mériteraient d'être améliorés dans le cadre d'une nouvelle initiative européenne en matière de mobilité transfrontalière.

1173. L'avenir des scissions transfrontalières. Complexes et délicates, les scissions transfrontalières s'apparentent à un fragile mécanisme d'horlogerie et le principal enjeu d'une initiative de plus grande envergure en la matière sera de préserver le savant équilibre entre les différents engrenages sous l'impulsion du ressort que représente la jurisprudence progressiste de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement. À l'issue de cette étude, il apparaît que le meilleur moyen pour faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne serait de procéder par le biais d'une nouvelle directive en la matière consacrant une procédure en sept étapes dont les principaux rouages seraient issus du régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés figurant dans la Directive Mobilité, moyennant toutefois un nombre important d'adaptations ou de corrections. Ces dernières, identifiées au gré de l'exposé, ont pu être mises en lumière au moyen d'une analyse détaillée des dispositions de la Directive Mobilité tout en tirant pleinement parti des enseignements (i) de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement, (ii) de l'expérience réussie des fusions transfrontalières, (iii) du régime établi des scissions internes figurant dans la Directive Sociétés et (iv) d'un vaste exercice de droit comparé entre les droits belge, luxembourgeois, allemand, autrichien et français. Cependant, les scissions transfrontalières ne constituent pas l'apanage des associés majoritaires contrôlant le processus ou des membres de l'organe de gestion à l'origine de celui-ci, mais sont également susceptibles d'impacter un nombre important d'autres *stakeholders*, au nombre desquels on compte principalement les créanciers, les associés minoritaires et les travailleurs. L'examen méthodique des risques engendrés par ce type d'opération pour chacune de ces catégories de parties prenantes combiné à l'évaluation des différents mécanismes de protection développés aussi bien par le législateur européen que par divers législateurs nationaux tout en tenant compte des enseignements de la Cour

de justice en la matière et de l'impérative exigence de parvenir à un équilibre entre les différents intérêts en présence permet d'aboutir à la conclusion qu'un régime revu des scissions transfrontalières doit inclure un système complexe de protection des intérêts des *stakeholders* articulé autour (i) d'un régime élaboré de protection des intérêts des créanciers composé de quatre lignes de défense successives progressivement plus intrusives du point de vue de la liberté d'établissement, (ii) d'un régime bicéphale de protection des intérêts des associés minoritaires composé d'un droit de retrait et d'un droit de contester le caractère adéquat du rapport d'échange et (iii) d'un régime de protection de la participation des travailleurs largement inspiré de celui applicable actuellement aux scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés mais intégrant un certain nombre d'innovations destinées à en renforcer la proportionnalité à l'aune de la liberté d'établissement.

1174. Une habile manœuvre de la Commission ? Au-delà de cette première conclusion, l'examen approfondi de la Directive Mobilité a permis d'identifier un nombre important de dispositions dont l'insuffisance *ab initio* laisse apparaître en filigrane la nécessité d'une nouvelle initiative européenne en la matière. À tel point que la future évaluation qui sera réalisée d'ici au 1er février 2027 par la Commission européenne[6365] ne laisse en réalité que peu de surprises quant à sa conclusion. On peut donc y voir en réalité une habile manœuvre politique de la part de la Commission européenne qui, en sélectionnant volontairement les points de friction dans le régime des scissions transfrontalières[6366] et en misant sur une hausse significative du nombre de ces opérations par le biais du cadre légal à tout le moins partiellement harmonisé de la Directive Mobilité, espère faire accepter plus aisément aux États membres réticents une nouvelle directive de nature plus ambitieuse. Les évolutions futures du droit de la mobilité transfrontalière des personnes morales au sein de l'Union européenne permettront peut-être de trancher cette question, mais préalablement, il sera déjà intéressant d'étudier dans quelle mesure les États membres auront, lors de la transposition nationale des dispositions de la Directive Mobilité, spontanément tendance à remédier aux imperfections du régime européen actuel des scissions transfrontalières.

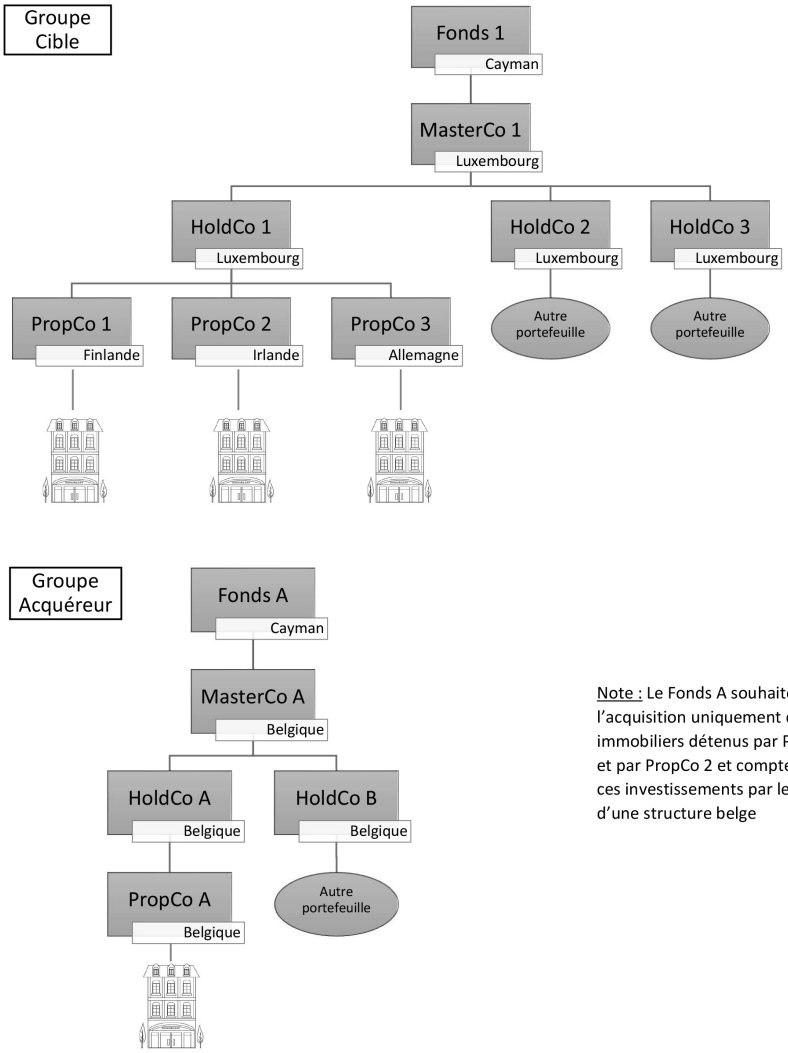
6365 Art. 4, § 1er de la Directive Mobilité.

6366 Pour une liste détaillée des différents aspects du régime des scissions transfrontalières laissant présager que la Commission avait, dès l'origine, l'intention de procéder en deux étapes pour faire des scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne, voir Annexe 4.

Annexes

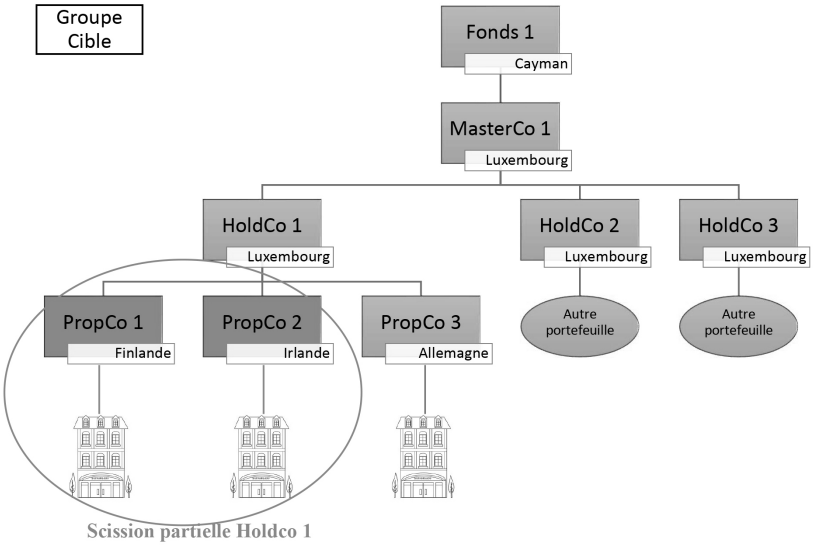
Annexe 1. Illustration de l'utilité d'une scission transfrontalière dans le cadre de la vente d'un portefeuille d'actifs

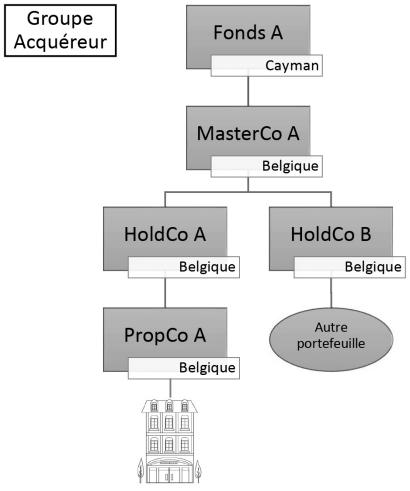
Étape 1 : structure pré-acquisition



Note : Le Fonds A souhaite faire l'acquisition uniquement des biens immobiliers détenus par PropCo 1 et par PropCo 2 et compte détenir ces investissements par le biais d'une structure belge

Étape 2 : restructuration

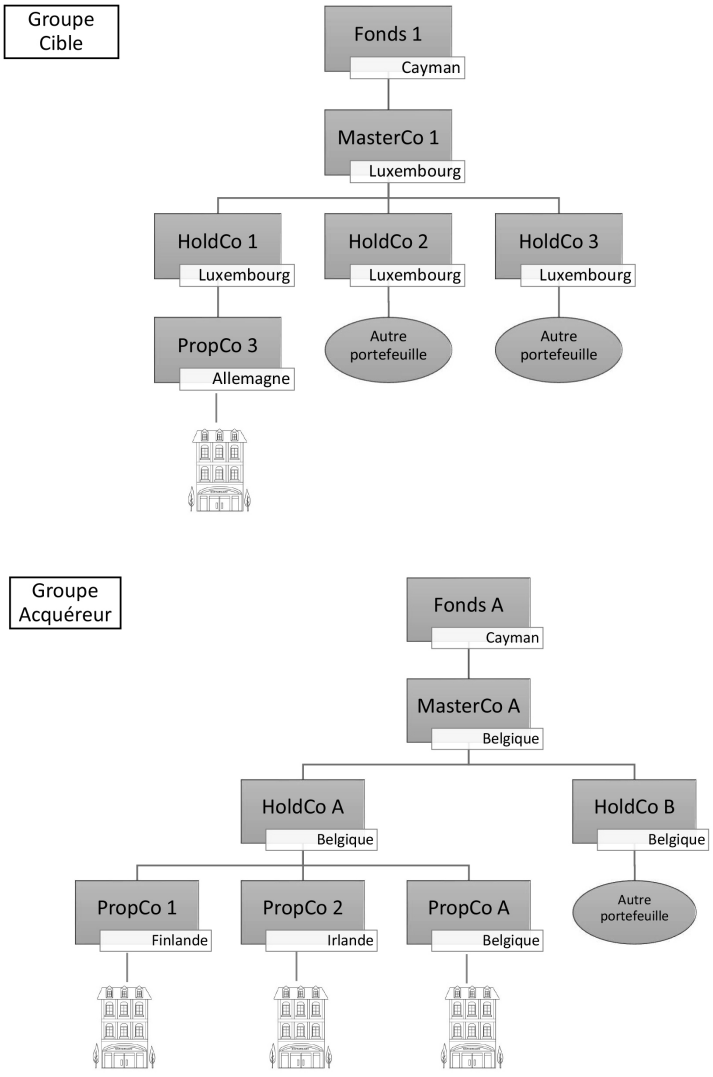




Note : Pour réaliser l'acquisition, il sera procédé comme suit :

- scission partielle transfrontalière de HoldCo 1 au profit de HoldCo A par le biais (i) de la transmission à titre universel d'une fraction du patrimoine de HoldCo 1 (Luxembourg) composée de PropCo 1 et de PropCo 2 et (ii) de l'émission de nouvelles actions de HoldCo A (Belgique) à MasterCo1 ;
- option de vente et d'achat portant sur les nouvelles actions émises par HoldCo A à MasterCo 1 signée au moment de la publication du projet commun de scission et exerçable à la date de prise d'effet de l'opération ; et
- convention de cession d'actions portant sur les nouvelles actions émises par HoldCo A dans le cadre de la scission et conclue entre MasterCo 1 en qualité de venderesse et MasterCo A en qualité d'acquéreuse et en présence de HoldCo A.

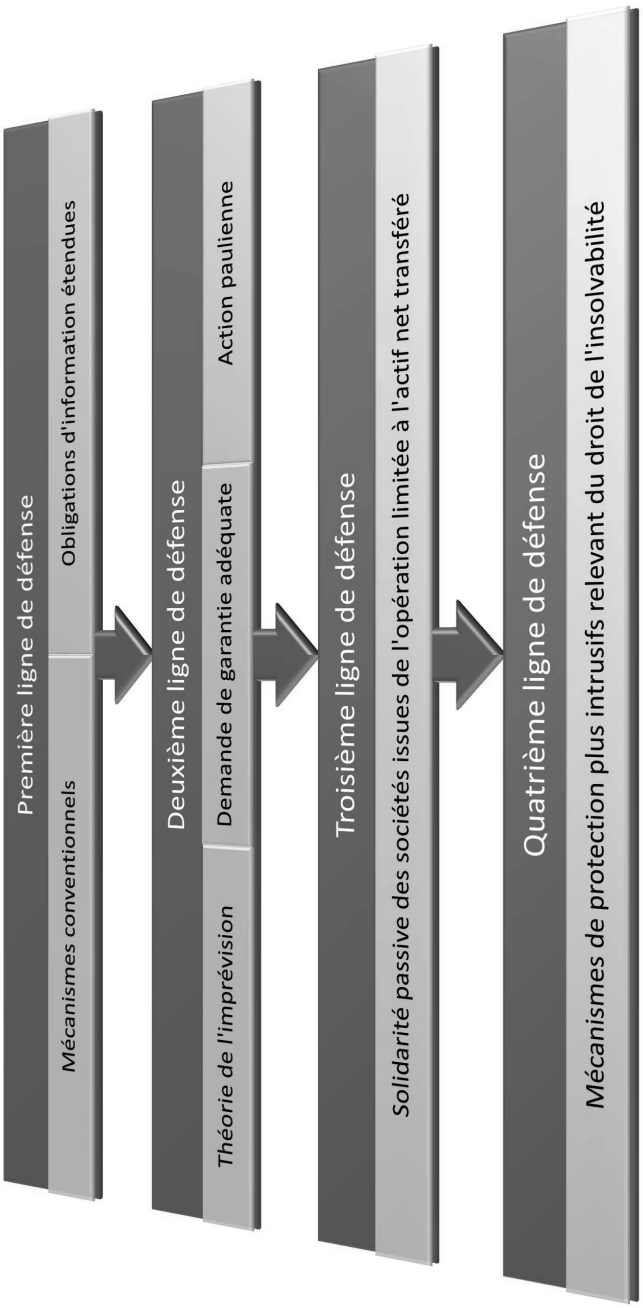
Étape 3 : structure post-acquisition



Annexe 2. Illustration chiffrée de calcul du rapport d'échange

	Société scindée	Société absorbante 1	Société absorbante 2
Evaluation	100 000,- EUR	200 000,- EUR	500 000,- EUR
Nombre d'actions	100	100	100
Valeur unitaire de chaque action	1 000,- EUR	2 000,- EUR	5 000,- EUR
Rapport d'échange		1 000/2 000 = 0,5 1 action de la société scindée équivaut à 0,5 action de la société absorbante 1. 1 action de la société absorbante 1 sera émise pour 2 actions de la société scindée.	1 000/5 000 = 0,2 1 action de la société scindée équivaut à 0,2 action de la société absorbante 2. 1 action de la société absorbante 2 sera émise pour 5 actions de la société scindée.
Valeur de la quote-part du patrimoine de la société scindée allouée		20 000,- EUR représentés par 20 actions de la société scindée	80 000,- EUR représentés par 80 actions de la société scindée
Nombre de nouvelles actions à attribuer aux actionnaires de la société scindée		10 actions	16 actions

Annexe 3. Schéma de la défense en profondeur des créanciers


Première ligne de défense
Mécanismes conventionnels
Obligations d'information étendues
Deuxième ligne de défense
Théorie de l'imprévision
Demande de garantie adéquate
Action paulienne
Troisième ligne de défense
Solidarité passive des sociétés issues de l'opération limitée à l'actif net transféré
Quatrième ligne de défense
Mécanismes de protection plus intrusifs relevant du droit de l'insolvabilité

Annexe 4. Liste des indices de l'habileté politique de la Commission

La présente Annexe 4 reprend l'intégralité des indices de l'habileté politique de la Commission identifiés au gré de l'exposé et qui laissent à penser que la Commission avait, dès l'origine, l'intention de procéder en deux étapes pour faire des scissions transfrontalières une réalité au sein des États membres :

(i) il est d'ores et déjà prévu que l'évaluation prévue par l'art. 4 de la Directive Mobilité qui aura lieu au plus tard le 1er février 2027 et le rapport que la Commission remettra au Parlement européen et au Comité économique et social européen, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, comprendra une évaluation « de la faisabilité de la définition de règles pour les types de scissions transfrontalières qui ne sont pas couverts par [la Directive Mobilité], y compris, en particulier, les scissions transfrontalières par acquisition »[6367] ;

(ii) la Commission n'a pas fait le choix de créer un tronc commun aux différents régimes de mobilité transfrontalière combiné à des parties spécifiques tenant compte des particularités de chaque type d'opération. Elle a ainsi pu volontairement alourdir les régimes et générer certaines incohérences en vue de justifier une intervention de plus grande envergure, la Commission ayant pris le soin de ne pas limiter le champ de son rapport aux seules transformations et scissions transfrontalières[6368] ;

(iii) la Proposition de la Commission entendait simplifier l'élaboration du projet de de scission en permettant aux parties de rédiger celui-ci dans « une langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales » en plus de la langue officielle des États membres concernés, étant entendu qu'il aurait été loisible à l'État membre de la société scindée de déterminer quelle version linguistique ferait foi en cas de divergences entre les différentes versions[6369]. Cette innovation ne fait que peu de sens dans l'hypothèse d'une scission au profit d'une ou de plusieurs nouvelles sociétés, mais elle est en revanche très utile dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante[6370] ;

(iv) l'obligation d'indiquer une date dans le projet commun de scission à partir de laquelle le droit de participer aux bénéfices sera acquis aux associés de la société scindée ne fait pas de sens dans le cas d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, mais présente une utilité non négligeable dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante[6371] ;

(v) la possibilité de prévoir des dates de prise d'effet comptable distinctes ne fait réellement de sens que dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante[6372] ;

(vi) la formulation générale de la mention relative aux « garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages » devant nécessairement figurer dans le projet commun de scission rend celle-ci directement

6367 À ce sujet, voir *supra* n° 346.
6368 À ce sujet, voir *supra* n° 381.
6369 Art. 160*sexies*, § 4 de la Proposition de la Commission.
6370 À ce sujet, voir *supra* n° 436.
6371 À ce sujet, voir *supra* n° 464.
6372 À ce sujet, voir *supra* n° 473.

compatible avec un régime plus général des scissions transfrontalières dans la mesure où malgré le champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité, elle n'est pas limitée aux seuls créanciers de la société scindée[6373] ;

(vii) le choix laissé par la Directive Mobilité aux États membres de dispenser la société scindée des obligations classiques de publication si celle-ci préfère au contraire opter pour une mise à disposition gratuite du projet et de l'avis aux *stakeholders* sur son site internet propre pendant une période continue d'au moins un mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale pourrait constituer une forme d'étape intermédiaire. En effet, se doutant de l'éventuelle réticence des États membres à l'égard d'une publication sur le seul site internet de la société dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, il est possible que la Commission ait préféré prévoir d'abord que celle-ci serait laissée à la discrétion des États membres pour ensuite se servir des conclusions qu'elle pourrait glaner de cette expérience pour justifier un alignement du régime des scissions transfrontalières sur celui des scissions internes lors d'une initiative ultérieure en la matière et rendre la reconnaissance d'une telle publication par les États membres obligatoire[6374] ;

(viii) la nécessité de déposer auprès du registre de la société scindée l'information selon laquelle ce registre est compétent pour la société scindée ainsi que le numéro d'immatriculation de la société scindée auprès de ce registre ne fait aucun sens dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière, mais ces indications prendraient en revanche tout leur sens dans le cadre d'un régime des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[6375] ;

(ix) l'exclusion contenue dans la Proposition de la Commission de contester la validité de la décision de l'assemblée générale sur la base du motif que la valeur totale des participations attribuées à un associé n'était pas équivalente à la valeur des actions détenues par celui-ci dans la société scindée ne prend tout son sens que dans l'hypothèse d'une scission transfrontalière asymétrique impliquant plus d'une société préexistante[6376] ;

(x) il n'est pas concevable que la Commission ait pu ignorer le fait que la décision d'une autorité nationale compétente de refuser d'émettre le certificat de conformité dans le cadre d'une scission transfrontalière par absorption au motif que ce type d'opération ne rentre pas dans le champ d'application *ratione materiae* de la disposition nationale ayant transposé la Directive Mobilité violerait le principe de non-discrimination des opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes si l'État membre en question reconnaît les scissions par absorption dans l'ordre interne. En revanche, cette situation, qui sème les germes d'une répétition des faits à

6373 À ce sujet, voir *supra* n° 521.
6374 À ce sujet, voir *supra* n°s 594 et 595.
6375 À ce sujet, voir *supra* n° 599.
6376 À ce sujet, voir *supra* n° 636.

la base de l'arrêt *Sevic* justifierait aisément une nouvelle initiative législative en la matière[6377] ;

(xi) l'absence de prohibition de prononcer la nullité d'une scission transfrontalière mixte ou par acquisition ayant déjà pris effet nuit à la sécurité juridique de ce type d'opération tant pour les associés concernés que pour les autres *stakeholders* pourtant davantage exposés dans ce type d'opérations que dans une simple scission par constitution de nouvelles sociétés. Cette incohérence flagrante permettrait également de justifier une intervention de la Commission en la matière lors de la révision de la Directive Mobilité au plus tard en 2027[6378] ;

(xii) l'attitude résolument plus protectrice des intérêts des associés minoritaires du législateur européen dans le cadre de la Directive Mobilité pourrait s'expliquer par la volonté de générer une discordance entre le régime des scissions internes et celui des scissions transfrontalières en vue de justifier une révision plus étendue du régime des scissions tant internes que transfrontalières et passer plus facilement outre les éventuelles réticences des États membres à cet égard[6379] ;

(xiii) l'introduction d'une procédure en contestation du rapport d'échange alors que seules les scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés ont fait l'objet d'une harmonisation ne fait véritablement de sens que si législateur européen cherche à préparer le terrain pour une mesure d'harmonisation de plus grande envergure[6380] ;

(xiv) le choix restrictif d'opter pour une harmonisation *a minima* de la protection des associés minoritaires permettra lors de l'adoption de la révision de la Directive Mobilité d'établir l'insuffisance d'une telle harmonisation et la nécessité d'aller un pas plus loin dans l'harmonisation, soit en proposant un nombre limité d'options, soit en procédant à une harmonisation complète[6381] ; et

(xv) la règle de permanence en matière de participation des travailleurs aboutit à la situation assez absurde où le régime de protection de la participation des travailleurs en cas de scission transfrontalière impliquant plus d'une société préexistante variera en fonction de l'opération l'ayant précédée[6382].

6377 À ce sujet, voir *supra* n° 655.
6378 À ce sujet, voir *infra* n° 669.
6379 À ce sujet, voir *supra* n°s 989 à 992.
6380 À ce sujet, voir *supra* n° 1064.
6381 À ce sujet, voir *supra* n° 1092.
6382 À ce sujet, voir supra, n° 1146.

Annexe 5.
Liste des modifications nécessaires

La présente Annexe 5 reprend la liste des modifications du cadre légal actuel qui s'avèrent nécessaires en vue de faire de tous types de scissions transfrontalières une réalité au sein de l'Union européenne par le biais d'une nouvelle directive en la matière[6383] :

I. Aspects généraux :

1.1. Harmonisation préalable des scissions internes

i. harmonisation préalable du régime des scissions internes rendant notamment la reconnaissance de ces dernières obligatoires[6384] et extension du champ d'application *ratione personae* du régime des scissions internes de manière à ce que celles-ci couvrent également les autres sociétés de capitaux, à l'instar de la Directive Mobilité[6385].

1.2. Champ d'application

i. intégration obligatoire des sociétés soumises à des cadres de restructuration préventive dans le champ d'application *ratione personae* de la Directive Mobilité[6386] ;

ii. extension du champ d'application *ratione materiae* de la Directive Mobilité de manière à couvrir également les scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[6387] ;

iii. intégration de la règle figurant à l'article 151, § 2, a) de la Directive Sociétés selon laquelle aucune action d'une société bénéficiaire ne sera échangée contre les actions de la société scindée détenues par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société bénéficiaire en question. Cette règle figurerait avantageusement à l'article 160*novodecies*, § 6 qui ne traite que de l'hypothèse des actions détenues par la société scindée ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société en raison du champ d'application *ratione materiae* excessivement limité de la Directive Mobilité qui ne traite pas des scissions transfrontalières impliquant plus d'une société préexistante[6388] ; et

iv. clarification de la règle de conflit de lois applicable en présence de législations nationales contradictoires quant à la limite de 10 % applicable à la soulte en espèces en précisant qu'une scission transfrontalière avec une soulte en espèces supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, 10 % du pair comptable des titres ou actions représentant le capital des sociétés bénéficiaires doit être admise par tous les États membres concernés dès qu'une telle opération est admise par

6383 Sur le choix d'une directive à cet égard, voir *supra* n°s 399 à 402.
6384 À ce sujet, voir *supra* n° 330.
6385 À ce sujet, voir *supra* n°s 333 à 336.
6386 À ce sujet, voir *supra* n°s 337 à 340.
6387 À ce sujet, voir *supra* n°s 341 à 346.
6388 À ce sujet, voir *supra* n° 114.

le droit d'un seul des États membres concernés, et ce nonobstant l'existence d'une limite plus stricte du montant de la soulte en espèces dans l'hypothèse d'une opération interne dans les autres États membres, peu important que le droit de l'État membre autorisant la soulte supérieure soit celui de la société scindée ou d'une des sociétés bénéficiaires[6389].

1.3. Cohérence entre les différents régimes

i. assurer une cohérence entre les différents régimes de mobilité transfrontalière que sont les fusions, les scissions et les transformations transfrontalières[6390].

II. Procédure de scission

2.1. Projet commun de scission

i. choix de la forme du projet commun de scission laissé à la discrétion des États membres[6391] ;

ii. intégration d'une règle relative à la langue du projet commun imposant aux États membres de permettre aux sociétés concernées (i) d'établir le projet commun de scission transfrontalière en anglais et (ii) de prévoir, lorsque l'État membre en question préfère ne pas laisser aux sociétés concernées le choix d'établir le projet de scission exclusivement en anglais, que cette version prévaudrait sur toutes les éventuelles traductions dans les langues officielles des États membres concernés qui pourraient être requises en vertu des législations nationales applicables. Pour assurer malgré tout une parfaite information des différents *stakeholders* potentiellement impactés par l'opération dans l'hypothèse où les États membres feraient le choix d'autoriser les sociétés concernées à ne rédiger le projet de scission qu'en anglais, cette flexibilité devrait en tout état de cause être combinée avec la possibilité pour les *stakeholders* autres que les associés d'en obtenir, sur simple demande et sans frais de leur part, une version dans une des langues nationales de l'État membre de la société concernée, étant entendu qu'en cas de divergences, la version anglaise prévaudrait nécessairement. Imposer aux parties de rédiger nécessairement le projet commun en anglais ne semble toutefois pas souhaitable en vue de promouvoir le recours aux scissions transfrontalières par les petites et moyennes entreprises[6392] ;

iii. obligation pour le projet de scission d'inclure la description de tous les avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet[6393] ;

iv. obligation d'inclure une description des principaux éléments intransmissibles du patrimoine de la société scindée[6394] ;

6389 À ce sujet, voir *supra* n° 454.
6390 À ce sujet, voir *supra* n°s 376 à 381.
6391 À ce sujet, voir *supra* n° 425.
6392 À ce sujet, voir *supra* n° 437.
6393 À ce sujet, voir *supra* n° 483.
6394 À ce sujet, voir *supra* n° 487.

v. réintégration de la règle figurant à l'origine dans la Proposition de la Commission au sujet du sort des éléments de patrimoine oubliés et qui prévoyait que (i) lorsqu'un élément du patrimoine actif de la société scindée n'est pas explicitement attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de ce dernier ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre-valeur sera répartie entre toutes les sociétés bénéficiaires (en ce compris la société scindée en cas de scission partielle) de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission et (ii) lorsqu'un élément du patrimoine passif de la société scindée n'est pas explicitement attribué dans le projet de scission, cet élément sera attribué aux sociétés bénéficiaires (en ce compris la société scindée en cas de scission partielle) proportionnellement à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission, étant entendu que chacune des sociétés issues de la scission en sera solidairement responsable, cette solidarité étant toutefois limitée à l'actif net attribué à chaque société à la date de la scission[6395] ;

vi. clarification de la mention relative aux effets probables de l'opération sur l'emploi en précisant que seuls les effets pertinents pour les associés doivent être mentionnés[6396] ;

vii. clarification de la mention relative aux documents comptables ayant servi de base à l'établissement des conditions de l'opération par le biais d'une liste, si ce n'est exhaustive, à tout le moins exemplative[6397] ;

viii. obligation de mentionner explicitement l'offre de soulte en espèces adéquate *qualitate qua* dans le projet commun de scission[6398] ;

ix. précision, pour peu que cela soit politiquement faisable, qu'il n'est pas loisible aux États membres de compléter le catalogue des mentions obligatoires[6399] ; et

x. clarification de la mention relative aux garanties en précisant qu'elles ne doivent figurer dans le projet de scission que si elles sont effectivement offertes[6400].

2.2. Le(s) rapport(s) de l'organe d'administration ou de direction

i. obligation d'intégrer une explication du critère utilisé pour la répartition des actions des sociétés bénéficiaires à attribuer[6401] ;

ii. intégration d'un droit au secret combiné à une obligation de motivation[6402] ;

6395 À ce sujet, voir *supra* n°s 496 à 498.
6396 À ce sujet, voir *supra* n° 504.
6397 À ce sujet, voir *supra* n°s 515 à 519.
6398 À ce sujet, voir *supra* n°s 520 et 1035.
6399 À ce sujet, voir *supra* n° 525.
6400 À ce sujet, voir *supra* n° 757.
6401 À ce sujet, voir *infra* n° 538.
6402 À ce sujet, voir *supra* n°s 544 à 546.

iii. introduction de la possibilité d'établir un rapport de l'organe de direction ou d'administration commun à toutes les sociétés impliquées[6403] ;

iv. introduction de la possibilité d'établir le rapport dans une « langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales », combinée à la possibilité pour les destinataires du rapport d'en demander sans frais une version dans une des langues nationales des sociétés concernées[6404] ;

v. introduction de la possibilité pour les travailleurs de la ou des sociétés concernées de renoncer à l'unanimité au rapport, ou à la partie du rapport, de l'organe de direction ou d'administration qui leur est destiné(e)[6405] ;

vi. permettre aux destinataires du ou des rapport(s) de l'organe de gestion ou d'administration de renoncer à l'unanimité au délai de mise à disposition de celui-ci, étant entendu qu'en présence d'un rapport ou d'une partie de rapport à destination des travailleurs, les seuls associés ne pourront disposer d'une telle faculté[6406] ; et

vii. prévoir une notification aux travailleurs que le rapport ou la partie du rapport de l'organe de gestion ou d'administration les concernant à fait l'objet d'une mise à disposition par voie électronique.

2.3. Le rapport d'expert indépendant

i. prévoir obligatoirement une procédure de désignation d'un expert commun ainsi que la possibilité d'établir un rapport unique pour toutes les sociétés impliquées dans l'opération de scission[6407] ;

ii. précision qu'en cas de rapport d'expert commun, les différents droits nationaux en la matière s'appliqueront cumulativement tout en privilégiant la norme la plus sévère[6408] ;

iii. extension du contrôle de l'expert indépendant à la méthode utilisée pour déterminer le critère de répartition des actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée[6409] ;

iv. prévoir que l'expert indépendant devra également inclure dans son rapport une indication sur la justification de l'utilisation de méthodes d'évaluation différentes, pour peu que différentes méthodes aient été utilisées à l'égard des sociétés impliquées dans l'opération[6410] ;

v. prévoir que le rapport d'expert indépendant devra également inclure un avis de l'expert indépendant sur le critère utilisé pour la répartition des actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée[6411] ;

6403 À ce sujet, voir *supra* n°s 548 à 551.
6404 À ce sujet, voir *supra* n° 552.
6405 À ce sujet, voir *supra* n°s 553 à 555.
6406 À ce sujet, voir *supra* n°s 556 et 557.
6407 À ce sujet, voir *supra* n° 571.
6408 À ce sujet, voir *supra* n° 581.
6409 À ce sujet, voir *supra* n° 582.
6410 À ce sujet, voir *supra* n° 583.
6411 À ce sujet, voir *supra* n° 583.

vi. introduction de la possibilité d'établir le rapport dans une « langue usuelle dans le domaine des affaires et des finances internationales », combinée à la possibilité pour les destinataires du rapport d'en demander sans frais une version dans une des langues nationales des sociétés concernées[6412] ; et

vii. précision qu'une renonciation au rapport d'expert n'est possible qu'avec l'accord unanime des associés de chacune des sociétés impliquées[6413].

2.4. Formalités de publicité

i. la publication du rapport d'expert indépendant moins les informations confidentielles devrait être rendue obligatoire[6414] ;

ii. les États membres devraient avoir l'obligation de dispenser la société scindée des obligations classiques de publication si celle-ci préfère au contraire opter pour une mise à disposition gratuite du projet et de l'avis aux *stakeholders* sur son site internet propre pendant une période continue d'au moins un mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale, comme en matière de scissions internes[6415] ;

iii. prévoir que les différents documents préparatoires additionnels doivent être disponibles dans la langue usuelle des affaires, tout en précisant que les destinataires pourront en obtenir une version dans une des langues nationales sans frais et sur simple demande[6416] ;

iv. prévoir une dispense de mise à disposition des documents préparatoires au siège social en cas de mise à disposition sur le site internet de la société concernée[6417] ; et

v. prévoir que l'obligation d'information en cas de modification importante du patrimoine actif et passif s'étend à toutes les sociétés impliquées dans une scission transfrontalière[6418].

2.5. L'approbation de l'assemblée générale

i. prévoir la faculté pour toutes les assemblées générales concernées d'approuver l'opération sous la condition suspensive et résolutoire qu'elles entérinent expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission[6419] ;

ii. préciser que l'entérinement des modalités relatives à la participation des travailleurs par l'assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si ces modalités requièrent une modification statutaire[6420] ;

[6412] À ce sujet, voir *supra* n° 585.
[6413] À ce sujet, voir *supra* n° 587.
[6414] À ce sujet, voir *supra* n° 593.
[6415] À ce sujet, voir *supra* n° 594.
[6416] À ce sujet, voir *supra* n° 609.
[6417] À ce sujet, voir *supra* n° 612.
[6418] À ce sujet, voir *supra* n° 614.
[6419] À ce sujet, voir *supra* n° 624.
[6420] À ce sujet, voir *supra* n° 626.

iii. prévoir une possibilité de déléguer l'entérinement exprès des modalités relatives à la participation des travailleurs à l'organe de direction ou d'administration ou, à tout le moins, prévoir que cette question sera dévolue aux États membres[6421] ;

2.6. Le double contrôle de légalité

i. attribution de la charge du contrôle de légalité à l'autorité nationale compétente de l'État membre de la société scindée[6422] ;

ii. prévoir la possibilité d'un contrôle unique pour la société scindée[6423] ;

iii. prévoir qu'en cas d'erreurs manifestes dans le certificat de conformité, l'autorité en charge du contrôle de légalité aura la possibilité de requérir de l'autorité nationale compétente qu'elle réitère son contrôle sur les points litigieux[6424] ; et

iv. mise en place d'un formulaire numérique standard européen de certificat de conformité qui, en fonction du choix des États membres, viendra soit s'ajouter, soit remplacer purement et simplement le certificat usuel[6425].

2.7. Immatriculation et prise d'effet

i. pour peu que le contrôle de légalité soit confié à l'autorité nationale compétente pour la société scindée, l'immatriculation des sociétés bénéficiaires ne devra plus faire l'objet d'une notification séparée puisque les formalités relatives à la constitution de ces dernières seront déjà couvertes par le certificat préalable et seules la radiation de la société scindée et la prise d'effet de l'opération devront être notifiées par le registre de la société scindée au registre des sociétés bénéficiaires[6426].

III. Les opérations simplifiées

i. intégrer une dispense de l'assemblée générale au niveau de la société scindée lorsque toutes les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions et parts de la société scindée[6427].

IV. Protection des créanciers

4.1. Mécanismes de protection

i. prévoir qu'une demande de garantie adéquate introduite par un créancier auprès de l'autorité nationale compétente n'aura pas d'effet suspensif sur l'opération[6428] ;

6421 À ce sujet, voir *supra* n°s 627 à 629.
6422 À ce sujet, voir *supra* n°s 641 ; 653 ; 659 et 660.
6423 À ce sujet, voir *supra* n° 644.
6424 À ce sujet, voir *supra* n° 648.
6425 À ce sujet, voir *supra* n°s 649 à 651.
6426 À ce sujet, voir *supra* n° 665.
6427 À ce sujet, voir *supra* n°s 681 et 682.
6428 À ce sujet, voir *supra* n°s 768 et 906.

ii. dans le cadre d'une demande de garantie adéquate, faire peser la charge de la preuve que l'opération ne compromet pas l'exécution de la créance sur la société au lieu d'imposer au créancier d'établir l'existence d'un risque crédible[6429] ;

iii. précision que la solidarité des sociétés bénéficiaires ne peut porter que sur des dettes de la société scindée antérieures à la date de prise d'effet de la scission[6430] ;

iv. prévoir que les États membres peuvent limiter la solidarité dans le temps[6431] ;

v. au niveau de la solidarité, envisager explicitement la situation où la dette demeure dans le patrimoine de la société scindée[6432] ; et

vi. précision que le régime de protection ne vient pas remettre en cause les mécanismes de protection conventionnels librement négociés par les parties[6433].

4.2. Aspects temporels

i. s'il n'est pas politiquement faisable de prévoir qu'une demande de garantie adéquate sera dénuée d'effet suspensif, prévoir à tout le moins un délai d'action inférieur à trois mois[6434] ;

ii. prévoir un délai de protection des créanciers supérieur à celui de la protection des associés minoritaires[6435] ;

iii. élaborer davantage le délai de protection des créanciers en précisant qu'en tout état de cause, celui-ci ne prendra fin qu'au plus tard un mois après la date de l'assemblée générale si cette dernière constitue la date limite d'exercice du droit de retrait[6436] ; et

iv. préciser que lorsque l'assemblée générale a fait le choix de subordonner la réalisation de l'opération à la condition qu'elle entérine expressément les modalités relatives à la participation des travailleurs, c'est cette dernière date qu'il conviendra de prendre en compte pour le calcul du délai[6437].

4.3. Articulation avec le droit de l'insolvabilité

i. rendre le mécanisme de la déclaration de solvabilité obligatoire et compléter celui-ci par un régime de responsabilité spécifique des membres de l'organe de gestion relevant du droit de l'insolvabilité et non du droit

6429 À ce sujet, voir *supra* n° 773.
6430 À ce sujet, voir *supra* n° 783.
6431 À ce sujet, voir *supra* n° 785.
6432 À ce sujet, voir *supra* n° 787.
6433 À ce sujet, voir *supra* n°s 882 et 892.
6434 À ce sujet, voir *supra* n° 909.
6435 À ce sujet, voir *supra* n° 1101.
6436 *Ibidem*.
6437 *Ibidem*.

des sociétés en cas d'insolvabilité d'une des sociétés issues de l'opération dans un certain délai suivant celle-ci[6438] ;

ii. supprimer la limite de l'actif net transféré pour la solidarité passive des sociétés bénéficiaires en cas d'insolvabilité d'une des sociétés participantes dans un certain délai suivant la réalisation de la scission[6439] ; et

iii. les créanciers disposant, en cas de procédure d'insolvabilité de leur société débitrice, d'un privilège découlant d'une disposition légale et couvert par une masse contrôlée par les autorités ne devraient pas bénéficier du droit de demander des garanties adéquates[6440].

4.4. **Nécessité d'une certaine flexibilité pour les sociétés impliquées**

i. réintégrer les deux présomptions que l'opération ne lèse pas les créanciers qui figurait dans la Proposition de la Commission, à savoir en présence d'un rapport d'expert concluant ou en cas d'octroi d'un droit de paiement de qualité équivalente[6441] ;

ii. limiter le jeu de la présomption liée à l'existence d'un rapport d'expert concluant aux seules hypothèses dans lesquelles, de l'avis de l'expert indépendant, la scission transfrontalière ne compromet pas le remboursement à terme des dettes de la société scindée[6442] ;

iii. préciser que l'expert indépendant visé dans la présomption peut être celui intervenant également dans le processus de scission transfrontalière[6443] ; et

iv. reformuler la deuxième présomption en prévoyant qu'elle jouera soit en cas de droit de paiement équivalant octroyé par un tiers garant, soit en cas de solidarité non limitée aux actifs nets transférés des sociétés bénéficiaires pour les dettes de la société scindée[6444].

4.5. **L'articulation avec la protection des titulaires de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux**

i. laisser explicitement le choix aux parties de déterminer quelle société bénéficiaire devra consentir des droits équivalents aux titulaires de titres de la société scindée[6445] ;

ii. préciser que les États membres pourront déterminer que le principe selon lequel les titulaires de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir de droits au moins équivalents à

6438 À ce sujet, voir *supra* n°s 913 à 916.
6439 À ce sujet, voir *supra* n° 916.
6440 À ce sujet, voir *supra* n° 923.
6441 À ce sujet, voir *supra* n°s 930 à 934.
6442 À ce sujet, voir *supra* n° 931.
6443 *Ibidem*.
6444 À ce sujet, voir *supra* n° 932.
6445 À ce sujet, voir *supra* n°s 939 à 943.

la suite de l'opération ne s'appliquera qu'en l'absence de dispositions contractuelles contraires[6446] ; et

iii. la notion de « *créancier* » utilisée dans le cadre d'un régime des scissions transfrontalières devrait être exclusive des titulaires de titres, autres que des actions, bénéficiant déjà d'une protection spécifique[6447].

4.6. L'harmonisation au niveau européen

i. une harmonisation de la protection des créanciers aurait dû passer par (i) une réforme du droit des scissions internes renforçant le degré d'harmonisation et (ii) une règle de droit international privé renvoyant aux différents droits nationaux pour ce qui est de la protection des créanciers pour tous types de scissions et inspirée de celle du régime des fusions transfrontalières[6448] ; et

ii. privilégier une harmonisation poussée d'un régime de protection des créanciers identique en cas de scission interne et de scission transfrontalière, tout en concédant aux États membres la possibilité de le compléter par des mesures spécifiques[6449].

V. Protection des associés minoritaires

5.1. Le droit de retrait

i. un droit de retrait ne devrait être concédé qu'aux seuls associés de la société scindée, sans laisser de possibilité pour les États membres d'étendre ce droit aux associés des sociétés bénéficiaires[6450] ;

ii. le droit de retrait devrait se limiter aux seules actions destinées à faire l'objet d'un échange contre des actions d'une société bénéficiaire soumise à un droit national distinct de celui de la société scindée[6451] ;

iii. prévoir que la condition d'une opposition à l'opération est également remplie lorsque (i) un associé n'a pu comparaître à l'assemblée générale parce qu'il n'y a indûment pas été admis, (ii) l'assemblée générale n'a pas été convoquée correctement ou (iii) l'objet de l'assemblée n'a pas été annoncé correctement[6452] ;

iv. prévoir qu'un associé minoritaire ne pourra exercer son droit de retrait qu'à l'égard des seules actions détenues au jour de la publication du projet commun de scission dans l'État membre de la société scindée, à

6446 À ce sujet, voir *supra* n° 947.
6447 À ce sujet, voir *supra* n° 949.
6448 À ce sujet, voir *supra* n° 956.
6449 À ce sujet, voir *supra* n° 966.
6450 À ce sujet, voir *supra* n°s 1019 à 1021.
6451 À ce sujet, voir *supra* n°s 1022 à 1026.
6452 À ce sujet, voir *supra* n° 1029.

l'exclusion de toute autre action acquise ou souscrite entre cette date de publication et la date de prise d'effet de l'opération[6453] ;

v. permettre explicitement à la société scindée de payer la « *soulte en espèces adéquate* » (i) au moyen d'un paiement en nature moyennant l'accord exprès de l'associé minoritaire concerné et (ii) par le biais d'une compensation entre la créance détenue par l'associé minoritaire sortant à l'encontre de la société bénéficiaire du fait de l'exercice de ce droit de retrait et toute créance potentiellement détenue par la société bénéficiaire à la suite de la scission à l'encontre de l'associé en question[6454] ;

vi. la décision de l'autorité compétente chargée de se prononcer sur le caractère adéquat de la soulte en espèces ne devrait pas avoir d'effet *erga omnes*[6455] ;

vii. prévoir que le montant de la soulte en espèces pourra être revu par la juridiction compétente, sans prohiber une éventuelle revue à la baisse[6456] ;

viii. prévoir à l'égard de la procédure en contestation du caractère adéquat de la soulte en espèces qu'en présence d'un rapport d'expert positif, la soulte en espèces figurant dans le projet de scission sera présumée adéquate jusqu'à preuve du contraire et inversement en cas de rapport d'expert négatif[6457] ;

ix. prévoir un ordre hiérarchique parmi les personnes autorisées à acquérir les actions des associés minoritaires de la société scindée faisant usage de leur droit de retrait selon lequel les actions en question devraient être offertes en priorité aux associés de la société scindée, puis aux associés des sociétés bénéficiaires, ensuite à d'éventuels tiers acquéreurs et, à défaut, obligatoirement rachetées par la société scindée[6458] ;

x. prévoir que des restrictions statutaires à la libre cessibilité des actions ne seront pas opposables à l'associé s'étant opposé à l'opération entre la date de l'assemblée générale s'étant prononcée sur la fusion et la date d'écoulement du délai d'exercice du droit de retrait[6459] ; et

xi. s'il s'avère impossible de faire preuve de flexibilité à l'égard de l'identité de l'acquéreur des actions de l'associé sortant, il convient d'exclure les associés d'une société cotée du bénéfice d'un droit de retrait[6460].

5.2. La contestation du rapport d'échange

i. imposer aux associés minoritaires susceptibles d'entrer dans le champ d'application *ratione personae* du droit de retrait de voter en faveur de

[6453] À ce sujet, voir *supra* n° 1033.
[6454] À ce sujet, voir *supra* n° 1034.
[6455] À ce sujet, voir *supra* n[os] 1040 à 1042.
[6456] À ce sujet, voir supra, n[os] 1043 à 1045.
[6457] À ce sujet, voir *supra* n° 1047.
[6458] À ce sujet, voir *supra* n[os] 1049 et 1050.
[6459] À ce sujet, voir *supra* n° 1051.
[6460] À ce sujet, voir *supra* n[os] 1053 et 1054.

l'opération lors de l'assemblée générale pour pouvoir contester le rapport d'échange[6461] ;

ii. les associés minoritaires des sociétés bénéficiaires devraient également disposer de la possibilité de contester le rapport d'échange[6462] ;

iii. indiquer que la décision rendue par la juridiction compétente sur le caractère adéquat du rapport d'échange sera dénuée d'effet *erga omnes*[6463] ;

iv. autoriser explicitement une révision du rapport d'échange qui soit défavorable aux associés minoritaires demandeurs[6464] ;

v. intégrer une obligation pour les États membres de faire de l'octroi d'actions supplémentaires, le remède principal à un rapport d'échange inadéquat, tout en reléguant la possibilité d'une soulte en espèces additionnelle à un rôle subsidiaire[6465] ;

vi. prévoir que la procédure en contestation du rapport d'échange pourra être intentée auprès de l'autorité ou l'organe compétent habilité auquel est soumise la société participant à la scission concernée et dans le respect des délais fixés par ce droit national[6466] ; et

vii. prévoir qu'en présence d'un rapport d'expert positif, le rapport d'échange sera présumé correct jusqu'à preuve du contraire et inversement[6467].

5.3. **Aspects temporels**

i. prévoir un droit de retrait exerçable dès la publication du projet de scission et exerçable au plus tard lors de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération[6468] ;

ii. prévoir que lorsque l'assemblée générale de la société scindée aura fait le choix d'approuver la scission sous la condition suspensive qu'elle entérine expressément les modalités relatives à la participation des travailleurs, c'est à la date de la seconde assemblée que le délai d'acceptation de la soulte en espèces prendra fin[6469] ;

iii. prévoir un délai de paiement de la soulte en espèces adéquate plus élaboré en fonction de l'identité de l'acheteur de sorte que (i) lorsque les actions sont rachetées par les associés de la société scindée, les associés des sociétés bénéficiaires ou encore des tiers, un délai de paiement par défaut de deux mois soit imposé, étant entendu que les parties pourraient y déroger conventionnellement en cas de besoin et (ii) lorsque la soulte

6461 À ce sujet, voir *supra* n° 1068.
6462 À ce sujet, voir *supra* n° 1069.
6463 À ce sujet, voir *supra* n°s 1070 à 1072.
6464 À ce sujet, voir *supra* n° 1073.
6465 À ce sujet, voir *supra* n°s 1074 à 1077.
6466 À ce sujet, voir *supra* n°s 1079 à 1081.
6467 À ce sujet, voir *supra* n° 1083.
6468 À ce sujet, voir *supra* n° 1101.
6469 *Ibidem*.

en espèces doit être versée par les sociétés bénéficiaires, le délai de paiement soit significativement plus long[6470] ;

iv. prévoir que le montant de la soulte en espèces ne pourra être contesté que dans un délai d'un mois à compter de la date d'acceptation de l'offre[6471] ; et

v. prévoir qu'une demande en réévaluation du rapport d'échange ne puisse être introduite que dans un délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale se prononçant sur l'opération.

VI. Participation des travailleurs

i. intégration d'un régime spécifique dédié à la protection des travailleurs propre à chaque opération, sans fastidieux renvoi à la Directive Participation des Travailleurs[6472] ;

ii. abandon du seuil flexible et retour au seuil des 500 travailleurs qui se trouvait dans le Premier Compromis de la Présidence[6473] ;

iii. précision de la règle de permanence en prévoyant, si les régimes de protection de la participation des travailleurs devaient rester différents en fonction de l'opération transfrontalière réalisée, que la question de la préservation de la participation en cas d'opération transfrontalière subséquente serait régie par les règles propres à cette dernière opération[6474] ;

iv. indication de la forme de l'information du choix de la société concernée d'appliquer les dispositions de référence et du délai maximum pour l'accomplissement de cette formalité. Il serait ainsi envisageable d'exiger simplement un écrit à destination des représentants des travailleurs, ou à défaut, des travailleurs eux-mêmes dans le mois de la prise de décision et en tous les cas, préalablement à la prise d'effet de l'opération[6475] ;

v. cohérence entre les régimes de protection des travailleurs tenant pleinement compte du caractère aisément substituable des différentes opérations[6476] ;

vi. prévoir la possibilité pour les sociétés concernées d'éluder l'ouverture de négociations en appliquant directement les dispositions de référence[6477] ;

vii. prévoir que lorsque le groupe spécial de négociation décide, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin à des négociations déjà engagées, cette majorité spécifique devra nécessairement

6470 À ce sujet, voir *supra* n°s 1102 à 1104.
6471 À ce sujet, voir *supra* n°s 1105 à 1107.
6472 À ce sujet, voir *supra* n° 1126.
6473 À ce sujet, voir *supra* n° 1128.
6474 À ce sujet, voir *supra* n° 1129.
6475 À ce sujet, voir *supra* n° 1130.
6476 À ce sujet, voir *supra* n° 1132.
6477 À ce sujet, voir *supra* n° 1133.

comprendre « les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents »[6478] ;

viii. prévoir explicitement que les dispositions relatives à la protection du régime de participation des travailleurs s'appliquent à la société scindée en cas de scission partielle[6479] ;

ix. utilisation de la définition de la notion de « dispositions de référence » qui se retrouve dans le régime des fusions transfrontalières, et non celle du régime de la constitution d'une société européenne par voie de transformation[6480] ;

x. prévoir que les dispositions de référence ne trouveront à s'appliquer que si, avant l'immatriculation de la scission transfrontalière, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins un tiers du nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des sociétés participantes[6481] ;

xi. prévoir qu'en l'absence de travailleurs affectés par un changement de *lex societatis*, le régime spécifique de protection des droits de participation des travailleurs ne devrait pas trouver à s'appliquer[6482] ;

xii. la mesure transitoire prévoyant que les règles de participation applicables à la société scindée continueront à s'appliquer jusqu'à la date d'application de toutes règles convenues d'un commun accord ultérieurement ou, en l'absence de telles règles, jusqu'à l'application des dispositions de référence devrait être abandonnée[6483] ;

xiii. prévoir que lors de la composition du groupe spécial de négociation, il y aura lieu de veiller à ce que des membres supplémentaires soient élus de manière à garantir que le groupe spécial de négociation comprenne au moins un membre représentant la société scindée[6484] ; et

xiv. le groupe spécial de négociation doit avoir la possibilité de consentir à une réduction des droits de participation, tout en prévoyant que si la participation concerne au moins vingt-cinq pourcents du nombre total de travailleurs employés par les sociétés participantes, une telle décision requerra une majorité des deux tiers des voix des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs et incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres[6485].

6478 À ce sujet, voir *supra* n° 1134.
6479 À ce sujet, voir *supra* n° 1135.
6480 À ce sujet, voir *supra* n°s 1137 à 1141.
6481 À ce sujet, voir n°s 1142 et 1143.
6482 À ce sujet, voir *supra* n° 1144.
6483 À ce sujet, voir *supra* n° 1145.
6484 À ce sujet, voir *supra* n° 1147.
6485 À ce sujet, voir *supra* n° 1148.

Glossaire

Ancien Règlement Insolvabilité	Règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, *J.O.*, L 160, 30 juin 2000, pp. 1–18.
AktG	Aktiengesetz (AktG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).
AktG 1937	Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien (Aktiengesetz) du 30 janvier 1937, disponible sur http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1937&size=45&page=261 (16/10/2020).
AnfG	Gesetz über die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Insolvenzverfahrens (Anfechtungsgesetz), disponible sur https://www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).
AnfO	Anfechtungsordnung, version consolidée disponible sur https://www.ris.bka.gv.at (07/11/2021).
Arrêt *Cadbury Schweppes*	C.J.C.E., gde ch., arrêt *Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd c. Commissioners of Inland Revenue*, 12 septembre 2006, C-196/04, EU:C:2006:544.
Arrêt *Cartesio*	C.J.C.E., gde ch., arrêt *CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt*, 16 décembre 2008, C-210/06, EU:C:2008:723.
Arrêt *Centros*	C.J.C.E., arrêt *Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen*, 9 mars 1999, C-212/97, EU:C:1999:126.
Arrêt *Daily Mail*	C.J.C.E., arrêt *The Queen c. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc*, 27 septembre 1988, C-81/87, EU:C:1988:456.
Arrêt *Eurofood*	C.J.C.E., gde ch., arrêt *Eurofood IFSC Ltd.*, 2 mai 2006, C-341/04, EU:C:2006:281.
Arrêt *Euro Park Service*	C.J., arrêt *Euro Park Service c. Ministre des finances et des comptes publics*, 8 mars 2017, C-14/16, EU:C:2017:177.

Arrêt *Feniks*	C.J., arrêt *Feniks sp. z o.o. c. Azteca Products & Services SL*, 4 octobre 2018, C-337/17, EU:C:2018:805.
Arrêt *Gebhard*	C.J.C.E., arrêt *Gebhard c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano*, 30 novembre 1995, C-55/94, EU:C:1995:411.
Arrêt *Handte*	C.J., arrêt *Jakob Handte & Co. GmbH c. Traitements mécano-chimiques des surfaces SA*, 17 juin 1992, C-26/91, EU:C:1992:268.
Arrêt *I.G.I.*	C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele, en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 30 janvier 2020, C-394/18, EU:C:2020:56.
Arrêt *Inspire Art*	C.J.C.E., arrêt *Inspire Art Ltd c. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam*, 30 septembre 2003, C-167/01, EU:C:2003:512.
Arrêt *Interedil*	C.J., arrêt *Interedil Srl, en liquidation c. Fallimento Interedil Srl et Intesa Gestione Crediti SpA*, 20 octobre 2011, C-396/09, EU:C:2011:671.
Arrêt *KA Finanz*	C.J., arrêt *KA Finanz AG c. Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group*, 7 avril 2016, C-483/14, EU:C:2016:205.
Arrêt *Kornhaas*	C.J., arrêt *Simona Kornhaas c. Thomas Dithmar*, 10 décembre 2015, C-594/14, EU:C:2015:806.
Arrêt *Kraus*	C.J.C.E., arrêt *Kraus c. Land Baden-Württemberg*, 31 mars 1993, C-19/92, EU:C:1993:125.
Arrêt *Lasteyrie du Saillant*	C.J.C.E., arrêt *Lasteyrie du Saillant c. Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie*, 11 mars 2004, C-9/02, EU:C:2004:138.
Arrêt *National Grid Indus*	C.J., gde ch., arrêt *National Grid Indus BV c. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam*, 29 novembre 2011, C-371/10, EU:C:2011:785.
Arrêt *Polbud*	C.J., gde ch., arrêt *Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.*, 25 octobre 2017, C-106/16, EU:C:2017:804.
Arrêt *Reitbauer*	C.J., arrêt *Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egge, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH c. Enrico Casamassima*, 10 juillet 2019, C-722/17, EU:C:2019:577.
Arrêt *Segers*	C.J.C.E., arrêt *Segers c. Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen*, 10 juillet 1986, EU:C:1986:308, C-79/85.
Arrêt *Sevic*	C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:762.

Arrêt *Überseering*	C.J.C.E., arrêt *Überseering BV c. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)*, 5 novembre 2002, C-208/00, EU:C:2002:632.
Arrêt *Vale*	C.J., arrêt *VALE Építési kft*, 12 juillet 2012, C-378/10, EU:C:2012:440.
Avis CAEM	Avis de la Commission des affaires économiques et monétaires à l'intention de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)) (Rapporteur Olle Ludvigsson), PE625.524v03-00, 14 novembre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).
Avis CAJ	Rapport de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)) (Rapporteure Evelyn Regner), A8-0002/2019, 9 janvier 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).
Avis CEAS	Avis de la Commission de l'emploi et des affaires sociales à l'intention de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)) (Rapporteure Anthea McIntyre), PE625.524v03-00, 21 novembre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).
Avis CESC	Avis du Comité économique et social européen sur a) une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés [COM(2018) 239 final — 2018/0113 (COD)] et sur b) une proposition de directive modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières [COM(2018) 241 final — 2018/0114 (COD)] (Rapporteur Dimitris Dimitriadis), EESC 2018/01917, 17 octobre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch, disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).
Code civil belge	Code civil belge, disponible sur www.ejustice.just.fgov.be (07/11/2021).

Code du travail luxembourgeois	Code du travail luxembourgeois disponible sur http://data.legilux.public.lu (07/11/2021).
Code de commerce français	Code de commerce français, disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr (07/11/2021).
The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations	The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019).
Compromis des Représentants Permanents	Note from the General Secretariat of the Council to the Permanent Representatives Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions, ST 5401 2019 INIT, 25 janvier 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).
Consultation publique de 2015	European Commission – Feedback Statement – Summary of responses to the public consultation on cross border mergers and divisions, October 2015, http://ec.europa.eu/internal_market/ (11/03/2016).
Consultation publique de 2017	Feedback statement to the 2017 public consultation on "EU Company Law upgraded: digital solutions and providing efficicient rules for cross-border operations of companies", 25 avril 2018, disponible sur http://ec.europa.eu (29/03/2019).
Convention de Rome	Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (version consolidée), *J.O.*, C 027, 26 janvier 1998, pp. 34–46.
CSA	Code des sociétés et des associations, version consolidée disponible sur https://www.ejustice.just.fgov.be (07/11/2021).
Deuxième Compromis de la Présidence	Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions – Presidency compromise proposal, ST 5380 2019 INIT, 15 janvier 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).
Directive ATAD	Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, *J.O.*, L 193, 19 juillet 2016, pp. 1–14.
Directive DAC 6	Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, *J.O.*, L 139, 5 juin 2018, pp. 1–13.

Directive Fiscale	Directive (CE) 2009/133 du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre (version codifiée), *J.O.*, L 310/34, 25 novembre 2009, pp. 317–329.
Directive Fusions et Scissions Electroniques	Directive (CE) 2009/109 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive (CE) 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions, *J.O.*, L 259, 2 octobre 2009, pp. 14–21.
Directive Mobilité	Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 321/1, 12 décembre 2019, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (07/11/2021).
Directive OPA	Directive (CE) 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, *J.O.*, L 142, 30 avril 2004, pp. 12–23.
Directive OPCVM	Directive (CE) 2009/65 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), version consolidée disponible sur https://eur-lex.europa.eu (07/11/2021).
Directive Outils Numériques	Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 186, 11 juillet 2019, pp. 80–104.
Directive Participation des Travailleurs	Directive (CE) 2001/86 du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, *J.O.*, L 294, 10 novembre 2001, pp. 22–32.
Directive Sociétés	Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 169, 30 juin 2017, pp. 46–127.

Dixième Directive	Directive (CE) 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 310, 25 novembre 2005, pp. 1–9.
DrittelbG	Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).
Étude EY	Assessment and quantification of drivers, problems and impacts related to cross-border transfers of registered offices and cross-border divisions of companies, EY, 5 février 2018, disponible sur https://ec.europa.eu (13/03/2020).
Étude Bech-Bruun et Lexidale	Bech-Bruun et Lexidale, *Study on the application of the cross-border mergers directive*, septembre 2013, disponible sur https://op.europa.eu (28/02/2020).
Étude d'impact	Impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions of April 25, 2018, SWD(2018) 141 final, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (28/02/2020).
Étude TGS Baltic	Study on minority shareholders protection, TGS Baltic, janvier 2018, disponible sur https://op.europa.eu (10/06/2020).
EU-VerschG	EU-Verschmelzungsgesetz, disponible sur www.jusline.at (07/11/2021).
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).
InsO	Insolvenzordnung (InsO) du 5 octobre 1994, disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).
Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales	Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, version consolidée disponible sur https://www.elvingerhoss.lu (07/11/2021).
Loi suisse sur les fusions et scissions	Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, disponible sur https://www.admin.ch (07/11/2021).
MitbestG	Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (MitbestG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).
Loi suisse sur le droit international privé	Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, disponible sur https://www.admin.ch (07/11/2021).

öAktG	Österreichisches Aktiengesetz, disponible sur www.jusline.at (07/11/2021).
öGmbHG	Österreichisches GmbH-Gesetz, disponible sur www.jusline.at (07/11/2021).
Premier Compromis de la Présidence	Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions – Presidency compromise proposal, ST 15678 2018 INIT, 18 décembre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).
Proposition de la Commission	Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2018 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), COM (2018) 241 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (15/02/2019).
Proposition de Cinquième Directive	Proposition d'une cinquième directive tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés, au sens de l'article 58 paragraphe 2 du traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers en ce qui concerne la structure des sociétés anonymes ainsi que les pouvoirs et obligations de leurs organes du 9 octobre 1972, COM(72) 887 final, *J.O.*, C 131, 13 décembre 1972, pp. 49–61.
Proposition Modifiée de Cinquième Directive	Proposition modifiée d'une cinquième directive fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant la structure des sociétés anonymes et les pouvoirs et obligations de leurs organes du 19 août 1983, COM(83) 185 final, *J.O.*, C 240, 9 septembre 1983, pp. 2–38.
Proposition du Parlement	Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)), P8_TA-PROV(2019)0429, 18 avril 2019.
Règlement Bruxelles I*bis*	Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), *J.O.*, L 351, 20 décembre 2012, pp. 1–32.
Règlement Insolvabilité	Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (07/11/2021).

Règlement Rome I	Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), *J.O.*, L 177, 4 juillet 2008, pp. 6–16.
Règlement Rome II	Règlement (CE) 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), *J.O.*, L 199, 31 juillet 2007, pp. 73–82.
Règlement GEIE	Règlement (CEE) 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), *J.O.*, L 199, 31 juillet 1985, pp. 1–9.
Règlement sur la Société coopérative européenne	Règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, *J.O.*, L 207, 18 août 2003, pp. 1–24.
Règlement sur la Société européenne	Règlement (CE) 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, *J.O.*, L 294, 10 octobre 2001, pp. 1–21.
SEAG	Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Ausführungsgesetz - SEAG), disponible sur http://www.gesetze-im-internet.de/ (07/11/2021).
Sixième Directive	Sixième directive (CEE) 82/891 du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, *J.O.*, L 378, 31 décembre 1982, pp. 47 à 54.
SpaltG	Spaltungsgesetz (SpaltG), disponible sur www.jusline.at (07/11/2021).
Troisième Directive	Troisième directive (CEE) 78/855 du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, *J.O.*, L 295, 20 octobre 1978, pp. 36 à 43.
TFUE	Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, *J.O.*, C 326, 26 octobre 2012, pp. 47–390.
TUE	Traité sur l'Union européenne (version consolidée), *J.O.*, C 326, 26 octobre 2012, pp. 1–390.
UmwG	Umwandlungsgesetz (UmwG), disponible sur https://www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).

Bibliographie

1. LEGISLATION

1.1. Législation européenne

1.1.1. *Traités et Accords*

Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, *J.O.*, L 29, 31 janvier 2020, pp. 7–187.

Traité sur l'Union européenne (version consolidée), *J.O.*, C 326, 26 octobre 2012, pp. 1–390.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, *J.O.*, C 326, 26 octobre 2012, pp. 47–390.

Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (22/05/2017).

1.1.2. *Règlements et conventions*

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 22, 22 janvier 2021, pp. 1–102.

Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, *J.O.*, L 141, 5 juin 2015, pp. 19–72.

Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), *J.O.*, L 351, 20 décembre 2012, pp. 1–32.

Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), *J.O.*, L 177, 4 juillet 2008, pp. 6–16.

Règlement (CE) 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), *J.O.*, L 199, 31 juillet 2007, pp. 73–82.

Règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, *J.O.*, L 166, 30 avril 2004, pp. 1–123.

Règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, *J.O.*, L 207, 18 août 2003, pp. 1–24.

Règlement (CE) 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, *J.O.*, L 294, 10 octobre 2001, pp. 1–21.

Règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, *J.O.*, L 160, 30 juin 2000, pp. 1–18.

Règlement (CEE) 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, *J.O.*, L 199, 31 juillet 1985, pp. 1–9.

Règlement (CEE) 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), *J.O.*, L 199, 31 juillet 1985, pp. 1–9.

Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (version consolidée), *J.O.*, C 027, 26 janvier 1998, pp. 34–46.

1.1.3. *Directives*

Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 321/1, 12 décembre 2019, pp. 1–44.

Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 186, 11 juillet 2019, pp. 80–104.

Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 172, 26 juin 2019, pp. 18–55.

Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, *J.O.*, L 139, 5 juin 2018, pp. 1–13.

Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 169, 30 juin 2017, pp. 46–127.

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 168, 30 juin 2017, pp. 12–82.

Directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, *J.O.*, L 144, 7 juin 2017, pp. 1–11.

Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/3/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 132, 20 mai 2017, pp. 1–25.

Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, *J.O.*, L 193, 19 juillet 2016, pp. 1–14.

Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, *J.O.*, L 146, 3 juin 2016, pp. 8–21.

Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, *J.O.*, L-332, 18 décembre 2015, pp. 1–10.

Directive (UE) 2014/59 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive (CEE) 82/891 du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil (CE) 2001/24, (CE) 2002/47, (CE) 2004/25, (CE) 2005/56, (CE) 2007/36, (UE) 2011/35, (UE) 2012/30 et (UE) 2013/36 et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 1093/2010 et (UE) 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 173, 12 juin 2014, pp. 190–348.

Directive (UE) 2012/30 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 315 du 14 novembre 2012.

Directive (UE) 2012/17 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 156, 16 juin 2012, pp. 1–9.

Directive (UE) 2011/35 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes, *J.O.*, L 110, 29 avril 2011, pp. 1–11.

Directive (CE) 2009/133 du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre, *J.O.*, L 310, 25 novembre 2009, pp. 34–46.

Directive (CE) 2009/109 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions, *J.O.*, L 259, 2 octobre 2009, pp. 14–21.

Directive (CE) 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième

alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'E.E.E.), *J.O.*, L 258, 1er octobre 2009, pp. 11–19.

Directive (CE) 2009/65 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), version consolidée disponible sur https://eur-lex.europa.eu (07/11/2021).

Directive (CE) 2009/38 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'E.E.E.), *J.O.*, L 122, 16 mai 2009, pp. 28–44.

Directive (CE) 2007/63 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, *J.O.*, L 300, 17 novembre 2007, pp. 47–48.

Directive (CE) 2006/43 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L 157, 9 juin 2006, pp. 87–107.

Directive (CE) 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'E.E.E.), *J.O.*, L 310, 25 novembre 2005, pp. 1–9.

Directive (CE) 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, *J.O.*, L 142, 30 avril 2004, pp. 12–23.

Directive (CE) 2002/14 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, *J.O.*, L 80, 23 mars 2002, pp. 29–34.

Directive (CE) 2001/86 du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, *J.O.*, L 294, 10 novembre 2001, pp. 22–32.

Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, *J.O.*, L 82, 22 mars 2001, pp. 16–20.

Directive (CE) 98/59 du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, *J.O.*, L 225, 12 août 1998, pp. 16–21.

Directive (CE) 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, *J.O.*, L 18, 21 janvier 1997, pp. 1–6.

Directive (CEE) 90/434 du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, *J.O.*, L 225, 20 août 1990, pp. 1–5.

Directive (CEE) 88/361 du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, *J.O.*, 8 juillet 1988, pp. 5–18.

Sixième directive (CEE) 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions de sociétés anonymes, *J.O.*, L 378, 31 décembre 1982, pp. 47–54.

Troisième directive (CEE) 78/855 du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, *J.O.*, L 295, 20 octobre 1978, pp. 36 à 43.

Quatrième directive (CEE) 78/660 du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, § 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, *J.O.*, L 222, 14 août 1978, pp. 11–31.

Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, *J.O.*, L 61, 5 mars 1977, pp. 26–28.

Première directive (CEE) 68/151 du Conseil, du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, *J.O.*, L 065, 14 mars 1968, pp. 8–12.

1.1.4. *Autres documents législatifs européens*

1.1.4.1. *Résolutions*

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)), P8 TA-PROV(2019)0429, 18 avril 2019.

Résolution du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), P8_TA(2017)0248, 13 juin 2017.

Résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire (2011/2046(INI)), P7_TA(2012)0019, 2 février 2012.

Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société (2008/2196(INI)), P6_TA(2009)0086, 10 mars 2009.

1.1.4.2. *Règlements d'exécution*

Règlement d'exécution (UE) 2015/884 de la Commission du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), *J.O.*, L. 144, 10 juin 2015, pp. 1–9.

1.1.4.3. *Avis*

Avis de la Commission de l'emploi et des affaires sociales à l'intention de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement

européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)) (Rapporteure Anthea McIntyre), PE625.524v03-00, 21 novembre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).

Avis du Comité économique et social européen sur a) une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés [COM(2018) 239 final — 2018/0113 (COD)] et sur b) une proposition de directive modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières [COM(2018) 241 final — 2018/0114 (COD)] (Rapporteur Dimitris Dimitriadis), EESC 2018/01917, 17 octobre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).

Avis du Parlement européen du 16 novembre 1972 sur la proposition d'une troisième directive tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés, au sens de l'article 58 paragraphe 2 du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes, *J.O.*, C 129, 11 décembre 1972, pp. 50–57.

1.1.4.4. *Communications et communiqués*

Communiqué de presse du Conseil de l'Union européenne, « L'UE va faciliter la mobilité transfrontalière des entreprises », 27 mars 2019, disponible sur https://www.consilium.europa.eu (19/03/2020).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 octobre 2015, Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, COM(2015) 550 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (04/05/2018).

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 17 juin 2015, Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne : cinq domaines d'action prioritaires, COM(2015) 302 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (04/05/2018).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 12 décembre 2012, Plan d'action : droit européen des sociétés et gouvernance d'entreprise - un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), COM(2012) 740 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (11/06/2020).

1.1.4.5. *Propositions et projets*

Analysis of the final compromise text with a view to agreement on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions, ST 7426 2019 INIT, 22 mars 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions – Presidency compromise proposal, ST 5380 2019 INIT, 15 janvier 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions – Presidency compromise proposal, ST 15678 2018 INIT, 18 décembre 2018, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, COM (2018) 241 final, 25 avril 2018, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (15/02/2019).

Proposition de directive du Parlement et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux du 18 novembre 2003, COM(2003) 703 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (08/12/2017).

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 sur la loi applicable aux obligatoires non contractuelles ("Rome II"), COM(2003) 427 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu (07/11/2021).

Richtlinienvorentwurf zur Verlegung des Gesellschaftssitzes innerhalb der EU, Doc XV/6002/97, *ZIP*, 1997, pp. 1721–1724.

Proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du Traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, COM (84) 727 final, 23 janvier 1985.

Proposition modifiée d'une cinquième directive fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant la structure des sociétés anonymes et les pouvoirs et obligations de leurs organes du 19 août 1983, COM(83) 185 final, *J.O.*, C 240, 9 septembre 1983, pp. 2–38.

Projet de convention sur la fusion internationale de sociétés anonymes, *Bulletin des Communautés européennes*, suppl. 13/73.

Proposition d'une cinquième directive tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés, au sens de l'article 58 paragraphe 2 du traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers en ce qui concerne la structure des sociétés anonymes ainsi que les pouvoirs et obligations de leurs organes du 9 octobre 1972, COM(72) 887 final, *J.O.*, C 131, 13 décembre 1972, pp. 49–61.

Proposition d'une troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, au sens de l'article 58, paragraphe 2 du Traité, pour protéger les intérêts, tant des associés que des tiers, en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes du 5 juin 1970, COM (70)633, pp. 1–41.

1.1.4.6. *Notes*

Note du Secrétariat général du Conseil au Comité des représentants permanents et au Conseil, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations., fusions et scissions transfrontalières – Résultat de la première lecture du Parlement européen et procédure de rectificatif (Strasbourg, les 18 avril 2019 et 22 octobre 2019), ST 8499 2019 INIT, 29 octobre 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).

Note from the General Secretariat of the Council to the Permanent Representatives Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the

Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions, ST 5401 2019 INIT, 25 janvier 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).

1.1.4.7. *Rapports*

Rapport de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018–2018/0114(COD)) (Rapporteure Evelyn Regner), A8-0002/2019, 9 janvier 2019, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).

Projet de rapport du 15 décembre 2016 de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières, (2016/2065(INI)), disponible sur www.europarl.europa.eu (08/03/2017).

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique e social européen et au Comité des régions sur l'application du Règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE), COM/2012/072 final, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (15/11/2020).

Final report on the opportunities for the internationalisation of European SMEs, 2011, disponible sur https://publications.europa.eu (29/03/2019).

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), (COM(2010) 676 final – SEC(2010) 1391), 17 novembre 2010, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (25/10/2019).

Rapport final du Groupe de haut niveau d'experts en Droit des Sociétés (2002), disponible sur http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_fr.pdf (26/05/2016).

Rapport de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (COM(2003)0703 – C5-0561/2003–2003/0277(COD)) (Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne), P.E. Doc., A6-0089/2005 du 25 avril 2005, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (27/10/2017).

Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l'université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l'université de Paris I, *J.O.C.E.*, C 282, 31 octobre 1980.

1.1.4.8. *Études*

EWIV-Statistik des Europäischen EWIV-Informationszentrums (bei LIBERTAS – Europäisches Institut GmbH), disponible sur https://www.libertas-institut.com (15/11/2020).

Impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions of April

25, 2018, SWD(2018) 141 final, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (04/05/2018).

Assessment and quantification of drivers, problems and impacts related to cross-border transfers of registered offices and cross-border divisions of companies, EY, 5 février 2018, disponible sur https://ec.europa.eu (13/03/2020).

Study on minority shareholders protection, TGS Baltic, janvier 2018, disponible sur https://op.europa.eu (10/06/2020).

Study on the application of the cross-border mergers directive, Bech-Bruun, Lexidale, septembre 2013, disponible sur https://op.europa.eu (28/02/2020).

1.1.4.9. *Consultations*

Feedback statement to the 2017 public consultation on "EU Company Law upgraded: digital solutions and providing efficicient rules for cross-border operations of companies", 25 avril 2018, disponible sur http://ec.europa.eu (29/03/2019).

Consultation de la Commission européenne sur la modernisation du droit européen des sociétés : règles relatives aux solutions numériques et à l'efficacité des opérations transfrontalières lancée le 10 mai 2017 et clôturée le 6 août 2017, disponible sur http://ec.europa.eu (11/05/2018).

Feedback statement – Summary of responses to the public consultation on cross border mergers and divisions, October 2015, disponible sur http://ec.europa.eu (15/06/2016).

Feedback statement – Summary of responses to the public consultation on the future of European company law, July 2012, disponible sur http://ec.europa.eu (15/06/2016).

Consultation de la Commission européenne lancée le 20 février 2012 et clôturée le 14 mai 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés, disponible sur http://ec.europa.eu (11/05/2018).

1.1.4.10. *Déclarations*

Déclaration de l'Estonie sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, 8 novembre 2019, 13691/19 ADD1, disponible sur https://eur-lex.europa.eu (19/03/2020).

1.1.4.11. *Lettres*

ETUC letter on the proposal for a directive on the company law package to Commissioner Thyssen du 22 mai 2018, disponible sur https://www.etuc.org (23/07/2020).

1.2. Législation belge

1.2.1. *Codes, lois, conventions collectives de travail et autres normes*

Code des sociétés et des associations, disponible sur www.ejustice.just.fgov.be (21/11/2019).

Code de droit économique, disponible sur www.ejustice.just.fgov.be (21/11/2019).

Codes des sociétés,

Loi du 11 décembre 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre, modifiée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, *M.B.*, 12 janvier 2009.

Loi du 29 juin 1993 modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, *M.B.*, 21 juillet 1993.

Arrêté-loi belge du 23 août 1944 relatif au séquestre des biens, droits et intérêts ennemis, *Bull. usuel*, 1944, n° 107.

Arrêté-loi du 10 novembre 1918 relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens et intérêts appartenant à des sujets des nations ennemies, *Pasin.*, 1918, n° 132.

Convention collective de travail n° 32*bis* du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32*ter* du 2 décembre 1986, 32*quater* du 19 décembre 1989, 32*quinquies* du 13 mars 2002 et 32*sexies* du 27 septembre 2016, disponible sur http://www.cnt-nar.be (20/10/2017).

Norme de l'IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés du 16 mai 2014, disponible sur https://www.ibr-ire.be (01/09/2021), pp. 1–15.

1.2.2. *Travaux préparatoires*

Proposition de loi portant le Livre 5 "Les obligations" du Code civil, Doc., *Ch.*, 2020–2021, n° 55-1806/001.

Proposition de loi portant insertion du livre 5 "Les obligations" dans le nouveau Code civil, *Doc.*, Ch., 2018–2019, n° 54-3709/001.

Projet de loi introduisant le Code des sociétés et association et portant des dispositions diverses, avis du Conseil d'État, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54–3119/002.

Projet de loi introduisant le Code des sociétés et association et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 54–3119/001.

Projet de loi introduisant le Code des sociétés et associations et portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2017–2018, n° 51–3119/002.

Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différent ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre, modifiée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, *Doc.*, Ch., 2007–2008, n° 52–1398/001.

Projet de loi portant des dispositions diverses, *Doc.*, Ch., 2007–2008, n° 52–1012/001.

Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, *Doc.*, Ch., 1989–1990, 1214/1.

1.3. Législation luxembourgeoise

1.3.1. *Codes, lois et autres normes*

Code de commerce, disponible sur http://data.legilux.public.lu (22/11/2019).

Code du travail, disponible sur http://data.legilux.public.lu (07/11/2021).

Loi du 23 mars 2007 modifiant 1. La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 2. La loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, et 3. La loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle, disponible sur http://data.legilux.public.lu (27/06/2017).

Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, disponible en version coordonnée sur www.lbr.lu (07/11/2021).

Loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, disponible sur http://legilux.public.lu/ (16/10/2020).

Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, version consolidée disponible sur https://www.elvingerhoss.lu (07/11/2021).

Norme professionnelle NP2018-07 du 19 juin 2018 de l'IRE luxembourgeois sur les diligences professionnelles du réviseur d'entreprises dans le cadre des opérations de fusions et scissions, www.ire.lu (01/09/2021).

1.3.2. *Travaux préparatoires*

Lettre d'André PRÜM au gouvernement luxembourgeois du 12 novembre 2018, disponible sur https://gouvernement.lu (11/01/2019).

Procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2015 de la sous-commission « Modernisation du droit luxembourgeois des sociétés » de la Commission juridique, *Doc.*, Ch. des députés, 2014–2015, n° 5730, disponible sur https://chd.lu (26/09/2019).

Projet de loi relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital et portant transposition : (i) de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ; (ii) de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital et (iii) de la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855(CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, *Doc.*, Ch. des députés, 2007–2008, n° 5829, disponible sur https://chd.lu (26/09/2019).

Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, commentaire des articles, *Doc.*, Ch. des députés, 2001–2002, n° 499, disponible sur https://chd.lu (26/09/2019).

Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, *Doc.*, Ch. des députés, 1984–1985, n° 2897, disponible sur https://chd.lu (26/09/2019).

Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avis de la Chambre de commerce sur la fusion des sociétés anonymes, *Doc.*, Ch. des députés, 1984–1985, n° 2897, disponible sur https://chd.lu (26/09/2019).

Projet de loi modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avis de la Chambre de commerce relatif aux scissions des sociétés anonymes, *Doc.*, Ch. des députés, 1984–1985, n° 2897/02, disponible sur https://chd.lu (26/09/2019).

1.4. Législation allemande

1.4.1. *Codes, lois et autres normes*

Umwandlungsgesetz (UmwG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).

Bürgerlisches Gesetzbuch (BGB), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).

Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehment (VAG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (17/01/2020).

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).

Insolvenzordnung (InsO) du 5 octobre 1994, disponible sur www.gesetze-im-internet.de (07/11/2021).

Pfandbriefgesetz (PfandBG), disponible sur www.gesetze-im-internet.de (17/01/2020).

Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien (Aktiengesetz) du 30 janvier 1937, disponible sur http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1937&size=45&page=261 (16/10/2020).

1.4.2. *Travaux préparatoires*

Stellungnahme der Europäischen Kommission zu dem Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen c(201) 114 final, zu *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18.

Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM(2018) 241 final ; Ratsdok. 8561/18, *BT-Drs.*, 2018, n° 179/18.

Entwurf eines Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbau- und Entsorgungskosten im Kernenergiebereich (Rückbau- und EntsorgungskostennachhaftungsG), *BT-Drs.*, 2015, n° 18/6615.

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drucksache 16/2919 – Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, *BT-Drs.*, 2007, n° 16/4193.

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, *BT-Drs.*, 2006, n° 16/2919.

Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Europäischen Gesellschaft, zu Art. 1 (§§ 8, 13 SEAG), *BT-Drs.*, 2004, n° 15/3656.

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Europäischen Gesellschaft (SEEG), *BT-Drs.*, 2004, n° 15/3405.

Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG), *BT-Drs.*, 1994, n° 12/6699.

1.5. Législation suisse

1.5.1. *Codes, lois et autres normes*

Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, disponible sur https://www.admin.ch (07/11/2021).

Code des obligations suisse dans sa version en vigueur au 25 juin 2002, disponible sur https://www.admin.ch (12/12/2019).

Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, disponible sur https://www.admin.ch (07/11/2021).

1.5.2. *Travaux préparatoires*

Message du conseil fédéral suisse concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 13 juin 2000, n° 00.052, disponible sur https://www.admin.ch (12/12/2019), pp. 3995–4183.

1.6. Législation française

Code de commerce, disponible sur www.legifrance.gouv.fr (07/11/2021).

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (16/10/2020).

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, disponible sur www.legifrance.gouv.fr (06/01/2020).

Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code de commerce, disponible sur www.legifrance.gouv.fr (7/12/2017).

Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, disponible sur www.legifrance.gouv.fr (7/12/2017).

Position – recommandation AMF n° 2011/11. Opérations d'apport ou de fusion, disponible sur http://www.amf-france.org (19/06/2017), pp. 1–4.

1.7. Législation autrichienne

Österreichisches Aktiengesetz, disponible sur www.jusline.at (07/11/2021).

Österreichisches GmbH-Gesetz, disponible sur www.jusline.at (07/11/2021).

EU-Verschmelzungsgesetz, disponible sur www.jusline.at (07/11/2021).

Spaltungsgesetz (SpaltG), disponible sur www.jusline.at (07/11/2021).

Unternehmensgesetzbuch (UGB), disponible sur www.jusline.at (28/04/2017).

Arbeitsverfassungsgesetz (ArVG), disponible sur www.jusline.at (25/07/2020).

1.8. **Législation italienne**

Codice Civile, disponible sur www.altalex.com (18/07/2019).

1.9. **Législation danoise**

Danish Companies Act, disponible sur https://danishbusinessauthority.dk (18/07/2019).

1.10. **Législation chypriote**

Cypriot Companies Law, disponible sur www.fbscyprus.com (10/10/2019).

1.11. **Législation britannique**

Companies Act 2006, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019).

The Companies, Limited Liability Partnerships and Partnerships (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, disponible sur www.legislation.gov.uk (18/13/2021).

The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, disponible sur www.legislation.gov.uk (28/11/2019).

1.12. **Autres documents législatifs**

European Model Companies Act, 1st ed., 2017, disponible sur https://papers.ssrn.com (18/10/2019).

Principes d'UNIDROIT (version de 2016), disponibles sur https://www.unidroit.org (03/01/2020).

2. DOCTRINE

2.1. **Doctrine juridique en langue anglaise**

2.1.1. *Thèses et monographies*

BECK, G., *The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU*, Oxford, Hart Publishing, 2012.

CONWAY, G. *The Legal Limits of Legal Reasoning and the European Court of Justice*, Cambridge, CUP, 2012.

MALLIN, Chr., *Corporate governance*, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2007.

MARCIANO, Al., *Law and economics : a reader*, London, Routledge, 2009.

2.1.2. *Ouvrages généraux*

DAVIES, P., *Principles of modern company law*, 8th ed., Sweet & Maxwell, London, 2008.

WHISH, R. *Competition Law*, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2009.

2.1.3. *Articles et ouvrages collectifs*

ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, S., « Proposal regarding the use of digital tools and processes in company law: the practitioner's perspective », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 149–189.

ARMOUR, J., HANSMANN, H., KRAAKMAN, R. et PARGENDLER, M., « What is Corporate Law ? » in *The Anatomy of Corporate Law – A Comparative and Functional Approach*, 3e éd., Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 1–28.

ARMOUR, J., « Legal capital : an outdated concept ? », *EBOR*, 2006, pp. 5–27.

ARMOUR, J., « Who should make corporate law ? EC Legislation versus regulatory competition », ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge, *Working Paper* No. 307, 2005, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–52.

ARMOUR, J., « Share capital and creditor protection : efficient rules for a modern company law », *Modern Law Review*, 2000, pp. 355–378.

BACHNER, Th., « The battle over jurisdiction in European insolvency law », *ECFR*, 2006/3, pp. 310–329.

BARTMANN, St., « The adopted proposal for an EU Directive on cross-border operations: a realistic compromise », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 140–142.

BEBCHUK, L. A. et FERRELL, A., « Federalism and corporate law : the race to protect managers from takeovers », *Columbia Law Review*, vol. 99, n° 5, juin 1999, pp. 1168–1199.

BIERMEYER, Th. et MEYER, M., « European Commission proposal on corporate mobility and digitalization: between enabling (cross-border corporate) freedom and fighting the "bad guy" », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 110 et 111.

BIERMEYER, Th. et MEYER, M., « An empirical research on cross-border mergers at EU level » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 35–52.

BIERMEYER, Th. et MEYER, M., *Cross-border corporate mobility in the EU – Empirical findings 2020–1st edition*, disponible sur https://papers.ssrn.com (30/09/2021), pp. 1–172.

BIERMEYER, Th., « Shaping the space of cross-border conversions in the EU: between right and autonomy », *C.M.L.R.*, 2013, pp. 571–590.

BINARD, S. et SCHUMMER, L., « The case for further flexibility in matters of cross-border mobility », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 31–37.

BIRKMOSE, H. S., « Cross-border mergers: the Danish experience » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 275–294.

BLAUBERGER, M. et SCHMIDT, S., « The European Court of Justice and its political impact », *West European Politics*, 2017, pp. 907–918.

BÖCKLI, P., DAVIES, P., FERRAN, E., FERRARINI, G., GARRIDO, J., HOPT, K., PIETRANCOSTA, Al., PISTOR, K., SKOG, R., SOLTYNSINSKI, St., WINTER, J. and WYMEERSCH, Ed., *Response to the European Commission's Consultation on the Future of European Company Law*, May 2012, disponible sur http://ec.europa.eu (11/03/2016).

BRIDGLAND, N. et KULIŃSKA, M., « Brexit and EU corporate mobility », *C.J.*, 2018/2-3, pp. 59–66.

CARADET, B. et HERBERT, J., « Capital and financial markets », *I.B.L.J.*, 2001, 2, pp. 217–223.

CARY, W. L., « Federalism and corporate law : reflections upon Delaware », *The Yale Law Journal*, vol. 83, n° 4, mars 1974, pp. 663–705.

CHEFFINS, Br. et ARMOUR, J., « The past, present and future of shareholder activism by hedge funds », *Journal of Corporation Law*, 2011, vol. 37, n° 1, pp. 51–103.

CHRISTIE, A., « The new hedge fund activism : activist directors and the market for corporate quasi-control », Journal of corporate law studies, 2019, vol. 19, n° 1, pp. 1–41.

CORBISIER, I., « The implementation of the cross-border mergers directive in Luxembourg » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 401–409.

CORBISIER, I. et BERNARD, F., « Cross-border mobility within the EU and specifically in Luxembourg and Belgium: same destination, different roads », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 18–30.

Council of Bars and Law Societies of Europe, *Response to European Commission consultation on cross-border mergers and divisions*, 22 février 2015, disponible sur www.ccbe.eu (11/03/2016).

DAWSON, M., DE WITTE, Br. et MUIR, E. (dir.), *Judicial Activism at the European Court of Justice*, Northampton, Edward Elgar, 2013.

DIAS SIMOES, F., « Legal capital rules in Europe : is there still room for creditor protection », *I.C.C.L.R.*, 2013, 24(4), pp. 166–172.

ECKARDT, M., et KERBER, W., "Horizontal and Vertical Regulatory Competition in EU Company Law: The Case of the European Private Company (SPE)", *Andràssy Working Paper Series*, N° 28, 2013, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–24.

EIDENMÜLLER, H., « Free choice in international company insolvency law in Europe », *E.B.O.R.*, 2005, pp. 423–447.

ELDAR, O., et MAGNOLFI, L., « Regulatory Competition and the Market for Corporate Law », *Yale International Center for Finance Working Paper*, November 2015, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–67.

ENRIQUES, L., « Company Law Harmonization Reconsidered: What Role for the EC ? », *ECGI Working Paper Series*, N° 53, novembre 2005, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–27.

ENRIQUES, L. et GELTER, M., « Regulatory competition in European company law and creditor protection », *EBOR*, 2006, pp. 417–453.

ENRIQUES, L. et MACEY, L., « Creditors versus capital formation : the case against the European legal capital rules », *Cornell Law Review*, 2001, pp. 1165–1204.

EUROPEAN COMPANY LAW EXPERTS (ECLE), « The Commission's 2018 proposal on corporate mobility – An assessment », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 196–221.

FABRIS, D., « European companies' "mutilated freedom". From the freedom of establishment to the right of cross-border conversion », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 106–113.

FRANÇOIS, B., « Cross-border mergers in France » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 295–324.

FRANKENREITER, « Are Advocates General Political ? – Policy preferences of EU Member State governments and the voting behavior of members of the European Court of Justice », 20 février 2017, disponible sur https://www.ssrn.com (5/07/2019), pp. 1–38.

FRAZZANI, S., ANGELICI, C., HOFFMANN, J. MEDICI, S. et SCIAUDONE, F., *The Polbud judgment and the freedom of establishment for companies in the European Union : problems and perspectives*, Study for the JURI committee, PE 608.833, October 2018, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (04/05/2018), pp. 1–41.

GABOR, B., « Regulatory Competition in the Internal Market – Comparing Models for Corporate Law, Securities Law and Competition Law », Private Regulation Series, Cheltenham (UK), Edward Elgar, 2013, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016).

GARCIMARTÍN, F. et GANDÍA, E., « Cross-Border Conversions in the EU : The EU Commission Proposal », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 15–43.

GEENS, K. et WYCKAERT, M., « Cross-border mergers and minority protection – An open-ended harmonization », *Utrecht Law Review*, mars 2008, vol. 4, n° 1, pp. 40–52.

VAN GELDER, G., « The Polbud-case and new EU company law proposal: expanding the possibilities for cross-border conversions in Europe », *EC Tax Review*, pp. 260–266.

GELTER, M., « Centros, the Freedom of Establishment for Companies, and the Court's Accidental Vision for Corporate Law », *ECGI Working Paper Series*, N° 287, février 2015, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–36.

GELTER, M., « The Structure of Regulatory Competition in European Corporate Law », John M. Olin Centre for Law, Economics and Business, *Fellows' Discussion Paper Series*, N° 20, 7/2008, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–50.

GERNER-BEUERLE, C., MUCCIARELLI, F., SCHUSTER, E. et SIEMS, M., « Cross-border reincorporations in the European Union, the case for comprehensive harmonization », *Journal of Corporate Law Studies*, 2018, vol. 18, pp. 1–42.

GERNER-BEUERLE, C. et SCHUSTER, E., « The costs of separation : friction between company and insolvency law in the single market », *Journal of Corporate Law Studies*, octobre 2014, pp. 287–332.

GILOTTA, S., « The implementation of the cross-border mergers Directive in Italy: an overview with a critical assessment of dissenting shareholders' appraisal » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 379–400.

GRIMMEL, A., « Politics in Robes ? The European Court of Justice and the Myth of "Judicial Activism" », *Discussion Paper N° 2/11*, disponible sur https://www.ssrn.com (05/05/2019), pp. 3–27.

HANSEN, L., L., « Merger, moving and division across national borders – When case law breaks through and overtakes directives », *EBLR*, 2007, pp. 181–204.

HICKS, H., LEVERE, D. et STEVENSON, R., « Select cross-border tax issues in reverse morris trust transactions », *International Tax Journal*, November – December 2017, pp. 5–53.

HJI PANAYI, Chr., « Corporate Mobility in Private International Law and European Community Law: Debunking Some Myths », *Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies Research Paper*, N° 26/2009, pp. 1–79.

HORSLEY, Th., « Reflections on the role of the Court of justice as the motor of European integration : legal limits to judicial lawmaking », *C.M.L.R.*, n° 50, 2013, pp. 932–964.

JOHNSTON, A. et SYRPIS, Ph. « Regulatory competition in European company law after Cartesio », *E.L. Rev.*, 2009, 34(3), pp. 378–404.

KAHAN, M., « The State Competition for Incorporations », *ECGI Working Paper Series*, N° 263, août 2014, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–57.

KAHAN, M. et KAMAR, E., « The Myth of State Competition in Corporate Law », *Stanford Law Review*, 2002, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 679–749.

KELEMEN, R. D., « The political foundations of judicial independence in the European Union », *Journal of European Public Policy*, 2012, pp. 43–58.

KHAN, A., « Corporate mobility, market access and the internal market », *E.L. Rev.*, 2015, pp 371–390.

KIRCHMAIER, Th., « The Performance Effects of European Demergers », Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London, May 2003, disponible sur http://papers.ssrn.com (20/05/2016).

KIRCHNER, Chr., PAINTER, R. and KAAL, W., "Regulatory Competition in EU Corporate Law after Inspire Art: Unbundling Delaware's Product for Europe", *Law and Economics Working Paper Series*, N°LE04-001, 2004, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–49.

KNILL, Chr. et LEHMKUHL, D., « The National Impact of European Union Regulatory Policy: Three Europeanization Mechanisms », *European Journal of Political Research*, 2002, pp. 255–280.

KRAAKMAN, J., « Gatekeepers : the anatomy of a third-party enforcement strategy », *Journal of Law, Economics and Organization*, 1986, Vol. 2(1), pp. 53–104.

LATELLA, D., « The "COMI" concept in the revision of the European Insolvency Regulation », *ECFR*, 4/2014, pp. 479–494.

MANKOWSKI, P., « Does contract suffice to protect the creditors of a company and their interests ? » in M. LUTTER (Ed.), *Legal capital in Europe*, Berlin, De Gruyter Recht, 2006, pp. 394–410.

MARRISON, V., « Tracking stock », *I.C.C.L.R.*, 2000, 11(7), pp. 235–239.

MARTINEZ-ECHEVARRIA, Al., « The mutual influence between cross-border merger and common merger regimes in Spanish law » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 443–476.

MERDURO, N., (sous la direction de), *Law and economics: critical concepts in law*, London, Routledge, 2007.

MERKT, H., « Creditor protection through mandatory disclosure », *EBOR*, 2006, pp. 95–122.

MILMAN, D., « Schemes of arrangement and other restructuring regimes under UK company law in context », *Co. L.N.*, 2011, 3101, pp. 1–4.

MOCK, S., « The implementation of the cross-border mergers Directive (2005/56/EC) in Germany: a story of insufficiencies and (better) alternatives » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 325–342.

MORTELMANS, K., « The relationship between the Treaty Rules and Community Measures for the establishment and functioning of the Internal Market: towards a concordance rule ? », *C.M.L.R.*, 2002, pp. 1303–1346.

MÖSLEIN, Fl., « Back to the digital future ? On the EU Company Law Package's approach to digitalization », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 4 et 5.

MUCCIARELLI, F., « The hidden voyage of a dying Italian company, from the Mediterranean Sea to Albion », *ECFR*, 4/2012, pp. 571–579.

MUCHA, A. et RADWAN, Ar., « Cross-border mergers: the experiences from Poland » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 425–442.

MUKWIRI, J., « Cross-border mergers directive and its impact in the UK » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 477–503.

MÜLBERT, P., *A synthetic view of different concepts of creditor protection – or a high-level framework for corporate creditor protection*, ECGI – Law Working Paper n° 60, 2006, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–51.

DE NICOLA, N., « Actio pauliana and divisions (IGI v. Cicenia, C-394/18): not everything that is done, is well done », *ECLJ*, 2020, vol. 17, issue 3, pp. 97–101.

OMLOR, S., « Digitalization and EU Company Law: innovation and tradition in tandem », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 6–12.

PAPADOPOULOS, Th., « Reviewing the implementation for the cross-border mergers Directive » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 3–34.

PAPADOPOULOS, Th., « Experiences from the implementation of the cross-border mergers Directive in Cyprus » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 245–276.

PAPADOPOULOS, Th., « Experiences from the implementation of the cross-border mergers Directive in Greece » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 343–378.

PAPADOPOULOS, Th., « The Magnitude of EU Fundamental Freedoms: Application of the Freedom of Establishment to the Cross-Border Mergers Directive », *EBLR*, 2012, disponible sur http://papers.ssrn.com (19/05/2016), pp. 517–546.

PAPADOPOULOS, Th., « EU regulatory approaches to cross-border mergers: exercising the right of establishment », *E.L. Rev.*, 2011, 36(1), pp. 71–97.

PAYNE, J., « The role of the court in debt restructuring », *C.L.J.*, 2018, 77(1), pp. 124–150.

PIEPER, J., « European Cross-Border Mergers after SEVIC », *Comp. Law.*, 2009, 30(6), pp. 169–173.

POSNER, R. A., « Utilianarism, economics and legal theory », *The Journal of Legal Studies*, janvier 1979, vol. 8(1), pp. 103–140.

PROFKOLA, Kr., « Cross-border mergers between companies: Remaining practical problems after the 10th Council Directive of the European Union », 31 septembre 2008, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016), pp. 1–37.

RAAIJMAKERS, G. et OLTHOFF, Th., « Creditor protection in cross-border mergers ; unfinished business », *Utrecht Law Review*, vol. 4, 2008/1, pp. 34–39.

RASMUSSEN, H., *On Law and Policy in the European Court of Justice*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1986.

REYNOLDS, St., SCHERRER, A. et TRULI, E., « Ex-post assessment of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions », December 2016, PE 593.796, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (15/06/2017).

RICKFORD, J., « Legal approaches to restricting distributions to shareholders : balance sheet tests and solvency tests », *EBOR*, 2006, vol 7(1), pp. 135–179.

RICKFORD, J., « The proposed tenth company law directive on cross border mergers and its impact in the UK », *EBLR*, 2005, n° 16, pp. 1393–1414.

RICKFORD, J., « Reforming Capital – Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance », *EBLR*, 2004, n° 15, pp. 919–1027.

RINGE, W.-G., « Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment », *E.L. Rev.*, 2017, 42(2), pp. 270–279.

RINGE, W.-G., « Forum shopping under the EU Insolvency Regulation », *E.B.O.R.*, 2005, pp. 579–620.

RINGE W.-G., « Corporate Mobility in the European Union – a Flash in the Pan ? », *University of Oxford Legal Research Paper Series*, N° 34, 2013, disponible sur http://papers.ssrn.com (11/03/2016).

ROBERT-TISSOT, S. P., « Consent not to be unreasonably withheld », *Comp. Law*, 1997, 18(4), pp. 116–118.

ROEST, J., « Corporate Mobility – The involvement of employees », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 74–105.

SANTELLA, P., « Capital maintenance in the EU : is the Second Company Law Directive really that restrictive ? », *EBOR*, 2008, vol. 9(3), pp. 427–461.

SCHALL, A., « The forthcoming ECJ decision of the Kornhaas case – The final chapter of the European Traveller's Tales ? », *ECFR*, 2015, pp. 280–298.

SCHARPF, Fr., « Perpetual momentum: directed and unconstrained ? », *Journal of European Policy*, 2012, pp. 127–139.

SCHINDLER, C. P., « Cross-border mergers in Europe – Company Law is Catching-Up – Commentary on the ECJ's Decision on *Sevic Systems AG* », *ECFR*, 3/2006, pp. 109–119.

SCHMIDT, J., « Accomplishments and deficits of the Company Law Package », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 222–271.

SCHMIDT, J., « The mobility aspects of the EU Commission's Company Law Package : or – "The Good, the Bad and the Ugly" », *ECLJ*, February 2019, vol. 16, issue 1, pp. 13–17.

SCHMIDT, J., *Cross-border mergers and divisions, transfers of seat : Is there a need to legislate ?*, Juin 2016, PE 556.960, disponible sur http://www.europarl.europa.eu (15/06/2017).

SCHÖN, W., « The future of legal capital », *EBOR*, 2004, vol. 5(3), pp. 429–448.

SEPE, S., « Corporate agency problems and equity contracts », *Journal of Corporation Law*, 2010, vol. 36(1), pp. 113–182.

SERETAKIS, Al., « Appraisal rights in the US and the EU » in Th. PAPADOPOULOS (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 65–80.

SIEMS, M., « *Sevic*: beyond cross-border-mergers », *EBOR*, n° 8, 2007, disponible sur http://papers.ssrn.com (20/05/2016), pp. 307–316.

SINGHAL, S., « Financing of leveraged buy-outs », *Comp. Law.*, 2008, 29(12), pp. 355–359.

SPINDLER, G., « Digitalization and corporate law – A view from Germany », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 106–148.

TEICHMANN, Chr., « The Company Law Package – Content and State of Play », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 3–14.

UGLIANO, A., « The new cross-border merger directive : Harmonisation of European company law and free movement », *EBLR*, 2007, n° 18, pp. 585–617.

VELD, Chr. et VELD-MERKOULOVA, Y., « Value creation through spin-offs: a review of the empirical evidence », disponible sur http://papers.ssrn.com (20/05/2016).

VERBRUGH, M. A., « Implementation of the cross-border merger Directive in the Netherlands » in PAPADOPOULOS, Th. (coord.), *Cross-border mergers – EU perspectives and national experiences*, Cham, Springer, 2019, pp. 411–424.

VERNIMMEN, P., QUIRY, P., DALLOCCHIO, M., LE FUR, Y. et SALVI, A., *Corporate Finance – Theory and Practice*, Chichester, John Wiley & Sons, Ltd, 2005.

VOSSESTEIN, G. – J., « Transfer of the registered office – The European Commission's decision not to submit a proposal for a Directive », *Utrecht Law Review*, mars 2008, vol. 4, n° 1, pp. 53–65.

WEATHERHILL, S., « Harmonisation : how much, how little ? », *EBLR*, 2005, pp. 533–545.

WINNER, M., « Protection of creditors and minority shareholders », *ECFR*, 1-2/2019, pp. 44–73.

WINNER, M., « Creditor protection in mergers in Europe » in KOVÁCS, Er. et WINNER, M. (dir.), *Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues*, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp. 49–71.

WOUTERS, J., « European company law *: quo vadis* ? », *C.M.L.R.*, 2000, vol. 37, issue 2, pp. 257–307.

WYCKAERT, M. et JENNE, F., « Corporate mobility in a European context » in K. GEENS et K. J. HOPT (éd.), *The European Company Law Action Plan Revisited – Reassessment of the 2003 priorities of the European Commission*, Leuven, Leuven University Press, 2010, pp. 287–332.

WYMEERSCH, E., « Is a directive on corporate mobility needed ? », *EBOR*, mars 2007, vol. 8, n° 1, pp. 161–169.

ZHEN QU, Ch., « Sanctioning schemes of arrangement: the need for granting the court a curative power », *J.B.L.*, 2016, 1, pp. 13–29.

2.2. Doctrine juridique en langue française

2.2.1. *Thèses et monographies*

AYDOGDU, R. et CAPRASSE, O., *Les conflits entre actionnaires – Prévention et résolution*, Bruxelles, Larcier, 2010.

CLÉMENT-WILTZ, L. (dir.), *Le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles, Bruylant, 2018.

COMBET, M., *L'établissement des sociétés en droit de l'Union européenne – Contribution à l'étude de la création jurisprudentielle d'un droit subjectif*, Paris, mare & martin, 2017.

CORBISIER, I., *La société : contrat ou institution ?*, Bruxelles, Larcier, 2011.

CORBISIER, I. et BURBI, D., *Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 – Regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé*, Bruxelles, Larcier 2011.

DUPIN, C., *Les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux dans l'Union européenne – Aspects de droit social*, Neuilly S/Seine, LexisNexis, 2013.

ERNST, Ph. et VERSTRAELEN, J., *Réorganisations juridiques de sociétés*, coll. Etudes pratiques de droit fiscal, n° 16, Bruxelles, Kluwer, 2002.

LAGRANGE, F., *Nature juridique de la fusion des sociétés*, thèse, Paris II, 2001.

LAMON, H., *Acquisitions, financement et cessions d'entreprises – Instruments financiers, structures d'acquisition et mécanismes de contrôle sous l'angle fiscal, comptable et financier*, Bruxelles, Larcier, 2015.

LEDAIN SANTIAGO, R., *La circulation du cautionnement – Contribution à l'étude du transfert à titre particulier et de la transmission à titre universel du contrat de cautionnement*, Windhof, Promoculture, Larcier, 2014.

MENJUCQ, M., *Droit international et européen des sociétés*, 6e éd., Paris, L.G.D.J., 2021.

NGUYEN, T.-V.-N., *La protection des créanciers sociaux dans les opérations emportant transmission universelle de patrimoine*, thèse, Paris II, 2003.

RAFFRAY, R., *La transmission universelle du patrimoine des personnes morales*, Nouvelle bibliothèque de thèses, Paris, Dalloz, 2011, vol. 108.

ROUTIER, R., *Les fusions de sociétés commerciales – Prolégomènes pour un nouveau droit des rapprochements*, Paris, L.G.D.J., 1994.

SCHMEIDLER, J., *La protection des créanciers dans les fusions internationales de sociétés : droit international et comparé*, thèse de doctorat, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2011.

SIMONART, V., *La personnalité morale en droit privé comparé*, Bruxelles, Bruylant, 1995.

TILQUIN, Th., *Traité des fusions et scissions*, Bruxelles, Kluwer, 1993.

WALBROECK, M., *Droit international, intégration européenne et libre marché – Etudes de droit communautaire européen 1965–2008*, Bruxelles, Bruylant, 2011.

WAREMBOURG-AUQUE, F., *La succession aux biens d'une personne morale de droit privé*, thèse, Lille, 1977.

WESTENDORF, H., *Le transfert des sûretés*, Collection de thèses, Issy-les-Moulineaux, Defrénois, 2015, tome 54.

2.2.2. *Ouvrages généraux*

ANCEL, P., *Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois – Approche comparative*, Bruxelles, Larcier, 2015.

BLUMANN, Cl. et DUBOIS, L., Droit institutionnel de l'Union européenne, 5e éd., LexisNexis, Paris, 2013.

BOURASSIN, M., BREMOND, V. et JOBARD-BACHELLIER, M.-N., *Droit des sûretés*, 7e éd., Paris, Sirey, 2020.

CACHARD, O., *Droit international privé*, Bruxelles, Bruylant, 2018.

CHAUMONT, C., « Cours général de droit international public », *R.C.A.D.I.*, 1970/1, t. 129, pp. 333–528.

VAN CLEYNENBREUGEL, P., *Droit matériel de l'Union européenne – Libertés de circulation et marché intérieur*, Bruxelles, Larcier, 2017.

CULOT, H., CULOT, L., DE CORDT, Y., GOLLIER, J.-M., HANNOUILLE, A., KONINGS, N., MAGNUS, F., PARISIS, G., DE PIERPONT, G., VAN DE VELDEN, K. et WOLFF, S., *Société anonyme*, Bruxelles, Bruylant, 2014.

COZIAN, M., VIANDIER, Al. et DEBOISSY, Fl., *Droit des sociétés*, 34e éd., Paris, LexisNexis, 2021.

DEKLERCK, L. et BLOCKERYE, TH., *Plus-values et moins-values*, Bruxelles, Larcier, 2009.

DELVAUX, P., *La Société anonyme*, Luxembourg, 2007/2008.

HAINAUT-HAMENDE, P., *Les sociétés anonymes*, t. II, Bruxelles, Larcier, 2009.

LE CANNU, P. et DONDERO, Br., *Droit des sociétés*, 5e éd., Paris, LGDJ – Lextenso éditions, 2013.

MALHERBE, J., DE CORDT, Y., LAMBRECHT, Ph., MALHERBE, Ph. et CULOT, H., *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020.

MALHERBE, J., DE CORDT, Y., LAMBRECHT, Ph. et MALHERBE, Ph., *Précis de droit des sociétés*, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011.

DE PAGE, H., *Traité élémentaire de droit civil belge*, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1967.

POELMANS, Ol., *Droit des obligations au Luxembourg – Principes généraux et examen de jurisprudence*, Bruxelles, Larcier, 2013.

RAVARANI, G., *La responsabilité civile des personnes privées et publiques*, 3e éd., Luxembourg, Pasicrisie Luxembourgeoise, 2014.

RESTEAU, Ch., *Traité des sociétés anonymes*, 3e éd., Bruxelles, Swinnen, 1982.

RIGAUX, Fr. et FALLON, M., *Droit international privé*, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2005.

STEICHEN, Al., *Précis de droit des sociétés*, 6e éd., Luxembourg, éditions Saint-Paul, 2018.

THIRION, N. (sous la coordination de), *Droit international et européen des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2009.

VANDER ELST, R. et WESER, M., *Droit international privé belge et droit conventionnel international*, t. I, *Conflit de lois*, Bruxelles, Bruylant, 1983.

VAN OMMESLAGHE, P., *Traité de droit civil belge*, Bruxelles, Bruylant, 2013.

VAN OMMESLAGHE, P., *Droit des obligations*, Bruxelles, Bruylant, 2010.

VAN RYN, J., *Principes de droit commercial*, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1954.

WÉRY, P., *Droit des obligations*, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2016.

WÉRY, P., *Droit des obligations*, vol. 1, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2021.

WINANDY, J.-P., *Manuel de droit des sociétés*, Bertrange, Legitech, 2019.

2.2.3. *Articles et contributions à des ouvrages collectifs*

ALBERTINI, M., « Bouleversement du contrat par la crise : quelles clauses pour négocier ? », *Aides Pratiques et Ingénierie Sociétaire*, n° 111, Mai 2010, p. 5, disponible sur www.lexis360.fr (08/01/2020), pp. 1–5.

ALFANDARI, El. et JEANTIN, M., « Fusion de coopératives. Domaine d'application du droit d'opposition », *RTD com.*, 1993, p. 335, disponible sur www.dalloz.fr (06/12/2019), pp. 1 et s.

ALTER, C., BAR, S. et ROZENBERG, F., « Les effets du contrat », *Obligations. Traité théorique et pratique*, Bruxelles, Kluwer, septembre 2005, II.1.7–1 – II.1.7. – 180.

AMIEL-COSME, L., "Tryptique de la solidarité des sociétés, parties à un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions", Note sous Cour de cassation (com.) 8 février 2011, F-D, n° 10-273, Sté Hydraulique PB c/ Sté Duffort-Biguet Immobilier, *Rev. soc.*, 2012, pp. 33 et s.

ARSAN, I., « Que reste-t-il du critère du siège réel après l'arrêt Polbud ? », *Droit des sociétés*, n° 3, mars 2018, disponible sur http://www.lexisnexis.com (31/05/2018), pp. 1–13.

ATHLAN, L. et TORCK, St., « Les scissions transfrontalières », *Cah. dr. entr.*, n° 6, novembre 2011, dossier 36, pp. 1–10.

AUTENNE, Al. et DE WOLF, M., « La mobilité transfrontalière des sociétés en droit européen : le cas particulier du transfert de siège social, regards croisés de droit des sociétés et de droit fiscal », *Cah. dr. eur.*, 2007, pp. 647–694.

D'AVOUT, L., « Suites de la jurisprudence Centros: les sociétés off shore rattrapées par le droit local de l'insolvabilité », note sous C.J.U.E., 10 décembre 2015, aff. C-594/14, *La Semaine Juridique Edition Générale*, n° 11, 14 mars 2016, p. 304, disponible sur www.lexis360.fr (14/01/2020), pp. 1–8.

AYDOGDU, R., « Les procédures de résolution des conflits internes » in ANDRÉ-DUMONT, A.-P. et TILQUIN, Th., *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 280–314.

BEITZKE, G., « Les conflits de lois en matière de fusions de sociétés (droit communautaire et droit international privé) », *R.C.D.I.P.*, 1967, I, pp. 1–22.

BÉRARD, P.-Y., « Les fusions à l'épreuve de l'*intuitus personae* », *RTD com.*, 2007, p. 279, disponible sur www.dalloz.fr (09/01/2020), pp. 1–43.

BERNARD, F., « L'avènement des scissions transfrontalières », *D.A. O.R.*, 2018/3, n° 127, pp. 5–48.

BERNARD, Al., « Law and Economics: une science idiote ? », *Recueil Dalloz*, 2008, p. 2806, disponible sur www.dalloz.fr (02/01/2020), p. 1.

BIQUET-MATHIEU, C., « Soubresauts en matière d'imprévision. Les arrêts des 19 juin 2009 et 14 octobre 2010 », *Rev. Dr. ULg.*, 2012, pp. 239–257.

BOISSEAU, L., « La vague des scissions de sociétés touche l'Europe », *Les Echos*, 14 novembre 2017, disponible sur www.lesechos.fr (07/11/2021).

BOMPOINT, D., « Le droit de retrait des actionnaires minoritaires de sociétés cotées après la directive n° 2019/2121 sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières », *BJS*, juillet 2020, n° 07-08, disponible sur www.lextenso.fr (13/08/2020), pp. 1–3.

BONHOMME, R. et BOUTEILLE, M., « Fasc. F-250 : Clauses de variation de prix. – Guide de rédaction et exemples. – Formules », *JurisClasseur Contrats-Distribution*, 15 septembre 2012, pp. 1–16.

BONNEAU, Th., « Cautionnement », note sous Cass. com., 17 juillet 2001, *Droit des sociétés*, n° 11, novembre 2001, comm. 157.

BOONE, D. et PIETTE, Ch., « Fusion et rétroactivité », *JurisNews*, N° 7-8/2014, pp. 275–282.

BORGHETTI, J.-S., « Fixation et révision du prix », *RDC*, hors-série juin 2018, p. 25, disponible sur www.lextenso.fr (08/01/2020), pp. 1–11.

BROHEZ, A., DE SCHUTTER, K., DHAENE, M., GUBBELS, A., KETELS, L., PALMAERS, G. et SAELENS, F., *Les réorganisations transfrontalières, Evolutions législatives récentes en droit des sociétés, droit social et droit fiscal*, Waterloo, Kluwer, 2009.

BUCHER, E.-Ch., « Les clauses portant sur l'imprévision », *Contrats Concurrence Consommation*, n° 3, mars 2019, form. 3, disponible sur www.lexis360.fr (08/01/2020), p. 1–6.

LE CANNU, P., « La sécurisation des fusions : le maintien des cautionnements garantissant les créances de l'absorbée », note sous Cour de cassation (Com.) 8 novembre 2005, pourvoi n° 01-12.896, *RTD com.*, 2006, pp. 145 et s.

LE CANNU, « Cautions et fusions ; l'aubaine se fait plus rare », *BJS*, mars 2006, p. 345, disponible sur www.lextenso.fr (07/01/2020), pp. 1–3.

LE CANNU, P., « De la SA à la SAS, pourquoi transformer à l'unanimité si l'on peut fusionner à la majorité ? », *BJS*, 2005, pp. 557 et s.

CATHIARD, C., « Les nouvelles modalités du contrôle des opérations de transformations, fusions et scissions transfrontalières : s'assurer de l'absence de fins abusives, frauduleuses ou criminelles », *BJS*, juillet 2020, n° 07-08, disponible sur www.lextenso.fr (13/08/2020), pp. 1–3.

CARREAU, D. et LETRÉGUILLY, H., « Offres publiques : OPA, OPE, OPR », *Répertoire de droit commercial*, juin 2012, n° 479.

CHABOT, P.-A., « La transmission des sûretés immobilières », *Revue pratique de l'immobilier*, 2009/3, pp. 209–233.

CHEMINADE, Y. « Nature juridique de la fusion de sociétés anonymes », *RTD com.*, 1970, pp. 15 et s.

CLÉMENT-WILTZ, L., « Introduction : analyser juridiquement le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne », in CLÉMENT-WILTZ, L. (dir.), *Le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 13–35.

CLEVENBERGH, O., « Les changements significatifs défavorables ('Material Adverse Change') dans les contrats de cession d'actions ou d'actifs en droit belge », *RDC-TBH*, 2011/1, pp. 5–29.

COIPEL, M. et DAVAGLE, M., « Associations sans but lucratif », *Rép. not.*, Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 8, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 796, n° 1047.

COMBET, M., « Le renforcement du droit à transformation des sociétés dans le marché intérieur », *La Semaine Juridique*, n° 51, 18 décembre 2017, disponible sur http://www.lexisnexis.com (31/05/2018), pp. 1–9.

Commission des Normes Comptables belge, *Annuaire 2020 CNC*, Bruxelles, Larcier, 2020.

Commission des Normes Comptables belge, *Annuaire 2017 CNC*, Bruxelles, Larcier, 2017.

CONAC, P.-H., « Le retour du courage politique à Bruxelles : l'Odyssée du "Paquet droit des sociétés" de 2018 », *Rev. Soc.*, janvier 2019, pp. 7–9.

CONAC, P.-H., « Le retour du courage politique à Bruxelles : l'Odyssée du "Paquet droit des sociétés" de 2018 », *Rev. Soc.*, janvier 2019, pp. 31–41.

CONAC, P.-H., CORBISIER, I., DELCORDE, J.-A., GUILLAUME, Fl., MENJUCQ, M., RIASSETTO, I., SEIFERT, Ach., SPANG, J.-P., TILQUIN, Th. et WINANDY, J.-P., *Fusions transfrontalières de sociétés – Droit luxembourgeois et droit comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011.

CORBISIER, I., « Les nouvelles dispositions européennes en matière de mobilité transfrontalière : légitimation du retour à une certaine forme de protectionnisme ? », *RPS-TRV*, 2019, pp. 809 et 810.

CORBISIER, I., « Arrêt « Polbud » : la consécration de la *possibilité* d'un principe inconditionnel de libre mobilité », *J.D.E.*, 2018/4, pp. 135–137.

CORBISIER, I., « Arrêt Polbud de la C.J.U.E. : de la créature de droit national au sujet de droit de l'Union européenne », *RPS-TRV*, 2018, pp. 153 et 154.

CORBISIER, I., « L'arrêt *Polbud* de la C.J.U.E. ou le Luxembourg à la croisée des chemins – Maintien d'un critère de rattachement appliqué de manière ambiguë ou choix franc d'un libéralisme rendu possible par la Cour de justice ? », *J.T.L.*, 2018, pp. 33–39.

CORBISIER, I., « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *RPS-TRV*, 2017, pp. 416–468.

COUPET, C., « Fusion ou scission de la société créancière ou débitrice : même sort pour la caution », note sous Cass. com., 8 mars 2017, *Droit des sociétés*, n° 10, octobre 2017, pp. 21–24.

CROISANT, G., « Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 10/07/2019 », *RDC-TBH*, 2019/5, p. 701.

CULOT, H., « La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée », *RDC-TBH*, 2018/9, pp. 967–983.

CULOT, H. et THOUMSIN, P.-Y., « Contrôle et maintien du capital : une réforme sans audace », *J.T.*, 2009/6, pp. 93–99.

CULOT, H. et VAN BUGGENHOUT, M., « Droit européen des sociétés : vers une réforme du « capital » ? », *J.D.E.*, 2007/7, n° 141, pp. 193–200.

DABIN, L., « Régime juridique des marchés financiers et des valeurs mobilières », *Rép. not.*, Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 11, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 104.

DAL. G.-A. et VAN DEN ABBEELE, M., « Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993 » in *Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés*, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 11–74.

DAL. G.-A. et VAN DEN ABBEELE, M., « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, pp. 210–276.

DARIOSECQ, S. et MÉTAIS, N., « Les clauses d'exclusion, solution à la mésentente entre associés », *BJS*, septembre 1998, n° 9, p. 908, disponible sur www.lextenso.fr (04/11/2020), pp. 1–4.

DELABRUYÈRE, S., « Réflexions économiques sur l'Europe juridique et judiciaire », *Recueil Dalloz*, 2005, p. 1652, disponible sur www.dalloz.fr (02/01/2019), pp. 1–3.

DELAHAYE, A., « La scission d'une société », *R.P.S.*, 1985, pp. 141–161.

DELEBECQUE, Ph. et SIMLER, Ph., « Droit des sûretés », *La Semaine Juridique Edition Générale*, n° 42, 17 octobre 2001, disponible sur www.lexis360.fr (10/12/2019), pp. 1–16, n°s 1–60.

DELVAUX, Th., « Fusion internationale et liberté de circulation, note sous C.J.C.E. », 13 décembre 2005, n° C-411/03, *J.T.*, 2006, pp. 145–148.

DELVAUX, Th., « La concurrence entre ordres juridiques est-elle efficace ? Quelques réflexions à propos de la liberté d'établissement des sociétés – n° 6919 », *RPS*, 2004/3, pp. 207–273.

DÉMARE-LAFONT, S., « Les inégalités sociales en Mésopotamie : quelques précautions de vocabulaire », *Droit et cultures*, 69/2015-1, disponible sur https://journals.openedition.org (28/03/2019), pp. 1–13.

DEVLEESCHOUWER, D., « Le Nouveau Code des Sociétés et des Associations – Aperçu de quelques nouveautés concernant la gouvernance des sociétés anonymes », *IN FORO*, n° 62, 01/2019, pp. 11–26.

DEVOS, D., « La réparation du préjudice du créancier demandeur à l'action paulienne », *R.C.J.B.*, 1995, pp. 317–339.

DIEUX, X. et DE WOLF, P., « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : Capita Selecta », *J.T.*, 2019, pp. 501–527.

DROSS, W., « ART. 1341-2 – Fasc. unique : Régime général des obligations », *JurisClasseur*, 1er novembre 2016, nos 1–117.

DUBERTRET, M., « L'*intuitus personae* dans les fusions », *Rev. Soc.*, 2006, p. 721, disponible sur www.dalloz.fr, pp. 1–39.

DUBOUT, E., « Le libéralisme politique de la Cour de justice – Le cas de la liberté d'entreprise » in CLÉMENT-WILTZ, L. (dir.), *Le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 145–175.

DUFEU, Y., « Déterminants du choix d'intégration et de désintégration verticale des entreprises », *Finance Contrôle Stratégie*, mars 2008, vol. 11, n° 1, pp. 131–154.

DUMONT, A.-P., « Les titres et leur transfert » in NAVEZ, E.-J. (dir.), *Le nouveau droit des sociétés et associations*, *Le nouveau droit des sociétés et des associations*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 301–318.

ESPESSON-VERGEAT, B., « Le jeu des clauses d'agrément et de préemption lors de la transmission universelle du patrimoine de la société », *Recueil Dalloz*, 2003, pp. 1216 et s.

EVRARD, M. et VAN DER VAEREN, E., « Les fusions transfrontalières : un pas de plus vers une Europe harmonisée », *D.A. O.R.*, 2007, pp. 103–123.

FALLON, M. et NAVEZ, E.-J., « La transformation transfrontalière d'une société par transfert du siège statutaire après l'arrêt *Polbud* », *R.P.S.*, 2018, pp. 348–385.

FALLON, M. et WAUTELET, M., « Le nouveau droit européen de l'insolvabilité – Le règlement Insolvabilité II, pour une efficacité accrue des procédures transfrontières à la lumière de l'acquis », *J.T.*, 2017, pp. 589–605.

FONTEYN, J., « Ne dites plus "capital", dites "capitaux propres" », *RPS-TRV*, 2019/3, pp. 271–283.

GAVOTY, C. et ULLMANN, P., « L'absorption par une société par actions simplifiée exige-t-elle le consentement unanime des associés de la société absorbée ? », *BJS*, 2001, pp. 831 et s.

GEENS, K., « Les effets de la fusion » in *Les fusions et scissions internes de sociétés*, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 1993, pp. 133–164.

GEORGE, Fl., « La cession des contrats dans les transmissions d'universalité en droit belge » in *La transmission des obligations en droit français et en droit belge : approches de droit comparé.*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 1181–1283.

GERMAIN, M., « L'opposition en droit des sociétés », *LPA*, 4 avril 2007, p. 21, disponible sur www.lextenso.fr (05/12/2019), pp. 1–5.

GIBRILA, D. et AZARIAN, H., « Fasc. 1109 : Sociétés. – Transformation, fusion, scission et prorogation de la société », *JurisClasseur Commercial*, 1er septembre 2018, n° 1–119.

GLANSDORFF, Fr., « La force majeure », *J.T.*, 2019, pp. 355–358.

GOLDMANN, S. et LAGASSE, S., « Comment appréhender le déséquilibre contractuel en droit commun ? », in R. JAFFERALI (coord.), *Le droit commun des contrats. Questions choisies*, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 115–127.

HAFTEL, B., « Revirement et extension du champ de la « matière contractuelle » dans les relations à trois personnes », *RDC*, 2019/1, pp. 85–89.

HAINAUT-HAMENDE, P., « La société anonyme. Deuxième partie : Opérations sur le capital. Emissions publiques. Transformation. Fusion – Scission », *Rep. not.*, Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 3/2, Bruxelles, Larcier, 2009.

HAINAUT-HAMENDE, P. et RAUCQ, G., « La société anonyme. Première partie : constitution et fonctionnement », *Rép. not.*, Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 3/1, Bruxelles, Larcier, 2005.

HALLOUIN, J.-C., « La société de crédit absorbante peut continuer de bénéficier de la garantie dont la société de crédit absorbée bénéficiait (cautionnement) », *Recueil Dalloz*, 1998, pp. 183 et s.

HO-DAC, M., « L'affirmation d'un droit au transfert intra-européen du siège statutaire avec changement de loi applicable : un nouvelle donne pour la reconnaissance mutuelle des sociétés dans l'Union », *R.A.E.*, 2017/4, pp. 727–737.

HO-DAC, M., « Un pas supplémentaire en faveur de la mobilité européenne des sociétés : le droit au transfert de siège social avec changement de droit applicable », *R.A.E.*, 2012/3, pp. 653–660.

HORSMANS, G., « Les nullités et les sanctions » in *Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal*, éd. du jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles, 1993, pp. 215–261.

HOSS, P., « Les nouveaux droits des actionnaires » in *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 207–248.

HOUPIN, C., « De la situation des actionnaires et des créanciers, en cas de fusion de sociétés en ce qui concerne le règlement de la société absorbée », *Journ. soc.*, 1933, pp. 449 et s.

HOUTCIEFF, D., « La révision pour imprévision résiste-t-elle au droit des contrats spéciaux ? », *Gaz. Pal.*, 7 avril 2020, n° 14, p. 36, disponible sur www.lextenso.fr (08/01/2020), pp. 1–2.

HOUTCIEFF, D., « Le sort du cautionnement garantissant le bail en cas de fusion-absorption de la société créancière ou débitrice », *La Semaine Juridique Edition Générale*, n° 49, 7 décembre 2005, II 10170, disponible sur www.lexis360.fr (10/12/2019), pp. 1–8.

HOUTCIEFF, D., « Contribution à l'étude de l'*intuitus personae* – Remarques sur la considération de la personne du créancier par la caution », *RTD civ.*, 2003, pp. 3 et s.

HEYMANN, J., « Transformation transfrontalière d'une société et liberté d'établissement », *RCDIP*, 2013, pp. 236 et s.

IDOT, L., « Règlement « procédures d'insolvabilité » - Domaine de la lex fori concursu », note sous C.J.U.E., 10 décembre 2015, aff. C-594/14, Kornhaas, *Revue Europe*, février 2016, p. 1.

JAFFERALI, R., « Arrêt « Feniks » : action paulienne et compétence internationale à la lumière du règlement Bruxelles I*bis* », *J.D.E.*, 2019, pp. 252 et 253.

JEANTIN, M., « La transmission universelle du patrimoine d'une société », *Les activités et les biens de l'entreprise – Mélanges J. Derruppé*, Paris, Joly et Litec, pp. 287–300.

KEUTGEN, G. et TOSSENS, J.-F., « La situation des actionnaires et leurs recours » in *Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal*, éd. du jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles, 1993, pp. 115–160.

KEUTGEN, G., « La directive européenne sur les fusions nationales », *R.P.S.*, 1979, pp. 98–120.

KLEINER, C., « L'action paulienne peut relever du for contractuel », *Gaz. Pal.*, 19 février 2019, n° 7, pp. 77 et 78.

KLEINER, J., « Le transfert de siège social en droit international privé », *Journal du droit international privé*, n° 2, avril 2010, disponible sur www.lexis360.fr (06/11/2020), pp. 1–24.

KOROM, V., « La liberté d'établissement des personnes morales et l'affaire *Cartesio* : un pas en arrière ? », *R.L.D.A.*, mars 2009, pp. 10–16.

KOVAR, R., « La mobilité des sociétés dans l'espace européen », note sous C.J.C.E., 16 décembre 2008 (CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt), aff. C-210/06, *Recueil Dalloz*, février 2009, pp. 465–470.

LAMON, H. « Les transferts de siège vers et en dehors de la Belgique » in *Les fusions transfrontalières d'entreprises*, Bruxelles, Séminaire Vanham & Vanham du 26 avril 2007, pp. 1–51.

LAMON, H., « Emigration ou immigration de sociétés sous l'angle juridique belge et communautaire : tout est-il permis ? », *R.G.F.*, 2005/5, pp. 2–13.

LECOURT, B., « Chronique de droit européen des sociétés – Evènement historique en droit européen des sociétés : adoption de la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », *Rev. Soc.*, mai 2019, pp. 360–364.

LECOURT, B., « La réforme du régime des fusions transfrontalières », *Rev. Soc.*, janvier 2019, pp. 24–31.

LECOURT, B., « Chronique de droit européen des sociétés – Les droits des actionnaires minoritaires au sein de l'Union européenne », *Rev. Soc.*, novembre 2018, n° 11, pp. 677 à 684.

LECOURT, B., « Décret n° 2006-448 du 14 avril 2006 relatif à la société européenne », *Rev. Soc.*, 2006, p. 439, disponible sur www.dalloz.fr (06/12/2019), pp. 1–3.

LECOURT, B., « Adoption de la directive sur les fusions transcommunautaires », *Rev. Soc.*, 2005, p. 923, disponible sur www.dalloz.fr (06/12/2019), pp. 1–4.

LECOURT, B., « L'avenir du droit français des sociétés », *Rev. Soc.*, 2004, p. 223, disponible sur www.dalloz.fr (06/12/2019), pp. 1–25.

LECOURT, B., « De l'utilité de l'action paulienne en droit des sociétés », *Aspects actuels du droit des affaires. Mélanges en l'honneur de Yves Guyon*, Dalloz, Paris, 2003, pp. 615–656.

LEGEAIS, D., « Dettes nées après la fusion-absorption », note sous Cass. com., 17 mai 2017, *Revue de droit bancaire et financier*, juillet – août 2017, comm. 162.

LEGEAIS, D., « Sort du cautionnement garantissant le bail en cas de fusion-absorption de la société créancière ou débitrice », note sous Cass. com., 8 novembre 2005 et Cass. com., 8 novembre 2005, *La Semaine Juridique – Entreprise et Affaires*, n° 1, 5 janvier 2006, p. 1 000, disponible sur www.lexis360.fr (10/12/2019), pp. 1–7.

LENAERTS, K., « Le concept d'abus de droit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de fiscalité directe » in *L'Europe au présent !*, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 825–851.

LENCOU, D. et MENJUCQ, M., « Les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux : enfin une réalité, mais des difficultés persistantes ! », *Recueil Dalloz*, avril 2009, pp. 886 et s.

LEUNEN. C.-A., L'HOMME, T. et FILBICHE, J., « Augmentations de capital dans les sociétés cotées, clauses de changement de contrôle et assistance financière » in *L'impact du nouveau droit des sociétés sur la gouvernance des institutions financières et sur les transactions financières - De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de governance van financiële instellingen en op financiële transacties*, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 201–233.

LIBCHABER, R., « Les équilibres propres à l'action paulienne », *RDC*, 2019/1, pp. 53–55.

LIENHARD, Al., « Confirmation de la validité des clauses soumettant à agrément les fusions-absorptions », *Recueil Dalloz*, 2003, pp. 1438 et s.

LIENHARD, Al., « Conditions de maintien du cautionnement en cas de fusion ou de scission de la banque bénéficiaire », *Recueil Dalloz 2001*, pp. 2414 et s.

LIMPENS, A., « Le cautionnement de dettes futures donnerait-il naissance en droit belge à une obligation de couverture ? », *R.C.J.B.*, 2001, pp. 141–165.

LUBY, M., « Impromptu sur la directive n° 2005/56 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux », *Droit des sociétés*, n° 6, juin 2006, étude 11, pp. 1–6.

LUBY, M., « Liberté d'établissement des sociétés et fusions transfrontalières », *Recueil Dalloz*, 2006, disponible sur www.dalloz.fr (15/06/2016), pp. 1–10.

MAHIEU, M., « L'interprétation du droit communautaire » in M. VAN DE KERCHOVE (dir.), *L'interprétation en droit – approche pluridisciplinaire*, Bruxelles, Presses de l'Université Saint-Louis, 1978, pp. 241–265.

MALHERBE, Ph., « Allègements et développements en matière de fusions » in *Droit des sociétés – Millésime 2011*, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 341–359.

MAQUET, S. et WILLERMAIN, D., « Les restructurations des sociétés : de la théorie à la pratique » in NAVEZ, E.-J. (dir.), *Le nouveau droit des sociétés et associations*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 453–527.

MAQUET, S., « Les fusions transfrontalières en droit belge des sociétés » in *Actualités en droit des sociétés*, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 31–71.

MARESCAU, Kr. et FINK, A., « Mobilité transfrontalière des sociétés et concurrence réglementaire au niveau du droit des sociétés », *R.P.S.*, 2014/2, pp. 193–244.

MARTY, R., « Cautionnement de dettes futures et fusion-absorption de sociétés », *La Semaine Juridique – Entreprises et Affaires*, n° 22, 31 mai 2018, pp. 37–40.

MASSET, E., « Avec le nouveau Code des sociétés et associations, la responsabilité des administrateurs est adaptée », *La semaine fiscale*, n° 378, mai 2019, pp. 1 et 2.

MASTRULLO, Th., « La protection des créanciers dans la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés », *BJS*, juillet 2020, n° 07-08, p. 63, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–3.

MASTRULLO, Th., « Les scissions transfrontalières », *BJS*, n° 07-08, p. 456, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–8.

MASTRULLO, Th., « Champ d'application matériel : première rencontre entre le droit européen des procédures d'insolvabilité et le droit d'établissement des sociétés », *Revue des procédures collectives*, n° 6, novembre 2016, comm. 171, disponible sur www.lexis360.fr (14/01/2020), pp. 1–6.

MASTRULLO, Th., « Critères et date d'appréciation du centre des intérêts principaux : les précisions de l'arrêt Interedil Srl », *Rev. Soc.*, 2012, pp. 120–122.

MAITROT DE LA MOTTE, A., « Les spécificités de la libre circulation des capitaux : l'exemple de la contestation des entraves fiscales » in *L'unité des libertés de circulation*, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 289–329.

MELIN, F., « Déplacement de siège social dans la Communauté européenne », note sous C.J.C.E., 16 décembre 2008 (CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt), aff. C-210/06, *J.C.P. E.*, 2009, pp. 42–45.

MENJUCQ, M., « Les transformations transfrontalières », *BJS*, juillet 2018, n° 07-08, p. 450, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–8.

MENJUCQ, M., « Les scissions transfrontalières », *Rev. Soc.*, janvier 2019, pp. 17–24.

MENJUCQ, M., « La Cour de justice libéralise la transformation transfrontalière de sociétés », *La Semaine Juridique*, n° 3, 18 janvier 2018, disponible sur http://www.lexisnexis.com (31/05/2018), pp. 1–9.

MENJUCQ, M., « Une nouvelle étape dans la libéralisation des fusions transfrontalières », note sous Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2017, n° C-14/16, Euro Park Service c/ Ministre des finances et des comptes publics, *Rev. Soc.*, juillet-août 2017, pp. 435–438.

MENJUCQ, M., « La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux » in *Fusions transfrontalières de sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 15–26.

MENJUCQ, M., « Les opérations transfrontalières de rapprochement et de mobilité à l'épreuve de la diversité des droits nationaux », *Cah. dr. entr.*, n° 6, novembre 2011, dossier 34, disponible sur www.lexis360.fr (06/11/2020), pp. 1–10.

MORELLI, N., « Le sort du cautionnement dans les opérations de fusion », *BJS*, juillet 2004, p. 932, disponible sur www.lextenso.fr (07/01/2020), pp. 1–10.

MOULIN, J.-M., « Fusion, scission et apport partiel d'actif », *Répertoire de droit des sociétés*, Paris, Dalloz, janvier 2011, pp. 1–111.

MOURLON BEERNAERT, F., « *Intuitus personae* et sociétés », *RPS-TRV*, 2017/3, pp. 274.

LE NABASQUE, H., « Les fusions et les scissions transfrontalières », *Rev. Soc.*, 2013, pp. 412–415.

LE NABASQUE, H., « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », *Rev. Soc.*, 2008, pp. 493–530.

NAVEZ, A., « Chapitre 4 – La société à responsabilité limitée » in NAVEZ, E.-J. (dir.), *Le Code des sociétés et associations*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 99–168.

NAVEZ, E.-J. et NAVEZ, A., « Chapitre 12 – Les réorganisations de personnes morales », in NAVEZ, E.-J. (dir.), *Le Code des sociétés et associations*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 329–358.

NELISSEN GRADE, J.-M., « La réalisation de la fusion – Les opérations conduisant à la fusion » in *Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal*, Bruxelles, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 1993, pp. 71–133.

NICOLAS, Al. « Hardship : prévoir l'imprévisible », *C.J.*, 2013/3, pp. 92–94.

NIHOUL, P. et LAGASSE, D., « Les permis d'urbanisme et de bâtir », in *L'urbanisme dans les actes*, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 339–411.

NOTARNICOLA, S., « À propos de l'action paulienne : quand le créancier poursuit la condemnation du tiers acquéreur au paiement des sommes dues par le débiteur indélicat », note sous Anvers, 3 janvier 2005, *R.G.D.C.*, 2008, pp. 167–171.

OST, F., « L'interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur » in VAN DE KERCHOVE, M. (dir.), *L'interprétation en droit – approche pluridisciplinaire*, Bruxelles, Presses de l'Université Saint-Louis, 1978, pp. 66–129.

OUDIN, M., « La transmission des contrats de distribution », *RTD com.*, 2011, pp. 447 et s.

PARLEANI, G., « Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux ou « transformations transfrontalières » », *Rev. Soc.*, janvier 2019, pp. 9–17.

PARLEANI, G., « Le transfert du siège », *Rev. Soc.*, 2013, p. 408, disponible sur www.dalloz.fr (03/08/2018), pp. 1–15.

PARLEANI, G., « L'arrêt *Cartesio* ou l'ingénieuse incitation à la migration intra communautaire des sociétés », note sous C.J.C.E., 16 décembre 2008 (CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt), aff. C-210/06, *Rev. Soc.*, 2009, pp. 147–162.

PARREIN, Fl., « De wet van 8 Juni 2008 en de grensoverschrijdende fusie », *RW*, 23 octobre 2010, n° 8, pp. 306–320.

PASTEGER, D., « Arrêt *Cartesio* : nouvelles précisions sur les modalités de transfert du siège social au regard de la liberté d'établissement », *J.T.*, 2009, pp. 794–798.

PATARD, D. « Notion de créancier public », *Rép. not.*, tome XIII, La procédure notariale, Livre 4/12, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, n° 171.

PHILIPPE, D., « L'introduction de l'imprévision en droit belge » in *Le droit des affaires en évolution – Le droit civil en mouvement / Tendensen in het bedrijfsrecht – Het burgerlijk recht in beweging*, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 55–68.

PHILIPPE, D., « À propos du déséquilibre du contrat et de l'obligation de renégociation », note sous Mons, 30 mai 2013, *J.L.M.B.*, 2014/23, pp. 1083–1094.

PHILIPPE, D., « Chapitre 6 – Les clauses relatives au changement de circonstances dans les contrats à long terme », in *La rédaction des contrats internationaux*, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 143–191.

PHILIPPE, D., « La force majeure et le hardship » in *Les principes UNIDROIT relatifs aux contrats de commerce international (Ed. 2010) et l'arbitrage / De UNIDROIT-principes inzake internationale handelscontracten (editie 2010) en arbitrage*, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 97 - 124.

PHILIPPE, D., « L'imprévision », *J.T.*, 2007/35, pp. 738–741.

PHILIPPE, D.-E. et PHILIPPE, D., « Transmission *ut universi en cas d'*opérations de restructuration d'entreprises : principe et exceptions » in *Obligations. Traité théorique et pratique*, Bruxelles, Kluwer, 2014, pp. 103–127.

PICOT, F., « Investissements et libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne », *RAE*, 2014/4, pp. 669–687.

POIRMEUR, Y., « Comprendre la « justice politique » au niveau européen », in L. CLÉMENT-WILTZ (dir.), *Le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 55–72.

Position – recommandation AMF n° 2011/11. Opérations d'apport ou de fusion, disponible sur http://www.amf-france.org (19/06/2017), pp. 1–4.

POTTIER, E. et LEFÈVRE, F., « La responsabilité des organes » in PIERRE, A., DUMONT, A. et TILQUIN, Th. (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 174–199.

POTTIER, E. et WYCKAERT, M., « Fusions et scissions transfrontalières : perspectives, contraintes et alternatives », in *Les restructurations d'entreprises sous l'angle fiscal*, Séminaire Vanham & Vanham, 18 novembre 1999.

PRÜM, A., « Faut-il réformer le droit luxembourgeois des contrats ? - Contribution pour les Mélanges en l'honneur du professeur Claude Witz », Luxembourg Faculty of Law, Economics and Finance, Law working paper series, Paper number 2018-005, 2 mai 2018, disponible sur https://papers.ssrn.com (14/01/2020), pp. 1–23.

PRÜM, A., « Fusions de banques et survie des cautionnements consentis en faveur des établissements absorbés », *Revue de droit bancaire et financier*, n° 1, janvier 2006, alerte 1.

RÉMERY, J.-P., « L'application à une filiale du règlement communautaire relatif aux procédures d'insolvabilité », *Rev. Soc.*, 2006, pp. 371–381.

RENAULD, J. et KEUTGEN, G., « Obstacles à une concentration internationale des entreprises dans le cadre de la C.E.E. », *R.P.S.*, 1970, n° 5606, pp. 269–292.

RIASSETTO, I., « Les dirigeants de sociétés » in G. RAVARANI, (sous la direction de), *La responsabilité civiles des personnes privées et publiques*, Luxembourg, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, pp. 645–654.

RUE, G., « Les clause de changement de contrôle », *B.J.S.*, 2011/459, p. 15.

RUPPERT, D., « La mobilité des sociétés », in *Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 162–174.

SCHLUMBERGER, E., « Le sort des associés dans les opérations de mobilité transfrontalière », *BJS*, juillet 2020, n° 07-08, p. 52, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–4.

SCHLUMBERGER, E., « Les fusions transfrontalières », *BJS*, juillet 2018, n° 07-08, p. 463, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–9.

SCHLUMBERGER, E., « Droit européen des sociétés (octobre 2015 – mars 2016) », *Rev. soc.*, juillet 2016, pp. 11–15.

SCHMITT, A., « Regards sur les transferts d'actifs, de branche d'activité et d'universalité (articles 308*bis*-1 à 5 de la loi sur les sociétés commerciales), *ACE*, 2014/3, pp. 18–25.

SEIFERT, A., « Comment recodifier le dialogue social au sein de l'entreprise ? », *J.T.L.*, 17/2011, pp. 117–122.

SEIFERT, A., « L'implication des travailleurs dans une fusion transfrontalière », *in* P.-H. CONAC (sous la dir. de), *Fusions transfrontalières de sociétés – Droit luxembourgeois et droit comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 121–142.

SIBONY, A.-L., « La transformation transfrontalière d'une société est une modalité d'établissement », *RTD eur.*, 2013, pp. 181–188.

SIMONART, V., « L'ordre public et le droit des sociétés », *RDC-TBH*, 1994, pp. 96–130.

SIMONART, V., « L'ordre public et le droit des sociétés » in ROMAIN, J.-F., *L'ordre public : concept et applications*, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 81–136.

SOTIROPOULOU, A., « Réflexions sur l'abus et la fraude en matière de transformations transfrontalières des sociétés », *BJS*, juin 2020, n° 120/5, p. 54, disponible sur www.lextenso.fr (07/11/2021), pp. 1–9.

SPANG, J.-P., « La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois : regard du praticien » in *Fusions transfrontalières de sociétés – Droit luxembourgeois et droit comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 81–97.

SPIELMANN, D. et DUPONG, H., « Quelques réflexions sur la théorie de l'imprévision », in *Le bicentenaire du Code civil : une contribution luxembourgeoise*, Luxembourg, Portalis, 2008, pp. 145–164.

STOFFEL-MUNCK, Ph., « L'imprévision et la réforme des effets du contrat », *RDC*, hors-série avril 2016, p. 30, disponible sur www.lextenso.fr (08/01/2020), pp. 1–8.

TENENBAUM, Al., « Action paulienne et détachement des travailleurs : nouveautés jurisprudentielle et législative », *RDC*, 2019/1, pp. 154–158.

TILLEUX, A. et WEEMAELS, E., « Les nouvelles obligations en matière de fusions et de scissions – Le droit des sociétés se prépare à entrer dans le XXIe siècle », *J.T.*, 2 mars 2013, n° 6511, pp. 145–157.

TILQUIN, Th. et DELCORDE, J.-A., « Les restructurations transfrontalières en droit belge » in *Fusions transfrontalières de sociétés – Droit luxembourgeois et droit comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 169–232.

TILQUIN, Th., DELCORDE, J.-A., MALHERBE, Ph., GARABEDIAN, D. et GEEREBAERT, P., « Les fusions transfrontalières », *Cah. jur.*, 2010/2, pp. 29–40.

TILQUIN, Th., « L'arrêt KA Finanz AG : la fusion transfrontalière et la protection des créanciers », *RDC-TBH*, 2018/1, pp. 64–70.

TILQUIN, Th. et DELCORDE, J.-A., « La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit belge après la transposition de la directive 2005/56/CE », *R.P.S.*, 2009, pp. 7–100.

TILQUIN, Th., « Fusions et scissions – Aspects transfrontaliers », *Joly Sociétés – Traité*, 30 juin 2006, pp. 1–27.

TILQUIN, Th., « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, pp. 5–56.

TILQUIN, Th., « Le transfert d'une universalité ou d'une branche d'activité », *J.T.*, 1996, pp. 493–509.

T'KINT, F. et CORBISIER, I., « La transmission des contrats et la protection des créanciers » in *Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés*, Centre Jean Renauld, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 161–213.

TOADER, C., « Méthodes d'interprétation en droit de l'Union européenne en matière de protection du consommateur : une approche pratique » in KRONENBERGER, V., D'ALESSIO, M. T. et PLACCO, V. (coord.), *De Rome à Lisbonne : les juridictions de l'Union européenne à la croisée des chemins*, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 441–458.

TUBEUF, C., « Enrichissement sans cause, gestion d'affaires et "*culpa in contrahendo*" », *RDC-TBH*, 2006/8, pp. 535–548.

VAMPARYS, X., « Fusions et transmissibilité des conventions conclues *intuitu personae* », *BJS*, mai 2006, p. 591, disponible sur www.lextenso.fr (07/01/2020), pp. 1–3.

VAN OMMESLAGHE, P., « La proposition de troisième directive sur l'harmonisation des fusions de sociétés anonymes », in *Quo vadis, ius societatum ? – Liber Amicorum Pieter Sanders 21 september 1912–1972*, s.l., Kluwer – Deventer Martinus Nijhoff – 'S-Gravenhage, 1972.

VAN OMMESLAGHE, P., « Les principes généraux relatifs à la fusion et à la scission selon les directives et les lois nouvelles » in *Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal*, éd. du jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles, 1993, pp. 1–69.

VAN OMMESLAGHE, P., « Les fusions transfrontalières de sociétés selon la directive communautaire du 26 octobre 2005 » in *Les fusions transfrontalières d'entreprises*, Bruxelles, Séminaire Vanham & Vanham du 26 avril 2007, pp. 1–40.

VAN OMMESLAGHE, P. et DIEUX, X., « Examen de jurisprudence (1979 à 1990) – les sociétés commerciales », *R.C.J.B.*, 1992, pp. 573–705.

VAN RYN, J. et VAN OMMESLAGHE, P., « Examen de jurisprudence des sociétés commerciales », *R.C.J.B.*, 1973, pp. 511–572.

VAN RYN, J. et VAN OMMESLAGHE, P., « Examen de jurisprudence des sociétés commerciales », *R.C.J.B.*, 1967, pp. 277–393.

VAN RYN, J., « Conséquences juridiques du transfert en Belgique du siège social d'une société étrangère et du transfert à l'étranger d'une société belge », note sous cass., 12 novembre 1965, *R.C.J.B.*, 1966, pp. 399–410.

VERDURE, Chr., « La réglementation des fusions transfrontalières : une nouvelle étape dans la modernisation du droit européen des sociétés », *RDIDC*, 1/2008, pp. 95–124.

VERMEYLEN, J., « Arrêt "Vale Epítesí" : la mobilité transfrontalière du siège statutaire est-elle un droit ? », *J.D.E.*, 2012/9, pp. 276–278.

VIVANT, M. « Fasc. 4900 – Régime international », *JCl. Brevets*, 6 juin 2018, n°s 1–110.

VOGEL, L. et VOGEL, J., « Possibilités, limites et exclusions du recours à la théorie de l'imprévision dans la crise du Covid-19 », *AJ contrat*, 2020, p. 275, disponible sur www.dalloz.fr (04/11/2020), pp. 1–7.

VOGEL, L., « Titre 3 – Libre circulation des capitaux » in *Traité de droit économique – Tome 4 : Droit européen des affaires*, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 297–317.

VON KUEGELGEN, M., « La cession des permis d'urbanisme, de lotir et d'urbanisation », *Jurim Pratique*, 2012/2, pp. 335–377.

WÉRY, P., « L'action paulienne, sa nature juridique et ses rapports avec la réparation en nature en matière extra-contractuelle », note sous Cass., 26 avril 2013, *R.C.J.B.*, 2015/1, pp. 66–102.

WÉRY, P., « La théorie générale du contrat », *Rép. not.*, Tome IV, Les obligations, Livre 1/1, Bruxelles, Larcier, 2010.

M. WESTRADE, « L'apport en nature : quelques réflexions relatives à son déroulement pratique », *C.J.*, 4/2009, pp. 100–103.

WILLERMAIN, D., « Restructuration de sociétés : première analyse du Livre 12 du CSA » in GEENS, K. et HORSEMANS, G., *Le projet de Code des sociétés et associations – Het ontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen*, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 323–343.

WILLERMAIN, D., « Les fusions transfrontalières de sociétés », *J.T.*, 10 octobre 2009, n° 6365, pp. 581–592.

DE WOLF, M., « Les aspects comptables et révisoraux du nouveau droit des fusions et scissions de sociétés » in *Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal*, éd. du jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles, 1993, pp. 259–308.

2.3. Doctrine en langue allemande

2.3.1. *Thèses et monographies*

ALLMENDINGER, Chr., *Die Beschlussfassung zum grenzüberschreitenden Wegzug im Binnenmarkt*, Baden-Baden, Nomos, 2016.

BEHRENS, Fr., *Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach der Richtlinie 2005/56/EG (Verschmelzungsrichtlinie)*, Göttingen, Cuvillier Verlag, 2007.

BEUTEL, D., *Der neue rechtliche Rahmen grenzüberschreitender Verschmelzungen in der EU – Einflüsse des Gemeinschaftsrechts auf die Schaffung nationaler Rechtsgrundlagen grenzüberschreitender Verschmelzungen unter Beteiligung deutscher Kapitalgesellschaften*, München, Herbert Utz Verlag, 2008.

VON BISMARCK, W., *Grenzüberschreitende Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften in Europa – Gestaltungsvorschläge für eine 14. gesellschaftsrechtliche Richtlinie*, 2005, Frankfurt am Main, Peter Lang.

CASCORBI, A., *Demerger-Management – Wertorientierte Desintegration von Unternehmen*, Wiesbaden, Deutsche Universitäts-Verlag, 2003.

FAHRION, T., *Das Schicksal der besonderen Rechte von Aktionären bei grenzüberschreitendn Verschmelzungen von deutschen und französischen Aktiengesellschaften*, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2011.

FRENZEL, R., *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften – Zur Umsetzung der Zehnten Gesellschaftsrechtlichen Richtlinie in deutsches Recht*, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2008.

FRITZ, M., *Die Spaltung von Kapitalgesellschaften – Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Reformvorschläge*, Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 1991.

GRAML, R., *Unternehmenswertsteigerung durch Desinvestition: Eine Analyse unter Berücksichtigung des Management Buy-Outs*, Frankfurt am Main u. a., Peter Lang Verlag, 1996.

GRASMANN, G., *System des internationalen Gesellschaftsrechts*, Herne, Neue Wirtschafts-Briefe, 1979.

GRUNDMANN, St., *Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts durch den europäischen Gerichtshof*, Konstanz, Hartung-Gorre, 1997.

HENNRICHS, J., *Formwechsel und Gesamtrechtsnachfolge bei Umwandlungen*, Berlin, Duncker & Humblot, 1995.

HORNUF, L., *Regulatory Competition in European Corporate and Capital Market Law : An Empirical Analysis*, thèse, Ludwig-Maximilians-Unversität München, 2010.

KRAUSE, Ci., *Die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften im deutschen und französischen Recht*, Berlin, W. de Gruyter, 1966.

KULENKAMP, S., *Die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU*, Mannheim, Nomos, 2008.

LENNERZ, U., *Die internationale Verschmelzung und Spaltung unter Beteiligung deutscher Gesellschaften* ; Köln, 2001.

LUTTER, M. et HOMMELHOFF, P. (sous la direction de), *Die Europäische Gesellschaft – Prinzipien, Gestaltungsmöglichkeiten und Grundfragen aus der Praxis*, Köln, Otto Schmidt, 2005.

MITTERECKER, J., *Grenzüberschreitende Verschmelzungen*, Wien, Verlag Österreich, 2014.

NOHLEN, N., *Binnenmarktkonformer Minderheitenschutz bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung von Aktiengesellschaften*, Baden-Baden, Nomos, 2012.

PRÜM, Th., *Die grenzüberschreitende Spaltung*, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 2006.

REIK, A., *Grenzüberschreitende Restrukturierungen von Unternehmen – Eine bilaterale Untersuchung zwischen Deutschland und Frankreich*, thèse, Würzburg, 2001, disponible sur https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de (15/01/2019).

SCHEIFELE, M., *Die Gründung der Eurpäischen Aktiengesellschaft (SE)*, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2004.

SCHÖNE, T., *Die Spaltung unter Beteiligung von GmbH gem. §§ 123 ff. UmwG – Grundlagen, Anteilsgewährung, Beschlußfassung, Informationspflichten*, Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 1998.

SCHOTT, T., *Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften*, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2009.

STEIGER, A., *Grenzüberschreitende Fusion und Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften innerhalb der EU nach spanischem und portugiesischem Recht*, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 1997.

TASMA, M., *Leveraged Buyout und Gläubigerschutz*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012.

TEICHMANN, Chr., *Binnenmarktkonformes Gesellschaftsrecht*, Berlin, De Gruyter Recht, Oktober 2006.

THISSEN, S., *Strategisches Desinvestitionsmanagement : Entwicklung eines Instrumentarium zur Bewährung ausgewählter Desinvestitionsformen*, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2000.

TROST, E., *Mitbestimmungsgestaltung bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen*, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2016.

WENG, A., *Zulässigkeit und Durchführung grenzüberschreitender Verschmelzungen*, Berlin, Duncker & Humblot, 2008.

WINNER, M., *Wert und Preis im Zivilrecht*, Wien, Springer, 2008.

WÖHLERT, H.-T., *Gestaltungsfreiheit und Gläubigerschutz bei Spaltungen*, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2010.

WOLTER, Chr., *Der Gläubigerschutz bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften unter Beteiligung einer GmbH*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012.

ZIEGLER, Th., *Gesellschafts- und Steuerrechtliche Probleme der Fusion zwischen deutschen und französischen Aktiengesellschaften*, thèse, Tübingen, 1997.

ZIMMER, D., *Internationales Gesellschaftsrecht – Das Kollisionsrecht der Gesellschaften und sein Verhältnis zum Internationalen Unternehmensrecht*, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaftsrecht, 1996.

2.3.2. *Ouvrages généraux*

ALTMEPPEN, H. et ROTH, G., *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG – Kommentar*, München, C.H. Beck, 2019.

BAMBERGER, H.G., HAU, W., POSECK, R. et ROTH, H. (dir.), *Bürgerliches Gesetzbuch – Kommentar*, 4e éd., 2019.

CALLIESS, Chr. et RUFFERT, M. (dir.), *EUV/AEUV – Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta*, 5e éd., München, C.H.Beck, 2016.

DAUNER-LIEB, B. et SIMON, St. (dir.), *Kölner Kommentar zum UmwG*, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2009.

GRABITZ, E., HILF, M. et NETTESHEIM, M. (dir.), *Das Recht der Europäischen Union*, 65. EL, C.H. Beck, Munich, août 2018.

GRUNEWALD, B., MAIER-REIMER, G. et WESTERMANN, K. P. (dir.), *Bürgerliches Gesetzbuch*, 15e éd., Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 2017.

HARATSCH, A., KOENIG, Chr. et PECHSTEIN, M., *Europarecht*, 11e éd., Tübingen, Mohr Siebeck, 2018.

HOBER, St. *Europarecht*, 9e éd., München, Verlag Franz Vahlen, 2017.

KALLMEYER, H. (dir.), *Umwandlungsgesetz*, 7e éd., Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 2020.

KALSS, S. (dir.), *Verschmelzung, Spaltung, Umwandlung*, 2e éd., Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2010.

KIEL, H., LUNK, St. et OETKER, H. (dir.), *Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht*, vol. 4, 4e éd., München, C.H. BECK, 2018.

KINDL, P., MELLER-HANNICH, C. et WOLF, H.-J. (dir.), *Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung*, 3e éd., Baden-Baden, Nomos, 2015.

LUTTER, M. (dir.), *Umwandlungsgesetz*, 6e éd., Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 2019.

LUTTER, M., HOMMELHOFF, P. et TEICHMANN, Chr. (dir.), *SE Kommentar*, 2e éd., Köln, Dr. Otto Schmidt Verlag, 2015.

MANKOWSKI, P., MÜLLER, M. et SCHMIDT, J., *Europäische Insolvenzordnung 2015 – Kommentar*, 1re éd., München, C.H. Beck, 2016.

SAENGER, I. (dir.), *Zivilprozessordnung : ZPO*, 8e éd., 2019, Baden-Baden, Nomos.

SCHMITT, J., HÖRTNAGL, R. et STRATZ, R.-Chr., *Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz*, 8e éd., München, C.H. Beck, 2018.

SEMLER, J. et STENGEL, A. (dir.), *Umwandlungsgesetz*, 4e éd., C. H. Beck, München, 2017.

SPINDLER, G. et STILZ, E., (dir.), *Kommentar zum Aktiengesetz*, 4e éd., C.H. Beck, München, 2019.

WIDMANN, S. et MAYER, M. (dir.), *Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz*, Stollfuß Medien, Bonn, *s.d.*.

2.3.3. *Articles et contributions à des ouvrages collectifs*

ADENSAMER, N. et ECKERT, G., « Das Kollisionsrecht der grenzüberschreitenden Verschmelzung (Teil I) », *GeS*, 2007, pp. 95–143.

BARTHEL, D., « Die Niederlassungsfreiheit der Gesellschaften nach EuGH "Cartesio" - die Suche nach dem Gleichgewicht zwischen Wettbewerb im Binnenmarkt und nationalstaatlicher Regelungsautonomie », *EWS*, 2010, pp. 316–330.

BARZ, C. H., « Rechtliche Fragen zur Verschmelzung von Unternehmen », *AG*, 1972, pp. 1–7.

BAYER, W. et SCHMIDT, J., « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport Europäisches Unternehmensrecht 2017/18 », *BB*, 2018, pp. 2562–2578.

BAYER, W. et SCHMIDT, J., « Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften : Formwechsel durch isolierte Satzungssitzverlegung », *ZIP*, 2017, pp. 2225–2234.

BAYER, W. et SCHMIDT, J., « Das Vale-Urteil des EuGH: Die endgültige Bestätigung der Niederlassungsfreiheit als „Formwechselfreiheit" », *ZIP*, 2017, pp. 1481–1488.

BAYER, W. et SCHMIDT, J., « Gläubigerschutz bei (grenzüberschreitenden) Verschmelzungen », *ZIP*, 2016, pp. 841–849.

BAYER, W., « Die Erosion der deutschen Mitbestimmung », *NJW*, 2016, pp. 1930–1936.

BAYER, W. et SCHMIDT, J., « Der Referentenentwurf zum 3. UmwÄndG: Vereinfachungen bei Verschmelzungen und Spaltungen und ein neuer verschmelzungspezifischer Squeeze out », *ZIP*, 2010, pp. 953–963.

BAYER, W. et SCHMIDT, J., « Grenzüberschreitende Sitzverlegungen und grenzüberschreitende Sitzverlegungen nach MoMiG, Cartesio und Trabrennbahn. Europäischer Rahmen, deutsche lex lata und rechtspolitische Desiderata », *ZHR*, 2009/173, pp. 735–774.

BAYER, W. et SCHMIDT, J., « Die neue Richtlinie über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *NJW*, 7/2006, pp. 401–407.

BAYER, W. et SCHMIDT, J., « Der Schutz der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch die Niederlassungsfreiheit », *ZIP*, 2006, pp. 210–213.

BAYER, W. et SCHMIDT, J., « Der Regierungsentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes – Eine kritische Stellungnahme », *NZG*, 2006, pp. 841–846.

BAYER, W., « Auswirkungen der Niederlassungsfreiheit nach den EuGH-Entscheidungen Inspire Art und Überseering auf die deutsche Unternehmensmitbestimmung », *AG*, 2004, pp. 534–538.

BAYER, W., « 1000 Tage neues Umwandlungsrecht – Eine Zwischenbilanz », *ZIP*, 1997, pp. 1613–1626.

BAYER, W., « Informationsrechte bei der Verschmelzung von Aktiengesellschaften », *AG*, 1988, pp. 323–331.

BEHME, C., « Der grenzüberschreitende Formwechsel von Gesellschaften nach Cartesio und Vale », *NZG*, 2012, pp. 936–939.

BEHME, C. et NOHLEN, N., « Zur Wegzugsfreiheit von Gesellschaften – Der Schlussantrag von Generalanwalt Maduro in der Rechtssache Cartesio (C-210/06) », *NZG*, 2008, pp. 496–498.

BEHRENS, P., « Die neue Lektion aus Luxemburg zur internationalen Mobilität von Gesellschaften: Grenzüberschreitende Verschmelzungen sind möglich ! », *EuZW*, 2006, p. 65.

BEHRENS, P., « Gemeinschaftsrechtliche Grenzen der Anwendung inländischen Gesellschaftsrechts auf Auslandsgesellschaften nach Inspire Art », *IPRax*, 2004, pp. 20–26.

BEHRENS, P., « Das Internationale Gesellschaftsrecht nach dem Überseering Urteil des EuGH und den Schlussanträgen zu Inspire Art », *IPRax*, 2003, pp. 193–207.

BEHRENS, P., « Die Umstrukturierung von Unternehmen durch Sitzverlegung oder Fusion über die Grenze im Licht der Niederlassungsfreiheit im Europäischen Binnenmarkt (Art 52 und 58 EWGV) », *ZGR*, 1994, pp. 1–25.

BEHRENS, P., « Die grenzüberschreitende Sitzverlegung von Gesellschaften in der EWG – Zu EuGH, 27-09-1988 – Rs 81/87 – Daily Mail and General Trust Plc », *IPRax*, 1999, pp. 193–207.

BENZ, N., HÜBNER, L. et ZIMMERMANN, A., « Gesellschafterschutz in der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *ZIP*, 2018, pp. 2254–2261.

BINZ, M. et MAYER, G., « Die ausländische Kapitalgesellschaft & Co. KG im Aufwind ? – Konsequenzen aus dem „Überseering"-Urteil des EuGH v. 5.11.2002 », *GmbHR*, 2003, pp. 249–257.

BLASCHE, S., « Vinkulierungsklauseln in GmbH-Gesellschaftsverträgen », *RNotZ*, 2013, pp. 513–534.

BLECKMANN, Al., « Zur Dogmatik des Niederlassungsrecht im EWG-Vertrag », *WiVerw*, 1987, pp. 119–136.

BOCK, V., « Institutioneller Gläubigerschutz nach § 30 Abs. 1 GmbHG beim Downstream-merger nach einem Anteilskauf ? », *GmbHR*, 2005, pp. 1023–1030.

BOLLACHER, Ph., « Keine Verletzung der Niederlassungsfreiheit durch nationale Beschränkungen des Wegzugs von Gesellschaften – Besprechung zu EuGH, RIW 2009, 70 – Cartesio », *RIW*, 2009, pp. 150–154.

BÖLLHOFF, D., BRAST, Chr., GRÜGER, N., « Demerger als Instrument strategischer Konzernorganisation – Eine fallstudienbasierte Analyse », *ZFO*, 2007/01, pp. 23–30.

BORMANN, J. et STELMASZCZYK, P., « Digitalisierung des Gesellschaftsrechts nach dem EU-Company Law Package – Zum neuen EU-Rechtsrahmen für die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften », *NZG*, 2019, pp. 601–612.

BORMANN, J. et STELMASZCZYK, P., « Grenzüberschreitende Verschmelzungen nach dem EU-Company Law Package », *ZIP, 2018*, pp. 300–312.

BORMANN, J. et STELMASZCZYK, P., « Grenzüberschreitende Spaltungen und Formwechsel nach dem EU-Company Law Package », *ZIP, 2018*, pp. 353–365.

BÖTTCHER, L. et KRAFT, J., « Grenzüberschreitender Formwechsel und tatsächliche Sitzverlegung – Die Entscheidung VALE des EuGH », *NJW*, 2012, pp. 2701–2704.

BRANDES, St., « Mitbestimmungsvermeidung mittels grenzüberschreitender Verschmelzungen », *ZIP*, 2008, pp. 2193–2199.

BRANDI, T. Ol., « Grenzüberschreitender (Heraus-)Formwechsel – praktische Erfahrungen und Vergleich mit Reformvorschlägen im EU Company Law Package », *BB*, 2018, pp. 2626–2635.

BRUPPACHER, « Unternehmensverkauf als strategischer Erfolgsfaktor », in *Meilensteine im Management: Mergers & Acquisitions*, Basel, Frankfurt am Main, Stuttgart, Helbing & Lichtenhahn / Schäffer Verlag für Wirtschaft und Steuern GmbH, 1990, pp. 267–282.

BUNGERT, H., « Grenzüberschreitende Verschmelzungsmobilität – Anmerkung zur *SEVIC*-Entscheidung des EuGH », *BB*, 2006, pp. 53–56.

BUTTERSTEIN, Al., « Modernisierung des EU-Gesellschaftsrechts zur Stärkung der grenzüberschreitenden Mobilität von Gesellschaften », *EuZW*, 2018, pp. 838–845.

CAMPOS-NAVE, J., « Die Liberalisierung der Wegzugsfreiheit in Europa », *BB*, 2008, pp. 1410–1414.

CAMPOS NAVE, J., « Die Wegzugsbesteurung als Einschränkung der europäischen Niederlassungsfreiheit », *NZG*, 2004, pp. 897 et 898.

CASPER, M., « Numerus Clausus und Mehrstaatlichkeit bei der SE-Gründung », *AG*, 2007, pp. 97–105.

DAV, « Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des RL 2017/1132/(EU) in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen COM (2018) 241 », *NZG*, 2018, pp. 857–867.

DAV, « Handelsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *NZG*, 2006, pp. 737–744.

DORR, R. et STUKENBORG, G., « „Going to the Chapel": Grenzüberschreitende Ehen im Gesellschaftsrecht – Die ersten transnationalen Verschmelzungen nach dem UmwG », *DB*, 2003, pp. 647–653.

DRYGALA, T. et VON BRESSENSDORF, T., « Gegenwart und Zukunft grenzüberschreitender Verschmelzungen und Spaltungen », *NZG*, 2016, pp. 1161–1168.

DRYGALA, T. « Zur grenzüberschreitenden Verschmelzung », *EWiR*, 2006, pp. 25 et s.

DRINHAUSEN, Fl. et GESELL, H., « Gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten grenzüberschreitender Mobilität von Unternehmen in Europa », *BB-Special*, 8/2006, pp. 3–17.

DRINHAUSEN, Fl. et KEINATH, A., « Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes – Erleichterung grenzüberschreitender Verschmelzungen für deutsche Kapitalgesellshaften ? », *BB*, 2006, pp. 725–732.

DRINHAUSEN, Fl. et KEINATH, A., « Die grenzüberschreitende Verschmelzung inländischer Gesellschaften nach Erlass der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in Europa », *RIW*, 2006, pp. 81–87.

DUURSMA-KEPPLINGER, H.-C., « Aktuelle Entwicklungen zur internationalen Zuständigkeit für Hauptinsolvenzverfahren – Erkenntnisse aus Staubitz-Schreiber und Eurofood », *ZIP*, 2007, pp. 896–903.

DZIDA, B., « Die Unterrichtung des „zuständigen" Betriebsrats bei innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *GmbHR*, 2009, pp. 459–465.

DZIDA, B. et SCHRAMM, N., « Arbeitsrechtliche Pflichtangaben bei innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *NZG*, 2008, pp. 521–527.

EBENROTH, C. T. et EYLES, U., « Die innereuropäische Verlegung des Gesellschaftssitzes als Ausfluß der Niederlassungsfreiheit ? (Teil 1) - Die Mobilität von Unternehmen im Spannungsfeld von Harmonisierungsbestrebungen und der Anerkennung divergierender Rechtsstandards », *DB*, 1989, pp. 363–372.

EBENROTH, C. T. et OFFENLOCH, T., « Kollisionsrechtliche Untersuchung grenzüberschreitender Ausgliederungen », *RIW*, 1997, pp. 1–14.

EBKE, W., « Überseering: Die wahre Liberalität ist Anerkennung », *JZ*, 2003, pp. 927–933.

EBKE, W., « Das Centros-Urteil des EuGH und seine Relevanz für das deutsche Internationale Gesellschaftsrecht – Das Schicksal der Sitztheorie nach dem Centros-Urteil des EuGH », *JZ*, 1999, pp. 656–661.

EIDENMÜLLER, H. et ENGERT, A., « Rechtsökonomik des Mindestkapitals im GmbH-Recht », *GmbHR*, 2005, pp. 433–438.

EIDENMÜLLER, H., « Wettbewerb der Gesellschaftsrechte in Europa », *ZIP*, 2002, pp. 2231–2245.

ENGELMEYER, C., « Das Spaltungsverfahren bei der Spaltung von Aktiengesellschaften », *AG*, 1996, pp. 193–208.

ENNEKING, F. et HECKSCHEN, H., Gesellschafterhaftung beim down-stream merger, *DB*, 2006, pp. 1099–1101.

FLEISCHER, H. et EMPT, M., « Gesellschaftsrechtliche Durchgriffs- und Konzernhaftung und öffentlich-rechtliche Altlastenverantwortlichkeit », *ZIP*, 2000, pp. 905–913.

FORSTHOFF, U., « EuGH fördert Vielfalt im Gesellschaftsrecht – Traditionelle deutsche Sitztheorie verstößt gegen Niederlassungsfreiheit », *DB*, 2002, pp. 2471–2477.

FRANZ, T., « Grenzüberschreitende Sitzverlegung und Niederlassungsfreiheit – eine systematische Betrachtung offener und geklärter Fragen », *EuZW*, 2016, pp. 930–936.

FRENZEL, R., « Immer noch keine Wegzugsfreiheit für Gesellschaften im Europäischen Binnenmarkt – die Cartesio-Entscheidung des EuGH », *EWS*, 2009, pp. 158–164.

FRENZEL, R., « Grenzüberschreitende Verschmelzung nach Ablauf der Umsetzungsfrist », *RIW*, 2008, pp. 12–20.

FRISCHHUT, M., « Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften – ein Überblick über die Zehnte gesellschaftsrechtliche Richtlinie », *EWS*, 2006, pp. 55–60.

FROBENIUS, T., « „Cartesio": Partielle Wegzugsfreiheit für Gesellschaften in EuropSt. », *DStR*, 2009, pp. 487–492.

FUENTES NAHARRO, M., « Cross-border conversions and the company law package » in KOVÁCS, Er. et WINNER, M. (dir.), *Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues*, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp. 13–48.

GARCIMARTÌN, F., « The EU Insolvency Regulation recast, scope, jurisdiction and applicable law », *ZEuP*, 2015, pp. 694–731.

GESELL, H. et KRÖMKER, M., « Grenzüberschreitende Verschmelzungen nach SEVIC: Praxisbericht über die Verschmelzung einer niederländischen auf eine deutsche Kapitalgesellschaft », *DB*, 2006, pp. 2558–2563.

GEYRHALTER, V. et WEBER, Th., « Transnationale Verschmelzungen – im Spannungsfeld zwischen SEVIC Systems und der Verschmelzungsrichtlinie », *DStR*, 2006, pp. 146–151.

GEYRHALTER, V., « Niederlassungsfreiheit contra Sitztheorie – Good Bye Daily Mail », *EWS*, 1999, pp. 201–203.

GHEMAVAT, P. et GHADAR, F., « Globale Megafusionen – ökonomisch nur selten zwingend geboten », *HBM*, 2001/1, pp. 32–41.

GÖTTE, M. et MÜCKL, P., « Unternehmensmitbestimmung und grenzüberschreitende Unternehmensmobilität », *BB*, 2018, pp. 2036–2043.

GOTTSCHALK, E., « Zur Frage grenzüberschreitender Verschmelzungen und der Eintragungsfähigkeit in das nationale Handelsregister », *EuZW*, 2006, pp. 83 et 84.

GÖTZE, C., WINZER, Th., et ARNOLD, Chr. « Unternehmerische Mitbestimmung – Gestaltungsoptionen und Vermeidungsstrategien », *ZIP*, 2009, pp. 245–254.

GROHMANN, U. et GRUSCHINSKE, N., « Beschränkungen des Wegzugs von Gesellschaften innerhalb der EU – die Rechtssache Cartesio », *EuZW*, 2008, pp. 463 et 464.

GROHMANN, U. et GRUSCHINSKE, N., « Die identitätswahrende grenzüberschreitende Satzungssitzverlegung in Europa – Schein oder Realität ? », *GmbHR*, 2008, pp. 27–31.

GROHMANN, U. et GRUSCHINSKE, N., « Grenzüberschreitende Mobilität von Kapitalgesellschaften in Europa – Die Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *GmbHR*, 2006, pp. 191–194.

GRUNEWALD, B., « Der Gläubigerschutz bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach dem Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des UmwG », *Der Konzern*, 2007, pp. 106–109.

GRZESZICK, B. et VERSE, D., « Auswirkungen eines harten Brexit auf britische Gesellschaften in Deutschland – der Gesetzgeber ist gefordert ! », *NZG*, 2019, pp. 1129–1137.

GÜNES, M., « Grenzüberschreitende Verschmelzungen unter Beteiligung von Kapitalgesellschaften aus Drittstaaten », *IStR*, 2013, pp. 213–219.

HABERSACK, M., « Sekundärrechtlicher grenzüberschreitender Formwechsel ante portas », *ZHR*, 2018, pp. 495–503.

HAHN, H., « Zum Gläubigerschutz bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften – Eine vergleichende Untersuchung des Entwurfs eines handelsrechtlichen Umwandlungsgesetzes vom 3. 8. 1988 und des französischen Gesetzes vom 24. 6. 1966 über die Handelsgesellschaften », *GmbHR*, 1991, pp. 242–245.

HARITZ, D. et VON WOLFF B., « Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrecht. Zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *GmbHR*, 2006, pp. 340–345.

HARRER, Fr., Internationale Verschmelzung, *GesRZ*, 1995, pp. 141–150.

HECKSCHEN, H., « Gläubigerschutz bei Spaltungen », *GWR*, 2020, p. 175.

HECKSCHEN, H., « Das Company Law Package und die Auswirkungen für das Notariat – Digitalisierungs- und Umwandlungsrichtlinie », *NotBZ*, 2020, pp. 241–248.

HECKSCHEN, H., « Inhalt und Umfang der Gesamtrechtsnachfolge – sog. Vertrauensstellungen und Mitgliedschaften », *GmbHR*, 2014, pp. 626–638.

HECKSCHEN, H., « Die Reform des Umwandungsrechts », *DNotZ*, 2007, pp. 444–465.

HECKSCHEN, H., « Ist das deutsche Umwandlungsrecht gemeinschaftsrechtswidrig ? », *NotBZ*, 2005, pp. 315–320.

HEIDENHAIN, M., « Spaltungsvertrag und Spaltungsplan », *NJW*, 1995, pp. 2873–2881.

HEIDENHAIN, M., « Fehlerhafte Umsetzung der Spaltungsrichtlinie », *EuZW*, 1995, pp. 327–330.

JOCHUM, H. et HEMMELRATH, Al., « Der grenzüberschreitende Hinausformwechsel in Europa – Ein Beitrag zur richterlichen Weitsicht und zum RL-Vorschlag der EU-Kommission v. 25.4.2018 für die Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 », *IStR*, 2019, pp. 517–524.

JUNG, C., « Die „deutsche"Limited als Gesellschaft sui generis ? – Eine Diskussion bezüglich gesellschaftsrechtlicher Anerkennungsmöglichkeiten englischer Scheinauslandsgesellschaften », *GmbHR*, 2020, pp. 752–758.

HERRLER, S. et SCHNEIDER, S., « Grenzüberschreitende Verschmelzungen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung zwischen Deutschland und Österreich », *GmbHR*, 2011, pp. 795–806.

HERRLER, S., « Ermöglichung grenzüberschreitender Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften durch Umänderung es Umwandlungsgesetzes – Umsetzung des Verschmelzungsrichtlinie unter Vernachlässigung der primärrechtlichen Rahmenbedingungen », *EuZW*, 2007, pp. 295 et s.

HIPPELI, M., « Das Company Law Package der EU-Kommission vom 25.04.2018 », *jurisPR-HaGesR*, 7/2018, Anm, 1, pp. 1–5.

HOFFMANN, J., « Mitbestimmungsfreie Gesellschaften deutschen Rechts durch grenzüberschreitenden Formwechsel », *EuZW*, 2018, pp. 785–786.

HOFFMANN, J., « Gläubigeranfechtungsklagen und Zuständigkeit nach Angabe der EuGVVO – Anmerkung zu EuGH, Urt. V. 4.10.2018 – C-337/17- Feniks », *GPR*, 2019, pp. 168–173.

HÜBNER, L., « Auswirkungen einer grenzüberschreitenden Verschmelzung auf Anleiheverträge », *IPRax*, 2016, pp. 553–558.

KALLMEYER, H., « Der gemeinsame Verschmelzungsplan für grenzüberschreitende Verschmelzungen », *AG*, 2007, pp. 472–475.

KALLMEYER, H. et KAPPES, St., « Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen nach Sevic Systems und der EU-Verschmelzungsrichtlinie », *AG*, 2006, pp. 224–238.

KALLMEYER, H., « Tragweite des Überseering-Urteils des EuGH vom 5.11.2002 zur grenzüberschreiten Sitzverlegung », *DB*, 2002, pp. 2521–2522.

KALSS, S., « Gläubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften », *ZGR*, 1/2009, pp. 74–125.

KAPPES, St., « Zulässigkeit grenzüberschreitender Verschmelzungen », *NZG*, 2006, pp. 101–103.

KIEM, R., « Die Ermittlung der Verschmelzungsrelation bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *ZGR*, 2007, pp. 542–570.

KIENINGER, E. – M., « Grenzüberschreitende Verschmelzungen in der EU – das SEVIC-Urteil des EuGH », *EWS*, 2006, pp. 49–54.

KIEM, R., « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im deutschen Umwandlungsgesetz », *WM*, 2006, pp. 1091–1099.

KINDLER, P., « Unternehmensmobilität nach „Polbud": Der grenzüberschreitende Formwechsel in Gestaltungspraxis und Rechtspolitik », *NZG*, 2018, pp. 1–7.

KINDLER, P., « Unternehmen im Binnenmarkt – Transparenz und Nachhaltigkeit », *DNotZ - Sonderheft*, 2016, pp. 75–102.

KINDLER, P. et SAKKA, S., « Die Neufassung der Europäischen Insolvenzordnung », *EuZW*, 2015, pp. 460–466.

KINDLER, P., « Der reale Niederlassungsbegriff nach dem VALE-Urteil des EuGH », *EuZW*, 2012, pp. 888–892.

KINDLER, P., « Sitzverlegung und internationales Insolvenzrecht », *IPRax*, 2006, pp. 114–116.

KINDLER, P., « Der Wegzug von Gesellschaften in Europa », *Der Konzern*, 2006, pp. 811–821.

KINDLER, P., « Niederlassungsfreiheit für Scheinauslandsgesellschaften ? – Die „Centros"-Entscheidung des EuGH und das internationale Privatrecht », *NJW*, 1999, pp. 1993–2000.

KINDLER, P., « Neue Offenlegungspflichten für Zweigniederlassungen ausländischer Kapitalgesellschaften - Zur Umsetzung der Elften gesellschaftsrechtlichen Richtlinie der EG in deutsches Recht », *NJW*, 1993, pp. 3301–3306.

KISKER, Ol., « Unternehmerische Mitbestimmung in der Europäischen Gesellschaft, der Europäischen Genossenschaft und bei grenzüberschreitender Verschmelzung im Vergleich », *RdA*, 2006, pp. 206–212.

KLEIN, St., « Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *RNotZ*, 2007, pp. 565–608.

KLEINERT, J. et PROBST, P., « Endgültiges Aus für Sonderanknüpfungen bei (Schein-) Auslandsgesellschaften », *DB*, 2003, pp. 2217 et 2218.

KLOSTER, L. « Eu-grenzüberschreitende Verschmelzungen sind (steuerneutral) durchführbar », *GmbHR*, 2003, pp. 1413–1417.

KNAIER, R., « Crossing borders, digitally ? Das "Company Law Package" auf dem Prüfstand », *GmbHR*, 2018, R148 – R150.

KNAIER, R., « Unionales Umwandlungsrecht – Die Zukunft der Unternehmensmobilität im Binnenmarkt », *GmbHR*, 2018, pp. 607–624.

KNAIER, R., note sous OLG Frankfurt, 3 janvier 2017, *DNotZ*, 2017, pp. 390–394.

KNOBBE-KEUK, B., « Umzug von Gesellschaften in Europa », *ZHR*, 1990, pp. 325–356.

KOCH, U., « Die Entwicklung des Gesellschaftsrechts in den Jahren 1989/90 - Rechtspolitische Entwicklungen, Steuerrecht, deutsches internationales Gesellschaftsrecht, Recht der Personengesellschaften », *NJW*, 1992, pp. 404–419.

KÖNIG, D. et BORMANN, J., « "Genuine Link" und freie Rechtsformwahl im Binnenmarkt – Trendwende bei der Anerkennung von "Scheinauslandgesellschaften" durch die VALE-Entscheidung des EuGH ? », *NZG*, 2012, pp. 1241–1244.

KOPPENSTEINER, H.-G., « Zur grenzüberschreitenden Verschmelzung », *Der Konzern*, 2006, pp. 40–55.

KOPPENSTEINER, H.-G., « Grundlagenkritische Bemerkungen zum EWG-Entwurf eines Übereinkommens über die internationale Verschmelzung von Aktiengesellschaften », *RabelsZ*, 1975, pp. 405–443.

KRAFT, J. et NOACK, Ul., « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität – der Richtlinienvorschlag im Company Law Package », *DB*, 2018, pp. 1577–1582.

KRAUSE, N. et KULPA, N., « Grenzüberschreitende Verschmelzungen – Vor dem Hintergrund der SEVIC-Entscheidung und der Reform des deutschen Umwandlungsrecht », *ZHR 171*, 2007, pp. 38–78.

KRUSE, C. et KRUSE, Co., « Grenzüberschreitende Konzernverschmelzungen – Vorgaben und Vereinfachungen der §§ 122a ff. UmwG », *BB*, 2010, pp. 3035–3038.

KUMPAN, Chr. et PAUSCHLINGER, Ph., « Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2016 », *EuZW – Sonderausgabe*, 2017, pp. 3–8.

KUNKEL, C., « Zulässige nicht verhältniswahrende Spaltung in Form des „Spaltung zu Null" », *jurisPR-HaGesR*, 9/2013, pp. 1–3.

KUNTZ, Th., « Internationales Umwandlungsrecht – zugleich eine Besprechung des Urteils „Sevic-Systems" », *IStR*, 2006, pp. 224–232.

KUNTZ, Th., « Zur Möglichkeit grenzüberschreitender Fusionen – Die Schlussanträge in Sachen SEVIC Systems Aktiengesellschaft », *EuZW*, 2005, pp. 534–528.

KUSSMAUL, H., RICHTER, L. und RUINER, Chr., « Grenzenlose Mobilität ?! - Zum Zuzug und Wegzug von Gesellschaften in Europa », *EWS*, 2009, pp. 1–10.

LANGE, K., « Zur Niederlassungsfreiheit im Zusammenhang mit der Eintragung einer inländischen Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft », *DNotZ*, 1999, pp. 599–607.

LÄNGSFELD, Al., « (Un-)Wirksamkeit von Change-of-Control-Klauseln – Zum neuen § 225 a IV 3 InsO », *NZI*, 2014, pp. 734–739.

LEHMANN, M. et LEIBLE, St., « Die Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ("Rom I") », *RIW*, 2008, pp. 528–543.

LEIBLE, St. et HOFFMANN, J., « Cartesio – fortgeltende Sitztheorie, grenzüberschreitender Formwechsel und Verbot materiellrechtlicher Wegzugsbeschränkungen », *BB*, 2009, pp. 58–63.

LEIBLE, St. et HOFFMANN, J., « Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Binnenmarkt nach "Sevic" – Zugleich eine Besprechung von EuGH RIW 2006, 240 – Sevic », *RIW*, 2006, pp. 161–166.

LEUTNER, G. et WAGNER, Th., « Verabschiedung der EG-Verschmelzungsrichtlinie », *GPR*, 2006, pp. 32–37.

LIMMER, P., « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Sevic-Urteil des EuGH und den Neuregelungen des UmwG (Teil I) », *ZNotP*, 2007, pp. 241–256.

LIMMER, P., « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Sevic-Urteil des EuGH und den Neuregelungen des UmwG (Teil II) », *ZNotP*, 2007, pp. 282–288.

LOUVEN, Chr., « Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie », *ZIP*, 2006, pp. 2021–2028.

LOUVEN, Chr. et WENG, A., « Die Ausgliederung von Pensionsverbindlichkeiten – neue Optionen bei Unternehmensverkäufen », *BB*, 2006, pp. 619–624.

LUNK, H. et HINRICHS, L., « Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach dem MgVG », *NZA*, 2007, pp. 773–780.

LUTTER, M. et T. DRYGALA, « Internationale Verschmelzungen in Europa », *JZ*, 2006, pp. 770–776.

LUTTER, M., « "Überseering" und die Folge », *BB*, 2003, pp. 7–10.

LUTZI, T., « Feniks aus der Asche : Internationale Zuständigkeit für die actio pauliana nach der EuGVVO », *RIW*, 2019/5, pp. 252–258.

LUY, Th., « Die Austrittserklärung des Minderheitsgesellschafters nach dem Company Law Package », *GmbHR*, 2019, pp. 1105–1109.

LUY, Th., « Grenzüberschreitende Umwandlungen nach dem Company Law Package », *NJW*, 2019, pp. 1905–1910.

MAIDL, J., « Rechtsbeziehungen des Zielunternehmens in der M&A Transaktion – Change of Control Klausel als neue Spaltungsbremse ? », *NZG*, 2018, pp. 726–729.

MANKOWSKI, P., « Insolvenzrecht gegen Gesellschaftsrecht 2:0 im europäischen Spiel um § 64 GmbHG », *NZG*, 2016, pp. 281–286.

MANKOWSKI, P., « Klärung von Grundfragen des europäischen Internationalen Insolvenzrechts durch die Eurofood Entscheidung ? », *BB*, 2006, pp. 1753–1759.

MANKOWSKI, P., « Entwicklungen im Internationalen Privat- und Prozessrecht 2003/2004 », *RIW*, 2004, pp. 481–497.

MANKOWSKI, P., « Die Qualifikation der culpa in contrahendo – Nagelprobe für den Vertragsbegriff des europäischen IZPR und IPR », *IPRax*, 2003, pp. 127–135.

MAUL, S., TEICHMANN, Chr. et WENZ, Ma., « Der Richtlinienvorschlag zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *BB*, 2003, pp. 2633–2641.

MEILICKE, W. et RABBACK, D., « Die EuGH-Entscheidung in der Rechtssache SEVIC und die Folgen für das deutsche Umwandlungsrecht nach Handelsrecht und Steuerrecht », *GmbHR*, 2006, pp. 123–127.

MEILICKE, W., « Auswirkungen der „Centros-Entscheidung" auf die 14. EU-Sitzverlegungs-Richtlinie », *GmbHR*, 1999, pp. 896 et 897.

MERTENS, K., « Aktuelle Fragen zur Verschmelzung von Mutter- auf Tochtergesellschaften – down stream merger », *AG*, 2005, pp. 785–792.

MERTENS, K., « Zur Universalsukzession in einem neuen Umwandlungsrecht », *AG*, 1994, pp. 66–78.

MOCK, S., « Zur Qualifikation der insolvenzrechtlichen Gläubigerschutzinstrument des Kapitalgesellschaftsrechts », *IPRax*, 2016, pp. 237–243.

MÖRSDORF, O., « Der Entwurf einer Richtlinie für grenzüberschreitende Umwandlungen – Meilenstein oder Scheinriese ? », *EuZW*, 2019, pp. 141–148.

MÖRSDORF, O., « Nun also doch! – Die überraschende Umdeutung der Niederlassungsfreiheit zur Rechtswahlfreiheit durch den EuGH im Urteil Polbud », *ZIP*, 2017, pp. 2381–2389.

MÖRSDORF, O. et JOPEN, Chr., « Grenzüberschreitender Formwechsel einer Gesellschaft („Vale") », *ZIP*, 2012, pp. 1394–1401.

MÖSTL, M., « Grenzen der Rechtsangleichung im europäischen Binnenmarkt – Kompetenzielle, grundfreiheitliche und grundrechtliche Schranken des Gemeinschaftsgesetzgebers », *EuR*, 2002, pp. 318–322.

MÜLLER, C., « Richtlinie zu grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen in Kraft getreten », *AG*, 2020, R5 – R6.

MÜLLER, H.-F., « Der Schutz der Minderheitsgesellschafter bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *Der Konzern*, 2007, pp. 81–88.

MÜLLER, H.-F., « Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrechts: Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung », *ZIP*, 2007, pp. 1081–1088.

MÜLLER, H.-F., « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums », *NZG*, 2006, pp. 286–290.

MÜLLER, H.-F., « Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem neuen Richtlinienentwurf der EU-Kommission », *ZIP*, 2004, pp. 1790–1797.

MÜLLER – GRAFF, P.-Chr., « Gesellschaftsrecht im Kontext des Europäischen Wirtschaftsordnungsrechts », *EWS*, 2009, pp. 489–502.

MÜLLER -STEWENS, G., SCHÄFER, M. et SZELESS, G., « Wertschaffung durch strategische Desinvestitionen », *M&A Review*, 2001/1, pp. 13–18.

NAGEL, B., « Die Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung », *NZG*, 2006, pp. 97–101.

NEYE, H.-W., « Die neue Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », *ZIP*, 2005, pp. 1893–1898.

NEYE, H.-W. et TIMM, B., « Mehr Mobilität für die GmbH in Europa – Das neue Recht der grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *GmbHR*, 2007, pp. 561–565.

NEYE, H.-W. et TIMM, B., « Die geplante Umsetzung der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften im Umwandlungsgesetz », *DB*, 2006, pp. 488–493.

NOACK, M., « Das Company Law Package – Vorschläge der Europäischen Kommission zur Harmonisierung des materiellen Schutzes der Minderheitsgesellschafter bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen », *AG*, 2018, pp. 780–788.

NIKOLEYCZIK, T. et FÜHR, Th., « Mitbestimmungsgestaltung im grenzüberschreitenden Konzern unter besonderer Berücksichtigung der SE und grenzüberschreitender Verschmelzungen », *DStR*, 2010, pp. 1743–1750.

OECHSLER, J., « Die Richtlinie 2005/56/EG über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten », *NZG*, 2006, pp. 161–166.

OECHSLER, J., « Die Sitzverlegung der Europäischen Aktiengesellschaft nach Art. 8 SE-VO », *AG*, 2005, pp. 373–380.

OPLUSTIL, Kr. et SCHNEIDER, M., « Zur Stellung der Europäischen Aktiengesellschaft im Umwandlungsrecht », *NZG*, 2003, pp. 13–17.

PAEFGEN, W., « "Cartesio": Niederlassungsfreiheit minderer Güte », *WM*, 2009, pp. 529–536.

PAEFGEN, W., « Umwandlung, europäische Grundfreiheiten und Kollisionsrecht », *GmbHR*, 2004, pp. 463–476.

PAEFGEN, W., « Umwandlung über die Grenze - ein leichtes Spiel ? », *IPRax*, 2004, pp. 132–137.

PASSARGE, M. et STARK, M., « Gläubigerschutz bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes », *GmbHR*, 2007, pp. 803–810.

KUMPEN, Chr. et PAUSCHINGER, Ph., « Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2016 », *EuZW*, 2016, pp. 327–332.

PÖLLATH, R. et PHILIPP, Chr., « Unternehmenskauf und Verschmelzung : Pflichten und Haftung von Vorstand und Geschäftsführer », *DB*, 2005, pp. 1503–1509.

PRIESTER, H.-J., « EU-Sitzverlegung – Verfahrensablauf », *ZGR*, 1999, pp. 36–53.

PÜTZ, L., « Die Unternehmensmitbestimmung nach dem „Company Law Package" der EU – Erste Überlegungen zur Umsetzung der neugefassten Mobilitäts-Richtlinie (EU) 2017/1132 in das deutsche Recht », *AG*, 2020, pp. 117–123.

REHBERG, M., « Internationales Gesellschaftsrecht im Wandel: Das Überseering-Urteil des EuGH und seine Folgen », *IPRax*, 2003, pp. 175–181.

RIEBLE, V., « Verschmelzung und Spaltung von Unternehmen und ihre Folgen für Schuldverhältnisse mit Dritten », *ZIP*, 1997, pp. 301–314.

ROTH, G. H., « Das Ende der Briefkastengründung ? – Vale contra Centros », *ZIP*, 2012, pp. 1744–1745.

ROTH, W.-H., « „Centros" – Viel Lärm um nichts ? - Besprechung der Entscheidung EuGH », *ZGR*, 2000, pp. 311–338.

SAMSON, Chr. et FLINDT, S., « Internationale Unternehmenszusammenschlüsse », *NZG*, 2006, pp. 290–296.

SANDHAUS, S., « Richtlinienvorschlag der Kommission zur Vereinfachung der Berichts- und Dokumentationspflichten bei Verschmelzungen und Spaltungen », NZG, 2009, pp. 41–46.

SANDROCK, O., « Sitztheorie, Überlagerungstheorie und der EWG-Vertrag : Wasser, Öl und Feuer », *RIW*, 1989, pp. 505–513.

SCHALL, A., « EuGH bestätigt grenzüberschreitenden Rechtsformwechsel in der EU! », *DB*, 2017, pp. 4–5.

SCHALL, A., « Das Kornhaas-Urteil gibt grünes Licht für die Anwendung des § 64 GmbHG auf eine Limited mit Sitz in Deutschland – Alles klar dank EuGH! », *ZIP*, 2016, pp. 289–295.

SCHMIDT, J., « Brexit : Implikationen des EU-UK TCA im Bereich des Gesellschaftsrechts », *GmbHR*, 2021, pp. 229–240.

SCHMIDT, J., « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU – Eckpunkte des Rechtsrahmens und Herausforderungen bei der Umsetzung », *ZEuP*, 2020, pp. 565–590.

SCHMIDT, J., « BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zum Europäischen Unternehmensrecht 2019/20 », *BB*, 34/2020, pp. 1794–1809.

SCHMIDT, J., « Die Entscheidung des EuGH in der Rs. I.G.I. », *EuZW*, 2020, pp. 372–374.

SCHMIDT, J., « Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität 2.0 : Die MobilR eröffnet ab 2023 neue Wege », *BB*, 3.2020, p. 1.

SCHMIDT, J., « Coming soon: „Company Law Package Part 2 - Implementation" », *EuZW*, 2019, pp. 801 et 802.

SCHMIDT, J., « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 2) », *Der Konzern*, 2018/07-08, pp. 273–285.

SCHMIDT, J., « EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellschaften (Teil 1) », *Der Konzern*, 2018/06, pp. 229–244.

SCHMIDT, J., Bestimmung des COMI des Insolvenzschuldners durch wertende Gesamtbetrachtung des Einzelfalls („Interedil") », *EWiR*, 2011, pp. 345 et 346.

SCHMIDT, J., « Eurofood – Eine Leitentscheidung und ihre Rezeption in Europa und den USA », *ZIP*, 2007, pp. 405–410.

SCHMIDT, Cl. et MAUL, S., « Niederlassungsfreiheit: Eintragung einer grenzüberschreitenden Verschmelzung in das nationale Handelsregister darf nicht verweigert werden - SEVIC Systems », *BB*, 2006, pp. 11–14.

SCHMIDT, S. et SCHETTLER, M., « Ziele von Unternehmenszusammenschlüssen », *Zeitschrift Führung und Organisation*, 1999/6, pp. 312–317.

SCHMIDT, K., « Gläubigerschutz bei Umstrukturierungen – Zum Referentenentwurf eines Umwandlungsgesetzes », *ZGR*, 1993, pp. 366–395.

SCHOLLMEYER, E., « Der Verschmelzungs-, Spaltungs- und Formwechselbericht nach der neuen Umwandlungsrichtlinie », *AG*, 2019, pp. 541–550.

SCHOLLMEYER, E., « Die „künstliche Gestaltung" - der Herr Tur Tur unter den Rechtsfiguren », *NZG*, 2018, pp. 977–978.

SCHOLLMEYER, E., « Von der Niederlassungsfreiheit zur Rechtswahlfreiheit ? – Das „Polbud"-Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 25. Oktober 2017 », *ZGR*, 2018, pp. 186–201.

SCHUBERT, Cl., « Beteiligung von Arbeitnehmern in ausländischen Betrieben und Tochtergesellschaften an der Unternehmensmitbestimmung in deutschen Konzernen », *AG*, 2017, pp. 369–378.

SCHULTE, Chr., « Grenzüberschreitende Umwandlungen und Spaltungen – Das Company Law Package in der möglichen registergerichtlichen Umsetzung bis zu einer Transformation in nationales Recht », *GmbHR*, 2020, pp. 139–146.

SCHULTZ, P., « Zur Anfechtung (actio pauliana) der Spaltung einer Gesellschaft durch ihre Gläubiger mit dem Ziel der Unwirksamerklärung der Spaltung ihnen gegenüber („I.G.I.") », *EWiR*, 2020, pp. 357 et 358.

SCHURR, Fr., « Schutzbestimmungen und Verfahrensregeln in der neuen Richtlinie zu grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen », *EuZW*, 2019, pp. 539–544.

SCHWEDHELM, R., STRECK, M. et MACK, A., « Die Spaltung der GmbH nach neuem Umwandlungsrecht », *GmbHR*, 1995, pp. 7–15.

SEDEMUND, J., « EU-weite Verschmelzungen : Gesellschaftsrechtliche Vorgaben und steuerliche Implikationen des SEVIC-Urteils des EuGH vom 13.12.2005 », *BB*, 2006, pp. 519–522.

SEIBOLD, B., « Der grenzüberschreitende Herein-Formwechsel in eine deutsche GmbH – Geht doch ! », *ZIP*, 2017, pp. 456–462.

SEIFERT, A., « Employee participation in the board and corporate restructuring – The perspective of EU Law » in Er. KOVÁCS et M. WINNER (dir.), *Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues*, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp. 133–158.

SIEMS, M., « Sevic : Der letzte Mosaikstein im internationalen Gesellschaftsrecht der EU », *EuZW*, 2006, pp. 135–140.

SIMON, St. et RUBNER, D., « Die Umsetzung der Richtlinie über grenzüberschreitende Verschmelzungen ins deutsche Recht », *Der Konzern*, 2006, pp. 835–843.

SPINDLER, G. et GÖTTINGEN, O. B., « Der Gläubigerschutz im Gesellschaftsrecht nach Inspire Art », *RIW*, 2004, pp. 7–16.

STELMASZCZYK, P., « Die neue Umwandlungsrichtlinie – harmonisierte Verfahren für grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *GmbHR*, 2020, pp. 61–76.

STELMASZCZYK, P., « Der materielle Stakeholderschutz nach der neuen Umwandlungsrichtlinie », *ZIP*, 2019, pp. 2437–2447.

STELMASZCZYK, P., « Grenzüberschreitender Formwechsel durch isolierte Verlegung des Satzungssitzes – EuGH präzisiert den Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit », *EuZW*, 2017, pp. 890–894.

STIEGLER, S., Gläubigeranfechtung und Spaltungsrecht Zugleich Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 30.1.2020 – C-394/18, GmbHR 2020, 418 », *GmbHR*, 2020, pp. 405–411.

STIEGLER, S., « Zehn Jahre Internationale Verschmelzungsrichtlinie – Erreichtes, Stand und Perspektiven », *GmbHR*, 2016, pp. 406–414.

STÖBER, M., « Die Auswirkungen einer Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz auf einen laufenden Zivilprozess », *NZG*, 2006, pp. 574–577.

STOCKENHUBER, P., « Das österreichische Spaltungsgesetz », *RIW*, 1994, pp. 278–286.

TEICHMANN, Chr., « Grundlinien eines europäischen Umwandlungsrechts: Das "EU-Company Law Package 2018" », *NZG*, 2019, pp. 241–248.

TEICHMANN, Chr. et KNAIER, R., « Grenzüberschreitender Formwechsel nach "Polbud" – Die neue Umwandlungsfreiheit im Binnenmarkt », *GmbHR*, 2017, pp. 1314–1324.

TEICHMANN, Chr., « Der Fall "Polbud" : Formwechsel in die Briefkastengesellschaft », *GmbHR*, 2017, pp. R356 – R357.

TEICHMANN, Chr., « Cartesio: die Freiheit zum formwechselnden Wegzug », *ZIP*, 2009, pp. 393–404.

TEICHMANN, Chr., « Binnenmarktmobilität von Gesellschaften nach „Sevic" », *ZIP*, 2006, pp. 355–363.

THIELE, R. et KÖNIG, M., « Die Anforderungen an die Bezeichnung der zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und Pasivvermögens gem. § 126 I Nr. 9 UmwG », *NZG*, 2015, p. 178–185.

THOLE, CHR., « Die Reform der Europäischen Insolvenzverordnung », *ZEuP*, 2014, pp. 39–76.

VERSE, D. et WIERSCH, R., « Die Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2014-2015 », *EuZW*, 2016, pp. 330–338.

VETTER, J., « Die Regelung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im UmwG », *AG*, 2006, p. 613–626.

VOSSIUS, O., « Gründung und Umwandlung der deutschen Europäischen Gesellschaft (SE) », *ZIP*, 2005, pp. 741–749.

WACHTER, Th., « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (II) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *GmbH-StB*, 2018, pp. 317–332.

WACHTER, Th., « Neues zum Europäischen Umwandlungsrecht (I) – Grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel », *GmbH-StB*, 2018, pp. 283–296.

WACHTER, Th., « Verstoß einer die Sitzverlegung von vorheriger Auflösung der Gesellschaft machender innerstaatlicher Regelung gegen die Niederlassungsfreiheit – Polbud », *NZG*, 2017, pp. 1308–1314.

WACHTER, Th., « Ausländische GmbH: Rechts- und Parteifähigkeit einer liechtensteinischen Kapitalgesellschaft mit tatsächlichem Verwaltungssitz im Inland », *GmbHR*, 2005, pp. 1483–1485.

WEISS, S. et WÖHLERT, H.-T., « Die „Sevic-Entscheidung" des EUGH - „sudden death" für Societas Europaea und Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung und Wegbereiter für grenzüberschreitende Spaltungen ? », *WM*, 2007, pp. 580–585.

WELLER, M.-Ph., « Zum identitätswahrenden Wegzug deutscher Gesellschaften », *DStR*, 2004, pp. 1218–1220.

WENG, A., « Die Rechtssache Cartesio – Das Ende Daily Mails ? », *EWS*, 2008, pp. 264–272.

WICKE, H., « Optionen und Komplikationen bei der Umsetzung des Richtlinienvorschlags zum grenzüberschreitenden Formwechsel (Teil II) », *DStR*, 2018, pp. 2703–2710.

WICKE, H., « Optionen und Komplikationen bei der Umsetzung des Richtlinienvorschlags zum grenzüberschreitenden Formwechsel (Teil I) », *DStR*, 2018, pp. 2642–2647.

WICKE, H., « EuGH : Grenzüberschreitender Formwechsel kann ohne Verlegung des Verwaltungssitzes in Zuzugstaat zulässig sein », *DStR*, 2017, pp. 2684–2691.

WOLF, U., « Der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen bei Gesellschaften - eine Anmerkung zu der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Interedil (C-396/09) », *GPR*, 2012 pp. 149–153.

ZWIRLEIN, S., « Grenzüberschreitender Formwechsel – europarechtlich veranlasste Substitution im UmwG – Zugleich Besprechung von KG, Beschluss v. 21.3.2016, 22 W 64/15 », *ZGR*, 2017, pp. 114–128.

ZIMMER, D., « Wie es Euch gefällt ? Offene Fragen nach dem Überseering-Urteil des EuGH », *BB*, 2003, pp. 1–7.

ZIMMER, D. « Mysterium „Centros" – Von der schwierigen Suche nach der Bedeutung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes », *ZHR*, 2000, pp. 23–42.

ZÖLLNER, W., « Aktienrechtsreform in Permanenz – Was wird aus den Rechten des Aktionärs ? », *AG*, 1994, pp. 336–441.

ZWIRLEIN, S., GROSSERICHTER, H. et GÄTSCH, A., « Handlungsoptionen für Gesellschaften englischen Rechts in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der LLP », *NZG*, 2017, pp. 1041–1046.

2.4. Doctrine en langue néerlandaise

2.4.1. *Thèses et monographies*

BIERMEYER, T., *Stakeholder Protection in Cross-Border Seat Transfers in the EU: between freedom and boundaries,* Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2015.

BYTTEBIER, K., *Fusies en overnames*, Brugge, die Keure, 2007.

ROELOFS, R., *Grensoverschrijdende juridische Splitsing van Kapitaalvennootschappen*, Deventer, Kluwer, 2014.

2.4.2. *Articles et ouvrages collectifs*

MARESCEAU, Kr., « De invoering van de statutaire zetelleer en de procedure tot grensoverschrijdende omzetting », in *Le projet de Code des sociétés et associations – Het ontwerp Wetboek van vennootschapen en verenigingen*, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 55–77.

MEEUSEN, J., « Het Polbud-arrest van het Hof van Justitie : Europese vennootschapsmobiliteit op nieuwe wegen », *RW*, 16 décembre 2017, p. 602.

MORBÉE, K., « Hof van Justitie 8 maart 2017, C-14/16, Euro Park Service », *T.F.R.*, 2017, n° 523, p. 501.

PALMAERS, G. et GUBBELS, A., « De grensoverschrijdende fusie », *T.F.R.*, 2008/4, pp. 251–282.

PARREIN, Fl., « De wet van 8 Juni 2008 en de grensoverschrijdende fusie », *RW*, 23 octobre 2010, n° 8, pp. 306–320.

DE POTTER DE TEN BROECK, M., « De imprevisieleer : de rechter met de pen in de hand », *RW*, 2 juin 2018, n° 40, pp. 1563–1575.

WAUTERS, M., « Fusie, splitsing en andere herstructureringen : de verslagplicht op drift ? », *T.R.V.*, 2010, pp. 539–549.

DE WULF, H., « Borgtocht en fusie, enkele opmerkingen », *RDC-TBH*, 2017/5, pp. 549–551.

DE WULF, H., « Grensoverschrijdende fusies na *Sevic* en de Tiende Richtljn », *R.B.D.I.P.R.-T.I.P.R.*, avril 2006, pp. 80–96.

WYCKAERT, M., « Grensoverschrijdende fusies – De procedurele kant », in *Grensoverschrijdende fusies zjn een feit*, Bruxelles, Knops Publishing, 2009, pp. 47–77.

WYCKAERT, M., « Grensoverschrijdende Fusies », *T.R.V.*, 2006, pp. 90–103.

2.5. **Doctrine économique, militaire, sociologique et archéologique**

2.5.1. *Doctrine économique*

AKERLOF, G., « Market for "lemons" : quality uncertainty and the market mechanism », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, 1970, pp. 488–500.

ALLEN, J., LUMMER, S., Mc CONNELL, J. et REED, D., « Can takeover losses explain spin-off gains ? », *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1995/4, pp. 465–485.

ANDRUSHKO, A., « The Reverse Synergy : Another Way of Thinking », *I.J.E.P.T.*, avril 2012, vol. 2, n° 2, pp. 68–74.

ARMOUR, J., « Share capital and creditor protection : efficient rules for a modern company law », *Modern Law Review*, 2000, pp. 355–378.

BARNETO, P., « Scission et option d'abandon d'un conglomérat », *Finance*, 2002/15, pp. 48–52.

BAUCHARD, Fl., « Jacques Stern, la réussite d'une scission d'entreprises », *Les Echos*, 6 février 2014, disponible sur www.lesechos.fr (22/02/2016).

BESSIÈRE, V., KAESTNER, M. et LAFONT, A. – L., « Hedge fund activism : insights from a French clinical study », *Applied Financial Economics*, 2011, n° 21, pp. 1225–1234.

BERGER, P.G. et OFEK, E., « Diversification's effect on firm value », *Journal of Financial Economics*, 1995/37, pp. 39–65.

BESTER, H. et RITZBERGER, K., « Strategic pricing, signalling, and costly information acquisition », International *Journal of Industrial Organization*, 2001, vol. 19, issue 9, pp. 1347–1361.

BOSSE, D., PHILLIPS, R. et HARRISON, J., « Stakeholders, reciprocity, and firm performance », *SMJ*, n° 30, 2009, pp. 447–456.

BRIDOUX, Fl. et STOELHORST, J. W., « Microfoundations for stakeholder theory: managing stakeholders with heterogenous motives », *SMJ*, n° 35, 2014, pp. 107–125.

BURG, D. et VILARS, T., « Philips engage une scission historique de ses activités », *Les Echos*, 23 septembre 2014, disponible sur www.lesechos.fr (21/02/2017).

CAMPBELL, A., « When a spinoff makes strategic sense », *Harvard Business Review*, 2014/08, disponible sur https://hbr.org (6/01/2017), pp. 1–6.

CAVALE, S. et WENDLANDT, A., « Coty buying P&G beauty business for $12.5 billions », 9 juillet 2015, disponible sur https://www.reuters.com (07/09/2020).

CREMERS, K. J. M., GUERNSEY, S. B. et SEPE, S. M., *Stakeholder orientation and firm value*, avril 2019, disponible sur http://www.fmaconferences.org/ (15/10/2020), pp. 1–55.

DAHIYA, S., HALLAK, I. et MATTHYS, Th., « Targeted by an activist hedge fund, do the lenders care ? », *Journal of Corporate Finance*, 2020, n° 62, pp. 1–25.

DELANGEAIS, L., « Comment Frans van Houten a métamorphosé Philips », *Capital*, 10 février 2016, disponible sur www.capital.fr (21/02/2021).

DESAI, H. et JAIN, Pr., « Firm performance and focus: long-run stock market performance following spinoffs », *Journal of Financial Economics*, n° 54, 1999, pp. 75–101.

DOMADENIK, P., LIZAL, L. et PAHOR, M., « The effect of enterprise break-ups on performance. The case of the former Yugoslav Republic of Macedonia », *Revue économique*, 2012/5 (Vol. 63), pp. 849–866.

DONALDSON, Th. et PRESTON, L. E., « The stakeholder theory of the corporation : concepts, evidence and implications », *Academy of Management Review*, 1995, vol. 20, n° 1, pp. 65–91.

DUHAIME, I. et PATTON, G., « Selling off », *The Wharton Magazine*, 1980, pp. 43–47.

DUHAIME, I. et GRANT, J., « Factors influencing divestment decision-making : Evidence from a field study », *SMJ*, 1984/4, pp. 301–318.

FENG, Y., NANDY, D. et TIAN, Y., « Executive compensation and the corporate spin-off decision », *Journal of Economics and Business*, n° 77, 2015, pp. 94–117.

GARRO, A. M., « Force majeure, hardship and other excuses », *RDIDC*, 2015/2, pp. 217–231.

GUINOT, D., « Covid-19, l'endettement des entreprises, une menace pour les banques », *Le Figaro*, 23 juin 2020, disponible sur https://www.lefigaro.fr/ (28/10/2020).

HARRISON, J., BOSSE, D. et PHILLIPS, R., « Managing for stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive advantage », *SMJ*, n° 31, 2010, pp. 58–74.

HAMILTON, R. et KONG CHOW, Y., « Why managers divest – Evidence from New Zealand's largest companies », *SMJ*, 1993/6, pp. 479 et s.

HANNA, D., « How GM destroyed its Saturn success », *Forbes*, 3 août 2010, disponible sur http://www.forbes.com/2010/03/08/saturn-gm-innovation-leadership-managing-failure.html (27/01/2017).

HAWAWINI, G. et VIALLET, Cl., *Finance for Executives – Managing for Value Creation*, 4th ed., Mason, South-Western Cengage Learning, 2011.

HAYWARD, M. et HAMBRICK, D., « Explaining the premiums paid for large acquisitions: Evidence of CEO hubris », *Administrative Science Quarterly*, 1997/42, pp. 103–127.

HERVEY, R., « Saturn – Le pari de General Motors », *Le Monde Diplomatique*, août 1986, disponible sur https://www.monde-diplomatique.fr/1986/08/HERVEY/39411 (27/01/2017).

HERWEG, F. et MÜLLER, D., « Overconfidence in the markets for lemons », *Scandinavian Journal of Economics*, 2016, vol. 118(2), pp. 354–371.

HILL, A., « How C&W's radical restructure fell short », *F.T.*, 10 décembre 2012, disponible sur www.ft.com (22/02/2017).

HILLMAN, A. et KEIM, G., « Shareholder value, stakeholder management, and social issues: what's the bottom line ? », *SMJ*, 2001, n° 22, pp. 135.

JACQUIN, J.-B., « Procter & Gamble – Coty : l'obsession fiscale pollue la stratégie », *Le Monde*, 10 juillet 2015, disponible sur https://www.lemonde.fr (07/09/2020).

JONES, Th., HARRISON, J. et FELPS, W., « How applying instrumental stakeholder theory can provide sustainable competitive advantage », *Academy of Management Review*, 2018, vol. 43, n° 3, pp. 371.

KLEIN, A. et ROSENFELD, J., « The long-run performance of sponsored and conventional spin-offs », *Financial Management*, 2010, pp. 227–247.

KRISHNASWAMI, S. et SUBRAMANIAM, V., « Information asymmetry, valuation, and the corporate spin-off decision », *Journal of Financial Economics*, n° 53, 1999, pp. 73–112.

LACHAPELLE, T., « Altria Philip Morris Should Become One Company Again », *Bloomberg*, 28 juillet 2015, disponible sur www.bloomberg.com (21/02/2017).

LEDERER, E. et BENHAMOU, E., « Covid-19, en deux mois, l'endettement des entreprises a bondi de 90 milliards d'euros », *Les Echos*, 29 mai 2020, disponible sur https://www.lesechos.fr/ (28/10/2020).

LETESSIER, I., « Coty et Procter créent un géant de la beauté », *Le Figaro*, 10 juillet 2014, disponible sur https://www.lefigaro.fr/societes/2015/07/09/20005-20150709ARTFIG00265-coty-et-procter-creent-un-geant-de-la-beaute.php (17/02/2017).

LINN, S. et ROZEFF, M., « The effect of voluntary spin-off on stock prices : the anergy hypothesis », *Advances in Financial Planning and Forecasting*, 1985, pp. 265–291.

MULHERIN, J. H. et BOONE, A. L., « Comparing acquisitions and divestitures », *J.C.F.*, 2000/6, pp. 117–139.

PRODHAN, G. et BURGER, L., « Bayer va scinder MaterialScience et se recentrer sur la santé », 18 septembre 2014, disponible sur http://fr.reuters.com/ (10/02/2017).

RADDA, A., AKANNO, S., UZODINMA, I., ABBA, S. et ABDULKADIR, A., « Demerger or Break-up of Companies: A Management Strategy or Tragedy », *IJMOS*, 2015/4(4), pp. 179–185.

ROLLIN, Fr., « La hausse de l'endettement va-t-elle nous précipiter dans une seconde récession ? », *Capital*, 21 octobre 2020, disponible sur https://www.capital.fr (28/10/2020).

SLOAN, A., « For tax techis, P&G's deal with Coty is a thing of beauty », *The Washington Post*, 16 juillet 2015, disponible sur https://www.washingtonpost.com (07/09/2020).

Mc TAGGART, J., KONTES, P. et MANKINS, M., *Value Imperative – Managing for superior shareholder returns*, University of Michigan, Free Press, 1994.

TEALL, J. L., *Financial trading and investing*, 2nd ed., London, Academic Press, 2018.

THÉRIN, Fr., « Comment Osram a su rester le roi de l'ampoule électrique », *Capital*, 6 mars 2018, www.capital.fr (06/08/2021).

THOMAS, D., « Liberty Global completes Pounds 3.5 billion deal for CWC », *F.T.*, 16 mai 2016, disponible sur www.ft.com (14/10/2020).

THOMAS, D., « End of the line for Cable & Wireless », *F.T.*, 17 novembre 2015, disponible sur www.ft.com (14/10/2020).

VELD, Chr. et VELD-MERKOULOVA, Y., « Do spin-offs really create value ? – The European case », *Journal of Banking & Finance*, n° 28, 2004, pp. 1111–1135.

WAJSBROT, S., « La lampe à incandescence s'éteint en Europe », *Les Echos*, 28 décembre 2012, disponible sur www.lesechos.fr (06/07/2021).

WALLENDER III, H. W., « A planned approach to divestment », *Management Review*, juillet 1973, pp. 54–58.

2.5.2. *Doctrine militaire*

COUTAU-BÉGARIE, H., *Traité de stratégie*, Paris, Economica, 1999.

Mémento sur la défense en profondeur appliquée aux systèmes d'information du Secrétariat général de la défense nationale français du 19 juillet 2004, disponible sur https://www.ssi.gouv.fr (23/11/2020).

2.5.3. *Doctrine sociologique*

ALBERT, M., *Capitalisme contre capitalisme*, Paris, Seuil, 1991.

SCIULLI, D., *Corporate power in civil society – An application of societal constitutionalism*, New York, New York University Press, 2001.

2.5.4. *Doctrine archéologique*

BELAIEW, N. T., « Au sujet de la valeur probable de la mine sumérienne », *Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale*, 1929, vol. 26, n° 3, pp. 115–132.

2.6. Autres documents et communications

Communication de Covestro du 23 février 2016, « Successful first year for Covestro », disponible sur www.investor.covestro.com (10/02/2017).

Communication de Bayer AG du 1er septembre 2015, « L'ancien Bayer MaterialScience est maintenant légalement et économiquement indépendant – Covestro opérationnel », disponible sur www.bayer.be (10/02/2017).

OECD, *Policies for productivity : the design of insolvency regimes across countries*, 2018, disponible sur www.oecd.org (16/01/2020).

X., « Wacker Chemie erwägt Abspaltung der Halbleiter Sparte », *Die Welt*, 10 mars 2015, disponible sur www.welt.de (21/02/2017).

X., « Cable Wireless plc. – Demerger update and interim management statement », 2 février 2010, disponible sur www.investegate.co.uk (22/02/2017).

X., « Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie denkt über eine Abspaltung seiner Halbleitersparte Siltronic nach », disponible sur www.finanzen.net (21/02/2017).

X., « Distrigaz S.A. : proposition de scission approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires », 30 novembre 2011, disponible sur www.fluxys.com (17/07/2017).

X., *Demande d'inscription au premier marché de Euronext Brussels de toutes les parts sociales D de Distrigaz (nouvelle)*, disponible sur www.fluxys.com (17/07/2017).

X., « La scission d'Eridania Béghin-Say bénéfique aux actionnaires », *Les Echos*, 21 août 2001, disponible sur www.lesechos.fr (23/02/2017).

3. JURISPRUDENCE

3.1. Jurisprudence européenne

3.1.1. *Arrêts de la Cour*

2020

C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele, en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 30 janvier 2020, C-394/18, EU:C:2020:56.

2019

C.J., arrêt *Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egge, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH c. Enrico Casamassima*, 10 juillet 2019, C-722/17, EU:C:2019:577.

C.J., gde ch., arrêt *N Luxembourg 1 e.a. c. Skatteministeriet*, 26 février 2019, C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, EU:C:2019:134.

2018

C.J, arrêt *Feniks sp. z o.o. c. Azteca Products & Services SL*, 4 octobre 2018, C-337/17, EU:C:2018:805.

C.J., arrêt *E.ON Czech Holding AG c. Michael Dědouch, Petr Streitber et Pavel Suda*, 7 mars 2018, C-560/16, EU:C:2018:167.

2017

C.J., gde ch., arrêt *Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.*, 25 octobre 2017, C-106/16, EU:C:2017:804.

C.J., arrêt *Trustees of the P Panayi Accumulation and Maintenance Settlements c. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*, 14 septembre 2017, C-646/15, EU:C:2017:682.

C.J., arrêt *Euro Park Service c. Ministre des finances et des comptes publics*, 8 mars 2017, C-14/16, EU:C:2017:177.

2016

C.J., gde ch., arrêt *Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) c. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis*, 21 décembre 2016, C-201/15, EU:C:2016:972.

C.J., arrêt *SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA c. Fazenda Pública*, 24 novembre 2016, C-464/14, EU:C:2016:896.

C.J., gde ch., arrêt *Ullens de Schooten c. État belge*, 15 novembre 2016, C-268/15, EU:C:2016:874.

C.J., arrêt *Promoimpresa Srl c. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro et Regione Lombardia et Mario Melis e.a. c. Comune di Loiri Porto San Paolo et Provincia di Olbia Tempio*, 14 juillet 2016, C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558.

C.J., arrêt *Höszig Kft. c. Alstom Power Thermal Services*, 7 juillet 2016, C-222/15, EU:C:2016:525.

C.J., ord. *Leonmobili Srl, Gennaro Leone c. Homag Holzbearbeitungssyteme GmbH, Custela del Fallimento Leonmobili Srl, ICO Srl, Arturo Salice SpA, Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino, Deutsche Bnk SpA, Fida Srl et Elica SpA*, 24 mai 2016, C-353/15, EU:C:2016:374.

C.J., arrêt *Profit Investment SIM SpA c. Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, Profit Holding SpA, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore et E3 SA*, 20 avril 2016, C-366/13, EU:C:2016:282.

C.J., arrêt *KA Finanz AG c. Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group*, 7 avril 2016, C-483/14, EU:C:2016:205.

2015

C.J., arrêt *Simona Kornhaas c. Thomas Dithmar*, 10 décembre 2015, C-594/14, EU:C:2015:806.

C.J., arrêt *Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE c. OCA Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña*, 15 octobre 2015, C-168/14, EU:C:2015:685.

C.J., arrêt *Jaouad El Madjoub c. CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH*, 21 mai 2015, C-322/14, EU:C:2015:334.

C.J., arrêt *Modelo Continente Hipermercados SA c. Autoridade para as Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT)*, 5 mars 2015, C-343/13, EU:C:2015:146.

C.J., gde ch., arrêt *Conseil de l'Union européenne et Commission européenne c. Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe*, 13 janvier 2015, C-404/12, EU:C:2015:5.

2014

C.J., arrêt *Kronos International Inc. c. Finanzamt Leverkusen*, 11 septembre 2014, C-47/12, EU:C:2014:2200.

C.J., arrêt *Strojírny Prostějov, a.s., ACO Industries Tábor s.r.o. c. Odvolací finanční ředitelství*, 19 juin 2014, C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011.

C.J., arrêt *Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company c. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy*, 10 avril 2014, C-190/12, EU:C:2014:249.

C.J., arrêt *Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona c. Generalidad de Cataluña*, 20 mars 2014, C-139/12, EU:C:2014:174.

C.J., gd ch., arrêt *O c. Minister voor Immigratie, Intgratie en Asiel et Minister voor Immigratie, Intgratie en Asiel c. B.*, 12 mars 2014, C-456/12, EU:C:2014:135.

C.J., arrêt *DMC Beteiligungsgesellschaft mbH c. Finanzamt Hamburg-Mitte*, 23 janvier 2014, C-164/12, EU:C:2014:20.

2013

C.J., arrêt *Yvon Welte c. Finanzamt Velbert*, 17 octobre 2013, C-181/12, EU:C:2013:662.

C.J., arrêt *Elodie Giersch e.a. c. État du Grand-Duché de Luxembourg*, 20 juin 2013, C-20/12, EU:C:2013:411.

C.J., arrêt *Refcomp SpA c. Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network et Climaveneta SpA*, 7 février 2013, C-543/10, EU:C:2013:62.

2012

C.J., gde. ch., arrêt *Test Claimants in the FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue et The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*, 13 novembre 2012, C-35/11, EU:C:2012:707.

C.J., arrêt *Marianne Scheunemann c. Finanzamt Bremerhaven*, 19 juillet 2012, C-31/11, EU:C:2012:481.

C.J., arrêt *VALE Építési kft*, 12 juillet 2012, C-378/10, EU:C:2012:440.

C.J., arrêt *Staatssecretaris van Financiën c. L. A. C. van Putten e.a.*, 26 avril 2012, C-578/10 à C-580/10, EU:C:2012:246.

2011

C.J., gde ch., arrêt *National Grid Indus BV c. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam*, 29 novembre 2011, C-371/10, EU:C:2011:785.

C.J., arrêt *Wienand Meilicke et autres c. Finanzamt Bonn-Innenstadt*, 30 juin 2011, C-262/09, EU:C:2011:438.

C.J., arrêt *Prunus SARL, Polonium SA c. Directeur des services fiscaux*, 5 mai 2011, C-384/09, EU:C:2011:276.

C.J., gde ch., arrêt *Lesoochranárske zoskupenie VLK c. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky*, 8 mars 2011, C-240/09, EU:C:2011:125.

C.J., arrêt *Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH et Österreichische Salinen AG c. Finanzamt Linz*, 10 février 2011, C-437/08 et C-436/08, EU:C:2011:61.

2010

C.J., 16 décembre 2010 (*Commission c. France*), C-89/09.

C.J., arrêt *Établissements Rimbaud SA c. Directeur général des impôts et Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence*, 28 octobre 2010, C-72/09, EU:C:2010:645.

C.J., gde ch., arrêt *Schmelz c. Finanzamt Waldviertel*, 26 octobre 2010, C-97/09, EU:C:2010:632.

C.J., arrêt *Idryma Typou AE c. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis*, 21 octobre 2010, C-81/09, EU:C:2010:622.

C.J., arrêt *Commission c. Allemagne*, 21 janvier 2010, C-546/07, EU:C:2010:25.

C.J., arrêt *Société de Gestion Industrielle (SGI) c. État belge*, 21 janvier 2010, C-311/08, EU:C:2010:26.

2009

C.J.C.E., arrêt *Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG c. Finanzamt München II*, 17 septembre 2009, C-182/08, EU:C:2009:559.

C.J.C.E, gde ch., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République italienne*, 19 mai 2009, C-531/06, EU:C:2009:315.

C.J.C.E., 19 mai 2009 (*Commission c. Italie*), C-222/97.

C.J.C.E., Commission des Communautés européennes c. République italienne, 26 mars 2009, C-326/07, EU:C:2009:193.

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Danske Slagterier c. Bundesrepublik Deutschland*, 24 mars 2009, C-445/06, EU:C:2009:178.

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Hein Persche c. Finanzamt Lüdenscheid*, 27 janvier 2009, C-318/07, EU:C:2009:33.

2008

C.J.C.E., gde ch., arrêt *CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt*, 16 décembre 2008, C-210/06, EU:C:2008:723.

C.J.C.E., arrêt *Hans Eckelkamp et autres c. Belgische Staat*, 11 septembre 2008, C-11/07, EU:C:2008:489.

C.J.C.E., arrêt *Commission c. France*, 17 juillet 2008, C-389/05, EU:C:2008:411.

C.J.C.E., arrêt *Finanzamt Hamburg-Am Tierpark c. Burda GmbH*, 6 juin 2008, C-284/06, EU:C:2008:365.

2007

C.J.C.E., arrêt *Skatteverket c. A.*, 18 décembre 2007, C-101/05, EU:C:2007:804.

C.J.C.E., arrêt *Columbus Container Services BVBA & Co. c. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt*, 6 décembre 2007, C-298/05, EU:C:2007:754.

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République fédérale d'Allemagne*, 23 octobre 2007, C-112/05, EU:C:2007:623.

C.J.C.E., arrêt *Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (ELISA) c. Directeur général des impôts et Ministère public*, 11 octobre 2007, C-451/05, EU:C:2007:594.

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Oy AA*, 18 juillet 2007, C-231/05, EU:C:2007:439.

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato c. Lucchini SpA, anciennement Lucchini Siderurgica SpA*, 18 juillet 2007, C-119/05, EU:C:2007:434.

C.J.C.E., arrêt *Commission c. Allemagne*, 18 juillet 2007, C-490/04, EU:C:2007:430.

C.J.C.E., arrêt *J. van der Weerd et autres (C-222/05), H. de Rooy sr. et H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van 't Oever et autres (C-224/05) et B. J. van Middendorp (C-225/05) c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit*, 7 juin 2007, C-222/05 à C-225/05, EU:C:2007:318.

C.J.C.E., arrêt *Winfried L. Holböck c. Finanzamt Salzburg-Land*, 24 mai 2007, C-157/05, EU:C:2007:297.

C.J.C.E., ord. *Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH c. Finanzamt Emmendingen*, 10 mai 2007, C-492/04, EU:C:2007:273.

C.J.C.E., ord. *Skatteverket c. À et B*, 10 mai 2007, C-102/05, EU:C:2007:275.

2006

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Test Claimants in the FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue*, 12 décembre 2006, C-446/04, EU:C:2006:774.

C.J.C.E., arrêt *Fidium Finanz AG c. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, 3 octobre 2006, C-452/04, EU:C:2006:631.

C.J.C.E., arrêt *Centro di Musicologia Walter Stauffer c. Finanzamt München für Körperschaften*, 14 septembre 2006, C-386/04, EU:C:2006:568.

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd c. Commissioners of Inland Revenue*, 12 septembre 2006, C-196/04, EU:C:2006:544.

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Eurofood IFSC Ltd.*, 2 mai 2006, C-341/04, EU:C:2006:281.

C.J.C.E., arrêt *Héritiers de M. E. A. van Hilten-van der Heijden c. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen*, 23 février 2006, C-513/03, EU:C:2006:131.

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Susanne Staubitz-Schreiber*, C-1/04, 17 janvier 2006, EU:C:2006:39.

2005

C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:762.

C.J.C.E., arrêt *Marks & Spencer plc c. David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes)*, 13 décembre 2005, C-446/03, EU:C:2005:763.

2004

C.J.C.E., arrêt *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, 14 octobre 2004, C-36/02, EU:C:2004:614.

C.J.C.E., gde ch., arrêt *Caixa Bank France c. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*, 5 octobre 2004, C-442/02, EU:C:2004:586.

C.J.C.E., arrêt *Lasteyrie du Saillant c. Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie*, 11 mars 2004, C-9/02, EU:C:2004:138.

2003

C.J.C.E., arrêt *Inspire Art Ltd c. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam*, 30 septembre 2003, C-167/01, EU:C:2003:512.

C.J.C.E., arrêt *Försäkringsaktiebolaget Skandia (pub) et Ola Ramstedt c. Riksskatteverket*, 26 juin 2003, C-422/01, EU:C:2003:380.

C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. Royaume d'Espagne*, 13 mai 2003, C-463/00, EU:C:2003:272.

C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord*, 13 mai 2003, C-98/01, EU:C:2003:273.

2002

C.J.C.E., arrêt *Lankhorst-Hohorst GmbH c. Finanzamt Steinfurt*, 12 décembre 2002, C-324/00, EU:C:2002:749.

C.J.C.E., arrêt *Überseering BV c. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)*, 5 novembre 2002, C-208/00, EU:C:2002:632.

C.J.C.E., arrêt *Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA et ADP GSI SA*, 17 octobre 2002, C-79/01, EU:C:2002:592.

C.J.C.E., arrêt *Rolf Dieter Banner*, 3 octobre 2002, C-136/00, EU:C:2002:558.

C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. Royaume de Belgique*, 4 juin 2002, C-503/99, EU:C:2002:328.

C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République française*, 4 juin 2002, C-483/99, EU:C:2002:327.

C.J.C.E., arrêt *Andersen og Jensen ApS c. Skatteministeriet*, 15 janvier 2002, C-43/00, EU:C:2002:15.

2001

C.J.C.E., arrêt *Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.*, 13 septembre 2001, C-169/99, EU:C:2001:439.

C.J.C.E., arrêt *Metallgesellschaft Ltd e. a., Hoechst AG et Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) c. Commissioners of Inland Revenue et HM Attorney General*, 8 mars 2001, C-397/98 et C-410/98, EU:C:2001:134.

C.J.C.E., arrêt *Mac Quen, Pouton, Godts, Antoun c. Grandvision Belgium SA*, 1er février 2001, C-108/96, EU:C:2001:67.

2000

C.J.C.E., arrêt *Emsland-Stärke GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, 14 décembre 2000, C-110/99, EU:C:2000:695.

C.J.C.E., arrêt *Coreck Maritime GmbH c. Handelsveem BV e.a.*, 9 novembre 2000, C-387/98, EU:C:2000:606.

C.J.C.E., arrêt *C. Baars c. Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem*, 13 avril 2000, C-251/98, EU:C:2000:205.

1999

C.J.C.E., arrêt *Klaus Konle c. Republik Österreich*, 1er juin 1999, C-302/97, EU:C:1999:271.

C.J.C.E., arrêt *Ciola c. Land Vorarlberg*, 29 avril 1999, C-224/97, EU:C:1999:212.

C.J.C.E., arrêt *Royal Bank of Scotland plc c. Elliniko Dimosio (État hellénique)*, 29 avril 1999, C-311/97, EU:C:1999:216.

C.J.C.E., arrêt *Manfred Trummer et Peter Mayer*, 16 mars 1999, C-222/97, EU:C:1999:143.

C.J.C.E., arrêt *Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen*, 9 mars 1999, C-212/97, EU:C:1999:126.

1998

C.J.C.E., arrêt *Ministero delle Finanze c. IN.CO.GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl, Camed Srl, Pomezia Progetti Appalti Srl (PPA), Edilcam Srl, A. Cecchini & C. Srl, EMO Srl, Emoda Srl, Sappesi Srl, Ing. Luigi Martini Srl, Giacomo Srl et Mafar Srl*, 22 octobre 1998, C-10/97 à C-22/97, EU:C:1998:498.

C.J.C.E., arrêt *Imperial Chemical Industries plc (ICI) c. Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes))*, 16 juillet 1998, C-264/96, EU:C:1998:370.

C.J.C.E., arrêt *Safety Hi-Tech Srl c. S. & T. Srl.*, 14 juillet 1998, C-284/95, EU:C:1998:352.

C.J.C.E., arrêt *Nicolas Decker c. Caisse de maladie des employés privés*, 28 avril 1998, C-120/95.

1997

C.J.C.E., arrêt *procédure pénale c. René Kieffer et Romain Thill*, 25 juin 1997, C-114/96, EU:C:1997:316.

C.J.C.E., arrêt *Unità Socio-Sanitaria Locale n° 47 di Biella (USSL) c. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, 16 janvier 1997, C-134/95, EU:C:1997:16.

1996

C.J.C.E., arrêt *P. H. Asscher c. Staatssecretaris van Financiën*, 27 juin 1996, C-107/94, EU:C:1996:251.

1995

C.J.C.E., arrêt *Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional c. Sanz de Lera, Jiménez et Kapanoglu*, 14 décembre 1995, C-163/94, C-165/94 et C-250/94, EU:C:1995:451.

C.J.C.E., arrêt *Gebhard c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano*, 30 novembre 1995, C-55/94, EU:C:1995:411.

1994

C.J.C.E., arrêt *Meyhui NV c. Schott Zwiesel Glaswerke AG*, 9 août 1994, C-51/93, EU:C:1994:312.

1993

C.J.C.E., arrêt *Federación de Distribuidores Cinematografícos*, 4 mai 1993, C-17/92, EU:C:1993:172.

C.J.C.E., arrêt *Kraus c. Land Baden-Württemberg*, 31 mars 1993, C-19/92, EU:C:1993:125.

1992

C.J.C.E., arrêt *Jakob Handte & Co. GmbH c. Traitements mécano-chimiques des surfaces SA*, 17 juin 1992, C-26/91, EU:C:1992:268.

C.J.C.E., arrêt *Powell Duffryn c. Wolfgang Petereit*, 10 mars 1992, C-214/89, EU:C:1992:115.

1991

C.J.C.E., arrêt *Ligur Carni Srl et Genova Carni Srl contre Unità Sanitaria Locale n. XV di Genova et Ponente SpA c. Unità Sanitaria Locale n. XIX di La Spezia et CO.GE.SE.MA Coop a r l.*, 15 décembre 1993, C-277/91, C-318/91 et C-319/91, EU:C:1993:927.

C.J.C.E., arrêt *Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia (ERT AE) c. Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP) et Kouvelas*, 18 juin 1991, C-260/89, EU:C:1991:254.

C.J.C.E., arrêt *Klaus Höfner et Fritz Elser c. Macrotron GmbH*, 23 avril 1991, C-41/90, EU:C:1991:161.

1989

C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République hellénique*, 30 mai 1989, C-305/87, EU:C:1989:218.

1988

C.J.C.E., arrêt *The Queen c. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc*, 27 septembre 1988, C-81/87, EU:C:1988:456.

C.J.C.E., arrêt *Christopher Stanton et SA belge d'assurances "L'Étoile 1905" contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)*, 7 juillet 1988, C-143/87, EU:C:1988:378.

C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République italienne*, 14 janvier 1988, C-63/86, EU:C:1988:9.

1987

C.J.C.E., arrêt *Ministère public c. André Gauchard*, 8 décembre 1987, aff. 20/87, ECLI:EU:C:1987:532.

1986

C.J.C.E., arrêt *Commission des Communautés européennes c. République fédérale d'Allemagne*, 4 décembre 1986, C-205/84, EU:C:1986:463.

C.J.C.E., arrêt *Segers c. Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen*, 10 juillet 1986, C-79/85, EU:C:1986:308.

C.J.C.E., arrêt *Parti écologiste "Les Verts" c. Parlement européen*, 23 avril 1986, C-294/83, EU:C:1986:166.

1985

C.J.C.E., arrêt *F. Berghoefer GmbH & Co. KG c. ASA SA*, 11 juillet 1985, C-221/84, EU:C:1985:337.

1984

C.J.C.E., arrêt *Denkavit Nederland BV c. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten*, 17 mai 1984, C-15/83, EU:C:1984:183.

C.J.C.E., arrêt *Graziana Luisi et Giuseppe Carbone c. Ministero del Tesoro*, 31 janvier 1984, C-286/82 et C-26/83, EU:C:1984:35.

1979

C.J.C.E., arrêt *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, 20 février 1979, C-120/78, EU:C:1979:42.

1978

C.J.C.E., arrêt *Société Les Commissionnaires Réunis SARL c. Receveur des douanes ; SARL Les fils de Henri Ramel c. Receveur des douanes*, 20 avril 1978, C-80 et 81/77, EU:C:1978:87.

1974

C.J.C.E., arrêt *Reyners c. État belge*, 21 juin 1974, C-2/74, EU:C:1974:68.

1973

C.J.C.E., arrêt *Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. c. Commission des Communautés européennes*, 21 février 1973, C-6/72, EU:C:1973:22.

3.1.2. *Conclusions des Avocats généraux*

Av. gén., M. SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt *I.G.I. Srl c. Maria Grazia Cicenia, Mario di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele en présence de Construziono Ing. Iandolo Srl*, 26 septembre 2019, C-394/18, EU:C:2019:790.

Av. gén., J. KOKOTT, concl. préc. C.J., gde ch., arrêt *Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., en liquidation*, 4 mai 2017, C-106/16, EU:C:2017:351.

Av. gén., Y. BOT, concl. préc. C.J., arrêt *KA Finanz AG c. Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group*, 7 avril 2016, C-483/14, EU:C:2015:757.

Av. gén. M. NIILO JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *VALE Építési kft*, 12 juillet 2012, C-378/10, EU:C:2011:841.

Av. gén., M. M. POIARES MADURO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt*, 16 décembre 2008, C-210/06, EU:C:2008:294.

Av. gén. M. D. R.-J. COLOMER, concl. préc. C.J., arrêt *Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH c. Deko Marty Belgium NV*, 16 octobre 2008, C-339/07, EU:C:2008:575.

Av. gén., A. TIZZANO, concl. préc. C.J.C.E., gde ch., arrêt *SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied*, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:437.

Av. gén., M. D. R.-J. COLOMER, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Überseering BV c. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)*, 5 novembre 2002, C-208/00, EU:C:2001:655.

Av. gén., M. M. DARMON, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *The Queen c. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc*, 27 septembre 1988, C-81/87, EU:C:1988:286.

3.2. Jurisprudence belge

3.2.1. *Cour de cassation*

Cass., 12 avril 2013, *R.G.D.C.*, 2013, p. 478.

Cass., 4 février 2013, *R.G.D.C.*, 2016/7, pp. 412–414.

Cass., 25 janvier 2013, *Pas.*, 2013/1, pp. 237–239.

Cass., 14 octobre 2010, *Pas.*, 2010, p. 2648.

Cass., 19 juin 2009, *Pas.*, 2009, p. 1590.

Cass., 16 mars 2009, *RDC*, 2009, pp. 956 et 957.

Cass., 20 avril 2006, *Pas.*, 2006, p. 884.

Cass., 9 février 2006, *Pas.*, 2006/2, pp. 336–341.

Cass., 5 janvier 2006, *Pas.*, 2006, pp. 40–49.
Cass. 14 avril 1994, *Pas.*, 1994, I, p. 365.
Cass., 26 octobre 1989, *Pas.*, 1990, I, n° 125, p. 248.
Cass., 11 janvier 1988, *Pas.*, 1988, I., n° 286, p. 558.
Cass., 30 avril 1970, *Pas.*, 1970, I, p. 749.
Cass., 16 novembre 1966, *Pas.*, 1967, I, p. 354.
Cass., 8 mai 1930, *Pas.*, 1930, I, p. 202.
Cass., 19 mai 1921, *Pas.*, 1921, I, p. 380.
Cass., 5 juin 1902, *Pas.*, 1902, I, p. 264.

3.2.2. *Conseil d'État*

C.E., 29 juin 1987, n° 28.267, *Pas.*, IV, 1990, p. 114.

3.2.3. *Autres juridictions*

Bruxelles, 21 juin 2016, *RDC-TBH*, 2017, pp. 544–550.
Gand, 2 avril 2012, *N.J.W.*, 2013, p. 32.
Liège, 12 septembre 2005, *J.L.M.B.*, 2007/23, p. 986.
Comm. Bruges (prés.), 13 juin 2001, *D.A. O.R.*, 2001, p. 280.
Bruxelles, 4e ch., 11 octobre 1999, n° 6804, *RPS*, 2000/2, pp. 146–155.
Liège, 30 juin 1989, *R.P.S.*, 1990, p. 173.
Mons, 17 mai 1988, *J.L.M.B.*, 1988, p. 1314.
Bruxelles, 6 décembre 1991, *T.R.V.*, 1992, p. 253.
Bruxelles, 4e ch., 11 octobre 1999, n° 6804, *RPS*, 2000/2, pp. 146–155.
Liège, 31 mars 1939, *R.P.S.*, 1939, p. 294.
Comm. Hasselt (réf.), 16 juillet 1997, *T.R.V.*, p. 331.
Comm. Tongres (réf.), 8 juillet 1997, *T.R.V.*, 1999, p. 335.
Comm. Bruxelles, 6 décembre 1935, *R.P.S.*, 1936, p. 20.
Comm. Bruxelles, 30 mars 1932, *R.P.S.*, 1932, p. 190.

3.3. Jurisprudence luxembourgeoise

3.3.1. *Cour de cassation*

Cass., 24 octobre 2013, n° 64/13, *Pas.*, 36, p. 393.

3.3.2. *Autres juridictions*

T.A. Luxembourg, 25 avril 2018, nos 181613, 184874 et 186633.
C.A. Luxembourg, 13 février 2014, n° 38087.
C.A. Luxembourg, 1er février 2012, nos 33072 et 33104.
C.A. Luxembourg, 20 janvier 2011, n° 35625, *Bull. Barreau 5/2011*, p. 71.
C.A. Luxembourg (4e ch.), 19 janvier 2005, *D.A. O.R.*, 2006/2, n° 78, pp. 158–160.

C.A. Luxembourg, 28 janvier 2004, n° 27591.
T.A. Luxembourg, 14 janvier 2002, *B.I.J.*, 2004/7, p. 119.
C.A. Luxembourg, 1er octobre 1997, nos 12583, 12771, 12859, 12896 et 20243.
C.A. Luxembourg, 9 février 1994, n° 14595.
T.A. Luxembourg, 8 avril 1987, n° 35197.

3.4. Jurisprudence française

3.4.1. *Cour de cassation*

Cass. com., 20 janvier 2015, n° 14-10.010 (F-D), *AJ Contrats d'affaires – Concurrence – Distribution*, 2015, p. 143.
Cass. com., 7 janvier 2014, n° 10-18.319, *RJDA*, 3/2014, n° 223.
Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, *RJDA*, 5/2013, n° 410.
Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-16.428, *RJDA*, 4/2010, n° 371.
Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-18.007, *Recueil Dalloz*, 2008, p. 1623.
Cass. com., 15 mai 2007, *BJS*, 1er octobre 2007, n° 10, p. 1075.
Cass. com., 7 juin 2006, *Recueil Dalloz*, 2006, p. 1685.
Cass. com., 13 décembre 2005, *RTD com.*, 2006, p. 429.
Cass. com., 21 janvier 2004, n° 00-14.549, *RJDA*, 6/04, n° 712.
Cass. com., 6 mai 2003, *BJS*, 2003, n° 10, pp. 812 et 813.
Cass. com., 21 janvier 2003, n° 97-13.027, *Bull. civ.*, 2003, IV, n° 9.
Cass. com., 29 octobre 2002, *Recueil Dalloz*, 2003, p. 429.
Cass. crim., 20 novembre 2001, *BJ*, 2004, p. 65.
Cass. com. 17 juillet 2001, *Recueil Dalloz*, 2001, p. 2414.
Cass. com. 17 juillet 2001, *Juris-Data*, n° 010686.
Cass., 3e civ., 16 février 2000, *Droit des sociétés*, n° 5, mai 2000, comm. 78.
Cass. civ., 27 mai 1997, n° 95-12.386, *RJDA*, 1997, n° 1163.
Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-12.018, *BJ*, 1997, p. 643.
Cass. com., 10 octobre 1995, n° 93-15.619, *BJ*, 1995, p. 1058.
Cass. com., 1er juin 1993, *BJS*, 1993, p. 892.
Cass. com., 12 juillet 1992, *BJ*, 1992, p. 1111.
Cass. com., 17 juillet 1990, n° 89-11.059, *Rev. Soc.*, 1991, p. 67.
Cass. com., 3 juin 1986, *BJS*, 1986, p. 757.
Cass. com., 16 juillet 1985, *Bull. civ. IV*, n° 218.
Cass., 30 mai 1971, *Clunet*, 1972, p. 836.
Cass. com., 4 juin 1996, *BJ*, 1996, p. 932.
Cass. civ., 6 mars 1876, *Recueil Dalloz*, 1876, I, p. 193.

3.4.2. *Conseil d'État*

C.E. France, 30 mars 1916, *Recueil Lebon*, p. 143.

3.4.3. *Autres juridictions*

C.A. Bordeaux, 4e ch., 18 février 2019, n° 17/03333, disponible sur www.lexis360.fr (07/01/2020), pp. 1–10.

C.A. Versailles, 12e ch., sect. 2, 27 janvier 2005, *BJ*, 2005, p. 612.

C.A. Paris, 28 décembre 1992, *BJ*, 1993, p. 434.

T. com. Nantes, 31 janvier 1974, *Gaz. Pal.*, 1974, 1, p. 433.

3.5. **Jurisprudence allemande**

3.5.1. *Bundesverfassungsgericht*

BVerfG, Urteil v. 1. März 1979, *NJW*, 1979, p. 593.

3.5.2. *Bundesgerichtshof*

BGH, 1er décembre 2003 (II ZR 161/02), *NZG*, 2004, pp. 186 à 189.

BGH, 24 octobre 1988 (II ZB 7/88), *BGHZ 105*, 1989, pp. 338 et s.

3.5.3. *Autres juridictions*

OLG Frankfurt, 3 janvier 2017, 20 W 88/15, *ZIP*, 2017, pp. 611–617.

KG, 21 mars 2016, 22 W 64/15, *ZIP*, 2016, pp. 1223–1225.

OLG Nürnberg, 19 juin 2013, 12 W 520/13, *ZIP*, 2014, pp. 128–130.

LG Koblenz, 16 septembre 2003, 4 HK T 1/03, *ZIP*, 2003, p. 2210.

3.6. **Jurisprudence autrichienne**

Oberster Gerichtshof Österreichs, 20 janvier 2009, 4OB188/08p, disponible sur www.ris.bka.gv.at (04/05/2017), pp. 1–49.

Oberster Gerichtshof Österreichs, 20 mars 2003, 6OB283/02i, disponible sur www.ris.bka.gv.at (04/05/2017), pp. 1–17.

Oberster Gerichtshof Österreichs, 11 novembre 1999, 6Ob4/99b, disponible sur www.ris.bka.gv.at (18/07/2019), pp. 1–9.

3.7. **Jurisprudence britannique**

Re Indah Kiat International Finance Co. BV [2016] B.C.C. 418.

Re Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privat bank" [2015] EWHC 3299 (Ch).

Re Codere Finance (UK) Ltd. [2015] EWHC 3778 (Ch).

Re Diamonds Resorts (Europe) Ltd [2013] B.C.C. 275.

Sovereign Life Assurance Co v. Dodd [1892] 2 Q.B. 573.

4. SITES INTERNET

European company (SE) database – ECDB, http://ecdb.worker-participation.eu/ (29/05/2020).

European Law Institute, https://www.europeanlawinstitute.eu (09/10/2020).

BRIS, https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_at_european_level-105-en.do (27/10/2020).

Portail suisse des petites et moyennes entreprises, https://www.kmu.admin.ch (16/06/2017).

5. DOCUMENTS SOCIAUX

Projet de scission du 13 septembre 2020 de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois TRANSLATE 4 U au profit de la société à responsabilité limitée de droit belge TRANSLATE 4U2, disponible sur https://www.lbr.lu (13/10/2020).

Common draft terms of merger (second-step statutory merger agreement) between Wright Luxembourg S.A. and Wright Medical Ltd. du 13 mars 2020, disponible sur https://www.lbr.lu (28/05/2020).

Common draft terms of the cross-border merger between Wright Medical Group N.V. as absorbed company and Wright Luxembourg S.A. as absorbing company du 13 mars 2020, disponible sur https://www.lbr.lu (28/05/2020).

Projet commun de scission de la société luxembourgeoise Immo Finland S.à r.l. du 29 janvier 2018, disponible sur https://www.lbr.lu (19/04/2018).

Prospectus of The Procter & Gamble Company offer to exchange all the shares of common stock of Galleria Co. that are owned by The Procter & Gamble Company and will be converted into shares of class A common stock of Coty Inc. for shares of common stock of The Procter & Gamble Company, September 1st, 2016, disponible sur https://www.sec.gov (07/09/2020).

Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, und der OSRAM Licht AG, München, über die Abspaltung einer Mehrheitsbeteiligung an OSRAM gemäß § 127 Satz 1 Umwandlungsgesetz vom 28 November 2012, disponible sur https://www.siemens.com (08/03/2018).

Minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of CONSOIL GEOTECHNIK S.à r.l. of May 28, 2013, disponible sur https://www.lbr.lu (19/04/2018).

Index alphabétique

Renvois à la page

A

Absorption du patrimoine de la société scindée, 110

Abus
- Actif net négatif, 122
- Associés minoritaires, 685, 824, 836, 837, 848, 868, 874, 887, 890
- Créanciers, 632, 634, 684, 685, 713, 715, 719, 745, 750, 757, 769, 783
- Disposition anti-abus, 312, 338, 514, 518, 523, 527, 535, 686, 690, 742, 743, 744, 771, 874, 927
- Expert indépendant, 780, 894
- *Forum shopping*, 764, 770, 774, 775, 804, 805
- Incohérence des régimes, 341
- Liberté d'établissement, 146, 163, 172, 177, 178, 189, 190, 191, 194, 196, 204, 969
- Participation des travailleurs, 928, 938

Acheteur, 870

Actif net négatif, 121, 576, 687, 874, 907

Action paulienne, 667

Apathie rationnelle, 647, 662, 665, 679, 695, 702, 709, 736, 745

Apport d'actifs, 67

Apport en nature, 99

Approbation de l'assemblée générale
- Caractère facultatif, 510
- Conditions de présence et de majorité, 502
- Condition suspensive et résolutoire, 503
- Contestation de la décision, 511
- Délai, objet et forme du procès-verbal, 500
- Droit applicable, 499
- Modification du projet de scission, 507
- Opposition des associés minoritaires, 835

Arrêt *Cartesio*, 166

Arrêt *Centros*, 172, 585

Arrêt *Daily Mail*, 165

Arrêt *Euro Park Service*, 162

Arrêt *Eurofood*, 766, 770

Arrêt *Feniks*, 675

Arrêt *Handte*, 677

Arrêt *I.G.I. Srl*, 669

Arrêt *Inspire Art*, 175, 586, 603, 630

Arrêt *Interedil*, 766, 768

Arrêt *KA Finanz*, 595, 604, 606, 611, 753, 785, 789

Arrêt *Kornhaas*, 758, 805

Arrêt *Modelo Continente Hipermercados*, 116

Arrêt *Polbud*, 186, 587, 603, 827, 924

Arrêt *Reitbauer*, 676

Arrêt *Segers*, 171

Arrêt *Sevic*, 152, 587, 603, 827, 923

Arrêt *Überseering*, 173, 587, 827, 923

Arrêt *Vale*, 180, 587, 827, 924

Aspects temporels
- Associés minoritaires, 901
- Créanciers, 671, 747, 906

Associés ayant des droits spéciaux, 418

Associés minoritaires
- Aspects temporels, 901
- Enjeux, 822
- Harmonisation, 896
- Liberté d'établissement, 826
- Mécanismes de protection, 832
- Nécessité d'un régime renforcé en cas d'opération transfrontalière, 828

Asymétrie d'information, 80

Avantages particuliers, 420, 421, 442

B

Branche d'activités
- Apport, 67
- Notion, 67, 740
- Respect de l'intégrité, 425, 428, 620, 739

Business judgement rule, 711

C

Calendrier indicatif de l'opération, 444

Capacité de scission, 399

Centre des intérêts principaux (COMI), 578, 765, 805

Certificat préalable, 184, 192, 313, 319, 329, 516, 518, 519, 523, 524

Clause attributive de juridiction, 729

Clause d'agrément, 726, 841

Clause d'exigibilité immédiate, 725

Clause d'intransmissibilité, 718

Clause d'*intuitu personae*, 720

Clause d'*intuitu societatis*, 720

Clause de droit applicable, 606, 607

Clause de *hardship*, 732

Clé de répartition pour les éléments inconnus ou oubliés, 445

Company Law Package
- Champ d'application, 300
- Différences de traitement, 337
- Disposition anti-abus, 312
- Insuffisances, 297
- Présentation, 293

Conditions de majorité, 836

Conflit d'agence, 467, 468, 628, 653

Contrat *intuitu personae*, 115, 573

Contrat *sui generis*, 102

Contrôle de conformité
- Autorités nationales compétentes, 527
- Communication du certificat, 524
- Délais applicables, 518
- Droit applicable, 516
- Entités concernées, 516
- Issue du contrôle, 518
- Objet du contrôle, 517

– Origine, 514
– Protection des créanciers, 686

Contrôle de légalité
– Autorités nationales compétentes, 527
– Délais applicables, 526
– Objet du contrôle, 525
– Origine, 514

Créanciers
– Articulation avec la protection des titulaires de titres autres que des actions, 784
– Aspects temporels, 747
– Enjeux, 574
– Equilibre, 582
– Flexibilité, 775
– Harmonisation, 794
– Incidence du droit de l'insolvabilité, 758
– Liberté d'établissement, 584
– Mécanismes de protection, 627
– Nécessité d'un régime renforcé, 591
– Notion, 571, 793
– Principes de droit international privé, 588
– Protection renforcée des créanciers de la société scindée, 613
– Risques, 575

Critère du contrôle, 147

D

Dates
– Date de participation aux bénéfices, 411
– Date de prise d'effet, 529
– Date de prise d'effet comptable, 414
– Date du rapport d'échange, 408
– Dates des comptes utilisés pour définir les conditions de l'opération, 441

Debt push down, 687

Déclaration de l'organe de direction ou d'administration, 632

Déconcentration, 73

Décote de diversification, 80

Défense en profondeur, 804

Demande de garantie adéquate, 638

Disposition anti-abus, 312, 338, 514, 518, 523, 527, 535, 686, 690, 742, 743, 744, 771, 874, 927

Dispositions de référence, 926, 928, 933, 935

Dissolution sans liquidation, 109

Droit au secret, 457

Droit de l'insolvabilité, 758

Droit de retrait, 843, 847

Droit de veto, 681, 750, 836

Droit international privé
– Action paulienne, 675
– Arrêt *Vale*, 184, 192
– Associés minoritaires, 512, 833, 869, 892
– Contenu du projet commun, 398
– Créanciers, 430, 588
– Droit belge, 273, 277
– Droit luxembourgeois, 277
– Droit suisse, 254
– Evaluation, 440
– Forme du projet commun, 387
– Principes, 237
– Prise d'effet, 528

E

Effet de séparation, 78

Effet *erga omnes*, 864

Effets probables sur l'emploi, 433

Effet suspensif, 639, 867

Elément d'extranéité, 122

Eléments oubliés ou inconnus, 428, 445, 613, 619, 652

Employee buy-out, 74

Enjeux
- Associés minoritaires, 822
- Créanciers, 574
- Travailleurs, 915

Equilibre
- Associés minoritaires, 825
- Créanciers, 582
- Travailleurs, 922

Equity carve-out, 74

Expert indépendant
- Associés minoritaires, 876
- Créanciers, 674, 777, 779
- Etendue de la mission, 474
- Nomination, 467
- Pouvoirs, 471

F

Flexibilité
- Action paulienne, 678
- Associés minoritaires, 871, 872, 875, 888
- Choix des garanties, 648
- Créanciers, 582, 775, 806
- Droit d'opposition, 697
- Droits au moins équivalents, 787
- Emploi des langues, 394, 522
- Participations préalables, 120
- Possibilité de modifier le projet de scission, 507
- Rapport de l'organe d'administration, 449
- Titres autres que des actions, 789
- Travailleurs, 933

Forum shopping, 729, 765, 768, 770, 775, 804

Fraude, 743
- Associés minoritaires, 874
- Créanciers, 299, 573, 667, 680, 741
- Disposition anti-abus, 312, 514, 518
- Expert indépendant, 894
- Liberté d'établissement, 163, 177

Fusion, 66

Fusion par absorption, 66

Fusion par constitution de nouvelle société, 66

Fusion silencieuse, 66

Fusion transfrontalière, 66

G

Garanties adéquates, 588

Garanties offertes aux créanciers, 443

Gatekeeper approach, 467, 674, 777, 779, 876

Gebhard test, 142, 924

Gestion séparée des patrimoines, 703

Groupe spécial de négociation, 941, 942

H

Habileté politique, 356, 511, 549, 821, 832, 840, 880, 900, 973, 999

Harmonisation
- Associés minoritaires, 896
- Créanciers, 794, 807
- Général, 347

I

Immatriculation, 528

Imprévision, 697

Information
- Créanciers, 586, 620, 630
- Evaluation du patrimoine de la société absorbée, 438
- Participation des travailleurs, 436

– Sociétés impliquées, 399
– Travailleurs, 931

Interdépendance fonctionnelle, 611, 763, 775, 800, 977

L

Law and economics, 716

Leveraged buy-out, 687

Liberté d'établissement
– Associés minoritaires, 827, 839, 878, 883
– Champ d'application, 151
– Conditions, 143
– Créanciers, 584, 602
– Entraves, 141
– Général, 137
– Interprétation, 140
– Justification des entraves, 142
– Primaire, 139, 156
– Secondaire, 139, 156
– Travailleurs, 923, 943

Limite de l'actif net, 621, 656, 779, 805

M

Management buy-out, 74

Mécanismes de protection conventionnels, 716

Mécanismes de protection *ex ante*, 594, 748, 804

Mécanismes de protection *ex post*, 594, 748, 804

Mécanismes de protection individuels, 628, 712

Mécanismes de protection institutionnels, 628, 660, 712

Mesures de publicité
– Délais applicables, 488
– Etendue, 490
– Mise à disposition des documents préparatoires, 492
– Publication classique et numérique, 484

Méthode de l'adaptation, 245

Méthodes dérivées, 350

Modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires, 409

Montage artificiel, 317, 319, 321, 323, 324, 326, 327, 331, 333, 336, 337, 338, 535, 691

N

Nationalité
– Critère du contrôle, 147
– Général, 143, 144
– Sociétés apatrides, 149
– Sociétés binationales, 149
– Théorie de la superposition, 148
– Théorie du siège réel, 146
– Théorie du siège statutaire ou de l'incorporation, 144
– Théories intermédiaires, 148
– Thèse de la combinaison, 149

Nature juridique, 97

Neutralité, 656

Notifications entre registres, 528

Nullités, 531, 742

O

Organe spécial de négociation, 933

Outsourcing, 74

P

Participation des travailleurs, 915, 918

Participations préalables, 119

Perpetuatio fori, 601, 662, 663, 664, 666, 782

Porteurs de titres autres que des actions, 418

Présomption, 663, 778

Principe avant-après, 925, 929

Principe d'effectivité, 183, 184, 191, 525, 562, 974

Principe d'équivalence, 191, 194, 198, 200, 204, 562, 623, 792, 974, 975

Prix de rachat, 862

Projet commun
- Caractère nécessairement commun, 380
- Contenu, 395
- Forme, 385
- Interprétation, 620
- Nature juridique, 381
- Organe compétent, 378

R

Race to the bottom, 145, 794

Raison impérieuse d'intérêt général
- Associés minoritaires, 826
- Créanciers, 584, 585
- Travailleurs, 944

Rapport d'échange
- Contestation, 511, 877, 878
- Date, 408
- Difficultés particulières d'évaluation, 448
- Etablissement, 263, 400, 413
- Explication, 453
- Illustration chiffrée, 401
- Limites, 402
- Modification, 497
- Risque, 823
- Vérification, 473, 476, 876

Rapport de l'expert indépendant
- Exemption, 483
- Langue, 480
- Objectifs, 473
- Principe, 467
- Rapport unique, 473
- Renonciation, 481

Rapport de l'organe d'administration
- Avis des représentants des travailleurs, 466
- Contenu, 451
- Droit au secret, 457
- Langue, 461
- Mise à disposition, 464
- Niveau de détail variable, 458
- Objectifs, 449
- Organe compétent, 449
- Principe, 448
- Rapport unique, 459
- Renonciation, 461

Reformatio in peius, 866, 887

Règle de permanence, 930, 939

Règlement Insolvabilité, 578, 586, 765, 770, 771

Répartition des actions ou des titres des sociétés bénéficiaires, 117, 118, 430

Répartition des éléments d'actif et de passif, 422, 426, 581, 619, 739

Risque crédible, 645

Risques
- Associés minoritaires, 822
- Créanciers, 575
- Travailleurs, 917, 918

Rule of reason, 142

S

Scission asymétrique, 118, 823, 836, 879

Scission émigration, 164

Scission hétérogène, 609

Scission immigration, 170

Scission mixte, 65

Scission par absorption, 65

Scission par constitution de nouvelles sociétés, 65

Scission par séparation, 68

Scission partielle, 157
- Notion, 65
- Participation des travailleurs, 934, 938
- Porteurs de titres, 786
- Solidarité, 658

Scission silencieuse, 65, 123, 127, 259, 539, 544, 555, 576, 968

Scissions simplifiées
- Droit belge, 543
- Droit luxembourgeois, 544
- Fusions transfrontalières, 541
- Position du législateur européen, 540
- Scissions internes, 542
- Scissions par constitution de nouvelles sociétés, 540
- Scissions transfrontalières par acquisition, 544

Scission totale, 65

Scission transfrontalière, 65

Sélection adverse, 629

Sell off, 74

Seuil d'occupation, 927

Société cotée, 875

Sociétés apatrides, 149

Sociétés binationales, 149

Solidarité, 651, 652

Soulte en espèces, 119, 259, 400, 443, 848, 862

Soulte négative, 407

Split off, 74

Split up, 74

Statuts des sociétés issues de l'opération, 435

Synergies négatives, 77, 862

T

Théorie de la différenciation, 148

Théorie de la superposition, 148

Théorie de Lennerz, 248

Théorie du siège réel ou du principal établissement, 146

Théorie du siège statutaire ou de l'incorporation, 144

Thèse de la combinaison, 149

Thèse de la transformation, 100

Titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux, 784

Transfert de siège, 164

Transformation transfrontalière, 68, 179

Transmission à titre universel
- Créanciers, 575
- Etendue et limites, 114
- Justification, 111
- Principe, 110

Travailleurs
- Dimension politique, 921
- Enjeux, 915
- Equilibre, 922
- Liberté d'établissement, 923, 943
- Participation, 915
- Risques, 918
- Scissions mixtes et par absorption, 924

U

Upstream divisions, 542

V

Vereinigungstheorie, 248, 257, 588

Table des matières

Remerciements 7

Préface 9

Liste des abréviations utilisées 11

English summary 15

Sommaire 31

Introduction générale 35

PARTIE I
Les scissions transfrontalières sous l'angle des parties immédiates

Introduction de la première partie 53

TITRE I
Les scissions transfrontalières, un procédé de déconcentration économique des entreprises

Introduction du titre I 59

Chapitre 1. Définition et comparaison avec d'autres types de restructuration 63

Section 1. Définition 65

Section 2. Scissions et autres restructurations 66

§1. Scissions et fusions transfrontalières 66

§2. Scissions et apports d'actifs 67

§3. Scissions et transformations transfrontalières 68

§4. Scissions transfrontalières et transferts de siège 69

Chapitre 2. L'intérêt économique des scissions 71
Section 1. Aveu d'échec ou tactique offensive ? 73
Section 2. Typologie 73
Section 3. Les motifs d'une scission 75
§1. Présentation 75
§2. La concentration sur le core business 75
A. Présentation 75
B. L'hypothèse de la correction d'erreur 76
C. L'hypothèse des synergies négatives 77
D. L'hypothèse de la réorientation stratégique 79
§3. La limitation des effets de la décote de diversification 79
§4. La correction de l'asymétrie d'information 80
§5. Les résultats financiers décevants 81
§6. Les besoins excessifs en ressources et capitaux 82
§7. L'environnement concurrentiel 83
§8. Une mesure anti-OPA 84
§9. Le droit de la concurrence et les motifs purement juridiques 85
Section 4. Analyse de la création de valeur engendrée par une scission 87
§1. Shareholder value vs. stakeholder value 87
§2. Le choix de la scission comme mode de déconcentration 91
§3. Une création de valeur immédiate ou différée 91
A. Présentation 91
B. L'impact de l'annonce de l'opération 92
C. L'impact sur le long terme 92
§4. Un outil de restructuration efficace mais pas sans risques 93
Section 5. Conclusion sur l'intérêt économique des scissions 95

Chapitre 3. La nature juridique des scissions 97
Section 1. Présentation 99
Section 2. La définition du législateur européen 99
Section 3. L'inadéquation de la qualification d'apport en nature 99
Section 4. La thèse de la transformation 100
Section 5. Un contrat *sui generis* 102
Section 6. Conclusion sur la nature juridique des scissions 105

Chapitre 4. Les éléments caractéristiques des scissions transfrontalières 107
Section 1. Une dissolution sans liquidation 109
Section 2. L'absorption du patrimoine de la société scindée 110
§1. Les trois éléments constitutifs de l'absorption 110

A. Présentation 110
B. Le fractionnement du patrimoine de la société scindée 110
C. La transmission à titre universel 110
1. Le principe 110
2. Une justification malaisée 111
D. La confusion entre les fractions de patrimoine de la société scindée et celui des sociétés bénéficiaires 114
§2. Un principe aux contours incertains 114
Section 3. L'attribution de nouvelles actions aux associés de la société scindée 117
§1. La notion d'attribution 117
§2. Les principes de répartition 118
§3. La soulte en espèces 119
§4. Les participations préalables 119
§5. Le cas des sociétés à l'actif net négatif 121
Section 4. Un élément d'extranéité bien déterminé 122
Section 5. Conclusion sur les éléments caractéristiques des scissions transfrontalières 123

Conclusion sur le procédé de déconcentration économique que constituent les scissions transfrontalières 125

TITRE II
Les scissions transfrontalières sous l'angle des libertés fondamentales

Introduction du titre II 131

Chapitre 1. Les scissions transfrontalières sous l'angle de la liberté d'établissement 137
Section 1. Présentation 139
Section 2. Les conditions pour qu'une société puisse bénéficier de la liberté d'établissement 143
§1. Présentation 143
§2. La constitution en conformité avec la législation d'un État membre 143
§3. Le rattachement à la lex societatis d'un État membre 144
A. Une liberté de choix des États membres 144
B. Les différents critères de rattachement 144
1. La théorie du siège statutaire ou de l'incorporation 144
2. La théorie du siège réel ou du principal établissement 146
3. Le critère du contrôle 147

4. Les théories intermédiaires ... 148
C. Les conséquences de la multiplicité des critères de rattachement .. 149
§4. Au-delà des sociétés de capitaux ... 150
§5. L'incidence de l'assimilation aux personnes physiques sur les scissions transfrontalières ... 151
§6. Un champ d'application *ratione loci* dépassant l'Union européenne .. 151
Section 3. Les scissions transfrontalières, un mode particulier d'exercice de la liberté d'établissement ... 151
§1. Les enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Sevic* ... 152
A. Les faits en cause ... 152
B. Les enseignements de la Cour de justice ... 152
§2. L'incidence sur les scissions transfrontalières ... 153
§3. Les limites de la jurisprudence Sevic ... 160
§4. Les enseignements de la Cour de justice dans l'arrêt *Euro Park Service* ... 162
A. Les faits en cause ... 162
B. Les enseignements de la Cour de justice ... 163
C. L'incidence sur les scissions transfrontalières ... 163
Section 4. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de transfert de siège social ... 164
§1. L'incidence de la nature particulière des scissions ... 164
§2. Les scissions émigration ... 164
A. Présentation ... 164
B. Les enseignements de la Cour de justice en matière d'émigration 165
1. L'arrêt *Daily Mail* ... 165
1.1. Les faits en cause ... 165
1.2. Les enseignements de la Cour ... 165
2. L'arrêt *Cartesio* ... 166
2.1. Les faits en cause ... 166
2.2. Les enseignements de la Cour de justice ... 167
C. Les enseignements de la Cour appliqués aux scissions transfrontalières ... 169
§3. Les scissions immigration ... 170
A. Présentation ... 170
B. Les enseignements de la Cour de justice en matière d'immigration ... 170
1. L'arrêt *Segers* ... 171
1.1. Les faits en cause ... 171
1.2. La décision de la Cour ... 171
2. L'arrêt *Centros* ... 172
2.1. Les faits en cause ... 172

2.2. Les enseignements de la Cour 172
3. L'arrêt *Überseering* 173
3.1. Les faits en cause 173
3.2. Les enseignements de la Cour de justice 174
4. L'arrêt *Inspire Art* 175
4.1. Les faits en cause 175
4.2. Les enseignements de la Cour de justice 176
C. Les enseignements de la Cour de justice appliqués aux scissions transfrontalières 177
1. Les scissions transfrontalières du point de vue de l'État d'accueil 177
2. La justification d'une entrave à une scission transfrontalière dans l'État d'accueil 178
§4. La nécessité d'une analyse additionnelle de la jurisprudence en matière de liberté d'établissement 179
Section 5. L'application des enseignements de la Cour de justice en matière de transformation transfrontalière 179
§1. Introduction 179
§2. L'arrêt *Vale* 180
A. Les faits en cause 180
B. Les enseignements de la Cour 180
1. Les transformations transfrontalières constituent des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement » 180
2. La reconnaissance de l'existence d'une entrave à la liberté d'établissement et son éventuelle justification 182
3. Une règle de conflit de lois 182
4. Un *obiter dictum* à la portée incertaine 185
§3. L'arrêt *Polbud* 186
A. Les faits en cause 186
B. La décision de la Cour 187
§4. Les enseignements de la Cour de justice appliqués aux scissions transfrontalières 188
A. Une incidence générale sur la mobilité des sociétés au sein de l'Union européenne 189
B. L'incidence des principes d'effectivité et d'équivalence 191
C. Les enseignements en droit international privé 192
D. L'incidence de l'absence de normes de droit dérivé 193
E. Une liberté de scission encadrée 194
F. Le cas particulier des scissions de sociétés de participation financière 194
G. Le cas particulier des scissions par constitution de nouvelles sociétés 196

Section 6. Les limites des enseignements en matière de liberté d'établissement ... 196
§1. L'absence d'une décision portant explicitement sur les scissions transfrontalières ... 197
§2. L'absence de description des modalités concrètes de réalisation de la scission ... 198
§3. L'exigence d'une discrimination ... 200
§4. La justification des entraves à la liberté d'établissement ... 201
§5. Réticence des États membres et « rules jungle » ... 203
Section 7. Conclusion sur les scissions transfrontalières sous l'angle de la liberté d'établissement ... 204

Chapitre 2. Les scissions transfrontalières sous l'angle de la libre circulation des capitaux ... 207
Section 1. Présentation ... 209
Section 2. Les enseignements de l'arrêt *Sevic* ... 210
Section 3. Les scissions transfrontalières, une modalité particulière d'exercice de la libre circulation des capitaux ? ... 211
§1. Présentation ... 211
§2. Le champ d'application *ratione materiae* ... 211
Section 4. L'articulation entre la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux ... 217
Section 5. L'impact sur les scissions transfrontalières avec les États tiers ... 218
§1. Une application alternative de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux ? ... 219
§2. Deux limites propres à l'exercice de la libre circulation des capitaux impliquant un État tiers ... 219
§3. Les dérogations générales ... 220
§4. Une politique jurisprudentielle restrictive ... 221
Section 6. Conclusion sur les scissions transfrontalières sous l'angle de la libre circulation des capitaux ... 222

Conclusion sur les scissions transfrontalières sous l'angle des libertés fondamentales ... 225

TITRE III
Les scissions transfrontalières :
entre droit international privé et initiatives nationales

Introduction du titre III ... 231

Chapitre 1. Les principes de droit international privé appliqués aux scissions transfrontalières ... 235

Section 1. Présentation 237
Section 2. La capacité générale ou active de scission 237
Section 3. La capacité concrète de scission 238
Section 4. Les règles de conflit de lois applicables 238
§1. Un conflit de lois omniprésent 238
§2. Les différentes théories 239
A. La primauté du droit de la société scindée (*Übertragungstheorie*) 239
B. La primauté du droit des sociétés bénéficiaires (*Aufnahmetheorie*) 240
C. L'application tantôt cumulative, tantôt distributive des droits des sociétés impliquées (*Vereinigungstheorie*) 241
1. Présentation 241
2. Analyse de deux règles de conflit de lois fondamentales appliquées aux scissions transfrontalières 243
3. La nécessité de recourir à la méthode de l'adaptation 245
D. La théorie de Lennerz 248
1. L'échec de la *Vereinigungstheorie* 248
2. Un régime plus conforme à la complexité de l'opération 249
3. Appréciation critique 251
E. La théorie de la concordance (*Konkordanzlehre*) 252
F. La situation en droit suisse 254
G. L'application par analogie du régime des fusions transfrontalières 255
1. Présentation 255
2. Les insuffisances d'un tel régime 260
2.1. Présentation 260
2.2. Les insuffisances propres au régime des fusions transfrontalières 261
2.3. Les insuffisances intrinsèques à une application par analogie 265
Section 5. Aspects de droit international privé dépassant le cadre de la *lex societatis* 267
Section 6. Conclusion sur les principes de droit international privé appliqués aux scissions transfrontalières 268

Chapitre 2. Initiatives nationales en matière de scissions transfrontalières 271
Section 1. La situation en droit international privé belge 273
§1. La situation avant l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations 273
A. La difficile reconnaissance des opérations transfrontalières 273
B. La reconnaissance implicite des scissions transfrontalières, mais un régime absent 274
§2. Le régime du CSA 275

Section 2. La situation en droit international privé luxembourgeois 277
Section 3. Une situation foncièrement insatisfaisante 277

Conclusion sur les principes de droit international privé et les initiatives nationales en matière de scissions transfrontalières 281

TITRE IV
Company law package et nécessité d'une nouvelle initiative européenne

Introduction du titre IV 287

Chapitre 1. Le nouveau régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés 291
Section 1. Présentation 293
Section 2. Les insuffisances du nouveau régime 297
§1. Présentation 297
§2. L'absence d'harmonisation préalable du régime des scissions internes 298
§3. Un champ d'application volontairement limité 300
A. Un champ d'application *ratione personae* limité 300
1. La limite des sociétés de capitaux 300
2. La question de l'exclusion des sociétés en situation précaire 302
B. Un champ d'application *ratione materiae* limité 306
§4. La disposition anti-abus 312
A. La Proposition de la Commission 312
B. Un mécanisme anti-abus critiquable à plus d'un titre 314
C. Les évolutions au cours du processus législatif 324
1. Le durcissement du CESE, de la CAEM, de la CEAS et de la CAJ 324
2. Le revirement au gré des compromis 328
D. Directive mobilité et insuffisances restantes 331
§5. Des différences de traitement injustifiées 337
Section 3. Conclusion sur le nouveau régime des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés 343

Chapitre 2. L'avenir de la réglementation des scissions transfrontalières en Europe 345
Section 1. Présentation 347
Section 2. La nécessité d'une intervention du législateur européen 347
§1. L'enseignement des fusions transfrontalières 347
§2. Les insuffisances des méthodes dérivées 350

§3. Une insécurité juridique persistante 354
§4. La nécessité de protéger les stakeholders de manière adéquate..... 355
§5. Une attitude ambiguë du législateur européen 356
Section 3. La forme d'une intervention du législateur européen..... 358
Section 4. Conclusion sur l'avenir de la réglementation des scissions transfrontalières en Europe..... 361

Conclusion sur le *company law package* et la nécessité d'une nouvelle intervention européenne..... 363

TITRE V
Les contours d'un régime européen des scissions transfrontalières

Introduction du titre V..... 369

Chapitre 1. La procédure générale de scission transfrontalière 373
Section 1. Présentation 375
Section 2. Les négociations préliminaires..... 375
Section 3. Le projet commun de scission 378
§1. L'organe compétent..... 378
§2. Les objectifs du projet de scission 380
§3. Une caractéristique essentielle..... 380
§4. La nature juridique du projet commun de scission 381
§5. La forme du projet commun de scission 385
A. Les exigences minimales de la Directive Sociétés..... 385
B. Une certaine diversité au sein des États membres 386
C. La règle de conflit de lois applicable..... 387
D. Une règle de conflit de lois qui ne fait pas l'unanimité 389
E. Le cas particulier de la scission par constitution de nouvelles sociétés 390
§6. La langue du projet commun de scission..... 391
§7. Le contenu du projet commun de scission 395
A. Présentation 395
B. Le contenu inspiré des scissions internes 399
1. Les informations relatives aux sociétés concernées..... 399
2. Le rapport d'échange et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces..... 400
2.1. Le principe et ses limites..... 400
2.2. L'importance de la soulte..... 404
2.3. La date du rapport d'échange..... 408

2.4. Une mention facultative dans certaines hypothèses 409
3. Les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires.. 409
4. La date à partir de laquelle les actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toutes modalités particulières relatives à ce droit 411
5. La ou les date(s) de prise d'effet comptable 414
6. Les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard 418
7. Les avantages particuliers attribués aux experts et aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle 420
8. La description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif de la société scindée 422
8.1. Présentation 422
8.2. Les éléments visés 423
8.3. L'étendue de l'obligation 424
8.4. Une répartition libre 426
8.5. Le sort des éléments oubliés 428
9. Les informations relatives à la répartition des actions ou des titres des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée 430
C. Le contenu inspiré du régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés 431
1. Présentation 431
2. Analyse des mentions additionnelles 433
2.1. Les effets probables sur l'emploi 433
2.2. Les statuts des sociétés issues de l'opération 435
2.3. Les informations relatives à la participation des travailleurs . 436
2.4. Les informations relatives à l'évaluation du patrimoine de la société absorbée 438
2.5. Les dates des comptes utilisés pour définir les conditions de l'opération 441
2.6. Les modalités d'attribution d'une soulte en espèces 443
2.7. Les garanties offertes aux créanciers 443
D. Le contenu inspiré des scissions transfrontalières par constitution de nouvelles sociétés 444
1. Le calendrier indicatif de l'opération 444
2. L'indication d'une clé de répartition pour les éléments inconnus ou oubliés 445
E. Autres mentions obligatoires 445
F. Le contenu facultatif 446

Section 4. Le rapport des organes d'administration ou de direction 448
§1. Le principe 448
§2. L'organe compétent 449
§3. Les objectifs du rapport des organes de direction ou d'administration 449
§4. Le contenu du rapport 451
A. Le principe 451
B. Le rapport ou la section destiné(e) aux associés 452
1. Un contenu plus complet que dans le cadre d'une opération interne 452
2. L'absence d'informations relatives aux créanciers 455
C. Le rapport ou la section destiné(e) aux travailleurs 455
D. Le contenu additionnel imposé par les législateurs nationaux 456
§5. Le droit au secret 457
§6. Un niveau de détail variable 458
§7. La possibilité d'un rapport commun 459
§8. La langue du rapport 461
§9. La renonciation au rapport de l'organe de direction ou d'administration 461
§10. La mise à disposition du ou des rapport(s) de l'organe de direction ou d'administration 464
§11. L'annexion de l'avis des représentants des travailleurs 466
Section 5. Le rapport d'expert indépendant 466
§1. Le principe 467
§2. La nomination de l'expert indépendant 467
A. Les caractéristiques de l'expert 467
B. La solution excessive de la Proposition de la Commission 468
§3. Les pouvoirs de l'expert indépendant 471
A. Au-delà d'un simple droit d'investigation 471
B. Quid des informations confidentielles ? 472
§4. Les objectifs du rapport d'expert 473
§5. La possibilité d'un rapport unique 473
§6. L'étendue de la mission de contrôle de l'expert 474
A. L'objet du contrôle de l'expert 474
B. La vérification du projet commun 475
C. Le contrôle du rapport d'échange 476
D. Le contrôle du montant de la soulte en espèces 477
E. L'incidence du caractère transfrontalier de l'opération 478
F. L'incidence des spécificités d'une scission 479
§7. Le contenu du rapport d'expert 479
§8. La langue du rapport 480
§9. La renonciation au rapport d'expert 481
§10. L'exemption du rapport d'expert 483

Section 6. Mesures de publicité 484
§1. Publication classique et ère numérique 484
A. Une étape essentielle 484
B. Publication numérique 486
§2. Les délais applicables 488
§3. Une obligation de publication dépassant le seul projet commun 490
§4. La mise à disposition des documents préparatoires 492
A. Le principe 492
B. L'état comptable intérimaire 493
C. La mise à disposition de documents étrangers 495
D. La possibilité d'obtenir une copie 496
E. Les modalités de la mise à disposition 496
§5. L'obligation d'information en cas de modification importante du patrimoine actif et passif 497
Section 7. L'approbation de l'assemblée générale 499
§1. Présentation 499
§2. Délai, objet et forme du procès-verbal 500
§3. Les conditions de présence et de majorité 502
§4. La possibilité d'une condition suspensive et résolutoire portant sur le régime de participation des travailleurs 503
§5. La possibilité pour l'assemblée générale de modifier le projet de scission 507
§6. Une assemblée générale facultative 510
§7. La contestation de la décision de l'assemblée générale 511
Section 8. Le double contrôle de légalité 514
§1. Une règle de droit matériel inspirée du régime des fusions transfrontalières et de la société européenne 514
§2. Le premier contrôle ou contrôle de conformité 516
A. Le droit applicable 516
B. Les entités concernées 516
C. L'objet du contrôle 517
D. L'issue du contrôle 518
1. Présentation 518
2. La délivrance du certificat 519
3. Le refus de délivrance du certificat en dehors de la disposition anti-abus 523
§3. La communication du certificat 524
§4. Le second contrôle ou contrôle de légalité 525
A. L'objet du contrôle 525
B. Les délais applicables 526
§5. Les autorités nationales compétentes 527

Section 9. Immatriculation et prise d'effet 528
§1. Un régime compatible 528
§2. Les notifications entre registres 528
§3. La date de prise d'effet de l'opération 529

Chapitre 2. Le régime des nullités des scissions transfrontalières 531

Chapitre 3. Les opérations simplifiées 537
Section 1. Présentation 539
Section 2. La position du législateur européen 540
§1. Le régime des scissions transfrontalières 540
§2. Le régime des fusions transfrontalières 541
§3. Une nécessité reconnue en cas de scissions internes 542
Section 3. La situation en droit belge et en droit luxembourgeois 543
Section 4. *Quid* en cas de scission transfrontalière par acquisition ? 544

Conclusion sur les contours d'un régime européen des scissions transfrontalières 547

Conclusion de la première partie 553

PARTIE I
Les scissions transfrontalières sous l'angle des principaux *stakeholders*

Introduction de la deuxième partie 559

TITRE I
La protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière

Introduction du titre I 565

Chapitre 1. Aspects généraux de la protection des créanciers 569
Introduction du chapitre 1 571
Section 1. Notion de créancier 571
Section 2. Les enjeux de la protection des créanciers 574
§1. Une opération potentiellement au détriment des créanciers 575
§2. Un juste équilibre à trouver 582
A. La nécessité économique des scissions transfrontalières 582
B. L'incidence de la liberté d'établissement 584

Section 3. Les principes de droit international privé applicables à la protection des créanciers 588
Section 4. La nécessité d'un régime renforcé en cas d'opération transfrontalière ? 591
§1. Le régime des fusions transfrontalières 592
A. Perspective historique 592
B. Le régime de la Directive Sociétés 592
C. L'interprétation de la Cour de justice dans l'arrêt *KA Finanz* 595
§2. Analyse de droit comparé en matière de scissions transfrontalières 597
§3. Analyse de la Directive Mobilité 600
§4. L'incidence de la liberté d'établissement 602
§5. Les difficultés liées à la mise en œuvre des mécanismes de protection des créanciers 605
§6. L'incidence d'une scission transfrontalière sur le droit applicable au contrat 606
§7. Un droit national potentiellement moins protecteur 609
§8. Conclusion sur la nécessité d'un régime renforcé en cas d'opération transfrontalière 611
Section 5. La nécessité d'une protection renforcée des créanciers de la société scindée 613
§1. Position de la question 613
§2. La position du législateur européen 614
§3. Analyse de droit comparé 616
§4. La question des éléments oubliés ou inconnus du patrimoine de la société scindée 619
§5. Conclusion sur la nécessité d'une protection renforcée des créanciers de la société scindée 622
Section 6. Conclusion sur les aspects généraux de la protection des créanciers 622

Chapitre 2. Les contours de la protection des créanciers dans les scissions transfrontalières 625
Introduction du chapitre 2 627
Section 1. Les mécanismes de protection des créanciers 627
§1. Présentation 627
§2. Les mécanismes de protection prévus par les législateurs 627
A. Mécanismes de protection individuels et institutionnels 628
B. Les mécanismes de protection prévus par le législateur européen 628
1. L'information des créanciers 628
1.1. Présentation 628
1.2. Limites 631

2. La déclaration de l'organe de direction ou d'administration 632
2.1. Présentation 632
2.2. Limites 634
3. La possibilité de demander une garantie 638
3.1. Le principe 638
3.2. Les limites 649
4. La solidarité des sociétés bénéficiaires de la scission 652
4.1. Le principe 652
4.2. Les limitations 660
5. La compétence des juridictions de l'État de la société scindée .. 662
5.1. Le principe 662
5.2. Les limites 664
C. Les autres moyens de protection prévus par les législateurs nationaux 667
1. L'action paulienne 667
1.1. Le principe 667
1.2. Les limites 679
2. Le droit de veto 681
2.1. Le principe 681
2.2. Les limites 683
3. Le contrôle par une autorité nationale 686
3.1. Le principe 686
3.2. Les limites 690
4. Le droit d'opposition optionnel du droit français 691
4.1. Le principe 691
4.2. Les limites 693
5. La théorie de l'imprévision 697
5.1. Le principe 697
5.2. Les limites 702
6. La gestion séparée des patrimoines 703
6.1. Le principe 703
6.2. Les limites 704
7. La responsabilité solidaire des membres de l'organe de gestion de la société scindée 705
7.1. Le principe 705
7.2. Les limites 708
D. Conclusion sur les mécanismes de protection prévus par les législateurs 712
§3. Les mécanismes de protection conventionnels 716
A. Présentation 716
B. Une multitude de clauses distinctes 717

1. Typologie 717
2. Les clauses destinées à mettre fin au contrat 718
2.1. La clause d'intransmissibilité 718
2.2. La clause d'*intuitu personae* 720
2.3. La clause d'exigibilité immédiate ou « acceleration clause » 725
2.4. La clause d'agrément 726
2.5. La clause de changement de contrôle 727
3. Les clauses destinées à aménager les conséquences de l'opération sur le contrat 729
3.1. La clause attributive de juridiction en vertu du Règlement Bruxelles I*bis* 729
3.2. La clause d'adaptation générale, de renégociation ou de hardship 732
C. Les insuffisances des mécanismes de protection conventionnels 735
D. Conclusion sur les mécanismes de protection conventionnels 737
§4. Les autres moyens de protection envisageables 739
A. Le respect de l'intégrité des branches d'activités dans le projet commun de scission combiné à une solidarité des entités issues de la scission 739
B. L'annulation de l'opération de scission 742
§5. Conclusion sur les mécanismes de protection des créanciers 745
Section 2. Les aspects temporels de la protection des créanciers 747
§1. Présentation 747
§2. Le point de départ de la protection 747
A. Une grande diversité au sein des États membres 748
B. Avantages et inconvénients d'un système de protection *ex ante* 749
C. Avantages et inconvénients d'un système *ex post* 750
D. Inconvénients de la coexistence de différents mécanismes de protection 752
E. La position de la Directive Mobilité 753
§3. La durée de la protection 754
§4. Conclusion sur les aspects temporels de la protection des créanciers 756
Section 3. L'incidence du droit international de l'insolvabilité 758
§1. Présentation 758
§2. Le délicat équilibre entre « lex societatis » et « lex fori concursus » 758
§3. Le Règlement Insolvabilité et la lutte contre le « forum shopping » abusif 764
§4. Dispositions relatives à l'insolvabilité dans le régime des scissions transfrontalières 772
§5. Conclusion sur l'incidence du droit international de l'insolvabilité 775

Section 4. La nécessité d'une certaine flexibilité pour les sociétés impliquées 775
§1. Présentation 775
§2. Analyse de droit comparé 776
§3. Le régime de la Proposition de la Commission 778
§4. Conclusion sur la nécessité d'une certaine flexibilité pour les sociétés impliquées 784
Section 5. L'articulation avec la protection des titulaires de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux 784
§1. Présentation 784
§2. Les instruments visés 785
§3. La nécessité d'une protection accrue des titulaires 786
§4. La protection consacrée par le législateur européen 787
§5. La nécessité d'une certaine flexibilité pour l'émettrice 789
§6. Une possible dérogation contractuelle ? 791
§7. L'articulation avec les mécanismes généraux de protection des créanciers 792
§8. Conclusion sur l'articulation avec la protection des titulaires de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux 793
Section 6. L'harmonisation au niveau européen 794
§1. Présentation 794
§2. Les choix du législateur européen 794
A. Le régime de la Directive Sociétés 794
B. Le résultat des consultations publiques de 2015 et 2017 795
C. Le régime de la Directive Mobilité 796
§3. La nécessité d'une harmonisation des scissions transfrontalières et des scissions internes 797
§4. Le type d'harmonisation à privilégier 799
A. L'harmonisation complète 799
B. Le choix fermé entre plusieurs options 800
C. Le libre choix entre plusieurs options 801
D. L'harmonisation *a minima* 802
§5. Conclusion sur l'harmonisation au niveau européen 803
Section 7. Conclusion sur les contours de la protection des créanciers dans les scissions transfrontalières 804

Conclusion sur la protection des créanciers dans le cadre d'une scission transfrontalière 809

TITRE II
La protection des autres *stakeholders* dans le cadre d'une scission transfrontalière

Introduction du titre II 815

Chapitre 1. Les enjeux de la protection des associés minoritaires 819

Section 1. Présentation. 821

Section 2. Les enjeux d'une scission transfrontalière pour les associés minoritaires 822

§1. Une opération potentiellement au détriment des associés minoritaires 822

§2. Un juste équilibre à trouver 825

Section 3. L'incidence de la liberté d'établissement 826

Section 4. La nécessité d'un régime renforcé en cas d'opération transfrontalière 828

Section 5. Les différents mécanismes de protection des associés minoritaires. 832

§1. La position du législateur européen 832

A. Le régime des fusions transfrontalières avant l'adoption de la Directive Mobilité 832

B. Le régime des scissions internes 834

C. Le régime de la Directive Mobilité 835

§2. Un droit de s'opposer à la scission 835

A. Principes et limites 836

B. L'incidence des clauses d'agrément 841

§3. Un droit de retrait 843

A. Principe et limites 843

1. Un mécanisme *a priori* efficace 843

2. Un nombre important d'inconvénients 847

B. Les associés minoritaires jouissant du droit de retrait 848

1. La limitation aux associés de la société scindée 849

2. L'exigence d'un changement de *lex societatis* 851

3. L'exigence d'une opposition formelle au projet de scission 855

4. L'exigence d'une période de détention minimale 859

C. La nature de la soulte 860

D. La nécessité d'une information préalable 861

E. La nécessité d'une procédure de vérification du prix de rachat 862

1. La notion de soulte en espèces adéquate selon le législateur européen 862

2. La possibilité limitée de contester le montant de la soulte en espèces 863

3. L'effet de la décision de l'autorité nationale compétente 864
4. Une révision nécessairement en faveur des associés minoritaires ? 866
5. L'effet suspensif d'une procédure de contestation sur la procédure de scission 867
6. Appréciation critique 868
F. La nécessité d'une règle de droit international privé 869
G. La personne de l'acheteur 870
H. La requalification de l'associé minoritaire sortant en créancier chirographaire 873
I. L'exclusion des sociétés cotées 875
§4. L'intervention de l'expert indépendant 876
§5. Le droit de contester le rapport d'échange 877
A. Principe et limites 878
1. Un mécanisme connu 878
2. Limites 879
B. Quid de la répartition des actions des sociétés bénéficiaires ? 879
C. La question des titulaires de ce droit 880
1. Une condition superflue 880
2. Un mécanisme alternatif 881
3. L'exigence d'un vote positif 882
4. La situation des associés des sociétés bénéficiaires 883
D. La délicate question de l'effet *erga omnes* 884
E. La *reformatio in peius* 887
F. La nécessité d'une certaine flexibilité 888
G. L'incidence de l'absence d'harmonisation des méthodes d'évaluation 891
H. La nécessité d'une règle de droit international privé 892
I. Un mécanisme inutile ? 894
§6. Conclusion sur les différents mécanismes de protection des associés minoritaires 895
Section 6. L'harmonisation au niveau européen 896
§1. Le régime antérieur à l'adoption de la Directive Mobilité 896
§2. Le choix du législateur européen lors de l'adoption de la Directive Mobilité 898
§3. Un nouvel exemple de l'habileté politique de la Commission 900
Section 7. Les aspects temporels de la protection des associés minoritaires 901
§1. Présentation 901
§2. Aspects temporels de l'exercice du droit de retrait 902
A. Le délai d'acceptation de l'offre de retrait 902
B. Le délai de paiement de la soulte en espèces 906

§3. Aspects temporels du droit de contester le montant de la soulte en espèces 908
§4. Aspects temporels du droit de contester le rapport d'échange 910
Section 8. Conclusion sur les enjeux de la protection des associés minoritaires 912

Chapitre 2. Les enjeux d'une scission transfrontalière pour la participation des travailleurs 915
Section 1. Présentation 917
Section 2. Une opération potentiellement au détriment de la participation des travailleurs 918
Section 3. Une dimension politique significative 921
Section 4. La nécessité d'un juste équilibre 922
Section 5. L'incidence de la liberté d'établissement 923
Section 6. La compatibilité du régime de la Directive Mobilité avec les scissions mixtes et par absorption 924
§1. Un régime très similaire 925
§2. Les principales réformes du régime des fusions transfrontalières 927
A. Un seuil d'occupation plus flexible 927
B. La protection du régime de participation pendant quatre ans 929
C. L'information des travailleurs 931
§3. Éléments de comparaison entre le régime des fusions transfrontalières et celui des scissions transfrontalières 931
A. Un régime très protecteur 931
B. L'exclusion apparente de la possibilité d'appliquer les dispositions de référence sans négociations préalables 933
C. L'absence de la condition de représentation transfrontalière 934
D. Scission partielle et « société issue de la scission transfrontalière » 934
E. L'application des dispositions de référence 935
1. Une double définition 935
2. Une condition nécessaire en cas de scission transfrontalière 937
F. La scission partielle au profit d'une société sans travailleurs 938
G. L'instauration d'un régime de participation transitoire 939
H. La surprenante incidence de la règle de permanence 939
I. La composition du groupe spécial de négociation 941
J. Le cas particulier de la réduction des droits de participation 942
Section 7. La conformité du régime de participation des travailleurs à la liberté d'établissement 943
§1. Une entrave à la liberté d'établissement 943
§2. La justification objective de l'entrave 944
Section 8. Conclusion sur les enjeux d'une scission transfrontalière pour la participation des travailleurs 947

Conclusion sur la protection des autres *stakeholders* dans le cadre d'une scission transfrontalière 951

Conclusion de la deuxième partie 955

Conclusion générale 965

Annexes 983

Annexe 1. Illustration de l'utilité d'une scission transfrontalière dans le cadre de la vente d'un portefeuille d'actifs 985

Annexe 2. Illustration chiffrée de calcul du rapport d'échange 991

Annexe 3. Schéma de la défense en profondeur des créanciers 995

Annexe 4. Liste des indices de l'habileté politique de la Commission 999

Annexe 5. Liste des modifications nécessaires 1005

Glossaire 1021

Bibliographie 1029

Index alphabétique 1097